

eBook  
2020

Coleção Carreiras Jurídicas

# PROCESSUAL PENAL

**Autores:**

Lorena Ocampos  
e João Carlos de Freitas Júnior



Organizado por CP Iuris

ISBN 978-85-5805-012-8

# **DIREITO PROCESSUAL PENAL**

**1ª edição**

**Brasília**

**CP Iuris**

**2020**

**LORENA OCAMPOS.** Juíza de Direito Substituta da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Foi aprovada nos concursos para os cargos de Técnica Judiciária do Ministério Público da União (MPU) e de Analista Judiciária do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Foi Técnica e Analista Judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Pós-graduada em Direito e Contemporaneidade pela União Pioneira de Integração Social (UPIS/DF) em convênio com a Escola da Magistratura. Mestranda em Direito.

**JOÃO CARLOS FREITAS JR.** Aprovado em 1º lugar no concurso público para Delegado de Polícia Substituto da Polícia Civil do Estado de Goiás – PCGO. Aprovado em 2º lugar no concurso público para o cargo de Agente de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF. Aprovado em 2º lugar no concurso público para o cargo de Agente Administrativo do Ministério do Esporte – ME. Aprovado no concurso público para Analista Judiciário – Área Judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, tendo obtido a nota 39,80 dos 40 pontos possíveis na prova discursiva. Aprovado no concurso público para o cargo de Técnico Administrativo da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. Aprovado no concurso público para o cargo de Agente Administrativo do Ministério da Saúde – MS. Aprovado no concurso público para o cargo de Assistente de Chancelaria do MRE do Ministério das Relações Exteriores. Aprovado no concurso de admissão para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército nos anos de 2005 e 2006.

---

|                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Capítulo 1 – Introdução ao Direito Processual Penal .....</b>                                                                               | <b>41</b> |
| 1. Noções Gerais .....                                                                                                                         | 41        |
| 2. Finalidade .....                                                                                                                            | 42        |
| 3. Fontes.....                                                                                                                                 | 42        |
| 3.1. Fontes materiais ou de produção do Direito Processual Penal.....                                                                          | 43        |
| 3.2. Fontes formais ou de cognição do Direito Processual Penal.....                                                                            | 43        |
| 3.2.1. Fonte de cognição imediata ou direta .....                                                                                              | 43        |
| 3.2.2. Fonte de cognição mediata, indireta ou supletiva.....                                                                                   | 44        |
| Questões .....                                                                                                                                 | 45        |
| Comentários .....                                                                                                                              | 45        |
| <b>Capítulo 2 – Princípios Aplicáveis ao Processo Penal .....</b>                                                                              | <b>46</b> |
| 1. Noções Gerais .....                                                                                                                         | 46        |
| 1.1. Princípios constitucionais expressos .....                                                                                                | 46        |
| 1.2 Princípios constitucionais implícitos .....                                                                                                | 46        |
| 1.3. Princípios do processo penal propriamente ditos.....                                                                                      | 47        |
| 2. Princípios Constitucionais Expressos .....                                                                                                  | 47        |
| 2.1. Presunção de inocência ou do estado de inocência ou da situação jurídica de inocência ou da não culpabilidade (art. 5º, LVII, CF/88)..... | 47        |
| 2.1.1. Dimensão interna.....                                                                                                                   | 47        |
| 2.1.2. Dimensão externa .....                                                                                                                  | 48        |
| 2.1.3. (Im)possibilidade de execução provisória da pena .....                                                                                  | 48        |
| 2.1.3.1. Histórico.....                                                                                                                        | 49        |
| 2.1.3.2. Argumentos favoráveis à execução provisória da pena .....                                                                             | 49        |
| 2.1.3.3. Argumentos contrários à execução provisória da pena .....                                                                             | 49        |
| 2.1.3.4. Superada a jurisprudência do STF/STJ.....                                                                                             | 50        |
| 2.2. Igualdade processual ou paridade de armas (art. 5º, <i>caput</i> , CF/88).....                                                            | 50        |
| 2.3. Ampla defesa – (art. 5º, LV, CF/88) .....                                                                                                 | 50        |
| 2.3.1. Defesa técnica.....                                                                                                                     | 51        |
| 2.3.2. Autodefesa .....                                                                                                                        | 52        |



|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.4. Plenitude de defesa (art. 5º, XXXVIII, CF/88) .....                                                                 | 53 |
| 2.5. Princípio da prevalência do interesse do réu ou favor rei ou <i>in dubio pro reo</i> – (art. 5º, LVII, CF/88) ..... | 54 |
| 2.6. Contraditório (art. 5º, LV, CF/88) .....                                                                            | 55 |
| 2.7. Juiz natural (art. 5º, LIII, CF/88) .....                                                                           | 56 |
| 2.8. Publicidade (art. 5º, LX, e art. 93, IX, ambos CF/88; art. 792 do CPP).....                                         | 57 |
| 2.9. Vedação das provas ilícitas – (art. 5º, LVI, CF/88) .....                                                           | 58 |
| 2.11. Devido processo legal – (art. 5º, LIV, CF/88) .....                                                                | 59 |
| 2.12. Intranscendência ou pessoalidade (art. 5º, XLV, CF/88) .....                                                       | 60 |
| 2.13. Motivação das decisões .....                                                                                       | 60 |
| 3. Princípios Constitucionais Implícitos .....                                                                           | 61 |
| 3.1. Não autoincriminação ( <i>nemo tenetur se detegere</i> ) .....                                                      | 61 |
| 3.2. Iniciativa das partes .....                                                                                         | 62 |
| 3.3. Duplo grau de jurisdição .....                                                                                      | 62 |
| 3.4. Juiz imparcial .....                                                                                                | 62 |
| 3.5. Promotor natural .....                                                                                              | 63 |
| 3.6. Obrigatoriedade da ação penal pública e indisponibilidade da ação penal pública .....                               | 64 |
| 3.7. Oficialidade .....                                                                                                  | 64 |
| 3.8. Oficiosidade .....                                                                                                  | 64 |
| 3.9. Autoritariedade .....                                                                                               | 64 |
| 3.10. Vedação da dupla punição ou <i>ne bis in idem</i> .....                                                            | 64 |
| 4. Princípios propriamente ditos.....                                                                                    | 65 |
| 4.1. Busca da verdade real .....                                                                                         | 65 |
| 4.2. Oralidade, concentração, imediatidade, identidade física do juiz .....                                              | 65 |
| 4.3. Indivisibilidade da ação penal privada .....                                                                        | 66 |
| 4.4. Comunhão de provas .....                                                                                            | 67 |
| 4.5. Impulso oficial .....                                                                                               | 67 |
| 4.6. Lealdade processual ou probidade ou boa-fé .....                                                                    | 67 |
| Questões .....                                                                                                           | 68 |
| Comentários .....                                                                                                        | 70 |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Capítulo 3 – Sistemas Processuais Penais.....</b>                           | <b>73</b> |
| 1. Introdução .....                                                            | 73        |
| 2. Sistema Inquisitivo .....                                                   | 73        |
| 3. Sistema Acusatório.....                                                     | 75        |
| 4. Sistema Misto ou Inquisitivo Garantista .....                               | 76        |
| 5. Sistema Processual adotado no Brasil .....                                  | 76        |
| 5.1. Visão classicamente adotada (inclusive antes da Lei nº 13.964/2019) ..... | 76        |
| 5.2. Síndrome de Dom Casmurro (quadros mentais paranoicos) .....               | 79        |
| 5.3. Visão após a Lei nº 13.964 (Lei Anticrime).....                           | 80        |
| Questões .....                                                                 | 81        |
| Comentários .....                                                              | 82        |
| <b>Capítulo 4 – Disposições Gerais do CPP (Arts. 1º a 3º do CPP).....</b>      | <b>83</b> |
| 1. Aplicação da Lei Processual Penal no espaço (Art. 1º do CPP) .....          | 83        |
| 1.1. Territorialidade.....                                                     | 83        |
| 1.2. Exceções previstas no art. 1º do CPP .....                                | 83        |
| 1.2.1. Os tratados, convenções e regras de direito internacional .....         | 83        |
| 1.2.2. Prerrogativas constitucionais.....                                      | 84        |
| 1.2.3. Justiça militar .....                                                   | 84        |
| 1.2.4. Tribunal especial .....                                                 | 84        |
| 1.2.5. Crimes de imprensa.....                                                 | 84        |
| 1.3. Extraterritorialidade .....                                               | 84        |
| 2. Aplicação da Lei Processual Penal no tempo (Art. 2º do CPP) .....           | 85        |
| 3. Utilização subsidiária do CPP .....                                         | 87        |
| 4. Peculiaridades da Lei Processual Penal (Art. 3º do CPP) .....               | 87        |
| 4.1. Analogia .....                                                            | 87        |
| 4.2. Interpretação extensiva .....                                             | 87        |
| 4.3. Costumes .....                                                            | 88        |
| 4.4. Princípios gerais do direito .....                                        | 88        |
| Questões .....                                                                 | 88        |
| Comentários .....                                                              | 90        |
| <b>Capítulo 5 – Juiz das Garantias (Arts. 3º-A a 3º-F do CPP) .....</b>        | <b>92</b> |
| 1. Lei Anticrime (Lei nº 13.964/2019) .....                                    | 92        |

|                                                                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>2. Juiz das Garantias (Arts. 3º-A a 3º-F do CPP) .....</b>                                                                                                 | <b>93</b>  |
| 2.1. Controle da legalidade do flagrante e da prisão cautelar (art. 3º-B, incisos I, II e III) ....                                                           | 94         |
| 2.2. Controle das investigações e violação da duração razoável (art. 3º-B, incisos IV, X e IX) .....                                                          | 95         |
| 2.3. Garantir os direitos do investigado e conduzidos (art. 3º-B, incisos XIII e XIV) .....                                                                   | 95         |
| 2.4. Produzir antecipadamente provas (art. 3º-B, inciso VII) .....                                                                                            | 95         |
| 2.5. Prorrogar o prazo de duração do inquérito (art. 3º-B, inciso VIII) .....                                                                                 | 96         |
| 2.6. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento (art. 3º-B, inciso IX) ..... | 97         |
| 2.7. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação (art. 3º-B, inciso X) .....                         | 97         |
| 2.8. Analisar as cautelares probatórias (art. 3º-B, incisos V, VI, XI) .....                                                                                  | 97         |
| 2.9. Determinar a instauração de incidente de insanidade mental (art. 3º-B, inciso XIII) ....                                                                 | 97         |
| 2.10. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia .....                                                            | 97         |
| 2.11. Homologar delação premiada e acordo de não persecução penal (art. 3º-B, inciso XVII) .....                                                              | 97         |
| 2.12. Receber a denúncia .....                                                                                                                                | 98         |
| 2.13. Outras matérias inerentes às atribuições definidas no <i>caput</i> deste artigo (art. 3º-B, inciso XVIII) .....                                         | 98         |
| 2.14. Exclusão da figura do juiz das garantias no juizado especial criminal .....                                                                             | 98         |
| 2.15. Termo final de atuação do juiz das garantias .....                                                                                                      | 98         |
| 2.16. Autos acautelados na secretaria do juízo das garantias .....                                                                                            | 98         |
| 2.17. Designação do juiz das garantias conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal .....                         | 99         |
| 2.18. Da vedação à exploração da imagem de pessoa submetida à prisão .....                                                                                    | 99         |
| 2.19. Críticas .....                                                                                                                                          | 99         |
| <b>Capítulo 6 – Investigação Criminal .....</b>                                                                                                               | <b>100</b> |
| 1. Introdução .....                                                                                                                                           | 100        |
| 2. Conceito de Polícia Administrativa e Polícia Judiciária .....                                                                                              | 100        |
| 3. Conceito de Inquérito Policial (Arts. 4º a 23, CPP) .....                                                                                                  | 100        |
| 4. Natureza Jurídica .....                                                                                                                                    | 101        |
| 5. Valor Probatório .....                                                                                                                                     | 101        |
| 6. Características do Inquérito Policial .....                                                                                                                | 103        |

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.1. Administrativo.....                                                        | 104 |
| 6.2. Inquisitivo (investigativo).....                                           | 104 |
| 6.3. Inexistência de nulidades.....                                             | 105 |
| 6.4. Escrito (art. 9º, CPP).....                                                | 106 |
| 6.5. Sigiloso (art. 20, CPP) .....                                              | 106 |
| 6.6. Oficialidade .....                                                         | 108 |
| 6.7. Autoritariedade .....                                                      | 108 |
| 6.8. Oficiosidade .....                                                         | 108 |
| 6.9. Indisponibilidade (art. 17, CPP) .....                                     | 108 |
| 6.10. Dispensabilidade.....                                                     | 109 |
| 7. Incomunicabilidade .....                                                     | 109 |
| 8. Atribuição no Inquérito Policial.....                                        | 109 |
| 9. Início e Conclusão Do Inquérito Policial .....                               | 110 |
| 9.1. De ofício pela autoridade policial .....                                   | 110 |
| 9.2. Por requisição da autoridade competente (Ministério Público ou Juiz) ..... | 111 |
| 9.3. Por requerimento do ofendido ou representante legal .....                  | 111 |
| 9.4. Por delação de terceiro ou <i>delatio criminis</i> .....                   | 111 |
| 9.5. Por requisição do Ministro da Justiça .....                                | 111 |
| 9.6. Pela lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF) .....                  | 111 |
| 9.7. Observações .....                                                          | 111 |
| 10. Notitia Criminis .....                                                      | 112 |
| 10.1. De cognição direta/imediata/espontânea.....                               | 112 |
| 10.2. De cognição indireta/mediata/provocada.....                               | 112 |
| 10.3. De cognição coercitiva .....                                              | 112 |
| 10.4. De cognição inqualificada (denúncia anônima) .....                        | 113 |
| 11. Conclusão do Inquérito Policial .....                                       | 114 |
| 11.1. Trâmite nos delitos de ação penal pública .....                           | 114 |
| 11.2. Trâmite nos delitos de ação penal privada .....                           | 116 |
| 12. Prazo para a conclusão do Inquérito Policial.....                           | 117 |
| 12.1. Natureza dos prazos de conclusão do IP .....                              | 118 |
| 13. Diligências investigatórias.....                                            | 119 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>14. Outras providências previstas no CPP que o Delegado de Polícia poderá fazer ou representar ainda na fase do IP .....</b>                                                                                                                                                                           | <b>122</b> |
| 14.1. Atenção ao art. 13 do CPP .....                                                                                                                                                                                                                                                                     | 122        |
| 14.2. Representar acerca da prisão preventiva (quem decreta é o juiz), conforme art. 311 do CPP .....                                                                                                                                                                                                     | 122        |
| 14.3. Representar acerca da prisão temporária (quem decreta é o juiz), conforme art. 2º da Lei nº 7.960/89.....                                                                                                                                                                                           | 122        |
| 14.4. Arbitrar fiança, conforme art. 322 do CPP .....                                                                                                                                                                                                                                                     | 123        |
| 14.5. Representar pelo exame de insanidade mental (quem ordena o exame é o juiz), conforme art. 149 do CPP .....                                                                                                                                                                                          | 123        |
| 14.6. Restituir coisas apreendidas, conforme art. 120 do CPP .....                                                                                                                                                                                                                                        | 123        |
| 14.7. Representar pela medida assecuratória do sequestro, conforme art. 127 do CPP.....                                                                                                                                                                                                                   | 123        |
| 14.8. Requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos, conforme art. 13-A do CPP .....                                                                                                                    | 123        |
| 14.9. Requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso ..... | 124        |
| 14.10. Declarar-se suspeita, quando ocorrer motivo legal.....                                                                                                                                                                                                                                             | 124        |
| <b>15. Tratamento diferenciado para agentes de segurança pública e membros das forças armadas na fase de investigação criminal (art. 14-a, cpp) .....</b>                                                                                                                                                 | <b>124</b> |
| <b>16. Arquivamento e Desarquivamento do IP .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>126</b> |
| 16.1. Observação importante a respeito da Lei nº 13.964/19 (Lei Anticrime).....                                                                                                                                                                                                                           | 126        |
| 16.2. Arquivamento tradicional .....                                                                                                                                                                                                                                                                      | 126        |
| 16.3. Motivos do arquivamento (artigos 395 e 397, CPP) .....                                                                                                                                                                                                                                              | 127        |
| 16.4. Desarquivamento: art. 18, CPP; Súmula nº 524, STF .....                                                                                                                                                                                                                                             | 127        |
| 16.5. Irretratibilidade do pedido de arquivamento .....                                                                                                                                                                                                                                                   | 128        |
| 16.6. Arquivamento implícito .....                                                                                                                                                                                                                                                                        | 128        |
| 16.7. Arquivamento indireto.....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 129        |
| 16.8. Arquivamento provisório .....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 129        |
| 16.9. Recurso contra decisão judicial de arquivamento? .....                                                                                                                                                                                                                                              | 129        |
| 16.10. A vítima de crime de ação penal pública incondicionada não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento do inquérito ou peças de informação.....                                                                                                                                          | 130        |

|                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 16.11. Comentários à alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 no art. 28 do CPP .....                                  | 130        |
| 17. Trancamento do Inquérito Policial .....                                                                             | 132        |
| 18. Indiciamento .....                                                                                                  | 133        |
| 19. Informativos de Jurisprudência .....                                                                                | 134        |
| 19.1. Supremo Tribunal Federal .....                                                                                    | 134        |
| 19.2. Superior Tribunal de Justiça .....                                                                                | 136        |
| Questões .....                                                                                                          | 136        |
| Comentários .....                                                                                                       | 138        |
| <b>Capítulo 7 – Acordo de Não Persecução Penal – ANPP (Art. 28-A do CPP) .....</b>                                      | <b>141</b> |
| 1. Conceito e histórico.....                                                                                            | 141        |
| 2. Ação Penal Privada.....                                                                                              | 142        |
| 3. Direito Intertemporal .....                                                                                          | 143        |
| 4. Prescrição .....                                                                                                     | 144        |
| 5. Ações Penais Originárias.....                                                                                        | 144        |
| 6. Pressupostos para o ANPP .....                                                                                       | 144        |
| 7. Obrigações do Investigado.....                                                                                       | 148        |
| 8. Vedações Legais/Não Cabimento do Acordo .....                                                                        | 150        |
| 9. Crimes Hediondos .....                                                                                               | 151        |
| 10. Justiça Especializada (Militar e Eleitoral) .....                                                                   | 151        |
| 11. Homologação Judicial .....                                                                                          | 152        |
| 12. É admissível que o ANPP seja negociado e homologado na Audiência de Custódia (do art. 287 e art. 310 do CPP)? ..... | 153        |
| 13. Dupla Aceitação Defensiva .....                                                                                     | 153        |
| 14. Registrados pelos meios ou recursos de gravação audiovisual .....                                                   | 153        |
| 15. Vítima será intimada .....                                                                                          | 153        |
| 16. Não gera reincidência em antecedentes criminais ao investigado .....                                                | 154        |
| 17. Cumprimento .....                                                                                                   | 154        |
| 18. Detração .....                                                                                                      | 154        |
| 19. Recusa, por parte do MP, em propor o ANPP .....                                                                     | 155        |
| 20. Concurso de agentes.....                                                                                            | 155        |
| 21. Descumpridas as cláusulas do ANPP e rescisão .....                                                                  | 155        |
| 22. Rescisão após decisão declaratória de extinção de punibilidade .....                                                | 155        |
| 23. É um direito subjetivo do investigado?.....                                                                         | 155        |
| 24. Acordo de Não Persecução Cível .....                                                                                | 156        |
| Questões .....                                                                                                          | 156        |

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Comentários .....                                                              | 158 |
| Capítulo 8 – Ação Penal (Arts. 24 a 62 do CPP) .....                           | 160 |
| 1. Introdução .....                                                            | 160 |
| 1.1. Condições gerais da ação .....                                            | 160 |
| 1.1.1. Possibilidade jurídica do pedido .....                                  | 160 |
| 1.1.2. Interesse de agir.....                                                  | 160 |
| 1.1.3. Legitimidade da parte.....                                              | 161 |
| 1.1.4. Justa causa.....                                                        | 161 |
| a) Justa causa duplicada .....                                                 | 161 |
| b) Justa causa triplicada .....                                                | 162 |
| 1.2. Condições específicas da ação .....                                       | 162 |
| 1.3. Condição de prosseguibilidade (condição superveniente da ação) .....      | 163 |
| 1.4. Condições objetivas de punibilidade.....                                  | 164 |
| 2. Classificação das ações penais .....                                        | 164 |
| 3. Princípios aplicáveis na ação penal pública.....                            | 165 |
| 3.1. Princípio da Obrigatoriedade .....                                        | 165 |
| 3.2. Princípio da Indisponibilidade (indesistibilidade) .....                  | 167 |
| 4. Espécies de ação penal pública .....                                        | 168 |
| 4.1. Ação Penal Pública Incondicionada.....                                    | 169 |
| 4.2. Ação Penal Pública Condicionada à Representação .....                     | 169 |
| 4.3. Ação Penal Pública Condicionada à Requisição do Ministro da Justiça ..... | 172 |
| 5. Princípios aplicáveis na ação penal privada .....                           | 172 |
| 5.1. Princípio da Oportunidade/Conveniência .....                              | 172 |
| 5.2. Princípio da Disponibilidade .....                                        | 173 |
| 5.3. Princípio da Indivisibilidade .....                                       | 173 |
| 6. Espécies de ação penal privada .....                                        | 174 |
| 6.1. Propriamente Dita/Exclusivamente Privada.....                             | 174 |
| 6.2. Personalíssima.....                                                       | 175 |
| 6.3. Subsidiária da Pública/Acidentalmente Privada/Ação Penal Supletiva.....   | 175 |
| 7. Observações .....                                                           | 176 |

|                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.1. Exigência de Capacidade Postulatória .....                                                                                     | 176 |
| 7.2. Qual a função do Ministério Público na ação penal privada? .....                                                               | 176 |
| 8. Requisitos da peça inicial acusatória .....                                                                                      | 177 |
| 8.1. Análise do art. 41 do CPP .....                                                                                                | 177 |
| 8.1.1. Exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias .....                                                               | 177 |
| 8.1.2. Classificação do delito .....                                                                                                | 178 |
| 8.1.3. Individualização do acusado .....                                                                                            | 178 |
| 8.1.4. Rol de testemunhas.....                                                                                                      | 179 |
| 8.1.5. Pedido de condenação .....                                                                                                   | 179 |
| 8.1.6. Endereçamento.....                                                                                                           | 179 |
| 8.1.7. Nome e assinatura .....                                                                                                      | 179 |
| 8.2. Prazo para oferecimento de denúncia .....                                                                                      | 179 |
| 8.3. Prazo para oferecimento de queixa-crime .....                                                                                  | 180 |
| 8.4. Recebimento da denúncia ou da queixa-crime.....                                                                                | 181 |
| 8.5. Rejeição da denúncia e da queixa-crime .....                                                                                   | 182 |
| 9. Causas de extinção de punibilidade .....                                                                                         | 182 |
| 9.1. Decadência.....                                                                                                                | 182 |
| 9.2. Renúncia .....                                                                                                                 | 183 |
| 9.3. Perdão.....                                                                                                                    | 184 |
| 9.4. Perempção (art. 60 do CPP).....                                                                                                | 185 |
| 10. Casos especiais.....                                                                                                            | 186 |
| 10.1. Ação penal nos crimes contra a honra de funcionário público praticado no exercício de suas funções (Súmula nº 714, STF) ..... | 186 |
| 10.2. Ação penal nos crimes de lesões corporais leves e culposas na Lei Maria da Penha (art. 41, da Lei nº 11.340/06).....          | 187 |
| 11. Conceitos importantes.....                                                                                                      | 188 |
| 11.1. Ação penal secundária .....                                                                                                   | 188 |
| 11.2. Ação penal adesiva .....                                                                                                      | 188 |
| 11.3. Ação penal indireta.....                                                                                                      | 188 |
| 11.4. Ação penal popular .....                                                                                                      | 188 |
| 11.5. Ação penal pública subsidiária da pública .....                                                                               | 189 |



|                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.6. Ação de prevenção geral .....                                                                                                              | 189 |
| 11.7. Ação penal de segundo grau.....                                                                                                            | 189 |
| 11.8. Ação penal <i>ex officio</i> .....                                                                                                         | 189 |
| 12. Informativos de Jurisprudência .....                                                                                                         | 189 |
| 12. 1. Supremo Tribunal Federal .....                                                                                                            | 189 |
| 12.2. Superior Tribunal de Justiça .....                                                                                                         | 190 |
| Questões .....                                                                                                                                   | 190 |
| Comentários .....                                                                                                                                | 193 |
| Capítulo 9 – Da Ação Civil <i>Ex Delicto</i> (arts. 63 a 68 do CPP) .....                                                                        | 194 |
| 1. Introdução .....                                                                                                                              | 194 |
| 2. Ação de execução <i>ex delicto</i> (art. 63 do CPP).....                                                                                      | 195 |
| 2.1. Principais características .....                                                                                                            | 195 |
| 2.2. Análise do art. 387, IV, do CPP.....                                                                                                        | 196 |
| 2.3. Valor mínimo de reparação em sentença penal condenatória irrecorrível de crimes ambientais .....                                            | 198 |
| 2.4. Sentença que concede o perdão judicial .....                                                                                                | 198 |
| 2.5. Sentença penal condenatória proferida em país estrangeiro .....                                                                             | 198 |
| 2.7. Extinção das pretensões punitiva e executória.....                                                                                          | 198 |
| 2.6. Inadequação da via do <i>habeas corpus</i> para impugnação do valor fixado.....                                                             | 199 |
| 2.7. Revisão criminal e eliminação do título executivo judicial .....                                                                            | 199 |
| 2.8. Valor mínimo para reparação do dano fixado em sentença condenatória e crimes de abuso de autoridade .....                                   | 199 |
| 2.9. Possibilidade de interposição de apelação (art. 593 do CPP) para impugnar decisão a respeito da fixação do valor mínimo de indenização..... | 199 |
| 3. Ação civil ex delitCo (art. 64 do CPP) .....                                                                                                  | 199 |
| 3.1. Principais características .....                                                                                                            | 199 |
| 3.2. Possibilidade de suspensão da ação civil.....                                                                                               | 200 |
| 3.3. Prazo prescricional .....                                                                                                                   | 201 |
| 4. Situações que impedem a propositura da ação civil <i>ex delicto</i> .....                                                                     | 201 |
| 4.1. Análise dos arts. 65 a 67 do CPP .....                                                                                                      | 201 |
| 4.2. Análise do art. 386 do CPP .....                                                                                                            | 203 |
| 5. Legitimidade no caso de interessado pobre (art. 68 do CPP) .....                                                                              | 203 |

|                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Questões .....                                                                                        | 204 |
| Comentários .....                                                                                     | 206 |
| Capítulo 10 – Da Jurisdição e Competência (Arts. 69 A 91, CPP).....                                   | 208 |
| 1. Jurisdição .....                                                                                   | 208 |
| 1.1. Características da jurisdição .....                                                              | 208 |
| 1.1.1. Substitutividade .....                                                                         | 208 |
| 1.1.2. Inércia.....                                                                                   | 208 |
| 1.1.3. Lide.....                                                                                      | 208 |
| 1.1.4. Atuação do Direito .....                                                                       | 209 |
| 1.1.5. Imutabilidade.....                                                                             | 209 |
| 1.2. Princípios gerais da jurisdição .....                                                            | 209 |
| 1.2.1. Juiz Natural .....                                                                             | 209 |
| 1.2.2. Investidura.....                                                                               | 209 |
| 1.2.3. Indeclinabilidade.....                                                                         | 209 |
| 1.2.4. Inafastabilidade .....                                                                         | 209 |
| 1.2.5. Improrrogabilidade .....                                                                       | 210 |
| 1.2.6. Indelegabilidade.....                                                                          | 210 |
| 1.2.7. Irrecusabilidade (ou Inevitabilidade).....                                                     | 210 |
| 1.2.8. Unidade .....                                                                                  | 210 |
| 1.2.9. Correlação .....                                                                               | 210 |
| 2. Competência.....                                                                                   | 210 |
| 2.1. Espécies de competência .....                                                                    | 211 |
| 2.1.1. Competência absoluta e competência relativa .....                                              | 212 |
| 2.1.1.1. Espécies .....                                                                               | 212 |
| 2.1.1.1.2. Momento adequado para alegação e possibilidade de prorrogação .....                        | 212 |
| 2.1.1.1.3. Possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa no Processo Penal..... | 212 |
| 2.1.1.1.4. Exceção de incompetência .....                                                             | 213 |
| 2.1.1.1.5. Consequências do reconhecimento da incompetência absoluta e da incompetência relativa..... | 213 |
| 2.1.1.1.6. Coisa julgada no caso de incompetência absoluta e incompetência relativa..                 | 213 |

|                                                                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1.1.7. Quadro-resumo das principais características das competências absoluta e relativa .....                                                     | 214 |
| 3. Fixação da Competência Criminal.....                                                                                                              | 215 |
| 3.1. Justiça Militar .....                                                                                                                           | 216 |
| 3.1.1. Diferenças entre a Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados .....                                                             | 216 |
| 3.1.1.1. Competência criminal .....                                                                                                                  | 216 |
| 3.1.1.2. Ações judiciais contra atos disciplinares militares .....                                                                                   | 217 |
| 3.1.1.3. Acusado .....                                                                                                                               | 217 |
| 3.1.2. Lei nº 13.491/17.....                                                                                                                         | 220 |
| 3.1.2.1. Crimes previstos na legislação penal comum .....                                                                                            | 220 |
| 3.1.2.2. Crimes dolosos praticados por militares contra a vida de civis.....                                                                         | 223 |
| 3.2. Justiça Eleitoral.....                                                                                                                          | 224 |
| 3.2.1. Conexão entre crime comum e crime eleitoral .....                                                                                             | 225 |
| 3.2.2. Conexão entre crime militar e crime eleitoral.....                                                                                            | 226 |
| 3.2.3. Conexão entre crime doloso contra a vida e crime eleitoral .....                                                                              | 226 |
| 3.3. Justiça do Trabalho .....                                                                                                                       | 226 |
| 3.4. Justiça Federal .....                                                                                                                           | 226 |
| 3.4.1. Competência dos Tribunais Regionais Federais.....                                                                                             | 226 |
| 3.4.2. Competência dos juízes federais .....                                                                                                         | 227 |
| 3.4.2.1. Crimes políticos .....                                                                                                                      | 227 |
| 3.4.2.2. Crimes praticados contra a União .....                                                                                                      | 227 |
| 3.4.2.3. Crimes previstos em tratado ou convenção internacional .....                                                                                | 230 |
| 3.4.2.4. Incidente de Deslocamento de Competência para a Justiça Federal.....                                                                        | 231 |
| 3.4.2.5. Crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ..... | 232 |
| 3.4.2.6. Habeas corpus .....                                                                                                                         | 234 |
| 3.4.2.7. Mandado de segurança em matéria criminal .....                                                                                              | 234 |
| 3.4.2.8. Crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves .....                                                                                        | 234 |
| 3.4.2.9. Crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro .....                                                                            | 236 |
| 3.4.2.10. Disputa sobre direitos indígenas.....                                                                                                      | 237 |

|                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>3.5. Foro por prerrogativa de função.....</b>                                                      | <b>237</b> |
| <b>3.5.1. Infração penal cometida durante o exercício do cargo (regra da contemporaneidade) .....</b> | <b>237</b> |
| 3.5.1.1. Marco temporal para fins de possível prorrogação de competência do Tribunal competente ..... | 238        |
| 3.5.1.2. Infração penal praticada após o exercício funcional .....                                    | 238        |
| <b>3.5.2. Infração penal relacionada com o exercício funcional.....</b>                               | <b>238</b> |
| 3.5.2.1. Mandatos sucessivos .....                                                                    | 239        |
| 3.5.2.2. Infração penal cometida por Desembargador .....                                              | 239        |
| <b>3.5.3. Impossibilidade de concessão de foro por prerrogativa de função .....</b>                   | <b>239</b> |
| <b>3.5.4. Crimes dolosos contra a vida .....</b>                                                      | <b>239</b> |
| <b>3.5.5. Foro por prerrogativa de função e local da infração.....</b>                                | <b>240</b> |
| <b>3.5.6. Exceção da verdade.....</b>                                                                 | <b>241</b> |
| <b>3.6. Competência de foro e competência de juízo.....</b>                                           | <b>241</b> |
| <b>3.6.1. Lugar da infração.....</b>                                                                  | <b>242</b> |
| 3.6.1.1. Casuísticas importantes .....                                                                | 242        |
| 3.6.1.1.1. Cheque sem fundo .....                                                                     | 242        |
| 3.6.1.2. Crimes plurilocais .....                                                                     | 243        |
| 3.6.1.3. Crimes à distância .....                                                                     | 244        |
| 3.6.1.4. Crimes cometidos na divisa de localidades sujeitas a jurisdições distintas ....              | 244        |
| 3.6.1.5. Infração continuada ou permanente .....                                                      | 245        |
| <b>3.6.2. Determinação da competência pelo domicílio ou pela residência do réu.....</b>               | <b>245</b> |
| 3.6.2.1. Ignorância quanto ao lugar da infração.....                                                  | 245        |
| 3.6.2.2. Ação penal de iniciativa privada .....                                                       | 246        |
| <b>3.6.3. Natureza da infração penal.....</b>                                                         | <b>246</b> |
| <b>3.6.4. Competência por distribuição .....</b>                                                      | <b>247</b> |
| <b>3.6.5. Competência por prevenção .....</b>                                                         | <b>248</b> |
| <b>3.6.6. Modificação de competência (conexão e continência) .....</b>                                | <b>250</b> |
| 3.6.6.1. Conexão (art. 76 do CPP).....                                                                | 250        |
| 3.6.6.2. Continência (art. 77 do CPP).....                                                            | 252        |

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.6.6.3. Consequências da conexão e/ou continência .....                             | 253 |
| 3.6.6.4. Juízo prevalente.....                                                       | 254 |
| 3.6.6.5. Separação obrigatória de feitos.....                                        | 256 |
| 3.6.6.6. Separação facultativa dos feitos .....                                      | 257 |
| 3.6.6.7. Perpetuação da competência nos casos de conexão e/ou continência.....       | 258 |
| 3.6.7. Crimes cometidos fora do território brasileiro .....                          | 260 |
| 3.6.7.1. Crime cometido por brasileiro no exterior e negativa de extradição .....    | 260 |
| 4. Informativos de Jurisprudência .....                                              | 261 |
| 4.1. Supremo Tribunal Federal .....                                                  | 261 |
| 4.2. Superior Tribunal de Justiça .....                                              | 262 |
| Questões .....                                                                       | 262 |
| Comentários .....                                                                    | 262 |
| Capítulo 11– Das questões prejudiciais (art. 92 a 94, CPP) .....                     | 264 |
| 1. Diferenças entre questões prejudiciais e questões preliminares (ou prévias) ..... | 264 |
| 2. Classificação das Questões Prejudiciais .....                                     | 264 |
| 2.1. Espécies de questões prejudiciais heterogêneas .....                            | 264 |
| 2.1.1. Heterogênea/extrapenal obrigatória .....                                      | 264 |
| 2.1.2. Heterogênea/extrapenal facultativa .....                                      | 265 |
| 2.1.3. Questão prejudicial total e parcial .....                                     | 266 |
| 3. Informativos de Jurisprudência .....                                              | 266 |
| 3.1. Superior Tribunal de Justiça .....                                              | 266 |
| Questões .....                                                                       | 267 |
| Comentários .....                                                                    | 268 |
| Capítulo 12 – Das questões incidentais (art. 145 a 154, CPP) .....                   | 269 |
| 1. Incidente de falsidade documental (art. 145 a 148, CPP).....                      | 269 |
| 1.1. Procedimento.....                                                               | 269 |
| 1.2. Recurso cabível e não formação de coisa julgada material .....                  | 269 |
| 2. Incidente de insanidade mental (art. 149 a 154, CPP) .....                        | 269 |
| 2.1. Legitimados para o requerimento de instauração do incidente .....               | 270 |
| 2.2. Suspensão do curso do processo e não suspensão da prescrição .....              | 270 |
| 2.3. Inexistência de recurso .....                                                   | 270 |

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.4. Quantidade de Peritos .....                                                                    | 271 |
| 2.5. Duração do incidente .....                                                                     | 271 |
| 2.6. Consequências do exame .....                                                                   | 271 |
| 3. Informativos de Jurisprudência .....                                                             | 272 |
| 3.1. Superior Tribunal de Justiça .....                                                             | 272 |
| Questões .....                                                                                      | 273 |
| Comentários .....                                                                                   | 273 |
| Capítulo 13 – Exceções e conflito de competência (arts. 95 a 117, CPP) .....                        | 274 |
| 1. Conceito e natureza jurídica .....                                                               | 274 |
| 1.1. Classificação das exceções em razão de suas consequências .....                                | 274 |
| 1.2. Espécies de exceções .....                                                                     | 274 |
| 2. Exceção de suspeição (arts. 96 a 107, CPP) .....                                                 | 274 |
| 2.1. Reconhecimento de ofício da suspeição .....                                                    | 275 |
| 2.2. Oposição da exceção de suspeição perante o juízo de primeira instância.....                    | 275 |
| 2.2.1. Possibilidade de produção de provas e número de testemunhas .....                            | 276 |
| 2.2.2. Necessidade de petição escrita .....                                                         | 276 |
| 2.2.2.1. Exceção de suspeição oral no Tribunal do Júri .....                                        | 276 |
| 2.2.3. Assistente de acusação .....                                                                 | 276 |
| 2.2.4. Momento para alegação .....                                                                  | 277 |
| 2.2.5. Aceitação pelo juiz da oposição da exceção de suspeição .....                                | 277 |
| 2.2.6. Não aceitação pelo juiz da oposição da exceção de suspeição.....                             | 277 |
| 2.2.6.1. Julgamento pelo Tribunal da exceção de suspeição não aceita pelo juiz.....                 | 278 |
| 2.2.7. Possibilidade de suspensão do processo principal .....                                       | 278 |
| 2.2.8. Recursos cabíveis .....                                                                      | 279 |
| 2.3. Exceção de suspeição perante Tribunais .....                                                   | 279 |
| 2.3.1. Reconhecimento de ofício .....                                                               | 279 |
| 2.3.2. Oposição de exceção de suspeição pelas partes .....                                          | 279 |
| 2.4. Exceção de suspeição de membro do Ministério Público .....                                     | 280 |
| 2.5. Exceção de suspeição de serventuários, de funcionários da justiça, peritos e intérpretes ..... | 280 |
| 2.6. Suspeição do Delegado de Polícia.....                                                          | 281 |

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3. Exceção de incompetência (arts. 108 e 109, CPP).....                                    | 281 |
| 3.1. Possibilidade de reconhecimento de ofício da nulidade relativa.....                   | 281 |
| 3.1.1. Momento limítrofe para que o juiz reconheça a incompetência relativa de ofício..... | 281 |
| 3.2. Oposição de exceção pela parte .....                                                  | 282 |
| 3.3. Recursos cabíveis.....                                                                | 283 |
| 4. Exceção de ilegitimidade .....                                                          | 283 |
| 4.1. Legitimidade <i>ad causam</i> e <i>ad processum</i> .....                             | 283 |
| 4.1.1. Classificação da exceção de ilegitimidade quanto aos seus efeitos .....             | 284 |
| 4.2. Oposição de exceção de ilegitimidade .....                                            | 284 |
| 4.3. Recursos cabíveis.....                                                                | 285 |
| 5. Exceção de litispendência .....                                                         | 285 |
| 5.1. Disposições gerais.....                                                               | 285 |
| 5.2. Impossibilidade de exceção de litispendência em razão de inquérito policial .....     | 285 |
| 5.3. Procedimento da exceção de litispendência .....                                       | 286 |
| 5.4. Critérios para se determinar qual ação penal será extinta .....                       | 286 |
| 5.5. Possibilidade de conflito de competência .....                                        | 286 |
| 5.6. Recursos cabíveis.....                                                                | 286 |
| 6. Exceção de coisa julgada.....                                                           | 287 |
| 6.1. Disposições gerais.....                                                               | 287 |
| 6.2. Coisa julgada formal, material e soberanamente julgada .....                          | 287 |
| 6.2.1. Coisa julgada formal.....                                                           | 287 |
| 6.2.2. Coisa julgada material .....                                                        | 287 |
| 6.2.3. Coisa soberanamente julgada .....                                                   | 288 |
| 6.3. Limites da coisa julgada .....                                                        | 288 |
| 6.3.1. Limites objetivos .....                                                             | 288 |
| 6.3.1.1. Crime continuado (art. 71 do CP).....                                             | 289 |
| 6.3.1.2. Concurso formal de crimes (art. 70 do CP) .....                                   | 289 |
| 6.3.1.3. Crimes permanentes .....                                                          | 289 |
| 6.3.1.4. Crimes habituais .....                                                            | 290 |
| 6.3.2. Limites subjetivos.....                                                             | 290 |

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.4. Existência de duas sentenças condenatórias .....                                   | 291 |
| 6.5. Procedimento da exceção de coisa julgada .....                                     | 291 |
| 6.6. Recursos cabíveis.....                                                             | 291 |
| 7. Oposição de mais de uma exceção .....                                                | 291 |
| 8. Processamento em apartado e não suspensão do processo principal .....                | 291 |
| 9. Impedimento e incompatibilidade .....                                                | 292 |
| 10. Conflito de competência .....                                                       | 292 |
| 10.1. Disposições gerais e espécies de conflito .....                                   | 292 |
| 10.2. Existência de conflito de jurisdição antes da instauração do processo penal ..... | 293 |
| 10.3. Procedimento do conflito de competência.....                                      | 293 |
| 10.3.1. Legitimados.....                                                                | 293 |
| 10.3.2. Assistente do Ministério Público .....                                          | 293 |
| 10.3.3. Rito procedimental.....                                                         | 293 |
| 10.3.4. Tribunais competentes para dirimir os conflitos .....                           | 294 |
| 10.3.4.1. Advocatária .....                                                             | 296 |
| 11. Conflito de atribuições no âmbito do Ministério Público.....                        | 296 |
| 12. Informativos de Jurisprudência .....                                                | 297 |
| 12. 1. Supremo Tribunal Federal .....                                                   | 297 |
| 12.2. Superior Tribunal de Justiça .....                                                | 298 |
| Questões .....                                                                          | 298 |
| Comentários .....                                                                       | 299 |
| Capítulo 14 – Da restituição das coisas apreendidas (art. 118 a 124-a, CPP) .....       | 301 |
| 1. Introdução e procedimento .....                                                      | 301 |
| 2. Vedações .....                                                                       | 301 |
| 3. Prazo para alienação das coisas apreendidas.....                                     | 302 |
| 3.1. Coisas apreendidas sujeitas ao confisco.....                                       | 302 |
| 3.2. Coisas apreendidas não sujeitas ao confisco .....                                  | 303 |
| 4. Destinação dos bens apreendidos .....                                                | 303 |
| 4.1. Utilização pelo poder público .....                                                | 303 |
| 4.2. Instrumentos do crime e bens confiscados .....                                     | 303 |
| 4.3. Obras de arte ou outros bens de relevante valor cultural ou artístico .....        | 303 |
| 5. Informativos de Jurisprudência .....                                                 | 304 |



|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1. Superior Tribunal de Justiça .....                                | 304 |
| Questões .....                                                         | 304 |
| Comentários .....                                                      | 305 |
| Capítulo 15 – Das Medidas Assecuratórias (Art. 125 a 144-A, CPP) ..... | 306 |
| 1. Introdução .....                                                    | 306 |
| 2. Sequestro.....                                                      | 306 |
| 2.1. Sequestro de bens imóveis.....                                    | 306 |
| 2.1.1. Introdução .....                                                | 306 |
| 2.1.2. Requisitos .....                                                | 306 |
| 2.1.3. Legitimados .....                                               | 306 |
| 2.1.4. Procedimento, embargos e apelação .....                         | 307 |
| 2.1.5. Levantamento.....                                               | 307 |
| 2.2. Sequestro de bens móveis.....                                     | 308 |
| 2.3. Destinação dos bens sequestrados .....                            | 308 |
| 2.4. Utilização do bem pelo poder público.....                         | 309 |
| 3. Hipoteca legal .....                                                | 309 |
| 3.1. Introdução.....                                                   | 309 |
| 3.2. Requisitos.....                                                   | 309 |
| 3.3. Legitimados .....                                                 | 310 |
| 3.4. Possibilidade de caução pelo réu .....                            | 310 |
| 4. Arresto.....                                                        | 310 |
| 4.1. Arresto prévio (ou preventivo) .....                              | 310 |
| 4.2. Arresto subsidiário de bens móveis .....                          | 311 |
| 4.2.1. Rendas dos bens móveis .....                                    | 311 |
| 4.2.2. Suscetibilidade de penhora.....                                 | 311 |
| 5. Disposições comuns à hipoteca legal e ao arresto.....               | 311 |
| 5.1. Necessidade de autos apartados .....                              | 311 |
| 5.2. Alcance das garantias.....                                        | 311 |
| 5.3. Levantamento do arresto e cancelamento da hipoteca .....          | 312 |
| 5.4. Legitimidade do Ministério Público .....                          | 312 |
| 5.5. Remessa dos autos ao juízo cível .....                            | 312 |

|                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6. Venda antecipada dos bens sequestrados, hipotecados ou arrestados.....                                   | 312 |
| 7. Informativos de Jurisprudência .....                                                                     | 313 |
| 7.1. Supremo Tribunal Federal .....                                                                         | 313 |
| 7.2. Superior Tribunal de Justiça .....                                                                     | 313 |
| Questões .....                                                                                              | 314 |
| Comentários .....                                                                                           | 314 |
| Capítulo 16 – Das provas (art. 155 a 250, CPP) .....                                                        | 316 |
| 1. Introdução e teoria geral da prova (art. 155 a 157, CPP) .....                                           | 316 |
| 1.1. Princípios aplicáveis.....                                                                             | 316 |
| 1.1.1. Contraditório .....                                                                                  | 316 |
| 1.1.2. Imediatidade.....                                                                                    | 316 |
| 1.1.3. Concentração .....                                                                                   | 316 |
| 1.1.4. Comunhão .....                                                                                       | 317 |
| 1.2. Sistema de valoração da prova adotado pelo CPP .....                                                   | 317 |
| 1.3. Elementos de informação produzidos na investigação policial.....                                       | 317 |
| 1.4. Estado civil das pessoas .....                                                                         | 319 |
| 1.5. Ônus probatório .....                                                                                  | 319 |
| 1.6. Iniciativa probatória do juiz.....                                                                     | 319 |
| 1.7. Inadmissibilidade das provas ilegais .....                                                             | 320 |
| 1.7.1. Ilícitude por derivação (teoria dos frutos da árvore envenenada) .....                               | 321 |
| 1.7.1.1. Teoria ou exceção da fonte independente .....                                                      | 321 |
| 1.7.1.2. Descoberta inevitável (exceção da fonte hipotética independente) .....                             | 322 |
| 1.7.1.3. Descontaminação do julgado .....                                                                   | 323 |
| 2. Provas em espécie.....                                                                                   | 323 |
| 2.1. Do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral (arts. 158 a 184, CPP)..... | 323 |
| 2.1.1. Introdução, conceito, infrações que o exigem, espécies e local/horário de realização.....            | 323 |
| 2.1.2. Prioridade na realização do exame de corpo de delito .....                                           | 325 |
| 2.1.3. Número de peritos .....                                                                              | 325 |
| 2.1.4. Ausência do exame de corpo de delito .....                                                           | 325 |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1.5. Divergência entre os peritos .....                        | 326 |
| 2.1.6. Não adstrição ao laudo .....                              | 326 |
| 2.1.7. Possibilidade de recusa à realização de perícia .....     | 326 |
| 2.1.8. Exame pericial por carta precatória.....                  | 326 |
| 2.1.9. Assistente técnico .....                                  | 327 |
| 2.1.10. Esclarecimentos periciais e formulação de quesitos ..... | 327 |
| 2.1.11. Cadeia de custódia .....                                 | 328 |
| 2.2. Interrogatório do réu (arts. 185 a 196, CPP) .....          | 329 |
| 2.2.1. Introdução .....                                          | 329 |
| 2.2.2. Necessidade de acompanhamento por advogado.....           | 329 |
| 2.2.3. Fases do interrogatório .....                             | 329 |
| 2.2.4. Advertência quanto ao direito ao silêncio .....           | 330 |
| 2.2.5. Momento para a realização do interrogatório .....         | 331 |
| 2.2.6. Faculdade de perguntas pela acusação e defesa .....       | 331 |
| 2.2.7. Interrogatório de corréus .....                           | 331 |
| 2.2.8. Interrogatório do réu preso .....                         | 332 |
| 2.2.9. Oralidade do interrogatório.....                          | 332 |
| 2.2.10. Designação de intérprete.....                            | 333 |
| 2.3. Confissão (arts. 197 a 200, CPP).....                       | 333 |
| 2.3.1. Introdução .....                                          | 333 |
| 2.3.2. Características da confissão .....                        | 333 |
| 2.3.3. Espécies de confissão .....                               | 333 |
| 2.4. Declarações do ofendido (art. 201, CPP) .....               | 334 |
| 2.5. Testemunhas (arts. 202 a 225, CPP) .....                    | 335 |
| 2.5.1. Introdução e capacidade para ser testemunha .....         | 335 |
| 2.5.2. Características da prova testemunhal .....                | 335 |
| 2.5.2.1. Oralidade .....                                         | 335 |
| 2.5.2.2. Objetividade.....                                       | 336 |
| 2.5.2.3. Retrospectividade.....                                  | 336 |

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.5.2.4. Individualidade e incomunicabilidade.....                           | 336 |
| 2.5.3. Deveres das testemunhas.....                                          | 336 |
| 2.5.3.1. Dever de depor.....                                                 | 336 |
| 2.5.3.2. Dever de comparecimento.....                                        | 337 |
| 2.5.3.3. Dever de dizer a verdade.....                                       | 338 |
| 2.5.4. Presença do réu gerando constrangimento à vítima ou à testemunha..... | 339 |
| 2.5.5. Forma de inquirição das testemunhas.....                              | 340 |
| 2.5.6. Momento adequado para indicação do rol de testemunhas.....            | 340 |
| 2.5.7. Espécies de testemunhas.....                                          | 340 |
| 2.6. Reconhecimento de pessoas e coisas (arts. 226 a 228, CPP).....          | 342 |
| 2.6.1. Introdução.....                                                       | 342 |
| 2.6.2. Procedimento e inexistência de nulidade.....                          | 342 |
| 2.6.2.1. Procedimento em juízo e proteção ao reconhecedor.....               | 343 |
| 2.6.3. Reconhecimento fotográfico.....                                       | 343 |
| 2.6.4. Reconhecimento fonográfico ou clichê fônico.....                      | 343 |
| 2.6.5. Reconhecimento por videoconferência.....                              | 343 |
| 2.7. Acareação (arts. 229 e 230, CPP).....                                   | 343 |
| 2.8. Documentos (arts. 231 a 238, CPP).....                                  | 344 |
| 2.8.1. Introdução e espécies.....                                            | 344 |
| 2.8.2. Momento para a produção da prova documental (em sentido lato).....    | 345 |
| 2.8.3. Cartas particulares.....                                              | 346 |
| 2.8.4. Requisição de documento pelo juiz.....                                | 346 |
| 2.8.5. Documentos em língua estrangeira.....                                 | 346 |
| 2.8.6. Restituição de documentos.....                                        | 346 |
| 2.9. Indícios (art. 239, CPP).....                                           | 347 |
| 2.9.1. Indícios como prova indireta.....                                     | 347 |
| 2.9.2. Indício como prova semiplena.....                                     | 347 |
| 2.9.3. Contraindícios.....                                                   | 347 |
| 2.10. Busca e apreensão (arts. 240 a 250, CPP).....                          | 348 |

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.10.1. Conceitos e natureza jurídica .....                                                    | 348 |
| 2.10.2. Momento para a realização .....                                                        | 348 |
| 2.10.3. Iniciativa da medida .....                                                             | 348 |
| 2.10.4. Formalidades do mandado .....                                                          | 349 |
| 2.10.5. Espécies de busca .....                                                                | 350 |
| 2.10.5.1. Busca pessoal .....                                                                  | 350 |
| 2.10.5.2. Busca domiciliar.....                                                                | 351 |
| 2.10.6. Busca em território de jurisdição alheia .....                                         | 355 |
| 2.10.7. Busca infrutífera.....                                                                 | 355 |
| 2.10.8. Acesso a mensagens de aplicativos telemáticos.....                                     | 355 |
| 3. Informativos de Jurisprudência .....                                                        | 356 |
| 3.1. Supremo Tribunal Federal .....                                                            | 356 |
| 3.2. Superior Tribunal de Justiça .....                                                        | 357 |
| Questões .....                                                                                 | 363 |
| Comentários .....                                                                              | 365 |
| Capítulo 17 – Sujeitos processuais (arts. 251 a 281, CPP) .....                                | 368 |
| 1. Introdução .....                                                                            | 368 |
| 2. Juiz (arts. 251 a 256, CPP) .....                                                           | 368 |
| 2.1. Princípio do Juiz natural .....                                                           | 369 |
| 2.2. Prerrogativas dos magistrados .....                                                       | 369 |
| 2.3. Vedações aos magistrados .....                                                            | 370 |
| 2.4. Imparcialidade dos juízes .....                                                           | 371 |
| 2.5. Causas de impedimento (art. 252 do CPP).....                                              | 371 |
| 2.5.1. Efeito das causas de impedimento .....                                                  | 371 |
| 2.6. Juízos coletivos (art. 253 do CPP).....                                                   | 372 |
| 2.7. Causas de suspeição (art. 254 do CPP) .....                                               | 372 |
| 2.7.1. Efeito das causas de suspeição.....                                                     | 373 |
| 2.8. Cessaç o e manuten o das causas de impedimento ou de suspeição (art. 255 do CPP)<br>..... | 373 |
| 2.9. Animosidade por má-f  (art. 256 do CPP) .....                                             | 373 |
| 2.10. Incompatibilidade .....                                                                  | 373 |

|                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>3. Do Ministério Público (Arts. 257 e 258, CPP).....</b>                                                | <b>374</b> |
| 3.1. Disposições constitucionais .....                                                                     | 374        |
| 3.2. Garantias dos membros do Ministério Público .....                                                     | 374        |
| 3.3. Vedações aos membros do Ministério Público .....                                                      | 374        |
| 3.4. Atuação do Ministério Público .....                                                                   | 375        |
| 3.5. Causas de impedimento e suspeição dos membros do Ministério Público (art. 258 do CPP) .....           | 375        |
| 3.6. Princípio do Promotor natural e imparcial ou promotor legal .....                                     | 375        |
| <b>4. Do acusado e seu defensor (arts. 259 a 267, CPP) .....</b>                                           | <b>375</b> |
| 4.1. Acusado: definição e peça acusatória sem dados qualificativos (art. 259 do CPP).....                  | 375        |
| 4.2. Condução coercitiva do acusado (art. 260 do CPP) .....                                                | 376        |
| 4.2.1. Autoridade competente para a determinação da condução coercitiva do investigado acusado .....       | 376        |
| 4.3. Da indisponibilidade da defesa técnica (art. 261 do CPP).....                                         | 377        |
| 4.4. Curador (art. 262 do CPP).....                                                                        | 377        |
| 4.5. Direito de escolha do próprio defensor (arts. 263 e 264 do CPP).....                                  | 377        |
| 4.6. Abandono da causa e não comparecimento à audiência (art. 265 do CPP) .....                            | 378        |
| 4.7. Constituição de advogado no ato de interrogatório (art. 266 do CPP) .....                             | 379        |
| 4.8. Impedimento do advogado (art. 267 do CPP) .....                                                       | 379        |
| <b>5. Do assistente de acusação (arts. 268 a 273 do CPP) .....</b>                                         | <b>379</b> |
| 5.1. Conceito, tipos de ação penal que o admitem, legitimados e momento de ingresso (art. 268 do CPP)..... | 379        |
| 5.2. Desnecessidade de procuração com poderes especiais para a Defensoria Pública .....                    | 379        |
| 5.3. Poderes do assistente de acusação.....                                                                | 379        |
| 5.4. Intimação e não comparecimento do assistente (arts. 271, §2º, e 457 do CPP) .....                     | 381        |
| 5.5. Oitiva do MP e recurso contra a inadmissão do assistente (arts. 272 e 273 do CPP) ...                 | 381        |
| <b>6. Funcionários da Justiça (Art. 274 do CPP) .....</b>                                                  | <b>382</b> |
| <b>7. Peritos (art. 275 a 280) .....</b>                                                                   | <b>382</b> |
| 7.1. Conceito e disciplina judiciária (art. 275 do CPP) .....                                              | 382        |
| 7.2. Nomeação dos peritos (art. 276 do CPP) .....                                                          | 382        |
| 7.3. Possibilidade de multa por recusa ao encargo e/ou por desídia (art. 277 do CPP) .....                 | 382        |

|                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.4. Possibilidade de condução coercitiva do perito (art. 278 do CPP) .....                           | 382        |
| 7.5. Pessoas que não poderão funcionar como perito (art. 279 do CPP) .....                            | 383        |
| 7.6. Suspeição dos peritos (art. 280 do CPP) .....                                                    | 383        |
| 8. Intérpretes (art. 281 do CPP) .....                                                                | 383        |
| 9. Informativos de Jurisprudência .....                                                               | 383        |
| 9.1. Supremo Tribunal Federal .....                                                                   | 383        |
| 9.2. Superior Tribunal de Justiça .....                                                               | 383        |
| Questões .....                                                                                        | 384        |
| Comentários .....                                                                                     | 384        |
| <b>Capítulo 18 – Prisão, Medidas Cautelares e Liberdade Provisória (Arts. 282 a 350 do CPP) .....</b> | <b>386</b> |
| 1. Mudança de paradigma .....                                                                         | 386        |
| 1.1. Antes de 2011.....                                                                               | 386        |
| 1.2. Após 2011 (Lei nº 12.403/2011).....                                                              | 386        |
| 1.3. Lei Anticrime (13.964/2019) .....                                                                | 386        |
| 2. JUIZ DAS GARANTIAS .....                                                                           | 387        |
| 3. Disposições gerais .....                                                                           | 388        |
| 3.1. Análise dos arts. 283 e 293 do CPP .....                                                         | 388        |
| 3.2. Uso da força .....                                                                               | 389        |
| 3.3. O que precisa constar no mandado de prisão? .....                                                | 389        |
| 3.4. Uso de algema .....                                                                              | 390        |
| 3.5. Banco Nacional de Mandados de Prisão .....                                                       | 391        |
| 3.6. Prisão especial .....                                                                            | 391        |
| 4. Prisão em flagrante .....                                                                          | 393        |
| 4.1. Noções gerais .....                                                                              | 393        |
| 4.2. Legitimidade para prender em flagrante.....                                                      | 393        |
| 4.3. Espécies de flagrante delito.....                                                                | 394        |
| 4.4. Crime permanente.....                                                                            | 395        |
| 4.5. Crime habitual .....                                                                             | 395        |
| 4.6. Crime continuado .....                                                                           | 395        |
| 4.7. Crime de ação penal privada e condicionada à representação .....                                 | 396        |
| 4.8. Infração de menor potencial ofensivo .....                                                       | 396        |

|                                                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.9. Sujeitos do flagrante .....                                                                                                                            | 396 |
| 4.9.1. Sujeito ativo.....                                                                                                                                   | 396 |
| 4.9.2. Sujeito passivo .....                                                                                                                                | 396 |
| 4.10. Autoridade competente .....                                                                                                                           | 396 |
| 4.11. Procedimentos e formalidade .....                                                                                                                     | 397 |
| 4.12. Testemunhas instrumentárias .....                                                                                                                     | 397 |
| 4.13. Envio do auto de prisão em flagrante .....                                                                                                            | 398 |
| 4.14. Nota de culpa .....                                                                                                                                   | 398 |
| 4.15. Remessa à autoridade.....                                                                                                                             | 398 |
| 5. Análise do art. 310 do CPP .....                                                                                                                         | 398 |
| 5.1. Audiência de custódia .....                                                                                                                            | 399 |
| 5.2. Finalidades da audiência de custódia.....                                                                                                              | 401 |
| 5.3. Não é cabível a realização de audiência de custódia por meio de videoconferência (Informativo nº 663, STJ): .....                                      | 402 |
| 5.4. A decisão tomada em audiência de custódia pelo relaxamento da prisão em flagrante não faz coisa julgada e permite que o promotor ofereça denúncia..... | 403 |
| 5.5. Prisão preventiva obrigatória/automática .....                                                                                                         | 403 |
| 5.6. Responsabilização pela não realização da audiência de custódia .....                                                                                   | 404 |
| 5.7. É possível o juiz “converter a prisão em flagrante em preventiva” de ofício? .....                                                                     | 405 |
| 6. Prisão preventiva .....                                                                                                                                  | 405 |
| 6.1. Conceito .....                                                                                                                                         | 405 |
| 6.2. Análise do art. 311 do CPP .....                                                                                                                       | 406 |
| 6.3. Pressupostos, fundamentos e admissibilidade da prisão preventiva .....                                                                                 | 406 |
| 6.4. Pressupostos positivos: fumaça do cometimento do delito ( <i>fumus commissi delicti</i> ).....                                                         | 408 |
| 6.5. Pressupostos negativos (art. 314 do CPP) .....                                                                                                         | 408 |
| 6.6. Fundamentos .....                                                                                                                                      | 408 |
| 6.7. Condições de admissibilidade da prisão preventiva .....                                                                                                | 410 |
| 6.8. Modalidades de prisão preventiva .....                                                                                                                 | 411 |
| 6.9. Sistema recursal .....                                                                                                                                 | 412 |
| 6.10. Apresentação espontânea .....                                                                                                                         | 413 |
| 6.11. Preventiva X excludente de ilicitude .....                                                                                                            | 413 |



|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.13. Caráter provisório da prisão preventiva (art. 316, <i>caput</i> , do CPP) ..... | 414 |
| 6.14. Prazo para revisão da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP) .....  | 415 |
| 7. Prisão domiciliar .....                                                            | 416 |
| 8. Medidas cautelares diversas da prisão .....                                        | 418 |
| 8.1. Introdução.....                                                                  | 418 |
| 8.2. O art. 319 é rol taxativo ou exemplificativo?.....                               | 419 |
| 8.3. Aplicação de forma isolada ou cumulativamente .....                              | 421 |
| 8.4. Análise dos arts. 319 e 320 do CPP .....                                         | 421 |
| 8.5. Análise do art. 282 do CPP .....                                                 | 423 |
| 8.6. Existe prazo de duração das cautelares? .....                                    | 425 |
| 8.7. Detração penal .....                                                             | 425 |
| 9. Fiança .....                                                                       | 426 |
| 9.1. Quebra da fiança .....                                                           | 427 |
| 9.2. Perda da fiança .....                                                            | 427 |
| 9.3. Cassação da fiança .....                                                         | 428 |
| 9.4. Reforço da fiança .....                                                          | 428 |
| 9.5. Dispensa da fiança .....                                                         | 428 |
| 10. Prisão temporária.....                                                            | 428 |
| Questões .....                                                                        | 430 |
| Comentários .....                                                                     | 435 |
| Capítulo 19 – Comunicação dos Atos Processuais (Arts. 351 a 372 do CPP) .....         | 441 |
| 1. Citação.....                                                                       | 441 |
| 1.1. Espécies de citação .....                                                        | 441 |
| 1.1.1. Por mandado (art. 351do CPP).....                                              | 442 |
| 1.1.2. Citação porcartaprecatória (art. 353 do CPP).....                              | 442 |
| 1.1.3. Citação do militar (art. 358 do CPP).....                                      | 443 |
| 1.1.4. Citação do funcionário público (art. 359 do CPP) .....                         | 443 |
| 1.1.5. Citação do preso (art. 360 do CPP) .....                                       | 443 |
| 1.1.6. Citação no estrangeiro (art. 368 do CPP) .....                                 | 443 |
| 1.1.7. Citação em legações estrangeiras (art. 369 do CPP) .....                       | 444 |
| 1.1.8. Citação por hora certa .....                                                   | 444 |

|                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.1.9. Citação por edital .....                                                                                         | 445 |
| 2. Intimação.....                                                                                                       | 448 |
| 3. Revelia.....                                                                                                         | 450 |
| 4. Contagem de prazos .....                                                                                             | 450 |
| 5. Informativos de Jurisprudência.....                                                                                  | 451 |
| 5.1. Supremo Tribunal Federal .....                                                                                     | 451 |
| 5.2. Superior Tribunal de Justiça .....                                                                                 | 451 |
| Questões .....                                                                                                          | 451 |
| Comentários .....                                                                                                       | 453 |
| Capítulo 20 – Da sentença (arts. 381 a 392 do CPP) .....                                                                | 456 |
| 1. Introdução .....                                                                                                     | 456 |
| 2. Classificação das sentenças.....                                                                                     | 457 |
| 3. Requisitos da sentença .....                                                                                         | 458 |
| 3.1. Relatório .....                                                                                                    | 458 |
| 3.2. Fundamentação.....                                                                                                 | 458 |
| 3.3. Dispositivo.....                                                                                                   | 460 |
| 4. Embargos de declaração .....                                                                                         | 460 |
| 5. Emendatio libelli (art. 383 do CPP) .....                                                                            | 460 |
| 6. <i>Mutatio libelli</i> (art 384 do CPP).....                                                                         | 461 |
| 7. Análise do art. 385 do CPP .....                                                                                     | 464 |
| 8. Sentença absolutória (art. 386 do CPP) .....                                                                         | 464 |
| 9. Providências ao proferir a sentença condenatória .....                                                               | 465 |
| 9.1. Fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, CPP) .....                  | 466 |
| 9.2. Necessidade de fundamentação da prisão que decorre de sentença condenatória recorrível (art. 387, § 1º, CPP) ..... | 467 |
| 9.3. Detração penal (art. 387, § 2º, CPP).....                                                                          | 467 |
| 10. Intimação da sentença.....                                                                                          | 468 |
| Questões .....                                                                                                          | 469 |
| Comentários .....                                                                                                       | 470 |
| Capítulo 21 – Procedimento Penal.....                                                                                   | 473 |
| 1. Introdução .....                                                                                                     | 473 |
| 2. Procedimento Comum.....                                                                                              | 474 |
| 2.1. Procedimento Comum Ordinário (arts. 395 a 405 do CPP) .....                                                        | 474 |

|                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.2. Procedimento Comum Sumário (arts. 531 a 538 do CPP).....                                                     | 479 |
| 2.3. Procedimento Comum Sumaríssimo (Lei nº 9.099/95).....                                                        | 480 |
| 2.3.1. A respeito da fixação da competência dos Juizados .....                                                    | 480 |
| 2.3.2. Competência territorial .....                                                                              | 482 |
| 2.3.3. Princípios norteadores e objetivos .....                                                                   | 482 |
| 2.3.4. Conexão ou continência .....                                                                               | 482 |
| 2.3.5. Regras para a prática de atos processuais .....                                                            | 483 |
| 2.3.6. Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO (art. 69) .....                                                  | 483 |
| 2.3.7. Audiência preliminar – composição civil dos danos .....                                                    | 483 |
| 2.3.8. Audiência preliminar – transação penal .....                                                               | 484 |
| 2.3.10. Fase recursal dos juizados especiais criminais.....                                                       | 488 |
| 2.3.10.1. Apelação (art. 82) .....                                                                                | 488 |
| 2.3.10.2. Embargos de declaração.....                                                                             | 488 |
| 2.3.11. Suspensão condicional do processo .....                                                                   | 489 |
| 3. Procedimentos Especiais previstos no Código de Processo Penal .....                                            | 494 |
| 3.1. Procedimento para crimes de responsabilidade cometidos por funcionário público (arts. 513 a 518 do CPP)..... | 494 |
| 3.2. Procedimento Especial dos crimes contra a honra (arts. 519 a 523 do CPP) .....                               | 495 |
| 3.3. Procedimento Especial dos crimes contra a propriedade imaterial (arts. 524 a 530-I do CPP) .....             | 497 |
| 3.4. Procedimento Especial do Tribunal do Júri (arts. 406 a 497 do CPP).....                                      | 497 |
| 3.4.1. <i>Judicium accusationis</i> .....                                                                         | 498 |
| 3.4.1.1. Impronúncia (art. 414 do CPP).....                                                                       | 499 |
| 3.4.1.2. Desclassificação (art. 419 do CPP).....                                                                  | 499 |
| 3.4.1.3. Absolvição sumária (art. 415 do CPP).....                                                                | 499 |
| 3.4.1.4. Pronúncia (art. 413 do CPP).....                                                                         | 500 |
| 3.4.2. <i>Judicium causae</i> : fase do julgamento .....                                                          | 501 |
| 4. Informativos de Jurisprudência .....                                                                           | 506 |
| 4.1. Supremo Tribunal Federal .....                                                                               | 506 |
| 4.2. Superior Tribunal de Justiça .....                                                                           | 508 |
| QUESTÕES .....                                                                                                    | 514 |

|                                                                                                                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Comentários .....                                                                                                                                                                              | 521 |
| Capítulo 22 – Das Nulidades (Arts. 563 a 573, CPP) .....                                                                                                                                       | 527 |
| 1. Conceito .....                                                                                                                                                                              | 527 |
| 1.1. Vícios ocorridos durante a investigação .....                                                                                                                                             | 527 |
| 1.2. Espécies de irregularidades .....                                                                                                                                                         | 528 |
| 1.3. Espécies de atos processuais .....                                                                                                                                                        | 528 |
| 1.5. Princípios informativos das nulidades.....                                                                                                                                                | 529 |
| 1.5.1. Não há nulidade sem prejuízo (Princípio do <i>pas de nullité sans grief</i> ).....                                                                                                      | 529 |
| 1.5.2. Não há nulidade por omissão de formalidade que só interesse à parte contrária (princípio do interesse) .....                                                                            | 529 |
| 1.5.3. Não há nulidade provocada pela parte (princípio da lealdade ou da boa-fé).....                                                                                                          | 530 |
| 1.5.4. A nulidade de ato processual relevante pode desencadear a dos consequentes (princípio da causalidade, efeito expansivo, sequencialidade, contaminação ou consequentialidade) .....      | 530 |
| 1.5.5. Princípio da conservação dos atos processuais (confinamento da nulidade).....                                                                                                           | 531 |
| 1.5.6. Não há nulidade de ato irrelevante para o deslinde da causa.....                                                                                                                        | 531 |
| 1.5.7. Princípio da convalidação, aproveitamento ou proteção .....                                                                                                                             | 531 |
| 2. Espécies de nulidades .....                                                                                                                                                                 | 531 |
| 2.1. Nulidades absolutas.....                                                                                                                                                                  | 531 |
| 2.2. Nulidades relativas .....                                                                                                                                                                 | 532 |
| 2.2.1. Momento para a arguição das nulidades relativas .....                                                                                                                                   | 533 |
| 2.2.2. Convalidação das nulidades relativas (art. 572, CPP) .....                                                                                                                              | 534 |
| 3. Nulidades em espécie.....                                                                                                                                                                   | 535 |
| 3.1. Incompetência do juízo (art. 564, inciso I, 1ª parte, CPP) .....                                                                                                                          | 535 |
| 3.1.1. Consequências do reconhecimento da incompetência.....                                                                                                                                   | 535 |
| 3.2. Suspeição do juízo (art. 564, inciso I, parte final, CPP) .....                                                                                                                           | 536 |
| 3.3. Suborno do juiz (art. 564, inciso I, parte final, CPP) .....                                                                                                                              | 536 |
| 3.4. Ilegitimidade de parte (art. 564, inciso II, CPP) .....                                                                                                                                   | 536 |
| 3.4.1. Saneamento da ilegitimidade <i>ad processum</i> (art. 568 do CPP) .....                                                                                                                 | 536 |
| 3.5. Falta de denúncia, queixa-crime ou representação e, nos processos de contravenções penais, de portaria ou de auto de prisão em flagrante (art. 564, inciso III, alínea <i>a</i> , CPP) .. | 537 |

|                                                                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.6. Ausência do exame de corpo de delito, ressalvado o disposto no art. 167 do CPP (art. 564, inciso III, alínea <i>b</i> , CPP).....                                                                 | 537 |
| 3.7. Falta de nomeação de defensor ao acusado presente, que não o tiver, ou ao ausente, e de curador ao menor de 21 (vinte e um) anos (art. 564, inciso III, alínea <i>c</i> , CPP) .....              | 537 |
| 3.8. Não intervenção do Ministério Público (art. 564, inciso III, alínea <i>d</i> , CPP) .....                                                                                                         | 538 |
| 3.9. Ausência de citação (circundução), do interrogatório do acusado e de concessão dos prazos à acusação e à defesa (art. 564, inciso III, alínea <i>e</i> , CPP) .....                               | 538 |
| 3.10. Ausência da decisão de pronúncia (art. 564, inciso III, alínea <i>f</i> , 1ª parte, CPP) .....                                                                                                   | 539 |
| 3.11. Falta do libelo acusatório e da entrega da respectiva cópia, com o rol de testemunhas, nos processos perante o Tribunal do Júri (art. 564, inciso III, alínea <i>f</i> , parte final, CPP) ..... | 539 |
| 3.12. Falta de intimação do acusado para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia (art. 564, inciso III, alínea <i>g</i> , CPP).....             | 540 |
| 3.13. Falta de intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade, nos termos estabelecidos pela lei (art. 564, inciso III, alínea <i>h</i> , CPP) .....                                 | 540 |
| 3.14. Falta da presença de pelo menos 15 (quinze) jurados para a constituição do júri (art. 564, inciso III, alínea <i>i</i> , CPP).....                                                               | 541 |
| 3.15. Falta do sorteio dos jurados do Conselho de Sentença em número legal (art. 564, inciso III, alínea <i>j</i> , 1ª parte, CPP).....                                                                | 541 |
| 3.16. Inobservância da incomunicabilidade dos jurados (art. 564, inciso III, alínea <i>j</i> , parte final, CPP) .....                                                                                 | 542 |
| 3.17. Nulidade na formulação dos quesitos e das respectivas respostas (art. 564, inciso III, alínea <i>k</i> e parágrafo único, CPP).....                                                              | 542 |
| 3.18. Falta da acusação e da defesa, na sessão de julgamento em plenário do Tribunal do Júri (art. 564, inciso III, alínea <i>l</i> , CPP) .....                                                       | 543 |
| 3.19. Falta da sentença (art. 564, inciso III, alínea <i>m</i> , CPP) .....                                                                                                                            | 543 |
| 3.20. Falta do recurso de ofício, nos casos em que a lei o tenha estabelecido (art. 564, inciso III, alínea <i>n</i> , CPP) .....                                                                      | 543 |
| 3.21. Falta de intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para ciência das sentenças e despachos de que caiba recurso (art. 564, inciso III, alínea <i>o</i> , CPP) .....                        | 544 |
| 3.22. Inocorrência de quórum legal para o julgamento nos Tribunais Superiores, Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais (art. 564, inciso III, alínea <i>p</i> , CPP).....                  | 544 |
| 3.23. Omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato (art. 564, inciso IV, CPP).....                                                                                                   | 544 |
| 3.23.1. Omissões da peça acusatória ou da representação (art. 569 do CPP).....                                                                                                                         | 544 |
| 3.24. Ausência de fundamentação (art. 564, inciso V, CPP) .....                                                                                                                                        | 545 |
| 4. Informativos de Jurisprudência.....                                                                                                                                                                 | 546 |

|                                                                                                                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.1. Supremo Tribunal Federal .....                                                                                                                                                            | 546        |
| 4.2. Superior Tribunal de Justiça .....                                                                                                                                                        | 546        |
| Questões .....                                                                                                                                                                                 | 547        |
| Comentários .....                                                                                                                                                                              | 547        |
| <b>Capítulo 23 – Dos Recursos Criminais (Arts. 574 a 646, CPP) .....</b>                                                                                                                       | <b>549</b> |
| 1. Teoria geral dos recursos (arts. 574 a 580, CPP) .....                                                                                                                                      | 549        |
| 1.1. Conceito, fundamentos e características.....                                                                                                                                              | 549        |
| 1.2. Natureza jurídica .....                                                                                                                                                                   | 550        |
| 1.3. Princípios atinentes .....                                                                                                                                                                | 550        |
| 1.3.1. Duplo grau de jurisdição .....                                                                                                                                                          | 550        |
| 1.3.2. Taxatividade dos recursos .....                                                                                                                                                         | 551        |
| 1.3.3. Unirrecorribilidade das decisões .....                                                                                                                                                  | 551        |
| 1.3.4. Fungibilidade recursal ("teoria do recurso indiferente", "teoria do 'tanto vale'",<br>princípio da permutabilidade dos recursos ou princípio da conversibilidade dos recursos)<br>..... | 552        |
| 1.3.5. Voluntariedade .....                                                                                                                                                                    | 552        |
| 1.3.6. Disponibilidade .....                                                                                                                                                                   | 554        |
| 1.3.7. <i>Non reformatio in pejus</i> (efeito prodrômico da sentença).....                                                                                                                     | 554        |
| 1.3.7.1 <i>Non reformatio in pejus</i> indireta .....                                                                                                                                          | 555        |
| 1.3.8. <i>Reformatio in melius</i> .....                                                                                                                                                       | 555        |
| 1.4. Juízo de admissibilidade dos recursos (juízo de prelibação) .....                                                                                                                         | 556        |
| 1.4.1. Pressupostos recursais objetivos .....                                                                                                                                                  | 556        |
| 1.4.1.1. Cabimento do recurso.....                                                                                                                                                             | 556        |
| 1.4.1.3. Forma legal.....                                                                                                                                                                      | 560        |
| 1.4.1.4. Preparo .....                                                                                                                                                                         | 560        |
| 1.4.2. Pressupostos recursais subjetivos .....                                                                                                                                                 | 561        |
| 1.4.2.1. Legitimidade.....                                                                                                                                                                     | 561        |
| 1.4.2.2. Interesse em recorrer.....                                                                                                                                                            | 564        |
| 1.4.3. Efeitos dos recursos.....                                                                                                                                                               | 565        |
| 1.4.3.1. Efeito extensivo .....                                                                                                                                                                | 565        |
| 1.4.3.2. Efeito devolutivo .....                                                                                                                                                               | 566        |

|                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.4.3.3. Efeito suspensivo .....                                                                                                                                                                                  | 566 |
| 1.4.3.4. Efeito translativo .....                                                                                                                                                                                 | 566 |
| 1.4.3.5. Efeito regressivo, iterativo ou diferido.....                                                                                                                                                            | 567 |
| 2. Dos recursos em espécies (arts. 581 a 620, CPP) .....                                                                                                                                                          | 567 |
| 2.1. Do recurso em sentido estrito (arts. 581 ao 592, CPP) .....                                                                                                                                                  | 567 |
| 2.1.1. Conceito, noções acerca do cabimento e possibilidade de interpretação extensiva .....                                                                                                                      | 567 |
| 2.1.2. Hipóteses fora do Código de Processo Penal .....                                                                                                                                                           | 567 |
| 2.1.3. Prazo para interposição e apresentação de razões/contrarrazões .....                                                                                                                                       | 568 |
| 2.1.3.1. Regra geral .....                                                                                                                                                                                        | 568 |
| 2.1.3.2. Lista geral de jurados .....                                                                                                                                                                             | 569 |
| 2.1.4. Hipóteses de cabimento do RESE .....                                                                                                                                                                       | 569 |
| 2.1.4.1. Rejeição da peça acusatória .....                                                                                                                                                                        | 569 |
| 2.1.4.2. Incompetência do juízo .....                                                                                                                                                                             | 570 |
| 2.1.4.3. Procedência das exceções (salvo as de suspeição, impedimento e incompatibilidade).....                                                                                                                   | 570 |
| 2.1.4.4. Pronúncia do réu .....                                                                                                                                                                                   | 570 |
| 2.1.4.5. Decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante..... | 571 |
| 2.1.4.6. Quebramento ou perdimento da fiança.....                                                                                                                                                                 | 571 |
| 2.1.4.7. Extinção da punibilidade .....                                                                                                                                                                           | 571 |
| 2.1.4.8. Indeferimento do pedido de extinção da punibilidade .....                                                                                                                                                | 572 |
| 2.1.4.9. Concessão ou denegação da ordem de <i>habeas corpus</i> .....                                                                                                                                            | 572 |
| 2.1.4.12. Inclusão ou exclusão de jurados da lista geral .....                                                                                                                                                    | 574 |
| 2.1.4.13. Decisão que denega a apelação ou a julga deserta .....                                                                                                                                                  | 574 |
| 2.1.4.14. Suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial .....                                                                                                                                          | 574 |
| 2.1.4.15. Decisão sobre o incidente de falsidade .....                                                                                                                                                            | 574 |
| 2.1.4.16. Recusa à homologação da proposta de acordo de não persecução penal ....                                                                                                                                 | 574 |
| 2.1.5. Antigas hipóteses de cabimento do RESE que foram revogadas pela LEP.....                                                                                                                                   | 575 |
| 2.1.6. Aspectos procedimentais do RESE.....                                                                                                                                                                       | 575 |

|                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1.6.1. Competência para julgamento .....                                                                    | 575 |
| 2.1.6.2. Formação de instrumento .....                                                                        | 576 |
| 2.1.6.3. Ausência de efeito suspensivo.....                                                                   | 577 |
| 2.1.6.4. Efeito regressivo (iterativo ou diferido) .....                                                      | 578 |
| 2.2. Da apelação (arts. 593 ao 603, CPP) .....                                                                | 578 |
| 2.2.1. Apelação plena (ou ampla) ou limitada (parcial ou restrita) .....                                      | 578 |
| 2.2.1.1. Regra geral .....                                                                                    | 578 |
| 2.2.1.2. Rito do Júri .....                                                                                   | 579 |
| 2.2.2. Prazos .....                                                                                           | 579 |
| 2.2.3. Razões e contrarrazões recursais: ausência e possibilidade de apresentação na instância superior ..... | 580 |
| 2.2.4. Hipóteses de cabimento .....                                                                           | 580 |
| 2.2.4.1. Juízo singular .....                                                                                 | 580 |
| 2.2.4.2. Decisões do Tribunal do Júri .....                                                                   | 581 |
| 2.2.5. Princípio da unirrecorribilidade das decisões (unicidade ou singularidade recursal) .....              | 584 |
| 2.2.6. Competência para julgamento .....                                                                      | 585 |
| 2.2.7. Efeito suspensivo .....                                                                                | 585 |
| 2.3. Embargos infringentes e de nulidade (art. 619, CPP) .....                                                | 586 |
| 2.3.1. Introdução e cabimento .....                                                                           | 586 |
| 2.3.2. Divergência parcial .....                                                                              | 586 |
| 2.3.3. Prazo e forma de interposição .....                                                                    | 586 |
| 2.4. Embargos de declaração .....                                                                             | 587 |
| 2.4.1. Introdução e cabimento .....                                                                           | 587 |
| 2.4.2. Prazos .....                                                                                           | 587 |
| 2.4.2.1. Juízo singular ("embarginhos") .....                                                                 | 587 |
| 2.4.2.2. Acórdãos de Tribunais de 2ª instância .....                                                          | 588 |
| 2.4.2.3. Juizados Especiais Criminais .....                                                                   | 588 |
| 2.4.3. Efeitos infringentes nos embargos declaratórios.....                                                   | 589 |
| 2.5. Carta testemunhável (arts. 639 ao 646, CPP).....                                                         | 589 |



|                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.5.1. Introdução .....                                                                                             | 589 |
| 2.5.2. Cabimento .....                                                                                              | 589 |
| 2.5.3. Procedimento .....                                                                                           | 590 |
| 2.5.4. Prazo e forma de processamento.....                                                                          | 590 |
| 2.5.4.1. Efeito regressivo (iterativo ou diferido) .....                                                            | 590 |
| 2.5.5. Ausência de efeito suspensivo .....                                                                          | 590 |
| 2.5.6. Possibilidade, no julgamento da carta, de enfrentamento da questão objeto do recursodenegado ou obstado..... | 590 |
| 2.6. Agravo em execução (art. 197, da Lei nº 7.210/84 — LEP) .....                                                  | 590 |
| 2.6.1. Introdução .....                                                                                             | 590 |
| 2.6.2. Procedimento .....                                                                                           | 591 |
| 2.6.3. Prazo e forma de interposição .....                                                                          | 591 |
| 2.6.4. Ausência de efeito suspensivo .....                                                                          | 591 |
| 2.7. Correição parcial.....                                                                                         | 591 |
| 2.7.1. Introdução .....                                                                                             | 591 |
| 2.7.2. Hipóteses de cabimento .....                                                                                 | 591 |
| 2.7.3. Natureza jurídica.....                                                                                       | 592 |
| 2.7.4. Legitimidade .....                                                                                           | 592 |
| 2.7.5. Efeito regressivo (iterativo ou diferido).....                                                               | 592 |
| 2.7.6. Prazo .....                                                                                                  | 593 |
| 3. Informativos de Jurisprudência.....                                                                              | 593 |
| 3.1. Supremo Tribunal Federal .....                                                                                 | 593 |
| 3.2. Superior Tribunal de Justiça .....                                                                             | 593 |
| Questões .....                                                                                                      | 594 |
| Comentários .....                                                                                                   | 596 |
| Capítulo 24 – Habeas Corpus (Arts. 647 a 667, CPP) .....                                                            | 599 |
| 1. Conceito, natureza jurídica e espécies (art. 647 do CPP) .....                                                   | 599 |
| 1.1. Punição disciplinar (art. 647, parte final, do CPP) .....                                                      | 599 |
| 1.2. Necessidade de risco ou efetivo cerceamento da liberdade de locomoção.....                                     | 600 |
| 1.3. <i>Habeas corpus</i> substitutivo .....                                                                        | 600 |

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.4. <i>Habeas corpus</i> como substitutivo da revisão criminal .....                   | 601 |
| 1.5. <i>Habeas corpus</i> e suspensão condicional do processo .....                     | 601 |
| 1.6. <i>Habeas corpus</i> e transação penal .....                                       | 601 |
| 2. Formalidades .....                                                                   | 601 |
| 2.1. Impetrante, paciente e impetrado.....                                              | 601 |
| 2.2. Petição inicial (art. 654, § 1º, do CPP) .....                                     | 602 |
| 2.3. Hipóteses de impetração (art. 648 do CPP) .....                                    | 602 |
| 2.3.1. Novo pedido de <i>habeas corpus</i> .....                                        | 604 |
| 2.4. Competência para julgamento .....                                                  | 604 |
| 2.4.1. Ministros de Estado e Comandantes do Exército, Marinha ou Aeronáutica .....      | 605 |
| 2.4.2. Juizados Especiais Criminais.....                                                | 605 |
| 2.4.3. Membro do Ministério Público como autoridade coatora .....                       | 605 |
| 2.4.4. Juiz das Garantias.....                                                          | 606 |
| 2.4.5. Cessaç o da compet ncia (art. 650, § 1º, CPP).....                               | 606 |
| 2.5. Rito procedimental (arts. 655 a 664, CPP) .....                                    | 606 |
| 2.5.1. Disposi  es gerais .....                                                         | 606 |
| 2.5.2. Possibilidade de concess o de liminar.....                                       | 606 |
| 2.5.2.1. Impossibilidade de novo HC contra decis o liminar.....                         | 607 |
| 2.5.3. Pedido de informa  es .....                                                      | 607 |
| 2.5.4. Necessidade de prova pr -constitu da .....                                       | 607 |
| 2.5.5. Rito perante o ju zo de primeira inst ncia .....                                 | 608 |
| 2.5.6. Rito perante os Tribunais de Justi a ou Tribunais Regionais Federais .....       | 608 |
| 2.5.7. Concess o do <i>habeas corpus</i> e prosseguimento do processo .....             | 609 |
| 2.5.8. Concess o de <i>habeas corpus</i> e reconhecimento de nulidade do processo ..... | 609 |
| 2.5.9. Possibilidade de pagamento de custas .....                                       | 609 |
| 2.5.10. Extens o da concess o da ordem ao corr u .....                                  | 610 |
| 2.5.11. Interven  o de terceiros .....                                                  | 610 |
| 2.6. Recursos contra as decis es proferidas em <i>habeas corpus</i> .....               | 610 |
| 2.7. Impossibilidade de complementa  o de fundamenta  o pelo Tribunal .....             | 611 |
| 2.8. <i>Habeas corpus</i> coletivo .....                                                | 611 |

|                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3. Informativos de Jurisprudência .....                                                                        | 612 |
| 3.1. Supremo Tribunal Federal .....                                                                            | 612 |
| 3.2. Superior Tribunal de Justiça .....                                                                        | 613 |
| Questões .....                                                                                                 | 613 |
| Comentários .....                                                                                              | 613 |
| Capítulo 25 – Do Mandado de Segurança em Matéria Criminal .....                                                | 615 |
| 1. Conceito e natureza jurídica .....                                                                          | 615 |
| 2. Prazo decadencial para impetração.....                                                                      | 615 |
| 3. Cabimento .....                                                                                             | 615 |
| 3.1. Vedações ao ajuizamento do mandado de segurança .....                                                     | 616 |
| 3.1.1. Impossibilidade de utilização do MS para concessão de efeito suspensivo a recurso .....                 | 617 |
| 4. Legitimidade .....                                                                                          | 617 |
| 4.1. Legitimação ativa.....                                                                                    | 617 |
| 4.2. Legitimação passiva .....                                                                                 | 617 |
| 5. Formalidades .....                                                                                          | 617 |
| 5.1. Competência para julgamento .....                                                                         | 617 |
| 5.1.1. Juizados Especiais Criminais.....                                                                       | 618 |
| 5.1.2. Membros do Ministério Público.....                                                                      | 619 |
| 5.3. Procedimento.....                                                                                         | 619 |
| 5.3.1. Procedimento perante os Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais Superiores ..... | 619 |
| 5.3.2. Procedimento perante o juiz de primeira instância.....                                                  | 620 |
| 5.4. Recursos cabíveis.....                                                                                    | 620 |
| 6. Hipóteses comuns de utilização do mandado de segurança em matéria criminal.....                             | 621 |
| 7. Informativos de Jurisprudência .....                                                                        | 621 |
| 7.1. Supremo Tribunal Federal .....                                                                            | 621 |
| 7.2. Superior Tribunal de Justiça .....                                                                        | 622 |
| Questões .....                                                                                                 | 622 |
| Comentários .....                                                                                              | 622 |
| Capítulo 26 – Da Revisão Criminal (Arts. 621 a 631, CPP).....                                                  | 624 |
| 1. Conceito e natureza jurídica .....                                                                          | 624 |

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>2. Pressupostos.....</b>                                                         | <b>624</b> |
| 2.1. Desnecessidade de esgotamento de todas as instâncias ordinárias .....          | 624        |
| 2.2. Extinção da punibilidade .....                                                 | 624        |
| 2.3. Tribunal do Júri (soberania dos veredictos — art. 5º, XXXVIII, c, CF/88) ..... | 624        |
| 2.4. Juizado Especial Criminal.....                                                 | 625        |
| <b>3. Prazo .....</b>                                                               | <b>625</b> |
| <b>4. Legitimidade ativa .....</b>                                                  | <b>625</b> |
| 4.1. Desnecessidade de advogado.....                                                | 625        |
| 4.2. Legitimidade do Ministério Público .....                                       | 625        |
| 4.3. Desnecessidade de recolhimento à prisão .....                                  | 626        |
| <b>5. Hipóteses de cabimento .....</b>                                              | <b>626</b> |
| 5.1. Mudança de entendimento jurisprudencial .....                                  | 626        |
| <b>6. Competência para julgamento .....</b>                                         | <b>627</b> |
| <b>7. Procedimento .....</b>                                                        | <b>627</b> |
| <b>8. Procedência do pedido .....</b>                                               | <b>627</b> |
| 8.1 Jus rescindens e jus rescisorium .....                                          | 628        |
| <b>9. Possibilidade de indenização .....</b>                                        | <b>628</b> |
| <b>10. Reiteração de pedidos .....</b>                                              | <b>628</b> |
| <b>11. Recursos cabíveis .....</b>                                                  | <b>629</b> |
| <b>12. Lei penal mais benéfica.....</b>                                             | <b>629</b> |
| <b>13. Informativos de Jurisprudência .....</b>                                     | <b>629</b> |
| 13.1. Superior Tribunal de Justiça .....                                            | 629        |
| <b>Questões .....</b>                                                               | <b>630</b> |
| <b>Comentários .....</b>                                                            | <b>630</b> |
| <b>Referências Bibliográficas .....</b>                                             | <b>631</b> |

## CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO AO DIREITO PROCESSUAL PENAL

### 1. NOÇÕES GERAIS

Direito substantivo é o ramo do Direito responsável pela definição de relações concretas dos membros de uma sociedade. Também chamado de Direito material, o seu foco está no que deve ser feito e não em como algo deve ser feito. Exemplo: Direito Penal.

Direito adjetivo é o ramo do direito responsável pela definição de procedimentos para a concretização das normas materiais. Também chamado de Direito formal, o seu foco está em como fazer e não no que deve ser feito. Exemplo: Direito Processual Penal.

Exemplificando, o art. 121 do Código Penal assim prevê:

Homicídio simples – “Art. 121. Matar alguém: Pena – reclusão, de seis a vinte anos.”

Essa norma apresenta um determinado comportamento proibido e informa que uma pena será aplicada caso alguém o pratique. Portanto, se você matar alguém, poderá ser apenado com reclusão de 6 a 20 anos.

É fácil notar que o art. 121 do Código Penal Brasileiro tem um caráter claramente material ou substantivo. Afinal de contas, define uma relação concreta. Veja que o legislador define apenas que o autor de um homicídio simples será apenado com a reclusão de 6 a 20 anos. No entanto, o Código Penal não explica como se dará a investigação criminal do fato; o início do processo para se chegar à aplicação da pena; não trata de pontos importantes como o processo de escolha do juiz responsável para julgar o caso; se compete à Justiça Federal ou Estadual julgar os casos de homicídio, dentre outros.

Isso acontece porque o Código Penal tem um caráter fundamentalmente material. Não cabe a ele tratar de como fazer as coisas, pois isso é assunto de Direito adjetivo! Dessa forma, as normas formais e adjetivas do Direito Penal foram separadas e, via de regra, estão concentradas em outro Código: o Código de Processo Penal (CPP), sendo objeto de estudo da nossa disciplina, o Direito Processual Penal.

Portanto, em uma primeira visão, o Direito Processual Penal cuida do instrumento que será utilizado para, ao final, ser imposta a sanção penal ou a absolvição, a depender da comprovação da culpa ou não do acusado.

José Frederico Marques afirma que o “Direito Processual Penal é o conjunto de normas que regulam a aplicação jurisdicional do Direito Penal, bem como as atividades persecutórias da Polícia Judiciária, e a estruturação dos órgãos da função jurisdicional e respectivos auxiliares.”

O Direito Processual Penal visto como instrumento de aplicação do direito material é, portanto, uma visão clássica do direito processual penal.

Em uma segunda visão, mais moderna, visão constitucional-garantista do processo (processo penal constitucional), fala-se em processo penal justo, em que não basta apenas punir, exercer o poder punitivo estatal, deve-se buscar, ainda, seguir todas as regras, princípios, direitos fundamentais.

Como o Direito Processual Penal, apesar de possuir intrínseca relação com o direito material, também tutela importantes valores como a liberdade e a proteção do indivíduo, deve se dar cumprimento aos direitos e garantias fundamentais previstos, devendo todo o regramento ser respeitado (a título de exemplo: presunção de inocência, o sistema acusatório, o convencimento motivado, a proibição de provas ilícitas, o fortalecimento do Ministério Público).

Assim, o processo penal deve ser entendido não só como meio de aplicação do Direito Penal no caso concreto (visão clássica), mas também como uma forma de proteção dos direitos fundamentais do indivíduo contra a força do Estado na persecução penal (visão moderna – processo penal constitucional).

Lembrando que, durante a persecução penal, o Estado investiga (Polícia Judiciária), acusa (Ministério Público – na ação penal pública e como fiscal da lei na ação penal privada), julga (juiz), enquanto o réu apenas se defende de todo este aparato contra ele.

Atenção: a persecução penal é o todo, havendo uma fase pré-processual (investigações criminais, que abrangem o inquérito policial) e uma fase processual (ação penal, que se inicia com o oferecimento e recebimento da peça inicial acusatória).

| Persecução Penal      |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Investigação Criminal | Fase Processual |

Portanto, o processo penal é “instrumento pelo qual se busca a reconstrução dos fatos afirmados em um processo, para fins de atuação do direito material por meio da preservação dos direitos constitucionais, servindo também de contenção para a atuação do Estado” (DEZEM, 2019, p. 60).

## 2. FINALIDADE

A finalidade do Direito Processual Penal pode ser dividida em mediata e imediata (TAVORA; ALENCAR; 2020, p. 50):

| FINALIDADES DO DIREITO PROCESSUAL PENAL                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| MEDIATA                                                  | IMEDIATA                                                  |
| Alcançar a pacificação social com a solução do conflito. | Viabilizar a aplicação do direito penal, concretizando-o. |

Portanto, classicamente, o Direito Processual Penal possui a finalidade de fazer valer o direito de punir do Estado (*jus puniendi*). De forma mediata, também busca a própria proteção da sociedade, a paz social, a defesa dos interesses jurídicos, a convivência harmônica das pessoas no território da nação (MIRABETE, 2007, p. 45).

## 3. FONTES

Falar em fontes significa imaginar a origem de algo. Portanto, falar em fontes do Direito Processual Penal significa buscar a origem das normas que regulamentam o processo penal.

Embora a classificação das fontes do direito seja criticável, pois não revela o caráter unitário do Direito, ela é ainda utilizada pela doutrina majoritária, sobretudo como forma de deixar o estudo mais didático, razão pela qual aqui também será utilizada apenas por critério metodológico.

A doutrina clássica divide as fontes do Direito em fontes formais (de cognição) e fontes materiais (de produção) (NUCCI, 2018, p. 81; MIRABETE, 2007, p. 32). Fontes formais são o modo de expressão da norma jurídica positiva, e fontes materiais são as que constituem a matéria com que é atingido o conteúdo do preceito jurídico (MARQUES, 1997, p. 39).

| FONTES FORMAIS OU DE COGNIÇÃO                     | FONTES MATERIAIS OU DE PRODUÇÃO                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Qual o veículo do direito?<br>(lei, decreto etc.) | Quem elabora a norma?<br>(União, Estados, Município) |



### 3.1. FONTES MATERIAIS OU DE PRODUÇÃO DO DIREITO PROCESSUAL PENAL

A Constituição Federal estabelece que compete à União, de maneira privativa, legislar sobre matéria processual. Nesse sentido, o art. 22, I, da CF/88 diz:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.”

Dessa forma, sempre que um Estado legislar sobre matéria processual, haverá inconstitucionalidade, uma vez que a matéria processual é de competência privativa da União.

A Constituição Federal prevê três exceções em que se permite aos Estados legislar em matéria referente a processo penal:

a) em havendo Lei Complementar autorizante, poderá o Estado legislar sobre matéria de Direito Processual Penal, nos termos do art. 22, parágrafo único da CF/88:

“Art. 22, parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.”

b) possibilidade de legislação concorrente entre a União, Estado e o Distrito Federal em se tratando de: i) direito penitenciário; ii) custas dos serviços forenses; iii) criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas; iv) procedimentos em matéria processual. Tudo conforme o art. 24, incisos I, IV, X e XI da CF/88:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

IV - custas dos serviços forenses;

X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;

XI - procedimentos em matéria processual;

c) cabe aos Estados a edição de lei de organização judiciária (em projeto de lei de iniciativa de Tribunal de Justiça), nos termos do art. 125, § 1º, CF/88:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

### 3.2. FONTES FORMAIS OU DE COGNIÇÃO DO DIREITO PROCESSUAL PENAL

É aquela que revela a lei e pode ser fonte de cognição mediata ou imediata.

#### 3.2.1. FONTE DE COGNIÇÃO IMEDIATA OU DIRETA

Quanto ao modo em que o direito processual penal é veiculado, é preciso ressaltar que a regra é a lei. Lei que deve ser considerada em sentido estrito, tendo em vista não ser possível a criação de normas processuais penais por meio de medida provisória, nos termos do art. 62, § 1º, CF/88:



Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

b) direito penal, processual penal e processual civil;

**Atenção:** o Presidente da República pode legislar, via Decreto, sobre o indulto e comutação de penas, conforme art. 84, XII, CF/88, sendo-lhe, porém, vedado legislar sobre direito penal e processual penal via medida provisória, como visto acima.

É de se ressaltar também que a norma processual penal pode ser veiculada pela Constituição Federal e em tratados e convenções internacionais. Dada a prevalência da Constituição Federal, não se pode ignorar a prevalência de normas constitucionais importantíssimas aplicáveis ao direito processual penal. Sobre tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos é importante se atentar para a previsão constitucional de que se forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

### 3.2.2. FONTE DE COGNIÇÃO MEDIATA, INDIRETA OU SUPLETIVA

Desdobra-se em costumes e princípios gerais do direito.

Discute-se se o costume pode ser considerado fonte do direito processual penal. Costume é a regra de conduta praticada de modo constante, uniforme e com consciência de obrigatoriedade, podendo ser: i) *secundum legem*: ratificam o quanto descrito na lei; ii) *praeter legem*: suprem lacunas legais; iii) *contra legem*: contrariam a lei. Atenção, no entanto, que os costumes não revogam as leis.

Para parte da doutrina, porém minoritária, o costume não pode ser considerado fonte primária do processo penal, mas pode ser considerada uma fonte secundária (MARQUES, 2007, p. 19). Para a corrente majoritária, entende-se que os costumes podem servir de base para expressas normas processuais penais (NUCCI, 2018, p. 85). Além disso, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no art. 4º, prevê expressamente a possibilidade de utilização do costume, o que reforça que também pode ser utilizado no direito processual penal (MIRABETE, 2007, p. 35; TOURINHO FILHO, 2017, p. 183).

Desse modo, o costume pode auxiliar na aplicação e mesmo na interpretação do direito processual penal, desde que seja para garantir direitos ao acusado, ou seja, para beneficiá-lo (DEZEM, 2019, p. 73). Nesse sentido, decidiu o STJ em caso relativo ao Direito Penal, mas que pode ser pensado também para a nossa disciplina (REsp 2.202/SP).

Os princípios gerais do direito também podem ser fontes formais do processo penal, sendo considerados aqueles estabelecidos de acordo com a consciência ética de um povo, ou seja, premissas éticas extraídas da legislação ou do ordenamento como um todo. O art. 3º do CPP autoriza expressamente a sua utilização no direito processual penal.

| FONTE FORMAL                   |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Imediata/direta                | <b>Constituição Federal, tratados internacionais de direitos humanos, lei</b> |
| Mediata, indireta ou supletiva | <b>Costumes e princípios gerais do direito</b>                                |

**Atenção:** há divergência em se definir a doutrina e a jurisprudência como fontes do direito. Vem prevalecendo na doutrina que elas são, na verdade, formas de se interpretar o Direito, sobretudo por não possuírem efeitos obrigatórios. Tenha atenção, apenas, às súmulas vinculantes do STF e às decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Como nesses casos há força obrigatória, a doutrina aponta que podem ser estas consideradas verdadeiras fontes do Direito.



**QUESTÕES**

**1- (2017/FAPEMS/PC-MS/Delegado de Polícia)**As fontes do Direito Processual Penal são classificadas pela doutrina com a distinção daquelas que criam a norma das que a exteriorizam. Sobre esse tema, afirma-se, com exatidão, que

- a) os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos, ratificados pelo Brasil por meio do procedimento exigido pela norma constitucional, são considerados como fontes materiais do Direito Processual Penal, pois equivalem às emendas constitucionais.
- b) cabe à União, de forma exclusiva e privativa, a elaboração de normas processuais penais, bem como legislar sobre direito penitenciário. Em questões específicas de direito local, aos Estados-membros pode ser atribuída a competência para legislar sobre processo penal, através de lei ordinária.
- c) o costume, considerado fonte de cognição supletiva, é admitido para afastar ou tornar inaplicável norma processual penal e, com isto, revogar dispositivos legais, principalmente aqueles que não se compatibilizam com o sistema processual democrático inaugurado pela Constituição Federal de 1988.
- d) apesar de a lei processual penal não autorizar explicitamente a utilização dos princípios gerais do direito, são constantemente utilizados diversos princípios processuais constitucionais na interpretação dos casos concretos.
- e) o Presidente da República, somente por meio de Decreto, pode legislar sobre indulto e comutação de penas. Trata-se de competência privativa instituída pela Constituição Federal vigente, embora possa tal atribuição ser delegada por aquele aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União.

**2- (2014/VUNESP/PC-SP/Delegado de Polícia)**Em se tratando de processo penal, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, uma fonte direta e uma fonte indireta.

- a) Costume e lei.
- b) Costume e jurisprudência.
- c) Doutrina e jurisprudência.
- d) Princípios gerais do direito e doutrina.
- e) Lei e costume.

**3- (2013/CESPE/TJ-PI/Titular notarial – adaptada)**Julgue o item:

I - A lei é fonte imediata do processo penal, e, dado o princípio da reserva legal, aos estados-membros é vedado sobre ele legislar.

**COMENTÁRIOS**

**1. Gabarito: E.**

- a) INCORRETA. Os tratados internacionais são fontes formais imediatas.
- b) INCORRETA. A competência para legislar sobre direito penitenciário é concorrente, conforme art. 24, I, CF/88.
- c) INCORRETA. Costumes não podem revogar leis.
- d) INCORRETA. Essa autorização está expressamente prevista no art. 3º do CPP.
- e) CORRETA. Art. 84 da CF/88.

**2. Gabarito: E.** Fontes diretas/imediatas: Constituição Federal, tratados internacionais de direitos humanos, lei. Fontes indiretas/mediatas/supletivas: costumes e princípios gerais do direito.

**3. Gabarito: INCORRETA.** O art. 22, parágrafo único, CF/88, prevê que Lei Complementar pode autorizar os estados-membros a legislar sobre questões específicas.

## CAPÍTULO 2 – PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO PROCESSO PENAL

### 1. NOÇÕES GERAIS

Princípio significa início, começo. É a base que inaugura determinado instituto e que lhe dá alicerce. Por isso, antes do estudo efetivo de diversos institutos importantes do processo penal, cumpre analisar cada um dos princípios do processo penal.

O ideal seria que cada princípio fosse detalhado quando do estudo da matéria diretamente a ele relacionada. Contudo, a fim de facilitar o estudo, são apresentados, desde já neste capítulo, os princípios que regem a matéria.

Não é correto imaginar a aplicação isolada dos princípios que a seguir serão estudados. Via de regra, eles formam um todo único de sistema protetivo. A explicação isolada, no entanto, facilita a compreensão.

Para fins didáticos, foi feita a separação em três categorias, abaixo descritas.

#### 1.1. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS

Estão expressos na Constituição Federal e são aplicáveis ao Processo Penal.

1. Presunção de inocência;
2. Igualdade processual ou paridade de armas;
3. Ampla defesa;
4. Plenitude de defesa;
5. Favor rei – *in dubio pro reu*;
6. Contraditório;
7. Juiz natural;
8. Publicidade;
9. Vedação das provas ilícitas;
10. Economia processual, celeridade processual, duração razoável do processo;
11. Devido processo legal;
12. Intranscendência ou pessoalidade;
13. Motivação das decisões.

#### 1.2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS IMPLÍCITOS

Não vêm expressamente previstos na Constituição Federal, mas dela retiram seu fundamento.

1. Não autoincriminação (*nemo tenetur se detegere*);
2. Iniciativa das partes;
3. Duplo grau de jurisdição;
4. Juiz imparcial;
5. Promotor natural;
6. Obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal pública;
7. Oficialidade;
8. Oficiosidade;
9. Autoritariedade;
10. Vedação de dupla punição (*ne bis in idem*).



### 1.3. PRINCÍPIOS DO PROCESSO PENAL PROPRIAMENTE DITOS

Não possuem sede constitucional, mas sim, em normas infralegais (Código de Processo Penal, legislação extravagante) e se aplicam propriamente ao direito processual penal.

1. Busca da verdade real;
  2. Oralidade, concentração, imediatidade e identidade física do juiz;
  3. Indivisibilidade da ação penal privada;
  4. Comunhão de provas;
  5. Impulso oficial;
  6. Lealdade processual;
- Abaixo há análise de cada um deles.

## 2. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS

### 2.1. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU DO ESTADO DE INOCÊNCIA OU DA SITUAÇÃO JURÍDICA DE INOCÊNCIA OU DA NÃO CULPABILIDADE (ART. 5º, LVII, CF/88)

Está expressamente previsto em nossa Constituição Federal:

“Art. 5º, LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.”

Também chamado de presunção da não culpabilidade, é um dever de tratamento de como se deve tratar a pessoa que está dentro de uma persecução penal, que está sendo investigada, e que está sendo processada e não possui uma decisão definitiva a respeito daquela situação.

Possui duas dimensões: a) interna (como o juiz trata, como o MP trata) ao processo, e b) externa (como a sociedade trata aquela pessoa, como a mídia trata aquela pessoa).

#### 2.1.1. DIMENSÃO INTERNA

a) É dever da acusação demonstrar os elementos que comprovem que o acusado é culpado.

Internamente, deve-se olhar para a acusação. Se na acusação, o MP ofereceu uma denúncia dizendo que João praticou um delito de roubo, então, incumbe esse ônus probatório, acusatório para o MP ao longo do processo demonstrar que o delito existiu, que foi João que o praticou, e apontar as provas, as testemunhas, a vítima.

b) A dúvida conduz à absolvição do réu (*in dubio pro reo*).

O ônus da acusação é todo do titular da ação penal. Se ao final da instrução processual o magistrado não se convencer, a dúvida deverá conduzir à absolvição do réu, porque a acusação não foi capaz de provar suas alegações, continuando o acusado a ser considerado inocente. Além disso, havendo dúvida, deve ser adotada a solução que mais beneficie o réu. Está previsto no art. 386, incisos II, V, VI e VII, do CPP:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

II - não haver prova da existência do fato;

V - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VI - existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VII - não existir prova suficiente para a condenação.



c) As prisões preventivas e temporárias devem ter caráter sempre excepcional (só sendo decretadas quando há verdadeira necessidade da medida). Assim como as prisões cautelares, outras medidas restritivas de direitos, tais como prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica, proibição de visitar determinados lugares, e outras, também devem ser decretadas apenas excepcionalmente. Qualquer outra medida constritiva de direitos individuais também previstas na nossa legislação somente pode ser decretada de forma excepcional. Ex.: quebra de sigilo; mandado de busca e apreensão.

### 2.1.2. DIMENSÃO EXTERNA

A dimensão externa cuida da imagem do investigado; aqui há a preocupação com julgamentos, juízos populares, com a mídia, com a população, em razão do amplo acesso às redes sociais, à internet. Desse modo, muitos casos são expostos na mídia, sendo normal a veiculação de notícias sobre crimes praticados, prisões decretadas ou revogadas, índices de criminalidade de determinada cidade. A mídia fiscaliza todo o processo, desde a prisão, o andamento processual, a conclusão (se houve condenação).

Se a mídia divulga um caso em que a pessoa acabou de ser presa, é um momento muito inicial, muita coisa pode vir a acontecer ao longo desse processo para verificar se a pessoa vai ser condenada ou não.

Ex.: Caso Escola Base. Os proprietários foram acusados de praticar pedofilia, atos contra a dignidade sexual das crianças que nela estudavam. Na época, houve divulgação, baseada em rumores, que não se confirmaram, o que acabou com a reputação dos donos da escola, vindo esta a falir. Não houve sequer condenação. Os donos, após tudo isso, não tiveram uma vida normal.

**Atenção:** a nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019) prevê vedação da exposição de preso ou acusado.

Exposição de preso ou detento:

Art. 13. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a:

I - exhibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública;

II - submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei;

III - (VETADO).

III - produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro: (Promulgação partes vetadas)

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência.

### 2.1.3. (IM)POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA

Trânsito em julgado é a expressão utilizada para informar que não há mais possibilidade de recurso de uma determinada decisão. Na esfera penal, ao dizer que transitou em julgado uma determinada sentença, dizemos que chegou a hora da execução das penas cominadas (se houver).

Se o indivíduo é condenado definitivamente a uma pena e passa a cumpri-la, dizemos que está havendo a execução definitiva da pena.

Por outro lado, se uma pessoa é condenada, mas ainda falta julgar algum recurso que ele interpôs e ele inicia o cumprimento da pena imposta, dizemos que está havendo aí uma execução provisória da pena. Isso porque a condenação ainda é provisória.

Esse assunto é polêmico e necessita de um estudo mais aprofundado para que possamos entender os motivos que levaram os Ministros do STF a decidirem, em 7 de novembro de 2019, pela impossibilidade de execução provisória da pena.

### 2.1.3.1. HISTÓRICO

O assunto deve ser analisado em quatro momentos históricos no STF:

i) até fevereiro de 2009 (da CF/88 até 2009), o STF entendia que era possível a execução provisória da pena. (STF, HC 68726);

ii) no dia 5 de fevereiro de 2009, o STF, ao julgar o HC 84078 (Rel. Min. Eros Grau), mudou de posição e passou a entender que não era mais possível a execução provisória da pena. O condenado poderia até aguardar o julgamento do REsp ou do RE preso, mas desde que estivessem previstos os pressupostos necessários para a prisão preventiva (art. 312 do CPP). Esse entendimento durou até fevereiro de 2016;

iii) no dia 17 de fevereiro de 2016, o STF, ao julgar o HC 126292 (Rel. Min. Teori Zavascki), retornou para a sua primeira posição e voltou a dizer que era possível a execução provisória da pena;

iv) no dia 7 de novembro de 2019, o STF, ao julgar as ADCs 43, 44 e 54 (Rel. Min. Marco Aurélio), retornou para a sua segunda posição e afirmou que o cumprimento da pena somente pode ter início com o esgotamento de todos os recursos.

A última posição, portanto, prevalece atualmente (impossibilidade de execução provisória da pena).

Para o devido aprofundamento sobre o tema, abaixo é colacionado resumo com os principais argumentos favoráveis e contrários à execução provisória da pena. Os trechos foram retirados do julgamento das ADCs 43, 44 e 54.

### 2.1.3.2. ARGUMENTOS FAVORÁVEIS À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA

i) É possível o início da execução da pena condenatória após a prolação de acórdão condenatório em 2º grau e isso não ofende o princípio constitucional da presunção da inocência.

ii) O recurso especial e o recurso extraordinário não possuem efeito suspensivo (art. 637 do CPP). Isso significa que, mesmo a parte tendo interposto algum desses recursos, a decisão recorrida continua produzindo efeitos. Logo, é possível a execução provisória da decisão recorrida enquanto se aguarda o julgamento do recurso.

iii) Até que seja prolatada a sentença penal, confirmada em 2º grau, deve-se presumir a inocência do réu. Mas, após esse momento, exaure-se o princípio da não culpabilidade, até porque os recursos cabíveis da decisão de segundo grau ao STJ ou STF não se prestam a discutir fatos e provas, mas apenas matéria de direito.

iv) É necessário equilibrar o princípio da presunção de inocência com a efetividade da função jurisdicional penal. Nesse equilíbrio, deve-se atender não apenas os interesses dos acusados, como também os da sociedade, diante da realidade do intrincado e complexo sistema de justiça criminal brasileiro.

v) “Em país nenhum do mundo, depois de observado o duplo grau de jurisdição, a execução de uma condenação fica suspensa aguardando referendo da Suprema Corte.”

### 2.1.3.3. ARGUMENTOS CONTRÁRIOS À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA

i) O art. 283 do CPP, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, prevê que “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”. Esse artigo é plenamente compatível com a Constituição em vigor.

ii) O inciso LVII do art. 5º da CF/88, segundo o qual “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, não deixa margem a dúvidas ou a controvérsias de interpretação.

iii) É infundada a interpretação de que a defesa do princípio da presunção de inocência pode obstruir as atividades investigatórias e persecutórias do Estado. A repressão a crimes não pode desrespeitar e transgredir a ordem jurídica e os direitos e garantias fundamentais dos investigados.

iv) A Constituição não pode se submeter à vontade dos poderes constituídos nem o Poder Judiciário embasar suas decisões no clamor público.

#### 2.1.3.4. SUPERADA A JURISPRUDÊNCIA DO STF/STJ

Como visto, no dia 7 de novembro de 2019, o STF, ao julgar as ADCs 43, 44 e 54 (Rel. Min. Marco Aurélio), retornou para a sua segunda posição e afirmou que o cumprimento da pena somente pode ter início com o esgotamento de todos os recursos. Logo, não é possível a execução provisória da pena.

Com isso, a jurisprudência, abaixo, firmada pelos Tribunais Superiores restou superada:

i) a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência. (STF, HC 126.292/SP – Informativo 814);

ii) STJ acompanha o entendimento do STF. (STJ, Edcl no Resp 1.484.415-DF – Informativo 581; STJ, QO na APn 675-GO – Informativo 582.)

**Atenção:** de acordo com a Súmula Vinculante nº 11, só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. A súmula tem o objetivo de evitar o uso de algemas para exposição pública do preso, pois violaria a presunção da inocência e o princípio da dignidade humana.

#### 2.2. IGUALDADE PROCESSUAL OU PARIDADE DE ARMAS (ART. 5º, CAPUT, CF/88)

O Estado possui uma estrutura para amparar suas atividades, por meio de órgãos como a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério Público, a Advocacia-Geral da União, seus Tribunais, dentre tantos outros. Além disso, via de regra, cabe a este mesmo Estado, com todo o seu aparato jurídico, iniciar a persecução penal para punir aqueles que venham a transgredir a Lei Penal.

Desse ponto de vista, veja que uma pessoa comum, ao ter um processo penal instaurado contra si, fica numa situação de desigualdade perante o Estado, que possui muito mais recursos para atuar do que um cidadão comum.

Em atenção a essa desigualdade que surge o princípio da paridade de armas, que visa assegurar que ambas as partes do processo (seja o acusador, na figura do Ministério Público, seja o réu) possuam iguais condições/oportunidades, o que é necessário para que o resultado do julgamento seja justo e imparcial.

Como consequência do princípio da paridade de armas é que surgem diversas prerrogativas. Exemplos:

a) direito de defesa técnica ao acusado que não possuir condições para pagar um advogado, sendo, portanto, assistido por um defensor dativo ou por um defensor público;

b) direito a tempos iguais para ambas as partes apresentarem suas alegações finais;

c) direito a prazos iguais para interposição de recursos criminais.

#### 2.3. AMPLA DEFESA – (ART. 5º, LV, CF/88)

Note que o princípio da ampla defesa também está previsto de forma expressa na Constituição Federal:

“Art. 5º, LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”



A ampla defesa é um princípio essencial ao devido processo legal, pois garante que o acusado disponha de todos os meios lícitos para defender seus direitos. Isto é, consiste em dar ao réu todas as possibilidades de defesa no curso do processo. Possui duas subespécies: a) defesa técnica, e b) autodefesa. Abaixo há análise de cada uma delas.

### 2.3.1. DEFESA TÉCNICA

Defesa técnica é a defesa exercida por profissional apto e inscrito nos quadros da OAB. Existe, no entanto, discussão na jurisprudência se o Defensor Público precisa estar inscrito nos quadros da OAB. Caso seja admitido que o Defensor Público não precise estar inscrito na OAB, então teremos a modificação no conceito de defesa técnica: é a defesa exercida por profissional apto que pode estar inscrito nos quadros da OAB (no caso do advogado) ou não (Defensor Público), (DEZEM, 2019, p. 111).

É indisponível e irrenunciável, e sua ausência é causa de nulidade absoluta do processo. Ninguém pode ser condenado sem dispor de uma defesa técnica.

Há todo um aparato estatal em face do réu e exatamente por isso ele não pode ser deixado sozinho, é necessário alguém habilitado, com conhecimento técnico-jurídico para auxiliá-lo durante o processo.

Por esse motivo é que o Estado tem obrigações como a de manter Defensorias Públicas e de nomear defensores dativos para aqueles que não têm condições de pagar um advogado.

A imprescindibilidade da defesa técnica no processo penal está prevista nos arts. 261 e 263 do CPP, devendo ser assegurada ainda que o réu esteja foragido ou seja revel (Informativo 430 do STJ):

Art. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor.

Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada.

Art. 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação.

Parágrafo único. O acusado, que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz.

Se ele próprio for advogado, pode a si mesmo defender-se, e na figura dele estará concentrada a autodefesa e a defesa técnica (os dois aspectos da ampla defesa). Para o que não possui habilitação, obrigatoriamente terá que existir uma defesa técnica em prol dele.

Como decorrência direta do estudo das principais características da defesa técnica, atenção a três enunciados sumulados pelo STF:

a) Súmula nº 523, STF: no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

A súmula resume a importância da defesa técnica no processo penal. Em decorrência de sua necessidade/imprescindibilidade, a falta da defesa técnica acarretará nulidade absoluta. Se, **no** entanto, houver defesa técnica, mas esta se demonstrar deficiente, havendo comprovação de prejuízos ao réu, será o caso de declaração de nulidade (neste ponto, relativa).

b) Súmula nº 707, STF: constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprimindo a nomeação de defensor dativo.

O direito de escolher a defesa técnica é do réu. Por isso, sempre deve ser oportunizada a ele a constituição de advogado de sua confiança. Vamos ao exemplo que retrata o enunciado acima: o Ministério Público ofereceu denúncia por roubo e o juiz a rejeitou. Cabe recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, I, CPP, que foi tempestivamente interposto pelo órgão ministerial com suas



razões. O magistrado não poderá pular a fase de dar conhecimento ao acusado da denúncia e nomear, desde já, um defensor dativo para apresentação das contrarrazões. Deverá o magistrado dar ciência ao acusado sobre tudo o que está acontecendo para que ele tenha a possibilidade de constituir advogado que seja de sua confiança para o oferecimento das contrarrazões. Apenas se o acusado não constituir advogado é que o juiz deverá suprir com a nomeação de defensor dativo (já que a defesa técnica é imprescindível), conforme, inclusive, já manifestado pelo STJ no Informativo 433, que fundamentou a edição da Súmula.

c) Súmula nº 708, STF: é nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro.

Caso o réu possua apenas um único advogado constituído nos autos e este renuncie, significa que o réu está sem defesa técnica, o que não é possível no processo penal. Portanto, não pode o Tribunal julgar a apelação sem que a situação seja regularizada, sob pena de ser um julgamento nulo (ninguém pode ser processado ou julgado sem defesa técnica). Desse modo, deverá o réu ser intimado para constituir novo advogado de sua confiança (lembrando, como visto acima, que o direito de constituir advogado é do réu, não podendo pular essa fase e nomear defensor dativo diretamente). Após a nova constituição, a apelação poderá ser julgada normalmente. Não confunda com a hipótese em que o réu possua diversos advogados constituídos nos autos. Nesse caso, se um renunciar, a defesa técnica ainda estará presente nos demais.

### 2.3.2. AUTODEFESA

Como o nome diz, é a defesa que o próprio réu realiza em seu favor, de forma pessoal. A maneira mais comum de exercitar a autodefesa ocorre quando o réu presta sua versão dos fatos durante o interrogatório ou comparece nas audiências para a oitiva de vítimas e testemunhas. Ao contrário da defesa técnica, é um elemento disponível, ou seja, o acusado só exerce a autodefesa se quiser. Isso ocorre porque o acusado também tem o direito constitucional ao silêncio. A autodefesa, conforme aponta a doutrina, é subdividida em três pontos importantes:

a) Direito de audiência: é o direito de ser ouvido. O momento próprio para isso é o do interrogatório, último ato da audiência de instrução e julgamento, conforme artigo 400 do CPP, possibilitando que a defesa conheça tudo o que foi produzido, para ao final verificar qual a melhor estratégia (ficar calado, confessar, esclarecer os fatos). Consiste no direito que tem o acusado de, pessoalmente, apresentar ao juiz da causa a sua defesa. Isso se manifesta por meio do interrogatório, sendo este o momento adequado para o acusado, em contato direto com o juiz, trazer a sua versão a respeito do fato da imputação (FERNANDES, 2002, p. 280).

b) Direito de presença: direito de estar presente nos atos processuais. O réu é cientificado para os atos, pois tem o direito de estar presente de forma direta (no ambiente da audiência) ou indireta (videoconferência).

Tanto o direito de audiência quanto o direito de presença são renunciáveis. Por exemplo, durante o interrogatório, o réu pode optar por ficar calado (direito ao silêncio); e, intimado da audiência, ele pode optar por não comparecer.

A disponibilidade da autodefesa não autoriza que o réu minta ou se cale na primeira parte do interrogatório judicial, que refere à sua qualificação pessoal (art. 187, § 1º, do CPP). Na segunda parte, ele pode exercer o direito constitucional ao silêncio (renunciando à autodefesa).

c) Direito de postular pessoalmente (FERNANDES, 2002, p. 280).

Em alguns momentos do processo penal o acusado pode requerer, peticionar, agir, pessoalmente, sem necessidade de defesa técnica. Ex.: *habeas corpus* (que poderá ser impetrado pelo réu, em seu favor, sem advogado, desde que não seja apócrifo); na fase de execução penal, o condenado pode peticionar ao juiz da execução penal mesmo sem a defesa técnica assinar com ele; na fase recursal, o réu tem legitimidade, podendo apresentar a sua interposição recursal (a peça de razões deve ser apresentada por defesa técnica), conforme art. 577 do CPP.

Após apresentadas as principais características da autodefesa, é importante ressaltar dois pontos:



a) Súmula nº 522, STJ: a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

Vamos a um exemplo: João foi preso em flagrante por roubo e no momento da abordagem policial, bem como ao delegado de polícia, afirmou se chamar José. Após o procedimento de identificação criminal, pois ele não apresentou identidade civil, constatou-se que ele era João e que, portanto, apresentou falsa identidade.

Durante certo tempo, tentou-se emplacar a tese de que a utilização de falsa identidade era para fins de autodefesa. No entanto, os Tribunais firmaram entendimento pela tipicidade da conduta. No exemplo dado, João responderá pelo roubo (art. 157 do CP) e pelo delito de falsa identidade (art. 307 do CP).

b) Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor (art. 217 do CPP).

Vamos a um exemplo: roubo praticado em residência, em concurso de agentes, com emprego de arma, em que as vítimas foram amarradas e mantidas restritas até a subtração dos bens. No dia da audiência de instrução e julgamento, a vítima informou que não seria capaz de depor na frente do réu por sentir medo, sentir-se constrangida, em decorrência da violência empregada no dia do roubo. Diante dessa situação, e sob justificação em ata, o réu será retirado da sala de audiência, procedendo-se à prática do ato por videoconferência. O réu fica em sala separada da vítima, que é ouvida na sala de audiência. Pelo sistema de videoconferência, o réu exerce seu direito de presença, de forma indireta. No entanto, nas comarcas que não possuem o equipamento, o ato não será adiado, devendo o réu ser retirado da sala, prosseguindo na inquirição da vítima com a presença do seu defensor (defesa técnica), (fica a defesa técnica, sai o réu).

Observe, nesse ponto, portanto, que a própria lei (CPP) relativiza o direito de presença do réu.

No caso de acusado que seja advogado e que, portanto, exerce a sua autodefesa e a sua defesa técnica na mesma pessoa, o magistrado deverá ter uma atenção a mais. Em se tratando de comarca que não haja o sistema de videoconferência, o réu deverá ser retirado da sala e o juiz nomeará um advogado para a prática daquele ato (oitiva da vítima), para suprir a necessidade de defesa técnica diante da impossibilidade de o réu permanecer pessoalmente no local do depoimento.

#### **Atenção:**

a) a revisão criminal é uma espécie de ação na qual um condenado, cuja sentença inclusive já transitou em julgado, requer ao tribunal que o condenou a revisão de sua sentença, sob alegação de que houve um erro, por exemplo. O instituto decorre diretamente do princípio da ampla defesa. É interessante notar que, no entanto, o Estado (por meio do Ministério Público) não tem o direito de pedir a revisão criminal em desfavor do condenado;

b) outra consequência importante da ampla defesa é o dever do magistrado de fiscalizar a eficiência da defesa técnica do réu. Caso o juiz perceba que a defesa técnica está causando prejuízo à situação do réu, pode ele próprio nomear outro defensor ou fazer com que o acusado encontre um (decorrência da Súmula nº 523, STF);

c) de acordo com o Informativo nº 922 do STF, a sustentação oral do representante do Ministério Público que diverge do parecer juntado ao processo, com posterior ratificação, não viola a ampla defesa.

## **2.4. PLENITUDE DE DEFESA (ART. 5º, XXXVIII, CF/88)**

A instituição do Tribunal do Júri é regida pelo princípio da plenitude de defesa, nos termos da Constituição Federal.



Art. 5º, XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

- a) a plenitude de defesa;
- b) o sigilo das votações;
- c) a soberania dos veredictos;
- d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Antes mesmo de tratar do conceito desse princípio, já devemos deixar claro o seguinte: o princípio da plenitude de defesa não se aplica a todo o tipo de procedimento penal, mas apenas aos procedimentos do tribunal do júri, que recebeu um tratamento especial na Constituição Federal, o que denota a maior seriedade com que são tratadas as acusações de crimes dolosos contra a vida, possibilitando que o réu seja julgado por seus semelhantes (outros cidadãos brasileiros) e não por um único magistrado (togado).

Essa mudança no procedimento traz consigo uma consequência que agrava um pouco a situação do acusado: o voto dos jurados é sigiloso, o que dispensa a fundamentação da decisão tomada (sistema da íntima convicção). Com isso, veja que o júri não depende de uma análise muito técnica do conjunto probatório, de forma que, se os jurados se sentirem convencidos da materialidade e da autoria do delito por parte do réu, poderão condená-lo sem estar vinculados a fundamentar juridicamente sua escolha.

Com isso, veja que o trabalho da defesa em desconstituir os argumentos da acusação se torna mais pesado do que seria diante de um magistrado, que é especialista em Direito e que deve analisar o conjunto probatório de uma maneira mais formal.

A plenitude de defesa, portanto, permite ao réu a utilização de argumentos que não seriam válidos perante um juiz singular, tais como justificativas de cunho moral, social, religioso, espiritual e até mesmo sentimentais.

Em outras palavras, a plenitude de defesa assegura ao acusado o direito de utilizar uma argumentação mais ampla para assegurar seu direito à liberdade do que poderia ser feito em um tribunal comum, atendendo às peculiaridades do tribunal do júri.

## 2.5. PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO RÉU OU FAVOR REI OU *IN DUBIO PRO REO*— (ART. 5º, LVII, CF/88)

Havendo dúvida, deve ser adotada a solução que mais beneficie o réu, em regra, absolvendo-o. É dar importância ao brocardo *in dubio pro reo* e decorre do princípio da presunção de inocência (em sua dimensão interna).

Está previsto no art. 386, incisos II, V, VI e VII, do CPP:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

II - não haver prova da existência do fato;

V - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VI - existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Além disso, existe outra consequência interessante desse princípio. Imagine que um juiz, ao interpretar a lei, chegue a duas respostas distintas, ou seja, houve dúvida na interpretação da lei, e ele deverá escolher entre duas hipóteses diferentes. Nesse caso, a escolha é simples: o juiz deverá utilizar a interpretação que seja mais benéfica ao réu, ou seja, a interpretação favorável ao acusado.

### Atenção:

a) com fundamento no *in dubio pro reo*, o STF já decidiu que, verificado empate no julgamento de ação penal, deve prevalecer a decisão mais favorável ao réu (STF, APn 565);



b) o princípio do *in dubio pro societate* significa que, na dúvida, havendo indícios mínimos da autoria, deve-se dar prosseguimento à ação penal, ainda que não se tenha certeza de que o réu foi o autor do suposto delito. Em uma tradução literal, seria algo como “na dúvida, em favor da sociedade”. Contrapõe-se ao princípio do *in dubio pro reo* (“na dúvida, em favor do réu”). A doutrina mais moderna critica a existência desse princípio afirmando que ele é contrário às garantias conferidas ao réu. Apesar disso, a jurisprudência continua aplicando esse princípio em duas fases: a) no momento do oferecimento/recebimento da denúncia, prevalece o princípio do *in dubio pro societate* (STF, Inq 4506/DF - Info 898); e b) a pronúncia do réu para o julgamento pelo Tribunal do Júri não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente, nessa fase processual, a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada, apenas, a materialidade do crime, uma vez que vigora o princípio *in dubio pro societate* (STF, ARE 986566 AgR; STJ, AgRg no AREsp 1193119/BA).

## 2.6. CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, CF/88)

Mais um dos princípios previstos expressamente na Constituição Federal:

CF/1988: “Art. 5º, LV – Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

O princípio do contraditório, assim como o princípio da ampla defesa, está diretamente relacionado com o devido processo legal. Para que o processo penal seja legítimo, é absolutamente necessária a existência do contraditório, ou seja, de ouvir a outra parte sobre os fatos e as provas apresentados no curso do processo.

Também chamado por alguns de princípio da bilateralidade da audiência, a formulação clássica do princípio afirma que este consiste na ciência bilateral dos atos do processo e a possibilidade de contrariá-los (ALMEIDA, 1973, p. 82). Portanto, pressupõe conhecimento dos atos e termos do processo, sem dúvida.

Porém, atualmente, implica ainda na possibilidade de efetiva participação de tais atos, podendo neles influir, como ocorre na produção das provas. As partes no processo devem atuar em igualdade de condições.

Contraditório, então, é o direito de participação, estando apto a reagir, ou seja, de manter uma contraposição em relação à acusação e de estar informado de todos os atos do processo. É, portanto, norteado por três pontos principais: direito de participação, de reação, e de informação.

Quanto ao direito de participação, poderá o réu efetivamente participar, estar presente, se manifestar durante o processo. Por isso, cita-se como exemplo o réu presente na audiência de instrução e julgamento para oitiva de vítimas e testemunhas.

Quanto ao direito de reação, possui o réu a possibilidade de efetivamente reagir ao que foi apontado pela acusação. Cita-se como exemplo, no procedimento comum ordinário, o réu, por sua defesa técnica, oferecer resposta à acusação após o recebimento da denúncia e sua consequente citação. Ou quando, após recurso interposto pelo Ministério Público, o réu apresentar peça de contrarrazões.

Quanto ao direito de informação, serão estudadas em capítulo próprio as espécies de comunicação dos atos processuais e será analisado que a regra é o réu ser cientificado pessoalmente de todos os atos, devendo ser informado de tudo o que ocorre ao longo do processo, salvo quando é decretada sua revelia (art. 367 do CPP) até a sentença.

O princípio do contraditório possui duas subespécies: a) contraditório imediato/real/direto, e b) contraditório mediato/diferido/postergado.

Na primeira espécie, quando a prova é produzida, as partes exercem o contraditório direto. Ex.: a vítima é ouvida na audiência de instrução e julgamento e estão presentes todos os atores do processo penal, incluindo juiz, Ministério Público, defesa e réu. As partes poderão

demonstrar suas teses e exercer o contraditório de forma direta na prova colhida (tomada de depoimento da vítima).

Na segunda espécie, no momento da produção da prova, não é possível permitir que as partes tomem conhecimento. Ex.: interceptação telefônica. Delegado requereu a interceptação, Ministério Público foi ouvido e o Juiz deferiu a produção da prova, entendendo como único meio de conduzir a investigação. Não tem como intimar a defesa ou o réu para tomar conhecimento dessa prova que será produzida, porque isso poderia acarretar frustração da produção dessa prova cautelar. Desse modo, a interceptação é realizada, quando ela terminar é juntada a transcrição, que segundo os Tribunais Superiores não precisa ser integral, e, após, a defesa poderá exercer seu contraditório. Por ser exercido em um momento posterior à produção da prova, é chamado de diferido, postergado ou mediato.

**Atenção:** não tem aplicação na fase pré-processual, porque não existem efetivamente partes nem acusação formal no inquérito policial. Isso não impede que o investigado e a vítima requeiram provas a serem colhidas pela autoridade policial, com o fito de comprovar as suas alegações, conforme art. 14 do CPP. Não obsta, ainda, que o investigado seja assistido por advogado e tenha acesso aos autos do inquérito (Súmula Vinculante nº 14). A fase pré-processual será detalhadamente estudada em capítulo próprio.

## 2.7. JUIZ NATURAL (ART. 5º, LIII, CF/88)

Apenas o juiz da causa pode conduzir o processo, conforme preceitua o art. 5º, LIII, CF/88:

“Art. 5º, LIII – ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;”

Também encontra previsão no Pacto de São José da Costa Rica, que prevê em seu art. 8º, 1:

### Artigo 8º - Garantias judiciais

1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.

O princípio do juiz natural compreende a adoção de três garantias que dele decorrem: a) proibição de tribunais de exceção, *ex post facto*; b) garantia do juiz competente; e c) somente exercem jurisdição os órgãos instituídos pela Constituição Federal (DEZEM, 2019, p. 139).

Veda-se, com isso, o tribunal ou juiz de exceção, que seria aquele escolhido após a ocorrência de uma infração penal e para determinado caso concreto. Tribunais de exceção, portanto, são aqueles criados temporariamente para julgar um caso (ou alguns casos) após a prática de um determinado delito.

Um exemplo foi o de Tribunal de Nuremberg, criado pelos aliados para julgar os nazistas por seus crimes de guerra. Independentemente das justificativas históricas para tal e dos horrendos crimes praticados durante o nazismo, é bastante óbvio que um tribunal criado para julgar um caso específico dificilmente terá garantida a sua imparcialidade.

Como consequência do princípio do juiz natural, há o direito de ser julgado por autoridades determinadas pela lei e não de forma arbitrária, o que busca garantir a imparcialidade do julgador.

**Atenção:**

a) a redistribuição de feitos decorrente da criação de vara com idêntica competência com a finalidade de igualar os acervos dos juízos e dentro da estrita norma legal não viola o princípio do juiz natural (STJ, HC 102.193/SP);

b) a convocação excepcional de juízes de primeiro grau para integrar câmaras julgadoras em tribunais não ofende o princípio do juiz natural (STF, HC 101473);

c) Súmula nº 704, STF: não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Nos casos em que um réu comum (que não possui foro por prerrogativa de função) for julgado em conjunto com uma autoridade que tem tal prerrogativa (portanto seu processo será remetido para o tribunal competente para julgar a autoridade), não haverá violação ao princípio do juiz natural;

d) não viola o princípio do juiz natural o desaforamento de julgamentos do tribunal do júri (art. 427 do CPP).

## 2.8. PUBLICIDADE (ART. 5º, LX, E ART. 93, IX, AMBOS CF/88; ART. 792 DO CPP)

Os atos processuais, via de regra, são públicos, havendo a possibilidade de limitação da publicidade de certos atos se houver cabal necessidade. Atenção aos seguintes dispositivos legais:

### Constituição Federal

Art. 5º, LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

Art. 93, IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

### Código de Processo Penal

Art. 792. As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou previamente designados.

§ 1º Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual, puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou o tribunal, câmara, ou turma, poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes.

§ 2º As audiências, as sessões e os atos processuais, em caso de necessidade, poderão realizar-se na residência do juiz, ou em outra casa por ele especialmente designada.

O princípio da publicidade garante que os atos processuais – mesmo relacionados à aplicação do direito penal – sejam, em regra, públicos. O cidadão, em um contexto democrático como o estruturado pela CF/88, tem o direito de ser comunicado de todos os atos que são praticados pelo Estado, dando-se a devida transparência. É a chamada publicidade ampla, geral, popular ou plena.

Apenas excepcionalmente é que, estando presentes alguns requisitos, um determinado procedimento pode ser considerado sigiloso, como é o caso, por exemplo, de um processo em que o réu é acusado de estupro de vulnerável, em que há necessidade de se preservar a intimidade da vítima. É a chamada publicidade restrita ou específica.

Mesmo assim, a justificativa deve ser sólida o suficiente para justificar a negativa de informações por parte do Estado ao seu povo.

## 2.9. VEDAÇÃO DAS PROVAS ILÍCITAS – (ART. 5º, LVI, CF/88)

Sua importância é tamanha que é citado de forma expressa tanto na Constituição Federal quanto no CPP:

Art. 5º, LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

§ 2º Considera-se descoberta inevitável aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

§ 3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente.

Como se vê, a CF/88 e o CPP somente fazem referência à prova ilícita, a qual, segundo o Código, é aquela obtida em violação a normas constitucionais ou legais, pouco importando a natureza das normas violadas, isto é, se de cunho material ou processual.

Todavia, a doutrina distingue as provas ilícitas das provas ilegítimas. Haveria um gênero "prova ilegal" dentro do qual estariam as provas ilícitas e as ilegítimas. As ilícitas são as obtidas "através da violação de regra de direito material (penal ou constitucional)", por exemplo, a confissão obtida por meio de tortura. Noutro giro, as ilegítimas são aquelas obtidas "mediante violação à norma de direito processual", como ocorre, por exemplo, quando, "ao ouvir determinada testemunha, o magistrado se esqueça de compromissá-la", incorrendo "em violação à regra do art. 203 do CPP" (LIMA, 2020, p. 685-686).

Nos termos do art. 157, §3º, do CPP, preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. Frise-se, porquanto importante para concursos: as partes podem acompanhar o incidente de inutilização da prova declarada ilícita.

Como visto, as provas ilícitas são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo. Esse regramento seria inócuo se tal ilicitude não se estendesse às provas derivadas das ilícitas. Noutras palavras: "de nada adiante dizer que são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos se essa ilicitude também não se estender às provas que dela derivam" (LIMA, 2020, p. 689).

Nesse contexto, as "provas ilícitas por derivação são aquelas que, embora lícitas na própria essência, decorrem exclusivamente de uma outra prova, considerada ilícita, ou de uma situação de ilegalidade, restando, portanto, contaminadas" (AVENA, 2017, p. 330).

Em relação às provas ilícitas por derivação, adotamos, portanto, a "teoria norte-americana dos Frutos da Árvore Envenenada (*fruits of the poisonous tree*), segundo a qual o defeito existente no tronco contamina os frutos" (AVENA, 2017, p. 330), nos termos do art. 157, §1º, do CPP, o qual disciplina que são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas.

Assim, pela regra dos frutos da árvore envenenada, se uma determinada prova, ainda que obtida por meio lícito, deriva de uma prova ilícita, a ilicitude da primeira contaminará a segunda, devendo haver o desentranhamento das duas.

Contudo, não se pode afirmar que, havendo uma prova ilícita nos autos, todas as demais também o são, já que, como regra, somente estarão contaminadas aquelas que derivam da ilícita. Esse é o teor da teoria ou exceção da fonte independente.

No ponto, muito cuidado com a redação dos §§1º e 2º do art. 157 do CPP, porquanto o legislador fez uma confusão entre a teoria da fonte independente e da descoberta inevitável.



Por definição, a teoria ou exceção da fonte independente é verificada quando, conforme o próprio nome sugere, não há uma relação de dependência entre as provas. A teoria ou exceção da fonte independente é extraída do art. 157, §1º, segunda parte, do CPP, o qual aduz que são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Note-se: a teoria ou exceção da fonte independente é aplicável quando não há relação/nexo de causalidade entre as provas dos autos, pelo que se pode concluir que, ainda que haja uma prova ilícita no processo, não necessariamente deverá haver o desentranhamento de todas as provas acostadas aos autos. As que não se originaram da ilícita, isto é, nasceram de outra fonte ("fonte independente"), não serão consideradas ilícitas.

Em resumo (muito importante para fins de diferenciação das teorias da fonte independente e da descoberta inevitável): na teoria ou exceção da fonte independente, as provas, de fato, isto é, no caso concreto, derivaram de fontes autônomas, razão pela qual a ilicitude de uma não contamina a outra.

Na teoria da descoberta inevitável, também conhecida como exceção da fonte hipotética independente, ao contrário do que ocorre na teoria ou exceção da fonte independente, há uma relação de causalidade/dependência entre a prova ilícita e a prova obtida por meio lícito, contudo, mesmo assim, a derivada não será considerada ilícita, porquanto, hipoteticamente, poderia ter sido obtida por uma fonte autônoma.

Em outras palavras,

de acordo com a teoria da descoberta inevitável, também conhecida como exceção da fonte hipotética independente, caso se demonstre que a prova derivada da ilícita seria produzida de qualquer modo, independentemente da prova ilícita originária, tal prova deve ser considerada válida (LIMA, 2020, p. 693).

**Atenção:** a prova ilícita não pode ser aceita para servir de base à condenação do réu. Pelo contrário, a garantia constitucional da inadmissibilidade da prova ilícita pode ser afastada no caso de ser a única fonte de prova da inocência do réu.

## 2.10. Economia processual, celeridade processual, duração razoável do processo – (art. 5º, LXXVIII, CF/88)

Temos aqui mais um princípio para o qual o constituinte deu grande importância, visto que o inseriu de forma expressa no art. 5º da CF/88:

“Art. 5º, LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

O princípio da duração razoável do processo, na verdade, é praticamente autoexplicativo. Para que a prestação jurisdicional seja efetiva, deve ser realizada em um tempo razoável.

Como já asseverou a própria presidente do Supremo Tribunal Federal: “O cidadão já sabe que essa história de que a Justiça tarda, mas não falha, não é verdadeira. Justiça que tarda, falha.” (Ministra Cármen Lúcia).

Nesse sentido, percebe-se que a duração razoável do processo está intimamente relacionada com outros princípios, como o da economia processual e da celeridade, no sentido de que o Estado deve atuar sempre de forma eficiente e rápida.

## 2.11. DEVIDO PROCESSO LEGAL – (ART. 5º, LIV, CF/88)

Está previsto a nível constitucional no art. 5º, LIV, CF/88:

“Art. 5º, LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;”

O objetivo desse princípio é garantir que ninguém seja submetido às pesadas sanções penais sem a tramitação de um processo que respeite a legalidade. É, portanto, a garantia contra ações arbitrárias do Estado.

Perceba que esse é um princípio com um alcance bastante amplo, pois, para que seja respeitado em sua plenitude, todos os outros princípios e normas relacionados ao Direito Processual Penal também devem ser observados.

Segundo a doutrina, divide-se em devido processo legal substantivo (*substantive due process*) e devido processo legal processual (*procedural due process*). O primeiro significa que as leis devem ser razoáveis e racionais quando se referem a atos do Estado e o segundo engloba diversos outros princípios, sendo o que alguns denominam de “princípio síntese”, englobando, portanto, os princípios do juiz natural, do contraditório, da ampla defesa, juiz imparcial e etc.

## 2.12. INTRANSCENDÊNCIA OU PESSOALIDADE (ART. 5º, XLV, CF/88)

Art. 5º, XLV – nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;

O processo penal é instaurado apenas em face de quem efetivamente cometeu o crime, bem como somente a pessoa condenada irá cumprir a sanção penal.

## 2.13. MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES

O princípio da motivação das decisões judiciais encontra guarida no art. 93, IX, CF/88:

“Art. 93, IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...).”

Também encontra previsão no art. 381, III, do CPP, deixando claro que a motivação não se refere tão somente à matéria de fato, mas, também, à matéria de direito:

“Art. 381. A sentença conterá: III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;”

É importante ressaltar que o CPC de 2015 traz norma bastante útil para o entendimento sobre a correta fundamentação a ser feita em uma sentença, nos termos do art. 489, § 1º, CPC. Com as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime), o CPP passa a ter previsão bem semelhante no art. 315, § 2º:

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;



VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Em que pese o dispositivo legal tenha sido inserido pelo legislador no título relativo à “prisão, medidas cautelares e liberdade provisória”, resta evidente pela redação dada ao § 2º que não se aplica apenas no regime de prisões, mas também em qualquer sentença ou decisão no âmbito do processo penal dada a utilização da redação “qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão”.

Exceções ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88):

a) decisões tomadas pelo conselho de sentença no Tribunal do júri (princípio constitucional do sigilo das votações — sistema da íntima convicção);

b) recebimento da denúncia nos procedimentos que não preveem defesa preliminar; Mero “juízo de prelibação”, exceção à motivação, cabível recebimento tácito se o juiz se omitir sobre o recebimento, mas determinar prosseguimento do feito (STF, AgR no HC 107066/SP; STJ, Ag no REsp 1450363, 2017). Assim, o recebimento da denúncia, o mero juízo de prelibação não requer motivação específica, com exceção dos procedimentos que preveem defesa antes do ato de análise da denúncia.

c) despachos de mero expediente (não possuem cunho decisório).

### 3. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS IMPLÍCITOS

#### 3.1. NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO (*NEMO TENETUR SE DETEGERE*)

É o princípio que veda a produção de prova contra si mesmo e não encontra previsão expressa na Constituição Federal, mas decorre do previsto no art. 5º, LXIII da CF/88:

“Art. 5º, LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado.”

Por força do direito de não produzir prova contra si mesmo, doutrina e jurisprudência têm adotado o entendimento de que não se pode exigir um comportamento ativo do acusado. Assim, sempre que a produção da prova tiver como pressuposto uma ação por parte do acusado (ex.: acareação, reconstituição do crime, exame grafotécnico, bafômetro etc.), será indispensável seu consentimento.

##### Atenção:

a) enquanto testemunha, o indivíduo tem a obrigação de dizer a verdade (art. 203 do CPP). Porém, se das perguntas que lhe forem formuladas puder resultar uma autoincriminação, a testemunha deixa de ser testemunha e passa a ser tratada como imputado ou investigado, tendo direito ao *nemo tenetur se detegere*. Precedente: STF: “(...) Paciente que, embora rotulado de testemunha, em verdade encontrava-se na condição de investigado. Direito constitucional ao silêncio. Atipicidade da conduta. Ordem concedida para trancar a ação penal ante patente falta de justa causa para prosseguimento”. (STF, HC 106.876/RN; STF, Pleno, HC 73.035/DF; STF, RHC 122.279/RJ);

b) não há, no Brasil, o crime de perjúrio (mentira do próprio acusado em juízo). O direito de permanecer em silêncio insere-se no alcance concreto da cláusula constitucional do devido processo legal. E nesse direito ao silêncio inclui-se até a prerrogativa processual de o acusado negar, ainda que falsamente, perante a autoridade policial ou judiciária, a prática da infração penal (STF, HC 68.929/SP).



### 3.2. INICIATIVA DAS PARTES

Cabe à acusação a iniciativa de movimentação do Poder Judiciário, não podendo o magistrado iniciar o processo de ofício. Assim, caberá ou ao Ministério Público (na ação penal pública) ou ao particular (na ação penal privada) a decisão pelo ajuizamento da ação (denúncia e queixa-crime, respectivamente).

Esse princípio não encontra previsão expressa no sistema legal, mas previsão implícita na Constituição, como decorrência do art. 5º, LIX, CF/88 (NUCCI, 2018, p. 100). É a manifestação clara do sistema acusatório que implica na necessária separação entre as funções de julgar, acusar e defender.

**Atenção:** pode o magistrado dar início à execução de sentença penal condenatória no juízo da execução, que se apresenta como processo autônomo no sistema processual penal em relação ao processo de conhecimento (DEZEM, 2019, p. 136).

### 3.3. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

Não possui previsão no texto da Constituição, mas é reconhecido pela doutrina com base no art. 8º, h, da Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de San José da Costa Rica, referendado pelo Decreto nº 678/1992.

Prevê o Pacto de San José da Costa Rica:

Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura, se a prisão ou a detenção forem ilegais. Nos Estados-partes cujas leis preveem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa.

O duplo grau de jurisdição, portanto, é o princípio do direito processual penal, expressamente reconhecido na Convenção Americana de Direitos Humanos, que garante ao indivíduo o direito de revisão de sua causa em uma instância superior.

Por força desse princípio, não há que se falar em um julgamento único, todo indivíduo tem direito à reavaliação de seu pleito perante a Justiça. Decorre da própria estrutura do Poder Judiciário e da irresignação natural da parte sobre a decisão.

Há exceção evidente ao princípio nos casos de julgamento em competência originária dos Tribunais. Assim, por exemplo, no caso de competência originária do STF, não caberá recurso a outro Tribunal, pois este simplesmente não existe. No máximo, como visto em alguns julgamentos, como exemplo na Ação Penal 470 que tramitou no STF, haverá possibilidade de embargos de declaração, que podem até ter efeitos modificadores do resultado, e embargos infringentes, desde que haja previsão legal ou regimental.

### 3.4. JUIZ IMPARCIAL

É princípio que decorre do princípio constitucional do juiz natural, com a finalidade, portanto, de complementá-lo. Mesmo o magistrado estando previamente investido na jurisdição, pode não ser imparcial, motivo pelo qual há regras de suspeição e impedimento previstas nos arts. 254 e 252 do CPP.

Suspeição:

Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes.

I – se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;



II – se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III – se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV – se tiver aconselhado qualquer das partes;

V – se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

VI – se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo

Impedimento:

Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:

I – tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;

II – ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;

III – tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;

IV – ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.

As regras de suspeição e impedimento se estendem ao MP e aos Defensores, conforme se vê dos seguintes dispositivos legais:

Ministério Público:

Art. 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes.

Defensores Públicos

Art. 134, CF/88. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Art. 267, CPP. Nos termos do art. 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz.

Por fim, frisa-se que o princípio está previsto expressamente no art. 8º, 1, do Pacto de São José da Costa Rica, referendado pelo Decreto 678/92:

Artigo 8º - Garantias judiciais

1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.

### 3.5. PROMOTOR NATURAL

Não se pode nomear qualquer membro do Ministério Público para atuar em casos determinados, havendo necessidade de previsão antecipada – em regramentos internos – de qual



órgão ministerial deve atuar em determinadas situações. Há muita controvérsia doutrinária a respeito desse princípio, posto não possuir expressa previsão no texto constitucional.

Normalmente, entre os membros do Ministério Público, há aceitação de tal princípio: haverá uma regra de distribuição de feitos predeterminada pela instituição, que não pode ser alterada, exceto nos casos expressamente previstos em lei, evitando-se assim o chamado “acusador de exceção”.

**Atenção:** parte da doutrina dispõe sobre a existência do princípio do delegado natural, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.830/2013. O dispositivo determina que o inquérito policial não poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, salvo por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. Recebendo a notícia de crime, deve ela ser distribuída ao delegado que possui atribuição para presidir a investigação e só poderá ser redistribuído excepcionalmente, nas situações legalmente descritas (SILVA, 2020, p. 28). No entanto, o STF não reconhece esse princípio (STF, ROHC 126885/RJ).

### 3.6. OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA E INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA

Em linhas gerais, preenchidos os requisitos legais, os órgãos oficiais incumbidos de investigação e de promover a ação penal pública são obrigados a atuar (arts. 5º e 24, ambos do CPP). O Ministério Público não pode desistir da ação ou de recurso que tenha sido interposto (arts. 42 e 576, ambos do CPP), nem o Delegado de Polícia pode arquivar autos de inquérito policial (art. 17 do CPP).

Os princípios serão aprofundados no capítulo sobre ações penais.

### 3.7. OFICIALIDADE

Assim como a persecução penal deve ser iniciada por autoridades públicas (delegados de polícia e promotores), ela também deve ser exercida por órgãos oficiais do Estado, o que veda sua delegação a particulares, com exceção da ação penal privada.

Assim, no caso da ação penal pública, a titularidade é privativa do Ministério Público, conforme o disposto no art. 129, I, da CF/88, sendo possível, apenas em caso de inércia de tal órgão, a ação penal privada subsidiária da pública.

### 3.8. OFICIOSIDADE

As autoridades públicas incumbidas da persecução penal devem agir de ofício, sem necessidade de provocação ou assentimento de outrem.

As exceções serão detalhadas nos capítulos sobre investigação criminal e ação penal.

### 3.9. AUTORITARIEDADE

A persecução penal deve ser iniciada e conduzida por autoridades públicas. Nesse sentido, apenas a autoridade policial (delegado de polícia) e os promotores têm legitimidade para atuar propondo a instauração, respectivamente, de inquéritos policiais e de processos penais.

### 3.10. VEDAÇÃO DA DUPLA PUNIÇÃO OU *NE BIS IN IDEM*

Significa que ninguém deve ser processado e punido duas vezes pela prática da mesma infração penal (*ne bis in idem*). Tal garantia está prevista implicitamente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos:

“Art. 8.º, 4 -O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos.”



Caso sejam propostas duas ações penais, de acordo com a doutrina, dois são os critérios adotados para se determinar qual ação penal deverá ser extinta (LIMA, 2017, p. 1126):

a) prevenção: se um dos juízes se tornou preventivo em relação aos demais, já que, por exemplo, durante a investigação policial, decretou uma medida cautelar do tipo prisional, ele deverá julgar o caso, sendo irrelevante a data de distribuição das demais ações penais. É dizer: se um juiz se tornou preventivo em primeiro lugar, a ele competirá o julgamento daquela imputação, pouco importando a data de distribuição das demais ações penais; e

b) distribuição: se não ocorreu a prevenção, o critério a ser adotado é a data da distribuição. É dizer: somente tramitará a ação penal que primeiro foi distribuída, devendo haver a extinção de todas as demais.

Diante de duas sentenças condenatórias pelo mesmo fato, assentou o STJ, no julgamento do RHC nº 69.586/PA, de relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, que deve prevalecer a que primeiro transitou em julgado, pouco importando a pena aplicada em cada uma delas. É dizer: o critério que será utilizado para se determinar qual sentença prevalecerá é a data do trânsito em julgado e não o *quantum* de pena aplicado em cada sentença condenatória, sendo esse ponto bastante importante para as provas de concurso.

Os assuntos referentes à litispendência e à coisa julgada serão detalhados em capítulo próprio das exceções no processo penal.

## 4. PRINCÍPIOS PROPRIAMENTE DITOS

### 4.1. BUSCA DA VERDADE REAL

Classicamente, afirma-se que o processo penal, diferentemente do processo civil, não se contenta somente com a verdade formal, mas deve o magistrado buscar uma reconstrução histórica dos fatos. Um suposto “princípio da verdade real” é muitas vezes citado em manifestações do Ministério Público e até mesmo em acórdãos de diversos Tribunais.

No entanto, a doutrina vem questionando a sua existência. É que a lei estabelece diversas restrições ao juiz quanto ao que pode ser aceito como prova, havendo a proibição das provas ilícitas e daquelas não produzidas sob o contraditório. É preciso ressaltar que o processo não pode e não deve prescindir da busca da verdade, mas, ao mesmo tempo, não se deve iludir com a ideia de que seja possível atingir a verdade real. No processo, atinge-se a verdade possível, dentro dos limites impostos pela CF e pelas leis.

Nesses termos, entende a doutrina: “a verdade real, em termos absolutos, pode se revelar inatingível. Afinal, a revitalização no seio do processo, dentro do fórum, numa sala de audiência, daquilo que ocorreu muitas vezes anos atrás, é, em verdade, a materialização formal daquilo que se imagina ter acontecido (TAVORA; ALENCAR; 2020; p. 49).

### 4.2. ORALIDADE, CONCENTRAÇÃO, IMEDIATIDADE, IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ

O § 2º do art. 399 do CPP estabelece que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença, com o que o CPP adotou expressamente o princípio da identidade física do juiz. A jurisprudência, no entanto, não considera o princípio absoluto. Ressalta-se, por oportuno, que as exceções não vieram previstas no CPP, devendo ser utilizadas exceções previstas no processo civil. Desse modo, no caso de convocação, licença, promoção, aposentadoria, afastamentos ou outro motivo que impeça o juiz que tiver presidido a instrução de sentenciar o feito, os autos passarão ao substituto do magistrado. Nesse sentido, decisão do STJ:

1. De acordo com o princípio da identidade física do juiz, que passou a ser aplicado também no âmbito do processo penal após o advento da Lei n.º 11.719, de 20 de junho de 2008, o magistrado que presidir a instrução criminal deverá proferir a sentença no feito, nos termos do § 2.º do artigo 399 do Código de Processo Penal.

2. Em razão da ausência de outras normas específicas regulamentando o referido princípio, nos casos de convocação, licença, promoção ou de outro motivo que impeça o juiz que tiver presidido a instrução de sentenciar o feito, por analogia - permitida pelo artigo 3.º da Lei Adjetiva Penal -, deverá ser aplicada a regra contida no artigo 132 do Código de Processo Civil, que dispõe que os autos passarão ao sucessor do magistrado. Doutrina. Precedente (STJ, HC 242.115/PE).

As exceções ao princípio previstas no art. 132, *caput*, do CPC de 1973, citadas no julgado acima, continuam sendo aplicadas, por analogia, no processo penal, ainda que esse dispositivo não encontre correspondência no CPC de 2015.

Além disso, a Lei nº 12.019/2010, que alterou o texto originário da Lei nº 8.038/1990, trouxe a figura do Magistrado instrutor, que permite que os Ministros do STF e do STJ convoquem desembargadores, bem como juízes, pelo prazo de seis meses, prorrogável por igual período, até o máximo de dois anos, para a realização de interrogatório e de outros atos da instrução, na sede do tribunal ou no local em que deva produzir o ato. Os julgadores convocados não substituem os Ministros na atividade de julgamento, mas apenas auxiliam na instrução. Como a previsão está em lei ordinária também (Lei nº 8.038/1990), aceita-se o magistrado instrutor como exceção ao princípio da identidade física do juiz.

O princípio da identidade física do juiz exige, por decorrência lógica, a observância dos subprincípios da oralidade, concentração dos atos e imediatidade. Foi seguindo essa lógica que se procedeu à alteração processual penal, operada pelas Leis nº 11.689/2008 e nº 11.719/2008, para criar condições de máxima eficácia dos subprincípios. É um “encadeamento sistêmico”, que começa com a necessidade de uma atuação direta e efetiva do juiz em relação à prova oralmente produzida, sem que possa ser mediatizada através de interposta pessoa” (LOPES JR., 2018, p. 187).

Pelo princípio da oralidade, deve haver predominância da palavra falada tanto em depoimentos, debates, alegações finais. Desse modo, os depoimentos são colhidos de forma oral, não podendo haver a substituição por outro meio.

Como corolário desse princípio, decorrem outros, como o da imediatidade do juiz com as partes e com as provas e o da concentração.

Como decorrência da concentração, busca-se concentrar toda a produção da prova na audiência.

Pela imediatidade, decorre a proximidade do juiz com a prova por ele colhida. Quando procede ao interrogatório do acusado, à tomada de declarações da vítima ou à inquirição de testemunhas, pela imediatidade que haverá entre eles, o juiz reunirá condições de compreender melhor como os fatos se deram.

**Atenção:** aplicam-se normalmente as ressalvas ao princípio da identidade física do juiz quanto ao julgamento de embargos de declaração. Se o juiz que proferiu a sentença e entrar de férias logo de imediato, por exemplo, o substituto irá julgar os embargos (STJ, HC 155.811-AL).

#### 4.3. INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA

Está previsto no art. 48 do CPP, é aplicável apenas na ação penal privada (STF, HC 104356/RJ; STF, HC 178406/RS) e significa que a ação penal deve ser proposta contra todos os autores e partícipes do delito. Visa essencialmente evitar a vingança privada.

Ex.: se o crime foi cometido por “A” e por “B”, a ação penal privada deverá ser ajuizada contra os dois, não podendo, em regra, ser proposta apenas contra um deles, salvo se houver algum motivo jurídico que autorize (um deles já morreu, é doente mental, é menor de 18 anos, não há provas contra ele etc.).

O tema será aprofundado no capítulo referente à ação penal.





#### 4.4. COMUNHÃO DE PROVAS

Pelo princípio da comunhão, "uma vez trazidas aos autos, as provas não mais pertencem à parte que as acostou, mas sim ao processo, podendo, desse modo, ser utilizadas por quaisquer dos intervenientes, seja o juiz, sejam as demais partes" (AVENA, 2017, p. 317-318).

#### 4.5. IMPULSO OFICIAL

Uma vez iniciada a ação penal, o juiz tem o dever de promover o seu andamento até a sua etapa final, de acordo com o procedimento previsto em lei (art. 251, CPP). Não se permite a paralisação indevida da ação penal, tendo em vista se tratar de interesse do Estado punir o autor de uma infração penal praticada (NUCCI, 2018, p. 109).

No princípio da iniciativa das partes, a atuação é anterior à ação penal (cabe à acusação dar início à ação penal); no princípio do impulso oficial, uma vez iniciada a ação penal, cabe ao magistrado zelar pelo seu regular funcionamento.

#### 4.6. LEALDADE PROCESSUAL OU PROIBIDADE OU BOA-FÉ

Não encontra previsão expressa no Código de Processo Penal, admitindo-se a aplicação analógica do processo civil que prevê que aquele que participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé.

No entanto, o princípio encontra aplicação em normas do CPP que são dele decorrentes, como no caso do art. 479 do CPP que determina que durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Tal artigo é manifestação do princípio do contraditório e, também, do princípio da lealdade processual.

É possível verificar a aplicação desse princípio em alguns julgados do STJ, principalmente para verificação de ocorrência de nulidades, como pode se ver abaixo:

IV - Se foi oportunizado ao recorrente o direito de manifestar-se, na forma do art. 396-A do Código de Processo Penal, por mais de uma vez, no curso da instrução processual, e se as petições apresentadas pela Defesa foram interpretadas pelo Juízo de 1º grau como estratégia defensiva de postergar as teses de mérito para o final da instrução, não há qualquer nulidade a ser reconhecida. V - No sistema processual penal aplicam-se os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu, sob pena de violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* (STJ, RHC 94.446/MS).

1. A recorribilidade vazia, infundada, como *in casu*, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. 2. O manejo recursal com finalidade meramente protelatória autoriza a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a pendência de julgamento de agravo em recurso extraordinário anteriormente interposto. 3. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de encaminhamento dos autos ao STF, após a publicação do acórdão, independentemente da eventual interposição de outro recurso. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1194589/AM.)

No entanto, a mesma jurisprudência que reconhece o dever de lealdade processual, rejeita a aplicação da litigância de má-fé no processo penal:

4. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é cabível a imposição de multa por litigância de má-fé no âmbito do processo penal, porquanto sua aplicação constituiria



indevida analogia *in malam partem*, haja vista ausência de previsão expressa no Código de Processo Penal. (STJ, HC 401.965/RJ.)

**Atenção:** é crime a fraude destinada a produzir efeitos no processo penal, conforme art. 347 do CP (fraude processual).

## QUESTÕES

**1- (2019/CEBRASPE/TJ-PA/Juiz de Direito Substituto)** Acerca de princípios processuais constitucionais, assinale a opção correta.

- a) Em razão do princípio da inocência, caso o crime seja um fato típico, antijurídico e culpável, caberá à acusação provar a inexistência da causa de exclusão da antijuridicidade alegada pelo réu.
- b) Em razão do princípio *in dubio pro reo*, a qualificadora do crime de roubo pelo uso de arma será excluída se o réu alegar ter utilizado um simulacro de arma de fogo que tenha sido confundido pela vítima.
- c) Fere os princípios do contraditório e da ampla defesa a não intimação da defesa acerca da expedição de carta precatória para oitiva de testemunha arrolada residente em outra comarca.
- d) O princípio do juiz natural impede o desaforamento de julgamentos do tribunal do júri para comarca que não seja circunvizinha de local que gere dúvida acerca da imparcialidade dos jurados.
- e) Fere o princípio da vedação de provas ilícitas a apreensão, sem prévia autorização judicial de busca, de substância entorpecente na residência de investigado por associação criminosa para o tráfico ilícito de drogas.

**2- (2019/MPE-SP/MPE-SP/Promotor de Justiça Substituto)** Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A ação persecutória do Estado para revestir-se de legitimidade não pode se apoiar em elementos probatórios ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à garantia constitucional do devido processo legal, que tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas mais expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso sistema de direito positivo.
- b) Na hipótese de o órgão legitimado pela investigação e propositura das medidas judiciais pertinentes demonstrar que obteve legitimamente novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova, esta deverá ser admitida, porque não se considera corrompida pela nódoa da ilicitude originária.
- c) Considerando a inidoneidade jurídica da prova ilicitamente obtida, eventual prova produzida de modo válido em momento subsequente, mas derivada de prova comprometida da ilicitude originária, deve ser declarada ilícita por derivação (a doutrina dos frutos da árvore envenenada).
- d) A realização de gravação ambiental por um dos interlocutores sem conhecimento do outro é considerada lícita.
- e) Por meio de um juízo de ponderação de interesses, a garantia constitucional da inadmissibilidade da prova ilícita pode ser afastada a fim de permitir, no caso concreto, a prevalência do interesse público consubstanciado na eficácia da repressão penal.

**3- (2019/CEBRASPE/TJ-PR/Juiz Substituto)** Acerca do princípio da identidade física do juiz, é correto afirmar que

- a) a doutrina relaciona esse princípio com os subprincípios da oralidade, da concentração dos atos e da imediatidade.
- b) o Código de Processo Penal dispõe expressamente hipóteses de limitação de aplicação desse princípio.
- c) o STF restringiu a eficácia desse princípio ao estabelecer o encerramento da instrução processual penal como marco para a prorrogação da competência quanto aos limites do foro por prerrogativa de função.
- d) a oposição de embargos declaratórios contra sentença condenatória proferida por juiz substituto é hipótese na qual se prorroga a competência desse magistrado, em obediência ao referido princípio.

**4- (2018/FCC/DPE-MA/Defensor Público)** “Um homem acusado de assalto foi morto por linchamento pela população em São Luís do Maranhão. Segundo a Polícia Militar (PM), J.F.B. agiu com um comparsa na abordagem de um eletricitista em uma parada de ônibus, na Avenida Marechal Castelo Branco” (Portal G1 MA, 10/04/2018). A notícia acima demonstra a NÃO observância do seguinte princípio do processo penal democrático:

- a) contraditório.
- b) jurisdicionalidade ou necessidade.
- c) imparcialidade.



- d) juiz natural.
- e) paridade de armas.

**5- (2016/FACET/Prefeitura/Procurador jurídico)** Sobre o princípio de vedação de autoincriminação, passemos a analisar as seguintes assertivas:

- I. O direito ao silêncio se aplica a testemunha, ante a indagação de autoridade pública de cuja resposta possa advir imputação da prática de crime ao declarante.
- II. O indiciado em inquérito policial ou acusado em processo criminal pode ser compelido pela autoridade a fornecer padrões vocais para a realização de perícia sob pena de responder por crime de desobediência.
- III. O acusado em processo criminal tem o direito de permanecer em silêncio, sendo certo que o silêncio não importará em confissão, mas poderá ser valorado pelo juiz de forma desfavorável ao réu.
- IV. O STF já pacificou entendimento de que é lícito ao juiz aumentar a pena do condenado, utilizando como justificativa o fato do réu ter mentido em juízo, dada a reprovabilidade de sua conduta.

Assinale:

- a) Se apenas as afirmativas I e II estiverem correta.
- b) Se apenas as afirmativas II e III estiverem correta.
- c) Se apenas as afirmativas I e IV estiverem correta.
- d) Se apenas as afirmativas I, II e IV estiverem correta.
- e) Se apenas a afirmativa I estiver correta.

**6- (2018/VUNESP/TJ-SP/Juiz Substituto)** São princípios constitucionais processuais penais explícitos e implícitos, respectivamente:

- a) intrascendência das penas e motivação das decisões; e intervenção mínima (ou *ultima ratio*) e duplo grau de jurisdição.
- b) contraditório e impulso oficial; e adequação social e favor rei (ou *in dubio pro reo*).
- c) dignidade da pessoa humana e juiz natural; e insignificância e identidade física do juiz.
- d) não culpabilidade (ou presunção de inocência) e duração razoável do processo; e não autoacusação (ou *nemo tenetur se detegere*) e paridade de armas.

**7- (2018/CEBRASPE/SEFAZ-RS/Técnico Tributário da Receita Estadual)** Iniciada a audiência de instrução, o juiz determinou que o réu da ação penal fosse algemado. Nesse caso, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o juiz agiu lícitamente se comprovado que

- a) o crime tenha sido cometido com violência.
- b) a vítima estava na sala de audiência.
- c) o crime é punível com pena de reclusão.
- d) o réu tem transtorno psicológico.
- e) a segurança do próprio réu estava em risco.

**8- (2018/VUNESP/MPE-SP/Analista jurídico— adaptada)** Em relação aos princípios que regem o processo penal, julgue os itens:

- I - a Constituição Federal garante expressamente os princípios da independência e da imparcialidade do juiz.
- II - o direito ao julgamento em prazo razoável está previsto na Constituição Federal e pode ter como termo inicial ato realizado na fase de inquérito policial.
- III - sobre o princípio da motivação das decisões judiciais, há previsão no CPP quanto à denominada *motivação per relationem*.
- IV - o art. 20, do CPP, que garante o sigilo das investigações no inquérito policial, não foi recepcionado pela Constituição Federal, que previu expressamente o princípio da publicidade.

**9- (2018/FGV/AL-RO/Consultor Legislativo)** Analise as assertivas a seguir, que tratam sobre os princípios aplicáveis ao Direito Processual Penal.

- I. Com base no princípio da presunção de inocência, a prisão preventiva deve ser decretada apenas quando as medidas cautelares alternativas não forem suficientes, não mais havendo prisão automática em razão de sentença condenatória de primeira instância;
- II. Com base no princípio da irretroatividade da lei processual penal, uma lei de conteúdo exclusivamente processual penal, em sendo mais gravosa ao réu, não poderá retroagir para atingir fatos anteriores a sua entrada em vigor.

**10- (2018/FGV/TJ-AL/Analista Judiciário)** Carlos conduzia seu veículo automotor de maneira tranquila, quando foi parado em uma operação que verificava a condução de veículo automotor em via pública sob a influência de álcool. Apesar de estar totalmente consciente de seus atos, Carlos havia ingerido 07 (sete) latas de cerveja, razão pela qual temia que o teste do “bafômetro” identificasse percentual acima do permitido em lei. De acordo com a jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores, Carlos:

- a) não é obrigado a realizar o exame, que exige um comportamento positivo seu, respeitando-se a regra de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, diferentemente do que ocorreria se fosse necessária apenas cooperação passiva;
- b) é obrigado a realizar o exame, tendo em vista que esse é indispensável para a configuração do tipo, sempre podendo o resultado ser utilizado como meio de prova;
- c) não é obrigado a realizar o exame, pois ninguém é obrigado a produzir prova contra si, seja através de cooperação ativa seja com cooperação passiva, como no caso de ato de reconhecimento de pessoa;
- d) é obrigado a realizar o exame, ainda que este seja desnecessário para a configuração do tipo, que pode ser demonstrado por outros meios de prova;
- e) é obrigado a realizar o exame, mas seu resultado poderá ou não ser utilizado como meio de prova de acordo com a vontade de Carlos, já que ninguém é obrigado a produzir prova contra si.

## COMENTÁRIOS

### 1. Gabarito: C

- a) INCORRETA. Cabe à defesa provar a inexistência da causa de exclusão da antijuridicidade alegada pelo réu.
- b) INCORRETA. Não basta o réu alegar ter utilizado um simulacro de arma de fogo que tenha sido confundido pela vítima, ele deve comprovar.
- c) CORRETA. Fere os princípios do contraditório e da ampla defesa a não intimação da defesa acerca da expedição de carta precatória para oitiva de testemunha arrolada residente em outra comarca. (Súmula nº 273 STJ.)
- d) INCORRETA. Não viola o princípio do juiz natural o desaforamento de julgamentos do tribunal do júri para comarca que não seja circunvizinha de local que gere dúvida acerca da imparcialidade dos jurados (art. 427 do CPP).
- e) INCORRETA. Havendo suspeitas de que existe droga em determinada casa, será possível que os policiais invadam a residência mesmo sem ordem judicial e ainda que contra o consentimento do morador. No entanto, no caso concreto, devem existir fundadas razões que indiquem que ali está sendo cometido um crime. Essas razões que motivaram a invasão forçada deverão ser posteriormente expostas pela autoridade, sob pena de ela responder nos âmbitos disciplinar, civil e penal. Além disso, os atos praticados poderão ser anulados. O STF possui uma tese fixada sobre o tema: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas *a posteriori*, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral) (Info 806).

### 2. Gabarito: E

- a) CORRETA. A ação persecutória do Estado para revestir-se de legitimidade não pode se apoiar em elementos probatórios ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à garantia constitucional do devido processo legal, que tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas mais expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso sistema de direito positivo (inciso LVI, do art. 5º, da CF; art. 157, do CPP; STF, RHC 90.376/2007).
- b) CORRETA. De acordo com o parágrafo 1º, do art. 157, do CPP e a jurisprudência do STF (HC 116.931/2015 - tese reproduzida na alternativa).
- c) CORRETA. Trata-se da doutrina dos frutos da árvore envenenada (parágrafo 1º, do art. 157, do CPP; RHC 90.376/2007).
- d) CORRETA. Captação, por meio de fita magnética, de conversa entre presentes, ou seja, a chamada gravação ambiental, autorizada por um dos interlocutores, vítima de concussão, sem o conhecimento dos demais. Ilícitude da prova excluída por caracterizar-se o exercício de legítima defesa de quem a produziu (STF, HC 74.678 e HC 75.261).

e) INCORRETA. A prova ilícita não pode ser aceita para servir de base à condenação do réu. Pelo contrário, a garantia constitucional da inadmissibilidade da prova ilícita pode ser afastada no caso de ser a única fonte de prova da inocência do réu.

**3. Gabarito: A**

a) CORRETA. A alternativa está de acordo com a doutrina majoritária no assunto, podendo citar Aury Lopes Júnior, Fernando Capez e Renato Marcão.

b) INCORRETA. O CPP não prevê limitações expressas a esse princípio. Aliás, a própria consagração da identidade física do juiz como regra expressa no processo penal é recente, com o advento da Lei nº 11.719/2008 que conferiu nova redação ao art. 399, § 2º do CPP. Temos de buscar as limitações e exceções a esse princípio no processo civil.

c) INCORRETA. Em verdade, é a publicação do despacho de intimação das partes para a apresentação de alegações finais que traduz o marco a partir do qual não mais haverá alteração da competência para o processamento e julgamento do feito, mesmo que o agente público acusado passe a ocupar outro cargo ou deixe o cargo que ocupava; vide Ação Penal (AP) 937/RJ, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, cuja decisão final foi exarada na data de 3 de maio de 2018.

d) INCORRETA. Aplicam-se normalmente as ressalvas ao princípio da identidade física do juiz quanto ao julgamento de embargos de declaração. Se o juiz que proferiu a sentença e entrar de férias logo de imediato, o substituto irá julgar os embargos (STJ HC 155.811-AL).

**4. Gabarito: B.** Se a Constituição Federal enfatiza que “ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (art. 5º, LIV), que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente” (art. 5º, LXI), que “a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juízo competente” (art. 5º, LXII), que “a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária” (art. 5º, LXV) e que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI), fica evidente que a Carta Magna impõe a sujeição de toda e qualquer medida cautelar de natureza pessoal à apreciação do Poder Judiciário.

**5. Gabarito: E**

I – CORRETO. Enquanto testemunha, o indivíduo tem a obrigação de dizer a verdade, porém se das perguntas que lhe forem formuladas puder resultar uma autoincriminação, a testemunha deixa de ser testemunha e passa a ser tratada como imputado ou investigado, tendo direito ao *nemo tenetur se detegere*. Precedente: STF: “(...) Paciente que, embora rotulado de testemunha, em verdade encontrava-se na condição de investigado. Direito constitucional ao silêncio. Atipicidade da conduta. Ordem concedida para trancar a ação penal ante patente falta de justa causa para prosseguimento”. (STF, HC 106.876/RN; STF, Pleno, HC 73.035/DF; STF, RHC 122.279/RJ.)

II – INCORRETO. Princípio da não autoincriminação.

III – INCORRETO. De acordo com o art. 186, parágrafo único, do CPP, prevê que o silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa.

IV – INCORRETO. Não há, no Brasil, o crime de perjúrio (mentira do próprio acusado em juízo). O direito de permanecer em silêncio insere-se no alcance concreto da cláusula constitucional do devido processo legal. E nesse direito ao silêncio inclui-se até mesmo por implicitude, a prerrogativa processual de o acusado negar, ainda que falsamente, perante a autoridade policial ou judiciária, a prática da infração penal. (STF, HC 68.929/SP.)

**6. Gabarito: D**

a) INCORRETA. O princípio da intervenção mínima é princípio do direito penal e não do direito processual penal, como requeria o comando da questão.

b) INCORRETA. O princípio da adequação social é de direito penal e não de direito processual penal e porque o princípio *in dubio pro reo* está previsto no CPP (art. 386) e não na Constituição.

c) INCORRETA. O princípio da insignificância é de direito penal e não de direito processual penal e porque o princípio da identidade física está previsto no CPP (art. 399, §2º).

d) CORRETA. O princípio da não culpabilidade ou presunção de inocência decorre expressamente do art. 5º, LVII, CF/88, assim como o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LVIII, CF/88. Veja que, após o ponto e vírgula, a alternativa previa os princípios implícitos. O direito à não autoacusação ou *nemo*

*tenetur se detegere* não está expressamente previsto na CF/88, mas decorre do direito ao silêncio. O princípio da paridade de armas, por outro lado, decorre do princípio do contraditório.

**7. Gabarito: E**

Súmula Vinculante nº 11: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

A súmula tem o objetivo de evitar o uso de algemas para exposição pública do preso, pois violaria a presunção da inocência e o princípio da dignidade humana.

**8. Gabarito: C**

I – INCORRETO. Os princípios mencionados decorrem do princípio constitucional do juiz natural, mas não possuem expressa previsão na Constituição Federal.

II – CORRETO. Basta lembrar que a razoável duração do processo engloba o âmbito judicial e o âmbito administrativo (inquérito policial, portanto). Art. 5º (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004.)

III – INCORRETO. A motivação por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, à precedente ou à decisão anterior nos autos do mesmo processo é chamada pela doutrina de motivação ou fundamentação *per relationem* ou *aliunde*. Também é denominada de motivação referenciada, por referência ou por remissão. Não possui previsão legal, sendo adotada por construção jurisprudencial.

IV – INCORRETO. O art. 20 do Código de Processo Penal prevê que a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. O artigo foi recepcionado e é adotado na prática.

**9. Gabarito: B**

I – CORRETO. De acordo com o art. 282, § 6º, e art. 310, II, ambos do CPP, a prisão preventiva é exceção e somente será cabível quando o magistrado justificar a não aplicação de medidas cautelares diversas. A utilização excepcional das prisões vai ao encontro do princípio da presunção de inocência.

II – INCORRETO. A lei processual penal tem aplicação imediata, atingindo, inclusive, os processos que já estão em curso, pouco importando se traz ou não situação gravosa ao imputado.

**10. Gabarito: A.** Por força do direito de não produzir prova contra si mesmo, doutrina e jurisprudência têm adotado o entendimento de que não se pode exigir um comportamento ativo do acusado. Assim, sempre que a produção da prova tiver como pressuposto uma ação por parte do acusado (ex.: acareação, reconstituição do crime, exame grafotécnico, bafômetro etc.), será indispensável seu consentimento.

## CAPÍTULO 3 – SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS

### 1. INTRODUÇÃO

Paulo Rangel define o sistema processual penal como sendo “o conjunto de princípios e regras constitucionais, de acordo com o momento político de cada Estado, que estabelece as diretrizes a serem seguidas à aplicação do direito penal a cada caso concreto.” (RANGEL, 2010, p. 49.)

A principal função da estrutura processual é a de garantia contra o arbítrio estatal, conformando-se o processo penal à Constituição Federal, de sorte que o sistema processual estaria contido dentro do sistema judiciário, que por sua vez é espécie do sistema constitucional, que deriva do sistema político (PRADO, 2006, p. 55).

Dessa forma, o sistema processual de cada Estado varia com o contexto político-social em que se encontra. Nos Estados totalitários, a moldura da legalidade se estende, aumentando o espaço para a discricionariedade e para o campo de atuação do Estado-juiz. Já nos Estados democráticos, a atuação do juiz é mais restrita, encontrando seu limite nos direitos individuais.

Como ensina a doutrina: em um Estado Democrático de Direito, o sistema acusatório é a garantia do cidadão contra qualquer arbítrio do Estado. *A contrario sensu*, no Estado totalitário, em que há supressão dos direitos e garantias individuais, o sistema inquisitivo encontra sua guarida (RANGEL, 2010, p. 49).

A doutrina tende a definir o sistema processual penal de cada Estado tomando por base uma característica considerada principal ou considerando a presença de todos os princípios de forma integral para definir um ou outro sistema.

São encontradas três espécies de sistemas processuais (tipos de processo penal): sistema acusatório, sistema inquisitivo e sistema misto.

De acordo com a jurisprudência (STF e STJ), é clara a opção do legislador constituinte pelo sistema acusatório. Já sobre quais são as características desse sistema, a jurisprudência não demonstra a necessária reflexão. É preciso estudar o tema à luz da doutrina.

Passamos à análise de cada um.

### 2. SISTEMA INQUISITIVO

Típico dos sistemas ditatoriais, contempla um processo judicial em que podem estar reunidas, na pessoa do juiz, as funções de acusar, defender e julgar, não existindo a obrigatoriedade de que haja uma acusação realizada por órgão público, sendo lícito ao juiz desencadear o processo criminal *ex officio*. Nessa mesma linha, faculta-se ao magistrado substituir as partes e determinar a produção das provas que reputar necessárias para elucidar o fato.

O sistema processual penal inquisitivo, como ensina Rangel (2010, p. 48), surgiu nos regimes monárquicos e se aperfeiçoou durante o direito canônico, passando a ser adotado em quase todas as legislações europeias dos séculos XVI, XVII e XVIII. Surgiu com sustento na afirmativa de que não se poderia deixar que a defesa social dependesse da boa vontade dos particulares. Desse modo, a concentração das funções de acusar e julgar nas mãos do Estado-juiz foi a solução encontrada e a característica principal do sistema inquisitivo, o que, claramente, comprometia a imparcialidade do julgador, que passou a tomar a iniciativa da própria acusação que viria a ser julgada por ele mesmo.

Principais características:

- Concentração de poderes – acusar, defender e julgar – nas mãos de um único órgão do Estado (juiz acusador/inquisidor)

A mesma pessoa, na figura do juiz, pode exercer as funções de acusar, defender e julgar, indistintamente.

- A confissão do réu é tida como a rainha das provas na busca da verdade, inclusive se for mediante tortura

A confissão era a prova máxima, suficiente para a condenação no sistema de prova tarifada. Fala-se em total inutilidade da defesa, pois, se o acusado confirma a acusação, não há necessidade de advogado (LOPES JR, 2018, p. 186).

Coutinho, ao tratar do sistema da prova tarifada ou legal, ensina que

muitas legislações aceitaram a previsão da possibilidade de o juiz incorrer em erro, no momento de valoração dos meios de prova utilizados, razão pela qual fixou-se, na lei, uma hierarquia de valores referentes a tais meios. Veja-se, nesse sentido, o sistema processual inquisitório medieval, no qual a confissão, no topo da estrutura, era considerada prova plena, a rainha das provas (*regina probationum*), tudo como fruto do tarifamento previamente estabelecido. Transferia-se o valor do julgador à lei, para evitar-se manipulações; e isso funcionava, retoricamente, como mecanismo de garantia do arguido, que estaria protegido contra os abusos decorrentes da subjetividade. Sem embargo, a história demonstrou, ao revés, como foram os fatos retorcidos, por exemplo, pela adoção irrestrita da tortura. (COUTINHO, p. 3.)

- Predominância de procedimentos escritos

Traço distintivo desse sistema e normalmente objeto de confusão é o fato de ele ser escrito e não oral. É comum que identifiquem a oralidade como integrante do sistema inquisitivo e a escrita como integrante do sistema acusatório quando se trata do oposto. Faz parte de nossa cultura cartorial e burocrática identificar a escrita como sendo algo mais seguro em oposição à oralidade. Para se concluir que o sistema escrito só pode se relacionar com o sistema inquisitorial, basta aliar essa característica com o processo sigiloso fazendo com que o processo inquisitivo seja totalmente autorreferente e surdo para seu entorno social (DEZEM, 2019, p. 94).

- Procedimento sigiloso/secreto

O processo não é público, tendo caráter sigiloso atribuído pelo juiz por meio de ato discricionário seu e à margem de fundamentação adequada.

- Sem contraditório e ampla defesa (devido à falta de contraposição entre acusação e defesa)

O acusado não possui garantias no decorrer do processo criminal (ampla defesa, contraditório, devido processo legal etc.), o que dá margem a excessos processuais. A própria defesa do réu é bastante restrita, não lhe sendo assegurado, ao contrário do que ocorre no modelo acusatório, o direito de manifestar-se depois da acusação para refutar provas e argumentos trazidos ao processo pelo acusador.

- Impulso oficial e liberdade processual
- Liberdade de o juiz colher provas (disparidade entre juiz e acusado)

Essa característica é devido ao fato de o juiz ser o único órgão que acusa, defende e julga. Então, o juiz deve dar início ao processo e ao longo de todo o procedimento ele pode produzir provas de ofício, gerir e instruir o processo.

- Réu é mero objeto do processo

A regra é o encarceramento e a incomunicabilidade do réu.

Como não há a presunção de inocência, é possível, de regra, a decretação da prisão provisória do réu no curso da ação penal, circunstância esta que faz com que, em grande parte dos casos, permaneça o réu preso durante o sumário da culpa.

- Não há imparcialidade

O juiz se liga intimamente à causa e não está sujeito à recusa, não havendo causas de impedimento nem suspeição.

- Incompatível com os direitos e garantias individuais

Como o réu é visto como objeto e não como sujeito, não há que se falar em direitos e garantias individuais.



### 3. SISTEMA ACUSATÓRIO

A origem do sistema acusatório remonta ao direito grego e romano, que se desenvolve referendado pela participação direta do povo no exercício da acusação e como julgador, de forma que a persecução penal e o exercício da ação penal eram encarregados a um órgão distinto do juiz, não pertencente ao Estado (LOPES JR., 2018, p. 175).

Principais características:

- Processo das partes
- Nítida separação entre as atividades de acusar e julgar

Há clara divisão entre as funções de acusar, defender e julgar, incumbindo cada uma destas condutas a um sujeito processual distinto.

- Liberdade de acusação
- Procedimento em regra é oral

O princípio aplicável ao processo penal é o da oralidade, principalmente devido à reforma processual de 2008.

- Publicidade no procedimento

A publicidade é ampla, geral e plena. A título de exceção, a publicidade pode ser restringida, é o que ocorre nos casos em que há violação à privacidade e à intimidade.

- Igualdade de posições/isonomia/paridade entre as partes

Tratamento igualitário das partes com igualdade de oportunidades no processo.

- Contraditório e possibilidade de resistência por parte da defesa
- Livre sistema de produção de provas

Com ausência de tarifa probatória, sustentando-se a sentença pelo livre convencimento motivado do órgão jurisdicional.

- Maior participação popular na justiça penal (publicidade/transparência)

O processo penal sendo público permite que qualquer pessoa o acompanhe, havendo transparência, o que permite um controle social sob o sistema de justiça.

- Réu é sujeito de direitos

O réu passa a ser titular de direitos e garantias fundamentais e não um mero objeto.

- Presunção de inocência
- Liberdade do réu é a regra

A prisão é imposta a título de exceção.

- O juiz não possui atividade instrutória (a iniciativa probatória deve ser das partes)

A atuação do juiz é passiva, no sentido de que ele deve se manter afastado da iniciativa e da gestão da prova, atividades a cargo das partes.

É nessa característica que pesam as críticas doutrinárias a respeito do nosso sistema acusatório, já que o CPP é muito antigo e as reformas sempre foram parciais, mantendo resquícios do sistema inquisitório.

- Instituição da coisa julgada atendendo à segurança jurídica
- Possibilidade de impugnar as decisões

**Atenção:** Ferrajoli (1999, p. 606) define as seguintes garantias: publicidade, oralidade, legalidade do processo e motivação da decisão judicial. Tais garantias são condições necessárias para que o debate transcorra com transparência e igualdade de oportunidades, ou seja, no ambiente que se espera da estrutura dialética do processo.



#### 4. SISTEMA MISTO OU INQUISITIVO GARANTISTA

Surgido após a Revolução Francesa, é um modelo processual intermediário entre o sistema acusatório e o sistema inquisitivo vistos anteriormente. Isso porque, ao mesmo tempo em que há a observância de garantias constitucionais, mantém ele alguns resquícios do sistema inquisitivo, a exemplo da faculdade que assiste ao juiz quanto à produção probatória *ex officio*. Na medida em que resulta de uma fusão entre as características dos outros dois modelos, o sistema misto, na atualidade, vem sendo chamado também de inquisitivo garantista (DEZEM, 2019, p. 95).

O sistema misto, assim, é dividido em duas fases: a primeira, consistente na instrução preliminar, tocada pelo juiz e nitidamente inquisitiva; e a segunda, judicial, sendo a acusação feita por órgão distinto do que irá realizar o julgamento.

Visto por Jacinto Coutinho como um “monstro de duas cabeças”, Aury Lopes Jr. aponta como principal defeito do modelo o fato de que

[...] a prova é colhida na inquisição do inquérito, sendo trazida integralmente para dentro do processo e, ao final, basta o belo discurso do julgador para imunizar a decisão. Esse discurso vem mascarado com as mais variadas fórmulas, do estilo: a prova do inquérito é corroborada pela prova judicializada; cotejando a prova policial com a judicializada; e assim todo um exercício imunizatório (ou melhor, uma fraude de etiquetas) para justificar uma condenação, que na verdade está calcada nos elementos colhidos no segredo da inquisição. O processo acaba por converter-se em uma mera repetição ou encenação da primeira fase (LOPES JR, Aury, 2009, p. 30).

Nesse sistema, a imparcialidade do magistrado continuou comprometida, mantendo-se o juiz na colheita das provas antes mesmo da acusação, quando deveria este ser retirado da fase persecutória, “entregando-se a mesma ao Ministério Público, que é quem deve controlar as diligências investigatórias realizadas pela polícia de atividade judiciária, ou, se necessário for realizá-las pessoalmente, formando sua *opinio delicti* e iniciando a ação penal” (RANGEL, 2010, p. 52).

Aury Lopes Junior, no entanto, critica a classificação do sistema como misto, considerando-a insuficiente e redundante, uma vez que “não existem mais sistemas puros (são tipos históricos), todos são mistos”. Para o autor, é preciso localizar “o princípio informador de cada sistema”, seu núcleo, de modo que, em sua essência, seria sempre puramente inquisitivo ou puramente acusatório; misto, apenas em relação a elementos secundários emprestados de um para outro sistema.

Alguns autores sustentam que o sistema brasileiro é o misto, analisando as disposições constitucionais em conjunto com o sistema legal do Código de Processo Penal e demais legislações extravagantes. Entre esses autores, encontra-se Guilherme de Souza Nucci que sustenta que

fosse verdadeiro e genuinamente acusatório o nosso sistema, não se poderia levar em conta, para qualquer efeito, as provas colhidas na fase inquisitiva, o que não ocorre em nosso processo na esfera criminal, bastando fazer a leitura do art. 155 do CPP. O juiz leva em consideração muito do que é produzido durante a investigação, como a prova técnica (aliás, produzida uma vez só durante o contraditório), os depoimentos colhidos e, sobretudo – lamentavelmente – a confissão extraída do indiciado (NUCCI, 2018, p. 51-52).

#### 5. SISTEMA PROCESSUAL ADOTADO NO BRASIL

##### 5.1. VISÃO CLASSICAMENTE ADOTADA (INCLUSIVE ANTES DA LEI Nº 13.964/2019)

Os princípios norteadores do sistema, advindos da Constituição Federal, possuem inspiração acusatória (ampla defesa, contraditório, publicidade, separação entre acusação e julgador, imparcialidade do juiz, presunção de inocência etc.). Os doutrinadores, por sua vez, que consideram o sistema processual penal brasileiro acusatório sempre se basearam na posição adotada pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 129, inciso I, que dispõe ser atividade privativa do



Ministério Público promover a ação penal pública, o que afastaria qualquer possibilidade de persecução pelo órgão julgador. Nesse sentido, posiciona-se Paulo Rangel, afirmando que “no direito pátrio, vige o sistema acusatório, pois a função de acusar foi entregue, privativamente, a um órgão distinto: o Ministério Público, e, em casos excepcionais, ao particular.” (RANGEL, 2010, p.56). Nesse sentido também se posicionam Antônio Cintra, Ada Pellegrini e Cândido Dinamarco. (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2007, p. 64-66.)

O STF já teve a oportunidade de analisar a matéria e declarou que o sistema vigente é o sistema acusatório, conforme acórdão abaixo:

PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da ação penal. (AP 883, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/3/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 11/5/2018 PUBLIC 14/5/2018.)

No mesmo sentido, o STJ:

2. Na ocasião, esclareceu-se que a jurisprudência tanto do Pretório Excelso quanto deste Sodalício é assente no sentido da desnecessidade de prévia autorização do Judiciário para a instauração de inquérito ou procedimento investigatório criminal contra agente com foro por prerrogativa de função, dada a inexistência de norma constitucional ou infraconstitucional nesse sentido, conclusão que revela a observância ao sistema acusatório adotado pelo Brasil, que prima pela distribuição das funções de acusar, defender e julgar a órgãos distintos. (STJ, HC 329.128/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe 23/5/2018.)

Nunca se negou, no entanto, a “impureza” do sistema brasileiro, considerando que resquícios do sistema inquisitivo sempre permearam a lei processual penal. Não basta uma separação inicial, com o Ministério Público formulando a acusação (art. 129, I, CF/88) e, depois, ao longo do procedimento, permitir que o juiz assuma um papel ativo na busca da prova ou mesmo na prática de atos tipicamente da parte acusadora (LOPES JR, 2018, p. 194), por exemplo, permitir que o juiz de ofício:

a) converta a prisão em flagrante em preventiva (art. 310), pois isso equivale à prisão decretada de ofício:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

**Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a**



**segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal (...) (STJ, 5ª Turma, RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/2/2020 – grifo nosso).**

b) determine busca e apreensão (art. 242):

“Art. 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes.”

c) determine o sequestro (art. 127):

“Art. 127. **O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa.**”

d) ouça testemunhas além das indicadas pelas partes (art. 209):

“Art. 209. **O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.**”

e) proceda ao interrogatório do réu a qualquer tempo (art. 196):

“Art. 196. **A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes.**”

f) determine diligências durante a fase processual e até mesmo no curso da investigação preliminar (art. 156, I e II):

**Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:**

**I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;**

**II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.**

g) reconheça agravantes ainda que não tenham sido alegadas e condene ainda que o Ministério Público tenha postulado a absolvição (art. 385):

“Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.”

h) altere a classificação jurídica do fato (art. 383):

**Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.**

**§ 1º Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei.**

**§ 2º Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.**



Desse modo, fica evidente a insuficiência de uma separação inicial de atividades se, depois, o juiz assumir um papel claramente inquisitorial. O juiz deve manter uma posição de afastamento ao longo de toda a persecução penal.

Por isso, Geraldo Prado sempre defendeu que o que prevalecia no Brasil era a teoria da aparência acusatória, uma vez que a Constituição Federal, com todas as garantias e a privatividade da ação penal pública dada ao Ministério Público, de fato se filiou ao sistema acusatório, mas, levando em consideração o concreto estatuto jurídico dos sujeitos processuais e a dinâmica dos tribunais, diz que se deve admitir que o princípio e o sistema acusatórios ainda eram meras promessas (PRADO, 1999, p. 171).

## 5.2. SÍNDROME DE DOM CASMURRO (QUADROS MENTAIS PARANOICOS)

A expressão “Síndrome de Dom Casmurro” faz referência à obra “Dom Casmurro”, de Machado de Assis, na qual Bento de Albuquerque Santiago (Bentinho) narra sua história de amor com Capitu e o ciúme que advém desse relacionamento, em virtude das dúvidas quanto à eventual traição de sua esposa com seu melhor amigo (Escobar).

É a história de um bacharel em Direito, mergulhado numa trama psicológica em que cada fato observado serve para contaminar a sua subjetividade e confirmar uma hipótese previamente estabelecida: a traição de Capitu. Bentinho sempre foi uma criança fechada, razão pela qual foi apelidado de Dom Casmurro. Com o passar dos anos, desistiu da vida interna no seminário para se entregar ao amor que sentia por Capitu, filha de seus vizinhos. Dedicou-se ao estudo, formou-se em Direito, tornando-se advogado, casou-se com a mulher que se apaixonou e teve um filho chamado Ezequiel. Esteve sempre ao lado da família um grande amigo, de nome Escobar, companheiro desde a época do seminário, que veio então a falecer.

E foi no velório que Bento enxergou algo que ainda não havia percebido: o comportamento de sua esposa, sofrida pela morte do amigo, era a conduta e o indício de que um adultério pairava no ar. O ciúme aumentou e com ele o quadro mental paranóico. Ao que lhe parece, seu filho, Ezequiel, estava tomando a feição de Escobar. A ideia tomou parte de sua estrutura psicológica e começou a investigar então essa possibilidade que já era, para ele, uma certeza indubitável. Só que em momento algum da sua narrativa Dom Casmurro ou qualquer outro personagem envolvido em sua história de vida traz ou demonstra indícios palpáveis, provas incontestáveis ou certezas inalienáveis sobre a acusação, transformando-a em realidade. Nunca chegaremos nem próximo ao fato histórico imputado à Capitu. A hipótese já foi tomada como decisão por Bentinho, desde o início do livro. Este é o ponto: a verdade construída por Bentinho (MELCHIOR, 2012, p. 153-154).

Assim, a expressão (Síndrome de Dom Casmurro – quadros mentais paranoicos) foi trazida para o processo penal para designar o juiz que, dotado de poderes investigatórios ou quando se aproxima da acusação ao longo do processo penal, primeiro decide, pois já teve contato com tudo antes de julgar e já possui uma decisão. Portanto, ao invés de analisar aquela prova de uma forma imparcial, o juiz sai à procura de material probatório para alicerçar e justificar a sua já tomada decisão.

Ao proceder ao recolhimento da prova, o magistrado antecipa a formação do juízo quanto à solução do litígio, pois, assumindo a iniciativa probatória, saberá o que deseja encontrar, gerando uma tendência que retirará a indispensável imparcialidade para apreciar os elementos carreados aos autos, comprometendo a estrutura dialética do processo. Abre-se ao juiz a possibilidade de decidir antes e, depois, sair em busca do material probatório suficiente para confirmar a sua versão, isto é, o sistema legitima a possibilidade da crença no imaginário, ao qual toma como verdadeiro (COUTINHO, 1998, p. 37).

Atribuir poderes instrutórios ao juiz (como os mencionados no tópico anterior) é um grave erro, que acarreta destruição completa do processo penal democrático, tendo em vista que ele passa a ter quadros mentais paranoicos (LOPES JR, 2018, p. 202).

Exatamente em razão do sistema processual acusatório – que cuidou de separar de maneira bem nítida as funções de acusar, defender e julgar –, não deve o magistrado ter uma participação ativa na primeira fase da *persecutio criminis*, de maneira a indicar o caminho pelo qual a investigação deve seguir. Nesse cenário, poderia o juiz começar a realizar os chamados quadros mentais paranoicos (Síndrome de Dom Casmurro), em franco prejuízo do investigado (MARÇAL; MASSON, 2015, p. 94).

### 5.3. VISÃO APÓS A LEI Nº 13.964 (LEI ANTICRIME)

A Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime), sancionada no dia 24 de dezembro de 2019, com entrada em vigor em janeiro de 2020, modificou muitas matérias nos campos penal e processual penal, trazendo avanços incontestáveis em direção aos preceitos de um processo penal acusatório. Assim, instituiu o juiz das garantias, consagrou a cadeia de custódia das provas, proibiu a decretação de medida cautelar de ofício pelo magistrado, instituiu prazo de revisão da decisão sobre prisão provisória, e previu as audiências de custódia no texto do CPP.

O artigo 3º-A, do CPP, consagra na legislação infraconstitucional o sistema acusatório já previsto no modelo constitucional:

“Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.”

O CPP, então, passa a prever uma estrutura verdadeiramente acusatória que deve ser corretamente desenvolvida com o consequente não aproveitamento de algumas regras inquisitórias do processo penal. Não foi outro o ímpeto da reforma promovida, vedando a iniciativa do juiz na fase de investigação, assim como a atuação probatória em substituição ao órgão de acusação.

Visando harmonizar nosso CPP ao sistema constitucional (acusatório), a nova lei cria a figura do juiz das garantias (art. 3º-A ao 3º-F), órgão jurisdicional com a missão de acompanhar as diversas etapas da investigação, responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autoridade prévia do Poder Judiciário (art. 3º-B). A ideia parte da premissa de que o juiz atuante na fase preliminar da persecução penal – inquérito policial – e que tem contatos com elementos de investigação, pode ter sua imparcialidade fragilizada ao formar concepções.

Na fase de investigação e recebimento da acusação, atuará o Juiz das Garantias, enquanto na fase de julgamento, o Juiz de Julgamento não receberá nem se contaminará pelo produzido na fase anterior, já que somente provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas e antecipação de provas serão encaminhados. O restante deverá permanecer acautelado no Juiz das Garantias (CPP, art. 3-B, § 3º), com acesso às partes (CPP, art. 3-B, § 4º).

A reforma promovida pela Lei nº 13.964/2019 foi parcial e não global, mantendo no CPP artigos que ainda permitem a atividade de ofício do juiz tanto na fase investigativa como na fase judicial (arts. 127, 156, 196, 209, 242, 310, 383 e 385). Em busca da concretização do sistema acusatório processual almejado na Constituição Federal e no CPP, o que se deve é aplicar uma interpretação constitucional a todos os dispositivos do CPP, mesmo aqueles não revogados expressamente. Isto é, o núcleo do art. 3º-A deve guiar a leitura de todo o restante das normas, devendo compatibilizar os atos que serão praticados com o novo modelo, com a finalidade de adaptar a mentalidade dos juízes para que corretamente apliquem a estrutura acusatória.

A título de exemplo, o art. 3º-A do CPP veda expressamente a iniciativa do juiz na fase de investigação, mas o legislador não realizou a revogação expressa do art. 156, I, do CPP, que autoriza ao magistrado ordenar, de ofício, mesmo antes de iniciada a ação penal, ou seja, na fase de investigação, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes.

Apesar de eu entender que essa previsão é flagrantemente inconstitucional, de pronto, a doutrina ainda não firmou entendimento pela revogação tácita do dispositivo, bem como não há manifestação ainda da jurisprudência. Dessa forma, para provas, não obstante a importância de que

se conheça as críticas, a tendência é que prevaleça a possibilidade de atuação do juiz e que o examinador continue cobrando a literalidade do CPP (quanto aos artigos: arts. 127, 156, 196, 209, 242, 310, 383 e 385).

Precisaremos aguardar para verificar qual será o posicionamento adotado, sobretudo em se considerando que até o fechamento desta obra os artigos 3º-A ao 3º-F estão com eficácia suspensa, nos termos da decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal proferida pelo Ministro Relator Luiz Fux na data de 22 de janeiro de 2020 (STF – ADI 6298/DF).

## QUESTÕES

**1. (2018/FCC/Câmara Legislativa do DF/Consultor Legislativo)** Uma reforma que pretenda incorporar traços do sistema acusatório na legislação processual penal vigente deve orientar-se no sentido de

- a) concentrar a gestão da prova na pessoa do juiz.
- b) ampliar os espaços de oralidade nos atos processuais.
- c) reduzir a imediação judicial na produção da prova.
- d) limitar a publicidade dos atos processuais.
- e) ampliar a tarifação e a taxatividade das provas.

**2. (2018/CESPE/ABIN/Oficial Técnico de Inteligência)** Acerca dos princípios gerais, das fontes e da interpretação da lei processual penal, bem como dos sistemas de processo penal, julgue o item que se segue. A publicidade, a imparcialidade, o contraditório e a ampla defesa são características marcantes do sistema processual acusatório.

**3. (2017/CESPE/DPE-AL/Defensor Público)** No processo penal, as características do sistema acusatório incluem I. clara distinção entre as atividades de acusar e julgar, iniciativa probatória exclusiva das partes e o juiz como terceiro imparcial e passivo na coleta da prova.

II. neutralidade do juiz, igualdade de oportunidades às partes no processo e repúdio à prova tarifada.

III. predominância da oralidade no processo, imparcialidade do juiz e supremacia da confissão do réu como meio de prova.

IV. celeridade do processo e busca da verdade real, o que faculta ao juiz determinar de ofício a produção de prova.

Estão certos apenas os itens

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) I, III e IV.
- e) II, III e IV.

**4. (2016/CESPE/PC-PE/Delegado de polícia – adaptada)** Em consonância com a doutrina majoritária e com o entendimento dos tribunais superiores, assinale a opção correta acerca dos sistemas e princípios do processo penal. Julgue os itens.

I) O sistema processual acusatório não restringe a ingerência, de ofício, do magistrado antes da fase processual da persecução penal.

II) No sistema processual inquisitivo, o processo é público; a confissão é elemento suficiente para a condenação; e as funções de acusação e julgamento são atribuídas a pessoas distintas.

**5. (2015/CESPE/DPE-RN/Defensor Público Substituto)** Assinale a opção correta a respeito dos sistemas de processo penal e da interpretação da lei processual penal segundo o CPP e o entendimento do STJ. Julgue o item: no sistema inquisitivo, a confissão é considerada a rainha das provas e predominam nele procedimentos exclusivamente escritos.

**6. (2014/FUNCAB/PC-RO/Delegado de Polícia Civil)** Assinale a alternativa em que se encontra uma característica do sistema acusatório.

- a) O julgador é protagonista na busca pela prova.
- b) As decisões não precisam ser fundamentadas.

- c) A atividade probatória é atribuição natural das partes.
- d) As funções de acusar e de julgar são concentradas em uma pessoa.
- e) As decisões são sempre sigilosas.

### COMENTÁRIOS

1. Gabarito: B. Segundo Ferrajoli, são características do sistema acusatório a separação rígida entre o juiz e a acusação, a paridade entre acusação e defesa (paridade de armas), a publicidade e a oralidade.

2. CORRETA. O sistema penal brasileiro é acusatório. Isso se dá pela incidência de diversos dispositivos constitucionais garantidores, como da tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV), do devido processo legal (art. 5º, LIV), da garantia do acesso à justiça (art. 5º, LXXIV), da garantia do juiz natural e imparcial (art. 5º, XXXVII e LIII), do tratamento paritário das partes (art. 5º, *caput* e I), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, LVI e LXII), da publicidade dos atos processuais e motivação dos atos decisórios (art. 93, IX) e da presunção da inocência (art. 5º, LVII).

3. Gabarito: A. Cuidado com os itens incorretos.

Item III: INCORRETO. Não haverá supremacia da confissão como meio de prova. Isso é resquício de sistema inquisitório, em que há tarificação de provas.

Item IV: INCORRETO. Muitos doutrinadores do processo penal têm dito que hoje não se pode mais falar em princípio da busca da verdade real ou da busca da verdade material porque o juiz tem tido os seus poderes reduzidos no campo de instrução criminal e porque o processo penal tem um sistema acusatório, cabendo ao órgão acusatório, e não ao juiz, trazer as provas para o processo.

4. Item I: INCORRETA. No sistema acusatório existe clara distinção entre as funções de acusar, defender e julgar. Assim, é da essência do sistema acusatório a restrição ao juiz de atuar nos atos pré-processuais. Contudo, embora haja muita discussão na doutrina, existem artigos que facultam ao juiz a ingerência em atos anteriores à ação penal, principalmente, quando tais atos referem-se a tutelar liberdades individuais (vide art. 156 do CPP).

Item II: INCORRETA. No sistema inquisitivo, acusação e julgamento são funções atribuídas ao mesmo órgão. Também não é público, e sim sigiloso.

5. ITEM CORRETO. O sistema inquisitivo é caracterizado pela concentração de poder nas mãos do julgador, que exerce, também, a função de acusador; a confissão do réu é considerada a rainha das provas; não há debates orais, predominando procedimentos exclusivamente escritos; os julgadores não estão sujeitos à recusa; o procedimento é sigiloso; há ausência de contraditório; e a defesa é meramente decorativa.

6. Gabarito: C. O sistema acusatório possui nítida separação entre o órgão acusador e o julgador; há liberdade de acusação, reconhecido o direito ao ofendido e a qualquer cidadão; predomina a liberdade de defesa e a isonomia entre as partes no processo; vigora a publicidade do procedimento; o contraditório está presente; existe a possibilidade de recusa do julgador; há livre sistema de produção de provas; predomina maior participação popular na justiça penal; e a liberdade do réu é a regra.



## CAPÍTULO 4 – DISPOSIÇÕES GERAIS DO CPP (ARTS. 1º A 3º DO CPP)

### 1. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL PENAL NO ESPAÇO (ART. 1º DO CPP)

#### 1.1. TERRITORIALIDADE

A lei processual penal no espaço orienta-se pelo princípio da territorialidade, de forma que a lei brasileira se aplica aos processos que tramitarem em nosso país. Por exemplo, uma carta rogatória expedida por um juiz estrangeiro a ser cumprida no Brasil seguirá as leis processuais brasileiras, pois esse cumprimento ocorrerá dentro do território brasileiro. Trata-se do princípio *lex fori*, que se justifica pela soberania nacional.

Conforme a doutrina, o CPP adota o princípio da territorialidade absoluta (*locus regit actum*), no sentido de que, no Brasil, não se admite a aplicação de direito processual estrangeiro, apesar de admitir a aplicação de regras de direito internacional. Adota, também, o princípio da territorialidade estrita, no sentido de que a lei processual brasileira, ao contrário do que ocorre com a lei penal, não tem extraterritorialidade. Contudo, isso não quer dizer que ela não será aplicada a crimes cometidos fora do território nacional, pois, se o crime for aqui julgado, a lei processual brasileira será aplicada.

No que diz respeito à aplicação da lei processual no espaço, a regra está no *caput* do art. 1º do CPP:

“Art. 1º, CPP: o processo penal rege-se-á, em todo o território brasileiro, por este código, ressalvados (...)”

A regra geral, portanto, é que o Código de Processo Penal seja aplicado às ações penais e correlatas que tiverem curso no território nacional (*lex fori*), mas são definidas também, no Código, situações específicas de exceções. É necessário olhar com cuidado para essas hipóteses, já que se referem à normatização própria de Tratados Internacionais ou do Código Penal Militar (procedimento específico), e à prerrogativa de função. O inciso V não tem aplicação prática porque os delitos de imprensa deixaram de existir (vide ADPF 130/DF).

#### 1.2. EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 1º DO CPP

São os casos em que o processo penal corre no território brasileiro, mas não é aplicável o CPP, mas sim outra legislação:

Art. 1º.

I - os tratados, as convenções e regras de direito internacional;

II - as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República, e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade (Constituição, arts. 86, 89, § 2º, e 100);

III - os processos da competência da Justiça Militar;

IV - os processos da competência do tribunal especial (Constituição, art. 122, no 17);

V - os processos por crimes de imprensa. (Vide ADPF nº 130)

Parágrafo único. Aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos nos nºs. IV e V, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso.

Abaixo algumas considerações:

##### 1.2.1. OS TRATADOS, CONVENÇÕES E REGRAS DE DIREITO INTERNACIONAL

A subscrição do documento pelo Estado brasileiro integra os esforços internacionais para conter determinados crimes especialmente nocivos à comunidade internacional. Mesmo que o



ato seja praticado no Brasil, haverá de ser respeitado o regramento processual internacional a que o País haja anuído. Desse modo, o país pode se comprometer a não aplicar o CPP a determinados delitos cometidos em seu território.

É o que acontece, por exemplo, com os embaixadores, que possuem a chamada imunidade diplomática, originada pela ratificação do Brasil a um tratado internacional (no caso, a Convenção de Viena). Um embaixador que cometer um crime no Brasil terá o direito de ser processado e julgado, de regra, em seu país de origem, não sendo alcançado pelo nosso Código de Processo Penal.

### 1.2.2. PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS

De acordo com as prerrogativas do indivíduo, em razão do cargo por ele ocupado, pode ser que uma conduta realizada por ele não seja alcançada pela justiça comum e pelo CPP. É o caso, por exemplo, do Presidente da República, que em crimes de responsabilidade não é processado pelos trâmites previstos no CPP, e sim por órgãos do Poder Legislativo, de acordo com procedimentos previstos na Constituição Federal. No processo de *impeachment* serão adotadas normas da Constituição Federal e da Lei nº 1.079/1950.

### 1.2.3. JUSTIÇA MILITAR

Os procedimentos de competência da Justiça Militar não são submetidos ao CPP em razão desta possuir o Código de Processo Penal Militar (CPPM).

Legislação específica que prevê procedimento diverso daquele estabelecido pelo CPP, por exemplo, os crimes militares, aos quais se aplica o Código de Processo Penal Militar, ou ainda os crimes eleitorais, aos quais se aplica o Código Eleitoral.

### 1.2.4. TRIBUNAL ESPECIAL

Na sistemática original do CPP, que foi promulgado em 1942, existia o Tribunal de Segurança Nacional, que possuía competência para julgar os crimes que atentassem contra a existência, segurança e integridade do Estado, ou contra a economia popular, porém com a promulgação da Constituição de 1946, esse tribunal deixou de existir, portanto o inciso IV do art. 1º, CPP, não mais se aplica. Atualmente, os crimes contra a segurança nacional estão previstos na Lei nº 7.170/1983, sendo a Justiça Federal competente para seu julgamento.

### 1.2.5. CRIMES DE IMPRENSA

Anteriormente à Constituição de 1988, os crimes de imprensa eram previstos pela Lei nº 5.250/1967, a qual não foi recepcionada pela atual Carta Maior, conforme a decisão do STF na ADPF 130/2009. O inciso V, art. 1º, CPP, portanto, também não é mais aplicado.

## 1.3. EXTRATERRITORIALIDADE

Via de regra, a lei processual penal não possui atributos de extraterritorialidade, ou seja, deve ser aplicada em território soberano, sem mais considerações. No entanto, existem três exceções pontuais, nas quais poderá ser aplicada a lei processual penal brasileira em território diferente do nacional. Como pode se perceber, as hipóteses são bem mais restritas do que as de aplicação no Código Penal.

Exceções:





**Territórios *nullius*:** seriam as vulgarmente chamadas “terras de ninguém”, que não pertencem a nenhum país. Nesse caso, não haveria jurisdição estrangeira em tal tipo de território, por isso, a lei processual penal brasileira poderia ser aplicada;

**Expressa autorização de Estado estrangeiro:** como o Estado estrangeiro exerce jurisdição sobre seu próprio território, pode também afastá-la se assim julgar conveniente, portanto, caso determine que é a lei processual brasileira que deve ser lá aplicada, o Brasil poderá extravasar a área de aplicação da lei processual penal nacional excepcionalmente;

**Território ocupado durante a guerra:** em situações de guerra, caso o Brasil invada um determinado território, ocupando-o, poderá exercer jurisdição sobre esse local.

Para fins de prova, você apenas precisa conhecer que essas possibilidades existem. Mais importante que elas, tenha atenção aos incisos do art. 1º do CPP que já analisamos.

## 2. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL PENAL NO TEMPO (ART. 2º do CPP)

Por força do art. 2º do CPP, incide no processo penal o princípio da aplicabilidade imediata, no sentido de que a norma processual se aplica tão logo entre em vigor, sem prejuízo da validade dos atos já praticados anteriormente. O fundamento da aplicação imediata da lei processual é que se presume seja ela mais perfeita do que a anterior, por atentar mais aos interesses da Justiça, salvaguardar melhor o direito das partes, garantir defesa mais ampla ao acusado etc. Portanto, ao contrário da lei penal, que leva em conta o momento da prática delituosa (*tempus delicti*), a aplicação imediata da lei processual leva em consideração o momento da prática do ato processual (*tempus regit actum*).

Pouco importa se o fato delituoso objeto do processo tenha sido cometido anteriormente à entrada em vigor da lei processual. Qualquer que seja a data do crime, a lei processual a ser aplicada é a que vigora ao tempo da prática do ato processual.

Assim, não importa quando o crime foi cometido: a lei nova deve ser aplicada ao caso em andamento, com a ressalva de que não haverá necessidade de repetição dos atos processuais já realizados. Abaixo o dispositivo legal:

“Art. 2º A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.”

São efeitos do princípio *tempus regit actum*, previsto no CPP:

a) as normas processuais têm aplicação imediata, pouco importando se o fato que deu origem ao processo é anterior à sua entrada em vigor;

b) os atos processuais realizados sob a égide da lei anterior são considerados válidos; os atos já encerrados não são reabertos, mesmo tendo mudado a lei processual;

c) a lei processual não retroage, mas é aplicada imediatamente a todos os casos em andamento, sejam as novas regras mais restritivas ou não (desde que, óbvio, não sejam inconstitucionais). Se houvesse retroação, caso benéfico, tudo teria que ser repetido, o que não é exigido pelo art. 2º do CPP, que ressalva expressamente os atos já realizados.

Sobre o tema, a doutrina dispõe a respeito de três sistemas processuais:

O sistema da unidade processual não é adotado no Brasil. De acordo com ele, o processo é entendido como um só, com a consequência de que, uma vez iniciado sob a vigência de determinada lei processual, deve seguir até o fim sob a regência dessa mesma lei, mesmo que tenha havido alteração no ordenamento.

O sistema das fases processuais também não é adotado no Brasil e divide o processo, como o nome diz, em fases, de modo que, iniciada uma etapa – ex.: fase instrutória – deve ser aplicada a lei que estava em vigor quando ela começou, não se aplicando eventual modificação, senão para a fase seguinte.

De acordo com o sistema do isolamento dos atos processuais, o processo é visto como uma sucessão de atos isolados, de modo que se deve aplicar, para cada ato, a lei em vigor quando é realizado. É o sistema adotado no Brasil, como se depreende do art. 2º do CPP.

**Atenção:** há, porém, uma ressalva, que diz respeito às normas mistas, ou seja, de caráter processual e material. Ela não deixa de ser uma lei processual, mas os efeitos que produz em face da sua supressão do ordenamento jurídico trazem uma consequência não só no direito processual como também no direito material, naquilo que diz respeito ao exercício do poder punitivo do Estado. Se a norma contiver disposições de ordem material e processual, deve prevalecer as regras de caráter material, aplicando-se o art. 2º e parágrafo único do CP. Assim, se o conteúdo penal for benéfico ao acusado, esta parte da lei retroage e as regras processuais são aplicadas desde logo. Se, porém, o conteúdo penal for prejudicial ao acusado, não poderá ser aplicada a lei, mesmo no seu aspecto processual.

A doutrina chegou a cogitar da cisão na aplicação da lei, ou seja, naquilo que ela possui de processual, se aplicaria desde logo, como base no dispositivo em exame. E, no ponto em que é apenas penal, não poderia ser aplicada, posto que desfavorável ao réu (art. 1º CP). No entanto, o STF se manifestou em sentido contrário.

Portanto:

- a) no caso de normas puramente processuais, aplica-se, desde logo, o art. 2º do CPP;
- b) no caso de normas mistas, ou seja, que misturem aspectos penais e processuais, o aspecto penal deve prevalecer, de modo que a nova lei não se aplicará se os dispositivos de natureza penal forem mais gravosos ao imputado.

Essa diferenciação é tão importante que o próprio legislador, em alguns casos, se preocupou em registrar de forma expressa que a norma híbrida deve ser aplicada da maneira mais favorável:

Lei de Introdução ao Código de Processo Penal: “Art. 2º À prisão preventiva e à fiança aplicar-se-ão os dispositivos que forem mais favoráveis.”

Ao editar o CPP, o legislador emitiu também uma lei de introdução a tal código, de modo a esclarecer certos pontos obscuros do diploma legal. Um dos artigos que merece destaque é o posto acima, no qual o legislador determina que em casos de prisão preventiva e fiança, aplicam-se os dispositivos mais favoráveis.

Acontece que normas de prisão preventiva e fiança, embora costumeiramente incluídas no CPP (de conteúdo essencialmente processual), afetam diretamente o direito à liberdade do acusado, ou seja, algo de conteúdo material, tangível que será praticado contra ele, deixando de ser meramente procedimental. Com isso, deve ser considerada como norma híbrida. Como foi visto, a partir do momento que se considera como uma norma como híbrida (apresentando tanto conteúdo de direito formal quanto material), deve sempre prevalecer a norma mais benéfica para o acusado.

Portanto, para as provas, o importante não é que você decore quais são normas híbridas e quais são apenas processuais, mas sim que observe a norma e tente perceber se ela também afeta algum direito material. Em caso afirmativo, você estará diante de uma norma híbrida.

Resumindo:

- norma penal (material): retroage em benefício;
- norma processual penal (art. 2º do CPP): aplica-se desde logo; não importa se beneficia ou prejudica; não invalida os atos já praticados;
- norma híbrida (material e processual): também pode retroagir de forma benéfica; é exceção no CPP; a regra são as normas processuais comuns; exemplos: fiança, decadência, prisão preventiva.



### 3. UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPP

Em alguns casos, uma lei especial poderá trazer procedimentos específicos para os crimes que são por ela disciplinados. É o caso, por exemplo, da Lei de Drogas, que disciplina procedimentos específicos para os seus delitos.

No entanto, muitas vezes a lei não disciplina todos os procedimentos necessários para a apuração completa do delito, e sim apenas alguns pontos. Quando isso acontece, o CPP deve ser utilizado de forma complementar (subsidiária).

### 4. PECULARIDADES DA LEI PROCESSUAL PENAL (ART. 3º DO CPP)

Ao estudar o direito processual penal, diversos institutos são importantes, tais como a interpretação extensiva, a interpretação analógica e a analogia. O art. 3º do CPP permite a aplicação de todos esses institutos no processo penal.

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.”

É importante que façamos uma breve abordagem.

#### 4.1. ANALOGIA

A analogia é uma forma de integração da lei, utilizada quando o intérprete efetivamente “pega emprestada” outra norma para suprir uma omissão na legislação e conseguir oferecer uma solução para o caso. Consiste em estender a um caso não previsto aquilo que o legislador previu para outro caso, desde que em igualdade de condições. Justifica-se o seu uso uma vez que, em face da infinidade de condutas humanas, jamais será possível ao ordenamento jurídico estabelecer uma previsão normativa que discipline e esgote cada uma delas (PÂNCORA, 2017, MÉTODO, p. 37).

É o caso, por exemplo, de o Ministério Público, ao oferecer denúncia, não formular a proposta de suspensão condicional do processo a que alude o art. 89 da Lei nº 9.099/1995, podendo fazê-lo. Não concordando com essa atitude, deverá o juiz aplicar, por analogia, o art. 28 do CPP (Súmula nº 696, STF).

No Direito Penal, a analogia só pode ser utilizada em benefício do acusado. O juiz não pode utilizar uma norma “emprestada” para prejudicar o réu. Já no Direito Processual Penal, a analogia pode ser utilizada sem restrições (tanto em benefício quanto em prejuízo do acusado).

Assim, há uma lacuna, que pode ser integrada por meio da analogia. Para tanto, toma-se a regra existente para situações semelhantes: *ubi eadem ratio, ibi idem jus* (onde há a mesma razão de fato, há o mesmo direito).

#### 4.2. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA

Além da analogia, há ainda a chamada interpretação extensiva, que nada mais é do que a ampliação do sentido de uma determinada norma, para que ela alcance todo o efeito que se espera dela. Isto é, existe uma norma que regula o caso concreto, porém sua eficácia é limitada a outra hipótese, razão pela qual é necessário ampliar seu alcance.

É importante observar que tanto o Direito Penal quanto o Direito Processual Penal admitem a interpretação extensiva e, no caso do CPP, tal previsão existe de forma expressa, sedimentada no texto do art. 3º.

Ex.1: ampliação pelo STJ das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito (RESE) previstas no artigo 581 do CPP por meio de interpretação extensiva:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de

prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; (Redação dada pela Lei nº 7.780, de 22.6.1989)

O CPP só fala que é cabível o recurso em sentido estrito no caso de indeferimento ou revogação de prisão preventiva, nada fala da prisão temporária, mas o STJ estende a previsão legal para os casos de prisão temporária.

Ex.2: aplicação das causas de suspeição ou impedimento dos juízes para os jurados que desempenham a função de julgador no Tribunal do Júri.

#### 4.3. COSTUMES

Conduta praticada de forma reiterada, de forma constante, que aparentemente é obrigatória, mas que não revoga normas (sequer tacitamente), mas acaba sendo uma conduta constante a ser adotada e que é uma forma de suprir, de autointegrar as normas e isso vale também para o direito processual penal; “são regras de condutas praticadas de modo geral, constante e uniforme (elemento interno), com a consciência de sua obrigatoriedade (elemento externo)” (MIRABETE). É de se ressaltar que os costumes não têm o condão de revogar normas.

#### 4.4. PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO

Princípios gerais do direito: “são premissas éticas extraídas da legislação e do ordenamento jurídico em geral” (MIRABETE).

#### QUESTÕES

- 1. (2012/FEMPERJ/TEC-RJ)** Quanto à aplicação da lei processual penal no espaço, é correto afirmar:  
a) orienta-se pelas mesmas regras da aplicação da lei penal no espaço;  
b) aplica-se o princípio da extraterritorialidade no processo penal, quando o crime ocorre no exterior;  
c) quando a autoridade judiciária brasileira cumpre uma carta rogatória, aplica lei do Estado rogante;  
d) orienta-se pelo princípio da territorialidade, que determina a exclusão da lei processual penal estrangeira em território brasileiro;  
e) vige a regra do local do crime, adotando-se a norma processual do local onde a infração se consumou.
- 2. (2018/CESPE/STJ/Analista Judiciário)** Com relação à aplicação e à eficácia temporal da lei processual penal, julgue o item subsequente. O Código de Processo Penal será aplicado a todas as ações penais e correlatas que tiverem curso no território nacional, nelas incluídas as destinadas a apurar crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República.
- 3. (2017/FAPEMS/PC-MS/Delegado de Polícia – adaptada)** Com relação às regras da lei processual no espaço e no tempo, o Código de Processo Penal vigente adota, respectivamente, os princípios da *lex fori* e da aplicação imediata. Com base nessa informação, é correto afirmar que as normas do Código de Processo Penal vigente são inaplicáveis, ainda que subsidiariamente, no âmbito da Justiça Militar e aos processos da competência do tribunal especial.
- 4. (2016/CESPE/Polícia Científica - PE – adaptada)** Em relação ao direito processual penal, é correto afirmar que a lei processual penal brasileira adota o princípio da absoluta territorialidade em relação a sua aplicação no espaço: não cabe adotar lei processual de país estrangeiro no cumprimento de atos processuais no território nacional.
- 5. (2015/CESPE/TJDFT)** Acerca da aplicabilidade da lei processual penal no tempo e no espaço e dos princípios que regem o inquérito policial, julgue o item a seguir. Em relação à aplicação da lei processual penal no espaço, vigora o princípio da territorialidade.
- 6. (2015/FAPEC/MPE-MS/Promotor de Justiça Substituto – adaptada)** Julgue o item: o princípio da *lex fori* admite relativização no processo penal.

**7. (2015/FCC/TJ-RR/Juiz Substituto – adaptada)** Analise o item: a lei processual penal brasileira será aplicada nos atos processuais praticados em outro território que não o brasileiro, em casos de extraterritorialidade da lei penal.

**8. (2018/VUNESP/PC-BA/Delegado de Polícia)** Aplicar-se-á a lei processual penal, nos estritos termos dos arts. 1º, 2º e 3º do CPP,

- a) aos processos de competência da Justiça Militar.
- b) ultratativamente, mas apenas quando favorecer o acusado.
- c) retroativamente, mas apenas quando favorecer o acusado.
- d) desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.
- e) com o suplemento dos princípios gerais de direito sem admitir, contudo, interpretação extensiva e aplicação analógica.

**9. (2018/CESPE/TJ-CE/Juiz Substituto – adaptada)** Julgue os itens a seguir, a respeito do inquérito policial e das disposições preliminares do Código de Processo Penal. I - Aos processos em curso, a lei processual penal será aplicada imediatamente, mantendo-se, todavia, os atos praticados sob a égide da lei anterior.

**10. (2018/FGV/TJ-SC/Técnico Judiciário)** No curso de ação penal em que Roberto figurava como denunciado, entrou em vigor lei que versava sobre processamento de ação penal em procedimento comum ordinário, com conteúdo exclusivamente processual penal, prejudicial ao réu. O técnico judiciário, no momento de auxiliar no processamento do feito, deverá aplicar a:

- a) lei processual penal em vigor na época dos fatos, em virtude do princípio da irretroatividade da lei mais gravosa, não admitindo o Código de Processo Penal interpretação extensiva ou analógica da lei processual;
- b) lei processual penal em vigor na época dos fatos, em virtude do princípio da irretroatividade da lei mais gravosa, admitindo o Código de Processo Penal interpretação extensiva, mas não aplicação analógica da lei processual;
- c) lei processual penal em vigor na época dos fatos, em virtude do princípio da irretroatividade da lei mais gravosa, admitindo o Código de Processo Penal interpretação extensiva e aplicação analógica da lei processual;
- d) nova lei processual penal, ainda que desfavorável ao réu, respeitando-se os atos já praticados, admitindo o Código de Processo Penal interpretação extensiva, mas não aplicação analógica da lei processual;
- e) nova lei processual penal, ainda que desfavorável ao réu, respeitando-se os atos já praticados, admitindo o Código de Processo Penal interpretação extensiva e aplicação analógica da lei processual.

**11. (2018/VUNESP/PC-SP/Delegado de Polícia)** Tício está sendo processado pela prática de crime de roubo. Durante o trâmite do inquérito policial, entra em vigor determinada lei, reduzindo o número de testemunhas possíveis de serem arroladas pelas partes no procedimento ordinário. A respeito do caso descrito, é correto que

- a) não se aplica a lei nova ao processo de Tício em razão do princípio da anterioridade.
- b) a lei que irá reger o processo é a lei do momento em que foi praticado o crime, à vista do princípio *tempus regit actum*.
- c) em razão do sistema da unidade processual, pelo qual uma única lei deve reger todo o processo, a lei velha continua ultra-ativa e, por isso, não se aplica a nova lei, mormente por ser esta prejudicial em relação aos interesses do acusado.
- d) não se aplica a lei revogada ao processo de Tício em razão do princípio da reserva legal.
- e) não se aplica a lei revogada porque a instrução ainda não se iniciara quando da entrada em vigor da nova lei.

**12. (2018/CESPE/STJ/Analista Judiciário)** Com relação à aplicação e à eficácia temporal da lei processual penal, julgue o item subsequente. Uma nova norma processual penal terá aplicação imediata somente aos fatos criminosos ocorridos após o início de sua vigência.

**13. (2018/CESPE/PC-MA/Investigador de Polícia)** Acerca da aplicação da lei processual no tempo e no espaço e em relação às pessoas, julgue os itens a seguir.

- I - O Brasil adota, no tocante à aplicação da lei processual penal no tempo, o sistema da unidade processual.
- II - Em caso de normas processuais materiais — mistas ou híbridas —, aplica-se a retroatividade da lei mais benéfica.

**14. (2017/CESPE/TRF-1ª Região/Técnico Judiciário)** Acerca dos princípios que regem o processo penal brasileiro, julgue o item subsequente. A lei processual penal deverá ser aplicada imediatamente, sem que isso prejudique a validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, tampouco constitua ofensa ao princípio da irretroatividade.

**15. (2017/FAPEMS/PC-MS/Delegado de Polícia – adaptada)** Com relação às regras da lei processual no espaço e no tempo, o Código de Processo Penal vigente adota, respectivamente, os princípios da *lex fori* e da aplicação imediata. Com base nessa informação, é correto afirmar que a lei processual penal atende a regra do *tempus regit actum*, porém a repetição de atos processuais anteriores é exigida por lei em observância da interpretação constitucional, além disso, não é possível alcançar os processos que apuram condutas delitivas consumadas antes da sua vigência.

## COMENTÁRIOS

**1.** Gabarito: D. Enquanto a lei penal aplica o princípio da territorialidade (art. 5º do CP) e da extraterritorialidade incondicionada e condicionada (art. 7º do CP), a lei processual penal adota o princípio da territorialidade ou da *lex fori*. A atividade jurisdicional é um dos aspectos da soberania.

**2.** ERRADA. Conforme inciso III do art. 1º do CPP: O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código, ressalvados: II - as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República, e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade.

**3.** ERRADA. As regras do CPP são aplicáveis em todo território inclusive na Justiça Militar e no tribunal especial, de modo supletivo, conforme reza o art. 1º, III e IV. Lembrando que no inciso IV, assim como no V, somente não será aplicado quando lei especial que os regulam não dispuserem de modo diverso. (Art. 1º, parágrafo único, do CPP.)

**4.** ERRADA. O nosso ordenamento processual adota o princípio da territorialidade absoluta em relação à aplicação da lei processual penal brasileira no espaço, ou seja, não cabe adotar lei processual de país estrangeiro no cumprimento de atos processuais no território nacional. Todavia, é importante ressaltar a possibilidade de utilização de normas previstas em tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Entretanto, isso não configura aplicação de lei estrangeira (lembre-se que o tratado passou a fazer parte do nosso ordenamento jurídico).

**5.** CORRETA. Conforme art. 1º, do CPP, aplica-se o princípio da territorialidade absoluta.

**6.** CORRETA. O art. 1º do CPP consagra o princípio da territorialidade (*lex fori - locus regit actum*). Por esse princípio, a eficácia da lei processual penal de um Estado circunscreve-se aos limites de seu próprio território, não ultrapassando, portanto, os limites deste, haja vista a função jurisdicional refletir parcela da soberania nacional. São três as exceções apontadas pela doutrina: a) territórios *nullius*; b) expressa autorização de Estado estrangeiro; e c) território ocupado em caso de guerra.

**7.** INCORRETA. O princípio da extraterritorialidade aplica-se ao direito penal, mas não ao direito processual penal (art. 1º, do CPP).

**8.** Gabarito: D

a) INCORRETA. Nos termos do art. 1º, III, do CPP, o processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, pelo seu Código, ressalvados os processos da competência da Justiça Militar.

b) INCORRETA. Nos termos do art. 2º, do CPP, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Não possui relevância o fato de a norma vir a favorecer ou prejudicar o réu.

c) INCORRETA. Nos termos do art. 2º, do CPP, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Não possui relevância o fato de a norma vir a favorecer ou prejudicar o réu.

d) CORRETA, conforme literalidade do art. 2º, do CPP.



e) INCORRETA. Nos termos do art. 3º, do CPP, a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

9. CORRETA, nos termos do art. 2º, do CPP.

10. Gabarito: E, conforme arts. 2º e 3º, ambos do CPP.

11. Gabarito: E. O Código de Processo Penal adotou o sistema de isolamento dos atos processuais, sendo assim, a nova lei, quando tratando apenas de procedimento, será aplicada imediatamente sem prejuízos dos atos já praticados.

12. INCORRETA. Em virtude da adoção, no Direito Processual Penal, do princípio do *tempus regit actum*, a lei processual penal aplicável será a lei vigente no momento em que o ato for praticado: a) a lei processual aplica-se de forma imediata, mesmo aos processos já em andamento iniciados sob a égide de lei anterior; b) os atos processuais praticados sob a vigência de lei anterior são válidos e não são atingidos pela nova lei processual, ainda que seja benéfica ao réu. Logo, a lei processual penal não retroage nem mesmo em benefício do agente.

13. Item I: INCORRETO. O art. 2º, do CPP, adota o sistema do isolamento dos atos processuais, prevendo que a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Item II: CORRETO. Se a nova lei processual tiver um caráter misto, ou seja, mistura-se com as regras de direito penal, prevalecerá o seu caráter de norma de direito penal. Por tal razão, se a lei penal favorecer o réu será aplicada a retroatividade da lei penal benéfica.

14. CORRETA. Em virtude da adoção, no Direito Processual Penal, do princípio do *tempus regit actum*, a lei processual penal aplicável será a lei vigente no momento em que o ato for praticado: a) a lei processual aplica-se de forma imediata, mesmo aos processos já em andamento iniciados sob a égide de lei anterior; b) os atos processuais praticados sob a vigência de lei anterior são válidos e não são atingidos pela nova lei processual, ainda que seja benéfica ao réu.

15. INCORRETA. De acordo com o que se pode extrair do art. 2º, do CPP, os atos processuais praticados sob a vigência de lei anterior são válidos e não são atingidos pela nova lei processual, ainda que seja benéfica ao réu.

**CAPÍTULO 5 – JUIZ DAS GARANTIAS (ARTS. 3º-A A 3º-F DO CPP)****1. LEI ANTICRIME (LEI Nº 13.964/2019)**

A Lei Anticrime (Lei nº 13.964/2019) foi sancionada no dia 24 de dezembro de 2019 e passou a vigor no dia 23 de janeiro de 2020, modificando muitas matérias nos campos penal e processual penal. O pacote instituiu muitos retrocessos: o recrudescimento do tempo de cumprimento da pena (para 40 anos); o aumento do requisito temporal para a progressão de regime (agora em percentuais); o tratamento diferenciado a policiais que praticam crimes contra civis em contextos de garantia de lei e ordem; a instituição de modalidade de prisão preventiva obrigatória; execução imediata da pena em alguns casos do Tribunal do Júri; dentre outros.

Ao mesmo tempo, trouxe avanços incontestáveis em direção aos preceitos de um processo penal acusatório: instituiu o juiz das garantias; consagrou a cadeia de custódia das provas; proibiu a decretação de medida cautelar de ofício pelo magistrado; instituiu prazo de revisão da decisão sobre prisão provisória; previu as audiências de custódia no texto do CPP; dentre outros.

Em que pese não tenha sido uma reforma global, mas sim parcial, vários dispositivos foram inseridos ou modificados, alterando sensivelmente a realidade do processo penal brasileiro. Todas as novidades encontram-se detalhadas nesta obra e permanecerão ainda em discussão, já que a lei está envolta em polêmicas e controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais, muitas ainda pendentes de análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Isso ficou ainda mais evidente no campo do direito processual penal em razão da repercussão de alguns dispositivos como o do juiz das garantias, que trataremos em linhas gerais neste capítulo.

Além disso, é preciso destacar que, já no dia 15 de janeiro de 2020, antes da entrada em vigor da lei, o Presidente do STF, Min. Dias Toffoli, no uso de suas atribuições previstas no Regimento Interno do STF (art. 13), deferiu monocraticamente medida cautelar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6228, 6229 e 6300, concedendo parcialmente a medida cautelar pleiteada, *ad referendum* do Plenário, para:

- (i) suspender-se a eficácia dos arts. 3º-D, parágrafo único, e 157, § 5º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei nº 13.964/19;
- (ii) suspender-se a eficácia dos arts. 3º-B, 3º-C, 3º-D, *caput*, 3º-E e 3º-F do CPP, inseridos pela Lei nº 13.964/2019, até a efetiva implementação do juiz das garantias pelos tribunais, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da publicação desta decisão;
- (iii) conferir-se interpretação conforme às normas relativas ao juiz das garantias (arts. 3º-B a 3º-F do CPP), para esclarecer que não se aplicam às seguintes situações: (a) processos de competência originária dos tribunais, os quais são regidos pela Lei nº 8.038/1990; (b) processos de competência do Tribunal do Júri; (c) casos de violência doméstica e familiar; e (d) processos criminais de competência da Justiça Eleitoral.
- (iv) fixarem-se as seguintes regras de transição: (a) no tocante às ações penais que já tiverem sido instauradas no momento da efetiva implementação do juiz das garantias pelos tribunais (ou quando esgotado o prazo máximo de 180 dias), a eficácia da lei não acarretará qualquer modificação do juízo competente. O fato de o juiz da causa ter atuado na fase investigativa não implicará seu automático impedimento; (b) quanto às investigações que estiverem em curso no momento da efetiva implementação do juiz das garantias pelos tribunais (ou quando esgotado o prazo máximo de 180 dias), o juiz da investigação tornar-se-á o juiz das garantias do caso específico. Nessa hipótese, cessada a competência do juiz das garantias, com o recebimento da denúncia ou queixa, o processo será enviado ao juiz competente para a instrução e o julgamento da causa.



Essa decisão, no entanto, teve sua duração bem curta, tendo em vista que o Min. Luiz Fux, Relator das ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305, no dia 22 de janeiro de 2020, revogou a liminar anterior e ainda decidiu – de forma cautelar e monocrática – *ad referendum* do Plenário nos seguintes termos:

- (a) Revogo a decisão monocrática constante das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e suspendo *sine die* a eficácia, *ad referendum* do Plenário,
- (a1) da implantação do juiz das garantias e seus consectários (Artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3º-E, 3º-F, do Código de Processo Penal); e
- (a2) da alteração do juiz sentenciante que conheceu de prova declarada inadmissível (157, §5º, do Código de Processo Penal);
- (b) Concedo a medida cautelar requerida nos autos da ADI 6305, e suspendo *sine die* a eficácia, *ad referendum* do Plenário,
- (b1) da alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial (28, *caput*, Código de Processo Penal);
- (b2) Da liberalização da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas (Artigo 310, §4º, do Código de Processo Penal).

Apesar de ser a decisão do Relator das ADIs, trata-se apenas de medida cautelar de manifestação de apenas um dos 11 Ministros do STF, não podendo se afirmar qual será o rumo tomado pela Corte no julgamento dos temas.

De qualquer modo, na presente obra, trataremos das peculiaridades de cada uma das disposições da Lei Anticrime no que toca ao processo penal. Assim, independentemente da posição a ser tomada futuramente (e não se sabe quando) pelo STF, o leitor estará preparado para as provas de concursos públicos e para a prática penal.

## 2. JUIZ DAS GARANTIAS(ARTS. 3º-A A3º-F DO CPP)

Conforme destacado acima, quando do fechamento desta obra, todos os dispositivos referentes ao juiz das garantias encontravam-se com aplicabilidade suspensa por prazo indefinido, em razão de decisão monocrática cautelar proferida pelo Ministro Luiz Fux nas ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305 no dia 22 de janeiro de 2020.

A previsão da figura do juiz das garantias é, sem dúvidas, a maior polêmica trazida para o processo penal brasileiro pela Lei Anticrime (Lei nº 13.964/2019) que, para grande parcela da doutrina, foi uma alteração bastante aplaudida, sobretudo por concretizar o sistema acusatório no nosso processo penal.

O Juiz das Garantias é responsável (civil, penal e administrativamente) pelo controle de legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário (reserva de Jurisdição). Desse modo, o magistrado que atua na fase da investigação criminal e que tem contato com elementos de informação, produzidos sem contraditório e ampla defesa, tem a sua imparcialidade fragilizada ao formar concepções a partir de informações precipitadas e não contraditadas. Violada a imparcialidade, comprometido está o sistema acusatório (art. 3º-A, CPP).

Ressalta-se que a atuação do juiz de garantias se restringe apenas à fase pré-processual, sendo as questões pendentes apreciadas pelo juiz do processo, que não está adstrito ao que foi decidido preliminarmente. Ademais, seu exercício não abarca as infrações penais de menor potencial ofensivo.

A implementação do juiz de garantias revela uma preocupação em preservar o distanciamento do magistrado responsável pelo processo penal dos elementos que visam formar sua convicção, para evitar que haja sua contaminação e, por conseguinte, a quebra de sua imparcialidade, que pode comprometer a prestação jurisdicional.

Segundo o art. 3º-B do CPP, o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal. Esse controle da legalidade é abrangente, devendo respeitar não as leis, mas deve observância à Constituição Federal (TAVORA; ALENCAR, 2020, p. 235).

Além disso, o juiz das garantias é responsável pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Das garantias constitucionais (art. 5º) que expressam essa necessidade de controle imediato ou autorização prévia do juiz das garantias, podemos citar (TAVORA; ALENCAR, 2020, p. 235):

- i) a inviolabilidade domiciliar (inciso XI);
- ii) o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas (inciso XII);
- iii) a comunicação imediata da prisão ao juiz e à família do preso ou à pessoa por ele indicada (inciso LXII);
- iv) o relaxamento imediato da prisão ilegal (inciso LXV).

O rol de competências do juiz das garantias é aberto, exemplificativo (TAVORA; ALENCAR, 2020, p. 233), competindo-lhe especialmente as previsões do art. 3º-B, do CPP.

## **2.1. CONTROLE DA LEGALIDADE DO FLAGRANTE E DA PRISÃO CAUTELAR (ART. 3º-B, INCISOS I, II E III)**

O juiz das garantias deverá receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso LXII do *caput* do art. 5º da Constituição Federal e art. 306 do CPP, bem assim deverá receber o auto de prisão em flagrante para controle da legalidade da prisão, observando o art. 310, na nova redação.

Art. 5º, LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (...).

Deverá o juiz das garantias promover a audiência de custódia com a presença do conduzido, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente (art. 310 do CPP): I – relaxar a prisão ilegal; ou II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares da prisão, vedada a prisão de ofício (CPP, art. 311), ou, III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (vide art. 9º, Lei nº 13.689/19).

O não recebimento do APF nas 24 horas a contar da prisão, implica em relaxamento da prisão ilegal (art. 310, § 4º, CPP), apuração de responsabilidades, podendo-se decretar depois, nos autos, prisão preventiva.

Interessante observar que o juiz que participa da audiência de custódia nem sempre atuará como o juiz das garantias, uma vez que pode ter feito a audiência em um plantão judiciário. Contudo, caso tenha decidido, este magistrado do plantão estará proibido de atuar na fase de instrução (art. 3º-D).

## 2.2. CONTROLE DAS INVESTIGAÇÕES E VIOLAÇÃO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL (ART. 3º-B, INCISOS IV, X E IX)

A investigação criminal deve ser informada ao Juiz das Garantias, pouco importando se no âmbito do Ministério Público ou outra Instituição (ex.: Polícia), devendo-se controlar os respectivos prazos (CPP, art. 3-B, IV c/c § 2º), requisição de documentos e andamento (CPP, art. 3-B, X), trancando investigações desprovidas de fundamentos (CPP, art. 3-B, IX).

É importante notar que o inciso passa a prever que o juiz das garantias deve ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, mas não estabelece, pelo menos expressamente, a finalidade exata desta ciência, ou seja, o porquê de se comunicar ao juiz acerca da deflagração de um procedimento investigação, se não há, pelo menos por ora, necessidade de intervenção judicial para a adoção de determinada medida sujeita à cláusula de reserva de jurisdição. Por isso, o ideal é conjugar a leitura desse inciso com a do inciso IX do mesmo artigo, concluindo que o juiz das garantias deve tomar ciência de qualquer investigação criminal para que possa determinar seu trancamento, caso verifique que não havia fundamento para sua instauração ou continuidade.

## 2.3. GARANTIR OS DIREITOS DO INVESTIGADO E CONDUZIDOS (ART. 3º-B, INCISOS XIII E XIV)

Além de observar pelos direitos do preso, inclusive podendo determinar que seja trazido, a qualquer tempo, para esclarecimentos vinculados à violação de direitos, deve garantir acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos na investigação, salvo as diligências em andamento. Em caso de dúvidas, deve realizar o exame de sanidade mental (CPP, art. 3-B, XIII). Deverá vedar o uso da imagem do preso, podendo configurar abuso de autoridade (art. 13, I e II, da Lei nº 13.689/19). Será competente para conhecer e julgar dos *habeas corpus* impetrados antes do recebimento da denúncia (inc. XIV).

## 2.4. PRODUZIR ANTECIPADAMENTE PROVAS (ART. 3º-B, INCISO VII)

|                                                           | PROVAS CAUTELARES                                                                                                                                     | PROVA NÃO REPETÍVEL                                                                                                                                              | PROVAS ANTECIPADAS                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONCEITO</b>                                           | São aquelas em que há um risco de desaparecimento do objeto da prova em razão do decurso do tempo, em relação às quais o contraditório será diferido. | É aquela que, uma vez produzida, não tem como ser novamente coletada ou produzida, em virtude do desaparecimento, destruição ou perecimento da fonte probatória. | São aquelas produzidas com a observância do contraditório real, perante a autoridade judicial, em momento processual distinto daquele legalmente previsto, ou até mesmo antes do início do processo, em virtude de situação de urgência e relevância. |
| <b>MOMENTO E (DES)NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL</b> | Podem ser produzidas no curso da fase investigatória ou durante a fase judicial, sendo que, em regra, dependem de autorização judicial.               | Podem ser produzidas na fase investigatória e em juízo, sendo que, em regra, não dependem de autorização judicial.                                               | Podem ser produzidas na fase investigatória e em juízo, sendo indispensável prévia autorização judicial.                                                                                                                                              |
| <b>ESPÉCIE DE CONTRADITÓRIO</b>                           | Diferido ou postergado ou adiado ou sobre a prova.                                                                                                    | Diferido ou postergado ou adiado ou sobre a prova.                                                                                                               | Real ou para a prova.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>EXEMPLO</b>                                            | Interceptação telefônica, nos termos da Lei nº 9.296/96.                                                                                              | Exame de corpo de delito em vítima de lesões corporais leves.                                                                                                    | Oitiva de testemunha que está prestes a falecer, nos termos do art. 225 do CPP.                                                                                                                                                                       |

As provas antecipadas são revestidas de eficácia probatória sem a necessidade de serem renovadas no curso da ação penal. Se houver necessidade de produção de provas, a requerimento das partes, demonstrada a urgência, relevância e proporcionalidade, o ato pode ser realizado, garantido o contraditório e direito ao confronto, em decisão concretamente fundamentada, conforme Súmula nº 455 do STJ.

Pode o juiz das garantias agir de ofício ordenando a produção de provas consideradas urgentes e relevantes? O art. 156, em seu inciso I, faculta ao juiz ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida.

Antes do Pacote Anticrime, já havia algumas críticas doutrinárias em relação aos citados incisos do art. 156 do CPP. Contudo, a maioria da doutrina os considerava compatível com o ordenamento jurídico vigente, desde que a atuação do juiz, mormente no que diz respeito ao inciso II, se desse de forma subsidiária.

Todavia, com a Lei nº 13.964/19, essa discussão, certamente, dividirá a doutrina e os Tribunais pátrios, porquanto o art. 3º-A do CPP, que, até o fechamento desta obra, está com a eficácia suspensa, expressamente disciplina que o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a *iniciativa do juiz na fase de investigação* e a *substituição da atuação probatória do órgão de acusação*.

Posicionando-se quanto ao ponto, o Professor Renato Brasileiro de Lima foi enfático ao assentar que o art. 3º-A do CPP revogou tacitamente o art. 156, inciso I, do mesmo Código, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porquanto a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (LIMA, 2020, p. 108-109).

De igual forma, também houve a revogação tácita do art. 156, inciso II, do CPP, e "de todos os demais dispositivos constantes do Código de Processo Penal que atribuíam ao juiz da instrução e julgamento iniciativa probatória no curso do processo penal". Somente não estariam revogados, de acordo com o Professor, dispositivos que autorizem a intervenção pontual do juiz, como no caso do art. 212, parágrafo único, do CPP, o qual permite ao juiz complementar a inquirição das testemunhas (LIMA, 2020, p. 112).

Em sua obra, o renomado Professor também cita uma posição intermediária, segundo a qual "o art. 3º-A do CPP não revogou os incisos I e II do art. 156 do mesmo diploma legal, salvo no inciso I, no que tange à possibilidade de determinar, de ofício, a produção antecipada da prova na fase de investigação" – Enunciado nº 5 da Procuradoria-Geral de Justiça e Corregedoria-Geral do Ministério Público de São Paulo (LIMA, 2020, p. 109).

## 2.5. PRORROGAR O PRAZO DE DURAÇÃO DO INQUÉRITO (ART. 3º-B, INCISO VIII)

A doutrina e a jurisprudência majoritárias sempre entenderam que a investigação envolvendo investigado preso cautelarmente não poderia ser prorrogada, a não ser que fosse o investigado solto. A prisão cautelar pressupõe a existência de prova do delito e indícios de sua autoria (*fumus comissi delicti*), requisitos também demandados para a propositura da ação penal (art. 41 do CPP). Se ao final dos 10 dias previstos no artigo 10 do CPP o titular da ação penal não vislumbrasse elementos suficientes para a propositura da ação penal, tal fato seria indicativo de que a prisão não deve permanecer. Com a Lei nº 13.964/19 (pacote anticrime) temos mais uma novidade a ser destacada. A lei passou a prever o seguinte no CPP:

Art. 3º (...) § 2º Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até 15 (quinze) dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada.

Isto é, rompendo com o entendimento anterior, agora é possível a prorrogação do prazo de conclusão do inquérito policial de investigado preso. O juiz das garantias deverá ser provocado e poderá autorizar a prorrogação uma única vez por até 15 dias. Ao final desse prazo, se a investigação não tiver sido encerrada, a prisão cautelar deve ser relaxada imediatamente por ser considerada ilegal.

Outros prazos previstos na legislação extravagante continuam válidos (ex.: Lei de Drogas, Justiça Federal, crimes contra a economia popular etc.), em razão da aplicação do princípio da especialidade. Todos os prazos serão revisados em capítulo próprio.

## **2.6. DETERMINAR O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL QUANDO NÃO HOUVER FUNDAMENTO RAZOÁVEL PARA SUA INSTAURAÇÃO OU PROSSEGUIMENTO (ART. 3º-B, INCISO IX)**

## **2.7. REQUISITAR DOCUMENTOS, LAUDOS E INFORMAÇÕES AO DELEGADO DE POLÍCIA SOBRE O ANDAMENTO DA INVESTIGAÇÃO (ART. 3º-B, INCISO X)**

Como regra, essa providência exigirá requerimento do Ministério Público ou da pessoa interessada, seja ela investigado ou ofendido. É o sentido expresso no art. 3º-A, do CPP, e da interpretação sistemática da Lei Anticrime (Lei nº 13.964/19) (TAVORA; ALENCAR, 2020, p. 241).

## **2.8. ANALISAR AS CAUTELARES PROBATÓRIAS (ART. 3º-B, INCISOS V, VI, XI)**

Cabe ao juiz das Garantias analisar os pedidos de: (i) prisão provisória ou outra medida cautelar; (ii) interceptação telefônica; (iii) afastamento dos sigilos (fiscal, bancário, de dados e telefônico); (iv) busca e apreensão domiciliar; (v) acesso à informações sigilosas; e outros meios de provas.

Dessa forma, os meios de obtenção de prova submetidos à cláusula de reserva dependerão de requerimento expresso ou representação da autoridade policial se serão deliberados pelo juiz das garantias.

## **2.9. DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL (ART. 3º-B, INCISO XIII)**

Cuida-se de incidente que, nos termos do art. 149, *caput*, do CPP, visa extirpar eventual dúvida séria e razoável quanto à integridade mental do acusado/investigado. É dizer: para fins de instauração do incidente de insanidade mental, "é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento" (NUCCI, 2016, p. 293-294).

Se a providência for tomada em momento anterior ao recebimento da denúncia ou queixa-crime, a competência será do juiz das garantias. Por outro lado, se a dúvida surgir durante o processo, a competência será do juiz da instrução.

## **2.10. DEFERIR PEDIDO DE ADMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA ACOMPANHAR A PRODUÇÃO DA PERÍCIA**

Caso o exame pericial ocorra na fase pré-processual, a competência para análise será do juiz das garantias. O tema será detalhado no capítulo sobre provas.

## **2.11. HOMOLOGAR DELAÇÃO PREMIADA E ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 3º-B, INCISO XVII)**

O acordo de colaboração premiada e o acordo de não persecução penal estão sujeitos à homologação judicial, conforme os arts. 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/13 e art. 28-A, §§ 4º e 6º, do CPP,



respectivamente. Quando eles forem celebrados na fase investigatória, caberá ao juiz das garantias a competência para homologação.

## 2.12. RECEBER A DENÚNCIA

O Juiz das Garantias receberá a denúncia e determinará a citação do acusado, analisando a absolvição sumária. Superada essa fase, remeterá ao juiz de Julgamento para realização de instrução e julgamento (art. 3º-B, XIV; art. 3º-C, §1º). A separação serve para não contaminar os atos probatórios (art. 3º-B, §2º).

## 2.13. OUTRAS MATÉRIAS INERENTES ÀS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO *CAPUT* DESTE ARTIGO (ART. 3º-B, INCISO XVIII)

O inciso prevê uma cláusula de abertura, permissiva de interpretação analógica, desde que siga os parâmetros do *caput* do dispositivo legal (TAVORA; ALENCAR, 2020, p. 244).

## 2.14. EXCLUSÃO DA FIGURA DO JUIZ DAS GARANTIAS NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

Prevê o art. 3º-C que a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. O processo penal perante o juizado especial criminal (Lei nº 9.099/95), conforme estudaremos, é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, características incompatíveis com a figura do juiz das garantias (CUNHA, 2020, p. 99).

Além disso, a ressalva feita pelo legislador se justifica em razão de a prática de infrações de menor potencial ofensivo conduzir à lavratura de termo circunstanciado de ocorrência e não inquérito policial, não havendo uma investigação criminal propriamente dita, mas não somente a colheita de dados para a identificação dos envolvidos, das testemunhas, bem como a descrição resumida do fato delituoso, sendo pequena a chance de determinação de meios de obtenção de provas ou de medidas cautelares pessoais ou reais, afigurando-se correta a previsão do legislador (LIMA, 2020, p. 145).

## 2.15. TERMO FINAL DE ATUAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS

Prevê o art. 3º-C que a competência do juiz das garantias cessa com o recebimento da denúncia ou queixa, na forma do art. 399 do CPP.

A doutrina entende que onde se lê “art. 399 deste Código” deve ser lido “art. 366 do CPP”, sob pena de desvirtuamento do sistema (CUNHA, 2020, p. 99). Essa corrente entende que, após o recebimento da inicial (art. 396, CPP), que demanda apenas juízo de prelibação, a competência deveria passar a ser do juiz da instrução, que decidirá mérito. Aduz que o legislador acabou por inserir entre as competências do juiz das garantias, o qual deveria ser criado apenas para a fase da investigação, ou seja, até a viabilidade da acusação, o poder de decidir mérito, uma vez que será este mesmo magistrado quem analisará a defesa escrita do acusado (art. 396-A do CPP), bem como o cabimento ou não da absolvição sumária (art. 397 do CPP) (CUNHA, 2020, p. 100).

A doutrina entende, portanto, que o legislador incorreu em erro material (TAVORA; ALENCAR, 2020, p. 243).

## 2.16 AUTOS ACAUTELADOS NA SECRETARIA DO JUÍZO DAS GARANTIAS

Prevê o art. 3º-C, § 3º, que os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado.



## 2.17. DESIGNAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS CONFORME AS NORMAS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL

Prevê o art. 3º-E que o juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal.

## 2.18. DA VEDAÇÃO À EXPLORAÇÃO DA IMAGEM DE PESSOA SUBMETIDA À PRISÃO

Prevê o art. 3º-F que o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal.

## 2.19. CRÍTICAS

A introdução da figura do juiz das garantias no processo penal brasileiro levantou grandes discussões a respeito de sua constitucionalidade ou não. Além disso, é grande a resistência por alguns ao instituto, devendo ser analisados alguns argumentos contrários ao juiz das garantias que permanecem em discussão e que serão dirimidos pelo STF no julgamento das ADIs.

a) Nos termos do art. 3º-D do CPP, o juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos arts. 4º e 5º do CPP ficará impedido de funcionar no processo. Desse modo, nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste capítulo.

Para muitos, no entanto, a solução trazida pelo dispositivo legal acima, não resolve. A maioria das críticas ao instituto recai na incompatibilidade desse sistema diante da realidade da maioria dos Tribunais Federais e estaduais que contam com apenas um magistrado encarregado da jurisdição (CUNHA, 2020, p. 71). Nesses locais, sempre que o único magistrado da comarca atuar na fase do inquérito, ficará automaticamente impedido de atuar na fase do processo, impondo-se o deslocamento de outro magistrado de comarca distinta.

No entanto, é preciso ressaltar que a criação do juiz das garantias não incrementa volume de trabalho, ou seja, não gera nova demanda, sendo necessário apenas redistribuir o trabalho que antes cabia a apenas um juiz/juízo. Ademais, as dificuldades em decorrência da distância poderão ser contornadas com a tecnologia já implementada na maior parte do judiciário brasileiro<sup>1</sup>.

b) Existe corrente no sentido de que a previsão do juiz das garantias é inconstitucional, pois padece de vício formal/de iniciativa: o projeto deveria ter vindo de proposta do Judiciário (art. 93, d, CF/88). Para Renato Brasileiro (LIMA, 2020, p. 117),

a matéria versada em tais dispositivos – criação de uma nova causa de impedimento e repartição de competências entre magistrados para as fases de investigação e de instrução processual penal (competência funcional por fase da persecução penal) – insere-se no âmbito da competência legislativa privativa da União prevista no art. 22, inciso I, da Constituição Federal, porquanto versam sobre direito processual penal.

<sup>1</sup>BRAGA, Fernando. Porque a hora é de pensar sobre como implementar o juízo das garantias. Migalhas. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/317677/porque-a-hora-e-de-pensar-sobre-como-implementar-o-juizo-das-garantias>.



## CAPÍTULO 6 – INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

### 1. INTRODUÇÃO

Persecução penal, persecução criminal ou *persecutio criminis* é o conjunto de atividades desenvolvidas pelo Estado que possibilita atribuir punição ao autor de uma infração penal. Persecução significa perseguir, ir ao encalço. Em outras palavras, é "perseguir o crime" para identificar o seu autor, as suas circunstâncias, os seus motivos e demais elementos que, uma vez esclarecidos, possibilitarão a aplicação de uma punição ao culpado.

É composta por duas fases: o da investigação e o da ação penal. A primeira possui caráter preliminar e informativo, é inquisitiva e preparatória para a ação penal. A segunda é processual, ocorrendo o julgamento da pretensão punitiva.

| Persecução Penal                                                  |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Investigação Criminal<br>Preliminar, inquisitiva, de investigação | Fase Processual<br>Julgamento da pretensão punitiva estatal |

### 2. CONCEITO DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA E POLÍCIA JUDICIÁRIA

ADMINISTRATIVA - atuação PREVENTIVA, OSTENSIVA para impedir a ocorrência de infrações penais. Sua missão é proteger preventivamente a sociedade, mantendo-se o sentimento de paz e segurança. Ex.: a Polícia Militar (art. 144, § 5º, da Constituição Federal).

JUDICIÁRIA - atuação REPRESSIVA, após a prática da infração penal. Tem a missão de elaborar o Inquérito Policial (IP), consoante dispõe o art. 4º, *caput*, do CPP. No âmbito estadual, é exercida pela Polícia Civil (art. 144, § 4º, da Constituição Federal); no âmbito federal, é exercida pela Polícia Federal (art. 144, § 1º, incisos I e IV, da Constituição Federal). Nada impede que a Polícia Judiciária exerça função de polícia preventiva (atividade atípica), como ocorre com a Polícia Federal nos aeroportos internacionais e em fronteiras.

**Atenção:** grande parte da doutrina trata o termo polícia judiciária como sinônimo de polícia investigativa. No entanto, é preciso esclarecer a classificação tripartite defendida por Denilson Feitoza Pacheco que pode vir a cair em concursos públicos: a) polícia administrativa; b) polícia judiciária: agentes de segurança pública que atuam em suporte ao Estado-Juiz dando cumprimento a ordens emanadas pelo Poder Judiciário; e c) polícia investigativa: agentes de segurança pública que realizam investigação propriamente dita, atuando de maneira repressiva.

### 3. CONCEITO DE INQUÉRITO POLICIAL (ARTS. 4º A 23, CPP)

Inquérito policial é um procedimento preparatório para a ação penal, de caráter administrativo, inquisitorial (em regra, sem contraditório e ampla defesa), por meio do qual o Delegado de Polícia (que preside o IP) faz e /ou determina que se façam diversas diligências (providências) de investigação (oitiva de testemunhas, perícias etc.), com o objetivo de coletar elementos informativos, que comprovem a materialidade (existência) e a autoria do crime, para que o órgão acusatório (Ministério Público ou querelante) possa oferecer a peça inicial acusatória (denúncia ou queixa-crime).

No Brasil, a definição legal de inquérito policial não consta claramente em nenhum artigo do CPP, e, para ser obtida, deve se cotejar as definições dos artigos 4º e 6º do CPP (LOPES JR., 2013, p. 91), de modo que é um procedimento administrativo, sigiloso, escrito, inquisitivo, dispensável, elaborado pela polícia judiciária que tem por objetivo elucidar suposto fato criminoso. Diga-se suposto, pois ao final pode se chegar à conclusão de que infração penal não houve (ex.: a morte, em que inicialmente se suspeitava de homicídio, em verdade foi um suicídio).

É uma das formas de investigação (não é única forma). Investigação é gênero e o IP é uma das formas de se investigar, de se chegar a elementos informativos de materialidade (existência do delito) e de indícios de autoria (quem praticou o delito). Esses elementos são colhidos e investigados no IP para subsidiar o oferecimento da ação penal, seja ela pública (em que o titular é o MP), seja ela privada (em que o titular da ação é o ofendido).

**Atenção:** os elementos de prova colhidos na investigação também serão úteis para a verificação do *fumus comissi delicti* (aparência de autoria e materialidade) para a decretação de medidas cautelares, inclusive prisão provisória, pelo juiz.

**Atenção:** somente podemos falar em prova – no sentido técnico – quando ela for produzida sob o crivo do contraditório. No entanto, como iremos estudar, uma das características do inquérito policial é ser ele inquisitivo (investigativo). Desse modo, os elementos colhidos no inquérito policial não possuem essa marca, devendo ser tratados como “elementos informativos” e não como “prova”.

#### 4. NATUREZA JURÍDICA

É um procedimento preparatório da ação penal, de caráter administrativo. É peça que contém elementos de materialidade (existência do delito) e indícios de autoria, a subsidiar o ajuizamento da ação penal, com o intuito de formar a *opinio delicti* do titular da ação penal.

#### 5. VALOR PROBATÓRIO

A doutrina atribui pequeno valor probatório ao inquérito, entendido como peça de informação de valor relativo destinada a embasar o titular da ação penal à propositura da respectiva inicial acusatória. Nem tudo o que for colhido durante a fase de investigação irá preponderar, necessariamente, na ação penal. Os elementos de prova produzidos durante a investigação, em tese, devem ser confirmados em sede de contraditório judicial.

Não se pode condenar alguém na fase da sentença com base, exclusivamente, em um elemento que foi colhido na investigação. Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificado em juízo (Informativo 366/STF). Não significa que os elementos de prova do inquérito não serão utilizados, mas que a condenação não esteja baseada exclusivamente nesses elementos. O art. 155, do CPP, ressalva três espécies de prova que, em tese, não poderiam ser produzidas novamente, *in verbis*:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Antes da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), era bastante tranquilo afirmar que o juiz, para fundamentar sua decisão, poderia se valer dos elementos de informação produzidos na investigação policial, desde que o fizesse de forma subsidiária, isto é, a decisão poderia considerar os elementos colhidos na investigação, contudo, em regra, não poderia ser fundada somente neles<sup>2</sup>.

Tal interpretação nascia do termo *exclusivamente* usado no art. 155, *caput*, do CPP. É dizer: de acordo com essa corrente, que, repita-se, era amplamente aceita na doutrina e na jurisprudência, ao usar o mencionado termo, o legislador, tão somente, impediu que a condenação

---

<sup>2</sup>STF, HC 105837 – RS, 1.ª T., rel. Rosa Weber, 08/5/2012; STJ, AgRg no AREsp 446385 – RJ, 6.ª T., rel. Sebastião Reis Júnior, 25/8/2015.

estivesse baseada, de forma única e exclusiva, nos elementos de informação produzidos na investigação preliminar. Assim, o magistrado, de forma subsidiária, poderia buscar fundamentação junto às informações trazidas pela investigação.

Com efeito, em relação às provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, nada muda, porquanto, nos termos da própria redação do art. 155, *caput*, do CPP, o juiz continua podendo fundamentar sua decisão, inclusive de forma exclusiva, em tais provas. É dizer: a redação do art. 155, *caput*, do CPP, permite que o juiz fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos de informação colhidos na investigação, desde que tais elementos sejam provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas.

Para fins didáticos, colaciona-se tabela extraída da obra do Professor Renato Brasileiro de Lima acerca das provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas, que, como dito, poderão sozinhas embasar a decisão do magistrado, inclusive um decreto condenatório. Confira-se (LIMA, 2020, p. 658-659):

|                                                           | PROVAS CAUTELARES                                                                                                                                     | PROVA NÃO REPETÍVEL                                                                                                                                              | PROVAS ANTECIPADAS                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONCEITO</b>                                           | São aquelas em que há um risco de desaparecimento do objeto da prova em razão do decurso do tempo, em relação às quais o contraditório será diferido. | É aquela que, uma vez produzida, não tem como ser novamente coletada ou produzida, em virtude do desaparecimento, destruição ou perecimento da fonte probatória. | São aquelas produzidas com a observância do contraditório real, perante a autoridade judicial, em momento processual distinto daquele legalmente previsto, ou até mesmo antes do início do processo, em virtude de situação de urgência e relevância. |
| <b>MOMENTO E (DES)NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL</b> | Podem ser produzidas no curso da fase investigatória ou durante a fase judicial, sendo que, em regra, dependem de autorização judicial.               | Podem ser produzidas na fase investigatória e em juízo, sendo que, em regra, não dependem de autorização judicial.                                               | Podem ser produzidas na fase investigatória e em juízo, sendo indispensável prévia autorização judicial.                                                                                                                                              |
| <b>ESPÉCIE DE CONTRADITÓRIO</b>                           | Diferido ou postergado ou adiado ou sobre a prova.                                                                                                    | Diferido ou postergado ou adiado ou sobre a prova.                                                                                                               | Real ou para a prova.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>EXEMPLO</b>                                            | Interceptação telefônica, nos termos da Lei nº 9.296/96.                                                                                              | Exame de corpo de delito em vítima de lesões corporais leves.                                                                                                    | Oitiva de testemunha que está prestes a falecer, nos termos do art. 225 do CPP.                                                                                                                                                                       |

Essas provas são também denominadas elementos migratórios, sendo aqueles extraídos do inquérito e levados ao processo, podendo ser validamente valorados em eventual sentença penal condenatória. A lei permitiu o emprego dessas provas na formação do convencimento do juiz, ainda que de forma exclusiva, porque, na verdade, constituem provas em sentido estrito, despeito de terem sido colhidas na investigação (ALVES, 2013, p. 12). As provas cautelares se exaurem em si mesmas, podendo ser contraditadas no curso do processo, o mesmo ocorrendo com os atos irrepetíveis. As provas antecipadas, colhidas desta forma sob pena de perecimento, são produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não impede que sejam contraditadas também durante a ação penal.

**Atenção:** nesse ponto vale destacar a figura do juiz das garantias, uma das principais novidades inseridas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) no Código de Processo Penal. Lembrando que até o fechamento deste e-book as previsões dos artigos 3º-A ao 3º-F estão com a eficácia suspensa por decisão proferida pelo Min. Luiz Fux nas ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305. Caso, no entanto, as previsões voltem a vigorar, é importante sabermos interpretar o art. 155 à luz do

instituto do juiz das garantias. O art. 3º-C, § 3º, do CPP, disciplina que os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria deste juízo prevendo a exclusão física dos elementos de prova do inquérito na fase do processo, não sendo, no entanto, uma exclusão total, uma vez que o próprio art. 3ºC, § 3º traz ressalvas, por exemplo, provas irrepetíveis, cautelares.

Art. 3º-C, § 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 3º-D. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos arts. 4º e 5º deste Código ficará impedido de funcionar no processo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste Capítulo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Uma primeira corrente, interpretando de forma restritiva o art. 3º-C, §3º, do CPP, aduz que os autos da investigação policial continuarão acompanhando a denúncia ou queixa, sempre que servirem de base a uma ou outra, nos termos do art. 12 do CPP, que, para eles, não foi revogado pelo Pacote Anticrime. Para essa corrente, portanto, continua vigorando a interpretação no sentido de que o juiz pode se valer dos elementos de informação para fundamentar sua decisão, desde que não o faça de forma exclusiva. É dizer: o juiz continua a ter acesso a tudo o que foi produzido na investigação policial e, de forma subsidiária, pode se valer de tais elementos (LIMA, 2020, p. 163).

Noutro giro, uma segunda corrente disciplina que

o juiz da instrução e julgamento deverá receber apenas o sumário da primeira fase, contendo as provas irrepetíveis, antecipadas, e os meios de obtenção de prova, autuadas de modo incidental e separadas em blocos distintos, e não os autos na totalidade, os quais deverão permanecer acautelados na secretaria do juiz das garantias (LIMA, 2020, p. 164).

É dizer: o juiz da instrução e julgamento não tem mais acesso amplo aos elementos de informação produzidos na investigação, razão pela qual, por óbvio, não pode fundamentar sua decisão neles, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, as quais ele continuará tendo acesso.

A lei diz que haverá essa exclusão física exatamente para não influenciar o julgador com elementos de prova colhidos na fase da investigação. O julgador poderá se valer apenas daquilo que ele instruiu e viu ser produzido na fase da instrução processual, consolidando o sistema acusatório e trazendo efetividade aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A forma como essa exclusão se dará ainda não há resposta, pois, a previsão está em fase de discussões e é necessário que a jurisprudência e a doutrina se posicionem. De toda forma, por ora, eventuais questões de prova devem ser respondidas de acordo com a literalidade **do artigo 155 do CPP**.

## 6. CARACTERÍSTICAS DO INQUÉRITO POLICIAL

O IP (espécie) não é a única forma de investigação (gênero). Há outras formas, desde que previstas em lei. Exemplos:

a) inquérito parlamentar presidido por Comissão Parlamentar de Inquérito (art. 58, § 3º, CF/88);

b) inquérito policial militar presidido por polícia judiciária militar (art. 8º do Código de Processo Penal Militar);

c) investigação de autoridades com foro por prerrogativa de função;

d) inquérito por crime praticado por Juiz ou Promotor de Justiça é presidido pelo respectivo órgão de cúpula – Tribunal de Justiça ou Procuradoria de Justiça (art. 33, parágrafo único da Lei Complementar nº 33/79 - Lei Orgânica da Magistratura Nacional, e art. 41, parágrafo único da Lei nº 8.625/93 - Lei Orgânica do Ministério Público dos Estados).

Dentre as características, podemos citar:

### 6.1. ADMINISTRATIVO

O procedimento é realizado pela Polícia Judiciária, um órgão vinculado à Administração – Poder Executivo – e, por isso, se desenvolve tarefa de natureza administrativa, ou seja, não possui poderes jurisdicionais.

### 6.2. INQUISITIVO (INVESTIGATIVO)

A doutrina mais moderna tem preferido afirmar que inquérito é caracterizado por ser “investigativo”, porquanto o termo “inquisitivo” lembra passado sombrio de desrespeito a direitos e garantias fundamentais, tão comum no âmbito do sistema processual penal inquisitivo (SILVA, 2020, p. 43).

No curso do inquérito policial não vigora o princípio do contraditório, presente apenas na fase processual. Não há que se falar em existência de partes, nem na existência de acusação formal em face de alguém, daí porque desnecessário o contraditório.

**Exceção:** há contraditório e ampla defesa no inquérito para a decretação de expulsão do estrangeiro e para apurar falta administrativa. No último caso, atenção com o teor da Súmula Vinculante nº 5, ou seja, a defesa não necessariamente será promovida por advogado.

Súmula Vinculante nº 5: “a falta de defesa técnica por advogado, no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.”

**Atenção:** a referida súmula vinculante não se aplica para o procedimento de apuração de falta disciplinar previsto nos artigos 59 e 60 da Lei de Execução Penal, conforme posicionamento do STF (RE nº 398269/RS) e Súmula nº 533 do STJ:

Súmula nº 533, STJ: para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Dessa forma, em procedimento administrativo disciplinar, instaurado para apurar o cometimento de falta grave por réu condenado, tendo em vista estar em jogo a liberdade de ir e vir, deve ser observado amplamente o princípio do contraditório, com a presença de advogado constituído ou defensor público nomeado, devendo ser-lhe apresentada defesa, em observância às regras específicas contidas na Lei de Execução Penal (artigos 1º; 2º; 10; 44, III; 15; 16; 41, VII e IX; 59; 66, V, alínea a, VII e VII; 194), no CPP (artigos 3º e 261) e na própria CF/88 (art. 5º, LIV e LV).

**Atenção:** o direito de o investigado se fazer acompanhar por advogado ou defensor público existe e deve a ele ser informado. O que não se exige é a indispensabilidade da presença da defesa técnica. Isto é, é direito de o advogado assistir a seu cliente no bojo do procedimento, mas não pode ser confundido com a necessidade de presença obrigatória de advogado em toda e



qualquer oitiva na seara policial. O investigado tem direito de constituir, se quiser, advogado. Uma vez constituído, o delegado de polícia não pode impedir que o causídico acompanhe seu cliente na oitiva, sob pena de nulidade absoluta do ato. Nessa toada, é importante a leitura do inciso XXI, do artigo 7º, do Estatuto da OAB, inserido pela Lei nº 13.245/16:

Art. 7º: XXI - assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração: a) apresentar razões e quesitos;

### 6.3. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES

O inquérito policial é mero procedimento informativo e não ato de jurisdição, portanto, os vícios eventualmente ocorridos não contaminam ou influenciam a futura ação penal.

Dessa forma, eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório (STF, HC nº 73271/SP). É, portanto, incabível a anulação de processo penal em razão de suposta irregularidade verificada em inquérito policial (STF, RHC 131450/DF). As nulidades processuais estão relacionadas apenas a defeitos de ordem jurídica pelos quais são afetados os atos praticados ao longo da ação penal condenatória.

Segundo a jurisprudência, a suspeição de autoridade policial não é motivo de nulidade do processo, pois o inquérito é mera peça informativa, de que se serve o Ministério Público para o início da ação penal. Assim, é inviável a anulação do processo penal por alegada irregularidade no inquérito, pois, segundo jurisprudência firmada no STF, as nulidades processuais estão relacionadas apenas a defeitos de ordem jurídica pelos quais são afetados os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. STF. 2ª Turma. RHC 131450/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 3/5/2016 (Info 824).

**Atenção:** o art. 7º, XXI, do Estatuto da OAB, alterado pela Lei nº 13.245/2016 prevê uma exceção. Se for negado o direito de o advogado participar do interrogatório ou depoimento de seu cliente durante a apuração de infrações penais, haverá nulidade absoluta desses atos e, por consequência, nulidade também de todos os elementos informativos que, diretamente ou indiretamente, decorrerem deles.

Art. 7º São direitos do advogado:

XXI – assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração:

a) Apresentar razões e quesitos.

Se o investigado não indicar procurador constituído o ato será realizado independentemente da presença de defensor, não sendo necessária a nomeação de defensor dativo. É facultado ao delegado indeferir perguntas formuladas pelo advogado, por aplicação por analogia da previsão do artigo 212, do CPP, e com base também no artigo 14 do CPP.

**Atenção:** os vícios ocorridos no curso do inquérito policial, em regra, não repercutem na futura ação penal, ensejando, apenas, a nulidade da peça informativa, salvo quando houver violações de garantias constitucionais e legais expressas e nos casos em que o órgão ministerial, na formação da *opinio delicti*, não consiga afastar os elementos informativos maculados para a persecução penal em juízo, ocorrendo, desse modo, a extensão da nulidade à eventual ação penal. Caso a inicial acusatória esteja embasada tão somente em inquérito viciado, deverá ser rejeitada por falta de justa



causa, diga-se, pela ausência de lastro probatório mínimo e idôneo ao início do processo, com fundamento no art. 395, inciso III, do CPP (TAVORA, 2015, p. 102).

#### 6.4. ESCRITO (ART. 9º, CPP)

Todas as peças do IP devem ser escritas. Caso seja praticado algum ato oral, em regra, deve ser reduzido a termo. Eis o dispositivo:

“Art. 9º Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade.”

Documentar o ato praticado é importante meio de comprovar que ele foi levado a efeito observando as regras legais que regem a sua prática.

No entanto, atualmente se verifica uma tendência de mitigação a essa característica adotando-se, mesmo na fase pré-processual, o art. 405, §§ 1º e 2º, do CPP. Embora o dispositivo trate sobre a gravação da audiência de instrução e julgamento, pelos meios e recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, do investigado, indiciado, ofendido ou testemunhas, se aplica também na fase de investigações.

#### 6.5. SIGILOSO (ART. 20, CPP)

A autoridade assegurará no IP o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade e deve ser mantido para facilitar as investigações, além de proteger o investigado, enquanto objeto da ação investigatória, para que não ocorra o seu aniquilamento moral ou material pelo sistema repressivo (BARBOSA, 2009, p. 54). Por isso, o IP não deve ser disponibilizado para qualquer do povo. Esse sigilo, porém, não se estende ao juiz, ao MP e ao advogado.

- a) Sigilo interno: restrição de informações para o sujeito investigado;
- b) Sigilo externo: restrição para o público geral.

O sigilo interno merece uma análise mais minuciosa impondo-se o estudo do inciso XIV e dos §§ 10 a 12 do artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – Lei nº 8.906/94 e da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.

O advogado pode consultar o IP, mesmo que não tenha procuração nos autos, consoante o art. 7º, XIV, do Estatuto da OAB. Este dispositivo foi alterado pela Lei nº 13.245/2016, passando a prever, inclusive, que essa prerrogativa deve ser garantida não apenas no IP, mas em “investigações de qualquer natureza”, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade. Caso se trate de autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício de seus direitos (art. 7º, § 10, Estatuto da OAB):

Art. 7º São direitos do advogado: XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital;  
(...)

§ 10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso XIV. (Incluído pela Lei nº 13.245, de 2016)

§ 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. (Incluído pela Lei nº 13.245, de 2016)

§ 12. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso XIV, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de



autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. (Incluído pela Lei nº 13.245, de 2016)

É preciso tomar cuidado com a previsão da Súmula Vinculante nº 14. A regra é que o advogado tenha acesso amplo, mas esse acesso diz respeito ao que já está documentado nos autos do IP. O acesso irrestrito de autos de inquérito policial ao advogado do investigado traria evidente prejuízo às investigações e seria contrário à própria natureza do procedimento, ou seja, sigiloso por excelência. O teor da súmula deve ser estendido também a toda e qualquer investigação, não se restringindo aos autos do IP.

Súmula Vinculante nº 14: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Desse modo, somente atos perfeitos e acabados e cuja juntada aos autos do inquérito tenha sido determinada podem ser objeto de vista do advogado na defesa de seu cliente. Diligências em curso e as ainda não materializadas (ex.: interceptação telefônica em curso; representações de prisão e busca e apreensão ainda não analisadas pelo Poder Judiciário ou deferidas e não cumpridas; perícias ainda não realizadas; intimação de testemunhas ainda não ouvidas) não podem ter seu acesso franqueado, sob pena de evidente inutilidade das mesmas, decorrente da publicidade.

**Atenção:** o que fazer se o advogado pedir vista de determinada investigação que ainda tem diligências em curso ou outras já determinadas e ainda pendentes de realização? De acordo com a jurisprudência, deve o delegado de polícia despachar de forma fundamentada e determinar o desentranhamento das folhas que façam referência a tais diligências:

Conforme orientação firmada pelo Pretório Excelso, não se pode negar o acesso do advogado constituído, aos autos de procedimento investigatório, ainda que nele decretado o sigilo. Contudo, tal prerrogativa não se estende a atos que por sua própria natureza não dispensam a mitigação da publicidade (v.g., futuras interceptações telefônicas, dados relativos a outros indiciados). STJ, 5ª Turma, HC 103027/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 30/3/09.

Assim, a um só tempo foi respeitado o direito de vista do advogado do investigado e garantido o sigilo essencial ao desenrolar da apuração. Depois de terminada a diligência em curso que estava pendente, deve esta ser juntada aos autos, também por intermédio de despacho fundamentado da autoridade. Após, poderá a defesa ter vista dos autos.

**Atenção:** se o acesso for indevidamente negado, o advogado poderá se valer de Reclamação (por violação à súmula vinculante) ou Mandado de Segurança (por violação a direitos do advogado garantidos no art. 7º do Estatuto da OAB) ou *Habeas Corpus* (se estiver em jogo a liberdade de locomoção e a infração investigada for punida abstratamente com pena privativa de liberdade).

**Atenção:** em se tratando de investigação criminal que envolva organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), o seu sigilo poderá ser decretado pela autoridade judicial competente, para garantia da celeridade e eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, desde que devidamente precedido de autorização judicial, ressalvado os referentes às diligências em andamento (Súmula Vinculante nº 14). É o que prescreve o artigo 23 da Lei nº 12.850/2013:

Art. 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente, para garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.

Parágrafo único. Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista dos autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de 3 (três) dias que antecedem ao ato, podendo ser ampliado, a critério da autoridade responsável pela investigação.

## 6.6. OFICIALIDADE

São órgãos oficiais do Estado que conduzem o IP. No caso, a Polícia Judiciária (art. 144, §§ 1º, I e IV; e 4º, da CF/88).

## 6.7. AUTORITARIEDADE

O IP é conduzido por uma autoridade pública (art. 144, §§ 1º, I e IV; e 4º, CF/88), que é a autoridade policial, o Delegado de Polícia de carreira, a quem incumbe dar a direção das investigações. Essa disposição vem ainda consagrada na Lei de Investigação Criminal (Lei nº 12.830/13) no art. 2º, §1º.

O inquérito policial é conduzido de maneira discricionária pela autoridade policial, que deve determinar os rumos das diligências de acordo com as peculiaridades do caso concreto. O Delegado de Polícia, na qualidade de autoridade policial, continua conduzindo o inquérito policial de acordo com seu livre convencimento técnico-jurídico.

Reforçando essa ideia, a Lei nº 12.830, em seu artigo 2º, parágrafo 2º, prevê que “durante a investigação criminal, cabe ao Delegado de Polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos”.

Além disso, nos termos do artigo 14, do CPP, o requerimento para produção de provas feito pelo ofendido, pelo seu representante legal ou até mesmo pelo indiciado pode ser indeferido pela autoridade policial sob a alegação de que a diligência não é recomendável, afinal, vige a discricionariedade.

**Atenção:** o requerimento de realização de exame de corpo de delito, se o crime deixar vestígios, não pode ser indeferido pela autoridade policial, dada a previsão do artigo 158 do CPP que exige a confecção de laudo para a demonstração da materialidade delitiva.

## 6.8. OFICIOSIDADE

O delegado, verificando a existência de um delito de ação penal pública incondicionada, não pode se omitir, tem o dever de ofício de proceder à apuração do fato (art. 5º, I, do CPP).

**Atenção:** quando se tratar de ação penal privada ou pública condicionada à representação, faz-se necessário o consentimento/representação da vítima para que o Delegado dê início ao procedimento (art. 5º, §§ 4º; e 5º, CPP).

## 6.9. INDISPONIBILIDADE (ART. 17, CPP)

A autoridade policial não pode mandar arquivar autos de IP, mesmo se inexistirem elementos de materialidade ou indícios suficientes de autoria. Quem requer (promove) o arquivamento é o Ministério Público, titular da ação penal, e o juiz decide se homologa ou não. O procedimento de arquivamento do inquérito policial (e de outras investigações criminais) foi modificado sensivelmente pela Lei nº 13.964/19, mas isso será estudado em tópico específico.

## 6.10. DISPENSABILIDADE

O IP é prescindível, ou seja, não precisa existir antes de o ajuizamento da ação penal. Pode haver a propositura da peça inicial acusatória, com elementos de materialidade e indícios de autoria, sem necessariamente ter sido realizado o IP. É, portanto, dispensável à propositura da AP.

Atenção ao art. 39, § 5º, do CPP, que expressamente prevê que o Ministério Público pode dispensar o IP, se tiver em mãos elementos que possibilitem o imediato oferecimento da peça inicial:

“Art. 39, § 5º. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de quinze dias.”

Contudo, se o IP for a base para a propositura da ação, este vai acompanhar a inicial acusatória apresentada (art. 12, CPP).

Outros dispositivos legais também atestam a dispensabilidade do inquérito policial, como os artigos 27 e 46, § 1º, todos do CPP.

## 7. INCOMUNICABILIDADE

O art. 21 do CPP contempla a possibilidade de decretação da incomunicabilidade do preso durante o IP, por conveniência da investigação ou quando o interesse da sociedade o exigir, por deliberação judicial, mediante requerimento da autoridade policial ou MP, por até 3 dias.

Ocorre que, em face do art. 136, §3º, IV, da CF/88, não se admite a incomunicabilidade até mesmo na vigência do Estado de Defesa. Além disso, nem mesmo o Regime Disciplinar Diferenciado (mais severo), previsto na Lei de Execução Penal, admite a incomunicabilidade. Dessa forma, prevalece na doutrina o entendimento de que o art. 21 do CPP não foi recepcionado pela ordem constitucional vigente.

Cumpra mencionar, ainda, contra a incomunicabilidade do investigado, o artigo 7º, III, da Lei nº 8.906/94 e o artigo 8º, 2, d, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).

## 8. ATRIBUIÇÃO NO INQUÉRITO POLICIAL

A atribuição para a instauração do inquérito policial é do Delegado de Polícia em cuja área houve o crime, como determina o art. 4º do CPP:

A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas jurisdições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Parágrafo único: A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função.

Por não ser processo, o inquérito policial não obedece às regras de competência processual, que serão estudadas em capítulo específico. A delimitação territorial na qual a autoridade policial exerce as suas atribuições é conhecida como circunscrição.

Quanto ao critério territorial, a circunscrição é determinada pelo local em que se consumou a infração.

Quanto ao critério material, há previsão de criação de delegacias especializadas. Ex.: homicídios; entorpecentes; furtos etc.



Quanto ao critério em razão da pessoa, há previsão de criação de delegacias especializadas levando-se em consideração a vítima da infração. Ex.: delegacias da mulher, do turista, do idoso etc.

Nada impede, nas comarcas em que exista mais de uma circunscrição policial, que a autoridade com exercício em uma delas ordene diligências em outra, independentemente de precatórias ou requisições, podendo ainda prontamente atuar em razão de fatos que venham a ocorrer em sua presença (art. 22).

É mera irregularidade o fato de o IP tramitar em local diverso do da consumação da infração, afinal a violação dos critérios de atribuição não tem o condão de macular o futuro processo. O advogado do indiciado, entretanto, poderá impetrar HC para trancar o inquérito que tramita irregularmente, por desrespeito à fixação da atribuição. A não contaminação do futuro processo não é obstáculo ao combate do inquérito irregular.

**Atenção:** art. 2º, § 4º, Lei nº 12.830/13: o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia das investigações.

Dessa forma, para que o inquérito policial deixe a subordinação da presidência do Delegado de Polícia que o instaurou, deve o seu superior hierárquico – Delegado-Geral no âmbito da Polícia Civil, ou Superintendente Regional, no caso da Polícia Federal – fundamentar o ato administrativo de avocação ou redistribuição com concretos motivos: a) o interesse público deve prevalecer, por exemplo, no caso de determinada delegacia contar com material humano mais técnico e recursos mais avançados para o deslinde do feito, tal como uma equipe de repressão a crimes cibernéticos; ou b) no caso de inobservância dos preceitos insculpidos no ordenamento corporativo que prejudique a da investigação, como o descumprimento de ato normativo emanado do Chefe de Polícia.

Observa-se que a ausência de fundamentação da avocação ou redistribuição amparada nas circunstâncias legais (interesse público ou inobservância de norma interna) acarretará nulidade do ato.

## 9. INÍCIO E CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL

A instauração do IP está prevista no art. 5º, do CPP:

Art. 5º Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:

I - de ofício;

II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

§ 2º Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de Polícia.

### 9.1. DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE POLICIAL

Tomando conhecimento da prática de crime de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial tem o dever de instaurar o inquérito policial, sob pena de cometimento do crime de prevaricação (art. 319, CP). É instaurado por portaria, ato administrativo praticado pela autoridade policial.



## 9.2. POR REQUISIÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE (MINISTÉRIO PÚBLICO OU JUIZ)

No que tange à instauração do IP por ato do juiz, tendo em vista a adoção do sistema acusatório e da ação penal pública ser de titularidade do Ministério Público, não é mais recomendada essa forma de instauração. A providência mais adequada é que o Ministério Público, diante da notícia do crime, tome as providências cabíveis (art. 40, CPP). A Lei nº 11.719/08 alterou a redação do art. 531 do CPP, retirando do ordenamento jurídico a previsão de processo judicialiforme. Diante disso, entende a doutrina majoritária que o art. 26 do CPP foi tacitamente revogado. É pacífico o entendimento de que “requisição” se trata de sinônimo de ordem (apesar de não existir subordinação hierárquica entre delegado, Ministério Público e juiz). Por isso, diz-se que o delegado está obrigado a instaurar o inquérito quando requisitado. É instaurado por portaria, ato administrativo praticado pela autoridade policial. A autoridade policial pode deixar de instaurar inquérito policial se perceber que não há justa causa para tanto, desde que se trate de exigência manifestamente ilegal. A requisição deve estar lastreada na lei, não tendo, pois, supedâneo legal, não deve o delegado agir (NUCCI, 2015, p. 137).

## 9.3. POR REQUERIMENTO DO OFENDIDO OU REPRESENTANTE LEGAL

O próprio ofendido do delito ou quem tenha a qualidade para representá-lo requer à autoridade policial a instauração do inquérito policial. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura do IP caberá recurso para o chefe de polícia (art. 5º, § 2º, CPP). Para parte da doutrina, chefe de polícia é o Delegado-Geral de Polícia. Para outra parte, o Secretário de Segurança Pública. Segundo entendimento doutrinário, também é possível o manejo de mandado de segurança. É instaurado por portaria, ato administrativo praticado pela autoridade policial.

## 9.4. POR DELAÇÃO DE TERCEIRO OU *DELATIO CRIMINIS*

É a comunicação feita por qualquer pessoa do povo ao delegado acerca da ocorrência da infração penal em que caiba ação penal pública incondicionada (art. 5º, §3º, CPP). Pode ser feita oralmente ou por escrito. É instaurado por portaria, ato administrativo praticado pela autoridade policial.

## 9.5. POR REQUISIÇÃO DO MINISTRO DA JUSTIÇA

A instauração do IP, para alguns crimes, depende de autorização do Ministro da Justiça. Não é ordem, é mera autorização para o início da persecução penal (investigação + ação penal). É instaurado por portaria, ato administrativo praticado pela autoridade policial.

## 9.6. PELA LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (APF)

Embora não previsto no art. 5º do CPP, quando ocorrer a prisão em flagrante do investigado, o próprio auto de prisão em flagrante será a peça que dará início ao inquérito policial (que deve preencher os requisitos dos artigos 304 a 308 do CPP). Não se fala em Portaria.

## 9.7. OBSERVAÇÕES

Se o fato for de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial poderá agir de ofício. No entanto, se for uma ação penal pública condicionada à representação ou uma ação penal privada, a autoridade policial dependerá da manifestação da vítima para que o fato seja investigado. Atente-se ao seguinte dispositivo legal do CPP:

Art. 5º.  
(...)



§ 4º O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado.

§ 5º Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la.

Lembre-se que a manifestação ou representação da vítima não depende de formalidades. Basta que o MP ou o delegado verifique que de fato a pessoa quer investigar, processar. Doutrina e jurisprudência são uniformes em afirmar que a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal. (REsp 1472027/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017.)

A instauração de inquérito policial não interrompe a prescrição, não sendo causa prevista no art. 117 do CP:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

## 10. NOTITIA CRIMINIS

A notícia de uma determinada infração penal pode chegar de várias formas à autoridade policial. São elas:

### 10.1. DE COGNIÇÃO DIRETA/IMEDIATA/ESPONTÂNEA

A notícia que chega de forma espontânea ao delegado, em suas atividades rotineiras (rondas, entrevista de informantes, informações policiais, pela televisão, por acaso). Nesse sentido, o Informativo 652 do STJ em que o tribunal superior entendeu válida investigação iniciada pela autoridade policial em face de notícia veiculada em jornal – a comunicação foi considerada de natureza de cognição direta ou imediata (STJ. RHC 98.056).

### 10.2. DE COGNIÇÃO INDIRETA/MEDIATA/PROVOCADA

A notícia do crime chegou ao delegado de polícia por um terceiro, seja a vítima (ou representante legal), seja Ministério Público, seja Juiz, seja Ministro da Justiça, seja até por terceiro.

### 10.3. DE COGNIÇÃO COERCITIVA

Quando ocorre a captura em suposta situação flagrancial do autor do fato. Essa modalidade de prisão será detalhada no capítulo respectivo.





#### 10.4. DE COGNIÇÃO INQUALIFICADA (DENÚNCIA ANÔNIMA)

Nesse caso, o delegado não pode iniciar imediatamente o IP só com a denúncia anônima, posto que primeiramente deve realizar providências preliminares no sentido de confirmá-la. Sobre denúncia anônima, atenção às jurisprudências abaixo:

As notícias anônimas ("denúncias anônimas") não autorizam, por si só, a propositura de ação penal ou mesmo, na fase de investigação preliminar, o emprego de métodos invasivos de investigação, como interceptação telefônica ou busca e apreensão. Entretanto, elas podem constituir fonte de informação e de provas que não podem ser simplesmente descartadas pelos órgãos do Poder Judiciário. Procedimento a ser adotado pela autoridade policial em caso de "denúncia anônima": 1) Realizar investigações preliminares para confirmar a credibilidade da "denúncia"; 2) Sendo confirmado que a "denúncia anônima" possui aparência mínima de procedência, instaura-se inquérito policial; 3) Instaurado o inquérito, a autoridade policial deverá buscar outros meios de prova que não a interceptação telefônica (esta é a *ultima ratio*). Se houver indícios concretos contra os investigados, mas a interceptação se revelar imprescindível para provar o crime, poderá ser requerida a quebra do sigilo telefônico ao magistrado. STF. 1ª Turma. HC 106152/MS, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 29/3/2016 (Info 819).

Não é possível decretar medida de busca e apreensão com base unicamente em "denúncia anônima". STF. 1ª Turma. HC 106152/MS, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 29/3/2016 (Info 819).

Não é possível decretar interceptação telefônica com base unicamente em "denúncia anônima". STJ. 6ª Turma. HC 204.778/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 4/10/2012.

**Atenção:** é importante destacar a edição da Lei nº 13.608/18 que dispõe sobre o serviço telefônico de recebimento de denúncias e sobre recompensa por informações que auxiliem nas investigações policiais. De acordo com o art. 3º:

"Art. 3º O informante que se identificar terá assegurado, pelo órgão que receber a denúncia, o sigilo dos seus dados."

Parcela da doutrina enxergava na Lei nº 13.608/18 o que pode se chamar de *Whistleblower* ("reportante"), já que a referida lei dispõe sobre o "disque-denúncia", incentivando a colaboração do cidadão com as investigações, garantindo o anonimato e autorizando recompensas diversas na seara criminal. Desse modo, *Whistleblower* é a designação dada pela doutrina para se referir à pessoa que não está envolvida diretamente e nem indiretamente com os crimes praticados, mas que relata voluntariamente o que tem conhecimento às autoridades responsáveis. Ele não cometeu qualquer ilicitude e nem busca uma compensação penal ou processual penal, o que são importantes diferenciadores da figura do colaborador premiado.

**Atenção:** aquilo que era visto pela doutrina apenas como um pequeno embrião (com a edição da Lei nº 13.608 em 10 de janeiro de 2018) passou a ser regulamentado expressamente a partir da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) inserindo importantes considerações nos artigos 4º-A e 4º-C da Lei nº 13.608/18:

Art. 4º-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e suas autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista manterão unidade de ouvidoria ou correição, para assegurar a qualquer pessoa o direito de relatar informações sobre crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)  
Parágrafo único. Considerado razoável o relato pela unidade de ouvidoria ou correição e procedido o encaminhamento para apuração, ao informante serão asseguradas proteção integral contra retaliações e isenção de responsabilização civil ou penal em relação ao



relato, exceto se o informante tiver apresentado, de modo consciente, informações ou provas falsas. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 4º-B. O informante terá direito à preservação de sua identidade, a qual apenas será revelada em caso de relevante interesse público ou interesse concreto para a apuração dos fatos. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Parágrafo único. A revelação da identidade somente será efetivada mediante comunicação prévia ao informante e com sua concordância formal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 4º-C. Além das medidas de proteção previstas na Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, será assegurada ao informante proteção contra ações ou omissões praticadas em retaliação ao exercício do direito de relatar, tais como demissão arbitrária, alteração injustificada de funções ou atribuições, imposição de sanções, de prejuízos remuneratórios ou materiais de qualquer espécie, retirada de benefícios, diretos ou indiretos, ou negativa de fornecimento de referências profissionais positivas. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º A prática de ações ou omissões de retaliação ao informante configurará falta disciplinar grave e sujeitará o agente à demissão a bem do serviço público. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º O informante será ressarcido em dobro por eventuais danos materiais causados por ações ou omissões praticadas em retaliação, sem prejuízo de danos morais. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 3º Quando as informações disponibilizadas resultarem em recuperação de produto de crime contra a administração pública, poderá ser fixada recompensa em favor do informante em até 5% (cinco por cento) do valor recuperado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

## 11. CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL

### 11.1. TRÂMITE NOS DELITOS DE AÇÃO PENAL PÚBLICA

De acordo com o art. 10 do CPP, quando o Delegado de Polícia encerra o inquérito policial, ele deverá fazer um relatório sobre todas as diligências que foram realizadas , juntá-lo aos autos e encaminhar ao juiz competente. Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade policial poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz.

Artigo 10.

§ 1º a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente.

§ 2º No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiveram sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas.

§ 3º Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade (policial) poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz.

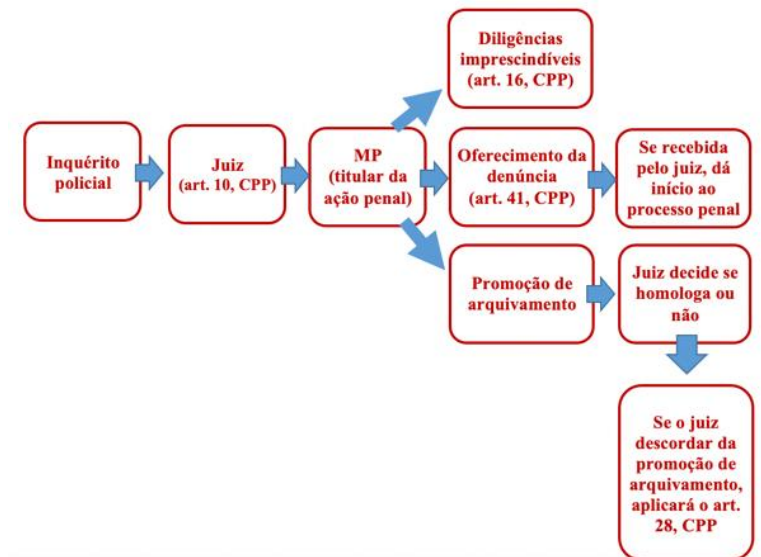
O relatório é a peça na qual o delegado descreverá o que foi realizado no IP. O Delegado não expõe juízo de valor no documento, apenas narra o que foi feito durante a investigação.

Esse relatório é encaminhado ao juiz, nos termos do art. 10 do CPP, para que ele determine que seja dada vista dos autos ao Ministério Público. A solução não é a melhor, a figura do juiz servindo de intermediário entre a polícia judiciária e o Ministério Público é completamente dispensável. O inquérito policial tem como destinatário o órgão estatal acusador, uma vez que sua razão de existir é elucidar fato supostamente criminoso, colhendo indícios de autoria e prova da materialidade, servindo de suporte para a confecção da inicial acusatória. Melhor seria a solução de trâmite do inquérito policial diretamente entre aparelho estatal policial e Ministério Público, salvo se

for levado a efeito representação de medida cautelar (busca e apreensão, prisão provisória, interceptação telefônica, dentre outras), que necessariamente deve ser encaminhada ao juízo competente, porque a este cabe a análise e deferimento ou não do pleito deduzido. Com as modificações promovidas pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/19), os pleitos serão analisados pela figura do juiz das garantias.

Quando receber o IP, o Promotor de Justiça terá as seguintes opções:

- a) oferecer denúncia (art. 41, CPP), caso entenda que já há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade;
- b) requerer ao juiz que devolva os autos ao Delegado de Polícia (baixa à delegacia) para que sejam realizadas novas diligências investigatórias imprescindíveis (art. 16, CPP), se entender que ainda não há elementos informativos suficientes;
- c) declinar ou suscitar conflito de competência/atribuição;
- d) requerer ao juiz o arquivamento do inquérito policial, caso conclua que não há crime ou que não existem “provas” suficientes, mesmo já tendo sido feitas todas as diligências investigatórias possíveis.



Se o MP oferecer denúncia, voltam os autos para o juiz e se processa a Ação Penal (caso recebida). Se o MP requerer novas diligências, voltam os autos ao juiz e este “baixa” para que o delegado de polícia realize as diligências.

Muitos criticam essa burocratização e fala-se muito em “tramitação direta” entre a delegacia e o MP, uma vez que os autores mais modernos de Processo Penal defendem que o § 1º do art. 10 do CPP não foi recepcionado pela CF/88.

A doutrina aponta que o inquérito policial deveria tramitar, em regra, apenas entre a Polícia e o Ministério Público, sem o Poder Judiciário como intermediário. Assim, quando o Delegado conclui o IP, em vez de remeter os autos ao juiz, enviará o procedimento diretamente ao Promotor de Justiça.

De igual modo, se o membro do *Parquet* deseja a realização de outras diligências, ele não precisa, em regra, pedir isso ao juiz, bastando que devolvesse à Polícia com essa requisição. Essa regra da tramitação direta somente seria excepcionada quando houvesse pedidos que dependessem do Poder Judiciário (reserva de jurisdição).



Percebendo que o procedimento trazido pelo CPP estava em contrariedade com o sistema acusatório ou, no mínimo, desatualizado, alguns Estados passaram a editar normas dentro do tribunal que permitem essa tramitação direta do IP entre as delegacias e o MP, sem ter que passar pelo crivo do juiz. Cabe lembrar, porém, que no CPP a previsão expressa é de que o relatório deve ser encaminhado ao JUIZ.

Além de o Ministério Público poder requisitar diligências complementares, a autoridade policial também pode pedir também a devolução dos autos do IP porque não terminou a investigação. Dessa forma, devolve o IP para o juiz e requer a prorrogação do prazo, dizendo o motivo pelo qual requer a prorrogação (ex.: precisa ouvir testemunhas, juntar o laudo, fazer o relatório etc.). O teor pode ser extraído dos §§ 2º e 3º do art. 10, CPP.

Os instrumentos do crime, bem como objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito policial (art. 11, CPP). Ex.: delito de roubo, no qual foi subtraído dinheiro, carteira, documentos etc., e no momento da detenção do sujeito, é apreendido junto a carteira, a faca, outros duzentos reais, revólver, outro aparelho de celular (de produto anterior de outro crime), etc. Tudo que foi apreendido acompanhará o IP, caso não seja restituído à vítima.

Atenção: em regra, no relatório final da autoridade policial, não há juízo de valor a respeito da investigação. No entanto, atenção para a previsão do art. 52 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06). Nesse caso, o Delegado relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que o levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e a natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

**Atenção:** Lei nº 13.964/19 (Lei Anticrime): a previsão do art. 10, § 1º, do CPP, sobre a conclusão do IP na ação penal pública estará revogada tacitamente caso volte o instituto do juiz das garantias, porque com a estrutura acusatória (art. 3º-A do CPP) o IP não precisará passar pelo juiz necessariamente, o IP tramitará diretamente entre polícia e órgão acusatório. O juiz das garantias atuará de forma importante no decorrer da investigação, como: receber a comunicação da prisão, analisar a audiência de custódia, competência com reserva de jurisdição para analisar interceptação telefônica, uma prova irrepetível, prova antecipada, decretação de prisão preventiva, de prisão temporária, duração e prorrogação do IP; mas as atuações são no sentido de resguardar as garantias do investigado e não de agir de forma mais incisiva e presente no IP.

## 11.2. TRÂMITE NOS DELITOS DE AÇÃO PENAL PRIVADA

Artigo 19 do CPP: Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado.

No caso de ação penal privada, os autos serão remetidos ao juízo competente, onde permanecerão em cartório, aguardando a iniciativa do ofendido para oferecimento da queixa-crime. Nada impede que os autos do IP, por traslado, sejam entregues ao requerente.

Isto é, o IP ficará guardado em cartório judicial esperando a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal durante o prazo decadencial de 6 meses. Se a vítima não desejar oferecer a ação, basta ficar inerte (extinção da punibilidade pela decadência – art. 38 do CPP).

**Atenção:** Lei nº 13.964/19 (Lei Anticrime): caso seja revogada a decisão que suspendeu a eficácia dos arts. 3º-A ao 3º-F e art. 28, todos do CPP: quanto ao inquérito policial relativo a crime de ação penal privada, cuja iniciativa é do querelante, não do MP, o art. 19, do CPP, será considerado revogado, seja por ser incompatível com o espírito da reforma processual, seja porque tal não figura entre as competências do juiz das garantias (art. 3º-B do CPP). Nesse caso, o inquérito policial, uma vez concluído, ficará, na própria polícia, à disposição do interessado. Nele não intervirá o MP. Nem se

remeterá ao juízo, aguardando a manifestação do interessado, sob pena de extinção de punibilidade pela decadência (art. 38 do CPP).

## 12. PRAZO PARA ACONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL

Artigo 10 do CPP: O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

Artigo 51, Lei nº 11.343/06: O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.

Parágrafo único: os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.

Inquérito policial federal (art. 66 da Lei nº 5.010/1966)

Art. 66. O prazo para conclusão do inquérito policial será de quinze dias, quando o indiciado estiver preso, podendo ser prorrogado por mais quinze dias, a pedido, devidamente fundamentado, da autoridade policial e deferido pelo juiz a que competir o conhecimento do processo.

**Atenção:** o prazo para a conclusão do IP de investigado solto começa a contar a partir da instauração do IP. O prazo para a conclusão do IP de investigado preso começa a contar a partir do dia em que, efetivamente, se cumpriu a ordem de prisão. Para o investigado preso em flagrante, é claro o dia em que se executou a prisão (dia em que foi preso em flagrante). Quando se tratar de investigado preso preventivamente ou temporariamente, deve se iniciar o prazo do dia em que o mandado foi cumprido e não do dia da decretação da prisão, muito menos do dia em que se expediu o mandado, mas sim do dia em que foi efetivamente preso.

**Atenção:** a doutrina e a jurisprudência majoritárias sempre entenderam que a investigação envolvendo investigado preso cautelarmente não poderia ser prorrogada, a não ser que fosse o investigado solto. A prisão cautelar pressupõe a existência de prova do delito e indícios de sua autoria (*fumus commissi delicti*), requisitos também demandados para a propositura da ação penal (art. 41 do CPP). Se ao final dos 10 dias previstos no artigo 10 do CPP o titular da ação penal não vislumbrasse elementos suficientes para a propositura da ação penal, tal fato seria indicativo de que a prisão não deve permanecer. Com a Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), temos mais uma novidade a ser destacada. A lei passou a prever o seguinte no CPP:

Art. 3º (...) § 2º Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até 15 (quinze) dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada.

Isto é, rompendo com o entendimento anterior, agora é possível a prorrogação do prazo de conclusão do inquérito policial de investigado preso. O juiz das garantias deverá ser provocado e poderá autorizar a prorrogação uma única vez por até 15 dias. Ao final desse prazo, se a investigação não tiver sido encerrada, a prisão cautelar deve ser relaxada imediatamente por ser considerada ilegal.

**Atenção:** no caso de crimes hediondos, caso tenha sido decretada a prisão temporária, o prazo para a conclusão do IP passa a ser de até 60 dias. Isso porque a prisão temporária em caso de crime hediondo tem o prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Como a prisão temporária só tem cabimento durante a fase de investigação, isso faz com que o prazo para a conclusão do IP acompanhe o prazo da prisão temporária.

**Atenção:** a legislação especial também prevê prazos específicos para a conclusão do inquérito policial, o que deve ser memorizado.

| PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL (EM DIAS) |                    |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                                                        | PRESO<br>(em dias) | SOLTO<br>(em dias)                   |
| REGRA GERAL<br>(ART. 10 DO CPP)                        | 10                 | 30                                   |
| ART. 51 da Lei nº 11.343/06<br>(Lei de Drogas)         | 30 + 30            | 90 + 90                              |
| IP MILITAR<br>Art. 20 do CPPM                          | 20                 | 40 + 20                              |
| IP FEDERAL<br>Art. 66 da Lei nº 5.010/66               | 15 + 15            | Sem previsão – aplica-se o CPP<br>30 |
| Art. 10 da Lei nº 1.051/51                             | 10                 | 10                                   |
| Lei nº 8.072/90<br>Lei dos Crimes Hediondos            | Até 60 dias        | Sem previsão – aplica-se o CPP       |

### 12.1. NATUREZA DOS PRAZOS DE CONCLUSÃO DO IP

1ª Corrente: prazo de natureza processual: exclui-se o dia do início e inclui o do final; se terminar em feriado, deverá ser estendido para o primeiro dia útil.

2ª Corrente: prazo de natureza penal: inclui-se o dia do início e termina o prazo no dia em que esgotar o prazo, ainda que termine em domingo.

Doutrina majoritária: estando o indiciado solto, o prazo tem como termo inicial a Portaria de Instauração do inquérito policial. Estando o indiciado preso, o prazo terá como termo inicial a data da efetivação da prisão. Trata-se, neste último caso, de prazo material, ou seja, inclui-se o dia do começo na contagem, não se prorrogando o prazo caso o último dia seja domingo, seja feriado.

**Atenção:** em que pese a conclusão do inquérito policial de investigado solto tenha um prazo impróprio, é possível a aplicação da duração razoável do processo (judicial e administrativo) para trancar o inquérito, garantindo, destarte, que o Estado não prolongue indevidamente o seu direito de punir. O Estigma de investigado/réu não pode se perpetuar por mera inércia das autoridades que atuam na persecução criminal. Sobre o tema, observe a jurisprudência abaixo:

*HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ESTELIONATO CONTRA ENTE PÚBLICO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE QUE OS FATOS INVESTIGADOS JÁ FORAM OBJETO DE OUTRO INQUÉRITO POLICIAL, ARQUIVADO A PEDIDO DO MPF. FRAUDE NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FINAM E PELA SUDAM E DESVIO DE RECURSOS. NÃO APURAÇÃO DE QUALQUER FATO QUE PUDESSE AMPARAR EVENTUAL AÇÃO PENAL, TANTO QUE NÃO OFERECIDA A DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO QUE DURA MAIS DE 7 ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. ORDEM CONCEDIDA. (...) 5. No caso,*



passados mais de 7 anos desde a instauração do Inquérito pela Polícia Federal do Maranhão, não houve o oferecimento de denúncia contra os pacientes. É certo que existe jurisprudência, inclusive desta Corte, que afirma inexistir constrangimento ilegal pela simples instauração de Inquérito Policial, mormente quando o investigado está solto, diante da ausência de constrição em sua liberdade de locomoção (HC 44.649/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJU 08.10.07); entretanto, não se pode admitir que alguém seja objeto de investigação eterna, porque essa situação, por si só, enseja evidente constrangimento, abalo moral e, muitas vezes, econômico e financeiro, principalmente quando se trata de grandes empresas e empresários e os fatos já foram objeto de Inquérito Policial arquivado a pedido do *Parquet* Federal. 6. Ordem concedida, para determinar o trancamento do Inquérito Policial 2001.37.00.005023-0 (IPL 521/2001), em que pese o parecer ministerial em sentido contrário. (HC 96.666/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2008, DJe 22/9/2008.)

### 13. DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS

Em que pese ser descrito e delineado no Código de Processo Penal a partir do art. 4º, o inquérito policial não conta com uma sequência de atos predeterminados como ocorre no processo judicial em que temos os atos concatenados nos procedimentos comuns e nos especiais.

Os artigos 6º e 7º, ambos do CPP, elencam as diligências que a autoridade policial poderá realizar logo que tiver conhecimento da prática da infração penal. É rol exemplificativo, não obrigatório e discricionário da autoridade policial.

Não significa que somente poderá fazer o que está descrito no rol do artigo 6º. Dependendo da natureza do crime, o delegado precisará realizar outras diligências que não estão previstas no CPP, por isso que o rol é exemplificativo.

Não é em toda investigação de qualquer delito que o delegado de polícia conseguirá fazer todas as diligências previstas no art. 6º, por isso ele não é obrigatório, é discricionário da autoridade. Visualizando a prática da infração penal, a autoridade policial verá o que será possível, quais diligências ele deverá tomar para a elucidação do caso.

**Atenção:** em que pese o inquérito policial ser inquisitivo, admite-se que o investigado, assim como a vítima, indique ou solicite a juntada de provas ou documentos com o fito de comprovar suas alegações. No entanto, a efetiva produção da prova requerida ou a juntada de documentos solicitada por essas pessoas está na esfera da discricionariedade da autoridade policial, que pode julgá-las irrelevantes ou protelatórias. No caso de admissão ou rejeição do elemento de prova, deve o delegado despachar de forma fundamentada. Para melhor compreensão, vide artigo 14 do CPP:

“Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade.”

#### De acordo com o art. 6º do CPP:

1) Dirigir-se ao local dos fatos, providenciando para que não se alterem o estado e a conservação das coisas, até a chegada dos peritos: a autoridade deve preservar o local do crime até a chegada dos peritos para que estes possam colher elementos de prova. Só após a liberação dos peritos é que os objetos poderão ser apreendidos e a cena do crime poderá ser alterada. O dispositivo possui a finalidade de evitar que alterações sejam feitas pelos autores do delito ou por populares que possam prejudicar a realização da perícia. A fim de garantir a preservação do local do crime, o Código Penal considera crime de fraude processual a conduta de inovar artificialmente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Previsão também constante no art. 312 do Código de Trânsito Brasileiro em que considera crime inovar artificialmente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial ou processo penal, o estado de lugar, de



coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente, o perito ou o juiz. Importante a leitura do artigo 169 do CPP:

Art. 169. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos.

Parágrafo único. Os peritos registrarão, no laudo, as alterações do estado das coisas e discutirão, no relatório, as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos.

2) Apreender objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos: o art. 11 do CPP, estabelece que tais objetos deverão acompanhar o inquérito, salvo se não mais interessarem à prova, hipótese em que serão restituídos aos seus proprietários. Segundo o STJ, a autoridade policial poderá apreender os objetos relacionados com a infração, mesmo antes da instauração do respectivo IP. É possível que se trate de uma busca pessoal, ou busca domiciliar. Devem ser apreendidos os instrumentos do crime, o objeto material do delito, objetos que possam ser úteis à prova, bem como aqueles adquiridos com o produto do crime (art. 91, II, b, CP).

3) Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias: exemplos: ouvir testemunhas, representar pela decretação de interceptação telefônica, busca domiciliar, dentre outros. No caso das testemunhas, ao contrário do que ocorre no curso da ação penal, não haverá número máximo que a autoridade pode ouvir. Se a testemunha for notificada e não comparecer, poderá ser determinada a sua condução coercitiva (art. 218, CPP). Se a testemunha reside em outra cidade, deverá ser expedida carta precatória. A Lei nº 13.431/2017 estabelece normas especiais relativas à oitiva de crianças e adolescentes testemunhas de crimes praticados com emprego de violência. Cumpre, ainda, destacar, aqui, a Lei nº 13.432/17 que regulamentou a atividade de detetive particular e permitiu a colaboração deste com a investigação criminal, desde que expressamente autorizada pelo contratante e com o necessário aceite do delegado de polícia. É o que prescreve o art. 5º:

Art. 5º O detetive particular pode colaborar com investigação policial em curso, desde que expressamente autorizado pelo contratante.

Parágrafo único. O aceite da colaboração ficará a critério do delegado de polícia, que poderá admiti-la ou rejeitá-la a qualquer tempo.

4) Ouvir o ofendido: não será compromissado a dizer a verdade. Se o ofendido for regularmente notificado e não comparecer, poderá ser conduzido coercitivamente (art. 201, § 1º, CPP). Tratando-se de crianças e adolescentes vítima de violência, a autoridade policial deve zelar pela observância das garantias previstas na Lei nº 13.431/2017.

5) Ouvir o indiciado: não se exigirá compromisso de dizer a verdade e deverá ser garantido o direito ao silêncio e a não autoincriminação. Em regra, o STJ tem interpretado que a não comunicação, por parte do delegado de polícia, dos direitos constitucionais ao silêncio e a não autoincriminação constitui nulidade relativa, exigindo-se prova efetiva do prejuízo para ser declarada. Eis a síntese:

RECURSO ORDINÁRIO EM *HABEAS CORPUS*. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DENÚNCIA. INTERROGATÓRIO POLICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NEGATIVA DA AUTORIA. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio do *pas de nullité sans grief* exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. 2. Hipótese em que a defesa não apontou qualquer prejuízo decorrente da suposta falta de informação, no interrogatório policial, do



direito ao silêncio. E o recorrente negou a autoria do delito. 3. Recurso ordinário a eu se nega provimento. STJ. 6ª Turma, RHC 72.510/MG, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/10/2016, DJE em 21/10/2016.

6) Proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações: o reconhecimento de pessoas e coisas deve obedecer aos artigos 226 e seguintes do CPP. Acareação significa colocar frente a frente pessoas que tenham prestado informações divergentes, na forma dos artigos 229 e 230 do CPP. Ambos os institutos serão detalhados em capítulo próprio.

7) Realizar o exame de corpo de delito e outras perícias: sempre que a infração deixar vestígios, a materialidade delitiva será demonstrada pela realização do exame de corpo de delito (art. 158, CPP).

8) Ordenar a identificação datiloscópica do indiciado e fazer juntar sua folha de antecedentes: a juntada da folha de antecedentes é necessária sempre que alguém for indiciado nos autos de inquérito policial. Sobre a identificação criminal, cumpre ressaltar que a Constituição Federal afirma que o civilmente identificado não será criminalmente identificado, apenas nos casos em que a lei permitir, conforme artigo 5º, LVIII, da CF/88:

“LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;”

A Lei nº 12.037/09 regulamenta o tema e lista quais documentos serão considerados aptos a comprovar a identidade civil:

Art. 2º A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos:

I – carteira de identidade;

II – carteira de trabalho; (Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019)

III – carteira profissional;

IV – passaporte;

V – carteira de identificação funcional;

VI – outro documento público que permita a identificação do indiciado.

Parágrafo único. Para as finalidades desta Lei, equiparam-se aos documentos de identificação civis os documentos de identificação militares.

Além disso, a lei lista os casos em que será manejada identificação criminal, ainda que seja apresentado documento de identificação:

Art. 3º Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando:

I – o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação;

II – o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado;

III – o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si;

IV – a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da defesa;

V – constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações;

VI – o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais.

Parágrafo único. As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito, ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado.

A identificação criminal é a conjugação do registro fotográfico e da identificação pelo processo datiloscópico, ou seja, colheita das impressões digitais de todos os dedos das mãos:

Art. 5º A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico, que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante, ou do inquérito policial ou outra forma de investigação.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso IV do art. 3º, a identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético.

9) Averiguar a vida pregressa do indiciado, do ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuam para a apreciação de seu temperamento e caráter.

10) Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa: a Lei nº 13.257/16, que trata de políticas públicas para a primeira infância, incluiu o inciso X, no artigo 6º do CPP.

11) Realizar a reprodução simulada dos fatos: de acordo com o art. 7º do CPP, para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, também denominada de reconstituição do crime. É vedada a reprodução simulada dos fatos se houver ofensa à moralidade (regras éticas de conduta) e à ordem pública (segurança e paz social). Portanto, não se fará a reconstituição do crime sexual, por exemplo. Com relação à obrigatoriedade da diligência, o investigado não está obrigado a efetivamente participar, pois não pode ser compelido a auto incriminar-se (conduta ativa de participar da reprodução simulada dos fatos). O STF possui posição no sentido de que o investigado sequer está obrigado a comparecer ao local da reprodução simulada dos fatos, não cabendo, pois, condução coercitiva, bem como a simples ausência do investigado a esta diligência, por si só, não permite a decretação de sua prisão preventiva (RHC nº 64354). Nesse sentido, ainda, há posição da doutrina (TÁVORA, 2020, p. 113).

## **14. OUTRAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO CPP QUE O DELEGADO DE POLÍCIA PODERÁ FAZER OU REPRESENTAR AINDA NA FASE DO IP**

### **14.1. ATENÇÃO AO ART. 13 DO CPP**

**Art. 13, CPP: Incumbirá ainda à autoridade policial**

**I - fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos;**

**II - realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público;**

**III - cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias;**

**IV - representar acerca da prisão preventiva.**

### **14.2. REPRESENTAR ACERCA DA PRISÃO PREVENTIVA (QUEM DECRETA É O JUIZ), CONFORME ART. 311 DO CPP**

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”

### **14.3. REPRESENTAR ACERCA DA PRISÃO TEMPORÁRIA (QUEM DECRETA É O JUIZ), CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 7.960/89**

“Art. 2º. A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.”

**14.4. ARBITRAR FIANÇA, CONFORME ART. 322 DO CPP**

Art. 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos. Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 (quarenta e oito) horas.

Atenção ao art. 24-A da Lei Maria da Penha (Do Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência) — Em que pese a pena máxima em abstrato seja menor de 4 (quatro) anos, não há possibilidade de fixação de fiança pela autoridade policial, tão somente pela autoridade judicial:

**Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:**

**Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.**

**§ 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.**

**§ 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.**

**§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.**

**14.5. REPRESENTAR PELO EXAME DE INSANIDADE MENTAL (QUEM ORDENA O EXAME É O JUIZ), CONFORME ART. 149 DO CPP**

Art. 149, CPP. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

§1º. O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente.

**14.6. RESTITUIR COISAS APREENDIDAS, CONFORME ART. 120 DO CPP**

“Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”

**14.7. REPRESENTAR PELA MEDIDA ASSECURATÓRIA DO SEQUESTRO, CONFORME ART. 127 DO CPP**

“Art. 127. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa.”

**14.8. REQUISITAR, DE QUAISQUER ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO OU DE EMPRESAS DA INICIATIVA PRIVADA, DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA VÍTIMA OU DE SUSPEITOS, CONFORME ART. 13-A DO CPP**

Art. 13-A. Nos crimes previstos nos arts. 148, 149 e 149-A, no § 3º do art. 158 e no art. 159 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e no art. 239 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos.

Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conterá:

I - o nome da autoridade requisitante;



II - o número do inquérito policial;

III - a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação.

#### **14.9. REQUISITAR, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ÀS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES E/OU TELEMÁTICA QUE DISPONIBILIZEM IMEDIATAMENTE OS MEIOS TÉCNICOS ADEQUADOS – COMO SINAIS, INFORMAÇÕES E OUTROS – QUE PERMITAM A LOCALIZAÇÃO DA VÍTIMA OU DOS SUSPEITOS DO DELITO EM CURSO**

Art. 13-B. Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência.

§ 2º Na hipótese de que trata o *caput*, o sinal:

I - não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei;

II - deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 (trinta) dias, renovável por uma única vez, por igual período;

III - para períodos superiores àquele de que trata o inciso II, será necessária a apresentação de ordem judicial.

§ 3º Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial.

§ 4º Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 (doze) horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz.

#### **14.10. DECLARAR-SE SUSPEITA, QUANDO OCORRER MOTIVO LEGAL**

Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, MAS deverão elas se declararem suspeitas, quando ocorrer motivo legal. Isto é, o delegado pode declarar-se suspeito, mas a parte não pode opor suspeição em face da autoridade policial (CUIDADO), tudo nos termos do art. 107 do CPP:

“Art. 107, CPP: Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas, quando ocorrer motivo legal.”

#### **15. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MEMBROS DAS FORÇAS ARMADAS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (ART. 14-A, CPP)**

O art. 14-A do CPP foi incluído pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019) e estabelece o acompanhamento das investigações por agentes de segurança pública em crimes relacionados ao uso da força letal:

Art. 14-A Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no art. 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o indiciado poderá constituir defensor.

§ 1º Para os casos previstos no *caput* deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da citação.

§ 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique defensor para a representação do investigado.

§ 3º - vetado

§ 4º - vetado

§ 5º - vetado

§ 6º As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a Garantia da Lei e da Ordem.

A Lei nº 13.964/2019 assegura aos servidores vinculados às instituições dispostas nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, que figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional ou missões para Garantia da Lei e da Ordem, o direito de constituir defensor para acompanhamento dos atos.

**Atenção:**

1. essa garantia alcança, além dos policiais, os membros das Forças armadas (Marinha, Aeronáutica e Exército) se os fatos investigados estiverem inseridos no contexto de missões para a garantia da lei e da ordem;

2. essa exigência não se faz em todo e qualquer procedimento investigativo, ainda que recaiam sobre agentes de segurança pública, mas apenas naqueles em que sejam investigados fatos relacionados ao uso de força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada;

3. esses agentes públicos deverão ser comunicados após a instauração de procedimento investigatório e podem constituir um defensor e, caso não o façam, a organização na qual o investigado estava vinculado à época dos fatos deve indicar um defensor para representá-lo. Em que pese o legislador tenha se utilizado do termo “citação”, há uma atecnia. Não se fala em citação em procedimento investigatório, mas sim notificação, como um ato genérico para se comunicar um ato;

4. só é obrigatória a comunicação ao servidor e a notificação ao órgão. Não é obrigatório que haja efetivo contraditório ou ampla defesa em favor do investigado na fase do inquérito policial. Essas previsões legais não podem chegar ao ponto de retirar a natureza jurídica não contraditória (portanto, inquisitiva) do inquérito policial. Se um dia for prevista a garantia do contraditório e da ampla defesa na fase extrajudicial, não poderá ser restrita a agentes ou autoridades de segurança pública e sim a qualquer cidadão (abaixo falaremos sobre isso e sobre uma suposta inconstitucionalidade do dispositivo legal);

5. bastam ser efetivadas as comunicações. Não ficará a investigação paralisada enquanto efetivamente não for indicada a defesa técnica. A cautela do art. 14-A não pode comprometer a investigação;

6. compatibilidade com a Súmula Vinculante nº 14: o dever de chamamento do investigado deve coexistir com o dever de apurar eficazmente o crime. Havendo diligências sigilosas, não ocorrerá previamente o chamamento do investigado, sob pena de comprometer a investigação;

7. essa norma ofende o princípio da igualdade? Poder se defender desde a fase investigativa é um direito garantido na Constituição e, por isso, entendemos que tal inovação é negativa. Não por garantir esse direito a agentes de segurança pública e membros das Forças Armadas, mas sim por excluir o restante da sociedade, criando um tratamento desigual e sem razão entre os cidadãos. Um policial militar que, por exemplo, venha a ser investigado pela prática do crime de homicídio praticado contra um cidadão terá direito à defesa desde a época das

investigações, mas um cidadão que pratica qualquer outro crime (furto, tráfico de drogas e etc.) também não deveria ter o mesmo direito?;

8. o não chamamento/notificação do investigado para acompanhar a investigação gera nulidade dos atos supervenientes;

9. o dispositivo legal não previu solução para o caso de o investigado, após a tentativa de chamamento do § 1º, não ser localizado. A doutrina sugere aplicar desde já o § 2º do mesmo dispositivo, sendo incompatível se falar em chamamento por edital, o que burocratizaria a investigação (CUNHA, ROGERIO SANCHES; 2020, p. 110).

## 16. ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO DO IP

### 16.1. OBSERVAÇÃO IMPORTANTE A RESPEITO DA LEI Nº 13.964/19 (LEI ANTICRIME)

A sistemática acerca da promoção de arquivamento foi modificada com a edição da Lei nº 13.964 (Pacote Anticrime). No entanto, para compreendermos o novo delineamento, é imprescindível saber em detalhes como ocorria antes da vigência da Lei Anticrime. Por isso, inicialmente vamos tratar do arquivamento em seu procedimento tradicional delineado na redação original do art. 28 do CPP. Ao final, iremos comparar com o novo sistema.

Saliento que na decisão cautelar monocrática exarada pelo Ministro relator Luiz Fux em janeiro de 2020, especificamente na ADI 6305 de autoria da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, houve a suspensão da aplicação do novo procedimento de arquivamento trazido pela Lei Anticrime, por prazo indeterminado, até o julgamento de mérito da ADI.

Dessa forma, como não há decisão final a respeito da constitucionalidade ou não da norma em comento, a opção é esmiuçar o tratamento anterior, que está vigente, e também tecer detalhes a respeito do novo tratamento dado pela Lei nº 13.964/19, preparando o leitor para as duas situações, independentemente do que será decidido pelo STF.

### 16.2. ARQUIVAMENTO TRADICIONAL

Como visto nas características do inquérito policial, o procedimento é indisponível e a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos (art. 17 do CPP). O arquivamento é ato complexo em que o Ministério Público se manifesta pelo arquivamento e o juiz decide se é o caso de arquivar ou não, fiscalizando o princípio da obrigatoriedade da ação penal. O juiz nunca teve autorização para arquivar o inquérito policial de ofício, sob pena de usurpar as funções ministeriais. Nesse ponto, é importante frisar que a Lei Anticrime não alterou essa compreensão, permanecendo a impossibilidade de se arquivar oficiosamente uma investigação criminal.

Se o Ministério Público não ofereceu a denúncia e requerer o arquivamento, ele deve demonstrar que há motivos para tanto. Se o juiz entender que não é caso de arquivamento, mandará os autos de inquérito policial ao Procurador-Geral de Justiça (ou Câmara de Coordenação e Revisão, no plano federal – art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93) para análise, nos termos do art. 28 do CPP. Se este concordar com os argumentos do magistrado, deve oferecer denúncia ou indicar membro do MP para fazê-lo em seu nome. Caso o Procurador-Geral concorde com as razões do promotor de justiça que requereu o arquivamento, deverá o magistrado mandar arquivar o feito. Abaixo, a previsão legal antes da Lei Anticrime:

Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.



Se o crime for praticado por investigado que detém foro por prerrogativa de função no STF, o pedido de arquivamento manejado pelo Procurador-Geral da República deve ser aceito pelo relator (nos termos do artigo 21, XV, do Regimento Interno do STF), uma vez que é inviável a aplicação do artigo 28 do CPP (STF, Tribunal Pleno. Inq 2028). Idêntico entendimento é adotado pelo STJ quando há pedido de arquivamento pelo Ministério Público que atua naquele órgão, em relação a inquérito que apure crime supostamente praticado por detentor de foro no STJ (STJ, QO no Inq 1041/DF). É o que a doutrina chama de arquivamento originário.

### 16.3. MOTIVOS DO ARQUIVAMENTO (ARTIGOS 395 E 397, CPP)

As hipóteses de arquivamento não foram expressamente disciplinadas pelo CPP. Deve-se aplicar o art. 395 para suprir a omissão, que traz as hipóteses de rejeição de denúncia ou queixa-crime pelo juiz. Com a reforma do CPP (Lei nº 11.719/08), passou-se, ainda, a admitir o julgamento antecipado da lide (art. 397 do CPP). As hipóteses que implicam na absolvição sumária, se já presentes e cabalmente demonstradas, também podem ser invocadas para lastrear o pedido de arquivamento.

Hipóteses em que o arquivamento faz coisa julgada FORMAL – podem ser desarquivados caso surjam novas provas:

- insuficiência de provas;
- ausência de pressuposto processual;
- ausência de condições da ação;
- falta de justa causa para a ação penal.

Hipóteses em que o arquivamento faz coisa julgada MATERIAL. A matéria não pode ser rediscutida não cabendo desarquivamento:

- atipicidade;
- existência manifesta de excludente de punibilidade (STJ. HC 307.562/RS). (Exceção: certidão de óbito falsa);
- existência manifesta de causas de excludente de culpabilidade.

A coisa julgada formal é endoprocessual porque envolve apenas a imutabilidade da decisão dentro do processo no qual ela foi exarada. Surgindo novas provas, o inquérito policial poderá ser desarquivado e a matéria rediscutida. Por sua vez, a coisa julgada material pressupõe a formal, mas sua imutabilidade vai além do processo no qual ela foi exarada, não podendo ser modificada em nenhum outro processo. Isto é, a matéria não poderá ser rediscutida.

**Atenção:** no que tange ao arquivamento de inquérito policial em face do reconhecimento de causa excludente de ilicitude, há divergência jurisprudencial.

Para o STJ, faz coisa julgada material e impede a rediscussão do caso penal. O mencionado art. 18 do CPP e a Súmula nº 524 do STF realmente permitem o desarquivamento do inquérito caso surjam provas novas. No entanto, essa possibilidade só existe na hipótese em que o arquivamento ocorreu por outras circunstâncias (STJ. RHC 46.666/MS, Informativo 554).

Para o STF, o arquivamento de inquérito policial em razão do reconhecimento de excludente de ilicitude não faz coisa julgada material. Logo, surgindo novas provas, é possível reabrir o inquérito policial, com base no art. 18 do CPP e na Súmula nº 524 do STF. (STF. 1ª Turma. HC 95211 Informativo 796). O arquivamento de inquérito policial por excludente de ilicitude realizado com base em provas fraudadas não faz coisa julgada material. (STF. Plenário. HC 87395/PR - Informativo 858.)

### 16.4. DESARQUIVAMENTO: ART. 18, CPP; SÚMULA Nº 524, STF

É possível que o delegado de polícia continue a apurar o caso, se tiver notícia de outros elementos de prova, na forma do artigo 18 do CPP. Importante destacar, ainda, que depois de





arquivado o inquérito policial, eventual ação penal só pode ser iniciada após a colheita de novas provas – inteligência da Súmula nº 524 do STF.

Art. 18 do CPP: depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.

Súmula nº 524, STF: arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas.

Caso a decisão de arquivamento faça apenas coisa julgada formal, uma nova prova é capaz de permitir o desarquivamento do IP. Para isso, é necessário que essa prova satisfaça dois requisitos:

Prova substancialmente nova: capaz de alterar o convencimento formado pelo magistrado e pelo promotor de justiça;

Prova formalmente nova: a prova não estava no IP, pois era desconhecida pelas autoridades.

Parte da doutrina sustenta que bastaria um desses dois requisitos para desarquivar.

### 16.5. IRRETRATABILIDADE DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO

Tendo o *Parquet* expressamente se manifestado pela ausência de elementos para denunciar, resta superada a possibilidade de que outro membro do MP, com base nos mesmos elementos de prova, proponha a ação penal, sob pena de afronta aos princípios institucionais da unidade e independência funcional:

De acordo com o entendimento manifestado por este STJ e pelo STF, o pedido de arquivamento de IP não é passível de revisão ou reconsideração sem que comprovada a existência de novos elementos probatórios, sendo vedado o reconhecimento de retratação em virtude do oferecimento da denúncia (STJ; REsp 1543202/SC).

### 16.6. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO

Ocorre quando o MP não menciona na denúncia um dos autores do fato delituoso ou um fato delituoso cometido pelos investigados. Quando o MP recebe os autos do inquérito policial pode tomar classicamente quatro caminhos:

- a) denunciar (art. 41 do CPP);
- b) requisitar novas diligências ao aparelho policial (art. 16 do CPP);
- c) declinar de sua atribuição e manifestar pelo declínio da competência pelo juízo;
- d) promover o arquivamento do inquérito policial.

Caso o MP decida denunciar alguns dos indiciados e não todos, pode-se entender que ele requereu o arquivamento (ainda que implicitamente/tacitamente) do procedimento investigatório em relação aos que deixaram de ser denunciados (arquivamento implícito subjetivo). Caso ele opte por denunciar o indiciado apenas por parte dos crimes a ele imputados pelo delegado de polícia, pode-se entender que ele requereu o arquivamento (ainda que implicitamente/tacitamente) dos fatos criminosos que ficaram fora da inicial acusatória (arquivamento implícito objetivo).

A jurisprudência não considera possível o arquivamento implícito, conforme HC 95344/RJ do STJ:

O não oferecimento imediato da denúncia com relação ao paciente não implica na renúncia tácita ao *jus puniendi* estatal, pois o princípio da indivisibilidade não é aplicável à

ação penal pública incondicionada, diferentemente da ação penal privada. Segundo o ordenamento jurídico pátrio, o arquivamento da ação penal pública depende de pedido expresso do Ministério Público, e somente pode ser determinado pelo juiz.

Na mesma linha, RHC 34.223-SP do STJ:

O MP não está obrigado a denunciar todos os envolvidos no fato tido por delituoso, não se podendo falar em arquivamento implícito em relação a quem não foi denunciado. Isso porque o *parquet* é livre para formar sua convicção, incluindo na denúncia as pessoas que ele entenda terem praticado o crime, mediante a constatação de indícios de autoria e materialidade.

Em caso de omissão, a melhor solução é que o juiz abra vista dos autos ao MP para que este se manifeste expressamente acerca da sua intenção de arquivar o procedimento investigativo em face dos investigados ou fatos omitidos.

### 16.7. ARQUIVAMENTO INDIRETO

Por vezes, ao invés de requerer o arquivamento ou retorno dos autos à polícia para novas diligências, o MP se manifesta no sentido da incompetência do juízo perante o qual oficia, recusando, portanto, sua atribuição para a apreciação do fato investigado. Assim agindo o MP não emitirá juízo de valoração sobre o fato, requerendo a declinação da competência para posterior remessa dos autos ao juízo competente. Abrem-se duas hipóteses:

- a) o juiz declina sua competência e assim não há qualquer problema a ser solucionado; ou
- b) não concorda – afirmando sua competência – e aí a solução apresenta certa complexidade.

O juiz não pode obrigar o MP a oferecer denúncia e, também, não ocorre na espécie a exceção de incompetência. Nesse caso, o conflito se dá entre o MP e um órgão da Jurisdição.

Sobre esse tema, o STF elaborou construção teórica possibilitando o controle do conflito, em segunda instância, entre os posicionamentos divergentes. Assim, pensou no arquivamento indireto, diante do qual o não oferecimento de denúncia pelo MP, ainda que fundado em razões de incompetência jurisdicional, e não na inexistência de crime, deveria receber tal manifestação como se de um arquivamento se tratasse e, portanto, deveriam os autos serem encaminhados para o órgão de controle revisional do respectivo Ministério Público (art. 28 do CPP).

Assim, o juiz que se julga competente fica vinculado à decisão da última instância do *Parquet*, e tal espécie de situação levou o nome de arquivamento indireto.

### 16.8. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO

Nestor Távora traz essa denominação ao arquivamento realizado pelo MP nos casos de ação penal pública condicionada à representação da vítima, quando a condição de procedibilidade não for realizada. Quando a vítima decair no direito de representar, o arquivamento provisório se tornará definitivo. Se, no entanto, ela oferecer representação dentro do prazo, poderá desarquivar o inquérito policial.

### 16.9. RECURSO CONTRA DECISÃO JUDICIAL DE ARQUIVAMENTO?

Em regra, não cabe recurso. Exceções apontadas pela doutrina:

Nos crimes contra a economia popular ou contra a saúde pública, haverá recurso de ofício:



Art. 7º, Lei nº 1.521/51 - Os juízes recorrerão de ofício sempre que absolverem os acusados em processo por crime contra a economia popular ou contra a saúde pública, ou quando determinarem o arquivamento dos autos do respectivo inquérito policial.

Art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 1.508/51 prevê o oferecimento de recurso em sentido estrito contra a decisão de arquivamento da representação dirigida por qualquer do povo ao MP nas contravenções penais do jogo do bicho e de aposta de corrida de cavalos fora do hipódromo (art. 58 e 60 do Decreto-Lei nº 6.259/44), embora a doutrina afirme que tal dispositivo não foi recepcionado pela CF/88, já que, em sendo a ação privativa do MP, requerendo o membro do MP o arquivamento, não haveria possibilidade de que terceira pessoa recorresse:

Art. 6º Quando qualquer do povo provocar a iniciativa do Ministério Público, nos termos do Art. 27 do Código do Processo Penal, para o processo tratado nesta lei, a representação, depois do registro pelo distribuidor do juízo, será por este enviada, *incontinenti*, ao Promotor Público, para os fins legais.

Parágrafo único. Se a representação for arquivada, poderá o seu autor interpor recurso no sentido estrito.

**Atenção:** no sistema atual, tendo em vista que o arquivamento não passa pelo crivo do controle judicial (art. 28, do CPP, modificado pela Lei Anticrime), não há que se falar em um recurso, muito menos de ofício, já que o arquivamento fica na estrutura do MP. Esse é o problema de uma reforma parcial e não uma reforma global do sistema, mas dá para argumentar que essas previsões estão revogadas tacitamente, porque não é possível passar pelo crivo judicial se o arquivamento permanece dentro do órgão de acusação, em consonância com a estrutura acusatória trazida expressamente pelo Pacote Anticrime.

#### 16.10. A VÍTIMA DE CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA NÃO TEM DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE IMPEDIR O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO OU PEÇAS DE INFORMAÇÃO

A vítima de crime de ação penal pública incondicionada não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento do inquérito ou peças de informação. Em regra, não há ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, passível de correção via mandado de segurança, na decisão judicial que, acolhendo promoção do Ministério Público, determina o arquivamento de inquérito policial. A norma inserta no art. 28 do Código de Processo Penal concede ao Juiz a prerrogativa de, considerando os elementos trazidos nos autos de inquérito ou nas peças de informações, anuir ou discordar do pedido de arquivamento formulado pelo órgão ministerial, não sendo cabível, em caso de concordância, a prévia submissão do pedido ao Procurador-Geral (STJ, MS 21.081/DF).

#### 16.11. COMENTÁRIOS À ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.964/19 NO ART. 28 DO CPP

| ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL                         |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTES DA LEI 13964/19                                      | DEPOIS DA LEI 13964/19                                                                                 |
| MP requeria o arquivamento ao juiz, que homologava ou não. | MP ordena o arquivamento e remete os autos à instância de revisão ministerial para fins de homologação |
| Arquivamento realizado na justiça                          | Arquivamento realizado no âmbito do MP                                                                 |

Artigo trazido pelo Pacote Anticrime:



Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

A Lei Anticrime dá nova redação ao art. 28, do CPP, para adequá-lo ao sistema acusatório, abolindo o controle judicial sobre a decisão de arquivamento do inquérito policial relativo à ação penal pública.

Houve mudança relevante no artigo 28 do CPP. O antigo dispositivo legal é bastante criticado pela doutrina, tendo em vista que o Ministério Público, titular da ação penal, apenas faz o “pedido” de arquivamento para o juiz de primeiro grau, que analisa a manifestação podendo, caso concorde, homologar, ou, em caso de discordância, remeter o caso para a apreciação do Procurador-Geral de Justiça, (como se fosse um recurso), chefe do respectivo Ministério Público Estadual. Essa previsão legal é criticada pela doutrina em razão de demonstrar um ativismo judicial característico de uma estrutura inquisitória que não é compatível com a Constituição Federal.

Com a reforma, muda o procedimento, indo ao encontro da disposição Constitucional do artigo 129 de que o Ministério Público é o titular e protagonista da ação penal pública. Agora não se pede mais para que o juiz analise a manifestação, não havendo como o juiz insistir na continuidade da persecução penal. É evidente a contaminação do juiz que, desde o início, manifesta a sua intenção de ver o suposto autor do fato processado na medida em que não concorda com o arquivamento.

Se o Ministério Público entender não ser o caso de oferecimento de denúncia e sim de arquivamento, não irá encaminhar ao juiz das garantias para análise, mas sim irá de imediato arquivar o procedimento que só será efetivamente extinto após a revisão obrigatória da instância superior da própria instituição ministerial (instância superior e colegiada).

Ponto importante da nova previsão do artigo 28 se refere à inclusão da vítima nesse processo de arquivamento dos autos. Naquele que obviamente tenha uma vítima definida/determinada. Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

Esse ponto é realmente positivo, pois, na sistemática anterior, a vítima não tinha fala, não podia se manifestar nem se indignar nos autos quanto à promoção e homologação do arquivamento. A jurisprudência era reiterada nesse sentido, inclusive pela impossibilidade do manejo da ação autônoma de impugnação do mandado de segurança em razão da ausência de direito líquido e certo. Permitindo que a vítima participe do processo, é dado um ar mais democrático à posição tomada pelo Ministério Público.

Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial, representando, portanto, a vítima entidade pública.

No atual sistema, se não for acolhido o pedido de arquivamento pela instância revisora na estrutura ministerial, então será designado outro membro para o oferecimento da denúncia, até porque os promotores possuem, dentre as suas prerrogativas, a independência funcional com sede constitucional.

Outro ponto relevante é perceber que, sem nenhuma intervenção do juiz, os autos deverão permanecer dentro da própria estrutura do Ministério Público. O Juiz das garantias terá, claro, atuação na fase investigativa, mas não para intervir no procedimento de arquivamento ou continuidade da investigação. Ele terá papel relevante para receber a comunicação da instauração da investigação, controlar o prazo de duração desta, verificar se possui elementos mínimos de controle, podendo inclusive conceder *habeas corpus* de ofício, dentre outras atividades. No entanto, no que se refere ao arquivamento, apenas deverá ser comunicado de que ele ocorreu, não podendo a autoridade judicial se imiscuir nessa atividade.

Em resumo, a abolição do controle judicial tem as seguintes implicações que o leitor deve estar atento:

- 1) o arquivamento do inquérito será feito pelo próprio Ministério Público, sem mediação judicial;
- 2) também o desarquivamento do inquérito caberá ao MP, sem intervenção judicial;
- 3) o controle da legalidade do ato caberá ao próprio MP, cuja instância de revisão homologará ou não a decisão de arquivamento;
- 4) o inquérito policial tramitará diretamente entre a Polícia e o MP;
- 5) o juiz das garantias só será provocado nos casos previstos em lei (art. 3º-B do CPP), aí incluída a prorrogação de prazo do inquérito quando o investigado estiver preso (art. 3º-B, VIII).

## 17. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL

Como vimos acima, o arquivamento não pode ser feito pelo Poder Judiciário de ofício, mas apenas pelo Ministério Público. Isso não significa que determinada investigação continuará a todo custo, uma vez que poderá ocorrer situações em que o Poder Judiciário decreta a extinção prematura das investigações reconhecendo que a manutenção acarreta constrangimento ilegal. É uma medida excepcional que pode ocorrer por provocação do investigado, de terceiros ou mesmo de ofício pelo magistrado.

A Lei Anticrime, ao regulamentar o juiz das garantias, passou a prever que essa concessão de *habeas corpus* para trancamento excepcional de uma investigação é da sua competência:

Art. 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente:

(...)

XII - julgar o *habeas corpus* impetrado antes do oferecimento da denúncia;

A regra, portanto, é a utilização do *habeas corpus* como forma de impugnação. No entanto, quando não houver risco à liberdade de locomoção aplica-se, de maneira supletiva, a ação autônoma do mandado de segurança. Esse entendimento pode ser extraído do seguinte enunciado:

Súmula nº 693 do STF: Não cabe *habeas corpus* contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada.



Exemplos de hipóteses de trancamento de IP:

- manifesta atipicidade;
- causa extintiva de punibilidade;
- IP instaurado sem representação ou requerimento (privada – pública condicionada);
- ausência de justa causa.

## 18. INDICIAMENTO

O indiciamento é a indicação do autor da infração colocado em evidência em ato formal da autoridade policial, é a cientificação ao suspeito de que ele passou a ser o principal foco da investigação (TÁVORA, 2020, p. 114). Indiciado é a pessoa eleita pelo Estado-investigação, dentro da sua convicção, como autora da infração penal (NUCCI, 2015, p. 140). O ato deve ser emanado de forma séria por despacho devidamente fundamentado ou no bojo do relatório final. É, assim, um ato posterior ao estado de suspeito e está baseado em um juízo de probabilidade e não de mera possibilidade. Só pode ser realizado quando existirem indícios razoáveis de probabilidade da autoria e não como um ato automático e irresponsável da autoridade policial (LOPES JR., 2013, p. 432). Deve haver um lastro mínimo de prova vinculando o suspeito à prática delitiva. É o que prescreve o § 6º, do artigo 2º, da Lei nº 12.830/13:

“Art. 2º. § 6º O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.”

Pode ser classificado como direto ou indireto. O direto é o indiciamento presencial, em que o investigado toma ciência de que está sendo indiciado e é interrogado acerca dos fatos pela autoridade policial; e o indireto é o levado a efeito sem a presença do indiciado (SILVA, 2020, p. 59).

A atribuição para efetuar o indiciamento é privativa da autoridade policial (Lei nº 12.830/13, art. 2º, § 6º), não sendo possível que o juiz, o MP ou uma CPI requisitem ao delegado de polícia o indiciamento de determinada pessoa. STF. 2ª Turma. HC 115015/SP, rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 27/8/2013.

A condição de indiciado poderá ser atribuída já no APF ou até mesmo no relatório final do delegado de polícia. Os Tribunais superiores têm considerado que o indiciamento formal, após o recebimento da denúncia, é causa de ilegal e desnecessário constrangimento à liberdade de locomoção, visto que não se justifica mais tal procedimento, própria da fase inquisitorial. STJ: HC 182.455/SP; HC 179.951/SP; HC 174.576/SP.

Há possibilidade de desindiciamento, caso a autoridade policial perceba que o ato de indiciamento foi praticado calcado em elementos que cedeu diante da colheita de outros mais robustos. Ao verificar o equívoco, deve realizar o desindiciamento por meio de despacho fundamentado com expedição de ofício ao instituto de identificação para que seja desconsiderada a anotação de indiciamento anterior (SILVA, 2020, p. 63).

**Atenção:** o STF reviu sua jurisprudência a respeito de competência por prerrogativa de função e passou a afirmar, em linhas gerais, que somente se aplica aos crimes cometidos: a) durante o exercício do cargo, e b) a ele relacionados (STF, AP 937 QO). Esse tema será estudado em detalhes em capítulo específico. Vamos imaginar que um crime seja praticado por um Senador com incidência dessa prerrogativa de função – preenchidos os requisitos. Nesses casos, haverá necessidade de autorização e supervisão judicial do STF para a investigação e, também, para a realização do indiciamento (STF, HC 133.835/MC - Informativo 825).

**Atenção:** existem duas autoridades que não podem ser indiciadas em razão de previsão expressa na lei que rege a carreira. É o caso dos magistrados (art.33, parágrafo único, da LC nº 35/79)



e membros do Ministério Público (art. 18, parágrafo único, da LC nº 75/73; e art. 40, parágrafo único, da Lei nº 8.625/93 (STF, HC 133.835/MC – Informativo 825).

## 19. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA

### 19.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SÚMULA VINCULANTE Nº 14: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

SÚMULA Nº 397, STF: “O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, consoante o regimento, a prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito.”

SÚMULA Nº 524, STF: “Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas.”

Informativo nº 714, STF: Denúncia (ação penal) formulada com base em inquérito civil . É possível o oferecimento de ação penal (denúncia) com base em provas colhidas no âmbito de inquérito civil conduzido por membro do Ministério Público. STF. Plenário. AP 565/RO, rel. Min. Cármen Lúcia, 7 e 8/8/2013. Esse é também o entendimento do STJ : (...) 3. O inquérito civil público, previsto como função institucional do Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição de República, pode ser utilizado como elemento probatório hábil a embasar a propositura de ação penal. 4. Muito embora não possa o membro do *Parquet* presidir o inquérito policial , é conferido , ao Ministério Público, o poder de investigar , como já fora decidido em *habeas corpus* julgados pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Quinta Turma. (...) (HC 179.223/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 20/8/2013) (...) Mostra-se cabível o oferecimento de denúncia com escólio em inquérito civil público. (APn.530/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 17/4/2013.)

Informativo nº 785, STF: O STF reconhece a legitimidade do MP para promover, por autoridade própria, investigações de natureza penal, mas ressaltou que essa investigação deverá respeitar alguns parâmetros que podem ser a seguir listados:

- 1) devem ser respeitados os direitos e garantias fundamentais dos investigados;
- 2) os atos investigatórios devem ser necessariamente documentados e praticados por membros do MP;
- 3) devem ser observadas as hipóteses de reversa constitucional de jurisdição, ou seja, determinadas as diligências somente podem ser autorizadas pelo Poder Judiciário nos casos em que a CF/88 assim exigir (ex.: interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário etc.)
- 4) devem ser respeitadas as prerrogativas profissionais asseguradas por lei aos advogados;
- 5) deve ser assegurada a garantia prevista na Súmula Vinculante nº 14 do STF;
- 6) a investigação deve ser realizada dentro de prazo razoável;
- 7) os atos de investigação conduzidos pelo MP estão sujeitos ao permanente controle do Poder Judiciário.

A tese fixada em repercussão geral foi a seguinte:

o MP dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reversa constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso país, os advogados (LEI 8.906/1994, ART. 7º, NOTADAMENTE OS INCISOS I, II, III, XI, XIII, XIV E XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado Democrático de Direito – do



permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (enunciado 14 da Súmula Vinculante), praticados pelos membros dessa instituição.

Adoção da teoria dos poderes implícitos: se a Constituição outorga determinada atividade-fim a um órgão, significa dizer que também concede todos os meios necessários para a realização dessa atribuição.

A CF/88 confere ao MP as funções de promover a ação penal pública (art. 129, I, CF/88). Logo, ela atribui ao *Parquet* também todos os meios necessários para o oferecimento da peça inicial acusatória, dentre eles a possibilidade de reunir provas para que fundamentem a acusação. Ademais, a CF/88 não conferiu à Polícia o monopólio da atribuição de investigar crimes. Em outras palavras, a colheita de provas não é atividade exclusiva da Polícia. Esse é o entendimento do STF e do STJ.

Além da teoria dos poderes implícitos, podemos citar outros dispositivos constitucionais que autorizam, de forma implícita, o poder de investigação do MP: art. 129, I, IV, VII, VIII, IX, CF/88.

A LC nº 75/1993, também de forma implícita, autoriza a realização de atos de investigação: art. 8º, I, V, VII. Esse entendimento foi reafirmado agora pelo Plenário do STF no julgamento do RE 593727, submetido à repercussão geral. Além disso, no Informativo nº 787, o STF reafirmou esse entendimento.

Informativo nº 815, STF: Compartilhamento no inquérito civil das provas colhidas em investigação criminal mesmo que acobertadas pelo sigilo. É possível compartilhar as provas colhidas em sede de investigação criminal para serem utilizadas, como prova emprestada, em inquérito civil público e em outras ações decorrentes do fato investigado. Esse empréstimo é permitido mesmo que as provas tenham sido obtidas por meio do afastamento ("quebra") judicial dos sigilos financeiro, fiscal e telefônico. STF. 1ª Turma. Inq 3305 AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 23/2/2016 (Info 815).

Informativo nº 824, STF: A suspeição de autoridade policial não é motivo de nulidade do processo, pois o inquérito é mera peça informativa, de que se serve o Ministério Público para o início da ação penal. Assim, é inviável a anulação do processo penal por alegação de irregularidade no inquérito, pois, segundo a jurisprudência firmada no STF, as nulidades processuais estão relacionadas apenas a defeitos de ordem jurídica pelos quais são afetados os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. STF. 2ª Turma. RHC 131450/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 3/5/2016 (Info 824).

Informativo nº 906, STF: O CPP, ao tratar sobre a condução coercitiva, prevê o seguinte: art. 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. O STF declarou que a expressão "para o interrogatório" prevista no art. 260 do CPP não foi recepcionada pela Constituição Federal. Assim, não se pode fazer a condução coercitiva do investigado ou réu com o objetivo de submetê-lo ao interrogatório sobre os fatos. STF. Plenário. ADPF 395/DF e ADPF 444/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 13 e 14/6/2018 (Info 906).

Informativo nº 933, STF: Não é necessária a intimação prévia da defesa técnica do investigado para a tomada de depoimentos orais na fase de inquérito policial: **não haverá nulidade dos atos processuais caso essa intimação não ocorra. O inquérito policial é um procedimento informativo, de natureza inquisitorial, destinado precipuamente à formação da *opinio delicti* do órgão acusatório. Logo, no inquérito há uma regular mitigação das garantias do contraditório e da ampla defesa. Esse entendimento justifica-se porque os elementos de informação colhidos no inquérito não se prestam, por si sós, a fundamentar uma condenação criminal. A Lei nº 13.245/2016 implicou um reforço das prerrogativas da defesa técnica, sem, contudo, conferir ao advogado o direito subjetivo de intimação prévia e tempestiva do calendário de inquirições a ser definido pela autoridade policial.** STF. 2ª Turma. Pet 7612/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12/3/2019 (Info 933).

A suspeição de autoridade policial não é motivo de nulidade do processo, pois o inquérito é mera peça informativa, de que se serve o Ministério Público para o início da ação penal: **RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA E NULIDADE DAS PROVAS: IMPROCEDÊNCIA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.** 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o não exaurimento da jurisdição nas instâncias antecedentes, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao *habeas corpus*, configura óbice ao conhecimento das ações e recursos posteriores, por inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a suspeição de autoridade policial não é motivo de nulidade do processo, pois o inquérito é mera peça informativa, de que se serve o Ministério Público para o início da ação penal. Precedentes. 3. É inviável anulação do processo penal por alegada irregularidade no inquérito, pois, segundo jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal, as nulidades processuais concernem tão somente aos defeitos de ordem jurídica pelos quais afetados os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. Precedentes. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 131450, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 3/5/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16/5/2016 PUBLIC 17/5/2016.)

## 19.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Súmula nº 234, STJ: “A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta seu impedimento ou suspeição para o oferecimento de denúncia.”

Súmula nº 444, STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

É possível a deflagração de investigação criminal com base em matéria jornalística: PROCESSO PENAL. RECURSO EM *HABEAS CORPUS*. GESTÃO FRAUDULENTA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA *RATIONE LOCI*. NÃO OCORRÊNCIA. ATOS DE GESTÃO. ATOS DECISÓRIOS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DO SUPOSTO DETENTOR DO FORO COMO TESTEMUNHA E NÃO COMO INVESTIGADO. INVESTIGAÇÃO DEFLAGRADA COM BASE EM *NOTITIA CRIMINIS* DE COGNIÇÃO IMEDIATA. NOTÍCIA VEICULADA EM IMPRENSA. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. POSSIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 8. É possível que a investigação criminal seja perscrutada pautando-se pelas atividades diurnas da autoridade policial, *verbi gratia*, o conhecimento da prática de determinada conduta delitiva a partir de veículo midiático, no caso, a imprensa. É o que se convencionou a denominar, em doutrina, de *notitia criminis* de cognição imediata (ou espontânea), terminologia obtida a partir da exegese do art. 5º, inciso I, do CPP, do qual se extrai que “nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado de ofício”. 9. *In casu*, “uma reportagem jornalística pode ter o condão de provocar a autoridade encarregada da investigação, a qual, no desempenho das funções inerentes a seu cargo, tendo notícia de crime de ação penal pública incondicionada, deve agir inclusive *ex officio* (a litude das provas apresentadas na reportagem não é tema que possa, no escopo exíguo de cognição do writ, ser aferida com mínima segurança, não sendo ocioso lembrar o sigilo da fonte, constitucionalmente assegurado)”, sem olvidar a “farta documentação que foi acostada pela autoridade policial e pelo próprio Parquet Federal”. 10. Recurso desprovido. (RHC 98.056/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2019, DJe 21/6/2019.)

## QUESTÕES



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



**1- (2019/VUNESP/TJSP/Juiz Substituto)** Nos literais e expressos termos do art. 13 do CPP, incumbe à autoridade policial, entre outras funções:

- a) providenciar o comparecimento do acusado preso, em Juízo, mediante prévia requisição.
- b) manter a guarda de bens apreendidos e objetos do crime até o trânsito em julgado da ação penal.
- c) fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos.
- d) cumprir as ordens de busca e apreensão e demais decisões cautelares que tenha requisitado.
- e) servir como testemunha em ações penais quando arrolada por qualquer das partes.

**2- (2015/MPE-SP/Promotor de Justiça)** Assinale a alternativa correta:

- a) O Tribunal está obrigado a acolher a manifestação de arquivamento de investigação criminal formulada pelo Procurador-geral de Justiça, na hipótese de competência originária.
- b) Na solução do conflito de atribuições entre órgãos do Ministério Público, tendo por objeto o foro competente para a propositura de virtual ação penal, o Procurador-geral de Justiça deverá designar outro Promotor de Justiça para atuar no feito e, dessa forma, preservar a independência funcional do vencido.
- c) A promoção de arquivamento do inquérito, apresentada no prazo legal, não impede a propositura da ação penal privada subsidiária à pública (CPP, artigo 29).
- d) A possibilidade de se produzirem novas provas autoriza o desarquivamento do inquérito policial pelo Ministério Público.
- e) O arquivamento do inquérito, pautado na atipicidade do fato, não impede o seu desarquivamento, desde que sejam produzidas novas provas.

**3- (2018/FCC/DPE-PE/Defensor Público)** Em razão de mandados expedidos por juiz competente, foram realizadas providências cautelares de interceptação telefônica e busca domiciliar na residência de Marcos para a obtenção de provas de crime de tráfico ilícito de entorpecentes a ele imputado e objeto de investigação em inquérito policial. Nessa situação, durante o procedimento investigatório, o advogado de Marcos

- a) terá direito de acessar os relatórios e as demais diligências da interceptação telefônica ainda em andamento.
- b) terá direito de acessar os relatórios de cumprimento dos mandados de busca e apreensão e os respectivos autos de apreensão.
- c) estará impedido de acessar os laudos periciais incorporados aos procedimentos de investigação.
- d) terá direito de acessar previamente documentos referentes às diligências do inquérito, inclusive os de cumprimento do mandado de busca e apreensão.
- e) estará impedido de acessar os autos de apresentação e apreensão já lavrados.

**4- (2018/CESPE/PC-MA/Delegado de Polícia Civil)** De acordo com as legislações especiais pertinentes, o inquérito policial deve ser concluído no

- a) prazo comum de quinze dias, estando o indiciado solto ou preso, nos casos de crimes de tortura.
- b) mesmo prazo estipulado para a apreciação das medidas protetivas, nos casos de crimes previstos na Lei Maria da Penha.
- c) prazo comum de dez dias, estando o indiciado solto ou preso, nos casos de crimes contra a economia popular.
- d) prazo de trinta dias, se o indiciado estiver solto, e de quinze dias, se ele estiver preso, de acordo com a Lei de Drogas.
- e) prazo de quinze dias, se o crime for de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme o Estatuto do Desarmamento.

**5- (2017/MPE-SP/MPE-SP/promotor de justiça substituto)** Assinale a alternativa correta.

- a) O inquérito policial, por ser peça informativa, é dispensável para a propositura da ação penal, mas sempre acompanhará a inicial acusatória quando servir de base para a denúncia ou a queixa.
- b) A autoridade policial poderá, a seu critério e em qualquer hipótese, nos termos do artigo 7º do Código de Processo Penal, determinar a reprodução simulada dos fatos com as participações obrigatórias do indiciado e do ofendido.
- c) Os elementos informativos do inquérito policial servem de base para o oferecimento da denúncia, mas não podem ser considerados para o reconhecimento da procedência ou não da ação penal.
- d) O arquivamento do inquérito policial se dá por decisão judicial e impede que a autoridade policial, de ofício, proceda a novas investigações.
- e) Nos crimes que dependem de representação, a autoridade policial só poderá instaurar inquérito policial em razão de iniciativa formal do ofendido, seu representante legal ou de procurador com poderes especiais.

**6- (2017/CESPE/PC-MT/delegado de polícia substituto)** O inquérito policial instaurado por delegado de polícia para investigar determinado crime

- a) não poderá ser avogado, nem mesmo por superior hierárquico.
- b) poderá ser avogado por superior hierárquico somente no caso de não cumprimento de algum procedimento regulamentar da corporação.
- c) poderá ser redistribuído por superior hierárquico, devido a motivo de interesse público.
- d) poderá ser avogado por superior hierárquico, independentemente de fundamentação em despacho.
- e) não poderá ser redistribuído, nem mesmo por superior hierárquico.

**7- (2017/FCC/DPE-RS/analista processual)** No tocante ao inquérito policial relativo à apuração de crime a que se procede mediante ação penal pública incondicionada, é correto afirmar:

- a) É vedada a instauração de inquérito policial de ofício.
- b) O ofendido não pode requerer diligência no curso de inquérito policial.
- c) A autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito.
- d) A autoridade policial poderá mandar instaurar inquérito a partir de comunicação de fato feita por qualquer pessoa, mas deve aguardar a iniciativa do ofendido ou seu representante legal para que seja instaurado.
- e) Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.

**8- (2014/VUNESPE/Oficial de Justiça)** Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial

- a) dependerá de anuência do membro do Ministério Público responsável pelo caso para proceder a novas investigações.
- b) não poderá proceder a novas investigações sem expressa autorização judicial.
- c) poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.
- d) dependerá de autorização judicial para proceder a novas investigações.
- e) deverá proceder a novas investigações, independentemente do surgimento de novas provas.

## COMENTÁRIOS

1. Gabarito: C, conforme art. 13, CPP.

2. Gabarito: A

a)

PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO E QUEBRA DE SIGILO FISCAL. CRIME TRIBUTÁRIO MATERIAL. SÚMULA VINCULANTE 24/STF. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO. ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de pedido de instauração de inquérito e de quebra de sigilo fiscal para apurar supostas irregularidades nas declarações anuais de ajuste de imposto de renda de magistrados do TJ/BA, encontradas a partir de procedimento instaurado pela Corregedoria Nacional de Justiça. 2. Hipótese em que o requerimento ministerial não indicava qual seria o crime a ser investigado, mas apenas fazia referências a supostas irregularidades nas declarações de imposto de renda. O Ministério Público foi instado a especificar o crime a ser investigado e a manifestar-se acerca da existência de lançamento, caso se tratasse de crime tributário material. 3. Após realizar diligências investigatórias, requereu o *Parquet* o arquivamento, sob o argumento de que, nos termos da Súmula Vinculante 24 do STF, não poderia haver a investigação de crimes tributários, já que não há lançamento definitivo e inexistem indícios de outras infrações penais. 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, nesta instância especial, os membros do Ministério Público Federal atuam por delegação do Procurador-Geral da República, de sorte que não há falar em aplicação do art. 28 do CPP, por isso que, nos feitos de competência originária, o pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público é irrecusável. Precedentes do STF. Inquérito arquivado. Inq 967/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/3/2015, DJe 30/3/2015.



- b) O PGJ deverá apenas decidir qual o membro com atribuição no caso para este propor denúncia.
- c) Se o MP requereu o arquivamento, ele não foi inerte, logo, impossível a propositura da ação penal privada subsidiária da pública.
- d) Não é a possibilidade, mas o efetivo surgimento de provas novas que pode autorizar o desarquivamento, caso tenha ocorrido apenas coisa julgada formal.
- e) O arquivamento do inquérito, pautado na atipicidade do fato, impede o seu desarquivamento, já que faz coisa julgada material.

**3. Gabarito: B.** Em regra, a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. No que tange ao acesso pelo advogado, de acordo com a Súmula Vinculante nº 14: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter amplo acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão competente de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” Dessa forma, o defensor terá AMPLO acesso aos elementos constantes em procedimento investigatório e que já se encontrem DOCUMENTADOS nos autos, como é o caso da letra b.

**4. Gabarito: C**

- a) Crime de Tortura: crimes hediondos, tráfico de entorpecentes, tortura ou terrorismo, o prazo é de trinta dias, prorrogável por mais trinta.
- b) Lei Maria da Penha: as providências previstas no artigo 12 da “Lei Maria da Penha” servem de guia para a autoridade policial instruir o inquérito policial. Trata-se de artigo muito semelhante ao artigo 6º do Código de Processo Penal referente a todos os inquéritos policiais. Para a concessão das medidas protetivas de urgência, a lei faz apenas uma única exigência: que haja requerimento da vítima ou do Ministério Público (art. 19, Lei nº 11.340/2006), deixando bem claro que não é necessária a realização de uma audiência com as partes, ou seja, a medida pode ser determinada independentemente da prévia oitiva do suposto agressor. Nem mesmo o Ministério Público precisa ser ouvido na hipótese de a medida ter sido requerida pela vítima (art. 19, §1º) — Não especifica um prazo.
- c) Crimes contra a economia popular: 10 dias tanto para indiciado preso quanto para indiciado solto.
- d) Crimes da Lei de Drogas: 30 dias para indiciado preso e 90 dias para indiciado solto. Podem ser duplicados em ambos os casos.
- e) Artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Parágrafo único. “Consideram-se também hediondos o (...) de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito”, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, todos tentados ou consumados.

**5. Gabarito: A**

- a) Dentre as características do IP está a dispensabilidade. No entanto, caso ele tenha servido de base para a denúncia ou queixa-crime, irá acompanhar os autos, conforme art. 12. CPP — O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.
  - b) Conforme art. 7º do CPP: “Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a MORALIDADE ou a ORDEM PÚBLICA.” ALÉM DISSO, o indiciado NÃO ESTARÁ obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos, pois ele não é obrigado a se autoincriminar.
  - c) Conforme art. 12 do CPP: “O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.”
  - d) Conforme art. 18 do CPP: “Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.”
- Súmula nº 524, STF: “Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.”
- e) Conforme art. 24 do CPP: “Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Além disso, não há necessidade de representação formal.”

**6. Gabarito: C**



Lei nº 12.830/2013: art. 2º As funções de Polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. § 4º O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação.

**7. Gabarito: E**

- a) Não é vedada, pois essa é uma das formas de instauração do IP nos crimes de ação penal pública incondicionada, conforme art. 5º do CPP.
- b) Pode requerer, conforme se observa no art. 14 do CPP.
- c) A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito, conforme art. 17 do CPP.
- d) Nesse ponto ocorre uma contradição, pois, tendo em vista que o enunciado versa acerca da instauração do IP nos casos de ação penal pública incondicionada, não há o que se falar em condicionamentos.
- e) “Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.”

**8. Gabarito: C, conforme art. 18, CPP.**



## CAPÍTULO 7 – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP (ART. 28-A DO CPP)

### 1. CONCEITO E HISTÓRICO

O denominado Projeto Anticrime, transformado na Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, por meio de seu artigo 3º, acrescentou ao Código de Processo Penal (CPP) o art. 28-A, que trata do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

A referida lei abraça o instituto de justiça criminal negocial, ou consensual, que amplia as possibilidades, anteriormente existentes, de realização de acordo com as autoridades públicas – em especial o Ministério Público (MP) – antes de haver acusação formal em decorrência da prática de crimes.

O ANPP foi criado originalmente pela Resolução nº 181 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Essa resolução, por sua vez, foi alterada pela Resolução de nº 183, de 24 de janeiro de 2018, também editada por aquele órgão.

A criação do instituto por meio de resolução, contudo, foi objeto de Ações Diretas de Inconstitucionalidade movidas pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB (ADI 5790) e pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (ADI 5793). O motivo principal de irresignação era a violação ao princípio da reserva legal, uma vez que a criação do acordo em resolução extrapolava o poder regulamentar conferido ao CNMP, ferindo regras de competência para legislar sobre penal e processo penal. As ações argumentavam que não havia lei em sentido estrito que regulamentasse a matéria e, portanto, o CNMP teria usurpado a competência privativa da União para legislar sobre processo penal (art. 22, I, Constituição Federal). Agora, com a inserção do instituto no CPP, a crítica perdeu o fundamento.

A redação original da Resolução nº 181/2017 era objeto de outra crítica por parte da doutrina, uma vez que havia em seu bojo disposição atestando a desnecessidade de homologação judicial do acordo firmado entre o órgão acusatório e o investigado, devidamente acompanhado de seu defensor. Nesse cenário, segundo a crítica doutrinária, o acordo descumpria os princípios da reserva legal, imparcialidade, inafastabilidade da jurisdição e, ainda, a própria cláusula de reserva de jurisdição. A redação utilizada no CPP encerra essa discussão, uma vez que se prevê expressamente a homologação judicial do ajuste de vontades, incluindo, nas disposições, a hipótese do não-cumprimento das disposições firmadas, quando ocorrerá a rescisão judicial do acordo, conforme veremos.

Na época em que houve a edição das citadas resoluções, não se via possibilidade de aplicação prática do ANPP, tendo em vista o contexto de insegurança jurídica trazido pelos fatos explicados nos parágrafos anteriores. Em razão disso, era sensível o desestímulo dos membros do Ministério Público em relação à celebração do acordo previsto nas normas jurídicas editadas pelo CNMP. O Ministério Público de alguns Estados chegaram a editar atos normativos recomendando que seus membros não fimassem o ajuste negocial antes do julgamento das ADIs.

A reforma processual penal, com o advento da Lei nº 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), positivou a intenção contida na resolução do CNMP sobre o ANPP. Isso acarretou minguagem das críticas ao instituto e, por outro lado, novo estímulo para os membros do Ministério Público aplicarem a medida, agora prevista em lei ordinária.

A lei essencialmente repete a disposição do art. 18 da Resolução nº 181 do CNMP, e, da mesma forma que na transação penal do art. 76 da Lei nº 9.099/95, a maior parte da doutrina passa a admitir que é possível haver mitigação do princípio da obrigatoriedade, previsto no art. 24 do Código de Processo Penal (STF, RE 795.567/PR), em detrimento do entendimento de que sua aplicação seria uma excepcionalidade.

Com efeito, o referido princípio deve ser interpretado como verdadeiro dever de agir imposto ao Ministério Público, exercitado por meio de oferecimento de denúncia, privilegiando a visão clássica e tradicional do processo penal, seja por meio de ajuste de vontades, seguindo a corrente mais moderna do processo penal. Neste último caso, qualquer alegação de omissão, inércia



ou desídia do *Parquet* seria acertadamente afastada. É cristalino que o Ministério Público não pode conceder favores ilegítimos e, sem justa causa, abrir mão de dar uma resposta às investigações criminais que se encontram em seu poder, mas isso não significa que o único caminho possível ao Ministério Público é aquele em que há oferecimento de denúncia e, consequentemente, início do processo penal. O Ministério Público deve agir buscando a solução mais promissora para o nosso sistema de justiça a depender da política criminal adotada.

O ANPP, como já dito, tem natureza de negócio jurídico pré-processual estabelecido entre o Ministério Público (MP) e o investigado com seu defensor (§ 3º), a ser proposto nos casos em que há prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e que a lei comine pena mínima inferior a 4 anos, mediante o cumprimento de determinadas condições (incisos I a V), decretando-se, ao final, a extinção de punibilidade do agente (§ 13º) e, consequentemente, evitando a deflagração da ação penal e a caracterização de reincidência. O investigado, por sua vez, assume a prática da conduta típica a ele imputada, aceitando cumprir, desde logo, obrigações menos severas do que a sanção penal, em abstrato, prevista para a violação legal a ele imputada.

Mencionado instituto tem natureza despenalizadora. Visa evitar a judicialização do fato típico e possibilitar uma pacificação social mais célere por meio da pronta resposta estatal, reduzindo assim, a sensação de impunidade na sociedade, mas dentro dos critérios de razoabilidade e em observância aos princípios de subsidiariedade e fragmentariedade do Direito Penal. Tem por objetivo, ainda, otimizar o gasto de recursos públicos de forma a atender aos princípios da celeridade, da economicidade e da efetividade. Além disso, os autores de crimes menos graves têm a oportunidade de evitar os desgastes advindos do ato de responder a um processo, evitando que haja estigmatização social indesejada e cuja origem é encontrada em eventual condenação criminal, mas passa também pelo cumprimento de pena, terminando por macular a vida pregressa da pessoa. Busca-se, além de evitar os efeitos sociais da condenação penal, a facilitação da ressocialização da pessoa. Portanto, é inquestionável que o instituto traz significativos benefícios à administração da justiça e aos jurisdicionados.

A aplicação prática do instituto é amplíssima, visto que quase a totalidade dos crimes não violentos prevê aplicação de pena mínima em patamar inferior a 4 anos, tais como: receptação, estelionato, apropriação indébita, furto simples e qualificado, corrupção passiva e ativa, peculato. A pena máxima prevista pelo tipo penal é irrelevante para o oferecimento do acordo.

Quando cabível a transação penal, o acordo não é aplicável (art. 28-A, § 2º, I), pois o primeiro instituto está previsto para as infrações de menor potencial ofensivo, ou contravenções penais, e crimes punidos com pena máxima não superior a 2 anos, ou seja, de competência dos juizados especiais criminais.

A suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95) foi esvaziada, uma vez que o ANPP é muito mais amplo por já compreender as hipóteses que comportariam a suspensão condicional do processo, isto é: todos os crimes punidos com pena mínima igual ou inferior a um ano. De todo modo, os institutos exigem requisitos distintos, como a diferenciação na exigência da confissão formal e circunstanciada, o que ainda abre espaço para a aplicação da suspensão condicional do processo.

## 2. AÇÃO PENAL PRIVADA

Por ser um benefício legal, a doutrina e a jurisprudência devem caminhar no sentido de o ANPP ser aplicado a crimes de ação penal privada, cabendo ao querelante propor o acordo. Contudo, não há óbice para que o MP faça a oferta exercendo a função de *custos legis* (art. 257, II do CPP) e diante da recusa de proposta pelo particular.

A doutrina e a jurisprudência majoritárias já se manifestaram pela aplicação de transação penal e de suspensão condicional do processo para as infrações penais de ação penal privada (STJ, AgRg no REsp 1356229/PR). Nesse mesmo sentido, o enunciado de número 112 do FONAJE – Fórum Nacional de Juízes Estaduais:

Enunciado 112 FONAJE: “Na ação penal de iniciativa privada, cabem transação penal e a suspensão condicional do processo, mediante proposta do Ministério Público.”

No entanto, existe corrente contrária que afirma não ser possível, pelos seguintes argumentos:

A iniciativa do acordo, segundo a lei, será sempre do Ministério Público, não se admitindo nos crimes de ação penal de iniciativa privada. Além da falta de previsão legal (tal como ocorre na transação penal e na suspensão condicional do processo), ficaria sem solução a hipótese em que houvesse a recusa da vítima em fazer a proposta, pois nem o Juiz poderia fazê-lo de ofício (dispondo de uma ação penal em um processo de estrutura acusatória, o que é inadmissível), tampouco o MP, cuja legitimidade de atuação limita-se às ações penais públicas (art. 129, I, CF). Este entendimento pode ser objetado pelo fato de que haverá casos nos quais autores de crimes mais graves (de ação penal pública) poderão ser beneficiados com o acordo, ao contrário de agentes que praticaram crimes menos graves (de ação penal de iniciativa privada). Trata-se de um sólido argumento jurídico; mas, é preciso lembrar que as ações penais de iniciativa privada obedecem a outros princípios: veja-se, por exemplo, a possibilidade do perdão, da perempção, da renúncia e da decadência, incabíveis nos crimes de ação penal pública. É do sistema, portanto.<sup>3</sup>

### 3. DIREITO INTERTEMPORAL

Com o advento do ANPP, surgiram controvérsias doutrinárias a respeito da possibilidade de sua aplicação às ações penais em curso e mesmo aquelas que se encontrem em fase processual posterior à sentença de mérito, com ou sem trânsito em julgado.

É fundamental reconhecer a natureza híbrida ou mista do ANPP. Seu cumprimento, se levado à cabo, é considerado como causa extintiva da punibilidade, de acordo com o §3º, evidenciando a prevalência de sua característica penal, de retroatividade obrigatória em obediência à CF/88, por ser mais favorável aos investigados/réus.

O ANPP, sem dúvidas, abarca as investigações criminais até o recebimento da denúncia, isso em decorrência da expressão “investigado” utilizada pela lei. Depois do recebimento da denúncia, a simples distinção feita pela letra da lei ao utilizar “réu” e “investigado” não pode, à luz dos princípios da presunção de inocência e isonomia, impedir a celebração do acordo de não persecução penal para quem está na situação de “réu”, sob pena de adotar tratamento desigual para situações fáticas similares.

Dessa forma, a benesse de oferecimento de acordo deve alcançar também processos nos quais haja desclassificação da imputação, pois incide, analogicamente, a Súmula nº 337 do STJ – aplicável na transação penal e suspensão condicional do processo:

Súmula nº 337 do STJ: “É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.”

Pode se defender, inclusive, a aplicação do ANPP mesmo quando houver condenação transitada em julgado, por força do art. 66, I, da LEP; e Súmula nº 611 do STF, competindo, assim, ao Juízo de execução abrir vista ao órgão do MP com atribuição para o propor o ANPP:

Súmula nº 611 do STF: “Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna.”

<sup>3</sup><https://romulomoreira.jusbrasil.com.br/artigos/801099518/o-novo-acordo-de-nao-persecucao-penal>

Ressalta-se que a semelhança entre os aludidos institutos é referendada pela própria Lei nº 13.964/2019, uma vez que em primeiro ponto, há afirmação em seu bojo sobre não ser aplicável o Acordo de Não Persecução Penal quando cabível a Transação Penal e, em segundo ponto, ao prever a possibilidade de não oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo na hipótese de descumprimento do acordo de não persecução penal. Assim, *mutatis mutandis*, deve-se reconhecer ser, o novel instituto despenalizador, passível de aplicação até o momento processual que antecede a prolação de sentença penal condenatória, ou, nos termos do enunciado da Súmula nº 337 do STJ, mesmo após essa.

Atenção à doutrina MAZLOUM<sup>4</sup>:

Iniludível, pois, a natureza híbrida da norma que introduziu o acordo, trazendo em seu bojo carga de conteúdo material e processual. O âmbito de incidência das normas legais desse jaez, que consagram inequívoco programa estatal de despenalização, deve ter aplicação alargada nos moldes previstos no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal: “A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.” Nesta senda, entendemos incidir também aos processos criminais em curso, apanhados pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal. Cabe ao Estado, agora, abrir ao réu a oportunidade de ter sua punibilidade extinta mediante a proposição de acordo pelo Ministério Público e consequente cumprimento das condições convencionadas.

#### 4. PRESCRIÇÃO

A prescrição não tem incidência e, portanto, não é contada enquanto o ANPP não for cumprido ou rescindido, nos termos do art. 116, III, do CP. Trata-se de nova causa suspensiva ou impeditiva da prescrição trazida pela Lei nº 13.964/2019.

Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

#### 5. AÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS

O ANPP é também aplicável às investigações relativas a ações penais originárias, de competência dos tribunais, por força da inclusão do art. 1º, §3º, na Lei nº 8.038/90.

Art. 1º, § 3º Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 28-A do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

#### 6. PRESSUPOSTOS PARA O ANPP

Pela própria posição topográfica que se encontra no Código, incluído no “Título III – Da Ação Penal” e não no “Título II – Do Inquérito Policial”, a aplicação do ANPP é possível em qualquer outra investigação criminal, seja inquérito policial, seja procedimento investigatório criminal, seja outro.

---

<sup>4</sup> <https://www.conjur.com.br/2020-fev-07/opinioao-acordo-nao-persecucao-penal-aplicavel-aco-es-curso>



O ANPP exige os seguintes requisitos cumulativos, previstos no art. 28-A:

- a) que não seja caso de arquivamento da investigação;
- b) que o crime seja praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa;
- c) que o crime seja punido com pena mínima inferior a 4 anos;
- d) que haja confissão formal e circunstanciada;
- e) necessidade e suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime.

Passamos à análise de cada um deles.

**a) que não seja caso de arquivamento da investigação (justa causa: casos de denúncia, não de arquivamento):**

Não cabe o acordo se por qualquer motivo for caso de arquivamento da investigação criminal oficialmente instaurada e em curso. Faltando justa causa por ausência de suporte probatório mínimo para a denúncia, faltarão justa causa para o acordo. Afinal, o ANPP é uma alternativa à denúncia e não uma alternativa ao arquivamento.

Além disso, o acordo não será possível se, por exemplo, incidir excludentes de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade. Tampouco se aplicará se a punibilidade estiver extinta ou não houver elementos de prova suficientes para o oferecimento de denúncia ou, ainda, se a prova obtida for ilícita. Nem se admitirá o acordo quando for manifesta a insignificância jurídico-penal da conduta. Nesses casos, o Ministério Público deverá se manifestar pelo reconhecimento dessas causas com consequente arquivamento da investigação. O acordo será, portanto, alternativa apenas à denúncia.

**b) que o crime seja praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa:**

Somente os crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, e não à coisa, são excluídos pela lei, por exemplo, o roubo, o estupro e o homicídio doloso. Já os delitos cometidos com violência à coisa, a exemplo do furto qualificado com rompimento de obstáculo ou destruição da coisa, são passíveis do acordo.

Também será possível o acordo nos crimes culposos, visto que a violência não é intencional, como as lesões corporais culposas e o homicídio culposos. A violência que impede a celebração de acordo é aquela presente na conduta e não no resultado.

**c) que o crime seja punido com pena mínima inferior a 4 anos:**

Exige-se, para aplicação do instituto, delito cuja pena mínima seja inferior a 4 anos. Logo, se a pena for igual ou superior a 4 anos não caberá a celebração de acordo. Melhor seria se a lei dissesse: pena igual ou inferior a 4 anos, à semelhança da previsão do art. 89 da Lei nº 9.099/95, quando ela trata da suspensão condicional do processo, em que a redação prevê pena “igual ou inferior a 1 ano”.

Para a apuração da pena mínima cominada, devem ser consideradas as causas de aumento e de diminuição e, quando se tratar de percentual variável de aumento de pena (1/3 a 2/3), será acrescido o patamar mínimo previsto (no caso, 1/3), diminuindo-se o patamar máximo legal quando se tratar de causa de redução de pena (redução de 2/3, e não de 1/3, como no caso de crime tentado).

Em caso semelhante, na suspensão condicional do processo, assim decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

Em se tratando de crime tentado, deve ser considerada a menor pena cominada em abstrato para o delito, reduzida pela fração máxima prevista no art. 14, II, do Código Penal, isto é, de 2/3, o que possibilita a suspensão condicional do processo, na medida em que a pena mínima em abstrato, com a redução pela tentativa, é inferior a 1 ano. (STJ; HC 505.156; Proc. 2019/0111147-1; SP; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21/10/2019.)

Isso porque incide o seguinte enunciado, analogicamente:

Súmula nº 723 do STF: “Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a um ano.”

Desse modo, o tráfico de drogas na forma simples, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é incompatível com o instituto do ANPP por cominar pena mínima de 5 anos de reclusão. Entretanto, o instituto é cabível no caso de tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º da mesma lei.

É preciso ressaltar que há corrente defendendo a impossibilidade de aplicação do ANPP no tráfico de drogas privilegiado, sustentando que a confirmação da causa de diminuição somente se materializará em sede de sentença, após a devida investigação e instrução, pois será verificado se o agente realmente não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa. A corrente coloca como um dos argumentos para sua posição que o juiz das garantias, que homologará o acordo, não tem competência para analisar se o investigado se dedica, ou não, a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

Todavia, penso que quando o legislador incluiu o inciso II no §2º do artigo 28-A, impedindo a proposta de ANPP quando o juiz das garantias verificar que há elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, abriu brecha para que verifique se incide ao investigado a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 no momento de análise de viabilidade do acordo.

Em outros casos da Lei de Drogas, a exemplo dos previstos nos art. 34-35 e 37-39, não há dúvidas de que será admitido o acordo, semelhantemente à situação do porte de droga para consumo, prevista no art. 28.

Havendo concurso material de crimes na forma do art. 69 do Código Penal, as penas mínimas previstas devem ser somadas para fins de apuração de viabilidade e aplicação do ANPP. E, no concurso formal e na continuidade delitiva, previstos nos artigos 70 e 71 do Código Penal, para realizar a apuração de viabilidade de acordo deve-se acrescer à pena mínima, cominada em abstrato ao tipo penal, o aumento mínimo previsto em lei. Se da soma resultar pena mínima inferior a 4 anos, a aplicação do acordo é possível.

Nesse sentido, incide o seguinte enunciado, também por analogia:

Súmula nº 243 do STJ: O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano.

Se oferecida a denúncia, o juiz ou tribunal proceder à desclassificação para crime que admita o acordo, deverá abrir para a manifestação do Ministério Público a respeito do cabimento do acordo. A Súmula nº 337 do STJ é aplicável analogicamente à transação penal e ao ANPP:

Súmula nº 337 do STJ: É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Assim, não devem ser levadas em consideração agravantes ou atenuantes, pois são circunstâncias genéricas, cujo *quantum* não vem estabelecido pela norma penal.

**d) que haja confissão formal e circunstanciada:**

Somente o investigado que confessar o crime, formalmente e circunstanciadamente, fará jus ao benefício. A confissão é a admissão, no todo ou em parte, da imputação penal. Diz-se confissão simples quando o réu confessa o delito, sem mais. Qualificada é a confissão que vem acompanhada de alegação de excludentes de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade como quando, por exemplo, o investigado afirma que praticou furto, mas estava em estado de necessidade ou, ainda, que não houve um fato típico, mas ato legal e consentido.

Para efeitos de aplicação do instituto, parte da doutrina entende que apenas a confissão simples permite a realização do ANPP. Isto é, é necessária a confissão simples e voluntária em que o investigado menciona o essencial da infração cometida, narrando a motivação e as circunstâncias juridicamente relevantes. A lei exige que seja, a confissão, circunstanciada inclusive para a aferição judicial de sua consistência e verossimilhança. A confissão detalhada e sem margem de dúvidas evita que terceiros venham a assumir ou serem responsabilizados pelo crime.

A confissão qualificada corresponde, em última análise, a uma alegação de inocência que se fundada e verossímil, é incompatível com o acordo de não persecução, afinal, quem, por exemplo, subtrai coisa alheia móvel em estado de necessidade, praticando furto famélico, atua conforme o direito e, logo, não comete crime. O ANPP somente pode ser firmado com alguém que se declara culpado, e não com alguém que se diz inocente.

Posição contrária, no entanto, entende que se o investigado confessa a autoria, mas indica fato que lhe favoreça, como alguma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, ou mesmo eximentes de pena, não há obstáculo legal para a formalização do acordo. Nesse sentido, observa-se que o STJ já decidiu que a chamada “confissão qualificada” deve ensejar a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Ora, se ela serve para atenuar a pena, porque não serviria para admitir o acordo?<sup>5</sup>

Obviamente, não é interpretado da mesma forma o silêncio do investigado, seja porque a lei exige confissão formal, seja porque, se preferir se calar, o investigado não está confessando delito algum, mas se valendo do direito constitucional a não autoincriminação (*nemo tenetur se detegere*).

A confissão deve ser feita também circunstancialmente, ou seja, devem estar detalhados todos os fatos, de maneira pormenorizada e sem margem para quaisquer dúvidas, atentando-se sempre para que ela tenha sido feita sem coação de nenhuma natureza, conforme exige o art. 8º, 3, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).

Se o investigado praticou, supostamente, duas ou mais infrações penais, tendo confessado apenas uma delas, o acordo somente poderá ser feito em relação ao fato admitido, devendo ser oferecida denúncia em relação ao outro fato caso haja justa causa.

---

<sup>5</sup><https://romulomoreira.jusbrasil.com.br/artigos/801099518/o-novo-acordo-de-nao-persecucao-penal>



Na forma da Lei nº 13.964/2019, a confissão do investigado será feita de modo escrito, ao contrário do que previa a Resolução nº 181/2017 do CNMP que, em seu art. 18, parágrafo 2º, estipulava ser possível a confissão feita de forma oral e registrada por meio de gravação audiovisual.

Essa confissão e a amplitude de sua validade jurídica deverão ser enfrentadas pela jurisprudência. É necessário que se discuta sobre a possibilidade de ela vir a fundamentar sentença penal condenatória na hipótese de rescisão do acordo e consequente instauração do processo penal por meio de oferecimento de denúncia, pois, nada obstante ter sido feita fora dos autos, de toda maneira ela foi formal e oralmente ratificada perante o Juiz, em uma audiência pública feita com a presença do Defensor do investigado – ainda que público ou dativo – e do membro do Ministério Público.

Entendo, no entanto, que quando se tomou a confissão do investigado, não havia acusação formal e tampouco instrução criminal em curso. Dessa forma não pode, aquela, servir de base para uma sentença condenatória, a não ser que, ao final da instrução, ela tenha sido ratificada em interrogatório judicial.

Em outras palavras, caso o investigado tenha confessado formalmente e circunstancialmente o fato para fins de viabilizar a aplicação do instituto do ANPP, chegando a ratificar suas declarações em audiência, mas, posteriormente, quando interrogado na audiência de instrução e julgamento, não confirma a confissão, o Juiz estará impedido de utilizar aquela confissão anterior para basear eventual sentença condenatória, afinal, como dito, a confissão não foi realizada no bojo de uma ação penal. Aliás, como se sabe, nem mesmo a confissão feita durante o interrogatório é prova irrefutável da autoria do crime.

## 7. OBRIGAÇÕES DO INVESTIGADO

A lei prevê diversas obrigações para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal. O rol não é taxativo, mas exemplificativo, já que o Ministério Público poderá propor outras medidas não previstas expressamente em lei, desde que proporcionais e compatíveis com a infração penal, na inteligência do art. 28-A, V, do CP. Tais condições podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, conforme o princípio da proporcionalidade/individualização do acordo.

As condições negociadas no ANPP precisam se revelar suficientes e necessárias para reprovação e prevenção do crime (leia-se infração penal), objeto do negócio jurídico. Trata-se de expressão subjetiva que demanda, indiscutivelmente, contornos mais explícitos e baseados no caso concreto.

Abaixo, as condições previstas em lei que podem ser fixadas cumulativamente ou não:

- a) reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
- b) renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
- c) prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
- d) pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito;



e) cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.

Passo a dispor a respeito de cada uma delas:

**a) reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo:**

A primeira obrigação é a reparação do dano ou a restituição da coisa à vítima, salvo na impossibilidade de fazê-lo, podendo ser total ou parcial. Nem sempre a reparação ou a restituição é possível, visto que o autor pode não dispor de recursos financeiros para tanto ou a coisa pode ter sido destruída, perdida ou transferida a outrem. Apesar disso, o acordo poderá ser firmado, mesmo porque a reparação/restituição não é uma obrigação essencial, mas accidental, que pode ou não figurar entre os deveres do investigado.

Haverá discussão sobre a possibilidade de se firmar, no acordo, indenização por danos morais. Embora havendo dificuldade para estabelecimento do *quantum* a ser firmado, tal fato não afasta, por si só, a possibilidade de fixação. A utilização de parâmetros monetários estabelecidos pela jurisprudência para casos similares, bem como a discussão e efetiva participação do ofensor, contribuem para a análise da reparação no ANPP.

**b) renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime:**

A segunda condição é a renúncia voluntária de bens, como instrumentos, produtos ou proveito do crime, e direitos indicados pelo MP. A renúncia cumpre o papel do confisco legal aquiescido que recai sobre bens e direitos, como objetos utilizados para executar a infração penal, tidos como instrumentos do crime, objetos conseguidos diretamente com a atividade criminosa, entendidos como produtos do crime, ou bens conseguidos com a utilização do produto criminoso, o proveito do crime.

**c) prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);**

**d) pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito:**

Os dois tópicos, “c” e “d”, são hipóteses que já figuram no artigo 43 do Código Penal como penas restritivas de direito e, agora, são aplicadas também mediante acordo e de forma atenuada, a revelar, inclusive, quão defasados estão os arts. 43 e 44 do CP, cujos casos de substituição por penas alternativas poderiam ser consideravelmente ampliados.

A jurisprudência possui entendimento firmado de que não há óbice para que se estabeleçam obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais, mas que, para os fins do benefício, se apresentam tão somente como condições para sua incidência em acordo, como no caso da suspensão condicional do processo (tese julgada pelo STJ sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 930 - AgRg no RHC 085835/PR; AgRg no RHC 083810/PR; RHC 084350/MG; RHC 064083/RS; HC 386626/SP; RHC 067813/RS; REsp 1498034/RS). O estabelecimento dessas obrigações deve ser feito com o prudente exercício da faculdade judicial disposta no art. 89, § 2º, da Lei nº 9.099/1995. As obrigações podem ser: a prestação de serviços comunitários ou a prestação

pecuniária, obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais mas que, para os fins do benefício, se apresentam tão somente como condições para sua incidência.

Atenção apenas para o fato de que, como as condições são firmadas em acordo e não em condenação, não se trata de uma sanção penal. Percebe-se, portanto, o equívoco do legislador ao prever que o acordo deverá ser executado no juízo da execução penal. Na VEP apenas se executa sanção penal. A sua execução, portanto, deve ficar a cargo do Ministério Público ou do juízo de conhecimento. Veremos como o tema será tratado na prática e como será analisado pela jurisprudência.

**e) cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada:**

O rol não é taxativo, mas exemplificativo, já que o MP poderá propor outras medidas não previstas de forma expressa na lei, desde que proporcionais e compatíveis com a infração penal.

O prazo determinado para a condição do inciso V, do artigo 28-A, do CPP, não pode ser superior àquele previsto no artigo 28-A, III, do CPP, ou seja, àquele correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de um a dois terços, já que uma condição genérica não pode perdurar por tempo superior à obrigação de natureza penal e estabelecida pelo próprio legislador.

## 8. VEDAÇÕES LEGAIS/NÃO CABIMENTO DO ACORDO

O acordo está vedado para os seguintes casos, por força do §2º:

a) se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;

b) se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;

c) ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo;

d) os crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.

Abaixo há a análise de cada um dos pontos.

**a) se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei:**

Quando cabível a transação penal, não será possível o ANPP. Se cabíveis o acordo e a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), ficará a critério do MP propor o que for mais adequado segundo as circunstâncias do caso, podendo o investigado manifestar preferência por um ou outro benefício, conforme seus interesses. Nos casos controversos, prevalecerá o benefício mais favorável ao investigado.

**b) se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas:**

A lei proíbe o acordo para o investigado reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas.

Haverá hipótese em que, apesar da habitualidade e demais características já ditas, o acordo será cabível, seja porque as condutas anteriores são insignificantes, como previsto na própria lei, seja porque o acordo de não persecução é socialmente recomendável.

O inciso traz um elemento subjetivo, pois deixa ao critério do Ministério Público analisar se a conduta é habitual ou não. Caso fosse mencionado crime habitual, a classificação do crime já responderia à questão, mas não, ele trouxe que a conduta é habitual, reiterada ou profissional.

Acredito que haverá discussão a respeito desse item. Ademais, a parte final do inciso traz uma exceção para desconsiderar as infrações penais pretéritas insignificantes. Há um erro conceitual, pois se forem insignificantes, deixam de ser infração penal, visto a ausência de tipicidade material. Como disse, acredito em discussões nesse ponto.

**c) ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo:**

A lei proíbe, ainda, o ANPP para o agente que foi beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo.

**d) os crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor:**

Por fim, o acordo está vedado para os crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar pouco importando, nesses casos, o sexo da vítima, e, também, para os praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

Quanto a infrações penais no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, há vedação de concessão de outros benefícios/acordos em razão da inaplicabilidade da Lei nº 9.099/95 a casos da Lei nº 11.343/06 (Lei Maria da Penha), (art. 41, Lei nº 11.343/06; STJ, Súmula nº 536; STF, ADI 4424 e ADC 19), razão pela qual a vedação se justifica.

## 9. CRIMES HEDIONDOS

No CPP, não há vedação expressa para a aplicação do ANPP em hipóteses de cometimento de crimes hediondos ou afins, desde que se adequem aos requisitos (§2º), diversamente do que dispunha a Resolução nº 181/2017 do CNMP, alterada pela Resolução nº 183, de 24 de janeiro de 2018, daquele Conselho. Naquele diploma havia previsão expressa atestando a impossibilidade de acordo em crimes hediondos ou equiparados, conforme abaixo:

“Art. 18, § 1º. Não se admitirá a proposta nos casos em que: V – o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340/2006.”

## 10. JUSTIÇA ESPECIALIZADA (MILITAR E ELEITORAL)

A Resolução nº 181 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), alterada pela Resolução nº 183, de 24 de janeiro de 2018, vedava o ANPP nos crimes militares que afetassem a hierarquia e a disciplina. Nos demais casos, autorizava o acordo de vontades, conforme abaixo:

“Art. 18, § 12. As disposições deste capítulo não se aplicam aos delitos cometidos por militares que afetem a hierarquia e a disciplina.”

A Lei nº 13.964/19 não trata do assunto. Portanto, em que pese a divergência que pode surgir quanto ao tema, tendo em vista o silêncio eloquente, é possível se compreender que o ANPP pode ser aplicado na Justiça Militar e na Justiça Eleitoral.

## 11. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL

O acordo deverá ser realizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor (art. 28-A, parágrafo 3º, CPP). Embora não haja previsão expressa no CPP, exige-se que o defensor do investigado esteja presente em qualquer ato de negociação do acordo, ainda que o ato detenha cunho meramente informal, à semelhança do que é válido para a colaboração premiada, consoante o art. 3º-C, parágrafo 1º, da Lei nº 12.850/2013, após o advento da Lei nº 13.964/2019.

Uma vez subscrita a proposta de negócio jurídico pelas partes, cabe ao Juiz – no caso, o das garantias do art. 3-C, XVII, do CPP (suspensão pela ADIn 6.299/DF) – se limitar à análise da voluntariedade do investigado (se houve vício de consentimento dos arts. 138 e seg. do Código Civil) e da legalidade do acordo (requisitos e inaplicabilidade do *caput* e § 2º), não podendo se imiscuir no “mérito ou no conteúdo” do negócio jurídico por não ser parte negociante, sob pena de violação da imparcialidade (art. 129, I, da CF/88).

A voluntariedade, sobretudo, é perquirida em audiência com oitiva do investigado na presença de seu defensor (§ 4º). Homologado o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal, lembrando que a homologação judicial do acordo suspende o prazo prescricional.

Ao analisar o ANPP, o juiz pode:

- a) homologar o ANPP, devolvendo para o início da execução no juiz da execução (§6º);
- b) se considerar inadequadas, insuficientes e abusivas as condições dispostas no ANPP, devolver os autos ao MP para que seja formulada a proposta do acordo, com concordância do investigado e seu defensor (§ 5º). Ou o MP reabre as negociações ou oferece a denúncia-crime;
- c) se entender que não é o caso de acordo, devolverá os autos ao MP para análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia (§ 8º). Mas se o MP discordar do juiz e insistir no ANPP? Ou seja, ele não quer oferecer denúncia. A Lei nº 13.964/19 escolheu um caminho inconstitucional ao prever que recusando o juiz a homologação (§ 7º), as partes poderão interpor recurso em sentido estrito (art. 581, XXV, CPP). No entanto, tal previsão viola o sistema acusatório (art. 3º-A, CPP) e a independência do MP (art. 129, CF/88), uma vez que o juiz não pode preordenar a atuação do Ministério Público para a propositura da ação penal. Admitir a eficácia do §8º do art. 28-A do CPP seria dizer que o juiz pode ordenar ao Ministério Público que denuncie. No entanto, o art. 129, I, da Constituição, atribui essa decisão (de acusar ou de não acusar) apenas ao *Parquet*. Diante desse quadro, sugere a doutrina que se utilize, por analogia, o artigo 28, do CPP, usado também no sentido inverso: quando o MP se recusa a propor o ANPP, o juiz aplica o art. 28, CPP (§ 14).

De qualquer modo, para provas objetivas, pode ser que o examinador cobre a letra seca do CPP, devendo o candidato responder na forma do art. 581, XXV, CPP. Se for o caso de uma questão subjetiva ou prova oral, o candidato deverá tecer detalhes.

## 12. É ADMISSÍVEL QUE O ANPP SEJA NEGOCIADO E HOMOLOGADO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (DO ART. 287 E ART. 310 DO CPP)?

O regramento do ANPP acrescido pela Lei nº 13.964/2019 não prevê a possibilidade de realização do ANPP na audiência de custódia. No entanto, o art. 18, parágrafo 7º, da Resolução do CNMP, permite a celebração do acordo na audiência de custódia:

“Art. 18, § 7º. O acordo de não persecução poderá ser celebrado na mesma oportunidade da audiência de custódia.”

A doutrina majoritária defende a realização do ANPP no ato da audiência de custódia. No entanto, é possível descrever algumas críticas a respeito de tal disposição.

Ressalto que não está previsto no escopo da audiência de custódia, quando tratado sobre seu conceito, finalidade e procedimento, a realização e homologação do ANPP.

O art. 3º-B, ao prever que o juiz das garantias detém competência para homologação do ANPP, afirma que o acordo será realizado “durante” a investigação. Por se tratar, ainda, de um acordo que envolve liberdade de negociar e autonomia da vontade, como se falar em uma decisão do preso, consciente e voluntária, em poder questionar ou negociar as obrigações/condições se este se encontra sob a tutela do Estado?

Veja-se que a lei concede ao Ministério Público um alto nível de discricionariedade, visto que admite expressamente a estipulação de obrigações não previstas no referido artigo. Ocorre que o acordo de não persecução penal é justamente uma negociação entre as partes, uma vez que, conforme o próprio *caput* do art. 28-A, determina que as condições deverão ser ajustadas, o que é difícil de visualizar na prática.

## 13. DUPLA ACEITAÇÃO DEFENSIVA

A versão final da proposta negociada é escrita e assinada pelo membro do MP, bem como pelo investigado e seu defensor (§ 3º), devendo ser encaminhada ao Juízo competente para homologação. Destaca-se a dupla aceitação defensiva: uma na negociação e outra na audiência de homologação. Em caso de discordância em um destes momentos, considera-se frustrada a tentativa de ANPP.

## 14. REGISTRADOS PELOS MEIOS OU RECURSOS DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL

A Resolução do CNMP determina que a confissão detalhada dos fatos e as tratativas do acordo devem ser registradas pelos meios e recursos de gravação audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações.

Art. 18, § 2º. “A confissão detalhada dos fatos e as tratativas do acordo serão registrados pelos meios ou recursos de gravação audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, e o investigado deve estar sempre acompanhado de seu defensor.”

A Lei nº 13.964/2019 não exigiu tais formalidades, mas elas merecem ser observadas já que são positivas, na medida do possível, dando mais transparência a toda a negociação e voluntariedade do negócio.

## 15. VÍTIMA SERÁ INTIMADA

A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento.

“Art. 28-A, § 9º, CPP. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento.”

Até agora não foi mencionada a vítima do suposto crime. Não há previsão legal para que a vítima participe do acordo ou da audiência de homologação, mesmo que uma das condições seja a reparação do dano à vítima.

É possível que na prática, no momento da audiência, chame a vítima para tentar firmar de forma mais adequada a reparação do dano, para que ela participe de forma mais democrática para a finalização daquela persecução penal.

No entanto, como frisado, a lei só exige que ela seja posteriormente intimada, porque ela tem que saber dos atos do procedimento. O próprio código prevê no art. 201, §1º, na parte de prova, capítulo do ofendido, que ele é comunicado dos atos de soltura, de prisão, de acórdão, de sentença. Assim, vemos que aqui se tem mais uma previsão de comunicação de atos processuais.

## 16. NÃO GERA REINCIDÊNCIA EM ANTECEDENTES CRIMINAIS AO INVESTIGADO

A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no art. 28-A, §2º, III, ou seja, o não oferecimento de acordo dentro do prazo de cinco anos:

“Art. 28-A, §2º, III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo;”

A finalidade é ter ciência se ele teve ou não o benefício. Não é para considerar de forma desfavorável ao autor do fato.

## 17. CUMPRIMENTO

O cumprimento das condições do ANPP é causa extintiva de punibilidade (§ 13º), competindo ao Juízo proferir a decisão de natureza declaratória quanto à extinção de punibilidade.

“Art. 28-A, § 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade.”

Isso ocorre para todas as formas mencionadas de justiça consensual. Na transação penal e na suspensão condicional do processo, cumprido o acordo, também ocorrerá a declaração de extinção à punibilidade.

## 18. DETRAÇÃO

Não possuindo nas condições fixadas na avença natureza de sanção penal, visto que são pactuadas e não impostas pelo Estado, se descumprido o ANPP, não há que se falar em posterior aplicação de detração penal pelas condições efetivamente cumpridas. Essa é a posição que tem sido por ora afirmada pela doutrina. A perda do referido tempo é, pois, consequência natural do descumprimento, ônus da desídia do próprio investigado que teve a oportunidade de cumprimento de todas as condições.





**19. RECUSA, POR PARTE DO MP, EM PROPOR O ANPP**

No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 do CPP.

**20. CONCURSO DE AGENTES**

Quando houver concurso de agentes (art. 29 do CP), o acordo poderá ser firmado com todos os coautores e partícipes do crime ou somente com alguns deles, a depender do preenchimento das condições. O ANPP poderá, portanto, tramitar simultaneamente com a ação penal em autos apartados.

**21. DESCUMPRIDAS AS CLÁUSULAS DO ANPP E RESCISÃO**

Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para efeito de rescisão e posterior oferecimento de denúncia, conforme consta do CPP:

“Art. 28-A, § 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de Denúncia.”

Como a validade do acordo exige decisão judicial, temos que a sua rescisão não se pode dar unilateralmente, exigindo-se, também aqui, decisão judicial que assegure o contraditório prévio.

Desse modo, ante a notícia de descumprimento de condição estipulada no acordo de não persecução penal, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa constitucionalmente determinados, a análise da rescisão pressupõe a oitiva do investigado e da defesa técnica.

Com a rescisão, a prescrição volta a correr e o Ministério Público pode (discrecionariamente) utilizar o descumprimento como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Abaixo, a previsão legal:

Art. 28-A, § 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.”

**22. RESCISÃO APÓS DECISÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE**

Um ponto intrigante é a descoberta superveniente do descumprimento de alguma condição, após a decisão declaratória da extinção de punibilidade (§ 13º). Poderia haver rescisão com efeito retroativo, desconsiderando aquela sentença?

É possível se concluir pela rescisão do acordo, a semelhança da previsão na suspensão condicional do processo do art. 89, § 5º da Lei nº 9.099/95, pois a decisão apenas reconhece um fato gerador – cumprimento das condições, que no caso inexistiu – e declara extinta a punibilidade (STF, HC 95.683/GO; STJ, RHC 95.804/DF).

**23. É UM DIREITO SUBJETIVO DO INVESTIGADO?**

Pelo art. 28-A do CPP percebe-se que o acordo não é um direito subjetivo do investigado. Logo, ainda que preenchidos todos os requisitos legais para o acordo, ele somente será





proposto pelo Ministério Público a depender do seu juízo de conveniência e oportunidade (discrecionabilidade). Se ele constituísse um direito subjetivo, o próprio juiz poderia propor o acordo no lugar do Ministério Público, o que jamais poderá ocorrer. É essa, inclusive, a posição adotada pelo STJ em outros institutos de justiça criminal consensual, como a transação penal e a suspensão condicional do processo, conforme enunciado sumulado:

Súmula nº 696 do STF: “Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal.”

**Não significa que o Ministério Público possa atuar de forma arbitrária ou ilegal. Tanto é que o seu comportamento é devidamente fiscalizado pelo investigado, que, caso tenha interesse no acordo, pode provocar o magistrado a aplicar o teor do art. 28 do CPP:**

“Art. 28-A, § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.”

De modo contrário ao exposto acima, por exemplo, Aury Lopes Jr. entende que – preenchidos os requisitos legais – se trata de direito público subjetivo do imputado, um direito processual que não lhe pode ser negado<sup>6</sup>.

De qualquer modo, essa é uma questão ainda gerará muita discussão, não havendo consenso entre os doutrinadores.

## 24. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL

Na linha do ANPP, a Lei nº 13.964/2019 trouxe ao ordenamento jurídico o acordo de não persecução penal cível, cuja celebração é cabível nas ações de improbidade administrativa, nos termos do art. 17, parágrafo 1º, da Lei nº 8.429/1992. Nessa ação, havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo de contestação, por prazo não superior a 90 dias (art. 17, parágrafo 10-A, da Lei nº 8.429/92, acrescido pelo “Pacote Anticrime”).

### QUESTÕES

**1- (MPE-PR - 2019 - MPE-PR - Promotor Substituto)**Sobre o acordo de não persecução penal, segundo a Resolução 181/17, alterada pela Resolução 183/18, ambas do Conselho Nacional do Ministério Público, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa incorreta:

- a) Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente previstas na própria Resolução.
- b) O descumprimento do acordo de não persecução pelo investigado também poderá ser utilizado pelo membro do Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.
- c) O acordo de não persecução não poderá ser celebrado na mesma oportunidade da audiência de custódia.
- d) Não se admitirá a proposta de acordo de não persecução nos casos em que for cabível a transação penal, nos termos da lei.

<sup>6</sup><https://www.conjur.com.br/2020-mar-06/limite-penal-questoes-polemicas-acordo-nao-persecucao-penal>



e) Se o juiz considerar incabível o acordo de não persecução, bem como inadequadas ou insuficientes as condições celebradas, fará remessa dos autos ao procurador-geral ou órgão superior interno responsável por sua apreciação, nos termos da legislação vigente.

**2- (Inédita)** São requisitos para o Acordo de Não Persecução Penal, EXCETO:

- a) a necessidade e suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime.
- b) que o crime seja punido com pena máxima inferior a 4 anos.
- c) que não seja caso de arquivamento da investigação.
- d) crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.
- e) confissão formal e circunstanciada.

**3- (Inédita)** Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

I – Não é possível o ANPP se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, mesmo quando insignificantes as infrações penais pretéritas.

II – Se o agente foi beneficiado nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo não será cabível ANPP.

III – Não será cabível ANPP se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais e nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

- a) Todas estão corretas.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Apenas II e III estão corretas.
- e) Todas estão incorretas.

**4- (Inédita)** Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

I – Quando houver concurso de agentes (CP, art. 29), o acordo de não persecução penal poderá ser firmado com todos os coautores e partícipes do crime ou somente com alguns deles, podendo o ANPP tramitar simultaneamente com a ação penal.

II – No caso de recusa de homologação do ANPP caberá recurso em sentido estrito.

III – O CPP prevê expressamente a possibilidade de o ANPP ser realizado em audiência de custódia.

- a) Todas estão corretas.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Apenas II e III estão corretas.
- e) Todas estão incorretas.

**5- (Inédita)** Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do ANPP.

a) Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.

b) Recusada a homologação do ANPP, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.

c) Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.

d) Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.

e) O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado não poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.

**6- (Inédita)** Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

I – Desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formalmente e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal.

II – Para que seja possível a aplicação do acordo de não persecução penal a pena mínima cominada ao delito deverá ser inferior a quatro anos, não sendo consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.

III – A homologação do acordo de não persecução penal, que será formalizado por escrito, firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor, será feita em audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.

- a) Todas estão corretas.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Apenas II e III estão corretas.
- e) Todas estão incorretas.

## COMENTÁRIOS

### 1. Gabarito: C

- a) CORRETA. Art. 28-A, *caput*, do CPP.
- b) CORRETA. Art. 28-A, § 11, do CPP.
- c) ERRADA. Art. 18, § 7º da Resolução nº 181-17 do CNJ: “§ 7º O acordo de não persecução poderá ser celebrado na mesma oportunidade da audiência de custódia.” (Redação dada pela Resolução nº 183, de 24 de janeiro de 2018).
- d) CORRETA. Art. 28, § 2º, I, do CPP.
- e) CORRETA. Art. 28-A, § 5º, do CPP.

### 2. Gabarito: B

O ANPP exige os seguintes requisitos (art. 28-A):

- que não seja caso de arquivamento da investigação;
- crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa;
- crime punido com pena mínima inferior a 4 anos;
- confissão formal e circunstanciada;
- necessidade e suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime.

### 3. Gabarito: D

Segundo o art. 28-A, § 2º, CPP: O disposto no *caput* deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

### 4. Gabarito: B

I – CORRETA – O benefício será analisado para cada agente, o concurso de agente não impede a análise do acordo.

II – CORRETA – Art. 581, CPP: “Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...)XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.”

III – INCORRETA – O § 7º do art. 18 da Resolução nº 181 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), alterada pela Resolução nº 183, de 24 de janeiro de 2018, daquele Conselho, previa expressamente a possibilidade de o acordo de não persecução penal ser celebrado na mesma oportunidade da audiência de custódia. Na atual redação do art. 28-A da Lei nº 13.964/2019 não consta tal previsão.

**5. Gabarito: E**

- a) CORRETA. Art. 28-A, § 10, CPP.
- b) CORRETA. Art. 28-A, § 8º, CPP.
- c) CORRETA. Art. 28-A, § 5º, CPP.
- d) CORRETA. Art. 28-A, § 4º, CPP.
- e) INCORRETA. Art. 28-A, §11, CPP.

**6. Gabarito: C**

I – CORRETA. Art. 28-A, CPP.

II – INCORRETA. Art. 28-A, § 1º, CPP: “Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o *caput* deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.” (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III – CORRETA. Art. 28-A, § 3º, CPP.



## CAPÍTULO 8 – AÇÃO PENAL (ARTS. 24 A 62 DO CPP)

### 1. INTRODUÇÃO

Ação é o direito público subjetivo de pedir ao Estado-Juiz a aplicação de uma sanção penal a uma pessoa que cometeu uma infração penal, infringido uma lei penal incriminadora. O direito de ação é abstrato, não se confundindo com o direito material deduzido em juízo.

É o direito de pedir ao Estado (representado por seus juízes) a aplicação do direito penal objetivo (FILHO, 2013, p. 162).

É o procedimento iniciado pelo titular da ação quando há indícios de autoria e de materialidade a fim de que o juiz declare procedente a pretensão punitiva estatal e condene o autor da infração penal (REIS, 2013, p. 71).

#### 1.1. CONDIÇÕES GERAIS DA AÇÃO

Para que ocorra o recebimento da peça inicial acusatória, é imprescindível o preenchimento das condições da ação penal, que são requisitos mínimos indispensáveis para o julgamento do mérito da causa. Se ausentes as condições, deve haver a rejeição da peça inicial, nos termos do art. 395, incisos II e III, do CPP.

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal;

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Parágrafo único. (Revogado).

O momento adequado, portanto, para a discussão a respeito das condições da ação é o da admissibilidade da inicial. Superada essa fase, resta ao magistrado o enfrentamento meritório (TÁVORA; ALENCAR, 2009, p. 125).

São condições gerais da ação:

- a) possibilidade jurídica do pedido;
- b) interesse de agir;
- c) legitimidade da parte;
- d) justa causa.

##### 1.1.1. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

O pedido deve se referir a uma providência admitida em tese pelo direito objetivo. Desse modo, haverá possibilidade jurídica do pedido quando a pretensão punitiva se dirige à aplicação de uma pena ou de uma medida de segurança e está lastreada em fato descrito abstratamente como infração penal (crime ou contravenção penal) no ordenamento jurídico.

##### 1.1.2. INTERESSE DE AGIR

É a condição que se baseia na pena provavelmente aplicada ao autor do fato, caso haja processo e ocorra condenação, levando-se em conta os requisitos pessoais do agente e também as circunstâncias componentes de infração penal, tendo o juiz, por sua experiência, e pelos julgados semelhantes, a noção de que será produzida uma instrução útil (NUCCI, 2013, p. 204).

### 1.1.3. LEGITIMIDADE DA PARTE

A ação penal deve ser oferecida pelo seu respectivo titular (Ministério Público na ação penal pública; e ofendido ou seu representante legal na ação penal privada) contra o suposto autor da infração penal (pessoa física maior de 18 anos no tempo do crime ou pessoa jurídica a depender do delito praticado). Lembre-se que os inimputáveis por doença mental ou por dependência de substância entorpecente podem ser réus em processo penal e, caso comprovada a prática dos fatos descritos na exordial acusatória, eles serão ao final absolvidos impropriamente com a imposição de medida de segurança ou tratamento médico adequado, no caso dos dependentes químicos).

### 1.1.4. JUSTA CAUSA

É o suporte probatório mínimo, caracterizado pelo *fumus boni iuris* (*fumus commissi delicti*) para o exercício da ação penal.

Os doutrinadores advertem que a ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva e da constatação da ocorrência da infração penal em tese (TÁVORA, 2020, p. 162).

O STF sintetizou, no Informativo nº 869 (HC 129678/SP), o trinômio que caracteriza a justa causa:

No que se refere à justa causa, considerou presente o trinômio que a caracteriza: tipicidade, punibilidade e viabilidade. A tipicidade é observada em razão de a conduta ser típica. A punibilidade, em face da ausência de prescrição. E a viabilidade, ante a materialidade, comprovada com o evento morte, e a autoria, que deve ser apreciada pelo tribunal do júri.

A doutrina aponta duas conceituações importantes para a prova:

#### A) JUSTA CAUSA DUPLICADA

Quando se falar em justa causa duplicada, lembre-se da Lei de Lavagem de Capitais – Lei nº 9.613/98. Atenção à leitura do seguinte dispositivo legal:

Art. 2º, § 1º: A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente.

Lavagem de dinheiro é a conduta segundo a qual a pessoa oculta ou dissimula a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade — de bens, direitos ou valores provenientes, diretamente ou indiretamente, de infração penal com o intuito de parecer que se trata de dinheiro de origem lícita. Em palavras mais simples, lavar é transformar o dinheiro “sujo” (porque oriundo de um crime) em dinheiro aparentemente lícito. A tipificação e os aspectos processuais do crime de lavagem de dinheiro são regulados pela Lei nº 9.613/98 que prevê que a lavagem de dinheiro depende de uma infração penal, que pode ser um crime ou uma contravenção penal.

Note que a norma fala expressamente em denúncia, tendo em vista que os delitos insertos na referida lei são de ação penal pública incondicionada, de titularidade do Ministério Público. Quando do oferecimento da denúncia, não basta para a Lei de Lavagem de Capitais a existência de elementos mínimos da própria lavagem. A justa causa vai além. Ela deve estar relacionada a um crime antecedente. O Ministério Público, portanto, ao oferecer a peça inicial

acusatória, tem que demonstrar que quanto a esse crime antecedente, também há um suporte mínimo probatório.

Não é preciso que esse crime antecedente já tenha sido julgado, não se fala aqui em certeza, mas sim em fumaça do cometimento do delito, ou seja, da materialidade e indícios de autoria não só do crime principal, mas também do crime antecedente. A matéria restou decidida pelo STF:

O processo e julgamento do crime de lavagem de dinheiro é regido pelo princípio da autonomia. Isso significa que, para a denúncia que imputa ao réu o delito de lavagem de dinheiro ser considerada apta, não é necessária prova concreta da ocorrência da infração penal antecedente, bastando a existência de elementos indiciários de que o capital lavado seja decorrente desta infração penal (STF. 1ª Turma. HC 93.368/PR, DJe de 25/8/2011).

O tema também foi analisado pelo STJ no Informativo nº 657. A aptidão da denúncia relativa ao crime de lavagem de dinheiro não exige uma descrição exaustiva e pormenorizada do suposto crime prévio, bastando a presença de indícios suficientes de que o objeto material da lavagem seja proveniente, diretamente ou indiretamente, de uma daquelas infrações penais mencionadas nos incisos do art. 1º da lei. Veja em detalhes o que foi decidido:

Se o Ministério Público oferece denúncia por lavagem de dinheiro, ele deverá narrar, além do crime de lavagem (art. 1º da Lei nº 9.613/98), qual foi a infração penal antecedente cometida. Importante esclarecer, contudo, que não é necessário que o Ministério Público faça uma descrição exaustiva e pormenorizada da infração penal antecedente, bastando apontar a existência de indícios suficientes de que ela tenha sido praticada e que os bens, direitos ou valores que foram “lavados” (ocultados ou dissimulados) sejam provenientes desta infração. Assim, a aptidão da denúncia relativa ao crime de lavagem de dinheiro não exige uma descrição exaustiva e pormenorizada do suposto crime prévio, bastando a presença de indícios suficientes de que o objeto material da lavagem seja proveniente, direta ou indiretamente, de infração penal. STJ. Corte Especial. APn 923-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/9/2019 (Info 657).

## B) JUSTA CAUSA TRIPLICADA

Seguindo no raciocínio adotado na justa causa duplicada, é preciso esclarecer que o crime antecedente também pode depender de um crime prévio, ou seja, também antecedente. Exemplo: o crime antecedente é o de receptação: quando se fala no art. 180, do CP, é prevista uma conduta de estar na posse, por exemplo, e outros verbos do art. 180, relacionados a uma infração anterior.

Vamos supor que ocorreu uma lavagem de dinheiro referente a esse veículo que era produto de crime anterior. A justa causa duplicada classicamente ocorre, mas pode se perceber que o crime antecedente (receptação) também depende da demonstração mínima de outro crime prévio (ex.: roubo, ou um furto).

## 1.2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA AÇÃO

Além das condições genéricas da ação penal, é preciso observar o preenchimento de condições específicas de procedibilidade:

- a) representação do ofendido;
- b) requisição do Ministro da Justiça.

Dentre as espécies de ação penal, existe a ação penal pública e a ação penal privada. A primeira se subdivide em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Nesta, é preciso preencher, para além das condições genéricas, uma condição específica, que pode



ser a representação da vítima ou a requisição do Ministro da Justiça. Portanto, para o Ministério Público proceder ao oferecimento da peça inicial acusatória (denúncia) deverá observar se essas condições foram preenchidas em complementação às condições genéricas da ação penal.

### 1.3. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE (CONDIÇÃO SUPERVENIENTE DA AÇÃO)

Não se confunde com a condição específica de procedibilidade, que é sinônimo de condição específica da ação penal, sendo necessária para se instaurar/proceder à persecução penal. No caso da condição de prosseguibilidade, denominada por alguns doutrinadores como condição superveniente da ação, a ação penal já está em andamento e esta deve ser implementada para que o processo possa seguir seu curso normal.

É o que ocorreu, por exemplo, na Lei nº 9.099/95, que trata a respeito do procedimento comum sumaríssimo (juizados especiais). A lei dos juizados passou a exigir a representação nos crimes de lesão corporal leve e culposa, devendo o ofendido ou seu representante legal ser intimado a oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência. Isto é, para os processos que estavam em trâmite perante o Juizado, a representação funcionou como condição de prosseguibilidade; para os processos que ainda fossem começar a representação serve como uma condição de procedibilidade.

**Atenção:** a Lei nº 13.964/19 (Lei Anticrime) inseriu no art. 171 o § 5º que modifica a natureza da ação penal, antes pública incondicionada. Atualmente, a ação penal é pública condicionada à representação, exceto nas hipóteses dos incisos. Tendo em vista que a nova previsão traz a necessidade de representação (causa extintiva de punibilidade), a regra deve ser analisada sob a perspectiva da aplicação da lei penal no tempo. Daí advém uma discussão doutrinária a respeito de sua aplicabilidade nos casos em que a inicial (denúncia) já tenha sido ofertada. Por um lado, parte da doutrina, como Aury Lopes Júnior, defende que a vítima deve ser chamada para manifestar seu interesse em ver prosseguir o processo (condição de prosseguibilidade), mesmo durante a ação penal, adotando-se por analogia a previsão do art. 90 da Lei nº 9.099/95. De outro modo, parte da doutrina defende que não se aplica a retroatividade de forma absoluta e que se a denúncia já foi ofertada, trata-se de ato jurídico perfeito, não sendo alcançado pela mudança, não devendo se falar em intimação da vítima, uma vez que o legislador na Lei Anticrime não exigiu essa manifestação, como fez no arts. 88 e 90, ambos da Lei nº 9.099/95 (CUNHA, 2020, p. 65). Mostra-se necessário que sejam observados direitos adquiridos processuais constituídos sob a égide da lei anterior, devendo-se atentar para a fase procedimental em que se encontra o feito, se na fase inquisitorial ou instrutória, sendo certo que, uma vez iniciada a ação penal, o feito deve prosseguir até a sentença, tornando-se desnecessária a abertura de prazo para a vítima representar (ou ratificar seu interesse) para continuidade do exercício do *jus puniendi* pelo Estado, o que, por outro lado, mostra-se imprescindível quando se encontrar o procedimento ainda na fase investigativa. Além disso, pode ser que nos autos do processo conste que a vítima manifestou, de forma inequívoca, que tem interesse que seja o autor do crime processado e punido (ex.: vítima manifestou sua intenção de que o acusado fosse processado criminalmente ao prestar informações e apresentar documentos na fase inquisitorial acerca dos fatos; a vítima foi à delegacia registrar ocorrência; narrou os fatos e apontou o paciente como autor do estelionato), reforçando a desnecessidade de nova manifestação. Abaixo, há os julgados das três Turmas Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

*HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. LEI Nº 13.964/2019. DENEGAÇÃO DA ORDEM.* Com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, conhecida como "Pacote Anti-crime", que introduziu o § 5º ao artigo 171 do Código Penal, a ação penal por crime de estelionato passou a ser condicionada à representação da vítima. Sucede que, no caso, a ação penal já está em curso, em fase de instrução. Como a representação não exige rigorismo formal, bastando a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse seja o autor do crime processado e punido, isso já constando do processo, desnecessário seja a



vítima intimada para formalizar a representação ou ratificar seu desejo. Ordem denegada. (Acórdão 1240370, 07042714420208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Estelionato. L. 13.964/19. Pacote Anti-crime. Ação pública condicionada à representação do ofendido. 1 - Com o advento da L. 13.964/19 (Pacote Anti-crime, a ação penal, no crime de estelionato, passou a ser pública condicionada à representação (§ 5º do art. 171 do CP). 2 - Se o ofendido demonstrou de modo irrefutável o interesse na persecução penal, tem-se por suprida a falta de representação. 3 - Embargos não providos. (Acórdão 1234222, 00036499020178070006, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. *HABEAS CORPUS*. CRIME DE ESTELIONATO. LEI N. 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. 1. Com o advento da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passará a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação. 2. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na hipótese dos autos, visto que a vítima foi à delegacia registrar ocorrência, narrou os fatos e apontou o paciente como autor do estelionato. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1237747, 07042783620208070000, Relator: WALDIR LEÔNIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 23/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

#### 1.4. CONDIÇÕES OBJETIVAS DE PUNIBILIDADE

Existem ainda as chamadas condições objetivas de punibilidade que são contidas no plano do direito material, tidas como aquelas das quais depende o aperfeiçoamento de elementos ou circunstâncias não previstas no tipo penal. Trata-se de circunstâncias exteriores ao crime, não integrantes do tipo e de acontecimento futuro e incerto (AVENA, 2009, p. 157). Conforme autorizada doutrina (FRAGOSO, 1985. p. 225), não existe crime antes que a condição objetiva de punibilidade se verifique. O fato somente se torna punível a partir do momento em que a condição se realiza.

São hipóteses de condições objetivas de punibilidade:

- a) sentença anulatória do casamento, no crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento (art. 236, parágrafo único, do CP);
- b) o ingresso no país do autor do crime praticado no estrangeiro, conforme art. 7º, §§ 2º, alíneas *a* e *b*, e 3º, do CP;
- c) declaração de procedência da acusação pela Câmara dos Deputados, no julgamento do Presidente da República, nos termos do art.86 da Constituição Federal;
- d) sentença que decreta a falência, concede recuperação judicial ou extrajudicial, nas infrações alimentares, conforme art. 180 da Lei nº 11.101/05.

#### 2. CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS

A ação penal pode ser de duas espécies: ação penal pública e ação penal privada. A diferença principal entre as duas é que a primeira tem como titular o Ministério Público, e a segunda é oferecida pelo ofendido ou seu representante legal (quando aquele for incapaz).

A Ação Penal Pública é subdividida em:

- a) Ação Penal Pública Incondicionada (quando seu exercício não exige o preenchimento de nenhuma condição prévia);
- b) Ação Penal Pública Condicionada (quando a lei exige, para sua deflagração, o adimplemento de condição de procedibilidade — Representação do Ofendido ou Requisição do Ministro da Justiça).

A Ação Penal Privada é subdividida em:

- a) Propriamente dita ou exclusiva (quando cabe à vítima ou seu representante legal intentá-la, podendo o direito de oferecer queixa-crime ou de prosseguir na ação já iniciada ser transferido ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nessa ordem, em caso de morte ou ausência do ofendido – art. 31 do CPP);
- b) Personalíssima (só pode ser manejada pela vítima – no caso de morte ou incapacidade desta ninguém poderá intentá-la ou prosseguir na ação iniciada);
- c) Subsidiária da pública (quando o Ministério Público não propõe a ação pública no prazo legal e a vítima propõe queixa-crime subsidiária em seu lugar).

**Atenção:** quando o Código Penal e a legislação extravagante dispõem sobre os tipos penais e não diz qual é a espécie de ação penal, deve ser adotada a regra, qual seja, de ação penal pública incondicionada. Quando o legislador quiser estabelecer uma ação penal de outra modalidade, que não seja ação penal pública incondicionada, precisa dizer expressamente no próprio tipo penal, ou em um parágrafo ou artigo dentro daquele capítulo esclarecendo a espécie a ser empregada. A maioria dos crimes (e todas as contravenções penais) é de ação penal pública incondicionada. Basta, portanto, o Ministério Público ter em mãos indícios de autoria e prova da materialidade da infração penal para que a peça seja oferecida em juízo, independentemente do preenchimento de qualquer condição específica anterior.

**Atenção:** seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal será pública (art. 24, § 2º, CPP).

**Atenção:** o art. 26 do CPP prevê que nas contravenções penais a ação penal será iniciada por portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. No entanto, a titularidade da ação penal pública – no caso das contravenções penais – é do Ministério Público, razão pela qual é unânime o entendimento de que o art. 26 não foi recepcionado pela nova ordem constitucional de 1988.

### 3. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS NA AÇÃO PENAL PÚBLICA

A ação penal pública, tanto a incondicionada como a condicionada, é regida pelos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade.

#### 3.1. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE

Extrai-se do art. 24, do CPP, o qual menciona que:

“Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.”

Observa-se que há uma imposição no início do artigo, quando o legislador diz “a ação penal será promovida pelo Ministério Público”. Portanto, havendo materialidade e indícios de autoria de infração que se apura mediante ação penal pública, estará o Ministério Público obrigado a oferecer denúncia, salvo se houver causa impeditiva, por exemplo, a prescrição, hipótese em que deverá requer o arquivamento do feito (REIS, 2013, P. 87).

No capítulo sobre inquérito policial foram vistas as possibilidades de agir que tem o Ministério Público, quando recebidas as peças de informações ou inquérito policial. Classicamente, ele pode pedir diligências imprescindíveis (art. 16, CPP), oferecer a denúncia (art. 41, CPP), promover o arquivamento (art. 28, CPP) ou se manifestar pelo declínio de competência. O que o Ministério Público não pode é ficar inerte, ou seja, o Ministério Público vai oferecer a Denúncia quando ele tiver elementos.

**Atenção:** o princípio da obrigatoriedade será fiscalizado de dois modos (arts. 28 e 29 do CPP).

O art. 28 foi analisado de forma detalhada no capítulo de investigação criminal, traçando as principais observações a respeito das normas antes e depois da vigência da Lei Anticrime.

Outra forma de fiscalização, ainda não tratada, é o art. 29 do CPP, que trata a respeito da ação penal privada subsidiária da pública ou também chamada de ação acidentalmente privada. Neste caso, houve inércia do Ministério Público. Assim, o próprio ofendido ou o seu representante legal oferecerá uma queixa-crime subsidiária. Abaixo, o dispositivo legal:

Art. 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

**Atenção:** o princípio ora estudado é mitigado, o que a doutrina chama de discricionariedade regrada:

a) Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) que foi estudado em capítulo próprio;

b) transação penal: está prevista no art. 76 da Lei nº 9.099/95, a qual tem determinados requisitos, no sentido de que, mesmo que o Ministério Público possua, para aquele crime de menor potencial ofensivo, a materialidade e os indícios de autoria, ele não oferecerá a denúncia. Preenchendo o autor do fato os requisitos legais, o Ministério Público vai oferecer o benefício da transação penal. Cumprindo o autor do fato delituoso os requisitos da transação penal, a extinção da punibilidade será declarada. Não será considerado reincidente, nem terá maus antecedentes. Dessa forma, o procedimento será arquivado, sem nenhum incidente, sem qualquer mácula para o autor do fato.

Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.

§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.

§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:

I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo;

III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.

§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz.

§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.

§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art. 82 desta Lei.



§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível.

A transação penal é um instituto específico, próprio da Lei nº 9.099/95. Para a transação penal ser concedida ao autor do fato, a pena máxima abstrata do delito não pode ser superior a 2 anos, que é exatamente a previsão de competência do rito sumaríssimo (art. 61 da Lei nº 9.099/95): contravenções penais ou delitos cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Importa lembrar que deve ser considerado o concurso material, a continuidade delitiva, o concurso formal, para verificação da pena máxima.

O instituto será analisado de forma detalhada no capítulo sobre o procedimento comum sumaríssimo (Lei nº 9.099/95).

c) parcelamento tributário: no art. 83, § 2º, da Lei nº 9.430/96, está previsto o instituto do parcelamento tributário, que vai suspender a pretensão à exigibilidade punitiva do Estado, no que se refere aos delitos previstos nesta lei. Então, esse parcelamento é também apontado como uma exceção ao princípio da obrigatoriedade.

Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente.

§ 2º É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no *caput*, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. (Incluído pela Lei nº 12.382, de 2011).

d) colaboração premiada: art. 4, § 4º, da Lei nº 12.850/13, alterado pela Lei nº 13.964/19.

Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:

§ 4º Nas mesmas hipóteses do *caput* deste artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se a infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - não for o líder da organização criminosa;

II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo.

### 3.2. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE (INDESISTIBILIDADE)

Apesar de ser o *dominus litis* e ter a privatividade da ação penal pública (art. 129, I, CF/88), não pode o Ministério Público dela desistir; ou seja, uma vez oferecida a denúncia, o Ministério Público não pode desistir da ação penal, conforme previsão do art. 42 do CPP. Também, na fase recursal, conforme art. 576 do CPP, o Ministério Público não pode desistir do recurso que ele interpôs.

“Art. 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal.”



“Art. 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto.”

No entanto, não podemos confundir com a possibilidade que o Ministério Público tem de pedir a absolvição no momento final do procedimento, em sede de alegações finais. Logo, o Ministério Público entendendo ser o caso de absolvição, pode requerê-la, sempre que constatar um dos motivos do art. 386 do CPP.

Após proferida a sentença e entendendo o Ministério Público que ela satisfaz a pretensão punitiva estatal, não estará obrigado a recorrer. Portanto, ele poderá renunciar à interposição de recurso, mas não poderá desistir daquele que interpôs.

Como exceção à indisponibilidade, temos outro instituto importantíssimo para a prova, que é a suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95. No decorrer do processo, observando o Ministério Público os requisitos legais, oferecerá o benefício. O tema será aprofundado quando do estudo da Lei nº 9.099/95. Por ora, é imprescindível a leitura do dispositivo legal:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições:

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; II - proibição de frequentar determinados lugares;

III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;

IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.

§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.

§ 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos.

#### 4. ESPÉCIES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA

A Ação Penal Pública é de titularidade do Ministério Público, atribuição que foi dada pela Constituição Federal (legitimação ordinária):

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;”

O Ministério Público oferece a peça inicial acusatória, chamada de Denúncia, nos casos de Ação Penal Pública Incondicionada e Condicionada.

A Ação Penal Pública é subdividida em:

- a) Ação Penal Pública Incondicionada;
- b) Ação Penal Pública Condicionada.





#### 4.1. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA

A Ação Penal Pública Incondicionada é a regra. A maioria esmagadora dos crimes (e todas as contravenções penais) é desta espécie. Quando a lei nada fala acerca da espécie de ação penal a ser manejada, é porque se trata de infração que se pune mediante tal modalidade. Para o Ministério Público promover a denúncia independe de qualquer condição de procedibilidade. Por exemplo, no delito de furto, após o inquérito policial, com a colheita de elementos de materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público não depende de nenhuma outra condição para o oferecimento da denúncia. Está prevista na primeira parte do art. 24 do CPP.

“Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.”

#### 4.2. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO

O Ministério Público apenas poderá processar o autor de crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima se esta o autorizar. O Ministério Público depende da representação do ofendido ou do seu representante legal para promover a ação penal. Portanto, possui natureza jurídica de condição específica de procedibilidade (é a chamada *delatio criminis* postulatória). É o que determina a segunda parte do art. 24 do CPP:

“Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.”

**Atenção:** conforme visto no capítulo sobre investigação criminal, o inquérito policial que apura crime de ação penal pública condicionada também só pode ser iniciado depois do assentimento da vítima ou do seu representante legal (art. 5º, § 4º, do CPP).

A representação, conforme cediço na doutrina e na jurisprudência, prescinde de rigores formais, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal no sentido de que se promova a responsabilidade penal do agente (STJ, HC 213571/MG). Desse modo, até mesmo o registro de ocorrência perante a autoridade policial supre a representação exigida, pois demonstra a intenção da vítima de responsabilizar o autor do delito (STJ, HC 7771/SP; STF, 73226-7; STF, INQ 3438).

Tem forma livre, podendo ser de forma oral ou de forma escrita, dirigida ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial, na forma do art. 39 do CPP:

“Art. 39. O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial.”

A representação feita oralmente deverá ser reduzida a termo devendo constar todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria, nos termos dos parágrafos do artigo analisado acima.

§ 1º A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo, perante o juiz ou autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida.

§ 2º A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria.





A representação possui prazo decadencial para ocorrer e está descrito no art. 38 do CPP:

Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

Parágrafo único. Verificar-se-á a decadência do direito de queixa ou representação, dentro do mesmo prazo, nos casos dos arts. 24, parágrafo único, e 31.

**Atenção:** o prazo não é contado a partir do dia da prática ou consumação do fato delituoso, mas sim a partir do dia em que a vítima toma conhecimento de quem é o autor do crime.

**Atenção:** o prazo decadencial deve ser contado na forma do art. 10 do CP, ou seja, incluindo o dia do início e excluindo o dia do final. Lembre-se que no Processo Penal o prazo é contado de maneira diversa, excluindo o dia do início e incluindo o do final. Logo, isso faz diferença no último dia, no caso de o ofendido deixar para representar no dia final.

Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

§ 1º A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente.

§ 2º No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas.

§ 3º Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz.

Da mesma forma, tudo o que foi acima explicado para a representação deve ser também utilizado para o oferecimento da queixa-crime na ação penal privada. Quando se tratar de ação penal privada, o art. 38 do CPP menciona que “decairá o direito de queixa”.

Frisa-se que a representação oferecida pela vítima não vincula nem o delegado de polícia na fase da investigação criminal nem o Ministério Público para o oferecimento da inicial denúncia. Mesmo diante da representação confeccionada perante o delegado de polícia, a autoridade policial pode denegar a instauração de inquérito policial. Mesmo havendo investigação, o Ministério Público pode não ofertar a denúncia.

O titular do direito de representação é o ofendido. Em havendo morte da vítima ou de declaração judicial de ausência, este direito será transferido ao CADI – cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

“Art. 24, § 1º. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.”

Apesar de o dispositivo legal não mencionar o “companheiro/companheira”, este/a goza do mesmo *status* de cônjuge para o processo penal, possuindo legitimidade para o oferecimento de representação (na ação penal pública condicionada) e de queixa-crime (na ação penal privada), (STJ. Corte Especial. APn 912-RJ – Informativo nº 654).

Trata-se um juízo de conveniência e oportunidade da vítima maior de dezoito anos e capaz. Será do seu representante legal (pais, tutor ou curador) se ela for menor de dezoito anos ou incapaz, nos termos da lei. Caso os interesses do menor colidam com os do representante legal, o juiz nomeará um curador, que não estará obrigado a oferecer representação, devendo avaliar se é conveniente à vítima.

Art. 33. Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal.

A representação poderá ser exercida por procurador com poderes especiais, com base no art. 39 do CPP:

“Art. 39. O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial.”

Se a vítima for menor de dezoito anos e o seu representante legal deixar escoar o prazo decadencial de seis meses sem manejar a representação, a punibilidade deve ser considerada extinta pela decadência ou depois de completar dezoito anos a vítima terá novos seis meses para representar?

Os Tribunais Superiores adotam o entendimento de que se permite que a vítima ofereça representação depois de completada a maioridade, mesmo que tenha contado a seus representantes legais quem foi o autor da infração penal e que estes tenham deixado escoar o prazo decadencial de seis meses. Cumpre analisar a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CRIMES CONTRA OS COSTUMES. ART. 214 DO CP. DUPLA TITULARIDADE. PRAZO DECADENCIAL DE 6 MESES PARA A REPRESENTAÇÃO, A PARTIR DA MAIORIDADE DA VÍTIMA. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTES TRIBUNAL. SÚMULAS 7 E 83/STJ E 594/STF. (...) 2. Na ocorrência do delito descrito no art. 214 do Código Penal — antes da revogação pela Lei nº 12.015/2009 —, o prazo decadencial para apresentação de queixa ou de representação é de 6 meses, após a vítima completar a maioridade, em decorrência da dupla titularidade, *lato sensu*, do direito de ação (Súmula 594/STF). (...) (EDcl no AgRg no REsp 1189268/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/8/2012, DJe 12/9/2012).

Uma vez apresentada a representação, pode a vítima se retratar até o oferecimento da denúncia, nos termos do CPP:

“Art. 25. A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia.”

Para a doutrina minoritária, não é possível a chamada retratação da retratação, ou seja, novo oferecimento de representação, desde que dentro do prazo decadencial de seis meses, ao argumento de que, com a retratação, opera-se a renúncia ao direito de oferecer representação, que é causa extintiva de punibilidade, nos termos do art. 107, V, do CP (FILHO, 2013, p. 185). Prevalece, no entanto, que é possível a retratação da retratação desde que dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP.

Em relação à Lei Maria da Penha, há uma forma específica de realização da retratação. Deve-se verificar o real motivo desta. Por isso, determina o art. 16 da Lei Maria da Penha que será realizada uma audiência com oitiva também do Ministério Público antes da decisão judicial. Atenção, pois essa audiência tem que ocorrer antes do recebimento da Denúncia. Note que o marco temporal é diverso daquele previsto no CPP. Enquanto o Código fala em “oferecimento de denúncia”, a Lei Maria da Penha frisa até o “recebimento da denúncia”. Além disso, no CPP não há forma específica como a descrita na lei especial.

“Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.”



#### 4.3. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REQUISIÇÃO DO MINISTRO DA JUSTIÇA

A requisição possui a mesma natureza jurídica da representação, qual seja, de condição específica de procedibilidade que autoriza o Ministério Público a processar o autor de crime de ação penal pública condicionada. A requisição do Ministro da Justiça é um ato político de autorização ao Ministério Público para que se proceda à ação penal.

Como exemplo de crimes de ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça é possível citar aqueles cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil e os delitos contra a honra do Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Atenção aos seguintes dispositivos do CP:

Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: (...);  
§ 3º - A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior: (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)  
b) houve requisição do Ministro da Justiça. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:

I - contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro;

Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.

Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do *caput* do art. 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3º do art. 140 deste Código.

Observa-se que, mesmo havendo a requisição, o ato não é de ordem e por isso não vincula nem obriga o Ministério Público a denunciar. É uma condição que ele tem que observar para denunciar, mas não necessariamente ajuizará a ação.

Para a corrente majoritária, a requisição, ao contrário da representação, não está sujeita a prazo decadencial analisado no art. 38 do CPP. Ela pode ser manejada até o implemento da prescrição da pretensão punitiva. Porém, posição minoritária entende que há, não sendo possível a distinção: a possibilidade de decadência prevista nas ações penais públicas condicionadas à representação deve ser aplicada por analogia também nesse caso.

Sobre a possibilidade de retratação, também há divergência da doutrina. Parte dela entende que o ato é irretratável, uma vez que o art. 25 do CP expressamente só admite a retratação da representação. A doutrina majoritária, no entanto, afirma que pode também o Ministro da Justiça se retratar, por aplicação analógica.

#### 5. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS NA AÇÃO PENAL PRIVADA

A ação penal privada é orientada pelos princípios da oportunidade ou conveniência, da disponibilidade e da indivisibilidade.

##### 5.1. PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE/CONVENIÊNCIA

Os bens jurídicos resguardados por delitos que possuam ação penal privada são específicos e ofendem muito mais a intimidade da vítima do que o seio social, cabendo a ela escolher se deseja processar ou não o agente. Portanto, há uma oportunidade/conveniência em oferecer a queixa-crime. Mediante critérios próprios de oportunidade ou conveniência, cabe ao ofendido deliberar acerca da sua vontade de apresentar a inicial acusatória. Se não quiser exercer o direito de queixa, poderá se utilizar da decadência (art. 38 do CPP) ou da renúncia (art. 49 do CPP).

**Atenção:** conforme visto no capítulo sobre investigação criminal, o inquérito policial que apura crime de ação penal privada também só pode ser iniciado depois do requerimento da vítima (art. 5º, § 5º, do CPP).

## 5.2. PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE

O ofendido pode dispor da ação penal privada, o que ocorre após a instauração do processo penal até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nesse caso, poderá desistir do seu intento. Poderá haver o perdão do ofendido (art. 51 do CPP), mas como se trata de um ato bilateral, será imprescindível a aceitação do réu para restar extinta a punibilidade. No caso da ação penal privada subsidiária da pública, haverá a incidência do princípio da disponibilidade, sem, contudo, as consequências de extinção da punibilidade da ação penal privada. A perempção também é uma opção para o ofendido não prosseguir com a demanda (art. 60 do CPP).

## 5.3. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE

É aplicado apenas na ação penal privada, tendo em vista que na ação penal pública o Ministério Público poderá, até sentença final (art. 569, CPP), incluir novos agentes delitivos por meio de aditamento à denúncia ou oferecer contra eles nova ação penal, caso já tenha sido proferida a sentença final, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF, HC 104356/RJ e HC 117589/SP; STJ, HC 178406/RS e APn 691/DF). Em sentido contrário, a doutrina minoritária entende que a ação penal, seja pública, seja privada, é indivisível, no sentido de que abrange todos aqueles que cometeram as infrações (FILHO, 2013, p. 170 e TÁVORA; ALENCAR, 2009, p. 127).

O princípio define que o ofendido deve propor a ação penal privada em face de todos os autores do fato e está previsto no art. 48 do CPP:

“Art. 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade.”

Caso se perceba que o ofendido ocultou deliberadamente algum dos autores, cabe ao juiz declarar extinta a punibilidade pela renúncia de todos, tanto os que constam na inicial acusatória como aqueles que foram omitidos, pois ela se estende a todos os autores do fato.

A fiscalização desse princípio incumbe ao Ministério Público, o qual não pode aditar a queixa para incluir coautores e partícipes, pois faltaria legitimidade *ad causam*, havendo a possibilidade, no entanto, de requerer a intimação do querelante para a inclusão do querelado faltante.

Em se tratando de omissão voluntária do querelante, ou seja, se o querelante deixou de incluir algum corréu, subentende-se que houve renúncia tácita, estendendo-se aos demais réus.

Exemplo: a vítima foi injuriada por A e por B e sabia da prática delituosa pelos dois agentes, só que, quando foi oferecer a queixa-crime, ela ofereceu apenas contra A, pois como B é seu primo, a pedido da família ela decidiu omiti-lo da inicial. Observa-se que a omissão ocorreu porque ela quis, visto que mesmo ela sabendo que B a havia injuriado, ela não quis oferecer queixa-crime contra ele. Em face do princípio da indivisibilidade (art. 48 do CPP), ela deveria oferecer contra os dois: A e B. Consequentemente, o não oferecimento contra os dois acarretará a extinção da punibilidade para ambos, pela renúncia. Assim, como ela não quis oferecer contra B, essa renúncia se estende para o A também. Portanto, foi uma omissão voluntária/deliberada.

Por outro lado, em se tratando de omissão involuntária do querelante, ou seja, não tendo consciência do envolvimento de outras pessoas, deverá ser instado pelo Ministério Público a aditar a peça para a inclusão do autor faltante, sob pena de, não o fazendo, subentender-se que houve ato voluntário/deliberado.

Exemplo: a vítima recebeu vários xingamentos por mensagem. Após as investigações se concluiu inicialmente que a conduta foi praticada apenas por A, sem saber que B agiu em concurso no envio das ofensas. Diante da conclusão, a vítima ofereceu a queixa-crime contra A. No curso da ação, logo após ela ter oferecida a queixa-crime, foi juntado relatório aos autos demonstrando que as mensagens também foram enviadas por B. No entanto, percebeu que, quando foi oferecida a queixa-crime, o ofendido não sabia que B era autor do fato. Logo, como isso foi involuntário, o Ministério Público atua como fiscal da lei na ação penal privada e analisa o princípio da indivisibilidade, podendo requerer a intimação do querelante para ele corrigir o polo passivo da ação. Se a vítima, agora sabendo que B praticou o delito, mesmo assim, preferir continuar com a demanda apenas contra A, o ato tornou-se uma omissão voluntária, devendo ser extinta a punibilidade tanto de A quanto de B. Caso o querelante decida incluir B, a ação penal prosseguirá contra os dois.

Veja precedente do STJ que corrobora essa ideia:

(...) O reconhecimento da renúncia tácita ao direito de queixa exige a demonstração de que a não inclusão de determinados autores ou partícipes na queixa-crime se deu de forma deliberada pelo querelante. STJ. 5ª Turma. HC 186.405/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 2/12/2014.

## 6. ESPÉCIES DE AÇÃO PENAL PRIVADA

A ação penal será privada quando a lei trazer em seu bojo a expressão “somente se procede mediante queixa”. O autor da ação penal privada (ofendido ou seu representante legal) é chamado de querelante, e o sujeito passivo da relação processual (autor do fato delituoso) chama-se querelado.

A Ação Penal Privada é subdividida em:

- a) propriamente dita ou exclusiva;
- b) personalíssima;
- c) subsidiária da pública.

### 6.1. PROPRIAMENTE DITA/EXCLUSIVAMENTE PRIVADA

A vítima ou seu representante legal decidem se vão propor a ação ou não, a qual é intentada mediante queixa-crime. Caso esteja morta ou ausente, essa legitimidade passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, ou seja, permite-se que haja uma sucessão, conforme art. 31 do CPP.

“Art. 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.”

Assim, em regra, falecendo ou estando ausente o ofendido, a queixa-crime poderá mesmo assim ser intentada ou, se já proposta, ter continuidade por parte do CADI.

Apesar de o dispositivo legal não mencionar o “companheiro/companheira”, este(a) goza do mesmo *status* de cônjuge para o processo penal, possuindo legitimidade para o oferecimento da queixa-crime (na ação penal privada), (STJ. Corte Especial. APn 912-RJ – Informativo nº 654).

## 6.2. PERSONALÍSSIMA

É aquela em que somente o ofendido possui titularidade. Caso este faleça, estará extinta a punibilidade do autor do fato. O único crime de ação penal privada personalíssima é o de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento previsto no art. 236 do CP:

Art. 236 - Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Parágrafo único - A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento.

O crime de adultério, que era outro exemplo de crime de ação penal privada personalíssima, foi revogado pela Lei nº 11.106/05.

Não é possível a chamada sucessão processual (arts. 31 e 36 do CPP).

Art. 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

Art. 36. Se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge, e, em seguida, o parente mais próximo na ordem de enumeração constante do art. 31, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou a abandone.

## 6.3. SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA/ACIDENTALMENTE PRIVADA/AÇÃO PENAL SUPLETIVA

Caso o Ministério Público, titular da ação penal pública, mantenha-se inerte, estará o ofendido autorizado a propor ação penal privada subsidiária da pública. Essa espécie de ação é permitida pela CF/88, em seu art. 5º, LIX:

“Art. 5º, LIX. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal.”

Verifica-se que o Ministério Público está inerte quando escoados os prazos do art. 46 do CPP sem que o órgão tenha oferecido denúncia, requisitado novas diligências à polícia judiciária, requerido o declínio de competência ou promovido o arquivamento do inquérito policial. É o entendimento do STF, exposto no acórdão seguinte, que vem sendo mantido:

O ajuizamento da ação penal privada subsidiária da pública pressupõe a completa inércia do Ministério Público, que se abstém, no prazo legal, (a) de oferecer denúncia, ou (b) de requerer o arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação, ou, ainda, (c) de requisitar novas (e indispensáveis) diligências investigatórias à autoridade policial. Precedentes. - O Supremo Tribunal Federal tem enfatizado que, arquivado o inquérito policial, por decisão judicial, a pedido do Ministério Público, não cabe a ação penal subsidiária. Precedentes. Doutrina. (HC 74276).

Extraí-se da leitura do art. 29 do CPP que o Ministério Público poderá retomar a titularidade da ação penal a qualquer tempo, caso o ofendido se mostre negligente. É a chamada ação penal indireta. É assim porque a ação penal privada subsidiária da pública é uma ação penal pública na origem e não perde sua natureza.

Art. 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de





prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

## 7. OBSERVAÇÕES

### 7.1. EXIGÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA

Se o querelante não for advogado, ele terá que constituir um para a propositura da queixa-crime, tendo em vista a necessidade de capacidade postulatória. Constituindo um procurador, a procuração deverá ter poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo comum.

Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

**Atenção:** quando o art. 44 diz o nome do querelante, na verdade a doutrina aponta que o objetivo do legislador era que constasse na procuração o nome do querelado.

**Atenção:** quando faz a menção do fato criminoso, o STJ possui entendimento de que basta que se diga na procuração qual o dispositivo legal que está sendo imputado ao querelado. Não precisa descrever o fato criminoso, podendo apenas ter uma mera indicação do artigo de lei.

**Atenção:** o STF entende que eventual vício no instrumento de procuração estará sanado se o próprio querelante for signatário da queixa, consoante se depreende de trecho do seguinte julgado:

Fatos típicos suficientemente descritos no instrumento de mandato. Queixa-crime assinada pelo advogado e pelo próprio querelante, o que sanaria eventual vício no instrumento do mandato (STF, inq. 112.206).

### 7.2. QUAL A FUNÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AÇÃO PENAL PRIVADA?

O Ministério Público exercerá função de fiscal da lei. A queixa, ainda que seja privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Este terá o prazo de três dias para o aditamento da peça inicial acusatória, conforme o §2º do art. 46 do CPP.

Art. 45. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo.

Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.

§ 1º Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação.

§ 2º O prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos, e, se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo.



O aditamento possui a finalidade de corrigir falhas formais na peça inicial acusatória. Assim, caso a vítima tenha oferecido queixa contra um coautor, sem contemplar o outro, o Ministério Público, zelando pela indivisibilidade da ação penal, proporá ao querelante que faça o aditamento (não é o próprio Ministério Público que fará), sob pena de implicar em renúncia do direito de queixa contra um deles, passível de ser aplicada aos demais. Não há cabimento no aditamento feito pelo Estado-acusação para incluir coautor, a pretexto de zelar pela indivisibilidade, pois substituirá a vítima no interesse e na legitimidade de agir, conforme jurisprudência:

Nos termos do artigo 45 do CPP, a queixa poderá ser aditada pelo Ministério Público, ainda que se trate de ação penal privativa do ofendido, desde que não proceda à inclusão de coautor ou partícipe, tampouco inove quanto aos fatos descritos, hipóteses, por sua vez, incorrentes na espécie (STJ, HC 85.039/SP).

## 8. REQUISITOS DA PEÇA INICIAL ACUSATÓRIA

### 8.1. ANÁLISE DO ART. 41 DO CPP

O art. 41 do CPP enumera os requisitos formais da peça inicial acusatória, seja ela a denúncia na ação penal pública, seja ela a queixa-crime na ação penal privada. Confira o dispositivo legal:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

De acordo com a doutrina, alguns desses requisitos são obrigatórios/essenciais e ou outros não essenciais/facultativos. Abaixo, há a análise de cada um deles.

#### 8.1.1. EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO, COM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS

É requisito de caráter obrigatório/essencial para a peça inicial acusatória.

O Ministério Público deve oferecer a denúncia narrando devidamente os fatos bem como todas as circunstâncias, haja vista que o que vincula a defesa (e, também, o juiz) é a narrativa dos fatos e não a tipificação da infração penal. Assim, o acusado deve saber exatamente do que está sendo acusado. Os fatos devem estar descritos também para que se saiba o que a acusação deve provar, uma vez que tem tal ônus.

Sobre o princípio da correlação, atenção ao seguinte julgado:

Princípio da correlação (congruência), causa de aumento e *emendatio libelli* - O princípio da congruência preconiza que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Assim, para que esse princípio seja respeitado é necessário apenas que haja a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena. Ex.: o MP ajuizou ação penal contra o réu por sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90). Na denúncia, o MP não pediu expressamente que fosse reconhecida a majorante do art. 12, I. Pediu-se apenas a condenação do acusado pelo crime do art. 1º, I. No entanto, apesar disso, na exordial o membro do MP narrou que o réu sonegou tributos em montante superior a R\$ 4 milhões. O juiz, na sentença, ao condenar o réu, poderá reconhecer a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, porque o fato que ela representa (vultosa quantia sonegada que gera dano à coletividade) foi narrado, apesar de não haver menção expressa ao dispositivo legal. STF. 2ª Turma. HC 129284/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 17/10/2017 (Info 882).



Na narrativa deve constar as qualificadoras e as causas de aumento, não sendo preciso incluir as circunstâncias agravantes, uma vez que elas podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, conforme art. 385 do CPP. Em que pese tal previsão no Código, parcela da doutrina critica veementemente esse dispositivo legal, afirmando que implica em violação ao princípio acusatório e à própria imparcialidade do magistrado.

Concluindo, é requisito essencial, uma vez que peça acusatória sem narrativa dos fatos ou com narrativa frágil é causa de rejeição da denúncia ou da queixa-crime, em razão de ser inepta (art. 395, I, do CPP).

### 8.1.2. CLASSIFICAÇÃO DO DELITO

É a tipicidade ou a definição jurídica do fato, que não vincula a defesa e o juiz, já que o acusado se defende dos fatos narrados.

Na sentença, o juiz julga adstrito aos fatos narrados na exordial acusatória. Neste momento, sobretudo em se levando em consideração a não alteração fática durante a instrução processual, é possível a aplicação da *emendatio libelli*, prevista no art. 383 do CPP. Leva-se em consideração os fatos, mesmo que a capitulação não seja a adequada.

Na *emendatio*, mantém-se os fatos narrados com todos as circunstâncias, adequando-se apenas a capitulação, para condenar aquele réu na capitulação correta, ainda que mais grave, nos termos do art. 383 do CPP.

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 1º Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 2º Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

Por isso que é imprescindível, obrigatório, essencial, a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias e, por outro lado, a classificação da infração pode vir a ser alterada pelo magistrado no momento de proferir a sentença penal condenatória.

**Atenção:** como visto, o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia, não de sua classificação jurídica, que pode, ao final, ser modificada pelo juiz, aplicando-se o art. 383 do CPP. O erro na classificação jurídica não traz a inépcia da denúncia, já que o juiz poderá corrigi-lo, conforme entende o STF:

Constando da denúncia a narração de fatos ligados à conduta do acusado, descabe tê-la como inepta, incumbindo ao MP a prova das acusações (STF, HC 92.258/SP).

### 8.1.3. INDIVIDUALIZAÇÃO DO ACUSADO

Em relação à individualização do acusado, é indispensável saber quem cometeu a infração penal. Não havendo qualificação completa, é preciso que estejam descritos elementos que deixem claro a identificação física do acusado.

Não é preciso retardar ou aguardar a qualificação completa para o oferecimento da peça inicial acusatória. Logo, em conjunto, deve ser feita a leitura do art. 259 do CPP, isso porque, a qualquer tempo, quando descoberta a qualificação completa, será feita a retificação nos autos.

Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.

#### 8.1.4. ROL DE TESTEMUNHAS

É elemento facultativo, pois em alguns casos pode não haver testemunha do fato. Exemplos: delito às escondidas que só tem o relato da vítima; e delito de natureza financeira ou tributária, em que se consegue comprovar a materialidade e indícios de autoria por documentos ou perícias em computadores.

Sobre o tema, atenção à seguinte jurisprudência:

O Ministério Público poderá emendar a inicial acusatória, desde que antes da formação da relação processual, para incluir o rol de testemunhas. Reflexo do princípio da cooperação (STJ, RHC 37.587/SC – Informativo nº 577).

Além dos elementos formais previstos no art. 41 do CPP, outros podem ser apontados, a saber:

#### 8.1.5. PEDIDO DE CONDENAÇÃO

O pedido de condenação é genérico, não precisa o órgão acusatório pleitear o quanto de pena que deseja ser aplicada ao réu, se condenado, bastando a solicitação tão somente da condenação, como retrato da procedência (total ou parcial) da pretensão punitiva estatal.

#### 8.1.6. ENDEREÇAMENTO

O autor da ação penal deverá indicar o órgão jurisdicional competente para processá-la e julgá-la, em que pese o erro quanto ao endereçamento não ser causa de inépcia da inicial (STF, RHC 60.216).

#### 8.1.7. NOME E ASSINATURA

A peça acusatória deve conter o nome e a assinatura do autor da ação.

Segundo os Tribunais Superiores e posição doutrinária dominante, a ausência de assinatura na denúncia, todavia, não ensejará a obrigatória rejeição da peça acusatória ou a nulidade *ab initio* do processo, caso não haja dúvidas acerca da autenticidade da peça acusatória, ou quando for facilmente identificável aferir quem a elaborou (STJ, HC 124.903/MG).

### 8.2. PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA

Em regra, tratando-se de investigado preso, o prazo para oferecimento de denúncia é de 5 dias e, estando o investigado solto, é de 15 dias.

Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.

Já na Lei de Drogas, será de 10 dias, tanto tratando-se de investigado preso como solto.



Art. 54. Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar uma das seguintes providências:

I - requerer o arquivamento;

II - requisitar as diligências que entender necessárias;

III - oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes.

Na Lei dos Crimes Contra a Economia Popular (Lei nº 1.521/51), será de 2 dias, tanto tratando-se de investigado preso como solto.

“Art. 10. § 2º. O prazo para oferecimento da denúncia será de 2 (dois) dias, esteja ou não o réu preso.”

No Código Eleitoral (Lei nº 1.521/51), será de 10 dias, tanto tratando-se de investigado preso como solto.

“Art. 357. Verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro do prazo de 10 (dez) dias.”

|                                                                       | Investigado Preso | Investigado Solto |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| CPP<br>(art. 46)                                                      | <b>5 dias</b>     | <b>15 dias</b>    |
| Lei de Drogas<br>(art. 54, inciso III)                                | <b>10 dias</b>    | <b>10 dias</b>    |
| Crimes Contra a Economia Popular<br>(art. 10, § 2º da Lei nº 1521/51) | <b>2 dias</b>     | <b>2 dias</b>     |
| Código Eleitoral<br>(art. 357)                                        | <b>10 dias</b>    | <b>10 dias</b>    |

**Atenção:** o prazo para oferecimento de denúncias nos crimes de imprensa, previsto na Lei nº 5.250/67, não mais subsiste, tendo em vista que o STF decidiu pela não recepção de toda essa lei (ADPF 130/DF).

O prazo para oferecimento de denúncia é impróprio, pois, passado o prazo, a denúncia ainda poderá ser proposta. Esse prazo se inicia a partir do momento em que o Ministério Público recebe os autos do IP ou as peças de informação, as quais irão subsidiar o oferecimento da denúncia.

O cuidado deve existir naqueles casos em que o investigado estiver preso e não seja observado o prazo previsto em lei. Nesse caso, haverá constrangimento legal se a prisão for mantida, devendo ocorrer imediatamente a determinação de soltura do suposto autor do fato. Em havendo investigados presos e soltos, conta-se o prazo como se todos estivessem presos.

### 8.3. PRAZO PARA OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME

O prazo para oferecimento da queixa-crime está previsto no art. 38 do CPP, ou seja, tudo o que foi abordado para a representação aplica-se à queixa-crime. Logo, o prazo para queixa-crime como regra é de seis meses, prazo de natureza decadencial, contado da data do conhecimento

do autor do fato. No caso de ação penal privada subsidiária da pública, o prazo de seis meses será contado não da data do conhecimento do autor do fato, mas sim quando caracterizada a inércia do Ministério Público, ou seja, quando esgotado o prazo de oferecimento de denúncia sem qualquer atuação do órgão acusatório. Os prazos deverão ser contados na forma do art. 10 do CP.

Cuidado com as exceções. A primeira está prevista no art. 236, parágrafo único do CP; e a segunda, no art. 529 do CPP.

Art. 236 - Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Parágrafo único - A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento.

Art. 529. Nos crimes de ação privativa do ofendido, não será admitida queixa com fundamento em apreensão e em perícia, se decorrido o prazo de 30 dias, após a homologação do laudo.

Parágrafo único. Será dada vista ao Ministério Público dos autos de busca e apreensão requeridas pelo ofendido, se o crime for de ação pública e não tiver sido oferecida queixa no prazo fixado neste artigo.

A primeira hipótese trata-se da chamada ação penal personalíssima, na qual temos um único caso na nossa legislação (art. 236, parágrafo único, do CP). Nesse caso, os seis meses do prazo da queixa-crime não serão contados da data em que se conhece o autor do crime, mas sim do trânsito em julgado da sentença que reconhece o erro ou o impedimento para a anulação daquele casamento.

A outra hipótese ocorre nos crimes contra a propriedade material que deixa vestígio. A partir da data da homologação do laudo, começa a correr o prazo da queixa-crime. No entanto, nesse caso, o prazo será de trinta dias e não de seis meses.

#### Atenção:

a) mesmo que a queixa-crime tenha sido apresentada perante juízo incompetente, o certo é que o seu simples ajuizamento é suficiente para obstar a decadência, interrompendo seu curso (STJ, RHC 25.611/RJ);

b) a demora na conclusão do inquérito policial não interrompe o prazo decadencial;

c) crime continuado: na hipótese de delitos praticados na forma do art. 71, do CPP, o prazo decadencial conta-se individualmente, para cada delito, regra idêntica à contagem da prescrição, conforme art. 119 do CP (NUCCI, 2008, p. 204);

d) crime permanente e crime habitual: conta-se da mesma forma da regra, ou seja, quando se sabe quem é o autor do delito, começa a correr o prazo decadencial de seis meses. Se houver o término do prazo de seis meses e ainda assim o crime persistir, continua sendo possível o oferecimento da ação penal, mas apenas para os fatos posteriores aos seis meses já vencidos (NUCCI, 2008, p. 205);

e) nos crimes de ação penal privada, caso o querelado esteja preso, tem o querelante o prazo de cinco dias para o ajuizamento da ação (interpretação extensiva da doutrina e da jurisprudência). O comum é de que o querelado esteja solto e o prazo para o querelante ajuizar a ação privada seja de seis meses. No entanto, na hipótese excepcionalíssima de o querelado estar preso por aquele processo, deverá ser adotado o prazo de preso para oferecimento de denúncia.

#### 8.4. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OU DA QUEIXA-CRIME

É preciso fundamentar o recebimento da peça inicial acusatória?



Segundo a jurisprudência dominante, é dispensável que o juiz fundamente o recebimento da denúncia ou da queixa-crime. O recebimento não se caracteriza como um ato decisório, pois influi o princípio do *in dubio pro societate*. Nesse sentido:

Esta Corte de Justiça, em consonância com o posicionamento adotado pelo STF, consagrou o entendimento da inexigibilidade de fundamentação complexa no despacho de recebimento da denúncia, dada a sua natureza interlocutória (STJ, HC 228.034/RJ).

Questiona-se: e nos procedimentos em que é apresentada uma defesa preliminar, que antecede o recebimento da inicial, como nos casos de crimes funcionais afiançáveis ou Lei nº 9.099/95?

Nesse caso, será necessária a fundamentação. Isso porque a defesa preliminar estabelece um contraditório inicial. Neste sentido, não há sentido em uma norma prever uma defesa preliminar e o juiz não enfrentar as questões ali trazidas antes do recebimento da denúncia. Portanto, para receber a exordial acusatória, deve o magistrado afastar as teses da defesa.

## 8.5. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA E DA QUEIXA-CRIME

O art. 395 do CPP estabelece que a denúncia ou a queixa serão rejeitadas quando:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Parágrafo único. (Revogado).

Forem manifestamente ineptas: será inepta quando não conter os requisitos essenciais analisados no art. 41 do CPP: descrição do fato com suas circunstâncias e descrição do acusado, de forma que permita a sua individualização física, ao menos. A decisão que rejeita a denúncia produz apenas coisa julgada formal, eis que não entra no mérito da causa;

Faltarem pressupostos processuais ou condições para o exercício da ação penal;

Faltar justa causa para o exercício da ação penal: é o suporte probatório mínimo, fundado na presença de materialidade e indícios suficientes de autoria. Isso porque a instauração de um processo penal já atinge de alguma forma o *status dignitatis* da própria pessoa. O STJ entende que se for o caso de aplicação do princípio da insignificância, é cabível o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, pois o fato seria atípico, não legitimando o oferecimento da denúncia.

**Atenção:** o STF possui jurisprudência no sentido de que resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória (HC 112.206/SP).

## 9. CAUSAS DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE

### 9.1. DECADÊNCIA

Está prevista no art. 38 do CPP e foi detalhada nos tópicos anteriores.

Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

Parágrafo único. Verificar-se-á a decadência do direito de queixa ou representação, dentro do mesmo prazo, nos casos dos arts. 24, parágrafo único, e 31.





**Atenção:** a decadência se aplica tanto na ação penal pública condicionada à representação como na ação penal privada.

**Atenção:** a decadência atinge também a ação penal privada subsidiária da pública. O art. 38 do CPP trata do assunto em sua parte final, dispondo que o prazo decadencial de seis meses, nesse caso (art. 29 do CPP), é contado do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. No entanto, a perda de tal prazo pela vítima não enseja a extinção de punibilidade, caracterizando-se a chamada decadência imprópria. Isto é, o único efeito dessa decadência é a exclusão de legitimidade do ofendido para a propositura da ação penal privada subsidiária da pública, autorizando, ainda, que o Ministério Público inicie a ação como seu autor. Portanto, esse prazo não atinge o Estado-acusação, de forma que o Ministério Público mantém o dever de denunciar, até que ocorra a prescrição (NUCCI, 2008, p. 212).

## 9.2. RENÚNCIA

Possui natureza jurídica de causa de extinção da punibilidade, conforme art. 107, V, do CP.

“Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;”

Significa abrir mão do direito de oferecer queixa-crime e é consequência do princípio da oportunidade ou conveniência, característico da ação penal privada. Se a vítima renunciar ao direito de processar um dos autores do fato, o ato se estenderá aos demais, ocorrendo a extinção de punibilidade de todos, por decorrência dos arts. 48 e 49 do CPP:

“Art. 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade.”

“Art. 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá.”

A renúncia ocorre antes do oferecimento da ação penal e é ato unilateral, ou seja, independe de aceitação do suposto autor do fato para a produção de efeitos, diferentemente do instituto do perdão.

Pode ser tácita, como a prática de ato incompatível com o desejo de oferecer a queixa-crime, ou expressa, oferecendo a vítima um documento constando expressamente o seu desejo de renunciar.

Art. 50. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais.

Parágrafo único. A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 (dezoito) anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro.

“Art. 57. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova.”

Havendo mais de uma vítima do fato, caso uma delas renuncie, não impedirá o direito de a outra vítima oferecer queixa-crime em face dos autores da infração.

**Atenção:** o art. 74, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, prevê uma modalidade de renúncia a ser aplicada tanto na ação penal privada como na ação penal pública condicionada à representação. A composição civil dos danos devidamente homologada acarreta renúncia ao direito de queixa-crime ou representação.





Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecurável, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.

Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação.

### 9.3. PERDÃO

O perdão é uma causa de extinção da punibilidade (art. 107, V, do CP) que possui relação direta com o princípio da disponibilidade (ocorre no curso do processo). Depois de iniciada a ação penal privada, o querelante pode perdoar o autor do delito até o trânsito em julgado da sentença. Não é por acaso que os artigos do CPP a respeito (por exemplo, o art. 51), fala em “querelado” ou em “querelante”, nomenclaturas que só existem quando já iniciadas a ação penal e antes de finalizada em definitivo. Atenção aos seguintes artigos do CP:

“Art. 105 - O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta ao prosseguimento da ação.”

“Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;”

“Art. 106 - O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito: § 2º - Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória.”

O perdão feito a um dos querelados se estenderá a todos (em decorrência do princípio da indivisibilidade) e é bilateral, que, para ter efeito, depende da aceitação do querelado. Assim, aquele que não o aceitar, continuará a ser processado. Os demais terão extinta a punibilidade.

**Atenção:** o querelado terá o prazo de três dias para dizer se aceita ou não e, permanecendo em silêncio, tal fato ensejará na aceitação e consequente extinção do processo.

Art. 106 - O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito:

I - se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita;

II - se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros;

III - se o querelado o recusa, não produz efeito.

§ 1º - Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação.

§ 2º - Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória.

“Art. 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar.”

Art. 58. Concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de três dias, se o aceita, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o seu silêncio importará aceitação.

Parágrafo único. Aceito o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade.

O perdão pode ser processual – feito nos próprios autos — ou extraprocessual, não se exigindo ratificação em juízo (art. 106 do CP e art. 56 do CPP), expresso ou tácito, pessoalmente ou por procurador especialmente para isso. Além disso, pode ser demonstrado por todos os meios de prova, conforme art. 57 do CPP.

“Art. 56. Aplicar-se-á ao perdão extraprocessual expresso o disposto no art. 50.”



“Art. 57. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova.”

Havendo mais de um querelante, o perdão do ofendido não compromete a ação dos demais querelantes.

**Atenção:** o art. 54 do CPP diz que se o querelado for menor de 21 anos, deverá ser observado o art. 52 do CPP quanto à aceitação do perdão. Este dispõe que se o querelante for menor de 21 anos e maior de 18 anos, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. Portanto, pela letra da lei, não há necessidade de que haja sempre o consentimento do representante legal. Ocorre que, hoje, em virtude das modificações há muito feitas no Código Civil quanto à maioridade, não há mais necessidade de qualquer intervenção do representante legal do querelado em tais casos, podendo ele mesmo, desde que maior de 18 anos, aceitar o perdão, sem necessidade de ratificação daquele.

“Art. 54. Se o querelado for menor de 21 anos, observar-se-á, quanto à aceitação do perdão, o disposto no art. 52.”

“Art. 52. Se o querelante for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito.”

Atenção à tabela comparativa:

| RENÚNCIA                                                                                                                                      | PERDÃO                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decorre do princípio da oportunidade/conveniência.                                                                                            | Decorre do princípio da disponibilidade.                                                                                                                    |
| É ato unilateral.<br>(Não depende de aceitação do querelado.)                                                                                 | É ato bilateral.<br>(Depende de aceitação do querelado.)                                                                                                    |
| Concedida antes do início do processo.                                                                                                        | Pode ser concedido após o início do processo até decisão definitiva.                                                                                        |
| Por força do princípio da indivisibilidade, a renúncia em relação a um autor do fato se estende aos demais, produzindo efeito quanto a todos. | Por força do princípio da indivisibilidade, o perdão em relação a um querelado se estende aos demais, apenas produzindo efeitos para aqueles que aceitaram. |

#### 9.4. PEREMPÇÃO (ART. 60 DO CPP)

A perempção também é uma causa de extinção da punibilidade, presumindo-se o desinteresse do querelante na ação penal. É a perda do direito de prosseguir no exercício da ação penal privada em virtude da negligência/desídia do querelante.

Ocorre nos casos listados no art. 60 do CPP:

Art. 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal:

I - quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos;



II - quando, falecendo o querelante, ou sobrevivendo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36;

III - quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais;

IV - quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor.

**Atenção:** não cabe o reconhecimento da perempção em face da desídia do querelante no curso da ação penal privada subsidiária da pública. Nesse caso, a titularidade da ação deve ser retomada pelo Ministério Público, por se tratar de ação penal pública na origem, conforme art. 29 do CPP. É o que a doutrina denomina ação penal indireta.

## 10. CASOS ESPECIAIS

### 10.1. AÇÃO PENAL NOS CRIMES CONTRA A HONRA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO PRATICADO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES (SÚMULA Nº 714, STF)

De acordo com o artigo 145 do CP, a regra dos crimes contra a honra é que eles são ação penal privada, uma vez que somente se procedem mediante queixa-crime. Contudo, o parágrafo único traz como uma das exceções justamente os crimes contra a honra de funcionário público em razão das funções exercidas (art. 141, II, do CP). Nesse caso, a regra abre espaço para a exceção legal que indica serem tais delitos manejados mediante ação penal pública condicionada à representação. Vejamos:

Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.

Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do *caput* do art. 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3º do art. 140 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.033, de 2009)

Ocorre que o STF admite tanto o manejo de queixa-crime (ação privada), como também denúncia, após representação (ação pública condicionada). Leia com atenção o seguinte entendimento sumulado:

Súmula nº 714: “É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.”

Na hipótese de o funcionário público optar pela representação ao Ministério Público e este arquivar representação por entender não ser o caso de oferecimento da denúncia, pode a vítima propor queixa-crime? De acordo com a jurisprudência do STF, fica preclusa a outra possibilidade, conforme HC 84.659/MS:

I. Ação penal: crime contra a honra do servidor público, *propter officium*: legitimação concorrente do MP, mediante representação do ofendido, ou deste, mediante queixa: se, no entanto, opta o ofendido pela representação ao MP, fica-lhe preclusa a ação penal privada: *electa una via*... II. Ação penal privada subsidiária: descabimento se, oferecida a representação pelo ofendido, o MP não se mantém inerte, mas entendendo insuficientes os elementos de informação, requisita a instauração de inquérito policial. (HC 84659, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 29/6/2005, DJ 19-08-2005 PP-00046 EMENT VOL-02201-02 PP-00384.)



**Atenção:** note que a Súmula nº 714, STF, afirma se tratar de “concorrência de legitimidade”. De acordo com parcela relevante da doutrina (TÁVORA, 2020), ao falar em “legitimidade concorrente” poderíamos inferir que o funcionário público poderia retomar a legitimidade para ajuizar queixa-crime, o que não ocorre, conforme ementa de jurisprudência acima. Dessa forma, apesar de parcela da doutrina apontar a atecnia na redação da súmula, na prova deverá ser respondido que se trata de legitimidade concorrente. Conforme ensina Eugênio Pacelli, caberá ao ofendido fazer a opção da legitimidade “concorrente” entre a utilização da ação penal privada e ação penal pública condicionada à representação.

## 10.2. AÇÃO PENAL NOS CRIMES DE LESÕES CORPORAIS LEVES E CULPOSAS NA LEI MARIA DA PENHA (ART. 41, DA LEI Nº 11.340/06)

Em regra, o crime de lesão corporal é processado mediante ação penal pública incondicionada. Excepcionalmente, porém, no caso da lesão dolosa de natureza leve e culposa, o oferecimento da ação penal dependerá de representação da vítima ou de seu representante legal (art. 88 da Lei nº 9.099/95).

No caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, de aplicação da Lei Maria da Penha, o STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 4424), pacificou a questão, reconhecendo que o art. 41 da Lei nº 11.340/06 não viola a Carta Maior.

“Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.”

AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – NATUREZA. A ação penal relativa a lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada – considerações. (ADI 4424, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/2/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31/7/2014 PUBLIC 01/8/2014)

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – GÊNEROS MASCULINO E FEMININO – TRATAMENTO DIFERENCIADO. O artigo 1º da Lei nº 11.340/06 surge, sob o ângulo do tratamento diferenciado entre os gêneros – mulher e homem –, harmônica com a Constituição Federal, no que necessária a proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a cultura brasileira. COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. O artigo 33 da Lei nº 11.340/06, no que revela a conveniência de criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, não implica usurpação da competência normativa dos estados quanto à própria organização judiciária. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – REGÊNCIA – LEI Nº 9.099/95 – AFASTAMENTO. O artigo 41 da Lei nº 11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a Lei nº 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no § 8º do artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coíbam a violência no âmbito das relações familiares. (ADC 19, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/2/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28/4/2014 PUBLIC 29/4/2014.)

Desse modo, a Lei nº 9.099/95 não se aplica aos casos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) e isso acarreta diversas consequências, sobretudo no que diz respeito à espécie de ação penal nos crimes de lesão corporal dolosa (mesmo que de natureza leve) cometido contra a mulher no ambiente doméstico e familiar, a qual dispensará a representação da ofendida e será da natureza pública incondicionada. No mesmo sentido, anos após, o STJ editou a seguinte súmula:

Súmula nº 542, STJ: “A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.”

## 11. CONCEITOS IMPORTANTES

### 11.1. AÇÃO PENAL SECUNDÁRIA

A lei estabelece uma modalidade de ação para um determinado crime. Se ocorrer uma circunstância especial, ou se determinado fato estiver presente, secundariamente haverá uma nova espécie de ação penal para aquele fato delituoso. Ex.: Em regra, o crime de injúria é de ação penal privada. Porém, se o crime for cometido contra o Presidente da República, se procederá mediante ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça, bem como se cometido o crime na modalidade de injúria racial (CP, art. 140, § 3º), a ação penal será pública condicionada à representação.

Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.

Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do *caput* do art. 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3º do art. 140 deste Código.

### 11.2. AÇÃO PENAL ADESIVA

Tem conceito divergente na doutrina. Para a primeira corrente, é a possibilidade de militarem no polo ativo o Ministério Público e o querelante quando houver conexão ou continência entre crimes de ação penal pública e privada ("litisconsórcio ativo"; uma dupla legitimação entre o Ministério Público e o Querelante). Para a segunda corrente, ocorre nos casos em que, não obstante o crime praticado seja de ação penal privada, o Ministério Público, vislumbrando ofensa a um bem jurídico maior, avoca o domínio da lide e promove ele mesmo o ajuizamento da ação por meio de uma denúncia. O ofendido (querelante), assim, interviria no processo apenas na qualidade de assistente. Segundo Tourinho Filho, no ordenamento jurídico alemão, o Ministério Público pode oferecer ação penal privada, desde que visualize a presença de interesse público. Nesse caso, o ofendido pode se habilitar como parte acessória.

### 11.3. AÇÃO PENAL INDIRETA

Caso o Ministério Público, titular da ação penal pública se mantenha inerte, estará o ofendido autorizado a propor ação penal privada subsidiária da pública. Verifica-se que o Ministério Público estará inerte quando escoados os prazos do art. 46 do CPP sem que o órgão tenha oferecido denúncia, requisitado novas diligências à polícia judiciária, requerido o declínio de competência ou promovido o arquivamento do inquérito policial. Extrai-se da leitura do art. 29 do CPP que o Ministério Público poderá retomar a titularidade da ação penal a qualquer tempo, caso o ofendido se mostre negligente. É a chamada ação penal indireta. É assim porque a ação penal privada subsidiária da pública é uma ação penal pública na origem e não perde sua natureza.

Art. 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

### 11.4. AÇÃO PENAL POPULAR

Segundo o entendimento prevalente, não foi recepcionada pela CF como ação criminal. Em geral, costuma-se mencionar o *habeas corpus*, porque ele pode ser proposto por qualquer pessoa. Todavia, o *habeas corpus* não é uma ação penal e sim possui natureza jurídica de ação de impugnação. Logo, não é possível raciocinar como uma ação penal comum. Trata-se de ação de

natureza constitucional, vocacionada à proteção do *status libertatis*. O segundo exemplo de ação penal popular mencionado pela doutrina é a faculdade de qualquer cidadão oferecer denúncia contra agentes políticos pela prática de crimes de responsabilidade. A título de exemplo, a Lei nº 1.079/50 dispõe que é permitido a qualquer cidadão denunciar o Presidente da República ou Ministros de Estado, por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. Ocorre que o termo “denúncia”, empregado no art. 14, não é usado no sentido de oferecer peça acusatória na ação penal pública, mas sim no de ser mera *notitia criminis*.

“Art. 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o Presidente da República ou Ministro de Estado, por crime de responsabilidade, perante a Câmara dos Deputados.”

#### **11.5. AÇÃO PENAL PÚBLICA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA**

Ocorre quando o Ministério Público com atribuição legal não maneja a ação penal pública, mostrando-se inerte, e a lei manda que seja acionado outro órgão do próprio Ministério Público – leitura do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 201/67; art. 27 da Lei 7492/86; e art. 109, § 5º, da Constituição Federal.

#### **11.6. AÇÃO DE PREVENÇÃO GERAL**

É aquela iniciada com o fito de aplicar exclusivamente ao demandado medida de segurança. Exemplo: sentença absolutória imprópria (art. 386, parágrafo único, III, do CPP).

#### **11.7. AÇÃO PENAL DE SEGUNDO GRAU**

É aquela oferecida diretamente nos tribunais, dispensando, portanto, a atuação do juiz de primeiro grau.

#### **11.8. AÇÃO PENAL EX OFFICIO**

É aquela proposta pelo juiz ou pela autoridade policial. No entanto, desde a promulgação da CF de 1988 adotou-se o sistema acusatório, agora reforçado pela Lei Anticrime, razão pela qual a ação penal pública será sempre proposta por seu titular, Ministério Público, conforme art. 129, I, da CF/88, — salvo na hipótese de inércia, quando se admite a ação penal privada subsidiária da pública. A ação penal privada será proposta pelo legitimado por meio de queixa.

### **12. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA**

#### **12. 1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL**

Súmula nº 524, STF: “Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.”

Súmula nº 554, STF: “O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não obsta ao prosseguimento da ação penal.”

Súmula nº 609, STF: “É pública incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal.”

Súmula nº 709, STF: “Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.”

Súmula nº 714, STF: “É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.”





Informativo nº 813, STF: Não oferecida a queixa-crime contra todos os supostos autores ou partícipes da prática delituosa, há afronta ao princípio da indivisibilidade da ação penal, a implicar renúncia tácita ao direito de querela, cuja eficácia extintiva da punibilidade estende-se a todos quantos alegadamente hajam intervindo no cometimento da infração penal. STF. 1ª Turma. Inq 3526/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 2/2/2016 (Info 813).

Informativo nº 898, STF: “No momento da denúncia, prevalece o princípio do *in dubio pro societate*.” STF. 1ª Turma. Inq 4506/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/4/2018 (Info 898).

## 12.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Informativo nº 577, STJ: Deve ser rejeitada a queixa-crime que, oferecida antes de qualquer procedimento prévio, impute a prática de infração de menor potencial ofensivo com base apenas na versão do autor e na indicação de rol de testemunhas, desacompanhada de Termo Circunstanciado ou de qualquer outro documento hábil a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a autoria e a materialidade do crime. STJ. 5ª Turma. RHC 61822-DF, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 17/12/2015 (Info 577).

Informativo nº 645, STJ: A jurisprudência se consolidou no sentido de que a natureza jurídica da remuneração pela prestação de serviço público, no caso de fornecimento de energia elétrica, prestado por concessionária, é de tarifa ou preço público, não possuindo caráter tributário. Não há como se atribuir o efeito pretendido aos diversos institutos legais, considerando que o disposto no art. 34 da Lei nº 9.249/1995 e no art. 9º da Lei nº 10.684/2003 fazem referência expressa e, por isso, taxativa, aos tributos e contribuições sociais, não dizendo respeito às tarifas ou preços públicos. Desse modo, no caso de furto de energia elétrica mediante fraude, o adimplemento do débito antes do recebimento da denúncia não extingue a punibilidade. STJ. 3ª Seção. RHC 101.299-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. Acd. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 13/3/2019 (Info 645).

É cabível a condenação do querelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao advogado do querelado. O princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada. Em outras palavras, é possível haver condenação em honorários advocatícios em ação penal privada. Assim, julgada improcedente a queixa-crime, é cabível a condenação do querelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao advogado do querelado. Conclusão que se extrai da incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade, o que permite a aplicação analógica do art. 85 do CPC/2015, conforme previsão constante no art. 3º do CPP. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 992.183/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 7/6/2018. STJ. Corte Especial. EDcl na APn 881/DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 3/10/2018.

“A denúncia que deixa de mencionar a legislação complementar a que se refere o tipo penal não atende o disposto no art. 41 do CPP **porque não descreve por completo a conduta delitiva, dificultando a compreensão da acusação e, por conseguinte, o exercício do direito de defesa.**” STJ. 5ª Turma. RHC 64430/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 19/11/2015.

## QUESTÕES

**1-(2020/CESPE/MPE-CE/Promotor de Justiça de Entrância Inicial)** João sofreu calúnia, mas veio a falecer dentro do prazo decadencial de seis meses, antes de ajuizar ação contra o ofensor. Ele não tinha filhos e mantinha um relacionamento homoafetivo com Márcio, em união estável reconhecida. João era filho único e tinha como parente próximo sua mãe. Nessa situação hipotética, o ajuizamento de ação pelo crime de calúnia

- a) deverá ser realizado por curador especial, a ser nomeado para essa finalidade.
- b) somente poderá ser promovido pela mãe de João.



- c) poderá ser realizado pelo Ministério Público.
- d) poderá ser realizado por Márcio.
- e) não é cabível, haja vista a morte de João.

**2- (2020/IBFC/TRE-PA/Analista Judiciário)** No que se refere às disposições do Código de Processo Penal sobre a ação penal, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F):

( ) Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

( ) O Ministério Público não poderá desistir da ação penal.

( ) Qualquer pessoa poderá intentar a ação privada.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V
- b) V, V, F
- c) V, F, V
- d) F, F, V

**3- (2019/MPE-GO/MPE-GO/Promotor de Justiça – adaptada)** No que se refere às ações penais, julgue os dois itens. I - A ação penal secundária está relacionada às hipóteses em que a lei estabelece que a apuração do crime será feita por meio de uma determinada modalidade de ação penal, prevendo, contudo, secundariamente, diante do surgimento de circunstâncias especiais, uma nova espécie de ação para aquela mesma infração. É o que se dá, por exemplo, com o crime de exercício arbitrário das próprias razões. II - A ação penal deve vir acompanhada de justa causa, que é o lastro probatório mínimo de que houve a prática de um crime. Em determinados crimes, por exemplo, como na lavagem de dinheiro e na receptação, é preciso que se demonstre uma justa causa duplicada.

**4- (2019/VUNESP/TJ-RJ/Juiz Substituto)** Oferecendo o ofendido ação penal privada subsidiária da pública, o Ministério Público, nos exatos termos do art. 29 do CPP,

- a) perde interesse processual e deixa de intervir nos autos.
- b) pode intervir em todos os termos do processo, contudo, sem capacidade recursal.
- c) perde a possibilidade de representar pelo arquivamento do inquérito e não pode repudiar a queixa.
- d) pode aditar a queixa.
- e) deixa de ser parte e passa a atuar como custos legis e não pode, por exemplo, fornecer elementos de prova.

**5- (2019/FGV/MPE-RJ/Analista processual)** Através do oferecimento de denúncia, o Ministério Público inicia um processo em que se imputa a determinada pessoa um crime de ação penal pública. Com base nas previsões do Código de Processo Penal, existem formalidades legais que devem ser observadas pelo Promotor de Justiça no momento de apresentar a inicial acusatória. A denúncia deverá conter:

- a) a classificação do crime, a qual não vincula o magistrado, que poderá dar nova classificação jurídica no momento da sentença com base em novos fatos descobertos durante a instrução, ainda que sem qualquer alteração da inicial acusatória;
- b) a qualificação do acusado, mas, caso sua identificação através do nome seja desconhecida, poderão constar esclarecimentos pelos quais possa ser identificado, tornando certa a identidade física;
- c) a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, não podendo a agravante da reincidência ser reconhecida se não imputada na inicial acusatória;
- d) a classificação do crime, que vinculará o magistrado no momento da sentença, ainda que não haja necessidade de alteração dos fatos narrados;
- e) o rol de testemunhas, computando-se no limite máximo as testemunhas referidas.

**6- (2017/VUNESP/TJ-SP/Juiz Substituto)** A legitimidade para a propositura de ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções é

- a) exclusiva do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido.
- b) concorrente do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido.
- c) concorrente do ofendido, mediante representação, e do Ministério Público, mediante ação pública incondicionada.
- d) exclusiva do ofendido, mediante queixa.

**7- (2017/CS-UFG/TJGO/Juiz Leigo)** Conforme dispõe expressamente o Código de Processo Penal, o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de

- a) 3 dias.
- b) 5 dias.
- c) 7 dias.
- d) 10 dias.
- e) 15 dias.

**8- (2017/IBFC/TJ-PE/Oficial de Justiça)** Sobre a ação penal privada, analise os itens abaixo.

I. A ação penal privada é uma modalidade de procedimento criminal cuja iniciativa é de exclusividade da vítima por meio do oferecimento de Queixa-crime. É observável apenas quando do cometimento de crimes contra a honra e dignidade sexual.

II. Ocorrerá a perempção do direito de ação quando o querelante se abster de fazer pedido condenatório na exordial acusatória.

III. Na hipótese de falecimento do ofendido, terão legitimidade para propor a ação penal privada o cônjuge da vítima, seus ascendentes, descendentes e irmãos, nesta ordem.

IV. O prazo para o exercício do direito de Queixa é de 6 (seis) meses, contados da data de consumação do delito.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I e II estão corretos.
- b) Apenas I e IV estão corretos.
- c) Apenas II e III estão corretos.
- d) Apenas II e IV estão incorretos.

**9- (2017/IBFC/TJ-PE/Oficial de Justiça)** A ação penal pública é de iniciativa exclusiva do Ministério Público e tem por objetivo dar concretude *ao jus puniendi* estatal. Acerca dessa modalidade de ação penal, assinale a alternativa correta.

- a) O prazo para oferecimento da denúncia é de 5 (cinco) dias, caso o acusado esteja preso, e de 20 (vinte) dias se estiver em liberdade.
- b) O Ministério Público poderá dispor da ação penal, podendo dela desistir sempre que achar adequado à defesa da coletividade, independentemente do eventual crime praticado pelo acusado.
- c) Quando do oferecimento da denúncia é imprescindível a qualificação do acusado.
- d) O direito de representação somente poderá ser exercido pessoalmente, vedada a sua realização por meio de procurador.
- e) Caberá ao Ministro da Justiça apresentar requisição para o prosseguimento de ação penal pública nos casos previstos em lei em que se verifica o cometimento de crimes em face do Presidente da República. A requisição é ato administrativo irrevogável e não há prazo legal para a sua apresentação.

**10- (2017/CESPE/PJC-MT/Delegado de Polícia Substituto)** Assinale a opção correta no que se refere à ação penal.

- a) Aplica-se a perempção como forma extintiva da punibilidade às ações penais exclusivamente privadas e às ações privadas subsidiárias das públicas.
- b) O princípio da indivisibilidade, quando não observado, impõe ao juiz a rejeição da denúncia nas ações penais públicas.
- c) Há legitimidade concorrente do ofendido e do MP para a persecução de crimes contra a honra de funcionário público em razão de suas funções.
- d) Na ação penal privada, todas as manifestações de disponibilidade pelo ofendido serão extensivas a todos os réus e(ou) responsáveis pelo fato delituoso, independentemente de qualquer reserva ou condição apresentada por eles.
- e) Diante de concurso formal entre um delito de ação penal pública e outro de ação penal privada, caberá ao representante do MP oferecer denúncia em relação aos dois crimes.

**11- (2017/FCC/TRE-PR/Analista Judiciário – área judiciária)** Sobre as diversas modalidades de ação penal, é correto afirmar:

- a) Em caso de morte do ofendido, o direito de intentar a ação privada propriamente dita se transmite ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão da vítima.

- b) O prazo decadencial para o oferecimento da requisição pelo Ministro da Justiça na ação penal condicionada é de seis meses.
- c) A ação penal privada subsidiária da pública fere o comando constitucional que atribui ao Ministério Público a titularidade da ação penal.
- d) Com a revogação do crime de adultério, deixou de existir no ordenamento jurídico brasileiro a chamada ação penal privada personalíssima.
- e) A perempção poderá ser reconhecida em qualquer momento do inquérito policial, bem como antes ou, ainda, após iniciada a ação penal.

## COMENTÁRIOS

1. Gabarito: D. “Art. 24, §1º, CPP –No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.”

A companheira, em união estável homoafetiva reconhecida, goza do mesmo *status* de cônjuge para o processo penal, possuindo legitimidade para ajuizar a ação penal privada. STJ. Corte Especial. APn 912-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 7/8/2019 (Info 654).

2. Gabarito: B. Atenção à leitura dos artigos 24, 30 e 42, todos do CPP.

3. Gabarito: Ambos os itens CORRETOS. Trazem a exata conceituação de ação penal secundária e de justa causa no processo penal.

4. Gabarito: D, nos termos do art. 29 do CPP.

5. Gabarito: B.

a) ERRADA. Se há nova classificação jurídica COM BASE EM NOVOS FATOS, tem-se o instituto da *mutatio libelli* (384, CPP). Nesse caso a denúncia ou queixa deverá ser aditada pelo Ministério Público.

b) CORRETA. Com base no artigo 381, CPP.

c) ERRADA. Independente da agravante estar explicitada na inicial acusatória o juiz deverá reconhecê-la ao proferir a sentença, nos termos do art. 387, I, do CPP.

d) ERRADA. Não é a classificação do crime que vincula o juiz, mas sim os FATOS NARRADOS.

e) ERRADA. Testemunhas referidas não são previstas inicialmente para depor. Elas surgem quando uma testemunha (arrolada) as indicam como detentoras de algum conhecimento que pode ajudar na elucidação dos fatos. De acordo com o art. 401, § 1º, do CPP, não se computam no limite máximo de testemunhas aquelas que não prestem compromisso e as referidas.

6. Gabarito: B. Súmula nº 714, STF: “É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.”

7. Gabarito: B, conforme art. 46 do CPP.

8. Gabarito: C.

Item I: INCORRETO. Exclusividade da vítima para oferecimento de queixa apenas na ação privada personalíssima (cabível apenas no crime do art. 236). Se pensar em ação penal privada *lato sensu*, incluindo a subsidiária da pública, a segunda parte também fica falsa.

Item II: CORRETO. Art. 60, CPP.

Item III: CORRETO. Art. 31, CPP.

Item IV: INCORRETO. Não é contado da data da consumação do delito. Art. 38, CPP: “contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso de ação privada subsidiária da pública, do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia.”

9. Gabarito: E.

a) INCORRETA. O prazo para oferecimento no caso de acusado solto é de 15 dias, conforme art. 46 do CPP.

b) INCORRETA. Por força do art. 42, do CPP, além do Princípio da Indisponibilidade da Ação Penal ou, de igual forma, conhecido como Princípio da Indesistibilidade, consiste na ideia de que, depois de iniciada ação penal, o

Ministério Público não pode dispor desta por meio da desistência, afinal a ação visa a defesa de um direito do Estado e não de somente um indivíduo. A mesma força principiológica também é vista nos recursos já interpostos, conforme art. 576, do CPP.

c) INCORRETA. De acordo com o art. 41, CPP, a denúncia ou queixa contera a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Nem sempre o Ministério Público possuirá nesse momento todos os dados do criminoso para oferecer a denúncia.

d) INCORRETA. Nos termos do art. 39, do CPP: “O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial.”

e) CORRETA. A requisição é ato de natureza política por meio do qual o Ministro da Justiça autoriza a propositura da ação penal por parte do Ministério Público em determinados delitos. A requisição pode ser feita a qualquer tempo enquanto não estiver extinta a punibilidade, não vincula o Ministério Público no sentido da obrigatoriedade da propositura da ação. Mesmo havendo requisição, compete ao Ministério Público o exame da presença dos requisitos necessários ao oferecimento da denúncia.

#### 10. Gabarito: C.

a) INCORRETA. No processo penal, a perempção resulta da inércia do querelante no curso da ação penal privada, impedindo a demanda de prosseguir, acarretando a extinção da punibilidade do querelado. As hipóteses estão no art. 60, CPP. A perempção apenas se aplica à ação penal privada exclusiva, e não na subsidiária à pública.

b) INCORRETA. Entendimento majoritário é no sentido que a indivisibilidade é aplicável apenas na ação penal privada (STJ).

c) CORRETA. Súmula nº 714 do STF: “É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.”

d) INCORRETA. Quanto ao perdão, ele aproveitará a todos os querelados, mas não produzirá efeitos em relação ao que o recusar.

e) INCORRETA. Quando há concurso formal entre um crime de ação penal pública e outro de ação penal privada, o órgão do Ministério Público não pode oferecer denúncia em relação aos dois. É imprescindível que se forme um litisconsórcio entre o Promotor e o titular do *jus querelandi*, para que ambos os delitos sejam objeto de acusação e possam ser apreciados conjuntamente na sentença, aplicando-se o disposto no art. 77, II, do CPP. Cada ação penal é promovida por seu titular, nos termos do art. 100, *caput*, do CP.

#### 11. Gabarito: A.

a) CORRETA. De acordo com o art. 31 do CPP.

b) INCORRETA. No caso de Ação Penal Pública mediante Requisição do Ministro da Justiça não há prazo para requisição (diferentemente da representação, que fica submetida ao prazo decadencial de 6 meses do conhecimento da autoria da AP). O Ministro da Justiça fica adstrito ao prazo prescricional do delito.

c) INCORRETA. A ação penal privada subsidiária da pública não fere o comando constitucional que atribui ao Ministério Público a titularidade da ação penal. Isso porque o Ministério Público continua sendo o titular da ação, sendo conferido à vítima apenas uma legitimação extraordinária. Destaque-se que, nessas hipóteses, o Ministério Público pode retomar a ação penal em caso de negligência da vítima.

d) INCORRETA. Ainda existe um caso de Ação Penal Privada Personalíssima, qual seja, a do art. 236 do CP.

e) INCORRETA. A perempção, instituto que se opera nas ações penais privadas, está prevista no art. 60, CPP, e acontece naqueles casos em que o autor é negligente, como uma forma de sanção. Isto é, ocorre durante a ação penal e não antes desta.

## CAPÍTULO 9 – DA AÇÃO CIVIL EX DELICTO (ARTS. 63 A 68 DO CPP)

### 1. INTRODUÇÃO

O tema da ação civil é daqueles que não podem ser estudados de forma isolada, possuindo múltiplas incidências normativas. São diversos os dispositivos que cuidam do tema e que serão estudados nesse capítulo, como os artigos 63 a 68, bem como o art. 387, IV, todos do Código de Processo Penal; os artigos 91 e 92 do Código Penal; o disposto no art. 313 e 509 do Código de

Processo Civil; e os artigos 927 e seguintes do Código Civil. Cuida-se em estudar quais os efeitos civis que podem ser gerados pela prática de uma infração penal.

No Brasil, adotou-se o sistema da independência entre a instância civil e a penal, no que toca à reparação do dano causado pela infração penal. Porém, trata-se de uma independência mitigada, eis que pode a ação penal condenatória servir de título executivo judicial (ação de execução *ex delicto*), mas, independentemente, é possível o ajuizamento da ação civil própria (ação civil *ex delicto*).

São, portanto, dois os possíveis caminhos a serem perseguidos para obtê-la. O primeiro está no art. 63 e o segundo no art. 64, ambos do CPP. Serão os caminhos analisados de forma detalhada.

## 2. AÇÃO DE EXECUÇÃO *EX DELICTO* (ART. 63 DO CPP)

### 2.1. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

O art. 63 do CPP traz a hipótese em que o ofendido pode aguardar a sentença penal condenatória para a execução do título judicial e obtenção da reparação do dano. Essa opção é chamada pela doutrina de ação de execução *ex delicto*.

A sentença penal condenatória, depois de transitada em julgado, produz diversos efeitos. Um deles é exatamente que a condenação gera a obrigação de o réu reparar o dano causado:

Código Penal

Art. 91 - São efeitos da condenação: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

A sentença penal condenatória transitada em julgado, inclusive, é título executivo judicial, conforme previsão do art. 515, VI, do CPC.

“Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;”

Só terá eficácia civil a sentença penal condenatória que tenha transitado em julgado. Se não houve, então não poderá ter início a execução do valor mínimo de indenização fixada na sentença e o processo de liquidação para se chegar à parte líquida do valor total de indenização.

Poderão propor a ação civil *ex delicto*: a) a vítima (ofendido); b) o seu representante legal; ou c) seus herdeiros (caso a vítima tenha morrido). De posse da sentença que condenou o réu, após o seu trânsito em julgado, o legitimado dispõe de um título que poderá ser executado no juízo cível para cobrar o ressarcimento pelos prejuízos sofridos em decorrência do crime. Cuidado que aqui podem ser quaisquer dos sucessores/herdeiros existentes e não somente cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Veja o que diz o CPP:

Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do *caput* do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido.

Pode ser proposta apenas contra o autor do crime, em decorrência do princípio da personalidade ou princípio da intranscendência da pena. Nesse sentido, Pacelli (2019, p. 203) que entende que “na hipótese de execução de sentença penal condenatória, o título executório é, obviamente, dirigido apenas contra o condenado”.

## 2.2. ANÁLISE DO ART. 387, IV, DO CPP

O art. 387, IV, do CPP, dispõe que o juiz, quando for proferir a sentença condenatória, fixará um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Veja a previsão legal:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (Vide Lei nº 11.719, de 2008)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

Antes da Lei nº 11.719/2008, que introduziu o art. 387, IV, no CPP, apesar de na sentença condenatória estar reconhecida a obrigação de indenizar, por se tratar de um efeito automático, não era possível que a vítima executasse imediatamente a sentença porque não havia sido definido o valor da indenização. Isto é, a sentença condenatória reconhecia que a vítima tinha o direito à indenização a ser paga pelo condenado, mas não dizia o quanto era devido. Trazia, portanto, um título executório incompleto, porque embora tornasse certa a exigibilidade do crédito, dependia de liquidação para apurar o *quantum* devido.

Com a valorização dos princípios da economia e celeridade processual e considerando que a legislação penal brasileira sempre buscou incentivar o ressarcimento à vítima, surgiu a necessidade de se repensar esse sistema, justamente para que se possa proteger com maior eficácia o ofendido, evitando que o alto custo e a lentidão da justiça levem a desistir de pleitear a indenização civil.

Dentro desse novo panorama, o legislador tentou facilitar a situação da vítima e, por meio da Lei nº 11.719/2008, alterou o CPP, prevendo que o juiz, ao condenar o réu, já estabeleça na sentença um valor mínimo que o condenado estará obrigado a pagar a título de reparação dos danos causados. O que surge, a partir da Lei nº 11.719/08, é a quantificação de um valor mínimo, ainda na esfera penal, dando liquidez a um título que era previsto.

De modo, viabilizou-se que, na esfera criminal, seja fixado montante mínimo à indenização dos danos eventualmente sofridos pela vítima do crime, permitindo a imediata execução, não se obstando, por outro lado, que o *quantum* total venha a ser ainda debatido no cível e eventualmente descontado, se for o caso, o valor já arbitrado.

Desse modo, se o juiz, na própria sentença, fixar um valor certo para a reparação dos danos, não será necessário que a vítima ainda faça a liquidação, bastando que execute este valor caso não seja pago voluntariamente pelo condenado. Assim, a vítima poderá executar, desde já, esse valor mínimo e, em relação aos danos totais efetivamente sofridos, deverá ser liquidado para depois ser executado.

No que se refere ao tema da lei processual penal no tempo, é preciso saber se a previsão do art. 387, IV, do CPP, é norma mista ou norma processual.

Doutrina minoritária (DEZEM, 2019, p. 348) entende que a previsão é norma processual penal pura, sendo regida pelo art. 2º do CPP com eficácia imediata. No entanto, o STF consolidou o entendimento de que essa norma, incluída pela Lei nº 11.719/08, é de natureza híbrida ou mista e que, portanto, possuindo um cenário desfavorável ao réu – diante da possibilidade de se ver condenado não somente na infração penal, mas também a uma reparação cível –, não poderá retroagir. Assim, nos delitos cometidos antes da alteração do CPP, não há como fixar valor mínimo. Logo, deverá liquidar a sentença no juízo cível, na forma do sistema anterior. Veja a ementa abaixo:

FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DA REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DO DELITO (ART. 387, IV, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PEDIDO ACOLHIDO APENAS EM PARTE. (...) 3. Afasta-se a estipulação de valor mínimo prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito. 4. Revisão criminal parcialmente procedente. (STF, RvC nº 5.437, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/3/15).



Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, para que seja fixado o valor da reparação, deverá haver pedido expresso e formal do Ministério Público (na denúncia – ação penal pública) ou do ofendido (na queixa-crime – ação penal privada). Confira o julgado abaixo:

(...) Este Tribunal sufragou o entendimento de que deve haver pedido expresso e formal, feito pelo parquet ou pelo ofendido, para que seja fixado na sentença o valor mínimo de reparação dos danos causados à vítima, a fim de que seja oportunizado ao réu o contraditório e sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. (...) (AgRg no AREsp 389.234/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 8/10/2013)

Além disso, o STJ decidiu que o juiz somente poderá fixar este valor se existirem provas nos autos que demonstrem os prejuízos sofridos pela vítima em decorrência do crime. Dessa feita, é importante que o Ministério Público ou eventual assistente de acusação junte comprovantes dos danos causados pela infração para que o magistrado disponha de elementos para a fixação de que trata o art. 387, IV, do CPP. Vale ressaltar, ainda, que o réu tem direito de se manifestar sobre esses documentos juntados e contraditar o valor pleiteado como indenização. Nesse sentido:

A fixação da reparação civil mínima também não dispensa a participação do réu, sob pena de frontal violação ao seu direito de contraditório e ampla defesa, na medida em que o autor da infração faz jus à manifestação sobre a pretensão indenizatória, que, se procedente, pesará em seu desfavor. (...) (REsp 1236070/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/3/2012)

No mesmo sentido o STJ (STJ, REsp 1.193.083-RS; e STJ, AgRg no REsp 1.206.643/RS). E na linha da jurisprudência firmada, anote-se a seguinte manifestação doutrinária acerca da matéria: “Não pode este arcar com qualquer montante se não tiver tido a oportunidade de se defender, produzir prova e demonstrar o que, realmente, seria, em tese, devido” (NUCCI, Guilherme. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017).

Dessa forma, como visto, junto com a sentença penal, haverá uma sentença cível líquida que, mesmo limitada, estará apta a ser executada. E quando se fala em sentença cível, em que se apura o valor do prejuízo causado a outrem, vale lembrar que, além do prejuízo material, também deve ser observado o dano moral que a conduta ilícita ocasionou. E nesse ponto, embora a legislação tenha introduzido essa alteração em 2008, até hoje não estabeleceu qual o grau de sua abrangência, pois apenas se referiu no dispositivo legal à “apuração do dano efetivamente sofrido”. Assim, para que se possa definir esses parâmetros, deve-se observar o escopo da própria alteração legislativa: promover maior eficácia ao direito da vítima em ver ressarcido o dano sofrido.

Considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de o fazer. Desse modo, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, no momento de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do CPP), pode quantificar o valor do dano moral sofrido pela vítima. (STJ, REsp 1.585.684-DF.)

Quanto à Lei Maria da Penha, o STJ estabeleceu que o dano é *in re ipsa*. Assim fixou em repetitivo (tema 983):

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (STJ, 3ª Seção, REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/2/2018, DJe 8/3/2018).



O julgador, no entanto, não está obrigado a sempre fixar o valor mínimo de reparação de dano. Em algumas situações ele não estará apto, exemplos: a) quando não houver prova do prejuízo; b) se os fatos forem complexos e a apuração da indenização demandar dilação probatória, o juízo criminal poderá deixar de fixar o valor mínimo, que deverá ser apurado em ação civil ; etc.) quando a vítima já tiver sido indenizada no juízo cível.

### 2.3. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA IRRECORRÍVEL DE CRIMES AMBIENTAIS

Sempre que possível, o juiz, na sentença penal condenatória por crime ambiental, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, poderá a execução ser efetuada pelo valor fixado na sentença, sem prejuízo da liquidação para a descoberta e reparação do valor efetivamente sofrido. Veja o art. 20 da Lei nº 9.605/98:

Art. 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do *caput*, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido.

Note que a redação é bastante similar à do CPP.

### 2.4. SENTENÇA QUE CONCEDE O PERDÃO JUDICIAL

Prevê a Súmula nº 18 do STJ que “a sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório”. De acordo, portanto, com a literalidade da súmula, não se poderia falar em execução da sentença em face da ausência de efeito condenatório. No entanto, para uma corrente doutrinária, a sentença que concede o perdão judicial possui natureza condenatória podendo ser executada no juízo cível. Nesse sentido, Nucci (2018, p. 240) e Távora e Alencar (2020, p. 200).

### 2.5. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM PAÍS ESTRANGEIRO

Será possível a execução no juízo cível após a homologação pelo STJ no Brasil, nos termos do art. 105, I, *i*, da CF/88.

### 2.7. EXTINÇÃO DAS PRETENSÕES PUNITIVA E EXECUTÓRIA

Se houver extinção da pretensão punitiva, não será possível a sua execução no juízo cível, pois não haverá a formação de título executivo judicial. Nesse sentido, atenção ao julgado:

Extinta a condenação pela prescrição, extingue-se também a condenação pecuniária fixada como reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV do CPP, pois dela decorrente, ficando ressalvada a utilização de ação cível, caso a vítima entenda que haja prejuízos a serem reparados (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1260305/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2013).

De modo diverso, se houver extinção da pretensão executória, ainda será possível a execução no juízo cível, pois todos os efeitos secundários da condenação persistem, como a obrigação de reparar os danos causados.



## 2.6. INADEQUAÇÃO DA VIA DO *HABEAS CORPUS* PARA IMPUGNAÇÃO DO VALOR FIXADO

A via processual do *habeas corpus* não é adequada para impugnar a reparação civil fixada na sentença penal condenatória, com base no art. 387, IV, do CPP, tendo em vista que a sua imposição não acarreta ameaça, sequer indireta ou reflexa, à liberdade de locomoção (STJ. 6ª Turma. AgRg no AgRg no REsp 1519523/PR).

## 2.7. REVISÃO CRIMINAL E ELIMINAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL

Atenção quando houver revisão criminal ajuizada em face de sentença penal condenatória irrecorrível acarretando posterior desconstituição da condenação. Note que a decisão terá o condão de eliminar o título executivo, que é a sentença condenatória proferida anteriormente. Desse modo, caso não tenha sido iniciada a execução penal ou ela esteja se desenvolvendo, faltará título executivo para o início ou continuidade desta execução (DEZEM, 2019, p. 351; NUCCI, 2018, p. 342; BADARÓ, 2018, p. 221).

Caso já tenha sido feito o pagamento na esfera cível e tenha sido extinta a execução pelo pagamento, não poderá haver repetição de indébito contra o exequente devendo a pretensão do então condenado voltar-se contra o Estado, seja pela via da revisão criminal, seja pela via de ação de conhecimento em primeiro grau (DEZEM, 2019, p. 351 e BADARÓ, 2018, p. 221). Em sentido contrário, Grego Filho (2013, p. 150) entende que é admissível a repetição do indébito. Além disso, para Nucci (2018, p. 342), “é possível a ação de restituição, onde se poderia então debater a culpa do pretense autor de ato ilícito”.

## 2.8. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO FIXADO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA E CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE

O art. 4º, I, da Lei nº 13.869/2019 possui conteúdo correlato ao que vem sendo estudado nos arts. 63 e 387, IV, ambos do CPP. O dispositivo da nova lei dispõe que é efeito da condenação, dentre outros, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, mas prevê expressamente a necessidade de requerimento do ofendido para que o juiz possa fixar, na sentença penal condenatória, o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

## 2.9. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO (ART. 593 DO CPP) PARA IMPUGNAR DECISÃO A RESPEITO DA FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO

Caso haja pedido expresso de valor mínimo de reparação dos danos, mas o magistrado deixar de reconhecê-lo ou mesmo fixar em valor que desagrade o ofendido, é possível a interposição de recurso de apelação, nos termos do art. 593 do CPP.

No caso de o juiz deixar de reconhecer o valor mínimo de reparação de danos, podem recorrer tanto o Ministério Público (que fez o requerimento na inicial acusatória) como a vítima, na condição de assistente de acusação.

No caso de o juiz ter fixado valor, no entanto, esse desagradar a vítima, apenas esta poderá recorrer na condição de assistente de acusação, faltando interesse ao Ministério Público, já que atendido o seu pedido da inicial.

## 3. AÇÃO CIVIL EX DELICTO (ART. 64 DO CPP)

### 3.1. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Mesmo que a sentença penal ainda não tenha transitado em julgado, a vítima, seu representante legal ou herdeiros poderão buscar a reparação dos danos no juízo cível. Não é preciso aguardar decisão irrecorrível. O CPP prevê essa possibilidade:

Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil. (Vide Lei nº 5.970, de 1973)

Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta, até o julgamento definitivo daquela.

**Atenção:** essa demanda é conhecida na doutrina como ação civil *ex delicto*. Tecnicamente, portanto, existe diferença entre a ação de execução (art. 63 do CPP) e a ação civil *ex delicto* (art. 64 do CPP). No entanto, alguns doutrinadores chamam ambas as demandas pelo gênero *ação civil ex delicto*.

Poderão propor a ação civil *ex delicto*: a) a vítima (ofendido); b) o seu representante legal; ou c) seus herdeiros (caso a vítima tenha morrido).

Já no polo passivo, diferentemente da ação de execução, poderá constar não apenas o autor do fato, mas também o responsável civil, conforme previsão do art. 64 do CPP. Atenção aos responsáveis pela reparação civil constantes do art. 932 do CC:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia.

**Atenção:** só pode o responsável cível ser sujeito passivo da ação civil *ex delicto*. No caso de execução do título judicial (sentença penal condenatória), apenas o autor do fato condenado que poderá integrar o polo passivo (princípio da pessoalidade). A previsão, entretanto, é criticada pela doutrina. Dezem (2019, p. 349) exemplifica

uma situação em que alguém que esteja a mando de outrem, de um empregador, acabe por cometer um crime de dano. Imaginemos o caso do entregador de pizza que quando vai levar a pizza para a residência acaba cometendo crime de dano no trânsito. A questão reside em saber se a sentença que condena o entregador de pizza pelo crime de dano poderá se voltar contra o proprietário da pizzeria ou contra a pizzeria quando da liquidação da sentença na esfera cível. (...) entendemos que a violação do contraditório e do devido processo legal é tamanha que não poderá em liquidação de sentença voltar-se contra o responsável legal do art. 932 do CC.

No mesmo sentido, Pacelli(2019, p. 203).

### 3.2. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO CIVIL

O parágrafo único do art. 64 do CPP menciona a possibilidade de o juízo cível suspender a ação cível se ele entender ser necessário.

Pacelli (2019, p. 197) entende que

o vocábulo poderá, constante do citado no art. 64, parágrafo único, do CPP, confere verdadeiro poder discricionário ao juiz cível, acerca da conveniência da suspensão do processo naquela instância. Embora alguns autores entendam que esse termo contemplaria verdadeiro dever, entendemos que a hipótese é mesmo de discricionariedade. Isso porque, somente a partir do exame do estágio de



desenvolvimento procedimental de um e de outro processo (a ação cível e a penal) é que se poderá avaliar a conveniência de se suspender o processo no cível.

Para Tourinho Filho (2013, p. 287), “não é faculdade do juiz, uma vez que o texto legal usa da expressão poderá, parecendo revelar uma simples faculdade do Juiz do Cível em suspender ou não o andamento da ação civil. Esse poderá, contudo, deve converter-se num deverá para que se evitem decisões conflitantes”.

A doutrina majoritária e a jurisprudência firmaram entendimento pela suspensão facultativa, a depender da fundamentação concreta do juízo cível:

É faculdade do juiz cível suspender a ação reparatória de danos morais até a resolução definitiva do processo criminal caso julgue haver prejudicialidade entre as demandas. Não há nulidade devido ao processamento simultâneo, sobretudo quando demonstrada a ausência de prejuízo no caso concreto. Incidência dos princípios da independência das instâncias e da instrumentalidade das formas. (STJ, 3ª Turma, REsp 1677957/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018).

O art. 313, § 5º do CPC traz que a suspensão do processo no cível não poderá ultrapassar o prazo de um ano, ao fim do qual o juiz retomará obrigatoriamente a sua jurisdição.

### 3.3. PRAZO PRESCRICIONAL

Quando há ação penal em andamento, a prescrição no cível ficará suspensa. A partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória é que o prazo prescricional para a ação civil começa a ter curso. Deve-se ter atenção ao art. 200 do CC.

“Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.”

A prescrição se opera em três anos, de acordo com o art. 206, § 3º, V, do CC/02.

“Art. 206. Prescreve: (...);§ 3º Em três anos: (...);V - a pretensão de reparação civil;”

A jurisprudência do STJ reforça a previsão:

1. O art. 200 do Código Civil de 2002 dispõe que, “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”. 2. Agravo interno improvido. (STJ, 3ª Turma, Ag Int no REsp 1720865/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 1º/6/2018)

## 4. SITUAÇÕES QUE IMPEDEM A PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL EX DELICTO

### 4.1. ANÁLISE DOS ARTS. 65 A 67 DO CPP

É certo que tanto o juízo criminal como o cível buscam a verdade , em especial quando ambos analisam o mesmo fato. Entretanto, o critério de apreciação da prova no primeiro é um e , no segundo, é outro. Assim, pode o autor ter cometido um ato ilícito gerador do dever de indenizar, embora não tenha sido penalmente responsabilizado pelo fato. Em outras palavras, em regra, a existência de decisão penal absolutória não impede o prosseguimento da ação civil . Assume relevância, portanto, a análise dos arts. 65, 66 e 67 do CPP.

O art. 65 do CPP prevê as situações em que a sentença penal fará coisa julgada no juízo cível e deve ser lido em conjunto com o art. 188 do CC. Abaixo, ambos os dispositivos legais.

“Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.”

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.

A regra é que a absolvição por falta da ilicitude da conduta não enseja a possibilidade de reparação civil. Porém, a doutrina aponta duas exceções. Uma é o caso de *aberratio ictus* na legítima defesa, em que alguém é obrigado a se defender e, ao fazê-lo, atinge terceiro não envolvido no episódio, caso em que este último pode exigir indenização do causador do dano e este tem direito de regresso contra o agressor inicial.

Outra exceção ocorre no estado de necessidade: alguém, em estado de necessidade, para afastar perigo causado pelo outro, pode causar dano a terceiro; este terá direito à indenização e o causador do dano terá direito de regresso contra o causador do perigo.

O CPP prevê expressamente causas que não impedem o oferecimento da ação civil indenizatória. São as previsões dos arts. 66 e 67, ambos do CPP.

“Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.”

Dessa forma, a decisão criminal que não declara a inexistência material do fato permite o prosseguimento da execução do julgado proferido na ação cível ajuizada por familiar da vítima do ato ilícito (STJ, REsp 1117131/SC).

Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:

I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação;

II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;

III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.

O arquivamento do inquérito policial não atinge o direito de indenização, porque sequer se trata de decisão definitiva, eis que o caso pode ser reaberto com provas novas.

A decisão que julga extinga a punibilidade apenas afeta o direito do Estado de aplicar a lei penal. Porém, não há qualquer impedimento para a ação de indenização, pois o fato continua sendo considerado ilícito, sendo também um ilícito civil.

Um fato pode ser penalmente atípico, mas, ao mesmo tempo, um ilícito civil, capaz de gerar direito à indenização.

| Impede o Ajuizamento da Ação Civil Ex Delicto                                          | NÃO Impede o Ajuizamento da Ação Civil Ex Delicto                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Absolvição por estar provada a inexistência do fato (não há ilícito penal, nem civil). | Absolvição por não constituir o fato infração penal (atipicidade). |
| Absolvição por excludentes de ilicitude, com exceções que devem ser estudadas.         | Arquivamento do inquérito policial.                                |

|  |                                        |
|--|----------------------------------------|
|  | Extinção da punibilidade.              |
|  | Excludente da culpabilidade.           |
|  | Absolução por insuficiência de provas. |

#### 4.2. ANÁLISE DO ART. 386 DO CPP

A responsabilidade civil é independente da criminal, conforme afirma o art. 935 do CC. O dispositivo afirma também que não se pode mais questionar sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Essa é a ideia da eficácia preclusiva subordinante da sentença penal. Vejamos quais são os reflexos na ação civil *ex delicto* diante das hipóteses do art. 386 do CPP.

- a) **provada a inexistência do fato: não há responsabilidade civil;**
- b) **não haver prova da existência do fato: pode haver discussão na esfera cível;**
- c) **não constituir o fato infração penal: pode haver ilícito civil e dever de indenizar;**
- d) **estar provado que o réu não concorreu para a infração penal: não há responsabilidade civil;**
- e) **não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal: pode haver discussão na esfera cível;**
- f) **prova de excludente de culpabilidade: pode haver discussão na esfera cível;**
- g) **prova da excludente de ilicitude: g.1) legítima defesa: em regra, torna o ato ilícito também na esfera cível, sendo exceção o caso de *aberratio ictus*; g.2) estado de necessidade: em regra, torna o ato lícito também na esfera cível, sendo exceção o caso em que o lesado não foi o causador do perigo; g.3) estrito cumprimento de dever legal: torna o ato lícito também na esfera cível; g.4) torna o ato lícito também na esfera cível.**

#### 5. LEGITIMIDADE NO CASO DE INTERESSADO POBRE (ART. 68 DO CPP)

De acordo com o art. 68 do CPP, quem promoverá a ação de execução ou a ação *civil ex delicto* em favor da vítima “pobre” será o MP. Confirma o dispositivo legal:

“Art. 68. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre (art. 32, §§ 1º e 2º), a execução da sentença condenatória (art. 63) ou a ação civil (art. 64) será promovida, a seu requerimento, pelo Ministério Público.”

“Pobre”, na forma da lei, será aquele que não pode prover as despesas do processo sem privar-se dos recursos indispensáveis à sua manutenção ou de sua família.

O STF, contudo, entendeu que, a partir da Constituição Federal de 1988, essa legitimidade não mais pertence ao Ministério Público (e sim à Defensoria Pública). Isso porque o constituinte conferiu à Defensoria (e não ao MP) a competência para promover a assistência jurídica dos necessitados (art. 134 da CF/88).

Havia, no entanto, um problema de ordem prática: quando o STF proferiu essa decisão, a Defensoria Pública ainda não estava totalmente instalada nas diversas cidades do país (como ainda hoje, infelizmente, não está). Logo, seria prejudicial às vítimas se o STF simplesmente proibisse o MP de propor a ação civil *ex delicto* já que, na maioria dos lugares não havia Defensoria e o ofendido ficaria desassistido.

Por conta disso, o STF adotou a seguinte solução: ele declarou que o art. 68 do CPP estava em processo de inconstitucionalidade progressiva e que deveria continuar válido até que a Defensoria Pública estivesse totalmente instalada. Assim, nos locais onde há Defensoria Pública, o MP não pode ajuizar as ações de que trata o art. 68. Por outro lado, onde não existir a Defensoria, o *Parquet* continua tendo, ainda, legitimidade. Veja a ementa do julgado:



Ao Estado, no que assegurado constitucionalmente certo direito, cumpre viabilizar o respectivo exercício. Enquanto não criada por lei, organizada — e, portanto, preenchidos os cargos próprios, na unidade da Federação — a Defensoria Pública, permanece em vigor o artigo 68 do Código de Processo Penal, estando o Ministério Público legitimado para a ação de ressarcimento nele prevista. (STF. Plenário. RE 135328, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 29/6/1994).

Assim, naqueles Estados onde houver Defensoria Pública estruturada, será ela o órgão que irá promover a execução da sentença ou ajuizará a ação civil propriamente dita. Porém, naqueles Estados onde não houver a estrutura da Defensoria Pública, continuará o Ministério Público a agir.

Atenção porque essa situação (existência da Defensoria Pública) não acarreta, de pronto, simples extinção do processo sem julgamento do mérito. A extinção do feito antes da intimação da Defensoria pode ocasionar prejuízo irreparável à parte necessitada, que, até então, recebia assistência do Ministério Público. Antes de o magistrado reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil *ex delicto*, é indispensável que a Defensoria Pública seja intimada para tomar ciência da demanda e, sendo o caso, assumir o polo ativo da ação. Se essa providência não for adotada, haverá violação do art. 68 do CPP. Veja o julgado:

O reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público para, na qualidade de substituto processual de menores carentes, propor ação civil pública *ex delicto*, sem a anterior intimação da Defensoria Pública para tomar ciência da ação e, sendo o caso, assumir o polo ativo da demanda, configura violação ao art. 68 do CPP. STJ. 4ª Turma. REsp 888.081-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 15/9/2016 (Info 592).

## QUESTÕES

**1- (2020/CESPE/TJ-PA/Analista Judiciário)** Impede a propositura de ação civil indenizatória a decisão penal que

- a) arquivar o inquérito policial.
- b) julgar extinta a punibilidade do agente.
- c) reconhecer a inexistência material do fato.
- d) absolver o réu em razão de o fato imputado não constituir crime.
- e) absolver o réu em razão de não existir prova suficiente para sua condenação.

**2- (2019/MPE-SC/MPE-SC/Promotor de Justiça)** Segundo o Código de Processo Penal, não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil: o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação; a decisão que julgar extinta a punibilidade; e a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.

**3- (2019/CEBRASPE/TJDFT/Titular de Serviços de Notas e de Registros)** Joaquim foi vítima de crime de lesão corporal de natureza grave praticado, em tese, por Francisco, o que resultou em sérios prejuízos patrimoniais à vítima bem como em instauração de processo criminal contra o suposto autor do delito. Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta, considerando os dispositivos processuais que regem a ação civil *ex delicto*.

- a) Joaquim deverá aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, para, somente depois, executá-la na esfera cível.
- b) A absolvição de Francisco com base no reconhecimento de causa exculpante faz coisa julgada no juízo cível.
- c) Joaquim poderá propor ação civil *ex delicto*, de caráter cognitivo, valendo-se de cautelares do Código de Processo Penal para assegurar o patrimônio do réu que garanta indenização conferida pelo juízo cível.
- d) A requerimento de Joaquim, caso ele seja pobre, a ação civil poderá ser promovida pelo Ministério Público.
- e) A sentença penal absolutória que reconhecer, categoricamente, que a conduta de Francisco é materialmente atípica não impedirá a propositura da ação civil por Joaquim.



**4- (2018/COMPERVE/TJ-RN/Juiz leigo)** Jesuína é viúva de Américo, o qual foi vítima de homicídio. Segundo o Código de Processo Penal, durante a persecução penal no tocante à possibilidade de reparação de danos em favor de Jesuína,

- a) transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do *caput* do art. 387 daquele Código, dispensando-se a liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido.
- b) faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.
- c) diante de sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil não poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato.
- d) a sentença condenatória, mesmo sem trânsito em julgado, pode ser executada no juízo cível, para o efeito da reparação do dano pelo ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.

**5- (2018/CEBRASPE/TJ-CE/Juiz Substituto – adaptada)** Considerando a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção correta, acerca da ação civil *ex delicto*, da competência, da jurisdição e dos processos incidentes. Analise os itens a seguir. I - A sentença que concede o perdão judicial depois de reconhecida a culpa do réu enseja reparação civil *ex delicto*. II - A sentença absolutória do juízo criminal que declare a inexistência do fato ou que o réu não tenha concorrido para o crime faz coisa julgada no juízo cível, obstando a reparação civil *ex delicto*.

**6- (2017/CEBRASPE/TRE-BA/Analista Judiciário)** João foi vítima de um crime de furto praticado por Pedro. A res furtiva não foi recuperada pela vítima. Instaurado inquérito, apuraram-se a autoria e a materialidade e ofereceu-se a denúncia contra Pedro. Nessa situação hipotética, a propositura da ação civil *ex delicto* contra Pedro

- a) estará prejudicada, por haver litispendência.
- b) independará da existência da ação penal.
- c) será inadmissível, pois ninguém pode ser punido duas vezes pela prática do mesmo fato.
- d) dependerá do trânsito em julgado da sentença penal.
- e) dependerá da condenação do acusado por órgão jurisdicional colegiado.

**7- (2016/VUNESP/Prefeitura de Alumínio/SP/Procurador jurídico)** O termo inicial do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação de indenização por danos decorrentes de crime (ação civil *ex delicto*), de ação proposta contra empregador em razão de crime praticado por empregado no exercício do trabalho que lhe competia, é a data

- a) da prática do ato ilícito.
- b) da data da lesão.
- c) do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
- d) da data do conhecimento do fato por parte do titular lesado.
- e) da data do conhecimento do fato por parte do empregador.

**8- (2016/UFMT/TJ-MT/Analista judiciário)** Sobre a ação civil, assinale a afirmativa INCORRETA.

- a) A ação de ressarcimento de danos poderá ser proposta no juízo cível contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil.
- b) A decisão que julgar extinta a punibilidade não impedirá a propositura da ação civil.
- c) O despacho de arquivamento do inquérito não impedirá a propositura da ação civil.
- d) Intentada a ação penal, o juiz da ação civil não poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela.

**9- (2013/MPE-SP/MPE-SP/Promotor de Justiça Substituto)** Assinale a alternativa que está em desacordo com disposições legais relacionadas com reparação de danos causados pelo delito.

- a) É permitido ao juiz, na sentença condenatória criminal, estabelecer valor mínimo para a reparação de danos, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
- b) A sentença absolutória criminal, fundamentada no reconhecimento categórico da inexistência material do fato, obsta a propositura da ação civil.
- c) A ação civil para reparação do dano pode ser proposta pelo ofendido ainda que arquivado o inquérito policial instaurado para a apuração do delito.

- d) Tratando-se de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada, a homologação do acordo para a reparação do dano decorrente de infração penal de menor potencial ofensivo acarreta para o ofendido a renúncia ao direito de queixa ou de representação.
- e) Impede a propositura da ação civil a sentença absolutória no juízo criminal que decidir que o fato imputado não constitui crime.

**10- (2014/FCC/TJ-PA/Juiz Substituto)** Acerca da ação civil *ex delicto*, é correto afirmar:

- a) Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, fixado pelo Juiz na decisão condenatória, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido.
- b) O ofendido poderá optar por promover a execução, para o efeito da reparação do dano, no juízo cível ou criminal.
- c) A execução da sentença penal condenatória, para efeito da reparação do dano, é ato personalíssimo do ofendido e não se estende aos seus herdeiros.
- d) A ação para ressarcimento do dano não poderá ser proposta no juízo cível contra o autor do crime e o responsável civil enquanto pendente ação penal para apuração dos mesmos fatos.
- e) De acordo com o Código de Processo Penal, a decisão que julga extinta a punibilidade é causa impeditiva da propositura da ação civil.

### COMENTÁRIOS

1. Gabarito: C, conforme arts. 66 e 67, ambos do CPP.

2. Gabarito: item CORRETO, conforme art. 67 do CPP.

3. Gabarito: E.

- a) INCORRETA. A execução da sentença condenatória não se confunde com o direito de propositura da ação civil, que poderá ser intentada antes mesmo da decisão condenatória definitiva, com base no art. 64.
- b) INCORRETA. As causas exculpantes (causas excludentes de culpabilidade) não produzem coisa julgada no cível, possibilitando a ação de conhecimento para apurar culpa, diferentemente da situação do art. 65 do CPP.
- c) INCORRETA. A ação civil *ex delicto*, de caráter cognitivo, isto é, de conhecimento, de ressarcimento do dano, ou mesmo ação civil *ex delicto* em sentido estrito, é promovida no âmbito cível. Trata-se, de fato, de uma ação ordinária de indenização. Nesse contexto, não há que se falar em envolvimento de aplicação de cautelares previstas no Código de Processo Penal.
- d) INCORRETA. O art. 68 do CPP expressa que quando o titular do direito de reparação do dano for pobre nos termos do art. 32, § 1º, o Ministério Público é o legitimado para propor a ação que visa tal reparação. Entretanto, com o advento da Constituição Federal de 1988, foi criada a Defensoria Pública, com o escopo de defender e orientar juridicamente, em todos os graus, os interesses das pessoas de baixa renda. Dessa maneira, o STF decidiu a questão no sentido de que caso exista em determinado Estado a Defensoria Pública, esta será a legitimada para propor em nome do necessitado a ação civil *ex delicto*. Caso este órgão não exista, a legitimidade é do Ministério Público. Portanto, nas localidades em que surgir a Defensoria Pública, cessará para o Ministério Público a legitimidade para a propositura da ação civil *ex delicto*.
- e) CORRETA, conforme art. 67, III, do CPP.

4. Gabarito: B.

- a) INCORRETA. De acordo com o art. 63, parágrafo único, do CPP, transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do *caput* do art. 387 deste código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido.
- b) CORRETA, nos termos do art. 65 do CPP.
- c) INCORRETA. De acordo com o art. 66 do CPP, não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.
- d) INCORRETA. Apenas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme art. 63 do CPP.

5. Gabarito: item I – INCORRETO. O perdão judicial apaga todos os efeitos da condenação (Súmula nº 18, STJ). Dessa forma, a sentença que o concede, por si só, não enseja a reparação civil *ex delicto*, sendo necessário para essa finalidade que a vítima ajuíze a ação civil de indenização. Em que pese à divergência doutrinária, essa foi a

posição adotada pela banca examinadora nessa prova. Lembrando que para parte da doutrina, mesmo a sentença que concedeu o perdão judicial pode ser executada.

Item II – CORRETO, conforme art. 66 do CPP e art. 935 do CC.

**6.** Gabarito: B. A responsabilidade civil independe da penal, de maneira que é possível o desenvolvimento paralelo, e independente de uma ação penal e uma ação civil sobre o mesmo fato (CPP, art. 64, *caput*). Assim, se o ofendido ou seus herdeiros desejarem, não necessitarão aguardar o término da ação penal, podendo ingressar, desde logo, com ação civil reparatória (processo de conhecimento).

**7.** Gabarito: C. Nos termos do art. 200 do CC, quando a ação civil se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. A partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória é que o prazo prescricional para a ação civil começa a ter curso. Nessa hipótese, a prescrição opera-se no prazo de 3 (três) anos, consoante o art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

**8.** Gabarito: D.

a) CORRETA, conforme art. 64, *caput*, do CPP.

b) CORRETA, conforme art. 67, II, do CPP.

c) CORRETA, conforme art. 67, I, do CPP.

d) INCORRETA. Conforme art. 64, parágrafo único, do CPP, intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta, até o julgamento definitivo daquela.

**9.** Gabarito: E.

a) CORRETA, de acordo com o art. 387 do CPP.

b) CORRETA, de acordo com o art. 66 do CPP.

c) CORRETA, de acordo com o art. 67, I, do CPP.

d) CORRETA, de acordo com o art. 74, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

e) INCORRETA. Nos termos do art. 67, III, do CPP, não impedirá a propositura da ação civil a sentença absolutória no juízo criminal que decidir que o fato imputado não constitui crime.

**10.** Gabarito: A.

a) CORRETA, de acordo com o art. 63, parágrafo único, e art. 387, IV, ambos do CPP.

b) INCORRETA. A execução da sentença penal condenatória se dará no juízo cível.

c) INCORRETA. Nos termos do art. 63 do CPP, podem promover a execução o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.

d) INCORRETA. A ação cível pode ser proposta enquanto pendente processo criminal e ao juiz é facultado suspender o curso da ação cível até o julgamento definitivo da ação penal, nos termos do parágrafo único do art. 64 do CPP.

e) INCORRETA. Nos termos do art. 67, II, do CPP, a decisão que julga extinta a punibilidade não impede a propositura da ação cível.

## CAPÍTULO 10 – DA JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA (ARTS. 69 A 91, CPP)

### 1. JURISDIÇÃO

Por jurisdição entende-se "o poder atribuído, constitucionalmente, ao Estado para aplicar a lei ao caso concreto, compondo litígios e resolvendo conflitos", substituindo a vontade das partes, reconhecendo, satisfazendo ou assegurando o direito material de um dos polos da relação jurídica processual instaurada (NUCCI, 2016, p. 156).

Nesse contexto, considerando que, via de regra, a autotutela resta vedada, "coube ao Poder Judiciário a missão constitucional de certificar o direito, dirimindo as demandas que lhe são apresentadas" (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 375).

Portanto, em regra, o poder de aplicar o direito ao caso concreto compete ao Poder Judiciário, contudo, a própria Constituição Federal outorga a outros órgãos o exercício da jurisdição em situações específicas, como ocorre com o julgamento pelo Senado Federal de determinadas autoridades da República por crimes de responsabilidade, nos termos do art. 52 da CF/88 (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 375).

Assim, embora o exercício da jurisdição seja naturalmente vinculado ao Poder Judiciário, não se trata de uma competência exclusiva dos juízes e tribunais pátrios, o que se mostra bastante relevante para provas de concurso público.

#### 1.1. CARACTERÍSTICAS DA JURISDIÇÃO

Aduz a doutrina que a jurisdição é dotada de algumas características importantes, destacando-se:

##### 1.1.1. SUBSTITUTIVIDADE

Considerando que, em regra, não há possibilidade de autotutela, salvo em casos excepcionais, compete ao Estado-juiz, substituindo a vontade das partes, resolver os litígios a ele apresentados, sendo a substitutividade característica essencial do processo penal, já que somente o Estado pode aplicar uma sanção penal a alguém (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 385).

##### 1.1.2. INÉRCIA

A instauração da ação penal depende de iniciativa das partes, restando vedado ao juiz iniciá-la de ofício, isto é, sem provocação de algum de seus legitimados. O princípio da inércia é relacionado com a necessidade de justa composição do litígio e de absoluta imparcialidade do julgador, garantias estas que estariam comprometidas se fosse dada ao magistrado a faculdade de iniciar uma ação penal sem a provocação dos legitimados constitucionais – Ministério Público, mediante denúncia, e o particular, mediante queixa-crime. No processo penal condenatório, hoje, não há nenhuma exceção a esse princípio (AVENA, 2017, p. 431).

No ponto, cumpre ressaltar que o art. 26 do CPP, o qual previa que a ação penal, nas contravenções, seria iniciada com o APF ou por meio de portaria da autoridade judiciária ou policial (procedimento judicialiforme), não foi recepcionado pela CF/88, porquanto, em se tratando de ação penal pública, necessário o oferecimento de denúncia pelo MP (art. 129, inciso I, CF/88).

##### 1.1.3. LIDE

Em teoria geral do processo, estuda-se que a lide é o conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida. No processo penal, discute-se a existência de uma lide propriamente dita, porquanto "a acusação e a defesa estariam em busca do mesmo interesse, que é a realização de



justiça", sendo, na esfera penal, irrelevante a existência de conflito entre as partes, "pois o bem em jogo é indisponível" (TÁVORA; ALENCAR, p. 48).

#### 1.1.4. ATUAÇÃO DO DIREITO

É objetivo da atuação jurisdicional "aplicar o direito ao caso concreto, restabelecendo-se a paz social violada pela infração cometida" (TÁVORA; ALENCAR, p. 386).

Em relação à jurisdição processual penal, entende-se que seu exercício tem por finalidade primária proteger a liberdade alheia, já que somente há falar em restrição da liberdade de alguém se respeitado o devido processo legal. Secundariamente, a jurisdição penal objetiva a concretização pelo poder jurisdicional das normas abstratamente trazidas pelo legislador (TÁVORA; ALENCAR, p. 386).

#### 1.1.5. IMUTABILIDADE

Objetivando a pacificação social, o exercício da jurisdição deve ter caráter definitivo, isto é, em regra, o provimento jurisdicional, materializado na sentença penal transitada em julgado, não poderá sofrer modificações, salvo exceções, a exemplo da revisão criminal em benefício do réu (TÁVORA; ALENCAR, p. 386).

### 1.2. PRINCÍPIOS GERAIS DA JURISDIÇÃO

Além das citadas características, a doutrina ainda anota que, no processo penal, o exercício da jurisdição é regido por uma série de princípios, destacando-se:

#### 1.2.1. JUIZ NATURAL

Decorre da CF/88 ao dispor que ninguém será processado ou sentenciado por autoridade que não tenha competência fixada em normas predeterminadas (art. 5º, inciso LIII), o que abrange, também, a vedação ao juízo ou tribunal de exceção (art. 5º, inciso XXXVII) (AVENA, 2017, p. 431).

Conforme será mais bem analisado no capítulo atinente aos sujeitos processuais, o princípio constitucional do juiz natural exige que a determinação do juiz competente se dê por normas previamente estabelecidas, vedando-se designações casuísticas. É dizer: mesmo antes do cometimento de determinada infração penal, de antemão, já sabemos qual é o juízo competente para seu processo e julgamento.

#### 1.2.2. INVESTIDURA

Apenas quem estiver legalmente investido de jurisdição poderá exercê-la, isto é, somente tais sujeitos poderão aplicar o direito objetivo ao caso concreto (AVENA, 2017, p. 431).

#### 1.2.3. INDECLINABILIDADE

Nenhum juiz pode subtrair-se ao exercício da jurisdição, restando vedado, nesse sentido, o chamado *non liquet*, estando o magistrado, ainda que inexistir norma específica para o caso, impossibilitado de se abster de julgá-lo (AVENA, 2017, p. 431).

#### 1.2.4. INAFASTABILIDADE

De acordo com o art. 5º, inciso XXXV, CF/88, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.



### 1.2.5. IMPRORROGABILIDADE

Na esfera criminal, mesmo que entrem em acordo, as partes não podem subtrair ao juízo natural o conhecimento de determinada causa (NUCCI, 2016, p. 156).

### 1.2.6. INDELEGABILIDADE

Não pode o julgador transferir o poder jurisdicional a quem não o possui (NUCCI, 2016, p. 156).

No ponto, interessante assentar que, no caso da carta precatória ou de ordem, não há delegação de jurisdição, divergindo a doutrina quanto à natureza jurídica de tal fenômeno processual, isto é, se simples ato de cooperação ou delegação de competência.

Parcela da doutrina sustenta que só há falar em delegação de competência propriamente dita no caso da carta de ordem, tendo em vista que a autoridade expedidora poderia, por exemplo, produzir determinada prova, mas prefere transferir essa atribuição a outro magistrado. Segundo essa parcela da doutrina, no caso da carta precatória, há simples ato de cooperação, não havendo falar em delegação de competência, porquanto o juízo deprecante não possui poderes para produzir a prova, por conta própria, no juízo deprecado. Para eles, se o juízo deprecante não possui tal poder, por óbvio, não pode delegá-lo, já que ninguém pode delegar aquilo que não possui (NUCCI, 2016, p. 157).

Noutro giro, parcela da doutrina sustenta que, "tanto na precatória quanto na carta de ordem transmite-se a possibilidade de realizar atos jurisdicionais que a autoridade deprecada *não poderia fazer sem a autorização do deprecante*". Para eles, o fato dessa autorização decorrer de lei não retira a característica da delegabilidade da competência. Assim, para a referida parcela doutrinária, quando um juiz expede uma carta precatória para oitiva de uma testemunha em Comarca diversa, não está delegando jurisdição ao juiz da outra Comarca, porquanto este já a detém. Em verdade, o juiz deprecante está delegando o exercício da competência, isto é, o limite para o exercício jurisdicional (NUCCI, 2016, p. 157).

### 1.2.7. IRRECUSABILIDADE (OU INEVITABILIDADE)

Salvo nos casos de impedimento ou suspeição do magistrado, que serão estudados em capítulo próprio, não podem as partes recusar a atuação de determinado juiz (AVENA, 2017, p. 432).

### 1.2.8. UNIDADE

A jurisdição é una e indivisível, "diferenciando-se apenas no tocante à sua aplicação e ao grau de especialização, podendo ser civil – federal ou estadual; penal – federal ou estadual; militar – federal ou estadual; eleitoral ou trabalhista" (NUCCI, 2016, p. 156-157).

### 1.2.9. CORRELAÇÃO

Ao proferir sentença, o julgador deverá observar a exata correspondência entre sua decisão e os fatos narrados na inicial acusatória. Em decorrência do princípio em voga, conforme será visto em capítulo próprio, alterando-se a descrição fática da conduta, há necessidade de aditamento da inicial acusatória (*mutatio libelli*), nos termos do art. 384 do CPP.

## 2. COMPETÊNCIA

Por competência entende-se a "delimitação da jurisdição, ou seja, o espaço dentro do qual pode determinada autoridade judiciária aplicar o direito aos litígios que lhe forem apresentados, compondo-os" (NUCCI, 2016, p. 171).



Assim, considerando que se mostra humanamente impossível que o um juiz sozinho decida todos os litígios ocorridos, embora a jurisdição seja uma e indivisível, seu exercício deve ser partilhado entre diversos órgãos jurisdicionais, funcionando a competência, nesse sentido, como o limite da jurisdição, isto é, "o âmbito legislativamente delimitado, dentro do qual o órgão exerce o Poder Jurisdicional" (TÁVORA; ALENCAR, p. 386).

## 2.1. ESPÉCIES DE COMPETÊNCIA

A doutrina pátria, tradicionalmente, tem dividido a competência em quatro espécies, a saber:

I) Ratione materiae: nos termos do art. 69, inciso III, do CPP, a competência *ratione materiae* é aquela fixada em razão da natureza da infração penal praticada, como ocorre, por exemplo, no caso da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida (LIMA, 2019, p. 351);

II) Ratione functionae ou personae (foro por prerrogativa de função): nos termos do art. 69, inciso VII, do CPP, determinadas pessoas, em razão das funções por elas desempenhadas, serão processadas e julgadas originariamente por tribunais, como ocorre, por exemplo, com o Presidente da República, que será processado e julgado, no caso de infração penal comum, pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso I, alínea b, CF/88;

III) Ratione loci: nos termos do art. 69, inciso I e II, do CPP, a competência *ratione loci* é determinada em razão de critérios territoriais, isto é, objetiva identificar o juízo territorialmente competente (foro competente). Tem por parâmetros o local da consumação do delito (regra geral), além do domicílio ou residência do réu (TÁVORA; ALENCAR, p. 388);

IV) Competência formal: tem por critério de fixação os atos processuais, isto é, a competência é fixada por meio da distribuição legal de funções dos julgadores ao longo de um mesmo processo ou de um segmento ou de uma fase de seu regular desenvolvimento (LIMA, 2019, p. 352). Subdivide-se em três espécies:

IV.a) Competência funcional por fase do processo: a depender da fase do processo, a competência será exercida por determinado órgão jurisdicional, como ocorre, por exemplo, na divisão de competência entre o juízo do processo e o juízo das execuções, nos moldes dos arts. 65 e 66 da Lei de Execuções Penais (LIMA, 2019, p. 352);

IV.b) Competência funcional por objeto do juízo: cada órgão jurisdicional exerce a competência em relação a determinadas questões específicas a serem decididas no processo, como ocorre, por exemplo, no Tribunal do Júri, no qual compete ao Conselho de Sentença o julgamento acerca da existência do fato delituoso e de sua autoria. Ao juiz-presidente compete materializar a decisão dos jurados em sentença absolutória ou condenatória, dosando a pena, além de decidir outras questões de direito surgidas no decorrer da sessão de julgamento (LIMA, 2019, p. 352);

IV.c) Competência funcional por grau de jurisdição: a competência é dividida entre órgãos jurisdicionais superiores e inferiores, havendo processos que já nascem nos Tribunais (competência originária; competência por prerrogativa de função) e outros que os alcançam por intermédio da interposição de recursos (princípio do duplo grau de jurisdição) (LIMA, 2019, p. 352).

A doutrina, agrupando as espécies de competência funcional, diz que essa pode ser subdividida em duas classificações: **a) competência funcional horizontal**: ocorre no caso da competência funcional por fase do processo e por objeto do juízo, isto é, quando não existe hierarquia entre os órgãos jurisdicionais envolvidos; e **b) competência funcional vertical** ou

**hierárquica:** verifica-se no caso da competência funcional por grau de jurisdição, na qual há hierarquia entre os órgãos jurisdicionais envolvidos (LIMA, 2019, p. 352-353).

## 2.1.1. COMPETÊNCIA ABSOLUTA E COMPETÊNCIA RELATIVA

### 2.1.1.1. ESPÉCIES

Apesar de não existir disposição legal expressa quanto ao ponto, a doutrina e a jurisprudência são unânimes em dividir as espécies de competência em absoluta e relativa (LIMA, 2019, p. 353).

As competências do tipo absoluta, nas quais predomina o interesse público, têm origem em normas constitucionais, sendo inseridas nessa categoria as seguintes espécies: 1) competência em razão da matéria (*ratione materiae*); 2) competência por prerrogativa de função (*ratione personae* ou *funcionae*); e 3) competência funcional (LIMA, 2019, p. 353).

Em contrapartida, a competência do tipo relativa, em que há a predominância do interesse das partes, tem origem em normas infraconstitucionais, estando nela inseridas: 1) competência *ratione loci* (em razão do local), seja pelo lugar da infração, seja pelo domicílio ou residência do réu; 2) competência por prevenção (Súmula nº 706 do STF); 3) competência por distribuição; e 4) competência por conexão ou continência (LIMA, 2019, p. 353).

| COMPETÊNCIA ABSOLUTA                                                                                                                                                                                                                          | COMPETÊNCIA RELATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Competência em razão da matéria (<i>ratione materiae</i>);</li> <li>Competência por prerrogativa de função (<i>ratione personae</i> ou <i>funcionae</i>); e</li> <li>Competência funcional.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Competência <i>ratione loci</i> (em razão do local), seja pelo lugar da infração, seja pelo domicílio ou residência do réu;</li> <li>Competência por prevenção (Súmula nº 706 do STF);</li> <li>Competência por distribuição; e</li> <li>Competência por conexão ou continência.</li> </ul> |

### 2.1.1.2. MOMENTO ADEQUADO PARA ALEGAÇÃO E POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO

Conforme será mais bem analisado nos capítulos atinentes às exceções, nulidades e revisão criminal, a incompetência absoluta, justamente pela predominância do interesse público, poderá ser alegada e/ou reconhecida pelo juiz a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória ou absolutória imprópria, não havendo, nesse sentido, a possibilidade de sua prorrogação.

Noutro giro, envolvendo interesse predominantemente privado, a incompetência relativa deve ser arguida pela parte no momento oportuno, sob pena de preclusão. Isto é: caso não seja alegada pela parte no momento processual adequado para tanto, haverá a prorrogação da competência, razão pela qual o juízo relativamente incompetente tornar-se-á competente.

### 2.1.1.3. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA RELATIVA NO PROCESSO PENAL

No Processo Penal, não se aplica a Súmula nº 33 do STJ, sendo permitido que o juiz, de ofício, isto é, sem necessidade de provocação das partes, reconheça a incompetência relativa, o que é muito importante para as provas de concurso.

Assim, aqui no Processo Penal, tanto a incompetência absoluta quanto a incompetência relativa podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz, não havendo necessidade de arguição pelas partes, embora existente a chamada exceção de incompetência, que será estudada em capítulo próprio.



#### 2.1.1.4. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA

Conforme será trabalhado com mais detalhes no capítulo atinente às exceções, embora exista alguma divergência doutrinária quanto ao ponto, entende-se que, diferentemente do "processo civil, a exceção de incompetência pode veicular tanto a incompetência absoluta quanto a relativa" (LIMA, 2017, p. 1122).

#### 2.1.1.5. CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E DA INCOMPETÊNCIA RELATIVA

Tal tema será estudado mais profundamente no capítulo atinente às nulidades, interessando-nos assentar, nesse momento, que a doutrina majoritária rechaça a diferenciação entre as consequências advindas da incompetência absoluta e da incompetência relativa, apegando-se à literalidade da norma inserta no art. 567 do CPP<sup>7</sup>. Para eles, pouco importa se a nulidade é do tipo absoluta ou do tipo relativa. Somente haverá necessidade de repetição dos atos decisórios, podendo ocorrer a simples ratificação dos instrutórios, não havendo falar na necessidade de repetição desses últimos perante o juízo competente.

O STF, afastando-se da literalidade do artigo citado, a partir do julgamento do HC nº 83.006/SP, de relatoria da Min. Ellen Gracie, passou a entender que, mesmo no caso de incompetência absoluta, poderá haver a simples ratificação dos atos decisórios, que, por essa razão, não precisariam ser repetidos perante o juízo competente.

#### 2.1.1.6. COISA JULGADA NO CASO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E INCOMPETÊNCIA RELATIVA

Questionamento que pode aparecer nas provas de concurso diz respeito aos efeitos de eventual sentença proferida por juízo incompetente.

No que diz respeito à incompetência relativa, bem tranquila se mostra a questão, porquanto, havendo prorrogação de competência, seja pela não arguição da parte no momento oportuno, seja pelo não reconhecimento de ofício pelo juízo, não há falar em juízo incompetente, já que a prorrogação de competência o torna competente.

Logo, pouco importa o tipo de sentença proferida, isto é, se condenatória, absolutória própria, absolutória imprópria ou extintiva da punibilidade; no caso de incompetência relativa, não há, por essa razão, fundamento para eventual desconstituição da coisa julgada formada.

Em relação à incompetência absoluta, mister se faz diferenciar as espécies de sentença, já que distintos os seus efeitos, a saber:

I) SENTENÇAS ABSOLUTÓRIAS PRÓPRIAS: nesses casos, considerando a impossibilidade de revisão criminal *pro societate*, isto é, em prejuízo do réu, não há a possibilidade de desconstituição da coisa julgada formada. Logo, ainda que proferidas por juízo absolutamente incompetente, as sentenças absolutórias próprias transitadas em julgado não podem ser revistas. Trata-se, pois, de um excepcional caso de preclusão de uma nulidade absoluta;

Conforme será visto com mais detalhes no capítulo atinente às nulidades, via de regra, só há falar em preclusão em relação às nulidades do tipo relativa. Contudo, diante da impossibilidade de revisão criminal *pro societate*, sendo proferida sentença absolutória própria, ainda que viciada com nulidade absoluta, não há possibilidade da desconstituição da coisa julgada formada, operando-se, nesse sentido, a preclusão de uma nulidade absoluta.

---

<sup>7</sup>A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente.

II) SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE: assunto mais espinhoso diz respeito à possibilidade ou não de revisão criminal de sentença extintiva da punibilidade, o que será verificado a depender do momento em que se deu a declaração da extinção da punibilidade do agente;

Se a declaração da extinção da punibilidade ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria, como se verifica, por exemplo, na Prescrição da Pretensão Punitiva (PPP), não será cabível. Em contrapartida, se ocorreu após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria, como se dá, por exemplo, no caso de Prescrição da Pretensão Executória (PPE), será admissível.

Assim, se uma sentença extintiva da punibilidade for proferida por juízo absolutamente incompetente, em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria, não há possibilidade de desconstituição da coisa julgada formada, como ocorrerá, por exemplo, no caso de sentença que reconhece a PPP.

Noutro giro, se a sentença extintiva da punibilidade for proferida por juízo absolutamente incompetente, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria, como ocorre, por exemplo, no caso do reconhecimento da PPE, haverá possibilidade de desconstituição da coisa julgada formada, já que possível o ajuizamento de eventual revisão criminal.

No que diz respeito à sentença concessiva do perdão judicial, também chamada de "absolvição anômala", não é cabível o manejo da revisão criminal, já que tal sentença não é do tipo condenatória ou absolutória imprópria, mas, sim, "declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório", a teor da Súmula nº 18 do STJ (LIMA, 2017, p. 1813-1814).

Logo, caso a concessão do perdão judicial se dê por juízo absolutamente incompetente, diante da impossibilidade de ajuizamento da revisão criminal, não há falar na possibilidade de desconstituição da coisa julgada formada.

III) SENTENÇA CONDENATÓRIA OU ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA: caso a sentença proferida por juízo absolutamente incompetente seja do tipo condenatória ou absolutória imprópria (aplicação de medida de segurança), diante da possibilidade de ajuizamento de revisão criminal após o seu trânsito em julgado, admite-se a desconstituição da coisa julgada formada, razão pela qual se diz que, nesses casos, a nulidade absoluta pode ser arguida a qualquer momento.

#### 2.1.1.7. QUADRO-RESUMO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS COMPETÊNCIAS ABSOLUTA E RELATIVA

Para fins didáticos, compilamos as principais características das duas espécies de competência no quadro abaixo:

| <u>COMPETÊNCIA ABSOLUTA</u>                                                                                                                                                                                                              | <u>COMPETÊNCIA RELATIVA</u>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Há a predominância do interesse público.                                                                                                                                                                                                 | Há a predominância do interesse privado.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Origina-se de normas constitucionais.                                                                                                                                                                                                    | Origina-se de normas infraconstitucionais.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>Exemplos</u> : competência em razão da matéria ( <i>ratione materiae</i> ); competência por prerrogativa de função ( <i>ratione personae</i> ou <i>funcionae</i> ); e competência funcional.                                          | <u>Exemplos</u> : competência <i>ratione loci</i> (em razão do local), seja pelo lugar da infração, seja pelo domicílio ou residência do réu; competência por prevenção (Súmula nº 706 do STF); competência por distribuição; e competência por conexão ou continência.     |
| Poderá ser alegada e/ou reconhecida pelo juiz a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória ou absolutória imprópria, não havendo, nesse sentido, a possibilidade de sua prorrogação. | Deve ser arguida pela parte no momento oportuno, sob pena de preclusão. Isto é: caso não seja alegada pela parte no momento processual adequado para tanto, haverá a prorrogação da competência, razão pela qual o juízo relativamente incompetente tornar-se-á competente. |

|                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pode ser reconhecida de ofício pelo juiz.                                                                       | Pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, não se aplicando a Súmula nº 33 do STJ.                               |
| Apesar de alguma divergência doutrinária, entende-se que pode ser arguida por meio de exceção de incompetência. | Apesar de alguma divergência doutrinária, entende-se que pode ser arguida por meio de exceção de incompetência. |

### 3. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA CRIMINAL

Para se determinar qual o juízo competente para julgar determinada infração penal, primeiramente, deve ser avaliado se aquele fato está sujeito à jurisdição brasileira, porquanto, ainda que cometido em nosso território, há possibilidade de não ser de competência de órgão jurisdicional pátrio, nos termos, por exemplo, do art. 1º, inciso I, do CPP.

Verificando-se se tratar de fato sujeito à jurisdição brasileira, diversos outros questionamentos devem ser respondidos até que se chegue ao juízo competente, podendo este "caminho da fixação da competência" ser compilado da seguinte forma (LIMA, 2019, p. 364-365):

I) COMPETÊNCIA DE JUSTIÇA: o primeiro questionamento a ser feito diz respeito à Justiça competente para julgar tal fato delituoso, isto é, indaga-se qual é o ramo da Justiça que deve processar e julgar aquela infração penal. Doutrinariamente, as Justičas são subdivididas em Justičas Especiais e Comuns. Nas primeiras, isto é, nas chamadas Justičas Especiais, encontram-se: a) Justiça Militar (da União e dos Estados/DF); b) Justiça Eleitoral; e c) Justiça do Trabalho. Nas segundas, isto é, nas chamadas Justičas Comuns, encontram-se: a) Justiça Federal; e b) Justiça Estadual e do Distrito Federal e dos Territórios.

Em relação à Justiça Comum, da qual fazem parte a Justiça Federal e a Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios, é interessante assentar que a Justiça Federal, apesar de ser uma Justiça Comum, é especial em relação à Justiça Estadual.

Assim, não sendo o fato atrelado a nenhuma Justiça Especial, isto é, Militar, Eleitoral ou Trabalhista, deve-se analisar, em um primeiro momento, se o fato é da Justiça Comum Federal. Caso não seja, tendo em vista o seu caráter residual, o julgamento daquela infração penal competirá à Justiça Comum dos Estados ou do Distrito Federal e dos Territórios;

II) COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA: o segundo questionamento diz respeito ao foro por prerrogativa de função. Nesse sentido, indaga-se se aquela infração penal cometida deve ser, de forma originária, isto é, sem passar pela primeira instância, processada e julgada por algum Tribunal pátrio;

III) COMPETÊNCIA DE FORO OU TERRITORIAL: o terceiro questionamento diz respeito ao foro territorialmente competente para processar e julgar a infração penal cometida. Se estivermos na Justiça Estadual, indaga-se, portanto, qual a comarca competente para o processo e julgamento daquele fato. Na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o questionamento diz respeito à circunscrição judiciária competente. Na Justiça Federal, a pergunta tem relação com a seção e subseção judiciárias competentes. Na Justiça Militar da União, descobre-se qual é a circunscrição judiciária militar competente. Na Justiça Eleitoral, desvenda-se qual é a zona eleitoral competente;

IV) COMPETÊNCIA DE JUÍZO ESPECIALIZADO: o quarto questionamento diz respeito à existência de eventual juízo especializado dentro do foro territorialmente competente, como ocorre, por exemplo, no caso de órgãos jurisdicionais especializados em delitos de trânsito, em infrações penais relacionadas às drogas, às organizações criminosas, aos crimes contra o sistema financeiro, à lavagem de ativos etc. Caso não exista juízo especializado, o fato deve ser processado pelos juízos criminais comuns. Existindo mais de um juízo comum, a competência, via de regra, será determinada pela distribuição;

V) COMPETÊNCIA INTERNA OU DE JUIZ: se, dentro de uma mesma vara, houver mais de um juiz, a competência será determinada pela distribuição;

VI) COMPETÊNCIA RECURSAL: nesse caso, questiona-se qual o órgão competente para processar e julgar eventual recurso interposto contra determinada decisão judicial. Via de regra, a competência recursal é do órgão jurisdicional superior àquele que proferiu a decisão combatida. Todavia, é possível que a competência recursal seja do próprio órgão que prolatou a decisão guerreada, como ocorre, por exemplo, no caso dos embargos de declaração.

O Código de Processo Penal, em seu art. 69, diz que a competência será determinada de acordo com sete critérios, a saber: I - o lugar da infração; II - o domicílio ou residência do réu; III - a natureza da infração; IV - a distribuição; V - a conexão ou continência; VI - a prevenção; e VII - a prerrogativa de função.

### 3.1. JUSTIÇA MILITAR

Em concursos públicos não atrelados à área militar, o que mais chama atenção em relação à Justiça Castrense são as alterações promovidas pela Lei nº 13.491/17, que serão estudadas em tópico separado.

Todavia, também é alvo recorrente nos concursos públicos, a diferenciação entre a Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados, razão pela qual iniciemos nossa análise por tal aspecto.

#### 3.1.1. DIFERENÇAS ENTRE A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E A JUSTIÇA MILITAR DOS ESTADOS

##### 3.1.1.1. COMPETÊNCIA CRIMINAL

No que toca à competência criminal, tanto a Justiça Militar da União quanto a Justiça Militar dos Estados somente têm competência para o processo e julgamento dos crimes militares. Tanto é que o art. 124, *caput*, da CF/88, diz que compete à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Semelhantemente, o art. 125, §4º, primeira parte, da CF/88, diz que compete à Justiça Militar dos Estados processar e julgar os militares estaduais nos crimes militares definidos em lei (LIMA, 2019, p. 371).

Logo, considerando que às Justiças Militares somente compete o julgamento dos crimes militares, mesmo havendo conexão entre um crime comum e um crime militar, deverá haver a separação dos processos, o que, inclusive, está previsto no art. 79, inciso I, do CPP e no art. 102, alínea *a*, do CPPM (LIMA, 2019, p. 371).

Quanto ao ponto, isto é, conexão entre crime militar e crime comum, assunto recorrente em provas de concurso é a Súmula nº 90 do STJ, a qual, confirmando o exposto acima, aduz que "compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar, e à Comum pela prática do crime comum simultâneo àquele" (LIMA, 2019, p. 371).

#### a) Crime militar absorvido por crime comum

Situação interessante diz respeito à absorção do crime militar por um crime comum, o que não justificará a instauração de processo criminal perante a Justiça Militar. Assim, se o agente se utilizar indevidamente de uniforme de oficial das Forças Armadas, que é crime militar (art. 172, CPM) de competência da Justiça Militar da União (crime-meio), para a prática do crime de estelionato (crime-fim), somente haverá persecução penal pelo último crime, já que este absorverá o primeiro, não sendo instaurado processo criminal na Justiça Castrense pelo crime do art. 172 do CPM (LIMA, 2019, p. 371).

#### b) Crime doloso contra a vida praticado por militar estadual



Conforme art. 125, §4º, da CF/88, a Justiça Militar dos Estados não tem competência para julgar crimes dolosos contra a vida de civis praticados por militar estadual, ainda que em serviço. Diferentemente, o art. 124 da CF/88, que trata da Justiça Militar da União, não trouxe tal ressalva, tendo a Lei nº 13.491/17, de forma expressa, determinado que compete à Justiça Militar da União o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por militar das Forças Armadas contra civis, que será melhor analisado em tópico próprio (LIMA, 2019, p. 371).

Nesse tópico, reforça-se a incompetência da Justiça Militar Estadual para o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida de civis praticados por militar estadual, ainda que em serviço, já que se trata de uma grande diferença em relação à Justiça Militar da União.

### **3.1.1.2. AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES MILITARES**

A competência da Justiça Militar dos Estados vai além do processo e julgamento dos crimes militares definidos em lei. De acordo com o art. 125, §4º, da CF/88, à Justiça Militar dos Estados também compete o julgamento das ações judiciais contra atos disciplinares militares, o que não ocorre na Justiça Militar da União, já que esta, nos termos do art. 124 da CF/88, somente tem competência para o julgamento dos crimes militares definidos em lei (LIMA, 2019, p. 371).

Destarte, se um militar das Forças Armadas quiser questionar judicialmente uma punição disciplinar por ele sofrida, deverá buscar a Justiça Comum Federal. Noutro giro, se um militar estadual intentar anular uma punição disciplinar que lhe fora imposta, deverá buscar a Justiça Militar Estadual (LIMA, 2019, p. 371).

#### **3.1.1.2.1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE PRATICADO POR MILITAR ESTADUAL**

O STJ, no julgamento do CC 100.682/MG, de relatoria do Min. Castro Meira, assentou que compete à Justiça Comum Estadual (e não à Justiça Militar Estadual) o julgamento de Ação Civil Pública por ato de improbidade praticado por militar estadual. De acordo com o Tribunal da Cidadania, a competência da Justiça Castrense Estadual "abrange, tão-somente, as ações judiciais propostas contra atos disciplinares militares, vale dizer, ações propostas para examinar a validade de determinado ato disciplinar ou as consequências desses atos" (LIMA, 2019, p. 371).

### **3.1.1.3. ACUSADO**

#### **3.1.1.3.1. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL**

Nos termos do art. 125, §4º, da CF/88, a Justiça Militar Estadual não alcança os civis, já que somente tem competência para processar e julgar os militares dos estados, isto é, os policiais militares e os bombeiros militares (LIMA, 2019, p. 371).

Logo, se um civil praticar determinado crime contra as instituições militares estaduais, será julgado na Justiça Comum Estadual, já que, repita-se, a Justiça Castrense Estadual não alcança os civis (Súmula nº 53 do STJ), (LIMA, 2019, p. 371).

#### **3.1.1.3.2. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO DE MILITAR ESTADUAL**

Tendo em vista que a Justiça Militar Estadual não tem competência para julgar civis, importante se mostra analisar a situação do militar estadual que deixa o cargo após o cometimento do fato delituoso, isto é, deixa de ser militar estadual depois da infração penal.

Nesse caso, ele ainda será julgado pela Justiça Militar Estadual, porquanto a condição de militar estadual deve ser verificada quando da prática do crime (*tempus delicti*), sendo desimportante, por exemplo, que, antes da instauração do competente inquérito policial militar, o agente deixe as fileiras das corporações militares estaduais (LIMA, 2019, p. 373-374).



### 3.1.1.3.3. CRIMES COMETIDOS EM COAUTORIA POR CIVIL E MILITAR ESTADUAL

No caso de coautoria entre um civil e um militar estadual, duas situações bem distintas podem surgir, merecendo cada uma delas uma análise em apartado.

A primeira situação diz respeito à coautoria em crime que esteja previsto tanto na legislação penal militar como na legislação penal comum. Nesse caso, haverá a separação dos processos, isto é, o civil responderá pelo crime comum perante a Justiça Comum Estadual e o militar estadual responderá pelo crime militar perante a Justiça Militar Estadual. É o que ocorrerá, por exemplo, se um policial militar e um civil, em concurso de agentes, subtraírem uma arma de fogo da Polícia Militar do interior de um quartel. O militar estadual responderá pelo crime militar de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 240, §6º, inciso IV, c/c art. 9º, inciso II, alínea e, ambos do CPM). O civil responderá pelo crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, §4º, inciso IV, do CP (LIMA, 2019, p. 371).

A segunda situação diz respeito à coautoria em crime que somente esteja previsto na legislação penal militar, isto é, em crime que não esteja previsto na legislação penal comum. Nessa hipótese, o civil não poderá responder por aquele fato, já que a Justiça Comum jamais poderá julgar o agente pela prática de um crime militar. É o que ocorre, por exemplo, se um civil, em coautoria com um militar estadual, praticar a conduta definida como o crime de ingresso clandestino em um quartel da PM, nos termos do art. 302 do CPM. O militar estadual será julgado pela Justiça Militar Estadual. O civil não responderá (LIMA, 2019, p. 371).

### 3.1.1.3.4. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

O art. 124, *caput*, da CF/88, ao se referir à competência da Justiça Militar da União, somente diz que a ela compete o julgamento dos crimes militares definidos em lei, nada dizendo quanto à condição do acusado (LIMA, 2019, p. 374).

Nesse sentido, diferentemente do que estudamos em relação à Justiça Militar Estadual, que somente julga militares estaduais, a Justiça Militar da União tem competência para o processo e julgamento tanto dos militares quanto dos civis, sendo essa uma importante diferença para as provas de concurso (LIMA, 2019, p. 374).

Assim, a competência da Justiça Militar da União é fixada, tão somente, em razão da matéria (*ratione materiae*), enquanto que a competência da Justiça Militar Estadual é fixada em decorrência da matéria (*ratione materiae*) e da condição pessoal do acusado (*ratione personae*) (LIMA, 2019, p. 374-375).

### 3.1.1.3.5. ÓRGÃOS JURISDICIONAIS DE 1ª INSTÂNCIA

Na Justiça Militar Estadual, nos termos do art. 125, §5º, da CF/88, a primeira instância é exercida tanto pelos Conselhos de Justiça quanto, singularmente, pelo juiz de direito do juízo militar (LIMA, 2019, p. 375).

Nesse contexto, ainda de acordo com o referido dispositivo legal, ao juiz de direito do juízo militar compete julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Em contrapartida, ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, compete processar e julgar os demais crimes militares.

Na Justiça Militar da União, após alterações trazidas pela Lei nº 13.774/2018, a primeira instância será exercida por juiz federal da Justiça Militar ou pelos Conselhos de Justiça. Ao juiz federal da Justiça Militar compete, singularmente, o julgamento do crime militar praticado por civil ou por militar em conjunto com civil. Ao Conselho de Justiça compete processar e julgar os crimes militares praticados exclusivamente por militares federais (LIMA, 2019, p. 375).

**3.1.1.3.6. ÓRGÃOS JURISDICIONAIS DE 2ª INSTÂNCIA**

Na Justiça Militar Estadual, a segunda instância, nos termos do art. 125, §3º, da CF/88, é exercida pelo Tribunal de Justiça Militar nos estados que o possuem (atualmente, apenas Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul), ou pelo próprio Tribunal de Justiça, nos estados que não possuem Tribunal de Justiça Militar. À segunda instância da Justiça Militar Estadual compete julgar os recursos interpostos das decisões prolatadas pelo juiz de direito do juízo militar, nos processos de sua competência (inclusive no que diz respeito às ações judiciais contra atos disciplinares militares), e pelos Conselhos de Justiça (LIMA, 2019, p. 378).

Assim, é muito importante salientar que o Superior Tribunal Militar não exerce qualquer competência recursal em relação à Justiça Militar Estadual, pelo que eventual recurso contra decisão de primeira instância da Justiça Castrense dos Estados deverá ser julgado pelo Tribunal de Justiça Militar ou pelo Tribunal de Justiça, sem prejuízo de interposição de Recurso Especial no STJ ou Recurso Extraordinário no STF (LIMA, 2019, p. 378).

Na Justiça Militar da União, nos termos do art. 122 da CF/88, a segunda instância é exercida pelo próprio Superior Tribunal Militar, que, apesar do nome "superior", em verdade, funciona, basicamente, como um "Tribunal de Apelação" (LIMA, 2019, p. 378).

Portanto, eventual recurso interposto em desfavor de decisão do juiz federal da Justiça Militar ou dos Conselhos de Justiça da Justiça Castrense Federal deverá ser julgado pelo próprio Superior Tribunal Militar, o qual, além de ser dotado de algumas competências originárias, funciona, como dito, como tribunal de revisão (LIMA, 2019, p. 378).

Tendo em vista que, nos termos do art. 105, inciso III, da CF/88, só há falar em Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça contra as causas decididas, em única ou última instância, pelos *Tribunais Regionais Federais* ou pelos *tribunais* dos Estados, do Distrito Federal e Territórios; não cabe Recurso Especial contra acórdão condenatório ou absolutório proferido pelo Superior Tribunal Militar (LIMA, 2019, p. 377-378).

Noutro giro, conforme art. 102, inciso III, da CF/88, as decisões do Superior Tribunal Militar poderão ser combatidas pelo Recurso Extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal (LIMA, 2019, p. 378).

**3.1.1.3.7. QUADRO-RESUMO DAS DIFERENÇAS ENTRE A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E A JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL**

Para fins didáticos, colaciona-se tabela extraída da obra do Professor Renato Brasileiro de Lima, na qual são elencadas as principais diferenças entre a Justiça Militar da União e a Justiça Militar Estadual (LIMA, 2019, p. 378):

| JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO                                                                                                                                                                                          | JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Competência criminal: crimes militares. Com o advento da Lei n. 13.491/17, consideram-se crimes militares não apenas os crimes previstos no Código Penal Militar, mas também os previstos na legislação penal; | 1. Competência criminal: crimes militares. Com o advento da Lei n. 13.491/17, consideram-se crimes militares não apenas os crimes previstos no Código Penal Militar, mas também os previstos na legislação penal; |
| 1.1. Tem competência para o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida cometidos por militares das Forças Armadas contra civis (CPM, art. 92, §2º, incluído pela Lei n. 13.491/17);                    | 1.1. Não tem competência para o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida cometidos por militares estaduais, ainda que em serviço, contra civis (CF, art. 125, §4º);                                  |
| 2. Competência cível: não tem competência para o processo e julgamento de ações judiciais contra atos disciplinares militares;                                                                                    | 2. Competência cível: é dotada de competência para o processo e julgamento de ações judiciais contra atos disciplinares militares;                                                                                |
| 3. Acusado: pode processar e julgar tanto civis quanto militares;                                                                                                                                                 | 3. Acusado: pode processar e julgar somente os militares dos Estados;                                                                                                                                             |
| 4. Critério de fixação da competência: competência                                                                                                                                                                | 4. Critério de fixação da competência: competência                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"ratione materiae" (crimes militares);</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>"ratione materiae" (crimes militares + ações judiciais contra atos disciplinares militares) e "ratione personae" (militares dos Estados);</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>5. Órgãos jurisdicionais de 1ª instância:</b><br><b>a) Juízes Federais da Justiça Militar: têm competência monocrática para o processo e julgamento de civis, e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;</b><br><b>b) Conselhos Especial e Permanente de Justiça: julgam os crimes militares praticados apenas por militares federais;</b> | <b>5. Órgãos jurisdicionais de 1ª instância:</b><br><b>a) Juiz de Direito do Juízo Militar: julga, monocraticamente, os crimes militares cometidos contra civis e a ações judiciais contra atos disciplinares militares;</b><br><b>b) Conselhos Especial e Permanente de Justiça: julgam os demais crimes militares;</b> |
| <b>6. Presidência dos Conselhos de Justiça: Juiz Federal da Justiça Militar;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6. Presidência dos Conselhos de Justiça: Juiz de Direito do Juízo Militar;</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>7. Órgão jurisdicional de 2ª instância: Superior Tribunal Militar.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7. Órgão jurisdicional de 2ª instância: Tribunal de Justiça Militar, nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul; Tribunal de Justiça do Estado, nos demais estados da Federação.</b>                                                                                                                  |

### 3.1.2. LEI Nº 13.491/17

Em resumo, a Lei nº 13.491/17 trouxe duas significativas mudanças em relação à competência da Justiça Militar. A primeira delas diz respeito à ampliação da competência da Justiça Castrense, que não mais está restrita apenas aos crimes militares previstos no Código Penal Militar, sendo também de sua competência o processo e julgamento de delitos previstos na legislação penal comum (art. 9º, inciso II, CPM). A segunda alteração diz respeito à competência da Justiça Militar da União para processar e julgar crimes dolosos contra a vida de civis cometidos por militares das Forças Armadas (art. 9º, §2º, CPM) (LIMA, 2019, p. 383).

#### 3.1.2.1. CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PENAL COMUM

A partir da nova redação do art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar, introduzida pela Lei nº 13.491/17, a Justiça Militar passou a ter competência para o processo e julgamento dos crimes militares previstos no Código Penal Militar (como já era antes da nova lei) e dos crimes previstos na legislação penal, caso sejam cometidos nas seguintes circunstâncias (LIMA, 2019, p. 383):

- a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado;
- b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
- c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;
- d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
- e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;
- f) revogada.

##### 3.1.2.1.1. ABRANGÊNCIA DO TERMO "LEGISLAÇÃO PENAL"

A expressão "legislação penal", inserta na parte final do art. 9º, inciso II, do CPM, não se refere apenas aos crimes previstos no Código Penal Comum, mas também àqueles previstos na chamada legislação penal extravagante, como ocorre, por exemplo, com a Lei de Tortura (Lei nº 9.455/97) e com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) (LIMA, 2019, p. 383).

### 3.1.2.1.2. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 172 DO STJ

Antes da Lei nº 13.491/17, os crimes militares eram somente aqueles previstos no Código Penal Militar. Assim, ainda que o fato fosse cometido por um militar em serviço e em lugar sujeito à administração militar, se não houvesse previsão no CPM, não poderia a conduta ser taxada de crime militar (LIMA, 2019, p. 384).

Não por outro motivo, o STJ editou a Súmula nº 172, a qual aduz que "competete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço". Tendo em vista que o crime de abuso de autoridade é previsto em legislação extravagante (antiga Lei nº 4.898/68 e nova Lei nº 13.869/19), não poderia ser considerado crime militar, já que não está previsto no CPM (LIMA, 2019, p. 384).

Atualmente, portanto, restou superado o entendimento consagrado pela Súmula nº 172 do STJ, sendo possível que a Justiça Militar julgue o crime de abuso de autoridade, desde que preenchidas as condições previstas no art. 9º, inciso II, do CPM (LIMA, 2019, p. 384).

### 3.1.2.1.3. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 DO STJ

O mesmo raciocínio vale para a Súmula nº 6 do STJ, segundo a qual "competete à Justiça Comum Estadual processar e julgar delito decorrente de acidente de trânsito envolvendo viatura de Polícia Militar, salvo se autor e vítima forem policiais militares em situação de atividade".

A referida redação sumular baseava-se no fato de que os crimes insertos no CTB não poderiam ser taxados de crimes militares, já que não são previstos no CPM, o que mudou com a Lei nº 13.491/17 (LIMA, 2019, p. 384).

Doravante, se o militar em serviço praticar, por exemplo, crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), deverá ser processado e julgado perante a Justiça Militar, pouco importando se a vítima é civil ou militar (LIMA, 2019, p. 384).

### 3.1.2.1.4. RELEITURA DA SÚMULA Nº 75 DO STJ

A Súmula nº 75 do STJ apregoa que "competete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o policial militar por crime de promover ou facilitar a fuga de preso de estabelecimento penal", devendo tal enunciado ser reinterpretado à luz das mudanças introduzidas pela Lei nº 13.491/17 (LIMA, 2019, p. 384).

Antes da Lei nº 13.491/17, o enunciado em comento devia ser assim interpretado: se o militar em serviço promovesse ou facilitasse a fuga de preso de estabelecimento penal de natureza militar, seria ele processado e julgado perante a Justiça Militar, pelo crime do art. 178 do CPM. Por outro lado, se o estabelecimento prisional não fosse de natureza militar, o agente deveria ser processado e julgado perante a Justiça Comum, pelo crime do art. 351 do CP. Com as mudanças, passou a ser possível que o militar seja processado e julgado pelo crime do art. 351 do CP perante a Justiça Castrense, desde que o cometa nas condições previstas no art. 9º, inciso II, do CPM (LIMA, 2019, p. 384).

Nesse sentido, após as mudanças introduzidas pela Lei nº 13.491/17, a Súmula nº 75 do STJ deve ser lida da seguinte forma: "Competete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o policial militar pelo crime de promover ou facilitar a fuga de preso de estabelecimento penal (CP, art. 351), mas desde que o agente não se encontre em uma das hipóteses do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar" (LIMA, 2019, p. 385).

### 3.1.2.1.5. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O JULGAMENTO DE CONTRAVENÇÕES PENAIAS

Conforme já visto, a partir da Lei nº 13.491/17, a Justiça Militar tem competência para julgar os crimes previstos no CPM e na legislação penal comum. Todavia, não tem competência para



o julgamento de contravenções penais, já que, à luz dos arts. 124, *caput*, e 125, §4º, ambos da CF/88, a Justiça Castrense somente tem competência para julgar os crimes militares definidos em lei (LIMA, 2019, p. 385).

Logo, se um militar federal ou estadual, em serviço e em lugar sujeito à administração militar, praticar fato definido como contravenção penal, será ele julgado pela Justiça Comum Estadual, ainda que atente contra interesse da União, já que a Justiça Federal de 1ª instância não tem competência para o processo e julgamento de contravenções penais, conforme será mais bem trabalhado em tópico próprio (LIMA, 2019, p. 385).

### **3.1.2.1.6. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR POR REGRAMENTO ESPECÍFICO CONTIDO EM NORMA CONSTITUCIONAL E/OU ORDINÁRIA**

Em uma primeira leitura, ao mencionar que os crimes militares são aqueles previstos no Código Penal Militar e na legislação penal comum, a Lei nº 13.491/17 deixa a impressão de que a Justiça Castrense passou a ter competência para o processo e julgamento de qualquer crime previsto na legislação penal comum, ainda que haja norma especial em relação à competência para o processo de determinado crime. Todavia, essa interpretação literal da Lei nº 13.491/17 deve ser afastada, por duas razões, a saber (LIMA, 2019, p. 385):

**I) HIERARQUIA NORMATIVA:** tendo em vista que a Lei nº 13.491/17 é de natureza ordinária, não pode se sobrepor à Constituição Federal no que toca à fixação de competência. Assim, se, por exemplo, a CF/88, em seu art. 121, determina que à Justiça Eleitoral compete o julgamento dos crimes eleitorais, um crime eleitoral praticado por militar em serviço não poderá ser de competência da Justiça Militar, já que a Justiça Eleitoral é a competente para o julgamento do fato; e

**II) PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NORMATIVA:** a Lei nº 13.491/17 e o próprio Código Penal Militar deverão ser tratados como normas gerais no que diz respeito à fixação da competência. Portanto, se uma norma especial outorgar a competência à determinada Justiça, ficarão a Lei nº 13.491/17 e o CPM afastados pela regra específica, prevalecendo a máxima de que a norma especial afasta a norma geral, no que com ela for incompatível. É o que ocorre, por exemplo, com os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, já que a Lei nº 7.492/86, em seu art. 26, determina que compete à Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso VI, da CF/88, o julgamento de tais fatos, restando afastada a competência da Justiça Militar, ainda que a conduta delituosa seja praticada por militar em serviço.

Nesse contexto, o art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar, deve ser lido da seguinte forma: “os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, mas desde que não haja previsão constitucional e/ou legal outorgando referida competência à outra Justiça, quando praticados.” (LIMA, 2019, p. 385).

### **3.1.2.1.7. TEMPERAMENTOS EM RELAÇÃO À SÚMULA Nº 90 DO STJ**

A Súmula nº 90 do STJ, a qual aduz que “compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar, e à Comum pela prática do crime comum simultâneo àquele”, continua válida, contudo, após a Lei nº 13.491/17, deve ser lida com certo temperamento (LIMA, 2019, p. 385).

Com o alargamento da competência da Justiça Militar, vários crimes outrora considerados comuns passaram a ser crimes militares, já que estes, após o advento da Lei nº 13.491/17, abrangem, além dos crimes previstos no CPM, aqueles insertos na legislação penal comum. Logo, antes da referida lei, se, por exemplo, um militar em serviço praticasse um crime de lesão corporal e outro de abuso de autoridade, haveria a separação dos processos, sendo o primeiro julgado pela Justiça Militar, já que previsto no art. 209 do CPM, e o segundo pela Justiça Comum, porquanto inserto na Lei de Abuso de Autoridade (antiga Lei nº 4.898/68 e nova Lei nº 13.869/19).



Todavia, com a Lei nº 13.491/17, tal panorama foi alterado, sendo ambas as infrações (lesão corporal e abuso de autoridade) julgadas pela Justiça Militar, já que não há, na Lei nº 13.869/19, regramento específico quanto à fixação de competência (LIMA, 2019, p. 385-386).

Noutro giro, é possível que ainda haja a separação de processos, isto é, que a Súmula nº 90 do STJ seja aplicada em sua literalidade, o que acontecerá se o crime previsto na legislação penal comum tiver regra específica quanto à fixação de competência. É o que ocorrerá, por exemplo, no caso de um militar que cometer um crime militar de peculato em detrimento de patrimônio sob a administração militar (art. 303, c/c art. 9º, inciso II, alínea e, CPM) e lavar o dinheiro daí proveniente, já que a própria Lei de Lavagem de Capitais (Lei nº 9.613/98) outorga competência à Justiça Estadual ou Federal para julgar tais crimes. Assim, o crime de peculato será julgado pela Justiça Militar, enquanto o crime de lavagem de ativos será processado pela Justiça Estadual ou Federal, conforme o caso (LIMA, 2019, p. 385-386).

### 3.1.2.1.8. CRIMES MILITARES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PENAL COMUM PRATICADOS POR CIVIS

Tendo em vista que o art. 9º, inciso III, do CPM, faz referência a seu inciso II, entende-se que também competirá à Justiça Militar da União o julgamento de civis que cometerem crimes militares previstos na legislação penal comum, desde que praticados (LIMA, 2019, p. 386):

- a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
- b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;
- c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
- d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.

Logo, a mudança introduzida pela Lei nº 13.491/17, no inciso II, do art. 9º do Código Penal Militar, também repercutirá no inciso III, "do que se pode concluir que os crimes militares cometidos por civis da competência da Justiça Militar da União abrangem não apenas aqueles previstos no Código Penal Militar, mas também os previstos na legislação especial" (LIMA, 2019, p. 386).

### 3.1.2.2. CRIMES DOLOSOS PRATICADOS POR MILITARES CONTRA A VIDA DE CIVIS

Conforme estudado acima, o art. 125, §4º, da CF/88, expressamente afasta da Justiça Militar dos Estados a competência para julgar crimes dolosos contra a vida de civis praticados por militar estadual. Logo, se um militar dos Estados praticar um crime doloso contra a vida de um civil, será julgado pelo Tribunal do Júri, conforme determinação expressa do art. 9º, §1º, do CPM, com a redação dada pela Lei nº 13.491/17.

Diferentemente, o art. 124 da CF/88, que trata da Justiça Militar da União, não trouxe tal afastamento de competência, tendo a Lei nº 13.491/17, de forma expressa, determinado que compete à Justiça Militar da União o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por militar das Forças Armadas contra civis, desde que cometidos no contexto (art. 9º, §2º, CPM):

- I – do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa;
- II – de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante; ou

III – de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no art. 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais:

- a) Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica;
- b) Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999;
- c) Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal Militar; e
- d) Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.

Logo, diferentemente do que ocorre com os militares estaduais, que serão julgados pelo Tribunal do Júri, os militares do Exército, Marinha e da Aeronáutica serão julgados pela própria Justiça Militar da União, caso cometam crimes dolosos contra a vida de civis, em algum dos contextos insertos no art. 9º, §2º, do CPM, como ocorre, por exemplo, em operações de Garantia da Lei e da Ordem determinadas pelo Presidente da República.

Muito importante ressaltar a hipótese de crime doloso contra a vida de civil praticado por militar das Forças Armadas em concurso de agentes com militar estadual, em algum dos contextos fáticos arrolados pelo art. 9º, §2º, do CPM. Nesse caso, haverá separação dos processos, sendo o militar das Forças Armadas julgado pela Justiça Militar da União e o militar estadual julgado pelo Tribunal do Júri (LIMA, 2019, p. 427).

### 3.2. JUSTIÇA ELEITORAL

A Justiça Eleitoral tem competência para o processo e julgamento das chamadas infrações eleitorais, isto é, aquelas insertas na legislação eleitoral (Código Eleitoral e legislação eleitoral especial), e, além destas, das infrações comuns que lhes sejam conexas (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 409).

Nota-se, portanto, que a competência da Justiça Eleitoral é definida em razão da matéria, somente sendo de sua alçada os crimes eleitorais insertos no Código Eleitoral, por exemplo, crimes contra a honra, praticados durante a propaganda eleitoral, e os que a lei, eventualmente e expressamente, defina como eleitorais. Fora disso, isto é, se o crime não estiver previsto no Código Eleitoral ou não for definido como crime eleitoral pela legislação eleitoral especial, salvo o caso de conexão, seu processo e julgamento não serão de competência da Justiça Eleitoral (LIMA, 2019, p. 429).

Importante assentar que, para fim de definição da competência da Justiça Eleitoral, não é suficiente que a conduta tenha sido praticada em razão de motivação política ou mesmo eleitoral, já que se mostra imprescindível que haja lei (Código Eleitoral ou legislação eleitoral especial) definindo-a como crime eleitoral. É dizer: ainda que a conduta seja fundada em motivação política ou eleitoral, se ela não estiver expressamente prevista como crime eleitoral, seu processo e julgamento não serão de competência da Justiça Eleitoral (LIMA, 2019, p. 430).

De igual forma, para fim de fixação da competência da Justiça Eleitoral, não é suficiente que a conduta seja praticada durante o período eleitoral. Em outras palavras, se a conduta for praticada em tal período, mas não for definida legalmente como crime eleitoral, seu julgamento não será de competência da Justiça Eleitoral (LIMA, 2019, p. 430).

Portanto, o primeiro passo para se definir a competência da Justiça Eleitoral é saber se aquela conduta é tipificada como crime eleitoral pelo Código Eleitoral ou pela legislação eleitoral especial, contudo, tal fato, por si só, não basta. É dizer: o fato da conduta ser tipificada como crime eleitoral, por si só, não atrairá a competência da Justiça Eleitoral, sendo necessário avaliar o conteúdo material da conduta perpetrada, que somente será julgada pela Justiça eleitoral se "atentar contra a liberdade de exercício dos direitos políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular" (LIMA, 2019, p. 430).

Nessa linha, julgando caso envolvendo o crime de destruição de título eleitoral de terceiro (art. 339 do Código Eleitoral), o STJ, no julgamento do CC 127.101/RS, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, assentou que, se tal conduta for perpetrada com a finalidade exclusiva de impedir a identificação pessoal de outrem, isto é, sem guardar qualquer vinculação com pleitos

eleitorais, a competência para o julgamento deste fato não será da Justiça Eleitoral (LIMA, 2019, p. 430).

### 3.2.1. CONEXÃO ENTRE CRIME COMUM E CRIME ELEITORAL

Tema bastante relevante para as provas de concurso diz respeito à conexão de crimes comuns, de competência da Justiça Federal e/ou da Justiça Estadual, com crimes eleitorais, sendo alvo de constantes questionamentos a competência para o processo e julgamento de ambos os fatos delituosos.

Enfrentando o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão de relatoria do Min. Marco Aurélio (Inq 4435 AgR-quarto/DF), assentou que compete à Justiça Eleitoral o julgamento dos crimes comuns praticados em conexão com crimes eleitorais, pouco importando se o crime comum é de competência da Justiça Federal ou Estadual.

Ainda de acordo com o referido precedente, cabe à Justiça Eleitoral analisar, caso a caso, a existência de conexão de delitos comuns aos delitos eleitorais e, em não havendo, remeter os casos à Justiça competente.

Nota-se, nesse sentido, que, havendo a prática de um crime de competência da Justiça Federal e/ou Estadual e um crime eleitoral, a princípio, competirá à Justiça Eleitoral o julgamento de ambas as infrações penais cometidas.

Todavia, pode ser que a própria Justiça Eleitoral, a quem compete tal análise, entenda que não há conexão entre os crimes praticados, caso em que haverá a separação dos processos, competindo à Justiça Federal e/ou Estadual o julgamento do crime comum e à Justiça Eleitoral o processamento do crime eleitoral. Frise-se, quanto ao ponto, que a análise quanto à existência ou não de conexão cabe à Justiça Eleitoral e não à Justiça Federal e/ou Estadual.

#### 3.2.1.1. Críticas ao entendimento jurisprudencial acima

Como dito, o STF assentou que, havendo conexão entre crime comum e crime eleitoral, ambas as infrações penais, a princípio, devem ser julgadas pela Justiça Eleitoral, pouco importando se o crime comum é de competência da Justiça Federal e/ou Estadual.

Ocorre que a doutrina critica bastante tal entendimento da Corte Suprema, porquanto haveria a necessidade de se fazer duas análises distintas: I) conexão entre crime comum de competência da Justiça Federal e crime eleitoral; e II) conexão entre crime comum de competência da Justiça Estadual e crime eleitoral.

No primeiro caso — conexão entre crime comum de competência da Justiça Federal e crime eleitoral — a doutrina sustenta que deve haver separação dos processos, já que ambas as competências originam-se diretamente da própria Constituição Federal, que prevê, em seu art. 109, os casos que devem ser julgados pela Justiça Federal e, em seu art. 121, aqueles atrelados à Justiça Eleitoral (LIMA, 2020, p. 493-494).

É dizer: se as competências da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral emanam diretamente da própria CF/88, isto é, originam-se de normas constitucionais, tais competências não podem ser alteradas pela regra infraconstitucional de conexão, prevista no art. 69, inciso V, do CPP, porquanto regras constitucionais não podem ser afastadas por normas infraconstitucionais (LIMA, 2020, p. 493-494).

No segundo caso — conexão entre crime comum de competência da Justiça Estadual e crime eleitoral — considerando que a competência da Justiça Estadual é residual, isto é, não se origina diretamente da Constituição Federal, sustenta a doutrina que, nos termos do art. 78, inciso IV, do CPP, ambas as infrações penais deverão ser julgadas pela justiça especial, isto é, pela Justiça Eleitoral (LIMA, 2020, p. 493).

### 3.2.2. CONEXÃO ENTRE CRIME MILITAR E CRIME ELEITORAL

Conforme estudado em tópicos precedentes, a própria Constituição Federal determina que compete à Justiça Militar da União e/ou dos Estados processar e julgar os crimes militares definidos em lei, pelo que se pode dizer que a competência da Justiça Castrense é oriunda da própria Carta Magna, o que impede a Justiça Eleitoral de exercer força atrativa sobre os crimes militares. É dizer: tendo a própria Constituição definido a competência da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar, no caso de conexão entre crimes eleitorais e crimes militares, haverá a separação dos processos (LIMA, 2019, p. 431).

### 3.2.3. CONEXÃO ENTRE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E CRIME ELEITORAL

A par de respeitável corrente doutrinária em sentido diverso, majoritariamente, entende-se que, verificando-se a conexão entre crime doloso contra a vida e crime eleitoral, deve haver separação dos processos, sendo o primeiro julgado pelo Tribunal do Júri e o segundo pela Justiça Eleitoral, porquanto ambas as competências originam-se diretamente da própria Constituição Federal (NUCCI, 2016, p. 163).

É dizer: se a própria CF/88 determina que compete ao Tribunal do Júri o processamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea *d*) e à Justiça Eleitoral o julgamento dos crimes eleitorais (art. 121, *caput*), tais competências não podem ser alteradas pela regra infraconstitucional de conexão, prevista no art. 69, inciso V, do CPP (NUCCI, 2016, p. 163).

Assim, considerando a premissa de que regras constitucionais não podem ser afastadas por normas infraconstitucionais, a única forma de se respeitar o regramento constitucional atinente ao Tribunal do Júri e à Justiça Eleitoral, é separar os processos.

## 3.3. JUSTIÇA DO TRABALHO

Após o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, a Justiça do Trabalho passou a ter competência para processar e julgar "os mandados de segurança, *habeas corpus* e *habeas data*, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição", conforme disposto no art. 114, inciso IV, da CF/88.

Interessante assentar que o julgamento de tais ações somente competirá à Justiça do Trabalho se o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, razão pela qual nem todo *habeas corpus* impetrado contra ato de Juiz do Trabalho será julgado pela Justiça do Trabalho. Caso o ato não guarde relação com as matérias sujeitas à justiça trabalhista, o *writ* deverá ser julgado pelo Tribunal Regional Federal competente, nos termos do art. 108, inciso I, alínea *a*, da CF/88 (LIMA, 2020, p. 495-496).

Como visto, por expressa determinação constitucional, a Justiça do Trabalho irá processar e julgar os *habeas corpus* atinentes a matérias sujeitas à sua jurisdição, o que não lhe confere, todavia, competência criminal, isto é, não detém a Justiça do Trabalho competência para o processo e julgamento de infrações penais, ainda que atreladas ao contexto das relações trabalhistas (AVENA, 2017, p. 448).

## 3.4. JUSTIÇA FEDERAL

### 3.4.1. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS

A competência dos Tribunais Regionais Federais está disposta no art. 108 da CF/88, que merece ser lido à inteireza, destacando-se que os juízes federais, incluídos os da justiça castrense e da trabalhista, e os membros do MPU têm foro por prerrogativa de função perante tais Tribunais, o que é bem importante nos concursos públicos, porquanto abre a possibilidade da Justiça Federal julgar contravenções penais.

Conforme será mais bem trabalhado adiante, os juízes federais, isto é, a Justiça Federal de 1ª instância, não têm competência para processar e julgar as contravenções penais, mesmo que cometidas em conexão com crimes de sua competência.

Ocorre que, caso a contravenção penal seja praticada por detentor de foro por prerrogativa de função perante um Tribunal Regional Federal, tal infração será julgada por este TRF, isto é, não se pode afirmar, de forma peremptória, que a Justiça Federal, em sentido amplo, não tem competência para processar e julgar as contravenções penais. O que não pode acontecer é um juiz federal, isto é, Justiça Federal de 1ª instância, julgar tais infrações penais, já que somente tem competência para processar crimes praticados em algum dos contextos insertos no art. 109 da CF/88.

### **3.4.2. COMPETÊNCIA DOS JUÍZES FEDERAIS**

#### **3.4.2.1. CRIMES POLÍTICOS**

Nos termos do art. 109, inciso IV, primeira parte, da CF/88, compete aos juízes federais (Justiça Federal de 1ª instância), processar e julgar os crimes políticos, isto é, aqueles previstos na Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/83) e que lesam ou expõem a perigo de lesão: I - a integridade territorial e a soberania nacional; II - o regime representativo e democrático, a Federação e o Estado de Direito; e III - a pessoa dos chefes dos Poderes da União (art. 1º).

Além do mais, nos termos do art. 2º da Lei de Segurança Nacional, considerando que alguns dos crimes nela previstos também são tipificados pelo Código Penal, Código Penal Militar ou legislações penais esparsas, para se verificar se a conduta é ou não um crime político, devem ser avaliadas as seguintes características: I - a motivação e os objetivos do agente; e II - a lesão real ou potencial aos bens jurídicos mencionados no artigo anterior (LIMA, 2020, p. 499).

O art. 30 da Lei nº 7.170/83 dispõe que compete à Justiça Militar o processo e julgamento dos crimes nela previstos, o que não foi recepcionado pela Constituição Federal vigente, já que esta, em seu art. 109, inciso IV, primeira parte, estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar os crimes políticos (AVENA, 2017, p. 449).

##### **3.4.2.1.1. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL**

Merece bastante atenção a situação prevista no art. 102, inciso II, alínea *b*, da CF/88, o qual dispõe que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, em recurso ordinário, o crime político, não cabendo, nesse sentido, interposição de apelação contra a decisão do juiz federal de 1ª instância, seja a sentença condenatória, seja absolutória (LIMA, 2020, p. 499).

Portanto, o crime político é julgado, em primeira instância, por um juiz federal, e, em segunda e última instância, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que, nesse caso, funcionará como verdadeiro Tribunal de Apelação (LIMA, 2020, p. 499).

##### **3.4.2.2. CRIMES PRATICADOS CONTRA A UNIÃO**

De acordo com o art. 109, inciso IV, segunda parte, da CF/88, compete aos juízes federais (Justiça Federal de 1ª instância) processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral.

###### **3.4.2.2.1. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DA UNIÃO**

Tema bastante recorrente em provas de concurso diz respeito às sociedades de economia mista da União, já que estas não estão arroladas no citado art. 109, inciso IV, da CF/88. Por esta razão, se a infração penal for praticada em detrimento de sociedades de economia mista, ainda



que pertencentes à União, a competência para seu processo e julgamento recairá sobre a Justiça Comum Estadual e não Federal, nos termos da Súmula nº 42 do STJ.

#### 3.4.2.2.2. FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS

Apesar de não constarem expressamente do art. 109, inciso IV, da CF/88, os crimes praticados em desfavor das fundações públicas federais, sejam elas de direito público, sejam elas de direito privado, serão processados e julgados pela Justiça Federal.

#### 3.4.2.2.3. CONTRAVENÇÕES PENAIS

Outro tema de suma importância para as provas de concurso diz respeito às contravenções penais, que estão excluídas da competência dos juízes federais, isto é, da Justiça Federal de 1ª instância. Atente-se para isso: não é correto afirmar que a Justiça Federal não tem competência para o processo e julgamento de contravenções penais, já que o art. 109, inciso IV, da CF/88, somente excluiu tal competência dos juízes federais, isto é, da Justiça Federal de 1ª instância, o que não impede que a Justiça Federal de 2ª instância julgue tais infrações penais, conforme será mais bem trabalhado adiante.

Nesse contexto, praticada uma contravenção penal, ainda que em desfavor de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, salvo se praticada por detentor de foro por prerrogativa de função, a competência para seu processo e julgamento será da Justiça Comum Estadual de 1ª instância e não Federal, nos termos da Súmula nº 38 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Detalhe importante diz respeito à conexão entre crime e contravenção penal, porquanto, ainda que ambas as infrações penais tenham sido praticadas em desfavor de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, haverá separação obrigatória dos processos, sendo o crime julgado pela Justiça Federal e a contravenção penal pela Justiça Estadual. É dizer: no caso de conexão entre crime de competência da Justiça Federal e contravenção penal, não haverá a reunião de processos perante o juízo federal de 1ª instância, que, como dito, não tem competência para o julgamento de contravenções penais.

Noutro giro, se a contravenção penal for praticada por detentor de foro por prerrogativa de função perante Tribunal Regional Federal, como ocorre, por exemplo, no caso de juiz federal, tal infração será processada e julgada por aquele Tribunal Federal, sendo esse um exemplo no qual a Justiça Federal é competente para o processo de contravenções penais.

Assim, apesar da simplicidade da regra contida no art. 109, inciso IV, da CF/88, muita atenção deve ser dada ao fato de que a Justiça Federal de 2ª instância tem competência para o processo e julgamento de contravenções penais, caso estas sejam praticadas por detentores de foro por prerrogativa de função perante os Tribunais Regionais Federais (AVENA, 2017, p. 450).

#### 3.4.2.2.4. CRIMES EM DESFAVOR DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS

Nos termos da Súmula nº 147 do STJ, “competete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal, quando relacionados com o exercício da função”. Percebe-se, portanto, que, caso o crime não esteja relacionado com o exercício funcional, ainda que praticado em desfavor de servidor público federal, a competência para seu processo e julgamento recairá sobre a Justiça Comum Estadual e não Federal, que somente atuará se o fato tiver relação com as funções exercidas por aquele servidor público (*propter officium*).

#### 3.4.2.2.5. CRIMES PRATICADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS

Conforme a Súmula nº 254 do extinto Tribunal Federal de Recursos, “competete à Justiça Federal processar e julgar os delitos praticados por funcionário público federal no exercício de suas



funções e com estas relacionados". Logo, assim como ocorre nos crimes praticados contra os servidores públicos federais, nos crimes por eles praticados, a condição de servidor público, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal.

Para que o crime praticado por servidor público federal seja processado e julgado pela Justiça Comum Federal, é necessário que tenha relação com as funções daquele servidor público (*propter officium*). Caso não haja, a competência para o processo e julgamento do fato recairá sobre a Justiça Comum Estadual.

#### 3.4.2.2.6. CRIMES CONTRA A FAUNA E A FLORA

A Súmula nº 91 do STJ dispunha que "competete à Justiça Federal processar e julgar crimes praticados contra a fauna". Todavia, atualmente, tal enunciado encontra-se superado. Assim, não havendo lesão ou perigo de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, afasta-se a competência da Justiça Federal, sendo os crimes contra o meio ambiente, aqui incluídos os delitos contra a fauna e a flora, via de regra, julgados pela Justiça Comum Estadual (AVENA, 2017, p. 450).

Importante não confundir bem da União com patrimônio nacional. Nos termos do art. 225, §4º, da CF/88, "a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais". Apesar de integrarem o patrimônio nacional, isto é, de serem bens do interesse do Brasil, mormente diante de eventuais ingerências estrangeiras, os ecossistemas citados no parágrafo transcrito não são bens da União. Por essa razão, eventuais crimes contra eles praticados, por não envolverem interesse direto da União, serão processados e julgados pela Justiça Comum Estadual (LIMA, 2020, p. 520).

#### 3.4.2.2.7. USO DE DOCUMENTO FALSO

Nos termos da Súmula nº 546 do STJ, "a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor", logo, para fins de definição da Justiça competente, pouco importa qual órgão ou entidade é responsável pela emissão do documento falsificado.

Vejamos, por exemplo, o caso do uso de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada. Nessa hipótese, como visto, não importa de quem é a responsabilidade para a emissão de tal documento. Em verdade, o que será levado em consideração, para fins de definição da competência, é o órgão ou entidade a qual o documento falsificado foi apresentado. Se, por exemplo, a CNH falsa foi apresentada a um Policial Rodoviário Federal, a competência para o processo e julgamento deste fato será da Justiça Federal. Por outro lado, se a CNH falsa foi apresentada a um Policial Militar, este fato deverá ser processado e julgado pela Justiça Estadual.

#### 3.4.2.2.8. MOEDA FALSA

Por atentar contra um serviço da União, isto é, contra o serviço de emissão de moedas, nos termos do art. 21, inciso VII, da CF/88, o crime de moeda falsa, inserto no art. 289 do CP, é de competência da Justiça Federal.

No ponto, muita atenção deve ser dada à falsificação grosseira de moedas, tema recorrente nas provas de concurso, porquanto duas situações bastante distintas podem ser questionadas.

A primeira delas diz respeito ao agente que é surpreendido com moedas grosseiramente falsas, como ocorre, por exemplo, com um cidadão que é abordado, em uma "blitz" policial, na posse de moedas grosseiramente falsas, no interior de seu automóvel. Nesse caso, por absoluta

impropriedade do objeto, o crime é impossível, nos termos do art. 17 do CP, evidenciando-se a atipicidade do fato.

A segunda delas diz respeito ao agente que se vale de moeda grosseiramente falsa para ludibriar outrem, como ocorre, por exemplo, no caso de um sujeito que, valendo-se de R\$2.000,00 (dois mil reais) em notas falsas, consegue adquirir um notebook de um idoso. Nessa hipótese, restará configurado o crime de estelionato, nos termos do art. 171 do CP, já que, valendo-se de um ardil (utilização de moeda grosseiramente falsificada), o agente obteve vantagem ilícita, em prejuízo alheio, sendo o fato de competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula nº 73 do STJ.

#### **3.4.2.2.9. ATOS INFRACIONAIS**

Os atos infracionais, ainda que praticados em desfavor de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não são de competência da Justiça Federal. Em verdade, o menor imputável que praticar um ato infracional está sujeito "à jurisdição do Juiz da Infância e da Juventude, no âmbito da Justiça Comum Estadual" (LIMA, 2020, p. 528).

#### **3.4.2.3. CRIMES PREVISTOS EM TRATADO OU CONVENÇÃO INTERNACIONAL**

De acordo com o art. 109, inciso V, da CF/88, compete aos juízes federais processar e julgar os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente.

Nota-se, portanto, que, por si só, o fato de o crime estar previsto em tratado ou convenção internacional não atrai a competência da Justiça Comum Federal. Para tanto, é necessário que, além disso, o crime tenha "repercussão internacional e não meramente interna ao País" (AVENA, 2017, p. 450).

##### **3.4.2.3.1. TRÁFICO DE DROGAS**

Partindo da premissa acima trabalhada, o crime de tráfico de drogas somente será de competência da Justiça Federal se evidenciada a sua transnacionalidade, isto é, se não estiver adstrito às fronteiras do Brasil.

É nesse sentido a Súmula nº 522 do STF, a qual aduz que, "salvo ocorrência de tráfico para o exterior, quando então a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes".

Logo, ainda que verificada a interestadualidade do tráfico, se o crime estiver adstrito ao território nacional, a competência será da Justiça Comum Estadual.

Para que seja evidenciado o tráfico transnacional, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06, não basta que a droga provavelmente tenha sido adquirida no exterior. É dizer: não sendo demonstrado que foi aquela pessoa a responsável por transpor as fronteiras do País com a droga apreendida, não se pode pressupor que o tráfico seja transnacional.

Caso contrário, se fosse utilizado o critério da provável aquisição no exterior, toda vez que fossem apreendidas porções de cocaína em nosso País, restaria evidenciado tráfico internacional, já que o Brasil não produz tal substância (AVENA, 2017, p. 450).

Nesse contexto, ainda que a droga seja apreendida em localidade próxima às fronteiras do Brasil, para que o fato seja de competência da Justiça Federal, é preciso averiguar se a pessoa surpreendida com a droga, de fato, está envolvida com atos de importação e transporte internacional ou se é mera revendedora que já teria adquirido a substância em nosso território (LIMA, 2020, p. 532).

Detalhe interessante diz respeito ao fato de que, para se verificar a competência da Justiça Federal, isto é, para que o tráfico seja considerado transnacional, necessário se faz que a substância apreendida no Brasil também seja considerada ilícita no país de origem ou de destino.

Caso contrário, o tráfico é interno, ou seja, de competência da Justiça Comum Estadual (LIMA, 2020, p. 532).

No que diz respeito à competência territorial, à luz da Súmula nº 528 do STJ, "competete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional". Assim, pouco importa por onde aquela droga entrou. O que importa, para fins de determinação do juízo federal competente, é o local da apreensão. Caso contrário, a justiça federal das fronteiras ficaria abarrotada de processos de tráfico.

#### **3.4.2.3.2. CONTRABANDO E DESCAMINHO**

O STJ, no julgamento do CC 160.748/SP, de relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, assentou que, ainda que inexistentes indícios de transnacionalidade da conduta, compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes de contrabando e descaminho, o que se mostra bem relevante nas provas de concurso, já que, via de regra, só há falar em competência da Justiça Federal se verificada a transnacionalidade da conduta.

#### **3.4.2.3.3. PORNOGRAFIA INFANTIL E PEDOFILIA POR MEIO DA INTERNET**

O fato dos crimes insertos no art. 241 e seguintes do ECA serem praticados pela internet, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, já que, nos termos do art. 109, inciso V, da CF/88, mostra-se necessário que o delito tenha caráter transnacional.

Nesse contexto, se um agente, em Brasília/DF, por meio do WhatsApp, envia uma fotografia que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente a uma pessoa que esteja no Rio de Janeiro/RJ, não há falar em competência da Justiça Federal, já que não satisfeito o requisito da transnacionalidade (LIMA, 2020, p. 537).

Noutro giro, se esse mesmo agente de Brasília/DF, posta tal fotografia em um *site* da rede mundial de computadores, isto é, abrindo a possibilidade de acesso por qualquer pessoa do mundo, restará configurada a transnacionalidade do delito, ainda que nenhuma pessoa de fora do Brasil tenha, de fato, acessado, invocando-se a competência da Justiça Federal. Logo, havendo divulgação do conteúdo na rede mundial de computadores, a competência para o processo e julgamento do fato é da Justiça Federal (LIMA, 2020, p. 537).

No que diz respeito à competência territorial, os Tribunais Superiores têm entendido que compete ao juízo do local do lançamento das fotos na internet, sendo desimportante a localização do provedor de acesso à rede mundial de computadores (LIMA, 2020, p. 537).

#### **3.4.2.4. INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL**

Conforme art. 109, inciso V-A, da CF/88, compete aos juízes federais processar e julgar as causas relativas a direitos humanos a que se refere o art. 109, §5º, da CF/88, o qual aduz que, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o PGR, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.

Nesse sentido, de acordo com a própria literalidade dos dispositivos legais transcritos, verifica-se que o Incidente de Deslocamento de Competência (IDC) é suscitado pelo Procurador-Geral da República perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase da investigação ou do processo judicial, a fim de que sejam respeitados tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte.

Nota-se, portanto, que não é necessário, para fins de suscitação do IDC, que o crime praticado seja dotado de caráter transnacional. Em verdade, para que se possa falar na federalização dos crimes contra os direitos humanos, dois pressupostos devem ser preenchidos, a saber (LIMA, 2020, p. 539):

- a) a existência de crime praticado com grave violação aos direitos humanos;
- b) demonstração concreta de risco de descumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais firmados pelo Brasil, resultante da inércia, negligência, falta de vontade política ou de condições reais do Estado-membro, por suas instituições, em proceder à devida persecução penal.

Como se nota, não é todo caso que envolva grave violação aos direitos humanos que será levado à Justiça Federal. Para que se retire o caso da Justiça Estadual, é necessário que os órgãos estaduais da persecução penal, sejam eles policiais, sejam eles judiciários, se mostrem inertes, negligentes ou sem condições reais de efetivar a necessária persecução penal. Assim, verificando-se uma gravíssima violação aos direitos humanos, mas não sendo observada atuação deficiente dos órgãos estaduais, não há falar no Incidente de Deslocamento da Competência.

#### **3.4.2.5. CRIMES CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E, NOS CASOS DETERMINADOS POR LEI, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E A ORDEM ECONÔMICO-FINANCEIRA**

De acordo com o art. 109, inciso VI, da CF/88, compete aos juízes federais processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira.

Depreende-se, portanto, que, em relação aos crimes contra a organização do trabalho, para que o processo e julgamento de tais delitos sejam de competência da Justiça Federal, não há necessidade de legislação infraconstitucional. É dizer: a competência da Justiça Federal, no caso dos crimes contra a organização do trabalho, emana diretamente da Constituição Federal.

Em contrapartida, no caso dos crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, só há falar em competência da Justiça Federal, se houver lei infraconstitucional prevendo tal situação. É dizer: a competência da Justiça Federal, no caso dos crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, não emana diretamente da Constituição Federal.

##### **3.4.2.5.1. CRIMES CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO**

Como visto, independentemente de legislação infraconstitucional, a CF/88 determina que compete aos juízes federais processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho. Interpretando tal dispositivo constitucional, a jurisprudência dos Tribunais Superiores assentou que só há falar em competência da Justiça Federal nos casos em que houver lesão aos direitos dos trabalhadores coletivamente considerados. É dizer: "tratando-se de simples lesão a direito individual, remanesce a competência residual da Justiça Estadual" (AVENA, 2017, p. 452).

Nesse contexto, permanece aplicável a Súmula nº 115 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que assim dispõe: "Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho, quando tenham por objeto a organização geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores considerados coletivamente".

Logo, nem todo crime inserto no Título IV do Código Penal, que trata "dos crimes contra a organização do trabalho", será de competência da Justiça Federal. Em verdade, a regra é que seja julgado pela Justiça Estadual, sendo de competência da Justiça Federal somente os casos que atentarem contra a organização geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores coletivamente considerados.

Tema bastante recorrente nas provas de concurso diz respeito ao crime de redução a condição análoga à de escravo, inserto no art. 149 do Código Penal, o qual, apesar de não constar no citado Título IV (e sim no Título I do CP), é considerado um crime contra a organização geral do trabalho e/ou os direitos dos trabalhadores considerados coletivamente, sendo, pois, um crime de competência da Justiça Federal (AVENA, 2017, p. 452).



### 3.4.2.5.2. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO

Como dito, para que os crimes contra o sistema financeiro fossem julgados pela Justiça Federal, exigiu o constituinte regulamentação infraconstitucional quanto ao ponto. Logo, somente serão de competência da Justiça Federal os casos expressamente previstos na legislação infraconstitucional.

No que diz respeito ao Sistema Financeiro Nacional, especial atenção deve ser dada à Lei nº 7.492/86, a qual, em seu art. 26, determina que "a ação penal, nos crimes previstos nesta lei, será promovida pelo Ministério Público Federal, perante a Justiça Federal".

Portanto, atendendo ao comando constitucional inserto no art. 109, inciso VI, da CF/88, o legislador infraconstitucional, ao editar a Lei nº 7.492/86, estatuiu que os crimes nela previstos serão de competência da Justiça Comum Federal, razão pela qual fica afastada a atuação da Justiça Comum Estadual.

### 3.4.2.5.3. CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICO-FINANCEIRA

Assim como ocorre em relação aos crimes contra o sistema financeiro, para que os crimes contra a ordem econômico-financeira fossem julgados pela Justiça Comum Federal, a Constituição Federal exigiu regulamentação infraconstitucional quanto ao ponto. Nesse sentido, somente serão de competência da Justiça Federal os casos expressamente previstos na legislação infraconstitucional.

Diferentemente do que ocorreu em relação aos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, o legislador infraconstitucional não previu que os crimes contra a ordem econômico-financeira fossem julgados pela Justiça Federal, razão pela qual, via de regra, tais delitos serão apreciados pela Justiça Estadual.

É o que se verifica, por exemplo, em relação aos crimes contra a economia popular, insertos na Lei nº 1.521/51, a qual nada diz respeito à competência. Portanto, silenciando o legislador, nos termos do art. 109, inciso VI, da CF/88, a competência para processar e julgar os crimes contra a economia popular recai sobre a Justiça Comum Estadual. É nesse sentido o teor da Súmula nº 498 do STF: "Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular".

De forma semelhante, a Lei nº 8.137/90, que trata dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, também foi silente em relação à competência, razão pela qual, via de regra, os crimes nela previstos serão de competência da Justiça Estadual.

Logicamente, se um crime previsto na Lei nº 8.137/90, como o delito de formação de cartel (art. 4º), atentar contra bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, tal fato deverá ser julgado pela Justiça Federal, com base no estudado art. 109, inciso IV, da CF/88 e não por seu inciso VI, ora estudado (LIMA, 2020, p. 546).

A Lei nº 8.176/91, a qual, em seu art. 1º, inciso I, traz o crime de venda de combustível adulterado, nada dispôs sobre a competência para seu processo e julgamento, razão pela qual fica afastada a competência da Justiça Federal. Nesse caso, pouco importa o fato de competirem à Agência Nacional de Petróleo o controle, a fiscalização e a regulação da atividade de distribuição e revenda de derivados do petróleo e álcool, "haja vista tratar-se de interesse genérico, reflexo e não-imediato, o que, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal com base no inciso IV do art. 109 da Carta Magna" (LIMA, 2020, p. 546).

Por sua vez, a Lei nº 9.613/98, que trata dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, quanto à competência, traz uma estrutura híbrida, isto é, tais fatos poderão ser julgados pela Justiça Estadual ou pela Justiça Federal.

A regra geral é que os crimes de lavagem de dinheiro serão processados e julgados pela Justiça Comum Estadual. Todavia, dispõe o art. 2º, inciso III, da Lei nº 9.613/98, que tais delitos são de competência da Justiça Federal, nos seguintes casos: a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da



União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; e b) quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.

#### 3.4.2.6. HABEAS CORPUS

De acordo com o art. 109, inciso VII, da CF/88, compete aos juízes federais processar e julgar os *habeas corpus*, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição.

Assim, será da competência do juiz federal, isto é, será julgado pela Justiça Federal de 1ª instância o *habeas corpus* impetrado contra ato de um delegado de Polícia Federal, porquanto tal autoridade não é dotada de foro por prerrogativa de função.

Em contrapartida, se a autoridade apontada como coatora for dotada de foro por prerrogativa de função, o *habeas corpus* contra ela impetrado não será de competência do juiz federal, como ocorre, por exemplo, no caso de ato praticado por procurador da república atuante na 1ª instância, que deve ser julgado pelo Tribunal Regional Federal respectivo, conforme será melhor estudado no capítulo atinente ao *habeas corpus*.

#### 3.4.2.7. MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA CRIMINAL

Conforme art. 109, inciso VIII, da CF/88, compete aos juízes federais processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais.

Portanto, será de competência do juiz federal, isto é, será julgado pela Justiça Federal de 1ª instância, o mandado de segurança impetrado contra ato de um delegado de Polícia Federal, que, por exemplo, denega ao advogado acesso às peças já documentadas em inquérito policial que tramita em sua delegacia, violando, pois, a Súmula Vinculante nº 14 do STF.

#### 3.4.2.8. CRIMES COMETIDOS A BORDO DE NAVIOS E AERONAVES

De acordo com o art. 109, inciso IX, da CF/88, compete aos juízes federais processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar.

##### 3.4.2.8.1. CRIMES COMETIDOS A BORDO DE NAVIOS

No que diz respeito à primeira parte do art. 109, inciso IX, da CF/88, nota-se que o constituinte foi bastante seletivo na escolha do termo por ele utilizado, já que, ao se valer da expressão "navios", teve a intenção de somente fixar a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento de crimes cometidos a bordo de "embarcações aptas para a navegação em alto-mar". É dizer: os crimes cometidos a bordo de "embarcações de pequeno porte ou de pequeno calado, tais como lanchas de recreio, botes com motor de popa, jet-skis, etc.", não são julgados pela Justiça Federal, mas, sim, pela Justiça Comum Estadual (LIMA, 2020, p. 551).

Outro detalhe importante em relação aos crimes cometidos a bordo de navios diz respeito ao fato de que, para fins de fixação da competência da Justiça Federal, é exigido que o navio "se encontre em situação de deslocamento internacional ou ao menos em situação de potencial deslocamento". Por essa razão, o STJ assentou que compete à Justiça Estadual processar e julgar crimes de homicídio e lesão corporal culposos ocorridos durante operação de carregamento de navio, porquanto a embarcação estava ancorada e não se encontrava nem mesmo em situação de potencial deslocamento (STJ, CC 116.011/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2011, DJe 1º/12/2011).





### 3.4.2.8.2. CRIMES COMETIDOS A BORDO DE AERONAVES

Diferentemente do que fez em relação aos navios, o constituinte, ao redigir a segunda parte do art. 109, inciso IX, da CF/88, não restringiu o alcance do termo por ele empregado, sendo de competência da Justiça Federal os crimes cometidos a bordo de aeronaves, pouco importando o seu porte. É dizer: para fins de fixação da competência da Justiça Federal, mostra-se desimportante o fato de a aeronave ser de grande, médio ou pequeno porte. Se for aeronave, o crime nela cometido será processado e julgado pela Justiça Federal.

Conquanto o constituinte não tenha sido seletivo em relação ao termo aeronave, não é tão fácil, inclusive em tese, saber o que é uma aeronave, cuja definição legal se encontra no art. 106, *caput*, da Lei nº 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), que assim dispõe: "Considera-se aeronave todo aparelho manobrável em vôo, que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas".

Enfrentando um caso que passava justamente pela conceituação de aeronave, o STJ, após assentar que o termo aeronave é "de difícil definição jurídica", disse que compete à Justiça Estadual processar e julgar crimes cometidos a bordo de "balões de ar quente tripulados", porquanto estes não se enquadrariam na conceituação legal de aeronave (CC 143.400/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe 15/5/2019).

Ainda no que diz respeito às aeronaves, tem-se que, diferentemente do que ocorre em relação aos navios, para fins de fixação da competência da Justiça Federal, mostra-se irrelevante o fato da aeronave se encontrar em solo ou sobrevoando. É dizer: ainda que a aeronave se encontre em terra, o crime nela cometido será de competência da Justiça Federal, ou seja, mesmo que a aeronave não esteja em deslocamento ou em situação de potencial descolamento, o crime cometido em seu interior deverá ser processado e julgado pela Justiça Federal (CC 143.343/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 30/11/2016).

### 3.4.2.8.3. FORO COMPETENTE NO CASO DE CRIMES COMETIDOS A BORDO DE EMBARCAÇÕES E AERONAVES

Em seus arts. 89, 90 e 91, o Código de Processo Penal disciplina o foro competente para processar e julgar as infrações penais praticadas a bordo de embarcações e aeronaves.

Um detalhe muito importante, que, muitas das vezes, passa despercebido, refere-se ao fato de que as regras insertas nos arts. 89, 90 e 91 do CPP somente são aplicáveis ao território nacional, isto é, somente podemos nos recorrer a elas, no caso da embarcação ou aeronave ser considerada território nacional. Caso contrário, não serão aplicadas as regras estatuídas pelos citados artigos, mas, sim, aquela trazida pelo art. 88 do mesmo Código, que disciplina o foro competente para processar e julgar fatos ocorridos fora do território nacional, que será analisado no último tópico desse capítulo.

Em outras palavras, somente são aplicáveis as regras trazidas pelos arts. 89, 90 e 91, do CPP, caso aquela embarcação ou aeronave seja considerada território nacional, porquanto, caso não seja território nacional, isto é, se tratar de extraterritorialidade da lei penal, quem determinará o foro competente é o art. 88 do CPP.

De acordo com a primeira parte do art. 5º, §1º, do Código Penal, as embarcações e aeronaves de natureza pública ou que estejam a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, serão consideradas território nacional, isto é, ser-lhe-ão aplicadas as regras dos arts. 89, 90 e 91, do CPP. Isto é, mesmo que as embarcações ou aeronaves públicas do Brasil ou que estejam a serviço do governo brasileiro se encontrem em águas ou no espaço aéreo de outro País, serão elas consideradas território do Brasil.

Em sentido contrário, respeitando-se a reciprocidade, as embarcações e as aeronaves estrangeiras de natureza pública ou que estejam a serviço de governo estrangeiro, ainda que se encontrem em nossas águas ou em nosso espaço aéreo, não serão consideradas território nacional, não sendo aplicáveis às infrações penais nelas cometidas as regras dos arts. 89, 90 e 91, do CPP.

Conforme a segunda parte do art. 5º, §1º, do Código Penal, as embarcações e as aeronaves brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, serão consideradas território nacional em duas situações, tão somente: I) por óbvio, se estiverem em território nacional, isto é, em nossas águas ou em nosso espaço aéreo; e II) estiverem no alto-mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto-mar, isto é, em território de nenhum outro País. Caso tais embarcações ou aeronaves se encontrem em águas ou no espaço aéreo de outro País, não serão aplicadas às infrações penais nelas cometidas as regras insertas nos arts. 89, 90 e 91, do CPP.

Em complementação à regra trazida pela segunda parte do art. 5º, §1º, do Código Penal, o §2º disciplina que, caso embarcações ou aeronaves estrangeiras de propriedade privada estejam em portos, águas, aeroportos ou em nosso espaço aéreo, serão consideradas território nacional, sendo aplicadas às infrações penais nelas cometidas as regras insertas nos arts. 89, 90 e 91, do CPP. É dizer: pela reciprocidade, se nossas embarcações e aeronaves privadas, quando estão em águas ou no espaço aéreo pertencentes a outro País, não são consideradas nosso território, tal regra também deve valer para as embarcações e as aeronaves estrangeiras de natureza privada.

Fixadas essas balizas, tem-se que o art. 89 do CPP disciplina que as infrações penais cometidas a bordo de embarcações serão processadas pela justiça (federal ou estadual) do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação, após o fato, ou, quando se afastar do País, pela do último em que houver tocado. Assim, sendo aplicável a regra do art. 89 do CPP, isto é, caso seja nosso território, a infração penal cometida a bordo de embarcações deverá ser julgada pela justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar após o crime. Caso aquela embarcação tenha se afastado do Brasil, o fato deverá ser julgado pela justiça do último porto brasileiro que a embarcação tocou antes de partir. Desse modo, duas regras devem ser observadas: I) se a embarcação não saiu do Brasil, a infração penal será julgada pela justiça do local do primeiro porto brasileiro em que ela tocar após o crime; e II) se a embarcação saiu do Brasil, a infração penal será julgada pela justiça do local do último porto brasileiro que ela tocou.

Semelhantemente, o art. 90 do CPP normatiza que as infrações penais cometidas a bordo de aeronaves serão julgadas pela justiça (federal) do território em que se verificar o pouso após o crime, ou pela comarca de onde houver partido a aeronave. Assim, sendo aplicável a regra do art. 90 do CPP, isto é, caso seja nosso território, a infração penal cometida a bordo de aeronave deverá ser julgada pela justiça do local onde ocorrer o pouso após o crime. Caso a aeronave tenha se afastado do Brasil, o fato deverá ser julgado pela justiça do local em que está situado o aeroporto de onde a aeronave partiu. Desse modo, duas regras devem ser observadas: I) se a aeronave não saiu do Brasil, a infração penal será julgada pela justiça do local do aeroporto brasileiro em que ela pousar depois do crime; e II) se a aeronave saiu do Brasil, a infração penal será julgada pela justiça do local do aeroporto brasileiro de onde ela partiu.

Caso as regras trazidas pelos arts. 89 e 90 do CPP não sejam suficientes à determinação da competência, nos termos do art. 91 do CPP, esta será fixada pela prevenção do juízo, que será estudada, com mais detalhes, em tópico próprio.

#### **3.4.2.9. CRIMES DE INGRESSO OU PERMANÊNCIA IRREGULAR DE ESTRANGEIRO**

Conforme art. 109, inciso X, primeira parte, da CF/88, compete aos juízes federais processar e julgar os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro.

Inicialmente, assenta-se que o dispositivo constitucional ora em análise deve ser entendido "no sentido de que compete aos juízes federais o processo e julgamento de todo e qualquer crime, previsto na legislação comum ou especial, cometido pelo estrangeiro com o intuito de regularizar o seu ingresso e permanência no Brasil" (LIMA, 2020, p. 553).

Ademais, importa registrar que o fato do crime ser cometido por estrangeiro, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal. É dizer: "a condição de estrangeiro, para fins de fixação de competência criminal, só tem relevância quando se trata de crime relacionado ao ingresso ou permanência irregular no país" (LIMA, 2020, p. 553).

### 3.4.2.10. DISPUTA SOBRE DIREITOS INDÍGENAS

De acordo com o art. 109, inciso XI, da CF/88, compete aos juízes federais processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas.

Trazendo tal dispositivo constitucional ao campo da competência criminal, tem-se que

não é o fato de ser índio o sujeito ativo ou o sujeito passivo da conduta delituosa que atrai a competência federal, sendo necessário que fique caracterizado estar o delito relacionado à disputa sobre direitos indígenas", isto é, "que atinja interesses gerais da população indígena, assumindo caráter transindividual (AVENA, 2017, p. 454).

É nesse sentido o teor da Súmula nº 140 do STJ, a qual aduz que "competete à justiça comum estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou como vítima".

Assim, ainda que o fato seja praticado no interior de uma reserva indígena, caso não guarde relação com a disputa sobre direitos indígenas, não será processado e julgado pela Justiça Federal, mas, sim, pela Justiça Comum Estadual (LIMA, 2020, p. 554).

### 3.5. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO

Em razão das funções públicas exercidas por determinados agentes, o ordenamento lhes confere a prerrogativa de serem julgados, originariamente, por um Tribunal, o que é denominado de foro por prerrogativa de função ou competência *ratione personae* ou *ratione functionae*. É dizer: o processo criminal já "nasce" perante um Tribunal, não se sujeitando ao crivo de um órgão judiciário de 1ª instância.

O foro por prerrogativa de função exerce dupla função de garantia, já que, em uma primeira vertente, "tem um caráter favorável ao acusado (outorga a ele o direito de ser julgado por órgão coletivo, que tem menor chance de ser objeto de constrangimentos por terceiros que o juízo singular)". Em uma segunda vertente de proteção, diz-se que o foro por prerrogativa de função "manifesta-se contra o réu (eis que também é menor o risco de coação efetuada pelo próprio réu relativamente a um órgão judicial coletivo, que a um órgão singular) (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 427).

Nesse sentido, considerando que, ao menos em tese, o foro por prerrogativa de função somente deve ser instituído em razão do cargo exercido e não da pessoa que o exerce, deve-se evitar a expressão "foro privilegiado", porquanto não se trata de um privilégio em relação à pessoa. Em verdade, o foro por prerrogativa de função deve ser visto como uma garantia ao exercício pleno das atribuições do cargo, porquanto o seu titular não pode estar sujeito a pressões infundadas de outras autoridades.

Assim, justamente pelo fato de não ser um privilégio pessoal do ocupante do cargo, os Tribunais Superiores têm restringido o alcance das normas que disciplinam o foro por prerrogativa de função, somente o mantendo nos casos em que tal instituto se mostre estritamente necessário ao imparcial exercício do cargo. Dada a importância em provas de concurso, em tópicos separados, vejamos alguns regramentos firmados pelos Tribunais Superiores nos últimos anos.

#### 3.5.1. INFRAÇÃO PENAL COMETIDA DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO (REGRAS DA CONTEMPORANEIDADE)

A primeira regra importante em relação à restrição do alcance das normas que disciplinam o foro por prerrogativa de função diz respeito à chamada regra da contemporaneidade, isto é, a infração penal somente será julgada pelo Tribunal respectivo se for praticada durante o exercício do cargo (após a diplomação ou investidura no cargo, conforme o caso) (STF. Plenário. AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/5/2018).

Logo, pela regra da contemporaneidade, que não se confunde com a regra da atualidade, se a infração penal for cometida antes do início do exercício do cargo, não há falar em

foro por prerrogativa de função. É dizer: ainda que a diplomação/investidura se dê durante o processo criminal ainda não findado, este não será deslocado ao foro por prerrogativa de função, porquanto o fato não foi praticado durante o exercício do cargo.

Esse não deslocamento do processo ao foro por prerrogativa de função é justamente o que diferencia a regra da contemporaneidade da regra da atualidade. Segundo esta última, caso a infração penal tenha "sido perpetrada em data anterior ao início do exercício de cargo ou função com prerrogativa de foro, o processo criminal deve ser remetido para o órgão competente para julgar o agente", sendo considerados válidos os atos processuais já praticados, nos termos da regra do *tempus regit actum* (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 431).

### **3.5.1.1. MARCO TEMPORAL PARA FINS DE POSSÍVEL PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL COMPETENTE**

A fim de evitar que o titular do cargo, buscando, por exemplo, uma eventual prescrição, voluntariamente se afastasse do cargo para que o processo fosse remetido à 1ª instância às vésperas de ser julgado pelo Tribunal, o STF assentou que "após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo" (STF. Plenário. AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/5/2018).

Assim, a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais funciona como o último marco temporal da perpetuação da competência, isto é, após ele, o processo será julgado por aquele Tribunal, ainda que o agente deixe o cargo, sendo desimportante o motivo pelo qual se deu seu afastamento.

### **3.5.1.2. INFRAÇÃO PENAL PRATICADA APÓS O EXERCÍCIO FUNCIONAL**

Como dito, pela regra da contemporaneidade, somente deverão ser julgadas pelos Tribunais respectivos as infrações penais cometidas após a diplomação/investidura no cargo dotado de foro por prerrogativa de função.

Obviamente, sendo o foro por prerrogativa de função um instituto voltado ao regular desempenho das funções inerentes ao cargo, se a infração penal for praticada após a cessação de seu exercício, não há falar em julgamento por Tribunal, já que não respeitada a regra da contemporaneidade.

É nesse sentido o teor da Súmula nº 451 do STF, a qual aduz que "a competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional".

### **3.5.2. INFRAÇÃO PENAL RELACIONADA COM O EXERCÍCIO FUNCIONAL**

Além de estabelecer que a infração penal deve ser praticada durante o exercício do cargo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores passou a exigir que, para ser julgada pelo Tribunal respectivo, a infração penal cometida deve guardar relação com as funções inerentes ao cargo dotado de foro por prerrogativa de função. É dizer: se a infração penal cometida não tiver relação com as funções vinculadas ao cargo, não há falar em foro por prerrogativa de função, sendo o fato julgado pela justiça de 1ª instância, federal ou estadual, conforme o caso (STF. Plenário. AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/5/2018).

Nesse contexto, se um Deputado Federal, após a sua diplomação, cometer uma lesão corporal leve em desfavor de sua companheira, fato este totalmente estranho ao exercício de seu mandato, será julgado pela Justiça Comum Estadual, já que a infração penal por ele cometida não guarda relação com o exercício funcional.

### 3.5.2.1. MANDATOS SUCESSIVOS

Privilegiando a regra de que, para ser julgada pelo Tribunal respectivo, a infração penal cometida deve guardar relação com o exercício do cargo, o STF assentou "que o recebimento de doação ilegal destinado à campanha de reeleição ao cargo de Deputado Federal é um crime relacionado com o mandato parlamentar", competindo-lhe o julgamento de tal fato. Para além disso, decidiu o STF que se mostra "desimportante a circunstância de este delito ter sido praticado durante o mandato anterior, bastando que a atual diplomação decorra de sucessiva e ininterrupta reeleição" (STF. Plenário. Inq 4435 AgR-quarto/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13 e 14/3/2019).

Nesse contexto, excepcionando, de certa forma, a regra da contemporaneidade, o STF assentou que, caso um detentor de cargo eletivo doe ilegalmente recursos destinados à sua reeleição, tal fato deverá ser julgado pelo Tribunal respectivo, já que guarda relação com o cargo, ainda que tenha sido praticado no mandato anterior, sendo exigido, todavia, que a nova diplomação decorra de sucessiva e ininterrupta reeleição.

Logo, se um Deputado Federal, eleito nas eleições gerais de 2014, para os anos de 2015-2018, tentando a reeleição nas eleições de 2018, doe, de forma ilegal, recursos à sua campanha, caso eleito, será julgado pelo STF, já que o mandato de 2019-2022 decorre de sucessiva e ininterrupta reeleição.

### 3.5.2.2. INFRAÇÃO PENAL COMETIDA POR DESEMBARGADOR

Nos termos do art. 105, inciso I, da CF/88, compete ao STJ processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns e de responsabilidade, os Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e dos Territórios.

Interpretando tal dispositivo constitucional, assentou o STJ que, ainda que a infração penal não guarde relação com o exercício do cargo de Desembargador, compete-lhe julgar tal fato, porquanto o instituto do foro por prerrogativa de função não visa somente o regular desempenho do cargo, mas, também, tem por objetivo mitigar a influência do réu sobre o julgador, mantendo-se a credibilidade da justiça criminal (QO na APn 878/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/11/2018, DJe 19/12/2018).

Nesse sentido, caso um Desembargador cometa o crime de embriaguez ao volante, fato este que em nada se relaciona com o cargo, competirá ao STJ processar e julgá-lo, porquanto não se mostra crível, na visão do próprio STJ, que um juiz de 1ª instância julgue um Desembargador, porquanto não reuniria as condições necessárias ao desempenho de suas atividades judicantes de forma imparcial.

### 3.5.3. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO

Com o viés de restringir o instituto do foro por prerrogativa de função, assentou o STF que "é inconstitucional dispositivo da Constituição Estadual que confere foro por prerrogativa de função, no Tribunal de Justiça, para Procuradores do Estado, Procuradores da ALE, Defensores Públicos e Delegados de Polícia" (STF. Plenário. ADI 2553/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 15/5/2019; grifos nossos).

### 3.5.4. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA

Tema de extrema relevância para as provas de concurso diz respeito aos crimes dolosos contra a vida, já que a competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme o caso, poderá afastar a regra do foro por prerrogativa de função.

Quanto ao ponto, a Súmula Vinculante nº 45 do STF, que tem redação idêntica à antiga Súmula nº 721 do próprio STF, é bastante clara ao dizer que "a competência constitucional do



Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual".

Assim, duas situações diametralmente opostas emergem da interpretação da referida súmula vinculante, porquanto o tratamento dado ao foro por prerrogativa de função trazido pela própria Constituição Federal não é o mesmo daquele previsto exclusivamente na Constituição Estadual.

Nesse contexto, se o foro por prerrogativa de função estiver previsto exclusivamente na Constituição Estadual, como ocorre, por exemplo, com os Secretários de Estado, caso estes cometam crimes dolosos contra a vida, deverão ser julgados pelo Tribunal do Júri e não pelo Tribunal indicado pela Constituição Estadual. É dizer: estando a regra do Tribunal do Júri inserta na Constituição Federal (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d), esta não pode ser afastada por uma norma prevista apenas na Constituição Estadual, razão pela qual tal agente não será julgado pelo Tribunal indicado na Constituição Estadual, mas, sim, pelo Tribunal do Júri, porquanto a competência deste emana diretamente da Carta Magna.

Noutro giro, se o foro por prerrogativa de função estiver previsto na própria Constituição Federal, mostra-se possível que a competência do Tribunal do Júri seja afastada, já que uma norma inserta na própria Constituição Federal tem aptidão para excepcionar outra regra lá prevista. É dizer: estando o foro por prerrogativa de função e o Tribunal do Júri previstos na Constituição Federal, deve a norma atinente ao foro por prerrogativa de função prevalecer sobre o regramento inerente ao Tribunal do Júri, caso o crime doloso contra a vida tenha relação com as funções do cargo e for praticado durante o seu exercício (LIMA, 2020, p. 572).

Logo, se um Deputado Federal, durante o exercício do mandato e em razão de suas funções, praticar um crime doloso contra a vida, deverá ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso I, alínea b, da CF/88, e não pelo Tribunal do Júri.

Assim, interpretando-se a Súmula Vinculante nº 45 do STF em conjunto com as regras da contemporaneidade e da necessária relação da infração penal com as funções inerentes ao cargo exercido, temos o seguinte panorama:

**a) FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO PREVISTO EXCLUSIVAMENTE NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA:** o fato deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri e não pelo Tribunal indicado pela Constituição Estadual;

**b) FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA ANTES OU DEPOIS DO EXERCÍCIO FUNCIONAL:** o fato deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri e não pelo Tribunal indicado pela Constituição Federal;

**c) FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA SEM RELAÇÃO COM AS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO, MESMO QUE COMETIDO DURANTE O EXERCÍCIO FUNCIONAL:** o fato deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri e não pelo Tribunal indicado pela Constituição Federal;

**d) FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DURANTE O EXERCÍCIO FUNCIONAL E EM RAZÃO DAS FUNÇÕES:** o fato deverá ser julgado pelo Tribunal indicado pela Constituição Federal e não pelo Tribunal do Júri.

Por fim, convém ressaltar que, conforme visto, no caso dos Desembargadores, o STJ dispensa o requisito da relação da infração penal com o exercício funcional, o que nos leva a concluir que, caso um Desembargador cometa um crime doloso contra a vida, ainda que sem relação com o cargo, deverá ser julgado pelo STJ, nos termos do art. 105, inciso I, da CF/88.

### 3.5.5. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO E LOCAL DA INFRAÇÃO

Conforme será estudado com mais detalhes adiante, nos termos do art. 70, *caput*, do CPP, em regra, a competência territorial é determinada pelo local da consumação delitiva. Se o crime



não se consumou, a regra é que a competência territorial seja determinada pelo local do último ato de execução.

Todavia, no caso de foro por prerrogativa de função, pouco importa a regra inserta no art. 70, *caput*, do CPP, mesmo que a infração penal tenha se consumado em território sujeito à competência de outro Tribunal.

Assim, se um juiz vinculado ao Tribunal de Justiça de Pernambuco cometer um crime de furto na cidade de Ipameri/GO, deverá o magistrado ser julgado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco e não pelo Tribunal de Justiça de Goiás.

### 3.5.6. EXCEÇÃO DA VERDADE

De acordo com o art. 85 do CPP, a exceção da verdade oposta contra detentor de foro por prerrogativa de função deverá ser julgada pelo Tribunal respectivo, porquanto, em última análise, poderá resultar na persecução criminal daquele agente.

Imagine a seguinte situação hipotética: Desembargador João ingressa com uma queixa-crime em desfavor de José, que não detém foro por prerrogativa de função, imputando-lhe a prática do crime de calúnia, nos termos do artigo 138, *caput*, do CP. Tal queixa-crime deverá ser ajuizada perante o Juizado Especial Criminal, já que se trata de infração penal de menor potencial ofensivo, porquanto a pena privativa de liberdade não ultrapassa o patamar de 2 (dois) anos, ainda que haja a pena cumulativa de multa. É dizer: o fato de o Desembargador figurar como querelante, isto é, no polo ativo da ação, não atrai, por si só, o foro por prerrogativa de função.

Todavia, se José ingressar com a exceção da verdade, isto é, intentar provar que aquele fato definido como crime, que ele havia imputado ao Desembargador, realmente aconteceu, ou seja, não é falso, a exceção da verdade, nesse caso, deverá ser julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo foro por prerrogativa de função dos desembargadores, nos termos do art. 105, inciso I, da CF/88.

Percebam o raciocínio: José estava respondendo um processo criminal pelo crime de calúnia, que, nos termos do art. 138, *caput*, do CP, consiste em imputar falsamente a outrem fato definido como crime. José deseja, através da exceção da verdade, provar que sua imputação não é falsa, isto é, que o Desembargador João cometeu aquele fato definido como crime. Em outras palavras, é como se José estivesse "acusando" o Desembargador João de ter cometido um crime, logo, a exceção da verdade deverá ser julgada pelo foro por prerrogativa de função, já que, caso seja julgada procedente, isto é, caso o Tribunal entenda que o Desembargador cometeu aquele fato definido como crime, deverá ser responsabilizado criminalmente.

Não se pode confundir, entretanto, o julgamento da exceção da verdade com o seu juízo de admissibilidade e instrução. Como visto, o julgamento da exceção da verdade interposta em desfavor de detentor de foro por prerrogativa de função compete ao Tribunal respectivo. Todavia, o juízo de admissibilidade da exceção e sua instrução são de competência das instâncias ordinárias. É dizer: após admitir a exceção da verdade e instruí-la, a instância ordinária encaminha a exceção da verdade para o Tribunal responsável por seu julgamento (HC 311.623/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 17/3/2015).

### 3.6. COMPETÊNCIA DE FORO E COMPETÊNCIA DE JUÍZO

Depois de verificada qual é a Justiça competente para o processo e julgamento da infração penal cometida, isto é, se deverá ser julgada pela Justiça Militar, Eleitoral, Federal ou Estadual, além de perquirir se é caso de julgamento originário por Tribunal, é necessário averiguar qual o foro e qual o juízo competentes para o julgamento do fato, o que se faz com base nas regras estatuídas pelo próprio CPP.

De acordo com o art. 69 do Código de Processo Penal, a competência será determinada pelos seguintes critérios: "I - o lugar da infração; II - o domicílio ou residência do réu; III - a natureza

da infração; IV - a distribuição; V - a conexão ou continência; VI - a prevenção; VII - a prerrogativa de função.”

### 3.6.1. LUGAR DA INFRAÇÃO

Adotando a denominada teoria do resultado, o artigo 70, *caput*, do CPP, aduz que a competência territorial, que é do tipo relativa, será, em regra, determinada pelo local em que ocorrer a consumação delitiva, sendo desimportante, a princípio, o local em que a conduta foi praticada e, muito menos, o local em que ocorrer o exaurimento de seus efeitos.

Detalhe importante é que o critério adotado pelo artigo 70, *caput*, do CPP, diz respeito aos crimes cometidos integralmente dentro do território brasileiro, não podendo tal regra ser confundida com aquela inserta no art. 6º do CP, que disciplina os chamados crimes à distância, isto é, os crimes em que a conduta e a consumação ocorrem em território de dois países distintos.

Nesse contexto, adotando a chamada teoria da ubiquidade, o citado art. 6º do CP, ao disciplinar o lugar do crime, diz que se considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, o que tem por objetivo preservar a soberania brasileira para processar e julgar o fato, desde que uma parte da infração penal tenha sido perpetrada em território nacional (LIMA, 2020, p. 601).

Assim, caso a infração penal tenha sido integralmente praticada no território nacional, o foro competente será determinado, em regra, pelo local em que ocorrer a consumação delitiva, que se opera quando se reúnem todos os elementos da definição legal de determinado crime, nos termos do art. 14, inciso I, do CP.

Noutro giro, conforme a parte final do art. 70, *caput*, do CPP, no caso de tentativa, a competência territorial é determinada pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, devendo se ter bastante atenção quanto ao ponto, já que, muitas das vezes, em provas de concurso, o examinador aduz que a competência será determinada, no caso da tentativa, pelo local do primeiro ato de execução, o que não é verdade.

Nesse contexto, nos termos do art. 14, inciso II, do CP, caso a execução do crime tenha sido iniciada e, por razões alheias à vontade do agente, o delito não se consume, devemos olhar, para fins de determinação de competência, para o local em que o agente praticou o último ato executório, já que lá será o foro competente para processar e julgar esse crime tentado.

#### 3.6.1.1. CASUÍSTICAS IMPORTANTES

##### 3.6.1.1.1. CHEQUE SEM FUNDO

A consumação do crime de estelionato mediante a emissão de cheque sem fundo, inserto no art. 171, §2º, inciso VI, do CP, se dá no local em que ocorrer a recusa do pagamento, isto é, onde está localizada "a agência bancária que não quis pagar o cheque". Assim, se João, cuja agência bancária fica situada na cidade de Belo Horizonte/MG, compra, mediante a emissão de cheque sem fundo, um computador em São Paulo/SP, tal fato deverá ser julgado pelo foro da Comarca de Belo Horizonte/MG. Tal entendimento está sedimentado nas Súmulas nº 521 do STF e nº 244 do STJ (LIMA, 2020, p. 609).

##### 3.6.1.1.2. CHEQUE FALSO

Situação diametralmente oposta à descrita no item anterior diz respeito ao estelionato mediante a emissão de cheque falso, cuja tipicidade se extrai do próprio art. 171, *caput*, do CP, já que, nesse caso, a competência será determinada pelo local em que se der a obtenção da vantagem ilícita, nos termos da Súmula nº 48 do STJ.

Nesse contexto, valendo-se do mesmo exemplo do item anterior, se João, mediante a emissão de cheque falso, compra um computador em São Paulo/SP, tal fato deverá ser julgado pela justiça da capital paulista, porquanto lá se deu a obtenção da vantagem ilícita.

#### 3.6.1.1.3. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA POR MEIO DA INTERNET

A competência para processar e julgar o crime de furto qualificado pela fraude eletrônica por meio da internet, inserto no art. 155, §4º, inciso II, do CP, é determinada pelo lugar em que está localizada a agência bancária da qual os valores foram subtraídos, sendo desimportante o local em que se encontre o autor do fato criminoso (LIMA, 2020, p. 610).

Portanto, se João, estando na cidade de Recife/PE, após obter fraudulentamente a senha bancária de outrem, subtrai para si valores depositados na conta corrente de José, cuja agência bancária está situada na cidade de Porto Alegre/RS, competirá à justiça da capital gaúcha processar e julgar o fato.

#### 3.6.1.1.4. CONTRABANDO OU DESCAMINHO

Nos termos da Súmula nº 151 do STJ, "a competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal do lugar da apreensão dos bens".

Conforme estudado em capítulo próprio, ainda que inexistentes indícios de transnacionalidade da conduta, compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes de contrabando e descaminho, sendo a competência de foro determinada pelo lugar em que se der a apreensão dos bens, sendo desimportante o local pelo qual os produtos tenham ingressado no território brasileiro.

Desse modo, ainda que os bens tenham ingressado no Brasil pela cidade de Foz do Iguaçu/PR, caso tenham sido apreendidos na cidade de São Paulo/SP, competirá à Justiça Federal da capital paulista processar e julgar o fato (LIMA, 2020, p. 611).

#### 3.6.1.2. CRIMES PLURILOCAIS

Crimes plurilocais são aqueles em que a ação ou omissão ocorre em um determinado local, e o resultado em lugar distinto, ambos dentro do território nacional. Isto é, a conduta é perpetrada em determinado lugar do território brasileiro e o resultado é atingido em outro local, também do território nacional.

Como dito, pela regra geral do art. 70, *caput*, do CPP, o foro competente deveria ser determinado pelo local da consumação delitiva, isto é, para fins de determinação de competência, a princípio, não deveria ser importante o local da conduta.

Todavia, mormente no caso de crimes contra a vida, em uma verdadeira interpretação *contra legem*, a jurisprudência tem adotado a chamada teoria do esboço do resultado, que tem sido alvo de recentes questionamentos em provas concursais.

De acordo com a teoria do esboço do resultado, no caso dos crimes plurilocais, a competência não será determinada pelo local da consumação delitiva, mas, sim, pelo lugar em que a conduta foi perpetrada, isto é, onde se deu a ação ou omissão.

Assim, pela teoria do esboço do resultado, caso João desfira três disparos de arma de fogo em desfavor de José, na cidade de Formosa/GO e a vítima, socorrida pelo Corpo de Bombeiros daquele Estado, faleça em hospital de Brasília/DF, a competência para processar e julgar tal fato não será determinada pelo local da consumação (Brasília/DF), mas, sim, pelo local em que se passou a conduta delitiva (Formosa/GO).

Para os adeptos dessa teoria, que é aceita pela jurisprudência pátria tanto para o homicídio doloso como para o culposos, o processo e o julgamento do fato perante o foro do local da conduta melhor atende à busca da verdade real, porquanto otimiza a produção de provas, já que as

"testemunhas não são obrigadas a se deslocar a outra comarca para que sejam ouvidas". Além do mais, melhor atende ao "caráter intimidatório geral" da pena, já que, no local da conduta, o criminoso é punido "para sinalizar à sociedade o mal que pode advir da prática do delito" (LIMA, 2020, p. 604).

### 3.6.1.3. CRIMES À DISTÂNCIA

Crimes à distância são "aqueles que têm a sua execução iniciada em um determinado país e a sua consumação em outro" (AVENA, 2017, p. 457), sendo a eles aplicáveis, em um primeiro momento, as normativas trazidas pelos §§1º e 2º, do art. 70, do CPP.

De acordo com o art. 70, §1º, do CPP, se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumir fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução. Tal regramento se harmoniza com o art. 6º, primeira parte, do CP, porquanto, conforme este último dispositivo legal, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte.

Assim, tendo a execução sido iniciada no território nacional, ainda que a consumação delitiva se dê fora dele, a competência é da justiça brasileira, devendo o fato ser processado e julgado perante o foro do local do último ato de execução.

Conforme art. 70, §2º, do CPP, quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Tal regramento se harmoniza com a regra estatuída pelo art. 6º, segunda parte, do CP, porquanto, conforme este último dispositivo legal, considera-se praticado o crime no local onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

Portanto, tendo a conduta sido praticada fora do território nacional e a consumação ocorrido no território brasileiro, a justiça brasileira será competente para julgar tal fato, devendo o processo correr perante o foro do território brasileiro onde, embora parcialmente, tenha se produzido o resultado. De igual forma, sendo a conduta praticada fora do território brasileiro, mas visando ser consumada em nosso território, isto é, se a conduta deveria produzir o seu resultado aqui no Brasil, a justiça brasileira será competente para julgar aquele fato, devendo o processo **correr** perante o foro do local em que, embora parcialmente, a conduta deveria produzir seus regulares efeitos.

### 3.6.1.4. CRIMES COMETIDOS NA DIVISA DE LOCALIDADES SUJEITAS A JURISDIÇÕES DISTINTAS

De acordo com o art. 70, §3º, do CPP, quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.

Quanto ao referido dispositivo legal, note-se que não há dúvidas quanto ao local da consumação delitiva, isto é, geograficamente, é possível se determinar onde ocorreu a consumação do crime. Assim, a dúvida, no caso do art. 70, §3º, do CPP, não se dá em relação ao local em que se verificou a consumação delitiva, o que o difere da situação prevista no art. 72 do CPP, porquanto lá a incerteza diz respeito ao próprio lugar da infração.

No caso do art. 70, §3º, do CPP, mesmo sabendo o lugar da infração, não se consegue determinar a qual comarca aquele local é vinculado, seja porque é incerto o limite territorial entre duas ou mais comarcas. Isto é, não se sabe, ao certo, onde termina a competência de uma comarca e onde começa a outra; ou seja, porque a infração penal se consumou ou foi tentada nas divisas entre duas ou mais comarcas, não podendo se determinar, com exatidão, qual a comarca competente para processar e julgar o fato, o que será determinado pela prevenção.

Assim, ocorrendo a situação narrada pelo art. 70, §3º, do CPP, a competência territorial será determinada pela prevenção, isto é, nos termos do art. 83 do mesmo Código, será competente o juízo que tiver se antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa.

### 3.6.1.5. INFRAÇÃO CONTINUADA OU PERMANENTE

Nos termos do art. 71 do CPP, tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.

Infração penal do tipo continuada é verificada quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, nos termos do art. 71, *caput*, do CP.

Por sua vez, infração penal do tipo permanente é aquela cuja consumação se protraí no tempo, como ocorre nos clássicos exemplos dos crimes de sequestro, cárcere privado ou extorsão mediante sequestro. Nesses casos, enquanto a vítima estiver privada de sua liberdade ou com sua liberdade restringida, o crime estará se consumando.

Nesse contexto, se a infração penal do tipo continuada ou permanente for praticada em território de duas ou mais comarcas, qualquer delas é competente para julgar o fato, sendo a competência determinada pela prevenção, nos termos do art. 83 do CPP.

Exemplo bastante recorrente nas provas concursais diz respeito aos crimes de sequestro, cárcere privado ou extorsão mediante sequestro, em que a vítima é cooptada em determinado local, permanece, por um período, em cativeiro localizado em uma primeira cidade, depois vai para outro cativeiro, localizado em outra cidade, até ser libertada pela polícia.

Nesse caso, qualquer dessas comarcas é competente para processar e julgar o fato, sendo a competência determinada pela prevenção. Isto é, nos termos do art. 83 do CPP, será competente o juízo que tiver se antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa.

### 3.6.2. DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO DOMICÍLIO OU PELA RESIDÊNCIA DO RÉU

#### 3.6.2.1. IGNORÂNCIA QUANTO AO LUGAR DA INFRAÇÃO

De acordo com o art. 72, *caput*, do CPP, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou pela residência do réu, o que é chamado pela doutrina de foro supletivo ou subsidiário.

Assim, não se conhecendo o lugar da infração penal, isto é, não sendo possível, geograficamente, determinar-se onde a infração penal se consumou, estabelece o CPP que a competência será determinada, a princípio, pelo domicílio ou pela residência do réu. Apesar de simples tal regramento, em algumas provas concursais, o examinador traz assertivas nas quais expõe que, caso não se conheça o lugar da infração, a competência será determinada pelo domicílio ou pela residência da vítima, o que não é correto.

Nos termos do art. 72, §1º, do CPP, se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção. Desse modo, não se conhecendo o lugar da infração, a competência será determinada pelo local do único domicílio ou residência do réu.

Todavia, se o réu possuir mais de um domicílio ou mais de uma residência, a competência é determinada pela prevenção, isto é, nos termos do art. 83 do CPP, será competente o juízo que tiver se antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa.

Conforme art. 72, §2º, do CPP, se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato.

Interpretando a expressão "juiz que primeiro tomar conhecimento do fato", a doutrina tem entendido que ela se equivale à prevenção, isto é, caso o réu não tenha residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente "o juiz que primeiro decidir a respeito do fato" (MARCÃO, 2016, p. 235).





### 3.6.2.2. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA

Dispõe o art. 73 do CPP que, nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração, o que é denominado pela doutrina de foro por eleição no processo penal.

O primeiro cuidado atinente ao art. 73 do CPP diz respeito à sua inaplicabilidade em relação à ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, isto é, a expressão "nos casos de exclusiva ação privada" deve ser interpretada no sentido de que somente há falar em foro de eleição no caso de ação penal privada exclusiva ou personalíssima.

Outro detalhe importante está atrelado ao fato de que o foro de eleição se aplica independentemente de ser conhecido o lugar da infração. É dizer: se o fato for processável por intermédio de ação penal privada exclusiva ou personalíssima, ainda que seja conhecido o lugar da infração, o querelante poderá optar pelo foro de domicílio ou de residência do réu.

Por fim, convém lembrar que o querelante (vítima) somente poderá optar pelo foro de domicílio ou de residência do réu e não pelo foro de seu próprio domicílio ou residência, o que não é incomum de ser questionado nas provas concursais.

### 3.6.3. NATUREZA DA INFRAÇÃO PENAL

Após ser firmada a competência em razão matéria, isto é, *ratione materiae* (Justiça Militar, Eleitoral ou Comum) e depois de definido o foro competente, ou seja, o local em que a infração penal deverá ser julgada, é necessário estabelecer, dentro daquela comarca, qual é o juízo competente para o processo e o julgamento do feito (AVENA, 2017, p. 264-265).

Conforme art. 74, *caput*, do CPP, a competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

Desse modo, serão as leis de organização judiciária de cada ente da Federação que definirão, por exemplo, "dentre os vários juízes criminais de uma determinada Comarca, qual deles detém competência para julgar este ou aquele delito". Tal definição poderá ser fixada com base na "espécie de pena (reclusão, detenção, prisão simples), do tipo de infração (crime ou contravenção), da espécie delituosa (crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual etc.) e qualquer outro critério" (AVENA, 2017, p. 265).

Importante lembrar que o próprio *caput* do art. 74 do CPP faz ressalva ao Tribunal do Júri, porquanto sua competência se origina da própria Constituição Federal, a qual, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea *d*, determina que compete ao Tribunal do Júri processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, o que, aliás, é esmiuçado pelo art. 74, §1º, do CPP.

Ainda em relação ao Tribunal do Júri, registre-se que sua competência pode ser ampliada, isto é, o legislador ordinário não poderá retirar do Tribunal do Júri a competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, contudo, poderá prever que outros crimes, distintos dos dolosos contra a vida, sejam julgados pelo Tribunal do Júri (NUCCI, 2016, p. 196).

Outro detalhe importante diz respeito ao fato de que as leis de organização judiciária locais poderão prever que a primeira fase do rito bifásico do Tribunal do Júri seja processada perante outro juízo que não a própria Vara do Tribunal do Júri. Isto é, afigura-se possível, por exemplo, que a primeira fase do rito bifásico tramite perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Após a preclusão de eventual decisão de pronúncia, nos termos do art. 421, *caput*, do CPP, o processo deverá ser encaminhado ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri (HC 102.150/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 27/5/2014).

De acordo com o art. 74, §2º, primeira parte, do CPP, se, iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração da competência de outro, a este será remetido o processo. Imagine o seguinte exemplo: João foi denunciado pelo cometimento do crime de lesão corporal de natureza grave, cuja pena é de reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos (art. 129, §1º, do CP). Após a instrução, o juiz da 1ª Vara Criminal de Brasília/DF verifica que não há subsídio probatório para demonstrar a ocorrência de lesão corporal de natureza grave, desclassificando o fato para o crime de



lesão corporal leve, cuja pena é de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano (art. 129, *caput*, do CP). Nesse caso, deverá o juiz remeter o processo a um dos Juizados Especiais Criminais da circunscrição judiciária de Brasília/DF, a fim de que lá seja verificada a possibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e, não sendo possível, para que o juiz do Juizado Especial Criminal sentencie o caso, condenando ou absolvendo o réu (AVENA, 2017, 465).

Conforme o art. 74, §2º, segunda parte, do CPP, que traz uma regra de prorrogação de competência, se o juízo perante o qual o processo teve início for de jurisdição "mais graduada" que o juízo ao qual o processo deveria ser remitido, não haverá o encaminhamento dos autos a esse segundo juízo, prorrogando-se a competência do primeiro.

Atualmente, tal dispositivo legal carece de aplicabilidade, já que a competência da jurisdição "mais graduada", isto é, dos Tribunais, é fixada de acordo com as regras do foro por prerrogativa de função e não pela natureza da infração cometida. É dizer: atualmente, a jurisdição "mais graduada" que os juízes de primeira instância é representada pelos Tribunais e não existe a possibilidade de determinada lei de organização judiciária estabelecer, por exemplo, que o crime de lesão corporal grave seja julgado, de forma originária, pelo Tribunal, e o crime de lesão corporal leve seja julgado pelo juiz de primeira instância.

A regra estatuída pelo art. 74, §2º, segunda parte, do CPP, somente fazia sentido quando havia, em nosso ordenamento jurídico, juízes hierarquicamente inferiores aos juízes de Direito. Nesses casos, se o processo teve início perante os juízes de Direito e, durante o seu desenrolar, houve a desclassificação para crime de competência desses juízes hierarquicamente inferiores aos juízes de Direito, os autos não seriam a eles remetidos, mantendo-se a competência dos juízes de Direito para julgar o fato (NUCCI, 2016, p. 200).

Trazendo regra específica quanto ao rito bifásico do Tribunal do Júri, o art. 74, §3º, primeira parte, do CPP, disciplina que, se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á o disposto no art. 410 do mesmo Código. Atualmente, o art. 410, citado pelo art. 74, §3º, deve ser lido como art. 419, *caput*, do CPP.

Desse modo, se o juízo perante o qual tramitou a primeira fase do rito bifásico do Tribunal do Júri, ao final do denominado *judicium accusationis*, entender que não se trata de crime doloso contra a vida, deverá remeter os autos ao juízo competente. Esta decisão é passível de impugnação por intermédio do recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, inciso II, do CPP, porquanto se trata de decisão que concluiu pela incompetência do juízo.

Lado outro, o art. 74, §3º, segunda parte, do CPP, normatiza que, se a desclassificação for feita pelo próprio Tribunal do Júri, isto é, pelos próprios Jurados, caberá ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri proferir a sentença, nos termos do art. 492, §2º, do mesmo Código. Atualmente, o art. 492, §2º, citado pelo art. 74, §3º, deve ser lido como art. 492, §1º, do CPP.

Assim, se os Jurados entenderem que não se trata de crime doloso contra a vida, os autos não serão remetidos ao juízo abstratamente competente. Nessa hipótese, o próprio Juiz Presidente do Tribunal do Júri sentenciará o feito, aplicando, se for o caso, os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95.

### 3.6.4. COMPETÊNCIA POR DISTRIBUIÇÃO

A fixação de competência por distribuição ocorre quando, dentro de um mesmo foro, isto é, depois de descoberta a competência territorial, houver mais de uma vara criminal igualmente competente. É dizer: a competência por distribuição não se destina à definição do foro competente, mas, sim, do juízo perante o qual o feito deverá tramitar, sendo este critério adotado após a descoberta da comarca na qual o processo deverá ser julgado.

A título de exemplo, na circunscrição judiciária de Brasília/DF, há 8 (oito) varas criminais, todas com igual competência. Assim, definido que o fato criminoso deve ser julgado em Brasília/DF, ele deverá ser distribuído a uma dessas 8 (oito) varas, já que todas são igualmente competentes para processar e julgar fatos criminosos ocorridos na Capital Federal.

Na forma do art. 75, *caput*, do CPP, que deve ser lido à luz do art. 285, *caput*, do CPC, a distribuição, isto é, o sorteio dos processos para cada juízo igualmente competente, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade.

De acordo com o art. 75, parágrafo único, do CPP, a distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal.

Desse modo, se, antes do início da ação penal, já houve a distribuição, isto é, os autos já foram sorteados para um dos juízos, não haverá novo sorteio por ocasião do oferecimento da peça acusatória, porquanto o juízo inicialmente sorteado estará prevento.

Em relação ao citado art. 75, parágrafo único, do CPP, tem-se que, com o estabelecimento do juiz das garantias, dificilmente o juízo criminal comum restará prevento, já que, nos termos do art. 3º-B e seguintes do CPP, compete ao juiz das garantias a análise de diligências que outrora eram decididas pelo juízo criminal comum.

Nesse sentido, caso o juiz das garantias seja, de fato, implementado em nosso ordenamento<sup>8</sup>, a ele competirá, por exemplo, decidir sobre o requerimento de prisão preventiva formulado durante a investigação, nos termos do art. 3º-B, inciso V, do CPP. Outrora, esta diligência tornava o juízo criminal comum prevento, o que impedia, quando do oferecimento da peça acusatória correlata, nova distribuição, porquanto o juízo sorteado para a análise do pedido de prisão já estava prevento para a ação penal.

### 3.6.5. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO

Nos termos do art. 83 do CPP, a competência por prevenção é verificada toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa.

Assim, em uma primeira análise, prevenção nada mais é do que uma regra de fixação de competência na qual um juízo se torna competente para o processo e julgamento de determinada ação penal, porquanto se antecipou aos demais na prática de ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que essa "antecipação" tenha ocorrido em momento anterior ao oferecimento da peça acusatória.

Por juízes igualmente competentes entendem-se aqueles que possuem a mesma competência, tanto em razão da matéria quanto em razão do lugar, como ocorre, por exemplo, no caso de juízes que oficiam na mesma comarca, com idêntica competência, sendo a competência de cada um deles, via de regra, determinada por distribuição (AVENA, 2017, p. 463).

Em contrapartida, juízes com jurisdição cumulativa são os que, embora aptos a julgar a mesma matéria, oficiam em foros diferentes, como ocorre, por exemplo, no caso de juízes criminais de comarcas vizinhas (AVENA, 2017, p. 463).

Como se depreende do citado artigo, se um dos juízos tiver se antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da peça acusatória, este se tornará prevento para a futura ação penal, isto é, este juízo deverá processar e julgar a eventual ação penal que se originar daqueles fatos.

Nesse contexto, a fim de que essa diligência anterior ao oferecimento da exordial acusatória fixe a competência por prevenção, duas condições devem ser verificadas no caso concreto (LIMA, 2020, p. 634-635):

a) existência de prévia distribuição: o art. 83 do CPP deve ser compreendido em conjunto com o art. 75, parágrafo único, do mesmo Código, ou seja, só se pode cogitar de prevenção

---

<sup>8</sup>Até o fechamento desta obra, os arts. 3º-A a 3º-F do CPP estavam com a eficácia suspensa (STF, ADI 6.299 MC/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/2/2020).

da competência quando a decisão, que a determinaria, tenha sido precedida de distribuição, por isso que não previnem a competência decisões de juiz de plantão, nem as facultadas, em caso de urgência, a qualquer dos juízes criminais do foro. A título exemplificativo: fora do expediente judiciário, isto é, em período no qual não havia expediente no setor responsável pela distribuição dos feitos, em comarca com 4 (quatro) juízes criminais igualmente competentes, um juízo adota uma medida urgente que lhe fora requerida. Nessa hipótese, este juízo não se torna preventivo, porquanto sua anterior decisão foi adotada em caso de urgência; e

b) deve a medida ou diligência apresentar o mesmo caráter cautelar ou contra cautelar encontrado nas hipóteses exemplificadas na regra contida no parágrafo único do art. 75 do CPP. Vejamos alguns exemplos de diligências que previnem o juízo: b.1) concessão de fiança (arts. 321 a 350); b.2) conversão da prisão em flagrante em preventiva ou temporária (CPP, art. 310, II); b.3) decretação de prisão preventiva (arts. 311 a 316 do CPP) ou de prisão temporária (Lei nº 7.960/89); b.4) pedidos de medidas assecuratórias dos arts. 125 a 144 do CPP; b.5) pedidos de provas, como expedição de mandado de busca e apreensão, interceptação telefônica ou quebra de sigilo bancário; e b.6) manifestação do juízo acerca da regularidade da prisão em flagrante delito, quando comunicado nos termos do art. 5º, inciso LXII, da Carta Magna.

Nesse sentido, não tornam o juízo preventivo (LIMA, 2020, p. 636):

a) *habeas corpus* em primeiro grau (v.g., quando um *habeas corpus* é impetrado contra ato de um delegado), por se tratar de matéria especificamente constitucional;

b) quando o juiz remete cópia dos autos ao MP (art. 40 do CPP);

c) atos do juiz de plantão não tomam o juízo preventivo — após o fim do plantão, o processo deve ser objeto de distribuição; e

d) a simples antecedência de distribuição de inquérito policial, ou mesmo de ação penal ainda não despachada, também não gera a prevenção do juízo, por não conterem nenhuma atuação jurisdicional.

Superada a questão do juízo que se antecedeu aos demais, tem-se que a prevenção também funciona como critério subsidiário de fixação de competência, ora estabelecendo o foro competente, ora determinando o próprio juízo competente. Nesse sentido, quando nenhum critério é capaz de determinar a competência de um órgão jurisdicional específico, a prevenção é utilizada como critério de fixação de competência, funcionando, portanto, como norma de encerramento, evitando-se os chamados vazios de competência. É dizer: se nenhuma infração penal pode ficar sem juiz competente para julgá-la, a prevenção funciona como verdadeiro socorro em relação à fixação da competência (LIMA, 2020, p. 636).

Nesse contexto, abaixo são citadas algumas situações nas quais a prevenção funciona como critério subsidiário de fixação de competência (LIMA, 2020, p. 636-637):

a) crimes ocorridos na divisa de duas ou mais jurisdições, sendo o limite entre elas incerto ou, ainda que seja certo, não se saiba precisar exatamente o sítio do delito ou, também, quando a infração atingiu mais de uma jurisdição (art. 70, §3º);

b) crimes continuados ou permanentes, cuja execução se prolonga no tempo, podem atingir o território de mais de uma jurisdição (art. 71). Tanto o crime continuado quanto o crime permanente podem se desenvolver em lugares diferentes, sendo possível que o agente ultrapasse os limites territoriais de uma comarca, atingindo a esfera de competência de outros magistrados. Nesse caso, como a execução abrangeu o território de várias comarcas, qualquer uma delas seria, em tese, competente para apurar a infração penal, firmando-se a competência pela regra da prevenção;

c) quando o réu não possui domicílio certo ou tiver mais de uma residência (art. 72, §1º) ou mesmo quando não for conhecido seu paradeiro (art. 72, §2º), não tendo sido a competência firmada pelo lugar da infração (art. 72, *caput*);

d) havendo mais de um juiz competente, no concurso de jurisdições, sem possibilidade de aplicação dos critérios desempataadores do art. 78, II, *a e b* (art. 78, II, *c*); e

e) tendo a infração penal ocorrido a bordo de navios e aeronaves, em águas territoriais, no espaço aéreo correspondente ao território brasileiro, em rios e lagos fronteiriços ou em alto-mar, não sendo possível determinar o local de embarque ou chegada imediatamente anteriores ou posteriores à ocorrência do crime (CPP, art. 91).

### 3.6.6. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA (CONEXÃO E CONTINÊNCIA)

A conexão e a continência são causas modificativas da competência, isto é, em razão da conexão e/ou da continência, reúnem-se perante um mesmo juízo processos que, de acordo com as demais regras de fixação de competência, poderiam ser julgados separadamente. Nesse contexto, as regras atinentes à conexão e à continência "estabelecem vínculos de atração, que permitem uma reunião processual de elementos que seriam passíveis de processos distintos, perante órgãos jurisdicionais diversos" (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 442).

Um detalhe muito importante, o qual, muitas das vezes, passa despercebido, diz respeito ao fato de que a conexão e a continência somente são capazes de gerar a modificação de regras de competência relativa, não podendo alterar regras de competência absoluta.

Nesse contexto, a conexão e a continência, que estão previstas no Código de Processo Penal, isto é, na legislação ordinária, não têm o condão de alterar regras de competência previstas na Constituição Federal, já que, sendo estas do tipo absoluta, não admitem modificações, tratando-se de competência improrrogável/imodificável (LIMA, 2020, p. 639).

Portanto, ainda que haja, por exemplo, conexão entre um crime militar e um crime eleitoral, não haverá reunião de processos, porquanto, sendo ambas as competências originadas diretamente da Constituição Federal e estabelecidas em razão da matéria, as duas devem ser respeitadas, isto é, o crime militar deverá ser apreciado pela Justiça Militar e o crime eleitoral pela Justiça Eleitoral (LIMA, 2020, p. 639).

Corroborando tal entendimento, tem-se que o art. 54 do Código de Processo Civil, aplicável ao Processo Penal por força do art. 3º do CPP, dispõe que "a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção" (LIMA, 2020, p. 639).

#### 3.6.6.1. CONEXÃO (ART. 76 DO CPP)

A conexão, prevista no art. 76 do CPP, se consubstancia na "interligação entre duas ou mais infrações, levando a que sejam apreciadas perante o mesmo órgão jurisdicional". Logo, "infrações conexas são aquelas que estão interligadas, merecendo portanto, em prol da celeridade do feito e para evitar decisões contraditórias, apreciação em processo único" (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 442).

Nesse contexto, "a conexão é o liame que se estabelece entre dois ou mais fatos que, desse modo, se tornam ligados por algum motivo, oportunizando sua reunião no mesmo processo, de modo a permitir que os fatos sejam julgados por um só juiz, com base no mesmo substrato probatório, evitando o surgimento de decisões contraditórias. Desse modo, a conexão provoca a reunião de ações penais num mesmo processo e é causa de modificação da competência (relativa) mediante a prorrogação de competência" (STF, HC 96.453/MS, 2ª T., rel. Min. Ellen Gracie, j. 28/10/2008, DJe de 14/11/2008).

Logo, só há pensar em conexão nos casos em que se verificar a prática de duas ou mais infrações penais, sendo esta uma boa dica para as provas concursais. Se a questão não fizer menção à prática de mais de uma infração penal, o candidato não poderá pensar em taxar aquela situação fática narrada de conexão, já que esta, repita-se, exige o cometimento de duas ou mais infrações penais.

A depender de determinadas situações fáticas, 3 (três) espécies de conexão podem ser verificadas: I) conexão intersubjetiva; II) conexão objetiva, lógica, material ou teleológica; e III) conexão instrumental, probatória ou processual.



### 3.6.6.1.1. CONEXÃO INTERSUBJETIVA (ART. 76, INCISO I, CPP)

A conexão intersubjetiva, obrigatoriamente, envolve a prática de várias infrações penais (mais de uma) por várias pessoas. Assim, se várias pessoas cometem uma única infração, não é caso de conexão intersubjetiva, mas, sim, de continência por cumulação subjetiva (art. 77, inciso I, do CPP). Como dito, só há falar em conexão se houver a prática de mais de uma infração penal (LIMA, 2020, p. 640).

Com efeito, pouco importa a forma como os autores se relacionaram no cometimento dos fatos criminosos, isto é, se vários sujeitos cometeram várias infrações penais, o caso é de conexão intersubjetiva. O que pode variar, a depender do relacionamento travado entre os autores, é a espécie de conexão intersubjetiva, que se subdivide em (LIMA, 2020, p. 640):

I) CONEXÃO INTERSUBJETIVA POR SIMULTANEIDADE (CONEXÃO SUBJETIVO-OBJETIVA OU CONEXÃO INTERSUBJETIVA OCASIONAL): nos termos do art. 76, inciso I, primeira parte, do CPP, ocorre quando duas ou mais infrações houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas. Assim, a conexão intersubjetiva por simultaneidade é verificada quando duas ou mais infrações são praticadas ao mesmo tempo, por diversas pessoas ocasionalmente reunidas, isto é, sem intenção de reunião, as quais se aproveitam das mesmas circunstâncias de tempo e de local. Um bom exemplo de conexão intersubjetiva por simultaneidade é o caso de um saque simultâneo a um supermercado, praticado por várias pessoas que nem se conhecem;

II) CONEXÃO INTERSUBJETIVA POR CONCURSO (OU CONCURSAL): nos termos do art. 76, inciso I, segunda parte, do CPP, ocorre quando duas ou mais infrações houverem sido praticadas por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar. Nesse caso, o que é importa é o vínculo existente entre os autores dos crimes, isto é, pouco importa se as infrações foram praticadas em dias ou locais diferentes. Assim, se três sujeitos praticam quatro roubos no intervalo de dois meses, há, entre esses quatro crimes, uma relação de conexão intersubjetiva por concurso ou concursal, devendo todos os fatos serem processados num único processo;

III) CONEXÃO INTERSUBJETIVA POR RECIPROCIDADE: nos termos do art. 76, inciso I, parte final, do CPP, ocorre quando duas ou mais infrações houverem sido praticadas por várias pessoas, umas contra as outras, como se dá, por exemplo, no caso de lesões corporais recíprocas.

No que diz respeito à conexão intersubjetiva por reciprocidade, muito cuidado deve se ter com o crime de rixa, inserto no art. 137 do Código Penal, porquanto, nesse caso, não há conexão intersubjetiva por reciprocidade. Em verdade, não há, nem mesmo, conexão, porquanto o crime é único, desaparecendo o primeiro requisito da conexão (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 442).

### 3.6.6.1.2. CONEXÃO OBJETIVA, LÓGICA OU MATERIAL (ART. 76, INCISO II, CPP)

Nos termos do art. 76, inciso II, do CPP, ocorre a conexão objetiva "na hipótese em que um os mais crimes são cometidos objetivando facilitar, ocultar, conseguir a impunidade ou a vantagem de outro ou outros delitos" (AVENA, 2017, p. 467).

Nesse contexto, a conexão objetiva, lógica ou material se subdivide em duas espécies, a saber (AVENA, 2017, p. 467):

I) CONEXÃO OBJETIVA TELEOLÓGICA OU FINALISTA (art. 76, inciso II, 1º verbo, CPP): verifica-se quando uma infração penal é praticada com o fim de facilitar o cometimento de outra. Exemplo: sujeito que, visando sequestrar uma criança, pratica lesões corporais em desfavor dos pais do menor. É dizer: o agente comete o crime visando o cometimento de outro (olhar para o futuro);

II) CONEXÃO OBJETIVA CONSEQUENCIAL (art. 76, inciso II, demais verbos, CPP): verifica-se quando uma infração penal é praticada com o fim de ocultar, conseguir a impunidade ou vantagem





de infração penal pretérita. Exemplos: ocultação de cadáver com o fim de encobrir homicídio anterior; homicídio da única testemunha com o fim de conseguir a impunidade de crime por ela presenciado; homicídio de comparsa de roubo com o fim de se apossar de todo o produto do crime anterior. É dizer: o agente comete o crime visando se livrar de outro (olhar para o passado).

### 3.6.6.1.3. CONEXÃO INSTRUMENTAL, PROBATÓRIA OU PROCESSUAL (ART. 76, INCISO III, CPP)

Nos termos do art. 76, inciso III, do CPP, ocorre a conexão instrumental, probatória ou processual quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Logo, na conexão instrumental, não há nenhuma exigência em relação à necessidade de vínculo de tempo e espaço entre as duas infrações penais. É dizer: para se verificar a conexão probatória, basta que a prova de uma infração penal tenha o condão de influir na prova de outra. Exemplo clássico: a prova do furto anterior tem o condão de influenciar na prova do crime de receptação daquele bem subtraído, já que, caso se descubra, por exemplo, que, em verdade, não houve crime anterior, desaparece a figura da receptação (LIMA, 2020, 641).

### 3.6.6.2. CONTINÊNCIA (ART. 77 DO CPP)

A continência, nos termos do art. 77, do CPP, "é o vínculo que une vários infratores a uma única infração, ou a ligação de várias infrações por decorrerem de conduta única, ou seja, resultarem do concurso formal de crimes, ocasionando a reunião de todos os elementos em processo único" (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 443 - grifos no original).

Duas espécies de continência são citadas pela doutrina (LIMA, 2020, p. 641):

I) CONTINÊNCIA POR CUMULAÇÃO SUBJETIVA OU CONTINÊNCIA SUBJETIVA (art. 77, inciso I, CPP): ocorre quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. No ponto, é muito importante destacar a diferença entre continência por cumulação subjetiva e conexão intersubjetiva. Na continência por cumulação subjetiva ou continência subjetiva, dois ou mais sujeitos são acusados por uma única infração. Na conexão intersubjetiva, duas ou pessoas são acusadas pelo cometimento de duas ou mais infrações penais. É dizer: na continência, há várias pessoas e uma única infração penal. Na conexão, há várias pessoas e várias infrações penais. Como exemplo de continência por cumulação subjetiva, cita-se o homicídio praticado por dois agentes; e

II) CONTINÊNCIA POR CUMULAÇÃO OBJETIVA (art. 77, inciso II, CPP): ocorre nas hipóteses de concurso formal de crimes (art. 70, CP), *aberratio ictus* ou erro na execução (art. 73, segunda parte, CP), e *aberratio delicti* ou resultado diverso do pretendido (art. 74, segunda parte, CP). Como sabido, o concurso formal de crimes se verifica quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, comete dois ou mais crimes. No erro na execução, será aplicada a regra do concurso formal de crimes quando o agente, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, além de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. No resultado diverso do pretendido, também será aplicada a regra do concurso formal de crimes quando o agente, por erro na execução, atingir não somente o resultado inicialmente desejado. É dizer: além de atingir o resultado que desejava, o agente também alcançou resultado diverso de sua expectativa inicial, como se dá, por exemplo, no caso do agente que, visando atingir uma vitrine de uma loja com uma pedra, acaba por também acertar um vendedor do estabelecimento comercial.

Por fim, muito importante rememorar que, no caso do crime continuado, a competência não é determinada pelas regras de conexão ou continência, mas, sim, pela prevenção, conforme visto quando da análise do art. 71 do CPP (LIMA, 2020, p. 642).



### 3.6.6.3. CONSEQUÊNCIAS DA CONEXÃO E/OU CONTINÊNCIA

Sendo identificada, no mundo dos fatos, uma relação de conexão e/ou continência, duas consequências jurídicas poderão advir (LIMA, 2020, p. 642):

I) REUNIÃO DE PROCESSOS (PROCESSO E JULGAMENTO ÚNICO —SIMULTANEUS PROCESSUS): nos termos do artigo 79, *caput*, do CPP, a conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, isto é, em regra, deverá haver um único processo para julgamento, por exemplo, de infração penais cometidas em conexão. Da mesma forma, em regra, duas pessoas que cometerem a mesma infração, isto é, em continência por cumulação subjetiva, deverão ser julgadas no mesmo processado.

No caso de conexão e/ou continência entre crimes de ação penal pública e de ação penal de iniciativa privada, haverá a formação de um litisconsórcio ativo entre o Ministério Público, titular da ação pública, e a vítima (ou seu representante legal), titular da ação penal de iniciativa privada (LIMA, 2020, p. 642).

II) FORÇA ATRATIVA (FORUM ATTRACTIONIS OU VIS ATTRACTIVA): estabelecendo-se uma relação de conexão e/ou continência, um dos juízos exercerá sobre o outro força atrativa, isto é, atrairá para si o julgamento de todos os fatos, restando, nesse sentido, prorrogada a sua competência. Isto é: em razão da conexão e/ou continência, um juízo, que era relativamente competente para julgar um determinado fato, seja pelo critério do local do resultado delitivo, último ato de execução, domicílio do réu ou distribuição, deixará de sê-lo. Exemplo: João mata José na cidade de Brasília/DF. Logo após, na cidade de Novo Gama/GO, João oculta o cadáver de José. Separadamente considerados, pelo critério do local da consumação delitiva, o homicídio deveria ser julgado em Brasília/DF e a ocultação de cadáver em Novo Gama/GO. Todavia, em razão da conexão objetiva consequential da ocultação em relação ao homicídio, ambas as infrações serão processadas e julgadas pelo Tribunal do Júri de Brasília/DF. É dizer: nesse caso, restou afastada a regra inserta no artigo 70, *caput*, do Código de Processo Penal (local do resultado), prevalecendo a regra da conexão.

#### 3.6.6.3.1. AVOCATÓRIA

Conforme a primeira parte do artigo 82 do CPP, caso seja verificada uma relação de conexão e/ou continência entre os fatos, e, ainda assim, tenham sido instaurados processos distintos, o juízo prevalente deverá avocar os fatos que corram em outros juízos, fazendo com que todos eles sejam reunidos em um único processado.

Todavia, nos termos da segunda parte do artigo 82 do CPP, se já houve "sentença definitiva" em relação a um dos fatos, não haverá a reunião de processos perante o juízo prevalente. Nesse caso, a unidade de processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação de penas, nos termos da parte final do citado artigo. No mesmo sentido, é o teor da Súmula nº 235 do STJ, a qual aduz que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

Importante assentar que o termo "sentença definitiva" não se refere à sentença com trânsito em julgado, mas, sim, à decisão de mérito recorrível, a qual, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, desafia apelação (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 449).

Desse modo, ainda que haja relação de conexão e/ou continência entre os fatos, se os processos correram em juízos distintos e um deles já foi sentenciado, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado, não ocorrerá a reunião de processos. Nesse caso, após o trânsito em julgado de todas as sentenças, competirá ao juízo da execução penal somar (curso material ou formal impróprio) ou unificar as penas (curso formal próprio e crime continuado), nos termos do artigo 66, inciso III, alínea *a*, da Lei de Execução Penal (LIMA, 2020, p. 642-643).

#### 3.6.6.4. JUÍZO PREVALENTE

Como visto, a conexão e/ou a continência, em regra, fazem com que os processos sejam reunidos perante um único juízo, que é chamado de juízo prevalente. Nasce, pois, a necessidade de se identificar qual é o juízo prevalente.

##### 3.6.6.4.1. TRIBUNAL DO JÚRI

A primeira regra atinente ao juízo prevalente é trazida pelo art. 78, inciso I, do CPP, segundo o qual, no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri.

Assim, havendo conexão e/ou continência entre fatos de competência do Tribunal do Júri e de competência relativa de outro órgão da jurisdição comum, o Tribunal do Júri exercerá força atrativa, devendo lá ocorrer o julgamento de todos os fatos.

Importante destacar que, no caso do Júri, pouco importa qual a pena mais grave, isto é, se a do crime doloso contra a vida ou se a do crime comum. De igual forma, também não importa o número de infrações penais cometidas, ou seja, se foram cometidos mais crimes dolosos contra a vida ou crimes comuns. É dizer: se um dos fatos é um crime doloso contra a vida, todos os demais, que tiverem relação de conexão e/ou continência com aquele, deverão ser julgados pelo Tribunal do Júri.

##### 3.6.6.4.2. CONCURSO DE JURISDIÇÕES DA MESMA CATEGORIA

Se as jurisdições forem da mesma categoria, isto é, não houver hierarquia entre elas e não estiverem envolvidos fatos de competência do Tribunal do Júri, a primeira regra é extraída do art. 78, inciso II, alínea *a*, do CPP, segundo a qual, no concurso de jurisdições da mesma categoria, preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave.

Desse modo, pouco importando a quantidade de infrações cometidas, se, perante um determinado juízo, foi cometida uma infração mais grave, nele deverão correr todos os processos, porquanto este é o juízo prevalente. Exemplo: em uma parada de ônibus de Brasília/DF, um agente rouba um celular. Em Luziânia/GO, ocorre a receptação desse celular. Nesse caso, sendo o roubo o crime mais grave, todos os fatos, isto é, o crime de roubo e o de receptação, deverão ser processados e julgados em algum juízo criminal de Brasília/DF.

A infração mais grave é aquela que tenha pena máxima superior às demais, não importando, em um primeiro momento, a pena mínima. Caso as penas máximas sejam iguais, o desempate se dará por meio da pena mínima, isto é, o juízo prevalente será aquele perante o qual foi praticado o crime com maior pena mínima (HC 190.756/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012).

Em relação ao art. 78, inciso II, alínea *a*, do CPP, muito importante se mostra o estudo da Súmula nº 122 do STJ, segundo a qual "competem à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, *a*, do Código de Processo Penal".

Conforme se nota, havendo conexão entre um crime de competência da Justiça Federal e um crime de competência da Justiça Estadual, pouco importando qual o crime mais grave, isto é, qual o crime tem maior pena máxima, ambas as infrações penais deverão ser julgadas pela Justiça Federal.

Essa junção dos processos perante a Justiça Federal é justificada pelo fato de que sua competência se origina diretamente da Constituição Federal, razão pela qual a Justiça Federal exercerá força atrativa em relação à Justiça Estadual, cuja competência está disciplinada na legislação processual penal ordinária.

Aqui, importante lembrar que, no caso de conexão entre crime de competência da Justiça Federal e contravenção penal, não haverá a reunião de processos perante o juízo federal de

1ª instância, que, conforme visto em tópico próprio, não tem competência para o julgamento de contravenções penais.

Caso as infrações sejam de igual gravidade, isto é, não seja possível se identificar qual é a mais grave, dispõe o art. 78, inciso II, alínea *b*, do CPP, que, no concurso de jurisdições da mesma categoria, prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade.

Portanto, se as infrações penais cometidas forem de igual gravidade, o juízo prevalente será aquele perante o qual foi praticado o maior número de infrações. Exemplo: em Brasília/DF, um agente furta três celulares, praticando, portanto, três crimes de furto simples. Em Águas Lindas de Goiás/GO, ocorre a receptação dolosa de um dos celulares subtraídos. Em Santo Antônio do Descoberto/GO, há a consumação de outros dois crimes de receptação dolosa. Nesse caso, sendo as penas do crime de furto simples e de receptação dolosa idênticas, o foro prevalente será o de Brasília/DF, já que lá foi cometido o maior número de infrações penais.

Na hipótese de nenhum desses critérios ser suficiente para fixar a competência, esta será determinada, de acordo com o art. 78, inciso II, alínea *c*, do CPP, pela prevenção, conforme estudado em capítulo próprio. É dizer: se as infrações penais forem de igual gravidade e tiverem sido cometidas em idêntica quantidade, a solução para a fixação da competência é a prevenção. Exemplo: furto simples de um celular em Brasília/DF e receptação dolosa em Planaltina/GO. Nesse caso, somente a prevenção é que poderá fixar a competência.

#### 3.6.6.4.3. CONCURSO DE JURISDIÇÕES DE DIVERSAS CATEGORIAS

Nos termos do art. 78, inciso III, do CPP, no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação, isto é, o órgão jurisdicional de maior hierarquia.

Nesse contexto, havendo relação de conexão e/ou continência entre os fatos e um dos autores detenha foro por prerrogativa de função, é permitido que ambos os agentes sejam processados e julgados pelo Tribunal respectivo, isto é, pelo foro por prerrogativa de função de um deles, desde que respeitadas as regras atinentes ao foro por prerrogativa de função, mormente aquelas atualmente exigidas pelo STF/STJ. Exemplo: crime de lavagem de capitais cometido por Deputado Federal e diretor de grande empreiteira; nesse caso, é possível que os dois sejam processados e julgados pelo STF.

É nesse sentido o teor da Súmula nº 704 do STF, a qual aduz que "não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados".

Assenta-se, por oportuno, que, nesse caso, a reunião de processos não é obrigatória, podendo o Tribunal, isto é, o foro por prerrogativa de função — e não o juiz de primeira instância — decidir pela separação dos processos, ainda que haja relação de continência e/ou conexão entre os fatos, nos termos do art. 80 do CPP, que será mais bem analisado em tópico próprio.

Também no que diz respeito à temática em relação ao fato de um dos agentes ser detentor de foro por prerrogativa de função, muito importante registrar que, no caso de crime doloso contra a vida, não haverá a reunião de processos. Nessa hipótese, respeitadas as regras delineadas pelo STF/STJ e desde que o foro por prerrogativa de função esteja previsto na CF/88, o agente que o detenha será julgado pelo Tribunal especificado pela Carta Magna. Os demais agentes, isto é, aqueles que não detenham foro por prerrogativa de função, serão julgados pelo Tribunal do Júri. É dizer: sendo a competência do foro por prerrogativa de função e a do Tribunal do Júri definidas pela Constituição Federal, as duas regras devem ser respeitadas e a única forma de concretizar isso é separar os processos, já que uma norma infralegal (art. 69, inciso V, CPP) não pode afastar uma norma constitucional (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea *d*, CF/88) (LIMA, 2020, p. 574).

#### 3.6.6.4.4. CONCURSO ENTRE A JURISDIÇÃO COMUM E A ESPECIAL

Conforme art. 78, inciso IV, do CPP, no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta, ou seja, o foro prevalente é a justiça especial.

Nesse contexto, havendo uma relação de conexão e/ou continência entre fatos atrelados a alguma Justiça Especial e à Justiça Comum (Federal ou Estadual), a jurisdição especial exercerá força atrativa, competindo-lhe o julgamento de ambas as infrações penais.

Aqui, bastante importante rememorar o caso da conexão entre crime comum e crime eleitoral, porquanto, conforme a mais recente posição do STF, a princípio, competirá à Justiça Eleitoral o julgamento de ambas as infrações penais cometidas, pouco importando se o crime comum era de competência da Justiça Federal ou Estadual, o que é alvo de críticas doutrinárias, conforme visto em tópico próprio.

#### 3.6.6.5. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE FEITOS

Como dito, nos termos do art. 79, *caput*, do CPP, havendo uma relação de conexão e/ou continência entre os fatos, a regra é que haja a reunião de processos, isto é, que todos os fatos sejam processados e julgados perante o juízo prevalente.

Todavia, o próprio art. 79 do CPP traz importantes exceções a esta regra, isto é, elenca casos nos quais, embora verificada a conexão e/ou a continência, não haverá a reunião de processos. A saber:

I) CONCURSO ENTRE A JUSTIÇA COMUM E A JUSTIÇA MILITAR: nos termos do art. 79, inciso I, do CPP, mesmo havendo conexão e/ou continência entre fatos de competência da Justiça Comum e da Justiça Militar, não haverá reunião de processos, isto é, aquilo que for atrelado à Justiça Militar deverá ser por ela julgado. O que for de competência da Justiça Comum deverá ser processado e julgado por ela;

II) CONCURSO ENTRE A JUSTIÇA COMUM E A JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE: conforme art. 79, inciso II, do CPP, mesmo havendo conexão e/ou continência entre fatos de competência da Justiça Comum e do Juízo de Menores (Justiça da Infância e da Juventude), não haverá reunião de processos. Exemplo clássico e bastante recorrente no cotidiano forense é o roubo praticado por indivíduos maiores de idade em comparsaria com menores. Nesse caso, os maiores de idade deverão ser julgados pela Justiça Comum e os menores pela Justiça da Infância e da Juventude, não havendo falar em reunião de processos;

III) DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE À PRÁTICA DELITUOSA: nos termos do art. 79, §1º, do CPP, cessará, em qualquer caso, a unidade do processo, se, em relação a algum corréu, sobrevier o caso previsto no art. 152, o qual disciplina a hipótese de doença mental superveniente à prática delitiva. Assim, sendo constatada, durante o curso da ação penal, uma doença mental no acusado, duas situações diversas poderão ocorrer:

III.A) se a doença já existia à época do fato e privava o agente da capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o processo não será suspenso. Nesse caso, o agente deve ser absolvido impropriamente, nos termos do art. 386, parágrafo único, inciso III, do CPP (aplicação de medida de segurança); e

III.B) se a doença mental somente surgiu após o cometimento do fato, estamos diante da hipótese prevista no art. 79, §1º, do CPP. Nesse caso, o processo deverá ficar suspenso até que o agente se recupere. Caso haja corréu, o processo somente fica suspenso em relação àquele que foi acometido com a doença, por isso é que haverá a separação dos feitos. É dizer: o processo segue normalmente em relação ao corréu que não manifestou doença mental e fica suspenso em relação àquele que adoeceu, separando-se os procedimentos;

IV) CITAÇÃO POR EDITAL DE UM DOS CORRÉUS E NÃO-COMPARECIMENTO DESTA E NÃO-CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR: havendo a citação por edital de um dos corréus e não tendo ele comparecido ao processo e nem constituído advogado, nos termos do art. 366 do CPP, haverá, em relação a ele, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. É dizer: o processo segue normalmente em relação ao corréu que foi citado pessoalmente e fica suspenso em relação àquele que foi citado por edital e não compareceu e nem constituiu advogado, separando-se os procedimentos;

V) EXTINTA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA OU DE NÃO-COMPARECIMENTO DO ACUSADO À SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI, EM SE TRATANDO DE CRIME INAFIANÇÁVEL: o art. 79, §2º, do CPP, também disciplinava que haveria a separação de processos, quando houvesse corréu foragido que não pudesse ser julgado à revelia. Tal dispositivo legal somente fazia sentido antes da reforma processual de 2008, já que, naquela época, em se tratando de crime inafiançável, quando um dos acusados não fosse intimado pessoalmente da pronúncia ou deixasse de comparecer à sessão plenária, seu julgamento não poderia ser realizado, isto é, ele não poderia ser julgado à revelia, separando-se os feitos, porquanto o processo do corréu continuava. Atualmente, se o réu não for encontrado, será intimado da pronúncia por edital e, caso esteja solto, não comparecer à sessão plenária, seu julgamento ocorrerá à revelia, pouco importando se o crime é afiançável ou inafiançável. É dizer: se um dos corréus não for encontrado para ser intimado da pronúncia e/ou, caso esteja solto, não comparecer à sessão plenária, não haverá a separação dos processos, sendo todos os corréus julgados na mesma sessão plenária; e

VI) RECUSAS PEREMPTÓRIAS NO JÚRI: o art. 79, §2º, do CPP, também disciplinava que haveria a separação de processos no caso do antigo art. 461 do CPP, que, em resumo, normatizava que, caso um jurado fosse recusado pela defesa de um corréu, mas aceito pela defesa de outro e pelo Ministério Público, haveria a separação dos processos. É dizer: o jurado que foi aceito pela defesa de um corréu e pelo Ministério Público somente poderia participar do julgamento do réu cuja defesa lhe aceitou, o que obrigava a separação dos processos. Atualmente, tendo uma defesa recusado imotivadamente um jurado, este estará excluído do julgamento de todos os corréus, razão pela qual não mais se fala em separação de processos.

### 3.6.6.6. SEPARAÇÃO FACULTATIVA DOS FEITOS

O art. 80 do CPP disciplina que será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Assim, ainda que haja uma relação de conexão e/ou continência entre os fatos, nessas três hipóteses, poderá haver a separação dos processos (TÁVORA; ALENCAR, p. 451):

I) INFRAÇÕES PRATICADAS EM CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E/OU LUGAR DIFERENTES: caso o juiz verifique que a disparidade entre o tempo e/ou o lugar em que os fatos foram praticados atrapalhará a marcha procedimental e/ou a colheita probatória, é possível que determine a separação dos feitos, ainda que haja uma relação de conexão e/ou continência entre aqueles fatos. Exemplo: roubo de celular em Brasília/DF e receptação em Nova Crixás/GO, que fica a cerca de 450km da Capital Federal. Nesse caso, pode ser interessante que o roubo seja julgado em Brasília/DF e a receptação em Nova Crixás/GO, dada a distância entre as cidades, o que pode dificultar/atrasar a produção probatória em um único procedimento;

II) NÚMERO EXCESSIVO DE ACUSADOS: uma quantidade excessiva de acusados pode gerar o prolongamento imoderado da instrução processual, implicando na extensão desproporcional do tempo de prisão provisória, que, por esta razão, se tornará ilegal. Assim, considerando a determinação constitucional de que o processo não se alongue por prazo maior que o razoável (art. 5º, inciso LXXVIII, CF/88), principalmente quando houver réus presos e soltos, caberá ao magistrado,



de ofício ou por provocação, verificar a conveniência de manter a unidade do processo ou de determinar a sua separação; e

III) QUALQUER OUTRO MOTIVO RELEVANTE: trata-se de cláusula aberta, a qual permite ao juiz, desde que fundamente sua decisão, concretizar a separação de processos, ainda que haja uma relação de conexão e/ou continência entre os fatos. Exemplo: crimes cometidos por agente detentor de foro por prerrogativa de função em comparsaria com agentes que não detenham foro por prerrogativa. Nesse caso, pode o Tribunal competente — isto é, o foro por prerrogativa de função — determinar a separação dos processos, julgando o agente detentor do foro e deixando que os demais agentes sejam julgados pelo juiz de primeira instância.

### 3.6.6.7. PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA NOS CASOS DE CONEXÃO E/OU CONTINÊNCIA

O art. 81, *caput*, do CPP assenta que, verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos, operando-se a chamada perpetuação de sua competência.

Conforme se nota, havendo a reunião de processos pela conexão e/ou continência, a perpetuação da competência permite que o juízo prevalente, "mesmo que venha a absolver ou desclassificar a infração que determinou a atração, continue competente para julgar as demais" (TÁVORA; ALENCAR, 451).

Exemplo: crime de roubo cometido em Brasília/DF e receptação qualificada em Caldas Novas/GO. Nesse caso, ambos os processos devem ser reunidos em Brasília/DF, porquanto lá foi cometido o crime mais grave (art. 78, inciso II, alínea *a*, CPP). Ao final do processo, o juiz de Brasília/DF desclassifica o crime de roubo para o crime de furto simples, cuja pena é bem menor do que a cominada ao crime de receptação qualificada. Nesse caso, o juiz de Brasília/DF se mantém competente para o julgamento de ambas as infrações penais (furto simples e receptação qualificada), já que se operou a perpetuação de sua competência, nos termos do art. 81, *caput*, do CPP (LIMA, 2020, p. 651).

Ainda em relação ao exemplo acima, note-se que, caso, desde o início, as infrações penais fossem furto simples em Brasília/DF e receptação qualificada em Caldas Novas/GO, o juízo desta última cidade exerceria força atrativa sobre o juízo da Capital Federal, nos termos do citado art. 78, inciso II, alínea *a*, do CPP. Todavia, como o crime de furto simples adveio da desclassificação do crime de roubo, o juízo de Brasília/DF, nos termos do art. 81, *caput*, do CPP, se mantém competente para o processo e o julgamento de ambas as infrações penais.

O instituto da "perpetuação da competência atende ao princípio da economia processual e da própria celeridade, na medida em que toda a prova já fora colhida perante este juízo". De mais a mais, deve ser considerado que, tendo em vista a inserção do princípio da identidade física do juiz no processo penal (art. 399, §2º, CPP), "eventual remessa do processo ao outro juízo traria como consequência inevitável a renovação da instrução processual, causando indevido retrocesso na marcha procedimental" (LIMA, 2020, p. 652).

#### 3.6.6.7.1. TRIBUNAL DO JÚRI

No que diz respeito ao estudo da perpetuação (ou não) da competência no caso do Tribunal do Júri, três situações distintas podem ser verificadas (LIMA, 2020, p. 652):

I) DESCCLASSIFICAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO DO JÚRI: nos termos do art. 419, *caput* e parágrafo único, do CPP, quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da inexistência de crime doloso contra a vida e não for competente para o seu julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja, ficando o acusado preso à disposição deste outro juízo. No que diz respeito à infração penal conexa e/ou continente, disciplina o art. 81, parágrafo único, do CPP, que,



se o juiz vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente. Logo, excetuando a regra da perpetuação da competência, inserta no *caput* do art. 81 do CPP, no caso do rito bifásico do Júri, se o juízo sumariante impronunciar, absolver sumariamente ou desclassificar o crime inicialmente tido por doloso contra a vida, deverá remeter as infrações penais conexas e/ou continentes ao juízo competente. Exemplo: João é acusado de homicídio doloso em Teresópolis/RJ e ocultação de cadáver em Petrópolis/RJ. Em razão da conexão, os fatos foram reunidos perante o juízo de Teresópolis/RJ. Caso o juízo da Vara do Tribunal do Júri de Teresópolis/RJ, ao final da primeira fase, impronuncie ou absolva sumariamente João em relação ao crime de homicídio doloso, deverá remeter o crime de ocultação de cadáver ao juízo criminal competente. Caso desclassifique o crime de homicídio doloso para culposo, ambas as infrações deverão ser remetidas ao juízo criminal comum;

II) DESCCLASSIFICAÇÃO NA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI: caso a desclassificação seja concretizada pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 492, §§1º e 2º, do CPP, caberá ao juiz-presidente o julgamento da infração penal desclassificada e das conexas e/ou continentes, não havendo a remessa dos autos a outro juízo. No exemplo do tópico acima, ao juiz-presidente do Tribunal do Júri de Teresópolis/RJ caberia o julgamento do homicídio culposo e da ocultação de cadáver; e

III) ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA: se os jurados absolverem o acusado em relação ao crime doloso contra a vida, também competirá ao Conselho de Sentença o julgamento das infrações penais conexas e/ou continentes com aquele, aplicando-se a regra do art. 81, *caput*, do CPP. No exemplo acima, caso os jurados absolvam João do crime de homicídio doloso, deverão ser quesitados em relação ao crime de ocultação de cadáver.

### 3.6.6.7.2. JUSTIÇA FEDERAL

No caso da Justiça Comum Federal, quatro situações distintas podem ser verificadas, a saber:

I) DESCCLASSIFICAÇÃO DO ÚNICO CRIME QUE TRAMITAVA PERANTE O JUÍZO FEDERAL: nesse caso, o juízo federal deverá remeter os autos ao juízo estadual, porquanto, em última análise, está reconhecendo sua incompetência absoluta, não se aplicando a regra do art. 81, *caput*, do CPP, mormente porque a competência da Justiça Federal é do tipo absoluta. Exemplo: João é acusado de tráfico internacional de drogas perante um juízo federal. Ao final da instrução, o juiz federal entende que não restou provada a internacionalidade da conduta. Nesse caso, desaparecendo a competência da Justiça Federal, os autos deverão ser remetidos ao juízo estadual competente (LIMA, 2020, p. 652-653);

II) DESCCLASSIFICAÇÃO DO CRIME FEDERAL E EXISTÊNCIA DE INFRAÇÕES PENAS ESTADUAIS CONEXAS E/OU CONTINENTES: de igual forma, o juízo federal deverá remeter os autos ao juízo estadual competente. Exemplo: José é acusado de tráfico internacional de drogas e latrocínio em conexão. Ambas as infrações penais, nos termos da estudada Súmula nº 122 do STJ, deverão ser reunidas perante o juízo federal. Se o juiz federal, ao final da instrução, entender que o tráfico é interno, deverá remeter os autos ao juízo estadual competente, porquanto desapareceu a competência da Justiça Federal;

III) ABSOLVIÇÃO DO CRIME FEDERAL E EXISTÊNCIA DE INFRAÇÕES PENAS ESTADUAIS CONEXAS E/OU CONTINENTES: nesse caso, o juízo federal permanece competente para o julgamento das infrações penais conexas e/ou continentes ao crime federal. Exemplo: João é acusado de tráfico internacional de drogas e roubo em conexão. Ambas as infrações penais, nos termos da estudada Súmula nº 122 do STJ, deverão ser reunidas perante o juízo federal. Caso o juiz federal, na sentença, absolva João quanto ao crime de tráfico internacional de drogas, por insuficiência probatória, por exemplo,

permanecerá competente para o julgamento do crime de roubo, nos termos do art. 81, *caput*, do CPP. É dizer: ao absolver João quanto ao crime de tráfico, o juízo federal se disse competente em relação àquele fato, estendendo a sua competência para os demais crimes, nos termos do citado artigo (LIMA, 2020, p. 652-653); e

IV) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME FEDERAL E EXISTÊNCIA DE INFRAÇÕES PENAS ESTADUAIS CONEXAS E/OU CONTINENTES: nesse caso, sobrevivendo a prescrição do crime federal, "desaparece o interesse da União, devendo haver o deslocamento da competência para a Justiça Estadual" (HC 108.350/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2009, DJe 24/8/2009). Exemplo: João foi acusado de desobediência a servidor público federal e crimes ambientais. Havendo a prescrição do crime contra a Administração Pública Federal, que motivou a reunião dos processos perante o juízo federal, este deverá remeter os autos ao juízo comum estadual.

### 3.6.7. CRIMES COMETIDOS FORA DO TERRITÓRIO BRASILEIRO

Nos termos do art. 88 do CPP, no processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da Capital do Estado onde houver por último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da Capital da República.

Assim, no caso da extraterritorialidade da lei penal brasileira, duas regras devem ser observadas:

I) AGENTE QUE JÁ RESIDIU NO BRASIL: o foro competente é o juízo da Capital do Estado onde houver por último residido o acusado; e

II) AGENTE QUE NUNCA RESIDIU NO BRASIL: o foro competente é o juízo da Capital da República.

Desse modo, nota-se que nem sempre a ação penal correrá perante o juízo da Capital da República, já que, caso o agente tenha residido no Brasil, o processo penal deverá tramitar perante o juízo da Capital do Estado em que o agente por último residiu.

Exemplo: na França, João, que nunca residiu no Brasil, comete um crime contra o patrimônio da União. Nesse caso, nos termos do art. 7º, inciso I, alínea *b*, do CP, embora praticado no exterior, será aplicada a lei penal brasileira. Como João nunca residiu no Brasil, o processo deverá tramitar perante uma das varas criminais federais da Capital da República, porquanto o crime foi praticado em detrimento da União.

Muito importante é perceber que nem sempre o fato será de competência da Justiça Federal. É dizer: o fato de o crime ser praticado fora do Brasil, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal. No exemplo, o crime será processado pela Justiça Federal, porquanto foi praticado em detrimento da União, nos termos do art. 109, inciso IV, da CF/88. Exemplo: João, que, no Brasil, somente residiu em Juiz de Fora/MG, pratica, na África do Sul, crime contra o patrimônio da cidade do Rio de Janeiro/RJ. Nesse caso, nos termos do art. 7º, inciso I, alínea *b*, CP, embora praticado no exterior, será aplicada a lei penal brasileira. Como João, no Brasil, residiu por último em Juiz de Fora/MG, o fato deverá ser processado perante uma das varas criminais comuns da Capital de Minas Gerais, isto é, Belo Horizonte/MG.

#### 3.6.7.1. CRIME COMETIDO POR BRASILEIRO NO EXTERIOR E NEGATIVA DE EXTRADIÇÃO

Há uma importante divergência entre o STF e o STJ no que diz respeito à Justiça competente para processar e julgar crime cometido por brasileiro no exterior, cuja extradição tenha sido negada pelo Brasil. Exemplo: João, brasileiro nato, na China, comete um crime de furto contra um chinês e foge para o Brasil. Como é brasileiro nato, João não poderá ser extraditado para a China, devendo ser processado pela justiça brasileira.

Para o STF, a competência será da Justiça Estadual. A fim de que fosse julgado pela Justiça Federal, seria necessário que a situação se encaixasse em uma das hipóteses do art. 109 da CF/88 (1ª Turma. RE 1.175.638 AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 2/4/2019 - Info 936).

Noutro giro, de acordo com o STJ, "competete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre crime praticado no exterior que tenha sido transferida para a jurisdição brasileira, por negativa de extradição" (3ª Seção. CC 154.656-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/4/2018 - Info 625).

#### 4. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA

##### 4.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Súmula Vinculante nº 45, STF: "A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual."

Súmula nº 498, STF: "Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular."

Súmula nº 451, STF: "A competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional."

Súmula nº 521, STF: "O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado."

Súmula nº 706, STF: "É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção."

**HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA RECORRER DO ÉDITO CONDENATÓRIO. ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU QUE MAJOROU A REPRIMENDA. ACÓRDÃO ANULADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE DEVE SER APRECIADA PELA VIA PRÓPRIA E PELO TRIBUNAL COMPETENTE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. I – Um juízo de primeiro grau não pode rescindir um acórdão de instância superior, mesmo na hipótese de existência de nulidade absoluta, sob pena de violação das normas processuais penais e constitucionais relativas à divisão de competência. II – Agiu bem o Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que não compete ao juízo da execução reconhecer uma nulidade, ainda que absoluta, ocorrida no curso de processo findo, ocasionando verdadeira rescisão de decisão proferida por instância superior. III – Também não caberia ao STJ analisar, *per saltum*, a alegada nulidade absoluta, pois a Corte Regional limitou-se a anular a decisão do juízo da execução que rescindiu indevidamente o seu julgado, sem manifestar-se, expressamente, sobre eventual nulidade decorrente da ausência de intimação do paciente. IV – Pelos mesmos fundamentos, não pode esta Corte analisar o pedido de anulação da ação penal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência outorgada no art. 102 da Constituição Federal. V – *Habeas corpus* parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. (HC 110358, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 12/6/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31/7/2012 PUBLIC 1º/8/2012.)**

**COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – HOMICÍDIO – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – FUNÇÃO – VINCULAÇÃO – AUSÊNCIA. A suposta prática de homicídio, desvinculada da condição funcional de policial rodoviário federal, não faz incidir a competência da Justiça Federal, a qual, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, pressupõe o cometimento de delito em detrimento de bens, serviços ou interesse da União. (HC 157012, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 10/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26/2/2020 PUBLIC 27/2/2020.)**



#### 4.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Súmula nº 38, STJ: “Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.”

Súmula nº 42, STJ: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.”

Súmula nº 48, STJ: “Compete ao Juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque.”

Súmula nº 53, STJ: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado de prática de crime contra instituições militares estaduais.”

Súmula nº 73, STJ: “A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual.”

Súmula nº 122, STJ: “Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal.”

Súmula nº 140, STJ: “Compete à justiça comum estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou como vítima.”

Súmula nº 244, STJ: “Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos.”

#### QUESTÕES

**1-TRF 2ª Região (TRF 2ª Região 2014 – adaptada)** É da competência penal da Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse de fundações públicas federais.

**2- TJ/PR (Cespe/UnB 2019 – adaptada)** A respeito de competência jurisdicional, é correto afirmar que o juízo de admissibilidade da exceção da verdade relacionada ao crime de calúnia em desfavor de autoridade pública com foro por prerrogativa de função é de competência das instâncias ordinárias.

**3- TJ/PR (Cespe/UnB 2019 – adaptada)** A respeito de competência jurisdicional, é correto afirmar que a competência constitucional do tribunal do júri é uma cláusula pétrea, razão pela qual é inadmitida a sua ampliação por lei ordinária.

**4- MPDFT (MPDFT 2015 – adaptada)** O crime de furto de uma carteira de um passageiro, cometido a bordo de aeronave comercial pousada no aeroporto de Brasília, deve ser julgado na Vara Criminal da Justiça comum local do Distrito Federal.

**5- MPE/SP (MPE/SP 2005 – adaptada)** Haverá conexão material quando a prova de uma infração ou de qualquer circunstância influir na prova de outra.

**6- TRF 1ª Região (Cespe/UnB 2011 – adaptada)** Havendo conexão entre crimes de competência estadual e federal, firma-se a segunda para conhecer, processar e julgar o feito, consoante preceito contido em verbete sumular do STJ e, mesmo que sobrevenha declaração de extinção da punibilidade em relação ao crime que atraiu a competência federal, permanece este juízo competente para julgar as demais infrações, em face do princípio da *perpetuatio jurisdictionis*, nos termos expressos do CPP.

#### COMENTÁRIOS

1. Gabarito: CORRETO. Apesar de não constarem expressamente do art. 109, inciso IV, da CF/88, os crimes praticados em desfavor das fundações públicas federais, sejam elas de direito público, sejam elas de direito privado, serão processados e julgados pela Justiça Federal.
2. Gabarito: CORRETO. O julgamento da exceção da verdade interposta em desfavor de detentor de foro por prerrogativa de função compete ao Tribunal respectivo. Todavia, o juízo de admissibilidade da exceção e sua instrução são de competência das instâncias ordinárias. É dizer: após admitir a exceção da verdade e instruí-la, a instância ordinária encaminha a exceção da verdade para o Tribunal responsável por seu julgamento (HC 311.623/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 17/3/2015).
3. Gabarito: ERRADO. Em verdade, o legislador ordinário não poderá retirar do Tribunal do Júri a competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, contudo, poderá prever que outros crimes, distintos dos dolosos contra a vida, sejam julgados pelo Tribunal do Júri (NUCCI, 2016, p. 196).
4. Gabarito: ERRADO. No que diz respeito aos crimes cometidos a bordo de aeronaves, tem-se que, diferentemente do que ocorre em relação aos navios, para fins de fixação da competência da Justiça Federal, mostra-se irrelevante o fato da aeronave se encontrar em solo ou sobrevoando. É dizer: ainda que a aeronave se encontre em terra, o crime nela cometido será de competência da Justiça Federal, ou seja, mesmo que a aeronave não esteja em deslocamento ou em situação de potencial descolamento, o crime cometido em seu interior deverá ser processado e julgado pela Justiça Federal (CC 143.343/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 30/11/2016).
5. Gabarito: ERRADO. Nesse caso, considerando que a prova de uma infração influencia na prova de outra, estamos diante da chamada conexão instrumental, probatória ou processual, nos termos do art. 76, inciso III, do CPP.
6. Gabarito: ERRADO. Nesse caso, sobrevivendo a prescrição do crime federal, "desaparece o interesse da União, devendo haver o deslocamento da competência para a Justiça Estadual" (HC 108.350/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2009, DJe 24/8/2009).



## CAPÍTULO 11– DAS QUESTÕES PREJUDICIAIS (ART. 92 A 94, CPP)

## 1. DIFERENÇAS ENTRE QUESTÕES PREJUDICIAIS E QUESTÕES PRELIMINARES (OU PRÉVIAS)

| QUESTÕES PREJUDICIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                       | QUESTÕES PRELIMINARES (OU PRÉVIAS)                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ocorrem quando há alguma questão de direito material referente a determinada elementar/tipicidade do crime que deve ser resolvida – Exemplo: no crime de abandono material (art. 244, CP), deve ser provado que a pessoa abandonada realmente é filho para que haja a tipificação do crime. | São questões processuais que dizem respeito ao próprio processo e seu regular desenvolvimento.                                                                                                          |
| São questões que interferem no próprio julgamento de mérito do crime. É dizer: no exemplo acima, se restar provado que o acusado não é pai do abandonado, não há falar em crime de abandono.                                                                                                | Caso seja reconhecida, a decisão da questão preliminar tem o único efeito de impedir o julgamento do mérito da causa. É dizer: não interfere no mérito em si, mas, sim, na apreciação ou não do mérito. |
| São autônomas. Podem ser objeto de processo distinto.                                                                                                                                                                                                                                       | São vinculadas ao processo. São absolutamente dependentes.                                                                                                                                              |
| Podem ser resolvidas pelo juízo penal ou pelo juízo cível.                                                                                                                                                                                                                                  | São resolvidas somente pelo juízo penal.                                                                                                                                                                |

## 2. CLASSIFICAÇÃO DAS QUESTÕES PREJUDICIAIS

As questões prejudiciais podem ser classificadas em:

a) **HOMOGÊNEA/COMUM/IMPERFEITA/NÃO DEVOLUTIVA**: é aquela em que a sua resolução pertence ao mesmo ramo do direito. Exemplo: crime de furto e receptação. A questão prejudicial (crime de furto) e a questão prejudicada (crime de receptação) pertencem ao mesmo ramo do direito;

b) **HETEROGÊNEA/INCOMUM/PERFEITA/DEVOLUTIVA/EXTRAPENAL/JURISDICIONAIS**: é aquela em que a sua resolução pertence a outro ramo do direito. Exemplo: no crime de bigamia, a questão prejudicial quanto à nulidade do casamento anterior pertence ao direito civil e não ao direito penal.

## 2.1. ESPÉCIES DE QUESTÕES PREJUDICIAIS HETEROGÊNEAS

Ao contrário das chamadas questões prejudiciais homogêneas, as heterogêneas, que também interferem no próprio mérito/existência do crime, versam sobre outros ramos do direito, tais como civil, comercial e tributário (AVENA, 2017, p. 235). Vigorando no CPP o sistema eclético ou misto, há duas espécies de questões prejudiciais heterogêneas:

a) **HETEROGÊNEA/EXTRAPENAL OBRIGATÓRIA**: sistema da prejudicialidade obrigatória — prevista no artigo 92, CPP); e

b) **HETEROGÊNEA/EXTRAPENAL FACULTATIVA**: sistema da prejudicialidade facultativa — prevista no artigo 93, CPP.

## 2.1.1. HETEROGÊNEA/EXTRAPENAL OBRIGATÓRIA

Nos termos do art. 92, *caput*, do CPP, se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia, que o juiz repute séria e fundada, sobre o estado civil das



peçoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente.

Caso o crime cujo processo foi suspenso seja de ação penal pública, o Ministério Público, quando necessário, promoverá a ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada, com a citação dos interessados, conforme parágrafo único do art. 92 do CPP.

Assim, a questão prejudicial heterogênea obrigatória possui as seguintes características importantes:

- possui relação com o estado civil das pessoas;
- implica na suspensão obrigatória do processo criminal até que se resolva a questão prejudicial no juízo extrapenal;
- essa suspensão se dá por prazo indeterminado (duração indefinida) – até que haja decisão transitada em julgado no juízo cível a respeito da questão prejudicial;
- a prescrição também ficará suspensa (art. 116, inciso I, CP);
- a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial pode se dá de ofício pelo juiz ou pelo requerimento das partes (art. 94, CPP);
- a decisão definitiva proferida pelo juízo cível faz coisa julgada no juízo penal;
- a decisão judicial que determina a suspensão do processo penal está sujeita a recurso em sentido estrito (art. 581, inciso XVI, do CPP); e
- todavia, a decisão que não decreta a suspensão é irrecorrível, cabendo, no entanto, HC (art. 93, §2º, CPP).

### 2.1.2. HETEROGÊNEA/EXTRAPENAL FACULTATIVA

Nos termos do art. 93, *caput*, do CPP, se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do juízo cível, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente.

Nesse caso, o juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for imputável à parte. Expirado o prazo, sem que o juiz cível tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver, de fato e de direito, toda a matéria da acusação ou da defesa, conforme art. 93, §1º, do CPP.

Havendo a suspensão, e tratando-se de crime de ação pública, incumbirá ao Ministério Público intervir imediatamente na causa cível, para o fim de promover-lhe o rápido andamento, nos termos do art. 93, §3º, do CPP.

Desse modo, a questão prejudicial heterogênea facultativa apresenta as seguintes características marcantes:

- o processo criminal será suspenso facultativamente pelo juiz, quando o tema estiver na seara extrapenal, não estando relacionado com o estado civil das pessoas (questão prevista no artigo anterior – art. 92, CPP);
- a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial pode se dá de ofício pelo juiz ou pelo requerimento das partes (art. 94);
- se o juiz não suspender, deverá enfrentar a questão prejudicial na sentença;
- também ficará suspensa a prescrição (art. 116, inciso I, CP);
- é necessário que já haja uma ação cível em andamento, ou seja, é necessário que a questão prejudicial já esteja em discussão no juízo cível;

- o processo ficará suspenso por prazo determinado. É dizer: o juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for imputável à parte. Expirado o prazo, sem que o juiz cível tenha proferido a decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência plena para resolver, de fato e de direito, toda a matéria;
- a decisão definitiva proferida pelo juízo cível faz coisa julgada no juízo penal;
- a decisão judicial que determina a suspensão do processo penal está sujeita a recurso em sentido estrito (art. 581, inciso XVI, do CPP); e
- contudo, a decisão que não decreta a suspensão é irrecorrível, cabendo, no entanto, HC (art. 93, §2º, CPP).

### 2.1.3. QUESTÃO PREJUDICIAL TOTAL E PARCIAL

A questão prejudicial total é verificada quando a sua solução tiver o condão de fulminar a existência do crime. Exemplo: o reconhecimento da invalidade do casamento anterior implicará na atipicidade do crime de bigamia, ou seja, diante da questão prejudicial, o crime some por completo.

Noutro giro, a questão prejudicial parcial se restringe ao reconhecimento de circunstâncias do crime (agravantes, atenuantes, qualificadoras etc.), deixando incólume a sua existência.

## 3. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA

### 3.1. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA E CRIME DE DESCAMINHO. Ainda que o descaminho seja delito de natureza formal, a existência de decisão administrativa ou judicial favorável ao contribuinte - anulando o auto de infração, o relatório de perdimento e o processo administrativo fiscal - caracteriza questão prejudicial externa facultativa que autoriza a suspensão do processo penal (art. 93 do CPP). O STF, por ocasião do julgamento do HC 99.740-RJ (DJe 1º/2/2011), firmou compreensão no sentido de que a consumação do delito de descaminho e a abertura de processo-crime não estão a depender da constituição administrativa do débito fiscal porque o delito de descaminho é formal e prescinde do resultado. E, secundando o entendimento do Pretório Excelso, este STJ, por ambas as Turmas com competência em matéria penal, vem também decidindo que o descaminho é crime formal, e que a persecução penal independe da constituição do crédito tributário, como se colhe em reiterados precedentes. Do exposto, resulta que, sendo desnecessária a constituição definitiva do crédito tributário para a tipificação do delito, não fica a ação penal - instaurada para a apuração de crime de descaminho - no aguardo de processo administrativo, ação judicial ou execução fiscal acerca do crédito tributário, tendo em vista a independência entre as esferas. Todavia, a existência de decisão administrativa ou judicial favorável ao contribuinte provoca inegável repercussão na própria tipificação do delito, caracterizando questão prejudicial externa facultativa que autoriza a suspensão do processo penal (art. 93 do CPP). (REsp 1.413.829-CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 11/11/2014 - Info 488.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM *HABEAS CORPUS*. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. SUSPENSÃO FACULTATIVA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias afirmaram existência de provas suficientes de materialidade do crime, em especial laudo necroscópico, apto a ensejar o prosseguimento da instrução processual. 2. É facultativa a suspensão da ação penal em razão da pendência de realização de laudo complementar na esfera cível. Tendo sido devidamente fundamentada o indeferimento do pedido de suspensão, não resta falar em constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental no Recurso



em *Habeas Corpus* desprovido.(AgRg no RHC 104.044/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 5/8/2019.)

RECURSO EM *HABEAS CORPUS*. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. AÇÃO ANULATÓRIA NA ESFERA CÍVEL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INALTERADA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO FACULTATIVA A CRITÉRIO DO JUÍZO CRIMINAL. ARTIGO 93 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.1. Este Sodalício pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. 2. No caso concreto, busca-se o trancamento, ou a suspensão, da ação penal que apura a prática de crime contra ao ordem tributária, ao argumento de que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa em razão de tutela antecipada concedida em ação anulatória que tramita na Vara da Fazenda Pública Estadual. Contudo, o mero ajuizamento de ação anulatória não desconstitui, *per si*, o crédito tributário. Persiste a condição de procedibilidade da ação penal exigida na Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal - STF, segundo a qual "não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo." No caso em análise, é incontroverso que houve constituição definitiva do tributo e esgotamento da via administrativa.3. A suspensão do processo penal em virtude de questão prejudicial prevista no art. 93 do Código de Processo Penal - CPP é facultativa, dependendo da discricionariedade do juízo diante das particularidades do caso concreto. Precedentes.4. Esta Corte Superior tem admitido a suspensão da ação penal apenas na hipótese de desconstituição do crédito tributário por sentença judicial, mesmo com recurso pendente de julgamento, o que não é o caso dos autos. Precedentes.5. Recurso desprovido.(RHC 88.672/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/2018.)

## QUESTÕES

**1- MPE/GO (MPE/GO 2019 – adaptada)** Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia, que o Juiz repute séria e fundada, sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso por até 1 (um) ano. Expirado o prazo, sem que o Juiz cível tenha proferido decisão, o Juiz criminal fará prosseguir o processo.

**2- MPE/SC (MPE/SC 2019 – adaptada)** Consoante o Código de Processo Penal, se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia, que o juiz repute séria e fundada, sobre o estado civil das pessoas, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente.

**3- TJ/BA (Cespe/UnB 2019 – adaptada)** Subsistindo questão prejudicial sobre o estado civil do réu, o juiz criminal deverá continuar o trâmite processual e decidir a questão como preliminar de mérito por ocasião da prolação da sentença.

**4- MPE/BA (FUNDEP 2018 – adaptada)** Para que se dê a suspensão do processo criminal, nas hipóteses da chamada prejudicial facultativa, é indiferente, segundo o CPP, que já exista ou não ação proposta no juízo cível.

**5- MPE/MS (MPE/MS 2018 – adaptada)** É irrecorrível a decisão de indeferimento da suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial.

**6- MPE/PR (MPE/PR 2014 – adaptada)** Se pendente o julgamento de ação anulatória do 1º casamento de TÍBIO no juízo cível, que redunde na suspensão do processo criminal por crime de bigamia, este imputado a TÍBIO em razão do seu 2º casamento, temos a existência de questão prejudicial obrigatória.

**7- DPE/SP (FCC 2013 – adaptada)** A apresentação pelo acusado da prática de furto, no curso do processo, de prévio contrato de compra e venda que o identifique como o comprador da *res furtiva*, impõe ao magistrado a suspensão do processo criminal e o encaminhamento das partes ao juízo cível, por tratar-se de questão prejudicial de natureza heterogênea.

#### COMENTÁRIOS

**1.** Gabarito: ERRADO. Tratando-se de questão prejudicial heterogênea obrigatória, já que diz respeito ao estado civil das pessoas, a suspensão se dará por prazo indeterminado. Isto é: até que haja decisão transitada em julgado no juízo cível a respeito da questão prejudicial.

**2.** Gabarito: ERRADO. Tratando-se de questão prejudicial heterogênea obrigatória, já que diz respeito ao estado civil das pessoas, a suspensão do curso da ação penal é obrigatória.

**3.** Gabarito: ERRADO. Tratando-se de questão prejudicial heterogênea obrigatória, já que diz respeito ao estado civil das pessoas, a suspensão do curso da ação penal é obrigatória.

**4.** Gabarito: ERRADO. Na questão prejudicial facultativa, para que haja suspensão do curso do processo penal, é necessário que já haja ação cível quanto àquela questão, ou seja, é necessário que a questão prejudicial já esteja em discussão no juízo cível.

**5.** Gabarito: CORRETO. Nos termos do art. 93, §2º, CPP, a decisão que não decreta a suspensão é irrecurável, cabendo, no entanto, HC.

**6.** Gabarito: CORRETO. No caso do crime de bigamia, a questão atinente à nulidade do primeiro casamento é prejudicial heterogênea obrigatória, porquanto diz respeito ao estado civil das pessoas (heterogênea, isto é, não diz respeito ao direito penal) e o juiz, obrigatoriamente, deverá suspender o curso do processo penal (por isso, obrigatória).

**7.** Gabarito: ERRADO. Tendo em vista que não diz respeito ao estado civil das pessoas, trata-se de questão prejudicial heterogênea facultativa. É dizer: o juiz poderá suspender o processo, nos termos do art. 93, *caput*, do CPP.



## CAPÍTULO 12 – DAS QUESTÕES INCIDENTAIS (ART. 145 A 154, CPP)

### 1. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL (ART. 145 A 148, CPP)

O incidente de falsidade documental "trata-se de procedimento que tem por objetivo constatar a autenticidade de um documento inserido nos autos do processo criminal, inclusive aqueles que tenham sido produzidos por meio eletrônico, conforme autorizado pelo art. 11, *caput*, da Lei 11.419/2006" (AVENA, 2017, p. 298).

Embora haja alguma divergência na doutrina, "prevalece o entendimento de que o incidente de falsidade pode ser utilizado para a apuração do *falsum* material e do ideológico" (LIMA, 2020, p. 1289).

A instauração do incidente de falsidade documental, que não suspende o curso do processo penal, poderá ser determinada de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes, nos termos do art. 147 do CPP.

Caso a arguição da falsidade documental seja feita por procurador, será exigida procuração com poderes especiais, conforme art. 146 do CPP.

#### 1.1. PROCEDIMENTO

O incidente de falsidade documental deverá observar o seguinte procedimento (art. 145 do CPP):

- instaurado o procedimento de incidente de falsidade documental, será autuado em autos apartados, tendo a parte contrária o prazo de 48h para apresentar resposta;
- após isso, o juiz assinará o prazo de 3 dias, sucessivamente, a cada uma das partes, para prova de suas alegações;
- depois, haverá a decisão do juiz:
  - sendo procedente aquilo deduzido no incidente, haverá o desentranhamento do documento, sendo encaminhado ao MP, para adoção das providências cabíveis;
  - sendo improcedente o incidente, o documento permanecerá nos autos.

#### 1.2. RECURSO CABÍVEL E NÃO FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL

Em qualquer um dos casos, isto é, reconhecida ou não a falsidade, a decisão desafia recurso em sentido estrito (art. 581, inciso XVIII, CPP).

Por fim, nos termos do art. 148 do CPP, a decisão que julga o incidente só fará coisa julgada endoprocessual, ou seja, dentro do processo incidental. Não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil.

### 2. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL (ART. 149 A 154, CPP)

Cuida-se de incidente que, nos termos do art. 149, *caput*, do CPP, visa extirpar eventual dúvida séria e razoável quanto à integridade mental do acusado/investigado. É dizer: para fins de instauração do incidente de insanidade mental, "é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento" (NUCCI, 2016, p. 293-294).

Nesse contexto, o exame de insanidade mental não é automático ou obrigatório, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado/investigado<sup>9</sup>, o que não se verifica, por exemplo, quando o réu, em juízo, sem nada provar, alega ser usuário de drogas<sup>10</sup>.

Tratando-se de prova pericial constituída em favor da defesa, não é possível determiná-lo compulsoriamente na hipótese em que a defesa se oponha à sua realização<sup>11</sup>.

## 2.1. LEGITIMADOS PARA O REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE

Nos termos do art. 149, *caput*, do CPP, o juiz poderá determinar a instauração do incidente de ofício. Além disso, poderão requerê-lo:

- ✓ Ministério Público;
- ✓ defesa;
- ✓ curador do acusado (art. 149, §2º, do CPP);
- ✓ ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro do acusado;
- ✓ na fase do inquérito: o delegado de polícia poderá representar pela instauração do incidente, nos termos do art. 149, §1º, do CPP.

Em que pese a autoridade policial possua atribuição para determinar diligências durante a fase de inquérito, nos termos do art. 6º do CPP, não poderá instaurar o incidente de insanidade mental. Este é determinado apenas pelo juiz. O delegado, se assim entender, deverá representar ao juiz competente.

## 2.2. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E NÃO SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO

Conforme art. 149, §2º, do CPP, quando determinar a realização do exame de insanidade mental, o juiz nomeará curador ao acusado, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.

Dois pontos são relevantes quanto ao citado artigo: I) somente a ação penal é suspensa. É dizer: se o incidente de insanidade mental for instaurado durante o inquérito policial, as investigações não são suspensas; e II) a instauração do incidente não suspende o curso da prescrição.

## 2.3. INEXISTÊNCIA DE RECURSO

Não existe recurso legalmente previsto para a impugnação da decisão que determina a realização do incidente de insanidade mental. Logo, trata-se de decisão irrecorrível. Todavia, parcela da doutrina sustenta que, "como espécie de sucedâneo recursal, é cabível a impetração de mandado de segurança, visto que a própria Lei nº 12.016/09 afasta o *writ of mandamus* para a impugnação de decisões judiciais apenas se contra elas for cabível recurso com efeito suspensivo" (LIMA, 2020, p. 1296).

Em relação à decisão que denega o pedido de instauração do incidente, "é cabível a impetração de *habeas corpus*, desde que haja risco potencial à liberdade de locomoção, sem prejuízo de a parte prejudicada suscitar a nulidade do feito por ocasião da interposição de futura e eventual apelação" (LIMA, 2020, p. 1296).

9AgRg no REsp 1503533/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 25/5/2018);

10RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017).

<sup>11</sup>STF. 2ª Turma. HC 133.078/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 6/9/2016 (Info 838, STF).



## 2.4. QUANTIDADE DE PERITOS

Apesar de o art. 150, *caput*, do CPP se referir a "peritos", no plural, o exame de insanidade mental, perícia oficial que é, deverá ser realizado por apenas um perito oficial, nos termos do art. 159, *caput*, do CPP.

Como sabido, "a Lei n. 11.690/2008 alterou a redação do art. 159, de modo a afastar a necessidade de peritos para a generalidade das perícias, mas o legislador ordinário se esqueceu de atualizar e colocar na mesma linha de pensamento o vetusto art. 150, cuja interpretação deve levar em conta a regulamentação mais recente" (MARCÃO, 2016, p. 346).

## 2.5. DURAÇÃO DO INCIDENTE

O exame de insanidade mental, nos termos do art. 150, §1º, do CPP, não durará mais de 45 dias, salvo se o perito demonstrar a necessidade de maior prazo. Trata-se, pois, de prazo prorrogável. Para facilitar a realização do exame, caso não haja prejuízo, o juiz poderá autorizar sejam os autos entregues ao perito (art. 150, §2º, CPP).

## 2.6. CONSEQUÊNCIAS DO EXAME

A depender do resultado do exame de insanidade mental, poderão advir as seguintes consequências:

I) EXAME CONSIDEROU O AGENTE IMPUTÁVEL AO TEMPO DA INFRAÇÃO E NO MOMENTO EM QUE FOI AVALIADO: o processo seguirá sem o curador (que havia sido nomeado);

II) EXAME CONSIDEROU O AGENTE INIMPUTÁVEL/SEMI-IMPUTÁVEL AO TEMPO DA INFRAÇÃO: o processo continuará com o curador. Se foi considerado inimputável, o juiz proferirá sentença de absolvição imprópria, aplicando medida de segurança (desde que haja prova da materialidade e autoria delitivas). Se foi considerado semi-imputável, o juiz, na terceira fase da dosagem de pena, aplicará a causa especial de diminuição da pena (art. 26, CP);

III) EXAME CONSIDEROU QUE A DOENÇA SOBREVEIO À INFRAÇÃO (AÇÃO PENAL AINDA ESTÁ EM CURSO): ocorrerá a chamada "crise de instância". É dizer: o processo ficará suspenso (a prescrição não), aguardando o restabelecimento do agente para o prosseguimento do processo;

IV) EXAME CONSIDEROU QUE A DOENÇA SOBREVEIO À INFRAÇÃO (JÁ SE INICIOU A EXECUÇÃO PENAL):

IV.A) DOENÇA TRANSITÓRIA:

aplica-se o art. 41 do CP, ou seja, o condenado deve ser transferido para hospital penitenciário, sem necessidade de substituição da pena por medida de segurança. Com a recuperação de sua higidez mental, o acusado deverá voltar a cumprir o restante da pena, computando-se como tempo de cumprimento da pena o período de internação (LIMA, 2020, p. 1306);

IV.B) DOENÇA DE CARÁTER DURADOURO OU PERMANENTE: "a pena privativa de liberdade deve ser convertida em medida de segurança, *ex vi* do art. 183 da LEP" (LIMA, 2020, p. 1307).

### 3. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA

#### 3.1. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO OBRIGATORIEDADE. VIA ELEITA INADEQUADA PARA AFERIR A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA.** 1. O exame a que se refere o art. 149 do Código de Processo Penal é imprescindível apenas quando houver dúvida fundada a respeito da higidez mental do acusado, tanto em razão da superveniência de enfermidade no curso do processo ou pela presença de indícios plausíveis de que, ao tempo dos fatos, era incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou determinar-se de acordo com esse entendimento. 2. O Juiz que presidiu o feito não detectou qualquer anormalidade no interrogatório do acusado, ou mesmo durante a instrução processual, a fim de justificar a instauração do incidente de sanidade mental, sendo certo que somente após a confirmação da pronúncia a defesa alegou ser o paciente portador de suposta enfermidade. 3. Não se vislumbra ilegalidade no acórdão hostilizado que, de maneira fundamentada, confirmou a decisão de primeiro grau e entendeu inexistir qualquer suspeita a respeito da perturbação mental do paciente. Assim, a inversão do decidido demandaria o exame aprofundado de matéria fático-probatória, inviável na via estreita do *habeas corpus*. 4. Ordem denegada. (HC 60.977/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 14/11/2011.)

**AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AFASTAR AS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO.** 1. Nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. Dessa leitura, depreende-se que o exame não é automático ou obrigatório, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado (AgRg no REsp 1503533/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 25/5/2018). 2. No caso, a defesa não se desincubiu de realçar dúvida razoável acerca da inimputabilidade da agravante e as instâncias ordinárias entenderam desnecessária a perícia. 3. Assim, para modificar os fundamentos utilizados mostra-se necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 104.137/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019.)

**RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E EXAME TOXICOLÓGICO. INDEFERIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.** 1. A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento. Precedentes. 2. A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado. 3. No caso, as instâncias ordinárias foram categóricas em afirmar que não existia nos autos dúvida quanto à higidez mental do recorrente e que este tinha consciência, entendia o caráter ilícito de suas ações e dirigiu o seu comportamento de acordo com esse entendimento, sendo, pois, inviável a modificação de tais conclusões na via do recurso ordinário, por demandar o revolvimento do material fático-probatório. 4. Recurso Ordinário em *Habeas Corpus* desprovido. (RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017.)

## QUESTÕES

**1- MPE/MG (FUNDEP – adaptada)** O incidente de falsidade, segundo a visão doutrinária prevalente, tem por fim a averiguação apenas da falsidade material do documento.

**2- MPE/MT (FCC 2019 – adaptada)** À luz do que disciplina o Código de Processo Penal sobre o incidente de falsidade,

- a) a decisão irrecurável não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil.
- b) a decisão irrecurável só fará coisa julgada nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público para apurar a autoria da falsidade.
- c) tendo em vista o princípio da imparcialidade, não é possível que o juiz, de ofício, proceda à verificação da falsidade.
- d) não há previsão legal sobre a possibilidade de diligências no curso do incidente.
- e) é desnecessária a exigência de poderes especiais, na arguição de falsidade, feita por procurador constituído.

**3- TJ/PR (Cespe/UnB 2019 – adaptada)** A respeito de questões e processos incidentes em âmbito penal, é correto afirmar que o juiz, no incidente de insanidade mental, pode, de ofício e independentemente da anuência da defesa, determinar a apresentação compulsória do acusado em exame médico.

**4- DPE/PR (FCC 2017 – adaptada)** Em relação à insanidade mental do acusado, a suspensão processual continua até que o acusado se restabeleça, se a doença mental sobrevier à infração.

**5-DPE/MG (FUNDEP 2014 – adaptada)** A instauração do incidente de insanidade mental do acusado não suspende o processo se já iniciada a ação penal.

## COMENTÁRIOS

1. Gabarito: ERRADO. Embora haja alguma divergência na doutrina, "prevalece o entendimento de que o incidente de falsidade pode ser utilizado para a apuração do *factum* material e do ideológico" (LIMA, 2020, p. 1289).

2. Gabarito: A.

- a) CORRETO. Nos termos do art. 148 do CPP, a decisão que julga o incidente de falsidade documental só fará coisa julgada endoprocessual, ou seja, dentro do processo incidental. Não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil.
- b) ERRADO. Nos termos do art. 148 do CPP, a decisão que julga o incidente de falsidade documental só fará coisa julgada endoprocessual, ou seja, dentro do processo incidental. Não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil.
- c) ERRADO. A instauração do incidente de falsidade documental, que não suspende o curso do processo penal, poderá ser determinada de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes, nos termos do art. 147 do CPP.
- d) ERRADO. Nos termos do art. 145 do CPP, instaurado o procedimento de incidente de falsidade documental, será autuado em autos apartados, tendo a parte contrária o prazo de 48h para apresentar resposta. Após isso, o juiz assinará o prazo de 3 dias, sucessivamente, a cada uma das partes, para prova de suas alegações.
- e) ERRADO. Caso a arguição de falsidade documental seja feita por procurador, será exigida procuração com poderes especiais, conforme art. 146 do CPP.

3. Gabarito: ERRADO. Tratando-se de prova pericial constituída em favor da defesa, não é possível determiná-lo compulsoriamente na hipótese em que a defesa se oponha à sua realização (STF. 2ª Turma. HC 133.078/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 6/9/2016 - Info 838, STF).

4. Gabarito: CORRETO. Caso seja constatado que a doença sobreveio à infração penal e o processo ainda esteja em curso, este será suspenso até que o acusado se restabeleça, não havendo a suspensão da prescrição (crise de instância).

5. Gabarito: ERRADO. Conforme art. 149, §2º, do CPP, quando determinar a realização do exame de insanidade mental, o juiz nomeará curador ao acusado, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.

## CAPÍTULO 13 – EXCEÇÕES E CONFLITO DE COMPETÊNCIA (ARTS. 95 A 117, CPP)

### 1. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA

Entende-se por exceções

as defesas indiretas apresentadas por qualquer das partes, com o intuito de prolongar o trâmite processual, até que uma questão processual relevante seja resolvida, bem como com a finalidade de estancar, definitivamente, o seu curso, porque processualmente incabível o prosseguimento da ação (NUCCI, 2016, p. 247).

Nesse contexto, as exceções são utilizadas "quando não há o propósito de atacar diretamente o mérito da lide principal, mas sim obstaculizar ou transferir o seu julgamento" (AVENA, 2017, p. 239).

Assim, por intermédio das exceções, não se discute a existência ou não da infração penal, sua tipicidade, ilicitude ou culpabilidade do agente ou se há ou não provas suficientes ao decreto condenatório.

O que a parte busca com as exceções não é a condenação ou absolvição do agente, mas, tão somente, impedir a continuidade do processo instaurado ou retardar o seu regular prosseguimento.

#### 1.1. CLASSIFICAÇÃO DAS EXCEÇÕES EM RAZÃO DE SUAS CONSEQUÊNCIAS

No que diz respeito às suas consequências, as exceções podem ser classificadas em peremptórias, as quais fulminam o processo, e dilatórias, que, embora não acarretem a extinção do processo, retardam o seu regular andamento, como ocorre, por exemplo, com a procedência da exceção de incompetência.

#### 1.2. ESPÉCIES DE EXCEÇÕES

De acordo com a literalidade do art. 95 do CPP, poderão ser opostas as exceções de suspeição, incompetência do juízo, litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada.

Embora não estejam arroladas no citado artigo, também existem as exceções de impedimento e de incompatibilidade, às quais será aplicado o procedimento estabelecido para a exceção de suspeição, nos termos do art. 112 do CPP.

### 2. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (ARTS. 96 A 107, CPP)

Para se evitar repetição desnecessária, os casos de suspeição serão estudados no capítulo atinente aos sujeitos processuais. Por ora, estudaremos o rito procedimental atinente à alegação de suspeição do juiz, isto é, a forma como se dá o processamento de eventual exceção de suspeição.

Nesse sentido, como dito no item acima, o mesmo procedimento estabelecido para a exceção de suspeição deve ser seguido em relação às exceções de impedimento e incompatibilidade, razão pela qual sempre que nos referirmos à suspeição, o leitor deve se lembrar do impedimento e da incompatibilidade.

Com efeito, a exceção de suspeição, que é de natureza dilatória, tem por objetivo afastar o juiz suspeito do processo (art. 254, CPP), já que há uma presunção relativa (*juris tantum*) no sentido de que aquele magistrado não é dotado da imparcialidade necessária ao julgamento da causa.



Percebe-se, portanto, que o sujeito passivo da exceção de suspeição é o próprio magistrado e não o juízo perante o qual ele atue, já que as hipóteses de suspeição recaem sobre sua pessoa.

Nos termos do art. 96 do CPP, a arguição da exceção de suspeição deve preceder a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente, devendo se ter bastante atenção em relação a esta última parte do referido dispositivo legal.

De fato, não pode um juiz suspeito decidir qualquer outra questão, já que pesa em seu desfavor uma presunção relativa de parcialidade, comprometendo toda e qualquer decisão por ele proferida.

Não é crível, por exemplo, que um juiz suspeito decida se o juízo perante o qual atua é ou não competente para julgar determinada causa, salvo se a suspeição estiver fundada em motivo superveniente.

Logo, via de regra, a exceção de suspeição deve ser alegada em momento anterior a qualquer outra, contudo, pode ser que, na prática, seu fundamento somente apareça depois que outra exceção já havia sido alegada.

Quanto ao ponto, a título elucidativo, imagine a seguinte situação: logo após o recebimento da peça acusatória, o réu apresenta exceção de coisa julgada, alegando que já foi absolvido pelos fatos narrados na inicial. Após o julgamento da exceção de coisa julgada, o juiz aconselha o Ministério Público a adotar determinado posicionamento em relação ao objeto do processo principal, tornando-se suspeito, nos termos do art. 254, inciso IV, do CPP, razão pela qual, nessa hipótese, a alegação da exceção de suspeição não terá precedido à de coisa julgada.

## 2.1. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA SUSPEIÇÃO

De acordo com o art. 97 do CPP, o juiz que espontaneamente afirmar suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal, e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimadas as partes, não havendo previsão legal de recurso contra a decisão do magistrado que se declara suspeito.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci (NUCCI, 2016, p. 249), se o substituto verificar ausência de fundamento legal na declaração de suspeição do juiz que lhe enviou os autos, poderá suscitar conflito de competência, havendo a possibilidade, ademais, das partes representarem disciplinarmente o magistrado que age sem razão legal.

Noutro giro, ainda de acordo com o renomado professor (NUCCI, 2016, p. 249), caso o juiz invoque razões de foro íntimo para declarar a sua suspeição, deverá, reservadamente, informar os motivos ao Conselho Superior da Magistratura, a fim de que este órgão aprove ou não a razão alegada. Evita-se, com tal procedimento, o abuso na utilização dessa prerrogativa, que não poderá ser usada para que os juízes, por exemplo, se abstenham de julgar processos complexos.

## 2.2. OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

Conforme o art. 98 do CPP, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas.

Nota-se, pois, que a própria parte, independentemente de capacidade postulatória, isto é, não precisa ser advogado, poderá assinar a petição de oposição de suspeição, o que é bastante importante para as provas de concurso.

Detalhe importante diz respeito à necessidade de procuração com poderes especiais, "ou seja, deve constar da procuração que o outorgante confere ao mandatário inclusive poderes para intentar a exceção de suspeição", não servindo, para tanto, "procuração dotada meramente da cláusula *ad judicium*" (LIMA, 2017, p. 1115).

Assim como ocorre em relação à queixa-crime, "é dominante o entendimento no sentido de que essa ausência de procuração com poderes especiais pode ser suprida se a parte assinar a petição em conjunto com seu advogado" (LIMA, 2017, p. 1115).

Em relação à Defensoria Pública, o STJ tem entendido que, mesmo se o assistido estiver fora do distrito da culpa, é necessária a apresentação pelo Defensor Público da procuração com poderes especiais (REsp 1.431.043/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 27/4/2015), o que vem sendo alvo de críticas doutrinárias.

### 2.2.1. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS E NÚMERO DE TESTEMUNHAS

Pela própria redação do art. 98 do CPP e pelo fato de se tratar de um incidente processual, conclui-se que é possível a produção de provas em sede do procedimento de suspeição do magistrado.

Em relação à prova testemunhal, sendo o art. 98 do CPP omissivo no que diz respeito ao número máximo de testemunhas, a doutrina tem se utilizado, por analogia, do art. 357, §6º, do CPC/15, isto é, poderão ser arroladas até 3 (três) testemunhas para cada fato que se pretenda provar (NUCCI, 2016, p. 250).

### 2.2.2. NECESSIDADE DE PETIÇÃO ESCRITA

No rito comum, a exceção de suspeição do juiz deve, necessariamente, ser oposta por petição escrita, destoando das demais espécies de exceções. Elucida-se.

Conforme será visto em tópico próprio, dispõe o art. 108, *caput*, do CPP, que a exceção de incompetência poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa.

Por sua vez, o art. 110, *caput*, do CPP, diz que, nas exceções de litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada, será observado, no que lhes for aplicável, o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo.

Assim, sendo observado, nas exceções de litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada, o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo, é de se concluir que, assim ocorre com esta última, todas elas poderão ser opostas verbalmente ou por escrito.

#### 2.2.2.1. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ORAL NO TRIBUNAL DO JÚRI

Conforme art. 106 do CPP, a suspeição dos jurados deverá ser arguida oralmente, decidindo de plano o presidente do Tribunal do Júri, que a rejeitará se, negada pelo recusado, não for imediatamente comprovada, o que tudo constará da ata.

Portanto, em relação aos jurados do Tribunal do Júri, o CPP determina que a suspeição seja arguida oralmente, devendo o juiz presidente decidí-la de pronto.

Se o jurado a que foi dirigida a exceção de suspeição não a reconhecer, a parte que a arguiu deverá prová-la imediatamente. Caso contrário, deverá o juiz presidente negá-la. É dizer: se a parte não provar imediatamente a suspeição do jurado por ela reputado suspeito, o juiz presidente do Tribunal do Júri não a acolherá.

### 2.2.3. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

Questão bastante controversa diz respeito ao fato de o assistente de acusação possuir ou não legitimidade para opor exceção de suspeição.

Parcela da doutrina entende que é dado ao assistente do Ministério Público opor exceção de suspeição, já que ele tem interesse de exercer os poderes que lhe são conferidos pelo art. 271 do CPP perante um juiz imparcial.



Exige-se, tão somente, que o ofendido assine a petição de oposição de suspeição juntamente com o procurador ou que este possua poderes especiais para tanto (NUCCI, 2016, p. 250).

Outra parcela da doutrina, discordando da primeira, defende que não é dado ao assistente do Ministério Público opor exceção de suspeição do juiz, sustentando tal posicionamento no fato de o STJ ter precedente no sentido da taxatividade do rol do art. 271 do CPP (STJ, REsp 604.379/SP) (AVENA, 2017, 240).

A nosso ver, considerando que o próprio CPP confere ao assistente de acusação outros poderes não arrolados no art. 271 do CPP, tais como requerer medidas cautelares pessoais (arts. 282, §2º e 311, CPP) e o desaforamento no âmbito do rito do Júri (art. 427, CPP), perfilhamo-nos à primeira corrente, porquanto, sendo a suspeição causa de nulidade absoluta, é interesse do assistente do Ministério Público que ela seja reconhecida.

#### 2.2.4. MOMENTO PARA ALEGAÇÃO

A doutrina e a jurisprudência têm entendido "que a exceção de suspeição deve ser oposta pelas partes tão logo tomarem conhecimento de um dos motivos do art. 254", sob pena de preclusão. É dizer: se a parte conhecer da causa de suspeição do juiz e não opor a exceção ora estudada "na primeira oportunidade possível, dar-se-á preclusão, subentendendo-se que o silêncio da parte seria equiparado ao reconhecimento da capacidade moral do juiz para proferir a decisão com imparcialidade" (LIMA, 2017, p. 1116).

Todavia, conforme será visto em capítulo próprio, de forma majoritária, a despeito de alguma divergência, entende-se que a suspeição é causa de nulidade absoluta do ato praticado, sendo "plenamente possível que a matéria volte a ser apreciada pelo Tribunal competente". Assim, tendo em vista que as causas de suspeição dizem respeito a questões atinentes ao princípio do devido processo legal e à garantia de imparcialidade do julgador, a nulidade absoluta daí originada "pode ser reconhecida a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, quer por meio de *habeas corpus*, quer por meio de revisão criminal" (LIMA, 2017, p. 1116).

#### 2.2.5. ACEITAÇÃO PELO JUIZ DA OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

Se o juiz reconhecer a suspeição, assim como vimos no caso do próprio magistrado se declarar suspeito, este deverá encaminhar os autos a seu substituto legal, não havendo recurso legalmente previsto para se discutir tal decisão.

Nesse contexto, dispõe o art. 99 do CPP que, caso reconheça a suspeição, deverá o juiz sustar a marcha procedimental, mandar juntar aos autos a petição do recusante, com os documentos que a instruem, e, por despacho, se declarar suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto.

#### 2.2.6. NÃO ACEITAÇÃO PELO JUIZ DA OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

Caso não reconheça a suspeição, nos termos do art. 100, *caput*, do CPP, o juiz mandará autuar a petição em apartado, dará sua resposta dentro do prazo de 3 (três) dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e, em seguida, determinará sejam os autos da exceção remetidos, dentro de 24h (vinte e quatro horas), ao Tribunal a que competir o julgamento.

Portanto, caso o juiz não concorde com a exceção de suspeição contra ele oposta, deverá, após apresentar a sua resposta, encaminhar os autos ao Tribunal a que estiver vinculado, sendo esta outra importante diferença entre a exceção de suspeição e as demais, as quais são julgadas pelo próprio juízo de primeira instância.

### 2.2.6.1. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO ACEITA PELO JUIZ

Caso o relator a quem tiver sido distribuída a exceção de suspeição verificar a sua manifesta improcedência, a rejeitará liminarmente, nos termos do art. 100, §2º, do CPP, sendo tal decisão impugnável pela via do agravo regimental (LIMA, 2017, p. 1117).

Sendo reconhecida, preliminarmente, a relevância da arguição, o Tribunal, com citação do excipiente (parte que alega a suspeição) e do excepto (juiz), marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas, seguindo-se o julgamento, independentemente de mais alegações.

Portanto, após a oitiva de eventuais testemunhas, será julgada a exceção, não havendo novas alegações das partes depois da fase instrutória.

#### 2.2.6.1.1. CONSEQUÊNCIAS DO JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PELO TRIBUNAL

Nos termos do art. 101 do CPP, duas consequências poderão advir do julgamento pelo Tribunal da exceção de suspeição não aceita pelo juiz:

I) PROCEDÊNCIA: se o pedido for julgado procedente, ficarão nulos os atos do processo principal, pagando o juiz as custas, no caso de erro inescusável;

Importa destacar que a nulidade referida atingirá os atos praticados pelo juiz depois do surgimento da suspeição, sendo irrelevante, para tal finalidade, o momento no qual tal vício foi revelado.

Assim, se o juiz é amigo íntimo ou inimigo capital do réu, refaz-se o processo desde o princípio, já que tal causa de suspeição, prevista no art. 254, inciso I, do CPP, é anterior ao próprio processo. Por outro lado, caso o juiz, na audiência de instrução e julgamento, tenha aconselhado o Ministério Público (art. 254, inciso IV, CPP), os atos praticados antes desse fato não serão atingidos pela mácula da nulidade.

Também é interessante registrar que, caso o erro do juiz seja inescusável, isto é, tendo ele totais condições de verificar a suspeição (ou o impedimento) aventado pela parte, deverá o magistrado arcar com as custas processuais, já que, em decorrência de seu erro, foram praticados atos processuais que deverão ser refeitos. Havendo nítida má-fé do magistrado, abre-se a possibilidade de sua punição disciplinar (NUCCI, 2016, p. 252).

II) IMPROCEDÊNCIA: no caso do pedido ser julgado improcedente, sendo evidenciada a malícia do excipiente, a este será imposta uma multa.

Ademais, embora o art. 101 do CPP seja omissivo quanto ao ponto, entende-se que também será imposta ao excipiente, no caso de ser evidenciada a sua malícia, a obrigação de arcar com as custas processuais, já que, nos termos do art. 804 do CPP, "a sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido". (LIMA, 2017, p. 1117.)

Ainda sobre a malícia do excipiente, registra-se que este também poderá ser responsabilizado criminalmente por delito contra a honra (NUCCI, 2016, p. 252).

### 2.2.7. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL

Conforme será estudado adiante, à luz do art. 111 do CPP, a oposição das exceções, via de regra, não suspende o curso do processo principal.

Todavia, no caso da exceção de suspeição, dispõe o art. 102 do CPP que, se a parte contrária reconhecer a procedência da arguição, poderá, a seu requerimento, ser sustado o andamento do processo principal, até que se julgue o incidente da suspeição.

Assenta-se que, embora não haja disposição legal quanto ao ponto, é interessante que a parte contrária do processo principal seja intimada a se manifestar em relação à arguição de

suspeição do juízo. Isto é: ainda que não exista previsão legal para tanto, é salutar que o juiz intime a parte que não opôs à exceção de suspeição para que se manifeste quanto a ela.

Nesse contexto, se a parte que não a arguiu concordar com os fundamentos da parte que a arguiu e requerer o sobrestamento do processo principal, é de todo prudente que isso ocorra, porquanto, ao fim e ao cabo, ambas as partes estão entendendo pela suspeição do magistrado, sendo evidente que, muito provavelmente, o julgador a quem fora distribuído aquele processo é, de fato, suspeito.

## 2.2.8. RECURSOS CABÍVEIS

Dispõe o art. 581, inciso III, do CPP, que caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição.

Assim, salvo a de suspeição, a procedência das demais exceções é impugnável pela via do recurso em sentido estrito.

Tal distinção entre a exceção de suspeição e as demais se justifica pelo fato da primeira ser a única julgada pelo Tribunal, razão pela qual não há falar em recurso em sentido estrito, que é recurso cabível exclusivamente contra decisão de primeira instância.

Como visto acima, se o juiz de primeira instância reconhecer a suspeição, deverá encaminhar os autos ao substituto legal, não havendo recurso contra tal decisão.

Noutro giro, se o juiz de primeira instância não aceitar a suspeição, após sua defesa, encaminhará os autos ao Tribunal, que julgará procedente ou improcedente a exceção, não sendo cabível RESE contra tal decisão de segunda instância.

Superada a análise do não cabimento de RESE, entende-se que, "presentes seus pressupostos legais, é plenamente possível a interposição dos recursos extraordinários (RE e REsp), sem prejuízo da utilização dos *writs* constitucionais do *habeas corpus* e do mandado de segurança" (LIMA, 2017, p. 1118).

## 2.3. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PERANTE TRIBUNAIS

### 2.3.1. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Assim como ocorre em relação aos juízes de primeira instância, os Desembargadores dos Tribunais de segunda instância e os Ministros dos Tribunais Superiores "também devem se declarar suspeitos de ofício, ou espontaneamente acolher a arguição de suspeição interposta pela parte, ficando a cargo do regimento interno a determinação de quem será o substituto legal" (LIMA, 2017, p. 1118).

Nos termos do art. 103, *caput*, do CPP, se o relator tiver de se declarar suspeito, este exporá seus motivos nos autos e os apresentará em mesa para nova distribuição. Se a suspeição tiver de ser reconhecida pelo revisor, este a declarará nos autos e passará o feito ao seu substituto na ordem da preferência, cabendo ao regimento interno definir quem é o substituto legal.

Se o terceiro juiz ou vogal, isto é, aquele que não é nem relator nem revisor, tiver de se dar por suspeito, deverá fazê-lo verbalmente, na sessão de julgamento, registrando-se na ata a declaração, nos termos do art. 103, §1º, do CPP.

Caso o próprio presidente do Tribunal se der por suspeito, competirá ao seu substituto (via de regra, o vice-presidente) designar dia para o julgamento e presidi-lo, conforme art. 103, §2º, do CPP.

### 2.3.2. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PELAS PARTES

Se a parte opor exceção de suspeição em desfavor de Desembargador ou Ministro, deverá ser observado, no que lhe for aplicável, o rito previsto nos arts. 98 a 101 do CPP, conforme

disposição trazida pelo art. 103, §3º, do mesmo Código, sendo possível que os respectivos regimentos internos tragam regramentos específicos quanto à temática.

Caso o Desembargador ou Ministro não reconheça a suspeição alegada pela parte, a exceção será julgada pelo tribunal pleno, funcionando como relator o presidente, conforme art. 103, §4º, do CPP.

Se a exceção não aceita tiver sido oposta em desfavor do próprio presidente do Tribunal, funcionará como relator o vice-presidente, em atendimento ao disposto no art. 103, §5º, do CPP.

#### **2.4. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

Da mesma forma como ocorre em relação aos membros do Poder Judiciário, "o órgão do ministério público também deve se declarar suspeito espontaneamente, fazendo-o perante o juiz do processo, hipótese em que os autos serão remetidos ao órgão ministerial substituto" (LIMA, 2017, p. 1118).

Caso o membro do Ministério Público não se declare suspeito, a parte poderá arguir a sua suspeição, devendo, para tanto, expor seus motivos em petição escrita, nos termos do art. 98 do CPP, salvo no rito do Tribunal do Júri, no qual a arguição deverá ser feita oralmente (LIMA, 2017, p. 1118).

Sendo oposta a exceção pela parte, o membro do Ministério Público será ouvido pela autoridade judiciária perante a qual atue. Caso o membro do Ministério Público reconheça a suspeição levantada pela parte contrária, os autos serão encaminhados a seu substituto legal (LIMA, 2017, p. 1118).

Se "o órgão ministerial não reconhecer a procedência da arguição, deverá apresentar sua resposta em até 3 (três) dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas", competindo à própria autoridade judiciária perante a qual atue o membro do Ministério Público recusado julgar a exceção, não cabendo recurso contra tal decisão, nos termos do art. 104 do CPP.

Assim, para fins de concursos públicos, é muito importante frisar três pontos em relação à exceção de suspeição de membro do Ministério Público: I) a exceção será julgada pela própria autoridade judiciária perante a qual atue o membro do Ministério Público recusado; II) o membro recusado será ouvido e poderá apresentar suas provas; e III) a decisão da autoridade judiciária é irrecorrível.

No que diz respeito à irrecorribilidade da decisão da autoridade judiciária, a doutrina entende que "é cabível a impetração de mandado de segurança, a fim de se resguardar o direito líquido e certo do órgão ministerial afastado de atuar em determinado feito, consectário lógico da garantia da inamovibilidade (CF, art. 128, § 5º, I, "b")" (LIMA, 2017, p. 1118).

Por fim, assenta-se que, ao contrário do que ocorre em relação ao juiz, entende-se que o vício decorrente da suspeição de membro do Ministério Público acarreta, tão somente, nulidade relativa do ato (LIMA, 2017, p. 1118).

#### **2.5. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE SERVENTUÁRIOS, DE FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA, PERITOS E INTÉRPRETES**

Conforme art. 105 do CPP, as partes poderão também arguir de suspeitos os peritos, os intérpretes e os serventuários ou funcionários de justiça, decidindo o juiz de plano e sem recurso, à vista da matéria alegada e prova imediata.

No ponto, é muito importante ressaltar a impossibilidade de dilação probatória. Assim, ao contrário do que ocorre em relação à exceção de suspeição de membro do Ministério Público, no que diz respeito aos peritos, intérpretes e serventuários ou funcionários de justiça, não há falar na oitiva de tais atores processuais, já que o juiz decide de plano.

Tal como ocorre em relação à exceção de suspeição de membro do Ministério Público, não há recurso legalmente previsto para se impugnar a decisão da autoridade judiciária, sendo



possível, entretanto, que, "se a parte lograr êxito em comprovar o prejuízo daí decorrente, nada impede que eventual nulidade relativa seja reconhecida em preliminar de futura apelação" (LIMA, 2017, p. 1120).

## 2.6. SUSPEIÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA

De acordo com a redação do art. 107 do CPP, não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas, quando ocorrer motivo legal.

Assim, não há falar em oposição de exceção de suspeição em relação às autoridades de polícia judiciária.

Todavia, se a própria autoridade policial perceber que está incurso em uma das causas de suspeição, previstas no art. 254 do CPP, deverá se declarar suspeita.

## 3. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA (ARTS. 108 E 109, CPP)

### 3.1. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE RELATIVA

Conforme art. 109 do CPP, se, em qualquer fase do processo, o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior.

Assim, diferentemente do que ocorre no Processo Civil, aqui no Processo Penal é dado ao juiz reconhecer de ofício tanto a incompetência absoluta como a relativa, não se aplicando, pois, a Súmula nº 33 do STJ (AVENA, 2017, p. 248).

Portanto, sendo a matéria apreciável de ofício, "o fato de a parte arguir a incompetência sem o fazê-lo por meio da oposição de uma exceção, quer o faça no bojo da resposta à acusação (CPP, art. 396-A), quer o faça em sede de memoriais (CPP, art. 403, § 3º), não impede que o magistrado conheça e aprecie a preliminar" (LIMA, 2017, p. 339).

No entanto, se a incompetência for do tipo relativa (ex.: territorial) e a parte não argui-la no momento oportuno, isto é, em sua primeira manifestação no processo (seja em preliminar da resposta à acusação, seja por intermédio de exceção de incompetência), haverá a incidência do fenômeno da preclusão, não podendo mais ser alegada pela parte.

#### 3.1.1. MOMENTO LIMÍTROFE PARA QUE O JUIZ RECONHEÇA A INCOMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO

Como visto, no processo penal, o juiz pode reconhecer de ofício tanto a incompetência absoluta quanto a incompetência relativa.

No que diz respeito à incompetência absoluta, tendo em vista a ocorrência de nulidade do tipo absoluta, esta pode ser reconhecida a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria.

O juiz de primeira instância poderá reconhecer a incompetência absoluta até a prolação da sentença, ato no qual se encerra o exercício de sua jurisdição perante aquele processo, podendo a incompetência absoluta, após isso, ser suscitada e/ou reconhecida pelas instâncias recursais e/ou superiores.

Em relação à incompetência relativa, discute a doutrina qual seria o momento limítrofe para que esta seja reconhecida pelo juiz de ofício.

Conforme será estudado adiante, o CPP, em seu art. 108, *caput*, foi expresso ao afirmar que a incompetência relativa deve ser alegada pela parte até o momento da apresentação da resposta à acusação, sob pena de preclusão. Todavia, o CPP não regulamentou expressamente até que momento o juiz poderia reconhecer a incompetência relativa de ofício.



Uma primeira corrente doutrinária, que sempre prevaleceu, aduz "que o juiz poderia declinar de ofício de sua incompetência relativa até o momento da sentença, pois, uma vez proferida sua decisão, teria esgotado sua jurisdição no caso concreto" (LIMA, 2019, p. 356).

Com o advento do princípio da identidade física do juiz, uma segunda corrente, com fulcro no art. 399, §2º, do CPP, diz que o magistrado de primeira instância somente pode reconhecer a incompetência relativa até o início da instrução criminal. Após isso, haveria a preclusão da matéria, inclusive para o magistrado (LIMA, 2019, p. 356).

Uma terceira parcela da doutrina restringe um pouco mais o limite temporal para o reconhecimento de ofício da incompetência relativa, afirmando que o juiz tem até a fase do julgamento antecipado do mérito para reconhecê-la. Assim, para esta parcela da doutrina, até a decisão de que trata o art. 397 do CPP (possibilidade de absolvição sumária), o juiz pode reconhecer a incompetência relativa de ofício. Após isso, opera-se a preclusão (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 525).

### 3.2. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PELA PARTE

Não sendo a incompetência reconhecida de ofício pelo juiz, dispõe o art. 108, *caput*, do CPP, que a exceção de incompetência do juízo, que tem natureza dilatória, poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa.

Muita atenção à literalidade do dispositivo acima transcrito, já que ele exige que a exceção de incompetência seja oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa. Assim, em provas objetivas, o candidato deve ter muita atenção em relação ao momento processual adequado para a oposição da exceção de incompetência, que, como dito, tem como marco legal o prazo de defesa.

Tal ponto pode gerar muita confusão em relação às espécies de incompetência, já que não há prazo para se arguir a incompetência do tipo absoluta. É dizer: se o item de sua prova somente transcrever o art. 108, *caput*, do CPP, e disser que a exceção de incompetência (sem diferenciar qual tipo de incompetência) deve ser oposta no prazo de defesa, gabarita como correta, já que se trata de literalidade normativa.

Noutro giro, se a questão não estiver cobrando somente a literalidade normativa, deve ser lembrado que a incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria.

Após as alterações insertas no CPP pela Lei nº 11.719/08, o "prazo de defesa" a que se refere o art. 108, *caput*, do CPP, deve ser entendido como o prazo para a resposta à acusação, que deve ser apresentada em até 10 (dez) dias após a regular citação, nos termos do art. 396, *caput*, do CPP.

Embora exista alguma divergência doutrinária quanto ao ponto, entende-se que, diferentemente do "processo civil, a exceção de incompetência pode veicular tanto a incompetência absoluta quanto a relativa" (LIMA, 2017, p. 1122).

Deve ser lembrado que, conforme exposto no tópico acima, como o juiz pode conhecer de ofício de ambas as espécies de incompetência, poderá reconhecê-las, ainda que a parte as tenha alegado sem se valer da exceção propriamente dita.

Nos termos do art. 108, §1º, do CPP, se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá.

Em relação ao citado parágrafo, dois aspectos merecem bastante atenção, a saber:

I) NECESSIDADE DE OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO: sendo a exceção oposta pela defesa, exige o art. 108, §1º, do CPP, que haja a oitiva do Ministério Público, devendo o juiz, antes de decidir o pleito, encaminhar os autos ao órgão ministerial; e

II) ENVIO DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE E POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS ANTERIORES: no que diz respeito à possibilidade de ratificação ou não dos atos anteriormente praticados, o aluno





deve ler tal dispositivo legal em conjunto com o art. 567 do CPP, podendo ser cobrada a própria literalidade dos mencionados artigos ou a sua interpretação doutrinária/jurisprudencial.

Nesse sentido, conforme será visto no capítulo atinente às nulidades, aduz o art. 567 do CPP que "a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente".

Muitas das questões cobram somente a literalidade do artigo, devendo o candidato ter em mente que o legislador não especificou a qual espécie de incompetência ele se referia, isto é, se absoluta ou relativa.

Outras questões fazem uma digressão doutrinária/jurisprudencial um pouco mais aprofundada, que, ao fim e ao cabo, pelo menos para a maioria da doutrina, aproxima-se da literalidade do artigo. Elucida-se.

Parcela minoritária da doutrina divide o art. 567 do CPP em consequências advindas da nulidade absoluta e consequências oriundas da nulidade relativa, diferenciando-as. Para eles, no caso das nulidades do tipo absoluta, tanto os atos instrutórios quanto os decisórios deverão ser anulados, isto é, nada do que foi produzido perante o juízo absolutamente incompetente será aproveitado. Em relação às nulidades relativas, essa parcela da doutrina entende que somente haverá a necessidade de anular os atos decisórios, podendo haver simples ratificação dos atos instrutórios. Isto é, no caso de nulidade relativa, devem ser refeitos, perante o juízo competente, apenas os decisórios, já que os instrutórios podem ser simplesmente ratificados (não necessitam ser refeitos).

A doutrina majoritária rechaça essa diferenciação, apegando-se à literalidade da norma. Para eles, pouco importa se a nulidade é do tipo absoluta ou relativa. Somente haverá necessidade de repetição dos atos decisórios, podendo ocorrer a simples ratificação dos instrutórios, não havendo falar na necessidade de repetição desses últimos perante o juízo competente.

Afastando-se de ambas as correntes, e até mesmo da literalidade do artigo, o STF, a partir do julgamento do HC nº 83.006/SP, de relatoria da Min. Ellen Gracie, passou a entender que, mesmo no caso de incompetência absoluta, poderá haver a simples ratificação dos atos decisórios, que, por essa razão, não precisariam ser repetidos perante o juízo competente.

Diante de tudo isso, o candidato deve se atentar ao comando da questão, verificando se lhe está sendo cobrado o texto da lei, o entendimento da doutrina ou do STF, devendo, no caso de provas dissertativas, ser demonstrado o conhecimento de todas elas.

Não sendo reconhecida a incompetência do juízo, o juiz continuará no feito, fazendo tomar por termo a declinatória, se formulada verbalmente, nos termos do art. 108, §2º, do CPP.

### 3.3. RECURSOS CABÍVEIS

Se o juiz disser que o juízo perante o qual atua é incompetente, isto é, reconheça de ofício a incompetência ou julgue procedente a exceção de incompetência, contra tal decisão caberá recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, inciso II, do CPP.

Em contrapartida, se o juiz assentar a competência do juízo perante o qual atue, isto é, julgar improcedente a exceção de incompetência, não há recurso legalmente previsto para se impugnar tal decisão, "o que, no entanto, não impede que a questão seja novamente ventilada em *habeas corpus* (ou mandado de segurança, caso não haja risco à liberdade de locomoção), ou em preliminar de futura e eventual apelação" (LIMA, 2017, p. 1123).

## 4. EXCEÇÃO DE ILEGITIMIDADE

### 4.1. LEGITIMIDADE AD CAUSAM E AD PROCESSUM

A legitimidade *ad causam*, também chamada de legitimidade para agir, "é a pertinência subjetiva da ação", sendo, pois, "a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito

propor a demanda judicial e a um determinado sujeito ocupar o polo passivo dessa mesma demanda", sendo ela uma das condições da ação penal (LIMA, 2017, p. 1124).

Assim, pela legitimidade *ad causam*, verifica-se, por exemplo, se quem propôs a ação penal poderia figurar no polo ativo daquela demanda.

Nesse contexto, sendo verificado, por exemplo, que o Ministério Público denunciou Fulano por suposta prática de crime de injúria simples, nos termos do art. 140, *caput*, do CP, falta ao órgão ministerial legitimidade para agir ou legitimidade *ad causam*, isto é, não poderia o Ministério Público figurar no polo ativo daquela demanda, devendo a peça acusatória ser rejeitada pelo juiz, nos termos do art. 395, inciso II, do CPP.

Em contrapartida, a legitimidade *ad processum* é "fenômeno relacionado à capacidade de estar em juízo, tida como pressuposto processual de validade", referindo-se, nesse sentido, "à capacidade de exercer direitos e deveres processuais, ou seja, de praticar validamente atos processuais" (LIMA, 2017, p. 1124-1125).

Por exemplo, não tem legitimidade *ad processum* a vítima "menor de 18 (dezoito) anos, que não tem capacidade processual para oferecer queixa-crime, razão pela qual sua incapacidade é suprida por seu representante legal" (LIMA, 2017, p. 1125).

Portanto, a legitimidade *ad causam* diz respeito à análise casuística da pertinência subjetiva de determinado sujeito em relação a uma demanda específica.

Noutro giro, a legitimidade *ad processum* tem relação com a possibilidade de determinado sujeito praticar atos processuais em todo e qualquer processo, isto é, diz respeito "à capacidade de estar ou integrar validamente uma relação processual, em qualquer processo" (AVENA, 2017, p. 163).

#### 4.1.1. CLASSIFICAÇÃO DA EXCEÇÃO DE ILEGITIMIDADE QUANTO AOS SEUS EFEITOS

No caso da ilegitimidade *ad causam*, a exceção de ilegitimidade terá natureza peremptória, já que aquela ação penal instaurada deverá ser extinta, porquanto ao menos um de seus polos está ocupado por quem não tem pertinência subjetiva com a demanda, havendo nulidade absoluta dos atos praticados.

Por outro lado, em se tratando de ilegitimidade *ad processum*, a exceção de ilegitimidade terá natureza dilatória, porquanto, nos termos do art. 568 do CPP, a nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais, havendo, tão somente, nulidade relativa de tais atos, não sendo necessária a extinção do processo.

#### 4.2. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE ILEGITIMIDADE

Caso o juiz não reconheça de ofício a ilegitimidade, a parte poderá alegá-la, seguindo a exceção de ilegitimidade o mesmo rito previsto para a de incompetência, nos termos do art. 110, *caput*, do CPP.

Conforme será visto com mais detalhes no capítulo atinente às nulidades, verificando-se a ilegitimidade *ad causam*, ocorrerá nulidade do tipo absoluta, havendo presunção de prejuízo, devendo o processo ser anulado desde o seu início. Nesse caso, se ainda não tiver ocorrido a extinção da punibilidade do agente, "é plenamente possível que a parte legítima ofereça nova peça acusatória" (LIMA, 2017, p. 1125).

Nesse sentido, diferentemente do que ocorre com a exceção de incompetência relativa, que deve ser alegada pela parte no prazo de defesa, a exceção de ilegitimidade *ad causam* poderá ser alegada a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria.

Em contrapartida, a ilegitimidade *ad processum* acarreta, no máximo, nulidade relativa, podendo o vício referente à representação processual ser sanado a todo tempo, mediante ratificação



dos atos processuais, nos termos do art. 568 do CPP, que não é aplicável à ilegitimidade *ad causam*, já que esta gera nulidade absoluta, nos termos acima estudados.

Portanto, assim como ocorre com a exceção de incompetência relativa, a exceção de ilegitimidade *ad processum* deve ser arguida pela parte no prazo de defesa, isto é, logo na resposta à acusação, sob pena de preclusão, já que se trata de nulidade do tipo relativa.

#### 4.3. RECURSOS CABÍVEIS

No rito comum ordinário e sumário, nos termos do art. 581, inciso I, do CPP, caso o juiz rejeite a peça acusatória por ilegitimidade de parte, caberá recurso em sentido estrito. Se estivermos no rito sumaríssimo, tendo o juiz rejeitado a peça acusatória em razão da ilegitimidade de parte, contra tal decisão caberá apelação, nos termos do art. 82, *caput*, da Lei nº 9.099/95.

Caso o juiz julgue procedente a exceção de ilegitimidade, isto é, reconheça a ilegitimidade *ad causam* ou *ad processum* de qualquer das partes, caberá recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, inciso III, do CPP.

Em contrapartida, se o juiz julgar improcedente a exceção de ilegitimidade, ou seja, não reconhecer a ilegitimidade *ad causam* ou *ad processum* de qualquer das partes, não há recurso legalmente previsto para se impugnar tal decisão, o que não impede, entretanto, "que a matéria seja ventilada em preliminar de futura e eventual apelação, sem prejuízo da utilização dos remédios constitucionais do *habeas corpus* e do mandado de segurança" (LIMA, 2017, p. 1125).

### 5. EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA

#### 5.1. DISPOSIÇÕES GERAIS

A exceção de litispendência, que é do tipo peremptória, é "cabível na hipótese de tramitarem, no mesmo juízo ou em juízos diversos, duas ou mais ações contra o mesmo réu, envolvendo o mesmo fato", sendo ela oponível, portanto, "quando houver ações penais idênticas em andamento" (AVENA, 2017, p. 249).

Assim, "no processo penal, a litispendência ocorre quando um mesmo acusado encontra-se respondendo a dois processos penais condenatórios distintos, porém relacionados à mesma imputação" (LIMA, 2017, p. 1125).

Diferentemente do que ocorre no processo civil, aqui no processo penal, para fins de verificação de litispendência, basta que haja identidade no polo passivo da demanda (réu) e na imputação, pouco importando o polo ativo da ação penal. É dizer: se, em decorrência do mesmo fato, o Ministério Público ingressa com uma ação penal pública e o querelante ajuíza uma ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, estará verificada a litispendência (LIMA, 2017, p. 1125).

Outra diferença importante em relação ao processo civil é que, no processo penal, a litispendência já estará verificada com o recebimento da nova peça acusatória, não sendo necessária, ao contrário do que ocorre no processo civil, a ocorrência de citação válida (LIMA, 2017, p. 1125).

#### 5.2. IMPOSSIBILIDADE DE EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA EM RAZÃO DE INQUÉRITO POLICIAL

Não há falar em exceção de litispendência no caso de dois ou mais inquéritos policiais terem sido instaurados em desfavor do mesmo investigado em razão de idênticos fatos, já que tal instituto é restrito à tramitação de duas ações penais em tais circunstâncias.

Assim, se uma determinada delegacia de polícia municipal instaura um inquérito policial para investigar um crime que lá ocorreu e uma delegacia especializada da capital daquele Estado também instaura inquérito para investigar aquele sujeito pelo mesmo fato, não há falar em litispendência, já que não existem duas ações penais em curso.

Nesse caso, "a solução a ser adotada pelo investigado apenas poderá ser a impetração de *habeas corpus* ou de mandado de segurança, conforme seja ou não o crime investigado punido

com prisão (Súmula nº 693 do STF)", a fim de que um dos inquiridos seja trancado, "em face do constrangimento ilegal decorrente da dupla investigação policial acerca da mesma conduta" (AVENA, 2017, p. 249).

### 5.3. PROCEDIMENTO DA EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA

Nos termos do art. 110, *caput*, do CPP, a exceção de litispendência, no que lhe for aplicável, deve seguir o mesmo rito da exceção de incompetência, sendo bastante importante diferenciar a exceção de litispendência da exceção de incompetência relativa, no que tange ao momento processual adequado para sua alegação.

Como visto, a exceção de incompetência relativa deve ser arguida pela parte no prazo de defesa, isto é, logo na resposta à acusação, sob pena de preclusão, já que se trata de nulidade do tipo relativa.

Noutro giro, sendo a nulidade advinda da litispendência do tipo absoluta, não há falar em preclusão temporal, podendo haver a sua alegação a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria.

### 5.4. CRITÉRIOS PARA SE DETERMINAR QUAL AÇÃO PENAL SERÁ EXTINTA

De acordo com a doutrina, dois são os critérios adotados para se determinar qual ação penal deverá ser extinta (LIMA, 2017, p. 1126):

I) PREVENÇÃO: se um dos juízes se tornou prevento em relação aos demais, já que, por exemplo, durante a investigação policial, decretou uma medida cautelar do tipo prisional, ele deverá julgar o caso, sendo irrelevante a data de distribuição das demais ações penais. É dizer: se um juiz se tornou prevento em primeiro lugar, a ele competirá o julgamento daquela imputação, pouco importando a data de distribuição das demais ações penais; e

II) DISTRIBUIÇÃO: se não ocorreu a prevenção, o critério a ser adotado é a data da distribuição. É dizer: somente tramitará a ação penal que primeiro foi distribuída, devendo haver a extinção de todas as demais.

### 5.5. POSSIBILIDADE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Caso um acusado responda a duas ações penais pelo mesmo fato perante juízos distintos, na hipótese de ambos os juízos se declararem competentes para o julgamento da imputação, "não obstante o reconhecimento da litispendência, a questão deve ser resolvida pela suscitação de um conflito positivo de competência" (LIMA, 2017, p. 1127), que será estudado em capítulo próprio.

### 5.6. RECURSOS CABÍVEIS

Caso o juiz julgue procedente a exceção de litispendência, isto é, reconheça que duas ou mais ações penais tramitam em desfavor do mesmo agente por idêntico fato, caberá recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, inciso III, do CPP.

Em contrapartida, se o juiz julgar improcedente a exceção de litispendência, ou seja, não reconhecer a identidade das ações, não há recurso legalmente previsto para se impugnar tal decisão, o que não impede, entretanto, que a matéria seja "questionada em preliminar de futura e eventual apelação, sem prejuízo da utilização dos remédios constitucionais do *habeas corpus* e do mandado de segurança" (LIMA, 2017, p. 1127).

## 6. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA

### 6.1. DISPOSIÇÕES GERAIS

Trata-se de "exceção de natureza peremptória, que tem seu fundamento remoto na circunstância de que ninguém pode ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato", sendo oponível "quando se encontrar em tramitação processo criminal por fato já decidido em outro processo por sentença transitada em julgado" (AVENA, 2017, p. 251).

De forma semelhante à exceção de litispendência, é cabível a exceção de coisa julgada quando alguém estiver respondendo a um processo criminal por fato que já foi objeto de análise em outra ação penal, sendo que, na exceção de coisa julgada, ao contrário do que ocorre na de litispendência, um dos processos já transitou em julgado, isto é, esgotaram-se todas as vias recursais.

### 6.2. COISA JULGADA FORMAL, MATERIAL E SOBERANAMENTE JULGADA

#### 6.2.1. COISA JULGADA FORMAL

A coisa julgada formal, também chamada de preclusão máxima, é o fenômeno de ordem endoprocessual que impede a revisão da decisão judicial anteriormente prolatada, desde que mantidas as mesmas circunstâncias fáticas, isto é, "não produz nenhum reflexo em relações processuais futuras, ainda que versem sobre o mesmo fato e o mesmo sujeito passivo", não havendo falar em exceção de coisa julgada (AVENA, 2017, p. 252).

Um relevante exemplo de coisa julgada formal ou endoprocessual é encontrado no art. 414 do CPP, segundo o qual, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado, sendo possível, se surgirem novas provas, enquanto não extinta a punibilidade do agente, a formulação de nova denúncia.

Nesse sentido, a decisão de impronúncia somente é imutável enquanto não surgirem novas provas, isto é, se não forem produzidos novos elementos de convicção, não há a possibilidade de sua revisão. Contudo, surgindo novas provas, abre-se caminho para o oferecimento de nova denúncia contra o mesmo sujeito passivo em razão do mesmo fato, não podendo ele opor exceção de coisa julgada.

Assim, se Fulano, em janeiro de 2019, por exemplo, foi impronunciado pelo suposto cometimento de um determinado crime doloso contra a vida, nada impede que, surgindo novas provas, seja ele novamente denunciado pelo mesmo crime em abril de 2021, desde que não tenha se verificado a prescrição da pretensão punitiva estatal.

#### 6.2.2. COISA JULGADA MATERIAL

A coisa julgada material "é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito e, ao contrário da coisa julgada formal, produz reflexos em relações processuais distintas que envolvam o mesmo fato e o mesmo réu", sendo ela oponível por intermédio da exceção de coisa julgada (AVENA, 2017, p. 253).

Logo, enquanto a coisa julgada formal "é a imutabilidade da decisão no processo em que foi proferida, a coisa julgada material projeta-se para fora do processo, tornando a decisão imutável e indiscutível além dos limites do processo em que foi proferida", razão pela qual a decisão gravada pela coisa julgada material "não mais poderá ser alterada ou desconsiderada em qualquer outro processo" (LIMA, 2017, p. 1128).

Assentada a grande diferença entre tais institutos, "não se pode deixar de reconhecer que há relação entre ambos, na medida em que, para que ocorra a coisa julgada material, é necessário, antes, que ocorra a coisa julgada formal, ou seja, a preclusão de todos os recursos possíveis" (AVENA, 2017, p. 253).

Portanto, a coisa julgada material é também coisa julgada formal, contudo, o contrário não é verdadeiro, já que nem toda coisa julgada formal é também material. Nas provas de concurso, o examinador pode se referir à coisa julgada material como "coisa julgada formal e material", o que está correto, sendo esse "seu nome completo".

### 6.2.3. COISA SOBERANAMENTE JULGADA

Como visto, o fenômeno da coisa julgada torna a decisão imutável, seja no âmbito do processo em que foi proferida (coisa julgada formal), seja fora dele (coisa julgada material).

Todavia, no âmbito do processo penal, no que diz respeito à sentença penal condenatória ou absolutória imprópria transitada em julgado, esta imutabilidade é relativa, já que, a qualquer momento, antes ou depois de extinta a pena, mesmo após a morte do condenado ou do absolvido impropriamente, é possível o ajuizamento da revisão criminal, nos termos dos arts. 622 e 623 do CPP.

Noutro giro, em se tratando de sentença absolutória própria ou extintiva da punibilidade transitada em julgado, a imutabilidade é absoluta, porquanto, ainda que surjam novas provas, aquele fato não poderá ser revisto, já que não se admite a revisão criminal *pro societate*, conforme será visto com mais detalhes em capítulo próprio.

Portanto, sendo proferida sentença absolutória própria ou extintiva da punibilidade, diante de sua imutabilidade absoluta, diz-se que a coisa julgada daí advinda é do tipo soberana, já que não poderá ser rescindida.

Conforme será visto em capítulo próprio, as nulidades absolutas podem ser alegadas a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria, já que, via de regra, não estão sujeitas ao fenômeno da preclusão.

Todavia, excepcionando tal regramento, tem-se que, transitando em julgado uma sentença absolutória própria ou extintiva da punibilidade, ainda que, posteriormente, seja descoberta alguma nulidade absoluta, por exemplo, a incompetência absoluta do juízo, nada poderá ser feito, porquanto operou-se a coisa soberanamente julgada.

Em resumo, tem-se que a sentença penal condenatória ou absolutória imprópria com trânsito em julgado faz coisa julgada, podendo ser revista em casos excepcionais. A sentença absolutória própria ou extintiva da punibilidade faz coisa soberanamente julgada, porquanto inadmissível a sua revisão.

## 6.3. LIMITES DA COISA JULGADA

### 6.3.1. LIMITES OBJETIVOS

Os limites objetivos da coisa julgada dizem respeito ao fato da vida que foi imputado ao réu no primeiro processo criminal e objeto de posterior sentença, sendo desimportante a classificação jurídica formulada pelo órgão de acusação (LIMA, 2017, p. 1128).

Assim, o que é atingido pela coisa julgada "é a realidade *histórica* (ocorrida), e não a realidade *imputada* ou descrita na acusação" (PACELLI, 2017, p. 163), não sendo permitida nova acusação diante de alterações periféricas na anterior imputação.

Nesse contexto, imagine a seguinte situação: João é acusado de, no dia 26/07/2020, por volta das 15h, ter subtraído para si um computador de Maria, tendo, por este fato, sido denunciado pelo crime de furto simples (realidade imputada ou descrita na acusação). Na sentença, João foi absolvido, por falta de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Posteriormente, descobriram-se novas provas quanto ao fato, sendo revelado que, em verdade, João havia se utilizado de violência no ato (realidade histórica ou ocorrida). Nesse caso, João não poderá ser novamente acusado, já que o fato da vida (subtração) já foi julgado, pouco importando as alterações periféricas na imputação. Isto é: não importa se, na primeira ação, o órgão de acusação não narrou a violência, porquanto a forma como se deu a subtração (fato da vida) é circunstância periférica.



Pelo exemplo acima, percebe-se que, se o denunciado for absolvido quanto à realidade imputada ou descrita na acusação (no caso, furto), ainda que, posteriormente, seja descoberta a realidade histórica ou ocorrida (roubo), não poderá ele ser novamente acusado pelo mesmo fato da vida, dada a proteção trazida pela coisa julgada material.

Nos termos do art. 110, §2º, do CPP, a exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal, que tiver sido objeto da sentença, não podendo ser utilizada, ao menos em regra, "para questionar a fundamentação da sentença, nem tampouco eventual questão prejudicial devolutiva relativa incidentalmente apreciada pelo juízo penal (CPP, art. 93)" (LIMA, 2017, p. 1130).

#### **6.3.1.1. CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CP)**

Sendo determinado sujeito acusado e condenado por 4 (quatro) crimes de estelionato em continuidade delitiva, mostra-se plenamente possível que este mesmo agente venha a responder por um quinto crime de estelionato descoberto posteriormente, ainda que cometido na mesma série de continuidade delitiva que os anteriores, porquanto tal crime, isoladamente considerado, não foi objeto da imputação contida no primeiro processo, razão pela qual não está protegido pelos limites objetivos da coisa julgada (LIMA, 2017, p. 1130).

No que diz respeito à dosimetria de pena, tem-se que a reprimenda deste quinto estelionato deverá ser aplicada isoladamente, isto é, como se não fizesse parte de uma série de continuidade delitiva. Posteriormente, o juízo das execuções penais, considerando a ficção jurídica atinente ao crime continuado, poderá incluir esse quinto crime na série pela qual o acusado havia sido condenado, unificando as penas (LIMA, 2017, p. 1130).

#### **6.3.1.2. CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70 DO CP)**

Tendo um determinado sujeito, por exemplo, praticado dois crimes em concurso formal (homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), o normal é que ambas as infrações sejam processadas e julgadas em um mesmo processo, tendo em vista a ocorrência do fenômeno da continência (art. 77, inciso II, CPP) (LIMA, 2017, p. 1130).

Nada obstante, se, em um primeiro momento, somente for imputado ao acusado o cometimento do crime de homicídio culposo, eventual condenação quanto a essa imputação não fará coisa julgada em relação ao crime de lesão corporal culposa. É dizer: após a condenação em definitivo do agente pelo crime de homicídio culposo, poderá haver nova denúncia contra ele, dessa vez lhe imputando o segundo resultado de sua conduta (lesão corporal culposa) (AVENA, 2017, p. 256).

Entretanto, considerando que, no concurso formal, o agente alcança dois ou mais resultados com uma única conduta (comissiva ou omissiva), se ele tiver sido absolvido por inexistência do fato (art. 386, inciso I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, inciso IV, CPP), a sentença absolutória quanto ao crime de homicídio culposo fará coisa julgada em relação ao crime de lesão corporal culposa. A razão é simples: se, no concurso formal de crimes, o agente pratica uma conduta e alcança dois ou mais resultados, tendo o juiz reconhecido que não houve conduta (inexistência do fato) ou que o agente não concorreu ou participou para a concretização daquela conduta (negativa de autoria), logicamente, nenhum resultado poderá ser imputado àquele sujeito (LIMA, 2017, p. 1130).

#### **6.3.1.3. CRIMES PERMANENTES**

Em relação aos crimes permanentes, isto é, os crimes cuja consumação se protraí no tempo, duas análises devem ser feitas, já que produzem resultados bem diferentes.

A primeira delas diz respeito ao crime de associação criminosa, nos termos do art. 288, *caput*, do CP. Em tal exemplo, que também serve para as organizações criminosas ou qualquer

vínculo estável e permanente de pessoas para o cometimento de crimes, é possível se visualizar tal situação: Fulano, no dia 7 de novembro de 2020, é denunciado pelo crime do art. 288, *caput*, do CP, já que integra uma determinada associação criminosa constituída com o fim específico de cometer crimes. Ocorre que, mesmo após a denúncia, Fulano continua vinculado àquela associação criminosa. Pergunta-se: poderá haver nova denúncia contra Fulano por integrar a mesma associação criminosa?

De acordo com Renato Brasileiro de Lima, a resposta é positiva, já que, caso o acusado, mesmo após a primeira denúncia, tenha se mantido associado de maneira estável e permanente a outras 2 (duas) pessoas com o objetivo de praticar crimes, esse novo fato delituoso não está protegido pelos limites objetivos da coisa julgada (LIMA, 2017, p. 1130). Por outro lado, o STF, no julgamento do HC nº 103.171/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, analisando o antigo crime de quadrilha ou bando, assentou que não seria cabível a apresentação de sucessivas denúncias.

A segunda análise que deve ser feita em relação aos crimes permanentes diz respeito, por exemplo, ao crime de sequestro (art. 148, CP) cometido no território de diversas comarcas. Nesse caso, "processado e sentenciado o agente por decisão transitada em julgado em uma dessas comarcas, não poderá ser novamente acionado pelo mesmo delito em qualquer outra, em face da coisa julgada material que se operou com o trânsito em julgado da primeira decisão" (AVENA, 2017, p. 256-257).

#### 6.3.1.4. CRIMES HABITUAIS

Para haver a consumação de um crime habitual, como o crime de curandeirismo (art. 284, *caput*, CP), é preciso que o agente pratique determinada conduta de forma reiterada, não havendo falar em consumação delitiva quando do cometimento de somente um ato.

Nesse sentido, um determinado agente somente poderá ser denunciado uma única vez em relação a um mesmo ciclo delitivo. É dizer: se Fulano foi denunciado pelo fato de, no período compreendido entre janeiro de 2019 e dezembro de 2020, ter praticado o curandeirismo, somente poderá responder a um processo penal pelo crime do art. 284, *caput*, do CP.

Todavia, se, após a denúncia, Fulano começar um novo ciclo delitivo, poderá ser, novamente, denunciado por curandeirismo, já que esse novo período de condutas criminosas não está protegido pela coisa julgada material.

#### 6.3.2. LIMITES SUBJETIVOS

A coisa julgada material somente alcança o sujeito que foi processado por determinado fato, não protegendo, em regra, eventuais coautores ou partícipes que não tenham sido denunciados por aquela conduta criminosa.

Imagine a seguinte situação: Fulano é acusado de, em comparsaria com outro agente não identificado, ter cometido um determinado crime no dia 20 de dezembro de 2019, por volta das 21h. Fulano é processado e julgado em definitivo por aquele fato. Após isso, descobre-se quem foi o seu comparsa. Pergunta-se: é possível haver nova denúncia em favor do comparsa de Fulano? Via de regra, sim, já que a coisa julgada formada em relação a Fulano não alcançará o seu comparsa, salvo se Fulano foi absolvido por inexistência do fato (art. 386, inciso I, do CPP) ou por atipicidade da conduta (art. 386, inciso III, do CPP).

Nesse contexto, se Fulano foi condenado ou absolvido por qualquer outra razão, nada impede que seu comparsa seja, posteriormente, denunciado pelo mesmo fato.

Todavia, se o juiz entender que restou provado que o fato não aconteceu, não poderá haver denúncia em desfavor do comparsa de Fulano, porquanto, se o fato não existiu para Fulano, logicamente, não poderá ter existido para seu suposto comparsa.

De igual forma, se a conduta é atípica para Fulano, também deverá ser assim considerada para seu comparsa, pelo menos em regra, porquanto, no que diz respeito à atipicidade material, seus requisitos podem ser objeto de análise subjetiva, isto é, se determinado agente preenche ou não os pressupostos para aplicação do princípio da insignificância.

#### 6.4. EXISTÊNCIA DE DUAS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS

Diante de duas sentenças condenatórias pelo mesmo fato, assentou o STJ, no julgamento do RHC nº 69.586/PA, de relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, que deve prevalecer a que primeiro transitou em julgado, pouco importando a pena aplicada em cada uma delas. É dizer: o critério que será utilizado para se determinar qual sentença prevalecerá é a data do trânsito em julgado e não o *quantum* de pena aplicado em cada sentença condenatória, sendo esse ponto bastante importante para as provas de concurso.

#### 6.5. PROCEDIMENTO DA EXCEÇÃO DE COISA JULGADA

Nos termos do art. 110, *caput*, do CPP, a exceção de coisa julgada, no que lhe for aplicável, deve seguir o mesmo rito da exceção de incompetência, sendo bastante importante diferenciar a exceção de coisa julgada da exceção de incompetência relativa, no que tange ao momento processual adequado para sua alegação.

Como visto, a exceção de incompetência relativa deve ser arguida pela parte no prazo de defesa, isto é, logo na resposta à acusação, sob pena de preclusão, já que se trata de nulidade do tipo relativa.

Noutro giro, sendo absoluta a nulidade advinda da coisa julgada material, não há falar em preclusão temporal, podendo haver a sua alegação a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria.

#### 6.6. RECURSOS CABÍVEIS

Caso o juiz julgue procedente a exceção de coisa julgada, caberá recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, inciso III, do CPP.

Por outro lado, se o juiz a julgar improcedente, não há recurso legalmente previsto para se impugnar tal decisão, o que não impede, entretanto, que a matéria seja "questionada em preliminar de futura e eventual apelação, sem prejuízo da utilização dos remédios constitucionais do *habeas corpus* e do mandado de segurança" (LIMA, 2017, p. 1132).

#### 7. OPOSIÇÃO DE MAIS DE UMA EXCEÇÃO

Dispõe o art. 110, §1º, do CPP, que, caso a parte houver de opor mais de uma exceção, deverá fazê-lo numa só petição ou articulado.

Nesse contexto, se, por exemplo, a parte intentar alegar a incompetência do juízo e a existência de coisa julgada material, deverá opor as duas exceções em uma só petição ou articulado, não devendo protocolar duas petições em separado.

#### 8. PROCESSAMENTO EM APARTADO E NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL

De acordo com o art. 111 do CPP, as exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal. Nesse contexto, são extraídas duas importantes regras quanto ao processamento das exceções:

I) PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS: justamente por não suspenderem o curso do processo principal, as exceções serão processadas em autos apartados, isto é, não correrão nos mesmos autos do processo principal, que, como regra, não será paralisado em decorrência da oposição de alguma exceção;

II) NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL: via de regra, o processo principal não será sobrestado em decorrência da oposição de exceção, conforme expressamente previsto no dispositivo legal em comento.



No entanto, deve ser rememorado que, à luz do art. 102 do CPP, no caso da exceção de suspeição, se a parte contrária reconhecer a procedência da arguição, poderá, a seu requerimento, haver a suspensão do processo principal, até que se julgue o incidente da suspeição.

Logo, a regra é que não haverá a suspensão do processo principal. Contudo, no caso da exceção de suspeição, a depender do reconhecimento da procedência da arguição pela parte contrária, poderá haver o sobrestamento do processo principal, já que, ao fim e ao cabo, as duas partes estão alegando a suspeição do juiz.

## 9. IMPEDIMENTO E INCOMPATIBILIDADE

Para se evitar repetição desnecessária, os conceitos de impedimento e de incompatibilidade serão estudados no capítulo atinente aos sujeitos processuais.

Nesse momento, interessa-nos, tão somente, entender que, à luz do art. 112 do CPP, o magistrado, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguido pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para a exceção de suspeição.

Portanto, principalmente para concursos públicos, no capítulo atinente às exceções, é de suma importância saber que a alegação de incompatibilidade ou impedimento legal de tais atores processuais deverá seguir o rito fixado para a exceção de suspeição.

## 10. CONFLITO DE COMPETÊNCIA

### 10.1. DISPOSIÇÕES GERAIS E ESPÉCIES DE CONFLITO

Nos termos do art. 113 do CPP, ocorre o chamado conflito de competência "quando dois ou mais juízes entendem, para a mesma causa, ser competentes para apreciá-la ou, ainda, quando nenhum juiz a chama para si". Na primeira hipótese, isto é, quando dois ou mais juízes se dizem competentes, há o denominado conflito positivo de competência (art. 114, inciso I, primeira parte, CPP). Na segunda hipótese, isto é, quando nenhum juízo se diz competente, opera-se o conflito negativo de competência (art. 114, inciso I, segunda parte, CPP) (NUCCI, 2016, p. 214).

À luz do art. 114, inciso II, do CPP, também haverá conflito de competência quando surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos, como ocorre, por exemplo, no caso de um juízo determinar o desmembramento de um processo, porquanto entende não estar presente nenhuma hipótese de conexão ou continência. Nesse caso, o juízo que recebeu a parte desmembrada, caso entenda ser necessária a reunião de processos, poderá suscitar conflito negativo de competência. Noutro giro, se um juízo entende exercer força atrativa sobre um processo que tramita em outro juízo, que discorda, isto é, não concorda com a advocatória oriunda do primeiro juízo, poderá suscitar um conflito positivo de competência (LIMA, 2017, p. 1132).

Interessante assentar que o CPP faz uso da expressão "conflito de jurisdição", a qual é bastante criticada pela doutrina pátria, porquanto a jurisdição é una e indivisível, não existindo, portanto, dentro do mesmo Estado soberano, conflito de jurisdição, mas, sim, de competência, que, como visto em capítulo próprio, é medida da jurisdição. O termo "conflito de jurisdição" pode ser usado "quando a mesma demanda for disputada por dois ou mais Estados soberanos", já que, nessa hipótese, de fato, há o exercício de mais de uma jurisdição (LIMA, 2017, p. 1132).

Parcela minoritária da doutrina entende que o "conflito de jurisdição" ocorre quando "existe divergência entre órgãos de jurisdições distintas (exemplos: Justiça Comum e Justiça Federal, Justiça Comum do Estado de Santa Catarina e Justiça Comum do Estado do Paraná)", enquanto que o "conflito de competência" será verificado "quando a divergência surgir entre dois ou mais órgãos da mesma justiça (exemplos: juiz da Comarca de Canoas e juiz da Comarca de São Leopoldo, ambos da Justiça Comum do Estado do Rio Grande do Sul)" (AVENA, 2017, p. 259).

## 10.2. EXISTÊNCIA DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO ANTES DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PENAL

Parcela minoritária da doutrina entende que só há falar em conflito de competência propriamente dito após o início da ação penal, já que, "enquanto a peça acusatória não for oferecida pelo legitimado ativo, teríamos apenas um conflito virtual de competência". Para eles, se, por exemplo, após requerimento do Ministério Público, o juiz, por razões de competência, determinar a remessa dos autos do inquérito policial a outro juízo, este, mesmo entendendo não ser competente, não poderia suscitar conflito negativo de competência, já que ainda não houve a instauração do processo criminal. Nesse caso, diante da impossibilidade de suscitação de conflito de competência, essa parcela da doutrina defende que a questão deverá ser resolvida por intermédio de um conflito de atribuições, que será estudado em tópico próprio (LIMA, 2017, p. 1132-1133).

Para a doutrina majoritária, no entanto, "o conflito de competência pode ser suscitado a qualquer momento, desde que antes do trânsito em julgado das sentenças, sendo de todo irrelevante saber se a peça acusatória já foi oferecida (ou não)", porquanto existe "a possibilidade de intervenção do órgão jurisdicional mesmo antes do oferecimento da peça acusatória, tal como se dá com o deferimento de medidas cautelares" (LIMA, 2017, p. 1133).

Quanto ao ponto, especial atenção deve ser conferida à Súmula nº 59 do STJ, a qual dispõe que "não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes". Nesse caso, se já tiver ocorrido o trânsito em julgado de qualquer das sentenças, a questão deve ser dirimida por intermédio da exceção de coisa julgada (LIMA, 2017, p. 1133).

## 10.3. PROCEDIMENTO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA

### 10.3.1. LEGITIMADOS

De acordo com o art. 115 do CPP, o conflito de competência, seja ele do tipo positivo, seja ele negativo, poderá ser suscitado pela parte interessada (inciso I), pelos órgãos do Ministério Público junto a qualquer dos juízos em dissídio (inciso II) ou por qualquer dos juízes ou tribunais em causa (inciso III).

### 10.3.2. ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Embora não conste expressamente do art. 115 do CPP, parcela da doutrina entende que o assistente de acusação é parte legítima para suscitar um conflito de competência, porquanto, o assistente do Ministério Público, nos termos do inciso I do citado artigo, é parte *interessada* "na prolação de um decreto condenatório válido, validade esta que se encontra diretamente relacionada ao fato de a sentença ter sido proferida por um juízo competente". Além do mais, tendo o assistente de acusação, nos termos do art. 427, *caput*, do CPP, legitimidade "para requerer o desaforamento, hipótese de deslocamento da competência territorial, não há por que não se conferir a ele a possibilidade de suscitar eventual conflito de competência" (LIMA, 2017, p. 1133).

### 10.3.3. RITO PROCEDIMENTAL

Nos termos do art. 116, *caput*, do CPP, os juízes e os tribunais suscitarão o conflito de competência perante o Tribunal competente, sob a forma de representação, na qual darão parte escrita e circunstanciada do conflito, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios. As partes, caso queiram suscitar o conflito, deverão fazê-lo por intermédio de requerimento, no qual exporão, de forma escrita e circunstanciada, os motivos em que se fundam o conflito.



Se o conflito for do tipo negativo, à luz do art. 116, §1º, do CPP, os juízes e tribunais poderão suscitar-lo nos próprios autos do processo, isto é, a marcha procedimental ficará paralisada até que se decida qual o juízo competente para julgar aquela causa.

Caso o conflito seja do tipo positivo, nos termos do art. 116, §2º, do CPP, serão formados autos em apartado, podendo o relator determinar (ou não) a imediata suspensão dos processos em curso.

Valendo-se do art. 955, caput, parte final, do CPC, o relator, em caráter provisório, poderá designar um dos juízes para resolver as questões urgentes.

Conforme art. 116, §3º, do CPP, expedida ou não a ordem de suspensão, o relator requisitará informações às autoridades em conflito, remetendo-lhes cópia do requerimento ou representação, devendo haver a prestação de informações no prazo fixado pelo relator (art. 116, §4º, CPP). De acordo com o art. 116, §5º, do CPP, recebidas as informações, e depois de ouvido o procurador-geral, o conflito será decidido na primeira sessão, salvo se a instrução do feito depender de diligência. Proferida a decisão acerca de qual é o juízo competente, as cópias necessárias serão remetidas, para a sua execução, às autoridades contra as quais tiver sido levantado o conflito ou que o houverem suscitado (art. 116, §6º, CPP). Na decisão do conflito, o tribunal deverá se pronunciar sobre a validade dos atos do juiz incompetente (art. 957, *caput*, parte final, CPC). (LIMA, 2017, p. 1134.)

Importante assentar que, nos termos do art. 955, parágrafo único, do CPC, é dado ao relator decidir de plano o conflito de competência, desde que sua decisão se funde em: I - súmula do STF, do STJ ou do próprio Tribunal; e II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (LIMA, 2017, p. 1134).

Por fim, sustenta a doutrina que é possível que o Tribunal entenda ser competente um terceiro juízo, estranho ao conflito de competência, já que "é possível que nenhuma das autoridades judiciárias em conflito seja realmente competente para o julgamento do feito, mas sim outra, que não chegou a intervir na controvérsia". Nesta hipótese, "o princípio da economia processual justifica seja declarada a sua competência, mesmo que não figurasse inicialmente entre os juízos conflitantes" (LIMA, 2017, p. 1134).

#### 10.3.4. TRIBUNAIS COMPETENTES PARA DIRIMIR OS CONFLITOS

Para se estabelecer qual o órgão jurisdicional competente para dirimir o conflito de competência, duas regras básicas devem ser obedecidas (LIMA, 2017, p. 1134-1135):

I) ONDE HÁ HIERARQUIA JURISDICIONAL, NÃO HAVERÁ CONFLITO DE COMPETÊNCIA: não há conflito de competência: a) entre o STF e o STJ; b) entre o STJ e outros tribunais de segundo grau da justiça ordinária; e c) entre Tribunal e juiz a ele vinculado. É dizer: se há hierarquia jurisdicional, compete ao Tribunal hierarquicamente superior dizer qual é a sua competência, e, conseqüentemente, o que compete ao órgão jurisdicional a ele subordinado; e

II) É O ÓRGÃO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR AOS CONFLITANTES QUEM RESOLVERÁ O CONFLITO: via de regra, para se saber quem resolverá o conflito, deverá se buscar o órgão hierarquicamente superior aos conflitantes.

Por ser bastante elucidativa, colaciona-se, com algumas alterações pontuais, tabela extraída da obra do Professor Norberto Avena, na qual são relacionados os órgãos conflitantes e os respectivos juízos responsáveis pela resolução daquele conflito. Confira-se (AVENA, 2017, p. 261-264):

| ÓRGÃOS CONFLITANTES                                                                                                                                                                                       | ÓRGÃO COMPETENTE PARA RESOLUÇÃO                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Conflitos entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer outros tribunais (exceto o STF).<br/><i>Exemplo</i>: conflito entre o STJ e o STM ou entre o</li> </ul> | Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, <i>o</i> , da CF) |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>STJ e o Tribunal de Justiça de Pernambuco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conflitos entre Tribunais Superiores (exceto o STF) e qualquer outro tribunal. <i>Exemplo</i>: conflito entre o STM e o Tribunal de Justiça de São Paulo.</li> <li>• Conflito entre Tribunais Superiores (exceto o STF). <i>Exemplo</i>: conflito entre o STM e o TSE.</li> </ul> <p>Observação: Por Tribunais Superiores compreendem-se o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Superior do Trabalho. Embora o STF também seja um Tribunal Superior, exclui-se da regra em exame, pois eventuais conflitos envolvendo-o são resolvidos pela advocatória.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conflitos envolvendo quaisquer tribunais, exceto os referidos no item supra. <i>Exemplo</i>: conflito entre os Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.</li> <li>• Conflitos envolvendo tribunal e juízes a ele não vinculados. <i>Exemplo</i>: conflito entre Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e Turma Recursal do Juizado Especial Criminal do mesmo Estado. Observe-se que a Turma Recursal do JEC não se vincula a Tribunal de Justiça, até porque este último não é grau recursal do primeiro.</li> <li>• Conflitos entre juízes vinculados a tribunais diversos. <i>Exemplos</i>: conflito entre Juiz Federal vinculado ao TRF da 1.ª Região e Juiz Federal vinculado ao TRF da 4.ª Região e conflito entre Juiz Federal vinculado ao TRF da 1.ª Região e Juiz Estadual investido na jurisdição federal da 4.ª Região. Neste último caso, se houver conflito entre juiz federal vinculado a Tribunal Regional Federal de uma região e juiz estadual que, investido da jurisdição federal, esteja vinculado a Tribunal Regional Federal de outra região, a competência para julgar o conflito será do STJ, não incidindo a Súmula 3 desse Tribunal.</li> </ul> | Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, d, da CF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conflitos entre juízes federais vinculados ao mesmo Tribunal Regional Federal. <i>Exemplo</i>: conflito entre Juiz Federal da 2.ª Vara e Juiz Federal da 3.ª Vara, ambos vinculados ao Tribunal Regional Federal da 4.ª Região.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tribunais Regionais Federais (art. 108, I, e, da CF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conflito entre juiz federal e juiz estadual investido na jurisdição federal na mesma região da Justiça Federal. A hipótese tem pertinência com a exegese da Súmula 3 do STJ, dispondo que “compete ao tribunal regional federal dirimir conflito de competência verificado, na respectiva região, entre juiz federal e juiz estadual investido de jurisdição federal”.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Tribunais Regionais Federais (Súmula 3, STJ)</p> <p>Observação: como dito acima, para falar na incidência da Súmula nº 3 do STJ, é preciso que o conflito se dê entre um juiz federal e um juiz estadual investido de jurisdição federal naquela região da Justiça Federal. Exemplo: juiz federal da 1ª região e juiz estadual investido de jurisdição federal na 1ª região da Justiça Federal. Nesse caso, o conflito será dirimido pelo TRF da 1ª região.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conflitos entre juízes estaduais vinculados ao mesmo Tribunal de Justiça. <i>Exemplo</i>: conflito entre Juiz Estadual de Jacareí e Juiz Estadual de</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tribunais de Justiça Estaduais (art. 101 da LC 35/1979)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guaratinguetá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Conflitos entre juiz do juízo comum e juiz do juizado especial criminal vinculados ao mesmo Tribunal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | <p>Tribunais de Justiça dos Estados, no âmbito da justiça estadual; e dos Tribunais Regionais Federais, no âmbito da justiça federal. (O STJ, no julgamento do CC 107.635/PR, em 17.03.2010, cancelou a Súmula 348 que dispunha sobre a competência do STJ para dirimir tais conflitos).</p> <p>Observação: se o conflito envolver juiz do juízo comum e juiz do juizado especial criminal vinculados a Tribunais diversos, deverá ser dirimido pelo STJ (art. 105, I, d, da CF)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Conflitos entre juízes eleitorais do mesmo Estado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       | Tribunais Regionais Eleitorais (art. 29, I, b, do Código Eleitoral)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Conflitos entre Tribunais Regionais Eleitorais de Estados diferentes.</li> <li>Conflitos entre juízes eleitorais de Estados diferentes.</li> </ul>                                                                                                                                                                  | <p>Tribunal Superior Eleitoral (art. 22, I, b, do Código Eleitoral)</p> <p>Observação: se o conflito envolver "um juiz eleitoral e um juiz federal (ou estadual), a competência para apreciá-lo será do Superior Tribunal de Justiça, haja vista tratar-se de juízes vinculados a tribunais diversos" (LIMA, 2017, p. 1138).</p>                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Impasses envolvendo o Supremo Tribunal Federal e qualquer outro Tribunal.</li> </ul> <p>Observação: Não é admissível conflito entre o STF e qualquer outro Tribunal, pois inexistente um órgão superior ao Pretório Excelso para solucioná-lo. A questão resolve-se, então, pela advocatória (art. 117 do CPP).</p> | Não se estabelece conflito nesse caso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 10.3.4.1. AVOCATÓRIA

Nos termos do art. 117 do CPP, "o Supremo Tribunal Federal, mediante advocatória, restabelecerá a sua jurisdição, sempre que exercida por qualquer dos juízes ou tribunais inferiores".

Assim, "se o STF considerar-se competente para deliberar sobre processo que tramita em instância inferior (juízos de 1ª Instância ou Tribunais), poderá avocá-lo, ou seja, trazer para si a decisão sobre a demanda", justificando-se tal procedimento "pelo fato de que não existe um órgão superior que possa resolver eventuais conflitos envolvendo o STF" (AVENA, 2017, p. 261).

Apesar de não constar expressamente do mencionado dispositivo legal, "há forte entendimento no sentido de que a faculdade de avocar, além do STF, estende-se igualmente ao STJ em relação a processos de sua competência originária" (AVENA, 2017, p. 261).

### 11. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O conflito de atribuições no âmbito do Ministério Público é a divergência estabelecida entre membros do Ministério Público sobre a responsabilidade ativa para a persecução penal, em razão da matéria ou das regras processuais que definem a distribuição das atribuições ministeriais, a partir do cometimento de fato supostamente definido como crime (LIMA, 2017, p. 1138).

Importante assentar que, caso a investigação criminal já esteja em tramitação perante o Poder Judiciário, não há falar em conflito de atribuições, mas, sim, em conflito de competência, que foi estudado no tópico acima.

É dizer: se o procedimento investigatório tramitar somente perante o Ministério Público e houver divergência entre os órgãos ministeriais acerca da responsabilidade ativa por sua condução, estaremos diante de um conflito de atribuições.

Todavia, no caso do inquérito policial, por exemplo, em que é obrigatória a intervenção judicial para que os autos sejam remetidos a outro juízo, não há falar em conflito de atribuições.

Para fins didáticos, extraindo-se as informações da obra do Professor Renato Brasileiro de Lima, organizamos uma tabela com os órgãos ministeriais conflitantes e as autoridades responsáveis pela resolução do conflito. Confira-se (LIMA, 2017, p. 1139-1140):

| <u>ÓRGÃOS MINISTERIAIS CONFLITANTES</u>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>AUTORIDADE COMPETENTE PARA RESOLUÇÃO</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Conflitos entre órgãos do Ministério Público pertencentes ao mesmo Estado da Federação.</li> </ul>                                                                                                                                                                             | Procurador-Geral de Justiça (art. 10, X, da Lei nº 8.625/1993).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Conflito no âmbito do Ministério Público Federal, ou seja, entre dois Procuradores da República.</li> </ul>                                                                                                                                                                    | Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com recurso para o Procurador-Geral da República (arts. 49, VIII, e 62, VII, da Lei Complementar nº 75/93).                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Conflito entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União (lembre-se que integram o MPU o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Ministério Público Militar).</li> </ul> | Procurador-Geral da República, como Chefe do Ministério Público da União (art. 26, VII, da Lei Complementar nº 75/93).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Conflito de atribuições entre órgãos do Ministério Público Federal e órgãos do Ministério Público Estadual.</li> </ul>                                                                                                                                                         | Procurador-Geral da República (STF. Plenário. ACO 924/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19/5/2016 - Info 826 e ACO 1567 QO/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 17/8/2016 - Info 835).                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Conflito de atribuições entre Ministérios Públicos de Estados diversos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | Procurador-Geral da República (STF. Plenário. ACO 924/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19/5/2016 - Info 826 e ACO 1567 QO/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 17/8/2016 - Info 835).<br><br>Observação: o STF, nos julgados acima referendados, não apreciou expressamente o tema. Contudo, tendo em vista os argumentos utilizados, muito provavelmente, o STF decidirá que é o PGR quem deve resolver o conflito entre Promotores de Justiça de Estados diversos. |

## 12. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA

### 12. 1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

**PGR E CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO ENTRE ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.** Cabe ao Procurador-Geral da República a apreciação de conflitos de atribuição entre órgãos do ministério público. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, resolveu questão de ordem no sentido do não conhecimento da ação e remeteu os autos ao Procurador-Geral da República. No caso, instaurara-se conflito negativo de atribuições entre ministério público estadual e ministério público federal, para apuração de crime contra o mercado de capitais previsto no art. 27-E da Lei 6.385/1976. O Tribunal consignou que a competência para a apreciação de conflitos de atribuição entre membros do ministério público, por não se inserir nas competências originárias do STF (CF, art. 102, I), seria constitucionalmente atribuída ao Procurador-Geral da República, como órgão nacional do ministério público. Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, que conheciam da ação. Pontuavam que a competência seria do STF e que conclusão diversa culminaria por nulificar, de modo absoluto, a autonomia institucional dos ministérios públicos estaduais. (INF 835 - ACO 1567 QO/SP, rel. Min. Dias Toffoli, 17/8/2016.)

## 12.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Súmula nº 3, STJ: “Compete ao Tribunal Regional Federal dirimir conflito de competência verificado, na respectiva Região, entre Juiz Federal e Juiz Estadual investido de jurisdição federal.”

Súmula nº 59, STJ: “Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes.”

Súmula nº 348, STJ (CANCELADA): “Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal, ainda que da mesma seção judiciária.”

Súmula nº 428, STJ: “Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária.”

**DIREITO PROCESSUAL PENAL. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. É exigível procuração com poderes especiais para que seja oposta exceção de suspeição por réu representado pela Defensoria Pública, mesmo que o acusado esteja ausente do distrito da culpa.** Segundo o art. 98 do CPP “Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas”. A recusa do magistrado por suspeição imputa parcialidade do juiz que não declarou sua suspeição ou impedimento quando supostamente deveria tê-lo feito de ofício, vinculando pessoalmente o excipiente acerca das alegações que podem, inclusive, representar crime contra a honra. Assim, a manifestação da inequívoca vontade da parte interessada na recusa do magistrado por meio da subscrição da petição pela própria parte ou, quando representada em juízo, por meio de procuração com poderes especiais, é exigência legal que não pode ser dispensada, sob pena de negativa de vigência ao comando expresso da norma. A propósito, a regularidade da representação processual é garantia da própria parte, evitando que o representante atue contra a vontade do representado. Ademais, não pode ser confundida com substituição da parte que se encontra ausente (ou foragido). Com efeito, ainda que independa de mandato para o foro em geral (art. 128, XI, da LC 80/1994), o defensor público não atua na qualidade de substituto processual, mas de representante processual, devendo juntar procuração sempre que a lei exigir poderes especiais, não havendo falar em violação qualquer do direito de acesso ao Poder Judiciário. (INF 560 -REsp 1.431.043-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 16/4/2015, DJe 27/4/2015.)

### QUESTÕES

**1- MPE/SC (MPE/SC 2019)** Estabelece o Código de Processo Penal que nas exceções de suspeição, litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada, será observado, no que lhes for aplicável, o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo. As exceções serão processadas em autos apartados e suspenderão, em regra, o andamento da ação penal.

**2- DPE/RR (Cespe/UnB 2013 – adaptada)** As exceções dilatórias e peremptórias objetivam estancar definitivamente o curso da ação penal, pondo fim à relação jurídica processual, por faltar alguma condição da ação ou pressuposto processual.

**3- TJ/PA (Cespe/UnB 2012 – adaptada)** As exceções de litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada devem ser processadas em autos apartados, ficando suspenso o andamento da ação penal.

**4- TRF 2ª Região (TRF 2ª Região 2014)** Com relação às exceções, em direito processual penal:

- a) Para a arguição da suspeição do juiz, é indispensável a capacidade postulatória.
- b) São dilatórias as exceções de ilegitimidade de parte, incompetência do juízo, suspeição, impedimento, incompatibilidade; são peremptórias as exceções de litispendência e coisa julgada.



c) Julgada procedente a exceção de suspeição, o processo continuará com a designação de outro juiz, mantidos os atos praticados pelo primeiro juiz antes do afastamento.

d) Recebida a exceção de coisa julgada, o processo ficará suspenso até que seja definitivamente julgada.

e) A jurisprudência predominante é no sentido de que a exceção de suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade em que o réu se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

**5- PGR (PGR 2017 – adaptada)** No julgamento de um conflito de competência entre dois juízos de primeiro grau, o Tribunal competente não pode declarar competente um terceiro juízo que não figure no julgamento, devendo solver a questão entre o suscitante e o suscitado.

**6- TJDF (Cespe/UnB 2015 – adaptada)** No caso de haver conflito negativo de competência entre um juízo criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília e um juízo criminal da Seção Judiciária Federal de Brasília, competirá ao TRF da 1.ª Região processar e julgar esse conflito de competência.

**7- TJDF (Cespe/UnB 2015 – adaptada)** No caso de exceção de impedimento do magistrado que atua no feito, que deve ser realizada em autos apartados, o magistrado poderá julgá-la procedente, situação em que remeterá os autos a seu substituto, ou improcedente, situação em que continuará a processar o feito.

**8- MPE/AC (Cespe/UnB 2014 – adaptada)** Ao promotor de justiça é vedado, no curso de processo penal, suscitar o conflito de jurisdição.

**9- MPE/SC (MPE/SC 2013)** Segundo o CPP, os juízes, tribunais e a parte interessada, sob a forma de representação, darão parte escrita e circunstanciada do conflito, perante o tribunal competente, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios.

**10- TJ/AL (Cespe/UnB 2008 – adaptada)** É incabível a oposição de suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito.

## COMENTÁRIOS

**1. Gabarito: ERRADO.** De acordo com o art. 110 do CPP, nas exceções de litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada, será observado, no que lhes for aplicável, o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo. A exceção de suspeição tem rito próprio, previsto nos arts. 96 a 107 do CPP. Ademais, nos termos do art. 111 do mesmo Código, via de regra, as exceções, que serão processadas em autos apartados, não suspenderão o curso do processo principal.

**2. Gabarito: ERRADO.** No que diz respeito às suas consequências, as exceções podem ser classificadas em peremptórias, as quais fulminam o processo, e dilatórias, que, embora não acarretem a extinção do processo, retardam o seu regular andamento, como ocorre, por exemplo, com a procedência da exceção de incompetência.

**3. Gabarito: ERRADO.** De fato, as exceções de litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada devem ser processadas em autos apartados, contudo, à luz do art. 111 do CPP, estas não suspenderão o curso do processo principal.

**4. Gabarito: E.**

a) De acordo com o art. 98 do CPP, a própria parte, independentemente de capacidade postulatória, isto é, não precisa ser advogado, poderá assinar a petição de oposição de suspeição.

b) A ilegitimidade *ad causam* tem natureza peremptória, enquanto a ilegitimidade *ad processum* é do tipo dilatória.

c) Nos termos do art. 101 do CPP, julgada procedente a suspeição, ficarão nulos os atos do processo principal, pagando o juiz as custas, no caso de erro inescusável. Assim, ficarão nulos os atos praticados pelo juiz após o surgimento do motivo da suspeição.

d) Conforme art. 111 do CPP, via de regra, as exceções não suspenderão o curso do processo penal.

e) A doutrina e a jurisprudência têm entendido "que a exceção de suspeição deve ser oposta pelas partes tão logo tomarem conhecimento de um dos motivos do art. 254", sob pena de preclusão. É dizer: se a parte conhecer da causa de suspeição do juiz e não a opor "na primeira oportunidade possível, dar-se-á preclusão, subentendendo-se que o silêncio da parte seria equiparado ao reconhecimento da capacidade moral do juiz

para proferir a decisão com imparcialidade". Todavia, de forma majoritária, entende-se que a suspeição é causa de nulidade absoluta do ato praticado, sendo "plenamente possível que a matéria volte a ser apreciada pelo Tribunal competente". (LIMA, 2017, p. 1116.)

**5. Gabarito: ERRADO.** Nos termos do CC 100.545/SP, o STJ assentou que "verificada a competência de um terceiro Juízo, estranho aos autos do Conflito de Competência, admite-se a remessa do feito a este". Assim, se estiverem em conflito positivo de competência, por exemplo, os juízos da Vara Criminal de Samambaia/DF e do Riacho Fundo/DF, poderá o TJDF decidir que a competência é, em verdade, da Vara Criminal do Recanto das Emas/DF.

**6. Gabarito: ERRADO.** O juízo criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília é vinculado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O juízo criminal da Seção Judiciária Federal de Brasília é vinculado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Logo, envolvendo o conflito dois juízes vinculados a Tribunais diversos, compete ao Superior Tribunal de Justiça, dirimi-lo, nos termos do art. 105, I, d, da CF/88.

**7. Gabarito: ERRADO.** Nos termos do art. 112 do CPP, a exceção de impedimento deve seguir o mesmo rito procedimental previsto para a de suspeição. Logo, se o juiz aceitar a exceção de impedimento, isto é, reconhecer o impedimento, deve remeter os autos a seu substituto legal, nos termos do art. 99 do CPP. Em contrapartida, caso o juiz não aceite a exceção de impedimento, deverá mandar autuar em apartado a petição, dará sua resposta dentro em três dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e, em seguida, determinará sejam os autos da exceção remetidos, dentro em 24 vinte e quatro horas, ao tribunal a quem competir o julgamento, nos termos do art. 100 do CPP. Logo, a questão erra ao dizer que o juiz continuará no feito, caso julgue improcedente a exceção de impedimento.

**8. Gabarito: ERRADO.** De acordo com o art. 115 do CPP, o conflito de competência, seja ele do tipo positivo, seja ele negativo, poderá ser suscitado pela parte interessada (inciso I), pelos órgãos do Ministério Público junto a qualquer dos juízos em dissídio (inciso II) ou por qualquer dos juízes ou tribunais em causa (inciso III).

**9. Gabarito: ERRADO.** Nos termos do art. 116, *caput*, do CPP, os juízes e os tribunais suscitarão o conflito de competência perante o Tribunal competente, sob a forma de representação, na qual darão parte escrita e circunstanciada do conflito, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios. As partes, caso queiram suscitar o conflito, deverão fazê-lo por intermédio de requerimento, no qual exporão, de forma escrita e circunstanciada, os motivos em que se fundam o conflito. A questão erra quando afirma que tanto as partes como os juízes e tribunais apresentarão representação.

**10. Gabarito: CORRETO.** De acordo com a redação do art. 107 do CPP, não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas, quando ocorrer motivo legal. Assim, não há falar em oposição de exceção de suspeição em relação às autoridades de polícia judiciária. Todavia, se a própria autoridade policial perceber que está incurso em uma das causas de suspeição, previstas no art. 254 do CPP, deverá se declarar suspeita.



**CAPÍTULO 14 – DA RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS (ART. 118 A 124-A, CPP)****1. INTRODUÇÃO E PROCEDIMENTO**

A restituição das coisas apreendidas, caso estas já não interessem ao processo, poderá se concretizar de duas formas, nos termos do art. 120, §§1º e 2º, do CPP: I) por termo nos próprios autos; e II) por procedimento incidental.

Caso não haja dúvida quanto à propriedade do bem e ele não tenha sido apreendido em poder de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 120, *caput* e §2º, do CPP, o próprio delegado de polícia, durante a investigação policial, poderá restituir os bens apreendidos. É dizer: a lei processual penal autoriza que a autoridade policial proceda à restituição das coisas apreendidas. Logo, não se trata de diligência exclusiva do juiz. Contudo, o delegado somente poderá realizá-la quando: I) não houver dúvida sobre a propriedade do bem; e II) o bem não tenha sido encontrado em poder de terceiro de boa-fé. Preenchidos tais requisitos, o delegado de polícia restituirá os bens por termo nos próprios autos.

Nesse contexto, se houver dúvida quanto à propriedade do bem ou se este for encontrado em poder de terceiro, somente o juiz poderá proceder à sua restituição. Nesse caso, a restituição deverá se dar por procedimento incidental e não por termo nos próprios autos.

Conforme art. 120, §1º, do CPP, se duvidosa a propriedade do bem, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 dias para a prova. Como dito, em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.

Nos termos do art. 120, §2º, do CPP, o incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro 2 dias para arrazoar. É dizer: reclamante e terceiro de boa-fé terão 5 dias para a prova e 2 dias para apresentarem suas alegações finais.

Se o juízo criminal não conseguir determinar quem é o verdadeiro proprietário do bem, remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea, conforme art. 120, §4º, do CPP. Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade, conforme art. 120, §5º, do CPP.

Em todo caso, havendo pedido de restituição, será sempre ouvido o Ministério Público, conforme expressa disposição do art. 120, §3º, do CPP.

Contra a decisão judicial proferida no incidente de restituição, seja qual for o seu resultado, isto é, se defere ou não o pedido, é cabível apelação, já que tal decisão tem natureza definitiva, nos termos do art. 593, inciso II, do CPP (LIMA, 2020, p. 1249-1250).

**2. VEDAÇÕES**

Conforme art. 118 do CPP, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. É dizer: se o bem ainda se mostra relevante ao deslinde da causa, não poderá haver a restituição, como ocorre, por exemplo, no caso de veículo furtado e ainda não periciado.

Ademais, conforme art. 119 do CPP, também não poderão ser restituídos os itens referidos no art. 91, inciso II, do CP, que disciplina o confisco em favor da União, que é um dos efeitos da condenação, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Confira-se:

Art. 91 - São efeitos da condenação:

(...)

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

- a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;
- b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Desse modo, conforme art. 91, inciso II, alínea *a*, do CP, a arma do crime, via de regra, não pode ser restituída, porquanto deverá ser confiscada em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Exemplo: se a arma usada no crime pertence a um policial, este poderá requerer a sua restituição.

De igual forma, em regra, também não poderá haver a restituição das coisas adquiridas com os proventos da infração (produto indireto), nos termos do art. 121 do CPP, já que estas também deverão ser confiscadas em favor da União, conforme art. 91, inciso II, alínea *b*, do CP. Em outras palavras: o produto indireto do crime (também chamado de proventos ou proveito da infração ou, ainda, frutos da infração — *fructus sceleris*) é objeto de confisco em favor da União e, em regra, não pode ser restituído, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé, nos termos da parte final do art. 119 do CPP.

Nesse caso, isto é, na impossibilidade de restituição, conforme art. 133 do mesmo Código, transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado. De acordo com o §1º do art. 133 do CPP, do dinheiro apurado, será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé, sendo o montante que sobrar ao poder público recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial (art. 133, §2º, CPP).

É dizer: João furta a moto de José. Com o dinheiro, compra um carro e o registra em seu nome. A moto é o produto direto da infração (*producta sceleris*). O carro é o produto indireto do crime (também chamado de proventos ou proveito da infração ou, ainda, frutos da infração — *fructus sceleris*). Com a condenação de João, o carro não pode ser lhe restituído, portanto, deverá ser leiloadado. Com o dinheiro, paga-se o prejuízo de José. Se sobrar algum valor, este será destinado ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial.

### 3. PRAZO PARA ALIENAÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS

#### 3.1. COISAS APREENDIDAS SUJEITAS AO CONFISCO

A Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) promoveu uma interessante modificação no art. 122 do CPP, que passou a ter a seguinte redação:

Art. 122. Sem prejuízo do disposto no art. 120, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no art. 133 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) Parágrafo único. (Revogado).

Antes do chamado Pacote Anticrime, o art. 122 do CPP tinha a seguinte redação:

Art. 122. Sem prejuízo do disposto nos arts. 120 e 133, decorrido o prazo de 90 dias, após transitar em julgado a sentença condenatória, o juiz decretará, se for caso, a perda, em favor da União, das coisas apreendidas (art. 74, II, *a* e *b* do Código Penal) e ordenará que sejam vendidas em leilão público. Parágrafo único. Do dinheiro apurado será recolhido ao Tesouro Nacional o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

Portanto, se for o caso de confisco, isto é, se a situação se enquadrar no art. 91, inciso II, do CP, o juiz não mais precisa aguardar o prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória para decretar o perdimento em favor da União. É dizer: tão logo haja o trânsito em julgado, se não for o caso de restituição, o juiz já pode determinar o perdimento e a venda dos bens em leilão público, nos termos do estudado art. 133 do CPP.



### 3.2. COISAS APREENDIDAS NÃO SUJEITAS AO CONFISCO

Caso as coisas apreendidas não estejam sujeitas ao confisco, isto é, caso não se enquadrem nas hipóteses do art. 91, inciso II, do CP, se, no prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes, nos termos do art. 123 do CPP. Tal dispositivo legal também "é aplicado às hipóteses de arquivamento do inquérito ou decisão declaratória extintiva da punibilidade" (LIMA, 2020, p. 1247).

## 4. DESTINAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS

### 4.1. UTILIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO

A Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), ao acrescentar no CPP o art. 133-A, previu que o juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades.

A prioridade na destinação dos bens, conforme §1º, é do órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem. Exemplo: se a investigação foi conduzida pela Polícia Federal, tal instituição terá prioridade na destinação do bem apreendido.

Nos termos do §2º, outros órgãos públicos, isto é, aqueles não vinculados de alguma forma à segurança pública, em sendo demonstrado o interesse público, também poderão ser destinatários de bens apreendidos, sequestrados ou sujeitos a qualquer medida assecuratória. Frise-se: a destinação dos bens apreendidos, sequestrados ou sujeitos a qualquer medida assecuratória não é exclusividade dos órgãos de segurança pública, o que pode ser objeto de provas concursais, mormente em primeiras fases.

Caso o bem seja veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável, conforme §3º.

Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem, nos termos do §4º do citado artigo.

### 4.2. INSTRUMENTOS DO CRIME E BENS CONFISCADOS

Nos termos do art. 124 do CPP, os instrumentos do crime e as coisas confiscadas, caso estas não possam ser leiloadas, deverão ser inutilizados ou recolhidos a museu criminal, se houver interesse na sua conservação. É dizer: pode ser interessante, por exemplo, dada a sua engenhosidade, que o Estado mantenha em um museu criminal uma arma de fogo de fabricação caseira.

### 4.3. OBRAS DE ARTE OU OUTROS BENS DE RELEVANTE VALOR CULTURAL OU ARTÍSTICO

A Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), ao acrescentar no CPP o art. 124-A, previu que, na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor



cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver a destinação dos bens a museus públicos.

Note-se, por oportuno, que a destinação a museus públicos de obras de arte e de outros bens de relevante valor cultural ou artístico somente é cabível se o crime não tiver vítima determinada.

## 5. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA

### 5.1. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. COISA APREENDIDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU DE NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO, COM A REMESSA DO INCIDENTE PARA O JUÍZO CÍVEL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE E SÉRIOS INDÍCIOS DE QUE O BEM É PRODUTO INDIRETO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.**1. São insuscetíveis de restituição, até a sentença condenatória transitada em julgado, objetos apreendidos na posse do Réu e sobre o qual parem sérios indícios de que foram adquiridos com os proventos de atividade criminosa.2. *In casu*, sustenta o Recorrente que é proprietário de veículo automotor, argumentando que havia tão-somente alugado o bem para o Réu da ação principal. Instado a fazer prova de seus direitos de proprietário, o Autor não logrou êxito.3. Não se aplica à hipótese o art. 120, § 4.º, do Código de Processo Penal, na medida em que o Juízo Criminal não decide o processo incidental de restituição, remetendo as partes para o Juízo Cível, caso a complexidade da questão acerca da propriedade demande ampla dilação probatória.4. Recurso desprovido.(REsp 788.301/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 10/9/2009, DJe 28/9/2009.)

**PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA REALIZADA HÁ MAIS DE SETE ANOS. RAZOABILIDADE.** I - A medida de busca e apreensão atende, no presente caso, aos requisitos legais que disciplinam sua realização (art.240 e seguintes do CPP). Contudo, há que se reconhecer que a medida excede prazo de duração recomendável, pois realizada há mais de 7 (sete) anos, sendo que não foi deflagrada, até o presente momento, ação penal referente aos fatos em apuração. II - O princípio da razoabilidade, vetor constitucional, embora implícito no texto magno, recomenda que situações como a presente não sejam canceladas pelo Poder Judiciário, pois se mostram desarrazoadas e divergentes do Estado de Direito. Recurso ordinário provido.(RMS 21.453/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2007, DJ 4/6/2007, p. 381.)

**RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE DINHEIRO. BUSCA E APREENSÃO. ART. 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.613/98. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.**1. Não há falar em infringência ao art. 4º, § 1º, da Lei 9.613/98, uma vez que o magistrado não estaria adstrito a determinar a constrição com base na Lei que trata tão somente de um dos delitos em apuração, não se sujeitando, portanto, ao prazo nela previsto para levantamento da medida.2. Realizada a constrição dos bens em 22.8.2003, o oferecimento da denúncia depois de transcorrido mais de sete anos do bloqueio, sem previsão para o término do processo, configura constrangimento ilegal a determinar a concessão de *habeas corpus* de ofício para liberação dos bens apreendidos. Precedentes.3. Recurso especial ao qual se nega provimento. *Habeas corpus* concedido de ofício para determinar a liberação dos bens apreendidos, mediante a nomeação de seu legítimo proprietário como depositário.(REsp 865.163/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2011, DJe 1º/7/2011.)

## QUESTÕES

**1- MPE/MG (FUNDEP 2019 – adaptada)** O recurso cabível contra a decisão judicial tomada no incidente de restituição de coisas apreendidas é a apelação.

**2- TJ/MT (VUNESP 2018 – adaptada)** Sobre a restituição das coisas apreendidas e medidas assecuratórias, é correto afirmar que a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada somente pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

**3- TJ/MT (VUNESP 2018 – adaptada)** Sobre a restituição das coisas apreendidas e medidas assecuratórias, é correto afirmar que, em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz deverá decidir sobre a qual parte cabe o direito de propriedade e determinar a restituição em favor desta, em autos apartados, após ouvido o Ministério Público.

**4- TJ/PB (Cespe/UnB 2015 – adaptada)** Os instrumentos do crime, se a perda for decretada em favor da União, bem como as demais coisas confiscadas, deverão ser inutilizados, sendo vedado que tais instrumentos ou coisas recebam qualquer outra destinação.

**5- DPU (Cespe/UnB 2015)** Os bens apreendidos com terceiro de boa-fé poderão ser restituídos pela autoridade policial quando não for necessária sua retenção para o esclarecimento dos fatos.

**6- MPE/PE (FCC 2014 – adaptada)** A restituição de coisas apreendidas não pode ocorrer antes do trânsito em julgado enquanto interessarem ao processo.

**7- MPE/PE (FCC 2014 – adaptada)** A restituição de coisas apreendidas dispensa a prévia manifestação do Ministério Público no respectivo incidente.

## COMENTÁRIOS

**1.** Gabarito: CORRETO. Seja qual for o seu resultado, isto é, se defere ou não o pedido, é cabível apelação, já que tal decisão tem natureza definitiva, nos termos do art. 593, inciso II, do CPP (LIMA, 2020, p. 1249-1250).

**2.** Gabarito: ERRADO. Caso não haja dúvida quanto à propriedade do bem e ele não tenha sido apreendido em poder de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 120, *caput* e §2º, do CPP, o próprio delegado de polícia, durante a investigação policial, poderá restituir os bens apreendidos.

**3.** Gabarito: ERRADO. Se o juízo criminal não conseguir determinar quem é o verdadeiro proprietário do bem, remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea, conforme art. 120, §4º, do CPP. Assim, o juízo criminal não é obrigado a restituir o bem. Se ficar em dúvida, pode remeter as partes ao juízo cível.

**4.** Gabarito: ERRADO. Nos termos do art. 124 do CPP, os instrumentos do crime e as coisas confiscadas, caso estas não possam ser leiloadas, deverão ser inutilizados ou recolhidos a museu criminal, se houver interesse na sua conservação.

**5.** Gabarito: ERRADO. Nos termos do art. 120, §2º, do CPP, se os bens forem apreendidos em favor de terceiro de boa-fé, o delegado de polícia não poderá restituí-los. Nesse caso, somente o juiz, que deverá se valer de procedimento incidental.

**6.** Gabarito: CORRETO. Nos termos do art. 118 do CPP, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. É dizer: se o bem ainda se mostra relevante ao deslinde da causa, não poderá haver a restituição, como ocorre, por exemplo, no caso de veículo furtado e ainda não periciado.

**7.** Gabarito: ERRADO. Havendo pedido de restituição, será sempre ouvido o Ministério Público, conforme expressa disposição do art. 120, §3º, do CPP.

**CAPÍTULO 15 – DAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS (ART. 125 A 144-A, CPP)****1. INTRODUÇÃO**

As medidas assecuratórias "são providências de cunho patrimonial adotadas em procedimentos incidentes" e que têm por objetivo "assegurar a recomposição do patrimônio lesado, com justa indenização ou reparação do dano causado à vítima, bem como o pagamento de eventuais penas pecuniárias e despesas processuais" (MARCÃO, 2016, p. 322).

O Código de Processo Penal disciplina três medidas assecuratórias, as quais "configuram verdadeiras medidas cautelares reais, a saber: (1) sequestro; (2) especialização de hipoteca legal; e (3) arresto" (MARCÃO, 2016, p. 322-323).

**2. SEQUESTRO****2.1. SEQUESTRO DE BENS IMÓVEIS****2.1.1. INTRODUÇÃO**

Nos termos do art. 125 do CPP, caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro, objetivando-se garantir a reparação do dano causado pela infração penal (art. 91, inciso I, do CP) e o confisco dos bens em favor da União (art. 91, inciso II, do CP).

Em relação ao citado art. 125 do CPP, destaca-se que, ainda que o bem já tenha sido transferido a terceiro, pouco importando se de boa ou má-fé, é possível sequestrá-lo.

Assim, por meio do sequestro, os imóveis adquiridos pelo investigado ou acusado com o que obteve da infração penal se tornarão indisponíveis. É dizer: o sequestro recai sobre bens imóveis que constituam o produto indireto da infração penal (também chamado de proventos ou proveito da infração ou, ainda, frutos da infração —*fructus sceleris*).

Finalizando a parte introdutória, convém mencionar que "não se aplicam ao sequestro as restrições consagradas na Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade de certos bens. Isto ocorre porque, de acordo com o art. 3.º, VI, daquele diploma, as normas lá previstas não incidem em relação a bens adquiridos como produto do crime" (AVENA, 2017, p. 274).

**2.1.2. REQUISITOS**

O requisito indispensável para a decretação do sequestro dos imóveis é a existência de indícios veementes de que o bem tenha sido adquirido com proventos da infração penal, ou seja, de que o bem tenha origem ilícita. A ideia é deixar indisponível um bem em relação ao qual haja indícios veementes de sua proveniência ilícita. Logo, para que seja decretada tal medida assecuratória, é necessária a existência de indícios veementes no sentido de que o bem tenha sido obtido com proventos de infração penal.

**2.1.3. LEGITIMADOS**

No que diz respeito à decretação do sequestro, o art. 127 do CPP disciplina que o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido (inclusive seus herdeiros, já que um dos objetivos é a reparação do dano), ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa. Frise-se: é cabível o sequestro dos bens imóveis ainda na fase de investigação policial.

Quanto ao ponto, é muito importante destacar que a possibilidade de decretação de ofício pelo juiz restou tacitamente derogada pelo Pacote Anticrime. É dizer: a Lei nº 13.964/19 não mais permite ao juiz a decretação de medidas cautelares de ofício, nos termos dos arts. 3º-A, 282,





§§2º e 4º, e 311, todos do CPP. Por esta razão, sendo o sequestro uma medida cautelar, não pode o juiz, nem mesmo durante a ação penal, decretá-lo de ofício.

Ainda quanto à legitimidade para decretação do sequestro, observa-se que o art. 3º-A da Lei nº 1.579/52, introduzido pela Lei nº 13.367/16, conferiu ao presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, por deliberação desta, “solicitar, em qualquer fase da investigação, ao juízo criminal competente medida cautelar necessária, quando se verificar a existência de indícios veementes da proveniência ilícita de bens” (AVENA, 2017, p. 275). Como se nota, o presidente da CPI pode solicitar ao juízo competente o sequestro. Contudo, a CPI, por força própria, isto é, sem a intervenção do Poder Judiciário, não poderá decretar tal medida, já que o sequestro se sujeita à cláusula de reserva de jurisdição.

#### 2.1.4. PROCEDIMENTO, EMBARGOS E APELAÇÃO

Após o sequestro, que deverá ser processado em autos apartados, o juiz ordenará sua inscrição no Registro de Imóveis, nos termos dos arts. 128 e 129, primeira parte, ambos do CPP.

Concretizado o sequestro, a pessoa que teve o bem constrito pode se valer dos embargos, que serão apreciados pelo juízo criminal que determinou a medida. No ponto, é muito importante diferenciar os tipos de embargos existentes, já que seu processamento variará conforme o embargante.

De acordo com o art. 129, segunda parte, do CPP, o sequestro admitirá embargos de terceiro. Aqui, o terceiro é totalmente estranho ao processo, isto é, houve um erro em relação ao bem sobre o qual recaiu a medida. Exemplo: o juiz determinou o sequestro da casa 1-A. Todavia, o sequestro foi registrado na casa 1-B.

Outros tipos de embargos estão disciplinados no art. 130 do CPP, segundo o qual o sequestro poderá ser embargado: I) pelo acusado, sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração; e II) pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé.

Logo, três são os possíveis embargantes: I) terceiro totalmente estranho ao processo; II) acusado; e III) terceiro adquirente a título oneroso (quem obteve o imóvel a título gratuito não pode se valer dos embargos). No ponto, é interessante frisar que o Ministério Público não é legitimado a embargar o sequestro concretizado.

A importância dessa diferenciação está no art. 130, parágrafo único, do CPP, segundo o qual, nos embargos do acusado e do terceiro adquirente a título oneroso, antes de passar em julgado a sentença condenatória, não poderá ser pronunciada decisão. É dizer: a decisão quanto aos embargos do acusado e do terceiro adquirente a título oneroso somente poderá ser prolatada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória do fato principal.

Esse procedimento, isto é, essa suspensão do julgamento dos embargos, não ocorre em relação aos embargos do terceiro totalmente estranho ao processo. Nesse caso, como o terceiro em nada se relaciona com o fato, o mais justo é que seus embargos sejam julgados o mais rapidamente possível, retirando-se a constrição de seu bem.

Além dos embargos, para a impugnação das medidas cautelares patrimoniais, “doutrina e jurisprudência também admitem a utilização da apelação (CPP, art. 593, II) e do mandado de segurança (Lei nº 12.016/09)” (LIMA, 2020, p. 1261).

#### 2.1.5. LEVANTAMENTO

Nos termos do art. 131 do CPP, ocorrerá o levantamento do sequestro, isto é, a medida perderá sua eficácia, por três razões:

I) SE A AÇÃO PENAL NÃO FOR INTENTADA NO PRAZO DE 60 DIAS, CONTADO DA DATA EM QUE FICAR CONCLUÍDA A DILIGÊNCIA: não se trata de um prazo absoluto, isto é, deve ser interpretado à luz do princípio da razoabilidade, admitindo eventual dilação em casos complexos e/ou quando houver



pluralidade de acusados. Se o excesso for abusivo, não encontrado qualquer justificativa, deve ser determinada a perda da eficácia da medida, liberando-se os bens (LIMA, 2020, p. 1262);

II) SE O TERCEIRO, A QUEM TIVEREM SIDO TRANSFERIDOS OS BENS, PRESTAR CAUÇÃO QUE ASSEGURE A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 91, INCISO II, ALÍNEA B, SEGUNDA PARTE, DO CP: se o terceiro garantir o futuro confisco "de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso", o sequestro será levantado. Frise-se: somente o terceiro é quem pode prestar essa caução. Por óbvio, ao acusado não é dado esse direito, já que o sequestro recai sobre bens adquiridos com os proventos da infração, não sendo razoável que tais bens sejam liberados em razão de oferecimento de caução pelo acusado;

III) SE FOR JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE OU ABSOLVIDO O RÉU, POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO: aqui, é importante frisar que o levantamento do sequestro somente ocorre após o trânsito em julgado da sentença absolutória ou declaratória extintiva da punibilidade; e

IV) PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS: "apesar do silêncio do art. 131 do CPP acerca do assunto, é evidente que a procedência dos embargos também acarreta o levantamento do sequestro, seja porque reconhecido que o bem constrito não fora adquirido pelo acusado com os proventos da infração penal, seja porque reconhecido que o terceiro comprou o bem sequestrado do acusado, tendo-o feito de boa-fé. Idêntico raciocínio também se aplica aos embargos do terceiro não adquirente (CPP, art. 129). Nesse caso, restará ao ofendido buscar resguardar o ressarcimento do seu prejuízo mediante a adoção de medidas cautelares patrimoniais contra outros bens do acusado, valendo-se da inscrição da hipoteca legal (CPP, art. 134) ou do arresto (CPP, art. 137)." (LIMA, 2020, p. 1264.)

## 2.2. SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS

Nos termos do art. 126 do CPP, é cabível o sequestro dos bens móveis adquiridos com os proventos da infração penal (produto indireto, também chamado de proventos ou proveito da infração ou, ainda, frutos da infração —*fructus sceleris*). O produto direto da infração (*producta sceleris*) não é objeto de sequestro, mas, sim, de busca e apreensão, nos termos do art. 240 e seguintes do CPP. Em resumo: o produto direto da infração é objeto de busca e apreensão. O proveito da infração é objeto de sequestro.

Ao sequestro de bens móveis, aplicam-se todas as disposições do sequestro de bens imóveis, salvo, por óbvio, a inserta no art. 128 do CPP (inscrição do sequestro no Registro de Imóveis).

## 2.3. DESTINAÇÃO DOS BENS SEQUESTRADOS

Conforme art. 133 do CPP, transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado. De acordo com o §1º do art. 133 do CPP, do dinheiro apurado, será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé, sendo o montante que sobrar ao poder público recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial (art. 133, §2º, CPP).

É dizer: João furta da casa de José uma mala com R\$10.000,00. Com o dinheiro, compra uma moto e a registra em seu nome. A mala com o dinheiro é o produto direto da infração (*producta sceleris*). A moto é o produto indireto do crime (também chamado de proventos ou proveito da infração ou, ainda, frutos da infração —*fructus sceleris*). Com a condenação de João, a moto não pode ser lhe restituída, portanto, deverá ser leiloada. Com o dinheiro, paga-se o prejuízo de José. Se sobrar algum valor, este será destinado ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial.

## 2.4. UTILIZAÇÃO DO BEM PELO PODER PÚBLICO

A Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), ao acrescentar no CPP o art. 133-A, previu que o juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades.

A prioridade na destinação dos bens, conforme §1º, é do órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem. Exemplo: se a investigação foi conduzida pela Polícia Civil do Estado de Goiás, tal instituição terá prioridade na destinação do bem apreendido.

Nos termos do §2º, outros órgãos públicos, isto é, aqueles não vinculados de alguma forma à segurança pública, em sendo demonstrado o interesse público, também poderão ser destinatários de bens apreendidos, sequestrados ou sujeitos a qualquer medida assecuratória. Frise-se: a destinação dos bens apreendidos, sequestrados ou sujeitos a qualquer medida assecuratória não é exclusividade dos órgãos de segurança pública, o que pode ser objeto de provas concursais, mormente em primeiras fases.

Caso o bem seja veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável, conforme §3º.

Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem, nos termos do §4º do citado artigo.

## 3. HIPOTECA LEGAL

### 3.1. INTRODUÇÃO

Diferentemente do que ocorre em relação ao sequestro, a hipoteca legal recai sobre bens imóveis de origem lícita, de propriedade do réu, objetivando, tão somente, garantir ao ofendido (ou sucessores) a indenização pelos danos causados pela infração penal e o pagamento das despesas judiciais, não havendo, na hipoteca legal, qualquer preocupação em relação ao confisco de bens em favor da União (LIMA, 2020, p. 1266).

A hipoteca legal também não está sujeita às restrições à impenhorabilidade dos bens de família, porquanto a Lei nº 8.009/90, em seu art. 3º, inciso VI, exclui dessa impenhorabilidade os bens que se destinem a execução de uma sentença penal condenatória (AVENA, 2017, p. 283).

Finalizando a parte introdutória, convém mencionar que "a hipoteca, mesmo inscrita no registro imobiliário, não torna o bem inalienável. Portanto, nada impede ao réu transferir -lhe o domínio. No entanto, por ocasião dos atos registrares, ficará ciente o adquirente de que está comprando bem que constitui garantia de uma dívida a ser satisfeita pelo réu, e que, futuramente, poderá vir a perder esse mesmo bem caso o acusado não cumpra a obrigação patrimonial decorrente do ilícito praticado" (AVENA, 2017, p. 286).

### 3.2. REQUISITOS

Nos termos do art. 134 do CPP, são requisitos da hipoteca legal: I) prova da materialidade do fato criminoso; e II) indícios de autoria. Note-se, pois, que, diferentemente do que ocorre em relação ao sequestro, na hipoteca legal, não é exigida a presença de indícios veementes

de que o bem tenha sido adquirido com proventos da infração penal, ou seja, de que o bem tenha origem ilícita.

### 3.3. LEGITIMADOS

Também de acordo com o citado art. 134 do CPP, a hipoteca legal somente poderá ser requerida pelo ofendido, seu representante legal ou por seus herdeiros, o que, em muito, se diferencia do sequestro, que pode ser objeto de requerimento do Ministério Público ou de representação do delegado de polícia.

Essa diferenciação se justifica pela finalidade das medidas. É dizer: se a hipoteca legal visa, tão somente, garantir ao ofendido (ou sucessores) a indenização pelos danos causados pela infração penal e o pagamento das despesas judiciais, conclui-se que o interesse é privado, isto é, próprio do ofendido. Como o sequestro também se destina a garantir o confisco em favor da União, o interesse é público, razão pela qual o Ministério Público pode requerer sua decretação e o delegado de polícia pode representar por tal medida.

### 3.4. POSSIBILIDADE DE CAUÇÃO PELO RÉU

Diferentemente do que ocorre no sequestro, nos termos do art. 135, §6º, do CPP, se o réu oferecer caução suficiente, em dinheiro ou em títulos de dívida pública, pelo valor de sua cotação em Bolsa, o juiz poderá deixar de mandar proceder à inscrição da hipoteca legal. Frise-se: o réu, caso ofereça caução suficiente, poderá evitar a hipoteca legal, já que esta recai sobre seu patrimônio lícito. No sequestro, que recai sobre bens de origem ilícita, o réu não pode evitá-lo com o oferecimento de caução. Tal direito, no sequestro, somente é dado ao terceiro adquirente, nos termos do art. 131, inciso II, do CPP.

## 4. ARRESTO

Previu o legislador processual penal dois tipos de arresto: I) arresto prévio (ou preventivo) e II) arresto subsidiário.

### 4.1. ARRESTO PRÉVIO (OU PREVENTIVO)

Conforme art. 136 do CPP, o arresto do imóvel poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, se no prazo de 15 dias não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal. Frise-se: caso o processo de inscrição da hipoteca legal não seja promovido em 15 dias, o arresto prévio (ou preventivo) será revogado.

Tendo em vista que o procedimento da hipoteca legal é bastante demorado,

esse arresto prévio do bem imóvel a que se refere o art. 136 do CPP funciona, portanto, como uma medida preparatória da inscrição da hipoteca legal, de natureza pré-cautelar, cuja finalidade é tornar os bens imóveis do acusado inalienáveis durante o lapso temporal necessário à tramitação do pedido de registro do gravame real (LIMA, 2020, p. 1274).

Assim, sendo o arresto prévio (ou preventivo) preparatório à hipoteca legal, "quaisquer bens imóveis do acusado poderão ser arrestados, para posteriormente ser objeto de especificação e registro, não se confundindo a medida em pauta com o sequestro previsto no art. 125, que se refere somente aos bens adquiridos com os proventos da infração" (LIMA, 2020, p. 1274).

Também devido ao seu caráter de preparação à hipoteca legal, "por meio de interpretação sistemática, como se trata de medida que visa acautelar bens imóveis para futura especialização e registro da hipoteca legal, o ideal é entender que a legitimidade para ambas as medidas é idêntica, abrangendo apenas o ofendido" (LIMA, 2020, p. 1274).

Por fim, assenta-se que "prevalece o entendimento de que, durante o processamento do arresto prévio, não é cabível a oposição dos embargos de que cuida o art. 130 do CPP, visto que se trata de instrumento destinado exclusivamente ao sequestro" (LIMA, 2020, p. 1274).

#### 4.2. ARRESTO SUBSIDIÁRIO DE BENS MÓVEIS

Conforme art. 137 do CPP, se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora, nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis.

Nesse contexto, "o arresto subsidiário de bens móveis a que se refere o art. 137 não é destinado a assegurar os imóveis que serão objeto de hipoteca, assemelhando-se, na verdade, à própria inscrição da hipoteca legal prevista no art. 134 do CPP, com a ressalva de que, ao contrário dela, recai apenas sobre bens móveis de origem lícita pertencentes ao acusado" (LIMA, 2020, p. 1275).

Frise-se: diferentemente do que ocorre no sequestro de bens móveis, o arresto subsidiário recai sobre bens móveis de origem lícita pertencentes ao acusado e visa, tão somente, garantir ao ofendido (ou sucessores) a indenização pelos danos causados pela infração penal e o pagamento das despesas judiciais.

Caso tais bens móveis sejam coisas fungíveis e facilmente deterioráveis, nos termos do art. 137, §1º, do CPP, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade, conforme art. 120, §5º, do CPP.

##### 4.2.1. RENDAS DOS BENS MÓVEIS

Conforme art. 137, §2º, do CPP, no caso do arresto subsidiário, das rendas dos bens móveis poderão ser fornecidos recursos arbitrados pelo juiz, para a manutenção do indiciado e de sua família. Tal medida se justifica pelo fato de que, diferentemente do que ocorre na hipoteca legal e no arresto prévio (ou preventivo), no arresto subsidiário, "é possível que um terceiro seja nomeado como depositário dos bens móveis arrestados", retirando do indiciado os frutos de tais bens (LIMA, 2020, p. 1277).

##### 4.2.2. SUSCETIBILIDADE DE PENHORA

Ao tratar do arresto subsidiário de bens móveis, o art. 137, *caput*, do CPP, foi enfático: somente poderão ser arrestados os bens suscetíveis de penhora.

Nesse sentido, ao contrário do que ocorre no "sequestro, inscrição da hipoteca legal e arresto prévio —, o arresto a que se refere o art. 137 do CPP não pode recair sobre bem móvel de família que garante a casa (Lei nº 8.009/90, art. 1º, parágrafo único), porquanto tais objetos são impenhoráveis" (LIMA, 2020, p. 1276-1277).

### 5. DISPOSIÇÕES COMUNS À HIPOTECA LEGAL E AO ARRESTO

#### 5.1. NECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS

Nos termos do art. 138 do CPP, o processo de especialização da hipoteca e do arresto correrão em auto apartado.

#### 5.2. ALCANCE DAS GARANTIAS

Conforme art. 140 do CPP, na hipoteca legal e no arresto, as garantias do ressarcimento do dano alcançarão também as despesas processuais e as penas pecuniárias, tendo preferência



sobre estas a reparação do dano ao ofendido. É dizer: a reparação do dano ao ofendido (ou sucessores) tem preferência sobre o pagamento das despesas processuais e das penas pecuniárias.

### 5.3. LEVANTAMENTO DO ARRESTO E CANCELAMENTO DA HIPOTECA

Nos termos do art. 141 do CPP, o arresto será levantado ou será cancelada a hipoteca, se, por sentença irrecorrível, o réu for absolvido ou for julgada extinta a punibilidade. Frise-se: para que haja o levantamento do arresto ou o cancelamento da hipoteca, é necessário o trânsito em julgado da sentença penal absolutória ou declaratória extintiva da punibilidade. Não basta, para tanto, a publicação de sentença recorrível.

### 5.4. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Conforme art. 142 do CPP, caberá ao Ministério Público promover a hipoteca legal ou o arresto, se houver interesse da Fazenda Pública, ou se o ofendido for pobre e o requerer.

Apesar de críticas doutrinárias, a jurisprudência entende "que o Ministério Público está legitimado para requerer o arresto e posterior hipoteca legal, visando resguardar o montante necessário para pagamento de multa, custas e reparação do prejuízo causado" (LIMA, 2020, p. 1269).

Em relação à vítima pobre, a legitimação do Ministério Público está condicionada a seu requerimento, isto é, o MP não pode agir de ofício. Ademais, nos moldes do art. 68 do CPP, entende-se que tal dispositivo legal padece de inconstitucionalidade progressiva (ou temporária). É dizer: enquanto a Defensoria Pública não estiver estruturada naquela comarca, o Ministério Público poderá agir. Depois que a Defensoria Pública se estruturar, o Ministério Público perderá a legitimidade prevista no art. 142 do CPP.

### 5.5. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO CÍVEL

Nos termos do art. 143 do CPP, passando em julgado a sentença condenatória, serão os autos de hipoteca ou de arresto remetidos ao juiz do cível. Assim, a hipoteca legal e o arresto são medidas que se iniciam no juízo criminal, contudo, terminam perante o juízo cível (AVENA, 2017, p. 286).

## 6. VENDA ANTECIPADA DOS BENS SEQUESTRADOS, HIPOTECADOS OU ARRESTADOS

Para preservação do valor dos bens sequestrados, hipotecados ou arrestados, sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção, o juiz determinará a alienação antecipada daqueles, que será concretizada, preferencialmente, por meio eletrônico, nos termos do art. 144-A, *caput* e §1º do CPP.

Conforme §2º, os bens deverão ser vendidos pelo valor fixado na avaliação judicial ou por valor maior. Caso não seja alcançado o valor estipulado pela administração judicial, será realizado novo leilão, em até 10 (dez) dias contados da realização do primeiro, podendo os bens ser alienados por valor não inferior a 80% (oitenta por cento) do estipulado na avaliação judicial.

Nos termos do §3º, o produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo até a decisão final do processo, procedendo-se à sua conversão em renda para a União, Estado ou Distrito Federal, no caso de condenação, ou, no caso de absolvição, à sua devolução ao acusado. Quanto ao ponto, é interessante mencionar que, apesar do §3º somente se referir à "decisão final do processo", considerando que uma das finalidades da medida é evitar a deterioração do bem constrito, entende-se que

nada obsta seja realizado o procedimento de venda antecipada também na fase anterior ao ajuizamento da denúncia ou da queixa-crime, bastando que estejam presentes os motivos legais: risco de deterioração ou depreciação, ou dificuldade de manutenção.



Nesta hipótese, o eventual não ajuizamento do processo criminal importará na entrega do valor obtido com a venda àquele a quem pertencia a coisa alienada (AVENA, 2017, p. 290).

Se a indisponibilidade recair sobre dinheiro, inclusive moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, o juízo determinará a conversão do numerário apreendido em moeda nacional corrente e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial, conforme §4º.

No caso da alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado de registro e licenciamento em favor do arrematante, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário, nos termos do §5º. É dizer: o arrematante recebe o bem totalmente regularizado, ficando as dívidas existentes a cargo do antigo proprietário.

Por fim, disciplina o §6º que o valor dos títulos da dívida pública, das ações das sociedades e dos títulos de crédito negociáveis em bolsa será o da cotação oficial do dia, provada por certidão ou publicação no órgão oficial.

## 7. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA

### 7.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

**DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARRESTO. ATO DE CORRUPÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. PENA DE MULTA.** 1. O Ministério Público possui legitimidade para requerer medidas assecuratórias da reparação de danos causados por atos de corrupção, bem como do pagamento da eventual pena de multa, seja no interesse da Fazenda Pública, seja no interesse da sociedade (CF, arts. 127, I, e 129, *caput*; CPP, arts. 134 e 142). 2. Para a decretação do arresto, devem ser verificados: (a) a plausibilidade do direito, representada (a.1) por indícios de materialidade e autoria e (a.2) pela estimativa do dano causado pelo delito, do valor das despesas processuais e do montante das penas pecuniárias; e (b) o perigo na demora. 3. A presença de indícios de materialidade e autoria dos crimes de corrupção passiva (art. 317, *caput*, do CP) e de tentativa de embaraço de investigações relacionadas a organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/13) está caracterizada pelo recebimento integral da denúncia oferecida no Inquérito nº 4506 contra os agravantes e outros acusados (minha relatoria para acórdão, Primeira Turma, j. 17.04.2018). 4. Embora exista uma tendência de se reconhecer a possibilidade de danos morais coletivos em decorrência de atos de corrupção, ainda não houve manifestação a respeito por parte do Supremo Tribunal Federal. É prematuro, portanto, arrestar antecipadamente bens dos agravantes para assegurar a reparação dessa espécie de danos. 5. É razoável o valor estimado pelo Ministério Público Federal, de R\$ 1.686.600,00 para cada agravado, para a incidência da medida cautelar, voltada a assegurar o pagamento da eventual pena pecuniária, a ser imposta em caso de condenação. 6. Na execução das penas de multa, na Ação Penal nº 470, boa parte dos condenados procurou furtar-se ao seu pagamento alegando insuficiência de patrimônio. 7. O perigo na demora é ínsito às medidas assecuratórias penais, sendo desnecessária a demonstração de atos concretos de dissipação patrimonial pelos acusados. 8. Agravo parcialmente provido. (Pet 7069 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 8/5/2019 PUBLIC 9/5/2019.)

### 7.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO. LAVAGEM DE DINHEIRO E SONEGAÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO AJUIZADOS COM FULCRO NO ART. 129 DO CPP. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO

PENAL CORRESPONDENTE. BOA-FÉ. SÚMULA 7/STJ. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. À hipótese prevista no art. 129 do CPP, que cuida da defesa apresentada por terceiro de boa-fé alheio à prática da infração penal, não se aplica o parágrafo único do art. 130, do referido Código, em que há, de algum modo, vínculo do embargante com o autor da infração penal ou com a prática do delito. Precedentes. 2. Inviável a alteração da conclusão sobre a existência ou não da boa-fé do agravante, não reconhecida pelas instâncias ordinárias, sem o revolvimento aprofundado de toda a matéria fático-probatória, providência sabidamente inviável na via eleita, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. A questão referente à eventual atraso no oferecimento da denúncia nem sequer foi abordada pelo acórdão recorrido, que entendeu pela existência de supressão de instância. Inafastável, na hipótese, o enunciado 211 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1569321/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 10/6/2016.)

### QUESTÕES

- 1- MPE/MG (FUNDEP 2018 – adaptada)** A exigência de trânsito em julgado da sentença condenatória, para o julgamento de embargos opostos ao sequestro, não se aplica ao terceiro inteiramente estranho ao fato criminoso.
- 2- MPE/PR (MPE/PR 2008 – adaptada)** O sequestro de bens imóveis poderá ser embargado, pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso ou gratuito, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé.
- 3- TJ/GO (FCC 2015 – adaptada)** Antônio acabou de sofrer hipoteca, determinada por juiz criminal, de imóvel que recebeu de seu pai. Nesse caso, o imóvel, de origem lícita, não poderia ter sido hipotecado.
- 4- DPE/MT (UFMT 2016 – adaptada)** A especialização da hipoteca pode ser requerida pelo ofendido, seu representante legal ou herdeiros, bem como pelo Ministério Público.
- 5- DPE/MG (FUNDEP 2019 – adaptada)** Revogar-se-á o arresto de bem imóvel se a inscrição da hipoteca legal não for promovida em 30 (trinta) dias.
- 6- TJ/PR (Cespe/UnB 2019 – adaptada)** A respeito de questões e processos incidentes em âmbito penal, é correto afirmar que o leilão público de bens sequestrados, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, está condicionado ao exclusivo requerimento da parte interessada.
- 7- TJ/SP (VUNESP 2018 – adaptada)** Quanto às medidas assecuratórias, é correto afirmar que o sequestro poderá recair sobre bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, desde que ainda não tenham sido transferidos a terceiros.

### COMENTÁRIOS

- 1. Gabarito: CORRETO.** Aos embargos opostos por terceiro totalmente estranho ao fato, não se aplica a disposição inserta no art. 130, parágrafo único, do CPP. Nesse caso, como o terceiro em nada se relaciona com o fato, o mais justo é que seus embargos sejam julgados o mais rapidamente possível, retirando-se a constrição de seu bem.
- 2. Gabarito: ERRADO.** Quem obteve o imóvel a título gratuito não pode se valer dos embargos insertos no art. 130, inciso II, do CPP (somente quem adquiriu a título oneroso).
- 3. Gabarito: ERRADO.** Diferentemente do que ocorre em relação ao sequestro, a hipoteca legal recai sobre bens imóveis de origem lícita, de propriedade do réu, objetivando, tão somente, garantir ao ofendido (ou sucessores) a indenização pelos danos causados pela infração penal e o pagamento das despesas judiciais (LIMA, 2020, p. 1266).



4. Gabarito: CORRETO. Conforme art. 134 do CPP, a hipoteca legal somente poderá ser requerida pelo ofendido, seu representante legal ou por seus herdeiros. Além disso, nos termos do art. 142 do CPP, se a vítima for pobre e assim se manifestar, o Ministério Público poderá requerer tal medida.

5. Gabarito: ERRADO. Nos termos do art. 136 do CPP, caso o processo de inscrição da hipoteca legal não seja promovido em 15 dias, o arresto prévio (ou preventivo) será revogado.

6. Gabarito: ERRADO. Conforme art. 133 do CPP, transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado.

7. Gabarito: ERRADO. Nos termos do art. 125 do CPP, caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro, objetivando-se garantir a reparação do dano causado pela infração penal (art. 91, inciso I, do CP) e o confisco dos bens em favor da União (art. 91, inciso II, do CP).

## CAPÍTULO 16 – DAS PROVAS (ART. 155 A 250, CPP)

### 1. INTRODUÇÃO E TEORIA GERAL DA PROVA (ART. 155 A 157, CPP)

Em sentido estrito, prova é a informação ou conjunto de informações trazidas aos autos em que materializada a persecução penal com a finalidade de, dentro do possível, reconstruir a dinâmica fática, formando o convencimento do magistrado acerca dos fatos em julgamento, já que o juiz é o seu destinatário final. Quanto ao ponto, não se pode confundir o conceito de prova com o de ato probatório, sendo este compreendido como a atividade concretizada com o fim de produzir a prova (MARCÃO, 2016, p. 351).

#### 1.1. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS

##### 1.1.1. CONTRADITÓRIO

Nos termos do art. 155, *caput*, do CPP, a fim que a informação ou conjunto de informações trazidas aos autos ganhem o *status* de prova, isto é, para que o juiz possa delas se valer como fundamento ao decreto condenatório, sua produção deve se submeter ao contraditório; sendo oportunizada à parte contrária o direito de ciência quanto àquelas informações (direito à informação) e de se contrapor ao seu conteúdo (direito de participação), tudo em conformidade com o art. 5º, inciso LIV, da CF/88.

O contraditório, isto é, a ciência da parte contrária quanto à informação juntada aos autos e a possibilidade de contraposição ao seu conteúdo, pode ser concretizado de duas formas:

I) CONTRADITÓRIO REAL OU PARA A PROVA: é aquele que se verifica no momento da produção da informação. É dizer: já em sua produção, a prova se submete ao contraditório, podendo as partes, enquanto a prova está sendo construída, intervirem na colheita daquela informação. É o que se verifica, por exemplo, nas provas colhidas em juízo; e

II) CONTRADITÓRIO DIFERIDO OU POSTERGADO OU ADIADO OU SOBRE A PROVA: é aquele que ocorre em momento no qual a informação já foi produzida, isto é, "a observância do contraditório é feita posteriormente, dando-se oportunidade ao acusado e a seu defensor de, no curso do processo, contestar a providência cautelar, ou de combater a prova pericial feita no curso do inquérito" (LIMA, 2020, p. 58). É o que ocorre, por exemplo, com a interceptação telefônica, já que, enquanto a diligência está em curso, nem mesmo ciência dela o investigado terá. Após o seu término, a defesa do interceptado poderá contraditar os elementos nela colhidos.

##### 1.1.2. IMEDIATIDADE

De acordo com o princípio da imediatidade "é necessário assegurar ao juiz o contato físico com as provas no ato de sua obtenção, inclusive para que possa ele conservar em sua memória aspectos importantes do momento em que tenham sido aquelas provas produzidas e, desse modo, valorá-las com maior exatidão no ato da sentença" (AVENA, 2017, p. 317).

Nesse contexto, pelo princípio da imediatidade, também chamado de imediatismo, deve o juiz colher diretamente todas as provas, em contato imediato com as partes, o que, todavia, não impede a produção de provas por videoconferência, que será analisada em tópico próprio (LIMA, 2020, p. 711).

##### 1.1.3. CONCENTRAÇÃO

Pelo princípio da concentração, "a produção probatória deve ser concentrada em uma só audiência ou, ao menos, no menor número possível delas. Este critério de condução do processo,



já inserido em diplomas legais, como a Lei 9.099/1995 (art. 81), foi incorporado ao Código de Processo Penal pela Lei 11.719/2008, ao estabelecer, nos arts. 400, 411 e 431 (procedimento ordinário, rito do júri e procedimento sumário, respectivamente), a concentração das provas orais em audiência única de instrução" (AVENA, 2017, p. 317).

Ainda de acordo com o princípio em voga, "caso não seja possível concentrar a produção da prova em uma única audiência, deve-se designar a próxima audiência para a data mais próxima" (LIMA, 2020, p. 711).

#### 1.1.4. COMUNHÃO

Pelo princípio da comunhão, "uma vez trazidas aos autos, as provas não mais pertencem à parte que as acostou, mas sim ao processo, podendo, desse modo, ser utilizadas por quaisquer dos intervenientes, seja o juiz, sejam as demais partes" (AVENA, 2017, p. 317-318).

### 1.2. SISTEMA DE VALORAÇÃO DA PROVA ADOTADO PELO CPP

De acordo com o art. 155, *caput*, do CPP, o juiz formará sua convicção pela *livre apreciação* da prova produzida em contraditório judicial, não podendo *fundamentar* sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Desse modo, pela redação do citado artigo, que deve ser lido em conjunto com o art. 93, inciso IX, da CF/88, extrai-se que o juiz é livre para fundamentar sua decisão, razão pela qual se diz que o Código de Processo Penal adotou o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado. É dizer: "o magistrado tem ampla liberdade na valoração das provas constantes dos autos, as quais têm, legal e abstratamente, o mesmo valor, porém se vê obrigado a fundamentar sua decisão" (LIMA, 2020, p. 683).

Excepcionando a regra da persuasão racional, no rito escalonado do Tribunal do Júri, os Jurados não fundamentam sua decisão, nos termos do art. 486 do CPP, razão pela qual, em relação aos Jurados do Tribunal do Júri, é aplicado o sistema da íntima convicção do julgador, também chamado de sistema da certeza moral do juiz ou da livre convicção. Frise-se: mesmo no Tribunal do Júri, somente os Jurados são regidos pelo sistema da íntima convicção. Ao juiz-presidente, continua valendo a regra da persuasão racional, sendo dele exigida a fundamentação de suas decisões.

### 1.3. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO POLICIAL

Como visto, o art. 155, *caput*, do CPP, aduz que, em regra, o juiz somente poderá formar seu convencimento pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. É dizer: a fundamentação do magistrado deve estar embasada nas provas produzidas em juízo, isto é, sob o crivo do contraditório real ou para a prova, não podendo, em regra, calcar-se nos elementos de informação angariados na investigação policial.

Antes da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), era bastante tranquilo afirmar que o juiz, para fundamentar sua decisão, poderia se valer dos elementos de informação produzidos na investigação policial, desde que o fizesse de forma subsidiária, isto é, a decisão poderia considerar os elementos colhidos na investigação, contudo, em regra, não poderia ser fundada somente neles<sup>12</sup>.

Tal interpretação nascia do termo *exclusivamente* usado no art. 155, *caput*, do CPP. É dizer: de acordo com essa corrente, que, repita-se, era amplamente aceita na doutrina e na jurisprudência, ao usar o mencionado termo, o legislador, tão somente, impediu que a condenação estivesse baseada, de forma única e exclusiva, nos elementos de informação produzidos na

<sup>12</sup>STF, HC 105837 – RS, 1.ª T., rel. Rosa Weber, 8/5/2012; STJ, AgRg no AREsp 446385 – RJ, 6.ª T., rel. Sebastião Reis Júnior, 25/8/2015.

investigação preliminar. Assim, o magistrado, de forma subsidiária, poderia buscar fundamentação junto às informações trazidas pela investigação.

Contudo, com o Pacote Anticrime, a questão deixa de ser pacífica, já que o art. 3º-C, §3º, do CPP, disciplina que os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado.

A partir do colacionado dispositivo do Pacote Anticrime, que, até o fechamento desta obra, está com a eficácia suspensa, duas correntes doutrinárias debatem sobre o tema.

Uma primeira corrente, interpretando de forma restritiva o art. 3º-C, §3º, do CPP, aduz que os autos da investigação policial continuarão acompanhando a denúncia ou queixa, sempre que servirem de base a uma ou outra, nos termos do art. 12 do CPP, que, para eles, não foi revogado pelo Pacote Anticrime. Para essa corrente, portanto, continua vigorando a interpretação no sentido de que o juiz pode se valer dos elementos de informação para fundamentar sua decisão, desde que não o faça de forma exclusiva. É dizer: o juiz continua a ter acesso a tudo o que foi produzido na investigação policial e, de forma subsidiária, pode se valer de tais elementos (LIMA, 2020, p. 163).

Noutro giro, uma segunda corrente disciplina que "o juiz da instrução e julgamento deverá receber apenas o sumário da primeira fase, contendo as provas irrepetíveis, antecipadas, e os meios de obtenção de prova, autuadas de modo incidental e separadas em blocos distintos, e não os autos na totalidade, os quais deverão permanecer acautelados na secretaria do juiz das garantias" (LIMA, 2020, p. 164). É dizer: o juiz da instrução e julgamento não tem mais acesso amplo aos elementos de informação produzidos na investigação, razão pela qual, por óbvio, não pode fundamentar sua decisão neles, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, as quais ele continuará tendo acesso.

Com efeito, em relação às provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, nada muda, porquanto, nos termos da própria redação do art. 155, *caput*, do CPP, o juiz continua podendo fundamentar sua decisão, inclusive de forma exclusiva, em tais provas. É dizer: a redação do art. 155, *caput*, do CPP, permite que o juiz fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos de informação colhidos na investigação, desde que tais elementos sejam provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas.

Para fins didáticos, colaciona-se tabela extraída da obra do Professor Renato Brasileiro de Lima acerca das provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas, que, como dito, poderão sozinhas embasar a decisão do magistrado, inclusive um decreto condenatório. Confira-se (LIMA, 2020, p. 658-659):

|                                                           | PROVAS CAUTELARES                                                                                                                                     | PROVA NÃO REPETÍVEL                                                                                                                                              | PROVAS ANTECIPADAS                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>CONCEITO</u>                                           | São aquelas em que há um risco de desaparecimento do objeto da prova em razão do decurso do tempo, em relação às quais o contraditório será diferido. | É aquela que, uma vez produzida, não tem como ser novamente coletada ou produzida, em virtude do desaparecimento, destruição ou perecimento da fonte probatória. | São aquelas produzidas com a observância do contraditório real, perante a autoridade judicial, em momento processual distinto daquele legalmente previsto, ou até mesmo antes do início do processo, em virtude de situação de urgência e relevância. |
| <u>MOMENTO E (DES)NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL</u> | Podem ser produzidas no curso da fase investigatória ou durante a fase judicial, sendo que, em regra, dependem de                                     | Podem ser produzidas na fase investigatória e em juízo, sendo que, em regra, não dependem de autorização judicial.                                               | Podem ser produzidas na fase investigatória e em juízo, sendo indispensável prévia autorização judicial.                                                                                                                                              |



|                                        |                                                          |                                                               |                                                                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | autorização judicial.                                    |                                                               |                                                                                 |
| <u>ESPÉCIE</u> DE <u>CONTRADITÓRIO</u> | Diferido ou postergado ou adiado ou sobre a prova.       | Diferido ou postergado ou adiado ou sobre a prova.            | Real ou para a prova.                                                           |
| <u>EXEMPLO</u>                         | Interceptação telefônica, nos termos da Lei nº 9.296/96. | Exame de corpo de delito em vítima de lesões corporais leves. | Oitiva de testemunha que está prestes a falecer, nos termos do art. 225 do CPP. |

#### 1.4. ESTADO CIVIL DAS PESSOAS

Nos termos do art. 155, parágrafo único, do CPP, somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil, o que é apontado pela doutrina como resqúcio de prova tarifada em nosso sistema processual penal (LIMA, 2020, p. 682).

Com efeito, para provar, por exemplo, que seu cliente está morto, não basta que o advogado produza prova testemunhal nesse sentido, sendo necessária a apresentação da certidão de óbito, nos termos do art. 62 do CPP, já que se trata de prova atinente ao estado civil das pessoas (LIMA, 2020, p. 682).

No mesmo sentido, a Súmula nº 74 do STJ disciplina que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil", o qual, nos termos da jurisprudência do próprio STJ, não se restringe à certidão de nascimento ou à identidade civil, podendo a menoridade do réu ser comprovada por outros documentos oficiais, como a declaração prestada perante autoridade pública (HC 363.054/MG, rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 25/4/2017, p. 3/5/2017).

#### 1.5. ÔNUS PROBATÓRIO

Ônus probatório pode ser definido como o "encargo atribuído às partes de provar, mediante meios lícitos e legítimos, a verdade das suas alegações, visando fornecer ao juiz os elementos necessários à formação de sua convicção" (AVENA, 2017, p. 321).

Nos termos do art. 156, *caput*, primeira parte, do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, razão pela qual a doutrina majoritária entende haver "uma efetiva distribuição do ônus da prova entre a acusação e a defesa no processo penal" (LIMA, 2020, p. 677).

Desse modo, para a doutrina majoritária, "à acusação caberá provar a existência do fato imputado e sua autoria, a tipicidade da conduta, os elementos subjetivos de dolo ou culpa, a existência de circunstâncias agravantes e qualificadoras". Noutro giro, à defesa "incumbirá a prova de eventuais causas excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de tipicidade, circunstâncias atenuantes, minorantes e privilegiadoras que tenha alegado" (AVENA, 2017, p. 321).

No que diz respeito ao grau de convencimento do juiz, tem-se que a acusação, de forma indene de dúvidas, deve provar sua alegação, já que em favor do réu milita a presunção de inocência. É dizer: a acusação deve se desincumbir de seu ônus probatório de uma forma que não restem dúvidas quanto aos fatos por ela alegado. A defesa, por sua vez, também considerando a regra da presunção de inocência, conseguirá se desincumbir de seu ônus ao trazer aos autos uma dúvida razoável quanto à sua alegação, nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP, já que, havendo fundada dúvida quanto à existência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, deverá ser proferida sentença absolutória (LIMA, 2020, p. 678).

#### 1.6. INICIATIVA PROBATÓRIA DO JUIZ

O art. 156, *caput*, segunda parte, do CPP, aduz que é facultado ao juiz de ofício:

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; e II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

Antes do Pacote Anticrime, já havia algumas críticas doutrinárias em relação aos citados incisos do art. 156 do CPP. Contudo, a maioria da doutrina os considerava compatível com o ordenamento jurídico vigente, desde que a atuação do juiz, mormente no que diz respeito ao inciso II, se desse de forma subsidiária.

Todavia, com a Lei nº 13.964/19, essa discussão, certamente, dividirá a doutrina e os Tribunais pátrios, porquanto o art. 3º-A do CPP, que, até o fechamento desta obra, está com a eficácia suspensa, expressamente disciplina que o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a *iniciativa do juiz na fase de investigação* e a *substituição da atuação probatória do órgão de acusação*.

Posicionando-se quanto ao ponto, o Professor Renato Brasileiro de Lima foi enfático ao assentar que o art. 3º-A do CPP revogou tacitamente o art. 156, inciso I, do mesmo Código, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porquanto a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (LIMA, 2020, p. 108-109).

De igual forma, ainda segundo o renomado Professor, também houve a revogação tácita do art. 156, inciso II, do CPP, e "de todos os demais dispositivos constantes do Código de Processo Penal que atribuíam ao juiz da instrução e julgamento iniciativa probatória no curso do processo penal". Somente não estariam revogados, de acordo com o Professor, dispositivos que autorizem a intervenção pontual do juiz, como no caso do art. 212, parágrafo único, do CPP, o qual permite ao juiz complementar a inquirição das testemunhas (LIMA, 2020, p. 112).

Em sua obra, o renomado Professor também cita uma posição intermediária, segundo a qual "o art. 3º-A do CPP não revogou os incisos I e II do art. 156 do mesmo diploma legal, salvo no inciso I, no que tange à possibilidade de determinar, de ofício, a produção antecipada da prova na fase de investigação" — Enunciado nº 5 da Procuradoria-Geral de Justiça e Corregedoria-Geral do Ministério Público de São Paulo (LIMA, 2020, p. 109).

### 1.7. INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS ILEGAIS

Nos termos do art. 5º, inciso LVI, da CF/88, são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, o que, no processo penal, foi regulamentado pelo art. 157 do CPP, cujo *caput* aduz que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

Como se vê, a CF/88 e o CPP somente fazem referência à prova ilícita, a qual, segundo o Código, é aquela obtida em violação a normas constitucionais ou legais, pouco importando a natureza das normas violadas, isto é, se de cunho material ou processual.

Todavia, a doutrina distingue as provas ilícitas das provas ilegítimas, o que, repita-se, não foi feito pelo Código e nem pela Carta Magna. Para a doutrina, haveria um gênero "prova ilegal", dentro do qual, como espécies desse gênero, estariam as provas ilícitas e as ilegítimas. As ilícitas são as obtidas "através da violação de regra de direito material (penal ou constitucional)", por exemplo, a confissão obtida através de tortura. Noutro giro, as ilegítimas são aquelas obtidas "mediante violação à norma de direito processual", como ocorre, por exemplo, quando, "ao ouvir determinada testemunha, o magistrado se esqueça de compromissá-la", incorrendo "em violação à regra do art. 203 do CPP" (LIMA, 2020, p. 685-686).

Em provas concursais, portanto, muita atenção ao ponto. O examinador pode cobrar o conceito legal de prova ilícita: aquela obtida em violação a normas constitucionais ou legais, pouco importando a natureza das normas violadas, isto é, se de cunho material ou processual, nos termos do art. 157, *caput*, do CPP. Também pode ser questionada a diferenciação doutrinária entre provas ilícitas e ilegítimas. As primeiras violam normas de direito material, e as segundas desobedecem a regras de direito processual.

Nos termos do art. 157, §3º, do CPP, preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o

incidente. Frise-se, porquanto importante para concursos: as partes podem acompanhar o incidente de inutilização da prova declarada ilícita.

### 1.7.1. ILICITUDE POR DERIVAÇÃO (TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA)

Como visto, as provas ilícitas são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo. Este regramento seria inócuo se tal ilicitude não se estendesse às provas derivadas das ilícitas. Em outras palavras: "de nada adiante dizer que são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos se essa ilicitude também não se estender às provas que dela derivam" (LIMA, 2020, p. 689).

Nesse contexto, as "provas ilícitas por derivação são aquelas que, embora lícitas na própria essência, decorrem exclusivamente de uma outra prova, considerada ilícita, ou de uma situação de ilegalidade, restando, portanto, contaminadas" (AVENA, 2017, p. 330).

Em relação às provas ilícitas por derivação, adotamos, portanto, a "teoria norte-americana dos Frutos da Árvore Envenenada (*fruits of the poisonous tree*), segundo a qual o defeito existente no tronco contamina os frutos" (AVENA, 2017, p. 330), nos termos do art. 157, §1º, do CPP, o qual disciplina que também são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas.

Assim, pela regra dos frutos da árvore envenenada, se uma determinada prova, ainda que obtida por meio lícito, deriva de uma prova ilícita, a ilicitude da primeira contaminará a segunda, devendo haver o desentranhamento das duas.

#### 1.7.1.1. TEORIA OU EXCEÇÃO DA FONTE INDEPENDENTE

Conforme acima estudado, a ilicitude de uma prova implica, em regra, na ilicitude das provas dela derivadas. Contudo, não se pode afirmar que, havendo uma prova ilícita nos autos, todas as demais também o são, já que, como regra, somente estarão contaminadas aquelas que derivam da ilícita. Esse é o teor da teoria ou exceção da fonte independente.

No ponto, muito cuidado com a redação dos §§1º e 2º do art. 157 do CPP, porquanto o legislador fez uma confusão bastante grande entre a teoria da fonte independente e da descoberta inevitável. Confira-se a redação dos citados parágrafos, que, em provas objetivas, deverá ser considerada pelo candidato:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

§ 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

Por definição, a teoria ou exceção da fonte independente é verificada quando, conforme o próprio nome sugere, não há uma relação de dependência entre as provas. É dizer: se, em um determinado processo, no qual existem as provas "A" e "B", que não derivam uma da outra, é declarada a ilicitude da prova "A", somente ela deverá ser desentranhada dos autos, já que a prova "B" não guarda com ela relação de dependência, isto é, não se originou dela. No exemplo, se a prova "B" derivasse da "A", pela regra da ilicitude por derivação, as duas deveriam ser desentranhadas. Contudo, como não há relação de dependência, a prova "B", caso tenha sido obtida por meio lícito, não deve ser retirada dos autos.

Em outras palavras: "de acordo com a teoria ou exceção da fonte independente, se o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova, que não guarde qualquer relação de dependência, nem decorra da prova originariamente ilícita, com esta não mantendo vínculo causal, tais dados

probatórios são admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária" (LIMA, 2020, p. 692).

A teoria ou exceção da fonte independente é extraída do art. 157, §1º, segunda parte, do CPP, o qual aduz que são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Note-se: a teoria ou exceção da fonte independente é aplicável quando não há relação/nexo de causalidade entre as provas dos autos, pelo que se pode concluir que, ainda que haja uma prova ilícita no processo, não necessariamente deverá haver o desentranhamento de todas as provas acostadas aos autos. As que não se originaram da ilícita, isto é, nasceram de outra fonte ("fonte independente"), não serão consideradas ilícitas.

Em resumo (muito importante para fins de diferenciação das teorias da fonte independente e da descoberta inevitável): na teoria ou exceção da fonte independente, as provas, de fato, isto é, no caso concreto, derivaram de fontes autônomas, razão pela qual a ilicitude de uma não contamina a outra.

#### 1.7.1.2. DESCOBERTA INEVITÁVEL (EXCEÇÃO DA FONTE HIPOTÉTICA INDEPENDENTE)

Na teoria da descoberta inevitável, também conhecida como exceção da fonte hipotética independente, ao contrário do que ocorre na teoria ou exceção da fonte independente, há uma relação de causalidade/dependência entre a prova ilícita e a prova obtida por meio lícito, contudo, mesmo assim, a derivada não será considerada ilícita, porquanto, hipoteticamente, poderia ter sido obtida por uma fonte autônoma.

Em outras palavras: "de acordo com a teoria da descoberta inevitável, também conhecida como exceção da fonte hipotética independente, caso se demonstre que a prova derivada da ilícita seria produzida de qualquer modo, independentemente da prova ilícita originária, tal prova deve ser considerada válida" (LIMA, 2020, p. 693).

Como se vê, na teoria da descoberta inevitável, como o próprio nome sugere, a prova seria produzida de qualquer forma, isto é, a autonomia entre as fontes de prova é hipotética. Dito de outra maneira: no caso concreto, as provas guardam relação de dependência, isto é, uma se origina da outra, todavia, a prova derivada, por hipótese, poderia ter sido obtida por outra fonte, por isso tal teoria é também chamada de exceção da fonte hipotética independente.

Assim, se, no caso concreto, ficar demonstrado que a prova derivada de uma prova ilícita já seria colhida por outra fonte, isto é, que a sua descoberta era inevitável, tal elemento não haverá de ser considerado ilícito, ainda que tenha se originado de uma prova ilícita. A teoria em análise, apesar de toda confusão feita pelo legislador, é extraída da parte final do §1º e do §2º do art. 157 do CPP.

A parte final do §1º do art. 157 do CPP normatiza que são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando as derivadas puderem ser obtidas por uma *fonte independente* das primeiras. Frise-se: o legislador chamou de fonte independente o que deveria ter chamado de descoberta inevitável, já que, na fonte independente, não há relação de derivação entre as provas. Nas provas objetivas, como dito, o candidato deverá se atentar à redação utilizada pelo legislador ordinário.

O §2º do art. 157 do CPP diz que fonte independente é aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, *seria* capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Novamente, o legislador fez confusão, já que usou a expressão "seria", isto é, usou um termo atinente à autonomia hipotética da prova, que é a característica marcante da teoria da descoberta inevitável e não da fonte independente.

Em resumo: na teoria ou exceção da fonte independente, a autonomia da prova é concreta, isto é, de fato, as provas foram obtidas de fontes diversas. Na teoria da descoberta inevitável, também chamada de exceção da fonte hipotética independente, a autonomia da prova é hipotética, isto é, não se verificou no caso concreto, já que as provas nasceram umas das outras.

### 1.7.1.3. DESCONTAMINAÇÃO DO JULGADO

O Projeto de Lei nº 4.205, de 2001 (nº 37/07 no Senado Federal), do qual se originou a Lei nº 11.690/08, acrescentou ao art. 157 do CPP o §4º, que tinha a seguinte redação: "O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão", o que era chamado pela doutrina de descontaminação do julgado (LIMA, 2020, p. 705).

De acordo com tal dispositivo, o magistrado (em sentido amplo) que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão, "pois não teria isenção de ânimo suficiente para apreciar o caso concreto com a imparcialidade que dele se espera" (LIMA, 2020, p. 705).

Todavia, essa alteração foi vetada pelo Presidente da República, que se utilizou dos seguintes fundamentos (Mensagem nº 350, de 9 de junho de 2008):

O objetivo primordial da reforma processual penal consubstanciada, dentre outros, no presente projeto de lei, é imprimir celeridade e simplicidade ao desfecho do processo e assegurar a prestação jurisdicional em condições adequadas. O referido dispositivo vai de encontro a tal movimento, uma vez que pode causar transtornos razoáveis ao andamento processual, ao obrigar que o juiz que fez toda a instrução processual deva ser, eventualmente substituído por um outro que nem sequer conhece o caso.

Ademais, quando o processo não mais se encontra em primeira instância, a sua redistribuição não atende necessariamente ao que propõe o dispositivo, eis que mesmo que o magistrado conhecedor da prova inadmissível seja afastado da relatoria da matéria, poderá ter que proferir seu voto em razão da obrigatoriedade da decisão coligada.

O Pacote Anticrime ressuscitou a descontaminação do julgado, já que o §5º do art. 157 do CPP, trazido pela Lei nº 13.964/19, diz que o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão.

Deste modo, com a entrada em vigor do Pacote Anticrime, ao tomar conhecimento de uma prova ilícita, o magistrado, além de determinar seu desentranhamento, deveria se afastar daquele caso concreto.

Todavia, em 15 de janeiro de 2020, a eficácia do citado §5º foi suspensa por liminar do Min. Dias Toffoli, tendo essa decisão sido mantida pelo Min. Luiz Fux no dia 22 de janeiro de 2020, devendo haver o acompanhamento dessa discussão no STF.

## 2. PROVAS EM ESPÉCIE

### 2.1. DO EXAME DE CORPO DE DELITO, DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DAS PERÍCIAS EM GERAL (ARTS. 158 A 184, CPP)

#### 2.1.1. INTRODUÇÃO, CONCEITO, INFRAÇÕES QUE O EXIGEM, ESPÉCIES E LOCAL/HORÁRIO DE REALIZAÇÃO

Conforme art. 158, *caput*, do CPP, quando a infração penal deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Frise-se: a confissão do acusado não pode suprir a falta do exame de corpo de delito.

As infrações penais que deixam vestígios, referidas pelo citado artigo, são chamadas de infrações não transeuntes ou de fato permanente (*delicta facti permanentis*), isto é, os vestígios não transitam. As infrações penais que não deixam vestígios são chamadas de transeuntes ou de fato transeunte (*delicta facti transeuntis*), porquanto os vestígios transitam. Como visto, no caso das primeiras — infrações penais não transeuntes — é obrigatória a realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Nesse contexto, exame de corpo de delito é



a perícia destinada à comprovação da materialidade das infrações que deixam vestígios (v.g., homicídio, lesões corporais, furto qualificado pelo arrombamento, dano etc.). A própria nomenclatura utilizada – “corpo de delito” – sugere o objetivo dessa perícia: corporificar o resultado da infração penal, de forma a documentar o vestígio, perpetuando-o como parte do processo criminal (AVENA, 2017, p. 360).

Não se pode confundir os conceitos de exame de corpo delito, corpo de delito e laudo de exame de corpo de delito. Confirmam-se:

I) EXAME DE CORPO DE DELITO: como dito, o exame de corpo de delito "é uma análise feita por pessoas com conhecimentos técnicos ou científicos sobre os vestígios materiais deixados pela infração penal para comprovação da materialidade e autoria do delito" (LIMA, 2020, p. 727). De acordo com o STF, "o exame de corpo de delito tem por objeto, segundo o art. 158 C. Pr. Penal, os vestígios deixados pela infração tal como concretamente praticado" (STF, HC 78.749/MS, 1ª T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 25/5/1999, DJe de 25/6/1999).

II) CORPO DE DELITO: "é o conjunto de vestígios materiais ou sensíveis deixados pela infração penal. A palavra *corpo* não significa necessariamente o corpo de uma pessoa. Significa sim o conjunto de vestígios sensíveis que o delito deixa para trás, estando seu conceito ligado à própria materialidade do crime" (LIMA, 2020, p. 727). Inclusive, com o Pacote Anticrime, atualmente, há um conceito legal de vestígio, nos termos do art. 158-A, §3º, CPP: Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal;

III) LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO:

é a peça técnica elaborada pelos peritos quando da realização do exame pericial. Subdivide-se em 4 (quatro) partes: a) preâmbulo: qualificação do perito oficial ou dos peritos não-oficiais e do objeto da perícia; b) exposição: narrativa de tudo que é observado pelos *experts*; c) fundamentação: motivos que levaram os *experts* à conclusão final; d) conclusão técnica: resposta aos quesitos (LIMA, 2020, p. 729).

Nos termos do art. 160, parágrafo único, do CPP, o laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos. Frise-se: o laudo de exame de corpo de delito deve ser entregue em, no máximo, 10 dias prorrogáveis.

Ainda de acordo com a redação do art. 158, *caput*, do CPP, o exame de corpo de delito poderá ser direto ou indireto. Em relação ao primeiro — exame de corpo de delito direto —, nenhuma discussão, sendo esse conceituado como o exame "feito por perito oficial (ou dois peritos não oficiais) sobre o próprio corpo de delito", como ocorre, por exemplo, no caso de exame sobre o próprio cadáver localizado (LIMA, 2020, p. 731). Todavia, em relação ao chamado exame de corpo de delito indireto, não há consenso na doutrina.

Uma primeira corrente diz que o exame de corpo de delito indireto "é aquele realizado com base em informações verossímeis fornecidas aos peritos quando não dispuserem estes do vestígio deixado pelo delito" (AVENA, 2017, p. 360), como ocorre, por exemplo, no caso do exame realizado por meio de "fotografias dos vestígios sensíveis ou o prontuário médico do atendimento da vítima no posto de saúde" (LIMA, 2020, p. 731).

Noutro giro, uma segunda corrente diz que o exame de corpo de delito indireto é o "suprimento da perícia pela prova testemunhal em razão do desaparecimento do vestígio" (AVENA, 2020, p. 360).

De acordo com o art. 161 do CPP, o exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora, não necessitando de ordem judicial para ser realizado, nos termos do art. 6º, inciso VII, do CPP.



### 2.1.2. PRIORIDADE NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO

Conforme art. 158, parágrafo único, do CPP, dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva: I - violência doméstica e familiar contra mulher; e II - violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.

Em relação ao inciso II, é importante assentar que nem todo crime contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência terá prioridade na realização do exame de corpo de delito. Para que haja prioridade, o crime deve ser cometido com violência, o que é se mostra bastante importante nas provas concursais de primeira fase.

### 2.1.3. NÚMERO DE PERITOS

Nos termos do art. 159, *caput*, do CPP, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Logo, após a Lei nº 11.690/08, o exame de corpo de delito é realizado por 1 (um) perito oficial somente. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poderá haver a designação de mais de 1 (um) perito oficial (art. 159, §7º, CPP).

Caso não haja perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Isto é: não havendo perito oficial, o exame deverá ser realizado por 2 (dois) peritos não oficiais, os quais obrigatoriamente devem ter diploma de curso superior, de preferência em área relacionada com a natureza do exame. Frise-se: o curso superior é obrigatório, mas a área de formação não necessariamente estará ligada ao exame (art. 159, §1º, CPP).

Na Lei de Drogas, no que diz respeito ao chamado laudo de constatação da natureza e quantidade da droga ("exame preliminar"), a falta de perito oficial é suprida por 1 (uma) pessoa idônea, isto é, por 1 (um) perito não oficial, nos termos do art. 50, §1º, da Lei nº 11.343/06, o que é uma exceção à necessidade de designação de 2 (dois) peritos não oficiais.

Os peritos não oficiais, todas as vezes que forem designados, prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, conforme art. 159, §2º, do CPP, o que não ocorre com o perito oficial, já que este último presta o compromisso somente no momento de sua posse no cargo público. É dizer: os peritos não oficiais prestam o compromisso todas as vezes que forem designados; e o perito oficial, não. Caso não seja tomado o compromisso dos peritos não oficiais, ter-se-á configurada mera irregularidade, não havendo nulidade do laudo (LIMA, 2020, p. 737).

### 2.1.4. AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO

Como dito, se a infração penal deixar vestígios, é obrigatória a realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto. A confissão do acusado não pode suprir o exame, nos termos do art. 158, *caput*, do CPP.

Todavia, conforme art. 167 do CPP, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. É dizer: a confissão do acusado não pode suprir a falta do exame de corpo de delito. Todavia, a prova testemunhal poderá supri-lo.

Nesse sentido, nos termos do art. 564, inciso III, alínea *b*, do CPP, se a infração penal for do tipo não transeunte (ou de fato permanente), caso não seja realizado o exame de corpo de delito (art. 158, *caput*, CPP), haverá nulidade do tipo absoluta, salvo se o exame não tiver sido realizado em razão do desaparecimento dos vestígios, situação na qual a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta (art. 167, CPP).

Logo, se era possível fazer o exame de corpo de delito, isto é, os vestígios não desapareceram, e, mesmo assim, o exame não foi feito, deverá ser reconhecida a nulidade absoluta do processo. Por outro lado, se não era possível fazer o exame de corpo de delito, já que os vestígios



desapareceram, a ausência do exame poderá ser suprida pela prova testemunhal (e não pela confissão), caso em que não haverá nulidade.

#### 2.1.5. DIVERGÊNCIA ENTRE OS PERITOS

Como dito, caso a perícia seja complexa, poderá ser designado mais de 1 (um) perito oficial. Ademais, na falta de perito oficial, o exame deverá ser realizado por 2 (dois) peritos não oficiais.

Nessas hipóteses, se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro; se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos, nos termos do art. 180 do CPP. Frise-se: os peritos não precisam chegar a um consenso acerca do exame.

#### 2.1.6. NÃO ADSTRIÇÃO AO LAUDO

Confirmando o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do Julgador, o art. 182 do CPP diz que o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. Assim, havendo outras provas nos autos, o juiz pode decidir de forma contrária ao resultado do laudo de exame de corpo de delito, desde que fundamente sua decisão.

Na doutrina, essa não adstrição ao laudo é chamada de sistema liberatório. Em contraposição ao sistema liberatório, existe o sistema vinculatório, segundo o qual "o magistrado fica vinculado ao laudo pericial, não podendo decidir de modo a contrariá-lo" (LIMA, 2020, p. 730).

#### 2.1.7. POSSIBILIDADE DE RECUSA À REALIZAÇÃO DE PERÍCIA

Conforme art. 184 do CPP, salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.

Desse modo, à exceção do exame de corpo de delito, que é obrigatório nas infrações penais de fato permanente (não transeuntes), o juiz e/ou o delegado de polícia poderão negar qualquer outra perícia requerida pelas partes. Exemplo: crime de embriaguez ao volante e requerimento de perícia no bafômetro. Se não houver nada que indique alguma irregularidade no aparelho, a perícia pode ser negada.

#### 2.1.8. EXAME PERICIAL POR CARTA PRECATÓRIA

Conforme art. 177, *caput*, do CPP, no exame por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo deprecado. Havendo, porém, no caso de ação privada, acordo das partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juízo deprecante. Em todo caso, os quesitos do juiz e das partes serão transcritos na precatória (art. 177, parágrafo único, CPP).

Desse modo, se o objeto ou o material a ser analisado se encontrar em comarca diversa, o exame pericial deverá ser realizado por intermédio de carta precatória, na qual serão transcritos os quesitos do juiz e das partes.

Em regra, é o juízo deprecado, ou seja, do local da diligência, que nomeia o perito. No entanto, se a ação penal for de iniciativa privada, havendo acordo entre as partes, a nomeação pode ser feita pelo juízo deprecante. É dizer: sempre será o juízo que nomeia o perito e não as partes. No caso da ação penal privada, o acordo é no sentido de que a nomeação se dê no juízo deprecante, mas, mesmo nesse caso, não serão as partes que nomearão os peritos.



### 2.1.9. ASSISTENTE TÉCNICO

A figura do assistente técnico pode ser conceituada como "o perito de confiança das partes, que irá atuar com o fito de ratificar ou infirmar o laudo oficial" (TÁVORA; ALENCAR, p. 664).

Desse modo, o assistente técnico é o "perito das partes", sendo dotado de conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos e responsável por trazer aos autos informações especializadas atinentes ao objeto da perícia (LIMA, 2020, p. 143).

Até o advento do Pacote Anticrime, era bem tranquilo afirmar que a figura do assistente técnico era exclusiva da fase processual da persecução penal. É dizer: nos termos do art. 159, §2º e §5º, inciso II, do CPP, o assistente técnico somente poderia existir "durante o curso do processo judicial".

Todavia, o art. 3º-B, inciso XVI, do CPP, acrescentado ao Código pelo Pacote Anticrime, aduz que compete ao juiz das garantias deferir o pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Assim sendo, considerando que o juiz das garantias somente atua na investigação, nos termos do art. 3º-B, *caput*, do CPP, "forçoso é concluir que, doravante, a admissão do assistente técnico indicado pelas partes poderá se dar desde então, e não mais apenas na fase processual, como ocorria até a entrada em vigor do Pacote Anticrime" (LIMA, 2020, p. 143).

Com a suspensão da eficácia de todos os dispositivos atinentes ao juiz das garantias, a possibilidade de indicação de assistente técnico, durante a investigação, também está suspensa, devendo o leitor acompanhar o tramitar das ações diretas de inconstitucionalidade junto ao STF.

No que diz respeito à sua atuação, importante ressaltar que o assistente técnico não atua em conjunto com o perito oficial ou com os peritos não oficiais. Em verdade, o "perito das partes" atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelo perito ou peritos designados para o caso, sendo as partes intimadas desta decisão, nos termos do art. 159, §4º, do CPP. Frise-se: é necessária decisão judicial autorizando o ingresso do assistente técnico, que somente atuará após a conclusão do laudo.

Contra a decisão judicial que admite ou inadmite o assistente técnico não cabe recurso, "o que não afasta a possibilidade do mandado de segurança (ou *habeas corpus*) manejado como sucedâneo recursal, e a discussão da negativa em preliminar de apelação, alegando-se eventual nulidade por cerceamento do direito de defesa ou de acusação" (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 665).

Inclusive, havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação, conforme art. 159, §6º, do CPP.

Ademais, assim como ocorre com os peritos oficiais, caso a perícia seja complexa, a parte poderá indicar mais de um assistente técnico (art. 159, §7º, CPP).

### 2.1.10. ESCLARECIMENTOS PERICIAIS E FORMULAÇÃO DE QUESITOS

Nos termos do art. 159, §3º, do CPP, serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos ao perito oficial ou aos peritos não oficiais, que, em síntese, são perguntas dirigidas aos *experts*.

Também é facultado às partes, no curso do processo judicial, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar, conforme art. 159, §5º, inciso II, do CPP. Frise-se: para que o perito seja ouvido em juízo, é preciso que seja intimado com antecedência mínima de 10 dias.



### 2.1.11. CADEIA DE CUSTÓDIA

Nos termos do art. 158-A, *caput*, do CPP, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Nesse contexto, por meio da cadeia de custódia, assegura-se

a preservação dos vestígios desde o contato primário até o descarte dos elementos coletados, garantindo-se a sua qualidade através da documentação cronológica dos atos executados em observância às normas técnicas previstas nas etapas da chamada cadeia de custódia (SANCHES, 2020, p. 174-175).

Percebe-se, portanto, que o grande objetivo da preservação da chamada cadeia de custódia é garantir a "autenticidade das evidências coletadas e examinadas, assegurando que correspondem ao caso investigado, sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração" (LIMA, 2020, p. 718).

Nos termos do art. 158-B do CPP, a cadeia de custódia é composta de uma série de atos, variando desde o reconhecimento de um vestígio até o descarte do material coletado. Nesse momento inicial, cremos que os conceitos insertos no art. 158-B do CPP serão cobrados de forma literal, razão pela qual devem ser lidos à inteireza.

Conforme a doutrina, as fases da cadeia de custódia, nos termos do citado art. 158-B do CPP, são divididas em duas:

#### I) FASE EXTERNA:

estão elencadas as etapas relacionadas aos passos entre a preservação do local do crime ou apreensões dos elementos de prova e a chegada do vestígio ao órgão pericial encarregado de processá-lo. Compreende, portanto, a preservação do local do crime, a busca, o reconhecimento (I), o isolamento (II), a fixação (III), a coleta (IV), o acondicionamento (V), o transporte (VI) e o recebimento do vestígio (VII) (SANCHES, 2020, p. 187); e

#### II) FASE INTERNA:

compreende todas as etapas entre o ingresso do vestígio no órgão pericial até a conclusão do laudo e remessa ao órgão requisitante. Envolve as etapas de recepção, conferência, classificação, guarda e/ou distribuição do vestígio, análise pericial propriamente dita (VIII), guarda e devolução do vestígio (IX), guarda de vestígios para contra perícia (X) e o registro da cadeia de custódia (XI) (SANCHES, 2020, p. 188).

O art. 158-C do CPP normatiza que a coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Ademais, fica proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização (art. 158-C, §2º, CPP).

No que diz respeito ao crime de fraude processual (art. 347, CP), alerta a doutrina que não haverá tipicidade na

simples entrada em local isolado, nem mesmo pela mera retirada de vestígios. O crime pressupõe que o agente atue não apenas com dolo de inovar no processo, mas também com a especial finalidade de induzir em erro o juiz ou o perito. Caso não estejam bem identificados o dolo e o elemento subjetivo específico, o fato será um indiferente penal (SANCHES, 2020, p. 193-194).



Outro detalhe importante, que demandará uma reestruturação bastante drástica, é que o legislador exigiu que todos os Institutos de Criminalística possuam uma central de custódia, que será destinada à guarda e controle dos vestígios, sendo a sua gestão vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal (art. 158-E, CPP).

Na central de custódia, deverá haver os serviços de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio (art. 158-E, §1º, do CPP).

Caso haja a movimentação do vestígio, tudo deve ser registrado, isto é, o grande objetivo da cadeia de custódia é conseguir rastrear o que aconteceu com o vestígio desde a sua localização até o seu descarte, garantindo-se que não houve indevida manipulação daquele elemento (art. 158-E, §§2º, 3º e 4º, CPP). Como dito, nesse momento inicial, é de suma importância a leitura dos arts. 158-A a 158-F do CPP.

## 2.2. INTERROGATÓRIO DO RÉU (ARTS. 185 A 196, CPP)

### 2.2.1. INTRODUÇÃO

Interrogatório judicial é o ato processual por meio do qual o juiz ouve o acusado sobre sua pessoa e sobre a imputação que lhe é feita. É a oportunidade que o acusado tem de se dirigir diretamente ao magistrado, quer para apresentar a versão da defesa acerca da imputação que recai sobre a sua pessoa, podendo, inclusive, indicar meios de prova, quer para confessar, ou até mesmo para permanecer em silêncio, fornecendo apenas elementos relativos a sua qualificação (LIMA, 2020, p. 742).

### 2.2.2. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO POR ADVOGADO

Nos termos do art. 185, *caput*, do CPP, o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

Desse modo, o acusado, ao ser interrogado pelo juiz, necessariamente, deverá estar acompanhado de defensor, seja ele constituído ou nomeado, sob pena de nulidade absoluta do ato (LIMA, 2020, p. 748).

Ademais, conforme art. 185, §5º, do CPP, em qualquer modalidade de interrogatório, inclusive por videoconferência, ao interrogando deve ser garantido "o direito de se entrevistar prévia e reservadamente com seu defensor" (LIMA, 2020, p. 747).

### 2.2.3. FASES DO INTERROGATÓRIO

Conforme visto no conceito inicial, nos termos do art. 187, *caput*, do CPP, o interrogatório é composto de duas fases (uma sobre a pessoa do acusado e outra sobre os fatos):

I) PREGRESSAMENTO: na primeira parte, o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais (art. 187, §1º, CPP). Nessa primeira parte, não há o direito de permanecer calado ou de falsear a verdade, podendo o interrogando responder criminalmente por tais atos.

Ademais, do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa (art. 185, §10, CPP).

II) **IMPUTAÇÃO**: na segunda parte, será perguntado sobre: I - ser verdadeira a acusação que lhe é feita; II - não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime, e quais sejam, e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela; III - onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta; IV - as provas já apuradas; V - se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem o que alegar contra elas; VI - se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido; VII - todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração; VIII - se tem algo mais a alegar em sua defesa (art. 187, §2º, CPP).

Na segunda fase, isto é, em relação aos fatos, o interrogando tem o direito de permanecer em silêncio e de não responder a nenhuma das perguntas que lhe forem feitas. Ademais, não será responsabilizado criminalmente por falsear a verdade.

Quanto ao ponto, muito cuidado deve se ter com as chamadas mentiras agressivas, que poderão implicar em responsabilização criminal do interrogando. Como visto, o réu, em regra, não será responsabilizado criminalmente por mentir em seu interrogatório, isto é, poderá se valer das chamadas mentiras defensivas: o réu, em seu interrogatório, pode inventar qualquer história, por mais fantasiosa que seja, contudo, não pode incriminar terceira pessoa ou falsamente assumir a autoria delitiva.

Portanto, não é direito do interrogando incriminar terceira pessoa ou de falsamente assumir a autoria delitiva, o que é chamado pela doutrina de mentiras agressivas, isto é, o réu, em seu interrogatório, incrimina terceira pessoa ou assume a autoria de crime que não cometeu, podendo ser responsabilizado pelos crimes insertos nos arts. 339 (denúnciação caluniosa) e 341 (autoacusação falsa), ambos do Código Penal.

#### 2.2.4. ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO

Nos termos do art. 186, *caput*, do CPP, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.

Assim sendo, após a fase do pregressamento, o juiz deve alertar ao interrogando sobre seu direito de permanecer em silêncio, o qual não importará em confissão e nem poderá ser interpretado em seu prejuízo (art. 186, parágrafo único, CPP).

Caso o juiz não advirta o réu quanto ao direito ao silêncio, ter-se-á configurada, tão somente, nulidade relativa, cuja declaração depende da comprovação do prejuízo<sup>13</sup>.

Em virtude da inexistência da advertência ao direito ao silêncio, é nula a “entrevista” realizada pela autoridade policial com o investigado, durante a busca e apreensão em sua residência, sem que tenha sido assegurado ao investigado o direito à prévia consulta a seu advogado e sem que ele tenha sido comunicado sobre seu direito ao silêncio e de não produzir provas contra si mesmo. Na visão da jurisprudência, tal ato se trata, em verdade, de um “interrogatório travestido de entrevista”, havendo violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação<sup>14</sup>.

De mais a mais, se o réu tem o direito de permanecer em silêncio, por óbvio, o exercício desse direito não pode lhe prejudicar, porquanto, caso o exercício de um direito acarrete prejuízo, em verdade, não se trata de um direito. Por essa razão, a parte final do art. 198 do CPP (“O silêncio do acusado não importará confissão, *mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz*”) não foi recepcionada pela CF/88.

<sup>13</sup>RHC 96.396/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018.

<sup>14</sup>STF. 2ª Turma. Rcl 33711/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/6/2019 (Info. 944).



### 2.2.5. MOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO

Como forma de garantir a ampla defesa, isto é, para que o réu somente seja ouvido após todas as demais provas terem sido carreadas aos autos, a jurisprudência entende que o interrogatório deve ser o último da instrução processual penal, nos termos do art. 400 do CPP, inclusive em relação a procedimentos especiais previstos em legislações esparsas, como ocorre, por exemplo, com a Lei de Drogas (STJ, Info. 609).

De toda a forma, o interrogatório é um ato não preclusivo, isto é, a todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes, nos termos do art. 196 do CPP. Inclusive, em grau recursal, no julgamento das apelações, poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado (art. 616, CPP).

Em relação à possibilidade de o juiz, de ofício, determinar novo interrogatório judicial, nos moldes do art. 196 do CPP, assim como dissemos em relação aos incisos do art. 156 do mesmo Código, a doutrina se debaterá acerca do tema, devendo a discussão ser acompanhada pelo leitor.

Como estudado em tópico acima, o Professor Renato Brasileiro de Lima advoga pela revogação tácita dos incisos do art. 156 do CPP, razão pela qual, em sua visão, qualquer iniciativa probatória de ofício pelo juiz estaria vedada. Logo, para ele, não há mais a possibilidade de o juiz determinar novo interrogatório de ofício, nos termos do art. 3º-A do mesmo Código.

Em contrapartida, conforme visto, há uma posição doutrinária no sentido de que a vedação à iniciativa probatória do juiz somente se aplica à fase de investigação. Assim, para essa corrente, remanesce a possibilidade de o juiz determinar novo interrogatório de ofício.

### 2.2.6. FACULDADE DE PERGUNTAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA

Nos termos do art. 188 do CPP, após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante.

Desse modo, no procedimento comum, o interrogatório, que é um ato personalíssimo, isto é, envolve o juiz e a pessoa do acusado, é regido pelo sistema presidencialista ou presidencial. É dizer: após fazer suas perguntas ao réu, o juiz questiona às partes se não restou esclarecido algum fato. Com base nas respostas das partes, o juiz, se entender pertinente e relevante, fará novas perguntas ao réu. Frise-se: no procedimento comum, "as intervenções realizadas ao interrogado pelas partes deverão ser feitas por intermédio do juiz, o qual poderá indeferir determinadas perguntas se as entender impertinentes (sem nenhuma relação com o fato investigado) ou irrelevantes (relativas ao fato apurado, mas sem nenhuma importância no respectivo esclarecimento)" (AVENA, 2017, p. 378).

Noutro giro, na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, em relação às partes, a situação muda. Conforme art. 474, §1º, do CPP, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular, diretamente, perguntas ao acusado. No que diz respeito aos Jurados, o sistema presidencialista ou presidencial é mantido, já que, nos termos do art. 474, §2º, do CPP, estes formularão perguntas por intermédio do juiz presidente.

### 2.2.7. INTERROGATÓRIO DE CORRÉUS

Conforme art. 191 do CPP, havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente, sendo o interrogatório, portanto, gravado pela característica da individualidade, "não sendo possível sequer que um assista ao interrogatório do outro, mesmo que já tenha sido interrogado" (AVENA, 2017, p. 378).

## 2.2.8. INTERROGATÓRIO DO RÉU PRESO

De acordo com o art. 185, §1º, do CPP, o interrogatório do réu preso será realizado, em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. Frise-se: a regra é que o interrogatório do réu preso se dê no próprio estabelecimento prisional em que o interrogando estiver recolhido. Como será visto, a condução do preso ao Fórum, pela lei, é a última opção. Tendo em vista que, na prática, isso não se verifica; muita atenção nas provas de concurso, já que o examinador perguntará as regras legais.

Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades (art. 185, §2º, CPP):

- I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosas ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;
- II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;
- III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código (o art. 217, *caput*, do CPP será analisado no tópico referente à prova testemunhal);
- IV - responder à gravíssima questão de ordem pública.

Desse modo, como medida excepcional, o juiz, de ofício ou a requerimento, poderá determinar o interrogatório por videoconferência, desde que tal medida seja necessária, devendo as partes serem intimadas da decisão que determinar a realização do interrogatório por videoconferência com 10 dias de antecedência (art. 185, §3º, CPP).

Nos termos do art. 185, §8º, do CPP, a videoconferência poderá ser usada para a realização de outros atos processuais diversos do interrogatório, tais como acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, inquirição de testemunha ou tomada de declarações do ofendido, o que tem sido questionado em provas de primeira fase.

Por fim, não sendo possível a realização do interrogatório no próprio estabelecimento prisional e não estando preenchidos os requisitos da videoconferência, será requisitada a apresentação do réu preso em juízo (art. 185, §7º, CPP).

## 2.2.9. ORALIDADE DO INTERROGATÓRIO

O interrogatório é gravado pela característica da oralidade, isto é, as perguntas e as respostas são emanadas de forma oral. Contudo, diante de suas peculiaridades, aos surdos, mudos e surdos-mudos, aplicam-se as regras do art. 192 do CPP. Confirmam-se:

Art. 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pela forma seguinte:

- I - ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele responderá oralmente;
- II - ao mudo as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito;
- III - ao surdo-mudo as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo modo dará as respostas.

Parágrafo único. Caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá no ato, como intérprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo.

Portanto,

no caso de surdez, serão as perguntas submetidas ao acusado por escrito, que as responderá oralmente; na hipótese de mudez, serão as perguntas realizadas oralmente, e respondidas por escrito pelo interrogando; se, por fim, surdo-mudo o réu, as perguntas e respostas serão realizadas por escrito (AVENA, 2017, p. 382).

#### 2.2.10. DESIGNAÇÃO DE INTÉRPRETE

Nos termos do art. 193, do CPP, se o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete, ainda que o juiz e os demais presentes na audiência falem o idioma estrangeiro.

### 2.3. CONFISSÃO (ARTS. 197 A 200, CPP)

#### 2.3.1. INTRODUÇÃO

A confissão é o "reconhecimento pelo réu da imputação que lhe foi feita por meio da denúncia ou da queixa-crime" (AVENA, 2017, p. 386). Nos termos do art. 190 do CPP, caso o réu confesse a prática delitiva, será perguntado sobre os motivos e circunstâncias do fato e se outras pessoas concorreram para a infração, e quais sejam.

Em consonância com o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do Julgador, o valor da confissão é relativo, isto é, se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância (art. 197 do CPP). É dizer: se a confissão não for corroborada por outros elementos de prova, o caso é de absolvição, já que, no sistema acusatório, a confissão não é a "rainha das provas" e não há hierarquia de provas.

Como dito, o silêncio do réu não importa em confissão e não poderá, de nenhuma forma, nem mesmo na dosagem de pena, prejudicar o acusado, não sendo recepcionada a parte final do art. 198 do CPP ("O silêncio do acusado não importará confissão, *mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz*").

No processo penal, a revelia do acusado não importa em reconhecimento dos fatos (confissão ficta), sendo seu único efeito, nos termos do art. 367 do CPP, o prosseguimento do feito sem a presença do acusado, que não será mais intimado dos atos processuais, à exceção da sentença, conforme art. 392 do CPP. É dizer: o réu revel, que tem capacidade recursal autônoma, deverá ser intimado da sentença, o que não ocorre em relação aos demais atos processuais.

#### 2.3.2. CARACTERÍSTICAS DA CONFISSÃO

A confissão, que é um personalíssimo, isto é, deve "ser realizada pelo próprio réu, não se admitindo seja feita por interposta pessoa, como o defensor e o mandatário", é também um ato divisível e retratável, nos termos do art. 200 do CPP (AVENA, 2017, p. 386).

Pela característica da divisibilidade, "o juiz pode considerar verdadeira uma parte da confissão e inverídica outra parte, não sendo obrigado a valorar a confissão como um *todo*" (AVENA, 2017, p. 387).

Noutro giro, pela característica da retratabilidade, "é perfeitamente possível que o acusado, após confessar o fato delituoso, resolva se retratar", isto é, afirmar que, em verdade, não cometeu o fato a ele imputado (LIMA, 2020, p. 761).

#### 2.3.3. ESPÉCIES DE CONFISSÃO

A par de diversas outras espécies trazidas pela doutrina, quatro classificações se mostram relevantes para as provas de concursos:

I) CONFISSÃO FICTA: "ocorre quando o acusado não contesta os fatos que lhe são imputados. No âmbito do processo penal, em virtude da regra probatória que deriva do princípio da presunção de inocência, não há falar em confissão ficta" (LIMA, 2020, p. 760);

II) CONFISSÃO DELATÓRIA: "também conhecida como chamamento de corréu ou delação premiada, ocorre quando o acusado confessa a prática do fato delituoso e delata coautores e partícipes" (LIMA, 2020, p. 760-761);

III) CONFISSÃO SIMPLES: "ocorre quando o acusado confessa a prática do fato delituoso, porém não invoca qualquer excludente da ilicitude ou da culpabilidade em seu benefício" (LIMA, 2020, p. 760); e

IV) CONFISSÃO QUALIFICADA: "ocorre quando o acusado confessa a prática do fato delituoso, mas alega que o praticou acobertado por uma excludente da ilicitude ou da culpabilidade" (LIMA, 2020, p. 760).

No que diz respeito à confissão qualificada, é importante assentar o teor da Súmula nº 545 do STJ, segundo a qual "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal". É dizer: ainda que o acusado alegue que praticou o fato acobertado por uma excludente da ilicitude ou da culpabilidade, caso sua confissão qualificada tenha sido utilizada na formação do convencimento do magistrado, será o réu merecedor da atenuante inserta no artigo 65, inciso III, alínea d, do CP, que deverá incidir na segunda fase da dosimetria de pena.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, a Súmula nº 630 do STJ aduz que "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". É dizer: o acusado, no crime de tráfico, somente se beneficiará da atenuante da confissão espontânea se confessar que a droga era destinada à difusão ilícita. Caso somente assuma a propriedade ou posse da substância, não haverá a incidência da referida circunstância atenuante.

#### 2.4. DECLARAÇÕES DO OFENDIDO (ART. 201, CPP)

Nos termos do art. 201, *caput*, do CPP, sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações.

O ofendido é "o sujeito passivo da infração penal, aquele que sofreu diretamente a violação da norma penal", tendo suas declarações a finalidade de "trazer para dentro do processo a versão prestada pela vítima da infração penal" (AVENA, 2017, p. 391).

A vítima, como se vê, não se confunde com a figura das testemunhas, razão pela qual não é computada no número máximo de testemunhas que cada parte pode arrolar, não presta o compromisso legal de dizer a verdade e não está sujeita ao cometimento do crime de falso testemunho (art. 342, CP).

Embora não preste o compromisso legal de dizer a verdade, a palavra da vítima reveste-se de importante valor probatório, mormente em crimes cometidos às escondidas, isto é, sem testemunhas, como ocorre, no mais das vezes, no caso de crimes sexuais<sup>15</sup>.

Conforme art. 201, §1º, do CPP, se o ofendido, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, poderá ser conduzido à presença da autoridade. Frise-se: o STF, no julgamento das ADPF de nº 395/DF e 444/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, somente proibiu a

<sup>15</sup>AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/6/2015, DJe 17/6/2015.

condução coercitiva do investigado ou do réu para o ato de interrogatório, conforme será visto, com mais detalhes, no capítulo atinente aos sujeitos do processo. Em relação ao ofendido, ainda se mostra possível a sua condução coercitiva.

Conforme art. 201, §2º, do CPP, o ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem, o que, por opção da vítima, poderá ocorrer por meio eletrônico (art. 201, §3º, do CPP).

Objetivando que o ofendido não tenha contato físico/visual com o acusado, antes do início da audiência e durante a sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido. Em relação ao art. 217, *caput*, do CPP, este será analisado no tópico referente à prova testemunhal.

No mesmo sentir, o juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação (art. 201, §6º, CPP).

Por fim, tendo em vista os nefastos efeitos que a infração penal pode causar à vítima, se o juiz entender necessário, poderá encaminhá-la para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado (art. 201, §5º, CPP).

## 2.5. TESTEMUNHAS (ARTS. 202 A 225, CPP)

### 2.5.1. INTRODUÇÃO E CAPACIDADE PARA SER TESTEMUNHA

Testemunha "é a pessoa que declara ter tomado conhecimento de algo, podendo, pois, confirmar a veracidade do ocorrido, agindo sob o compromisso de ser imparcial e dizer a verdade", sendo, no processo penal, mais um meio de prova, assim como ocorre com a confissão, a prova documental, pericial, dentre outros (NUCCI, 2016, p. 276).

Tema bastante recorrente em provas concursais diz respeito à capacidade para ser testemunha. No âmbito do processo penal, nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha. Frise-se: no processo penal, toda pessoa poderá ser testemunha, pouco importando a sua capacidade civil, podendo ser arrolados como testemunhas os menores de 18 (dezoito) anos, doentes e deficientes mentais (LIMA, 2020, p. 763-764).

### 2.5.2. CARACTERÍSTICAS DA PROVA TESTEMUNHAL

#### 2.5.2.1. ORALIDADE

A regra geral, nos termos do art. 204, *caput*, do CPP, é que o depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. Isto é, a testemunha deve prestar o seu relato de forma oral, sendo-lhe permitido, contudo, breve consultas a apontamentos, conforme art. 204, parágrafo único, do CPP.

Todavia, excetuando a regra geral da oralidade, o art. 221, §1º, do CPP, permite que as mais altas autoridades da República prestem seu testemunho por escrito. É dizer: conforme o citado dispositivo legal, o Presidente e o Vice-Presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas, formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz, lhes serão transmitidas por ofício. Frise-se: algumas autoridades, isto é, o Chefe e Subchefe do Poder Executivo Federal, os Chefes do Poder Legislativo Federal e do Poder Judiciário poderão optar por, caso sejam testemunhas, prestar seu depoimento por escrito.

Importante frisar que o dispositivo acima mencionado não se confunde com o inserto no art. 221, *caput*, do CPP, o qual permite que várias autoridades (rol muito mais amplo) possam ajustar previamente com juiz o local, dia e hora em que serão ouvidas.

É dizer: nos termos do art. 221, *caput*, do CPP, o Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estados e Territórios, os secretários de Estado, os prefeitos dos Municípios, os deputados às Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz.

Note-se, nesse sentido, que o rol é muito maior do que o referente às autoridades que podem testemunhar por escrito, o qual, como visto, está restrito à cúpula da República.

As autoridades arroladas no art. 221, *caput*, do CPP, à exceção daquelas que também estão no §1º, somente têm a prerrogativa de ajustar o local, dia e hora em que serão ouvidas. É dizer: o seu testemunho será oral.

De mais a mais, também excepcionando a regra da oralidade, nos termos do art. 223, parágrafo único, do CPP, tratando-se de mudo, surdo ou surdo-mudo, proceder-se-á na conformidade do estudado art. 192 do mesmo Código. Isto é: no caso de surdez, serão as perguntas submetidas à testemunha por escrito, que as responderá oralmente; na hipótese de mudez, serão as perguntas realizadas oralmente, e respondidas por escrito pela testemunha; se, por fim, surda-muda a testemunha, as perguntas e respostas serão realizadas por escrito.

#### 2.5.2.2. OBJETIVIDADE

Nos termos do art. 213 do CPP, o juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, *salvo* quando inseparáveis da narrativa do fato. Isto é: quando não for possível separar as apreciações pessoais da narrativa do fato, a testemunha poderá externá-las, como ocorre, por exemplo, "em um crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando a testemunha relata a suposta velocidade em que se encontrava o veículo dirigido pelo acusado. Nesse caso, não há como afastar sua apreciação subjetiva" (LIMA, 202, p. 764).

#### 2.5.2.3. RETROSPECTIVIDADE

Por óbvio, "a testemunha prestará depoimento sobre fatos passados, jamais sobre fatos futuros, sendo vedados, por exemplo, depoimentos de videntes, cartomantes etc.". Como exceção, isto é, podendo a testemunha projetar o futuro, a doutrina aponta o depoimento que tenha por objetivo fornecer ao Julgador informações técnicas. Por exemplo: "acusado de lesão corporal grave, buscando a desclassificação de seu delito, arrola, como testemunha especialista em ortopedia, o qual, exibidas radiografias do corpo da vítima, afirma, perante o juiz, que, com tratamento adequado, poderá ela recuperar a plenitude do movimento de membro em determinado período" (AVENA, 2017, p. 400).

#### 2.5.2.4. INDIVIDUALIDADE E INCOMUNICABILIDADE

Nos termos do art. 210, *caput*, primeira parte, do CPP, as testemunhas serão inquiridas cada uma de *per si*, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo ser reservados, antes do início da audiência e durante a sua realização, espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas (art. 210, parágrafo único, do CPP).

#### 2.5.3. DEVERES DAS TESTEMUNHAS

##### 2.5.3.1. DEVER DE DEPOR

Como dito, nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha. Conforme art. 206, primeira parte, do CPP, a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. É dizer: no processo penal, a regra geral é que toda e qualquer pessoa poderá ser arrolada como testemunha e não poderá se afastar da obrigação de depor.



Excepcionando a regra da obrigatoriedade de prestar depoimento, a segunda parte do art. 202 do CPP diz que, via de regra, poderão se recusar a depor o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado. Note-se: devido à proximidade com o réu (e não com a vítima), o CPP autoriza que determinadas pessoas se abstenham de depor.

Todavia, o próprio Código "excepciona a exceção". Isto é, nos termos da parte final do art. 202 do CPP, quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias, as pessoas acima arroladas voltam a ter a obrigação de depor, sem, contudo, prestarem o compromisso legal de dizer a verdade (art. 208 do CPP — é o que a doutrina chama de informantes).

Em resumo: I) toda pessoa pode ser testemunha; é obrigada a depor e presta o compromisso legal de dizer a verdade; II) algumas pessoas, devido à proximidade com o réu, podem se recusar a depor; e III) caso haja a necessidade dessas pessoas serem ouvidas, estarão elas obrigadas a depor, contudo, não prestarão o compromisso legal de dizer a verdade.

Por exemplo: o pai do réu pode ser arrolado como testemunha, já que toda pessoa pode ser testemunha. Em regra, ele poderá se recusar a depor. Contudo, se o pai do réu é a única testemunha do fato, terá ele a obrigação de depor, mas não prestará o compromisso legal de dizer a verdade.

Noutro giro, há pessoas que são proibidas de depor, isto é, não poderão ser arroladas como testemunhas, nos termos do art. 207 do CPP, o qual dispõe que são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Frise-se: se isso ocorrer, tais pessoas prestarão o compromisso legal de dizer a verdade, já que não estão excetuadas pelo art. 208 do CPP (AVENA, 2017, p. 401).

Nesse contexto, somente se a parte interessada autorizar e a pessoa quiser dar o seu testemunho, é que as pessoas inicialmente proibidas de depor poderão prestar o seu testemunho. Exemplo: João confessa ao padre que matou José. Se João autorizar e o padre quiser, poderá o religioso prestar o seu testemunho.

### 2.5.3.2. DEVER DE COMPARECIMENTO

Nos termos do arts. 218 e 219 do CPP, tendo sido "regularmente notificada para depor, a testemunha tem obrigação de comparecer a juízo sob pena de condução coercitiva, pagamento das despesas da condução, multa e, até mesmo, processo criminal por desobediência" (AVENA, 2017, p. 400).

Por oportuno, deve ser rememorado que, nos termos do art. 221, *caput*, do CPP, várias autoridades têm a prerrogativa de ajustar previamente com o juiz o local, data e hora em que serão ouvidas, logo, para elas, não há essa obrigação de comparecimento ao juízo.

De mais a mais, conforme foi dito em relação ao ofendido, ainda se mostra possível a condução coercitiva da testemunha. Repita-se: o que o STF afastou foi a condução coercitiva do investigado/acusado para o ato de interrogatório.

Logicamente, não estarão obrigadas a comparecerem e nem se sujeitarão à condução coercitiva, as pessoas que, por enfermidade ou por velhice, não puderem fazê-lo, devendo haver a inquirição dessas pessoas no local onde se encontrarem (art. 220, CPP).

### 2.5.3.2.1. CARTA PRECATÓRIA

Nos termos do art. 222, *caput*, do CPP, a testemunha que morar fora da jurisdição do juiz, no território nacional, será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes.

Conforme assenta a Súmula nº 273 do STJ, muito cobrada em concursos, "intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no



juízo deprecado". Frise-se: o juízo deprecante, isto é, que expediu a carta precatória, somente tem a obrigação de intimar as partes quanto à expedição da carta precatória. Não compete ao juízo deprecante intimar as partes quanto à data da audiência designada no juízo deprecado.

Ademais, nos termos da Súmula nº 155 do STF, que também é bastante recorrente em provas concursais, "é relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha". É dizer: o juízo deprecante tem a obrigação de intimar as partes quanto à expedição de carta precatória. Contudo, se não o fizer, verificar-se-á, tão somente, nulidade do tipo relativa, devendo a parte argui-la no momento oportuno e provar o prejuízo.

Em relação à presença do réu no juízo deprecado, duas situações devem ser analisadas. Caso ele esteja solto, tem a opção de comparecer ou não ao ato. Se o acusado estiver preso e solicitar sua presença no ato, de acordo com o STF, a ele deve ser garantido o direito de presença. Todavia, se o réu preso, devidamente intimado da expedição da carta precatória, não requereu o comparecimento, não há falar em nulidade do ato (LIMA, 2020, p. 768).

Conforme art. 222, §1º, do CPP, a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. Isto é: expedida a carta precatória, caso esta não retorne no prazo razoável fixado pelo juízo deprecante, este poderá proferir a sentença, ainda que a diligência não tenha sido cumprida. A todo tempo, uma vez devolvida, a precatória será juntada aos autos (art. 222, §2º, CPP).

Nos termos do art. 222, §3º, do CPP, caso a testemunha resida fora da jurisdição do juiz, sua oitiva poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento.

#### 2.5.3.2.2. CARTA ROGATÓRIA

Caso a testemunha resida em outro país, sua oitiva se dará por intermédio de carta rogatória, que somente será expedida se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio, nos termos do art. 222-A, *caput*, do CPP.

De acordo com o art. 222-A, parágrafo único, do CPP, assim como ocorre em relação às cartas precatórias, a expedição da carta rogatória não suspenderá a instrução criminal. A todo tempo, uma vez devolvida, a rogatória será juntada aos autos.

#### 2.5.3.3. DEVER DE DIZER A VERDADE

Nos termos do art. 203 do CPP, em regra, a pessoa arrolada como testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Isto é: "deve dizer o que sabe, não pode se calar sobre o que sabe, nem pode negar a verdade ou declarar fato inverídico" (LIMA, 2020, p. 769).

Todavia, há pessoas que, mesmo arroladas como testemunhas, não prestarão o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do art. 208 do CPP, o qual dispõe que não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 (quatorze) anos, nem às pessoas a que se refere o art. 206. Para fins didáticos, destrincha-se tal dispositivo. É dizer: não serão compromissados:

I) doentes mentais;

II) deficientes mentais;

III) menores de 14 (quatorze) anos. Frise-se: os menores de 14 (quatorze) anos podem ser testemunhas, já que toda pessoa pode. Contudo, serão ouvidos sem o compromisso legal de dizer a verdade; e

IV) ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, quando forem obrigados a depor, isto é,

quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.

#### 2.5.3.3.1. FALSO TESTEMUNHO

Nos termos do art. 342, *caput*, do Código Penal, cometerá o crime de falso testemunho ou falsa perícia o agente que fizer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral. A pena abstratamente cominada é de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Muito se discute se a ausência da tomada do compromisso legal de dizer a verdade tem o condão ou não de afastar a tipicidade do crime de falso testemunho. Embora haja forte corrente doutrinária em sentido contrário, os Tribunais Superiores têm se posicionado no sentido de que a tomada do compromisso é mera formalidade, havendo a tipicidade do crime de falso testemunho, ainda que não seja concretizado tal ato (LIMA, 2020, p. 769).

Caso o crime de falso testemunho tenha ocorrido na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, é imperioso que o Conselho de Sentença se pronuncie expressamente sobre a questão por meio de quesito especial, já que a resposta positiva dos Jurados ao referido quesito constitui verdadeira condição de procedibilidade da ação penal do crime de falso testemunho ocorrido no âmbito do Tribunal do Júri<sup>16</sup>.

#### 2.5.3.3.2. NÃO EXIGÊNCIA DE AUTOINCRIMINAÇÃO

Como dito, a testemunha tem o dever legal de dizer a verdade e de responder a todas as perguntas que lhe forem formuladas. Todavia, não é obrigada a produzir provas contra si mesma. É dizer: ainda que arrolada como testemunha, se a pessoa perceber que sua resposta poderá lhe autoincriminar, terá ela o direito a não responder àquele questionamento.

Assim, não importa o rótulo que se dê àquela pessoa, testemunha ou acusado, se a perguntar puder lhe autoincriminar, ela poderá se calar e não responder àquela pergunta em específico<sup>17</sup>.

#### 2.5.4. PRESENÇA DO RÉU GERANDO CONSTRANGIMENTO À VÍTIMA OU À TESTEMUNHA

Nos termos do art. 217, *caput*, do CPP, se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor. Qualquer medida adotada pelo juiz deverá constar do termo de audiência, assim como os motivos que a determinaram (art. 217, parágrafo único, CPP).

Desse modo, caso o juiz verifique que a presença do réu na sala de audiência poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, sua primeira opção é a oitiva da vítima ou testemunha por intermédio de videoconferência. É dizer: a retirada do réu da sala de audiência não é a primeira opção, o que recorrentemente é cobrado em provas de primeira fase.

Caso não seja possível a realização da oitiva da vítima ou da testemunha por videoconferência, o juiz determinará a retirada do réu da sala de audiência, prosseguindo na inquirição, com a presença de seu defensor.

<sup>16</sup>RHC 102.791/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 27/6/2019.

<sup>17</sup>HC 83.703, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 18/12/2003, Plenário, DJ de 23/4/2004.

### 2.5.5. FORMA DE INQUIRÇÃO DAS TESTEMUNHAS

Nos termos do art. 212, *caput*, do CPP, as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Caso algum ponto não tenha sido esclarecido, o juiz poderá complementar a inquirição (art. 212, parágrafo único, CPP).

Nota-se, nesse sentido, que as partes poderão formular perguntas diretamente à testemunha, ficando afastado o sistema presidencialista ou presidencial, já que as partes não fazem as perguntas por intermédio do juiz. Em outras palavras: as partes perguntam à testemunha, sendo dado ao juiz, tão somente, indeferir aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Se o magistrado entender que determinado ponto não foi esclarecido, poderá fazer novas perguntas à testemunha.

A testemunha, primeiramente, responderá às perguntas de quem a arrolou (*direct-examination* — se a testemunha, por exemplo, é somente da Defesa, o defensor deverá perguntar primeiro). Em seguida, será questionada pela parte contrária, isto é, pela parte que não a arrolou (*cross-examination*), cabendo ao magistrado, quando das perguntas das partes, apenas decidir sobre a admissibilidade dos questionamentos. Caso queira, o juiz poderá complementar a inquirição daquela testemunha (LIMA, 2020, p. 779).

Caso haja inversão da ordem, isto é, o juiz pergunte primeiro ou a parte que não arrolou a testemunha pergunte primeiro, de acordo com o STJ, ter-se-á configurada nulidade do tipo relativa, devendo a parte alegá-la em momento oportuno e provar o prejuízo, sob pena de preclusão (AVENA, 2017, p. 406).

Na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, as partes também perguntam diretamente à testemunha (art. 473, *caput*, do CPP). Contudo, os Jurados fazem suas perguntas por intermédio do juiz presidente, nos termos do art. 473, §2º, do CPP (sistema presidencialista ou presidencial).

### 2.5.6. MOMENTO ADEQUADO PARA INDICAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS

Sob pena de preclusão, isto é, de perder o direito de arrolar testemunhas, a acusação (Ministério Público ou querelante) deverá fazê-lo na peça acusatória (denúncia ou queixa-crime), nos termos do art. 41 do CPP. A Defesa, por sua vez, deverá indicar suas testemunhas na resposta à acusação, conforme art. 396-A, *caput*, do mesmo Código<sup>18</sup>.

### 2.5.7. ESPÉCIES DE TESTEMUNHAS

A doutrina traz uma série de classificações das testemunhas, destacando-se as seguintes:

#### I) TESTEMUNHA REFERIDA:

é aquela que, embora não tenha sido arrolada nos momentos ordinários (denúncia ou queixa, para acusação; resposta à acusação, para o réu), poderá ser inquirida pelo juiz *ex officio* ou a requerimento das partes em razão de ter sido citada por uma outra testemunha, chamada de referente (art. 209, § 1.º, do CPP). De acordo com o art. 401, § 1.º, do CPP, esta categoria não é considerada para efeito de contagem do número máximo de testemunhas admitido em cada procedimento penal (AVENA, 2017, p. 395);

#### II) TESTEMUNHA JUDICIAL:

<sup>18</sup> AgRg no HC 270.814/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019.



considera-se aquela inquirida pelo juiz independentemente de ter sido arrolada por qualquer das partes ou de ter sido requerida a sua oitiva. Neste caso, a inquirição *ex officio* fundamenta-se no poder-dever que assiste ao magistrado de, buscando a verdade real, determinar as providências necessárias para esclarecer as dúvidas que porventura tiver. Tratando desta espécie de prova testemunhal, estabelece o art. 209 do CPP que 'o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes' (AVENA, 2017, p. 395);

Apesar dessas duas primeiras classificações doutrinárias, à luz do Pacote Anticrime, é preciso acompanhar a evolução da doutrina/jurisprudência quanto à iniciativa probatória do juiz. Como já dissemos, há corrente no sentido de que toda e qualquer iniciativa probatória do juiz restou obstada pelo art. 3º-A do CPP, razão pela qual o juiz não poderia, de ofício, determinar a oitiva da chamada testemunha referida e/ou judicial. Por outro lado, na ótica de uma segunda corrente, considerando que a iniciativa probatória do juiz somente restou vedada na fase de investigação, o juiz, na ação penal, de ofício, poderia determinar tais diligências.

III) TESTEMUNHA PRÓPRIA: "é a testemunha chamada para ser ouvida sobre o fato objeto do litígio, seja porque os tenha presenciado, seja porque deles ouviu dizer" (AVENA, 2017, p. 395);

IV) TESTEMUNHA IMPRÓPRIA, INSTRUMENTÁRIA, INSTRUMENTAL OU FEDATÁRIA:

é a que prestará depoimento sobre fatos que não se referem diretamente ao mérito da ação penal. Neste caso, a testemunha não estará depondo sobre algo que presenciou ou soube ter ocorrido, e sim sobre um ato da persecução criminal que tenha assistido ou participado. É o caso, por exemplo, da testemunha que presenciou a apresentação de um preso em flagrante (art. 304, § 2.º, do CPP); a testemunha que esteve presente na audiência em que o interrogado confessou o crime espontaneamente, sem nenhuma coação; a testemunha que presenciou a apreensão de objeto realizada pela autoridade policial em diligência de busca (art. 245, § 7.º, do CPP) etc. (AVENA, 2017, p. 395);

V) TESTEMUNHA NUMERÁRIA: "são aquelas que são computadas para efeito de aferição do número máximo de testemunhas legalmente permitido, ou seja, as arroladas pelas partes e que prestam compromisso legal" (LIMA, 2020, p. 770). As testemunhas compromissadas também são chamadas de depoentes;

VI) TESTEMUNHAS EXTRANUMERÁRIAS:

não são computadas para efeito de aferição do número máximo de testemunhas legalmente permitido, podendo, portanto, ser ouvidas em número ilimitado. São testemunhas extranumerárias: as ouvidas por iniciativa do juiz (art. 209, *caput*, CPP), as que não prestam o compromisso legal e foram arroladas pelas partes, e as que nada sabem que interesse à decisão da causa (CPP, art. 209, § 2º) (LIMA, 2020, p. 770-771).

Em relação às testemunhas ouvidas por iniciativa do juiz, devem ser rememorados os comentários que fizemos acima. De mais a mais, as testemunhas não compromissadas também são chamadas de informantes ou declarantes. As que nada sabem são também chamadas de inócuas;

VII) TESTEMUNHA DIRETA: "também conhecida como testemunha visual, é aquela que depõe sobre fatos que presenciou ou visualizou" (LIMA, 2020, p. 771);

VIII) TESTEMUNHA INDIRETA, AURICULAR OU POR OUVIR DIZER: "é aquela que declara ao magistrado sobre o que não presenciou, mas soube ou ouviu dizer" (AVENA, 2017, p. 395);

IX) TESTEMUNHA REMOTA: "é aquela que presta seu depoimento por videoconferência" (LIMA, 2020, p. 771).

## 2.6. RECONHECIMENTO DE PESSOAS E COISAS (ARTS. 226 A 228, CPP)

### 2.6.1. INTRODUÇÃO

O reconhecimento de pessoas e coisas "é o ato formal por meio do qual uma pessoa tenta identificar outra pessoa ou coisa que tenha visto anteriormente e que possa ter relação com o objeto de determinada persecução penal" (MARCÃO, 2016, p. 483), podendo ser realizado na investigação policial ou na instrução processual penal em juízo.

Não se pode confundir reconhecimento de pessoas com o chamado retrato falado, que "é formado a partir de informações prestadas ao perito por pessoa que tenha visto o autor do delito, sendo considerado não um meio de prova, mas sim um meio de investigação" (LIMA, 2020, p. 787). Frise-se: o reconhecimento de pessoas e de coisas é meio de prova. O retrato falado é um meio de investigação, isto é, por si só, não poderá conduzir à condenação de alguém.

### 2.6.2. PROCEDIMENTO E INEXISTÊNCIA DE NULIDADE

O procedimento do reconhecimento de pessoas é disciplinado pelo art. 226, *caput*, do CPP, o qual traz as seguintes fases do meio de prova ora analisado:

I) a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II) a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

No que diz respeito ao inciso II, é importante frisar que o legislador, ao usar a expressão "se possível", foi bastante claro: não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento, pois o art. 226, inciso II, do CPP, determina que o agente será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiverem qualquer semelhança "se possível", sendo tal determinação, portanto, recomendável mas não essencial<sup>19</sup>.

III) se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; e

IV) do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Nos termos do art. 227 do CPP, no reconhecimento de objeto (instrumentos utilizados na prática do crime, armas, objetos furtados etc.), no que for aplicável, será adotado o mesmo procedimento em relação ao reconhecimento de pessoas.

Caso várias pessoas sejam chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas, conforme art. 228 do CPP, sendo o procedimento gravado pela característica da individualidade.

Apesar de o Código de Processo Penal estipular um rito formal para o reconhecimento de pessoas e coisas, a jurisprudência entende que as disposições do art. 226, *caput*, do CPP, funcionam como meras recomendações legais, razão pela qual eventuais irregularidades no procedimento não ensejam nulidade do ato (LIMA, 2020, p. 787).

<sup>19</sup> HC 7.802/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 20/5/1999, DJ 21/6/1999, p. 172.





### 2.6.2.1. PROCEDIMENTO EM JUÍZO E PROTEÇÃO AO RECONHECEDOR

Como visto, o art. 226, inciso III, do CPP, diz que, se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela, o que visa garantir, não só a livre produção da prova, mas também a segurança do reconhecedor.

Todavia, o parágrafo único do art. 226 do CPP diz que o disposto no citado inciso III não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento. É dizer: de acordo com o Código, essa proteção ao reconhecedor somente vale na fase de investigação. Na instrução criminal ou em plenário do Júri, o reconhecedor não teria esse direito, ou seja, a pessoa que foi reconhecida saberia quem o reconheceu.

Por óbvio, essa disposição resta inaplicável. Atualmente, "a jurisprudência e a doutrina majoritária optam pela não aplicação do indigitado preceito inscrito no art. 226, parágrafo único, do CPP, existindo nos fóruns mais modernos, salas especiais para o reconhecimento onde o reconhecedor não é visto pelo reconhecendo" (AVENA, 2017, p. 410).

### 2.6.3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Embora não encontre previsão legal, seja em virtude do princípio da busca da verdade real, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, a doutrina e a jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, têm admitido a utilização do reconhecimento fotográfico como meio de prova inominado, devendo ser observado, no que for aplicável, o mesmo procedimento para o reconhecimento de pessoas (LIMA, 2020, p. 788).

### 2.6.4. RECONHECIMENTO FONOGRÁFICO OU CLICHÊ FÔNICO

De igual forma, também tem sido admitida a utilização de reconhecimento fonográfico, no qual uma pessoa é reconhecida através de sua voz, devendo ser adotado, no que for possível, o mesmo procedimento para o reconhecimento de pessoas. Devido ao seu valor probatório relativo, não é possível que um decreto condenatório esteja baseado única e exclusivamente em um reconhecimento fonográfico (LIMA, 2020, p. 788).

Esclarece-se, por oportuno, que "esse reconhecimento fonográfico não se confunde com o exame pericial de verificação de locutor (ou de autenticidade de voz), tido como exame pericial feito por perito oficial (ou por dois peritos não oficiais) para verificar se a voz gravada em interceptações telefônicas judicialmente autorizadas provém (ou não) do aparelho fonador de determinada pessoa" (LIMA, 2020, p. 788).

### 2.6.5. RECONHECIMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA

Estando o reconhecedor ou a pessoa que deva ser reconhecida presa, preenchidos os demais requisitos, o ato poderá ser concretizado por meio de videoconferência, nos termos do art. 185, §8º, do Código de Processo Penal.

## 2.7. ACAREAÇÃO (ARTS. 229 E 230, CPP)

A acareação é o "ato processual em que pessoas que já foram ouvidas a respeito de determinado fato são colocadas frente a frente e reperguntadas sobre as divergências existentes entre as respectivas versões" (MARCÃO, 2017, p. 491).

Nos termos do art. 229, *caput*, do CPP, a acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou

circunstâncias relevantes, sendo os acareados, nos termos do parágrafo único, questionados para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acareação.

Pelo citado dispositivo legal, percebe-se que são bastante variadas as possibilidades de acareação, que poderá ocorrer: a) entre acusados ou investigados; b) entre acusado ou investigado e testemunha; c) entre testemunhas; d) entre acusado ou investigado e vítima; e) entre testemunha e vítima; e f) entre vítimas.

Considerando o conceito de acareação, a doutrina cita dois pressupostos à realização do procedimento em análise: "1) As pessoas a serem acareadas (acusados, testemunhas e ofendidos) já devem ter prestado suas declarações, perante o mesmo juízo e sobre os mesmos fatos e circunstâncias; 2) Deve haver divergência sobre ponto relevante no relato dessas pessoas, ou seja, é necessário que existam contradições ou versões discrepantes sobre fatos que realmente interessem ao deslinde do processo" (LIMA, 2020, p. 789).

Importante assentar que a acareação poderá ocorrer durante a investigação policial (art. 6º, inciso VI, do CPP) ou no curso da instrução processual penal em juízo, não havendo óbice que as próprias partes requeiram a realização do procedimento (LIMA, 2020, p. 789).

Nos termos do art. 230 do CPP, se ausente alguma testemunha, cujas declarações divirjam das de outra, que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedir-se-á precatória à autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente, pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. Essa diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente.

Com o advento da Lei nº 11.900/09, nos termos do art. 222, §3º, do CPP, ao invés de determinar a expedição de carta precatória para a oitiva da testemunha perante o juízo deprecado, poderá o juiz realizar a acareação por intermédio de videoconferência (LIMA, 2020, p. 789).

## 2.8. DOCUMENTOS (ARTS. 231 A 238, CPP)

### 2.8.1. INTRODUÇÃO E ESPÉCIES

Nos termos do art. 232, *caput*, do CPP, consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares.

Atualmente, a doutrina subdivide o gênero documento *lato sensu* em instrumentos e documentos *stricto sensu*. O gênero documento *lato sensu* se refere a "tudo aquilo capaz de retratar determinada situação fática, sejam papéis, sejam arquivos digitalizados na forma da Lei 12.682/2012 (que disciplina a digitalização, ao armazenamento em meio eletrônico, óptico ou equivalente e a reprodução de documentos públicos e privados), seja por meio de áudio ou vídeo, v.g., um DVD com imagens relativas ao fato imputado. Qualquer coisa, enfim, capaz de representar um ato ou um fato. Tal amplitude é importante, já que, em se considerando tais elementos como documentos, sua juntada aos autos deve seguir as mesmas regras atinentes à da prova documental" (AVENA, 2017, p. 411-412).

Por sua vez, instrumento, que é uma das espécies de documento em sentido lato, "consiste no documento confeccionado com o objetivo específico de servir de prova do ato nele materializado. Sua elaboração depende de forma especial prevista em lei" (AVENA, 2017, p. 412). Frise-se: instrumento já nasce com a finalidade de servir como prova.

O instrumento se divide em duas subespécies: I) instrumento público:

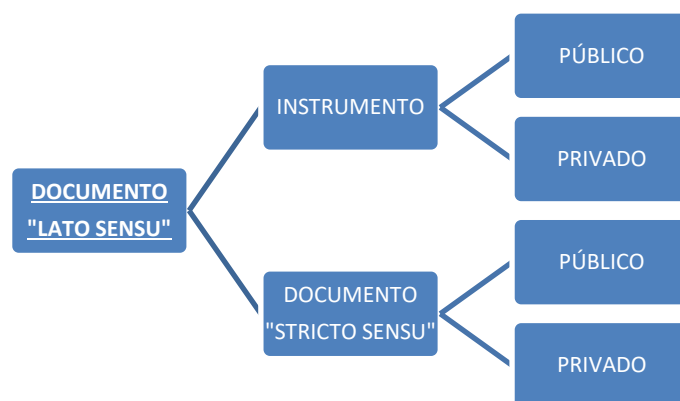
é aquele constituído perante a autoridade pública, no exercício de suas funções e que possua capacidade para lhe atribuir a presunção de verdade (fé pública). Tal presunção, evidentemente, não é absoluta, cedendo em face de prova em contrário. Exemplos: Instrumento público de procuração e a escritura de compra e venda de imóvel;

e II) instrumento particular:

é aquele para cuja constituição não houve a contribuição de qualquer agente público no exercício de função pública. Exemplo: letra de câmbio. Cabe ressaltar que, assinado que venha a ser perante um tabelião que reconheça a firma do signatário, o documento particular terá presunção de autenticidade (AVENA, 2017, p. 413).

Noutro giro, documento *stricto sensu* é definido como "todo escrito que não foi elaborado com o propósito direcionado de ser utilizado como prova, embora, eventualmente, possa vir a ter essa finalidade. Sua utilização como prova é casual", também havendo duas espécies: I) documento público; e II) documento particular (AVENA, 2017, p. 413).

Para fins didáticos, colaciona-se esquema gráfico extraído da obra do Professor Norberto Avena (AVENA, 2017, p. 413):



Nos termos do art. 232, parágrafo único, do CPP, à fotografia do documento (fotocópia), devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original. Frise-se: a reprodução do documento original, desde que autenticada, tem o mesmo valor do documento original.

## 2.8.2. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL (EM SENTIDO LATO)

Conforme art. 231 do CPP, salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.

Nesse sentido, conforme a redação do artigo acima colacionado, a qualquer momento, se não houver proibição legal, as partes poderão juntar documentos aos autos, desde que, por óbvio, o documento juntado seja submetido ao contraditório.

Atualmente, a exceção legal fica por conta do art. 479, *caput*, do CPP, segundo o qual, durante a Sessão Plenária do Júri, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Nos termos do parágrafo único, compreende-se na proibição referida pelo *caput* a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.

Importante frisar que o prazo de 3 dias úteis a que se refere o art. 479 do Código de Processo Penal deve ser respeitado não apenas para a juntada de documento ou objeto, mas também para a ciência da parte contrária a respeito de sua utilização no Tribunal do Júri<sup>20</sup>.

<sup>20</sup>REsp 1.637.288-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, julgado em 8/8/2017, DJe 1/9/2017 - Info. 610.

### 2.8.3. CARTAS PARTICULARES

Como não podia deixar de ser, dada a vedação à prova ilícita, dispõe o art. 233, *caput*, do CPP, que as cartas particulares, interceptadas ou obtidas por meios criminosos, não serão admitidas em juízo.

Em contrapartida, se alguém é o legítimo destinatário da carta, isto é, a recebeu por meios lícitos, poderá exibi-la em juízo, ainda que não haja consentimento do signatário, nos termos do parágrafo único do art. 233 do CPP. É dizer: "não teria sentido proibir que alguém possa usar em juízo, como prova de sua inocência, documento de que é portador e legítimo destinatário" (MARCÃO, 2017, p. 502).

### 2.8.4. REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO PELO JUIZ

Nos termos do art. 234 do CPP, se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível.

Conforme se nota, pela redação do citado artigo, o juiz, se tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, de ofício, isto é, sem requerimento das partes, poderá providenciar a sua juntada aos autos.

Mais uma vez, o estudado dispositivo legal esbarra na possibilidade ou não de iniciativa probatória pelo juiz. Para a corrente que defende que, com o Pacote Anticrime, restou vedada qualquer iniciativa probatória do juiz, tal dispositivo legal somente é aplicável a pedido das partes. Noutro giro, para a corrente que advoga no sentido de que somente restou vedada a iniciativa do juiz durante a investigação policial, o magistrado, desde que no curso da ação penal, poderá providenciar a juntada de documento cuja existência tenha notícia.

### 2.8.5. DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

Conforme art. 236 do CPP, os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público, ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade. Nesse contexto, pela redação do citado artigo, a juntada é sempre imediata, podendo haver ou não a tradução do documento estrangeiro trazido aos autos.

Apesar da literalidade do dispositivo legal, a doutrina sustenta que, "mesmo que as partes tenham conhecimento da língua estrangeira, impõe-se a tradução do documento para o Português, haja vista o princípio da publicidade dos atos processuais, do qual deriva a necessária acessibilidade de todos ao conteúdo do documento. A dispensa de tradução só deverá ocorrer quando o conteúdo do documento não interessar ao acerto do fato delituoso" (LIMA, 2020, p. 792-793).

### 2.8.6. RESTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS

Nos termos do art. 238 do CPP, os documentos originais, juntos a processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento, e ouvido o Ministério Público, ser entregues à parte que os produziu, ficando traslado nos autos. Frise-se: a restituição de que trata o art. 238 do CPP se refere aos documentos produzidos pelas partes e a processos findos.

Se os documentos foram apreendidos, aplicar-se-ão as regras trazidas pelos arts. 118 a 124 do CPP, que foram estudadas em tópico específico.



## 2.9. INDÍCIOS (ART. 239, CPP)

O vocábulo "indício", no Código de Processo Penal, é usado em dois sentidos: no art. 239, como prova indireta, e, em várias outras passagens, como prova semiplena (LIMA, 2020, p. 664). Vejamos.

### 2.9.1. INDÍCIOS COMO PROVA INDIRECTA

De acordo com o art. 239 do CPP, considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

Nesse contexto, "no sentido de prova indireta, a palavra indício deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial". É dizer: "partindo-se de um fato base comprovado, chega-se, por meio de um raciocínio dedutivo, a um fato consequência que se quer provar" (LIMA, 2020, p. 664).

Exemplo: uma testemunha, em juízo, diz que viu o acusado com uma faca suja de sangue e a vítima esfaqueada aos seus pés. Prova direta: o acusado portava uma faca suja de sangue e a vítima estava esfaqueada aos pés do acusado. Indício (prova indireta): o acusado esfaqueou a vítima com a faca que portava (LIMA, 2020, p. 664).

Ainda que haja bastante controvérsia, caso os indícios se revistam de natureza jurídica de prova indireta, o STJ tem precedentes no sentido de que a condenação poderá se calcar neles. Confira-se: "Vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre-convencimento, segundo o qual o magistrado, desde que fundamentadamente, pode decidir pela condenação, ainda que calcada em indícios veementes de prática delituosa" (STJ, HC 15.736/MG, 6ª T., rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 3-4-2001, DJ de 23/4/2001, p. 189). No mesmo sentido, STF: "Os indícios, dado ao livre-convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexos com o fato a ser provado seja lógico e próximo" (STF, HC 70.344/RJ, 2ª T., rel. Min. Paulo Brossard, j. 14/9/1993, DJ de 22/10/1993, p. 22.253).

### 2.9.2. INDÍCIO COMO PROVA SEMIPLENA

Ao longo do Código de Processo Penal, a palavra "indício" também é usada como "uma prova semiplena, ou seja, no sentido de um elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo" (LIMA, 2020, p. 665).

Nesses casos, "a expressão 'indício' refere-se a uma cognição vertical (quanto à profundidade) não exauriente, ou seja, uma cognição sumária, não profunda, em sentido oposto à necessária completude da cognição, no plano vertical, para a prolação de uma sentença condenatória". É o que se verifica, por exemplo, nos arts. 126, 312 e 413, *caput*, todos do Código de Processo Penal (LIMA, 2020, p. 665).

Quando significam prova semiplena, dúvidas não há: os indícios, por si sós, não podem conduzir a um decreto condenatório.

### 2.9.3. CONTRAINDÍCIOS

A doutrina chama de contraindícios as "circunstâncias que invalidam, em determinadas condições e circunstâncias, os indícios colhidos contra alguém" (AVENA, 2017, p. 416).

## **2.10. BUSCA E APREENSÃO (ARTS. 240 A 250, CPP)**

### **2.10.1. CONCEITOS E NATUREZA JURÍDICA**

Embora tenham sido colocados juntos na titulação do Capítulo XI do Título VII do Código de Processo Penal, busca e apreensão são termos que não se confundem. A busca é "o movimento desencadeado pelos agentes do Estado para a investigação, descoberta e pesquisa de algo interessante para o processo penal, realizando-se em pessoas ou lugares". Por sua vez, a apreensão significa a "medida assecuratória que toma algo de alguém ou de algum lugar, com a finalidade de produzir prova ou preservar direitos" (NUCCI, 2016, p. 473).

De mais a mais, assenta-se que poderá ocorrer apreensão sem busca, como se verificará, por exemplo, quando alguém — vítima, testemunha ou o próprio autor — se dirige à delegacia de polícia e entrega à autoridade policial a arma do crime ou outro objeto qualquer sobre o qual recaia interesse para a apuração dos fatos (MARCÃO, 2016, p. 513).

Apesar de estarem topograficamente situadas no capítulo atinente às provas, a busca e a apreensão "são medidas de natureza mista", isto é, "tanto a busca, quanto a apreensão, podem ser vistos, individualmente, como meios assecuratórios ou como meios de prova, ou ambos" (NUCCI, 2016, p. 473).

### **2.10.2. MOMENTO PARA A REALIZAÇÃO**

Tanto a busca como a apreensão — domiciliar ou pessoal — podem ser concretizadas antes da formal instauração do procedimento investigatório (inquérito policial, termo circunstanciado de ocorrência ou outro meio de investigação), no curso deste ou na fase judicial da persecução criminal (MARCÃO, 2016, p. 517).

A título de exemplo, ocorrerá busca, antes mesmo da formal instauração do procedimento investigatório, quando policiais militares, suspeitando que alguém porte droga consigo, procedam à busca e encontre a substância entorpecente, devendo o sujeito que sofreu a medida ser encaminhado à delegacia de polícia, onde a substância será apreendida (MARCÃO, 2016, p. 517).

### **2.10.3. INICIATIVA DA MEDIDA**

Conforme art. 242 do CPP, a busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes.

Nos termos do art. 5º, inciso XI, da CF/88, a busca e apreensão domiciliar depende de determinação judicial, que será materializada por meio de um mandado judicial de busca e apreensão domiciliar.

Por sua vez, conforme será estudado, com mais detalhes, mais à frente, há dois tipos de busca pessoal: por razões de segurança e de natureza processual penal. A primeira — por razões de segurança — não está regulamentada pelo Código de Processo Penal e, como o nome sugere, é executada em prol da segurança da coletividade, como ocorre, por exemplo, em shows ou jogos de futebol. A segunda — de natureza processual penal — está disciplinada no capítulo ora em análise e tem objetivos atrelados à persecução criminal.

De acordo com o art. 244 do CPP, que será estudado, com maior profundidade, mais à frente, a busca pessoal de natureza processual penal, em regra, também dependerá de mandado, sendo este dispensado em algumas situações elencadas no citado artigo. Frise-se: a regra é que a busca pessoal de natureza processual penal também depende de mandado, o qual, apesar de ser pouco tratado na doutrina, é chamado de mandado de busca e apreensão pessoal.

Diferentemente do que ocorre em relação ao mandado de busca e apreensão domiciliar, que somente pode ser expedido por ordem judicial, o mandado de busca e apreensão pessoal pode



ser expedido por ordem do juiz ou da autoridade policial, nos termos do art. 6º, inciso II, do CPP (AVENA, 2017, p. 423).

Fixadas essas premissas, no que diz respeito à busca e apreensão (domiciliar ou pessoal) determinada de ofício pelo magistrado, mais uma vez, a discussão esbarra na possibilidade ou não de iniciativa probatória pelo juiz. Além dessa discussão, deve ser levado em consideração, ademais, que, tendo a busca e apreensão natureza mista, isto é, meio de prova e medida assecuratória, a determinação da medida de ofício pelo juiz também restaria obstada pela impossibilidade de o magistrado, mesmo na ação penal, determinar medidas cautelares de ofício, nos termos dos arts. 3º-A, 282, §§2º e 4º, e 311, todos do CPP.

Destarte, considerando a natureza mista da busca e apreensão e toda a discussão por trás da iniciativa probatória do juiz e da impossibilidade de o magistrado, mesmo na ação penal, determinar medidas cautelares de ofício, cremos que se operou a derrogação tácita do art. 242 do CPP, somente podendo haver a expedição de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar ou pessoal por requerimento das partes.

Noutro giro, nada obsta que a autoridade policial expeça, de ofício, mandado de busca e apreensão pessoal. Ademais, nos casos em que se dispensa o mandado de busca pessoal, esta poderá ser executada de ofício pela autoridade policial, por seus agentes ou pelos membros das polícias ostensivas.

#### 2.10.4. FORMALIDADES DO MANDADO

Nos termos do art. 243 do CPP, tanto o mandado judicial de busca e apreensão (domiciliar ou pessoal) como o mandado de busca e apreensão pessoal expedido pela autoridade policial, deverão preencher os seguintes requisitos:

I) INDICAÇÃO PRECISA DA CASA OU PESSOA QUE SERÁ SUBMETIDA À MEDIDA: nos termos do inciso I do citado artigo, no caso de busca domiciliar, o mandado judicial deverá indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador. Se a busca for do tipo pessoal, o mandado deverá indicar o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem;

Assim, pela redação do art. 243, inciso I, do CPP, são proibidos os chamados mandados de busca e apreensão genéricos, isto é, mandados que autorizam a medida de busca e apreensão coletiva, genérica e indiscriminada para a entrada da polícia em qualquer residência<sup>21</sup>.

II) MOTIVO E FINS DA DILIGÊNCIA: nos termos do inciso II, o mandado de busca e apreensão deverá mencionar o motivo e os fins da diligência; e

III) SUBSCRIÇÃO PELO ESCRIVÃO E ASSINATURA DA AUTORIDADE QUE O FIZER EXPEDIR: nos termos do inciso III, o mandado de busca e apreensão deverá ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.

Caso também haja ordem de prisão, esta constará do próprio texto do mandado de busca, conforme §1º do estudado artigo. Tendo em vista que a busca pessoal, quando da prisão do agente, independerá de mandado (art. 244, CPP), tal dispositivo somente é aplicável à busca domiciliar. É dizer: I) se somente foi expedido mandado de prisão em desfavor do agente, a ordem poderá ser cumprida, inclusive, em sua residência, desde que obedecidos os demais regramentos constitucionais. Contudo, não poderá haver busca na residência do agente; II) se somente foi expedido mandado de busca domiciliar, a prisão só poderá ocorrer se houver situação de flagrante; e

<sup>21</sup>AgRg no HC 435.934/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 20/11/2019.

III) fora a situação de flagrante, para que haja prisão do agente e busca domiciliar, é preciso que o mandado contemple as duas ordens.

De acordo com o §2º, não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. É dizer: a regra geral é que não pode haver a apreensão de documento em poder do defensor do investigado ou acusado. Contudo, se esse documento fizer parte do corpo de delito do crime apurado, poderá ser determinada a sua apreensão.

#### 2.10.5. ESPÉCIES DE BUSCA

Nos termos do art. 240, *caput*, do Código de Processo Penal, a busca será domiciliar ou pessoal. Vejamos cada uma delas em separado.

##### 2.10.5.1. BUSCA PESSOAL

###### 2.10.5.1.1. CONCEITO E ESPÉCIES

A busca pessoal é diligência que recai sobre o corpo da pessoa, suas roupas ou objetos que tenha consigo (AVENA, 2017, p. 423). De acordo com a doutrina, há duas espécies de busca pessoal, a saber:

###### I) BUSCA PESSOAL POR RAZÕES DE SEGURANÇA:

é aquela realizada em festas, boates, aeroportos, rodoviárias, etc. Essa espécie de busca pessoal não está regulamentada pelo Código de Processo Penal, devendo ser executada de maneira razoável e sem expor as pessoas a constrangimento ou à humilhação. Sua execução tem natureza contratual, ou seja, caso a pessoa não se submeta à medida, não poderá se valer do serviço ofertado nem tampouco frequentar o estabelecimento (LIMA, 2020, p. 806);

e

II) BUSCA PESSOAL DE NATUREZA PROCESSUAL PENAL: conforme art. 240, §2º, do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver *fundada suspeita* de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação, objetos falsificados ou contrafeitos, armas, munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato ou qualquer elemento de convicção.

###### 2.10.5.1.2. (DES)NECESSIDADE DE MANDADO

Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal de natureza processual penal independe de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Conforme já introduzimos, a regra é que a busca pessoal de natureza processual penal também dependerá de mandado, que poderá ser expedido tanto pela autoridade judiciária, por provocação das partes, como pelo delegado de polícia, de ofício ou a requerimento.

Desse modo, de acordo com a própria redação do art. 244 do CPP, em apenas três situações, a busca pessoal de natureza processual penal independe de mandado, razão pela qual pode ser afirmado que, nem sempre, esta espécie de busca pessoal independe de mandado. Somente haverá a dispensa do mandado quando:

I) PRISÃO DO SUJEITO: a detenção do agente faz cessar a sua inviolabilidade pessoal, independentemente de ordem judicial, porquanto será ele recolhido ao cárcere e necessita estar livre de armas ou objetos perigosos à segurança do estabelecimento prisional. Além do mais, os objetos ou instrumentos, que possua consigo, poderão servir para a formação do conjunto probatório. É dizer: "se o bem maior – liberdade – está sendo violado legalmente, não teria sentido exigir-se mandado de busca pessoal, que protege a intimidade" (NUCCI, 2016, p. 488). Frise-se que qualquer espécie de prisão, isto é, provisória ou penal, autoriza a dispensa do mandado de busca pessoal (AVENA, 2017, p. 423);

II) FUNDADA SUSPEITA DE ESTAR CARREGANDO ARMA PROIBIDA, OBJETOS OU PAPÉIS QUE FORMEM A MATERIALIDADE DO DELITO: se há fundada suspeita, isto é, se há elementos concretos que indiquem a necessidade da medida, por exemplo, uma saliência sob a blusa de um sujeito ou a notícia levada ao policial de que o agente traz consigo algo de ilícito, independentemente de mandado, está autorizada a realização da busca pessoal (NUCCI, 2016, p. 484); e

III) EXISTÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR:

se a medida mais grave, que é a violação do domicílio, conta com a ordem judicial, seria ilógico não poder o exequente revistar as pessoas encontradas no local, mormente porque as provas buscadas poderiam ser colocadas nos bolsos ou pertences pessoais, inviabilizando o sucesso da diligência (NUCCI, 2016, p. 488);

#### 2.10.5.1.3. BUSCA PESSOAL EM MULHER

Nos termos do art. 249 do CPP, a busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.

Portanto, a regra é que a busca pessoal em mulher seja feita por outra mulher. Contudo, se isto não for possível, isto é, se importar retardamento ou prejuízo da diligência, a busca poderá ser feita por um homem, o que, com bastante frequência, é perguntado em provas de primeira fase.

#### 2.10.5.2. BUSCA DOMICILIAR

##### 2.10.5.2.1. INTRODUÇÃO E FUNDAMENTOS

Por afastar a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (art. 5º, inciso XI, da CF/88), a busca domiciliar exige *fundadas razões* e, nos termos do art. 240, §1º, terá as seguintes finalidades:

- a) prender criminosos;
- b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

No que diz respeito à alínea *b*, conforme estudado no capítulo atinente às medidas assecuratórias, deve ser rememorado que os bens móveis adquiridos com os proventos da infração penal (produto indireto, também chamado de proventos ou proveito da infração ou, ainda, frutos da infração —*fructus sceleris*) estão sujeitos ao sequestro, nos termos do art. 126 do CPP (e não à busca e apreensão). O que está sujeito à busca e apreensão, nos termos do dispositivo legal ora em estudo, é o produto direto da infração (*producta sceleris*). Em resumo: o produto direto da infração é objeto de busca e apreensão. O proveito da infração é objeto de sequestro.

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;



- f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;**
- g) apreender pessoas vítimas de crimes;**
- h) colher qualquer elemento de convicção.**

De acordo com o citado art. 5º, inciso XI, da CF/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Por sua vez, o art. 245, *caput*, primeira parte, do CPP, dispõe que as buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite.

Nesse contexto, interpretando os dois dispositivos de forma sistemática, tem-se que, as buscas domiciliares, para fins processuais penais, poderão ser feitas nas seguintes hipóteses:

- a) havendo consentimento do morador, durante o dia ou à noite, a busca poderá ser realizada sem mandado judicial. É dizer: sendo a necessidade de autorização judicial uma garantia ao morador, caso este abra mão de seu direito, a busca poderá ser realizada nessas condições;**
- b) não havendo consentimento do morador, a busca domiciliar exigirá mandado judicial e deverá ser realizada durante o dia; e**
- c) em caso de flagrante delito, com ou sem o consentimento do morador, a busca domiciliar poderá ser realizada, pouco importando se é dia ou noite.**

#### **2.10.5.2.2. NECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL**

Como dito, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a busca domiciliar exige autorização judicial, a qual será materializada por um mandado judicial.

O art. 241 do CPP dispõe que, quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado.

Em relação à primeira parte do art. 241 do CPP — busca realizada pela autoridade policial — não há discussão: tal dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal. É dizer: o delegado de polícia, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador, não poderá concretizar a busca domiciliar.

No que diz respeito à segunda parte do art. 241 do CPP — busca realizada pelo próprio juiz — a doutrina se debate.

Uma primeira corrente diz que "se a diligência de busca for realizada pela autoridade judiciária — coisa rara de se ver na prática, mas juridicamente possível —, não será necessária a expedição de mandado prévio, pois não tem sentido imaginar que o juiz deva despachar e fazer expedir documento autorizando ele mesmo" (MARCÃO, 2016, p. 518). No mesmo sentido, Nucci assenta que "o juiz, obviamente, quando acompanha a diligência, faz prescindir do mandado, pois não teria cabimento ele autorizar a si mesmo ao procedimento da busca" (NUCCI, 2016, p. 485).

Em contrapartida, uma segunda corrente aduz que "a possibilidade de o magistrado executar pessoalmente uma busca domiciliar representa clara e evidente afronta ao sistema acusatório adotado pela Carta Magna (CF, art. 129, I), além de violar a garantia da imparcialidade do magistrado, ressuscitando a famigerada figura do juiz inquisidor" (LIMA, 2017, p. 686).

Essa última corrente, caso não declarada a inconstitucionalidade do art. 3º-A do CPP, trazido pelo Pacote Anticrime, ganha muita força, porquanto, nos termos do citado dispositivo legal, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Assim, não podendo o magistrado substituir a atuação probatória da acusação, será difícil defender a aplicabilidade do art. 241 do CPP, também em relação à execução da busca domiciliar pelo juiz.

Por fim, ressalta-se que, por ser diligência gravada pela cláusula de reserva de jurisdição, a Comissão Parlamentar de Inquérito não tem autoridade para, por força própria, isto é, sem autorização judicial, determinar a busca domiciliar.

### 2.10.5.2.3. JUIZ COMPETENTE

Considerando o postulado constitucional do juiz natural (art. 5º, inciso LIII, da CF/88), somente o juiz competente para o julgamento de futura e eventual ação penal poderá deferir a medida de busca e apreensão domiciliar, sob pena de nulidade da diligência.

Em caso emblemático, que envolvia busca em imóvel funcional ocupado por uma Senadora da República, entendeu o STF que, embora o investigado fosse o marido da Senadora, tendo em vista que a ordem judicial não individualizou os bens que seriam de titularidade da Parlamentar e de seu marido, somente o próprio Supremo poderia ter ordenado a medida<sup>22</sup>.

### 2.10.5.2.4. CONCEITO DE CASA

Para fins processuais penais, o conceito de casa é extraído do art. 150, §4º, do CP, segundo o qual a expressão "casa" compreende: I - qualquer compartimento habitado; II - aposento ocupado de habitação coletiva; e III - compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. De acordo com o §5º do mesmo artigo, não se compreendem na expressão "casa": I - hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do nº II do parágrafo anterior ("quarto" ocupado, ainda que a ocupação se dê por pouco tempo); e II - taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero.

Em complementação, dispõe o art. 246 do CPP que serão aplicadas as regras da busca domiciliar à busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade.

Assim, inserem-se no conceito de casa, portanto, não só a casa ou habitação, mas também o escritório de advocacia, o consultório médico, o gabinete do delegado de polícia, o quarto ocupado de hotel ou motel, o quarto de hospital, empresas e lojas (do balcão para dentro), pátios, jardins, quintal, garagens, depósitos etc. (LIMA, 2020, p. 799).

No que diz respeito à busca em veículos ou embarcações, a análise deve ser um pouco mais detida:

I) PRIMEIRA HIPÓTESE: "não se exige, para a definição de 'casa', que ela esteja fixada ao solo, pois o conceito constitucional abrange as residências sobre rodas (*trailers* residenciais), barcos-residência, a parte traseira do interior da boleia do caminhão, etc.". Assim, se o sujeito, de fato, faz do veículo ou embarcação a sua residência e, no momento da diligência, o móvel esteja sendo usado como residência, este local estará acobertado pela inviolabilidade domiciliar, sendo a busca, nesse caso, regida pelas regras concernentes à busca domiciliar;

II) SEGUNDA HIPÓTESE: o sujeito faz do móvel sua residência, contudo, no momento da diligência, o veículo ou embarcação está sendo utilizado como meio de transporte. Nesse caso, o móvel não estará acobertado pela inviolabilidade domiciliar. A busca, nessa situação, será regida pelas regras atinentes à busca pessoal; e

III) TERCEIRA HIPÓTESE: se o veículo ou embarcação for utilizado somente como meio de transporte, isto é, se o agente não residir neles, não há falar em inviolabilidade domiciliar, sendo a busca, nessa situação, regida pelas regras atinentes à busca pessoal.

### 2.10.5.2.5. CONCEITO DE DIA

A Lei nº 13.869/19, a qual dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, em seu art. 22, §2º, inciso III, prevê que cometerá o crime de abuso de autoridade o agente que cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h ou antes das 5h.

<sup>22</sup> STF. 2ª Turma. Rcl 24473/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/6/2018.

A par das discussões doutrinárias acerca da constitucionalidade ou não do referido dispositivo legal, as quais devem ser acompanhadas pelo leitor, o fato é que, atualmente, há um conceito legal de dia e de noite: I) o dia se inicia às 5h e termina às 21h; e II) a noite começa às 21h e se encerra às 5h.

Nesse sentir, não havendo consentimento do morador, a busca e apreensão domiciliar dependerão de mandado judicial e a entrada na residência somente poderá ocorrer entre as 5h da manhã e 9h da noite.

#### 2.10.5.2.6. EXECUÇÃO DA BUSCA DOMICILIAR

Nos termos do art. 245, *caput*, do CPP, as buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

Nesse contexto, já analisada a questão sobre o horário da diligência, o primeiro ato dos executores, após, por óbvio, se identificarem como agentes do Estado, é ler o mandado ao morador, ou a quem o represente e intimá-lo a abrir a porta.

De acordo com o §1º, se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e o objeto da diligência. Conforme estudamos em relação ao art. 241 do CPP, diante das premissas atinentes ao sistema acusatório e das alterações trazidas pelo Pacote Anticrime, é difícil defender a possibilidade de o juiz executar a busca domiciliar. Por esta razão, a autoridade a que se refere o §1º é a autoridade policial. Logo, se o delegado de polícia se fizer presente, deverá declarar ao morador, ou a quem o represente, esta qualidade e o objeto da diligência.

Nos termos do §2º, caso o morador, ou quem o represente, não atenda à intimação de abrir a porta, esta será arrombada. Segundo o §3º, recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura. Frise-se: o emprego de força, para o descobrimento do que se procura, em um primeiro momento, somente é autorizado contra coisas e não contra pessoas. Caso as pessoas tentem impedir a busca, aí sim é que estará permitido o emprego da força contra esses sujeitos.

Segundo o art. 248 do CPP, em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência.

Na hipótese de não haver moradores no momento do cumprimento da diligência, será permitido o arrombamento da porta e o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, nos termos do §3º. Nesse caso, se houver e estiver presente, deverá ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho. Frise-se: não é obrigatório que um vizinho assista à diligência, o que somente deve ocorrer se existir vizinho e este estiver presente no momento da diligência. Preenchidos tais requisitos e, ainda assim, não tenha sido intimado um vizinho, ter-se-á configurada mera irregularidade (LIMA, 2020, p. 805).

Nos termos do §5º, caso seja determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la. Havendo a descoberta da pessoa ou coisa que se procurava, esta será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade policial ou de seus agentes (art. 245, §6º, do CPP).

Terminada a diligência, nos termos do §7º, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no §4º. Isto é: se a busca se deu em casa sem moradores, se houve a intimação de um vizinho para assisti-la, este também assinará o auto circunstanciado a que se refere o §7º.

Conforme já dissemos, todas essas formalidades deverão ser observadas quando se tiver de proceder a busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade, nos termos do art. 246 do CPP.



### 2.10.6. BUSCA EM TERRITÓRIO DE JURISDIÇÃO ALHEIA

De acordo com o art. 250, *caput*, do CPP, a autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta.

Nos termos do §1º, entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa, quando: a) tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista; e b) ainda que não a tenham avistado, mas sabendo, por informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias, que está sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço.

Caso as autoridades locais tenham fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que, nas referidas diligências, entrarem pelos seus distritos, ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas de modo que não se frustre a diligência, nos termos do §2º.

### 2.10.7. BUSCA INFRUTÍFERA

Caso a diligência reste infrutífera, isto é, não seja encontrada a pessoa ou coisa procurada, nos termos do art. 247 do CPP, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se o requerer. Frise-se: somente haverá a comunicação dos motivos da diligência a quem tiver sofrido a busca, se esta pessoa requerer. Caso não requeira, não estão os executores obrigados a declinar os motivos da diligência.

### 2.10.8. ACESSO A MENSAGENS DE APLICATIVOS TELEMÁTICOS

Em relação ao acesso dos órgãos da persecução criminal a mensagens de aplicativos telemáticos, como o WhatsApp, por exemplo, três situações devem ser analisadas em separado:

I) PRISÃO EM FLAGRANTE: na prisão em flagrante, a apreensão do aparelho celular independe de autorização judicial. É dizer: o próprio delegado de polícia, nos termos do art. 6º, incisos II e III, do CPP, poderá apreender o aparelho celular. Contudo, para se ter acesso às mensagens telemáticas contidas no aparelho, será necessária autorização do juiz competente<sup>23</sup>;

II) ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR PRÉVIA: caso o celular tenha sido apreendido em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar anteriormente expedido, ainda que não haja autorização expressa, poderá haver o acesso às mensagens registradas no aparelho. É dizer: a ordem de busca e apreensão determinada já é suficiente para permitir o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos<sup>24</sup>; e

III) MORTE DA VÍTIMA: caso a vítima tenha morrido e o celular tenha sido entregue à polícia pela pessoa que ficou viúva, a autoridade policial, independentemente de ordem judicial, pode acessar às mensagens contidas no aparelho que lhe fora entregue<sup>25</sup>.

<sup>23</sup>STJ. 5ª Turma. RHC 67.379-RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/10/2016 (Info. 593);

<sup>24</sup>STJ. 5ª Turma. RHC 77.232/SC, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 03/10/2017;

<sup>25</sup>STJ. 6ª Turma. RHC 86.076-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. Ac. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 19/10/2017 (Info. 617).

### 3. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA

#### 3.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Súmula nº 155, STF: “É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha.”

**MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO N. 8.008/2018 (ART. 1º, §3º). VÍTIMAS DE ESTUPRO. MENORES DE IDADE DO SEXO FEMININO. PERITO LEGISTA MULHER. OBRIGATORIEDADE. ALEGA OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 22, I, DA CFRB) E NORMAS GERAIS SOBRE PROCEDIMENTOS EM MATÉRIA PROCESSUAL (ART. 24, XI, DA CFRB). INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 24, XV, DA CFRB. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR OFENSA AO DIREITO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ACESSO À JUSTIÇA E AOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA PRIORIDADE ABSOLUTA (arts. 5º, XXXV, e 227, *caput*, da CRFB). SUSPENSÃO DA NORMA DEFERIDA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. DESDE QUE NÃO IMPORTE RETARDAMENTO OU PREJUÍZO DA DILIGÊNCIA. EFEITOS EX TUNC.** 1. A Lei Estadual n.º 8.008/2018 do Rio de Janeiro, que impõe a obrigatoriedade de que as crianças e adolescentes do sexo feminino vítimas de estupro sejam examinadas por perito legista mulher, não padece do vício de inconstitucionalidade formal, porque a regra concerne à competência concorrente prevista no art. 24, inciso XV, da CFRB, “proteção à infância e à juventude”. 2. Trata-se de regra que reforça o princípio federativo, protegendo a autonomia de seus membros e conferindo máxima efetividade aos direitos fundamentais, no caso, o direito da criança e da adolescente à absoluta prioridade na proteção dos seus direitos (CFRB, art. 227). Compreensão menos centralizadora e mais cooperativa da repartição de competências no federalismo brasileiro. A lei federal n. 13.431/2017 (Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência) reservou espaço à conformação dos Estados. Inconstitucionalidade formal afastada. 3. Lei impugnada em sintonia com o direito fundamental à igualdade material (art. 5º, I, da CRFB), que impõe especial proteção à mulher e o atendimento empático entre iguais, evitando-se a revitimização da criança ou adolescente, mulher, vítima de violência. 4. Risco evidenciado pela negativa de realização de atos periciais às vítimas menores de idade do sexo feminino por legistas homens, o que compromete, concretamente e de modo mais urgente, o direito de crianças e adolescente de acesso à justiça (art. 39 da Convenção sobre os Direitos das Crianças) e os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta (arts. 5º, XXXV, e 227 da CRFB). Inconstitucionalidade material concreta. Necessidade de interpretação conforme à Constituição. Desde que não importe retardamento ou prejuízo da diligência. 5. Medida cautelar deferida. Suspensão da norma impugnada. Efeitos excepcionais efeitos *ex tunc*, a fim de resguardar as perícias que porventura tenham sido feitas por profissionais do sexo masculino. (ADI 6039 MC, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13/3/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31/7/2019 PUBLIC 1º/8/2019.)

**RECLAMAÇÃO. 2. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS 395 E 444. CABIMENTO.** A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal deu sinais de grande evolução no que se refere à utilização do instituto da reclamação em sede de controle concentrado de normas. No julgamento da questão de ordem em agravo regimental na Rcl 1.880, em 23 de maio de 2002, o Tribunal assentou o cabimento da reclamação para todos aqueles que comprovarem prejuízos resultantes de decisões contrárias às teses do STF, em reconhecimento à eficácia vinculante *erga omnes* das decisões de mérito proferidas em sede de controle concentrado 3. Reclamante submetido a “entrevista” durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Direito ao silêncio e à não autoincriminação. Há a violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação, estabelecidos nas decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444, com a realização de interrogatório forçado, travestido de “entrevista”, formalmente documentado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no qual não se oportunizou ao sujeito

da diligência o direito à prévia consulta a seu advogado e nem se certificou, no referido auto, o direito ao silêncio e a não produzir provas contra si mesmo, nos termos da legislação e dos precedentes transcritos 4. A realização de interrogatório em ambiente intimidatório representa uma diminuição da garantia contra a autoincriminação. O fato de o interrogado responder a determinadas perguntas não significa que ele abriu mão do seu direito. As provas obtidas através de busca e apreensão realizada com violação à Constituição não devem ser admitidas. Precedentes dos casos *Miranda v. Arizona* e *Mapp v. Ohio*, julgados pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Necessidade de consolidação de uma jurisprudência brasileira em favor das pessoas investigadas. 5. Reclamação julgada procedente para declarar a nulidade da “entrevista” realizada e das provas derivadas, nos termos do art. 5º, LVI, da CF/88 e do art. 157, §1º, do CPP, determinando ao juízo de origem que proceda ao desentranhamento das peças. (Rcl 33711, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-184 DIVULG 22/8/2019 PUBLIC 23/8/2019.)

### 3.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Súmula nº 74, STJ: “Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil.”

Súmula nº 273, STJ: “Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.”

Súmula nº 545, STJ: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”

Súmula nº 630, STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

**AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APURAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS EM COMUNIDADES DE FAVELAS. BUSCA E APREENSÃO EM RESIDÊNCIAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO COLETIVA, GENÉRICA E INDISCRIMINADA CONTRA OS CIDADÃOS E CIDADÃS DOMICILIADOS NAS COMUNIDADES ATINGIDAS PELO ATO COATOR.** 1. Configurada a ausência de individualização das medidas de apreensão a serem cumpridas, o que contraria diversos dispositivos legais, dentre eles os arts. 240, 242, 244, 245, 248 e 249 do Código de Processo Penal, além do art. 5º, XI, da Constituição Federal: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Caracterizada a possibilidade concreta e iminente de ofensa ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. 2. Indispensável que o mandado de busca e apreensão tenha objetivo certo e pessoa determinada, não se admitindo ordem judicial genérica e indiscriminada de busca e apreensão para a entrada da polícia em qualquer residência. Constrangimento ilegal evidenciado. 3. Agravo regimental provido. Ordem concedida para reformar o acórdão impugnado e declarar nula a decisão que decretou a medida de busca e apreensão coletiva, genérica e indiscriminada contra os cidadãos e cidadãs domiciliados nas comunidades atingidas pelo ato coator (Processo n. 0208558-76.2017.8.19.0001). (AgRg no HC 435.934/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 20/11/2019)

**RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE ESPELHAMENTO, VIA WHATSAPP WEB, DAS CONVERSAS REALIZADAS PELO INVESTIGADO COM TERCEIROS. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DISPARIDADES RELEVANTES. ILEGALIDADE DA MEDIDA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL E DOS ATOS E PROVAS DEPENDENTES. PRESENÇA DE OUTRAS ILEGALIDADES. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE**

**PRIVACIDADE DETERMINADA SEM INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DETERMINAÇÃO ANTERIOR DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. FIXAÇÃO DIRETA DE PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, COM PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.** 1. Hipótese em que, após coleta de dados do aplicativo WhatsApp, realizada pela Autoridade Policial mediante apreensão judicialmente autorizada de celular e subsequente espelhamento das mensagens recebidas e enviadas, os Recorrentes tiveram decretadas contra si prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006. 2. O espelhamento das mensagens do WhatsApp ocorre em sítio eletrônico disponibilizado pela própria empresa, denominado WhatsApp Web. Na referida plataforma, é gerado um tipo específico de código de barras, conhecido como Código QR (*Quick Response*), o qual só pode ser lido pelo celular do usuário que pretende usufruir do serviço. Daí a necessidade de apreensão, ainda que por breve período de tempo, do aparelho telefônico que se pretende monitorar. 3. Para além de permitir o acesso ilimitado a todas as conversas passadas, presentes e futuras, a ferramenta WhatsApp Web foi desenvolvida com o objetivo de possibilitar ao usuário a realização de todos os atos de comunicação a que teria acesso no próprio celular. O emparelhamento entre celular e computador autoriza o usuário, se por algum motivo assim desejar, a conversar dentro do aplicativo do celular e, simultaneamente, no navegador da internet, ocasião em que as conversas são automaticamente atualizadas na plataforma que não esteja sendo utilizada. 4. Tanto no aplicativo, quanto no navegador, é possível, com total liberdade, o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas (registradas antes do emparelhamento) ou recentes (registradas após), tenham elas sido enviadas pelo usuário, tenham elas sido recebidas de algum contato. Eventual exclusão de mensagem enviada (na opção "Apagar somente para Mim") ou de mensagem recebida (em qualquer caso) não deixa absolutamente nenhum vestígio, seja no aplicativo, seja no computador emparelhado, e, por conseguinte, não pode jamais ser recuperada para efeitos de prova em processo penal, tendo em vista que a própria empresa disponibilizadora do serviço, em razão da tecnologia de encriptação ponta-a-ponta, não armazena em nenhum servidor o conteúdo das conversas dos usuários. 5. Cumpre assinalar, portanto, que o caso dos autos difere da situação, com legalidade amplamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, em que, a exemplo de conversas mantidas por e-mail, ocorre autorização judicial para a obtenção, sem espelhamento, de conversas já registradas no aplicativo WhatsApp, com o propósito de periciar seu conteúdo. 6. É impossível, tal como sugerido no acórdão impugnado, proceder a uma analogia entre o instituto da interceptação telefônica (art. 1.º, da Lei n.º 9.296/1996) e a medida que foi tomada no presente caso. 7. Primeiro: ao contrário da interceptação telefônica, no âmbito da qual o investigador de polícia atua como mero observador de conversas empreendidas por terceiros, no espelhamento via WhatsApp Web o investigador de polícia tem a concreta possibilidade de atuar como participante tanto das conversas que vêm a ser realizadas quanto das conversas que já estão registradas no aparelho celular, haja vista ter o poder, conferido pela própria plataforma online, de interagir nos diálogos mediante envio de novas mensagens a qualquer contato presente no celular e exclusão, com total liberdade, e sem deixar vestígios, de qualquer mensagem passada, presente ou, se for o caso, futura. 8. O fato de eventual exclusão de mensagens enviadas (na modalidade "Apagar para mim") ou recebidas (em qualquer caso) não deixar absolutamente nenhum vestígio nem para o usuário nem para o destinatário, e o fato de tais mensagens excluídas, em razão da criptografia *end-to-end*, não ficarem armazenadas em nenhum servidor, constituem fundamentos suficientes para a conclusão de que a admissão de tal meio de obtenção de prova implicaria indevida presunção absoluta da legitimidade dos atos dos investigadores, dado que exigir contraposição idônea por parte do investigado seria equivalente a demandar-lhe produção de prova diabólica. 9. Segundo: ao contrário da interceptação telefônica, que tem como objeto a escuta de conversas realizadas apenas depois da autorização judicial (*ex nunc*), o espelhamento via Código QR viabiliza ao investigador de polícia acesso amplo e irrestrito a toda e qualquer comunicação realizada antes da mencionada autorização, operando efeitos retroativos (*ex tunc*). 10. Terceiro: ao contrário da interceptação telefônica, que é operacionalizada sem a necessidade simultânea de

busca pessoal ou domiciliar para apreensão de aparelho telefônico, o espelhamento via Código QR depende da abordagem do indivíduo ou do vasculhamento de sua residência, com apreensão de seu aparelho telefônico por breve período de tempo e posterior devolução desacompanhada de qualquer menção, por parte da Autoridade Policial, à realização da medida constritiva, ou mesmo, porventura — embora não haja nos autos notícia de que isso tenha ocorrido no caso concreto —, acompanhada de afirmação falsa de que nada foi feito. 11. Hipótese concreta dos autos que revela, ainda, outras três ilegalidades: (a) sem que se apontasse nenhum fato novo na decisão, a medida foi autorizada quatro meses após ter sido determinado o arquivamento dos autos; (b) ausência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal a respaldar a limitação do direito de privacidade; e (c) ilegalidade na fixação direta do prazo de 60 (sessenta) dias, com prorrogação por igual período. 12. Recurso provido, a fim de declarar a nulidade da decisão judicial que autorizou o espelhamento do WhatsApp via Código QR, bem como das provas e dos atos que dela diretamente dependam ou sejam consequência, ressalvadas eventuais fontes independentes, revogando, por conseguinte, a prisão preventiva dos Recorrentes, se por outro motivo não estiverem presos. (RHC 99.735/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018.)

**PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANDAMUS NÃO CONHECIDO.** 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe *habeas corpus* substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O *habeas corpus* não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de *writ*. 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 5. *Habeas corpus* não conhecido. (HC 433.679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 6/3/2018, REPDJe 17/4/2018, DJe 12/3/2018.)

**RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41, DO CPP. INOBSERVÂNCIA. DADOS E DE CONVERSAS REGISTRADAS NO WHATSAPP. EXTRAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.** 1. A denúncia não descreve a conduta do recorrente quanto à imputação de porte ilegal de arma de fogo, não sendo possível identificar como teria ele contribuído para a consecução desse delito. 2. Não há ilegalidade na perícia de aparelho de telefonia celular pela polícia na hipótese em que seu proprietário — a vítima — foi morto, tendo o referido telefone sido entregue à autoridade policial por sua esposa, interessada no esclarecimento dos fatos que o detinha, pois não havia mais sigilo algum a proteger do titular daquele direito. 3. Recurso parcialmente provido, apenas para trancar a ação penal em relação ao recorrente, quanto à imputação concernente ao crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por inépcia formal da denúncia, sem prejuízo de que outra seja oferecida. (RHC 86.076/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 12/12/2017.)

**PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. DADOS ARMAZENADOS NO APARELHO CELULAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI N. 9.296/96. PROTEÇÃO DAS COMUNICAÇÕES EM FLUXO. DADOS ARMAZENADOS. INFORMAÇÕES**



**RELACIONADAS À VIDA PRIVADA E À INTIMIDADE. INVOLABILIDADE. ART. 5º, X, DA CARTA MAGNA. ACESSO E UTILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI N. 9.472/97 E DO ART. 7º DA LEI N. 12.965/14. TELEFONE CELULAR APREENDIDO EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ANÁLISE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS NELES ARMAZENADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.** I - O sigilo a que se refere o art. 5º, XII, da Constituição da República é em relação à interceptação telefônica ou telemática propriamente dita, ou seja, é da comunicação de dados, e não dos dados em si mesmos. Desta forma, a obtenção do conteúdo de conversas e mensagens armazenadas em aparelho de telefone celular ou smartphones não se subordina aos ditames da Lei n. 9.296/96. II - Contudo, os dados armazenados nos aparelhos celulares decorrentes de envio ou recebimento de dados via mensagens SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens (dentre eles o "WhatsApp"), ou mesmo por correio eletrônico, dizem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, sendo, portanto, invioláveis, no termos do art. 5º, X, da Constituição Federal. Assim, somente podem ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial, nos termos do art. 3º da Lei n. 9.472/97 e do art. 7º da Lei n. 12.965/14. III - A jurisprudência das duas Turmas da Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de ser ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos ("WhatsApp"), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, obtidos diretamente pela polícia no momento do flagrante, sem prévia autorização judicial para análise dos dados armazenados no telefone móvel. IV - No presente caso, contudo, o aparelho celular foi apreendido em cumprimento a ordem judicial que autorizou a busca e apreensão nos endereços ligados aos corréus, tendo a recorrente sido presa em flagrante na ocasião, na posse de uma mochila contendo tablets de maconha. V - Se ocorreu a busca e apreensão dos aparelhos de telefone celular, não há óbice para se adentrar ao seu conteúdo já armazenado, porquanto necessário ao deslinde do feito, sendo prescindível nova autorização judicial para análise e utilização dos dados neles armazenados. Recurso ordinário não provido. (RHC 77.232/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 16/10/2017.)

**PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO. ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO. NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PRETÓRIO EXCELSO NO BOJO DO HC 127.900/AM. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. ACUSADO INTERROGADO NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA PRETÉRITA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. QUANTUM DE INCIDÊNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. ILEGALIDADE MANIFESTA. INEXISTÊNCIA. 3. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N.º 11.343/06. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE LOCAL SEDE DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS. COMPROVAÇÃO DE MERCANCIA NO REFERIDO LOCAL. DESNECESSIDADE. PROXIMIDADE. SUFICIÊNCIA. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. 5. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DELITO NÃO HEDIONDO. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC Nº 118.533/MS. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO DA QUINTA E SEXTA TURMAS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 512/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 6. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.** 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 127.900/AM, deu nova conformidade à norma contida no art. 400 do CPP (com redação dada pela Lei n. 11.719/08), à luz do sistema constitucional acusatório e dos princípios do contraditório e da ampla defesa. O interrogatório passa a ser sempre o último ato da instrução, mesmo nos procedimentos regidos por lei especial, caindo por terra a solução de antinomias com arrimo no princípio da especialidade. Ressalvou-se, contudo, a incidência da nova compreensão aos processos nos quais a instrução não tenha se encerrado até a publicação da ata daquele julgamento (10.03.2016). *In casu*, o paciente



foi sentenciado em 3.8.2015, afastando-se, pois, qualquer pretensão anulatória. 2. O estabelecimento do redutor na fração de 1/6 não se mostrou, de modo flagrante, desarrazoado, diante da quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida em poder do paciente — 91 porções de cocaína —, a atrair a incidência do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. Motivada de maneira concreta a fixação do *quantum* de aplicação do referido benefício, não há falar em ilegalidade. 3. Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de mercancia nos referidos locais, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. Na espécie, o paciente foi flagrado praticando condutas descritas no art. 33, *caput*, da Lei n.º 11.343/06 nas imediações de local sede de atividades recreativas e esportivas, restando plenamente justificada a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos submete-se à regência do art. 44 do Código Penal, segundo o qual só faz jus ao benefício legal o condenado a pena inferior a 4 anos. Na espécie, tendo a reprimenda final alcançado 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, não é possível a pretendida substituição. 5. Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto. Outrossim, de acordo com o entendimento recentemente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC n.º 118.533/MS, julgado em 23.6.2016), "o crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda". Mudança de posicionamento quanto ao tema por parte da Quinta e Sexta Turmas desta Corte Superior, que culminou na revisão do entendimento anteriormente consolidado, pela Terceira Seção, e no cancelamento do enunciado n.º 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. Fixada a pena-base no mínimo legal, bem como aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, sendo a reprimenda final de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, é possível o estabelecimento do regime inicial semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. 6. *Habeas corpus* parcialmente concedido a fim de fixar o regime inicial semiaberto. (HC 403.550/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017.)

**PROCESSO PENAL, RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVAS EXTRAÍDAS DO APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL NÃO EVIDENCIADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO APLICÁVEL. LEI PENAL EM BRANCO HETERÓLOGA. SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA ELENCADE NA PORTARIA 344/98 DA ANVISA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.** 1. O entendimento perfilhado pela Corte *a quo* está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protraí no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Ainda, a prisão em flagrante é possível enquanto não cessar a permanência, independentemente de prévia autorização judicial. Precedentes. 2. Embora seja despcienda ordem judicial para a apreensão dos celulares, pois os réus encontravam-se em situação de flagrância, as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, que deve abranger igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda, através de sistemas de informática e telemática. Em verdade, deveria a autoridade policial, após a apreensão do telefone, ter

requerido judicialmente a quebra do sigilo dos dados nele armazenados, de modo a proteger tanto o direito individual à intimidade quanto o direito difuso à segurança pública. Precedente. 3. O art. 5º da Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados bancários e fiscais, devendo a mitigação de tal preceito, para fins de investigação ou instrução criminal, ser precedida de autorização judicial, em decisão motivada e emanada por juízo competente (Teoria do Juízo Aparente), sob pena de nulidade. Além disso, somente é admitida a quebra do sigilo quando houve indício razoável da autoria ou participação em infração penal; se a prova não puder ser obtida por outro meio disponível, em atendimento ao princípio da proibição de excesso; e se o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão. 4. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu (Precedentes). 5. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Mister se faz consignar que provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser privilegiado o princípio do *in dubio pro societate*. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o *jus accusationis* do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. 6. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do *writ*. Precedentes. 7. Esta Corte Superior de Justiça há muito consolidou seu entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, uma vez que o bem jurídico protegido é a saúde pública, sendo o delito de perigo abstrato, afigurando-se irrelevante a quantidade de droga apreendida" (AgRg no REsp 1578209/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 27/06/2016). 8. O cloreto de etila está elencado como substância psicotrópica na Portaria n. 344/98 da ANVISA, cuja comercialização é defesa em todo o território nacional, tratando-se de droga para fins do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, norma penal em branco heteróloga. 9. Recurso parcialmente provido, tão somente para reconhecer a ilegalidade das provas obtidas no celular do recorrente e determinar o seu desentranhamento dos autos. (RHC 67.379/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 9/11/2016.)

**PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. EXTREMA RELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENA. TESE DE AFRONTA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.** 1. Lastreada a condenação nos elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial, não é possível revê-los em sede de recurso especial no desiderato de obter conclusão diversa, não sendo o caso, aqui, de reavaliação da prova, como pretende fazer crer o recorrente. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade. Precedentes do STJ. 3. No tocante à pretensão de redução da pena imposta e indicação de ofensa ao art. 59 do Código Penal, o recorrente não demonstra de que forma o referido dispositivo teria sido violado, o que impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF. Além disso, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231/STJ. 4.

Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/6/2015, DJe 17/6/2015.)

### QUESTÕES

- 1- PGR (PGR 2005 – adaptada)** Em relação à prova no processo penal, considera-se acertado dizer que o ônus probante é, via de regra, da acusação, que desencadeia a perseguição, mas o réu assume tal encargo quando aduz, em seu favor, alguma excludente de ilicitude, dirimente de culpabilidade, ou, ainda, quando apresenta um álibi.
- 2- TJ/SP (VUNESP 2011 – adaptada)** As provas cautelares antecipadas podem ser consideradas pelo juiz na formação da sua convicção, ainda que não reproduzidas perante o contraditório.
- 3- TJ/DFT (TJ/DFT 2008 – adaptada)** No processo penal, todas as pessoas poderão ser testemunhas, inclusive os menores de quatorze anos, os doentes mentais e familiares do acusado.
- 4- DPE/RS (FCC 2018 – adaptada)** No crime de receptação, efetivada a prisão do agente com a posse do objeto de origem criminoso, opera-se a chamada inversão do ônus da prova no processo penal.
- 5- MPE/SP (MPE/SP 2019 – adaptada)** Considerando a inidoneidade jurídica da prova ilicitamente obtida, eventual prova produzida de modo válido em momento subsequente, mas derivada de prova comprometida da ilicitude originária, deve ser declarada ilícita por derivação (a doutrina dos frutos da árvore envenenada).
- 6- TJ/RO (VUNESP 2019 – adaptada)** O Juiz pode rejeitar a perícia requerida pelas partes, quando se mostrar irrelevante para o deslinde da causa.
- 7- MPE/MT (FCC 2019 – adaptada)** Seguindo a tendência da legislação brasileira de estabelecer prioridades de atendimento, o Código de Processo Penal estabelece que se dará prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, bem como em qualquer crime contra a pessoa ou o patrimônio de criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.
- 8- MP/DFT (MP/DFT 2015 – adaptada)** No rito ordinário, o interrogatório é realizado pelo sistema presidencial, não havendo previsão de perguntas diretas das partes ao réu.
- 9- TJ/RO (VUNESP 2019 – adaptada)** O interrogatório por videoconferência de réu preso não pode ser determinado de ofício pelo Juiz, mas somente após pedido da autoridade administrativa responsável pela unidade prisional.
- 10- DPE/SP (FCC 2009 – adaptada)** De acordo com a lei processual, o interrogatório do réu preso será realizado, em regra, pessoalmente, devendo o interrogando ser requisitado e escoltado ao juízo.
- 11- MP/DFT (MP/DFT 2013 – adaptada)** Não se estabelece restrição quanto à idade para poder testemunhar em processo penal.
- 12- MP/DFT (MP/DFT 2013 – adaptada)** Em julgamento de Repercussão Geral, o STF entendeu, por maioria, que não é nula a audiência de oitiva de testemunha, por carta precatória, de réu preso que não manifestou expressamente intenção de participar da audiência.
- 13- DPE/MG (FUNDEP 2014 – adaptada)** A expedição de carta precatória para oitiva de testemunha não suspenderá a instrução criminal e, de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, a ausência de intimação da expedição da referida precatória é causa de nulidade relativa do processo criminal.
- 14- TRF 2ª Região (TRF 2ª Região 2014 – adaptada)** A defesa deve ser intimada da expedição de carta precatória e da data da audiência no Juízo deprecado, sob pena de nulidade.
- 15- DPE/RO (VUNESP 2017 – adaptada)** Sobre os meios de prova, é correto afirmar que o juiz permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais se estas forem inseparáveis da narrativa do fato.

**16- MPE/RR (Cespe/UnB 2008 – adaptada)** Alex, ao ser interrogado em processo penal, não foi comunicado pelo juiz acerca de seu direito constitucional de se manter em silêncio. Durante seu interrogatório, confessou as infrações penais que lhe foram imputadas. Nessa situação, mesmo sendo considerado o interrogatório como meio de prova e de defesa, configura-se causa de nulidade relativa, em razão da aplicação do princípio *nemo tenetur se detegere*.

**17- MPE/AM (FMP Concursos 2015 – adaptada)** Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, determinará a pronta retirada do réu da sala de audiência, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.

**18- MPE/GO (MPE/GO 2019 – adaptada)** O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem. Por opção dele, as comunicações poderão ser feitas por meio eletrônico.

**19- MPE/SC (MPE/SC 2019)** Prescreve o Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoa, que não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento a disposição de que se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela.

**20- DPE/ES (Cespe/UnB 2009)** Quando for necessário fazer o reconhecimento judicial do acusado, não é obrigatório que ele seja colocado ao lado de outras pessoas que com ele guardem semelhança.

**21- TRF 2ª Região (TRF 2ª Região 2014 – adaptada)** Os documentos em língua estrangeira só serão juntados ao processo depois de traduzidos.

**22- MPE/GO (MPE/GO 2019 – adaptada)** As cartas particulares, interceptadas ou obtidas por meios criminosos, não serão admitidas em juízo. Entretanto, as cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, para a defesa de seu direito, devendo constar o consentimento expresso do signatário, evitando-se a violação da privacidade e a ilicitude da prova.

**23- DPE/RO (VUNESP 2017 – adaptada)** Sobre os meios de prova, é correto afirmar que não é permitida à parte a juntada de documentos em razões de apelação ou em suas contrarrazões.

**24- MPE/MA (MPE/MA 2014 – adaptada)** A busca pessoal dependerá de mandado judicial, ainda que houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

**25- MPE/SP (MPE/SP 2019 – adaptada)** Com base na orientação jurisprudencial assentada no STJ quanto à ilicitude da prova, é considerada ilícita a prova obtida através de busca pessoal em mulher realizada por policial masculino, por violar o direito à intimidade, quando comprovado que a presença de uma policial feminina para a realização do ato importará retardamento da diligência.

**26- MPE/MA (MPE/MA 2014 – adaptada)** Caso haja determinação judicial explícita e fundamentada, pode ser feita pessoalmente pelo delegado a busca domiciliar à noite, pouco importando o dissenso do morador.

**27- MPE/PI (Cespe/UnB 2019 – adaptada)** Em se tratando de celular de propriedade de vítima morta, é ilegal a realização de perícia sem prévia autorização judicial se o aparelho tiver sido entregue a autoridade policial pelo cônjuge da vítima.

**28- MPE/PI (Cespe/UnB 2019 – adaptada)** É lícito o acesso aos dados armazenados em celular apreendido após determinação judicial de busca e apreensão, mesmo que a decisão não tenha expressamente previsto tal medida.

**29- MPE/PR (MPE/PR 2017 – adaptada)** Ao definir regras sobre a medida de busca e apreensão, o Código de Processo Penal estabelece que não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito.

**30- TJ/DFT (Cespe/UnB 2015 – adaptada)** A busca domiciliar pode ocorrer durante o dia ou durante a noite. Nesta, será necessária a autorização do morador. Naquela, se o morador demonstrar resistência, será permitido o uso da força contra coisas existentes no local.

### COMENTÁRIOS

**1. CORRETO.** Para a doutrina majoritária, "à acusação caberá provar a existência do fato imputado e sua autoria, a tipicidade da conduta, os elementos subjetivos de dolo ou culpa, a existência de circunstâncias agravantes e qualificadoras". Noutro giro, à defesa "incumbirá a prova de eventuais causas excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de tipicidade, circunstâncias atenuantes, minorantes e privilegiadoras que tenha alegado" (AVENA, 2017, p. 321).

**2. CORRETO.** A redação do art. 155, *caput*, do CPP, permite que o juiz fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos de informação colhidos na investigação, desde que tais elementos sejam provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas.

**3. CORRETO.** No âmbito do processo penal, nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha. Frise-se: no processo penal, toda pessoa poderá ser testemunha, pouco importando a sua capacidade civil, podendo ser arrolados como testemunhas os menores de 18 (dezoito) anos, doentes e deficientes mentais (LIMA, 2020, p. 763-764).

**4. ERRADO.** No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC 433.679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 6/3/2018, REPDJe 17/4/2018, DJe 12/3/2018).

**5. CORRETO.** Pela regra dos frutos da árvore envenenada, se uma determinada prova, ainda que obtida por meio lícito, deriva de uma prova ilícita, a ilicitude da primeira contaminará a segunda, devendo haver o desentranhamento das duas.

**6. CORRETO.** Conforme art. 184 do CPP, salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.

**7. ERRADO.** Conforme art. 158, parágrafo único, inciso II, do CPP, nem todo crime contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência terá prioridade na realização do exame de corpo de delito. Para que haja prioridade, o crime deve ser cometido com violência.

**8. CORRETO.** No procedimento comum, o interrogatório, que é um ato personalíssimo, isto é, envolve o juiz e a pessoa do acusado, é regido pelo sistema presidencialista ou presidencial. É dizer: após fazer suas perguntas ao réu, o juiz questiona às partes se não restou esclarecido algum fato. Com base nas respostas das partes, o juiz, se entender pertinente e relevante, fará novas perguntas ao réu (art. 188 do CPP).

**9. ERRADO.** Nos termos do art. 185, §2º, CPP, o interrogatório por videoconferência poderá ser determinado pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes.

**10. ERRADO.** A regra é que o interrogatório do réu preso se dê no próprio estabelecimento prisional em que o interrogando estiver recolhido (art. 185, §1º, CPP). Não sendo possível a realização do interrogatório no próprio estabelecimento prisional e não estando preenchidos os requisitos da videoconferência, aí sim é que será requisitada a apresentação do réu preso em juízo (art. 185, §7º, CPP).

**11. CORRETO.** No âmbito do processo penal, nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha. Frise-se: no processo penal, toda pessoa poderá ser testemunha, pouco importando a sua capacidade civil, podendo ser arrolados como testemunhas os menores de 18 (dezoito) anos, doentes e deficientes mentais (LIMA, 2020, p. 763-764).

**12. CORRETO.** Se o acusado estiver preso e solicitar sua presença no ato, de acordo com o STF, a ele deve ser garantido o direito de presença. Contudo, se o réu preso, devidamente intimado da expedição da carta precatória, não requereu o comparecimento, não há falar em nulidade do ato (LIMA, 2020, p. 768).



**13. CORRETO.** Conforme art. 222, §1º, do CPP, a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. Ademais, nos termos da Súmula nº 155 do STF, que também é bastante recorrente em provas concursais, "é relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha".

**14. ERRADO.** Conforme assenta a Súmula nº 273 do STJ, "intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado". Frise-se: o juízo deprecante, isto é, que expediu a carta precatória, somente tem a obrigação de intimar as partes quanto à expedição da carta precatória. Não compete ao juízo deprecante intimar as partes quanto à data da audiência designada no juízo deprecado.

**15. CORRETO.** Nos termos do art. 213 do CPP, o juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Isto é: quando não for possível separar as apreciações pessoais da narrativa do fato, a testemunha poderá externá-las.

**16. CORRETO.** Caso o juiz não advirta o réu quanto ao direito ao silêncio, ter-se-á configurada, tão somente, nulidade relativa, cuja declaração depende da comprovação do prejuízo (RHC 96.396/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018).

**17. ERRADO.** Caso o juiz verifique que a presença do réu na sala de audiência poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, sua primeira opção é a oitiva da vítima ou testemunha por intermédio de videoconferência. É dizer: a retirada do réu da sala de audiência não é a primeira opção, o que recorrentemente é cobrado em provas de primeira fase. Caso não seja possível a realização da oitiva da vítima ou da testemunha por videoconferência, aí sim é que o juiz determinará a retirada do réu da sala de audiência, prosseguindo na inquirição, com a presença de seu defensor.

**18. CORRETO.** Conforme art. 201, §2º, do CPP, o ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem, o que, por opção da vítima, poderá ocorrer por meio eletrônico (art. 201, §3º, do CPP).

**19. CORRETO.** O art. 226, inciso III, do CPP, diz que, se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela, o que visa garantir, não só a livre produção da prova, mas também a segurança do reconhecedor. Todavia, o parágrafo único do art. 226 do CPP diz que o disposto no citado inciso III não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento. É dizer: de acordo com o Código, essa proteção ao reconhecedor somente vale na fase de investigação. Na instrução criminal ou em plenário do Júri, o reconhecedor não teria esse direito, ou seja, a pessoa que foi reconhecida saberia quem o reconheceu.

**20. CORRETO.** Não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento, pois o art. 226, inciso II, do CPP, determina que o agente será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiverem qualquer semelhança "se possível", sendo tal determinação, portanto, recomendável mas não essencial (HC 7.802/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 20/5/1999, DJ 21/6/1999, p. 172).

**21. ERRADO.** Conforme art. 236 do CPP, os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público, ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade. Nesse contexto, pela redação do citado artigo, a juntada é sempre imediata, podendo haver ou não a tradução do documento trazido aos autos.

**22. ERRADO.** Se alguém é o legítimo destinatário da carta, isto é, a recebeu por meios lícitos, poderá exibí-la em juízo, ainda que não haja consentimento do signatário, nos termos do parágrafo único do art. 233 do CPP.

**23. ERRADO.** Conforme art. 231 do CPP, salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Isto é: a qualquer momento, se não houver proibição legal, as partes poderão juntar documentos aos autos. Atualmente, a exceção legal fica por conta do art. 479, *caput*, do CPP.



**24. ERRADO.** Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independe de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

**25. ERRADO.** A regra é que a busca pessoal em mulher seja feita por outra mulher. Contudo, se isto não for possível, isto é, se importar retardamento ou prejuízo da diligência, a busca poderá ser feita por um homem, nos termos do art. 249 do CPP.

**26. ERRADO.** De acordo com o art. 5º, inciso XI, da CF/88, c/c art. 245, *caput*, primeira parte, do CPP, não havendo consentimento do morador, a busca domiciliar exigirá mandado judicial e deverá ser realizada durante o dia.

**27. ERRADO.** Caso a vítima tenha morrido e o celular tenha sido entregue à polícia pela pessoa que ficou viúva, a autoridade policial, independentemente de ordem judicial, pode acessar às mensagens contidas no aparelho que lhe fora entregue (STJ. 6ª Turma. RHC 86.076-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. Ac. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 19/10/2017 - Info. 617).

**28. CORRETO.** Caso o celular tenha sido apreendido em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar anteriormente expedido, ainda que não haja autorização expressa, poderá haver o acesso às mensagens registradas no aparelho. É dizer: a ordem de busca e apreensão determinada já é suficiente para permitir o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos (STJ. 5ª Turma. RHC 77.232/SC, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 3/10/2017).

**29. CORRETO.** Nos termos do §2º do art. 243 do CPP, não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. É dizer: a regra geral é que não pode haver a apreensão de documento em poder do defensor do investigado ou acusado. Contudo, se esse documento fizer parte do corpo de delito do crime apurado, poderá ser determinada a sua apreensão.

**30. CORRETO.** De acordo com o art. 5º, inciso XI, da CF/88, c/c art. 245, *caput*, primeira parte, do CPP, para que a busca domiciliar ocorra durante a noite, é necessário consentimento do morador. Ademais, nos termos do art. 245, §3º, do CPP, recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura.

## CAPÍTULO 17 – SUJEITOS PROCESSUAIS (ARTS. 251 A 281, CPP)

### 1. INTRODUÇÃO

Os sujeitos ou atores processuais são as pessoas que intervêm, de forma direta ou indireta, no curso da marcha processual, objetivando a concretização de determinados atos, sendo classificados em duas ordens (AVENA, 2017, p. 88):

I) SUJEITOS PRINCIPAIS OU ESSENCIAIS: são os que a presença é indispensável para que se tenha uma regular relação jurídica processual, sendo que, no processo penal, pertencem a esta categoria o juiz (Estado-juiz), o acusador (Ministério Público ou querelante, a depender do tipo de iniciativa da ação penal) e o acusado, devendo ser frisado que o advogado não é parte e sim representante do réu; e

II) SUJEITOS SECUNDÁRIOS OU ACESSÓRIOS OU COLATERAIS OU PRESCINDÍVEIS: são os que podem, de forma eventual, intervir no processo, deduzindo uma determinada pretensão. Todavia, a ausência desses atores não infirma a validade da relação processual instaurada, estando incluídos nesta categoria o assistente de acusação e os terceiros interessados, dentre os quais podem ser citados a vítima, seu representante legal ou sucessores, "que têm interesse na prolação de sentença condenatória para fins de reparação do prejuízo causado pelo delito, assim como o fiador do acusado, haja vista o disposto nos arts. 341 e 343 do CPP" (LIMA, 2017, p. 1205), que tratam do quebramento da fiança.

A par dessas duas categorias, a doutrina elenca uma terceira, que, embora não faça parte da relação jurídica processual, participa do curso do processo praticando atos que possibilitam o desenvolvimento regular da marcha procedimental, auxiliando o magistrado e as partes na solução do litígio, "tais como o escrivão, escrevente, distribuidor, porteiro de auditórios, oficial de justiça, perito, tradutor, intérprete, assim como os terceiros não interessados" (LIMA, 2017, p. 1205).

### 2. JUIZ (ARTS. 251 A 256, CPP)

Ao Estado-juiz é dada a função de, mediante atuação imparcial, aplicar o direito material ao caso concreto, substituindo a vontade das partes e pondo fim ao litígio instaurado, sempre objetivando o reestabelecimento da paz social, tendo a lei lhe conferido determinados poderes para a concretização de seu mister, dentre os quais se destacam (AVENA, 2017, p. 88-89):

I) PODERES DE POLÍCIA OU ADMINISTRATIVOS: são os que objetivam evitar a prática de atos perturbadores ao regular desenvolvimento da marcha processual, garantindo a disciplina e o decoro. Conferem ao juiz poderes para restringir a liberdade da parte ou de terceiro, não sendo necessária para seu exercício a participação da força policial, ainda que, em diversas hipóteses, é dado ao magistrado requisitá-la. A título exemplificativo, nos seguintes artigos, é possível verificar o exercício de poderes de polícia ou administrativos pelo magistrado:

Art. 251, CPP. Ao juiz incumbirá prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública.

Art. 497, CPP. São atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri, além de outras expressamente referidas neste Código: I – regular a polícia das sessões e prender os desobedientes;

Art. 794, CPP. A polícia das audiências e das sessões compete aos respectivos juízes ou ao presidente do tribunal, câmara, ou turma, que poderão determinar o que for conveniente à manutenção da ordem. Para tal fim, requisitarão força pública, que ficará exclusivamente à sua disposição.

II) PODERES JURISDICIONAIS: são os que dizem respeito à condução do processo propriamente dita, envolvendo, por exemplo, a tomada de decisões, a execução das determinações nelas contidas e a produção probatória, subdividindo-se em:

II.a) PODERES INSTRUMENTAIS OU DE MEIO: compreendem a prática de atos ordinatórios, que têm por objetivo dar andamento à marcha processual, como ocorre, por exemplo, com um despacho de mero expediente que determina a intimação da parte para manifestação; e a concretização de atos instrutórios, que visam coletar elementos probantes aptos a formar o convencimento do magistrado, como se dá, por exemplo, quando o juiz defere diligências probatórias requeridas pelas partes; e

II.b) PODERES FINALÍSTICOS OU PODERES-FINS: abrangem a prática de atos decisórios, como a decretação de prisão preventiva, concessão de liberdade provisória, sequestro de bens, prolação de sentença absolutória etc.; e a concretização de atos executórios, tais como a execução de sentença penal condenatória transitada em julgado.

## 2.1. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL

A CF/88, ao vedar, em seu art. 5º, inciso XXXVII, a criação de juízo ou tribunal de exceção e dispor, no inciso LIII, que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, trouxe o que se convencionou chamar de princípio do juiz natural, o qual exige que a determinação do juiz competente se dê por normas previamente estabelecidas, vedando-se designações casuísticas. É dizer: mesmo antes do cometimento de determinada infração penal, de antemão, já sabemos qual é o juízo competente para seu processo e julgamento.

Enfrentando o tema, o STF, no julgamento do RE 597.133/RS, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, assentou que não afronta o citado princípio o fato de os órgãos fracionários dos Tribunais (turmas, câmaras ou seções) serem compostos majoritariamente por juízes de primeiro grau convocados.

No mesmo sentido, a Suprema Corte, no julgamento da ADI 4.414/AL, de relatoria do Min. Luiz Fux, fixou que não viola o princípio do juiz natural a criação, por lei estadual, de varas especializadas em delitos praticados por organizações criminosas, mesmo que a competência territorial dessa vara abranja todo o Estado.

Por fim, à luz da Súmula nº 704 do STF, "Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados".

## 2.2. PRERROGATIVAS DOS MAGISTRADOS

A fim de conferir aos magistrados a isenção e a imparcialidade necessárias ao bom desempenho de suas funções jurisdicionais, a Constituição Federal lhes confere determinadas prerrogativas, das quais se destacam (AVENA, 2017, p. 90):

I) VITALICIEDADE: conforme art. 95, inciso I, CF/88, após dois anos de efetivo exercício, os juízes de primeira instância alcançarão a vitaliciedade, não podendo mais perder o cargo, salvo por sentença judicial transitada em julgado. Antes do cumprimento do citado prazo, dispõe o mencionado inciso que a perda do cargo depende de deliberação do Tribunal a que o magistrado estiver vinculado. Se a investidura se deu no cargo de desembargador ou ministro de Tribunal Superior, não há a exigência de cumprimento do prazo bienal, atingindo-se a vitaliciedade logo no ato da posse.

Importa assentar que a garantia da vitaliciedade "é adquirida pelo magistrado automaticamente com o decurso do prazo de dois anos, razão pela qual o pronunciamento dos órgãos superiores do Tribunal tem caráter meramente declaratório" (LIMA, 2017, p. 1212).

II) INAMOVIBILIDADE: nos termos do art. 95, inciso II, CF/88, ao magistrado é garantida a sua manutenção no local em que se encontra lotado, salvo se o próprio juiz quiser ser movimentado ou houver interesse público em sua movimentação. Nesse caso, deverá haver decisão da maioria absoluta do Tribunal ao qual o juiz está vinculado ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurando-se ao magistrado o exercício da ampla defesa, nos termos do art. 93, VIII, CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

Frise-se que, no julgamento do MS nº 27.958/DF, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, o STF assentou que a inamovibilidade também é extensível aos juízes substitutos, em relação aos quais tal garantia se dá no âmbito da Comarca. Assim, um juiz substituto, que esteja lotado na Comarca de Ipameri/GO, poderá substituir seus colegas afastados, todavia, não poderá ser movimentado para outra comarca, a não ser que queira ou por interesse público, na forma acima explicitada.

III) IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIOS: é instituída a fim de salvaguardar os magistrados de intentadas persecutórias por parte dos detentores do poder. Não se trata, porém, de um direito absoluto, comportando algumas exceções referendadas pelo art. 95, inciso III, da CF/88.

### 2.3. VEDAÇÕES AOS MAGISTRADOS

Também objetivando o bom desempenho das funções atreladas ao exercício da magistratura, a Constituição Federal, em seu art. 95, parágrafo único, traz uma série de vedações aos magistrados, destacando-se:

I) EXERCÍCIO DE OUTRO CARGO OU FUNÇÃO: nos termos do inciso I, aos magistrados é defeso "exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério";

Em relação ao exercício do magistério, é importante frisar que, embora a Constituição se valha da expressão "uma de magistério", desde que haja compatibilidade de horários, não há limitação numérica, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI nº 3.126/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes.

Também é importante registrar que aos magistrados, nos termos da Resolução nº 226/2016 do Conselho Nacional de Justiça, é vedado o exercício das "atividades de *coaching*, similares e congêneres".

II) RECEBIMENTO DE CUSTAS OU PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO: conforme inciso II, é vedado aos juízes "receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo";

III) DEDICAÇÃO À ATIVIDADE POLÍTICO-PARTIDÁRIA: enquanto não se aposentar, o magistrado não poderá se dedicar à atividade político-partidária, o que somente lhe será permitido após sua aposentadoria ou outro afastamento definitivo do cargo;

IV) RECEBIMENTO DE AUXÍLIOS OU CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS, ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS: dispõe o inciso IV que é vedado aos magistrados "receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei"; e

V) QUARENTENA DE SAÍDA: conforme o inciso V, é proibido aos magistrados "exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração", sendo de suma importância se atentar ao fato de que a vedação somente se estende ao juízo ou tribunal do qual o juiz se afastou. Logo, um Ministro do STJ, tão logo tenha se aposentado, isto é, antes do decurso do prazo de três anos, poderá advogar perante o STF, sendo-lhe somente vedado, antes da quarentena de saída, o exercício da advocacia frente ao STJ.

## 2.4. IMPARCIALIDADE DOS JUÍZES

A fim de que o magistrado possa exercer a judicatura em determinado caso concreto, é necessário que inexistam motivos capazes de prejudicar a sua imparcialidade, já que, tendo em vista ser ele um "órgão que proclama o Direito, não se considera justa uma decisão proferida por um juiz que não seja imparcial", sendo de suma importância o estudo dos institutos do impedimento, suspeição e incompatibilidades (LIMA, 2017, p. 1213).

## 2.5. CAUSAS DE IMPEDIMENTO (ART. 252 DO CPP)

Os motivos que ensejam o impedimento do juiz estão taxativamente dispostos no art. 252 do CPP, sendo todos eles de cunho objetivo, já que relacionados a um vínculo interno entre o magistrado e o objeto da contenda, havendo uma presunção absoluta (*juris et de jure*) de parcialidade do juiz.

Nos termos do inciso I do citado artigo, o magistrado não poderá atuar no processo em que "tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito".

Em relação a essa causa de impedimento, é sempre salutar rememorar que, embora não tenha havido disposição expressa quanto ao ponto, as vedações ali existentes se estendem ao companheiro heterossexual ou homossexual, a teor do art. 226, § 3º, CF/88.

Conforme inciso II, o magistrado também estará impedido de funcionar no processo em que ele próprio tiver atuado como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça, perito ou tiver servido como testemunha.

No ponto, impende assentar que a Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), ao acrescentar ao CPP o art. 3º-D, criou mais uma hipótese de impedimento referente ao exercício de funções anteriores, porquanto o magistrado que, na fase de investigação criminal, praticar qualquer ato incluído na competência do juiz das garantias, ficará impedido de funcionar no processo.

O inciso III dispõe que o magistrado não poderá exercer a judicatura no processo em que "tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão".

Aqui, é interessante assentar que, para parcela significativa da doutrina, tal dispositivo legal também é aplicável às Turmas Recursais, impedindo que o magistrado atue no mesmo processo como juiz de primeira instância do Juizado Especial Criminal e participe de seu julgamento no âmbito da respectiva Turma Recursal (LIMA, 2017, p. 1215).

Por ser o rol dos impedimentos do tipo taxativo, o STF, no julgamento do RHC nº 131.735/DF, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, assentou que "o magistrado que atuou como corregedor em processo administrativo instaurado contra o réu não está impedido de participar como julgador no processo criminal que tramita contra o acusado".

A seu turno, o inciso IV diz que o juiz é impedido de funcionar no processo em que "ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito", também devendo ser incluído o companheiro nesse dispositivo, à luz dos comentários relacionados ao inciso I.

Interessante anotar, finalizando o estudo dos impedimentos dos magistrados, que o STF, no julgamento da ADPF nº 378/DF, assentou que não são aplicáveis ao processo de *impeachment* as hipóteses de impedimento previstas no Código de Processo Penal.

### 2.5.1. EFEITO DAS CAUSAS DE IMPEDIMENTO

No que diz respeito aos efeitos de eventual impedimento do magistrado, a maioria da doutrina aduz que tais situações acarretariam na inexistência da decisão prolatada, porquanto, à luz do art. 252, *caput*, do CPP, o impedimento proíbe o magistrado de exercer a judicatura no processo

em que ocorrer, sendo um vício de maior gravidade em relação à suspeição, que tem como consequência o reconhecimento de nulidade absoluta, nos termos do art. 564, inciso I, do CPP (AVENA, 2017, 93).

## 2.6. JUÍZOS COLETIVOS (ART. 253 DO CPP)

Nos Tribunais e nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, conforme disposição trazida pelo art. 253 do CPP de forma taxativa, "não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive".

## 2.7. CAUSAS DE SUSPEIÇÃO (ART. 254 DO CPP)

As causas de suspeição estão, de forma exemplificativa, previstas no art. 254 do CPP e, via de regra, são circunstâncias subjetivas que estão atreladas a fatos externos ao processo, trazendo à tona uma presunção relativa (*juris tantum*) de parcialidade do magistrado, já que este "é suspeito quando se interessa por qualquer das partes" (LIMA, 2017, p. 1217).

Diz-se que o rol contido no art. 254 do CPP é do tipo exemplificativo, porquanto se admite a declaração de suspeição por razões de foro íntimo, usando-se, por analogia, do art. 145, § 1º, do CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP.

Nos termos do inciso I, haverá suspeição do magistrado que for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes.

Assenta-se que, para incidir tal causa de suspeição, não basta que o magistrado seja conhecido de qualquer das partes ou por elas demonstre civilidade, é necessário que a amizade ou a inimizade sejam intensas e partam do juiz, sendo desimportante o fato das partes nutrirem pelo magistrado tais sentimentos, porquanto a imparcialidade somente é exigida do julgador. (LIMA, 2017, p. 1217).

Interessante assentar que, para se verificar a referida causa de suspeição, a amizade íntima ou a inimizade capital deve ocorrer entre o magistrado e as partes, "aí compreendidas em seu sentido material, isto é, acusado e vítima, e não em relação ao advogado (representante do acusado), ao órgão do Ministério Público ou ao advogado do assistente de acusação" (LIMA, 2017, p. 1218).

Conforme inciso II, haverá suspeição do magistrado "se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia", devendo ser aí incluído o companheiro heterossexual ou homossexual, nos termos do art. 226, § 3º, CF/88.

Nos termos do inciso III, o juiz deverá declarar a sua suspeição "se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes".

Exemplificando a hipótese, suponhamos que João, filho do desembargador José, responde a processo criminal perante o juiz Pedro, que está sendo processado criminalmente pelo Tribunal a que é vinculado. Nesse caso, o desembargador José deverá se declarar suspeito de participar do julgamento do juiz Pedro (LIMA, 2017, p. 1218).

Conforme inciso IV, o juiz deverá se declarar suspeito "se tiver aconselhado qualquer das partes", já que é exigido do magistrado uma posição equidistante delas, não incidindo tal causa se o juiz, por exemplo, somente orientar uma das partes a procurar um advogado para a tutela de seus direitos (LIMA, 2017, p. 1218).

Nos termos do inciso V, haverá suspeição do magistrado que "for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes", porquanto, nessas hipóteses, o magistrado, muito provavelmente, não terá a imparcialidade necessária ao julgamento da causa.



À luz do inciso VI, o juiz é suspeito "se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo", já que, também nesses casos, o magistrado não conseguirá julgar a demanda com a imparcialidade que lhe é exigida.

### 2.7.1. EFEITO DAS CAUSAS DE SUSPEIÇÃO

Embora com alguma divergência, a maioria da doutrina explica que, atuando na causa um juiz suspeito, haverá nulidade absoluta daquele processo, nos termos do art. 564, inciso I, do CPP.

Diz-se absoluta a referida nulidade, porquanto, ao fazer referência às nulidades que poderão ser sanadas, o art. 572 do CPP nada falou em relação ao inciso I do art. 564 do mesmo Código, que faz referência à "incompetência, suspeição ou suborno do juiz". Logo, interpretando o art. 572 do CPP, a *contrario sensu*, chega-se à conclusão de que a suspeição é causa de nulidade absoluta, porquanto, ao contrário das nulidades relativas, aquela pode ser alegada a qualquer momento tempo, não se sujeitando à preclusão (LIMA, 2017, p. 1217).

### 2.8. CESSAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAUSAS DE IMPEDIMENTO OU DE SUSPEIÇÃO (ART. 255 DO CPP)

À luz do art. 255 do CPP, com a dissolução do casamento, cessam as causas de impedimento ou suspeição decorrentes do parentesco por afinidade, salvo se sobrevieram descendentes do vínculo conjugal. Logo, a regra é que o rompimento do matrimônio acarreta cessação das causas de impedimento ou de suspeição, todavia, ainda que ocorra a dissolução do vínculo marital, se sobrevierem descendentes, não ficarão afastadas tais causas.

De todo modo, mesmo no caso de dissolução de casamento sem descendentes, não poderá funcionar como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo.

### 2.9. ANIMOSIDADE POR MÁ-FÉ (ART. 256 DO CPP)

Como visto, se o juiz for inimigo capital de qualquer das partes, deverá se declarar suspeito para o julgamento da causa, nos termos do art. 254, inciso I, do CPP. Todavia, se a parte injuriar o magistrado ou de próprio der motivo para criar a referida causa de suspeição, esta não poderá ser declarada nem reconhecida, já que ninguém não pode se beneficiar da própria torpeza, nos termos do art. 256 do CPP.

### 2.10. INCOMPATIBILIDADE

Com pouca ou nenhuma precisão técnica, o art. 112 do CPP diz que, havendo *incompatibilidade* ou impedimento legal, o juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes deverão se abster de atuar no processo, declarando tais circunstâncias nos autos. Caso não o façam, a *incompatibilidade* ou o impedimento legal poderá ser arguido pelas partes, seguindo-se o procedimento estabelecido para a exceção de suspeição.

As causas de impedimento, como visto, estão elencadas, de forma taxativa, no art. 252 do CPP, enquanto as de suspeição, em um rol exemplificativo, foram listadas no art. 254 do mesmo Código.

Todavia, não cuidou o legislador de conceituar ou trazer as hipóteses de *incompatibilidades*, divergindo a doutrina quanto ao ponto.

Uma primeira corrente sustenta que as *incompatibilidades* seriam uma espécie de terceira categoria do gênero causas de afastamento do processo de algum dos funcionários públicos que nele atuam, estando suas hipóteses amparadas em razões de conveniência, gerando, à

semelhança do que ocorre com as causas de impedimento, a inexistência da decisão proferida, porquanto o juiz não poderá exercer a judicatura (LIMA, 2017, 1220).

Em contrapartida, uma segunda corrente defende que a *incompatibilidade* nada mais é do que a declaração de ofício de uma causa de suspeição, isto é, seria "a afirmação, sem provocação da parte interessada, da suspeição" (NUCCI, 2016, p. 213).

Um terceiro posicionamento, mais próximo da segunda corrente, diz que a *incompatibilidade* se confunde com a suspeição por razões de foro íntimo, o que geraria como consequência, caso um juiz incompatível atue no feito, o reconhecimento de nulidade absoluta (LIMA, 2017, 1220).

### 3. DO MINISTÉRIO PÚBLICO (ARTS. 257 E 258, CPP)

#### 3.1. DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

Conforme art. 127, *caput*, CF/88, "O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis", sendo ele, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo constitucional, regido por três princípios basilares:

I) UNIDADE: por tal característica, diz-se que os membros do Ministério Público "fazem parte de uma só instituição, a qual tem como chefe o Procurador-Geral da República (Ministério Público da União) ou o Procurador-Geral de Justiça (Ministério Público dos Estados) (TÁVORA; ALENCAR, 2017, 864);

II) INDIVISIBILIDADE: "o Ministério Público não se manifesta por meio deste ou daquele membro individual e pessoalmente considerado, mas sim pela atuação da Instituição como um todo" (AVENA, 2017, p. 95), podendo haver a substituição dos integrantes da carreira "uns pelos outros, segundo as prescrições legais" (LIMA, 2017, p. 1229); e

III) INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL: "cada órgão do Ministério Público delibera sobre o conteúdo do ato que deve praticar, não estando vinculado à sua atuação anterior ou a de outro órgão ministerial" (LIMA, 2017, p. 1230).

#### 3.2. GARANTIAS DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

De acordo com o art. 128, inciso I, CF/88, os membros do Ministério Público gozam das mesmas garantias dos magistrados, isto é, também estão protegidos pela vitaliciedade, após dois anos de efetivo exercício, inamovibilidade, salvo se quiserem ser movimentados ou por interesse público, e irredutibilidade de subsídios.

#### 3.3. VEDAÇÕES AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Também de forma paritária aos membros da magistratura, o art. 128, II, c/c seu § 6º, CF/88, traz uma série de vedações aos membros do Ministério Público, que merecem ser lidas à inteireza, destacando-se aquela que proíbe o exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério (alínea d).

No ponto, interessante assentar que, no julgamento da ADI nº 3.574, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, o STF assentou que, aos membros que ingressaram no Ministério Público após a CF/88, é vedado o exercício de cargos que estejam fora da estrutura da própria instituição, a exemplo de Ministérios ou Secretarias do Poder Executivo.

Em contrapartida, na ADPF nº 388, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, a Suprema Corte fixou que tal vedação, isto é, o exercício de cargos fora do Ministério Público, não alcança os membros que tenham ingressado na instituição antes do advento da CF/88.

### 3.4. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

À luz do art. 257 do CPP, no processo penal, o Ministério Público poderá atuar como parte formal ou como parte imparcial.

Conforme inciso I, lido em consonância com o art. 129, inciso I, CF/88, compete ao Ministério Público, aqui atuando como parte formal, promover, de forma privativa, a ação penal pública, sendo o *Parquet*, via de regra, o órgão legitimado ao oferecimento da peça acusatória.

Noutra banda, de acordo com o inciso II, analisado em conformidade com o *caput* do art. 129 da CF/88, ao Ministério Público compete fiscalizar a execução da lei, caso em que atua como parte imparcial, exercendo a função de *custos legis* ou *custos iuris*.

### 3.5. CAUSAS DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (ART. 258 DO CPP)

Dispõe o art. 258 do CPP que os membros do Ministério Público não atuarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, sendo a eles extensíveis, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes.

Aqui, interessante rememorar o teor da Súmula nº 234 do STJ, a qual dispõe que "A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia".

Como visto, a atividade de investigação criminal não é privativa das polícias judiciárias da União ou dos Estados, podendo ser conduzida pelo Ministério Público, caso em que o membro responsável por ela não estará impedido ou suspeito para o oferecimento da denúncia correlata.

### 3.6. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL E IMPARCIAL OU PROMOTOR LEGAL

À similitude do princípio do Juiz natural, valendo-se da expressão "processado" inserta no art. 5º, inciso LIII, CF/88, da inamovibilidade e da independência funcional dos membros do Ministério Público, a doutrina abarca o princípio do Promotor natural, que visa afastar a figura do acusador de exceção, impedindo a designação casuística e injustificada de determinado membro para atuar em um caso específico.

É importante destacar que, no julgamento do EREsp nº1.327.573/RJ, de relatoria do Min. Ari Pargendler, o STJ assentou que o Ministério Público Estadual tem legitimidade para atuar diretamente como parte em recurso submetido a julgamento perante o STJ, funcionando o Ministério Público Federal como *custos legis*. É dizer: a função de parte formal será exercida pelo Ministério Público Estadual e a de parte imparcial será manejada pelo Ministério Público Federal.

## 4. DO ACUSADO E SEU DEFENSOR (ARTS. 259 A 267, CPP)

### 4.1. ACUSADO: DEFINIÇÃO E PEÇA ACUSATÓRIA SEM DADOS QUALIFICATIVOS (ART. 259 DO CPP)

O acusado é a "pessoa que figura no polo passivo da relação processual penal, a quem é imputada a prática de uma infração penal e em face de quem se busca que seja realizada a pretensão punitiva do Estado" (AVENA, 2017, p. 97).

No processo penal, somente poderão figurar no polo passivo da relação jurídica processual a pessoa física, desde que maior de 18 (dezoito) anos e a pessoa jurídica, quando o processo for atinente a crime ambiental, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.605/98; art. 173, § 5º e art. 225, § 3º, da CF/88. Sendo a parte ilegítima, haverá nulidade do processo, conforme art. 564, inciso II, do CPP.

Quanto às pessoas jurídicas, rememora-se que não mais se exige a dupla imputação, isto é, que, ao lado delas, sejam denunciadas as pessoas físicas por elas responsáveis, conforme

assentado pelo STF no emblemático julgamento do RE nº 548.181/PR, de relatoria da Min. Rosa Weber, que tem sido seguido pelo STJ, como ocorreu, por exemplo, no julgamento do RMS nº 39.173/BA, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

Outra questão interessante diz respeito aos inimputáveis ou semi-imputáveis à época do fato, os quais poderão figurar no polo passivo da relação processual, já que a eles será aplicada uma medida de segurança, conforme art. 386, parágrafo único, inciso III, do CPP (sentença absolutória imprópria).

Conforme art. 41 do CPP, a peça acusatória deverá conter a qualificação do acusado ou os esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo.

Todavia, dispõe o art. 259 do mesmo Código que, caso seja certa a identidade física do acusado, a impossibilidade de identificá-lo com o seu verdadeiro nome ou outros dados qualificativos não retardará a ação penal. Sendo descobertos o nome ou os dados de qualificação do réu, a qualquer momento, no curso do processo, do julgamento ou da execução penal, far-se-á, por termo nos autos, sua retificação, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.

Em outras palavras, é possível uma denúncia ou queixa-crime em desfavor de alguém em relação ao qual não se tenha nenhum dado qualificativo, desde que sua identidade física seja certa.

#### 4.2. CONDUÇÃO COERCITIVA DO ACUSADO (ART. 260 DO CPP)

Dispõe o art. 260, *caput*, CPP, que não tendo o acusado atendido à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá determinar a sua condução coercitiva.

Quanto ao ponto, tema de suma importância para as provas de concurso diz respeito à condução coercitiva do acusado para o ato de interrogatório, enfrentado pelo STF no julgamento das ADPF de nº 395/DF e 444/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes.

De acordo com o Supremo, a expressão "para o interrogatório" não foi recepcionada pela CF/88, já que, entre outros, fere o direito à não autoincriminação e o princípio da dignidade humana, sujeitando o agente que determinar tal ato à responsabilidade disciplinar, civil e penal, além da ilicitude das provas obtidas e da responsabilidade civil do Estado.

Modulando os efeitos de sua decisão, o STF assentou que tal entendimento não afasta a validade dos julgamentos que ocorreram em data anterior, isto é, antes de 14 de junho de 2018, ainda que os interrogados tenham sido coercitivamente conduzidos para o referido ato processual.

É importante frisar que somente foi rechaçado pela Suprema Corte o instituto da condução coercitiva para o interrogatório, não sendo afastada a possibilidade de tal medida para o reconhecimento ou qualquer ato que, sem o investigado ou acusado, não possa ser realizado.

Portanto, mesmo após o julgamento das Ações acima mencionadas, afigura-se possível, por exemplo, desde que imprescindível à investigação criminal ou à instrução processual penal, a condução coercitiva de alguém para ser submetido a procedimento de reconhecimento pessoal, que não demanda nenhum comportamento ativo do sujeito passivo.

##### 4.2.1. AUTORIDADE COMPETENTE PARA A DETERMINAÇÃO DA CONDUÇÃO COERCITIVA DO INVESTIGADO ACUSADO

Embora haja bastante crítica doutrinária (LIMA, 2017, p. 739), o STF, no julgamento do HC nº 107.644/SP, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, e o STJ, no julgamento do RHC 25.475/SP, de relatoria do Min. Jorge Mussi, assentaram que a condução coercitiva do investigado também pode ser determinada pelo Delegado de Polícia, o que, logicamente, deve ser lido à luz do que restou decidido nas ADPF de nº 395/DF e 444/DF.

#### 4.3. DA INDISPONIBILIDADE DA DEFESA TÉCNICA (ART. 261 DO CPP)

Em consonância com o art. 5º, LV, CF/88, o art. 261, *caput*, do CPP, consagra que a defesa técnica, um dos escopos da ampla defesa, é indisponível, não podendo haver processo-crime em desfavor de alguém que não esteja assistido por um defensor, ainda que o acusado se encontre ausente ou foragido.

Nos termos do art. 564, inciso III, alínea c, CPP e da Súmula nº 523 do STF, a falta de defesa técnica configura nulidade absoluta, enquanto a deficiência da defesa técnica somente dará ensejo à anulação do processo se houver prova do prejuízo para o réu.

Frise-se, no que diz respeito à Súmula nº 523 do STF, que há nítida diferença entre os efeitos da ausência de defesa, que gera nulidade absoluta do processo, e da deficiência de defesa, que somente terá o condão de anular o processo se houver prova do prejuízo para o acusado.

Impende ressaltar que duas são as facetas da ampla defesa, a qual, nesse sentido, se manifesta por meio da defesa técnica, que é exercida por intermédio de profissional do direito legalmente habilitado, e da autodefesa, a qual é concretizada pelo próprio acusado, sendo esta última, ao contrário daquela, dispensável.

O acusado, no exercício de sua autodefesa, pode optar por permanecer em silêncio, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo, nos termos do art. 186, parágrafo único, do CPP.

A teor do parágrafo único do art. 261 do CPP, quando for realizada por defensor público ou dativo, a defesa técnica será sempre exercida através de manifestação fundamentada, o que não é exigido do defensor constituído pelo acusado, já que entre eles há, ao menos em tese, uma relação de confiança.

#### 4.4. CURADOR (ART. 262 DO CPP)

Com o advento do Código Civil de 2002, que previu a maioridade civil aos 18 (dezoito) anos completos, e a revogação expressa do antigo art. 194 do CPP, restou revogado tacitamente o art. 262 do mesmo Código, que exigia a nomeação de curador ao acusado menor de 21 (vinte e um) anos e maior de 18 (dezoito).

Também restou tacitamente revogada a parte final do art. 564, inciso III, alínea c, do CPP, que aduz haver nulidade no caso de ausência de nomeação de curador ao menor de 21 (vinte e um) anos.

#### 4.5. DIREITO DE ESCOLHA DO PRÓPRIO DEFENSOR (ARTS. 263 E 264 DO CPP)

Em consequência do postulado constitucional da ampla defesa, a parte inicial do art. 263 do CPP diz que o acusado tem o direito de escolher seu próprio defensor, somente sendo dado ao juiz nomear um patrono ao acusado, quando este, após ser intimado para tanto, não constituir sua defesa técnica.

Nesse contexto, se o advogado constituído pelo acusado, por exemplo, após ser intimado, deixar de apresentar os memoriais finais da defesa no prazo legalmente estabelecido no art. 403, § 3º, CPP, não pode o juiz, de pronto, nomear um defensor ao réu, que, em verdade, deve ser intimado para que constitua novo advogado. Quedando-se o acusado inerte ou expressamente se manifestando nesse sentido, poderá o juiz nomear-lhe um defensor (LIMA, 2017, p. 57).

De qualquer modo, dispõe a parte final do art. 263 do CPP que, a todo tempo, é resguardado ao acusado nomear um defensor de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação para tanto.

Frise-se que, não sendo o acusado pobre, este arcará com os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz, nos moldes do parágrafo único do art. 263 do CPP.

O defensor nomeado pelo juiz, sob pena de multa, é obrigado a assumir o encargo, salvo se houver motivo relevante impeditivo, nos termos do art. 264 do CPP.



Voltando à questão do direito de escolha do próprio advogado, duas Súmulas do STF merecem ser citadas, dada a importância delas no contexto e nas provas de concurso.

A primeira delas, de nº 707, aduz que "Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprimindo a nomeação de defensor dativo".

Assim, imagine, por exemplo, que, em um processo-crime sujeito ao rito comum ordinário, o juiz, com fulcro em qualquer dos incisos do art. 395 do CPP, rejeite a denúncia formulada pelo Ministério Público, o qual, inconformado, interpõe recurso em sentido estrito, conforme art. 581, inciso I, do mesmo Código. Nessa situação, no mais das vezes, o denunciado ainda não tem advogado, porquanto o procedimento se encontrava na fase de investigação preliminar. Com base no direito de escolher seu próprio advogado, não pode o juiz, sem intimar o denunciado para tanto, nomear-lhe um defensor dativo. Primeiramente, deve o juiz intimar o acusado para que, querendo, constitua um advogado para apresentar as contrarrazões ao RESE interposto pelo Ministério Público. Se o acusado não quiser constituir advogado ou não possuir condições para tanto, aí sim é que o juiz nomeará um defensor dativo.

A segunda delas, de nº 708, dispõe que "É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro".

Portanto, se o acusado era patrocinado por um único defensor e este renuncia aos poderes que lhe foram outorgados, deve o juiz intimar o acusado para que constitua outro advogado. Atente-se que o referido enunciado não tem aplicabilidade no caso da defesa ser formada por mais de um advogado.

Importa ressaltar que, ainda que a renúncia do advogado anterior tenha se dado após a apresentação de eventuais razões recursais, não pode o juiz nomear defensor dativo sem antes intimar o réu para constituir novo advogado.

A título exemplificativo, imagine que, após a prolação de sentença condenatória, o advogado interponha recurso de apelação, com base no art. 593, inciso I, do CPP, tendo o juiz, depois do regular recebimento do apelo, aberto-lhe prazo para a apresentação de suas razões, que são oferecidas pelo advogado no prazo legalmente estabelecido pelo art. 600, *caput*, do mesmo Código. Ocorre que, ao protocolar as razões recursais, o advogado junta também a petição de renúncia dos poderes de representação. Nesse caso, mesmo que já tenha havido a apresentação das razões recursais, o juiz deve intimar o réu para constituir novo advogado, caso o que tenha renunciado seja seu único defensor.

#### 4.6. ABANDONO DA CAUSA E NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA (ART. 265 DO CPP)

Discorre o art. 265, *caput*, do CPP, que, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos e outras sanções cabíveis, o advogado não poderá abandonar o processo, salvo por motivo imperioso, que deverá, previamente, ser comunicado ao juiz.

Se o advogado não puder comparecer à audiência designada, caso justifique sua ausência até a abertura do ato, o juiz poderá determinar o seu adiamento. Caso contrário, não justificando sua ausência até a abertura da audiência, o ato não será adiado, devendo o juiz nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito daquele ato, tudo em conformidade com os §§ 1º e 2º do art. 265 do CPP.

No Júri, conforme art. 456 do CPP, se ocorrer ausência justificada do advogado constituído, o juiz deve designar nova data, sem necessidade de comunicação à OAB ou à Defensoria Pública. Por outro lado, se a ausência for injustificada, o julgamento será adiado somente uma vez. Caso o acusado não constitua novo advogado, o juiz, imediatamente, comunicará o fato ao presidente da seccional da OAB, devendo constar da comunicação a data da nova sessão designada. Além disso, deverá o juiz intimar a Defensoria Pública para o novo julgamento, que será designado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 (dez) dias (LIMA, 2017, p. 1205-1206).



#### 4.7. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NO ATO DE INTERROGATÓRIO (ART. 266 DO CPP)

Dispõe o art. 266 do CPP que, se o acusado indicar seu advogado por ocasião do interrogatório, o defensor, independentemente de instrumento de mandato, estará constituído, o que se denomina de nomeação *apud acta*.

#### 4.8. IMPEDIMENTO DO ADVOGADO (ART. 267 DO CPP)

Conforme art. 267 do CPP, em atenção ao art. 252 do mesmo Código, os parentes do juiz não poderão funcionar como defensores, estando, pois, impedidos de exercer o seu mister.

### 5. DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (ARTS. 268 A 273 DO CPP)

#### 5.1. CONCEITO, TIPOS DE AÇÃO PENAL QUE O ADMITEM, LEGITIMADOS E MOMENTO DE INGRESSO (ART. 268 DO CPP)

De acordo com o art. 268 do CPP, na ação penal pública, em todos os seus termos, poderão intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta destes, seu cônjuge (ou companheiro), ascendente, descendente ou irmão.

Logo, o assistente de acusação é a vítima, ou qualquer das pessoas acima listadas, "que resolve se habilitar no processo penal referente a crime de ação penal pública" (LIMA, 2017, p. 1240).

São, portanto, legitimados à habilitação como assistente de acusação, o ofendido, ou seu representante legal em caso de incapacidade, ou, na sua falta, o cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão.

Não poderá, entretanto, intervir como assistente de acusação, o corréu no mesmo processo, conforme disposição expressa do art. 270 do CPP.

Importante frisar que somente há falar em assistente do Ministério Público no caso de crime cuja persecução criminal se dá por intermédio de ação penal pública, já que, na ação penal de iniciativa privada, o ofendido exercerá a função de querelante, apresentando a própria peça acusatória.

Além disso, é necessário que a infração penal conte com um sujeito passivo determinado, que pode ser pessoa física ou jurídica, não havendo falar em assistente da acusação no caso, por exemplo, de crimes de perigo, já que não há vítima determinada (LIMA, 2017, p. 1240).

Também é digno de nota que, à luz do art. 269 do CPP, o assistente do Ministério Público "será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar".

Logo, somente há falar na figura do assistente de acusação após o início da ação penal, não podendo haver sua habilitação durante as investigações policiais, e até o trânsito em julgado da sentença, não existindo tal figura na execução penal.

Conforme art. 430 do CPP, no Tribunal do Júri, o assistente de acusação "somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 (cinco) dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar".

#### 5.2. DESNECESSIDADE DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA

O STJ, no julgamento do HC nº 293.979/MG, de relatoria do Min. Gurgel de Faria, assentou que, quando a Defensoria Pública atuar como representante do assistente de acusação, mostra-se dispensável a juntada de procuração com poderes especiais.

#### 5.3. PODERES DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

O art. 271, *caput*, do CPP disciplina que, ao assistente de acusação, são conferidas as seguintes atribuições:

I) PROPOR MEIOS DE PROVA: requerida a produção de uma prova pelo assistente, por exemplo, um exame pericial, o juiz, após ouvir o Ministério Público, deferirá ou não tal postulação, com base no art. 271, § 1º, do CPP.

No que diz respeito à indicação de testemunhas a serem ouvidas em juízo, diverge a doutrina, havendo vozes em ambos os sentidos.

A parte da doutrina que bate pela impossibilidade de o assistente de acusação arrolar testemunhas sustenta-se no aspecto temporal do oferecimento da denúncia, momento adequado à apresentação do rol de testemunhas (art. 41 do CPP). Assim, somente havendo falar em assistente de acusação após o recebimento da denúncia, não há como o assistente arrolar testemunhas, já que o momento adequado para tanto, isto é, o oferecimento da denúncia, já passou (PACELLI, 2017, p. 228).

Em contrapartida, uma segunda parte da doutrina sustenta que, conquanto que a habilitação do assistente tenha se dado antes do início da audiência de instrução e julgamento, e desde que o Ministério Público não tenha indicado o número máximo de testemunhas a ele facultadas, poderia o assistente de acusação arrolar as suas (LIMA, 2017, p. 1247).

Interessante rememorar, quanto ao ponto, que, conforme art. 402 do CPP, o assistente de acusação é um dos legitimados a requerer diligências complementares após a audiência de instrução e julgamento.

II) REQUERER PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS: em se tratando de testemunhas (ou informantes) da acusação ou da defesa, as perguntas do assistente de acusação serão sempre formuladas depois do Ministério Público, diretamente às testemunhas ou aos informantes (LIMA, 2017, p. 1247);

III) ADITAR O LIBELO: com a revogação de tal instituto, diz-se que, embora não conste expressamente do art. 422 do CPP, é facultado ao assistente do Ministério Público o arrolamento de testemunhas a serem ouvidas na sessão plenária, desde que a acusação não tenha indicado o número máximo que a lei lhe permite. Ademais, embora também não conste expressamente do citado artigo, entende-se que é possível que o assistente de acusação indique diligências probatórias a serem realizadas na sessão plenária, ouvindo-se, em todo caso, o Ministério Público (PACELLI, 2017, p. 228);

IV) ADITAR OS ARTICULADOS: parte da doutrina entende que aditar os articulados, que são as manifestações por escrito das partes, nada mais é do que o direito que possui o assistente do Ministério Público de apresentar suas próprias alegações finais escritas (NUCCI, 2016, p. 524). Para outra parcela da doutrina, é facultado ao assistente de acusação se manifestar acerca dos articulados apresentados pelo Ministério Público ao longo do procedimento e em relação às alegações finais escritas do órgão ministerial, podendo o assistente de acusação, ademais, contrarrazoar os recursos apresentados pela defesa, porquanto as contrarrazões exercem o papel de articulados (LIMA, 2017, p. 1248);

V) PARTICIPAR DOS DEBATES ORAIS: podem ocorrer debates orais na audiência de instrução e julgamento (art. 403, § 2º, CPP), na sessão plenária do Tribunal do Júri (art. 476, § 1º, CPP) ou perante os Tribunais, isto é, no julgamento dos recursos interpostos (art. 610, parágrafo único, CPP) ou em processos de competência originária (art. 12, inciso I, Lei nº 8.038/90), sendo o assistente de acusação, em todas essas hipóteses, ouvido sempre depois do Ministério Público (LIMA, 2017, p. 1248);

VI) ARRAZOAR OS RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, OU POR ELE PRÓPRIO, NOS CASOS DOS ARTS. 584, § 1º, E 598: por ser um tema um pouco mais extenso, a legitimidade recursal do assistente de acusação será tratada no capítulo atinente aos recursos.

Além desses, ao longo do CPP, são encontrados outros poderes do assistente do Ministério Público, destacando-se:

VII) REQUERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS NÃO PRISIONAIS E/OU DE PRISÃO PREVENTIVA: conforme arts. 282, § 2º e 311 do CPP, o assistente de acusação é legitimado a requerer a decretação de medidas cautelares diversas da prisão e/ou de prisão preventiva, razão pela qual deveria ser cancelada a Súmula nº 208 do STF, que assim dispõe: "O assistente do Ministério Público não pode recorrer, extraordinariamente, de decisão concessiva de *habeas corpus*", porquanto foi editada em momento anterior à concessão da legitimidade ao assistente para o requerimento da prisão, isto é, antes da Lei nº 12.403/11.

Assim, tendo a Lei nº 13.964/19 mantido tal legitimidade, deve-se concluir que o assistente de acusação tem "interesse recursal para impugnar eventual decisão concessiva de *habeas corpus* durante o curso do processo penal" (LIMA, 2017, p. 1248), porquanto aquele que "pode o mais (requerer a prisão preventiva), pode o menos (pleitear providências menores ou recorrer para o mesmo fim) (TÁVORA; ALENCAR, 2017, 874).

VIII) REQUERER O DESAFORAMENTO: conforme art. 427, *caput*, do CPP, o assistente de acusação é legitimado a requerer ao Tribunal o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, preferindo-se as mais próximas.

Nesse sentido, ainda que o STJ entenda que "o rol do art. 271 do CPP é taxativo, de forma que o assistente de acusação exerce os poderes estritamente dentro dos limites conferidos por este dispositivo legal" (STJ, REsp 604.379/SP), ao longo do próprio CPP há outros poderes do assistente de acusação, que não estão previstos no referido artigo. É dizer: não se pode afirmar, de forma peremptória, que as atribuições do assistente do Ministério Público se limitam àquelas ali arroladas.

#### 5.4 INTIMAÇÃO E NÃO COMPARECIMENTO DO ASSISTENTE (ARTS. 271, §2º, E 457 DO CPP)

O art. 271, § 2º, CPP, diz que o processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente do Ministério Público, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado.

No Tribunal do Júri, conforme disposição expressa do art. 457, *caput*, do CPP, a ausência (justificada ou não) do assistente de acusação, tendo ele sido regularmente intimado, não acarretará adiamento do julgamento.

Rememora-se que, à luz do art. 370, § 1º, do CPP, a intimação do advogado do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado.

#### 5.5. OITIVA DO MP E RECURSO CONTRA A INADMISSÃO DO ASSISTENTE (ARTS. 272 E 273 DO CPP)

Nos termos do art. 272 do CPP, o Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente de acusação, não cabendo recurso contra o despacho que o admitir ou não, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão, conforme art. 273 do mesmo Código.

Logo, por imperativo legal, não cabe recurso contra a decisão que admite ou inadmite o assistente do Ministério Público, lecionando a doutrina, todavia, que é possível o manejo do mandado de segurança contra tal pronunciamento judicial.

## 6. FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA (ART. 274 DO CPP)

Os termos serventuários ou funcionários da Justiça são correlatos e designam a categoria profissional que, ocupando cargos criados por lei e percebendo vencimentos pagos pelos cofres públicos, prestam serviços ao Poder Judiciário (NUCCI, 2016, p. 526), sendo a eles aplicáveis as prescrições sobre suspeição dos juízes, conforme art. 274 do CPP.

## 7. PERITOS (ART. 275 A 280)

### 7.1. CONCEITO E DISCIPLINA JUDICIÁRIA (ART. 275 DO CPP)

O perito é o especialista em determinada matéria, incumbindo-lhe servir como auxiliar da justiça, a fim de esclarecer pontos específicos distantes do conhecimento jurídico dos magistrados, podendo ele ser oficial, isto é, funcionário do Estado, ou nomeado pelo juiz, caso em que deverá prestar o compromisso legal de bem desempenhar a sua função, conforme art. 159, § 2º, do CPP (NUCCI, 2016, p. 526).

Nos termos do art. 275 do CPP, o perito, mesmo o não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária, podendo ele ser sujeito ativo dos crimes contra a Administração Pública, previstos no Capítulo I, do Título XI, do Código Penal (NUCCI, 2016, p. 526).

### 7.2. NOMEAÇÃO DOS PERITOS (ART. 276 DO CPP)

Dispõe o art. 276 do CPP que as partes não poderão intervir na nomeação do perito, que será feita pelo juiz.

No caso de exame pericial realizado por intermédio de carta precatória, é interessante rememorar que, via de regra, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo deprecado. Contudo, em se tratando de ação penal de iniciativa privada e havendo acordo entre as partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juízo deprecante, conforme art. 177, *caput*, do CPP. Em todo caso, os quesitos do juiz e das partes serão transmitidos na carta precatória, a teor do parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

### 7.3. POSSIBILIDADE DE MULTA POR RECUSA AO ENCARGO E/OU POR DESÍDIA (ART. 277 DO CPP)

À luz do art. 277, *caput*, do CPP, sob pena de multa, o perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, salvo se apresentar justificativa plausível para tanto.

De igual forma, também será imposta a pena de multa ao perito que, sem justa causa, provada imediatamente, deixar de atender à intimação ou ao chamado da autoridade, não comparecer para o exame no dia e local designados ou não der o laudo, ou concorrer para que a perícia não seja feita, nos prazos estabelecidos, a teor do parágrafo único do art. 277 do CPP.

No ponto, é importante rememorar que, a teor do art. 159, § 5º, inciso I, do CPP, durante o processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar.

Ademais, conforme art. 160, parágrafo único, do CPP, o laudo atinente ao exame pericial deverá ser elaborado no prazo máximo de 10 (dez) dias, podendo, em casos excepcionais, ser prorrogado, a requerimento dos peritos.

### 7.4. POSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO COERCITIVA DO PERITO (ART. 278 DO CPP)

Complementando a ideia de obrigatoriedade trazida pelo art. 277 do CPP, o art. 278 do mesmo Código dispõe que, no caso de não comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução coercitiva.



## 7.5. PESSOAS QUE NÃO PODERÃO FUNCIONAR COMO PERITO (ART. 279 DO CPP)

A teor do art. 279 do CPP, não poderão funcionar como perito as pessoas que: I) estiverem sujeitas à interdição de direito atualmente mencionada no art. 47, incisos I e II, do CP; II) tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia; e III) os analfabetos e os menores de 21 (vinte e um) anos, devendo se ter muito cuidado com esse marco temporal nas provas objetivas, já que, por expressa disposição legal, a pessoa maior de 18 (dezoito) anos, mas menor de 21 (vinte e um), não poderá funcionar como perito.

## 7.6. SUSPEIÇÃO DOS PERITOS (ART. 280 DO CPP)

Disciplina o art. 280 do CPP que se estende aos peritos, no que lhes for aplicável, o disposto sobre suspeição dos juízes.

## 8. INTÉRPRETES (ART. 281 DO CPP)

O intérprete "é a pessoa conhecedora de determinados idiomas estrangeiros ou linguagens específicas, que serve de intermediário entre pessoa a ser ouvida em juízo e o magistrado e as partes" (NUCCI, 2016, p. 526), sendo ele, para todos os efeitos, equiparado ao perito, nos termos do art. 281 do CPP.

Interessante anotar que, mesmo que domine o idioma estrangeiro ou a linguagem específica, o juiz não poderá atuar como intérprete, já que haveria nítida violação ao sistema acusatório (art. 3º-A do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/19), porquanto estaria participando de forma direta e ativa da produção probatória (NUCCI, 2016, p. 527).

## 9. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA

### 9.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

**PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL E NULIDADE.** A 2ª Turma denegou *habeas corpus* em que pretendida anulação de ação penal em face de suposta violação ao princípio do promotor natural. Na espécie, o Procurador-Geral de Justiça designara promotor lotado em comarca diversa para atuar, excepcionalmente, na sessão do tribunal do júri em que o paciente fora julgado e condenado. Consignou-se que o postulado do promotor natural teria por escopo impedir que chefias institucionais do Ministério Público determinassem designações casuísticas e injustificadas, de modo a instituir a reprovável figura do "acusador de exceção". No entanto, não se vislumbrou ocorrência de excepcional afastamento ou substituição do promotor natural do feito originário, mas, tão-somente, a designação prévia e motivada de outro promotor para determinado julgamento, em conformidade com o procedimento previsto na Lei 8.625/93. (INF 644 - HC 98.841/PA, rel. Min. Gilmar Mendes, 11/10/2011.)

### 9.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**DIREITO PROCESSUAL PENAL. HIPÓTESE DE DEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA À ACUSAÇÃO.** É possível a intervenção dos pais como assistentes da acusação na hipótese em que o seu filho tenha sido morto, mas, em razão do reconhecimento de legítima defesa, a denúncia tenha imputado ao réu apenas o crime de porte ilegal de arma de fogo. (INF 574 - RMS 43.227-PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 3/11/2015, DJe 7/12/2015.)

**DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SEGURADORA INTERVIR COMO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO EM PROCESSO QUE APURE HOMICÍDIO DO SEGURADO.** A seguradora não tem direito líquido e certo de figurar como assistente do Ministério Público em ação penal na qual o beneficiário do seguro de vida é acusado de ter



**praticado o homicídio do segurado.** (INF 560 - RMS 47.575-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015.)

**DIREITO PROCESSUAL PENAL. NOMEAÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA EM JUÍZO. PROCURAÇÃO. JUNTADA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 115/STJ. A nomeação judicial de Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa de réu dispensa a juntada de procuração.** A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento que encontrava dissonância no âmbito das Turmas que a compõe. A Quinta Turma firmou entendimento de que "o advogado integrante do Núcleo de Prática Jurídica não está dispensado de apresentar a procuração ou ato de nomeação judicial, por ausência de previsão legal, visto que somente é equiparado à Defensoria Pública no tocante à intimação pessoal dos atos processuais", em contraposição ao entendimento da Sexta Turma, que se pronunciou pela desnecessidade da juntada de procuração quando se trata de defensor dativo, nos autos do AgRg nos EDcl no Ag 1.420.710-SC. O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do *munus* público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ. Além disso, não se mostra admissível a exigência de procuração, porquanto não raras as vezes sequer há contato do advogado dativo com o acusado, sendo certo que manter a exigência de mandato acarretaria gravosos prejuízos à defesa da população necessitada, inviabilizando o acesso à Justiça. (INF 624 - EAREsp 798.496-DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 11/4/2018, DJe 16/4/2018.)

## QUESTÕES

**1- TJ/CE (Cespe/UnB 2019)** A respeito dos sujeitos do processo penal, assinale a opção correta.

- a) Os advogados podem ser considerados pessoalmente sujeitos da relação jurídico-processual.
- b) Nas questões relativas à fiança, o terceiro prejudicado e o fiador do réu não podem assumir a condição de sujeitos ou partes secundárias na relação processual penal.
- c) Na excepcional situação da ação pública movida pelo ofendido — ação penal privada subsidiária da pública —, não há intervenção do MP.
- d) As causas de impedimento e de suspeição do juiz estendem-se aos membros do MP.
- e) As pessoas jurídicas, por não praticarem ações físicas intencionais, não podem figurar no polo passivo da relação processual penal.

**2- MP/PE (FCC 2008)** O ofendido ou seu representante legal poderá intervir no processo como assistente do Ministério Público. Quanto a essa intervenção, é correto afirmar:

- a) O assistente poderá ser admitido em qualquer fase da ação penal pública, enquanto não transitar em julgado a sentença.
- b) O assistente não poderá ser admitido após a prolação da sentença, ainda que pendente recurso da acusação.
- c) O assistente tem direito de pedir a repetição de prova produzida antes da sua admissão.
- d) Se o assistente, devidamente intimado, deixar de comparecer a qualquer ato de instrução, a audiência será redesignada, sendo ele intimado para a nova audiência, independentemente do motivo alegado para a ausência.
- e) Do despacho que não admitir a admissão do assistente cabe recurso em sentido estrito, nos termos do Código de Processo Penal.

## COMENTÁRIOS

**1. Gabarito: D**

- a) Os sujeitos ou atores processuais principais ou essenciais do processo penal são o juiz (Estado-juiz), o acusador (Ministério Público ou querelante, a depender do tipo de iniciativa da ação penal) e o acusado, não sendo considerado como parte o advogado, que, em verdade, é representante do réu.





- b) O terceiro prejudicado e o fiador do réu, nas hipóteses retratadas nos arts. 341 e 343 do CPP, que tratam do quebraamento da fiança, assumirão o papel de sujeitos ou atores processuais secundários ou acessórios ou colaterais.
- c) Conforme art. 29 do CPP, na ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, o Ministério Público deverá intervir em todos os termos do processo, sendo denominado, pois, de interveniente adesivo obrigatório.
- d) Nos termos do art. 258 do CPP, estendem-se aos membros do Ministério Público, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes.
- e) Quando o processo criminal for atinente a crime ambiental, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.605/98, art. 173, § 5º e art. 225, § 3º, da CF/88, poderá figurar no polo passivo da relação jurídica processual a pessoa jurídica.

**2. Gabarito: A**

- a) Conforme art. 269 do CPP, o assistente do Ministério Público, figura exclusiva da fase processual da persecução penal, "será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar".
- b) Nos termos do art. 269 do CPP, o assistente de acusação poderá ser admitido até o trânsito em julgado da sentença, não havendo óbice ao seu ingresso após a prolação da sentença, desde que antes de sua definitividade.
- c) De acordo com o art. 269 do CPP, o assistente do Ministério Público "receberá a causa no estado em que se achar", não sendo, por essa razão, a ele facultado pedir a repetição de prova produzida antes de seu ingresso.
- d) Dispõe o art. 271, § 2º, CPP, que o processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente do Ministério Público, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado.
- e) Nos termos do art. 273 do CPP, não cabe recurso contra a decisão que admite ou inadmite o assistente do Ministério Público, lecionando a doutrina, todavia, que é possível o manejo do mandado de segurança contra tal pronunciamento judicial.

## **CAPÍTULO 18 – PRISÃO, MEDIDAS CAUTELARES E LIBERDADE PROVISÓRIA (ARTS. 282 A 350 DO CPP)**

---

No presente capítulo não se propõe a esgotar a matéria, mas se pretende analisar os principais temas de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, sobretudo frisando as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime).

### **1. MUDANÇA DE PARADIGMA**

#### **1.1. ANTES DE 2011**

Antes de 2011, nosso sistema processual penal trabalhava com uma mentalidade dúplice/bipolar a respeito do tema de prisão e liberdade provisória. Ou o acusado respondia ao processo com total privação de sua liberdade (preso) ou poderia ser concedida a liberdade provisória, mediante o simples comparecimento a todos os atos processuais. Caso fosse exigida a fiança como medida de contracautela, o autor do fato era obrigado a não mudar de residência sem autorização judicial e de não se ausentar da comarca por mais de oito dias sem antes comunicar ao juiz. Assim, a única medida cautelar alternativa à prisão era a liberdade provisória.

#### **1.2. APÓS 2011 (LEI Nº 12.403/2011)**

Em 2011 ocorreu significativa mudança no título IX, com a Lei nº 12.403, que passou a dispor sobre medidas cautelares diversas da prisão, constantes no rol dos arts. 319 e 320, ambos do CPP. Além dessas alternativas à prisão preventiva, a lei previu, ainda, a possibilidade de o juiz substituir a prisão preventiva cumprida em estabelecimento prisional por prisão domiciliar, em situações restritas (art. 317 e 318).

Com essa nova realidade normativa, passou o magistrado a possuir mais opções – que não apenas a liberdade provisória com mera vinculação – para a proteção dos interesses que estejam sob ameaça em razão da existência de um processo penal. Assim, não é preciso sacrificar totalmente a liberdade do acusado, podendo ser impostas obrigações adequadas às peculiaridades do caso concreto, de modo proporcional à gravidade do crime (CRUZ, 2017, p. 175).

#### **1.3. LEI ANTICRIME (13.964/2019)**

O Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019) foi sancionado no dia 24 de dezembro e modificou muitas matérias nos campos penal e processual penal. No tema de prisão e medidas cautelares, foram feitas significativas mudanças, as quais serão objeto de detalhamento neste capítulo. Abaixo, resumo de algumas delas:

1. A lei dá nova redação ao art. 282, §2º, do CPP, abolindo o “de ofício” que constava da redação original, vedando, assim, a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, sem provocação expressa do Ministério Público ou do querelante ou sem representação da autoridade policial durante o inquérito policial.

2. A lei dá nova redação ao art. 311 do CPP, abolindo o “de ofício” que constava da redação original desses artigos, vedando, assim, a decretação da prisão preventiva sem provocação expressa do Ministério Público ou do querelante ou sem representação da autoridade policial durante o inquérito policial.

3. A nova redação do art. 282, §6º, do CPP, explicita a necessidade de justificar o porquê da não substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. Afinal, a cautelaridade é um requisito essencial de toda e qualquer medida cautelar, que deve ser aplicada proporcionalmente.



4. O art. 315, §2º, do CPP, *repete ipsis litteris* o art. 489, parágrafo único, do CPC, relativamente aos critérios legais para a definição de decisão fundamentada/desfundamentada. O art. 315 exige que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre fundamentada. A exigência é aplicável a toda e qualquer medida cautelar (§1º).

5. A lei dá nova redação ao art. 312 do CPP, acrescentando-lhe o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, enfatizando a cautelaridade da prisão preventiva.

6. A cautelaridade da prisão preventiva é reafirmada nos novos arts. 283 e 313 do CPP, cujo §2º diz de modo enfático: não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.

7. A prisão preventiva deve ser motivada com base em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos (arts. 312, §2º, e 315, §1º, ambos do CPP). A inovação é aplicável às medidas cautelares em geral, não apenas à prisão preventiva.

8. O art. 310, § 2º, do CPP, proíbe ao juiz conceder liberdade provisória para o reincidente ou membro de organização criminosa armada ou milícia ou que porta arma de fogo de uso restrito.

9. A prisão preventiva deverá ser revisada pelo órgão que a decretou a cada 90 (noventa) dias de sua decretação, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal (art. 316, parágrafo único, CPP).

10. O art. 310, do CPP, prevê expressamente a realização da audiência de custódia para os casos de análise de prisões em flagrante.

## 2. JUIZ DAS GARANTIAS

O Juiz das Garantias é responsável (civil, penal e administrativamente) pelo controle de legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário (reserva de Jurisdição). Desse modo, o magistrado que atua na fase da investigação criminal e que tem contato com elementos de informação, produzidos sem contraditório e ampla defesa, tem a sua imparcialidade fragilizada ao formar concepções a partir de informações precipitadas e não contraditadas. Violada a imparcialidade, comprometido está o sistema acusatório (art. 3º-A, CPP).

Ressalta-se que a atuação do juiz de garantias se restringe apenas à fase pré-processual, sendo as questões pendentes apreciadas pelo juiz do processo, que não está adstrito ao que foi decidido preliminarmente. Ademais, seu exercício não abarca as infrações penais de menor potencial ofensivo.

A implementação do juiz de garantias revela uma preocupação em preservar o distanciamento do magistrado responsável pelo processo penal dos elementos que visam formar sua convicção, para evitar que haja sua contaminação e, por conseguinte, a quebra de sua imparcialidade, que pode comprometer a prestação jurisdicional.

A novidade possui estrita relação com este título, uma vez que o recebimento da comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso LXII do *caput* do art. 5º da Constituição Federal, o recebimento do auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no art. 310 deste Código, e as decisões sobre requerimento de prisão preventiva, prorrogação, substituição ou revogação dela, se proferidas ao longo da investigação criminal, competem ao juiz das garantias, conforme art. 3º-B, incisos I, II, V e VI, do CPP, com redação dada pela Lei Anticrime (Lei nº 13.964/2019)<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Conforme destacado em capítulos anteriores, quando do fechamento desta obra, todos os dispositivos referentes ao juiz das garantias encontravam-se com aplicabilidade suspensa por prazo indefinido, em razão de decisão monocrática cautelar proferida pelo Ministro Luiz Fux nas ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305 no dia 22 de janeiro de 2020.



### 3. DISPOSIÇÕES GERAIS

O CPP prevê diversas formalidades para a efetivação de uma prisão processual nos arts. 283 a 300, que devem ser lidos na integralidade. Abaixo, segue análise dos dispositivos mais importantes:

#### 3.1. ANÁLISE DOS ARTS. 283 E 293 DO CPP

| ANTES DA LEI Nº 13.964/19                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEPOIS DA LEI Nº 13.964/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. | Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado.<br>§ 1º As medidas cautelares previstas neste Título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).<br>§ 2º A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). |

Há necessidade de ordem de prisão escrita e fundamentada para as prisões cautelares (prisão preventiva e prisão temporária), bem como nas decorrentes de sentença condenatória transitada em julgado. A exceção ocorre, apenas, na prisão em flagrante.

A Lei Anticrime alterou a redação do art. 283, do CPP, excluindo os termos “prisão temporária e prisão preventiva”, passando a utilizar o termo genérico “prisão cautelar”.

Nos termos do § 2º, a prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. É a Constituição Federal que dispõe sobre as restrições, *in verbis*:

Art. 5º, XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

| Durante o dia                      | Durante a noite             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Em caso de flagrante delito        | Em caso de flagrante delito |
| Em caso de desastre                | Em caso de desastre         |
| Para prestar socorro               | Para prestar socorro        |
| Para cumprir determinação judicial |                             |



Assim, o mandado de prisão somente poderá ser cumprido durante o dia.

Atenção:

- a) o conceito de domicílio está previsto no art. 150, § 4º, do CPP;
- b) a Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº13.869/19) dispõe em seu art. 22, § 1º, inciso III, que é crime a conduta de quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h00 ou antes das 05h00. Deve, então, ser este o parâmetro a ser considerado como “dia” – período compreendido entre 5h e 21h.

Já o art. 293, disciplina os atos para o executor do mandado de prisão. Sendo dia, o morador será intimado acerca da ordem de prisão. Caso se recuse a entregar o réu, não permitindo a entrada na residência, poderá a autoridade entrar à força na residência. Sendo noite, o executor, depois do intimar ao morador, não sendo atendido, guardará todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e, logo ao amanhecer, arrombará as portas e efetuará a prisão. Podendo, neste caso, levar à presença da autoridade, o morador que se recusou a entregar o réu oculto em sua casa.

Art. 293. Se o executor do mandado verificar, com segurança, que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso; sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e, logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão.

Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade, para que se proceda contra ele como for de direito.

Desse modo, no período noturno, só é possível o ingresso no domicílio alheio se o proprietário autorizar ou em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro.

### 3.2. USO DA FORÇA

Por força do art. 284 do CPP, o uso da força no cumprimento da prisão é medida excepcional, utilizada apenas para conter eventual resistência ou tentativa de fuga.

“Art. 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso.”

No momento da prisão, seja em flagrante delito, seja por mandado, podem ocorrer algumas circunstâncias que o magistrado deve ter atenção. Pode ser que a polícia atue de forma truculenta ou não, pode ser que a pessoa fuja, resista, agrida o policial etc.

### 3.3. O QUE PRECISA CONSTAR NO MANDADO DE PRISÃO?

Os arts. 285, 286, 288, 291 e 297, do CPP, apresentam os requisitos do mandado de prisão e as formalidades que devem ser respeitadas para o seu cumprimento, merecendo a leitura da íntegra.

De acordo com o art. 285, a autoridade judicial que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado: a) será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade; b) designará a pessoa, que tiver de ser presa, por seu nome, alcunha ou sinais característicos; c) mencionará a infração penal que motivar a prisão; d) declarará o valor da fiança arbitrada, quando afiançável a infração; e) será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução.

O art. 286 do CPP prevê que o mandado será passado em duplicata, e o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar da diligência. Da entrega deverá o preso passar recibo no outro exemplar; se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração, assinada por duas testemunhas.

Já o art. 288 do CPP dispõe que ninguém será recolhido à prisão, sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado recibo da entrega do preso, com declaração de dia e hora.

O art. 291 do CPP afirma que a prisão em virtude de mandado entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime a acompanhá-lo.

E, por fim, o art. 292 do CPP ressalta que se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas.

Destaque para o art. 287 do CPP que teve sua redação alteada pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime):

| ANTES DA LEI Nº 13.964/19                                                                                                                                                                   | DEPOIS DA LEI Nº 13.964/19                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará à prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado. | Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia. |

Assim, se a infração for inafiançável, poderá ser efetuada a prisão sem a exibição do mandado, desde que conferido, logo após o cumprimento, a identificação do conduzido. Deverá ser encaminhada ao juiz, para a realização da audiência de custódia.

Com isso, a audiência de custódia não se aplica apenas para as prisões em flagrante, também deve ser realizada para cumprimento de mandado, de preventiva, temporária, cumprimento de mandado para início de execução. (Vide § 1º, art. 1º; art. 13 da Resolução 213 do CNJ.)

### 3.4. USO DE ALGEMA

O uso da algema é excepcional e deve ser devidamente justificado pela autoridade que utilizou o equipamento, devendo ser respeitado o teor da Súmula Vinculante nº 11, que dispõe que somente é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Assim, por exemplo, se foi utilizada a algema no momento da prisão em flagrante, deverá a autoridade policial justificar por escrito no auto de prisão em flagrante; se foi mantida a algema na audiência de custódia, precisa restar fundamentada as razões na ata da audiência. O mesmo raciocínio deve ser usado nos demais atos processuais que se referirem a presos.

Importante, ainda, a redação do art. 292, parágrafo único, do CPP, incluída em 2017 pela Lei nº 13.434, que veda o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Dessa forma, não há justificativa para a utilização de algemas, deixando o legislador claro que é totalmente proibido o uso.



### 3.5. BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO

O Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2011 e já integrado em todos os tribunais, é uma ferramenta que possibilita o registro e consulta de informações sobre mandados de prisão. Tem a finalidade de facilitar o conhecimento por qualquer pessoa e o cumprimento de diligências por parte das autoridades policiais, assim como auxiliar os juízes no exercício de sua jurisdição. O Cadastro também traz mais segurança para a sociedade e eficiência para o Judiciário, já que todas as informações sobre pessoas procuradas pela Justiça ou presas em estados diversos estarão, agora, integradas.

O sistema é alimentado pelas ordens de todos os tipos de prisões, cumprimentos dos mandados, pelos dados de soltura de presos, revogações das prisões. Assim, o CNJ consegue revelar o panorama prisional do Brasil.

Para alimentar o sistema, nos termos do art. 289-A, do CPP, o juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão no banco de dados, e, assim, qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu.

Prevê, ainda, o § 2º, do mesmo artigo, que qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar, em seguida, o registro do mandado na forma do *caput* deste artigo.

### 3.6. PRISÃO ESPECIAL

A prisão especial está disciplinada no art. 295 do CPP e é uma forma de cumprimento da prisão antes do trânsito em julgado, de um indivíduo que, por razões do cargo público ou função pública ou privada exercida, goza de determinado privilégio quando da necessidade de sua prisão e tais benefícios são assegurados até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Logo, com o trânsito em julgado, cessa o direito à prisão especial, sendo o condenado submetido ao regime comum de cumprimento da pena, ressalvada a hipótese do art. 84, § 2º, da LEP, referente ao preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração criminal, o qual deverá ficar em dependência separada dos demais presos.

Dois são os efeitos gerados pela observância da prisão especial:

a) recolhimento do preso em local distinto da prisão comum (art. 295, § 1º, do CPP); não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento (§ 2º);

b) o preso especial não será transportado juntamente com o preso comum (art. 295, § 3º, do CPP).

Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum.

Terão direito à prisão especial: os ministros de Estado; os governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de Polícia; os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados; os cidadãos inscritos no "Livro de Mérito"; os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; os magistrados; os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República; os ministros de confissão religiosa; os ministros do Tribunal de Contas; os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função; os delegados de polícia e os guardas-civis dos Estados e Territórios, ativos e inativos.

O rol, no entanto, não é taxativo, podendo a legislação especial prever a prisão especial para outras carreiras.

Frise-se que até 2012 o Conselheiro Tutelar também possuía direito à prisão especial. No entanto, a Lei nº 12.696/12 retirou esse direito do art. 135 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

**Atenção:**

a) alguns doutrinadores, dentre eles Guilherme de Souza Nucci, frisam uma suposta inconstitucionalidade no art. 295 do CPP, pela previsão de um tratamento diferenciado, sem razão para existir. Entende o doutrinador que, na verdade, todos os presos cautelares (sem condenação definitiva) deveriam permanecer separados dos presos definitivos. A disciplina do art. 295 fere, então, o princípio da igualdade. O entendimento, no entanto, é minoritário;

b) a legislação prevê que os advogados e os integrantes de determinadas carreiras, se forem presos antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, possuem o direito de ficar recolhidos não em uma cela com grades, mas sim em uma sala de Estado-Maior. Veja a redação do Estatuto da OAB e de legislações de carreiras específicas, *in verbis*:

Art. 7º - Estatuto da OAB

V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, ~~assim reconhecidas pela OAB~~, e, na sua falta, em prisão domiciliar; (Vide ADIN 1.127-8)

LC nº 35/79 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional

Art. 33 - São prerrogativas do magistrado:

III - ser recolhido a prisão especial, ou a sala especial de Estado-Maior, por ordem e à disposição do Tribunal ou do órgão especial competente, quando sujeito a prisão antes do julgamento final;

Lei nº 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público

Art. 40. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, além de outras previstas na Lei Orgânica:

V - ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar ou à sala especial de Estado Maior, por ordem e à disposição do Tribunal competente, quando sujeito a prisão antes do julgamento final;

LC nº 80/94 – membros da Defensoria

Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União:

III - ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de Estado-Maior, com direito a privacidade e, após sentença condenatória transitada em julgado, ser recolhido em dependência separada, no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena;

Lei nº 13.327/2016 - Advogados públicos federais

Art. 38. São prerrogativas dos ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo, sem prejuízo daquelas previstas em outras normas:

V - ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de Estado Maior, com direito a privacidade, e ser recolhido em dependência separada em estabelecimento de cumprimento de pena após sentença condenatória transitada em julgado;

Esse direito só é garantido em caso de prisão provisória . Quando houver o trânsito em julgado da condenação, o cumprimento da pena deverá ocorrer em uma unidade prisional comum , como as demais pessoas. Segundo explicou o ex-Ministro Nelson Jobim, sala de Estado-Maior é o compartimento localizado na unidade militar que é utilizado por eles para o exercício de suas funções (Voto no HC 81632/SP, DJU em 21/3/2003).

A prática constata que a grande maioria das cidades brasileiras não possui salas de Estado-Maior, considerando que são poucas as localidades onde existem comandos de unidade militar das Forças Armadas.

Diante disso, a jurisprudência conferiu uma interpretação teleológica ao dispositivo e passou a entender que, quando a lei fala que determinada pessoa deve ficar presa em sala de Estado-Maior, isso significa que ela deverá ficar recolhida em um gabinete (escritório), sem celas, sem grades, e que ofereça instalações condignas, com condições adequadas de higiene e segurança. Esse gabinete (sala) pode ser localizado em unidades prisionais ou em batalhões da Polícia Militar

(STF. Plenário. Rcl 5826/PR e Rcl 8853/GO, rel. orig. Min. Cármen Lúcia, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, julgados em 18/3/2015 - Info 778).

No entanto, o advogado só fará jus a essa prerrogativa se estiver no livre exercício da profissão, o que não é o caso se ele estiver suspenso dos quadros da OAB. Assim, decretada a prisão preventiva de advogado, este não terá direito recolhimento provisório em sala de Estado-Maior caso sua inscrição na ordem esteja suspensa (STJ. 6ª Turma. HC 368.393-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 20/9/2016 - Info 591).

#### 4. PRISÃO EM FLAGRANTE

##### 4.1. NOÇÕES GERAIS

Prisão em flagrante é uma situação evidente, situação que chama atenção, que manifesta de forma clara a prática de uma infração penal. Significa, portanto, aquilo que ainda “queima” (TAVORA; ALENCAR, 2020. P. 462). Por isso, prisão em flagrante é a modalidade de prisão cautelar que se realiza no momento em que a ação se desenvolve ou que acabou de se desenvolver (NUCCI, 2019, p. 597).

É um ato administrativo na sua origem, pois não necessita de uma ordem judicial prévia. Temos uma previsão legislativa, que autoriza a qualquer pessoa, reprimir um ato, uma infração. E esse ato de repreensão pode ser por meio da prisão para cessar a prática delitiva.

No entanto, como será visto, esse ato administrativo na origem passará pelo crivo judicial.

Assim, a partir do momento que ocorre uma prisão em flagrante, o autor do fato é capturado e conduzido para a Delegacia, o Delegado lavra o auto de prisão em flagrante e realiza todas as comunicações necessárias. Envia o auto de flagrante para o juiz, que no prazo de 24h realiza a audiência de custódia para análise do auto de prisão em flagrante. Neste momento, passará pelo crivo judicial, para verificar se todo o procedimento da prisão foi executado de forma legal, válida.

Se o procedimento restou válido, haverá a homologação da prisão.

Em caso contrário, havendo ilegalidade da prisão, haverá o relaxamento.

##### Atenção para três situações:

a) Nas infrações de menor potencial ofensivo —Procedimento sumaríssimo —art. 69, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95): ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança.

b) Art. 48, § 2º, da Lei de Drogas: ratando-se da conduta prevista no art. 28 desta Lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários.

c) Art. 301 do Código de Trânsito Brasileiro: ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela.

##### 4.2. LEGITIMIDADE PARA PRENDER EM FLAGRANTE

O flagrante facultativo está previsto na primeira parte do art. 301 do CPP e é aquele realizado por qualquer pessoa do povo, que não está obrigada a realizá-lo. Trata-se, portanto, de hipótese de exercício regular de um direito (art. 23, III, do CP).

O flagrante obrigatório ou compulsório está previsto na parte final do art. 301 do CPP e é aquele imposto às autoridades policiais e seus agentes (art. 144 da CF/88), sob pena de responsabilização pela sua omissão, desde que seja possível a efetivação do flagrante. Trata-se de

hipótese de estrito cumprimento de dever legal (art. 23, III, CP). Se a prisão for realizada ilegalmente, o agente estatal poderá responder por abuso de autoridade.

#### 4.3. ESPÉCIES DE FLAGRANTE DELITO

O art. 302 do CPP prevê três espécies de flagrante delito. As demais estão previstas em leis especiais ou são tratadas pela doutrina.

**Flagrante próprio** (art. 302, I e II, CPP): o agente é surpreendido cometendo a infração penal ou quando acaba de cometê-la. A prisão deve ocorrer de imediato, sem o decurso de qualquer intervalo de tempo.

**Flagrante impróprio** (art. 302, III, CPP): o agente é perseguido, logo após a infração, em situação que faça presumir ser o autor do fato. Não existe um limite temporal para o encerramento da perseguição. O importante é demonstrar que ela foi ininterrupta.

**Flagrante presumido** (art. 302, IV, CPP): o agente é preso, logo depois de cometer a infração, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que presumam ser ele o autor da infração. Note que essa espécie não exige perseguição.

**Flagrante esperado**: a atividade da autoridade policial antecede o início da execução delitiva. A polícia antecipa-se ao criminoso, e, tendo ciência de que a infração ocorrerá, sai na frente, fazendo campana (tocaia), e realizando a prisão quando os atos executórios são deflagrados. Nada impede que o flagrante esperado seja realizado por particular.

No flagrante esperado, a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e passa a monitorar a atividade do agente de forma a aguardar o melhor momento para executar a prisão, não havendo que se falar em ilegalidade do flagrante. Acórdãos STJ: RHC 103456/PR; AgRg no HC 438565/SP; AgRg no AREsp 377808/MS.

Nesse caso não haverá influência na conduta do autor do fato.

Ex.: os agentes policiais ficaram em campana, permaneceram monitorando, esperando a conduta de Pedro.

**Flagrante preparado/provocado/crime de ensaio/delito putativo por obra do agente/delito de experiência**: o agente é induzido ou instigado a cometer o delito, e, neste momento, acaba sendo preso em flagrante. Ressalte-se, no entanto a Súmula nº 145 do STF: “Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.

##### Atenção:

O tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e de natureza permanente, razão pela qual a prática criminosa se consuma, por exemplo, a depender do caso concreto, nas condutas de "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo", antes mesmo da atuação provocadora da polícia, o que afasta a tese defensiva de flagrante preparado (STJ: AgRg no AREsp 1353197/SP, REsp 1556355/SC, HC 463572/SP, HC 340615/SP).

Frise-se neste ponto a diferença entre flagrante preparado, figura ilegal, e flagrante comprovado, que pode ser adotado.

No flagrante comprovado (agente disfarçado), há uma prática criminosa prévia que autoriza a prisão em flagrante. Não haverá agente provocador. Atenção à alteração promovida pela Lei Anticrime na Lei de Drogas:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,

ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

IV- Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Atenção à seguinte diferenciação:

a) Agente provocador: a sua atuação é ilegal, resultando na prática de crime impossível; é a verdadeira causa do crime, pois no sujeito provocado não há qualquer vontade original de praticar o crime, nem tinha ele o objeto material do ilícito.

b) Agente disfarçado: a sua atuação é legal; a sua atuação não cria o dolo do autor do crime, o qual já existe. Não possui qualquer envolvimento com o grupo criminoso, nem mesmo cativeira a sua confiança, não provocando o acontecer típico.

c) Agente infiltrado: a sua atuação é legal; imersão do policial na organização criminosa, por meio de interação com os seus membros, conquista de confiança deles, envolvimento intenso com o grupo. Art. 53, I, da Lei de Drogas.

Flagrante prorrogado/diferido/retardado/postergado/ação controlada: a autoridade policial tem a faculdade de aguardar, do ponto de vista da investigação criminal, o momento mais adequado para realizar a prisão, ainda que sua atitude implique na postergação da intervenção. Atente-se à leitura dos seguintes dispositivos legais: Art. 53, Lei nº 11.343/06; Art. 4º-B, Lei nº 9.613/98; e Arts. 8º e 9º, Lei nº 12.850/13.

Flagrante forjado: é aquele armado, fabricado, realizado para incriminar uma pessoa inocente. É uma modalidade ilícita de flagrante, onde o único infrator é o agente forjador, que pratica o crime de denúncia caluniosa, e sendo agente público, também é abuso de autoridade.

#### 4.4. CRIME PERMANENTE

Permanente é o crime cuja consumação se alonga no tempo, dependente da atividade do agente, que poderá cessar quando este quiser. Enquanto não cessar a permanência, a prisão em flagrante poderá ser realizada a qualquer tempo, mesmo que para tanto seja necessário o ingresso domiciliar.

“Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

#### 4.5. CRIME HABITUAL

O crime habitual é aquele que materializa o modo de vida do infrator, exigindo, para a consumação, a reiteração de condutas, que por sua repetição, caracterizam a ocorrência da infração. De acordo com a doutrina majoritária (TAVORA; ALENCAR, 2020, p. 479), não há como se precisar o momento para realizar ou justificar o flagrante, razão pela qual não há cabimento de prisão em flagrante.

#### 4.6. CRIME CONTINUADO

Na hipótese de continuidade delitiva (art. 71, CP), temos, indubitavelmente, várias condutas, simbolizando várias infrações; contudo, por uma fixação jurídica, irá haver, na sentença, a



aplicação da pena de um só crime, exasperada de um sexto a dois terços. Como existem várias ações independentes, irá incidir, isoladamente, a possibilidade de se efetuar a prisão em flagrante por cada uma delas. É o que se chama de flagrante fracionado.

#### **4.7. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA E CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO**

Nesses casos, para a lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá haver a manifestação de vontade do respectivo legitimado. Se a vítima não puder imediatamente ir à delegacia para se manifestar, por ter sido conduzida ao hospital ou por qualquer motivo relevante, poderá fazê-lo no prazo de entrega da nota de culpa. Caso a vítima não emita autorização, deve a autoridade policial liberar o ofensor, sem nenhuma formalidade, documentando o ocorrido em boletim de ocorrência, para efeitos de praxe.

#### **4.8. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO**

Nas infrações de menor potencial ofensivo, ao invés da lavratura do auto de prisão em flagrante, será lavrado termo circunstanciado de ocorrência, sendo o infrator imediatamente encaminhado aos juizados especiais criminais ou, se não for possível, deverá assumir o compromisso de comparecer, quando devidamente notificado (art. 69 da Lei nº 9.099/95). Com isso, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Caso contrário, o auto será lavrado, recolhendo-se o mesmo ao cárcere.

#### **4.9. SUJEITOS DO FLAGRANTE**

##### **4.9.1. SUJEITO ATIVO**

É aquele que efetua a prisão; pode ser qualquer pessoa, integrante ou não da força policial. Qualquer do povo poderá (flagrante facultativo) e as autoridades policiais e seus agentes deverão (flagrante obrigatório) prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

##### **4.9.2. SUJEITO PASSIVO**

É aquele detido em situação de flagrância. Em regra, pode ser qualquer pessoa.

Atenção aos casos especiais:

a) agentes diplomáticos, tais como embaixadores, secretários de embaixada, bem como familiares, além de funcionários de organizações internacionais (ex.: ONU) – Convenção de Viena – de regra, não podem ser presos em flagrante; não podem ser processados;

b) parlamentares federais e estaduais: apenas por crimes inafiançáveis, devendo o APF ser encaminhado em 24h para a respectiva casa legislativa para, por voto da maioria, decidir sobre a prisão;

c) magistrados (art. 33, II, LOMAN): apenas por crimes inafiançáveis; imediatamente encaminhado ao Presidente do Tribunal;

d) membros do MP (art. 40, III, LOMP): apenas por crimes inafiançáveis; imediatamente encaminhado ao PGJ;

e) advogado: terá direito de que a sua prisão seja comunicada expressamente à seccional da OAB (Art. 7º, IV, parte final, OAB);

f) Presidente da República: art. 86, 3º, CF/88: infrações comuns: não estará sujeito a prisão enquanto não houver sentença definitiva.

#### **4.10. AUTORIDADE COMPETENTE**

Em regra, a autoridade policial da circunscrição onde foi efetuada a prisão é a que possui atribuição para presidir a lavratura do auto de prisão em flagrante





#### 4.11. PROCEDIMENTOS E FORMALIDADE

A autoridade policial deverá comunicar imediatamente à família do preso ou pessoa por ele indicada a ocorrência da prisão (art. 306 do CPP).

Aquele que levou o preso até a presença da autoridade será ouvido, sendo suas declarações reduzidas a termo, colhida a sua assinatura, e sendo-lhe entregue cópia do termo e recibo de entrega do preso (art. 304, *caput*, do CPP). Na sequência, serão ouvidas as testemunhas que tenham algum conhecimento do ocorrido, e que acompanham o condutor.

Em que pese a lei ser omissa quanto à oitiva da vítima nesta fase, é de bom tom que a mesma seja ouvida, prestando sua contribuição para o esclarecimento do fato e para a caracterização do flagrante.

A lei fala em interrogatório do acusado (quando deveria falar conduzido), o que é uma evidente impropriedade, afinal ainda não existe imputação nem processo. O preso será ouvido, assegurando-se o direito ao silêncio. Admite-se a presença do advogado, embora não seja imprescindível à lavratura do auto (lembrando que esta fase possui como característica ser inquisitiva).

De acordo com tese nº 6, fixada pelo STJ na sua edição nº 120 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça: eventual nulidade no auto de prisão em flagrante devido à ausência de assistência por advogado somente se verifica caso não seja oportunizado ao conduzido o direito de ser assistido por defensor técnico (caso ele indique o seu advogado), sendo suficiente a lembrança, pela autoridade policial, dos direitos do preso previstos no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.

Deverá a autoridade policial fazer constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa (art. 304, § 4º, do CPP).

Ao final, convencida a autoridade que a infração ocorreu, que o conduzido concorreu para a mesma e que se trata de hipótese legal de flagrante delito, determinará ao escrivão que lave e encerre o auto de flagrante (art. 304, § 1º, primeira parte, do CPP). Não estando convencida a autoridade de que o fato apresentado autorizaria o flagrante, deixará de autuar o mesmo, relaxando a prisão que já existe desde a captura (art. 304, § 1º, parte final, do CPP). Também não permanecerá preso o conduzido que for admitido a prestar fiança, caso haja o pagamento. Se não o fizer, será levado para a audiência de custódia para a análise de sua situação flagrantial. Os termos de declaração do condutor e das testemunhas serão anexados ao auto, e este último será assinado pela autoridade e pelo preso.

#### 4.12. TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS

Testemunha instrumentária, imprópria, instrumental ou fedatária é a que prestará depoimento sobre fatos que não se referem diretamente ao mérito da ação penal. Nesse caso, a testemunha não deporá sobre algo que presenciou ou soube ter ocorrido, e sim sobre um ato da persecução criminal que tenha assistido ou participado. É o caso, por exemplo, da testemunha que esteve presente na audiência em que o interrogado confessou o crime espontaneamente, sem nenhuma coação; a testemunha que presenciou a apreensão de objeto realizada pela autoridade policial em diligência de busca (art. 245, § 7.º, do CPP) etc. (AVENA, 2017, p. 395).

Desse modo, nada viram ou sabem diretamente sobre a infração penal, mas possuem a finalidade de dar regularidade ao ato praticado, podendo ocorrer tanto na fase pré-processual quanto durante o processo.

Ao lavrar o auto de prisão em flagrante, a autoridade policial pode se valer de testemunhas instrumentárias em duas situações, nos termos do art. 304, §§ 3º e 4º, do CPP: a) quando não houver testemunhas da infração para serem ouvidas no auto de prisão em flagrante, a autoridade policial poderá se valer de duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso na delegacia; b) quando o acusado se recusar a assinar o auto de prisão em flagrante (ou a

nota de culpa), não souber assinar ou não puder assinar, a autoridade policial poderá se valer de duas pessoas para comprovar que o preso tomou ciência de todo o ocorrido. Assim, as duas pessoas vão testemunhar a leitura do auto de prisão em flagrante na presença do preso.

#### 4.13. ENVIO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública (art. 306, 1º, CPP). Chegando os autos ao Juiz, deverá realizar a audiência de Custódia pelo Juiz (art. 310, CPP).

#### 4.14. NOTA DE CULPA

A nota de culpa se presta a informar ao preso os responsáveis por sua prisão, bem como os motivos, contendo o nome do condutor e das testemunhas, sendo assinada pela autoridade. Será entregue em 24 horas da realização da prisão, mediante recibo. A entrega da nota de culpa é de vital importância para a validade da prisão.

#### 4.15. REMESSA À AUTORIDADE

O auto de prisão em flagrante, acompanhado de todas as oitivas colhidas, será encaminhado à autoridade judicial competente em 24 horas da realização da prisão.

### 5. ANÁLISE DO ART. 310 DO CPP

Conforme art. 310 do CPP, no primeiro momento de análise do auto de prisão em flagrante o juiz deverá verificar se a prisão é legal, ou seja, se foram cumpridas todas as formalidades para a lavratura do auto, bem como se há espécie válida de flagrante. Em caso negativo, deverá relaxar a prisão.

Se o flagrante for homologado, por ser legal, o juiz avança para a análise futura verificando se é preciso converter a prisão em flagrante em preventiva ou se é possível que seja concedida a liberdade provisória ao preso, com ou sem fiança, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (arts. 319 e 320 do CPP).

O Art. 310 do CPP sofreu alterações importantes com a Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime): inclusão do instituto da audiência de custódia no *caput* do artigo; inclusão dos §§ 2º, 3º e 4º. Observe o quadro abaixo:

| ANTES DA LEI Nº 13.964/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEPOIS DA LEI Nº 13.964/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:</p> <p>I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).</p> <p>II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).</p> | <p>Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da defensoria pública e o Membro do Ministério Público e, nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente:</p> <p>I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).</p> <p>II - converter a prisão em flagrante em</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.</p> <p>Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do <i>caput</i> do art. 23 do Decreto- Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.</p> | <p>preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).</p> <p>III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.</p> <p>§ 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do <i>caput</i> do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação.</p> <p>§2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.</p> <p>§ 3º A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no <i>caput</i> deste artigo, responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão.</p> <p>§ 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no <i>caput</i> deste artigo, a não realização de audiência de custódia, sem motivação idônea, ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.1. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Audiência de custódia é expressão que retrata a apresentação pessoal do conduzido à autoridade judicial logo depois de efetuada a sua prisão. Consiste em um instrumento de natureza pré-processual de porta de entrada do sistema de justiça criminal que pode ser definido na condução da pessoa presa, sem demora, à presença de uma autoridade judiciária que deverá, a partir de prévio contraditório estabelecido entre o Ministério Público e a defesa técnica (Defensoria Pública ou advogado constituído), exercer um controle imediato da legalidade e da necessidade da prisão, bem como apreciar se os direitos fundamentais da pessoa presa foram respeitados, sobretudo no que diz respeito à presença de abusos desde o momento de sua detenção até a realização da audiência.

O termo “Audiência de Custódia”, até então, não estava previsto na nossa legislação interna, se tratando, pois, de criação doutrinária. Inclusive, alguns julgadores e doutrinadores

preferem a expressão audiência de garantia ou audiência de apresentação, não havendo a terminologia “audiência de custódia” no direito comparado. O min. Luiz Fux, no julgamento da ADI 5240/SP, do qual fora relator, sugeriu a utilização do termo “Audiência de Apresentação”, alegando que a expressão “Audiência de Custódia” traduz a ideia de que a finalidade primordial da audiência é custodiar, manter a prisão da pessoa apresentada, o que não é o caso nem a finalidade do instituto. Entretanto, o legislador preferiu incluir no CPP a expressão comumente utilizada: audiência de custódia.

A implementação da audiência de custódia alinha-se com a necessária convencionalidade que deve guardar o processo penal brasileiro com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH) e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Político (PIDCP). A regra, inclusive, não é exclusividade dos países americanos, como se vê na Convenção Europeia de Direitos Humanos, em seu art. 5º, 3, que reproduz o texto da CADH em sua inteireza. Não obstante o ingresso formal no ordenamento jurídico brasileiro da CADH e do PIDCP em 1992, até o início do ano de 2015 não se teve notícia da realização de nenhuma apresentação pessoal. No Brasil, até então, se entendia – em postura totalmente contrária à evolução histórica dos direitos humanos – que as dificuldades de aplicação dessa garantia ensejariam a sua desconsideração e, assim, os autos eram analisados apenas no papel, sem necessidade de apresentação do preso, conforme antigo art. 310, CPP.

As audiências de custódia foram regulamentadas pelo CNJ na Resolução 213 de 15 de dezembro de 2015, ato normativo editado no exercício das prerrogativas institucionais do Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, § 4º, I, CF/88), cuja legitimidade constitucional foi expressamente reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que trouxe protocolos específicos sobre a prevenção e o combate à tortura, sobre o acompanhamento de medidas cautelares diversas da prisão, além da previsão de encaminhamento público para rede de proteção social. Sem dúvidas, é de suma importância a leitura de toda a Resolução.

Até o ano de 2015, não existiam, no Brasil, atos normativos que delineassem um modelo procedimental para a realização de apresentação do preso. Só quando o Supremo Tribunal Federal definiu a obrigatoriedade de sua realização na ADPF 347 é que as Cortes de justiça, por meio de resoluções, provimentos e portarias, passaram a fixar os ritos a serem observados. O procedimento, então, é unificado com a edição da Resolução nº 213 de 15 de dezembro de 2015.

Importante ressaltar que o art. 13 da citada Resolução prevê a possibilidade de a audiência de custódia ser realizada não só nos casos de prisão em flagrante, mas regulamentou que toda prisão cautelar (temporária ou preventiva) ou prisão definitiva, em consonância assim com os tratados e convenções de direito internacional que não restringem a apresentação pessoal apenas a casos de prisão em flagrante, mas apresentação que deve ser realizada em toda e qualquer situação de prisão, detenção ou retenção (dicção do art. 7.5 CADH). No caso de prisões por mandado, a audiência de custódia terá como finalidade a análise da legalidade de seu cumprimento e a função protetiva de coibir práticas de tortura e maus tratos no cumprimento das decisões.

Abaixo, fluxograma demonstrando todo o rito adotado desde a captura da pessoa em flagrante até o ato final da audiência de custódia:

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prisão em flagrante delito e apresentação da pessoa detida à autoridade policial                                         |
| Lavratura do Auto de Prisão em Flagrante pela Autoridade Policial (art. 304, CPP)                                        |
| Envio do Auto de Prisão em Flagrante (art. 306, CPP) e encaminhamento da pessoa presa à carceragem (detenção provisória) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encaminhamento do(a) autuado(a) para a realização de exame de corpo de delito no IML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Providências cartorárias e juntada da certidão de antecedentes criminais com a liberação para consulta pelas partes em audiência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entrevista prévia da pessoa presa com o advogado ou defensor público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Realização da audiência de custódia com os seguintes atos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. o juiz interroga a pessoa presa perguntando sobre a sua qualificação e as circunstâncias da prisão;</li> <li>2. possibilidade de perguntas pelo Ministério Público e, após, pela Defesa técnica;</li> <li>3. manifestação do Ministério Público e, após, pela Defesa técnica;</li> <li>4. autoridade Judicial decide: <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. relaxamento da prisão;</li> <li>4.2. concessão de liberdade provisória (com ou sem fiança como contracautela; com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas);</li> <li>4.3. conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva;</li> <li>4.4. substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar.</li> </ol> </li> </ol> |

## 5.2. FINALIDADES DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

1) Ajustar o processo penal brasileiro aos tratados, convenções e pactos internacionais de direitos humanos em prol de um processo penal democrático e sob controle de convencionalidade.

2) Promover um encontro da pessoa presa com a autoridade judicial, superando-se a fronteira do papel, não sendo um mero envio do auto de prisão em flagrante na forma que prevista pela legislação interna (art. 306 do CPP). Dessa forma, o preso não vai ser colocado na frente do juiz apenas meses ou anos depois na audiência de instrução e julgamento, como ocorria antes.

3) Assegurar uma célere análise da situação jurídica da prisão, antes do ingresso do autuado no sistema penitenciário, a fim de que seja exercido um controle acerca da legalidade e real necessidade da custódia antecipada, evitando, com isso, o nocivo contato com o ambiente carcerário e o encarceramento antecipado de pessoas que poderiam, desde o início, responder em liberdade.

4) Dar efetiva oportunidade de a autoridade judiciária analisar a situação do detido mais a fundo, havendo uma humanização do procedimento de apreciação sobre a necessidade de manutenção ou não de uma prisão cautelar.

5) Inibir atos de tortura, maus tratos, tratamento cruel e degradante que tenham sido despendidos contra os presos no ato de sua detenção até a chegada à audiência, sejam esses atos realizados por agentes estatais ou mesmo agressão por parte de outros presos que teve contato ou a população, assegurando a efetivação do direito à integridade das pessoas presas privadas de liberdade. Tais atos de violação a direitos fundamentais, apesar de ilegais, e dos muitos avanços no combate a essas práticas, ainda são recorrentes e uma realidade no país.

6) Permitir que a autoridade judicial tenha conhecimento das características pessoais do preso, como no caso de gestantes, indivíduos que sustentam sozinhos seus filhos menores de idade e presos com enfermidades severas ou dependência química que não poderiam receber o tratamento adequado se inseridos no sistema carcerário. Tem, assim, um papel fundamental na identificação de

importantes questões pessoais que podem influenciar na decisão do juiz e que muitas vezes a mera leitura do papel não se permite verificar.

7) Contribuir diretamente para a prevenção de desaparecimentos forçados e execuções sumárias, tendo sido este o motivo que levou a Corte Interamericana a analisar pela primeira vez o direito à apresentação imediata à autoridade judicial. A audiência permite identificar corretamente a pessoa apresentada para se confirmar se ela é realmente a pessoa contra quem foi expedida a ordem de prisão.

### 5.3. NÃO É CABÍVEL A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA (INFORMATIVO Nº 663, STJ):

Atenção ao caso analisado pelo STJ.

O Juízo Federal da 4ª Vara de Guarulhos – SP decretou a prisão preventiva de um determinado investigado. O cumprimento do mandado de prisão ocorreu na cidade de Curitiba/PR, sendo o encarceramento comunicado pela Superintendência da Polícia Federal no Paraná ao Juízo que a decretara. Na mesma data, o referido Juízo expediu carta precatória a uma das Varas Federais Criminais da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, a fim de que realizasse a audiência de custódia. A Juíza Federal no exercício da jurisdição da 1ª Unidade de Apoio de Curitiba/PR declarou-se incompetente para a realização do ato, entendendo, ainda, que poderia ser realizado pelo Juízo Deprecante (em Guarulhos) por meio de videoconferência. Após, ambos os Juízos reafirmaram sua incompetência, vindo o Juízo paranaense a suscitar o conflito decidido pelo STJ.

Em 15/12/2015, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 213, a qual "dispõe sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas." Em seu art. 13, a referida Resolução traz a disposição de que a apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos na Resolução.

A Resolução, ainda, é clara ao estabelecer que, no caso de cumprimento de mandado de prisão fora da jurisdição do Juiz que a determinou, a apresentação do preso, para a audiência de custódia, deve ser feita à autoridade competente na localidade em que ocorreu a prisão, de acordo com a Lei de Organização Judiciária local, de forma pessoal e não por videoconferência.

Cabe ressaltar que, mormente nos casos de prisão preventiva, a audiência de custódia não tem por escopo principal aferir a presença dos requisitos da custódia cautelar ou mesmo substituí-la por outras medidas, mas sim apenas, caso necessário, dar cumprimento à hipótese prevista no inciso IV do § 1º do art. 8º da norma, ou seja, adotar medidas necessárias à preservação do direito da pessoa presa. As demais medidas, ou não são aplicáveis no caso de prisão preventiva (incisos I e III), ou não possui o Juízo diverso do que decretou a prisão competência para a efetivar (inciso II).

Uma das finalidades precípua da audiência de custódia é aferir se houve respeito aos direitos e garantias constitucionais da pessoa presa. Assim, demanda-se que seja realizada pelo Juízo com jurisdição na localidade em que ocorreu o cumprimento do mandado (é o que se infere do art. 11 da Resolução). É essa a autoridade judicial que, naquela unidade de exercício do poder jurisdicional, tem competência para tomar medidas para resguardar a integridade do preso, bem assim de fazer cessar agressões aos seus direitos fundamentais, e também determinar a apuração das responsabilidades, caso haja relato de que houve prática de torturas e maus tratos. Nesse contexto, foge à *ratio essendi* do instituto a sua realização por meio de videoconferência.

Importante relembrar que o Ministro Dias Toffoli, no exercício do cargo de Presidente do Conselho Nacional de Justiça, na Reclamação para Garantia das Decisões nº 0008866-60.2019.2.00.0000, em 19/11/2019, deferiu medida liminar para suspender a Resolução CM nº 09/2019, que permitia a realização da audiência de custódia por videoconferência.



#### 5.4. A DECISÃO TOMADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PELO RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO FAZ COISA JULGADA E PERMITE QUE O PROMOTOR OFEREÇA DENÚNCIA

A decisão que, na audiência de custódia, determina o relaxamento da prisão em flagrante sob o argumento de que a conduta praticada é atípica não faz coisa julgada. Assim, esta decisão não vincula o titular da ação penal, que poderá oferecer acusação contra o indivíduo narrando os mesmos fatos e o juiz poderá receber essa denúncia (STF, HC 157.306/SP - Info 917).

Para melhor compreensão, um exemplo: no TJDF, há um núcleo de audiência de custódia em que se concentram todas as análises das prisões em flagrante do DF. Após a decisão tomada, o procedimento é enviado à vara do juízo competente para processamento e julgamento do caso. Vamos supor que Maria, reincidente em delitos de furto, foi presa em flagrante por ter novamente furtado alimentos em um supermercado no centro de Brasília. Na audiência de custódia, o Ministério Público se manifesta pela atipicidade material da conduta (pelo princípio da insignificância) e requer o relaxamento da prisão de Maria, concordando a defesa com o posicionamento. O magistrado, então, profere decisão nesse sentido. Após os autos serem distribuídos para a Vara competente, o membro do Ministério Público que lá atua, possuidor de entendimento diverso do seu colega, oferece a denúncia contra Maria. O juiz recebe a denúncia determinando os atos subsequentes do procedimento ordinário. A defesa atuante no juízo criminal, ao verificar manifestações contraditórias pelo membro do Ministério Público, impetra HC para tentar trancar a ação, afirmando que o magistrado já havia reconhecido causa excludente de tipicidade. No entanto, ao chegar o caso no STF, entendeu a Corte que a decisão tomada pelo juiz no núcleo de audiência de custódia não vincula o juiz e o promotor natural, razão pela qual manteve a tramitação da ação penal contra Maria.

#### 5.5. PRISÃO PREVENTIVA OBRIGATÓRIA/AUTOMÁTICA

A Lei Anticrime incluiu no art. 310 o § 2º que prevê que se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Assim, prevendo a legislação a “denegação da liberdade provisória”, o único caminho que o juiz possui é o da prisão preventiva, conforme art. 310, incisos II e III.

A questão que se coloca, entretanto, é a verificação da compatibilidade da restrição do art. 310, § 2º, CPP, em face da Constituição Federal.

O legislador, ao afastar a concessão da liberdade provisória de forma genérica, retira do juiz competente a oportunidade de, no caso concreto, analisar os pressupostos da necessidade do cárcere cautelar, em inequívoca antecipação de pena, colidindo com o art. 313, § 2º, CPP, e com diversos dispositivos constitucionais, mormente a presunção de inocência e o direito ao devido processo legal.

A prisão processual, pela excepcionalidade que a caracteriza, pressupõe inequívoca demonstração da base empírica que justifique a sua necessidade, não bastando apenas aludir-se a qualquer das previsões legais. A prisão provisória deve estar embasada em elementos concretos e não abstratamente.

Desse modo, um réu preso provisoriamente sem sequer existir o preenchimento dos requisitos concretos é uma completa violação do direito à liberdade, principalmente em um sistema jurídico em que encarcerar sempre deve ser exceção.

Revela-se inconstitucional, bem por isso, como anteriormente julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC 104.339/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES), a cláusula legal que, fundada no art. 44 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), veda, aprioristicamente, a concessão de liberdade provisória nas hipóteses dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação criminosa para o tráfico, dentre outros.

Sendo assim, é inconstitucional a prisão automática e obrigatória prevista no artigo 310, §2º, do CPP, visto que é proibida pela jurisprudência do STF a prisão *ex lege*, por violar a presunção de inocência e o devido processo legal.

## 5.6. RESPONSABILIZAÇÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Prevê o § 3º do art. 310, do CPP, que a autoridade que deu causa, sem motivação idônea, a não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no *caput* deste artigo, responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. Em complementação, o § 4º afirma que transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no *caput* deste artigo, a não realização de audiência de custódia, sem motivação idônea, ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.

É importante frisar que, quando do fechamento desta obra, o § 4º encontrava-se com aplicabilidade suspensa por prazo indefinido, em razão de decisão monocrática cautelar proferida pelo Ministro Luiz Fux nas ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305 no dia 22 de janeiro de 2020. Desse modo, ainda haverá discussão a respeito do prazo disposto no art. 310 (a audiência de custódia deve mesmo ser realizada dentro desse prazo exíguo de vinte e quatro horas após o decurso do prazo estabelecido no *caput* do artigo?), bem como se o flagrante deve ser relaxado nessa situação.

Percebe-se a obrigatoriedade na realização da audiência de custódia que somente não será feita se houver uma motivação idônea. Podemos citar como exemplo o momento atual de pandemia do Coronavírus. A esse respeito, abaixo decisão tomada no Núcleo de Audiência de Custódia do TJDFT motivando idoneamente a não realização da apresentação pessoal dos presos (audiência de custódia):

Não foi possível realizar a apresentação pessoal do autuado nos termos do art. 310, *caput*, do Código de Processo Penal, considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, veiculada pela Portaria nº 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020. Na data de 17 de março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ – recomendou aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia. Seguindo a recomendação, foi feita consulta à Secretaria de Saúde do TJDFT que, no Despacho nº 1306882 - Procedimento Administrativo - SEI 4439/20, atestou que “a circulação de pessoas e as atribuições do Núcleo de Audiência de Custódia potencializam o risco de transmissão da doença viral”, tornando-se inviável a realização da audiência de custódia no período de restrição sanitária relacionado com a pandemia do Covid-19. A preocupação se dá sobretudo pela intensa circulação de pessoas nas salas de audiência, muito próximas uma das outras, em que transitam inúmeras pessoas, dentre as quais estão os servidores, magistrados, partes, agentes de polícia e, ainda, pessoas presas que são apresentadas simultaneamente nos dois ambientes de realização das audiências. Há que se considerar, ainda, a suspensão das atividades presenciais do Setor Psicossocial do TJDFT, que hodiernamente realiza os atendimentos aos custodiados depois de realizadas as audiências de custódia. Em decorrência da medida de prevenção implementada por este tribunal, verifica-se a impossibilidade também do atendimento prévio à audiência de custódia, por equipe psicossocial ou de saúde, para a identificação de sintomas e perfis de risco. Desse modo, considerando o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e a importância de assegurar condições para a continuidade da prestação jurisdicional, preservando-se a saúde de magistrados, partes, servidores públicos e pessoas custodiadas, em 18 de março

de 2020, a Portaria Conjunta nº 30 da Presidência e Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no art. 5º, suspendeu a realização das audiências até 30 de abril de 2020, mantendo-se a competência do Núcleo de Audiência de Custódia para a apreciação dos Autos de Prisão em Flagrante.

## 5.7. É POSSÍVEL O JUIZ “CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA” DE OFÍCIO?

Uma das mais relevantes alterações do CPP realizada pela Lei Anticrime foi a de retirar a possibilidade de o juiz decretar medidas cautelares pessoais de ofício, seja ela prisão preventiva, seja ela medida cautelar diversa. Haverá a necessidade de provocação das partes, indo ao encontro, portanto, do sistema acusatório.

No entanto, ainda remanesce na jurisprudência do STJ a possibilidade de o juiz “converter a prisão em flagrante em prisão preventiva” de ofício, inclusive em recentes julgados a Corte continua a se manifestar nesse sentido. Para ela, o art. 310 do CPP é imperativo ao preceituar que o magistrado “deverá” decidir, tampouco condicionando o seu agir ao pronunciamento prévio do Ministério Público ou outro legitimado (HC 228913/MG).

Para as provas, você responderá de acordo com o posicionamento acima mesmo após a Lei Anticrime. No entanto, o entendimento merece críticas.

A jurisprudência mencionada foi firmada antes de 2015 (ou seja, antes das audiências de custódia), quando o magistrado analisava o auto de prisão em gabinete, sem manifestação prévia das partes. Portanto, após o delegado de polícia lavrar o auto de prisão em flagrante (art. 304 do CPP), remetia ao poder judiciário (art. 306 do CPP), e o juiz proferia sua decisão após a análise do papel, não havendo necessidade de dar vista às partes.

Na época, portanto, indagado o STJ a respeito desse procedimento, a jurisprudência se firmou no sentido de que o juiz devia analisar o flagrante e, se fosse o caso, poderia prender mesmo sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial.

Atualmente, no entanto, o auto de prisão em flagrante é analisado em audiência de custódia necessariamente com o contraditório prévio das partes que podem efetivamente influenciar na decisão judicial e ter seus argumentos analisados.

Frisa-se que nosso sistema é o acusatório e a Lei Anticrime promoveu alterações relevantes no sentido de retirar do magistrado a possibilidade de decretação de ofício de medidas cautelares pessoais. Desse modo, manter a possibilidade de o juiz, em audiência de custódia, com a presença das partes, com a manifestação prévia delas, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, fere o sistema. Um exemplo para a situação ficar mais clara: João foi preso em flagrante pela prática do delito de roubo e foi encaminhado para a audiência de custódia. No ato, após o interrogatório de garantia, o juiz passa a palavra ao Ministério Público, titular da ação penal, que se manifesta pela concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Na sequência, dada a palavra para a defesa, também se manifesta pela liberdade provisória concordando com a manifestação do órgão ministerial. Após, ao proferir a decisão, parece razoável e em consonância com o sistema que o juiz possa simplesmente desconsiderar as manifestações das partes (manifestações inclusive no mesmo sentido), seguir o seu entendimento e converter, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva? O STJ continua a entender que sim.

## 6. PRISÃO PREVENTIVA

### 6.1. CONCEITO

É a prisão de natureza cautelar mais grave, sendo uma ferramenta de encarceramento durante o inquérito policial e na fase processual. A preventiva só se sustenta se presentes o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração, os eventuais envolvidos, além de algum motivo legal que fundamente a necessidade do encarceramento. Por restringir a liberdade em seu grau máximo, é cercada de uma série de requisitos e limitações para que não se torne uma indevida

antecipação de pena, o que não é possível no processo penal por ser incompatível com o princípio da presunção de inocência.

## 6.2. ANÁLISE DO ART. 311 DO CPP

| ANTES DA LEI Nº 13.964/19                                                                                                                                                                                                                                                             | DEPOIS DA LEI Nº 13.964/19                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. | Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. |

A prisão preventiva pode ser decretada tanto no inquérito policial como na ação penal e poderá ser requerida pelo Ministério Público, pelo querelante na ação penal privada e pelo assistente de acusação. Ainda, quando se tratar da fase do inquérito policial, pode haver representação da autoridade policial.

A prisão preventiva somente poderá ser decretada pelo Poder Judiciário, em qualquer de suas instâncias. Assim, pode ser decretada pelo Juiz de direito, pelo Tribunal de apelação ou até mesmo pelos Tribunais Superiores.

Coerente com o sistema acusatório que adota expressamente (art. 3º-A), a lei dá nova redação art. 311 do CPP, abolindo o “de ofício” que constava da redação original, vedando assim a decretação de medidas cautelares, especialmente a prisão preventiva, sem provocação expressa dos legitimados.

**Atenção:** prevê o art. 20 da Lei Maria da Penha que, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Em que pese à nova redação dada ao art. 311 do CPP, que não permite que o juiz decrete a prisão preventiva de ofício, a legislação especial (Lei Maria da Penha) não foi alterada, havendo, ainda, previsão expressa de que naqueles casos o juiz poderá decretar a prisão de ofício. Em atenção ao sistema acusatório, mesmo que não tenha sido uma alteração global do ordenamento processual penal, deve ser considerado revogado tacitamente a previsão do art. 20 da Lei Maria da Penha por dispor de maneira flagrantemente contrária à nova intenção do legislador. No entanto, enquanto não há manifestação dos Tribunais Superiores, é preciso ter cuidado com provas objetivas de concursos públicos, que poderão cobrar a literalidade do art. 20 da lei especial.

## 6.3. PRESSUPOSTOS, FUNDAMENTOS E ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

Para que seja decretada a prisão preventiva haverá a necessidade de combinação dos seus requisitos e pressupostos. Para fins didáticos, dividimos todos eles de acordo com o seguinte entendimento:

**a) pressupostos positivos:** para que a prisão preventiva seja decretada, é preciso estar presente a fumaça do cometimento do delito (*fumus commissi delicti*), prevista no *caput* do art. 312 do CPP que se caracteriza pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria;

**b) fundamentos:** para a decretação da prisão preventiva, é preciso estar presente o perigo de colocar ou manter o agente em liberdade (*periculum libertates*), previsto no *caput* do art. 312 do CPP: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. A nova redação do art. 312, modificada pela Lei Anticrime, incluiu a expressão “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Em que pese o

destaque dado pelo legislador, é possível se compreender que tal fundamento está abarcado pela “garantia da ordem pública”;

**c) pressupostos negativos:** a prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, II e III do *caput* do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, conforme art. 314 do CPP. O art. 310, § 1º, do CPP, possui redação semelhante, ao dispor que “se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do *caput* do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação”;

**d) condições de admissibilidade da prisão preventiva ou também chamado de juízo de legalidade da prisão preventiva:** deve haver a presença de ao menos uma das condições de admissibilidade (art. 313 do CPP): crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do *caput* do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

É preciso ainda considerar um último momento na análise da decretação da prisão preventiva. O magistrado deve sempre lembrar que a prisão é a última opção (*ultima ratio*), por ser a medida restritiva mais gravosa do processo penal. Mesmo preenchidas todas as condições acima explicadas (pressuposto positivo; não haver pressuposto negativo; fundamentos; admissibilidade da prisão preventiva), deve o magistrado demonstrar o porquê as medidas cautelares diversas não são adequadas e suficientes. Assim, dispõe a importante redação do art. 282, § 6º, do CPP: a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

| ANTES DA LEI Nº 13.964/19                                                                                                                                                                                                                                              | DEPOIS DA LEI Nº 13.964/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. | Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.<br>§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).<br>§2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. |



#### 6.4. PRESSUPOSTOS POSITIVOS: FUMAÇA DO COMETIMENTO DO DELITO (*FUMUS COMISSI DELICTI*)

Para que se possa decretar a prisão preventiva é preciso a presença dos pressupostos positivos: a) prova da existência do crime; e b) indícios suficientes de autoria. É preciso ressaltar que devem estar presentes os dois elementos. Quanto ao segundo, exige a lei apenas “indícios” e não certeza da autoria.

O magistrado deverá, portanto, indicar de maneira concreta em sua decisão quais são os elementos que o convenceram da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria. Ex.: depoimento do condutor do flagrante; reconhecimento da vítima; relato detalhado das vítimas e testemunhas.

#### 6.5. PRESSUPOSTOS NEGATIVOS (ART. 314 DO CPP)

A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, II e III do *caput* do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, conforme art. 314 do CPP.

O art. 310, § 1º, do CPP, possui redação semelhante, ao dispor que “se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do *caput* do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação”.

Verificando que o crime foi praticado sob o manto de uma das causas excludentes de ilicitude não poderá ser decretada, em nenhum caso, a prisão preventiva. Do mesmo modo, se da análise do auto de prisão em flagrante o juiz verificar que o preso cometeu o fato em excludente de ilicitude, não poderá em nenhum caso, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

#### 6.6. FUNDAMENTOS

Não houve mudança no tratamento legal da prisão preventiva no que diz respeito aos motivos cautelares do art. 312 do CPP. Continua, portanto, a justificar a cautela extrema pelo menos uma das seguintes circunstâncias: necessidade da prisão para garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal.

As duas últimas exigências cautelares são de fácil percepção e exemplificação pela doutrina.

No que tange à conveniência da instrução criminal, eventuais ameaças, chantagens, intimidações ou promessas de vantagens para testemunhas ou ao ofendido, interferências no trabalho dos peritos, produção de prova documental falsificada e atos similares podem ensejar a decretação da prisão preventiva do investigado ou do acusado (CRUZ, 2017, p. 251). Desse modo, a instrução processual deverá ser protegida quando o agente indiciado ou processado praticar alguma conduta para se beneficiar ou para beneficiar terceiros, maculando a produção de elementos de informação ou a produção probatória.

Se o réu, ou alguém por ele, está ameaçando, tentando subornar ou influir no ânimo de testemunha ou corréu, prometendo recompensas para que a testemunha minta, destruindo documentos, forjando provas, criando álibi, produzindo documento falso etc. estará caracterizada a necessidade da prisão para conveniência da instrução criminal (MENDONÇA, 2011, p. 256).

No que toca ao fundamento da necessidade de se assegurar a aplicação penal, visa a proteger os fins do processo, ou seja, a definitiva prestação jurisdicional na sentença penal de que resulta condenação, com a imposição da sanção, portanto, qualquer iniciativa tenente a furtrar-se à aplicação da lei penal, como no caso de uma tentativa de fuga, poderá ser imposta a prisão preventiva.



A real tentativa de fuga (STJ. HC 207.564), compra de bens em outros lugares, venda de bens (STJ. HC 45.772), compra de passagens aéreas (STJ. HC. 46.501), já estar foragido (STJ. 206952), ausência constante de domicílio fixo (STJ. 198.675), ausência de vínculo no distrito da culpa (STJ. HC 223.900), já ter fugido para outro estado (STJ. HC 212.173) são indicativos mais palpáveis de se avaliar e, eventualmente, confrontar.

A conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação de lei penal são fundamentos prisionais de verdadeira natureza cautelar, diferenciando-se da ordem pública e da econômica. Protegem-se, naqueles casos, o processo penal e o direito penal, enquanto nestes há dúvida sobre as verdadeiras naturezas jurídicas e finalidades.

Mais difícil é dispor sobre a cautelaridade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, a qual possui uma abertura linguística que permitiu, ao longo dos anos, preenchimentos conceituais, tais como periculosidade do agente, hediondez, perversidade, participação em organização criminosa, gravidade do crime, clamor público, reincidência, reiteração delitiva, prisão para segurança do imputado, credibilidade das instituições e defesa social, dentre outros. No entanto, atualmente, em que o Brasil possui aproximadamente 40% de seus presos como provisórios e que o Poder Judiciário aciona o precitado fundamento, acaba por demonstrar que ele é hiperinterpretado, com limites semânticos problemáticos e significações variadas. Não fornece uma baliza segura ao legislador, asseguram e estimulam a atividade criativa do julgador, gerando, no campo do processo penal, desproteção de direitos fundamentais e descumprimento de garantias.

Admite a jurisprudência como conceito integrante de ordem pública:

a) probabilidade de reiteração de condutas criminosas que pode ser aferida por investigações e ações penais em andamento. Nesse sentido: “inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva” (STJ, RHC 055365/CE; RHC 054750/DF; RHC 052402/BA);

b) probabilidade de reiteração de condutas criminosas que pode ser verificada pelos atos infracionais praticados quando era adolescente. Nesse sentido:

A prática de atos infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, considerando que indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração. Não é qualquer ato infracional, em qualquer circunstância, que pode ser utilizado para caracterizar a periculosidade e justificar a prisão antes da sentença. É necessário que o magistrado analise: a) a gravidade específica do ato infracional cometido; b) o tempo decorrido entre o ato infracional e o crime; e c) a comprovação efetiva da ocorrência do ato infracional (STJ. 3a Seção. RHC 63.855-MG, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/5/2016).

c) gravidade concreta do crime:

A alusão genérica sobre a gravidade do delito, o clamor público ou a comoção social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão preventiva (STJ, RHC 055070/MS; HC 311162/SP; HC 299666/SP; RHC 048058/BA; HC 270156/CE).

A prisão cautelar deve ser fundamentada em elementos concretos que justifiquem, efetivamente, sua necessidade (STJ, HC 315093/SP; HC 311440/SP; RHC 056167/BA).

#### Atenção:

a) Clamor social ou clamor público deve ser compreendido como repercussão, alarde gerado pelo acontecimento, chamando atenção da sociedade, da mídia e da imprensa. É preciso ressaltar que delitos praticados por pessoas que não são públicas, ou delitos de menor gravidade, pena em abstrato pequena ou com *modus operandi* não violento não geram efeitos sociais relevantes. O clamor público, assim como a “intranquilidade” e o suposto “aumento da criminalidade”, não pode dar ensejo ao fundamento da ordem pública por consistirem em dados

genéricos sem conexão direta com o “fato delitivo”. O clamor público é fruto da estrutura social vigente e pode ser facilmente influenciada por interesses privados. O “alarme social” é um conceito de contornos vagos e imprecisos, facilmente manipulável, desconforme com o direito processual penal de um Estado de Direito Democrático. O alarde não permite a prisão preventiva dada a importância do direito à liberdade.

b) Deve ser lembrado, ainda, que não é lícito ao juiz emitir julgamentos com esteio em fatos que chegam ao seu conhecimento por vias estranhas ao processo.

c) Os fatos que justificam a prisão preventiva devem ser contemporâneos à decisão que a decreta (STJ, HC 214921/PA; HC 299733/RJ). O entendimento jurisprudencial foi adicionado ao art. 312, § 2º, do CPP pela Lei Anticrime.

## 6.7. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

Estão previstas no art. 313 do CPP:

| ANTES DA LEI Nº 13.964/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEPOIS DA LEI Nº 13.964/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:</p> <p>I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;</p> <p>II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do <i>caput</i> do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;</p> <p>III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;</p> <p>IV - (revogado).</p> <p>Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.</p> | <p>Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:</p> <p>I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;</p> <p>II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do <i>caput</i> do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;</p> <p>III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;</p> <p>IV - (revogado).</p> <p>Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.</p> <p>§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.</p> |

Para que seja decretada a prisão preventiva há necessidade da presença de ao menos uma das condições de admissibilidade. Não há necessidade de cumular todos os incisos do art. 313, bastando a presença de apenas um deles.

Além disso, é possível perceber pela leitura do dispositivo legal que não é possível a prisão preventiva no cometimento de contravenção penal, uma vez que em todas as três condições de admissibilidade somente fazem referência ao cometimento de crime e não de contravenção.

Vale dizer, ainda, que a prisão preventiva somente será possível nos crimes dolosos, não há nenhum inciso referente a crime culposos.

Abaixo alguns exemplos para a matéria ficar mais clara:

Exemplo 1: José foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de receptação (Art. 180 do Código Penal – pena: 01 a 04 anos de reclusão e multa). Em que pese seja tecnicamente primário e de bons antecedentes e seja civilmente identificado, possui, em sua Folha de Antecedentes Criminais, duas anotações pela prática de crimes patrimoniais, sem que essas ações tenham resultados definitivos. Em primeiro lugar, há fumaça do cometimento do delito (pressuposto positivo). Vamos supor que há elementos a indicar a prova de que a receptação existiu, bem como indícios de que foi José que a praticou. Além disso, não incide nenhuma causa de excludente de ilicitude (pressupostos negativos). É possível afirmar que há necessidade de se garantir a ordem pública pelo perigo de se colocar José em liberdade, uma vez que possui diversas anotações anteriores pela prática de delitos patrimoniais (fundamento da prisão: garantia da ordem pública). No entanto, a situação esbarra no art. 313 do CPP, não havendo legalidade, ou seja, admissibilidade na decretação da prisão de José. Note que, em que pese o delito seja doloso, a pena máxima da receptação não supera quatro anos. Além disso, José não possui condenação definitiva, não sendo considerado reincidente para fins do inciso II do art. 313 do CPP. José foi civilmente identificado e não se trata de caso de proteção de vulneráveis (mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência). Desse modo, pode até se afirmar que em um primeiro momento de análise que a prisão preventiva de José se mostra necessária, mas ela não poderá ser decretada, tendo em vista não preencher nenhum dos incisos do art. 313 do CPP. José deve ser posto em liberdade.

Exemplo 2: Carlos praticou de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor (Art. 303 da Lei nº 9.503/97 – pena: detenção de seis meses a dois anos), foi identificado corretamente nos autos e possui, em sua Folha de Antecedentes Criminais, três anotações referentes a condenações, com trânsito em julgado, pela prática da mesma infração penal, todas aptas a configurar reincidência quando da prática do delito ora investigado. Em primeiro lugar, há fumaça do cometimento do delito (pressuposto positivo). Vamos supor que há elementos a indicar a prova de que o crime existiu, bem como indícios de que foi Carlos que o praticou. Além disso, não incide nenhuma causa de excludente de ilicitude (pressupostos negativos). É possível afirmar que há necessidade de se garantir a ordem pública pelo perigo de se colocar Carlos em liberdade, uma vez que possui diversas condenações definitivas também por delitos de trânsito, demonstrando uma reiteração delitiva específica (fundamento da prisão: garantia da ordem pública). No entanto, a situação esbarra no art. 313 do CPP, não havendo legalidade, ou seja, admissibilidade na decretação da prisão de Carlos. Note que o crime é culposos, não preenchendo o inciso I do art. 313 do CPP que exige a prática de crime doloso. Além disso, em que pese possuir três condenações definitivas, todas elas foram por crimes culposos, não se encaixando no inciso II do art. 313 do CPP, que exige reincidência em crime doloso. Carlos foi civilmente identificado e não se trata de caso de proteção de vulneráveis (mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência). Desse modo, pode até se afirmar que em um primeiro momento de análise que a prisão preventiva se mostra necessária, mas ela não poderá ser decretada, tendo em vista não preencher nenhum dos incisos do art. 313 do CPP. Carlos deve ser posto em liberdade.

Por restringir a liberdade em seu grau máximo, a prisão preventiva é cercada de uma série de requisitos e limitações para que não se torne uma indevida antecipação de pena, o que não é possível no processo penal por ser incompatível com o princípio da presunção de inocência. Para deixar ainda mais claro isso, o legislador incluiu o § 2º ao art. 313 do CPP.

## 6.8. MODALIDADES DE PRISÃO PREVENTIVA

Caberá prisão preventiva:

a) como providência cautelar autônoma: o investigado ou acusado responde à investigação ou processo solto, não havendo vinculação a uma situação de prisão em flagrante

prévia. Em sendo o juiz provocado (art. 311 do CPP) com a demonstração de todos os pressupostos (arts. 312 e 313 do CPP), bem como sendo insuficientes ou inadequadas as medidas cautelares diversas, será a prisão preventiva decretada;

b) como conversão do auto de prisão em flagrante em preventiva: situação em que a análise da prisão preventiva está vinculada à uma situação prévia de prisão em flagrante. É o caso do art. 310 do CPP, em que na audiência de custódia o juiz decidirá sobre a situação do preso e uma das opções é converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, CPP);

c) como consequência do descumprimento de obrigação relativa à cautela pessoal imposta anteriormente: conforme dispõe o art. 312, § 1º, do CPP, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. O art. 282, § 4º, do CPP, esclarece que no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. Três observações importantes sobre essa modalidade de prisão preventiva:

c.1) o juiz não poderá mais decretar a prisão de ofício. O dispositivo legal também foi modificado pela Lei Anticrime suprimindo qualquer possibilidade de o juiz agir sem ser provocado;

c.2) a prisão não é automática (descumpriu então necessariamente tem que ser preso). Conforme a própria redação do art. 282, § 4º, do CPP, a prisão preventiva continua sendo a última opção. Se for suficiente, a medida cautelar pode ser substituída por outra ou cumulada com mais algumas. Apenas se nada disso puder ser feito que a prisão preventiva será decretada;

c.3) no caso de imposição de prisão preventiva como forma de sanção ao descumprimento de obrigações anteriores, será preciso demonstrar a necessidade da prisão com base no art. 312 do CPP, apenas, independentemente das circunstâncias ou hipóteses arroladas no art. 313 do CPP. Ex.: João é primário e de bons antecedentes e foi preso em flagrante pelo delito de receptação (pena de 1 a 4 anos de reclusão). Na audiência de custódia, João teve concedida a sua liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). No curso do processo, João descumpre todas as condições e o Ministério Público, como legitimado, requer a sua prisão. Neste caso, o juiz irá analisar a imposição ou não da segregação apenas com base no art. 312 do CPP, não precisando preencher o art. 313 (que na situação não estaria sequer presente).

## 6.9. SISTEMA RECURSAL

O juiz pode decretar a prisão preventiva atendendo a requerimento do MP ou do querelante ou do assistente de acusação; ou provocado por representação da autoridade policial. A preventiva terá cabimento durante toda a perseguição, tanto nos crimes de ação pública, quanto nos de ação penal privada, desde que atendidos os requisitos legais.

Nada impede que uma vez relaxada a prisão em flagrante, seja decretada, na sequência, a preventiva, se atendidas as exigências para a decretação da medida. Todavia, a preventiva é absolutamente incompatível com o instituto da liberdade provisória, seja ela com ou sem fiança.

As decisões interlocutórias que versem sobre prisão e liberdade são recorríveis quando desfavoráveis ao pleito carcerário. Negando a liberdade, são irrecurríveis, hipótese em que a defesa deverá se valer da ação autônoma de impugnação do *habeas corpus*.

Se o juiz de primeiro grau indeferir requerimento de prisão preventiva, ou revogar a medida, colocando o agente em liberdade, as duas decisões podem ser combatidas por meio do recurso em sentido estrito. Já se o juiz nega o pedido de revogação da preventiva, ou decreta a mesma, estas decisões, por ausência de previsão legal, não comportam recurso, cabendo a defesa invocar a ação de *habeas corpus*.

**6.10. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA**

A apresentação espontânea do agente à autoridade ilide a prisão em flagrante, por ausência de previsão legal autorizando o flagrante nestas situações. Nada impede, uma vez presentes os requisitos legais, que se represente pela decretação da prisão preventiva (art. 312, CPP), ou até mesmo pela temporária (Lei nº 7.960/89).

**6.11. PREVENTIVA X EXCLUDENTE DE ILICITUDE**

A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato sob o manto de excludente de ilicitude (art. 314, CPP). No caso de análise de auto de prisão em flagrante, se o juiz verificar que o agente praticou o fato em qualquer das condições das excludentes de ilicitude, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação (art. 310, § 1º, CPP).

**6.12. Fundamentação da prisão preventiva (art. 315 do CPP)**

O CPC de 2015 traz norma bastante útil para o entendimento sobre a correta fundamentação a ser feita em uma decisão. Confira o art. 489, § 1º, CPC:

Art. 489, § 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Com a Lei nº 13.964/2019, o CPP passa a ter previsão bem semelhante no art. 315, § 2º. Antes, a sua redação era muito simples, contendo uma afirmação redundante que já era prevista na Constituição Federal (necessidade de fundamentar as decisões judiciais).

| ANTES DA LEI Nº 13.964/19                                                                         | DEPOIS DA LEI Nº 13.964/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada. | Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.<br>§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.<br>§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:<br>I – se limitar à indicação, à reprodução ou à |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;</p> <p>II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;</p> <p>III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;</p> <p>IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;</p> <p>V – limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;</p> <p>VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Em que pese o dispositivo legal tenha sido inserido pelo legislador no título relativo à “prisão, medidas cautelares e liberdade provisória”, resta evidente pela redação dada ao § 2º que não se aplica apenas no regime de prisões, mas também em qualquer sentença ou decisão no âmbito do processo penal dada a utilização da redação “qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão”.

### 6.13. CARÁTER PROVISÓRIO DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 316, *CAPUT*, DO CPP)

| ANTES DA LEI Nº 13.964/19                                                                                                                                                                           | DEPOIS DA LEI Nº 13.964/19                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. | Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. |

Apesar de o art. 316 referir-se à prisão preventiva, há previsão idêntica para as medidas cautelares diversas no art. 282, § 5º, do CPP: o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Se for uma decisão a ser tomada a favor do réu, ou seja, para revogar a prisão ou uma medida cautelar, o magistrado não precisa ser provocado, podendo tomar a decisão de ofício. Isto é, caso as circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva ou da medida cautelar diversa não mais subsistam (submetidas à cláusula *rebus sic stantibus*), o juiz irá revogar a medida, podendo agir de ofício. Por outro lado, se houve nova alteração e a prisão voltar a ser necessária, o juiz poderá novamente decretá-la, conforme parte final do art. 316 do CPP.

Para provas de primeira fase em concursos públicos, provavelmente o examinador se valha da literalidade da lei para a cobrança da matéria. No entanto, em outras fases, bem como na prática penal, a parte final do art. 316 merece críticas.



Dispõe o legislador que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, novamente decretar a prisão preventiva se sobrevierem razões que a justifiquem. Prevê, portanto, que se os legitimados (art. 311 do CPP) um dia pediram a prisão preventiva e o juiz a decretou, mesmo que ele tenha revogado, se ele entender que novamente deverá prender o autor do fato, pode proceder de ofício, sem pedido, pois já houve uma manifestação prévia em algum momento do processo.

Em outras palavras, a primeira prisão não poderá ser decretada de ofício, mas, se o juiz tiver revogado a prisão, por entender que não existem mais motivos, poderá tornar a prender o acusado, se entender que existem novas razões que a justifiquem.

É possível visualizar flagrante contradição entre o texto legal e a busca do legislador em acabar (ou diminuir) com o ativismo judicial (sobretudo ao adotar expressamente o sistema acusatório), com a vedação da atuação de ofício do magistrado, principalmente quanto à decretação de prisões cautelares (conforme modificação pela Lei Anticrime dos arts. 282 e 311 do CPP).

O problema não está em possibilitar a decretação de nova prisão preventiva. A crítica que deve ser feita é no sentido de que essa nova prisão não pode ser decretada sem que ninguém a requeira, pois uma das maiores inovações e melhorias trazidas ao CPP foi exigir a provocação do magistrado para a sua atuação.

#### 6.14. PRAZO PARA REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP)

| ANTES DA LEI Nº 13.964/19                                                                                                                                                                           | DEPOIS DA LEI Nº 13.964/19                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. | Art. 316.<br>Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. |

Não havia antes da Lei Anticrime, bem como não há prazo determinado para a prisão preventiva, o que permite que ela se estenda de forma indefinida. A Lei nº 13.964/2019 trouxe um prazo para revisão periódica da prisão preventiva, ao acrescentar o parágrafo único ao artigo 316 do CPP, determinado que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

A instituição de um prazo para revisão da prisão preventiva é muito importante, especialmente se considerarmos a realidade brasileira, em que há um número elevado de presos provisórios (aproximadamente 40% do total da população carcerária) e que essas prisões se prolongam por um tempo longo. Trata-se de uma ferramenta que, se bem usada, poderá contribuir para a redução da superlotação carcerária.

Embora a lei não tenha fixado o prazo máximo de duração da prisão preventiva, tal como ocorre com a prisão temporária (Lei nº 7.960/89 – de regra, prazo de cinco dias, prorrogável por mais cinco; crimes hediondos e equiparados com prazo de 30 dias, prorrogável por mais trinta), impôs o dever do magistrado de reanalisar seus fundamentos a cada 90 dias (CPP, art. 316, parágrafo único). A rigor, portanto, a prisão preventiva vale apenas por esse prazo. Com efeito, se, decorrido o prazo legal, não houver pronunciamento judicial, a prisão será ilegal, devendo ser relaxada, podendo o magistrado incorrer em abuso de autoridade. Esse reexame é obrigatório e independe de provocação das partes, bem como pode ser feito bem antes dos 90 dias (pode revogar a prisão a qualquer tempo!). O que não se pode é ultrapassar esse prazo.

Quando o juiz ou tribunal entender que a prisão preventiva deve ser mantida, proferirá decisão, motivando a manutenção da prisão. Trata-se de uma decisão que reaprecia a anterior, acolhendo ou rejeitando seus fundamentos, acrescentando novos argumentos. Desse modo, não

valerá a simples ratificação da decisão (“Inalteradas as circunstâncias fáticas”), sem análise detalhada do caso. O juiz deve revisar, de ofício, a prisão preventiva para renová-la com fatos contemporâneos, devendo ser proferida uma nova decisão, devidamente fundamentada, não suprimindo uma simples formalidade de mera reiteração de termos anteriores.

Com a entrada em vigor da lei no dia 23 de janeiro de 2020, as prisões preventivas decretadas há mais de 90 dias foram reexaminadas imediatamente, uma vez que a norma, por ter caráter predominante de direito material, retroage para abarcar fatos pretéritos.

Exige a lei, portanto, que o juiz permaneça em constante monitoração das prisões decretadas para que atualize a decisão no prazo de 90 dias e não mantenha pessoas presas desnecessariamente.

## 7. PRISÃO DOMICILIAR

A prisão domiciliar consiste na substituição da prisão preventiva cumprida no sistema prisional para a prisão com recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, de onde apenas poderá se ausentar com prévia autorização judicial (art. 317 do CPP).

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for (art. 318 do CPP): I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV – gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea do requisito.

A Lei nº 13.257/2016, que prevê a formulação e implementação de políticas públicas voltadas para as crianças que estão na “primeira infância”, promoveu alterações relevantes no CPP, em especial no art. 318, ao alterar a redação do inciso IV e incluir os incisos V e VI.

Em que pese o art. 318 do CPP diga expressamente “substituir a prisão preventiva pela domiciliar”, a doutrina, em aplicação analógica, entende que a prisão temporária também pode ser substituída pelo cumprimento em domicílio.

Além disso, não se confunde com a medida cautelar diversa da prisão de recolhimento domiciliar noturno ou nos dias de folga. Enquanto a prisão domiciliar substitui a prisão preventiva, ou seja, é forma de cumprimento da prisão preventiva (em domicílio), o recolhimento domiciliar noturno ou em dias de folga é medida cautelar menos gravosa e diversa da prisão, mantendo-se o agente em liberdade, mas com restrições de horários.

O tema “prisão domiciliar” é tratado tanto no CPP como na LEP, sendo, entretanto, institutos diferentes, devendo se ter cuidado na leitura dos dois dispositivos legais (art. 117 da LEP e art. 318 do CPP) para não gerar confusão na prova de concurso público nem na prática penal. Abaixo, a comparação:

| PRISÃO DOMICILIAR – Art. 117 LEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRISÃO DOMICILIAR – Art. 318 CPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:</p> <p>I - condenado maior de 70 (setenta) anos;</p> <p>II - condenado acometido de doença grave;</p> <p>III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;</p> <p>IV - condenada gestante.</p> | <p>Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:</p> <p>I - maior de 80 (oitenta) anos;</p> <p>II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;</p> <p>III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;</p> <p>IV - gestante;</p> <p>V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;</p> <p>VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade</p> |

|  |                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | incompletos.<br>Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

O CPP, ao tratar da prisão domiciliar, está se referindo à possibilidade de o réu, em vez de ficar em prisão preventiva no estabelecimento prisional, permanecer recolhido em sua residência. Trata-se de medida aplicada em sede de cautela. A LEP, ao tratar da prisão domiciliar, está se referindo à possibilidade de a pessoa já condenada cumprir a sua pena privativa de liberdade na própria residência. Trata-se, portanto, de execução definitiva de pena na própria residência.

Registra-se que as hipóteses do rol do art. 117 da LEP são mais brandas que as do art. 318 do CPP, afinal, o preso já está em fase final de cumprimento de pena, em regime mais leve.

#### Atenção:

- Em 2018, foi analisado pelo STF *habeas corpus* (HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Info 891) impetrado por advogados de um movimento chamado “Coletivo de Advogados em Direitos Humanos” (CADHu) – com a intervenção da DPU – que pediram que a Corte reconhecesse, de forma ampla e geral, que as presas grávidas ou com filhos menores de 12 anos possuem direito à prisão domiciliar. O STF, na concessão da ordem, estabeleceu que, em regra, deve ser concedida a prisão domiciliar para todas as mulheres presas que sejam: gestantes; puérperas (que deu à luz há pouco tempo); mães de crianças (isto é, mães de menores até 12 anos incompletos); mães de pessoas com deficiência. Situações que se encaixam nos incisos III, IV e V do art. 318 do CPP.

- O mesmo julgado estabeleceu que não deve ser autorizada a prisão domiciliar se: b.1) a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; b.2) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); b.3) em outras situações excepcionais, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. No final de 2018, as exceções previstas nos itens 1 e 2 foram incluídas no art. 318-A do CPP, *in verbis*:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

- O julgado deve ser aplicado também para adolescentes que tenham praticado atos infracionais.

- O simples fato de que a mulher ser reincidente não faz com que ela perca o direito à prisão domiciliar. Deve ser analisado o caso concreto para verificar se a medida é adequada.

- Para apurar a situação de guarda dos seus filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará (STF, HC 143641/SP - Info 891).

- É possível que outras situações excepcionais, extraídas do caso concreto, demonstrem que a medida de substituição da prisão preventiva pela domiciliar não é adequada. Nesse caso, as razões deverão ser devidamente expostas e fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. O STF e STJ analisaram alguns casos relevantes em que a providência foi indeferida, em razão de a mulher ter se valido da própria residência para a prática de crimes ou de restar comprovado que ela não cuida de seus filhos ou dependentes:

Não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com filhos menores de 12 anos. O Tribunal de origem, ao analisar a questão, considerando o recente precedente do STF, no julgamento do HC n. 143.641, apresentou fundamento válido para afastar a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, ao destacar laudo pericial do assistente social, no qual consta que a paciente usava de sua própria residência para a prática delituosa (STJ, HC 441.781-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 12/6/2018, DJe 19/6/2018).

(...) embora a paciente seja genitora de pessoa portadora de deficiência, há informações de que a mesma se encontra amparada por familiares e que a paciente não prestava a devida assistência à filha deficiente, tendo sido necessárias diversas intervenções protetivas por parte da Vara da Infância e Juventude para resguardar seus interesses. Nesse contexto, é certa a inadmissibilidade da concessão da prisão domiciliar no caso dos autos (STJ, 5ª Turma, HC 443.697/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 11/9/2018). (...) *In casu*, tem-se “situação excepcional” que justifica a mitigação da decisão do Supremo Tribunal Federal no *habeas corpus* coletivo n.º 143.641/SP, na medida em que, embora a paciente tenha comprovado que é mãe de criança de onze anos de idade e encontra-se grávida, o crime foi praticado em sua residência, local onde supostamente a acusada não apenas comercializava como também armazenava os entorpecentes. (...) (STJ, 6ª Turma, HC 445.352/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/8/2018).

- A substituição da prisão preventiva pelo cumprimento em domicílio poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Ex.: poderá ser fixada a monitoração eletrônica para que seja fiscalizado o cumprimento adequado da prisão domiciliar (recolhimento integral em domicílio).

- Nada disse a Lei nº 12.403/11 quanto à detração nas hipóteses de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Em que pese o silêncio do legislador, funcionando a prisão domiciliar como forma de cumprimento de prisão preventiva (ou prisão temporária), o desconto do tempo de cumprimento da medida em caso de condenação, previsto no art. 42 do CP e no art. 387, § 2º do CPP, é medida de rigor e adequada. Nesse sentido, a jurisprudência:

O tempo de prisão cautelar efetivamente cumprida em regime domiciliar deve ser computado na pena privativa de liberdade, para fins de detração (CP, art. 42). (STJ, HC 11.225/CE, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 6/4/2000, DJ 2/5/2000, p. 153.)

## 8. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

### 8.1. INTRODUÇÃO

As medidas cautelares pessoais podem ser divididas em:

a) pessoais: a.1) prisões cautelares, ou seja, prisão preventiva e prisão temporária; a.2) medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP.

b) patrimoniais ou reais, que consistem nas medidas assecuratórias de sequestro, arresto e hipoteca legal;

c) instrutórias, relacionadas à obtenção da prova do crime em caráter urgente, por exemplo, busca e apreensão e interceptação telefônica.

Todas elas possuem o traço comum de necessitarem de demonstração da cautelaridade, sujeitando-se, portanto, a pressupostos e requisitos que, de modo geral, são conhecidos como a plausibilidade do direito reivindicado (*fumus boni iuris*) e o perigo da demora (*periculum in mora*).

No presente tópico, se cuidará de analisar as medidas cautelares pessoais diversas da prisão, previstas nos arts. 319 e 320, ambos do CPP. Tais condições podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente (art. 282, § 1º, do CPP), pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante

requerimento do Ministério Público (art. 282, § 2º, do CPP — não pode mais de ofício) e são medidas hábeis a substituir a prisão preventiva, que fica resguardada apenas para os casos em que tais providências menos gravosas sejam fundamentadas como inadequadas ou insuficientes (art. 282, § 6º, e art. 310, II, ambos do CPP).

São elas: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; IX - monitoração eletrônica e a proibição de ausentar-se do País será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no prazo de vinte e quatro horas.

## 8.2. O ART. 319 É ROL TAXATIVO OU EXEMPLIFICATIVO?

A doutrina discute se o rol acima transcrito (art. 319) é taxativo ou exemplificativo. Em outras palavras, indaga-se: pode o juiz impor ao investigado/acusado como condição para manter a sua liberdade ou evitar a sua segregação cautelar uma medida alternativa menos gravosa que a prisão e que não esteja prevista expressamente no CPP? Pode o juiz penal se valer de medidas alternativas à prisão cautelar não prevista, expressamente, no ordenamento jurídico?

É certo que no processo civil, em face da impossibilidade de o legislador antever todas as situações de risco, outorga-se expressamente ao juiz o poder de conceder a tutela de urgência que reputar mais apropriada ao caso concreto, ainda que não prevista em lei. Trata-se do chamado poder geral de cautela, previsto no art. 297 do Código de processo civil, contemplado como poder geral de editar tutelas provisórias, de urgência ou de evidência. No processo penal, discute-se se o mesmo raciocínio pode ser adotado, encontrando resistência doutrinária para a abertura do rol.

Para a doutrina majoritária, o rol do art. 319 é taxativo, inexistindo no processo penal um poder geral de cautela, não sendo admitidas, pois, medidas cautelares atípicas, até porque, em se tratando de restrição à liberdade do cidadão, toda e qualquer norma a esse respeito deve ser interpretada de forma restritiva. Afinal, o processo penal é um instrumento limitador do poder punitivo estatal (artigo 5º, LIV, CF/88), exigindo-se a observância da legalidade estrita e da tipicidade processual para qualquer restrição ao direito de liberdade. Conforme ensina Aury Lopes Jr.,

no processo penal, forma é garantia. Logo, não há espaço para ‘poderes gerais’, pois todo poder é estritamente vinculado a limites e à forma legal. O processo penal é um instrumento limitador do poder punitivo estatal, de modo que ele somente pode ser exercido e legitimado a partir do estrito respeito às regras do devido processo (LOPES JR., 2017, p. 584).

Também Badaró (2018, p. 715) caminha no mesmo sentido, ao rejeitar a utilização de medidas cautelares não expressamente previstas em lei, ante ao princípio da taxatividade das medidas cautelares pessoais, “evitando-se arbitrariedades e casuísmo, dando-se, portanto, total transparência às regras do jogo”. Daí se conclui que somente as medidas previstas no art. 319 e 320



(incluídas pela Lei nº 12.403/11) podem ser aplicadas ao investigado ou ao acusado em processo penal.

No mesmo âmbito de discussão, o Plenário do STF possui entendimento mais recente que, diante do postulado constitucional da legalidade em matéria penal/processual penal, inexistente no processo penal um poder geral de cautela dos juízes (Informativo nº 906). Nesse julgado, o STF decidiu pela impossibilidade de condução coercitiva para interrogatório, previsto no art. 260 do CPP, aduzindo que não foi a previsão recepcionada pela Constituição Federal por violação, dentre outros, aos princípios da presunção de inocência, do direito ao silêncio e da não autoincriminação. A condução coercitiva como medida cautelar autônoma é defendida como forma de reduzir a coerção do Estado sobre o indivíduo. Assim, para não se decretar a prisão temporária, substitui a prisão cautelar por medida cautelar menos gravosa, a partir do poder geral de cautela do Poder Judiciário, restringindo de modo mais suave a liberdade pessoal do investigado, conduzindo o suspeito coercitivamente somente enquanto as providências urgentes de produção de prova estiverem em curso (ARAS, 2013).

Para a doutrina minoritária, o poder geral de cautela, tradicional do processo civil, poderia também ser adotado na esfera do processo penal. O Ministro Rogério Schietti Cruz, em sua obra sobre prisão cautelar (2017, p. 230), afirma que não se pode subtrair do julgador a possibilidade de fazer uso de seu poder geral de cautela, de forma excepcional e motivada, tendo como objetivo evitar a prisão preventiva. Poderá o magistrado, então, impor ao investigado ou acusado medida que, embora não conste literalmente do rol positivado no art. 319 do CPP, seja prevista em outras normas do ordenamento, ou possa ser considerada, por meio de interpretação extensiva, abrangida na dicção de algum dos incisos que compõem o elenco das cautelares pessoais diversas da prisão. Tal corrente argumenta que não é razoável presumir que o legislador esgotou todas as hipóteses possíveis, antevendo as situações práticas (GUILHERME TAVARES, 2016, p. 231).

Vale recordar que legislações extravagantes também preveem medidas cautelares pessoais, como:

a) a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção (art. 294, *caput*, da Lei nº 9.503/97);

b) as medidas protetivas de urgência à vítima de violência doméstica e familiar contra mulher, previstas no art. 22 da Lei Maria da Penha, atentando-se que o rol foi ampliado recentemente pela Lei nº 13.984/2020 (incluindo os incisos VI e VII). O juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência: I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. VI – comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; e VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio.

Bem a propósito do tema, a própria Lei nº 11.340/06, prevê a possibilidade de serem aplicadas outras providências de cunho similar, ao estabelecer no final do *caput* do art. 22 a expressão “entre outras”, bem como prever no § 1º do mesmo artigo: “as medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público”.

Portanto, para a corrente minoritária, mostra-se possível e justificável que se faça uso da analogia e se aplique medida não prevista no CPP e na legislação extravagante, desde que presente a mesma *ratio essendi* da norma positivada, ou que se utilize de interpretação extensiva



(autorizada pelo art. 3º do CPP) de modo a abranger situações que a mera literalidade do preceito não autoriza (CRUZ, 2017, p. 229).

### 8.3. APLICAÇÃO DE FORMA ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE

Frisa-se que o art. 321 do CPP dispõe que “ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código”. Desse modo, não sendo o caso de decretação da prisão preventiva, a liberdade provisória poderá vir cumulada com o cumprimento de condições diversas. Tais medidas podem ser fixadas de forma isolada ou cumulada (art. 282, § 1º, do CPP). Ex.: Pode ser concedida liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas de comparecimento periódico em juízo e proibição de se ausentar da Comarca (incisos I e IV do art. 319 do CPP).

### 8.4. ANÁLISE DOS ARTS. 319 E 320 DO CPP

- Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades

O objetivo é o de verificar se o acusado continua à disposição do juízo para a prática de qualquer ato processual, devendo informar sobre suas atividades, como escolares, laborativas, sociais e outras, permitindo que o magistrado acompanhe os passos da vida cotidiana do réu e saiba o seu paradeiro sempre que precise. O comparecimento, na forma como previsto, deve se dar no juízo. Ex.: João deverá comparecer todo mês na 4ª vara criminal de Brasília para informar e justificar suas atividades.

- Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações

O objetivo é evitar que a frequência do réu a determinados lugares possa criar condições favoráveis para a repetição do crime objeto do processo. Note que o inciso diz expressamente que a fixação desta medida apenas se justifica quando estiver relacionada ao fato. Ex.: João novamente praticou furto em supermercado. Poderá ser concedida a liberdade provisória com a proibição que ele acesse ou frequente o supermercado vítima.

A maior dificuldade dessa medida cautelar é a fiscalização de seu cumprimento. Por isso, muitas vezes vem cumulada com a monitoração eletrônica (inciso IX).

- Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante

É medida similar à anterior, mas com um objetivo ainda mais específico, que é o de proteger determinada pessoa que está em risco. Desse modo, pode ser fixada para se evitar o contato do réu com determinadas pessoas. Ex.: João praticou diversos atos (ameaça, lesão, dano e xingamentos) contra dois parentes homens e, para garantir a integridade física e psíquica dessas vítimas, em sendo colocado o João em liberdade ou mantido em liberdade, a condição poderá ser fixada, já que “relacionada ao fato”.

Também haverá dificuldade na fiscalização da medida. Por isso, muitas vezes vem cumulada com a monitoração eletrônica (inciso IX).

- Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução

- Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos

O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga se justifica como alternativa à prisão preventiva para a salvaguarda do direito ameaçado pela completa liberdade do acusado. Ex.: João novamente praticou delito no período noturno, em que pese o fato em si não seja grave concretamente (furto). É uma modalidade menos gravosa de cautela, de forma que não priva totalmente o réu de sua liberdade, permitindo que saia durante o dia, mas tenta-se inibir ou cessar a prática de crimes.

Não se confunde com a prisão domiciliar de que tratam os arts. 317 a 318-B do CPP, que pode ser compreendida como uma espécie de prisão preventiva atenuada, devendo o acusado permanecer dentro de sua residência, em regra, em período integral. Há a restrição da liberdade do réu, mas ele cumpre em residência.

Portanto, enquanto a prisão domiciliar substitui a prisão preventiva, ou seja, é forma de cumprimento da prisão preventiva (em domicílio), o recolhimento domiciliar noturno ou em dias de folga é medida cautelar menos gravosa e diversa da prisão, mantendo-se o agente em liberdade, mas com restrições de horários.

Também haverá dificuldade na fiscalização da medida. Por isso, muitas vezes vem cumulada com a monitoração eletrônica (inciso IX).

- Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais

É providência cautelar específica, a ser utilizada principalmente para crimes funcionais, econômicos ou contra a ordem tributária, nas hipóteses em que se revela medida idônea para evitar a prática de novas infrações penais. A jurisprudência analisa caso a caso o cabimento da medida (STJ, RHC, 52276/SP, HC 322592, RMS 45696/CE; HC 266642);

- Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração

- Fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial

A fiança, como medida indicada no inciso VIII do art. 319 do CPP será analisada em tópico específico, podendo ser arbitrada cumulativamente ou não a outras medidas cautelares diversas, de acordo com o art. 319, § 4º, CPP. No entanto, em que pese a previsão legal neste sentido, parte da doutrina entende que tal medida não deve ser fixada com a internação provisória (prevista no inciso VII) ou com a monitoração eletrônica (prevista no inciso IX), sob pena de inviabilizar a imposição imediata de tais condições.

- Monitoração eletrônica

É medida principalmente voltada a dar eficácia a outras do rol do art. 319 do CPP, notadamente aquelas que impõem ao autor do fato permanecer em determinado local, não se aproximar de pessoas ou lugares, ou se recolher ao domicílio em determinados períodos.

A doutrina aponta três finalidades principais associadas ao uso do monitoramento eletrônico: detenção, restrição e vigilância (CRUZ, 2017, p. 211 e BLACK e SMITH, 2003).

- Detenção: assegurar que o suposto autor do fato permaneça em determinado lugar;
- Restrição: assegurar que o suposto autor do fato não acesse ou frequente determinados locais proibidos ou que se aproxime de determinadas pessoas;

- Vigilância: assegurar o permanente acompanhamento da pessoa que utiliza o equipamento.

As principais vantagens da utilização do monitoramento eletrônico são:

- redução da população carcerária;
- evitar os malefícios pessoais da prisão;
- o monitorado poder manter algumas rotinas e atividades, como seu trabalho, estudo, grupo familiar e social;
- o gasto público é bem inferior ao de uma prisão.

O uso do equipamento, no entanto, não é obrigatório, devendo o autor aceitar os seus termos e as condições de uso, embora, evidentemente, como é oferecido como uma alternativa à prisão preventiva, acaba levando o acusado a sujeitar-se de qualquer forma à medida (CRUZ, 2017, p. 212).

- Proibição de ausentar-se do país

De acordo com o art. 320 do CPP, a proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no prazo de vinte e quatro horas.

### 8.5. ANÁLISE DO ART. 282 DO CPP

| ANTES DA LEI Nº 13.964/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEPOIS DA LEI Nº 13.964/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:</p> <p>§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.</p> <p>§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo.</p> <p>§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único). (PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUTIVA, SUPLETIVA, SUBSIDIÁRIA).</p> | <p>Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:</p> <p>§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.</p> <p>§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem tal medida excepcional.</p> <p>§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. (PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUTIVA, SUPLETIVA, SUBSIDIÁRIA).</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>§ 5º O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.</p> <p>§ 6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).</p> | <p>§ 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.</p> <p>§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

O art. 282 foi sensivelmente modificado pela Lei Anticrime, trazendo alterações positivas:

a) No mesmo sentido que foi estudado para a prisão preventiva (medida mais gravosa), o juiz não poderá fixar medidas cautelares diversas sem ser provocado, não podendo mais fixá-las de ofício;

b) A legislação prevê, como regra, a necessidade de contraditório prévio antes da imposição da medida, conforme art. 282, § 3º: ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem tal medida excepcional.

c) O juiz poderá, de ofício, revogar medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista. Poderá, portanto, adotar comportamento mais favorável ao réu, de ofício.

d) O juiz poderá, de ofício, voltar a decretar medida cautelar, se sobrevierem razões que a justifiquem. Sobre este ponto, remetemos às mesmas considerações que fizemos no art. 316, *caput*, do CPP. O mesmo raciocínio exposto para o caso da prisão preventiva, também deve ser levado em consideração aqui, já que todas fazem parte do gênero medidas cautelares pessoais.

d) No caso de descumprimento de qualquer das medidas diversas impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código (art. 282, § 4º, CPP). Dessa forma, cabe prisão preventiva (subsidiária/supletiva) do descumprimento das medidas aplicadas, como uma espécie de sanção processual ao comportamento de quem demonstrou não merecer a medida menos gravosa. Ex.: João foi preso em flagrante por roubo. Na audiência de custódia, na forma do art. 310, do CPP, o magistrado, após ouvir as partes, homologou o auto de prisão em flagrante (por considerá-lo legal) e concedeu a liberdade provisória a João com as seguintes medidas cautelares diversas que naquela data se mostravam adequadas ao caso: i) proibição de se ausentar da Comarca; ii) recolhimento domiciliar noturno; iii) monitoração eletrônica. Após um mês, no curso do processo, as partes receberam a notícia de que João tinha saído da Comarca e rompido com a tornozeleira eletrônica. Neste caso, entendendo o legitimado, por exemplo, Ministério Público, que não há possibilidade de cumulação de outra medida, nem substituição de uma já aplicada por outra, poderá requerer a decretação da prisão preventiva de João como forma de sanção. O juiz, diante do requerimento,

poderá decretar a prisão, não podendo mais decretá-la de ofício (atenção à alteração promovida pela Lei Anticrime).

#### 8.6. EXISTE PRAZO DE DURAÇÃO DAS CAUTELARES?

Existem situações claras em que a medida cautelar não poderá ser mantida (CRUZ, 2017, p. 220):

- a) decisão de arquivamento de inquérito policial (art. 28 do CPP);
- b) rejeição da denúncia ou queixa-crime (art. 395 do CPP);
- c) impronúncia ou despronúncia ou absolvição sumária na primeira fase do Tribunal do Júri (arts. 414 e 415 do CPP);
- d) decisão de anulação do processo;
- e) declaração de extinção de punibilidade (art. 107 do CP);
- f) sentença absolutória (art. 386 do CPP).

Em todas elas, é possível observar a ausência de pressuposto imprescindível para a cautelar, qual seja, o *fumus comissi delicti*/fumaça do cometimento do delito.

Também não se mostra possível decretar ou manter uma medida cautelar pessoal se a sentença, mesmo que condenatória, impor somente pena de multa ao réu, ou o condenado já tenha permanecido preso preventivamente por mais tempo do que o quanto de pena fixado na sentença (realizando-se a detração penal – art. 42 do CP e art. 387, § 2º do CPP). Em ambas as hipóteses não existe requisito necessário para aplicação de medidas cautelares em geral, previsto no art. 283, § 1º, do CPP: “as medidas cautelares previstas neste Título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade”.

Quanto ao regramento da prisão preventiva, a Lei Anticrime trouxe nova previsão no art. 316 do CPP, o qual dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada noventa dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

A instituição de prazo para revisão da prisão preventiva é muito importante, especialmente se considerarmos a realidade brasileira, em que há um número elevado de presos provisórios e que essas prisões se prolongam por tempo demasiado longo. Trata-se de uma ferramenta que, se bem usada, poderá contribuir para a redução desse número e da superlotação carcerária.

Embora a lei não tenha fixado o prazo máximo de duração da prisão preventiva, tal como ocorre com a prisão temporária, impõe o dever de reanálise de seus fundamentos a cada 90 dias (CPP, art. 316, parágrafo único). A rigor, portanto, a prisão preventiva vale apenas por esse prazo. Com efeito, se, decorrido o prazo legal, não houver pronunciamento judicial algum, a prisão tornar-se-á ilegal, devendo ser relaxada. Esse reexame é obrigatório e independe de provocação das partes.

No caso das cautelares diversas da prisão, nada é previsto na legislação, devendo-se utilizar critérios de duração razoável da medida.

#### 8.7. DETRAÇÃO PENAL

De acordo com a interpretação literal do dispositivo do CP, as medidas cautelares não podem ensejar a detração penal, pois o art. 42 do CP é claro ao dispor que só é cabível no caso da prisão provisória. O art. 387, § 2º, do CPP, caminha no mesmo sentido: “o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Portanto, a legislação não menciona em momento algum a detração penal de medidas cautelares. Várias são as decisões do STJ nesse sentido. A título de exemplo:



Não é possível a detração, na pena privativa de liberdade, do tempo em que o Réu foi submetido a medida cautelar diversa da prisão, em razão da ausência de previsão legal. Precedentes. (STJ, AgRg no AREsp 1406675/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 5/6/2019.)

No entanto, impende esclarecer que a corrente contrária, pela possibilidade da detração em medidas do rol do art. 319 do CPP, já conquistou espaço no debate doutrinário, sendo também objeto de decisões no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e *non bis in idem* concedeu a detração em caso de recolhimento domiciliar noturno.

EMENTA *HABEAS CORPUS*. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Inexiste previsão legal para o cômputo do período de cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP) para fins de detração da pena, cujas hipóteses estão elencadas no artigo 42, do CP. Entretanto, o período de recolhimento noturno, por comprometer o *status libertatis* do acusado, deve ser reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do *non bis in idem*. 2. *Habeas corpus* não conhecido, mas concedido de ofício para restabelecer a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que deferiu o pedido apresentado pela defesa do paciente para que o período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno fosse computado para fins de detração da pena (STJ, HC 380.369 – DF).

Portanto, abertos os debates e análises dos casos concretos, verifica-se que existe campo de possibilidade de que todas as medidas restritivas do *status libertatis* impostas aos autores de crimes, em qualquer fase da persecução criminal, deverão ser objeto de detração penal no momento da sentença condenatória ou execução. Cabe, em princípio, ao legislador estabelecer as regras sobre o tema, mas a omissão legislativa, não impede o exercício do direito, com a aplicação dos princípios que balizam e limitam o poder punitivo estatal, tais como, o princípio da proporcionalidade e de *non bis in idem*.

## 9. FIANÇA

A fiança classicamente foi estudada como um instrumento para a obtenção da liberdade provisória, nas hipóteses sem que o investigado se encontrasse preso em flagrante. Com isso, sempre foi concebida como uma contracautela à prisão em flagrante. A liberdade provisória mediante fiança é sempre condicionada, exigindo a lei, além do implemento financeiro, uma série de obrigações ao afiançado, quais sejam: comparecimento perante a autoridade toda vez que for intimado para os atos do inquérito e da instrução; impossibilidade de mudar de residência sem prévia permissão da autoridade competente; proibição de ausentar-se por mais de oito dias de sua residência sem comunicar àquela autoridade o lugar em que poderá ser encontrado; vedação à prática de novas infrações (arts. 327 e 328, CPP).

Com a reforma introduzida no CPP pela Lei nº 12.403 no ano de 2011, a fiança foi incluída no rol do art. 319 do CPP, passando a ser uma das medidas cautelares diversas da prisão e que pode ser aplicada de forma isolada ou cumulativa com as demais condições.

A fiança pode ser aplicada a qualquer crime, salvo nos casos das vedações Constitucionais e legais, como é o caso do art. 5º, incisos XLII, XLIII, XLIV, da CF/88, e arts. 323 e 324 do CPP. Portanto, não será concedida nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos (devendo-se atentar que a Lei Anticrime ampliou o rol dos crimes hediondos), bem como nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Não será, igualmente, concedida fiança aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança



anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os arts. 327 e 328 deste Código; em caso de prisão civil ou militar; quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312).

A autoridade policial pode arbitrar fiança para o preso em flagrante quando a infração penal não tiver pena máxima superior a quatro anos (art. 322 do CPP), com a ressalva do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, que, apesar de possuir pena máxima baixa, o § 2º proíbe que o delegado fixe fiança, devendo necessariamente o caso ser levado às considerações da autoridade judicial (foi a autoridade judicial que decidiu anteriormente deferindo as medidas protetivas de urgência que foram descumpridas). Nos demais casos, em que a pena máxima em abstrato do delito for superior a quatro anos, apenas a autoridade judicial poderá arbitrar fiança.

Para determinar o valor a ser fixado, a autoridade policial ou judicial levará em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento (art. 326 do CPP), devendo ser fixado de acordo com a pena máxima cominada ao delito, nos seguintes patamares (art. 325 do CPP):

a) de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos;

b) de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.

Nos termos da lei, o juiz passa a dispor de determinada flexibilidade para poder alterar os valores fixados previamente (art. 325, § 1º, do CPP), podendo dispensar a fiança, reduzi-la até o máximo de 2/3 ou aumentá-la em até 1.000 vezes. Ex.: João foi preso em flagrante pela prática de delito de receptação, cuja pena em abstrato é de 1 a 4 anos de reclusão. Lavrado o auto de prisão em flagrante, a autoridade policial fixou R\$3.000,00 de fiança. Não foi efetuado o pagamento do valor da fiança e João foi encaminhado para a audiência de custódia. Na audiência, o juiz verificou que João não tem condições de efetuar o pagamento de qualquer valor, já que possui três filhos e é o único provedor da família. Nesse sentido, pode ser concedida a liberdade provisória com a dispensa/isenção do valor da fiança (ou seja, sem fiança).

## 9.1. QUEBRA DA FIANÇA

A quebra da fiança ocorre pelo descumprimento injustificado das obrigações do afiançado durante o curso do processo. Será considerada quebrada, nos termos do art. 341 do CPP, quando o acusado: regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer, sem motivo justo; deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo; descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança; resistir injustificadamente a ordem judicial; e praticar nova infração penal dolosa.

O quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva.

A decisão pela quebra da fiança comporta recurso em sentido estrito (art. 581, VII, CPP), que terá efeito suspensivo apenas quanto ao perdimento da metade do valor prestado em fiança (art. 584, § 3º, CPP). Esse recurso pode ser interposto até mesmo pelo terceiro que prestou fiança em favor de outrem. Julgado procedente, a fiança volta a subsistir, colocando-se imediatamente o agente em liberdade, nas mesmas condições anteriores (art. 342, CPP).

## 9.2. PERDA DA FIANÇA

Transitada em julgado a sentença condenatória, não pode o condenado frustrar a efetivação da punição, esquivando-se de se apresentar para o cumprimento da pena, ou evadindo-se para não ser encontrado pelo oficial ou outra autoridade encarregada de levá-lo ao cárcere. Se o fizer, será julgada perdida, na totalidade, o valor da fiança (art. 344, CPP).

A decisão que decreta a perda comporta recurso em sentido estrito (art. 581, VII, CPP).

### 9.3. CASSAÇÃO DA FIANÇA

A fiança será cassada quando for incabível, o crime for inafiançável ou em caso de inovação na classificação do delito. (arts. 338 e 339). A cassação da fiança funciona como a “retificação de um erro”, ocasião em que o valor será restituído, expedindo-se ordem de prisão imediatamente. A cassação só pode ser decretada pelo juiz (nunca pelo Delegado), sendo também cabível em 2º grau.

### 9.4. REFORÇO DA FIANÇA

O reforço é a necessidade de complementar a fiança (quando for tomada, por equívoco, em valor insuficiente; quando ocorrer a depreciação material ou perecimento de bens hipotecados ou caucionados, ou depreciação dos metais ou pedras preciosas; quando for inovada a classificação do delito, que tenha repercussão, em razão da alteração da pena, no quantitativo da fiança), nos termos do art. 340 do CPP. Se o reforço não for realizado, a fiança vai ser julgada sem efeito, com o consequente recolhimento ao cárcere, expedindo-se mandado de prisão. O bem que tinha sido dado em garantia será integralmente devolvido.

A decisão que julga sem efeito a fiança comporta recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo (art. 581, VII, CPP). Em face de situação de pobreza, o agente poderá ser dispensado do reforço, permanecendo em liberdade, com pleno efeito da fiança prestada.

### 9.5. DISPENSA DA FIANÇA

O art. 350 do CPP dispõe que o juiz, verificando ser impossível ao réu prestar a fiança por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações dos artigos 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício.

A dispensa não é uma discricionariedade do magistrado, mas visto como um direito do beneficiário, que não pode permanecer preso apenas em razão de não ter condições de efetuar o pagamento do valor.

## 10. PRISÃO TEMPORÁRIA

A prisão temporária foi introduzida no processo penal brasileiro pela Lei nº 7.960/89 e no início encontrou muita resistência doutrinária, ora por entender que na verdade se tratava da chamada “prisão para averiguação”, presente sobretudo na época ditatorial, ora por compreender a prisão temporária como inconstitucional, uma vez que foi introduzida no sistema por meio de uma medida provisória. Todavia, em nenhum momento essas objeções encontraram guarida na jurisprudência.

A temporária é a prisão de natureza cautelar, com prazo preestabelecido de duração, cabível exclusivamente na fase do inquérito policial, objetivando o encarceramento em razão das infrações seletamente indicadas na legislação. Serve para assegurar uma eficaz investigação policial, quando se tratar de uma infração penal de natureza grave (NUCCI, 2018, p. 594). Ela somente poderá ser decretada na fase de investigação criminal e não na fase de processo, ponto relevante de diferenciação com a prisão preventiva.

Portanto, a prisão temporária está adstrita à cláusula de reserva jurisdicional, e, em face do disposto no art. 2º da Lei nº 7.960/1989, somente pode ser decretada pela autoridade judiciária, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Jamais poderá ser decretada de ofício pelo juiz, pressupondo provocação.

As hipóteses de cabimento da prisão temporária vêm indicadas no artigo 1º da Lei 7.960/1989, sendo admitida nas seguintes hipóteses:

(inc. I) quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

(inc. II) quando o Indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos ao esclarecimento de sua identidade;

(inc. III) quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes.

A grande discussão sobre o cabimento da temporária diz respeito ao preenchimento dos elementos que justifiquem a decretação da medida. São diversas as correntes sobre o tema, prevalecendo a que admite a temporária com base no inciso III obrigatoriamente, pois ele materializaria a fumaça do bom direito para a decretação da medida (*fumus commissi delicti*), e, além dele, uma das hipóteses dos incisos I ou II: ou é imprescindível para as investigações, ou o indiciado não possui residência fixa, ou não fornece elementos para a sua identificação.

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Conjugação dos incisos I e III do art. 1º da Lei nº 7.960/89  |
| Conjugação dos incisos II e III do art. 1º da Lei nº 7.960/89 |

Apenas é cabível quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes, previstos em rol taxativo no art. 1º, inciso III (princípio da taxatividade): a) homicídio doloso (art. 121, *caput*, e seu § 2º); b) sequestro ou cárcere privado (art. 148, *caput*, e seus §§ 1º e 2º); c) roubo (art. 157, *caput*, e seus §§ 1º, 2º e 3º); d) extorsão (art. 158, *caput*, e seus §§ 1º e 2º); e) extorsão mediante sequestro (art. 159, *caput*, e seus §§ 1º, 2º e 3º); f) estupro (art. 213, *caput*, e sua combinação com o art. 223, *caput*, e parágrafo único); g) atentado violento ao pudor (art. 214, *caput*, e sua combinação com o art. 223, *caput*, e parágrafo único); h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 *caput*, e parágrafo único); i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1º); j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, *caput*, combinado com art. 285); l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; m) genocídio (arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956), em qualquer de suas formas típicas; n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976); o) crimes contra o sistema financeiro (Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986); p) crimes previstos na Lei de Terrorismo.

A lei fixa o prazo de 5 dias para a duração máxima da prisão temporária, podendo ser prorrogado por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade (art. 2º, *caput*), o que diferencia da prisão preventiva, pois nesta não há previsão de prazo de duração (em que pese a Lei Anticrime tenha trazido prazo de revisão a cada 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, CPP). Por sua vez, o art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90, nos casos de crimes hediondos e assemelhados (tráfico, terrorismo e tortura) prevê que a prisão temporária terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período e em caso de extrema e comprovada necessidade.

Em que pese a lei indicar que a prisão temporária tem o prazo de cinco dias (ou de 30 dias), será inconsistente a lei impedir o juiz de fixar prazo menor do que os mencionados, em face da excepcionalidade de qualquer medida limitadora da liberdade do indivíduo, sobretudo quando se trata de medida extrema como a prisão (CRUZ, 2017, p. 241). Tais prazos, portanto, devem ser compreendidos como limites máximos, o que implicará na avaliação, de cada caso, do tempo necessário de prisão temporária.

Além disso, como o juiz não pode decretá-la de ofício, também não poderá prorrogá-la de ofício. A prorrogação pressupõe requerimento fundamentado, cabendo ao magistrado deliberar quanto a sua admissibilidade. Incide, portanto, o princípio da inadmissibilidade de renovação automática da prisão temporária. Dependerá, sempre, de nova decisão judicial. Caso a representação seja do delegado de polícia, o juiz deverá ouvir o Ministério Público antes de decidir (art. 2º, § 1º, da Lei nº 7.960/89).

O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do recebimento da representação da autoridade policial ou do requerimento do MP (art. 2º, § 2º, da Lei nº 7.960/89).

Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva (art. 2º, § 7º, da Lei nº 7.960/89).

As decisões neste tópico mencionadas, seja de decretação da prisão temporária, seja sua prorrogação serão analisadas pelo juiz das garantias, nos termos do art. 3º-B, do CPP, que prevê em seu inciso V, que incumbirá a ele decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar.

Após a decretação da prisão, o mandado expedido deverá conter necessariamente o período de duração da prisão temporária, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado (art. 2º, parágrafo 4º-A, da Lei nº 7.960/89), devendo incluir no cômputo do prazo da prisão temporária (seja ela de cinco, seja ela de trinta dias), o dia do cumprimento do mandado de prisão (art. 10, CP – prazo de natureza penal).

Ressalta-se que os presos temporários deverão permanecer, obrigatoriamente, separados dos demais detentos (art. 3º, da Lei nº 7.960/89).

Por fim, uma vez oferecida a denúncia não mais subsiste o decreto de prisão temporária, que visa resguardar, tão somente, a integridade das investigações (STJ – HC 78437/SP).

| PRISÃO TEMPORÁRIA                                                                                                                                                                | PRISÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prevista em lei específica – Lei nº 7.960/89.                                                                                                                                    | Prevista no CPP.                                                                                                                                                           |
| Somente pode ser decretada na fase de investigação criminal.                                                                                                                     | Pode ser decretada em toda a persecução penal, seja na fase de investigação criminal ou na fase processual.                                                                |
| Não é possível a decretação de ofício pelo juiz.                                                                                                                                 | Não é possível a decretação de ofício pelo juiz.                                                                                                                           |
| Legitimados: requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade judicial.                                                                                         | Legitimados: requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação; representação da autoridade policial.                                         |
| Possui prazo de duração:<br>em regra, cinco dias, podendo ser prorrogado por mais cinco dias.<br>Crime hediondo ou equiparado: 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. | Não há previsão de prazo máximo para a prisão preventiva. No entanto, a Lei Anticrime trouxe ao CPP a necessidade de que a prisão preventiva seja revisada a cada 90 dias. |
| Cabimento: art. 1º, da Lei nº 7.960/89, devendo ser conjugado incisos I e III ou II e III.                                                                                       | Requisitos e cabimento: arts. 312 e 313 do CPP.                                                                                                                            |

## QUESTÕES

**1- (2018/FCC/Câmara Legislativa/inspetor de polícia legislativa)** Sobre a prisão, o Código de Processo Penal dispõe:

- As autoridades policiais e seus agentes, bem como qualquer do povo, deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
- Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão em flagrante, o preso deverá ser posto em liberdade.
- A custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver indícios da existência do crime e de sua autoria.
- Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.

e) Somente no curso do processo penal caberá a decretação de prisão preventiva pelo juiz, haja vista que, durante o inquérito policial, somente é possível a prisão em flagrante delito do investigado.

**2- (2020/CESPE/MPE-CE/Promotor de Justiça de entrância inicial)** De acordo com o Código de Processo Penal, é cabível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar a

- a) pessoa de setenta e cinco anos de idade condenada pela prática do crime de estelionato.
- b) gestante condenada pelo crime de furto qualificado, desde que já tenha ultrapassado o sétimo mês de gravidez.
- c) mulher que, condenada pelo crime de roubo, tenha filho de um ano de idade.
- d) homem que, condenado pelo crime de corrupção passiva, seja o único responsável pelos cuidados do seu filho de dez anos de idade.
- e) mulher que tenha praticado o crime de abandono de incapaz contra seu filho de cinco anos de idade.

**3- (2020/VUNESP/PM-SP/Cabo da Polícia Militar)** Em relação à prisão em flagrante, assinale a alternativa correta.

- a) Considera-se em flagrante delito quem é detido após a prática criminosa, ainda que não esteja na posse de objetos que o relacionem à prática delitiva, mas é foragido da Justiça.
- b) Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, cabendo a análise do cabimento da fiança sempre ao juiz de direito.
- c) Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste.
- d) A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante; mas, nesse caso, com o condutor, deverá assiná-lo pelo menos uma pessoa que haja testemunhado a apresentação do preso à autoridade.

**4- (2020/CESPE/TJ-PA/Oficial de Justiça)** De acordo com o entendimento do STF, o uso de algemas

- a) é uma excepcionalidade e deve ser justificado previamente, de forma oral ou por escrito.
- b) é restrito à prisão penal, sendo inadmissível na prisão cautelar, devido ao princípio da inocência.
- c) ensejará responsabilidade disciplinar, civil e penal da autoridade que o determinar, caso seja injustificado.
- d) ensejará a anulabilidade da prisão e dos atos subsequentes, caso seja injustificado.
- e) é lícito somente nas hipóteses de fundado receio de fuga e de perigo à integridade física de terceiros.

**5- (2019/FCC/DPE-AM/Analista Jurídico)** Conforme entendimento dos Tribunais Superiores sobre a prisão domiciliar prevista no Código de Processo Penal, é correto afirmar que:

- a) É medida cautelar alternativa à prisão incompatível com a detração penal.
- b) É medida destinada apenas às mulheres presas, tendo em vista o alto número do encarceramento feminino no Brasil.
- c) É vedada quando a acusada for reincidente em crime doloso, bem como quando o crime for cometido pela mãe contra seu próprio filho.
- d) Caso haja dúvida acerca da condição de guardião dos filhos, pode o juiz solicitar laudo social, desde que já efetive a medida em favor da mulher presa.
- e) Conforme expresso no Código de Processo Penal, pode ser decretada quando a mulher presa tenha cometido o crime de roubo, desde que primária e de bons antecedentes.

**6- (2020/MP-GO/MP-GO/Promotor de Justiça)** Sobre a prisão cautelar, outras medidas cautelares e a liberdade provisória previstas no Código de Processo Penal, analise as afirmativas abaixo:

I - A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

II - Dentre outras situações previstas em lei, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 70 (setenta) anos; extremamente debilitado por motivo de doença grave; ou quando o acusado for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência.

III - Embora o Código de Processo Penal seja silente sobre o assunto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou que o homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, poderá ser beneficiado com a prisão domiciliar, por questões humanitárias e em analogia à situação da mulher.



IV - Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer, sem motivo justo; deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo; descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança; resistir injustificadamente a ordem judicial; praticar nova infração penal dolosa ou culposa.

Pode-se afirmar que:

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas I está correta.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) Apenas III e IV estão corretas.

**7- (2019/FUNDEP/MP-MG/Promotor de Justiça substituto)** Acerca do instituto da liberdade provisória e das disposições que a disciplinam, é incorreta a afirmação seguinte:

- a) O quebramento injustificado da fiança importa na perda de metade de seu valor, com a consequente imposição de outras medidas cautelares, aí incluída a prisão preventiva, se presentes seus requisitos.
- b) A perda da fiança decorrente da não apresentação do condenado para o cumprimento da pena imposta independe de que esta seja privativa de liberdade ou não.
- c) A cassação da fiança ocorrerá na hipótese em que, instado a reforçá-la, o acusado não o fizer.
- d) Não se cogita de liberdade provisória mediante fiança nas hipóteses em que estejam presentes os requisitos de que depende a decretação da prisão preventiva e da temporária.

**8- (2019/VUNESP/TJ-RO/Juiz de Direito Substituto – adaptada)** Julgue os itens:

I - A prisão temporária, cabível na fase de inquérito, quando decretada em investigação por crime de lavagem de dinheiro, terá prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema necessidade.

II - A prisão temporária pode ser decretada de ofício pelo Judiciário, mas, no caso de representação pela Autoridade Policial, o Juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público.

**9- (2019/VUNESP/Procurador da Prefeitura de São José dos Campos)** Nos exatos termos do art. 302 do CPP, considera-se em flagrante delito quem

- a) cometeu a infração penal nas últimas 24h.
- b) é imediatamente reconhecido como autor do crime pela vítima.
- c) é avistado em conduta que gera fundada suspeita, logo após o crime.
- d) é encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.
- e) é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração.

**10- (2019/FGV/MPE-RJ/Analista do Ministério Público)** Bernardo foi preso em flagrante e indiciado pela prática do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos). O auto de prisão em flagrante foi encaminhado para os órgãos competentes, sendo determinada a realização, de imediato, da audiência de custódia. Foi acostada a Folha de Antecedentes Criminais, indicando que Bernardo, de fato, havia sido intimado da aplicação de medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, mas que não possuía condenação definitiva em seu desfavor.

Considerando as informações narradas, a prisão em flagrante a ser analisada em audiência de custódia é:

- a) legal, cabendo conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia das medidas protetivas de urgência aplicadas, mesmo diante da pena em abstrato inferior a 4 (quatro) anos e da primariedade do custodiado;
- b) legal, mas considerando a pena em abstrato prevista e a primariedade técnica do indiciado, não será possível a conversão da prisão em flagrante em preventiva por ausência dos pressupostos legais;
- c) legal, mas diante da pena em abstrato prevista, poderia a autoridade policial ter arbitrado fiança;
- d) ilegal, porque a pena máxima é inferior a 4 (quatro) anos e Bernardo é primário, devendo a prisão ser relaxada;
- e) ilegal, porque a pena máxima é inferior a 4 (quatro) anos e Bernardo é primário, devendo a prisão ser revogada.

**11- (2019/FEPESE/SJC-SC/Agente penitenciário)** De acordo com o Código de Processo Penal, a nota de culpa deverá conter:

- 1. a assinatura do preso.



2. o nome da autoridade policial.
3. os motivos da prisão.
4. o nome do condutor.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- b) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

**12- (2019/FGV/MPE-RJ/Oficial do Ministério Público)** Buscando concretizar a ideia de que a prisão preventiva somente deve ser decretada em situações excepcionais, o legislador previu uma série de medidas cautelares alternativas à prisão, que devem ser analisadas no momento de se apreciar a necessidade ou não da imposição da medida cautelar extrema.

Sobre o tema, de acordo com as previsões do Código de Processo Penal, é correto afirmar que:

- a) a suspensão do exercício da função pública poderá ser aplicada como cautelar alternativa diante de justo receio de sua utilização na prática de crimes, mas não da atividade de natureza econômica, sob pena de violação da livre concorrência;
- b) a internação provisória poderá ser aplicada se constatado o risco de reiteração e a inimizabilidade do agente, mas somente nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa;
- c) a monitoração eletrônica poderá ser aplicada como condição para concessão de prisão albergue domiciliar na execução penal, mas não como medida cautelar alternativa;
- d) o descumprimento das medidas cautelares alternativas e medidas protetivas de urgência não é fundamento para justificar a necessidade da prisão preventiva;
- e) a proibição de se ausentar da comarca sem informar ao juízo poderá ser aplicada pelo magistrado, mas não poderá haver retenção do passaporte do denunciado.

**13- (2019/FGV/MPE-RJ/Oficial do Ministério Público)** Lucas, oficial do Ministério Público, enquanto cumpria sua função em via pública, por volta de 15h, depara-se com Antônio conduzindo uma motocicleta com simulacro de arma de fogo na cintura e se surpreende com aquela situação, tendo em vista que identificou, pela placa, que aquela moto era de propriedade de seu colega de trabalho. Diante disso, Lucas entra em contato com seu colega, que confirma que fora vítima de um crime de roubo que teria sido praticado 30 minutos antes, descrevendo as características do autor do fato, que coincidiam com as de Antônio.

Considerando as informações expostas, em sendo confirmada a autoria, é correto afirmar que Lucas:

- a) não poderá realizar a prisão captura de Antônio, tendo em vista que, apesar da situação de flagrante, o ato somente pode ser realizado por agentes de segurança pública;
- b) não poderá realizar a prisão captura de Antônio, uma vez que inexistente situação de flagrante prevista em lei, apesar da identificação da autoria;
- c) poderá realizar a prisão captura de Antônio, pois constatada a situação de flagrante próprio prevista em lei;
- d) poderá realizar a prisão captura de Antônio, uma vez constatada a situação de flagrante presumido;
- e) poderá realizar a prisão captura de Antônio, já que há situação de flagrante esperado.

**14- (2019/CESPE/TJ-AM/Analista Judiciário)** Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Durante a investigação, apurou-se a participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de ofício a sua prisão temporária. A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação, julgue o item seguinte.

I - Recebida a denúncia, não será mais cabível prisão temporária para Lúcio e Carlos.

II - É ilegal a prisão temporária de Carlos, porque, apesar de o crime de latrocínio admiti-la, não poderia ter sido decretada de ofício pelo juiz.

**15- (2019/FCC/TJ-AM/oficial de justiça)** São medidas cautelares diversas da prisão,

- a) o reconhecimento de pessoas e a monitoração eletrônica.
- b) o comparecimento periódico em juízo e o recurso em sentido estrito.
- c) a proibição de ausentar-se da comarca e o regime aberto.
- d) a proibição de manter contato com pessoa determinada e o interrogatório.
- e) a fiança e a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares.

**16- (2019/MPE-SC/MPE-SC/Promotor de Justiça)** Julgue os itens a seguir:

I- Será exigido o reforço da fiança quando for inovada a classificação do delito, nos termos do Código de Processo Penal.

II - Nos termos do Código de Processo Penal, a proibição de ausentar-se do País será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

**17- (2019/CESPE/DPE-DF/Defensor Público)** Julgue o seguinte item.

I - Na audiência de custódia, ao entrevistar Valter, o juiz deverá abster-se de formular perguntas com a finalidade de produzir provas sobre os fatos objeto do auto da prisão em flagrante, mas deverá indagar acerca do tratamento recebido nos locais por onde o autuado passou antes da apresentação à audiência, questionando sobre a ocorrência de tortura e maus tratos.

II - Na audiência de custódia, caso não tenha advogado particular, Valter poderá contar com a assistência de defensor público, que acompanhará o ato na presença do juiz, do promotor de justiça, do secretário de audiência e dos policiais que promoveram a prisão.

**18- (2019/VUNESP/TJ-AC/Juiz de direito substituto)** Em relação à fiança, assinale a alternativa correta.

a) A fiança tomada por termo obrigará o afofado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como cassada.

b) Entender-se-á perdido, na totalidade, o valor da fiança, se, regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer, sem motivo justo.

c) A fiança será cassada quando o acusado deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo.

d) Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança.

**19- (2019/VUNESP/TJ-AC/Juiz de Direito Substituto)** Quanto à prisão temporária, assinale a alternativa correta.

a) Por se tratar de medida cautelar, dada a urgência, na hipótese de representação da autoridade policial, o Juiz poderá decidir independentemente de manifestação do Ministério Público.

b) Caberá prisão temporária em homicídio qualificado, mas não em homicídio simples.

c) A prisão temporária somente poderá ser executada depois da expedição de mandado judicial.

d) O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do prazo de 48 horas, contadas a partir do recebimento da representação ou do requerimento.

**20- (2019/INSTITUTO AOCP/PC-ES/Escrivão de polícia)** O Código de Processo Penal autoriza que o juiz substitua prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o agente for

a) maior de 60 anos.

b) debilitado por motivo de doença.

c) mulher, com filho de até 8 anos incompletos.

d) homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos.

e) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 8 anos de idade ou com deficiência.

**21- (2019/INSTITUTO AOCP/PC-ES/Escrivão de polícia)** Assinale a alternativa correta em relação à prisão temporária.

a) A prisão temporária terá prazo de 5 dias improrrogáveis.

b) Decretada a prisão temporária e findo o seu prazo, será ela convertida em preventiva necessariamente.

c) Caberá prisão temporária nas hipóteses de homicídio culposo e doloso.

d) A prisão temporária caberá quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade.

e) Sempre que possível, os presos temporários ficarão separados dos demais detentos.

**22- (2019/INSTITUTO AOCP/PC-ES/Escrivão de polícia)** Acerca dos valores da fiança, assinale a alternativa correta.

a) Será de 1 a 100 salários mínimos quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 anos.

- b) Será de 20 a 200 salários mínimos quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 anos.
- c) A depender da situação econômica do preso, a fiança poderá ser reduzida em até 2/5.
- d) A depender da situação econômica do preso, a fiança poderá ser aumentada em até 100 vezes.
- e) Em nenhuma hipótese, a fiança será dispensável.

**23- (2019/UFPR/TJ-PR/Titular de Serviços de Notas e de Registros)** Sobre a prisão em flagrante, assinale a alternativa correta.

- a) No caso em que o agente é perseguido, logo após o fato, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em circunstâncias que façam presumir ser autor da infração, a situação de flagrância durará pelo prazo de 24 horas, depois do qual não será mais possível a prisão em flagrante.
- b) Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.
- c) A falta de testemunhas da infração impedirá a autuação da prisão em flagrante.
- d) A comunicação da prisão ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada, deve ser feita em até 24 horas.
- e) Se for o caso de liberdade provisória, ao receber o auto da prisão em flagrante, o juiz a relaxará.

**24- (2019/CESPE/TJ-BA/Juiz de Direito Substituto)** Acerca de prisão, de liberdade provisória e de medidas cautelares, assinale a opção correta, com base no entendimento dos tribunais superiores.

- a) A gravidade específica do ato infracional e o tempo transcorrido desde a sua prática não devem ser considerados pelo juiz para análise e deferimento de prisão preventiva.
- b) A decisão sobre o pedido de prisão preventiva formulado durante audiência dispensa a oitiva da defesa, por se tratar de medida cautelar.
- c) A presença do defensor técnico é dispensável por ocasião da formalização do auto de prisão em flagrante, desde que a autoridade policial informe ao preso os seus direitos constitucionalmente garantidos.
- d) A decretação de prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública dispensa a prévia análise do cabimento das medidas cautelares diversas da prisão previstas no CPP.
- e) Quando o MP representar por prisão temporária, não será possível que se decrete a prisão preventiva, uma vez que isso representaria ofensa ao princípio da inércia da jurisdição.

**25- (2018/VUNESP/TJ-SP/Juiz Substituto)** Expedido mandado de prisão contra réu condenado, o executor do mandado, encontrando-o em casa de terceiro, e no período noturno, deverá

- a) intimar o morador a entregar o réu condenado e, em caso de recusa, convocar 2 (duas) testemunhas e entrar imediatamente e à força na casa para cumprir a ordem judicial.
- b) entrar na casa do terceiro, a quem dará voz de prisão pelo crime de favorecimento pessoal, cumprir o mandado de prisão e conduzir ambos à presença da Autoridade policial.
- c) intimar o morador a entregar o condenado e, em caso de recusa, esperar o amanhecer para ingressar na casa e efetuar a prisão.
- d) entrar na casa do terceiro, mesmo contra sua vontade, e efetuar a prisão do condenado em cumprimento ao mandado judicial.

## COMENTÁRIOS

1. Gabarito: D.

- a) INCORRETA. A alternativa trata a respeito da diferenciação de flagrante facultativo e obrigatório. De acordo com o art. 301, qualquer do povo poderá (doutrinariamente conhecido como flagrante facultativo) e as autoridades policiais e seus agentes deverão (doutrinariamente conhecido como flagrante obrigatório) prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
- b) INCORRETA. Nos termos do art. 308 do CPP, não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado à do lugar mais próximo.
- c) INCORRETA. De acordo com o art. 312 do CPP: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Note que é preciso haver “prova da materialidade e não apenas indícios”. Além disso, a Lei Anticrime (13.964/2019) adicionou na redação do art. 312, CPP, mais um requisito possível “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
- d) CORRETA. Alternativa de acordo com a previsão do § 4º do art. 304 do CPP.



e) INCORRETA. A prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase da persecução penal (investigação criminal ou ação penal). De acordo com o art. 311, com nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

**2. Gabarito: D.** A questão trata a respeito da substituição da prisão preventiva pelo cumprimento em prisão domiciliar, devendo ser lidos com atenção os arts. 318 e 318-A, ambos do CPP.

a) INCORRETA. Deve ser maior de 80 anos.

b) INCORRETA. Poderá a gestante ter a prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar, independentemente do mês da gestação, nos termos do art. 318, IV, CPP.

c) INCORRETA. Nos termos do art. 318-A, CPP, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa.

d) CORRETA. De acordo com o art. 318, VI, CPP.

e) INCORRETA. Nos termos do art. 318-A, CPP, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

**3. Gabarito: C.**

a) INCORRETA. Não se trata de espécie de flagrante delito.

b) INCORRETA. A autoridade policial poderá fixar fiança quando a pena máxima prevista à infração penal não ultrapassar 4 anos, nos termos do art. 322 do CPP.

c) CORRETA. Alternativa de acordo com o art. 304, § 3º, do CPP.

d) INCORRETA. De acordo com o art. 304, § 2º, do CPP, a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante; mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade.

**4. Gabarito: C.** Para responder à questão, é imprescindível a leitura da Súmula Vinculante nº 11: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

a) INCORRETA. A justificativa deve ser feita por escrito.

b) INCORRETA. As algemas podem ser utilizadas tanto na prisão penal, quanto na prisão cautelar, desde que se cumpram os requisitos previstos na Súmula Vinculante nº 11.

c) CORRETA.

d) INCORRETA. Ensejará a nulidade da prisão ou do ato processual e não a anulabilidade.

e) INCORRETA. A alternativa não mencionou que o perigo também pode ser em relação à integridade física própria. Não se restringe apenas à integridade física de terceiros. A assertiva também não mencionou que é lícito o uso de algemas em casos de resistência.

**5. Gabarito: D.**

a) INCORRETA. Em que pese o silêncio do legislador, funcionando a prisão domiciliar como modalidade de cumprimento de prisão preventiva, o desconto do tempo de cumprimento da medida em caso de condenação previsto no art. 42 do Código Penal é medida de rigor e adequada. Nesse sentido a jurisprudência e a doutrina majoritária.

b) INCORRETA. Pela leitura do art. 318, do CPP, é possível observar que não é somente as mulheres presas que podem ser beneficiadas pela prisão domiciliar. Exemplo: art. 318, inciso VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

c) INCORRETA. O simples fato a mulher ser reincidente não faz com que ela perca o direito à prisão domiciliar (STF, HC 143641/SP – Info 891). Quanto à segunda parte, a alternativa está correta. Não é possível a substituição pela prisão domiciliar quando o crime for cometido pela mãe contra o próprio filho, conforme art. 318-A, II, do CPP.

d) CORRETA. Para apurar a situação de guardião dos seus filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto,

cumprir desde logo a presente determinação. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará (STF, HC 143641/SP - Info 891).

e) INCORRETA. De acordo com o art. 318-A, I, do CPP, e prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa. Isto é, não pode ser concedida no caso de ter cometido o crime de roubo.

**6. Gabarito: B.**

I – CORRETO. Está literalmente de acordo com o art. 318-A do CPP.

II – INCORRETO. O item II confunde hipóteses de prisão domiciliar do art. 318, do CPP, com as hipóteses de prisão domiciliar do art. 117 da LEP. É preciso ficar atento às diferenciações.

III – INCORRETO. O CPP não é silente quanto à hipótese. Note que ela vem prevista no art. 318, V, CPP.

IV – INCORRETO. O art. 341 do CPP enumera as hipóteses em que a fiança restará quebrada. Dentre elas (art. 341, V) está quando o acusado pratica nova infração penal dolosa e não culposa.

**7. Gabarito: C.**

a) CORRETA. De acordo com o art. 343 do CPP.

b) CORRETA. De acordo com o art. 344 do CPP, entender-se-á perdido, na totalidade, o valor da fiança, se, condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena (seja privativa de liberdade, restritiva de direitos ou de multa) definitivamente imposta.

c) INCORRETA. A fiança será cassada quando for incabível, o crime for inafiançável ou em caso de inovação na classificação do delito. (Arts. 338 e 339, ambos do CPP).

d) CORRETA. Conforme art. 324, IV, do CPP.

**8. Gabarito:**

I – INCORRETO. A prisão temporária não pode ser decretada de ofício pelo Judiciário. (art. 2º, § 1º, da Lei nº 7.960/89).

II – INCORRETO. A prisão temporária somente é cabível nos crimes indicados no art. 1º, inc. III, da Lei nº 7.960/1989 e, ainda, nos crimes hediondos e equiparados (Lei nº 8.072/1990). Fora dessas hipóteses legais não é possível a decretação da prisão temporária, sob pena de caracterizar constrangimento ilegal. Assim, é ilegal a prisão temporária, por ausência de previsão legal, no delito de lavagem de dinheiro, de receptação, de furto, dentre outros.

**9. Gabarito: E.** A questão deve ser respondida se atentando para a leitura do art. 302 do CPP que dispõe sobre as espécies de flagrante delito.

**10. Gabarito: A.**

a) CORRETA. De acordo com o art. 313, IV, do CPP, que dispõe que será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

b) INCORRETA. Vide comentário da letra a.

c) INCORRETA. A autoridade policial não poderia ter fixado fiança, nos termos do art. 24-A, § 2º, da Lei Maria da Penha.

d) INCORRETA. Vide comentário da letra a.

e) INCORRETA. Vide comentário da letra a.

**11. Gabarito: D.** Nota de culpa é um documento que dá ciência ao preso de vários elementos importantes sobre a sua prisão em flagrante. A questão está de acordo com o art. 306, § 2º, do CPP, que dispõe que será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

**12. Gabarito: B.** A questão deve ser respondida se atentando para a leitura dos arts. 319 e 320, ambos do CPP.

a) INCORRETA. A suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais (319, VI, CPP).

b) CORRETA. De acordo com o art. 319, VII, do CPP.

c) INCORRETA. A monitoração também pode ser uma medida cautelar diversa da prisão nos moldes do art. 319, IX, do CPP.



- d) INCORRETA. Atenção ao art. 282, § 4º, e art. 313, IV, ambos do CPP.
- e) INCORRETA. O art. 320 do CPP prevê como medida cautelar diversa a proibição de ausentar-se do País será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

**13. Gabarito: D.**

- a) INCORRETA. Qualquer pessoa, no exercício regular do direito, pode prender quem se encontre em situação de flagrância (flagrante facultativo – art. 301, CPP).
- b) INCORRETA Vide resposta da letra D.
- c) INCORRETA. Vide resposta da letra D.
- d) CORRETA. Presente a hipótese de flagrante presumido – art. 302, IV, CPP.
- e) INCORRETA. Vide resposta da letra D.

**14. Gabarito:**

Item I – CORRETO. Uma vez oferecida a denúncia não mais subsiste o decreto de prisão temporária, que visa resguardar, tão somente, a integridade das investigações (STJ, HC: 78437/SP).

Item II – CORRETO. A prisão temporária não pode ser decretada de ofício pelo Juiz (art. 2º da Lei nº 7.960/89).

**15. Gabarito: E.** A questão deve ser respondida com a leitura atenta do art. 319 do CPP.

**16. Gabarito:**

Item I – CORRETO. O item está de acordo com o art. 340, III, do CPP.

Item II – INCORRETO. Nos termos do art. 320, do CPP, a proibição de ausentar-se do País será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no prazo de 24 horas.

**17. Gabarito:**

É importante a leitura do art. 310 do CPP (com nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019) e da Resolução nº 213 do CNJ. De lá, é possível retirar algumas observações importantes: esta audiência não tem finalidade de produzir provas, visa basicamente verificar se os direitos do preso foram respeitados; devem estar presentes o juiz, promotor e o membro da defensoria pública caso não tenha constituído advogado particular; vedado a presença de policiais que efetuaram a prisão ou investigação durante a audiência; prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia; não deve nesta audiência ser questionado o mérito da imputação.

Item I – CORRETO.

Item II – INCORRETO.

**18. Gabarito: D.**

- a) INCORRETA. É caso de fiança quebrada e não cassada.
- b) INCORRETA. É caso de fiança quebrada, perdendo metade do valor.
- c) INCORRETA. As hipóteses de cassação da fiança estão nos arts. 338 e 339 do CPP.
- d) CORRETA. Art. 341, III, CPP.

**19. Gabarito: C.**

- a) INCORRETA. O juiz deve ouvir o MP antes de decidir, conforme art. 2º, § 1º, da Lei nº 7.960/89.
- b) INCORRETA. Nos termos do art. 1º, *a*, em qualquer homicídio doloso cabe a prisão temporária.
- c) CORRETA, conforme art. 2º, § 5º, da Lei nº 7.960/89.
- d) INCORRETA. O prazo é de 24 horas, conforme art. 2º, § 2º, da Lei nº 7.960/89.

**20. Gabarito: D.** É imprescindível a leitura do art. 318 do CPP.

- a) INCORRETA. Maior de 80 anos.
- b) INCORRETA. Extremamente debilitado por motivo de doença grave.
- c) INCORRETA. Mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
- d) CORRETA, nos termos do art. 318, VI, CPP.
- e) INCORRETA. Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência.

**21. Gabarito: D.**





a) INCORRETA. O prazo poder ser prorrogado por nova decisão judicial. Nos termos do art. 2º, da Lei nº 7.960/89, a prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

b) INCORRETA. Nos termos do art. 2º, § 7º, da Lei nº 7.960/89, decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva.

c) INCORRETA. Somente homicídio doloso. Culposos, não.

d) CORRETA. Está de acordo com o art. 1º, II, da Lei nº 7.960/89, que prevê que caberá prisão temporária quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade.

e) INCORRETA. Nos termos do art. 3º, da Lei nº 7.960/89, os presos temporários deverão permanecer, obrigatoriamente, separados dos demais detentos.

**22. Gabarito: A.**

a) CORRETA. Está de acordo com o art. 325, I, do CPP.

b) INCORRETA. Nos termos do art. 325, II, do CPP, será de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.

c) INCORRETA. Poderá ser reduzida até o máximo de 2/3, conforme art. 325, § 1º, II, do CPP.

d) INCORRETA. Poderá ser aumentada em até 1.000 vezes, conforme art. 325, § 1º, III, do CPP.

e) INCORRETA. Poderá ser dispensada, nos termos do art. 325, § 1º, I, do CPP.

**23. Gabarito: B.**

a) INCORRETA. A lei não traz prazo definido. Enquanto não se encerrar a perseguição (portanto, ininterrupta), a situação de flagrância permanece.

b) CORRETA. Súmula nº 145, STF.

c) INCORRETA. De acordo com o art. 304, § 2º, do CPP, a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante; mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade.

d) INCORRETA. Nos termos do *caput* do art. 306, a comunicação será imediata.

e) INCORRETA. O relaxamento da prisão só se dá em caso de ilegalidade da prisão.

**24. Gabarito: C.**

a) INCORRETA. A prática de atos infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, considerando que indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração (STJ, RHC 47.671-MS, Info 554; STJ, RHC 63.855-MG).

b) INCORRETA. Nos termos do art. 282, § 3º, do CPP, ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.

c) CORRETA. De acordo com tese nº 6, fixada pelo STJ na sua edição nº 120 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça diz:

Eventual nulidade no auto de prisão em flagrante devido à ausência de assistência por advogado somente se verifica caso não seja oportunizado ao conduzido o direito de ser assistido por defensor técnico, sendo suficiente a lembrança, pela autoridade policial, dos direitos do preso previstos no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.

Direito de ser assistido por defensor técnico, sendo suficiente a lembrança, pela autoridade policial, dos direitos do preso previstos no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.

d) INCORRETA. Nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não

cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

e) INCORRETA. Pode o Magistrado decretar a prisão preventiva, mesmo que a representação da autoridade policial ou do Ministério Público seja pela decretação de prisão temporária, visto que, provocado, cabe ao juiz ofertar o melhor direito aplicável à espécie. Requerida a prisão temporária pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, o Magistrado poderá decretar a prisão preventiva, em decisão fundamentada, na qual aponte a presença dos requisitos do art. 312 do CPP (STJ, HC 362.962/RN).

**25.** Gabarito: C. De acordo com o art. 293, se o executor do mandado verificar, com segurança, que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso; sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e, logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. Com isso:

- a) INCORRETA.
- b) INCORRETA.
- c) CORRETA.
- d) INCORRETA.

## CAPÍTULO 19 – COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS (ARTS. 351 A 372 DO CPP)

### 1. CITAÇÃO

A citação é momento muito importante no processo penal, pois é o primeiro ato processual de comunicação ao acusado, ou seja, de dar ciência a ele de que existe uma acusação. É por meio dela que o Poder Judiciário comunica ao indivíduo a respeito de uma denúncia ou queixa-crime ajuizada e o convoca para ingressar no processo e se defender (exercício da ampla defesa e das demais garantias individuais).

Antes do ato, há apenas a figura do acusador (seja ele Ministério Público, seja ele ofendido/representante legal) e do juiz. Depois, haverá uma relação angular na qual existirão três personagens: o acusador, o juiz e o acusado/defesa. Por isso, de acordo com o art. 363 do CPP, o processo penal terá formado ou completado a sua formação quando realizada a citação do acusado.

De acordo com o art. 564, III do CPP, a falta de citação é causa de nulidade absoluta. Segundo a doutrina, a essa citação eivada de nulidade é dado o nome de citação circunduta (MIRABETE, 2007, p. 445). No entanto, o vício pode ser sanado (STJ, HC 444.422/SP), desde que o interessado compareça, antes de o ato consumir-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la (art. 570 do CPP). O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte. Porém, no caso dos procedimentos ordinário, sumário e do júri, por exemplo, com a citação do réu deve ser intimado a apresentar resposta à acusação. Assim, comparecendo o acusado posteriormente, deve o juiz possibilitar a resposta, anulando os atos de instrução já realizados.

Via de regra, a citação é realizada para viabilizar a apresentação de resposta à acusação no prazo de 10 dias, conforme previsão para os procedimentos comum ordinário e sumário no art. 396, *caput*, do CPP, e não mais para comparecer à audiência de interrogatório como previa no sistema anterior às alterações promovidas pela Lei nº 11.719/08. Outros procedimentos, por exemplo, o sumaríssimo, prevê que a citação se dará para o comparecimento na audiência (art. 78 da Lei nº 9.099/95); aqui a peça defensiva é apresentada antes do recebimento da denúncia (art. 81 da Lei nº 9.099/95). Essas diferenciações serão mais bem esclarecidas quando do estudo do procedimento comum em capítulo próprio.

**Atenção:** o Código Penal prevê os marcos interruptivos da prescrição. No entanto, a citação não é uma das causas, pois não é prevista no rol do art. 117 do CP. Não confunda processo civil com processo penal. Neste, o primeiro momento de interrupção da prescrição é o ato de recebimento da inicial acusatória. Além disso, a citação válida não torna prevento o juízo (este se tornou prevento antes), não sendo, ainda, causa de litispendência.

#### 1.1. ESPÉCIES DE CITAÇÃO

Existem duas espécies de citação: a) Citação real (pessoal); b) Citação ficta (presumida).

Na primeira delas, como o próprio nome diz, o acusado é citado pessoalmente, ou seja, ele mesmo recebe a comunicação. A citação pessoal pode ser dividida em subespécies, sendo de extrema importância o estudo de cada uma delas: a) Citação por mandado (art. 351); b) Citação por carta precatória (art. 353); c) Citação do militar (art. 358); d) Citação do funcionário público (art. 359); e) Citação do acusado que estiver preso (art. 360); f) Citação do acusado no estrangeiro (art. 368); g) Citação em legações estrangeiras (art. 369).

Na segunda delas, o acusado não é encontrado para ser comunicado pessoalmente da instauração do processo. Apesar disso, se forem cumpridos determinados requisitos legais, a lei presume que ele soube da existência do processo. Existem duas subespécies de citação ficta: a) Citação por hora certa (art. 362); b) Citação por edital (art. 361).

É preciso esclarecer que, diferentemente de outras legislações, no processo penal não são admitidas citações por correio, eletrônica, por *e-mail*, por telefone ou por procurador com poderes especiais.

**Atenção:** eventual defeito do ato de citação irá gerar por consequência nulidade relativa (STF, HC 109.577/MT).

Abaixo há análise de cada uma das formas de citação válidas no processo penal.

#### 1.1.1. POR MANDADO (ART. 351 DO CPP)

A regra é a citação pessoal, por mandado, quando o réu reside na mesma comarca ou local em que o juiz exerce a sua jurisdição (exemplo: o réu reside em Belo Horizonte e responde a processo na Vara Criminal de Belo Horizonte). É expedido um mandado de citação, devendo constar todas as informações da demanda (art. 352 do CPP), isto é, compondo todos os requisitos intrínsecos (que se encontram no mandado expedido).

A citação é feita por oficial de justiça que deverá ler o mandado ao citando e entregar a contrafé (cópia da denúncia ou da queixa), na qual se mencionarão dia e hora da citação (art. 357, I). Após isso, o oficial de justiça deve declarar, em certidão nos autos, a entrega da contrafé, e sua aceitação ou recusa (inciso II). São os chamados requisitos extrínsecos (que se encontram fora do mandado) da citação. Necessariamente ocorrerá na pessoa do acusado (ainda que outorgue poderes a advogado).

Atenção: se o réu for inimputável e essa circunstância já for conhecida, é possível a citação por meio da pessoa do curador, em analogia ao que dispõe o art. 245, § 5º, do CPC/2015.

#### 1.1.2. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA (ART. 353 DO CPP)

Ocorre quando o acusado residir fora do território em que o juiz exerce a sua jurisdição (exemplo: o réu reside em Goiânia e está sendo processado em Brasília). Fala-se em carta precatória porque a prática do ato é solicitada a outro juiz que não aquele que possui competência para o julgamento da ação penal. O juiz deprecante (onde tramita o processo) pede ao juiz deprecado (local em que o réu reside) o cumprimento do ato processual citatório (art. 353 do CPP).

As cartas precatórias seguem as mesmas disposições do mandado de citação (requisitos intrínsecos e extrínsecos), no que se refere às informações, devendo indicar o juízo deprecado e o juízo deprecante, a sede da jurisdição de um e de outro, o fim para que é feita a citação, com todas as especificações, e o juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer (art. 354 do CPP). Igualmente, haverá a certificação de toda a diligência por oficial de justiça (art. 357 do CPP).

Atenção: a figura da carta precatória itinerante está prevista no art. 355, § 1º, do CPP. É quando o juízo deprecado verifica que o réu na verdade se encontra em território de jurisdição de outro juiz, remetendo diretamente a precatória ao local onde se encontra o réu, sem necessidade de retorno ao juízo deprecante. O instituto atende ao princípio da economia processual. Veja abaixo:

Art. 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de traslado, depois de lançado o "cumpra-se" e de feita a citação por mandado do juiz deprecado.

§ 1º Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação.

Atenção: de regra, intimadas as partes da expedição da carta precatória, a elas cabe o respectivo acompanhamento, sendo desnecessária a intimação da data designada para a audiência no Juízo deprecado. Caso não ocorra a intimação da expedição da precatória, a jurisprudência entende se tratar de nulidade relativa. Veja os enunciados abaixo:

Súmula nº 273, STJ: “Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado.”

Súmula nº 155, STF: “É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de carta precatória para inquirição de testemunha.”

O entendimento acima é mitigado em relação à Defensoria Pública. As condições da Defensoria são variadas em cada Estado da Federação. Por vezes, não estão adequadamente estruturadas, com centenas de assistidos para poucos defensores, e, em especial, sem condições de acompanhar a prática de atos em locais distantes da sede do Juízo. Desse modo, se o réu for assistido pela Defensoria Pública no juízo deprecante e, na sede do juízo deprecado, houver defensoria instalada e estruturada, será também obrigatória a intimação acerca do dia do ato processual, sob pena de nulidade. Desse modo, expedida a carta precatória para localidade na qual exista Defensoria Pública estruturada, deve a instituição ser intimada da audiência designada para nela comparecer e defender o acusado necessitado. Não se justifica a nomeação de defensor dativo quando há instituição criada e habilitada à defesa do hipossuficiente (STF, RHC 106394).

### **1.1.3. CITAÇÃO DO MILITAR (ART. 358 DO CPP)**

A citação do militar será feita por intermédio do chefe do respectivo serviço (art. 358 do CPP), devendo o militar ser requisitado quando estiver fora de sua sede, o que equivale a dizer que será feita por meio de requisição ao superior hierárquico. A requisição deverá conter as mesmas informações constantes do mandado de citação. O oficial de justiça vai ao local indicado, entrega o mandado para o chefe do serviço e este cita o militar.

O procedimento vai ao encontro da hierarquia e da disciplina militar, evitando-se que o oficial de justiça ingresse nas dependências à procura do réu (NUCCI, 2008, p. 645).

### **1.1.4. CITAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO (ART. 359 DO CPP)**

O funcionário público deverá ser citado pessoalmente, ainda que o CPP faça referência à notificação (art. 359 do CPP), devendo ser notificado (agora sim) o chefe da repartição com o objetivo de preservar a continuidade do serviço público, permitindo a substituição do funcionário no dia e hora, se for o caso.

### **1.1.5. CITAÇÃO DO PRESO (ART. 360 DO CPP)**

A citação do réu preso deve ser pessoal, esteja onde ele estiver preso, sendo nula a citação por edital se ele estiver preso na mesma unidade da federação do juízo processante.

“Art. 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado.”

Súmula nº 351, STF: “É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição.”

### **1.1.6. CITAÇÃO NO ESTRANGEIRO (ART. 368 DO CPP)**

De acordo com o art. 368 do CPP, estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Somente é realizada quando o endereço é conhecido, pois, não se sabendo o paradeiro do réu, segue-se a regra das citações por edital.

O termo inicial da suspensão da prescrição é a determinação do juiz de expedição da carta rogatória e, como o legislador não estabeleceu seu termo final de maneira clara, este ocorrerá com a data da efetiva citação no exterior (DEZEM, 2019, p. 956).

A citação será feita por meio de carta rogatória, nos termos dos arts. 780 e 783 do CPP, sendo o pedido encaminhado pelo juiz ou tribunal ao Ministro da Justiça para envio pelas vias diplomáticas.

De acordo com o art. 222-A do CPP, as cartas rogatórias só serão expedidas se demonstradas previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio.

### 1.1.7. CITAÇÃO EM LEGAÇÕES ESTRANGEIRAS (ART. 369 DO CPP)

“Art. 369. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)”

A citação que deva ser cumprida em legação estrangeira será realizada mediante carta rogatória, desde que o acusado não se enquadre entre aquelas pessoas que, por força de tratados ou de convenções (como a Convenção de Viena), gozem de imunidade de jurisdição penal no Brasil.

Segundo a doutrina majoritária, não haverá suspensão do prazo prescricional, uma vez que o art. 369, do CPP é silente nesse sentido, ao contrário da hipótese prevista no art. 368 do CPP analisada no tópico acima (AVENA, 2017, p. 115).

### 1.1.8. CITAÇÃO POR HORA CERTA

A citação por hora certa já existia há muito tempo no processo civil e foi introduzida no processo penal apenas em 2008, por força da Lei nº 11.719/2008, que modificou a redação do art. 362 do CPP. Ocorre quando o oficial de justiça vai tentar citar o réu, mas nunca o localiza no endereço e percebe que o réu está, na verdade, se ocultando para não ser encontrado, buscando evitar o início dos atos processuais

Se o oficial de justiça constatar realmente essa situação, a lei autoriza que ele marque determinado dia e horário para voltar no endereço do réu e, nesta data designada, tentar novamente citar o indivíduo. Caso ele não esteja mais uma vez presente, a citação considera-se realizada e presume-se que o réu tomou conhecimento da ação penal que, nesta modalidade de citação ficta/presumida, irá seguir o seu curso normal.

Veja a previsão legal no CPP:

Art. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

Atenção: o CPP não especifica como se dará a citação por hora certa, fazendo referência ao estabelecido no Código de Processo Civil (CPC). Os arts. 227 a 229 do CPC/1973, mencionados acima pelo art. 362 do CPP, correspondem, atualmente, aos arts. 252 a 254 do CPC/2015. É o que determina o art. 1.046, § 4º do novo CPC:

“Art. 1.046 (...) § 4º As remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, passam a referir-se às que lhes são correspondentes neste Código.”

A citação por hora certa é cercada de cuidados. Veja a previsão legal do CPC a respeito dos requisitos da citação por hora certa:

Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação,



intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

Parágrafo único. Nos condomínios edifícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência.

§ 1º Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias.

§ 2º A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado.

§ 3º Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome.

§ 4º O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia.

Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.

Se o acusado, citado por hora certa, não integrar o processo, este segue seu curso normal (o oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia), sendo produzidas todas as provas necessárias e, ao final, o acusado será julgado (absolvido ou condenado). Para tanto, o juiz deverá encaminhar os autos à Defensoria Pública ou, não havendo órgão na localidade, nomear defensor dativo (art. 362, parágrafo único, do CPP) para que faça a defesa do réu, tendo em vista a imprescindibilidade da defesa técnica no processo penal (art. 261 do CPP).

**Atenção:** há questionamentos acerca da convencionalidade e da constitucionalidade da continuidade do processo na citação por hora certa. O Pacto São José da Costa Rica (art. 8º, 2, *b*) garante o direito de presença ao acusado, aparentemente incompatível com o art. 362 do CPP. No entanto, o STF entende que a citação por hora certa não viola a Constituição Federal, pois a ocultação do réu infringe cláusulas constitucionais como a do acesso à justiça, não podendo o acusado se utilizar de meios escuros para não ser pessoalmente citado (STF. Plenário. RE 635145–repercussão geral – Informativo 833).

**Atenção:** há divergência sobre a possibilidade de a citação por hora certa ser utilizada nos juizados especiais criminais, rito sumaríssimo, regido pela Lei nº 9.099/95. Para a primeira corrente, adotada por Norberto Avena, se o oficial de justiça informar que o réu está se ocultando para não ser citado, deverá o juiz declarar a incompetência do Juizado Especial e declinar os autos a uma das varas criminais comuns, seguindo os autos no procedimento comum sumário (art. 538 do CPP), conforme art. 66 da Lei nº 9.099/95, que afirma que a citação será pessoal. Para outra corrente, que prevalece no âmbito dos Juizados Especiais, é possível a citação por hora certa. Nesse sentido, enunciado nº 110 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais): no Juizado Especial Criminal é cabível a citação com hora certa.

### 1.1.9. CITAÇÃO POR EDITAL

É modalidade excepcional que somente ocorre após o esgotamento dos meios de localização do acusado (não é encontrado). O juiz deve esgotar os meios de encontrá-lo, verificando todos os endereços que constarem dos autos, não somente aquele que foi fornecido no

interrogatório policial, admitindo-se até mesmo consulta a registros de órgãos públicos. Se, mesmo assim, não for o acusado encontrado, deverá ser citado por edital com prazo de 15 dias (prazo de dilação), conforme determina o art. 361 do CPP.

O edital deverá ser afixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa, onde houver, devendo a afixação ser certificada pelo oficial de justiça que a tiver feito e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal com a data da publicação (art. 365, parágrafo único, do CPP).

O edital deverá conter: o nome do juiz que a determinar; o nome do réu, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constarem do processo; o fim para que é feita a citação; o juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer; o prazo, que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua afixação (art. 365 do CPP).

Após a citação por edital, se o réu comparecer ou constituir advogado o processo terá o seu seguimento normalmente. Veja a previsão legal:

“Art. 363, §4º - Comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo, o processo observará o disposto nos arts. 394 e seguintes deste Código (procedimento comum e especial).”

Nesse caso, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído (art. 396, parágrafo único). No entanto, se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, tal como determina o art. 366 do CPP.

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.

As hipóteses de incidência da suspensão, na forma do art. 366 do CPP, são três e de maneira cumulativa: a) deve o acusado ser citado por edital e b) não comparecer e c) não constituir advogado. Não ocorridas estas hipóteses cumulativas, não haverá incidência do mencionado dispositivo legal.

Por constituir modalidade de citação ficta, a citação por edital não garante que o acusado efetivamente tome conhecimento da sua existência, tratando-se apenas de uma presunção. Dessa forma, se houvesse o prosseguimento da ação, acarretaria sérios prejuízos aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O dispositivo legal nada diz quanto ao prazo máximo em que perdurará a suspensão. A jurisprudência e a doutrina entendem que a suspensão não pode ser indefinida, sob pena de ocorrer uma imprescritibilidade não prevista na Constituição Federal. Prevalece então o entendimento de que a suspensão perdura pelo prazo máximo em abstrato da prescrição previsto para a infração penal (Súmula nº 415, STJ).

Portanto, se João for acusado por furto (art. 155 do CP, com pena de 1 a 4 anos de reclusão) e citado por edital, a prescrição se dará pelo prazo previsto no art. 109, IV, do CP, ou seja, 8 anos. Desta forma, a prescrição ficará suspensa pelo prazo de 8 anos e, então, voltará a correr, mas não o processo. Este somente voltará a correr quando o réu comparecer ou constituir advogado.

Há, no STF, posicionamento antigo e em sentido contrário, mas minoritário. Nele, a Corte entende que o prazo de suspensão é indeterminado e ressalta que isso não constitui imprescritibilidade por não impedir a retomada do curso do prazo. O que ocorre é que a retomada está condicionada a um evento futuro e incerto: ou o réu comparece pessoalmente ou constitui advogado. Veja o julgado:

(...) A indeterminação do prazo da suspensão não constitui, a rigor, hipótese de imprescritibilidade: não impede a retomada do curso da prescrição, apenas a condiciona a

um evento futuro e incerto, situação substancialmente diversa da imprescritibilidade. 3. Ademais, a Constituição Federal se limita, no art. 5º, XLII e XLIV, a excluir os crimes que enumera da incidência material das regras da prescrição, sem proibir, em tese, que a legislação ordinária criasse outras hipóteses. 4. Não cabe, nem mesmo sujeitar o período de suspensão de que trata o art. 366 do C. Pr. Penal ao tempo da prescrição em abstrato, pois, "do contrário, o que se teria, nessa hipótese, seria uma causa de interrupção, e não de suspensão." 5. RE provido, para excluir o limite temporal imposto à suspensão do curso da prescrição (RE 460971).

Contra a decisão que suspende o processo cabe recurso em sentido estrito, por interpretação extensiva do art. 581, XVI, do CPP (suspensão do processo em virtude de questão prejudicial), conforme entendimento do STJ no REsp 246085/SP. Lembrando que a interpretação extensiva é técnica possível no processo penal, conforme art. 3º do CPP.

Durante o prazo de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, poderá o juiz determinar a produção antecipada de provas, que só pode ser autorizada quando efetivamente comprovada a sua real necessidade e concretamente fundamentada (ex.: testemunha ocular do fato que está com uma doença terminal), não a justificando o mero decurso do prazo, conforme enunciado abaixo:

Súmula nº 455 do STJ: "A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo."

É possível verificar na jurisprudência do STJ duas atenuações a essa súmula: a) se houver risco concreto de perecimento da prova testemunhal, tendo em vista a alta probabilidade de esquecimento dos fatos distanciados do tempo de sua prática (STJ, AgRg no HC 427.852/SP) e b) quando a testemunha for policial, dada a concreta possibilidade de esquecimento em razão da quantidade de casos que atendem diariamente (STJ, HC 425.852/SP).

Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz decretar prisão preventiva (art. 366 do CPP). No entanto, não se trata de prisão automática. Para que seja decretada a prisão preventiva, não basta que o réu não seja localizado, mas devem estar presentes os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP, devendo ser demonstrado, por exemplo, que o acusado fugiu, colocando-se em lugar incerto de modo deliberado, sabendo que seria acusado pelo crime. Precedentes do STF: HC 104.606/PE; HC 101.356/RJ; HC 106.426/MG; HC 102.354/PA; HC 103460. Lembre-se, ainda, que pelo sistema após a Lei nº 12.403/2011 e a Lei nº 13.964/2019, não somente devem estar presentes os pressupostos do art. 312 como deve ser demonstrado pelo magistrado que não seria suficiente nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, CPP).

#### Atenção:

1. É preciso ressaltar que prevalece na doutrina e na jurisprudência que não é possível a aplicação do art. 366 do CPP aos casos de crimes cometidos antes da vigência da Lei nº 9.271/96 que alterou a redação do dispositivo em comento, sob pena de se permitir a retroação da lei penal em prejuízo do acusado (STF, HC 74676/SP; STJ, HC 29814/SP).

2. A qualquer tempo, comparecendo o acusado ou constituindo advogado nos autos, deverá o juiz dar prosseguimento ao processo. Merece registro a previsão do art. 396, parágrafo único, do CPP, segundo o qual o prazo para a defesa do réu citado por edital (10 dias para apresentação da resposta à acusação) somente começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.

3. Não é cabível citação por edital nos juizados especiais criminais. Os autos serão remetidos ao juízo comum que adotará o procedimento comum sumário (art. 538, CPP).

4. Normalmente, o acusado que é citado por edital e que não comparece em juízo ou constitua defensor terá o processo e o curso da prescrição suspensos, por força do art. 366 do CPP.

No entanto, no caso de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98), há regra própria. Com efeito, o art. 2º, § 2º, da Lei nº 9.613/98 dispõe o seguinte:

Art. 2º, § 2º. No processo por crime previsto nesta Lei, não se aplica o disposto no art. 366 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento, com a nomeação de defensor dativo.

Dessa forma, o processo seguirá com a nomeação de defensor dativo, como ocorre na citação por hora certa. Naturalmente, há entendimento diverso no sentido de que a proibição de aplicação do art. 366 do CPP contida na Lei de Lavagem de Capitais é inconstitucional e fere o Pacto de São José da Costa Rica. Porém, é entendimento minoritário.

5. Súmula nº 366, STF: não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia.

Com a expedição do edital, busca-se dar ciência do acusado do conteúdo da acusação. Por isso, ela deveria ser transcrita. Todavia, segundo o entendimento jurisprudencial, basta que seja feita menção ao tipo legal, ou seja, à classificação do delito feita na denúncia.

6. Súmula nº 351, STF: é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição.

O STJ mantém, em alguns julgados, a aplicação literal do entendimento da Súmula nº 351 do STF apenas para os casos envolvendo réu preso no mesmo estado da federação, mantendo hígida a possibilidade de citação por edital de réu recluso em estado diverso do juízo processante. Portanto, só tem incidência nos casos de réu segregado no mesmo Estado em que Juiz processante atua, não se estendendo às hipóteses em que o acusado se encontra custodiado em localidade diversa daquela em que tramita o processo no qual se deu a citação por edital.

No entanto, isso é muito criticado pela doutrina. Não há diferença entre a prisão feita em um ou outro Estado da Federação. O réu está à disposição do Estado. Há doutrina (Pacelli) que entende que, em razão disso, essa súmula está ultrapassada, diante da nova redação do art. 360 do CPP, que assegura ao preso a citação pessoal.

## 2. INTIMAÇÃO

Enquanto por meio da citação o acusado toma conhecimento da existência de uma ação penal contra ele instaurada, pela intimação se dá conhecimento da prática dos demais atos processuais já praticados ou que ainda serão praticados. Na doutrina, é possível analisar a distinção entre o ato de intimação, como aquele que se dá ciência de algo já praticado, e o ato de notificação, como aquela em que se convoca alguém a fazer algo. No entanto, o CPP não faz essa diferença, adotando-se o único termo: intimação.

A intimação é, portanto, o meio procedimental que noticia a existência de ato processual e viabiliza o comparecimento e participação de terceiros no processo penal, como as testemunhas, vítimas, peritos, intérpretes que devem exercer determinada função na ação penal.

Em relação a esses e ao acusado, a intimação deverá ser feita nos mesmos moldes da regra da citação, ou seja, pessoalmente por expedição de mandado (art. 370 do CPP).

Já a intimação do advogado constituído pelo réu (tanto na ação penal pública quanto privada) e pelo querelante (na ação penal privada), bem assim pelos advogados dos assistentes de acusação, será feita pela imprensa. Não havendo órgão de publicação dos atos judiciais, a intimação será feita diretamente pelo escrivão, por mandado ou por via postal com comprovante de recebimento ou por qualquer meio idôneo (art. 370, §§ 1º e 2º, CPP).

Quando ao defensor dativo, a intimação deverá ser pessoal, via mandado, conforme dispõe o § 4º do art. 370 do CPP.



Os membros do Ministério Público possuem a prerrogativa de, quando forem ser intimados dos atos processuais, este ocorrer de forma pessoal. A lei determina que a intimação pessoal deve ocorrer por meio da entrega dos autos com vista, ou seja, mediante entrega dos autos. Essa prerrogativa vale tanto para os processos cíveis como para os criminais, conforme arts. 18, II, alínea *h*, da Lei Complementar nº 75/93; art. 41, IV, da Lei nº 8.625/93; art. 370, § 4º, do CPP; e art. 180 do CPC). Os julgados abaixo reforçam o entendimento:

(...) há, em relação ao Ministério Público, uma prerrogativa de ser intimado pessoalmente e com vista dos autos, para qualquer finalidade. Ou seja, não basta a intimação pessoal. Ademais, como dito, a LC nº 75/93 e a Lei nº 8.625/93 são leis específicas e não preveem formas diferenciadas de intimação, de modo que não é aplicável a intimação pessoal (por meio de mandado) prevista na lei geral” (STF, Rcl 17.694/RS).

Os membros do Ministério Público possuem a prerrogativa (o “direito”) de, quando forem ser intimados dos atos processuais, essa intimação ocorrer de forma pessoal. Essa prerrogativa da intimação pessoal vale tanto para os processos cíveis como para os criminais: art. 18, Lei Complementar nº 75/93 (estatuto do MPU); art. 41 da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do MP); art. 370, § 4º do CPP; art. 180 e 183 do CPC. O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado. STJ. 3ª Seção. REsp 1.349.935-SE, recurso repetitivo, Info 611).

Quanto à Defensoria Pública, o art. 44, I, o art. 89, I e o art. 128, I, todos da Lei Complementar nº 80/94, garantem, além da intimação pessoal, que esta se realize mediante entrega dos autos com vista. Desse modo, o mesmo entendimento adotado ao Ministério Público é aplicado para a Defensoria Pública:

Para que a intimação pessoal do Defensor Público se concretize, será necessária a remessa dos autos à Defensoria Pública. A intimação da Defensoria Pública, a despeito da presença do defensor na audiência de leitura da sentença condenatória, se aperfeiçoa com sua intimação pessoal, mediante a remessa dos autos. STF. 2ª Turma. HC 125270/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 23/6/2015 (Info 791).

Atenção: em matéria penal, o Ministério Público não tem prazo em dobro (Info. 533, STJ, 2014). A Defensoria Pública possui prazo em dobro, nos termos dos arts. 44, I, o art. 89, I e o art. 128, I, todos da Lei Complementar nº 80/94. O defensor dativo, não possuirá (STJ, AgRg no REsp 1.242.905/SP).

Atenção: devem ser intimados da sentença condenatória tanto o acusado quanto o seu defensor (os dois possuem legitimidade recursal, conforme art. 577 do CPP), não importando, porém, a ordem dos referidos atos processuais, sendo certo que o prazo para a interposição de recurso será contado da data da última intimação (STJ, HC 217.554/SC).

A respeito da intimação da sentença, é importante a leitura das regras próprias previstas no art. 392 do CPP:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

IV - mediante edital, nos casos do no II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;

V - mediante edital, nos casos do no III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;



VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça.

§ 1º O prazo do edital será de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, e de 60 dias, nos outros casos.

§ 2º O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo.

### 3. REVELIA

É quando o acusado, citado ou intimado pessoalmente ou por hora certa, deixa de apresentar defesa ou não comparece a algum ato processual, sem apresentar justificativa. Veja o dispositivo legal:

“Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.”

A revelia não implica em presunção de veracidade dos fatos narrados na peça acusatória, uma vez que o processo penal é regido pela presunção de inocência, incumbindo à acusação o ônus da prova em relação ao fato imputado ao réu. Por isso, em proteção à ampla defesa e, nos termos do art. 261 do CPP, o réu, mesmo revel, será representado por um defensor dativo nomeado pelo juiz.

A revelia torna desnecessária a intimação dos atos do acusado para os atos do processo até a sentença se: deixar de comparecer sem motivo justificado; mudar de residência sem comunicar o novo endereço; o réu for citado por hora certa e não comparecer (será nomeado defensor dativo e o processo segue à revelia do réu).

**Atenção:** há necessidade de intimação do réu, mesmo que revel, após a prolação de sentença (seguindo as regras do art. 392 do CPP), afinal, de acordo com o art. 577 do CPP tanto o acusado como seu advogado possuem legitimidade para a interposição de recurso.

### 4. CONTAGEM DE PRAZOS

Atenção às seguintes regras:

1. Conforme Súmula nº 710, do STF, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou carta precatória ou de ordem.

2. A contagem dos prazos é diferente da utilizada para os prazos penais. Segundo o § 1º do art. 798 do CPP, não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o dia do vencimento.

3. Todos os prazos correm em cartório e são contínuos ou peremptórios, não se interrompendo por férias, domingos ou dia de feriado (art. 798, *caput*, CPP).

4. O prazo que terminar em domingo ou dia de feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato (art. 798, §3º, CPP).

5. Conforme Súmula nº 310, do STF, quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houve expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir.

6. A informatização do processo judicial é objeto da Lei nº 11.419/2006, que, no § 3º do art. 4º, dispõe que a data da publicação será o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Assim, o prazo começará a ser contado somente do primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação (art. 798, § 1º, CPP).

7. Os prazos para o juiz proferir despachos, decisões e sentenças serão contados do termo de conclusão dos autos pelo escrivão/diretor de secretaria ao juiz (§1º). Prevê o art. 800 do CPP que o juiz possui dez dias para proferir decisão definitiva ou interlocutória mista; cinco dias para



proferir decisão interlocutória simples; um dia para proferir despacho de expediente. Os prazos são impróprios e não são preclusivos, pois o juiz, se não praticarem o ato processual no prazo, continua a ter que praticá-los. Em qualquer instância, o juiz, declarando motivo justo, poderá exceder por igual tempo os prazos a ele fixados (art. 800, §3º, CPP).

## 5. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA

### 5.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Súmula nº 155, STF: “É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de carta precatória para inquirição de testemunha.”

Súmula nº 310, STF: “Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houve expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir.”

Súmula nº 351, STF: “É nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia.”

Súmula nº 366, STF: “Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia.”

Súmula nº 701, STF: “No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo.”

Súmula nº 707, STF: “Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo.”

Súmula nº 710, STF: “No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem.”

### 5.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Súmula nº 273, STJ: “Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado.”

Súmula nº 415, STJ: “O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.”

Súmula nº 455, STJ: “A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.”

## QUESTÕES

**1- (2020/FGV/TJ-RS/Oficial de Justiça)** Quanto à intimação da sentença, é correto afirmar que:

- a) se dará mediante edital, no caso de infração afiançável, ainda que o réu tenha constituído advogado e este tenha sido intimado;
- b) é presumida quando o réu constitui advogado particular;
- c) a do Ministério Público se dará mediante mandado a ser cumprido por oficial de justiça;
- d) quando o réu constituir defensor, se dará na pessoa deste;
- e) será pessoal, no caso de réu preso.



**2- (2020/CESPE/TJ-PA/Oficial de Justiça)** Se um acusado, citado por edital, não comparecer para defender-se em ação penal pelo crime de falsidade ideológica, nem constituir advogado, o juiz

- a) deverá decretar a prisão preventiva do réu.
- b) determinará a interrupção do curso do prazo, que é prescricional.
- c) decretará revelia do réu e dará seguimento ao processo com defensor dativo.
- d) poderá determinar a produção de provas consideradas urgentes.
- e) suspenderá o processo e o curso do prazo, que é decadencial.

**3- (2019/VUNESP/TJ-RO/Juiz de Direito Substituto – adaptada)** Tício foi denunciado pelo Ministério Público pela prática de crime tributário (apenado com reclusão de 2 a 5 anos), em vista de sonegação de imposto, no montante de 1 milhão de reais. Citado, apresentou resposta à acusação, tendo arrolado 8 testemunhas de defesa, duas delas residentes fora da jurisdição, tendo sido expedidas cartas precatórias, com prazo de cumprimento de 90 dias. Ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, com exceção das duas residentes fora da jurisdição, tendo esgotado o prazo de cumprimento da precatória, Tício foi interrogado, abrindo-se vista às partes para apresentação de alegações finais. O órgão de acusação manifestou-se pela absolvição de Tício, por não restar comprovada a autoria. Já a defesa, alegou cerceamento de defesa, por não se aguardar o retorno das cartas precatórias. Conclusos os autos ao Juiz, foi proferida sentença condenatória. Na sentença, a despeito da não imputação pelo órgão da acusação, o Juiz reconheceu a causa de aumento prevista na legislação de crimes tributários, consistente na ocorrência de grave dano à coletividade, pelo valor sonegado, incidindo aumento da pena de 1/3. Diante da situação hipotética, julgue o item.

Haja vista a expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas de defesa residentes fora da jurisdição, o Juiz não poderia ter sentenciado o feito, devendo, ao contrário, ter suspenso o processo, até o retorno.

**4- (2019/FGV/MPE-RJ/Oficial do Ministério Público – adaptada)** Bruno foi denunciado como incurso nas sanções penais previstas no art. 215-A do Código Penal, sendo deferida sua liberdade provisória por ocasião da audiência de custódia. O denunciado foi citado e apresentou resposta à acusação, não sendo oferecida proposta de suspensão condicional do processo por responder a outras ações penais pelo mesmo tipo penal. Ocorre que, no momento da intimação para realização da audiência de instrução e julgamento, Bruno não foi localizado pelo oficial de justiça no endereço informado. O Ministério Público diligenciou e buscou a intimação de Bruno em todos os endereços obtidos, inclusive através de seus oficiais, não sendo o réu localizado, tendo apenas a irmã do acusado informado aos oficiais que ele tinha mudado de endereço, apesar de essa informação não ter sido prestada por Bruno ao juízo. Considerando apenas as informações expostas, após todas as diligências realizadas pelo Ministério Público, o magistrado poderá:

- a) poderá decretar a revelia do réu, persistindo ao Ministério Público a obrigação de comprovar a autoria e materialidade do crime, mas Bruno não mais precisará ser intimado pessoalmente para eventuais próximas audiências;
- b) poderá decretar a revelia do réu, que não gera presunção de veracidade dos fatos imputados, devendo Bruno continuar sendo intimado dos demais atos processuais que venham a ocorrer;
- c) não poderá decretar a revelia do réu, devendo a instrução prosseguir até o momento do interrogatório, quando a presença do acusado é indispensável;
- d) não poderá decretar a revelia do réu, devendo o processo, imediatamente, ficar suspenso, assim como o curso do prazo prescricional;
- e) poderá decretar a revelia do réu, gerando presunção de veracidade dos fatos imputados.

**5- (2018/CESPE/DPE-PE/Defensor Público)** Joana, residente em Brasília – DF, está sendo processada em Recife – PE pela prática de crime de associação criminosa e roubo qualificado. Citada e intimada para interrogatório, a acusada alegou não possuir condições financeiras para contratar advogado nem para arcar com os custos do deslocamento para acompanhar o processo. Apresentou, ainda, testemunhas do fato e informou o endereço dessas testemunhas no estado da Bahia. A respeito da oitiva das testemunhas indicadas por Joana e do interrogatório da acusada, assinale a opção correta.

- a) Incumbirá ao juiz de Recife intimar as partes sobre a expedição da carta precatória para a oitiva das testemunhas de defesa, sob pena de nulidade absoluta por ofensa ao devido processo legal.
- b) O juiz deverá intimar as partes da data em que será realizada a oitiva das testemunhas deprecadas, sob pena de nulidade por ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório.
- c) Expedida a carta precatória para a oitiva das testemunhas de defesa, não haverá suspensão da instrução processual, que seguirá seu curso, não se podendo alegar ter havido prejuízo para a ampla defesa.

- d) Joana deverá ser interrogada necessariamente em Recife, lugar sede do órgão julgador, sob pena de nulidade por ofensa ao princípio da identidade física do juiz.
- e) A oitiva das testemunhas de defesa indicadas pela acusada poderá ocorrer por intermédio de carta precatória, cuja devolução condicionará a prolação da sentença criminal.

**6- (2017/CESPE/TRF-1ª REGIÃO/Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal)** José, vereador do município de Luziânia – GO, foi denunciado pela prática de crime doloso contra a vida praticado contra Antônio, policial rodoviário federal que, no momento do crime, se encontrava no exercício de suas funções em Brasília – DF. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. Caso seja realizada a citação de José por carta precatória, o prazo para apresentação de resposta à acusação será contado da data da realização do ato, não da juntada da precatória aos autos da ação penal.

**7- (2017/CESPE/TRF-1ª REGIÃO/Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal)** José, vereador do município de Luziânia – GO, foi denunciado pela prática de crime doloso contra a vida praticado contra Antônio, policial rodoviário federal que, no momento do crime, se encontrava no exercício de suas funções em Brasília – DF. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. Na hipótese de o oficial de justiça verificar que, na ocasião da citação, José tenha se ocultado para não ser citado, será procedida a sua citação por edital.

**8- (2017/UFG/TJ-GO/Juiz leigo)** Segundo o Código de Processo Penal, estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante

- a) mandado de citação.
- b) edital de citação.
- c) carta precatória.
- d) carta de ordem.
- e) carta rogatória.

**9- (2017/VUNESP/TJ-SP/Juiz Substituto)** Em matéria de citações e intimações, é correto afirmar que

- a) os prazos são contados da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem.
- b) nula a citação por edital que apenas indica o dispositivo da lei penal, sem transcrever a denúncia ou queixa, ou resumir os fatos em que se baseia.
- c) a citação do acusado por edital, se ele não comparecer ou constituir advogado, permite a produção antecipada de provas, sob o fundamento de decurso do tempo, e autoriza o decreto de prisão preventiva, se for o caso.
- d) nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação ou publicação da pauta, inclusive em *habeas corpus*.

**10- (2017/CESPE/PC-GO/Delegado de Polícia Substituto)** Com referência a citação e intimação no processo penal, assinale a opção correta.

- a) A citação do réu preso poderá ser cumprida na pessoa do procurador por ele constituído na fase policial.
- b) As intimações dos defensores públicos nomeados pelo juízo devem ser realizadas mediante publicação nos órgãos incumbidos da publicidade dos atos judiciais da comarca, e não os havendo, pelo escrivão, por mandado ou via postal.
- c) Os prazos para a prática de atos processuais contam-se da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem.
- d) Em função dos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual, é admissível a citação por edital e por hora certa nos procedimentos sumaríssimos perante juizado especial criminal.
- e) No procedimento comum, não se admite a citação ficta nem tampouco a contumácia do réu.

## COMENTÁRIOS

1. Gabarito: E.

- a) INCORRETA. Não existe previsão nesse sentido no art. 392 do CPP.
- b) INCORRETA. Não existe previsão nesse sentido no art. 392 do CPP.



c) INCORRETA. O art. 392 do CPP não trata da intimação do MP, forçando que se recorra ao art. 370 do CPP, que trata das intimações em geral. O §4º do art. 370 estabelece que a intimação do MP e do Defensor devem ser pessoais.

d) INCORRETA. A intimação ocorrerá para o réu e o defensor, conforme art. 392 do CPP.

e) CORRETA, conforme inciso I, do art. 392.

2. Gabarito: D.

a) INCORRETA. A prisão preventiva não deve ser determinada de maneira automática e objetiva, tal como transmite a alternativa. Em outras palavras, a revelia do réu não constitui, por si só, fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. Assim, é dever do magistrado demonstrar, com dados concretos extraídos dos autos, a necessidade da custódia do investigado, mormente se evidenciada a necessidade da medida em qualquer das hipóteses previstas pelo artigo 312 do CPP.

b) INCORRETA. Não haverá interrupção, mas sim suspensão. É o que se extrai da simples leitura do art. 366 do CPP.

c) INCORRETA. Tenhamos em mente que a regra é a suspensão da ação e do prazo prescricional (366 do CPP). A hipótese trazida na alternativa diz respeito a uma exceção trazida pelo legislador na Lei nº 9.613/98 – que dispõe, dentre outros temas, sobre a lavagem de capitais. Se fosse o caso, não se aplicaria o art. 366 do CPP, prosseguindo-se o feito até o julgamento, com a nomeação de defensor dativo (art. 2º, § 2º da Lei nº 9.613/98). Como estamos tratando do delito de falsidade ideológica, a regra do art. 366 do CP merece ser aplicada.

d) CORRETA, se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, poderá o magistrado (faculdade) determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes, ainda nos termos delineados no art. 366 do CPP.

e) INCORRETA. O prazo é prescricional, não decadencial, conforme elucida o art. 366 do CPP.

3. Gabarito: item INCORRETO, conforme art. art. 222, §1º, CPP: a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal.

4. Gabarito: A.

Conforme art. 367, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Trata-se de caso de revelia que no processo penal não produz efeito da presunção da veracidade dos fatos, como no CPC, tendo o único efeito de promover o andamento regular do processo sem que o acusado tenha direito de ser intimado dos atos posteriores (até sentença).

5. Gabarito: C.

a) INCORRETA. Súmula nº 155, STF: é relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha.

b) INCORRETA. Súmula nº 273, STJ: intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.

c) CORRETA, de acordo com o art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. § 1º A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal.

d) INCORRETA. Não há ofensa à identidade física do juiz. Ela será interrogada por carta precatória.

e) INCORRETA. Não condiciona a sentença, conforme art. 222, §2º, do CPP, que prevê que, findo o prazo marcado para cumprimento da carta precatória, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos.

6. Gabarito: questão CORRETA, conforme Súmula nº 710, STF.

7. Gabarito: questão INCORRETA. É o caso de citação por hora certa, conforme art. 362, CPP.

8. Gabarito: E, conforme art. 368, CPP.

9. Gabarito: A.



- a) CORRETA. Súmula nº 710, STF.
- b) INCORRETA. Súmula nº 366, STF.
- c) INCORRETO, conforme art. 366, CPP, lida em conjunto com a Súmula nº 455, STJ.
- d) INCORRETA. Súmula nº 431, STF.

**10. Gabarito: C.**

- a) INCORRETA. Deve ser realizada pessoalmente, conforme art. 360, CPP.
- b) INCORRETA. A intimação do Ministério Público e do Defensor Público nomeado será pessoal, conforme art. 370, § 4º, CPP.
- c) CORRETA. Súmula nº 710, STF.
- d) INCORRETA. No procedimento comum sumaríssimo, a citação deve ser pessoal, conforme art. 66, Lei nº 9.099/95. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei, realizando o chamado declínio de competência. Na vara criminal comum será adotado o procedimento comum sumaríssimo (art. 538 do CPP).
- e) INCORRETA. Art. 362, CPP.

**CAPÍTULO 20 – DA SENTENÇA (ARTS. 381 A 392 DO CPP)****1. INTRODUÇÃO**

O juiz ao longo do processo pratica uma série de atos processuais. Alguns deles estão previstos no art. 800 do CPP, quais sejam: a) decisões interlocutórias mistas; b) decisões interlocutórias simples; e c) despachos. A doutrina define cada um desses atos judiciais da seguinte forma:

a) Despachos: decisões do magistrado, sem abordar questão controvertida, com a finalidade de dar andamento ao processo sem que haja carga de cunho decisório (NUCCI, 2018, p. 656). Por meio do despacho de mero expediente, o juiz cumpre o princípio do impulso oficial, por exemplo, designando audiência, determinando a intimação das partes etc.

b) Decisões interlocutórias: “são soluções dadas pelo juiz, acerca de qualquer questão controvertida, envolvendo a contraposição de interesses das partes, podendo ou não colocar fim ao processo” (NUCCI, 2018, p. 656/657). Há duas espécies de decisões interlocutórias: i) decisões interlocutórias simples: “decisões que dirimem uma controvérsia, sem colocar fim no processo ou ao processo ou a um estágio do procedimento” (NUCCI, 2018, p. 657). Ex.: decretação de prisão preventiva, deferimento de interceptação telefônica, determinação de busca e apreensão; ii) decisões interlocutórias mistas ou decisões com força de definitivas: “decisões que resolvem uma controvérsia, colocando fim ao processo ou a uma fase dele” (NUCCI, 2018, p. 657). Ex.: pronúncia e impronúncia.

c) Decisões definitivas: “são as tomadas pelo juiz, colocando fim ao processo, julgando o mérito em sentido lato, ou seja, decidindo acerca da pretensão do Estado, mas sem avaliar a procedência ou improcedência da imputação” (NUCCI, 2018, p. 657). Ex.: decisão que reconhece uma causa de extinção de punibilidade.

José Frederico Marques adota classificação um pouco diversa a respeito da conceituação de decisões interlocutórias mistas, dividindo em terminativa e não terminativa. Assim dispondo o autor: a) decisão interlocutória mista terminativa: é a decisão que põe fim ao processo sem resolver o mérito da causa; b) decisão interlocutória mista não terminativa: é a decisão que põe fim a uma fase do procedimento.

Além das decisões, temos ainda a sentença.

d) Sentença: “decisão terminativa do processo e definitiva quanto ao mérito, abordando a questão relativa à pretensão punitiva do Estado, para julgar procedente ou improcedente a imputação” (NUCCI, 2018, p. 657). Essa é a sentença que estudaremos neste capítulo e prevista no art. 381 do CPP. Atenção, pois, o CPP utiliza o termo “sentença” também nos dispositivos legais referentes às decisões interlocutórias mistas e decisões definitivas, que não avaliam a imputação propriamente dita. A sentença pode ser condenatória (art. 387 do CPP) ou absolutória (art. 386 do CPP). Se diz condenatória quando o juiz conclui pela procedência (total ou parcial) da pretensão punitiva estatal deduzida na peça inicial acusatória, impondo ao autor do fato determinada sanção penal. Se diz absolutória quando se julga improcedente a pretensão punitiva do Estado. Esta última possui duas subespécies: i) sentença absolutória própria: simples absolvição do réu, sem qualquer outra consequência/providência; ii) sentença absolutória imprópria: ocorre nos casos em que a existência do crime e a autoria são reconhecidas, mas o acusado, em razão de sua inimizabilidade, não é condenado, aplicando a sanção da medida de segurança, que também restringe a liberdade do agente. Como bem aponta a doutrina, há uma condenação disfarçada de absolvição, cabendo, inclusive revisão criminal.



## 2. CLASSIFICAÇÃO DAS SENTENÇAS

As sentenças podem ser classificadas de acordo com seus efeitos preponderantes, levando em consideração o elemento que prepondera ao ser proferida:

a) Declaratórias: “são as sentenças que absolvem ou julgam extinta a punibilidade” (NUCCI, 2018, p. 657).

b) Condenatórias: “são as sentenças que julgam procedente (total ou parcial) a pretensão punitiva estatal” (NUCCI, 2018, p. 657).

c) Constitutivas: são aquelas que constituem um novo estado jurídico, sendo raras no processo penal, podendo-se citar o exemplo daquela que em *habeas corpus* determina o trancamento de investigação criminal (TAVORA; ALENCAR, 2019, p. 591).

d) Mandamentais: contém uma ordem judicial, a ser imediatamente cumprida, sob pena de desobediência (TAVORA; ALENCAR, 2019, p. 592), como na expedição de alvará de soltura após a concessão de ordem de *habeas corpus*.

e) Executivas: já trazem no seu bojo sua eficácia executiva, como no instituto do sequestro (TAVORA; ALENCAR, 2019, p. 654).

A doutrina italiana apresenta classificação importante:

a) Sentença suicida ou incoerente: é aquela cujo dispositivo (ou conclusão) contraria sua fundamentação, sendo, portanto, considerada nula, a não ser que o vício seja sanado pelo órgão jurisdicional em virtude da oposição de embargos declaratórios. Ex.: condena na fundamentação e absolve no dispositivo.

b) Sentença autofágica: é aquela em que há o reconhecimento da imputação, mas o juiz acaba por declarar extinta a punibilidade, como no perdão judicial. Segundo o STJ, a sentença em questão é meramente declaratória (Súmula nº 18). Para outra corrente, a sentença é condenatória, subsistindo todos os efeitos secundários da condenação. Já prevaleceu na jurisprudência do STF no passado (RE 115.995; RE 104.978). Nesse sentido, ainda, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar (TAVORA; ALENCAR, 2019, p. 675), Noronha, Hungria, Damásio, Mirabete.

c) Sentença vazia: é aquela passível de anulação por falta de fundamentação. Diante da ausência de motivação do ato jurisdicional, é possível o reconhecimento de sua nulidade absoluta, haja vista a imposição de fundamentação pela Constituição Federal.

d) Sentença subjetivamente simples: proferida por um órgão singular. Ex.: juiz singular.

e) Sentença subjetivamente plúrima: emanada de órgão colegiado homogêneo. Ex.: desembargadores de determinada Turma, Câmara, Seção de um Tribunal.

f) Sentença subjetivamente complexa: é a que emana de vários órgãos, de várias vontades. Proferida por órgão colegiado heterogêneo, tal como o tribunal do júri (7 jurados + 1 juiz).

Atenção: sentença dupla ou dupla sentença: em uma de suas teorias, amplamente difundidas no Brasil, Zaffaroni trata da medida das penas criminais, intitulado um ensaio de sua autoria de *Las penas crueles y la doble punición (La medida del castigo, el deber de compensación por penas ilegales*, p. 355-376). O autor utiliza o termo *doble punición* ou dupla sentença na sua abordagem jurídica. Ambos se referem ao fato dos encarcerados, normalmente, não cumprirem simplesmente as penas que lhes foram impostas judicialmente. Não sofrem apenas os efeitos da pena em si (efeitos principais e secundário), mas muito além disso, sofrem dentro dos presídios

outras penas arbitrárias, que são cruéis, desumanas e degradantes, em razão das condições do sistema prisional que, na prática, são ignoradas pelo Estado (mazelas do sistema prisional).

### 3. REQUISITOS DA SENTENÇA

O título XII do Código de Processo Penal (CPP) é “Da Sentença”. Já no artigo inaugural do citado título, o legislador nos diz o que uma sentença criminal deve conter. O art. 381 do CPP apresenta os requisitos intrínsecos, elementos que devem necessariamente estar presentes, sob pena de nulidade, nos termos do art. 564, IV, do CPP.

Art. 381. A sentença conterá:

- I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las;
- II - a exposição sucinta da acusação e da defesa;
- III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;
- IV - a indicação dos artigos de lei aplicados;
- V - o dispositivo;
- VI - a data e a assinatura do juiz.

“Art. 564. IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato.”

Os requisitos acima elencados podem ser divididos nas seguintes partes:

#### 3.1. RELATÓRIO

Os incisos I e II do artigo 381 trazem o dever do relatório na sentença. Em simples palavras, relatar é contar a história do processo até a data em que os autos vieram conclusos para sentença.

O relatório de uma sentença penal pode ser mais detalhado ou não, a depender do estilo do julgador. Mas, vale ressaltar, o Diploma Processual dispõe que a exposição da acusação e da defesa deve ser sucinta.

A ausência de relatório acarreta nulidade absoluta, saldo nos processos em trâmite no Juizado Especial Criminal, em que o relatório é dispensado, conforme art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

“Art. 81, § 3º. A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do Juiz.”

#### 3.2. FUNDAMENTAÇÃO

A necessidade de fundamentação das decisões decorre da possibilidade de o juiz, ante a discricionariedade peculiar à sua função, incorrer em equívocos. A fundamentação permite o exame lógico da decisão, tanto pelos sujeitos do processo, como pelos Tribunais, e acaba por ser o meio que permite à sociedade fiscalizar a atuação do magistrado, uma vez que tem a sua disposição os fundamentos lógicos que explicam a escolha tomada no ato de decidir. Por isso, a presença da fundamentação no ato jurisdicional que encerra o processo é essencial.

Consiste, portanto, na obrigação de o juiz demonstrar todos os motivos que o levaram a decidir um caso de determinada forma. Isso acontece para que se demonstre uma transparência da atividade jurídica, sendo possível o exercício adequado do controle das decisões judiciais.

A carência de fundamentação é causa de nulidade absoluta, uma vez que a Constituição Federal exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, conforme art. 93, IX. Ademais, o



dever de fundamentação é exigido pelo sistema adotado no Brasil quanto à avaliação das provas, qual seja, o livre convencimento motivado. A previsão de nulidade absoluta está expressa no art. 564, V, CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime):

“Art. 564, V - em decorrência de decisão carente de fundamentação.”

**Atenção:** é nulo o acórdão que se limita a ratificar a sentença e a adotar o parecer ministerial, sem sequer transcrevê-los, deixando de afastar as teses defensivas ou de apresentar fundamento próprio. Isso porque, nessa hipótese, está caracterizada a nulidade absoluta do acórdão por falta de fundamentação. No entanto, a jurisprudência admite a chamada fundamentação *per relationem*, mas desde que o julgado faça referência concreta às peças que pretende encampar, transcrevendo delas partes que julgar interessantes para legitimar o raciocínio lógico que embasa a conclusão a que se quer chegar. A motivação ou fundamentação *per relationem* ou *aliunde*, também denominada de motivação referenciada, por referência ou por remissão, é aquela por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo. (STJ. 6ª Turma. HC 214.049-SP - Info 557). O entendimento também é adotado pelo STF:

O entendimento esposado na decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com o posicionamento desta Suprema Corte, no sentido de que a adoção dos fundamentos da sentença de 1º grau pelo julgado de Segunda Instância como razões de decidir, por si só, não caracteriza ausência de fundamentação, desde que as razões adotadas sejam formalmente idôneas ao julgamento da causa, sem que tanto configure violação da regra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal (HC 94384).

Atenção: o CPC de 2015 traz norma bastante útil para o entendimento sobre a correta fundamentação a ser feita em uma sentença. Confira o art. 489, § 1º, CPC:

Art. 489, § 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Com a Lei nº 13.964/2019, o CPP passa a ter previsão bem semelhante no art. 315, § 2º:

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Em que pese o dispositivo legal tenha sido inserido pelo legislador no título relativo à “prisão, medidas cautelares e liberdade provisória”, resta evidente pela redação dada ao § 2º que não se aplica apenas no regime de prisões, mas também em qualquer sentença ou decisão no âmbito do processo penal dada a utilização da redação “qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão”.

### 3.3. DISPOSITIVO

É a conclusão da fundamentação. A ausência também acarreta nulidade absoluta.

Atenção: a doutrina ainda aponta requisitos extrínsecos, como a data e a assinatura do juiz na sentença.

### 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Em possuindo a sentença vício de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, o art. 382 do CPP autoriza que qualquer das partes, no prazo de dois dias, peça ao juiz que a declare:

“Art. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.”

Já contra acórdão de Tribunal, o mesmo recurso está previsto no art. 619 do CPP:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

No Juizado Especial Criminal, esse recurso pode ser oposto contra sentença ou acórdão que contenha obscuridade, contradição e omissão e poderá ser oferecido no prazo de cinco dias, nos termos do art. 83 da Lei nº 9.099/95.

Art. 83. Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

### 5. EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP)

A *emendatio libelli* ocorre quando o juiz, ao condenar ou pronunciar o réu, altera a definição jurídica (a capitulação do tipo penal) do fato narrado na peça acusatória, sem, no entanto, acrescentar qualquer circunstância ou elementar que já não esteja descrita na denúncia ou queixa. É permitida, mesmo que seja para aplicar pena mais grave.

O juiz realiza a correção da capitulação no momento de proferir a sentença, não havendo nenhuma irregularidade ou invalidade em proceder dessa forma, principalmente porque o requisito imprescindível da denúncia é a descrição dos fatos com todas as suas circunstâncias (art. 41

do CPP) e não a capitulação, exatamente porque esta pode ser corrigida no momento de proferir a sentença.

Isto é, o autor da ação penal (Ministério Público ou ofendido), na peça inicial (denúncia ou queixa-crime), narrou corretamente os fatos e suas circunstâncias, mas se equivocou na imputação/tipificação deles.

O princípio da correlação ou da congruência significa que a sentença não poderá condenar o acusado por fatos não narrados na denúncia ou queixa, sob pena de incorrer em decisão *ultra* ou *extra petita*, sendo isso causa de nulidade absoluta.

No caso do art. 383 do CPP, como os fatos, desde o início, foram narrados corretamente, permite-se que o juiz, de ofício, realize a correção da tipificação jurídica, sem necessidade de aditamento à denúncia.

A *emendatio libelli* está prevista no art. 383 do CPP:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

§ 1º Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei.

§ 2º Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.

É possível que o tribunal, no julgamento de um recurso contra a sentença, faça *emendatio libelli*, desde que não ocorra *reformatio in pejus*. Nesse sentido:

Nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal, *emendatio libelli* consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intacta a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal. O momento adequado à realização da *emendatio libelli* pelo órgão jurisdicional é o momento de proferir sentença, haja vista que o *Parquet* é o titular da ação penal, a quem se atribui o poder-dever da capitulação jurídica do fato imputado. Como corolário da devolutividade recursal vertical ampla, inerente à apelação, desde que a matéria tenha sido devolvida em extensão, plenamente possível ao Tribunal realizar *emendatio libelli* para a correta aplicação da hipótese de incidência, desde que dentro da matéria devolvida e não implique *reformatio in pejus*, caso haja recurso exclusivo da defesa. (STJ, HC 427.965/SP).

**Atenção:** se em decorrência da *emendatio libelli* ocorrer a desclassificação do crime para outro juízo competente, a este deverão os autos serem remetidos, conforme § 2º do art. 383 do CPP. Ex.: está julgando um crime de lesão corporal seguida de morte, mas percebe se tratar de um delito de homicídio doloso, de competência do Tribunal do Júri.

**Atenção:** se em virtude da *emendatio libelli* for possível a concessão do benefício da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o juiz deverá abrir vista ao Ministério Público para que ofereça ao denunciado o benefício. Lembre-se do importante teor da Súmula nº 337 do STJ:

Súmula nº 337, STJ: “É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.”

## 6. MUTATIO LIBELLI(ART 384 DO CPP)

A *mutatio libelli* ocorre quando, no curso da instrução processual, surge prova de alguma circunstância que não havia sido narrada expressamente na denúncia ou queixa. Ex.: denúncia apresentada com a capitulação do crime de furto. Na audiência, a vítima afirma que no

momento da subtração o agente a ameaçou com uma faca. Devido à grave ameaça para subtrair o bem, o crime não é de furto, mas de roubo, sendo que esta circunstância não estava previamente narrada na inicial acusatória. Portanto, será necessário realizar o aditamento da denúncia. O instituto está previsto no art. 384 do CPP:

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente

§ 1º Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o art. 28 deste Código.

§ 2º Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento.

§ 3º Aplicam-se as disposições dos §§ 1º e 2º do art. 383 ao *caput* deste artigo.

§ 4º Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3 (três) testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento.

§ 5º Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá.

Importante analisar se o aditamento é de iniciativa e responsabilidade do Ministério Público ou se o juiz pode provocar essa atuação, havendo divergência doutrinária a respeito do tema.

De um lado a doutrina aponta que a iniciativa do aditamento deve ser inteiramente do Ministério Público, não cabendo ao juiz invocar o acusador para que realize a correção da inicial acusatória, sob pena de subversão à lógica do sistema processual penal que é regido pelo sistema acusatório LOPES JR., 2010, p. 405). E não procedendo o Ministério Público ao aditamento, em prol do sistema acusatório, nenhuma providência deve adotar o magistrado, vinculando-se ao que consta do conteúdo da exordial acusatória, o que provavelmente acarretará absolvição do réu.

De outro lado, entende parte da doutrina que o juiz, como fiscal do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, pode conceder o prazo de cinco dias para que o aditamento fosse realizado (NUCCI, 2018, p. 666).

Ressalte-se que a primeira linha de pensamento é reforçada pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime), que deu nova redação ao art. 28 do CPP, prevendo que o arquivamento do inquérito policial é efetivado por ato próprio do órgão de acusação não passando mais por controle judicial. Desse modo, é possível verificar que o § 1º do art. 384 do CPP restou prejudicado, já que faz menção ao art. 28 do CPP. No entanto, como frisado, se não há mais controle judicial do arquivamento, não haverá controle judicial na realização ou não de aditamento.

Deve ser destacada, ainda, a possibilidade de que o aditamento seja realizado pelo ofendido, mesmo na ação penal pública, em se tratando de inércia do Ministério Público, com base no art. 29 do CPP, que se refere à ação penal privada subsidiária da pública. Isto é, o ofendido oferecerá o aditamento após verificar que o órgão acusatório para tanto assim não procedeu (NUCCI, 2018, p. 665).

De qualquer sorte, se nem o Ministério Público nem o ofendido realizarem o aditamento da denúncia, nada impede que o membro do Ministério Público, em razão da absolvição pelos fatos apresentados anteriormente, ofereça nova denúncia para apurar, em novo processo, os fatos não contidos naquele (aditamento real/objetivo), ou em face de novos agentes (aditamento pessoal/subjetivo) (TÁVORA; ALENCAR, 2019, p. 197).

O aditamento será realizado no prazo de cinco dias por escrito, mas nada impede que seja realizado oralmente, desde que seja reduzido a termo, podendo o Ministério Público arrolar até mais três testemunhas. Após o magistrado abrirá para o contraditório da defesa, ouvindo o defensor do acusado também no prazo de 5 (cinco) dias. Admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de



qualquer das partes, designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento.

O aditamento à queixa ou denúncia faz com que o juiz, na sentença, fique adstrito aos novos fatos e circunstâncias, em mais uma aplicação importante do princípio da correlação ou congruência entre acusação e sentença. Em sendo assim, não pode o magistrado condenar o réu com base na imputação contida na inicial acusatória originária, ou seja, antes da realização do aditamento.

#### Atenção:

a) não é possível a realização de *mutatio libelli* em segunda instância. Caso o Tribunal, em grau de recurso, aprecie um fato não valorado pelo juiz, haverá supressão de instância. Nesse sentido é o entendimento sumulado pelo STF:

Súmula nº 453-STF: Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.

b) contra a decisão de recebimento do aditamento não cabe recurso e sim o manejo de ação autônoma de impugnação de *habeas corpus*. Por outro lado, da rejeição do aditamento cabe a interposição de recurso em sentido estrito, por interpretação extensiva à previsão do art. 581, I, CPP;

c) o recebimento do aditamento que acrescenta novo fato é causa interruptiva da prescrição (à semelhança do que ocorre no art. 117, I, CP), mas somente em relação a este novo fato (STJ, RHC 14937/RS; STF, HC 84606);

d) o réu denunciado por crime na forma consumada pode ser condenado em sua forma tentada, mesmo que não tenha havido aditamento à denúncia. A tentativa não é uma figura autônoma. Assim, não há nulidade por ofensa ao art. 384 do CPP quando o magistrado se limita a dar definição jurídica diversa (crime tentado) da que constou na denúncia (crime consumado), inclusive porque aplicará pena menos grave (STJ, HC 297.551-MG - Info 557);

e) o réu denunciado por crime na forma dolosa não pode ser condenado em sua forma culposa. Quando na denúncia não houver descrição sequer implícita de circunstância elementar da modalidade culposa do tipo penal, o magistrado, ao proferir a sentença, não pode desclassificar a conduta dolosa do agente (assim descrita na denúncia) para a forma culposa do crime. A prova que o réu tem que produzir para provar que não agiu com negligência, imprudência ou imperícia é diferente da prova que deverá produzir para demonstrar que não agiu com dolo (vontade livre e consciente). Assim, deve observar a regra inserta no art. 384, *caput*, do CPP, realizando o aditamento da inicial a fim de possibilitar a ampla defesa. (STJ, HC 297.551-MG - Info 557). Nesse sentido, é importante frisar o posicionamento de Gustavo Badaró que é referência no assunto sobre a correlação entre acusação e sentença:

Na verdade, o que faz com que uma imputação por ato doloso dê origem a uma sentença por delito culposos é a descoberta de novos fatos que indicam que o agente não teve consciência e vontade do resultado, mas, sim, que sua maneira de agir representou uma violação do dever de cuidado a todos imposto. Assim, não se pode admitir alteração do elemento subjetivo do delito sem que ocorra uma alteração da imputação, com a possibilidade de reação defensiva. Embora o elemento subjetivo, em si, não integre o fato processual, somente a alteração dos fatos lançados no processo é que permitirá concluir pela alteração do elemento subjetivo. (BADARÓ, 2013, p. 225.)

#### Atenção ao resumo:

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Emendatio libelli – art. 383 do CPP | Mutatio Libelli – art. 384 do CPP |
|-------------------------------------|-----------------------------------|



|                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fato está descrito na denúncia.                      | Fato não está descrito na denúncia.                 |
| Aplica-se em 1º e 2º graus.                          | Aplica-se apenas em 1º grau – Súmula nº 453 do STF. |
| Não precisa ouvir as partes (*críticas na doutrina). | Precisa ouvir as partes.                            |
| Não precisa de aditamento (é feito de ofício).       | Precisa de aditamento.                              |

## 7. ANÁLISE DO ART. 385 DO CPP

De acordo com o art. 385 do CPP, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Apesar de o art. 385 do CPP sofrer diversas críticas doutrinárias por infringir o sistema acusatório, sobretudo após a Lei nº 13.964/2019, como foi tratado no capítulo sobre sistemas processuais, a posição ainda é minoritária e nas provas o dispositivo legal é cobrado de forma literal, devendo o candidato ter atenção à letra da lei.

É possível que o juiz condene o réu, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. No entanto, isso somente será possível na ação penal pública. Entende a jurisprudência que não há adoção do sistema acusatório puro, de forma que não haveria problema em condenar apesar do pedido de improcedência (STJ, HC 444843). A doutrina ainda aponta outro argumento. Aduz que a pretensão da acusação é veiculada pela denúncia e não pelos memoriais. Assim, não podem estes limitar a pretensão (DEZEM, 2019, p. 985). Na ação penal privada, o querelante deverá requerer a condenação do acusado, necessariamente, caso contrário o juiz irá declarar extinta a punibilidade do autor do fato pela perempção, nos termos do art. 60, III, CPP.

Além disso, o art. 385 do CPP permite que o juiz reconheça na sentença penal condenatória agravantes, mesmo que nenhuma delas tenha sido alegada pela acusação. Para a corrente majoritária, tal conduta é possível. No mesmo sentido caminha o STJ, que entende que “não há ofensa ao princípio da congruência a condenação por agravantes não descritas na denúncia”. (HC 381.590/SC; AgRg no REsp 1612551/RJ).

## 8. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (ART. 386 DO CPP)

Sentença absolutória é aquela que julga improcedente a pretensão punitiva. Possui duas subespécies: i) sentença absolutória própria: simples absolvição do réu, sem qualquer outra consequência/providência; ii) sentença absolutória imprópria: ocorre nos casos em que a existência do crime e a autoria são reconhecidas, mas o acusado, em razão de sua inimputabilidade, não é condenado, aplicando a sanção da medida de segurança, que também restringe a liberdade do agente. Como bem aponta a doutrina, há uma condenação disfarçada de absolvição, cabendo, inclusive revisão criminal.

Os casos de absolvição própria do réu são aqueles previstos nos incisos I a VII do art. 386 do CPP (rol taxativo):

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

- I - estar provada a inexistência do fato;
- II - não haver prova da existência do fato;
- III - não constituir o fato infração penal;
- IV - estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;
- V - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;
- VI - existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;
- VII - não existir prova suficiente para a condenação.



Efeitos principais da sentença penal absolutória (art. 386, parágrafo único, CPP):

Art. 386.

Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz:

I - mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade;

II – ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas;

III - aplicará medida de segurança, se cabível.

Inciso I: o primeiro deles, é o direito de liberdade que terá o réu, independentemente de recurso da acusação, salvo se por outro motivo estiver preso.

Inciso II: o juiz deverá, dentre outras providências mencionadas no citado parágrafo, ordenar a cessação das medidas cautelares que foram provisoriamente aplicadas, tais como o sequestro, o arresto e a hipoteca legal.

Inciso III: admite a hipótese de aplicação da medida de segurança (art. 97, CP), na hipótese de sentença absolutória imprópria.

Efeitos civis da sentença penal absolutória (art. 66, CPP): se o juiz penal proferir sentença penal absolutória, de regra, essa circunstância não é impeditiva da propositura da ação civil. Isto é, pode, inclusive o ofendido, antecipar-se a propositura da ação penal e ingressar no juízo civil (art. 64, CPP) postulando a satisfação do dano em relação ao autor do crime e, se for o caso, em relação ao seu responsável civil (art. 932, CC).

Abaixo os reflexos na responsabilidade civil (ação civil *ex delicto*) diante das hipóteses do art. 386 do CPP.

- a) provada a inexistência do fato: não há responsabilidade civil;
- b) não haver prova da existência do fato: pode haver discussão na esfera cível;
- c) não constituir o fato infração penal: pode haver ilícito civil e dever de indenizar;
- d) estar provado que o réu não concorreu para a infração penal: não há responsabilidade civil;
- e) não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal: pode haver discussão na esfera cível;
- f) prova de excludente de culpabilidade: pode haver discussão na esfera cível;
- g) prova da excludente de ilicitude: g.1) legítima defesa: em regra, torna o ato ilícito também na esfera cível, sendo exceção o caso de *aberratio ictus*; g.2) estado de necessidade: em regra, torna o ato lícito também na esfera cível, sendo exceção o caso em que o lesado não foi o causador do perigo; g.3) estrito cumprimento de dever legal: torna o ato lícito também na esfera cível; g.4) torna o ato lícito também na esfera cível.

## 9. PROVIDÊNCIAS AO PROFERIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA

A sentença penal condenatória, além de ter que conter os elementos intrínsecos analisados no art. 381 do CPP, deverá necessariamente incluir os elementos previstos nos incisos do art. 387 do CPP, quais sejam:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

I - mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer;

II - mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - aplicará as penas de acordo com essas conclusões;

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

V - atenderá, quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, ao disposto no Título XI deste Livro;

VI - determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal em que será feita a publicação (art. 73, § 1º, do Código Penal).

§ 1º O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

### 9.1. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO (ART. 387, IV, CPP)

Dentre os elementos da sentença penal condenatória, merece destaque a previsão do inciso IV. A sentença penal condenatória, depois de transitada em julgado, produz diversos efeitos, dentre eles a obrigação de o réu reparar o dano causado pela infração penal. Dispõe o art. 91, I, do CP:

“Art. 91. São efeitos da condenação: I - Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;”

A sentença penal condenatória transitada em julgado, inclusive, é título executivo judicial, conforme previsão do art. 515, VI do CPC.

“Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;”

Assim, a vítima (ou seus sucessores), de posse da sentença definitiva que condenou o réu, poderá executar o título judicial no juízo cível para cobrar o ressarcimento pelos prejuízos sofridos em decorrência do crime.

Apesar de ser reconhecida a obrigação de indenizar (*an debeat*), antes da Lei nº 11.719/2008, não era possível que a vítima (ou seus sucessores) executasse imediatamente a sentença, porque não havia definição ainda do valor de indenização (*quantum debeat*). Com isso, era necessária a liquidação da sentença antes da execução.

O legislador, atento a essa situação da vítima, e, por meio da Lei nº 11.719/2008, alterou o CPP, prevendo que o juiz criminal, ao condenar o réu, poderá estabelecer um valor mínimo que o condenado estará obrigado a pagar a título de reparação dos danos causados.

Por isso, o artigo 387 do Código de Processo Penal dispõe, em seu inciso IV, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Para isso, é preciso que o autor da ação penal tenha requerido, na inicial acusatória, a condenação do acusado ao pagamento de indenização mínima à vítima (STJ, HC 321.279/PE).

Não será necessário que se promova a liquidação, bastando que se execute este valor caso não seja pago voluntariamente pelo condenado. Nada impede que a vítima pleiteie indenização maior no juízo cível, já que, como descrito no dispositivo legal supracitado, a indenização pode ser fixada pelo juiz criminal apenas no valor mínimo e não integral do dano. Assim, a vítima poderá executar desde logo este valor mínimo e pleitear um valor maior do que o fixado na sentença, bastando, para isso, que prove que os danos que sofreu foram maiores que a quantia estabelecida na sentença. Essa prova é feita em fase de liquidação no procedimento comum.

Observações:

a) A regra do art. 387, inciso IV, do CPP, é norma híbrida, de direito processual e material, razão pela qual não se aplica a delitos praticados antes da entrada em vigor da Lei nº



11.719/2008, que deu nova redação ao dispositivo (STJ, REsp 1.193.083-RS; STJ, AgRg no REsp 1.206.643/RJ; STF, RvC 5437/RO).

b) É possível que o autor da ação penal, Ministério Público ou querelante, não tenha pedido a fixação de indenização mínima na inicial acusatória. Nesse caso, é incabível a fixação de tal indenização, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência.

c) Tendo havido pedido de indenização mínima, o juiz pode/deve fixar indenização, inclusive, a título de dano moral (STJ, REsp 1.585.684-DF), em prestígio à ideia da justiça restaurativa e da terceira via da pena (função da pena de restaurar a situação que a vítima tinha antes da prática do crime).

d) A Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos representativos da controvérsia (Tema 983), assentou a tese de que nos casos de violência doméstica contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (STJ, 3ª Seção, REsp 1643051/MS).

e) O juiz, na sentença penal condenatória por crime ambiental, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, poderá a execução ser efetuada pelo valor fixado na sentença, sem prejuízo da liquidação para a descoberta e reparação do valor efetivamente sofrido, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.605/98.

f) Caso haja pedido expresso de valor mínimo de reparação dos danos, mas o magistrado deixar de reconhecê-lo ou mesmo fixado em valor que desagrada o ofendido, é possível a interposição de recurso de apelação, nos termos do art. 593 do CPP. No caso de o juiz deixar de reconhecer o valor mínimo de reparação de danos, podem recorrer tanto o Ministério Público (que fez o requerimento na inicial acusatória) como a vítima, na condição de assistente de acusação. No caso de o juiz ter fixado valor, no entanto, que desagrada a vítima, apenas esta poderá recorrer na condição de assistente de acusação, faltando interesse ao Ministério Público, já que atendido o seu “pedido” da inicial.

## **9.2. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO QUE DECORRE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (ART. 387, § 1º, CPP)**

A chamada prisão decorrente de sentença condenatória recorrível não é mais automática, assim, o réu não ficará mais necessariamente e automaticamente preso se for condenado. Isso apenas ocorrerá se houver necessidade exigindo-se nova decisão devidamente fundamentada pelo juiz.

Se o acusado permaneceu preso ao longo de toda a instrução processual, provavelmente, com a condenação, restará ainda mais evidente a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas, mesmo assim, o juiz deverá fundamentar a manutenção da prisão preventiva.

Quanto a isso, tem manifestado a jurisprudência que se o acusado permaneceu preso durante o processo e não houver alteração na situação fática, não há justificativa para que ele seja solto (STJ, HC 99736).

Por outro lado, se o acusado permaneceu solto durante o processo, para que seja imposta alguma medida cautelar, seja ela a mais gravosa (prisão preventiva) ou diversa, deverá o juiz motivar de maneira idônea a imposição da medida.

## **9.3. DETRAÇÃO PENAL (ART. 387, § 2º, CPP)**

Antes de fixar o regime inicial de cumprimento da pena, o juiz deve realizar a detração, ou seja, contabilizar o tempo de prisão provisória a que ficou submetido o réu.

O Código de Processo Penal dispõe no artigo 387, §2º, que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Como a detração é realizada antes de fixação do regime inicial, há três correntes sobre seus efeitos:

Primeira corrente: a detração só terá o condão de alterar o regime inicial a ser fixado se o tempo de prisão provisória corresponder, pelo menos, ao requisito objetivo de progressão de regime, conforme, de regra, o art. 112 da Lei de Execução Penal. Lembrando que o referido artigo também foi modificado pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime). Assim, por exemplo, se João, primário e que tenha praticado crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, foi condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão e está preso há 6 meses, o regime inicial de cumprimento de sua pena será o fechado (artigo 33, §2º, do CP), a despeito de restarem apenas 7 anos e 8 meses de reclusão a serem cumpridos, tendo em vista que não cumpriu 16% da pena imposta.

Segunda corrente: é a pena final, após a detração, o parâmetro para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, não sendo relevante aferir se o tempo de custódia cautelar supera a fração do requisito objetivo de cumprimento de pena. Assim, por exemplo, se João da Silva foi condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão e está preso há 6 meses, o regime inicial de cumprimento de sua pena será o semiaberto (artigo 33, §2º, do CP), pois restam apenas 7 anos e 8 meses de reclusão a serem cumpridos (pena não superior a 8 anos de reclusão).

Terceira corrente: para a progressão de regime é necessário que estejam presentes requisitos legais objetivos e subjetivos (art. 112, LEP), não bastando o cumprimento dos percentuais de progressão. Assim, a detração não tem o condão de alterar o regime inicial. Caberá ao juízo da execução verificar se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão.

## 10. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA

Quanto à intimação da sentença, o CPP tem um regramento minucioso. O acusado será, em qualquer hipótese, intimado pessoalmente. A intimação deverá ser feita sempre pessoalmente ao réu. Na hipótese de não ser encontrado, a intimação deverá ser feita por edital. O defensor do acusado também deverá ser intimado da sentença, pessoalmente ou por edital. Veja o que dispõe o CPP:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

IV - mediante edital, nos casos do no II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;

V - mediante edital, nos casos do no III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça.

§ 1º O prazo do edital será de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, e de 60 dias, nos outros casos.

§ 2º O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo.



Atenção: há necessidade de intimação do réu, mesmo que revel, após a prolação de sentença (seguindo as regras do art. 392 do CPP), afinal, de acordo com o art. 577 do CPP tanto o acusado como seu advogado possuem legitimidade para a interposição de recurso. Não importa, porém, a ordem dos referidos atos processuais de intimação, sendo certo que o prazo para a interposição de recurso será contado da data da última intimação (STJ, HC 217.554/SC; Súmula nº 710 do STF).

## QUESTÕES

**1- (2020/FCC/TJ-MS/Juiz Substituto)** Quanto à sentença, correto afirmar que o juiz

- a) poderá declarar a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, se qualquer das partes o requerer no prazo de 5 (cinco) dias.
- b) poderá, sem modificar a descrição contida na denúncia ou queixa, atribuir ao fato definição jurídica diversa e, havendo possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, procederá de acordo com o disposto na lei, ainda que, por força do crime continuado, a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a um ano.
- c) poderá proferir sentença condenatória, ainda que requerida a absolvição pela acusação, independentemente da natureza da ação.
- d) não fica adstrito aos termos do aditamento, se procedido após encerrada a instrução probatória em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação.
- e) poderá reconhecer circunstância agravante não alegada pela acusação, segundo previsto na legislação processual penal.

**2- (2019/MPE-SP/MPE-SP/Promotor de Justiça Substituto)** Sobre a correlação entre acusação e sentença, é correto afirmar que

- a) não se aplica a regra da *emendatio libelli* em grau de recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição e surpresa para a defesa.
- b) ao aplicar a regra da *emendatio libelli*, o juiz poderá condenar o acusado, sem manifestação das partes, aplicando-lhe, se for o caso, pena mais grave.
- c) ao aplicar a regra da *mutatio libelli*, o juiz deve apenas colher a manifestação das partes, ouvir eventuais testemunhas indicadas e sentenciar.
- d) ao aplicar a regra da *mutatio libelli*, o juiz deve provocar o aditamento da denúncia, colher a manifestação das partes, ouvir eventuais testemunhas indicadas e, após debates, sentenciar.
- e) ao aplicar a regra da *emendatio libelli*, o juiz deve colher a manifestação das partes antes de sentenciar, podendo, se for o caso, aplicar pena mais grave.

**3- (2019/MPE-SC/MPE-SC/Promotor de Justiça)** Julgue a afirmação: o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, quando o juiz proferir sentença condenatória.

**4- (2019/CEBRASPE/DPE-DF/Defensor Público)** Os irmãos José e Luís foram denunciados pela prática de contravenção penal de vias de fato, em situação de violência doméstica, com pena de prisão simples de quinze dias a três meses ou multa, em concurso de agentes, por terem puxado os cabelos da irmã Marieta. Após o recebimento da denúncia e várias tentativas, sem sucesso, de citação pessoal dos réus, o juiz competente os citou por edital, seguindo, assim, as regras do Código de Processo Penal.

Diante dessa situação hipotética, julgue o item que se segue. I - Caso Luís tenha comparecido pessoalmente, ainda que o órgão acusador tenha pleiteado a sua absolvição, segundo disposição legal, o juiz poderá condená-lo e reconhecer a existência de circunstância agravante pelo fato de a vítima ser sua irmã.

**5- (2019/CEBRASPE/DPE-DF/Defensor Público)** O Estado exerce sua pretensão punitiva a partir do ingresso da ação penal, garantindo-se ao acusado o devido e justo processo legal. Acerca do processo penal, julgue o item a seguir. Sentença penal concessiva de perdão judicial é classificada como suicida, em razão dos seus efeitos autofágicos.

**6- (2018/VUNESP/TJ-SP/Juiz Substituto)** Quanto à sentença penal, é correto afirmar que

- a) havendo fundada dúvida sobre a existência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, o fundamento legal para a absolvição será o da inexistência de prova suficiente para a condenação.
- b) encerrada a instrução probatória, se o juiz entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, prescindirá de abertura de vista ao Ministério Público para eventual aditamento da denúncia, se não resultar em aplicação de pena mais grave.
- c) preservada sua competência e sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá o juiz atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.
- d) o amplo efeito devolutivo dos recursos possibilita à segunda instância dar nova definição jurídica ao fato delituoso em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.

**7- (2018/FCC/MPE-PE/Analista Ministerial)** À luz do que dispõe o Código de Processo Penal sobre a sentença,

- a) qualquer das partes poderá, no prazo de 5 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.
- b) o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
- c) é vedado ao juiz, ainda que não modifique a descrição do fato contida na denúncia, atribuir-lhe definição jurídica diversa.
- d) a intimação da sentença será feita mediante edital se o réu estiver preso.
- e) nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, exceto se o Ministério Público tenha opinado pela absolvição.

**8- (2018/TRF 2ª REGIÃO/TRF-2ª REGIÃO/Juiz Federal Substituto)** Assinale a assertiva correta a respeito da sentença penal:

- a) A fundamentação da sentença penal tem por fim permitir o exame lógico da decisão, tanto pelos sujeitos do processo, como pelos tribunais e a própria sociedade.
- b) A motivação do juiz constante da fundamentação da sentença, tanto pode ser explícita quanto implícita, haja vista que o que transita em julgado é apenas o dispositivo.
- c) É válida a fundamentação da sentença penal que se limita a exarar: “está provado nos autos que a imputação ministerial é verdadeira”, haja vista a força da máxima *iura novit curia* para mostrar a convicção do juiz.
- d) É válida a fundamentação da sentença penal que se limita a consubstanciar reportes de ementas diversas de jurisprudência dos tribunais nacionais, que nela são mencionadas como amparo ao dispositivo da decisão.
- e) Não viola o princípio da motivação das decisões judiciais, o recebimento puro e simples da denúncia, haja vista que maiores considerações sobre os pressupostos processuais, a inépcia ou a justa causa, só são exigidos quando da decisão sobre a resposta preliminar.

**9- (2018/VUNESP/PC-SP/Delegado de Polícia – adaptada)** Acerca das sentenças e decisões em geral, julgue os itens.

- I) a possibilidade de o juiz dar ao fato definição jurídica diversa daquela constante da denúncia, prevista no art. 383, do Código de Processo Penal, depende de requerimento do Ministério Público, titular da ação penal.
- II) sentença subjetivamente plúrima é a sentença proferida por mais de um órgão, composto por julgadores de natureza diversa, como são as sentenças do tribunal do júri.
- III) em caso de aditamento da denúncia, previsto no art. 384 do Código de Processo Penal, o juiz não ficará adstrito na sentença aos termos do aditamento, podendo de forma fundamentada decidir de forma diversa.

## COMENTÁRIOS

**1. Gabarito:** E.

- a) INCORRETA. A questão trata a respeito do recurso de embargos de declaração, devendo ter atenção que, no CPP, os embargos possuem o prazo de 2 dias (art. 382, CPP). Atenção, pois em se tratando de procedimento comum sumaríssimo, os embargos terão o prazo de 5 dias (art. 83 da Lei nº 9.099/95).
- b) INCORRETA. A questão trata a respeito do instituto da *emendatio libelli*, prevista no art. 383 do CPP. A primeira parte da afirmação está correta. No entanto, para se analisar a possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, é preciso levar em consideração a fração da continuidade delitiva. Caso o

aumento conduza à pena mínima superior a 1 ano, não será possível a concessão do benefício previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95. Para responder à questão, deve se conhecer o enunciado da Súmula nº 723 do STF, que assim dispõe: não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a um ano.

c) INCORRETA. Apesar de o art. 385 do CPP sofrer diversas críticas doutrinárias, nas provas ele é cobrado de forma literal, devendo o candidato ter atenção à letra de lei. É possível que o juiz condene o réu, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. No entanto, isso somente será possível na ação penal pública. Na ação penal privada, o querelante deverá requerer a condenação do acusado, necessariamente (art. 60, CPP). Art. 385 - CPP. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

d) INCORRETA. Nos termos do art. 384, §4º, do CPP, havendo aditamento, o juiz, na sentença, fica adstrito aos termos.

e) CORRETA. Apesar de o art. 385 do CPP sofrer diversas críticas doutrinárias, nas provas ele é cobrado de forma literal, devendo o candidato ter atenção à letra de lei. Desse modo, conforme o CPP pode o juiz reconhecer circunstâncias agravantes ainda que não alegada pela acusação.

## 2. Gabarito: B.

a) INCORRETA. Apenas a *mutatio libelli* que não pode ser realizada em grau de recurso. Atenção ao enunciado da Súmula nº 453, do STF: não se aplicam à segunda instância o *caput* e parágrafo único, do art. 384, do CPP, que tratam do instituto da *mutatio libelli*, pois possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.

B) CORRETA. De acordo com o *caput* do art. 383, do CPP, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Segundo a doutrina majoritária, a *emendatio libelli* dispensa a intimação das partes, pois estas defendem-se dos fatos e não de sua capitulação jurídica.

c) INCORRETA. Ao aplicar a regra da *mutatio libelli*, o juiz deve aguardar que o Ministério Público faça, no prazo de 5 dias, o aditamento da denúncia ou queixa. Na sequência, deve ouvir, no mesmo prazo, o defensor do acusado. Após, designar dia e hora para continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado e realização de debates e julgamento (*caput* e parágrafo 2º, do art. 384, do CPP).

d) INCORRETA. Ao aplicar a regra da *mutatio libelli*, o juiz deve provocar o aditamento da denúncia, colher a manifestação das partes, ouvir eventuais testemunhas indicadas, proceder a novo interrogatório do acusado e, após debates, sentenciar (parágrafo 2º, do art. 384, do CPP).

e) INCORRETA. Ao aplicar a regra da *emendatio libelli*, o juiz, antes de sentenciar, se for o caso, pode aplicar pena mais grave, dispensando-se a manifestação das partes (*caput* do art. 383, do CPP). É uma atividade realizada de ofício.

## 3. Gabarito: CORRETA, de acordo com o art. 387, § 2º, do CPP.

## 4. Gabarito: CORRETO. O juiz pode reconhecer de ofício as agravantes de ofício, conforme art. 385 do CPP. Nesse sentido a jurisprudência do STJ (HC 381.590/SC).

## 5. Gabarito: INCORRETO. É classificada como autofágica. Lembre-se da diferenciação entre sentença suicida, autofágica e vazia.

## 6. Gabarito: C.

a) INCORRETA. Há previsão própria no art. 386, VI, do CPP.

b) INCORRETA. A questão trata a respeito do instituto da *mutatio libelli*. De acordo com o art. 384 do CPP, é necessário (ou seja, imprescindível) o aditamento da denúncia.

c) CORRETA, de acordo com o art. 383 do CPP.

d) INCORRETA. Não é possível a realização de *mutatio libelli* em grau de recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição e surpresa para a defesa. De acordo com a Súmula nº 453, do STF, não se aplicam à segunda instância o *caput* e parágrafo único, do art. 384, do CPP, que tratam do instituto da *mutatio libelli*, pois possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.

## 7. Gabarito: B.

- a) INCORRETA. Nos termos do art. 382, do CPP, qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.
- b) CORRETA, de acordo com o art. 387 do CPP.
- c) INCORRETA. Nos termos do art. 383, do CPP, o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave.
- d) INCORRETA. Nos termos do art. 392, I, do CPP, a intimação da sentença será feita ao réu, pessoalmente, se estiver preso.
- e) INCORRETA. Nos termos do art. 385, do CPP, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

**8. Gabarito: A.**

- a) CORRETA. A necessidade de fundamentação das decisões decorre da possibilidade do juiz, ante a discricionariedade peculiar a sua função, incorrer em arbitrariedades. Por isso, a presença da fundamentação no ato jurisdicional que encerra o processo é essencial.
- b) INCORRETA. O juiz deve demonstrar explicitamente todos os motivos que o levaram a decidir um caso de determinada forma. Isso acontece, para que se demonstre uma transparência da atividade jurídica, sendo possível o exercício adequado do controle das decisões jurisdicionais.
- c) INCORRETA. É nulo o acórdão que se limita a ratificar a sentença e a adotar o parecer ministerial, sem sequer transcrevê-los, deixando de afastar as teses defensivas ou de apresentar fundamento próprio. Isso porque, nessa hipótese, está caracterizada a nulidade absoluta do acórdão por falta de fundamentação (STJ, HC 214049-SP, Info 557).
- d) INCORRETA. A jurisprudência admite a chamada fundamentação *per relationem*, mas desde que o julgado faça referência concreta às peças que pretende encampar, transcrevendo delas partes que julgar interessantes para legitimar o raciocínio lógico que embasa a conclusão a que se quer chegar (STJ, HC 214.049-SP, Info 557).
- e) INCORRETA. O ato judicial que recebe a denúncia ou queixa não exige "fundamentação complexa", não precisando ser exaustivamente detalhado, havendo apenas um juízo de verossimilhança. Bastará ao juiz, portanto, explicitar que estão ausentes as causas de rejeição do art. 395, CPP, e que estão verificados os elementos de autoria e materialidade, determinando-se a citação do acusado. Nada mais. Conforme o STJ, "consagrou-se o entendimento no sentido da inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia" (HC 365.863). Mas veda-se o recebimento "puro e simples", como colocado na alternativa.

**9. Gabarito: E.**

- I) INCORRETO. Ao aplicar a regra da *emendatio libelli*, o juiz, antes de sentenciar, se for o caso, pode aplicar pena mais grave, dispensando-se a manifestação das partes (*caput* do art. 383, do CPP). É uma atividade realizada de ofício.
- II) INCORRETO. Trata-se de sentença subjetivamente complexa.
- c) INCORRETO. Nos termos do art. 384, §4º, do CPP, havendo aditamento, o juiz, na sentença, fica adstrito aos termos.

**CAPÍTULO 21 – PROCEDIMENTO PENAL****1. INTRODUÇÃO**

O processo é a via disponível para materialização do *jus puniendi*. Ele pode ser concretizado por meio dos procedimentos comum ou especial. O primeiro se subdivide em ordinário, sumário e sumaríssimo. O segundo pode ser encontrado no Código de Processo Penal (procedimento para apurar crimes dolosos contra a vida, crimes contra a honra, crimes funcionais e crimes contra a propriedade imaterial) ou em leis especiais (como o procedimento previsto na Lei nº 11.343/06 – Lei de Drogas) e somente terá aplicação se houver menção expressa na lei (art. 394, § 2º, CPP).

Para diferenciar quando deve ser utilizado cada um dos procedimentos comuns, atente-se à previsão do § 1º do art. 394 do CPP. O critério de aferição é o da pena privativa de liberdade máxima abstratamente cominada para o crime, pouco importando se há pena de multa cominada.

| PROCEDIMENTO | REGRA                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDINÁRIO    | Quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a quatro anos de pena privativa de liberdade. |
| SUMÁRIO      | Quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a quatro anos de pena privativa de liberdade.         |
| SUMARÍSSIMO  | Para as infrações de menor potencial ofensivo, na forma da lei.                                                               |

A definição de infração de menor potencial ofensivo está no art. 61 da Lei nº 9.099/95, que dispõe que assim se consideram as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa.

**Atenção:**

a) Na aferição da pena máxima devem ser levadas em consideração as qualificadoras, causas de aumento e causas de diminuição (devem ser considerados os índices de aumento máximo e de diminuição mínimo), concurso de crimes, como concurso material e formal, bem como continuidade delitiva. Desse modo, por exemplo, em havendo concurso material de crimes, as penas máximas devem ser somadas para a definição do procedimento adequado. Ainda, no concurso formal ou crime continuado, deve incidir a fração de aumento. Não são levadas em conta as agravantes e atenuantes, pois não integram o tipo penal e não se sabe ainda qual o patamar que será utilizado para agravar ou atenuar a pena (a lei não diz qual o montante deve ser considerado). Isso apenas é possível no momento da sentença condenatória.

b) O procedimento comum ordinário, por ser o mais abrangente e completo, deve ser aplicado de forma supletiva aos demais (procedimentos especiais, sumário e sumaríssimo), conforme art. 395, § 5º, CPP.

c) Nos termos do art. 394-A do CPP, os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias, esteja o réu preso ou solto no curso do processo.

d) Nos termos do art. 71, *caput*, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), é assegurada a prioridade de tramitação dos processos e procedimentos em que figure como parte pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância. Além disso, dentre esses processos, será dada, ainda, prioridade especial aos maiores de 80 anos (art. 71, § 5º).



## 2. PROCEDIMENTO COMUM

### 2.1. PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO (ARTS. 395 A 405 DO CPP)

O procedimento comum ordinário é aplicado aos crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a quatro anos, desde que não haja previsão de rito especial.

Em termos de fluxograma para melhor compreensão do procedimento, pode ele ser estruturado da seguinte forma:

1) Oferecimento da denúncia ou queixa-crime (arts. 41 e 46 do CPP): em regra, no prazo de quinze dias, para acusado solto, e cinco dias, se preso. A inicial deve estar em conformidade com os requisitos do artigo 41 do CPP.

2) Rejeição ou recebimento da denúncia ou queixa-crime (art. 396 do CPP): se estiverem presentes as situações do artigo 395 do CPP (inépcia da inicial, falta de condição da ação ou pressuposto recursal ou falta de justa causa), o juiz deverá rejeitar a denúncia ou queixa, cabendo recurso em sentido estrito dessa decisão (art. 581, I, CPP). No rito sumaríssimo que tramita perante o Juizado Especial Criminal, o recurso é o de apelação (art. 82, Lei nº 9.099/95). Do recebimento da denúncia ou queixa-crime não se admite recurso, porém o acusado poderá impetrar *habeas corpus* na tentativa de trancar a ação penal.

#### Atenção:

a) É o recebimento da inicial acusatória que determina a interrupção da prescrição (art. 117, I, do CP). Contudo, segundo posicionamento dos Tribunais Superiores, não interrompe a prescrição o recebimento da denúncia feito por juízo absolutamente incompetente, ainda que já tenha sido proferida sentença condenatória (STF, Inq 1544-PI; STJ, HC 28.667/PR).

b) O ato judicial que recebe a denúncia ou queixa não exige "fundamentação complexa", não precisando ser exaustivamente detalhado, havendo apenas um juízo de verossimilhança/juízo de prelibação (STJ, HC 365.863). Salienta-se, inclusive, que o ato de recebimento da denúncia ou queixa dispensa fundamentação expressa por parte do magistrado, sendo caso de fundamentação implícita, no sentido de, ao receber a inicial, implicitamente o juiz nega a existência das causas de rejeição do art. 395 do CPP (STF, RHC 87005/RJ).

c) Em alguns procedimentos (ex.: comum sumaríssimo – Lei nº 9.099/95), antes do recebimento da denúncia é oportunizado à defesa manifestar-se previamente, apresentado defesa preliminar. Se houver o contraditório prévio, para o juiz receber a denúncia ou queixa, deverá refutar todos os argumentos apresentados pela defesa.

d) O princípio do *in dubio pro societate* significa que, na dúvida, havendo indícios mínimos da autoria, deve-se dar prosseguimento à ação penal, ainda que não se tenha certeza de que o réu foi o autor do suposto delito. Em uma tradução literal, seria algo como “na dúvida, em favor da sociedade”. Contrapõe-se ao princípio do *in dubio pro reo* (“na dúvida, em favor do réu”). A doutrina mais moderna critica a existência desse princípio afirmando que ele é contrário às garantias conferidas ao réu. Apesar disso, a jurisprudência continua aplicando esse princípio em duas fases: a) no momento do oferecimento/recebimento da denúncia, prevalece o princípio do *in dubio pro societate* (STF, Inq 4506/DF - Info 898); e b) a pronúncia do réu para o julgamento pelo Tribunal do Júri não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente, nessa fase processual, a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada, apenas, a materialidade do crime, uma vez que vigora o princípio *in dubio pro societate* (STF, ARE 986566 AgR; STJ, AgRg no AREsp 1193119/BA).

3) Citação do réu para a apresentação de defesa escrita (art. 396 do CPP): ato pelo qual se dá ciência ao réu da ação penal promovida contra ele. O réu será citado para, no prazo de 10 dias, responder por escrito à acusação. A citação poderá ser: 1) Pessoal ou real: efetivando-se por meio de



mandado judicial (oficial de justiça – regra), por carta precatória (comarca diversa), por carta rogatória (outro país) ou do réu preso (pessoalmente no presídio); 2) Ficta ou presumida: 2.1) Por edital: ocorre quando o réu não puder ser encontrado, por estar em lugar incerto ou não sabido, devendo ser esgotados todos os meios de localização, sob pena nulidade (art. 564, IV, do CPP); 2.2) Por hora certa: quando for constatado que o réu se oculta para não ser citado (art. 362 do CPP). As formas de citação foram detalhadas em capítulo próprio.

4) Resposta à acusação no prazo de 10 dias (arts. 396 e 396-A do CPP): se a citação tiver sido pessoal ou por hora certa, o prazo começa a correr da data do seu recebimento, nos termos da Súmula nº 710 do STF (prazo processual). Da resposta escrita devem constar todas as teses defensivas e, além disso, o rol de testemunhas (sob pena de preclusão), se houver, no número máximo de oito (arts. 396-A e 401, ambos do CPP). É nesse momento também que devem ser apresentadas, em apartado, eventuais exceções (ex.: suspeição, impedimento, litispendência, coisa julgada etc.).

**Atenção:**

a) A resposta escrita é peça essencial do processo, de modo que deve ser obrigatoriamente apresentada, sob pena de nulidade absoluta do feito. Se o réu for citado pessoalmente ou por hora certa e a defesa escrita não for apresentada no prazo, tenha ou não defensor constituído nos autos, o juiz nomeará defensor dativo para apresentá-la (art. 396-A, § 2º, do CPP). Lembre-se que a defesa técnica é imprescindível no processo penal (arts. 261 e 263, ambos do CPP).

b) A profundidade do conteúdo da resposta à acusação será definida estrategicamente pelo defensor. Pode ser que neste momento, não vislumbrando qualquer possibilidade de absolvição sumária na próxima fase, a defesa apresente apenas uma defesa genérica e na instrução e julgamento alegue o que entender necessário.

c) Se o réu for citado por edital, não comparecendo ao processo no prazo determinado no edital, serão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional (art. 366 do CPP). Se posteriormente vier a ser encontrado, o acusado terá, a partir de então, o prazo de 10 dias para oferecer a defesa escrita. Nessa situação de incidência do artigo 366 do CPP, é importante que se observe o disposto nas Súmulas nºs 415 e 455 do STJ, comumente cobradas em provas. Desse modo, conforme previsão do art. 396, parágrafo único, do CPP, no caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.

5) Vista à parte contrária para manifestação a respeito de preliminares, teses e documentos juntados (conforme entendimento doutrinário).

Embora não haja previsão expressa no CPP a esse respeito, o juiz deverá conceder vista dos autos ao autor da ação penal (Ministério Público ou querelante) para que possa se manifestar sobre as preliminares e teses alegadas e documentos eventualmente juntados, em respeito ao contraditório (STF, HC 105739). Aplica-se, por analogia, o disposto no art. 409 do CPP, que se refere ao procedimento especial do Tribunal do Júri. Se a defesa, no entanto, preferiu apresentar defesa genérica e alegar suas teses apenas na instrução processual, não será necessário dar vista à parte contrária, podendo o juiz, desde já, partir para a próxima fase do procedimento e designar audiência de instrução e julgamento (já que não houve nenhuma alegação para absolver sumariamente o réu).

6) Absolvição sumária (chamado por parcela da doutrina de julgamento antecipado da lide *pro reo* – art. 397 do CPP): em face dos argumentos apresentados na defesa escrita o juiz, depois de ouvida a acusação, poderá, desde já, absolver sumariamente o réu quando verificar:

- 6.1) que o fato evidentemente não constitui crime;
- 6.2) a existência manifesta de excludente de ilicitude;
- 6.3) a existência manifesta de excludente de culpabilidade, salvo inimizabilidade;
- 6.4) extinção da punibilidade.

Caso o juiz não absolva sumariamente o acusado, então designará audiência de instrução, debates e julgamento.

**Atenção:**

a) Deve-se ficar atento e não confundir as hipóteses e o momento de rejeição da denúncia (art. 395 do CPP), absolvição sumária (art. 397 do CPP) e absolvição sumária da primeira fase do júri (art. 415 do CPP).

b) A inimizabilidade não pode ensejar a absolvição sumária do art. 397 do CPP: a inimizabilidade, neste caso, mesmo sendo a única tese defensiva, não poderá conduzir à absolvição sumária do réu. No processo penal, qualquer sanção a ser aplicada, seja ela pena, seja ela a medida de segurança, somente poderá vir após o devido processo legal e a comprovação da materialidade e autoria. A inimizabilidade gera a chamada absolvição imprópria, que envolve a aplicação de medida de segurança e que difere das hipóteses de absolvição própria estudadas no art. 386 do CPP. Desse modo, mesmo constatada a inimizabilidade do réu desde o início do processo, é preciso que ele passe por todas as etapas essenciais até o final do procedimento. Caso, ao final, seja constatada uma das hipóteses do art. 386 do CPP, o réu deverá ser absolvido propriamente sem aplicação de qualquer sanção. Caso seja constatado que há materialidade e indícios suficientes para a condenação, esta não será possível diante da inimizabilidade, e então o réu será absolvido imprópria com aplicação de medida de segurança. Não confunda com a absolvição sumária regulamentada no art. 415 do CPP, aplicável no procedimento do Júri, que será estudada em momento oportuno. No procedimento especial do Tribunal do Júri, é possível, ao final da primeira fase, a absolvição sumária pela inimizabilidade caso seja a única tese alegada pela defesa.

c) Da absolvição sumária caberá o recurso de apelação (art. 593, I, do CPP). Caso o Tribunal, no julgamento da apelação, reforme a decisão, entendendo ser inadequada a absolvição sumária, deverá determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a instrução e julgamento do feito (STJ, HC 260188/AC). Observe que não será possível o Tribunal efetivar a condenação, uma vez que o feito sequer tinha sido instruído, o que ensejaria supressão de instância.

7) Audiência de instrução, debates e julgamento (art. 400 do CPP): a ser realizada no prazo de 60 dias. O CPP, no entanto, não fixa qual o termo *a quo* para a contagem do prazo de 60 dias (e de 30 dias no sumário) para a realização da audiência de instrução e julgamento. Entende a doutrina que deverá se dar a partir da decisão que rejeitar o pedido de absolvição sumária e designar a data da audiência (DEZEM, 2019, p. 1003).

Sequência de atos desta audiência, prevista no artigo 400 do CPP:

- 1) declarações do ofendido;
- 2) inquirição das testemunhas da acusação;
- 3) inquirição das testemunhas da defesa;

(A testemunha – da acusação ou defesa que residir fora da comarca, no entanto, será ouvida mediante carta precatória);

4) esclarecimentos dos peritos (se houver prévio requerimento das partes – art. 400, § 2º, CPP);

- 5) acareações;
- 6) reconhecimentos;
- 7) interrogatório.

**Atenção:**

a) Princípio da concentração dos atos processuais: as provas serão produzidas, de regra, numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1º, CPP). Não haverá nulidade processual se houver a cisão para continuidade dos atos em próxima audiência de instrução. Ex.: não foi possível ouvir todas as

testemunhas em um só dia; determinada testemunha não compareceu, apesar de intimada, e a parte insistiu em sua oitiva, devendo ser designada nova data para a oitiva; a quantidade de vítimas, testemunhas e réus demonstra a impossibilidade de término da instrução em apenas um dia, sendo designadas várias datas.

b) Na instrução poderão ser inquiridas até 8 (oito) testemunhas arroladas pela acusação e 8 (oito) pela defesa, não se compreendendo nesse número as que não prestem compromisso e as referidas (art. 401 do CPP).

c) A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvada a possibilidade de o juiz entender relevante o depoimento daquela testemunha (art. 209 do CPP).

d) A expedição de carta precatória para oitiva de vítimas, testemunhas e réus não suspenderá a instrução criminal. Assim, findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos (art. 222, §2º, do CPP) (STJ, HC 388.688/SP; STJ, AgRg no RHC n. 105.154/SP; STJ, HC 538.161/SP).

e) Princípio da identidade física do juiz: O § 2º do art. 399 do CPP estabelece que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença, com o que o CPP adotou expressamente o princípio da identidade física do juiz. A jurisprudência, no entanto, não considera o princípio absoluto. Ressalta-se, por oportuno, que as exceções não vieram previstas no CPP, devendo ser utilizadas exceções do processo civil. Desse modo, no caso de convocação, licença, promoção, aposentadoria, afastamentos ou outro motivo que impeça o juiz que tiver presidido a instrução de sentenciar o feito, os autos passarão ao substituto do magistrado (STJ, HC 242.115/PE). As exceções ao princípio previstas no art. 132, *caput*, do CPC de 1973, continuam sendo aplicadas, por analogia, no processo penal, ainda que esse dispositivo não encontre correspondência no CPC de 2015. Além disso, a Lei nº 12.019/2010, que alterou o texto originário da Lei nº 8038/90, trouxe a figura do Magistrado instrutor, que permite que os Ministros do STF e do STJ convoquem desembargadores, bem como juízes, pelo prazo de seis meses, prorrogável por igual período, até o máximo de dois anos, para a realização de interrogatório e de outros atos da instrução, na sede do tribunal ou no local em que deva produzir o ato. Os julgadores convocados não substituem os Ministros na atividade de julgamento, mas apenas auxiliam na instrução. Como a previsão está em lei ordinária também (Lei nº 8.030/90), aceita-se o magistrado instrutor como exceção ao princípio da identidade física do juiz.

f) O interrogatório passa a ser o último ato da instrução, sendo que a Lei nº 11.719/2008, geral e posterior, deve preponderar, inclusive, sobre as disposições em contrário presentes em leis especiais: c.1) nos processos criminais que tramitam perante o STF e o STJ, cujo procedimento é regido pela Lei nº 8.038/90, o interrogatório também é o último ato de instrução. Apesar de não ter havido uma alteração específica do art. 7º da Lei nº 8.038/90, com base no CPP, entende-se que o interrogatório é um ato de defesa, mais bem exercido depois de toda a instrução, porque há possibilidade do contraditório mais amplo. Assim, primeiro devem ser ouvidas todas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa para, só então, ser realizado o interrogatório. (STF, AP 1027/DF). c.2) A realização do interrogatório ao final da instrução criminal, prevista no art. 400 do CPP, na redação dada pela Lei nº 11.719/2008, também se aplica às ações penais em trâmite na Justiça Militar, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Logo, na hipótese de crimes militares, o interrogatório também deve ser realizado depois da oitiva das testemunhas, ao final da instrução (STF, HC 127900/AM - Info 816). c.3) A exigência de realização do interrogatório ao final da instrução criminal, conforme o art. 400 do CPP, é aplicável a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial (inclusive a Lei de Drogas) (STF, HC 127900/AM - Info 816 e STJ, HC 403.550/SP – Info 609).

8) Possibilidade de requerimento de diligências (art. 402 do CPP): Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Frisa-se: apenas aquelas cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na

instrução. Dessa forma, se a diligência já poderia ter sido requerida, e não o foi por displicência da parte, deve ser indeferida por ter se operado a preclusão (TÁVORA; ALENCAR, 2020, p. 634). Não havendo a necessidade de diligências ou sendo estas indeferidas pelo juiz, serão oferecidas alegações finais orais na própria audiência de instrução e julgamento, sendo a sentença proferida imediatamente após.

9) Regra: alegações finais orais por 20 minutos para cada parte, prorrogáveis por mais 10 a critério do juiz. Se houver mais de um réu, o tempo de cada um será individual; se houver assistente da acusação, terá 10 minutos para falar depois da manifestação do Ministério Público, prorrogando-se por igual período o tempo da defesa, nos termos do art. 403 do CPP.

#### Atenção:

a) Aplica-se o princípio da oralidade, como regra. No entanto, o CPP prevê duas situações em que as alegações finais orais serão convertidas na apresentação de memoriais escritos:

Exceção 1: dada a complexidade da causa ou o número de acusados, pode o juiz conceder às partes o prazo de 5 dias para apresentarem memoriais escritos (ao invés de alegações orais) e o juiz terá o prazo de 10 dias para proferir sentença em gabinete (ao invés de proferir em audiência), conforme art. 403, §3º, CPP.

Exceção2: tendo sido necessária a realização de diligências, não haverá alegações orais finais. Nesse caso, após realizadas, abre-se o prazo para o oferecimento de alegações finais via memoriais escritos em 5 dias, sucessivos. Em seguida, o juiz proferirá sentença em 10 dias, conforme art. 404, CPP.

b) Na ação penal privada, se o querelante deixa de apresentar as alegações finais orais ou deixar de na peça requerer a condenação do querelado, haverá declaração de extinção de punibilidade do autor do fato pela perempção, nos termos do art. 60, incisos I e III, do CPP.

c) Alegações finais de corréus delator e delatado: deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o prazo concedido ao réu que o delatou (STF, Informativos 949 e 954; e art. 4º, § 10-A, da Lei nº 12.850/13, com redação dada pela Lei nº 13.964/19 – Lei Anticrime).

#### 10) Sentença (*emendatio libelli X mutatio libelli*)

Após a apresentação de alegações finais orais pelas partes, o juiz deverá proferir sentença oral na própria audiência. No entanto, se as alegações foram por memoriais escritos, a sentença será proferida também por escrito no prazo de 10 dias (arts. 403, § 3º, e art. 404, parágrafo único, ambos do CPP).

Se, no momento da prolação da sentença, o juiz perceber ser o caso de definição jurídica diversa da constante na denúncia ou queixa, poderá condenar o acusado, sem necessidade de aditamento pela acusação ou manifestação da defesa, ainda que em consequência seja aplicada pena mais grave. Trata-se do instituto da *emendatio libelli* (art. 383 do CPP). Se, no entanto, houver possibilidade, em tese, de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei, ou seja, abrirá vista à acusação para que se manifeste sobre a possibilidade ou não da proposta (art. 383, § 1º, CPP). Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos (art. 383, § 2º, CPP).

Por outro lado, caso, no término da instrução probatória, o órgão do Ministério Público entenda cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá aditar a denúncia, no prazo de 5 (cinco) dias. É a chamada *mutatio libelli* (art. 384 do CPP).

Os requisitos da sentença estão previstos no art. 381 do CPP e podem ser assim resumidos: relatório (resumo do processo), fundamentação (exposição dos motivos que levaram ao convencimento do juiz), dispositivo (é a conclusão do processo) e parte autenticativa (data e assinatura do juiz).

Ressalte-se que a sentença poderá apresentar vícios, tais como: obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição. Tais defeitos serão sanados por meio da oposição de embargos de declaração, interpostos em dois dias contados da intimação da sentença (art. 382 do CPP). Na Lei nº 9.099/95, o prazo de embargos é diverso, sendo de cinco dias (art. 83), conforme será estudado.

A publicação da sentença ocorre no momento em que for recebida pelo escrivão no cartório, porém, a intimação ocorre no momento em que é dada ciência às partes do conteúdo da sentença, na forma do art. 392, CPP.

Todos os elementos da sentença acima citados foram detalhados em capítulo próprio.

#### 11) Registro da audiência (art. 405 do CPP)

Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações.

Sobre o tema, já decidiu o STJ, inclusive, que o registro audiovisual de depoimentos colhidos em audiência dispensa sua degravação, salvo comprovada demonstração de sua necessidade. Isto é, as oitivas das testemunhas, vítima e réu e as alegações finais orais apresentada pelo órgão acusatório e a defesa, se forem feitas oralmente, não precisam ser transcritas/reduzidas a termo (STJ, HC 339.357/RS; RMS 36.625/MT).

Indo além, é válida, ainda, a sentença proferida de forma oral na audiência e registrada em meio audiovisual, ainda que não haja a sua transcrição. Desse modo, o § 2º do art. 405 do CPP, que autoriza o registro audiovisual dos depoimentos, sem necessidade de transcrição, deve ser aplicado também para os demais atos da audiência, dentre eles os debates orais e a sentença (STJ, 3ª Seção. HC 462.253/SC). Entende o STJ que o registro audiovisual da sentença prolatada oralmente em audiência é uma medida que garante mais segurança e celeridade ao procedimento.

## 2.2. PROCEDIMENTO COMUM SUMÁRIO (ARTS. 531 A 538 DO CPP)

É importante a leitura dos artigos 531 a 538 do CPP. O procedimento é bastante similar ao rito ordinário, com poucas alterações. As diferenças básicas são:

|                                                                                           | ORDINÁRIO                                                                                                                                                    | SUMÁRIO                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantidade de pena                                                                        | Quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a quatro anos de pena privativa de liberdade.<br>(art. 394, § 1º, I, do CPP) | Quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a quatro anos de pena privativa de liberdade.<br>(art. 394, § 1º, II, do CPP) |
| Prazo para realização da audiência                                                        | 60 dias<br>(art. 400 do CPP).                                                                                                                                | 30 dias<br>(art. 531 do CPP).                                                                                                                         |
| Número máximo de testemunhas a serem arroladas                                            | 8 testemunhas<br>(art. 401 do CPP).                                                                                                                          | 5 testemunhas<br>(art. 532 do CPP).                                                                                                                   |
| Permitidas diligências depois da audiência de instrução?                                  | Sim,<br>(art. 402 do CPP).                                                                                                                                   | Não há previsão legal.                                                                                                                                |
| Permitido o oferecimento de memoriais escritos em substituição às alegações finais orais? | Sim,<br>(art. 403, § 3º; e 404 do CPP).                                                                                                                      | Não há previsão legal.                                                                                                                                |



Não há, tal como existe no procedimento ordinário, previsão da possibilidade de requerimento de diligências, ao término da instrução, nem previsão da possibilidade de conversão das alegações finais orais em memoriais escritos. Não haver previsão expressa é diferente de ser proibido. Caso fosse proibido agir assim, haveria previsão expressa neste sentido, o que não ocorre. O procedimento ordinário tem aplicação subsidiária a todos os outros (do artigo 394, § 5º, do CPP) e a maioria da doutrina tem se manifestado favoravelmente à possibilidade de ambas as previsões serem aplicadas ao sumário.

Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento (seja pela necessidade de citação por edital, seja pela complexidade do caso – arts. 66 e 77, § 2º, ambos da Lei nº 9.099/95), deverá ser observado o procedimento sumário (art. 538 do CPP).

### 2.3. PROCEDIMENTO COMUM SUMARÍSSIMO (LEI Nº 9.099/95)

A Lei nº 9.099/95 trata do procedimento sumaríssimo e tem fundamento constitucional no art. 98, I, da CF/88 que dispõe que a União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão juzizados especiais competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei.

Além disso, o art. 394, § 1º, III, do CPP, prevê que o procedimento comum será sumaríssimo para as infrações de menor potencial ofensivo, na forma da lei.

A lei principal que trata a respeito do assunto é a Lei nº 9.099/95 que dispõe que os juzizados especiais criminais são competentes para processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo, assim consideradas as contravenções penais e os crimes que possuam pena máxima não superior a dois anos (art. 61 da Lei nº 9.099/95).

#### 2.3.1. A RESPEITO DA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS

a) Deve-se considerar a soma das penas máximas em abstrato em concurso material, ou, ainda, a devida exasperação, no caso de crime continuado ou de concurso formal, e ao se verificar que o resultado da adição ou exasperação é superior a dois anos, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal (STJ, RHC 084633/RJ; RHC 071928/MG; RHC 060883/SC; RHC 046646/SP; HC 326391/ES; HC 314854/RJ);

b) O crime de uso de entorpecente para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, é de menor potencial ofensivo, o que determina a competência do juizado especial criminal estadual (STJ, CC 144910/MS; RHC 015232/SP; CC 155280/RJ; CC 136251/MS);

c) No âmbito da Justiça Federal não haverá julgamento das contravenções penais. Conforme prevê o art. 109, IV, da CF/88, aos juízes federais compete processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Desse modo, uma contravenção penal, mesmo em detrimento, por exemplo, de um bem da União, será de competência do juizado especial criminal estadual.

d) O Estatuto do Idoso (art. 94 da Lei nº 10.741/03) prevê a aplicação do procedimento sumaríssimo aos crimes cometidos contra idosos cuja a pena máxima do delito não ultrapasse quatro anos. Aplica-se o procedimento a partir do recebimento da denúncia, não sendo permitida nenhuma medida despenalizadora prevista na Lei nº 9.099/95. O artigo em comento objetiva acelerar a punição de quem praticou ato contra o idoso e não significou ampliação do conceito de infração de menor potencial ofensivo que para os demais casos permanece o mesmo do art. 61 da Lei nº 9.099/95. Nesse sentido, atenção ao entendimento abaixo:



EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 39 E 94 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). RESTRIÇÃO À GRATUIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE SELETIVOS E ESPECIAIS. APLICABILIDADE DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI 9.099/1995 AOS CRIMES COMETIDOS CONTRA IDOSOS. 1. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.768/DF, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o art. 39 da Lei 10.741/2003. Não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade nessa parte. 2. Art. 94 da Lei n. 10.741/2003: interpretação conforme à Constituição do Brasil, com redução de texto, para suprimir a expressão "do Código Penal e". Aplicação apenas do procedimento sumaríssimo previsto na Lei n. 9.099/95: benefício do idoso com a celeridade processual. Impossibilidade de aplicação de quaisquer medidas despenalizadoras e de interpretação benéfica ao autor do crime. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição do Brasil, com redução de texto, ao art. 94 da Lei n. 10.741/2003. (ADI 3096, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/6/2010, DJe-164 DIVULG 2/9/2010 PUBLIC 3/9/2010 EMENT VOL-02413-02 PP-00358 RTJ VOL-00216-01 PP-00204.)

e) A Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) prevê a não aplicação da Lei nº 9.099/95, independentemente da pena (art. 41). Anote-se que a palavra “crime” constante no art. 41 se refere a crimes e contravenções penais cometidos contra mulher que signifiquem violência doméstica. Em 2014, o STF julgou constitucional a previsão legal. Por consequência, os institutos da Lei nº 9.099/95, como a transação penal, suspensão condicional do processo, não são aplicáveis às infrações praticadas no contexto da Lei Maria da Penha.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – GÊNEROS MASCULINO E FEMININO – TRATAMENTO DIFERENCIADO. O artigo 1º da Lei nº 11.340/06 surge, sob o ângulo do tratamento diferenciado entre os gêneros – mulher e homem –, harmônica com a Constituição Federal, no que necessária a proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a cultura brasileira. COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. O artigo 33 da Lei nº 11.340/06, no que revela a conveniência de criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, não implica usurpação da competência normativa dos estados quanto à própria organização judiciária. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – REGÊNCIA – LEI Nº 9.099/95 – AFASTAMENTO. O artigo 41 da Lei nº 11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a Lei nº 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no § 8º do artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coíbam a violência no âmbito das relações familiares (STF, ADC 19, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28/4/2014 PUBLIC 29/4/2014 – grifo nosso)

AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – NATUREZA. A ação penal relativa a lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada – considerações (STF, ADI 4424, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 9/2/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31/7/2014 PUBLIC 1º/8/2014 – grifo nosso).

f) Também é inaplicável a Lei nº 9.099/95 no âmbito da Justiça Militar (art. 90-A). Nesse sentido, atenção ao julgado abaixo:

CRIME MILITAR – PRIMEIRA INSTÂNCIA – JULGAMENTO. Atua no processo-crime militar o Conselho Permanente de Justiça. PROCESSO-CRIME MILITAR – LEI Nº 9.099/1995. É inaplicável ao processo-crime militar a Lei dos Juizados Especiais – Precedente: *habeas corpus* nº 99.743/RJ. (HC 124899, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 1º/8/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 14/8/2017 PUBLIC 15/8/2017.)

É importante frisar duas situações em que, apesar de inicialmente o fato ser de competência do Juizado especial criminal (por se tratar de contravenção penal ou crime com pena máxima não superior a dois anos), pode ser que o caso seja enviado ao Juízo comum, ou seja, que haja o declínio da competência ao juiz da Vara Criminal:

a) O art. 66 da Lei nº 9.099/95 prevê que a citação do acusado deve se dar de forma pessoal. Dessa forma, em sendo necessária a citação por meio de edital, ela não poderá ser feita no juizado. Portanto, não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. Mesmo após realizada a citação por edital no Juízo Comum, os autos lá permanecerão para a adoção das providências cabíveis, não haverá retorno ao juizado especial.

b) Nos termos do art. 77, § 2º, da Lei nº 9.099/95, se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes ao juízo comum.

Quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento, necessariamente será aplicado o procedimento sumário, independentemente da pena máxima prevista para tais infrações, nos termos do art. 538 do CPP.

Portanto, atenção às situações abaixo elencadas:

| CAUSA EXCLUÍDAS DO JECRIM                                                                                   | FUNDAMENTO LEGAL                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Crimes Militares.                                                                                           | Art. 90-A da Lei nº 9.099/95.                 |
| Crimes/contravenções penais contra mulher em situação de violência doméstica e familiar (Lei nº 11.340/06). | Art. 41 da Lei nº 11.340/06.                  |
| Impossibilidade de citação pessoal (A Lei nº 9.099/95 não admite citação por edital).                       | Art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. |
| Complexidade.                                                                                               | Art. 77, § 2º, da Lei nº 9.099/95.            |

### 2.3.2. COMPETÊNCIA TERRITORIAL

Adota-se a Teoria da Atividade: a competência do Juizado especial criminal será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal (art. 63, Lei nº 9.099/95). É diferente da regra do art. 70 do CPP, que adota a teoria do resultado.

### 2.3.3. PRINCÍPIOS NORTEADORES E OBJETIVOS

Nos termos do art. 62 da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais Criminais são regidos pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, e objetivam sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Trata-se aqui no direito penal de segunda velocidade, caracterizado pela mitigação de direitos fundamentais, com a imposição de pena não privativa de liberdade.

### 2.3.4. CONEXÃO OU CONTINÊNCIA

Devido à conexão ou continência, é possível que uma infração de menor potencial ofensivo não permaneça no Juizado Especial Criminal, tendo o seu trâmite em vara criminal ou vara do tribunal do júri. O que não significa que os institutos próprios dos juizados não sejam observados. Portanto, nessas hipóteses, é cabível a transação penal e a composição civil dos danos (art. 60, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95).

### 2.3.5. REGRAS PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS

Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da semana, a depender da Lei de Organização Judiciária (art. 64 da lei). Todavia, caso haja atos processuais em outras comarcas, a sua realização poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação (art. 65 da lei), incidindo o princípio da informalidade (art. 61 da lei). Exemplo: não é necessário expedir carta pretória para cumprimento de ato processual, desde que comprovada a efetiva comunicação.

A citação no juizado especial criminal deve ser feita de modo pessoal. Assim, não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei (art. 66, parágrafo único). Portanto, não se admite a citação por edital, devendo os autos serem remetidos ao juízo comum, em declínio, o qual seguirá o procedimento comum sumário (artigo 538, CPP).

Atenção: há divergência sobre a possibilidade de a citação por hora certa ser utilizada nos juizados especiais criminais, rito sumaríssimo, regido pela Lei nº 9.099/95. Para a primeira corrente, adotada por Norberto Avena, se o oficial de justiça informar que o réu está se ocultando para não ser citado, deverá o juiz declarar a incompetência do Juizado Especial e declinar os autos a uma das varas criminais comuns, seguindo os autos no procedimento comum sumário (art. 538 do CPP), conforme art. 66 da Lei nº 9.099/95, que afirma que a citação será pessoal. Para outra corrente, que prevalece no âmbito dos Juizados Especiais, é possível a citação por hora certa. Nesse sentido, enunciado nº 110 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais): no Juizado Especial Criminal é cabível a citação com hora certa.

|                                         |
|-----------------------------------------|
| FLUXOGRAMA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL |
| TERMO CIRCUNSTANCIADO                   |
| AUDIÊNCIA PRELIMINAR                    |
| RITO SUMARÍSSIMO PROPRIAMENTE DITO      |
| TURMA RECURSAL                          |

### 2.3.6. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – TCO (ART. 69)

A fase investigativa (pré-processual) é regulada pelo art. 69 da Lei nº 9.099/95. Desse modo, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência de uma infração de menor potencial ofensivo lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.

Devido à infração ser de menor potencial ofensivo, não será lavrado inquérito policial, mas termo circunstanciado, que conterá elementos para apurar a materialidade e indícios de autoria, embasando uma futura ação penal, se o caso.

Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança.

Enviado o termo circunstanciado ao juizado especial criminal, tem início a fase preliminar, em que será designada a chamada audiência preliminar.

### 2.3.7. AUDIÊNCIA PRELIMINAR – COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS

Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, em primeiro lugar, será tentada a chamada composição civil dos danos que, se aceita e homologada pelo juízo, importará em renúncia ao direito de queixa ou representação. Isto é, produzirá efeitos na ação penal privada e na ação penal pública condicionada à representação, nos termos do parágrafo único do art.

74 da lei. Caso homologada em ação penal pública incondicionada, não acarreta extinção da punibilidade, podendo o procedimento penal seguir normalmente. É de se notar também que o acordo somente produzirá efeitos quanto aos autores do crime que compuserem com a vítima. Para aqueles que não tiveram interesse em acordo, o procedimento seguirá.

**Atenção:**

a) Um dos objetivos do juizado especial criminal é a reparação do dano (art. 61), daí porque se inclui na tentativa de acordo o responsável civil. Exemplo: intima-se também o responsável legal caso o autor do fato estava agindo civilmente como preposto.

b) Nada impede que a composição civil dos danos seja feita posteriormente, inclusive no próprio termo de suspensão condicional o processo:

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ACORDO DE REPARAÇÃO CIVIL ENTRE AS PARTES. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LEI Nº 9.099/95. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. Embora a decisão de suspensão condicional do processo penal não faça coisa julgada material, em virtude da possibilidade de sua revogação, caso o beneficiário incida nas hipóteses previstas nos §§ 3º e 4º do artigo 89 da Lei nº 9099/99, durante o prazo de suspensão determinado, não há óbice legal que impeça o denunciado e a vítima de entabularem acordo, visando à reparação civil pelo crime, na mesma audiência em que fixadas as condições para suspensão do processo.2. O entendimento de que o acordo celebrado entre o denunciado e a vítima constitui título executivo atende ao espírito da Lei dos Juizados Especiais, que prima pela celeridade e concentração dos atos processuais, assim como pela simplificação dos procedimentos, a fim de incentivar as partes à autocomposição.3. Recurso especial provido (STJ, REsp 1123463/DF – grifo nosso).

c) A conciliação para a tentativa de se chegar a uma composição civil dos danos poderá ser conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua orientação. Estes são auxiliares da Justiça, recrutados, na forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em Direito, excluídos os que exerçam funções na administração da Justiça Criminal (art. 73).

d) A composição civil dos danos serve para reparar danos patrimoniais/morais decorrentes da prática delitiva, é homologada por sentença irrecorrível (ou seja, não cabe recurso) e se traduz em um título executivo judicial (art. 74).

Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo. No entanto, mesmo que não seja concedida na audiência preliminar, o não oferecimento não implica em decadência automática do direito (art. 75), pois poderá ser exercido dentro do prazo previsto no art. 38 do CPP, ou seja, seis meses a contar da data em que soube quem é o autor do fato.

Não alcançada a composição civil dos danos, poderá, ainda, ser proposta a transação penal, que objetiva a aplicação imediata de pena alternativa e é firmado, em regra, entre o Ministério Público e o autor do fato.

### 2.3.8. AUDIÊNCIA PRELIMINAR – TRANSAÇÃO PENAL

É orientada pelo princípio da discricionariedade regrada (abrandamento do princípio da obrigatoriedade da ação pública), uma vez que ocorre antes do oferecimento da peça inicial acusatória (momento pré-processual). Trata-se de proposta materializada pelo Ministério Público ao suposto autor do fato, que consiste na imediata aplicação de uma pena restritiva de direitos ou multa (art. 76, *caput*). Deve ter aceitação pelo autor do fato e seu defensor, não induz reincidência, não consta de antecedentes criminais e não terá efeitos civis. Contra ela cabe apelação (art. 76, § 5º).

É uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal (discricionariedade regrada; obrigatoriedade regrada). O Ministério Público está diante de elementos para propor a ação penal, mas não propõe e, ao invés, oferece o benefício, ou seja, é uma alternativa à denúncia. Se for o caso de arquivamento do procedimento, não poderá propor a transação penal e sim encerrá-lo.

O agente do delito, porém, não está obrigado a aceitar a transação penal, podendo recusar ou oferecer contraproposta. Caso aceite, não funciona como confissão de culpa, ficando registrada apenas para a não concessão do mesmo benefício dentro do prazo de 5 anos (art. 76, § 2º, II).

A transação penal é um instituto próprio da Lei nº 9.099/95, aplicável aos delitos previstos na mesma lei. É diferente da suspensão condicional do processo, que, em que pese tenha previsão dentro da Lei nº 9.099/95, pode ser aplicada inclusive em vara criminal, porque leva em consideração a pena mínima igual ou inferior a um ano, e não a pena máxima. Exemplo: delito de furto – art. 155, *caput*, CP – pena de 1 a 4 anos de reclusão. A vara criminal é competente para o julgamento do feito, tendo em vista a pena máxima ser igual a 4 anos, devendo ser adotado o procedimento comum ordinário. No entanto, a pena mínima é igual a um ano. Portanto, caso o autor do fato preencha os demais requisitos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, pode ser concedido o benefício da suspensão condicional do processo. O benefício tem previsão na Lei nº 9.099/95, mas será concedido na Vara Criminal em um feito que tramita no procedimento comum ordinário.

Não se admitirá proposta de transação penal quando (art. 76, § 2º, da Lei nº 9.099/95):

a) ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva. O autor do fato é reincidente em crime que o condenou necessariamente à pena privativa de liberdade. Caso possua condenação em contravenção penal, será possível a transação penal. Bem como, mesmo sendo condenado por crime, caso seja aplicada uma pena alternativa/restritiva de direitos ou então pena de multa, será possível a transação penal;

b) ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo. A concessão de transação penal não macula os antecedentes, ou seja, a vida pregressa da pessoa. No entanto, a concessão permanecerá anotada para que não receba o mesmo benefício nos próximos cinco anos, ou seja, só pode ser usada uma vez a cada cinco anos. O legislador não estabeleceu a partir de quando esse prazo de cinco anos será contado, entendendo a doutrina que o termo *a quo* é a data da audiência que concedeu e homologou o benefício (DEZEM, 2019, p. 1010);

c) não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, se necessária e suficiente a adoção da medida.

Se cumprida a transação penal, extingue a punibilidade do agente, nos termos do art. 76, §6º, da Lei nº 9.099/95.

O juiz não pode de ofício, e à revelia do MP, efetuar a proposta de transação penal. Nesse caso, o juiz deverá aplicar por analogia o art. 28 do CPP, remetendo os autos ao Procurador-Geral de Justiça, de acordo com a redação anterior à Lei Anticrime, em razão da suspensão da eficácia do novo dispositivo legal pelo Min. Luiz Fux na ADI 6305. Caso seja adotada a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, o agente interessado no recebimento do benefício deverá impugnar diretamente a omissão do Ministério Público no órgão de revisão ministerial mencionado no art. 28, § 1º, do CPP.

#### Atenção:

a) A transação penal não tem natureza jurídica de condenação criminal, não gera efeitos para fins de reincidência e Maus Antecedentes e, por se tratar de submissão voluntária à sanção penal, não significa reconhecimento da culpabilidade penal nem da responsabilidade civil (STJ, REsp 1327897/MA; AgRg no AREsp 619918/MT; AgRg no HC 248063/MG; HC 193681/SP; HC 239195/SP; REsp 844941/DF);

b) Da homologação da transação penal não cabe revisão criminal, exatamente por não ser considerada condenação. Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais superiores:



(...) Incabível o ajuizamento de revisão criminal contra sentença que homologa a transação penal (art. 76 da Lei n.º 9.099/95), já que não existiu condenação ou sequer houve análise de prova. Na verdade, ao se aplicar o instituto da transação penal, não se discute fato típico, ilicitude, culpabilidade ou punibilidade, mas apenas é possibilitada ao autor do fato uma aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa para que não exista o prosseguimento da ação penal, sendo o acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário e impugnável por meio do recurso de apelação.3. Recurso especial desprovido.(STJ, REsp 1107723/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 7/4/2011, DJe 25/4/2011 – grifo nosso.)

c) No caso de desclassificação ou procedência parcial da pretensão punitiva estatal é possível a aplicação por analogia da Súmula nº 337, STJ: “é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”. Nesse sentido, ainda:

(...) Segundo entendimento desta Corte Superior, havendo a procedência parcial da acusação ou a desclassificação do delito para outro que se amolde aos requisitos determinados pelos arts. 76 e 89 e da Lei n. 9.099/1995, os autos devem ser encaminhados ao Ministério Público para que se manifeste sobre a possibilidade de suspensão condicional do processo ou da transação penal. Inteligência da Súmula 337/STJ.3. Operada a desclassificação em segundo grau, é nulo o acórdão condenatório proferido sem conferir ao órgão ministerial a oportunidade de se manifestar acerca da possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo ao paciente. Precedentes.4. *Habeas Corpus* não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, mantida a desclassificação, anular o acórdão condenatório, a fim de que sejam os autos remetidos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo (STJ, HC 382.372/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 23/2/2017 – grifo nosso).

d) Em que pese a literalidade do art. 76 da Lei nº 9.099/95 prever expressamente o benefício apenas na ação penal pública e concedido pelo Ministério Público, entende a doutrina e jurisprudência majoritárias que também é possível a concessão na ação penal privada:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO QUERELANTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE.1. Embora admitida a possibilidade de transação penal em ação penal privada, este não é um direito subjetivo do querelado, competindo ao querelante a sua propositura.2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1356229/PR, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 19/3/2013, DJe 26/3/2013.)

No mesmo sentido, Enunciado 112 do Fórum Nacional dos Juízes Estaduais: “na ação penal de iniciativa privada, cabem transação penal e a suspensão condicional do processo, mediante proposta do Ministério Público”.

e) Caso o suposto autor do fato descumpra as cláusulas da transação penal, o Ministério Público pode continuar a persecução penal, seja oferecendo denúncia, seja requisitando a instauração de inquérito policial. A homologação da transação penal fará apenas coisa julgada formal. É o que dispõe a Súmula Vinculante nº 35: “a homologação da transação penal prevista no artigo 76 da lei 9099 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao MP a continuidade da persecução penal mediante o oferecimento de denúncia ou requisição do inquérito policial”;

f) Não sendo aceita ou não sendo possível a transação penal, o Ministério Público oferecerá denúncia oral (ou queixa oral pelo ofendido, tratando-se de ação penal privada). O autor



do fato já sairá citado. Note que, diferentemente dos procedimentos comuns ordinário e sumário, há a citação antes do recebimento da inicial acusatória. O procedimento sumaríssimo propriamente dito e suas diferenças com os procedimentos comum ordinário e sumário serão estudados em tópico seguinte.;

g) Frisa-se que a Lei de Crimes Ambientais dispõe que nas infrações de menor potencial ofensivo, a transação penal só pode ser proposta depois de firmada a composição do dano ambiental, salvo em caso de impossibilidade:

Lei nº 9.605/98

Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade.

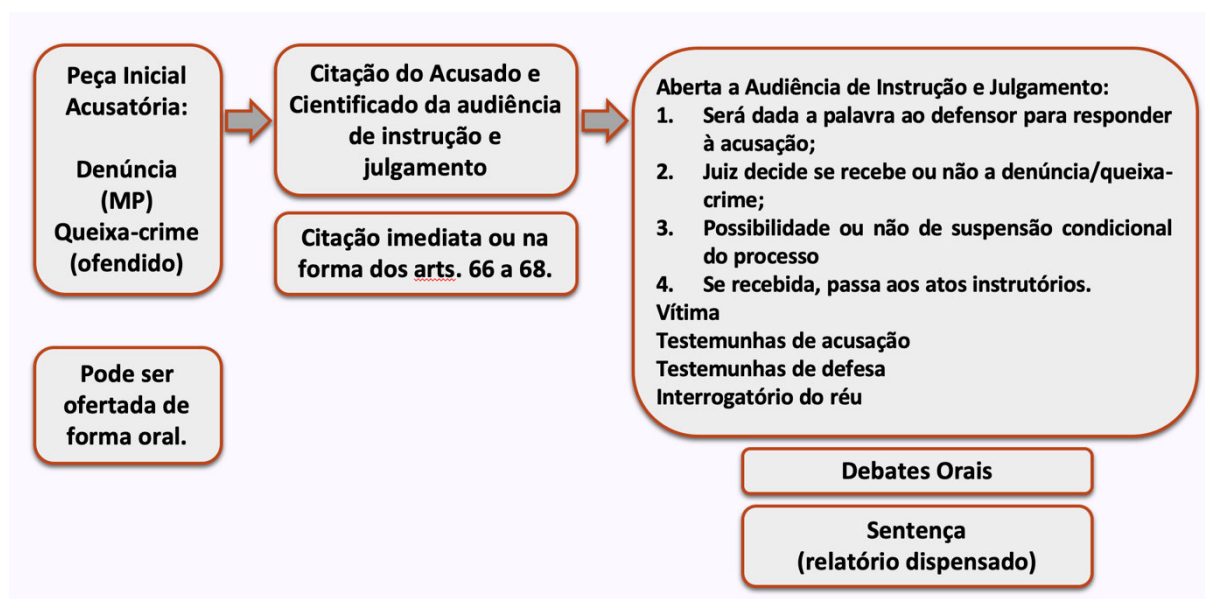
### 2.3.9. Procedimento sumaríssimo propriamente dito

Não sendo aceita ou não sendo possível a transação penal, o Ministério Público oferecerá denúncia oral (ou queixa oral pelo ofendido, tratando-se de ação penal privada), nos termos do art. 77. O autor do fato já sairá citado (art. 78). Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 68 (pessoalmente) e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes de sua realização. Note que, diferentemente dos procedimentos comuns ordinário e sumário, há a citação antes do recebimento da inicial acusatória.

Na audiência de instrução e julgamento, depois de se tentar nova conciliação, a defesa tentará convencer o juiz a não receber a denúncia ou queixa, em verdadeira defesa preliminar, na forma do art. 81 da lei. Caso a denúncia ou queixa seja rejeitada, caberá a interposição de recurso de apelação, com prazo de 10 dias, nos termos do art. 82.

Caso o juiz rejeite as alegações da defesa e receba a peça inicial acusatória, então serão ouvidas as vítimas, testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente (todas as provas produzidas, de regra, em uma mesma audiência). Serão feitos os debates orais e a prolação da sentença (que dispensa relatório).

Eis o resumo:



### 2.3.10. FASE RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

Nos juizados especiais criminais serão cabíveis os seguintes recursos e meios de impugnação:

- a) apelação (art. 82);
- b) embargos de declaração (art. 83);
- c) recurso extraordinário (art. 102, III, da CF/88);
- d) reclamação para o Tribunal de Justiça;
- e) revisão criminal;
- f) *habeas corpus*;
- g) mandado de segurança para a própria Turma Recursal (Súmula nº 376, STJ: compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial).

Abaixo há análise daqueles recursos previstos na Lei nº 9.099/95. Os demais serão estudados em capítulo próprio de recursos criminais e ações de impugnação.

#### 2.3.10.1. APELAÇÃO (ART. 82)

Possui algumas peculiaridades em relação ao CPP. Será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Isto é, o prazo de dez dias é único tanto para apresentação da peça de interposição como das razões. Cabe apelação da homologação da transação penal (art. 76), da rejeição da denúncia ou queixa (art. 82) e da sentença final do procedimento, seja ela absolutória, seja ela condenatória (art. 82). Lembrando que a decisão que homologa a composição civil dos danos é irrecorrível (art. 72). Será julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado (art. 82, *caput*).

#### 2.3.10.2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Os embargos de declaração são cabíveis no Juizado Especial Criminal e estão previstos no art. 83 da Lei nº 9.099/95. Cabem quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Também estão os embargos previstos no CPP, mas lá o prazo de oposição é de dois dias. Em ambas as legislações a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo de recurso próprio. Ressalte-se, porém, que erros materiais podem ser corrigidos de ofício pelo juiz.

| EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CPP                    | EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA LEI Nº 9.099/95 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Obscuridade, ambiguidade, contradição e omissão. | Obscuridade, contradição e omissão.       |
| Prazo de dois dias.                              | Prazo de cinco dias.                      |
| Interrompe o prazo recursal.                     | Interrompe o prazo recursal.              |
| Arts. 362 e 619, ambos do CPP.                   | Art. 83 da Lei nº 9.099/95.               |

#### Atenção:

a) Da decisão da Turma recursal não é cabível Recurso Especial para o STJ (Súmula nº 203, STJ), pois esse recurso somente é cabível de decisão de Tribunal e Turma Recursal não é Tribunal, e sim composta por três juízes de primeira instância. Contudo, poderá ser interposto recurso extraordinário contra decisão proferida por turma recursal de juizado especial criminal (Súmula nº 640, STF).

b) Mostra-se cabível a revisão criminal no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, que será analisada pela própria Turma Recursal:



(...) Apesar da ausência de expressa previsão legal, mostra-se cabível a revisão criminal no âmbito dos Juizados Especiais, decorrência lógica da garantia constitucional da ampla defesa, notadamente quando a legislação ordinária vedou apenas a ação rescisória, de natureza processual cível. 2. É manifesta a incompetência do Tribunal de Justiça para tomar conhecimento de revisão criminal ajuizada contra *decisum* oriundo dos Juizados Especiais. 3. A falta de previsão legal específica para o processamento da ação revisional perante o Colegiado Recursal não impede seu ajuizamento, cabendo à espécie a utilização subsidiária dos ditames previstos no Código de Processo Penal. 4. Caso a composição da Turma Recursal impossibilite a perfeita obediência aos dispositivos legais atinentes à espécie, mostra-se viável, em tese, a convocação dos magistrados suplentes para tomar parte no julgamento, solucionando-se a controvérsia e, principalmente, resguardando-se o direito do agente de ver julgada sua ação revisional. 5. Competência da Turma Recursal. (STJ, CC 47.718/RS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/8/2008, DJe 26/8/2008.)

c) Compete aos Tribunais de Justiça ou aos Tribunais Regionais Federais o julgamento dos pedidos de *habeas corpus* quando a autoridade coatora for Turma Recursal dos Juizados Especiais (STJ, HC 369717/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 25/4/2017, DJE 3/5/2017).

### 2.3.11. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

Suspensão condicional do processo é instituto despenalizador previsto na Lei nº 9.099/95 oferecido pelo Ministério Público (ação penal pública) ou pelo querelante (ação penal privada) ao acusado que tenha sido denunciado por infração cuja pena mínima seja igual ou inferior a um ano e que não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, desde que presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Apesar de prevista na Lei nº 9.099/95, aplica-se tanto no juizado especial criminal quanto fora dele, pois o ponto importante é a pena mínima abstratamente cominada à infração. Exemplo: delito de furto – art. 155, *caput*, CP – pena de 1 a 4 anos de reclusão. A vara criminal é competente para o julgamento do feito, tendo em vista a pena máxima ser igual a 4 anos, devendo ser adotado o procedimento comum ordinário. No entanto, a pena mínima é igual a um ano. Portanto, caso o autor do fato preencha os demais requisitos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, pode ser concedido o benefício da suspensão condicional do processo. O benefício tem previsão na Lei nº 9.099/95, mas será concedido, por exemplo, na Vara Criminal em um feito que tramita no procedimento comum ordinário.

Caso o acusado aceite a proposta, o processo ficará suspenso, pelo prazo de 2 a 4 anos (período de prova), desde que ele aceite cumprir determinadas condições impostas pela lei e a outras que podem ser fixadas. Período de prova é, portanto, o prazo no qual o processo ficará suspenso, devendo o acusado cumprir as condições impostas neste lapso temporal. O período de prova é estabelecido na proposta de suspensão e varia de 2 a 4 anos, nos termos do art. 89, *caput*, da Lei nº 9.099/95. Durante o período de suspensão do processo também ficará suspenso o curso do prazo prescricional (art. 89, § 6º).

O benefício, como visto, leva em consideração a pena mínima abstratamente cominada. No entanto, ele não será aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um ano, conforme previsão sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula nº 243, STJ e Súmula nº 723, STF). Incidem aqui para definir a quantidade de pena mínima as causas de aumento e as causas de diminuição da pena, mas não as agravantes e as atenuantes, assim como visto no caso da definição do procedimento a ser seguido.

Vale lembrar que a Lei nº 9.099/95 não é aplicável na Lei Maria da Penha. Dessa forma, não caberá suspensão condicional do processo (Súmula nº 536, STJ).

A suspensão condicional do processo pressupõe que tenha havido o recebimento da denúncia. Por isso, é instituto que excepciona o princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Importante ressaltar que o juiz deverá, primeiro, analisar os argumentos apresentados pela defesa em resposta à acusação e, apenas não sendo o caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), é que deverá ser marcada a audiência para a proposta da suspensão condicional do processo. A absolvição sumária é mais benéfica ao autor do fato do que se submeter a vários anos de cumprimento de condições. Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

*HABEAS CORPUS. (...) OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO ANTES DA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 89 DA LEI 9.099/1995 À LUZ DAS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 11.719/2008. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO .1. Embora o artigo 89 da Lei 9.099/1995 estabeleça que a proposta de suspensão condicional do processo deve ser feita no momento do oferecimento da denúncia, tal dispositivo deve ser compatibilizado com as modificações promovidas no procedimento comum ordinário pela Lei 11.719/2008. 2. Diante da possibilidade de absolvição sumária, mostra-se desarrazoado admitir que a suspensão condicional do processo seja oferecida ao denunciado antes da análise de sua resposta à acusação, na qual pode veicular teses que, se acatadas, podem encerrar a ação penal. (...) (STJ. HC n. 239.093/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29/10/2013).*

O juiz não pode de ofício, e à revelia do MP, efetuar a proposta de suspensão condicional do processo. Nesse caso, reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal (Súmula nº 696, STF). A redação dessa súmula está de acordo com a redação anterior à Lei Anticrime. Ressalta-se que o novo dispositivo está com a eficácia suspensa por decisão do Min. Luiz Fux na ADI 6305. Caso posteriormente venha a ser adotada a nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019, o agente interessado no recebimento do benefício deverá impugnar diretamente a omissão do Ministério Público no órgão de revisão ministerial mencionado no art. 28, § 1º, do CPP.

#### Observações:

1) O simples fato de estar sendo investigado em inquérito policial não induz qualquer óbice para a proposta da suspensão condicional do processo, tendo em vista que o art. 89, *caput*, afirma “não esteja sendo processado”. Portanto, a existência de inquérito policial em curso não é circunstância idônea a obstar o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo (STJ, RHC 079751/SP; HC 036132/BA).

2) Doutrina minoritária entende que a vedação do benefício quando o acusado estiver ainda sendo processado viola o princípio da presunção da inocência. No entanto, o STF rejeitou esta posição e entendeu pela constitucionalidade da previsão:

É constitucional a norma do art. 89 da Lei no 9.099/95, que estabelece os requisitos para a concessão do benefício da suspensão condicional do processo, entre eles o de não responder o acusado por outros delitos. Assim, a existência de ações penais em curso contra o denunciado impede a concessão do *sursis* processual por força do art. 89 da Lei no 9.099/95. (STF. 1ª Turma. AP 968/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22/5/2018 - Info 903 e STF. 2ª Turma. RHC 133945 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/6/2016.)

3) Mesmo que depois ele venha a ser absolvido, não caberá a concessão do benefício da suspensão condicional do processo:

Não cabe a concessão do benefício da suspensão condicional do processo se o acusado, no momento do oferecimento da denúncia, responde a outro processo criminal, mesmo



que este venha a ser posteriormente suspenso ou que ocorra a superveniente absolvição do acusado (STJ, AgRg no REsp 1154263/SC; AgRg no Ag 1386813/RS; REsp 1194424/MA).

4) O STJ entende pela interpretação extensiva e aplicação do requisito do art. 76, § 2º, II, da Lei nº 9.099/95, também para os casos de suspensão condicional do processo:

O prazo de 5 (cinco) anos para a concessão de nova transação penal, previsto no art. 76, § 2º, inciso II, da Lei n. 9.099/95, aplica-se, por analogia, à suspensão condicional do processo (STJ, RHC 080170/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgado em 28/3/2017, DJE 5/4/2017).

5) A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim de poder-dever do Ministério Público:

PENAL E PROCESSUAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. Consoante entendimento desta Corte, a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada. Hipótese em que a negativa da suspensão condicional do processo está amparada na ausência dos requisitos previstos no art. 77, II, do Código Penal, referidos pelo art. 89 da Lei n. 9.099/1995, sendo certo que, para a eventual desconstituição da conclusão das instâncias ordinárias, seria necessária a incursão no conjunto probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 607.902/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 17/2/2016.)

6) O denunciado poderá recusar a proposta, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos (art. 89, § 7º). No entanto, aceitando a proposta, o processo ficará suspenso (pelo período de prova de dois a quatro anos), submetendo o acusado ao cumprimento das seguintes condições, previstas de forma expressa no art. 89, § 1º, da Lei nº 9.099/95: I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; II - proibição de frequentar determinados lugares; III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz; IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. No entanto, conforme já decidiu o STJ, estas não são as únicas condições que podem ser impostas para cumprimento, não havendo óbice, inclusive, que sejam fixadas condições próprias das penas restritivas de direitos do art. 44 do CP:

Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no art. 89, § 2º, da Lei nº 9.099/95, obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais (tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária – art. 44, CP), mas que, para os fins do *sursis* processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência. (STJ. 3ª Seção. REsp 1.498.034-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 25/11/2015 - recurso repetitivo - Info 574.) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 TEMA 930.)

7) O STJ entendeu, ainda, que não há óbice em se fixar como condição especial a perda da fiança ou uma prestação pecuniária. Exemplo: João foi preso em flagrante pelo delito de receptação e efetuou o pagamento da fiança para ser colocado em liberdade. Durante o processo, foi oferecido o benefício da suspensão condicional do processo a João, fixando como condição que ele perdesse o valor que pagou de fiança para conversão em prestação pecuniária.

A perda do valor da fiança constitui legítima condição do *sursis* processual, nos termos do art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/95 (STJ, AgRg no RHC 085835/PR; AgRg no RHC 083810/PR; RHC 064083/RS; AgRg no RHC 069873/PR).



8) O assistente de acusação não possui legitimidade para o oferecimento do benefício ou para fixar condições na proposta, pois não é o titular da ação penal.

(...) não tem o assistente da acusação direito à inclusão de nova condição na proposta de suspensão condicional do processo apresentada pelo Ministério Público, pois tal atribuição pertence ao titular da ação penal, nos termos do art. 89 da Lei n.9.099/95, podendo o Magistrado fixar outras condições, conforme previsão expressa no § 2º de referido dispositivo. IV - Assim, não há violação a direito líquido e certo da agravante na decisão que, após manifestação contrária do Ministério Público, indefere o pedido do assistente de acusação de inclusão de nova condição na proposta, por entender que referida condição seria inadequada e demasiadamente onerosa ao agravado. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RMS 54.426/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 5/3/2018.)

9) Aceito o benefício, o processo ficará suspenso pelo período de prova de dois a quatro anos, dependendo do que constar da proposta. Não há incompatibilidade entre a aceitação e o posterior manejo de *habeas corpus* em favor do autor do fato aceitante. O impetrante poderá trancar a ação penal em curso.

A aceitação pelo paciente do benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, não inviabiliza a impetração de *habeas corpus* nem prejudica seu exame, tendo em vista a possibilidade de se retomar o curso da ação penal caso as condições impostas sejam descumpridas (STJ, HC 402718/SP; RHC 080363/SP; HC 380622/SP; HC 350564/SP; AgRg no RHC 043279/SP; HC 368703/SP).

10) Caso não haja a revogação da suspensão condicional do processo, encerrado o período de prova, o juiz irá declarar extinta a punibilidade do acusado. Assim, este processo não será considerado para macular a vida pregressa do autor do fato, servindo apenas para impedir nova concessão do benefício no prazo de cinco anos, como visto pela aplicação analógica do art. 76, § 2º, II, da Lei nº 9.099/95.

A extinção da punibilidade do agente pelo cumprimento das condições do *sursis* processual, operada em processo anterior, não pode ser sopesada em seu desfavor como maus antecedentes, personalidade do agente e conduta social (STJ, HC 385535/RJ; REsp 1533788/PE; HC 198815/SP; HC 156569/SP)

11) A lei prevê causas obrigatórias e facultativas de revogação do benefício. Nos termos do art. 89, § 3º, a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. Note que o dispositivo utiliza o verbo “será”, como verdadeira imposição. Dessa forma, em ocorrendo uma dessas causas, o benefício necessariamente será revogado. Nos termos do art. 89, § 4º, a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta. O dispositivo prevê, portanto, causas facultativas. Mesmo ocorrendo uma delas, o Ministério Público pode opinar pela continuidade do benefício, havendo discricionariedade na análise.

12) Pode ser que o acusado pratique alguma causa de revogação do benefício durante o período de prova, mas que isso apenas venha a ser descoberto após o prazo. Este problema existe porque a fiscalização no cumprimento da medida é falha por parte do Estado, não sendo conferidos os autos todos os meses, tendo em vista a carga de trabalho das Varas. Exemplo: João é processado por receptação (pena de reclusão de 1 a 4 anos). Por preencher todos os requisitos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, o Ministério Público oferece o benefício pelo período de prova de 2 anos e cumprimento de determinadas condições. No segundo ano do período de prova, João vem a ser processado por novo crime (agora de furto). No entanto, Ministério Público e juiz apenas ficam



sabendo do ocorrido após o período de prova dos 2 anos, quando os autos foram conclusos para análise da extinção ou não de punibilidade do agente. O que fazer nesta hipótese? Entende o STJ que o benefício será revogado (art. 89, § 3º), mesmo se descoberto posteriormente. O que importa para a análise é quando a circunstância foi efetivamente praticada (se durante ou não o período de prova).

Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. (STJ. 3ª Seção. REsp 1.498.034-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 25/11/2015 - recurso repetitivo - Info 574.)

13) Em que pese a literalidade do art. 89 da Lei nº 9.099/95 prever expressamente o benefício apenas na ação penal pública e concedido pelo Ministério Público, entende a doutrina e a jurisprudência que também é possível a concessão na ação penal privada. Cuidado com o Enunciado 112 do Fórum Nacional dos Juízes Estaduais: “na ação penal de iniciativa privada, cabem transação penal e a suspensão condicional do processo, mediante proposta do Ministério Público”.

14) É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva (Súmula nº 337, STJ). Os autos devem ser encaminhados ao Ministério Público para que se manifeste sobre a possibilidade de suspensão condicional do processo ou de transação penal.

Exemplo1– Desclassificação do crime: o Ministério Público propôs denúncia por furto qualificado (pena mínima ultrapassa um ano e, portanto, não cabe o benefício). Na audiência de instrução, a qualificadora não foi confirmada. O juiz, verificando o ocorrido e a possibilidade de desclassificação para furto simples, o que, em tese, caberia o benefício da suspensão condicional do processo, fundamenta a desclassificação e remete os autos ao Ministério Público para que analise o cabimento da suspensão condicional do processo.

Exemplo2– Procedência parcial da pretensão punitiva: o Ministério Público denuncia o réu por receptação e furto simples (pena mínima somada ultrapassa 1 ano – não cabe o benefício). No momento da sentença, o juiz verifica ser o caso de procedência parcial da pretensão punitiva estatal, caso profira sentença: condenação no furto e absolvição da receptação. Nesse caso, o agente faz jus ao benefício caso preencha os demais requisitos do art. 89. O juiz deverá remeter ao Ministério Público, que analisará se é caso de propor ou não o benefício.

Exemplo3– Exemplo que não se encaixa em procedência parcial da pretensão punitiva (Info 591 do STJ) e, portanto, não será aplicada a Súmula nº 337, STJ: o Ministério Público denunciou o réu por dois crimes e ele foi condenado nos dois em sentença em primeira instância, ou seja, houve procedência total. Após o Tribunal reconheceu a prescrição, em razão da pena concreta, em um dos crimes, remanescendo outro que, em tese, caberia a suspensão condicional do processo. No entanto, nessa hipótese, o STJ entendeu pela não aplicação do benefício, já que não houve procedência parcial da pretensão punitiva – a qual, de fato, foi integral/total – não sendo o caso de incidência da Súmula nº 337, STJ.

15) A suspensão condicional do processo é aplicável aos crimes ambientais, com as observações do artigo 28 da Lei nº 9.605/98:

Lei nº 9605/98

Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as seguintes modificações:

I - a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5º do artigo referido no caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do § 1º do mesmo artigo;

- II - na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período máximo previsto no artigo referido no *caput*, acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo da prescrição;
- III - no período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, III e IV do § 1º do artigo mencionado no *caput*;
- IV - findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão, até o máximo previsto no inciso II deste artigo, observado o disposto no inciso III;
- V - esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano.

### 3. PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

#### 3.1. PROCEDIMENTO PARA CRIMES DE RESPONSABILIDADE COMETIDOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO (ARTS. 513 A 518 DO CPP)

Quando o CPP dispõe sobre o procedimento especial para processar e julgar crimes de responsabilidade de funcionários públicos, quer se referir aos crimes tipificados nos artigos 312 a 326 do CPP (crimes praticados, no exercício de suas funções, por funcionários públicos contra a administração em geral). Dentre eles, há alguns que possuem pena máxima igual ou inferior a dois anos e, para esses, o rito será o sumaríssimo, já disposto em tópico próprio. Para esses crimes, sendo a pena máxima não superior a dois anos, segue-se o rito do juizado especial criminal, e não o rito especial ora comentado.

Antes da mudança pela Lei nº 12.403/2011, havia grande interesse nesse tema, pois somente seriam afiançáveis os crimes com pena mínima menor ou igual a dois anos. Agora, porém, não há mais que se falar nesse critério. Com o advento da citada lei em 2011, que alterou o CPP em matéria de prisões cautelares e liberdade provisória, todos os crimes funcionais atualmente são afiançáveis, e, portanto, o presente procedimento será aplicável a todos eles.

Além disso, em se tratando de crime funcional que o funcionário público possua foro por prerrogativa de função, não será aplicado esse procedimento e sim o da lei própria: Lei nº 8.038/90 (procedimento dos crimes de competência originária). O tema de competência em razão da pessoa foi tratado em capítulo próprio.

O procedimento para apuração dos chamados crimes funcionais é diferente do procedimento ordinário apenas no que se refere à existência da chamada defesa preliminar. Ofertada a denúncia, o juiz, antes de decidir pelo recebimento ou rejeição, notificará o denunciado para responder por escrito no prazo de 15 dias, conforme art. 514 do CPP. A não notificação do denunciado para ofertar a defesa preliminar escrita ocasiona nulidade relativa.

Depois da apresentação da resposta escrita, o juiz decidirá se recebe ou não a exordial acusatória e, se a receber, deverá dar andamento ao processo seguindo o procedimento ordinário.

É importante notar que o STJ editou a Súmula nº 330, cujo teor diz: “É desnecessária a resposta preliminar de que trata o art. 514 do CPP, na ação penal instruída por inquérito policial.” Assim, entende o STJ que, havendo inquérito policial, não há necessidade de defesa preliminar.

Todavia, mais recentemente, o STF entendeu que a defesa preliminar é obrigatória mesmo se a ação penal for instruída com o inquérito policial:

É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para o reconhecimento de nulidade decorrente da inobservância da regra prevista no art. 514 do CPP, é necessária a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. Improcede, pois, pedido de renovação de todo o procedimento criminal com base em alegações genéricas sobre a ocorrência de nulidade absoluta. 2. Ademais, se a finalidade da defesa preliminar está relacionada ao interesse público de evitar persecução criminal temerária contra funcionário público, a superveniência de sentença condenatória, que decorre do amplo debate da lide penal,



prejudica a preliminar de nulidade processual, sobretudo se considerado que essa insurgência só foi veiculada nas razões de apelação (STF, HC 128109/MG, 2ª T., Rel. Min. Teori Zavascki, j. 8/9/2015).

Desse modo, não há consenso na jurisprudência, devendo ficar atento para aos dois posicionamentos.

Nos termos do art. 514 do CPP, a defesa preliminar é oferecida antes do recebimento da denúncia ou queixa, e tem como objetivo exatamente impedir o recebimento da inicial acusatória (art. 515 do CPP).

#### **Atenção:**

a) se um particular pratica um crime funcional em concurso com um funcionário público, aquele não terá essa prerrogativa de apresentação da defesa antes do recebimento da denúncia ou queixa;

b) o funcionário público que não estiver ativo, por exemplo, foi exonerado, demitido, ou está aposentado, não fará jus à defesa preliminar;

c) se o funcionário público praticar crimes funcionais e não funcionais, em concurso, não terá direito de apresentar defesa preliminar em ambos os crimes;

d) a defesa preliminar é peça meramente facultativa. Pode ou não o funcionário público apresentar;

e) se o juiz não conceder o prazo previsto na lei (art. 514 do CPP), haverá tão somente nulidade relativa, dependendo, portanto, de comprovação de prejuízo.

Após o recebimento da peça inicial acusatória, seja ela denúncia, seja ela queixa, o juiz deverá determinar a citação do réu para que apresente resposta escrita (arts. 396 e 396-A, ambos do CPP). Em seguida, irá decidir sobre absolvição sumária (art. 397 do CPP) e, não sendo o caso, designará audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que as provas serão produzidas na forma do art. 400 do CPP. Após, podem ser requeridas diligências (art. 402 do CPP), oferecidas alegações finais orais ou via memoriais escritos (arts. 403 e 404, ambos do CPP) e proferida sentença oral ou escrita. Tudo conforme o detalhamento que estudamos na parte de procedimento comum ordinário.

### **3.2. PROCEDIMENTO ESPECIAL DOS CRIMES CONTRA A HONRA (ARTS. 519 A 523 DO CPP)**

Constituem crimes contra a honra: calúnia, injúria e difamação. Em regra, a ação é privada, procedendo-se mediante queixa. São exceções:

a) ofensa contra Presidente da República ou Chefe de Governo Estrangeiro: ação penal pública condicionada à requisição do ministro de Justiça;

b) ofensa contra funcionário público: ação penal pública condicionada à representação do ofendido. O STF entende que a legitimidade é concorrente do MP (representação) e ofendido (queixa) (Súmula nº 714 do STF);

c) injúria real (art. 140, § 2º): se da violência resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ação penal pública incondicionada; se da violência resultar lesão corporal de natureza leve, ação penal pública condicionada à representação;

d) injúria racial (art. 140, § 3º): ação penal pública condicionada à representação.

A atual redação do artigo 61 da Lei nº 9.099/95, modificado pela Lei nº 11.313/2006, passou a considerar infração de menor potencial ofensivo aquela cuja pena máxima abstrata seja igual ou inferior a dois anos, não fazendo restrições quanto ao rito para caracterização.

Portanto, passou a ser entendimento amplamente majoritário o de que os crimes contra a honra com pena máxima abstrata não superior a dois anos (todos, menos calúnia em concurso com o art. 141 do CP) seguem o rito sumaríssimo e não mais o especial, o que inclui praticamente todas

as hipóteses. Apenas naquelas bem restritas que eles não serão julgados no juizado especial criminal (TAVORA; ALENCAR, 2020, p. 667):

- a) o crime é eleitoral – aplica-se o Código Eleitoral e seu respectivo procedimento especial;
- b) o crime é militar – aplica-se o Código de Processo Penal Militar e seu respectivo procedimento;
- c) crime contra a honra praticado por agente com foro por prerrogativa de função – aplica-se a Lei nº 8.038/90;
- d) o fato é complexo e, portanto, haverá o declínio para a vara comum e adoção do procedimento comum sumário (art. 77, §2º, da Lei nº 9.099/95; art. 538 do CPP);
- e) necessidade de citação por edital e, portanto, haverá o declínio para a vara comum e adoção do procedimento comum sumário (art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95; art. 538 do CPP);
- f) a pena máxima do crime supera o patamar de dois anos de pena privativa de liberdade e, portanto, sai da competência do juizado especial criminal (art. 61 da Lei nº 9.099/95).

Das hipóteses acima mencionadas, apenas a última adotará o procedimento dos arts. 519 a 523 do CPP), o que demonstra que o procedimento especial aqui previsto se encontra bem esvaziado.

O procedimento previsto no CPP (arts. 519 e ss. do CPP) toma por base o rito ordinário, com duas alterações:

- a) audiência prévia de conciliação, anterior ao próprio recebimento da queixa (art. 520 do CPP);
- b) possibilidade de exceção da verdade e exceção da notoriedade do fato, quando cabíveis (art. 523 do CPP).

A sequência do rito será, portanto, a seguinte:

- a) oferecimento da denúncia ou queixa-crime (arts. 41 e 46 do CPP): no prazo de 15 (quinze) dias, em caso de réu solto, e cinco dias, em caso de réu preso;
- b) audiência de conciliação: cabível apenas quando a ação for exclusivamente privada. Trata-se de oportunidade, anterior ao recebimento, em que, intimados a comparecer em juízo querelante e querelado, o juiz verifica a possibilidade de eventual conciliação. É importante salientar que tal audiência não ocorrerá nos casos de ação penal pública, tendo em vista o princípio da indisponibilidade da ação penal. Não se permite na ação penal privada subsidiária da pública, tendo em vista que esta é, em sua origem, pública;

Atenção: o não comparecimento do querelante à audiência de conciliação implica apenas na impossibilidade de conciliação e não na perempção (STJ, REsp 605871). Além disso, o seu não comparecimento não permite a condução coercitiva para o ato de conciliar (TAVORA; ALENCAR, 2019, p. 668).

c) recebimento da denúncia ou queixa-crime: não admite recurso, porém o réu poderá impetrar *habeas corpus*. Se estiverem presentes as situações do artigo 395 do CPP, o juiz deverá rejeitar liminarmente a denúncia ou queixa, cabendo recurso em sentido estrito dessa decisão;

d) citação do réu para a apresentação de defesa escrita: pessoal, por hora certa ou por edital;

e) defesa escrita: no prazo de 10 dias, com rol de testemunhas. É também o momento oportuno à apresentação da exceção da verdade ou da notoriedade. No crime de injúria, não será cabível a exceção da verdade.

f) contestação da exceção da verdade: no prazo de dois dias, podendo ser arroladas testemunhas em substituição àquelas arroladas na queixa ou em complemento a elas, se o número legal ainda não tiver sido atingido;

g) julgamento antecipado *pro reo*: com absolvição sumária, nas hipóteses do art. 397 do CPP ou recebimento da ação;



h) Audiência de instrução: declarações do ofendido; inquirição das testemunhas da acusação; inquirição das testemunhas arroladas pela defesa; esclarecimentos dos peritos (se houver prévio requerimento das partes); acareações; reconhecimentos; interrogatório; alegações finais orais por 20 minutos para cada parte, prorrogáveis por mais 10 a critério do juiz (se houver mais de um réu, o tempo de cada um será individual; se houver assistente da acusação, terá 10 minutos para falar depois da manifestação do Ministério Público, prorrogando-se por igual período o tempo da defesa);

i) debates;

j) sentença.

Admite-se a retratação até a sentença e independerá da aceitação do ofendido para extinguir a punibilidade.

### 3.3. PROCEDIMENTO ESPECIAL DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL (ARTS. 524 A 530-I DO CPP)

Aplica-se tanto à ação penal pública quanto à ação penal privada.

Cuidado com o prazo decadência especial para o oferecimento de queixa-crime por delitos contra a propriedade imaterial que deixar vestígios. Segundo o art. 529, nos crimes de ação privada (art. 184, *caput*), não será admitida queixa com fundamento em apreensão e em perícia, se decorrido o prazo de 30 dias, após a homologação do laudo.

Ainda com relação aos que deixam vestígios, o art. 525 do CPP, aponta verdadeira condição de procedibilidade, aos dispor que a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito. Contudo, se o crime não deixar vestígios, a jurisprudência aponta que esse exame pericial é totalmente dispensável (STF, RHC 63540/SP).

Quanto ao laudo pericial, o art. 527 aponta que será realizado por 2 peritos nomeados pelo juiz, que verificarão a existência de fundamento. Porém, a doutrina aponta pela necessidade de presença de apenas um perito, em consonância com o art. 159 do CPP, que foi alterado em 2008 pela Lei nº 11.690.

Por fim, para este procedimento, são aplicáveis as demais regras do procedimento comum ordinário, conforme art. 524 do CPP, que foram estudadas em tópico próprio e estão previstas nos arts. 394 a 405 do CPP.

### 3.4. PROCEDIMENTO ESPECIAL DO TRIBUNAL DO JÚRI (ARTS. 406 A 497 DO CPP)

Devem seguir o procedimento especial do tribunal do júri os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, bem como as infrações que tenham com aqueles crimes relação de conexão (art. 5º, XXXVIII, da CF/88; e art. 78, III, do CPP). São crimes dolosos contra a vida os previstos nos arts. 121 a 127 do CP (homicídio, aborto, infanticídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio), não sendo de competência do Tribunal do Júri o delito de latrocínio (Súmula nº 603 do STF).

São princípios do Tribunal do Júri previstos na Constituição Federal (art. 5º, XXXVIII, CF/88):

a) plenitude de defesa;

b) sigilo das votações;

c) soberania dos veredictos;

d) competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

O tribunal do júri é órgão de primeira instância (justiça comum), de composição mista (heterogêneo – juiz de direito togado e jurados), temporário (funciona apenas em alguns períodos do ano) e horizontal (não há qualquer hierarquia entre o juiz de direito togado e os jurados). É composto pelo juiz de direito e 25 jurados (art. 447 do CPP), sorteados para formação do conselho de



sentença. O juiz de direito exerce a presidência do Tribunal do Júri e suas atribuições estão previstas no art. 497 do CPP.

Conforme previsto na lei, 25 jurados compõem o Tribunal do Júri, sendo necessários pelo menos 15 presentes no dia do julgamento para a instalação dos trabalhos do Tribunal do Júri (art. 463, *caput*, CPP). Dentre os presentes, serão sorteados 7 para compor o chamado Conselho de Sentença, que vão decidir se o réu deve ser condenado ou absolvido por meio de votação de quesitos na sala secreta.

O procedimento é bifásico (escalonado) e subdivide-se em dois momentos:

a) *Judicium accusationis*: fase da formação da culpa ou sumário da culpa ou instrução preliminar ou juízo de admissibilidade ou juízo de acusação: nessa fase, que é relativamente similar ao procedimento ordinário, ocorre o exame de admissibilidade da acusação (sumário de culpa);

b) *Judicium causae*: fase do julgamento ou da acusação em plenário ou juízo de mérito ou juízo da causa: fase que se passa efetivamente no tribunal do júri.

Abaixo, há o estudo de cada uma delas:

### 3.4.1. JUDICIUM ACCUSATIONIS

1) Oferecimento da denúncia ou queixa-crime: no prazo de 15 (quinze) dias em caso de réu solto, e cinco dias em caso de réu preso.

2) Recebimento da denúncia ou queixa-crime: não admite recurso, porém o réu poderá impetrar *habeas corpus*. Embora não conste expressamente no trecho da lei referente ao procedimento do júri, não parece haver dúvidas sobre a possibilidade de rejeição da inicial nas hipóteses previstas no artigo 395 do CPP (inépcia da inicial, falta de condição da ação ou pressuposto recursal ou falta de justa causa). Da decisão de rejeição liminar cabe recurso em sentido estrito (art. 581, I, CPP).

3) Citação do réu para a apresentação de defesa escrita.

4) Defesa escrita: no prazo de 10 dias (art. 406 do CPP). Nela, o acusado deverá arguir toda a matéria de defesa, além de arrolar testemunhas, no número máximo de 8 (oito). Não apresentada no prazo legal, o juiz deverá nomear defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos.

5) Manifestação da acusação sobre a defesa escrita (art. 409 do CPP): no prazo de cinco dias, deve ser ouvido o Ministério Público ou o querelante. Note-se que no procedimento ordinário não é prevista expressamente a possibilidade de contraditório após a apresentação da resposta escrita, mas lá é utilizada por analogia esta previsão, como visto.

6) Prazo máximo para a realização da audiência de instrução e julgamento (art. 410 do CPP): o dispositivo legal prevê que o juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes, no prazo máximo de dez dias (e não de 60 como visto no procedimento comum ordinário; nem de 30 como visto no procedimento comum sumário).

7) Audiência de instrução, debates e julgamento (art. 411 do CPP):

a) declarações do ofendido;

b) inquirição das testemunhas da acusação;

c) inquirição das testemunhas arroladas pela defesa;

d) esclarecimentos dos peritos (se houver prévio requerimento das partes);

e) acareações;

f) reconhecimentos;

g) interrogatório;

h) alegações finais orais por 20 minutos para cada parte, prorrogáveis por mais 10 a critério do juiz (se houver mais de um réu, o tempo de cada um será individual; se houver assistente da acusação, terá 10 minutos para falar depois da manifestação do Ministério Público, prorrogando-se por igual período o tempo da defesa);

i) sentença, que deve ser proferida em audiência ou no prazo de 10 dias. Não há previsão da substituição dos debates orais pelas alegações escritas. No entanto, em caso de



complexidade ou de ser necessária, ao fim da instrução, alguma diligência ulterior, será aplicado de forma subsidiária o procedimento ordinário.

8) Prazo para a conclusão da primeira fase (art. 412 do CPP): o procedimento será concluído no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

A decisão que encerra o *judicium accusationis* pode ser de: pronúncia (art. 413 do CPP); impronúncia (art. 414 do CPP); absolvição sumária (art. 415 do CPP) ou desclassificação (art. 419 do CPP).

#### 3.4.1.1. IMPRONÚNCIA (ART. 414 DO CPP)

Quando ausentes os indícios de autoria ou prova da materialidade do crime. Decisão meramente terminativa, não analisa mérito da causa (coisa julgada formal). Dessa sentença caberá apelação (art. 416 do CPP).

Será possível o oferecimento de nova denúncia ou queixa baseada em nova prova, desde que não extinta a punibilidade do réu (art. 414, parágrafo único).

#### 3.4.1.2. DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 419 DO CPP)

Ocorre quando o juiz se convence da existência de crime, porém não doloso contra a vida, devendo remeter os autos ao juízo competente (art. 419 do CPP). Essa hipótese de desclassificação é conhecida como desclassificação própria.

É recomendado que na decisão de declínio dos autos ao juízo competente, o juiz do tribunal do júri decida expressamente sobre a manutenção ou não da prisão do réu (TAVORA; ALENCAR, 2020, p. 703).

O juiz não deve capitular o delito, mas tão somente dizer que não é de sua competência. Isso ocorre porque a *opinio delicti* é do Ministério Público (art. 129, I, CF/88), devendo o magistrado apenas declarar que os fatos não constituem crime doloso contra a vida e, portanto, o júri não é competente para processá-lo e julgá-lo.

Se opera a chamada desclassificação imprópria quando o crime originariamente imputado na denúncia e, também, o crime desclassificado são dolosos contra a vida, a exemplo de operar uma desclassificação de homicídio para infanticídio. Chama-se impróprio em razão de os autos não serem remetidos para outro juízo e sim permanecerem no Tribunal do Júri (TAVORA; ALENCAR, 2020, p. 715).

Da desclassificação caberá recurso em sentido estrito (art. 581, II, CPP).

#### 3.4.1.3. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 415 DO CPP)

A absolvição sumária é um verdadeiro julgamento antecipado da lide penal, que exige um juízo de certeza e acarreta a formação de coisa julgada material, impedindo o oferecimento de nova ação penal versando sobre os mesmos fatos (TAVORA; ALENCAR, 2020, p. 708).

O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: a) provada a inexistência do fato; b) provado não ser ele autor ou partícipe do fato; c) o fato não constituir infração penal; e d) demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Nesta última hipótese, não poderá ser proferida a absolvição sumária se a excludente de culpabilidade for a inimizabilidade prevista no art. 26 do CP, salvo se ela for a única tese defensiva, conforme dispõe o parágrafo único do art. 415 do CPP. Desse modo, caso haja inimizabilidade e outra tese defensiva, então o magistrado deverá pronunciar o acusado para que os jurados decidam sobre a ocorrência ou não dessa segunda tese.

Da absolvição sumária cabe apelação (art. 416 do CPP).

#### 3.4.1.4. PRONÚNCIA (ART. 413 DO CPP)

Trata-se de juízo de admissibilidade da acusação que conduz o réu ao julgamento pelos jurados na segunda fase de plenário do júri. Deve ser proferida quando presentes dois requisitos, quais sejam, os indícios da autoria ou de participação e prova da materialidade do crime. São requisitos cumulativos e, na falta de um deles, a decisão a ser proferida é a de impronúncia estudada no art. 414 do CPP.

A jurisprudência entende que a decisão de pronúncia é tomada pela aplicação do *in dubio pro societate*:

**O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio *in dubio pro societate*, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (STF, ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/8/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29/8/2017 PUBLIC 30/8/2017 – grifo nosso).**

Ao proferir a decisão de pronúncia, o magistrado deverá analisar seus requisitos (materialidade e indícios suficientes de autoria), o tipo legal, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art. 413, § 1º, do CPP), devendo, ainda, decidir sobre a prisão do acusado (manutenção, liberdade ou aplicação de medidas cautelares diversas) (art. 413, § 3º, do CPP).

Não deverão constar da pronúncia, portanto, elementos como agravantes, atenuantes, causas de diminuição de pena ou concurso de crimes. Caso o juiz inclua na decisão, o tribunal irá retirá-las quando da análise do recurso cabível, que no caso é o recurso em sentido estrito, conforme art. 581, IV, do CPP.

##### Atenção:

a) Há divergência jurisprudencial sobre a possibilidade de a pronúncia ser baseada apenas em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial. O tema é polêmico e é possível encontrar dentro do próprio STJ decisões em ambos os sentidos: i) Muito embora a análise aprofundada seja feita somente pelo Júri, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial (STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.740.921-GO e 6ª Turma. HC 341.072/RS); ii) Embora a vedação imposta no art. 155 (decisão fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação) se aplique a qualquer procedimento penal, inclusive dos do Júri, não se pode perder de vista que o objetivo da decisão de pronúncia não é o de condenar, mas apenas o de encerrar o juízo de admissibilidade da acusação (*iudicium accusationis*). Na pronúncia opera o princípio *in dubio pro societate*, porque é a favor da sociedade que se resolvem as dúvidas quanto à prova, pelo Juízo natural da causa. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação, motivo pelo qual a vedação expressa do art. 155 do CPP não se aplica à referida decisão (STJ. 5ª Turma. HC 435.977/RS e 6ª Turma. REsp 1458386/PA).

b) O testemunho por ouvir dizer (*hearsay rule*), produzido somente na fase inquisitorial, não serve como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia, que submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri (STJ. 6ª Turma. REsp 1.373.356-BA - Info 603).

c) O juiz deve evitar o chamado excesso de linguagem ou, conforme chamado pela doutrina, eloquência acusatória, no momento de proferir a pronúncia. A sentença de pronúncia deve ser fundamentada. No entanto, é necessário que o juiz utilize as palavras com moderação a fim de se evitar que fique demonstrado na decisão que ele acredita firmemente que o réu é culpado pelo

crime. Não deve, portanto, demonstrar seu convencimento acerca do mérito da causa, o que poderia interferir no convencimento dos jurados, que irão receber uma cópia da sentença de pronúncia e das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo (art. 472, parágrafo único). Assim, se o Tribunal reconhecer que houve excesso de linguagem na pronúncia, ele deverá anular a decisão, assim como atos processuais seguintes, determinando que outra seja prolatada, não bastando mais o mero desentranhamento ou envelopamento da decisão (STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1.442.002-AL - Info 561).

d) Eficácia preclusiva: a pronúncia fixa os limites da imputação a serem observados em plenário. Por isso, conforme previsão do art. 476, *caput*, do CPP, a parte autora fará a acusação em plenário nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante.

e) A decisão de pronúncia interrompe a prescrição, nos termos do art. 117, II e III, do CP (decisão de pronúncia e decisão confirmatória da pronúncia). Cuidado ainda para o teor da Súmula nº 191 do STJ: “A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime”.

f) De acordo com o art. 420 do CPP, a intimação da decisão de pronúncia será feita: i) pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público; ii) ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no § 1º do art. 370 deste Código; e iii) por edital caso o acusado solto não seja encontrado.

g) A chamada despronúncia ocorrerá em duas situações, sempre precedidas por uma decisão de pronúncia: i) o juiz profere a pronúncia, mas na análise do juízo de retratação no recurso em sentido estrito decide por despronunciar o réu; e ii) o recurso em sentido estrito é analisado pelo Tribunal e este reforme a decisão, despronunciando o réu.

### 3.4.2. JUDICIUM CAUSAE: FASE DO JULGAMENTO

Abaixo há as principais características da fase de julgamento em plenário.

1) Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de cinco dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de cinco, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP). A intimação das partes é obrigatória, sob pena de nulidade, mas elas apenas se manifestarão se quiserem, sendo, portanto, mera faculdade (TÁVORA; ALENCAR; 2020, p. 717).

2) Em seguida, o juiz presidente saneará o processo, ordenando as diligências necessárias para não ocorrer qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa. Na sequência, fará relatório sucinto do processo, determinando a inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri (art. 423 do CPP).

3) Elaboração da lista dos jurados (arts. 425 e 426 do CPP).

4) Pode ocorrer o desaforamento (arts. 427 e 428 do CPP), que significa realizar o júri em localidade diferente daquela da consumação ou execução do crime, quando estiver presente uma das hipóteses da lei. É instituto que implica apenas e tão somente no deslocamento do julgamento da causa para comarca distinta daquela perante a qual tramitou a primeira fase do procedimento, de preferência comarca mais próxima, onde não subsistam mais os motivos.

#### Atenção:

- quem determinará o desaforamento é o Tribunal e não o juiz de primeira instância;



- são legitimados a requerer o desaforamento: Ministério Público, assistente, querelante ou acusado, ou mediante representação do juiz competente; o juiz presidente deverá ser ouvido quando a medida não tiver sido por ele solicitada;
- o pedido será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou Turma do Tribunal competente;
- poderá ser determinado nas seguintes hipóteses: i) interesse da ordem pública; ii) dúvida sobre a imparcialidade do júri; iii) segurança pessoal do acusado (não é a segurança do promotor, defensor, juiz, ou vítimas e parentes); e iv) comprovado excesso de serviço, se o julgamento não puder ser realizado em seis meses do trânsito em julgado da pronúncia;
- não se admitirá o pedido de desaforamento, na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado (art. 427, § 4º, CPP);
- aceleração do julgamento: não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo Tribunal do Júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao Tribunal que determine a imediata realização do julgamento (art. 428, § 2º, CPP);
- a comarca em que será realizado o julgamento da causa não necessariamente é a capital do estado. Para que esta seja a comarca escolhida, é preciso que haja justificativa plausível, conforme já decidido pelo STJ (Informativo nº 432);
- não há previsão de recurso contra a decisão que admite ou não o desaforamento, sendo possível, porém, o manejo de *habeas corpus*, a depender da situação em concreto.
- Súmula nº 712, STF: é nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do júri sem audiência da defesa.

5) Estando o processo em ordem, o juiz presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento, para a sessão de instrução e julgamento.

6) Sorteio dos jurados, sendo que o Tribunal do Júri é composto por 1 (um) juiz togado, seu presidente e por 25 (vinte e cinco) jurados, que serão sorteados dentre os alistados, 7 (sete) dos quais constituirão o conselho de sentença em cada sessão de julgamento.

#### Atenção:

Sobre os jurados:

- maiores de 18 anos de idade (art. 436, *caput*);
- exercem função obrigatória (art. 436, *caput*) – a recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado (art. 436, § 2º);
- os jurados podem se recusar a exercer o múnus público com base em convicção religiosa, filosófica ou política, mas deverá prestar um serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos enquanto não houver a prestação do serviço imposto (art. 438, *caput*);
- o exercício efetivo da função de jurado constitui serviço público relevante, estabelecendo presunção de idoneidade (art. 439);
- possuem direito à prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo (art. 295, X).
- possui direito de preferência, em igualdade de condições, em licitações públicas, concursos públicos, promoções e remoções (art. 440);
- os jurados possuem o dever de imparcialidade: para eles são aplicadas as regras de impedimentos e suspeição previstos para o magistrado nos artigos 252 e 254, ambos do CPP.

7) Convocação dos jurados sorteados e abertura da sessão de julgamento. O júri é formado por 25 jurados (e não mais 21), embora continue a exigência de 15 jurados para a instalação da sessão (art. 463, *caput*).

8) Constituição do conselho de sentença: 7 jurados. Esse conselho poderá conhecer de mais de um processo no mesmo dia, se as partes o aceitarem, hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso (art. 452).

**Atenção:**

No momento do sorteio dos jurados, as partes podem recusar os jurados. Note que o art. 468 do CPP dispõe que primeiro a defesa recusa e, depois dela, o Ministério Público. As recusas podem ser justificadas ou não.

- Recusa justificada: para que a parte consiga afastar da causa um jurado impedido ou suspeito, deverá formular prova sobre a causa de impedimento ou suspeição. Não há limites para o número de recusas motivadas que cada parte pode fazer. Se em virtude das recusas aceitas pelo magistrado, não restar o número de jurados para a formação do conselho de sentença, haverá o chamado estouro da urna, devendo ser designada nova data para julgamento de um ou mais de um acusado, com desmembramento dos processos e convocação de jurados suplentes.

- Recusa imotivada ou peremptória: no momento do sorteio, em plenário, cada uma das partes pode dispensar até 3 jurados sem qualquer tipo de justificativa (art. 468, *caput*). Quando for sorteado, o juiz ouve primeiro a defesa e depois o MP. O STJ já decidiu que o direito de a defesa recusar imotivadamente até 3 jurados é garantido em relação a cada um dos réus, ainda que as recusas tenham sido realizadas por um só defensor, em atenção à plenitude de defesa (Informativo nº 570).

9) Após o sorteio, os jurados ficam incomunicáveis e ocorre a exortação – prestação do compromisso legal (art. 472 do CPP).

10) Instrução em plenário: declarações do ofendido; oitiva das testemunhas de acusação; oitiva das testemunhas de defesa; acareações; reconhecimento de pessoas e coisas; esclarecimentos de perito; leitura de peças; e interrogatório do réu.

As perguntas podem ser feitas diretamente pelas partes, exceto pelos jurados, que precisam passar pelo juiz-presidente (art. 473, § 2º; e art. 474, § 2º, do CPP).

Os jurados podem também solicitar a oitiva de pessoa não arrolada como testemunhas pelas partes, cujo nome tenha sido mencionado durante o plenário. Nesse caso, na forma do art. 481 do CPP, admite-se a suspensão do julgamento para que seja diligenciado o paradeiro do depoente.

Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes (art. 474, §3º, CPP), o que está de acordo com a Súmula Vinculante nº 11, já estudada nesta obra.

11) Debates orais: encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. O assistente falará depois do Ministério Público. Finda a acusação, terá a palavra a defesa.

O tempo destinado à acusação e à defesa será de uma hora e meia para cada (art. 477 do CPP). Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo (§ 1º). Havendo mais de 1 (um) acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de uma hora (§ 2º).



12) A acusação poderá ir à réplica e a defesa, à tréplica (a tréplica só existe se a acusação promover a réplica), sendo admitida a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário (art. 476, § 4º). O tempo será de uma hora para a réplica e outro tanto para a tréplica (art. 477 do CPP). Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será elevado ao dobro (§ 2º).

O STJ já decidiu que o assistente de acusação possui direito à réplica, ainda que o Ministério Público tenha declinado do direito de replicar por ter anuído com a tese defensiva de legítima defesa do réu (Informativo nº 546).

É possível existirem apartes, ou seja, intervenções na fala do orador, desde que haja autorização expressa do juiz presidente. Cada aparte dura até três minutos, tempo este que será acrescido ao tempo do orador, tudo nos termos do art. 497, XII, do CPP.

Atente-se que se o MP disser, por exemplo, que não fará a réplica, mas sustente que não o fará, em razão de provas robustas nos autos, indicando ser o réu o autor do crime, estará ele, em verdade, replicando. Diante disso, a defesa terá o direito à tréplica integralmente.

Nos termos do art. 478, do CPP, durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado, ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.

A leitura em plenário do júri dos antecedentes criminais do réu não se enquadra nos casos apresentados pelo art. 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo óbice à sua menção por quaisquer das partes (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 456426/SP; HC 333390/MS; HC 356839/SC; REsp 1596509/SC; HC 068028/SC, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, Julgado em 5/12/2006, DJ 5/2/2007).

### 13) Formulação e leitura dos quesitos.

Após as manifestações do Ministério Público e da defesa, haverá a quesitação na sala secreta. Quem formula os quesitos é o juiz, pois é ele quem possui conhecimento técnico e jurídico para a formulação adequada.

Ordem de quesitação:

Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

I – a materialidade do fato;

II – a autoria ou participação;

III – se o acusado deve ser absolvido;

IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§ 1º A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do *caput* deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.

§ 2º Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do *caput* deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação: O jurado absolve o acusado?

§ 3º Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre:

I – causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

II – circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§ 4º Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2º (segundo) ou 3º (terceiro) quesito, conforme o caso.

§ 5º Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o



juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito.

§ 6º Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas.

Os jurados terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz presidente (art. 480, § 3º).

Antes de responderem aos quesitos, o juiz perguntará se há, entre os jurados, alguma dúvida ou esclarecimento que necessite ser feito, ou seja, se os jurados se consideram aptos a votar. Se estiverem aptos a votar, o juiz lerá os quesitos, fazendo os esclarecimentos aos jurados (art. 484, parágrafo único).

Quesitos: devem ser redigidos com clareza, de forma simples, com precisão. O juiz presidente levará em consideração os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes (art. 482, parágrafo único).

A votação é secreta, devendo ser realizada em sala própria, a presença apenas do juiz-presidente, do MP, do assistente de acusação, do querelante, do defensor do acusado, do escrivão e do oficial de justiça. O réu não estará presente. Quando não houver sala secreta, será realizada a votação no próprio plenário, com aquelas pessoas e sem o réu e a plateia (art. 484 e 485, § 1º).

A votação é feita em cédulas de SIM e NÃO, devendo-se colocar em um recipiente a resposta válida e em outro a inválida. Se os jurados responderem não a um dos quesitos de número I ou II (materialidade ou autoria), os demais estão prejudicados (art. 483, § 1º).

O jurado não precisa motivar, uma vez que o sistema de valoração da prova adotado é o da íntima convicção, da certeza moral do julgador. Isso é uma ressalva ao demais sistemas de valoração.

O juiz presidente conta a votação de cada quesito de forma simples e não por unanimidade (art. 489); o magistrado deverá encerrar a votação quando obtidos 4 votos pelo SIM ou pelo NÃO, não havendo como descobrir o placar da votação.

Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação dos quesitos a que se referirem tais propostas (art. 490).

Encerrada a votação, o juiz presidente irá proferir sentença em consonância com o que foi votado pelos jurados, na forma do artigo 492, incisos I e II, a qual será lida em plenário (art. 493), saindo as partes, desde já, intimadas.

#### 14) Sentença.

A sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento.

Da sentença caberá apelação, prevista no artigo 593, III, *a, b, c* ou *d*, do CPP.

#### 15) É feita uma ata da sessão.

#### Atenção:

- Nos termos do art. 479 do CPP, durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de três dias úteis. Compreende-se na proibição desse artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Nesse caso, dar-se ciência à outra parte. Conforme decidiu o STJ, o prazo de 3 dias úteis a que se refere o art. 479 do Código de Processo Penal deve ser respeitado não apenas para a juntada de documento ou objeto, mas também para a ciência da parte contrária a respeito de sua utilização no Tribunal do Júri. (REsp 1.637.288-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para

acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, julgado em 8/8/2017, DJe 1/9/2017 – Informativo 610, STJ.)

- Nos termos do art. 430 do CPP, o assistente de acusação só será admitido se ele tiver requerido a sua habilitação até 5 dias antes da data da sessão na qual ele pretenda atuar.
- Deve ser declarado nulo o júri em que membro do conselho de sentença afirma a existência de crime em plena fala da acusação, violando o dever de incomunicabilidade (STJ. 6ª Turma. HC 436.241-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/6/2018).
- A complementação do número regulamentar mínimo de 15 (quinze) jurados por suplentes de outro plenário do mesmo Tribunal do Júri, por si só, não enseja nulidade do julgamento. Configura-se nulidade apenas se restar comprovado o prejuízo (STJ, HC 168263/SP; HC 151729/SP; HC 227169/SP; HC 118491/SP; HC 132292/SP).

#### 4. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA

##### 4.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Súmula Vinculante nº 35: a homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.

Súmula nº 162, STF: “É absoluta a nulidade do julgamento pelo júri, quando os quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes.”

Súmula nº 206, STF: “É nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo.”

Súmula nº 640, STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de julgamento especial cível e criminal.”

Súmula nº 710, STF: “No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem.”

Súmula nº 712, STF: “É nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do Júri sem audiência da defesa.”

Súmula nº 713, STF: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.”

Súmula nº 723, STF: “Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a 01 (um) ano.”

**O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, POR ÓRGÃO JUDICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE, NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO PENAL.** - O recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente incompetente, não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal, eis que decisão nula não pode gerar a consequência jurídica a que se refere o art. 117, I, do Código Penal. Precedentes. Doutrina (Inq-QO 1544, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 7/11/2001, publicado em 14/12/2001, Tribunal Pleno – grifo nosso).

**À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o despacho de recebimento da denúncia não se enquadra no conceito de decisão contido no art. 93, IX, CRFB, sendo-lhe dispensada a fundamentação.** Estão devidamente descritos os fatos, em todas as suas circunstâncias, e o tempo do crime. A denúncia indicou o montante supostamente



desviado e a origem do suposto desvio, apontando os laudos contábeis que devem ser considerados como prova. A acusação também individualizou os valores que teriam sido ilegalmente percebidos pelos denunciados, com base em laudos técnicos, do modo que não procede a alegação de cerceamento de defesa. Denúncia que permite o exercício da ampla defesa pelos recorrentes. Ordem denegada. (STF, RHC 87005, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 16/5/2006, DJ 18-08-2006 PP-00072 EMENT VOL-02243-02 PP-00301 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 435-443 RT v. 96, n. 855, 2007, p. 518-522 – grifo nosso.)

**O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio *in dubio pro societate*, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.** IV - Agravo regimental a que se nega provimento (STF, ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/8/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29/8/2017 PUBLIC 30/8/2017 – grifo nosso). DEFESA PRÉVIA – ARTIGO 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONTRADITÓRIO. Quando a inversão implica nulidade absoluta, descabe transportar para a fase prevista no artigo 396 do Código de Processo Penal a ordem alusiva às alegações finais. **Apresentada defesa prévia em que são articuladas, até mesmo, preliminares, é cabível a audição do Estado-acusador, para haver definição quanto à sequência, ou não, da ação penal** (STF, HC 105739, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 7/2/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27/2/2012 PUBLIC 28/2/2012 – grifo nosso).

EMENTA *Habeas corpus*. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. **Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes.** Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. (...) (STF, HC 127900, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 3/3/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 2/8/2016 PUBLIC 3/8/2016 – grifo nosso.)

Embora inexistente previsão legal específica, **o réu delatado tem o direito de apresentar suas alegações finais somente após o réu delator . Isso porque, independentemente de estar despida de roupagem acusatória , a peça processual das alegações finais do réu colaborador, ao condensar todo o histórico probatório , pode ser determinante ao resultado desfavorável do julgamento em relação ao acusado , o que legitima este a merecer a oportunidade de exercer o contraditório** (STF, 2ª Turma. HC 157627 AgR/PR, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 27/8/2019 - Info 949 – grifo nosso).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 39 E 94 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). RESTRIÇÃO À GRATUIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE SELETIVOS E ESPECIAIS. APLICABILIDADE DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI 9.099/1995 AOS CRIMES COMETIDOS CONTRA IDOSOS. 1. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.768/DF, o Supremo

Tribunal Federal julgou constitucional o art. 39 da Lei 10.741/2003. Não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade nessa parte. 2. Art. 94 da Lei n. 10.741/2003: interpretação conforme à Constituição do Brasil, com redução de texto, para suprimir a expressão "do Código Penal e". **Aplicação apenas do procedimento sumaríssimo previsto na Lei n. 9.099/95: benefício do idoso com a celeridade processual. Impossibilidade de aplicação de quaisquer medidas despenalizadoras e de interpretação benéfica ao autor do crime.** 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição do Brasil, com redução de texto, ao art. 94 da Lei n. 10.741/2003. (STF, ADI 3096, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/6/2010, DJe-164 DIVULG 2/9/2010 PUBLIC 3/9/2010 EMENT VOL-02413-02 PP-00358 RTJ VOL-00216-01 PP-00204 – grifo nosso.)

**VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – GÊNEROS MASCULINO E FEMININO – TRATAMENTO DIFERENCIADO.** O artigo 1º da Lei nº 11.340/06 surge, sob o ângulo do tratamento diferenciado entre os gêneros – mulher e homem –, harmônica com a Constituição Federal, no que necessária a proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a cultura brasileira. **COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.** O artigo 33 da Lei nº 11.340/06, no que revela a conveniência de criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, não implica usurpação da competência normativa dos estados quanto à própria organização judiciária. **VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – REGÊNCIA – LEI Nº 9.099/95 – AFASTAMENTO. O artigo 41 da Lei nº 11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a Lei nº 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no § 8º do artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coibam a violência no âmbito das relações familiares** (STF, ADC 19, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 9/2/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28/4/2014 PUBLIC 29/4/2014 – grifo nosso)

**AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – NATUREZA. A ação penal relativa a lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada** – considerações (STF, ADI 4424, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 9/2/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31/7/2014 PUBLIC 1º/8/2014 – grifo nosso).

**CRIME MILITAR – PRIMEIRA INSTÂNCIA – JULGAMENTO.** Atua no processo-crime militar o Conselho Permanente de Justiça. **PROCESSO-CRIME MILITAR – LEI Nº 9.099/1995. É inaplicável ao processo-crime militar a Lei dos Juizados Especiais** – Precedente: *habeas corpus* nº 99.743/RJ. (STF, HC 124899, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 1º/8/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 14/8/2017 PUBLIC 15/8/2017 - grifo nosso.)

#### 4.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Súmula nº 191, STJ: “A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime.”

Súmula nº 203, STJ: “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais.”

Súmula nº 243, STJ: “O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano.”

Súmula nº 330, STJ: “É desnecessária a resposta preliminar de que trata o art. 514 do CPP, na ação penal instruída por inquérito policial.”

Súmula nº 337, STJ: “É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.”

Súmula nº 376, STJ: “Compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”

Súmula nº 415, STJ: “O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.”

Súmula nº 455, STJ: “A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.”

Súmula nº 536, STJ: “A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.”

Súmula nº 542, STJ: “A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.”

Súmula nº 588, STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Súmula nº 589, STJ: “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.”

Súmula nº 603, STF: “A competência para o processo e julgamento do latrocínio é do juiz singular e não do Tribunal do Júri.”

**Reconhecida a nulidade a partir do recebimento da denúncia, não mais subsistem os marcos interruptivos da prescrição** (STJ, HC 28.667/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/3/2009, DJe 27/4/2009 – grifo nosso).

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, **consagrou-se o entendimento no sentido da inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal** (STJ, HC 365.863/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 27/3/2017 – grifo nosso).

PROCESSUAL PENAL E PENAL. *HABEAS CORPUS* SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÂNSITO. PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL EM SEDE DE APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. (...) 2. **Viola os princípios do juiz natural, devido processo legal, ampla defesa e duplo grau de jurisdição a decisão do Tribunal que condena, analisando o mérito da ação penal em apelação ministerial interposta ante sentença de absolvição sumária.** 3. *Habeas corpus* não conhecido, mas, de ofício, concedida a ordem para reconhecer a nulidade do acórdão proferido em segunda instância na parte que analisou o mérito da causa, para determinar o prosseguimento da ação penal (STJ, HC 260.188/AC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 – grifo nosso).

**A expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, razão pela qual o feito prosseguirá, em respeito ao princípio da celeridade processual, procedendo-se à oitiva das demais testemunhas, ao interrogatório do acusado e, inclusive, ao julgamento da causa, ainda que pendente a devolução da carta pelo juízo deprecado** (STJ, HC 388.688/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 17/4/2017 – grifo nosso).

*HABEAS CORPUS*. FUGA DE PESSOA PRESA OU SUBMETIDA A MEDIDA DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ DIVERSO DO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA





AO DESLINDE DA QUESTÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. **De acordo com o princípio da identidade física do juiz, que passou a ser aplicado também no âmbito do processo penal após o advento da Lei n.º 11.719, de 20 de junho de 2008, o magistrado que presidir a instrução criminal deverá proferir a sentença no feito, nos termos do § 2.º do artigo 399 do Código de Processo Penal.** 2. **Em razão da ausência de outras normas específicas regulamentando o referido princípio, nos casos de convocação, licença, promoção ou de outro motivo que impeça o juiz que tiver presidido a instrução de sentenciar o feito, por analogia — permitida pelo artigo 3.º da Lei Adjetiva Penal —, deverá ser aplicada a regra contida no artigo 132 do Código de Processo Civil, que dispõe que os autos passarão ao sucessor do magistrado. Doutrina. Precedente.** 3. No caso em apreço, o impetrante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que o magistrado que teria presidido a instrução criminal não estaria impedido de proferir a sentença, ou seja, que não seria aplicável quaisquer das hipóteses excepcionais elencadas no citado dispositivo do Código de Processo Civil. 4. O rito do *habeas corpus* pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. 5. Ordem denegada. (STJ, HC 242.115/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/8/2012, DJe 15/8/2012 – grifo nosso.)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 127.900/AM, deu nova conformidade à norma contida no art. 400 do CPP (com redação dada pela Lei n. 11.719/08), à luz do sistema constitucional acusatório e dos princípios do contraditório e da ampla defesa. **O interrogatório passa a ser sempre o último ato da instrução, mesmo nos procedimentos regidos por lei especial, caindo por terra a solução de antinomias com arrimo no princípio da especialidade** (STJ, HC 403.550/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017 – grifo nosso).

PROCESSO PENAL. *HABEAS CORPUS*. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POR MEIO AUDIOVISUAL. TRANSCRIÇÃO PARCIAL DO SEU CONTEÚDO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 11.719/2008. FORMA ESCRITA. ART. 388 DO CPP. POSSIBILIDADE. VÍCIO FORMAL DO ATO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. **A previsão legal do único registro audiovisual da prova, no art. 405, § 2º do Código de Processo Penal, deve também ser compreendida como autorização para esse registro de toda a audiência — debates orais e sentença.** 2. **É medida de segurança (no mais completo registro de voz e imagem da prova oral) e de celeridade no assentamento dos atos da audiência.** 3. Exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra. Não há sentido lógico ou de segurança, e é desserviço à celeridade. 4. A ausência de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral. 5. A tese de inidoneidade dos fundamentos que embasaram o aumento da pena em 3/8, na terceira fase da dosimetria, não foi submetida ao crivo do Tribunal de Justiça, inviabilizando o exame desta Corte Superior por incabível análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. 6. *Habeas corpus* denegado (STJ, HC 462.253/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 4/2/2019 – grifo nosso).

*HABEAS CORPUS*. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita se revela inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação *ex officio*, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. RESISTÊNCIA E DESACATO. CONCURSO MATERIAL. PENAS QUE ULTRAPASSAM O LIMITE DE 2 (DOIS) ANOS PREVISTO PARA O JULGAMENTO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONCESSÃO DA



ORDEM DE OFÍCIO. 1. Pacificou-se neste Sodalício o entendimento de que para efeito de fixação da competência dos Juizados Especiais, deve ser levado em conta o somatório das penas máximas cominadas aos delitos no caso de concurso material de crimes, caso em que, ultrapassado o limite de 2 (dois) anos, encaminha-se o feito para a Justiça Comum. 2. Na espécie, verifica-se que o paciente está sendo acusado de praticar os crimes de resistência e desacato em concurso material, cujas penas máximas, somadas, ultrapassam o limite de 2 (dois) anos previsto nas Leis 9.099/1995 e 10.259/2001, o que revela que a competência para processar e julgar a ação penal em tela é da Justiça Comum, e não dos Juizados Especiais, como decidido na origem. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer a competência da 1ª Vara Criminal de Duque de Caxias para processar e julgar o feito (STJ, HC 314.854/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 7/5/2015, DJe 20/5/2015 – grifo nosso).

PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL X JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL ESTADUAL. AÇÃO PENAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA FUNDADA EM DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. CONDOTA QUE SE AMOLDA À POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 1. O crime de uso de entorpecente para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, é de menor potencial ofensivo, o que determina a competência do Juizado Especial estadual, já que ele não está previsto em tratado internacional e o art. 70 da Lei n. 11.343/2006 não o inclui dentre os que devem ser julgados pela Justiça Federal. (...) 6. Conflito conhecido, para declarar competente para o julgamento da ação penal o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Corumbá/MS, o suscitante (STJ, CC 144.910/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/4/2016, DJe 25/4/2016 – grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ACORDO DE REPARAÇÃO CIVIL ENTRE AS PARTES. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LEI Nº 9.099/95. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Embora a decisão de suspensão condicional do processo penal não faça coisa julgada material, em virtude da possibilidade de sua revogação, caso o beneficiário incida nas hipóteses previstas nos §§ 3º e 4º do artigo 89 da Lei nº 9099/99, durante o prazo de suspensão determinado, não há óbice legal que impeça o denunciado e a vítima de entabularem acordo, visando à reparação civil pelo crime, na mesma audiência em que fixadas as condições para suspensão do processo. 2. O entendimento de que o acordo celebrado entre o denunciado e a vítima constitui título executivo atende ao espírito da Lei dos Juizados Especiais, que prima pela celeridade e concentração dos atos processuais, assim como pela simplificação dos procedimentos, a fim de incentivar as partes à autocomposição. 3. Recurso especial provido (STJ, REsp 1123463/DF – grifo nosso).

PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS. PRESSUPOSTO ESSENCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO REALIZADA COM ESTEIO NO ART. 76 DA LEI N.º 9.099/95. TRANSAÇÃO PENAL. 1. A ação de revisão criminal ajuizada com fulcro no inciso III do art. 621 do Estatuto Processual pressupõe um reexame da sentença condenatória transitada em julgado, pois, nos termos do art. 625, § 1.º, do Código de Processo Penal, o pedido revisional deve ser instruído com a certidão de trânsito julgado de sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos. 2. Incabível o ajuizamento de revisão criminal contra sentença que homologa a transação penal (art. 76 da Lei n.º 9.099/95), já que não existiu condenação ou sequer houve análise de prova. Na verdade, ao se aplicar o instituto da transação penal, não se discute fato típico, ilicitude, culpabilidade ou punibilidade, mas apenas é possibilitada ao autor do fato uma aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa para que não exista o prosseguimento da ação penal, sendo o acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário e impugnável por meio do recurso de apelação. 3. Recurso especial desprovido. (STJ, REsp 1107723/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 7/4/2011, DJe 25/4/2011 – grifo nosso.)

PENAL. *HABEAS CORPUS* SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BENEFÍCIOS DA LEI N. 9.099/1995. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. *HABEAS CORPUS* NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe *habeas corpus* substitutivo de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. **Segundo entendimento desta Corte Superior, havendo a procedência parcial da acusação ou a desclassificação do delito para outro que se amolde aos requisitos determinados pelos arts. 76 e 89 e da Lei n. 9.099/1995, os autos devem ser encaminhados ao Ministério Público para que se manifeste sobre a possibilidade de suspensão condicional do processo ou da transação penal. Inteligência da Súmula 337/STJ.** 3. Operada a desclassificação em segundo grau, é nulo o acórdão condenatório proferido sem conferir ao órgão ministerial a oportunidade de se manifestar acerca da possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo ao paciente. Precedentes. 4. *Habeas Corpus* não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, mantida a desclassificação, anular o acórdão condenatório, a fim de que sejam os autos remetidos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo (STJ, HC 382.372/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 23/2/2017 – grifo nosso).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO QUERELANTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. 1. **Embora admitida a possibilidade de transação penal em ação penal privada, este não é um direito subjetivo do querelado, competindo ao querelante a sua propositura.** 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1356229/PR, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 19/3/2013, DJe 26/3/2013.)

A transação penal é um instituto que , por natureza e como regra , ocorre na fase pré - processual. Seu objetivo é impedir a instauração da *persecutio criminis in iudicio* (persecução penal em juízo). Se a transação penal foi aceita, isso significa que não existe ação penal em curso. Como não existe ação penal em curso, não se pode falar em *habeas corpus* para trancar a ação penal. **Logo, não se revela viável, após a celebração do acordo, pretender discutir em ação autônoma (HC) a existência de justa causa para ação penal . Trata-se de decorrência lógica , pois não há ação penal instaurada que se possa trancar** (STJ, HC 495.148-DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/9/2019 - Info 657 – grifo nosso).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COLÉGIO RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. AMEAÇA. AÇÃO PENAL QUE TEVE CURSO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA PARA A REVISÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO TÃO-SOMENTE QUANTO À AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REVER O DECISUM QUESTIONADO. IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE GRUPO DE TURMAS RECURSAIS. UTILIZAÇÃO ANALÓGICA DO CPP. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS SUPLENTE A FIM DE EVITAR O JULGAMENTO PELOS MESMOS JUÍZES QUE APRECIARAM A APELAÇÃO. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. 1. **Apesar da ausência de expressa previsão legal, mostra-se cabível a revisão criminal no âmbito dos Juizados Especiais, decorrência lógica da garantia constitucional da ampla defesa, notadamente quando a legislação ordinária vedou apenas a ação rescisória, de natureza processual cível.** 2. É manifesta a incompetência do Tribunal de Justiça para tomar conhecimento de revisão criminal ajuizada contra decisum oriundo dos Juizados Especiais. 3. A falta de previsão legal específica para o processamento da ação revisional perante o Colegiado Recursal não impede seu ajuizamento, cabendo à espécie a utilização subsidiária dos ditames previstos no Código de Processo Penal. 4. Caso a composição da Turma Recursal impossibilite a perfeita obediência aos dispositivos legais atinentes à espécie, mostra-se viável, em tese, a convocação dos magistrados suplentes para tomar parte no julgamento, solucionando-se a controvérsia

e, principalmente, resguardando-se o direito do agente de ver julgada sua ação revisional. 5. Competência da Turma Recursal (STJ, CC 47.718/RS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/8/2008, DJe 26/8/2008 – grifo nosso).

Compete aos Tribunais de Justiça ou aos Tribunais Regionais Federais o julgamento dos pedidos de *habeas corpus* quando a autoridade coatora for Turma Recursal dos Juizados Especiais (STJ, HC 369717/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 25/4/2017, DJe 3/5/2017).

PENAL E PROCESSUAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. **Consoante entendimento desta Corte, a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada.** Hipótese em que a negativa da suspensão condicional do processo está amparada na ausência dos requisitos previstos no art. 77, II, do Código Penal, referidos pelo art. 89 da Lei n. 9.099/1995, sendo certo que, para a eventual desconstituição da conclusão das instâncias ordinárias, seria necessária a incursão no conjunto probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 607.902/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 17/2/2016 – grifo nosso.)

**HABEAS CORPUS. (...) OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO ANTES DA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 89 DA LEI 9.099/1995 À LUZ DAS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 11.719/2008. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO .1. Embora o artigo 89 da Lei 9.099/1995 estabeleça que a proposta de suspensão condicional do processo deve ser feita no momento do oferecimento da denúncia, tal dispositivo deve ser compatibilizado com as modificações promovidas no procedimento comum ordinário pela Lei 11.719/2008.2. Diante da possibilidade de absolvição sumária, mostra-se desarrazoado admitir que a suspensão condicional do processo seja oferecida ao denunciado antes da análise de sua resposta à acusação, na qual pode veicular teses que, se acatadas, podem encerrar a ação penal. (...)** (STJ. HC n. 239.093/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29/10/2013 – grifo nosso.)

**Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no art. 89, § 2º, da Lei nº 9.099/95, obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais (tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária – art. 44, CP), mas que, para os fins do sursis processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência.** (STJ. 3ª Seção. REsp 1.498.034-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 25/11/2015 - recurso repetitivo - Info 574.) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 TEMA 930 – grifo nosso.)

**A perda do valor da fiança constitui legítima condição do sursis processual**, nos termos do art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/95 (STJ, AgRg no RHC 085835/PR; AgRg no RHC 083810/PR; RHC 064083/RS; AgRg no RHC 069873/PR – grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA INTERPOR RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INCLUSÃO DE NOVA CONDIÇÃO NA PROPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) O assistente da acusação não tem legitimidade para interpor recurso em sentido estrito contra decisão que concede a suspensão condicional do processo, tendo em vista que referida hipótese não se encontra no rol taxativo do art. 271 do Código de Processo Penal. III - De igual forma, **não tem o assistente da acusação direito à inclusão de nova condição na proposta de suspensão condicional do processo apresentada pelo Ministério Público, pois tal atribuição pertence ao titular da ação penal, nos termos do art. 89 da Lei n.9.099/95, podendo o Magistrado fixar outras condições, conforme previsão expressa no § 2º de referido dispositivo.** IV - Assim, não há violação a direito líquido e certo da agravante na decisão

que, após manifestação contrária do Ministério Público, indefere o pedido do assistente de acusação de inclusão de nova condição na proposta, por entender que referida condição seria inadequada e demasiadamente onerosa ao agravado. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 54.426/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 5/3/2018 – grifo nosso.)

**A extinção da punibilidade do agente pelo cumprimento das condições do sursis processual, operada em processo anterior, não pode ser sopesada em seu desfavor como maus antecedentes, personalidade do agente e conduta social** (STJ, HC 385535/RJ; REsp 1533788/PE; HC 198815/SP; HC 156569/SP – grifo nosso).

É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para o reconhecimento de nulidade decorrente da inobservância da regra prevista no art. 514 do CPP, é necessária a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. Improcede, pois, pedido de renovação de todo o procedimento criminal com base em alegações genéricas sobre a ocorrência de nulidade absoluta. 2. Ademais, se a finalidade da defesa preliminar está relacionada ao interesse público de evitar persecução criminal temerária contra funcionário público, a superveniência de sentença condenatória, que decorre do amplo debate da lide penal, prejudica a preliminar de nulidade processual, sobretudo se considerado que essa insurgência só foi veiculada nas razões de apelação (STF, HC 128109/MG, 2ª T., Rel. Min. Teori Zavascki, j. 8/9/2015).

**Se o Tribunal reconhecer que houve excesso de linguagem na pronúncia, ele deverá anular a decisão, assim como atos processuais seguintes, determinando que outra seja prolatada, não bastando mais o mero desentranhamento ou envelopamento da decisão** (STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 1.442.002-AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 28/4/2015 - Info 561).

## QUESTÕES

**1- (2020/CESPE/TJ-PA/Oficial de Justiça Avaliador)** De acordo com o Código de Processo Penal (CPP), no procedimento comum ordinário, após o recebimento de denúncia e o oferecimento de resposta à acusação pela defesa, o juiz absolverá sumariamente o denunciado na hipótese de

- a) haver dúvida quanto à autoria do réu ou à sua participação no crime.
- b) ficar comprovada a inimputabilidade mental do réu.
- c) a denúncia ser manifestamente inepta.
- d) faltar justa causa para o exercício da ação penal.
- e) o fato narrado evidentemente não constituir crime.

**2- (2020/CESPE/MPE-CE/promotor de justiça)** João foi denunciado, tendo sido arroladas pelo Ministério Público as testemunhas Antônio, Paula e Carla, esta última residente em outro estado da Federação. Outra testemunha, Diana, foi arrolada pela defesa. Designada a audiência de instrução, compareceram Antônio, Paula, Diana e João, sem que ainda houvesse resposta do cumprimento da carta precatória de Carla. O juiz ouviu todas as testemunhas presentes e realizou o interrogatório.

Nessa situação hipotética,

- a) não ocorreu nulidade processual, ainda que tenha havido, no mesmo momento processual, a oitiva de testemunhas e o interrogatório.
- b) o juiz não agiu corretamente, pois a oitiva da testemunha de defesa somente pode ocorrer antecipadamente com expressa autorização das partes.
- c) o juiz não agiu corretamente, pois o interrogatório deveria ter sido realizado somente após o retorno da carta precatória.
- d) ocorreu nulidade processual, pois o juiz não poderia ter ouvido a testemunha de defesa antes do retorno da carta precatória.
- e) ocorreu nulidade processual, visto que o feito estava suspenso; o juiz deveria ter marcado a audiência apenas após o retorno da carta precatória.

**3- (2019/CESPE/TJ-PA/Juiz de Direito Substituto)** A respeito de julgamento por tribunal do júri, assinale a opção correta.

- a) A afirmação pelos jurados da existência de crime de homicídio tentado prejudica a análise do quesito de desistência voluntária.
- b) A irresignação contra quesito formulado deve ser efetivada antes da leitura da sentença em plenário, sob pena de preclusão.
- c) Não se deve repetir votação de quesitos, mesmo que a resposta dos jurados ao quesito subsequente seja contraditória.
- d) A resposta negativa de quatro jurados sobre a materialidade do crime não suspende a votação, em razão dos efeitos cíveis do julgamento.
- e) Admite-se a juntada de documento novo para leitura em plenário desde que efetivada a qualquer tempo antes do início da sessão de julgamento.

**4- (2019/CESPE/TJDFT/Titular de Serviços de Notas e de Registros)** Em relação aos procedimentos comum e especial, julgue os itens a seguir.

I As hipóteses de absolvição sumária previstas para o procedimento ordinário e sumário são aplicáveis a todos os processos penais desenvolvidos em primeiro grau de jurisdição, ainda que estes não sejam regulados pelo Código de Processo Penal.

II No procedimento comum ordinário, o juiz, logo após o recebimento da denúncia, determinará a citação do réu para comparecer à audiência de instrução do feito.

III No procedimento sumaríssimo, oferecida a denúncia e não sendo encontrado o autor do fato para ser citado, o juiz encaminhará o feito ao juízo comum, devendo, então, ser observado o rito sumário.

IV O procedimento comum sumário é cabível quando a ação penal tiver por objeto crime cuja pena máxima privativa de liberdade seja igual ou inferior a quatro anos.

Estão certos apenas os itens

- a) I e III.
- b) I e IV.
- c) II e IV.
- d) I, II e III.
- e) II, III e IV.

**5- (2019/CESPE/TJ-BA/Juiz de Direito Substituto)** Acerca dos procedimentos relativos aos processos de competência do tribunal do júri, assinale a opção correta.

- a) Em decorrência do princípio do *in dubio pro societate*, o testemunho por ouvir dizer produzido na fase inquisitorial é suficiente para a decisão de pronúncia.
- b) É possível a exclusão, na decisão de pronúncia, de qualificadoras descritas na denúncia, quando elas forem manifestamente incabíveis.
- c) Em caso de inimizabilidade do réu, ainda que a tese da defesa seja de negativa da autoria, deve o juiz absolvê-lo sumariamente.
- d) É cabível recurso em sentido estrito contra decisão que tenha absolvido sumariamente o réu.
- e) Não é cabível excluir da lista geral de jurados o jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos doze meses que antecederam a publicação da referida lista.

**6- (2019/FCC/TJ-AL/juiz substituto)** No procedimento comum,

- a) o Juiz, se não rejeitar liminarmente a denúncia ou a queixa, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez dias, se ordinário, ou de cinco, se sumário.
- b) produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução e, realizada a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de cinco dias, suas alegações finais, por memorial, e, no prazo de dez dias, o Juiz proferirá a sentença.
- c) apresentada ou não a resposta no prazo legal, o Juiz, de imediato, ratificando o recebimento da denúncia ou da queixa, designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente.
- d) a audiência de instrução e julgamento deve ser realizada no prazo máximo de noventa dias, se ordinário, ou sessenta dias, se sumário, procedendo-se à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado as ouvidas por carta precatória, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.



e) a acusação e a defesa poderão arrolar até oito testemunhas, se ordinário o procedimento, não se compreendendo nesse número as que não prestem compromisso e as referidas, defeso ao Juiz, por expressa previsão legal, ouvir aquela que a parte houver manifestado desistência de inquirição.

**7- (2020/FCC/TJMS/Juiz Substituto)** Cabível a absolvição sumária

- a) se demonstrada a existência de causa de exclusão do crime, mas unicamente no procedimento do júri.
- b) se provado, no procedimento comum, não ser o acusado autor ou partícipe do fato.
- c) por inimizabilidade, em determinada situação, no procedimento do júri.
- d) se demonstrada, no procedimento comum, a manifesta existência de qualquer causa excludente da culpabilidade.
- e) sempre que demonstrada, no procedimento do júri, a existência de causa de isenção de pena.

**8- (2020/FCC/TJMS/Juiz Substituto)** Em relação aos Juizados Especiais Criminais, correto afirmar que

- a) a competência será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal ou pelo domicílio da vítima, a critério desta.
- b) cabível a interposição de recurso em sentido estrito, no prazo de 05 (cinco) dias, contra a decisão de rejeição da denúncia ou queixa, com abertura de vista para apresentação das razões em 08 (oito) dias.
- c) não cabe recurso especial contra decisão proferida por turma recursal, competindo a esta, porém, processar e julgar mandado de segurança contra ato de juizado especial.
- d) cabem embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias, quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão, sem interrupção, contudo, do prazo para a interposição de recurso.
- e) os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da semana, incabível, porém, a prática em outras comarcas.

**9- (2020/CESPE/TJ-PA/Oficial de Justiça)** Luís foi denunciado pela prática de crime de menor potencial ofensivo em um juizado especial criminal de Belém – PA, mas não foi encontrado para ser citado pessoalmente. Nessa situação hipotética,

- a) será determinada a citação por edital, com prazo de cinco dias.
- b) será nomeado defensor dativo para representar Luís na audiência de conciliação.
- c) o processo ficará suspenso até que Luís seja encontrado.
- d) o processo será encaminhado ao juízo comum.
- e) a vítima será intimada para informar o endereço atualizado de Luís.

**10- (2019/VUNESP/TJ-RJ/Juiz Substituto)** A aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multa, conhecida como “transação penal”, tal qual prevista no art. 76, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95, não será admitida se ficar comprovado

- a) que o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.
- b) ter sido o agente beneficiado anteriormente pela aplicação de pena restritiva ou multa na mesma modalidade de “transação penal”.
- c) ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime ou contravenção, à pena privativa de liberdade transitada em julgado.
- d) ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime ou contravenção, a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva.
- e) não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.

**11- (2019/FCC/TRF 3º REGIÃO/analista judiciário)** Sobre o procedimento sumaríssimo, previsto para julgamento de crimes de menor potencial ofensivo, de competência dos Juizados Especiais Federais Criminais, na esteira das Leis nº 10.259/2001 e nº 9.099/1995,

- a) interposto recurso de apelação pela parte se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.
- b) caberá agravo de instrumento no prazo de dez dias contra a decisão que rejeitar a denúncia.
- c) os embargos de declaração opostos contra sentença condenatória proferida suspendem o prazo para interposição de recurso.
- d) o recurso de apelação será interposto no prazo de quinze dias, contados da ciência pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição contando as razões e o pedido do recorrente.
- e) nenhum ato será adiado, sendo vedada a condução coercitiva de testemunha arrolada.



**12- (2019/CONSULPLAN/TJ-MG/Titular de Serviços de Notas e de Registros)** Com relação ao procedimento sumaríssimo e às regras aplicáveis ao Juizado Especial Criminal, assinale a alternativa correta.

- a) Contra as decisões da Turma Recursal, cabe recurso ordinário ao Tribunal de Justiça.
- b) A denúncia/queixa será recebida tão logo inicie a audiência de instrução e julgamento.
- c) Se houver, por qualquer motivo, remessa do feito do juizado especial para o juízo comum, o rito a ser aplicado será o sumário.
- d) Descumprido pelo autor do fato o acordo feito em transação penal, a ação penal não mais pode ser intentada, cabendo apenas a execução da medida acordada.

**13- (2019/MPE-SP/MPE-SP/Promotor de Justiça Substituto)** É correto afirmar, em relação à suspensão condicional do processo, que

- a) na ausência de proposta justificada do Ministério Público, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral.
- b) o juiz não poderá especificar, além daquelas previstas na Lei nº 9.099/95, outras condições a que fica subordinada a suspensão.
- c) não se admite a proposta nas ações penais de iniciativa privada, ante a ausência de previsão legal.
- d) na ausência de proposta do Ministério Público, poderá o juiz criminal fazê-lo, pois se trata de direito público subjetivo do acusado.
- e) nas ações penais de iniciativa privada, cabe ao Ministério Público ofertar a proposta, a qual deve ser ratificada pelo querelante.

**14- (2019/MPE-SP/MPE-SP/Promotor de Justiça Substituto)** Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O benefício da suspensão condicional do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 01 (um) ano.
- b) Para efeitos da Lei nº 9.099/95, são consideradas infrações de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa, nos termos da redação dada pela Lei nº 11.313/06.
- c) Para fins de aplicação do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, devem ser levadas em consideração as qualificadoras, os privilégios, as causas de diminuição e as causas de aumento, observando-se que, em se tratando de causas de diminuição ou de aumento de pena entre determinados limites ou com *quantum* variável, deve-se utilizar, nas causas de aumento, o patamar de maior aumento e, nas causas de diminuição, o patamar de menor redução.
- d) Nos termos do artigo 76, da Lei nº 9.099/95, é defeso proposta de transação penal se comprovado que o agente foi beneficiado anteriormente, no prazo de 5 (cinco) anos, por outra transação penal.
- e) Em caso de o Promotor de Justiça recusar-se a apresentar a proposta de transação penal, não poderá o Juiz formulá-la de ofício, sob pena de violação ao artigo 129, inciso I, da Constituição Federal.

**15- (2019/MPE-SC/MPE-SC/Promotor de Justiça)** Julgue o item a seguir. Na proposta de aplicação imediata de pena (art. 76 da Lei n. 9.099/1995) a autor de crime de menor potencial ofensivo praticado com violência doméstica contra mulher, deverão ser incluídas medidas protetivas de urgência (art. 22 da Lei n. 11.340/2006), sempre que a vítima as solicitar.

**16- (2019/VUNESP/TJ-RS/Titular de Serviços de Notas e de Registros)** Nos estritos termos do art. 63 da Lei nº 9.099/95, a competência dos Juizados Especiais Criminais é determinada

- a) pelo lugar em que a ocorrência policial foi registrada.
- b) pelo lugar do domicílio do acusado ou da vítima.
- c) pelo lugar em que foi praticada a infração penal.
- d) pela matéria.
- e) pela prevenção.

**17- (2019/MP-GO/MP-GO/Promotor de Justiça)** Procedimento incidental, o desaforamento consiste no deslocamento da competência de uma comarca para outra, para que nesta seja realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri, caso ocorra alguma das hipóteses excepcionais previstas nos artigos 427 e 428, do Código de Processo Penal. Dentre essas hipóteses, é incorreto afirmar:

- a) São circunstâncias que podem acarretar o desaforamento: se o interesse da ordem pública o reclamar, houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado.
- b) O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o Juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 1 (um) ano, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.
- c) Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
- d) Não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo Tribunal do Júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao Tribunal que determine a imediata realização do julgamento.

**18- (2019/VUNESP/TJ-RJ/Juiz Substituto)** De acordo com as previsões legalmente estabelecidas (CPP, art. 427 e 428), é correto afirmar que o desaforamento

- a) pode ser determinado, se houver dúvida quanto à imparcialidade do Júri.
- b) deve ser indeferido de pronto, se motivado unicamente por excesso de serviço do órgão judicial.
- c) pode ocorrer, a fim de preservar a segurança pessoal da vítima e de seus familiares.
- d) pode ser determinado de ofício pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri.
- e) quando deferido, deve levar o julgamento para Comarca de outra região do Estado.

**19- (2019/VUNESP/TJ-RO/Juiz Substituto)** Tício foi denunciado pelo Ministério Público pela prática de crime tributário (apenado com reclusão de 2 a 5 anos), em vista de sonegação de imposto, no montante de 1 milhão de reais. Citado, apresentou resposta à acusação, tendo arrolado 8 testemunhas de defesa, duas delas residentes fora da jurisdição, tendo sido expedidas cartas precatórias, com prazo de cumprimento de 90 dias. Ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, com exceção das duas residentes fora da jurisdição, tendo esgotado o prazo de cumprimento da precatória, Tício foi interrogado, abrindo-se vista às partes para apresentação de alegações finais. O órgão de acusação manifestou-se pela absolvição de Tício, por não restar comprovada a autoria. Já a defesa, alegou cerceamento de defesa, por não se aguardar o retorno das cartas precatórias. Concluídos os autos ao Juiz, foi proferida sentença condenatória. Na sentença, a despeito da não imputação pelo órgão da acusação, o Juiz reconheceu a causa de aumento prevista na legislação de crimes tributários, consistente na ocorrência de grave dano à coletividade, pelo valor sonegado, incidindo aumento da pena de 1/3. Diante da situação hipotética, assinale a alternativa correta.

- a) sentença condenatória não violou os princípios do contraditório e devido processo legal, pois pode o juiz condenar o réu, contrariamente à posição do órgão de acusação, não sendo obrigado aguardar o retorno de cartas precatórias, expedidas com prazo.
- b) Haja vista que o crime imputado a Tício processa-se sob o procedimento comum sumário, o número de testemunhas arroladas deveria ser de, no máximo, 5 (cinco).
- c) Haja vista a expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas de defesa residentes fora da jurisdição, o Juiz não poderia ter sentenciado o feito, devendo, ao contrário, ter suspenso o processo, até o retorno.
- d) Haja vista que o órgão de acusação, titular da ação penal, manifestou-se pela absolvição de Mévio, não poderia o Juiz ter proferido sentença condenatória.
- e) Haja vista que a denúncia ofertada pelo órgão de acusação não imputou a Tício qualquer causa que implicasse agravamento da pena, não poderia o Juiz ter reconhecido a causa de aumento consistente na ocorrência de grave dano à coletividade.

**20- (2019/FGV/MPE-RJ/Oficial do Ministério Público)** Fernando foi denunciado pela suposta prática do crime de aborto sem o consentimento da gestante. Em que pese no curso da instrução tenha sido deferida a revogação da prisão preventiva, Fernando permaneceu preso em razão de outro processo onde é imputada a prática de um crime de roubo majorado pelo emprego de arma. Após a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o juiz profere decisão pronunciando Fernando nos termos da denúncia.

Considerando apenas as informações expostas, é correto afirmar que Fernando:

- a) poderá, diante das alterações legislativas ocorridas no ano de 2008 no Código de Processo Penal, ser intimado da decisão de pronúncia através de edital, cabendo a interposição de recurso em sentido estrito para questionar a decisão do magistrado;

- b) poderá, diante das alterações legislativas ocorridas no ano de 2008 no Código de Processo Penal, ser intimado da decisão de pronúncia através de edital, cabendo a interposição de recurso de apelação para questionar a decisão do magistrado;
- c) poderá, diante das alterações legislativas ocorridas no ano de 2008 no Código de Processo Penal, ser intimado da decisão de pronúncia através de edital, cabendo a interposição de recurso de agravo para questionar a decisão do magistrado;
- d) deverá ser intimado pessoalmente da decisão de pronúncia, podendo esta ser questionada através de recurso de apelação;
- e) deverá ser intimado pessoalmente da decisão de pronúncia, podendo esta ser questionada através de recurso em sentido estrito.

**21- (2018/VUNESP/TJ-SP/Juiz substituto)** Reconheceu o artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, a instituição do júri. Quanto a ela, é correto afirmar que

- a) o efeito devolutivo da Apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da interposição.
- b) constatando o Juiz Presidente haver dúvidas sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, procederá de ofício o desaforamento, encaminhando os autos para julgamento em outra comarca da mesma região, comunicando imediatamente ao Presidente do Tribunal de Justiça.
- c) são relativas as nulidades do julgamento pelo júri, quando os quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes, bem como a falta de quesito obrigatório.
- d) não torna nulo o julgamento ulterior pelo júri a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo, embora cindido.

**22- (2019/CONSULPLAN/TJ-MG/Titular de Serviços de Notas e de Registros)** Quanto ao Procedimento Especial do Tribunal do Júri, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O desaforamento é permitido na pendência de recurso interposto contra a decisão de pronúncia.
- b) A instalação da sessão de julgamento sem o número mínimo legal de quinze jurados acarreta a nulidade do julgamento.
- c) A intimação ao réu da sentença de pronúncia em regra é pessoal, mas excepcionalmente pode ser editalícia, permitindo o julgamento à revelia.
- d) A sentença de absolvição sumária, prolatada ao fim do *judicium accusationis*, constitui hipótese de extinção do feito com julgamento do mérito e faz coisa julgada formal e material, sendo atacada pelo recurso de apelação.

**23- (2019/FCC/TJ-AL/Juiz substituto)** Ao final da primeira fase do procedimento do júri,

- a) o Juiz, ao pronunciar o réu, não pode reconhecer em seu favor a existência de causa especial de diminuição da pena.
- b) o Juiz deve sempre absolver o acusado desde logo no caso de inimputabilidade decorrente de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
- c) não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o Juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado, mas sempre será possível a formulação de nova denúncia ou queixa se houver prova nova.
- d) quando o Juiz se convencer da existência de crime diverso, em discordância com a acusação, deve sentenciar o feito, independentemente da natureza da infração reconhecida.
- e) o Juiz deve impronunciar o réu se ficar comprovado não ser ele autor ou partícipe do fato.

**24- (2019/CESPE/DPE-DF/Defensor Público)** Manoel foi denunciado pela prática de homicídio doloso; o processo seguirá as regras do rito do tribunal do júri. Considerando a situação hipotética precedente e acerca dos procedimentos relativos a processos da competência do tribunal do júri, julgue o item seguinte. Na sessão de julgamento pelo plenário do júri, Manoel, estando presente, tem direito de permanecer calado em seu interrogatório; no entanto, nos debates orais, o acusador poderá fazer uso do argumento de que “Quem cala, consente!”.

**25- (2019/CESPE/TJDFT/Titular de Serviços de Notas e de Registros)** Considerando os dispositivos processuais penais, julgue os itens subsecutivos, relativos à resposta à acusação.

I A resposta à acusação é uma peça processual de oferecimento obrigatório pelo acusado pessoalmente citado.

II É exigível a resposta à acusação somente nos processos que tratam de crimes para os quais se aplica o procedimento comum ordinário.

III A resposta à acusação viabiliza o julgamento antecipado da lide e a consequente absolvição sumária do acusado na hipótese de inimizabilidade do agente por doença mental.

IV Consiste a resposta à acusação em uma oportunidade processual na qual, entre outros pedidos, deve ser indicado o rol de testemunhas e requerida as suas oitivas, sob pena de preclusão.

Estão certos apenas os itens

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) I, III e IV.
- e) II, III e IV.

**26- (2019/VUNESP/TJ-AC/Juiz de direito substituto)** Em relação ao procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri, assinale a alternativa correta.

- a) O desaforamento não poderá ser determinado sob a alegação de excesso de serviço.
- b) O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave.
- c) Encerrada a instrução probatória, ainda durante a primeira fase, as alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 10 (dez) minutos, prorrogáveis por mais 10 (dez).
- d) O procedimento será concluído no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias.

**27- (2019/CESPE/TJ-PR/juiz substituto)** A respeito do procedimento de competência do tribunal do júri, assinale a opção correta.

- a) O quesito que se refere à desclassificação do delito deve ser respondido antes do quesito genérico da absolvição.
- b) No excesso de linguagem em decisão de pronúncia, a nulidade poderá ser evitada com a determinação do desentranhamento ou envelopamento da decisão.
- c) Os jurados poderão requerer a leitura de peças que se refiram, exclusivamente, às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis.
- d) A inércia da defesa para apresentar alegações finais, quando devidamente intimada, acarreta nulidade processual se o juiz não nomear defensor para suprir a omissão.

**28- (2019/CESPE/TJ-BA/juiz de direito substituto)** Acerca dos procedimentos processuais penais no Brasil, julgue os itens a seguir.

I Nos crimes contra a propriedade imaterial que deixem vestígios, o exame do corpo de delito será condição de procedibilidade para o exercício da ação penal.

II No procedimento sumário, o prazo para resposta à acusação é de cinco dias.

III Registro de depoimento tomado na audiência de instrução por meio audiovisual terá de ser encaminhado às partes, sendo obrigatória a transcrição.

IV No procedimento por crime funcional, em caso de ilícito afiançável, o réu será notificado para apresentar defesa preliminar por escrito no prazo de quinze dias.

Estão certos apenas os itens

- a) I e IV.
- b) II e III.
- c) III e IV.
- d) I, II e III.
- e) I, II e IV.

**29- (2019/MPE-SC/MPE-SC/Promotor de Justiça)** Julgue o item a seguir. No processo e julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial quando os crimes forem de ação privativa do ofendido, não será admitida queixa com fundamento em apreensão e em perícia, se decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, após a homologação do laudo.

**30- (2019/MP-GO/MP-GO/Promotor de Justiça)** Acerca do processo e do julgamento dos crimes de calúnia e injúria, de competência do juiz singular, é incorreto afirmar:

- a) Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as, separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando termo.
- b) Se depois de ouvir o querelante e o querelado, o juiz achar provável a reconciliação, promoverá entendimento entre eles, na sua presença.
- c) No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo da desistência e decorrido o prazo de 5 (cinco) dias sem retratação, a queixa será arquivada.
- d) Quando for oferecida a exceção da verdade ou da notoriedade do fato imputado, o querelante poderá contestar a exceção no prazo de dois dias, podendo ser inquiridas as testemunhas arroladas na queixa, ou outras indicadas naquele prazo, em substituição às primeiras, ou para completar o máximo legal.

## COMENTÁRIOS

**1. Gabarito: E.** Para responder à questão, é importante a leitura dos arts. 395, 397 e 415, todos do CPP. O art. 395 prevê as hipóteses de rejeição da denúncia, portanto, relacionadas às alternativas C e D. Nos demais artigos, estão previstas as possibilidades de realização da absolvição sumária, seja no procedimento comum, seja no procedimento especial do Tribunal do Júri. Tendo em vista que a questão foi expressa ao cobrar a aplicação no procedimento comum ordinário, deve ser assinalada a letra E, que está de acordo com o art. 397, III, do CPP.

**2. Gabarito: A.**

De acordo com o art. 222 do CPP, a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. Assim, findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos, *ex vi* do art. 222, §2º, do CPP. Também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 388.688/SP). Além disso, nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, a inversão da oitiva de testemunhas de acusação e defesa não configura nulidade quando a inquirição é feita por meio de carta precatória, cuja expedição não suspende a instrução criminal, a teor do que dispõe o art. 222 do Código de Processo Penal (AgRg no RHC n. 105.154/SP e HC 538.161/SP).

**3. Gabarito: A.**

a) CORRETA. O Supremo Tribunal Federal entende que

na tentativa de homicídio, respondido afirmativamente que o agente só não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, não há lógica em se questionar de desistência voluntária, que somente se configura quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução (art. 15 do Código Penal). *Habeas corpus* indeferido (HC no 89.921/PR, rel. Min. Ayres Britto, DJ 27/4/2007).

b) INCORRETA. Por força do art. 484, *caput*, do CPP, concluídos os debates, se os jurados disserem que estão habilitados a proceder ao julgamento (CPP, art. 480, §1º), o juiz presidente deve fazer a leitura dos quesitos, indagando das partes se têm requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata. Portanto, o momento processual oportuno para que as partes formulem eventuais impugnações aos quesitos elaborados pelo juiz presidente é este.

c) INCORRETA. De acordo com o art. 490 do CPP, se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas.

d) INCORRETA. De acordo com o art. 483, § 1º, do CPP, a resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do *caput* deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.

e) INCORRETA. De acordo com o art. 479 do CPP, durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

**4. Gabarito: A.**

l) CORRETO. Nos termos do art. 394, § 4º, do CPP, as disposições dos arts. 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código.



II) INCORRETO. Nos termos do art. 396 do CPP, nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias e não para a audiência de instrução.

III) CORRETO. Está de acordo com o art. 66 da Lei nº 9.099/95 e o art. 538 do CPP.

IV) INCORRETO. O procedimento comum sumário é cabível quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a quatro anos de pena privativa de liberdade. Em sendo igual a quatro anos, será adotado o procedimento comum ordinário, nos termos do art. 394, incisos I e II, do CPP.

**5. Gabarito: B.**

a) INCORRETA. O testemunho por ouvir dizer (*hearsay rule*), produzido somente na fase inquisitorial, não serve como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia, que submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri (STJ – Info 603).

b) CORRETA. Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou incabíveis (...) (STJ, AgRg no AREsp 630.056/MG).

c) INCORRETA. Nos termos do art. 415 do CPP, o juiz absolverá sumariamente por inimizabilidade o acusado apenas se for a única tese defensiva.

d) INCORRETA. Nos termos do art. 416 do CPP, da absolvição sumária cabe apelação.

e) INCORRETA. Nos termos do art. 426, § 4º, do CPP, o jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença nos 12 (doze) meses que antecederem à publicação da lista geral fica dela excluído.

**6. Gabarito: B.**

a) INCORRETA. Nos termos do art. 396 do CPP, tanto no procedimento ordinário como no sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

b) CORRETA. De acordo com os art. 403, § 3º, do CPP.

c) INCORRETA. Nos termos do art. 396-A, § 2º, do CPP, não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.

d) INCORRETA. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO: de acordo com o art. 400, na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 do CPP, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. PROCEDIMENTO SUMÁRIO: de acordo com o art. 531, na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 do CPP, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se, finalmente, ao debate.

e) INCORRETA. Ao contrário, o parágrafo 2º do art. 401 traz uma ressalva prevista no art. 209, que permite o juiz, quando julgar necessário, ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes e se lhe parecer conveniente, poderá ouvir as pessoas a que as testemunhas se referirem. Há doutrina minoritária sustentando a revogação tácita do dispositivo em virtude do sistema acusatório (art. 3º-A). No entanto, na prova a previsão ainda pode ser cobrada de forma literal.

**7. Gabarito: C.**

A respeito do tema de absolvição sumária, é importante a leitura dos artigos 397 e 415 do CPP. A alternativa cobra conteúdo importante que se diferencia nessas duas previsões. No primeiro artigo, aplicável no procedimento comum ordinário e sumário, não é possível a absolvição sumária do inimizável. Para se realizar a chamada absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança, é preciso chegar ao final do processo com toda a produção da prova. Por outro lado, no procedimento especial do Tribunal do Júri, previsto no art. 415, CPP, é possível a absolvição sumária por inimizabilidade, em determinada situação, qual seja, ter sido a única tese defensiva. Se houver outras teses, o réu será pronunciado e conduzido à segunda fase de plenário. Assim, os jurados poderão decidir a respeito da questão.

**8. Gabarito: C.**

a) INCORRETA. De acordo com o art. 63 da Lei nº 9.099/95, a competência será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal.



- b) INCORRETA. Não há recurso em sentido estrito nos Juizados Especiais Criminais. De acordo com o art. 82 da Lei nº 9.099/95, caberá recurso de apelação, o qual deverá ser interposto no prazo de 10 dias.
- c) CORRETA. A alternativa está de acordo com duas súmulas importantíssimas. Súmula nº 203 STJ: não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais e Súmula nº 376 do STJ: compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.
- d) INCORRETA. De acordo com o art. 83 da Lei nº 9.099/95, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão e o prazo é de 5 dias para a oposição da peça. No entanto, ao contrário do que diz a alternativa, de acordo com o § 2º do mesmo artigo a oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para interposição do recurso principal.
- e) INCORRETA. De acordo com o art. 65, § 2º, a prática dos atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação.

**9. Gabarito:** D. De acordo com o art. 66 da Lei nº 9.099/95, a citação deverá ser pessoal. Não sendo encontrado o acusado, o Juiz encaminhará o processo para o juízo comum. Importante acrescentar que lá o processo seguirá o procedimento comum sumário, nos termos do art. 538 do CPP.

**10. Gabarito:** E. Atenção na leitura do art. 76, § 2º, da Lei nº 9.099/95, que prevê as hipóteses em que não se admitirá a proposta de transação penal. Dessa forma, a letra E está de acordo com o inciso III do dispositivo.

**11. Gabarito:** A.

- a) CORRETA. Está de acordo com o art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.
- b) INCORRETA. Não há recurso de agravo de instrumento na Lei nº 9.099/95. De acordo com o art. 82, da rejeição da denúncia caberá a interposição de recurso de apelação no prazo de 10 dias.
- c) INCORRETA. Nos termos do art. 83, § 2º, da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição do recurso principal.
- d) INCORRETA. De acordo com o art. 82 da Lei nº 9.099/95, o recurso de apelação será interposto no prazo de 10 dias.
- e) INCORRETA. Nos termos do art. 80 da Lei nº 9.099/95, nenhum ato será adiado, determinando o Juiz, quando imprescindível, a condução coercitiva de quem deva comparecer.

**12. Gabarito:** C.

- a) INCORRETA. Caberá recurso extraordinário, de acordo com a Súmula nº 640 do STF.
- b) INCORRETA. Nos termos do art. 81 da Lei nº 9.099/95, aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.
- c) CORRETA. De acordo com o art. 538 do CPP.
- d) INCORRETA. Atenção à Súmula Vinculante nº 35: a homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.

**13. Gabarito:** A.

- a) CORRETA. De acordo com a Súmula nº 696 do STF: reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal.
- b) INCORRETA. De acordo com a letra de lei (art. 89, § 2º, da Lei nº 9.099/95), o juiz poderá especificar, além daquelas previstas na Lei nº 9.099/1995, outras condições a que fica subordinada a suspensão condicional do processo
- c) INCORRETA. De acordo com o STJ, no HC 18.590/2001, é cabível a suspensão condicional do processo também para os crimes de ação penal privada.
- d) INCORRETA. De acordo com a Súmula nº 696, do STF, na ausência de proposta do Ministério Público, o juiz não poderá conceder a suspensão condicional do processo.
- e) INCORRETA. De acordo com a doutrina do professor Renato Brasileiro, o Enunciado 112, do FONAJE, apenas prevê que, no caso de ações penais privadas, o oferecimento cabe diretamente ao Ministério Público, sem fazer menção sobre a necessidade de aquiescência pelo querelante. Contudo, o próprio autor adverte sobre a

existência de controvérsia sobre o assunto, pois há entendimento no sentido de que a proposta caberia ao querelante e não ao Ministério Público.

**14. Gabarito: C.**

- a) CORRETA. De acordo com a Súmula nº 243, STJ, o benefício da suspensão condicional do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano.
- b) CORRETA. Nos termos do art. 61, da Lei nº 9.099/95, são consideradas infrações de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa, nos termos da redação dada pela Lei nº 11.313/2006.
- c) INCORRETA. Para fins de aplicação do art. 89, da Lei nº 9.099/1995, devem ser levadas em consideração as qualificadoras, os privilégios, as causas de diminuição e as causas de aumento, observando-se que, em se tratando de causas de diminuição ou de aumento de pena entre determinados limites ou com *quantum* variável, deve-se utilizar, nas causas de aumento, o patamar de menor aumento e, nas causas de diminuição, o patamar de maior redução.
- d) CORRETA. De acordo com o parágrafo 4º, do art. 76, da Lei nº 9.099/1995, acolhendo a proposta de transação penal ofertada pelo Ministério Público e aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos.
- e) CORRETA. De acordo com a Súmula nº 696, do STF, reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do CPP. De acordo com a jurisprudência, o mesmo raciocínio aplica-se à transação penal.

**15. Gabarito: INCORRETO.** Súmula nº 536 do STJ: A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

**16. Gabarito: C.** Art. 63 da Lei nº 9.099/95. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal.

**17. Gabarito: B.** As alternativas A, C e D estão de acordo com os arts. 427 e 428 do CPP. No entanto, a letra B afirma que será o caso de desaforamento “se o julgamento não puder ser realizado no prazo de um ano”, ao contrário do previsto no art. 428: “se o julgamento não puder ser realizado no prazo de seis meses”.

**18. Gabarito: A.**

- a) CORRETA. Alternativa de acordo com o art. 427 do CPP.
- b) INCORRETA. Prevê o art. 428, CPP, que devem ser ouvidos o juiz presidente e a parte contrária antes da análise do pedido de desaforamento.
- c) INCORRETA. Prevê o art. 427 do CPP que pode ocorrer o desaforamento, a fim de preservar a segurança pessoal do acusado e não da vítima e seus familiares.
- d) INCORRETA. A análise do pedido de desaforamento é de competência do Tribunal, conforme dispõe o art. 427. Dessa forma, não há possibilidade de o juiz presidente do tribunal do Júri determinar a providência de ofício.
- e) INCORRETA. Prevê o art. 427 que, quando determinado, deve levar o julgamento para outra comarca da mesma região, preferindo-se as mais próximas.

**19. Gabarito: A.**

- a) CORRETA.
- b) INCORRETA. Tício foi denunciado por crime cuja pena máxima é de cinco anos. Em sendo igual/superior a quatro anos, o procedimento a ser adotado é o comum ordinário, conforme art. 394, § 1º, I, do CPP. Desse modo, na instrução poderão ser inquiridas até oito testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nos termos do art. 401 do CPP.
- c) INCORRETA. Nos termos do art. 222, § 1º, do CPP, a expedição de carta precatória não suspenderá a instrução criminal.

- d) INCORRETA. Nos termos do art. 385, do CPP, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
- e) INCORRETA. Vide assertiva D.

**20. Gabarito: E.** Nos termos do art. 420 do CPP, a intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado. Somente será intimado pessoalmente se o acusado que estiver solto não for encontrado, o que não é o caso de Fernando. Dessa forma, por estar preso por outro processo, deverá ser intimado pessoalmente no presídio. Além disso, consoante o art. 581, IV, CPP, da decisão de pronúncia cabe a interposição de recurso em sentido estrito.

**21. Gabarito: A.**

- a) CORRETA. De acordo com a Súmula nº 713, STF: o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
- b) INCORRETA. Nos termos da Súmula nº 712 do STF, é nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do Júri sem audiência da defesa.
- c) INCORRETA. Nos termos da Súmula nº 162 do STF, é absoluta a nulidade do julgamento pelo júri, quando os quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes.
- d) INCORRETA. Conforme Súmula nº 206 do STF, é nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo.

**22. Gabarito: A.**

- a) INCORRETA. De acordo com o art. 427, § 4º, na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese (se efetivado o julgamento), quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
- b) CORRETA. A exigência de um mínimo de 15 jurados para instalação não se trata de mera formalidade, mas margem de segurança para que se possa ocorrer a de recusa imotivada das partes.
- c) CORRETA, nos termos dos arts. 420 e 457, ambos do CPP.
- d) CORRETA. Sentença de absolvição sumária é uma decisão de mérito, de forma a fazer coisa julgada formal e material e encerrando o *iudicium accusationis*. Em conformidade com o artigo 593, inciso I do CPP, o recurso de apelação é o cabível.

**23. Gabarito: A.**

- a) CORRETA. Pode reconhecer somente qualificadoras e causa de aumento, conforme art. 413, § 1º, CPP.
- b) INCORRETA. Nos termos do art. 415 do CPP, somente se for a única tese alegada.
- c) INCORRETA. Somente até a extinção de punibilidade (sobretudo pela prescrição).
- d) INCORRETA. Deve remeter ao juízo competente. Trata-se de decisão de desclassificação: Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1º do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.
- e) INCORRETA. Deve absolver sumariamente.

**24. Gabarito: INCORRETO.** Nos termos do art. 478 do CPP, durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências ao silêncio do acusado.

**25. Gabarito: B.**

- I) CORRETO. O não oferecimento de peça defensiva obrigatória caracteriza vício processual que gera nulidade absoluta.
- II) INCORRETO. No procedimento sumário (aplicável aos crimes com pena maior que 2 anos e menor que 4 anos) também existe a resposta à acusação, que deve ser oferecida em 10 dias.
- III) INCORRETO. De acordo com o art. 397, II, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa de excludente de culpabilidade do agente, salvo a inimizabilidade.
- IV) CORRETO. Está de acordo com o art. 396-A do CPP.

**26. Gabarito: B.**

- a) INCORRETA. Conforme art. 428 do CPP, o desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço.

- b) CORRETA. Nos termos do art. 418 do CPP, o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave.
- c) INCORRETA. Nos termos do art. 411, § 4º, do CPP, as alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10.
- d) INCORRETA. Nos termos do art. 412 do CPP, o procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias.

**27. Gabarito: C.**

- a) INCORRETA. Nos casos em que a tese principal for absolutória (ex.: legítima defesa), o quesito de absolvição deve ser formulado antes que o de desclassificação (tese subsidiária). Isso se justifica com o objetivo de garantir a plenitude da defesa, já que a absolvição é mais vantajosa do que a mera desclassificação para outro crime menos grave (STJ, REsp 1509504-SP - Info 573).
- b) INCORRETA. Havendo excesso de linguagem, o Tribunal deverá anular a sentença de pronúncia e os consecutivos atos processuais, determinando-se que outra seja prolatada, não basta o desentranhamento e envelopamento (STF, RHC 127522/BA - Info 795; STJ, AgRg no REsp 1.442.002-AL - Info 561).
- c) CORRETA. De acordo com o art. 473, § 3º, do CPP.
- d) INCORRETA. Nos processos da competência do Júri Popular, o não oferecimento de alegações finais não é causa de nulidade do feito, pois o juízo de pronúncia é provisório, não havendo antecipação do mérito da ação penal. Ademais, a ausência da referida peça pode constituir, até mesmo, estratégia da Defesa, que opta por apresentar suas teses apenas no julgamento em plenário (STJ, HC 158.355/AP).

**28. Gabarito: A.**

- I) CORRETO. Nos termos do art. 525, no caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito.
- II) INCORRETO. Nos termos do art. 396, tanto no procedimento ordinário como no sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
- III) INCORRETO. Conforme o previsto no art. 405, § 2º, do CPP, no caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição.
- IV) CORRETO. De acordo com o art. 514 do CPP.

**29. Gabarito: INCORRETO.** O prazo é de 30 dias e não 15. De acordo com o art. 529 do CPP, nos crimes de ação privativa do ofendido, não será admitida queixa com fundamento em apreensão e em perícia, se decorrido o prazo de 30 dias, após a homologação do laudo.

**30. Gabarito:.**

- a) CORRETA, nos termos do art. 520 do CPP.
- b) CORRETA, nos termos do art. 521 do CPP.
- c) INCORRETA. Arquivada de plano, não há prazo de 5 dias. Art. 522. No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo da desistência, a queixa será arquivada.
- d) CORRETA, nos termos do art. 523 do CPP.

**CAPÍTULO 22 – DAS NULIDADES (ARTS. 563 A 573, CPP)****1. CONCEITO**

No processo penal, o termo nulidade é empregado com significados distintos, havendo duas correntes doutrinárias quanto à temática, a saber:

I) NULIDADE COMO SANÇÃO PROCESSUAL DE INEFICÁCIA: "uma primeira corrente (majoritária) compreende a nulidade como espécie de sanção aplicada ao ato processual defeituoso, privando-o de seus efeitos regulares" (LIMA, 2017, p. 1585), não sendo a nulidade, no processo penal, algo automático, "porquanto é preciso que o juiz se manifeste expressamente para que cessem os efeitos do ato processual viciado (salvo impossibilidade natural ou lógica de produção de seus efeitos normais)" (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 1492);

II) NULIDADE COMO DEFEITO DO ATO PROCESSUAL: "uma segunda corrente (minoritária) refere-se à nulidade como espécie de qualidade ou característica do ato processual ou do processo", sendo a palavra nulidade, portanto, utilizada "como expressão sinônima de defeito, vício, imperfeição, inobservância da forma legal" (LIMA, 2017, p. 1585). Para essa corrente, as nulidades "são os vícios que contaminam determinados atos processuais, praticados sem a observância da forma prevista em lei, podendo levar à sua inutilidade e consequente renovação" (NUCCI, 2016, p. 488).

**1.1. VÍCIOS OCORRIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO**

A doutrina majoritária entende que não há falar em nulidades no inquérito policial, já que não se trata de procedimento judicializado, sendo os vícios ou as irregularidades verificadas ao longo da investigação incapazes de contaminar a ação penal vindoura (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 1545).

Também é essa a posição dos Tribunais Superiores, os quais entendem que, mesmo havendo elementos informativos viciados ou irregulares no caderno inquisitorial, tais atos de investigação não têm o condão de afastar a validade da ação penal instaurada. Assim, é válida a denúncia sustentada em um inquérito policial em que havia elementos de informação viciados e não viciados.

Em contrapartida, o STJ, no julgamento do HC nº 100.879/RJ, de relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, assentou existir constrangimento ilegal em ação penal cuja base informativa somente era constituída de prova ilícita. É dizer: se, no inquérito policial, só há um elemento informativo e esse é viciado, a ação penal fundada nessa investigação submete o réu a constrangimento ilegal. Confira-se esse importante precedente do STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. *HABEAS CORPUS*. 1. AÇÃO PENAL INSTAURAÇÃO. BASE EM DOCUMENTAÇÃO APREENDIDA EM DILIGÊNCIA CONSIDERADA ILEGAL PELO STF E STJ. AÇÕES PENAS DISTINTAS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. 2. ILICITUDE DA PROVA DERIVADA. TEORIA DA ÁRVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS. DENÚNCIA OFERECIDA COM BASE EM PROVA DERIVADA DA PROVA ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. TRANCAMENTO. 3. ORDEM CONCEDIDA.

1. Tendo o STF declarado a ilicitude de diligência de busca e apreensão que deu origem a diversas ações penais, impõe-se a extensão desta decisão a todas as ações dela derivadas, em atendimento aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

2. Se todas as provas que embasaram a denúncia derivaram da documentação apreendida em diligência considerada ilegal, é de se reconhecer a imprestabilidade também destas, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada, trancando-se a ação penal assim instaurada.

3. Ordem concedida para trancar a ação penal em questão, estendendo, assim, os efeitos da presente ordem também ao co-réu na mesma ação LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO

RODRIGUES. (HC 100.879/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/8/2008, DJe 8/9/2008.) (Grifos nossos.)

## 1.2. ESPÉCIES DE IRREGULARIDADES

Considerando-se a gravidade do vício do ato processual praticado e as consequências daí advindas para o processo, as irregularidades são classificadas da forma que se segue (LIMA, 2017, 1583):

I) IRREGULARIDADES OU DEFEITOS SEM CONSEQUÊNCIA: embora o ato tenha sido praticado sem a fiel observância do modelo legalmente previsto, tal irregularidade não trará nenhuma consequência ao processo. É o que ocorria, por exemplo, com a utilização de abreviaturas em peças processuais, o que era vedado pelo art. 169, § 1º, CPC/73. Mesmo sendo proibido o seu uso, caso alguma peça processual as contivesse, isso não traria nenhuma consequência ao processo;

II) IRREGULARIDADES OU DEFEITOS QUE ACARRETAM TÃO SOMENTE SANÇÕES EXTRAPROCESSUAIS: é o que ocorre, por exemplo, no caso da multa prevista ao advogado que abandonar injustificadamente o processo, nos termos do art. 265, *caput*, do CPP. É dizer: o abono da causa somente trará consequências ao próprio advogado, não advindo nenhum prejuízo à validade do processo em andamento, desde que, obviamente, regularizada a defesa do réu;

III) IRREGULARIDADES OU DEFEITOS QUE PODEM ACARRETAR A INVALIDADE DO ATO PROCESSUAL: atentando contra interesse público ou interesse preponderante das partes, a irregularidade poderá acarretar a declaração de nulidade do ato, retirando sua aptidão à produção de efeitos regulares; e

IV) IRREGULARIDADES OU DEFEITOS QUE ACARRETAM A INEXISTÊNCIA JURÍDICA DO ATO PROCESSUAL: a gravidade da irregularidade é tão abrupta que se considera que o ato praticado nem mesmo existiu. É o que ocorre quando um juiz impedido prola sentença ou no caso de uma denúncia subscrita por um estagiário do Ministério Público.

## 1.3. ESPÉCIES DE ATOS PROCESSUAIS

Tendo em conta as espécies de irregularidades, a doutrina classifica os atos processuais da seguinte forma (LIMA, 2017, p. 1583-1584):

I) ATOS PERFEITOS: são aqueles cuja prática observou fielmente o modelo legalmente previsto, sendo eles válidos e eficazes, com aptidão à produção de todos os efeitos legais que lhe são inerentes;

II) ATOS MERAMENTE IRREGULARES: também são válidos e eficazes, possuindo aptidão à produção dos efeitos que lhe são característicos, contudo, estão eivados de irregularidades sem consequências ao processo ou de irregularidades que somente acarretam sanções extraprocessuais. É o que ocorre, por exemplo, à luz da Súmula nº 366 do STF, com o edital de citação que apenas indica o dispositivo legal que está incurso o acusado, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que a peça acusatória se baseia;

III) ATOS NULOS: são aqueles passíveis de decretação de ineficácia, declarando-se a nulidade absoluta ou relativa. Por serem juridicamente existentes, via de regra, produzem efeitos até que sejam declarados nulos. É o que ocorre, por exemplo, com uma decisão decretadora da prisão preventiva desprovida de fundamentação, que produzirá seus efeitos regulares até que seja afastada pelo Tribunal, com base no art. 93, inciso IX, CF/88;

IV) ATOS INEXISTENTES: dada a gravidade da irregularidade, são considerados pela doutrina uma espécie de "não ato", não podendo, em nenhuma hipótese, ser cogitada a sua convalidação.



#### 1.4. Sistemas de nulidades

A fim de reputar ou não o ato processual praticado como nulo, a doutrina, a despeito da existência de outras classificações, se vale de três sistemas (AVENA, 2017, p. 715):

I) SISTEMA FORMALISTA: o meio predomina sobre o fim, porquanto toda vez que o ato processual não for praticado da forma legalmente prevista, este deverá ser considerado nulo, sendo desimportante o fato de ter atingido ou não o seu objetivo;

II) SISTEMA LEGALISTA: são nulos apenas os atos que a lei, de forma expressa, assim considerar;

III) SISTEMA INSTRUMENTAL (OU INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS): a forma como o ato foi praticado deve sucumbir à sua finalidade, podendo o referido ato processual ser validado, ainda que não tenha obedecido à formalidade legalmente prevista. É o sistema, via de regra, adotado pelo direito brasileiro, nos termos do arts. 563 e 566 do CPP, que privilegiam o atingimento do resultado legalmente previsto para o ato.

#### 1.5. PRINCÍPIOS INFORMATIVOS DAS NULIDADES

##### 1.5.1. NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO (PRINCÍPIO DO *PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF*)

De acordo com o art. 563 do CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", somente havendo falar em declaração de nulidade, seja ela relativa, seja ela absoluta, se do ato praticado advier prejuízo.

Nesse contexto, pelo princípio ora estudado, ainda que a nulidade seja do tipo absoluta, somente haverá o seu reconhecimento se resultar do ato praticado efetivo prejuízo, o que tem sido recorrentemente cobrado em provas de concurso.

A título elucidativo, colacionam-se precedentes recentes da Quinta e Sexta Turmas do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...) a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio *pas de nulité sans grief*, previsto no art. 563, do CPP. (AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.) (Grifos nossos.)

(...) a jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que "todas as nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, demandam a demonstração do efetivo prejuízo para que possam ser declaradas" (AgRg no AREsp n. 713.197/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que, repito, não se verificou no presente caso. (AgRg no AREsp 1490192/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019.) (Grifos nossos.)

Como será tratado em capítulo próprio, no caso das nulidades do tipo absoluta, haverá uma presunção relativa de prejuízo, o que não significa dizer que necessariamente deverá ser declarada a nulidade do ato ou do processo, sendo esse ponto melhor trabalhado à frente.

##### 1.5.2. NÃO HÁ NULIDADE POR OMISSÃO DE FORMALIDADE QUE SÓ INTERESSE À PARTE CONTRÁRIA (PRINCÍPIO DO INTERESSE)

Dispõe o art. 565, parte final, do CPP, que nenhuma das partes poderá arguir nulidade referente à formalidade cuja observância só à parte contrária interesse, significando dizer "que somente a parte prejudicada poderá alegar a nulidade" (AVENA, 2017, p. 721).

Não poderá a defesa, por exemplo, arguir nulidade decorrente da falta do Promotor de Justiça à audiência de instrução, em processo no qual, mesmo com tal irregularidade, tenha sido proferida sentença absolutória, por evidente falta de interesse (AVENA, 2017, p. 722).

Importante frisar que o princípio do interesse somente é aplicável em relação às nulidades relativas, porquanto, "em se tratando de nulidade absoluta, como há, em regra, violação de norma protetiva de interesse público com status constitucional (v.g., devido processo legal, ampla defesa, contraditório), qualquer parte pode fazer a arguição" (LIMA, 2017, p. 1602-1603).

Ademais, o princípio ora em análise também não se aplica ao Ministério Público, a quem compete, nos termos do art. 127 da CF/88, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, dentre eles o direito à liberdade de locomoção. Logo, pode o Ministério Público pleitear a absolvição do acusado (art. 385, CPP) e "o reconhecimento de nulidade relativa em favor da defesa, seja quando atua como parte (ação penal pública), seja quando atua como fiscal da lei (ação penal privada)" (LIMA, 2017, 1603).

Portanto, pode o Ministério Público, por exemplo, pleitear o reconhecimento da nulidade de citação (nulidade absoluta) ou mesmo de nulidade relativa atinente à deficiência de defesa.

### **1.5.3. NÃO HÁ NULIDADE PROVOCADA PELA PARTE (PRINCÍPIO DA LEALDADE OU DA BOA-FÉ)**

De acordo com o art. 565, primeira parte, do CPP, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, compreendendo-se que tal norma proibitiva "alcança tanto as hipóteses em que estiver comprovada a má-fé, vale dizer, o dolo da parte em produzir a nulidade para, depois, dela se beneficiar, como aquelas em que obrou com culpa, v.g., por negligência processual" (AVENA, 2017, p. 722).

### **1.5.4. A NULIDADE DE ATO PROCESSUAL RELEVANTE PODE DESENCADear A DOS CONSEQUENTES (PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, EFEITO EXPANSIVO, SEQUENCIALIDADE, CONTAMINAÇÃO OU CONSEQUENCIALIDADE)**

Dispõe o art. 573, *caput*, do CPP, que, não tendo havido o saneamento do vício existente em determinado ato processual, este deverá ser renovado ou retificado.

Por sua vez, disciplina o art. 573, § 1º, do CPP, que "a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência", devendo ser frisado que a relação de dependência ou causalidade mencionada pela lei não necessariamente advém da cronologia dos atos (LIMA, 2017, p. 1602).

Depreende-se, por tal princípio, que, se um determinado ato processual, em decorrência de uma nulidade qualquer, for declarado ineficaz (nulidade originária), todos os atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência também não poderão produzir seus efeitos regulares (nulidade derivada).

Todavia, nem todos os atos que forem produzidos após o ato declarado ineficaz deverão seguir o mesmo caminho, porquanto não é a cronologia dos atos que determina a declaração de ineficácia dos atos posteriores, mas, sim, a existência de relação direta de dependência ou causalidade.

É dizer: é possível que um ato praticado após a declaração de ineficácia de um ato anterior produza todos os seus regulares efeitos, o que ocorrerá se o ato posterior não decorrer ou depender diretamente do ato anteriormente praticado.

Nesse contexto, a fim de esclarecer se a declaração de nulidade de um determinado ato prejudicará ou não a validade de atos praticados posteriormente, estabelece o art. 573, § 2º, do CPP, que o juiz ou Tribunal que pronunciar a nulidade deverá declarar os atos a que ela se estende.

### 1.5.5. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS (CONFINAMENTO DA NULIDADE)

O princípio do confinamento da nulidade ou da conservação dos atos processuais funciona como o inverso do princípio da causalidade, porquanto reclama a preservação da validade dos atos posteriores que não dependam ou sejam consequência direta de ato anterior declarado inválido (LIMA, 2017, p. 1602).

É dizer: o princípio da causalidade impõe a declaração de nulidade de ato posterior que dependa ou seja consequência direta de ato anteriormente declarado nulo. Por sua vez, o princípio da conservação apregoa que, se não for verificada essa relação de consequência ou dependência direta, o ato posterior deve ser preservado.

### 1.5.6. NÃO HÁ NULIDADE DE ATO IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA

De acordo com o art. 566 do CPP, "não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa".

Exemplificando, se uma determinada testemunha, ouvida sem a presença de intérprete, prestar seu depoimento em idioma estrangeiro, haverá desobediência ao comando estatuído pelo art. 223, *caput*, do CPP. Todavia, se a oitiva dessa testemunha não for utilizada pelas partes e pelo juiz como fundamentação, não se declarará a sua nulidade (NUCCI, 2016, p. 490).

### 1.5.7. PRINCÍPIO DA CONVALIDAÇÃO, APROVEITAMENTO OU PROTEÇÃO

Pelo princípio da convalidação, também denominado de princípio do aproveitamento ou da proteção, não haverá a declaração de nulidade de determinado ato processual se for possível suprir o defeito por ele apresentado (LIMA, 2017, p. 1604).

Via de regra, o princípio da convalidação somente é aplicável às hipóteses de nulidade relativa, já que, no mais das vezes, não há falar em saneamento ou convalidação de ato absolutamente nulo (LIMA, 2017, p. 1604).

Todavia, não se pode esquecer que, na hipótese de trânsito em julgado de sentença absolutória própria, estarão convalidadas as nulidades absolutas ocorridas ao longo daquele processo, já que não há falar em revisão criminal *pro societate*, servindo tal ação autônoma de impugnação, tão somente, para corrigir eventuais erros judiciais ocorridos em processos nos quais foi prolatada sentença condenatória ou absolutória imprópria (LIMA, 2017, p. 1604).

Assim, não havendo instrumento hábil à revisão de sentença absolutória própria com trânsito em julgado, eventual ato eivado de nulidade absoluta praticado durante a marcha procedimental restará convalidado, sendo este um importante caso de aplicação do princípio em tela em relação a atos absolutamente nulos.

## 2. ESPÉCIES DE NULIDADES

### 2.1. NULIDADES ABSOLUTAS

Nas chamadas nulidades absolutas, o ato processual praticado é eivado de vício atentatório ao "interesse público na existência de um processo penal justo", sendo duas as suas características fundamentais (LIMA, 2017, p. 1585):

I) PREJUÍZO PRESUMIDO: considerando que as nulidades absolutas, no mais das vezes, violam normas constitucionais protetivas de interesse público, tais como o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, grande parte da doutrina entende que o prejuízo advindo de tal espécie de nulidade é presumido.

Todavia, deve-se dar muita atenção ao fato de que essa presunção de prejuízo não é absoluta (*juris et jure*), mas, sim, relativa (*juris tantum*), havendo, em verdade, tão somente, uma inversão do ônus probante inserto no art. 156, *caput*, do CPP.

Conforme se extrai do citado dispositivo, em regra, o ônus da prova compete a quem alega. Todavia, tendo uma parte alegado a ocorrência de uma nulidade absoluta, ficará ela exonerada de provar a existência do prejuízo, já que este é presumido. Caso a parte contrária, isto é, a que não alegou a ocorrência da nulidade, queira manter o ato, à ela competirá provar que não houve prejuízo algum, operando-se a chamada inversão do ônus da prova. Se a parte contrária, de fato, conseguir demonstrar a inexistência de prejuízo, o ato processual não será declarado nulo, já que, tendo em vista o princípio do prejuízo, não há nulidade, mesmo que do tipo absoluta, se não houve prejuízo.

Diante da ausência de prejuízo, o STJ, no julgamento do HC nº 227.263/RJ, de relatoria do Min. Vasco Delia Giustina, Desembargador convocado do TJ/RS, não declarou a nulidade de julgamento no qual participou um desembargador que havia se declarado suspeito, porquanto, pelo placar do resultado, seu voto em nada o influenciou. No caso, em um órgão colegiado composto de 24 (vinte e quatro) desembargadores, apenas dois votaram contrariamente ao recebimento de denúncia contra uma promotora de justiça. É dizer: o voto do desembargador que havia se declarado suspeito nada influenciou no resultado da sessão de julgamento, não havendo, portanto, prejuízo.

Note-se, pois, que, mesmo diante de uma hipótese de nulidade absoluta (suspeição do julgador), o STJ não declarou a ineficácia do julgamento, porquanto não resultou do ato praticado efetivo prejuízo à parte, nos termos do que foi estudado acerca do princípio do *pas de nullité sans grief*.

II) ARGUIÇÃO A QUALQUER MOMENTO: conforme estudado no tópico atinente ao princípio da convalidação, aproveitamento ou proteção, em regra, os vícios do ato absolutamente nulo não poderão ser convalidados ou saneados, podendo a nulidade absoluta ser alegada a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória ou absolutória imprópria.

Deve-se rememorar que, no caso de sentença penal absolutória própria, os atos eivados de nulidade absoluta restarão convalidados com o trânsito em julgado da sentença, já que não há falar em revisão criminal *pro societate*, somente podendo ser manejada tal ação em benefício do condenado ou do absolvido impropriamente.

Questão importante diz respeito à necessidade de prequestionamento da nulidade absoluta perante os Tribunais Superiores.

À luz das Súmulas nº 356 do STF e nº 320 do STJ, "em sede de recurso extraordinário e especial, os tribunais superiores só poderão se manifestar sobre uma nulidade absoluta se a mesma tiver sido objeto de prequestionamento", sendo possível, todavia, caso não tenha havido o prequestionamento, que seja concedida ordem de *habeas corpus* de ofício, desde que não haja supressão de instância (LIMA, 2017, p. 1587).

## 2.2. NULIDADES RELATIVAS

Nas denominadas nulidades relativas, o ato processual praticado é eivado de vício atentatório a "norma infraconstitucional que tutela interesse preponderante das partes", sendo duas as suas características principais (LIMA, 2017, p. 1588):

I) INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO: ao contrário do que ocorre com as nulidades absolutas, em relação às nulidades relativas, não há presunção de prejuízo, competindo à parte que a invoca, de fato, provar a prejudicialidade do ato relativamente nulo; e

II) ARGUIÇÃO OPORTUNA, SOB PENA DE PRECLUSÃO E CONSEQUENTE CONVALIDAÇÃO: nos termos do art. 571 do CPP, as nulidades relativas, ao contrário das nulidades absolutas, devem ser alegadas em



momento oportuno, sob pena de preclusão e consequente convalidação do ato processual praticado. Assim, o vício das nulidades relativas pode ser removido (convalidado), permitindo-se que o ato produza seus efeitos regulares, seja pela preclusão temporal (decorso do tempo), seja pela preclusão lógica (a parte, tacitamente, aceitou seus efeitos).

### 2.2.1. MOMENTO PARA A ARGUIÇÃO DAS NULIDADES RELATIVAS

Tendo em vista que a legislação processual penal sofreu diversas alterações, o art. 571 do CPP deve ser lido à luz de tais modificações, sendo assim interpretado (LIMA, 2017, p. 1590-1594):

I- AS DA INSTRUÇÃO CRIMINAL DOS PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO JÚRI, NOS PRAZOS A QUE SE REFERE O ART. 406 (inciso I): interpretando-se tal dispositivo à luz das mudanças, chega-se à conclusão de que "as nulidades relativas da instrução criminal da 1ª fase do procedimento do júri, ocorridas após a apresentação da resposta à acusação, devem ser arguidas em sede de alegações orais (CPP, art. 411, §§ 4º, 5º e 6º), sob pena de preclusão temporal";

II- AS DA INSTRUÇÃO CRIMINAL DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR E DOS PROCESSOS ESPECIAIS, SALVO OS DOS CAPÍTULOS V E VII DO TÍTULO II DO LIVRO II, NOS PRAZOS A QUE SE REFERE O ART. 500 (inciso II): com as mudanças, tal dispositivo deve ser interpretado no sentido de que, nos processos perante o juiz singular, as nulidades relativas ocorridas entre o oferecimento da peça acusatória e a citação do acusado devem ser alegadas na resposta à acusação, nos termos do art. 396-A, *caput*, do CPP. Se a nulidade relativa ocorrer após a resposta à acusação, ela deverá ser alegada até fase de alegações finais orais (ou memoriais), sob pena de preclusão;

III- AS DO PROCESSO SUMÁRIO, NO PRAZO A QUE SE REFERE O ART. 537, OU, SE VERIFICADAS DEPOIS DESSE PRAZO, LOGO DEPOIS DE ABERTA A AUDIÊNCIA E APREGOADAS AS PARTES (inciso III): com todas as modificações ocorridas, entende-se que, no procedimento sumário, assim como ocorre no procedimento ordinário, as nulidades relativas ocorridas entre o oferecimento da peça acusatória e a citação do acusado devem ser alegadas na resposta à acusação, nos termos do art. 396-A, *caput*, do CPP. Por outro lado, se a nulidade relativa ocorrer após a resposta à acusação, ela deverá ser alegada até a fase de alegações finais orais, sob pena de preclusão;

IV- AS DO PROCESSO REGULADO NO CAPÍTULO VII DO TÍTULO II DO LIVRO II, LOGO DEPOIS DE ABERTA A AUDIÊNCIA (inciso IV): tal dispositivo, que se referia à aplicação de medida de segurança por fato não criminoso (arts. 549 a 555, CPP), foi tacitamente revogado pela reforma penal introduzida pela Lei nº 7.209/84;

V- AS OCORRIDAS POSTERIORMENTE À PRONÚNCIA, LOGO DEPOIS DE ANUNCIADO O JULGAMENTO E APREGOADAS AS PARTES (ART. 447) (inciso V): com as inúmeras mudanças, tal dispositivo deve ser assim interpretado: a) se a nulidade relativa tiver ocorrido na própria decisão de pronúncia, sua arguição deve ser feita no bojo do recurso em sentido estrito interposto contra ela, nos termos do art. 581, inciso IV, do CPP; e b) se a nulidade relativa ocorrer após a preclusão da sentença de pronúncia, deverá ser arguida imediatamente depois de anunciado o julgamento em plenário do júri e apregoadas as partes;

VI- AS DE INSTRUÇÃO CRIMINAL DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DOS TRIBUNAIS DE APELAÇÃO, NOS PRAZOS A QUE SE REFERE O ART. 500 (inciso VI): diante de todas as mudanças, sustenta-se que as nulidades relativas da instrução criminal dos processos de competência originária dos Tribunais deverão ser arguidas por ocasião da apresentação das alegações escritas (art. 11, *caput*, Lei nº 8.038/90), ou no momento da sustentação oral (art. 12, inciso I, Lei nº 8.038/90), sob pena de preclusão;

VII- SE VERIFICADAS APÓS A DECISÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA, NAS RAZÕES DE RECURSO OU LOGO DEPOIS DE ANUNCIADO O JULGAMENTO DO RECURSO E APREGOADAS AS PARTES (inciso VII): se as nulidades relativas forem verificadas na própria sentença ou após a sua prolação, deverão ser arguidas nas razões recursais ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes, isto é, por ocasião da sustentação oral no juízo *ad quem*.

Por interpretação extensiva, chega-se à conclusão de que as nulidades relativas ocorridas após as alegações finais orais das partes (ou memoriais) e antes da sentença, também deverão ser arguidas nas razões recursais ou na sustentação oral perante o Tribunal.

É importante frisar, ademais, que, embora o art. 571, inciso VII, do CPP, somente se refira às nulidades relativas ocorridas "após a decisão da primeira instância", também poderão ser arguidas, como preliminares no recurso interposto, aquelas que ocorreram ao longo do procedimento e não foram acolhidas pelo juízo de primeira instância, desde que tenham sido alegadas pela defesa no momento oportuno.

Exemplo: na resposta à acusação, a defesa sustentou a ocorrência de uma nulidade relativa, que não foi acolhida pelo juízo *a quo* por ocasião do saneamento do processo, tendo a douta autoridade judiciária determinado a designação da audiência una de instrução e julgamento. Como a defesa alegou essa nulidade no momento oportuno, poderá argui-la novamente por ocasião do recurso interposto contra a sentença proferida. Se a defesa não tivesse levantado tal nulidade no momento adequado, não poderia argui-la na fase recursal, porquanto já teria ocorrido o fenômeno da preclusão.

VIII- AS DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO, EM AUDIÊNCIA OU EM SESSÃO DO TRIBUNAL, LOGO DEPOIS DE OCORREREM (inciso VIII): se as nulidades relativas forem verificadas no julgamento em plenário do júri, em audiência ou em sessão do julgamento, estas deverão ser arguidas imediatamente depois de ocorrerem, sob pena de preclusão temporal e consequente convalidação do vício.

Obviamente, se forem alegadas no momento oportuno e rechaçadas pelo juízo, poderão ser novamente levantadas na fase recursal.

## 2.2.2. CONVALIDAÇÃO DAS NULIDADES RELATIVAS (ART. 572, CPP)

Conforme assentado acima, à luz do art. 572 do CPP, se as nulidades relativas não forem arguidas no momento oportuno, ou, se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim, ou se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos, ocorrerá a convalidação do ato relativamente nulo, restando o vício saneado.

O referido artigo, de forma expressa, aduz que poderá haver a convalidação das nulidades previstas no art. 564, inciso III, alíneas *d* e *e*, segunda parte, *g* e *h*, e inciso IV, do CPP, deixando a entender que todas elas são do tipo relativa, já que os atos eivados de nulidades absolutas não são passíveis de saneamento.

Entretanto, conforme será analisado com maior profundidade no capítulo atinente às nulidades em espécie, o referido artigo 572 do CPP deve ser interpretado com bastante cautela, já que ele também faz referência a nulidades absolutas, as quais não poderão ser convalidadas. Vejamos, de forma bem rápida, as nulidades por ele listadas, deixando claro que melhores comentários serão feitos no capítulo adiante:

I) Art. 564, inciso III, alínea *d*, CPP: trata da falta de intervenção do Ministério Público, que, conforme será visto, poderá ocasionar nulidade do tipo absoluta ou relativa;

II) Art. 564, inciso III, alínea *e*, segunda parte, CPP: trata da ausência de interrogatório do acusado, que poderá acarretar nulidade absoluta do processo, e da não concessão de prazos à acusação e à defesa, que gerará nulidade do tipo relativa, passível de convalidação;



III) Art. 564, inciso III, alínea *g*, CPP: trata da não intimação do réu para a sessão plenária do Tribunal do Júri, que, conforme a doutrina, gera nulidade absoluta do julgamento;

IV) Art. 564, inciso III, alínea *h*, CPP: trata da não intimação das testemunhas indicadas pelas partes para serem ouvidas na sessão plenária, que, se ocorrer por falha do juízo, acarretará nulidade absoluta do julgamento; e

V) Art. 564, inciso IV, CPP: trata da omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, que, a depender do caso, poderá gerar nulidade relativa, absoluta ou até mesmo a declaração de inexistência do ato.

### 3. NULIDADES EM ESPÉCIE

O CPP, em seu art. 564, traz um rol exemplificativo de nulidades, sendo algumas delas taxadas de absolutas, isto é, nas quais há presunção de prejuízo e outras de natureza relativa, não havendo tal presunção. Há, ainda, hipóteses de inexistência do ato, como se dá, por exemplo, no caso de impedimento do julgador. Passa-se à análise individualizada dos casos arrolados no CPP.

#### 3.1. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (ART. 564, INCISO I, 1ª PARTE, CPP)

Apesar de o art. 564, inciso I, 1ª parte, CPP não dispor expressamente quanto ao ponto, a doutrina explica que a incompetência absoluta, isto é, *ratione materiae* (em razão da matéria), *ratione personae/funcionae* (foro por prerrogativa de função) ou competência funcional, gera nulidade absoluta, havendo, portanto, presunção de prejuízo.

Em contrapartida, a incompetência relativa (ex.: em razão do local), gera, tão somente, nulidade do tipo relativa.

##### 3.1.1. CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA

Tema importante para as provas de concurso diz respeito ao art. 567 do CPP, o qual aduz que "a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente".

Muitas das questões cobram somente a literalidade do artigo, devendo o candidato ter em mente que o legislador não especificou a qual espécie de incompetência ele se referia, isto é, se absoluta ou relativa.

Outras questões fazem uma digressão doutrinária/jurisprudencial um pouco mais aprofundada, que, ao fim e ao cabo, pelo menos para a maioria da doutrina, aproxima-se da literalidade do artigo. Elucida-se.

Parcela minoritária da doutrina divide o art. 567 do CPP em consequências advindas da nulidade absoluta e consequências oriundas da nulidade relativa, diferenciando-as. Para eles, no caso das nulidades do tipo absoluta, tanto os atos instrutórios quanto os decisórios deverão ser anulados, isto é, nada do que foi produzido perante o juízo absolutamente incompetente será aproveitado. Em relação às nulidades relativas, essa parcela da doutrina entende que somente haverá a necessidade de anular os atos decisórios, podendo haver simples ratificação dos atos instrutórios. Isto é, no caso de nulidade relativa, devem ser refeitos, perante o juízo competente, apenas os decisórios, já que os instrutórios podem ser simplesmente ratificados (não necessitam ser refeitos).

A doutrina majoritária rechaça essa diferenciação, apegando-se à literalidade da norma. Para eles, pouco importa se a nulidade é do tipo absoluta ou relativa. Somente haverá necessidade de repetição dos atos decisórios, podendo ocorrer a simples ratificação dos instrutórios, não havendo falar na necessidade de repetição desses últimos perante o juízo competente.

Afastando-se de ambas as correntes, e até mesmo da literalidade do artigo, o STF, a partir do julgamento do HC nº 83.006/SP, de relatoria da Min. Ellen Gracie, passou a entender que,

mesmo no caso de incompetência absoluta, poderá haver a simples ratificação dos atos decisórios, que, por essa razão, não precisariam ser repetidos perante o juízo competente.

Diante de tudo isso, o candidato deve se atentar ao comando da questão, verificando se lhe está sendo cobrado o texto da lei, o entendimento da doutrina ou do STF, devendo, no caso de provas dissertativas, ser demonstrado o conhecimento de todas elas.

### 3.2. SUSPEIÇÃO DO JUÍZO (ART. 564, INCISO I, PARTE FINAL, CPP)

Conforme assentado quando do estudo dos sujeitos ou atores do processo penal, a suspeição do juízo é causa de nulidade absoluta, porquanto "importa em presunção *jure et jure* [absoluta] de que o juiz não é totalmente isento para officiar no feito" (AVENA, 2017, 725).

É importante rememorar que, no caso de impedimento do magistrado, entende-se que o ato por ele praticado é inexistente, algo mais grave do que a nulidade absoluta, conforme explanado em capítulo próprio.

### 3.3. SUBORNO DO JUIZ (ART. 564, INCISO I, PARTE FINAL, CPP)

Recebendo o juiz qualquer tipo de vantagem, seja ela financeira ou não, o ato por ele praticado estará eivado de nulidade absoluta, havendo presunção *juris tantum* (relativa) de prejuízo.

### 3.4. ILEGITIMIDADE DE PARTE (ART. 564, INCISO II, CPP)

Apesar de o CPP não fazer tal diferença, a doutrina divide as consequências da ilegitimidade *ad causam* e *ad processum* (LIMA, 2017, p. 1608):

I) ILEGITIMIDADE AD CAUSAM: entende-se que a "legitimidade para agir ou *legitimatío ad causam* é a pertinência subjetiva da ação", isto é, "a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito ocupar o polo passivo dessa mesma demanda" (LIMA, 2017, p. 1608).

Exemplo clássico de ilegitimidade *ad causam* é a propositura, pelo Ministério Público, de queixa-crime em desfavor de suposto autor de crime de injúria, já que tal delito contra a honra subjetiva, via de regra, é processável por intermédio de ação penal de iniciativa privada, nos termos do art. 145, primeira parte, do CP.

Verificando-se a ilegitimidade *ad causam*, ocorrerá nulidade do tipo absoluta, havendo presunção de prejuízo.

II) ILEGITIMIDADE AD PROCESSUM: trata-se de "fenômeno relacionado à capacidade de estar em juízo, tida como pressuposto processual de validade, capaz de ensejar, no máximo, uma nulidade relativa" (LIMA, 2017, p. 1608).

Haverá ilegitimidade *ad processum*, por exemplo, do menor de 18 (dezoito) anos que, sem a devida representação, ingressa com queixa-crime, ensejando, pois, o reconhecimento de nulidade relativa (LIMA, 2017, p. 1608).

#### 3.4.1. SANEAMENTO DA ILEGITIMIDADE AD PROCESSUM (ART. 568 DO CPP)

Dispõe o art. 568 do CPP que "a nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais", somente sendo tal dispositivo aplicável à ilegitimidade *ad processum* (nulidade relativa) e não à ilegitimidade *ad causam*, que, como visto, dá ensejo à nulidade absoluta.

### **3.5. FALTA DE DENÚNCIA, QUEIXA-CRIME OU REPRESENTAÇÃO E, NOS PROCESSOS DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, DE PORTARIA OU DE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (ART. 564, INCISO III, ALÍNEA A, CPP)**

Inicialmente, assenta-se que a segunda parte do dispositivo, isto é, a que diz respeito à instauração de processo criminal, por contravenção penal, através de portaria ou de auto de prisão em flagrante delito, não foi recepcionada pela Constituição Federal, nos termos do seu art. 129, inciso I. É dizer: sendo todas as contravenções penais, pelo menos pelo texto legal, sujeitas à ação penal de iniciativa pública incondicionada (art. 17 da LCP), esta somente poderá ser iniciada por denúncia do Ministério Público e não mais por portaria da autoridade policial ou auto de prisão em flagrante delito, o que era chamado de procedimento judicialiforme.

Nesse contexto, vigora a parte da alínea que diz respeito a processo criminal iniciado sem a correspondente peça acusatória (denúncia ou queixa-crime, conforme o caso) ou sem a representação do ofendido ou de seu representante legal, quando a lei assim dispõe.

Apesar de o artigo não ser expresso, entende-se que a ele deveria ser incluída a hipótese de falta de requisição do Ministro da Justiça, nos casos em que a lei a exige. Isto é, sendo a perseguição criminal sujeita à requisição do Ministro da Justiça, caso ela não se implemente, a nulidade verificada estará fundada também nessa alínea (AVENA, 2017, p. 728).

Assim, verificando-se a falta da peça acusatória (denúncia ou queixa-crime) ou das condições de procedibilidade (representação do ofendido ou de seu representante legal ou requisição do Ministro da Justiça), haverá nulidade do tipo absoluta.

Deve-se ter cuidado para não confundir a nulidade atinente à falta de tais peças processuais, a qual enseja nulidade absoluta, com a hipótese de omissão de formalidade que constitua elemento essencial de tais atos, nos termos do art. 564, inciso IV, do CPP, que será estudado em tópico próprio.

### **3.6. AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO, RESSALVADO O DISPOSTO NO ART. 167 DO CPP (ART. 564, INCISO III, ALÍNEA B, CPP)**

Se a infração penal for do tipo não transeunte (ou de fato permanente), caso não seja realizado o exame de corpo de delito (art. 158, *caput*, CPP), haverá nulidade do tipo absoluta, salvo se o exame não tiver sido realizado em razão do desaparecimento dos vestígios, situação na qual a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta (art. 167, CPP).

Logo, se era possível fazer o exame de corpo de delito, isto é, os vestígios não desapareceram, e, mesmo assim, o exame não foi feito, deverá ser reconhecida a nulidade absoluta do processo.

Em contrapartida, se não era possível fazer o exame de corpo de delito, já que os vestígios desapareceram, a ausência do exame poderá ser suprida pela prova testemunhal (e não pela confissão), caso em que não haverá nulidade.

### **3.7. FALTA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AO ACUSADO PRESENTE, QUE NÃO O TIVER, OU AO AUSENTE, E DE CURADOR AO MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS (ART. 564, INCISO III, ALÍNEA C, CPP)**

Conforme estudado no capítulo atinente aos sujeitos processuais, nos termos do art. 261, *caput*, do CPP, "nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor", isto é, mesmo que o acusado não queira receber a assistência de um advogado, necessariamente, deverá o juiz lhe nomear um defensor.

Rememora-se, à luz da Súmula nº 523 do STF, que a falta de defesa técnica acarreta nulidade absoluta do processo, enquanto a sua deficiência gera, tão somente, nulidade do tipo relativa.

Ademais, deve ser lembrado que, com o advento do Código Civil de 2002, que previu a maioria civil aos 18 (dezoito) anos completos, e a revogação expressa do antigo art. 194 do CPP, restou revogado tacitamente o art. 262 do mesmo Código, que exigia a nomeação de curador ao acusado menor de 21 (vinte e um) anos e maior de 18 (dezoito), restando, de igual forma, revogada a parte final do art. 564, inciso III, alínea c, do CPP.

### **3.8. NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (ART. 564, INCISO III, ALÍNEA D, CPP)**

De acordo com o art. 564, inciso III, alínea d, CPP, a não intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública, gera nulidade, devendo o estudo de tal dispositivo ser subdividido em duas análises:

I) FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA: caso o Ministério Público não seja intimado para a prática de determinado ato inerente à ação penal pública, haverá nítida violação à paridade de armas, acarretando nulidade absoluta (LIMA, 2017, p. 1613).

Por outro lado, deve-se ter atenção aos casos nos quais o Ministério Público é intimado para atos instrutórios, por exemplo, a oitiva de testemunhas, e não comparece. Nesse caso, tendo em vista que houve a regular intimação, entende-se que a nulidade verificada é do tipo relativa. Inclusive, no julgamento do HC nº 181.306/PE, de relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, o STJ não reconheceu a nulidade de processo no qual o Promotor de Justiça, em razão de acúmulo de duas comarcas, não compareceu à oitiva de testemunhas. Assentou o STJ se tratar de nulidade relativa, que, existindo algum prejuízo, somente poderia ser alegado pelo próprio Ministério Público e não pela defesa, à luz do princípio do interesse, conforme art. 565, parte final, do CPP (LIMA, 2017, p. 1613).

Frise-se, ademais, que, se o Ministério Público deixar de praticar atos postulatórios, tal como a apresentação de alegações finais orais (ou memoriais), haverá nulidade do tipo absoluta, já que ao Ministério Público é vedado desistir da ação penal, nos termos do art. 42 do CPP (princípio da indisponibilidade).

Em resumo: na ação penal pública, se o Ministério Público não for intimado a praticar determinado ato instrutório ou deixar de praticar atos postulatórios, intimado ou não, haverá nulidade absoluta. Se, devidamente intimado, deixar de praticar atos instrutórios, verificar-se-á nulidade relativa.

II) FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS CASOS DE AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA: nos termos do art. 5º, inciso LIX, CF/88, na ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, "o Ministério Público atua como interveniente adesivo obrigatório (ou parte adjunta), devendo intervir em todos os termos do processo, sob pena de nulidade (CPP, art. 564, III, "d")", sendo a nulidade aqui verificada taxada de relativa (LIMA, 2017, p. 1614).

### **3.9. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO (CIRCUNDUÇÃO), DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO E DE CONCESSÃO DOS PRAZOS À ACUSAÇÃO E À DEFESA (ART. 564, INCISO III, ALÍNEA E, CPP)**

Dispõe o art. 564, inciso III, alínea e, do CPP, que haverá nulidade por ausência de citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa, devendo o estudo de tal dispositivo legal ser partilhado em três:

I) AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ACUSADO PARA SE VER PROCESSAR: sendo a citação o ato pelo qual se dá ciência ao acusado do recebimento de uma peça acusatória oferecida em seu desfavor, chamando-o para se defender, sua ausência ou efetivação em desacordo com os pressupostos legais acarreta nulidade absoluta do processo, desde o seu início.

Todavia, à luz do disposto no art. 570 do CPP, que merece ser lido à inteireza, se, embora não tenha sido regularmente citado (isto é, o ato citatório não existiu ou foi praticado em desacordo com a lei), o acusado, ainda assim, compareceu ao processo, não haverá a declaração de nulidade, porquanto foi atingida a finalidade do ato de citação.

Em relação ao art. 570 do CPP, é preciso destacar que há nele uma impropriedade técnica quanto ao termo "sanada", já que, tratando-se de nulidade absoluta, não há falar em seu saneamento, conforme estudado acima.

Na verdade, "o comparecimento do réu não implica um 'saneamento' propriamente dito, mas apenas impede o reconhecimento da mácula em face da ausência de prejuízo" (AVENA, 2017, p. 732).

Por fim, é interessante ressaltar que a doutrina tem rotulado a citação inválida de citação circunduta.

II) AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO ACUSADO: a despeito do art. 564, inciso III, alínea e, do CPP, aduzir que haverá nulidade no caso de ausência de interrogatório do acusado, deve-se ter muita cautela em relação a esse dispositivo legal, já que o interrogatório é um desdobramento direto do direito de defesa.

Nesse contexto, deve-se assentar, em um primeiro momento que, havendo a sua regular intimação, é facultado ao acusado não comparecer ao ato de interrogatório, já que a ele é dado o direito de renunciar à sua autodefesa, não havendo nulidade alguma no ponto. É dizer: se o acusado pode comparecer ao interrogatório e permanecer em silêncio, também lhe é conferido o direito de nem se deslocar para o ato, porquanto pode o réu não ter interesse em contar sua versão dos fatos ao magistrado.

Por outro lado, se o acusado não for intimado para o ato de interrogatório ou, mesmo estando presente à audiência, o juiz se negar a interrogá-lo, ocorrerá nulidade do tipo absoluta, porquanto há nítida violação ao direito de defesa.

III) NÃO CONCESSÃO DE PRAZOS À ACUSAÇÃO E À DEFESA: apesar de não constar expressamente do referido dispositivo legal, tanto a não concessão de prazos às partes como a eventual redução dos prazos legalmente estabelecidos em lei acarretam nulidade relativa do ato, devendo ser arguidas em momento oportuno (LIMA, 2017, p. 1615).

### **3.10. AUSÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA (ART. 564, INCISO III, ALÍNEA F, 1ª PARTE, CPP)**

Por meio da decisão de pronúncia, encerra-se a primeira fase do procedimento do Júri, permitindo que o acusado seja, de fato, julgado pelos Jurados, juízes naturais da causa. Assim, a falta da decisão de pronúncia gera nulidade absoluta do processo, já que é condição imprescindível à submissão do acusado ao julgamento em plenário do Tribunal do Júri.

De igual forma, também haverá nulidade absoluta se ocorrer o que se denomina de eloquência acusatória, isto é, o juiz, ao fundamentar a decisão de pronúncia, deve se limitar a "apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no *animus judicandi* dos jurados", já que estes "podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos" (LIMA, 2017, p. 1616-1617).

### **3.11. FALTA DO LIBELO ACUSATÓRIO E DA ENTREGA DA RESPECTIVA CÓPIA, COM O ROL DE TESTEMUNHAS, NOS PROCESSOS PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 564, INCISO III, ALÍNEA F, PARTE FINAL, CPP)**

Com a extinção de tal ato processual, não há mais falar na nulidade prevista no art. 564, inciso III, alínea f, parte final, do CPP.

### **3.12. FALTA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, QUANDO A LEI NÃO PERMITIR O JULGAMENTO À REVELIA (ART. 564, INCISO III, ALÍNEA G, CPP)**

Antes da reforma processual instituída pela Lei nº 11.689/08, somente no caso de crime afiançável é que poderia haver sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri sem a presença do acusado, nos termos do antigo art. 415, §1º, do CPP. Logo, no caso de crime inafiançável, não havia possibilidade de se realizar a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri sem o réu estar presente.

Com a referida reforma processual, não há mais tal diferenciação, sendo, independentemente do tipo de crime (isto é, se afiançável ou inafiançável), possível o julgamento em sessão plenária do Tribunal do Júri sem a presença do acusado.

Assim, se regularmente intimado, o acusado não quiser comparecer à sessão de julgamento, não há falar em nulidade, já que o réu, tão somente, está exercendo um consectário do seu direito à autodefesa.

Se o acusado estiver preso, sendo ele também dotado do direito de estar presente à sessão plenária de julgamento, de modo a preservar a sua autodefesa, compete ao Poder Público conduzi-lo até o ato. Caso o acusado preso não seja levado à sessão plenária, haverá o adiamento do julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, nos termos da primeira parte do art. 457, §2º, do CPP. Por outro lado, se o acusado preso não quiser comparecer à sessão plenária, é possível que, juntamente com seu defensor, peça sua dispensa do ato, conforme a parte final do art. 457, §2º, do CPP.

Nesse contexto, estando o direito de presença à sessão plenária inserido no contexto da autodefesa, não sendo o acusado regularmente intimado para o ato, haverá nulidade, conforme art. 564, inciso III, alínea g, do CPP.

Em relação à espécie de nulidade ocasionada pela não intimação do acusado, alerta a doutrina que, embora o art. 572 do CPP sugira se tratar de nulidade relativa, já que permite sua preclusão temporal, deve tal nulidade ser taxada de "absoluta, porquanto haverá lesão à garantia constitucional da ampla defesa, já que o acusado, pelo fato de não ter sido intimado, será privado do exercício do direito de audiência e de presença, consectários lógicos da autodefesa" (LIMA, 2017, p. 1618).

Por fim, rememora-se que, caso o acusado, mesmo não tendo sido regularmente intimado para o ato, compareça à sessão plenária, não haverá declaração de nulidade do processo, nos termos estatuídos pelo art. 570 do CPP.

### **3.13. FALTA DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS NO LIBELO E NA CONTRARIEDADE, NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI (ART. 564, INCISO III, ALÍNEA H, CPP)**

Com a extinção do libelo acusatório e da contrariedade ao libelo, as partes deverão, no ato processual a que se refere o art. 422 do CPP, arrolar as testemunhas que querem ouvir na sessão plenária.

Dando início à segunda fase do procedimento do Júri, dispõe o referido art. 422 do CPP que, preclusa a decisão de pronúncia, o juiz-presidente determinará a intimação do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.

Assenta-se que, ao arrolarem suas testemunhas, "a acusação e a defesa devem declarar expressamente que o fazem em caráter de imprescindibilidade, postulando pela intimação por mandado em endereço indicado pelas partes", porquanto, à luz do art. 461 do CPP, somente haverá adiamento do julgamento por ausência de testemunha, se a parte que a arrolou tiver pedido sua intimação por mandado, declarando que não dispensa seu depoimento e indicando seu logradouro. Se a parte não indicou determinada testemunha com a cláusula de imprescindibilidade, "corre o risco





de, verificada a ausência da testemunha regularmente intimada, a sessão de julgamento ser realizada sem a sua oitiva (CPP, art. 461, *caput*, 1ª parte) (LIMA, 2017, p. 1618).

Independentemente de a testemunha ter sido ou não arrolada com a cláusula de imprescindibilidade, o juízo deverá adotar providências para intimá-la a comparecer à sessão de julgamento. Caso, em razão de não ter sido regularmente intimada por falha do juízo (falta de expedição de mandado, por exemplo), a testemunha não compareça, haverá nulidade do julgamento, nos termos do art. 564, inciso III, alínea *h*, do CPP.

Em relação à espécie de nulidade ocasionada pela não intimação de testemunha arrolada pela parte em momento oportuno, alerta a doutrina que, embora o art. 572 do CPP sugira se tratar de nulidade relativa, já que permite sua preclusão temporal, deve tal nulidade ser taxada de "absoluta, porquanto violados preceitos de natureza constitucional, como o direito de ação e o de defesa, dos quais o direito à prova é consectário lógico" (LIMA, 2017, p. 1618).

Se, embora não intimada, a testemunha compareça à sessão plenária de julgamento, não há falar em nulidade, nos termos do art. 570 do CPP.

### **3.14. FALTA DA PRESENÇA DE PELO MENOS 15 (QUINZE) JURADOS PARA A CONSTITUIÇÃO DO JÚRI (ART. 564, INCISO III, ALÍNEA I, CPP)**

Dispõe o art. 463, *caput*, do CPP, que, "comparecendo, pelo menos, 15 (quinze) jurados, o juiz presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento".

Logo, só há falar na constituição do Júri se comparecerem, no mínimo, 15 (quinze) dos 25 (vinte e cinco) jurados convocados, "valendo ressaltar que aqueles excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade são considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão" (LIMA, 2017, p. 1619).

É interessante registrar que o STF, no julgamento do HC nº 88.801/SP, de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, deliberou que não é possível o denominado empréstimo de jurados, que consiste na prática de chamar "jurados incluídos na lista convocada para outros julgamentos previstos para a mesma data em diferentes plenários do Júri, a fim de se perfazer o número mínimo previsto no art. 463, *caput*, do CPP" (LIMA, 2017, p. 1619).

Caso não compareçam, no mínimo, 15 (quinze) jurados e, ainda assim, o juiz presidente decida pela realização da sessão de julgamento, haverá nulidade do tipo absoluta, conforme art. 564, inciso III, alínea *i*, do CPP.

### **3.15. FALTA DO SORTEIO DOS JURADOS DO CONSELHO DE SENTENÇA EM NÚMERO LEGAL (ART. 564, INCISO III, ALÍNEA J, 1ª PARTE, CPP)**

Dispõe o art. 467 do CPP que "verificando que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz presidente sorteará 7 (sete) dentre eles para a formação do Conselho de Sentença".

Assim, "se acaso o julgamento vier a ser realizado sem que tenha havido prévio sorteio dos jurados para a composição do Conselho, há de ser declarada a nulidade absoluta do referido ato", nos termos do art. 564, inciso III, alínea *j*, 1ª parte, do CPP (LIMA, 2017, p. 1619).

Importa rememorar que, à luz do art. 449, inciso I, do CPP, "não poderá servir o jurado que tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior". Caso tal hipótese se verifique, isto é, participando do julgamento ulterior um jurado que já havia funcionado no julgamento anterior, haverá nulidade do último julgamento, conforme Súmula nº 206 do STF.

De igual forma, "não poderá servir o jurado que, no caso do concurso de pessoas, houver integrado o Conselho de Sentença que julgou o outro acusado" ou que "tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado", nos termos dos incisos II e III do art. 449 do CPP.

No que diz respeito à espécie de nulidade decorrente da participação de jurado impedido, tendo em vista que, atualmente, a votação é interrompida quando 4 (quatro) votos forem atingidos num mesmo sentido (art. 483, §§ 1º e 2º, CPP), “não é mais possível estabelecer qual terá sido o grau de influência do voto do jurado impedido para o resultado final da votação”. Logo, atualmente, é presumido o prejuízo decorrente da participação de jurado impedido, “do que se extrai a conclusão de que a nulidade, agora, tem natureza absoluta” (LIMA, 2017, p. 1620).

### **3.16. INOBSERVÂNCIA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS (ART. 564, INCISO III, ALÍNEA J, PARTE FINAL, CPP)**

Tendo em vista que o sigilo das votações é uma das características constitucionais do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea *b*, da CF/88, o CPP, em seu art. 466, §1º, impõe a incomunicabilidade dos jurados, havendo nulidade do julgamento acaso os jurados se comuniquem entre si e com terceiros ou manifestem sua opinião sobre o processo.

Convém ressaltar que a incomunicabilidade dos jurados não é absoluta, porquanto somente se refere a manifestações atinentes ao objeto do processo. Assim, não há falar em quebra da incomunicabilidade quando os jurados, logo depois de terem sido escolhidos para o Conselho de Sentença, na presença de todos, usarem telefone celular, para comunicarem a terceiros o fato de que haviam sido sorteados, sem qualquer alusão aos dados do processo que seria julgado (LIMA, 2017, p. 1620).

A despeito de alguma divergência doutrinária, tem prevalecido, no âmbito jurisprudencial, que a violação à incomunicabilidade dos jurados gera, tão somente, nulidade do tipo relativa, “condicionando-se o seu reconhecimento a que seja arguida no momento oportuno e à demonstração do efetivo prejuízo” (AVENA, 2017, p. 736-737).

### **3.17. NULIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS E DAS RESPECTIVAS RESPOSTAS (ART. 564, INCISO III, ALÍNEA K E PARÁGRAFO ÚNICO, CPP)**

De acordo com o art. 484, *caput*, do CPP, após a finalização dos debates no plenário do Tribunal do Júri, caso os jurados digam que estão aptos ao julgamento da causa, o juiz presidente deve ler os quesitos e indagar às partes se têm requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata. Também é obrigação do juiz presidente, explicar aos jurados, ainda em plenário, o significado de cada quesito, nos termos do art. 484, parágrafo único, do CPP.

Tem prevalecido, no âmbito da jurisprudência dos Tribunais Superiores, que os quesitos devem ser impugnados pelas partes tão logo sejam lidos e explicados pelo juiz presidente, sendo este o momento processual oportuno para tanto, sob pena de preclusão, vedando-se ulterior pedido de declaração de nulidade, conforme art. 564, parágrafo único, c/c art. 571, inciso VIII, ambos do CPP, dando a entender que a nulidade daí advinda é do tipo relativa.

Todavia, é possível que eventual vício na formulação de quesitos acarrete nulidade absoluta, não havendo falar em sua convalidação, o que ocorrerá no caso de o vício verificado ser tão grave “que seja capaz de causar prejuízo às teses das partes ou de induzir os jurados a erro ou dúvida sobre o fato submetido a sua apreciação, impedindo o conhecimento da vontade do Conselho de Sentença” (LIMA, 2017, p. 1622).

Nesse contexto, se o juiz presidente não formular o quesito atinente à absolvição do acusado (art. 483, §2º, CPP), ou se formular apenas um quesito em relação à autoria de dois crimes, em contrariedade ao disposto no art. 483, §6º, do CPP, a nulidade será do tipo absoluta, sendo incabível falar-se em preclusão (LIMA, 2017, p. 1622).

Não por outra razão, discorre a Súmula nº 156 do STF que “é absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório”.

Conforme a Súmula nº 162 do STF, que deve ser lida à luz da reforma processual introduzida pela Lei nº 11.689/08, porquanto não há mais quesitação quanto às “circunstâncias

agravantes" em sentido estrito, se o juiz presidente formular os quesitos atinentes às qualificadoras e/ou majorantes antes dos quesitos inerentes às causas de diminuição de pena, em contrariedade ao art. 483, §3º, do CPP, haverá nulidade absoluta.

Destarte, sendo tais nulidades do tipo absoluta, poderão ser alegadas a qualquer momento, pouco importando se não foram impugnadas tão logo ocorreu a leitura e a explicação dos quesitos aos jurados na sessão plenária.

### **3.18. FALTA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA, NA SESSÃO DE JULGAMENTO EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 564, INCISO III, ALÍNEA L, CPP)**

Tendo em vista que não há processo sem juiz, acusação e defesa (*actum trium personarum*), reputa-se nulo o julgamento no qual não haja acusador ou defensor. De igual forma, também será considerado nulo o julgamento em que, a despeito da presença física do acusador e do defensor, for verificada ausência de efetiva acusação e de defesa (LIMA, 2017, p. 1622).

Embora o dispositivo não faça tal diferenciação, é importante distinguir as consequências da falta do advogado do querelante e da ausência do órgão do Ministério Público.

No que diz respeito à ausência do advogado do querelante, tem-se que esta, a depender do tipo de iniciativa da ação penal, acarretará consequências distintas, a saber: (LIMA, 2017, p. 1622)

I) se for o caso de ação penal exclusivamente privada ou personalíssima (conexão entre dois crimes, um de ação penal pública e outro de ação penal de iniciativa privada, por exemplo), a ausência não justificada do advogado do querelante à sessão de julgamento dará ensejo à perempção, extinguindo-se a punibilidade do agente. Entende-se, quanto ao ponto, que, faltando injustificadamente à sessão de julgamento, o advogado do querelante estaria deixando de formular pedido de acusação, o que atrai o instituto da perempção, nos termos do art. 60, inciso III, do CPP c/c o art. 107, inciso IV, do CP; e

II) se for o caso de ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, a ausência injustificada do advogado do querelante deve ser considerada como negligência, possibilitando que o Ministério Público retome o processo como parte principal, conforme art. 29 do CPP (ação penal indireta).

Caso o órgão do Ministério Público não esteja presente à sessão plenária do Tribunal do Júri e, ainda assim, o julgamento seja realizado, haverá nulidade do tipo absoluta.

Por fim, rememora-se, à luz do art. 497, inciso V, do CPP, que, se o juiz considerar o acusado indefeso, poderá dissolver o Conselho e designar novo dia para o julgamento, com a nomeação ou a constituição de outro defensor.

### **3.19. FALTA DA SENTENÇA (ART. 564, INCISO III, ALÍNEA M, CPP)**

Não há falar em condenação ou absolvição sem a prolação de uma sentença, razão pela qual sua inexistência acarreta nulidade absoluta do processo, nos termos do art. 564, inciso III, alínea m, do CPP.

### **3.20. FALTA DO RECURSO DE OFÍCIO, NOS CASOS EM QUE A LEI O TENHA ESTABELECIDO (ART. 564, INCISO III, ALÍNEA N, CPP)**

Tendo em vista que o denominado recurso de ofício possibilita o reexame da matéria pelo Tribunal *ad quem*, sua não implementação acarretará nulidade absoluta, impedindo o trânsito em julgado do processo, nos termos da Súmula nº 423 do STF.

### **3.21. FALTA DE INTIMAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELA LEI, PARA CIÊNCIA DAS SENTENÇAS E DESPACHOS DE QUE CAIBA RECURSO (ART. 564, INCISO III, ALÍNEA O, CPP)**

Conforme art. 564, inciso III, alínea o, do CPP, haverá nulidade do tipo absoluta na falta de intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para ciência das sentenças e despachos de que caiba recurso, porquanto, não sendo as partes intimadas das decisões recorríveis, há nítida violação ao contraditório e à ampla defesa.

Impende assentar que, à luz da Súmula nº 431 do STF, “é nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em *habeas corpus*”. Portanto, a regra é que deverá haver a intimação prévia das partes ou a publicação da pauta de julgamento dos recursos criminais. Todavia, excepcionando tal regramento, tem-se que o julgamento de *habeas corpus* independe de pauta ou de qualquer tipo de comunicação às partes, cumprindo à defesa acompanhar a colocação do processo em mesa para julgamento (LIMA, 2017, p. 1628).

Noutro giro, se a defesa manifestou interesse na sustentação oral em sede de *habeas corpus* e o Tribunal não a intimou previamente da data da sessão, haverá nulidade absoluta do julgamento, já que houve nítida violação à ampla defesa (LIMA, 2017, p. 1628).

### **3.22. INOCORRÊNCIA DE QUÓRUM LEGAL PARA O JULGAMENTO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES, TRIBUNAIS DE JUSTIÇA E TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS (ART. 564, INCISO III, ALÍNEA P, CPP)**

Não havendo o número mínimo de Ministros ou Desembargadores exigido para a instalação de sessão de julgamento perante tais Tribunais, haverá nulidade absoluta do acórdão daí proveniente, nos termos do art. 564, inciso III, alínea p, do CPP.

### **3.23. OMISSÃO DE FORMALIDADE QUE CONSTITUA ELEMENTO ESSENCIAL DO ATO (ART. 564, INCISO IV, CPP)**

De acordo com o art. 564, inciso IV, do CPP, haverá nulidade por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo ser dispensada muita atenção quanto a esse dispositivo legal, mormente quando em confronto com o art. 572 do CPP. Elucida-se.

O art. 572 do CPP, ao afirmar que a nulidade inserta no art. 564, inciso IV, do CPP, restará sanada se não for arguida no momento oportuno, se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim ou se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos, dá a entender que a nulidade daí oriunda é do tipo relativa.

Todavia, o art. 572 do CPP não pode ser interpretado de forma isolada, havendo nulidade absoluta nos casos em que ocorrer violação aos consectários do devido processo legal, tal como se verificará se o ato praticado atenta contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Portanto, “a depender do grau de interesse público inerente à norma processual violada, este vício pode ser tratado como causa de nulidade relativa, de nulidade absoluta ou até mesmo de inexistência do ato” (LIMA, 2017, p. 1629).

Assim, por exemplo, se a sentença proferida não for assinada pelo juiz (art. 381, inciso VI, CPP), embora se trate de “formalidade que constitua elemento essencial do ato”, é evidente que a nulidade daí oriunda não é simplesmente do tipo relativa, havendo falar, em verdade, em inexistência do pronunciamento judicial, já que é a assinatura “que confere autenticidade à sentença, pouco importando o fato de ter sido publicada e registrada pelo escrivão no livro próprio” (LIMA, 2017, p. 1629).

#### **3.23.1. OMISSÕES DA PEÇA ACUSATÓRIA OU DA REPRESENTAÇÃO (ART. 569 DO CPP)**

De acordo com o art. 569 do CPP, as omissões da peça acusatória ou da representação poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.

Nesse sentido, assentou o STF, no julgamento do HC nº 85.636/PI, de relatoria do Min. Carlos Velloso, que, "desde que permitam o exercício do direito de defesa, as eventuais omissões da denúncia, quanto aos requisitos do art. 41 do CPP, não implicam necessariamente na sua inépcia, certo que podem ser supridas a todo tempo, antes da sentença final".

### 3.24. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 564, INCISO V, CPP)

Com fulcro no art. 93, inciso IX, da CF/88 e positivando entendimento jurisprudencial já bastante pacífico, a Lei nº 13.964/19 criou o inciso V do art. 564 do CPP, o qual aduz que haverá nulidade em decorrência de decisão carente de fundamentação.

Tendo em vista que a fundamentação é um "consectário lógico do devido processo legal" (CUNHA, 2020, p. 319), a nulidade por carência de fundamentação, considerando, inclusive, seu sustentáculo constitucional, deve ser taxada de absoluta, razão pela qual pode ser alegada em qualquer momento, havendo, ademais, presunção de prejuízo.

É interessante rememorar que, assim como fez o legislador com o CPC/15, a Lei nº 13.964/19, além de reputar nula a decisão carente de fundamentação, também elencou casos nos quais a decisão será considerada não fundamentada, nulificando-a. Confira-se o teor do art. 315, §2º, CPP:

§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse contexto, estão, agora legalmente, rechaçadas decisões decretadoras da prisão preventiva que se limitam, por exemplo, a mencionarem que o investigado ou o réu coloca em risco a ordem pública, sem o magistrado apontar, contudo, nenhum elemento sequer quanto ao ponto, restringindo-se a indicar, de forma abstrata, o art. 312 do CPP.

## 4. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA

### 4.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Súmula nº 155, STF: “É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha.”

Súmula nº 156, STF: “É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório.”

Súmula nº 160, STF: “É nula a decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.”

Súmula nº 162, STF: “É absoluta a nulidade do julgamento pelo júri, quando os quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes.”

Súmula nº 206, STF: “É nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo.”

Súmula nº 351, STF: “É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da Federação em que o juiz exerce a sua jurisdição.”

Súmula nº 356, STF: “O ponto omissis da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

Súmula nº 431, STF: “É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em *habeas corpus*.”

Súmula nº 523, STF: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Súmula nº 706, STF: “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção.”

Súmula nº 707, STF: “Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo.”

Súmula nº 708, STF: “É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro.”

Súmula nº 712, STF: “É nula a decisão que determina o desaforamento de processo de competência do Júri sem audiência de defesa.”

### 4.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Súmula nº 320, STJ: “A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento.”

AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - PETIÇÃO SUBSCRITA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS - SÚMULA 115 - RESSALVAS DO RELATOR. (...) Na instância especial é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Por efeito da preclusão consumativa, os recursos devem estar prontos e regularizados no momento da interposição, não se podendo aceitar, no recurso especial, a juntada posterior da procuração ainda que na instância local. (...) (AgRg no Ag 564.298/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/3/2007, DJ 7/5/2007, p. 313.)

PROCESSO PENAL. *HABEAS CORPUS*. ESTUPRO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RÉU QUE OCUPA CARGO DE JUIZ DE DIREITO (1) AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. RETRATAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. AFERIÇÃO DA



FIDEDIGNIDADE DA RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE *HABEAS CORPUS*. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA, APLICABILIDADE DA SÚMULA 594 DO STF. (2) COLHEITA DE PROVAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RATIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS EM INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. (3) INTERROGATÓRIO. NECESSIDADE DE REDESIGNAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 185. INEXISTÊNCIA. (4) AFASTAMENTO DO CARGO DE JUIZ. ART. 29 DA LOMAN. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (5) PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERTINÊNCIA. INDEFERIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. (6) INEXISTÊNCIA DO FATO. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APRECIACÕES VEDADAS EM SEDE DE *HABEAS CORPUS*. (...) 3. Inexiste nulidade no indeferimento de nova designação de interrogatório, quando o réu, intimado, deixa de atender ao chamado da Justiça, inteligência do art. 185 do Código de Processo Penal. (HC 82.661/RR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2008, DJe 25/8/2008.)

*HABEAS CORPUS*. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS PRESERVADA DURANTE A VOTAÇÃO DOS QUESITOS. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DAS PROVAS COLIGIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. A quebra da incomunicabilidade dos jurados é nulidade relativa, a qual, além de ser argüida em momento oportuno, deve, ao ser alegada, fazer-se acompanhada da comprovação do real prejuízo à defesa. *In casu*, consta da ata de julgamento que a advertência do magistrado de que os jurados não deveriam se comunicar foi realizada momentos após o julgamento do feito, porém antes do término da sessão, quando a votação dos quesitos havia sido concluída, o que em nada prejudicou a defesa.(...) (HC 36.678/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 2/8/2005, DJ 29/8/2005, p. 374.)

### QUESTÕES

- 1- MPE/PR (MPE/PR 2019 – adaptada)** Para decretação de nulidade, seja absoluta ou relativa, há necessidade de ter ocorrido prejuízo para a acusação ou para a defesa.
- 2- TJ/RJ (VUNESP 2016 – adaptada)** As nulidades processuais penais sofrem influência da instrumentalidade do processo, não se declarando qualquer tipo de nulidade se não verificado o prejuízo.
- 3- DPE/PE (Cespe/UnB 2015)** Nulidade ocorrida após a pronúncia deverá ser arguida na fase de especificação das provas que serão produzidas em plenário, sob pena de preclusão.
- 4- MPE/MS (MPE/MS 2013 – adaptada)** O Ministério Público não pode arguir a invalidade da citação, em razão da regra de que nenhuma das partes poderá arguir nulidade de formalidade cuja observância só a parte contrária interesse.
- 5- MPE/GO (MPE/GO 2019 – reaplicação/adaptada)** As nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes. Caso a nulidade ocorra na própria decisão de pronúncia, deve ser alegada em recurso em sentido estrito, a ser julgado pelo tribunal competente.
- 6- TJ/AL (FCC 2019 – adaptada)** Em tema de nulidades, correto afirmar que não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia.

### COMENTÁRIOS

- 1.** Gabarito: CORRETO. A jurisprudência do STJ "é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio *pas de nulité sans grief*, previsto no art. 563, do CPP". (AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.) (Grifos nossos.)

**2. Gabarito: CORRETO.** Os arts. 563 e 566 do CPP privilegiam o atingimento do resultado legalmente previsto para o ato, consagrando o princípio da instrumentalidade das formas. É dizer: a forma como o ato foi praticado deve sucumbir à sua finalidade, podendo o referido ato processual ser validado, ainda que não tenha obedecido à formalidade legalmente prevista. Ademais, seja no caso da nulidade absoluta, seja no caso da nulidade relativa, à luz do princípio do *pas de nullité sans grief*, somente há falar na declaração de nulidade se houver efetivo prejuízo à parte.

**3. Gabarito: ERRADO.** De acordo com o art. 571, inciso V, CPP, no rito do Tribunal do Júri, se a nulidade relativa ocorrer após a preclusão da sentença de pronúncia, deverá ser arguida imediatamente depois de anunciado o julgamento em plenário do júri e apregoadas as partes.

**4. Gabarito: ERRADO.** O princípio do interesse não se aplica ao Ministério Público, a quem compete, nos termos do art. 127 da CF/88, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, dentre eles o direito à liberdade de locomoção. Logo, pode o Ministério Público pleitear a absolvição do acusado (art. 385, CPP) e "o reconhecimento de nulidade relativa em favor da defesa, seja quando atua como parte (ação penal pública), seja quando atua como fiscal da lei (ação penal privada)" (LIMA, 2017, 1603). Portanto, é dado ao Ministério Público, por exemplo, pleitear o reconhecimento da nulidade de citação (nulidade absoluta) ou mesmo de nulidade relativa atinente à deficiência de defesa.

**5. Gabarito: CORRETO.** Conforme art. 571, inciso V, CPP, no rito do Tribunal do Júri, se a nulidade relativa ocorrer após a preclusão da sentença de pronúncia, deverá ser arguida imediatamente depois de anunciado o julgamento em plenário do júri e apregoadas as partes. Noutro giro, se a nulidade relativa tiver ocorrido na própria decisão de pronúncia, sua arguição deve ser feita no bojo do recurso em sentido estrito interposto contra ela, nos termos do art. 581, inciso IV, do CPP.

**6. Gabarito: CORRETO.** À luz da Súmula nº 366 do STF, "não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia".

## CAPÍTULO 23 – DOS RECURSOS CRIMINAIS (ARTS. 574 A 646, CPP)

### 1. TEORIA GERAL DOS RECURSOS (ARTS. 574 A 580, CPP)

#### 1.1. CONCEITO, FUNDAMENTOS E CARACTERÍSTICAS

Recurso pode ser definido como "o instrumento processual voluntário de impugnação de decisões judiciais, previsto em lei federal, utilizado antes da preclusão e na mesma relação jurídica processual, objetivando a reforma, a invalidação, a integração ou o esclarecimento da decisão judicial impugnada" (LIMA, 2020, p. 1729).

O fundamento basilar dos recursos é o duplo grau de jurisdição, que é uma "garantia individual, prevista implicitamente na Constituição Federal, voltada a assegurar que as decisões proferidas pelos órgãos de primeiro grau do Poder Judiciário não sejam únicas, mas, sim, submetidas a um juízo de reavaliação por instância superior" (NUCCI, 2016, p. 898).

Diante dos conceitos acima exarados e considerando o fato dos recursos estarem calcados no duplo grau de jurisdição, são eles dotados das seguintes características:

a) VOLUNTARIEDADE: "a existência de um recurso está condicionada à manifestação da vontade da parte, que demonstra seu interesse de recorrer com a interposição do recurso" (LIMA, 2020, p. 1729). É dizer: o reexame necessário, também chamado de recurso de ofício, que será visto adiante, em verdade, não tem natureza recursal, porquanto, como dito, o recurso é gravado pela voluntariedade (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 1330);

É importante frisar que a característica da voluntariedade dos recursos também se aplica ao Defensor Público ou dativo, isto é, mesmo os defensores não constituídos pelo réu não estão obrigados a recorrer<sup>27</sup>.

b) PREVISÃO LEGAL:

para que um recurso possa ser conhecido, é indispensável a análise do cabimento, compreendido pela doutrina como a previsão legal da existência do recurso. Portanto, se a lei não prevê recurso contra determinada decisão, significa dizer que tal decisão é irrecurável, o que, no entanto, não impede que a parte volte a questionar a matéria em preliminar de futura e eventual apelação, por meio de *habeas corpus* ou mandado de segurança (LIMA, 2020, p. 1729).

Exemplo: conforme visto no capítulo atinente aos incidentes processuais, não há recurso contra a decisão que indefere o incidente de insanidade mental do investigado ou acusado. Logo, por ausência de previsão legal, a parte prejudicada não tem nenhum recurso à sua disposição, contudo, poderá suscitar a nulidade do feito por ocasião da interposição de futura e eventual apelação;

c) ANTERIORIDADE À PRECLUSÃO OU À COISA JULGADA: "o recurso é interposto antes da formação da preclusão ou da coisa julgada" (LIMA, 2020, p. 1729); e

d) DESENVOLVIMENTO DENTRO DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL DE QUE EMANA A DECISÃO IMPUGNADA: "a interposição de um recurso não faz surgir uma nova relação jurídica processual. Na verdade, o que ocorre com a interposição de um recurso é o simples desdobramento da relação anterior, em regra perante órgão jurisdicional diverso e de hierarquia superior" (LIMA, 2020, p. 1729). Principalmente por essa última característica é que as ações autônomas de impugnação, como

<sup>27</sup> HC 153.909/RO, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 6/2/2012.

*habeas corpus*, revisão criminal e mandado de segurança, não se confundem com os recursos, já que elas inauguram uma nova relação jurídica processual (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 1330).

## 1.2. NATUREZA JURÍDICA

Em relação à natureza jurídica dos recursos, três correntes doutrinárias têm se debatido quanto ao ponto, a saber:

I) o recurso nada mais é do que um desdobramento ou uma decorrência do direito de ação, razão pela qual, ao ser interposto, o recurso se desenvolve em uma nova etapa da mesma ação (LIMA, 2020, p. 1730). É a corrente doutrinária que tem prevalecido;

II) o recurso é uma nova ação dentro do mesmo processo, isto é, a interposição recursal é o exercício de um novo direito de ação, incidentalmente em um mesmo processo (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 1330); e

III) o recurso é um meio adequado para se conseguir o reexame de uma decisão judicial, pouco importando se provocado pelas partes ou se determinado de ofício pelo juiz nos casos em que a legislação o obriga a adotar tal medida (LIMA, 2020, p. 1730).

## 1.3. PRINCÍPIOS ATINENTES

### 1.3.1. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

Como dito nas notas introdutórias, o fundamento basilar dos recursos é o duplo grau de jurisdição, isto é, "a possibilidade de um reexame integral (matéria de fato e de direito) da decisão do juízo *a quo*, a ser confiado a órgão jurisdicional diverso do que a proferiu e, em regra, de hierarquia superior na ordem judiciária" (LIMA, 2020, p. 1730).

Para a maioria da doutrina, o duplo grau de jurisdição não é uma garantia constitucional expressa, contudo, está inserido, de forma implícita, "na garantia do devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV) e no direito à ampla defesa (CF, art. 5º, inciso LV), com os meios e recursos a ela inerentes" (LIMA, 2020, p. 1731).

Desse modo, sendo uma garantia constitucional implícita, a regra é que haja a possibilidade do exercício do duplo grau de jurisdição. Contudo, algumas decisões não comportam recursos. Rememoremos alguns casos:

I) DENEGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE QUESTÃO PREJUDICIAL: quando ocorre a suspensão do processo, cabe recurso em sentido estrito (art. 581, inciso XVI, CPP). No entanto, se o juiz nega a suspensão, não há recurso legalmente previsto, (art. 93, §2º, CPP);

II) ADMISSÃO OU INADMISSÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: do despacho que admitir, ou não, o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão (art. 273, CPP);

III) IMPROCEDÊNCIA DAS EXCEÇÕES DE INCOMPETÊNCIA, LITISPENDÊNCIA, COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE DE PARTE: nos termos do art. 581, inciso II, do CPP, somente cabe recurso em sentido estrito da decisão que concluir pela incompetência do juízo, ou seja, se o juiz concluir pela competência (improcedência da exceção de incompetência), não cabe recurso. Ademais, nos termos do art. 581, inciso III, do CPP, somente cabe recurso em sentido estrito da decisão que julgar procedentes as exceções de litispendência, coisa julgada e ilegitimidade de parte. Isto é, se o juiz as julgar improcedentes, não há recurso;

IV) DECISÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: conforme o analisado art. 104 do CPP, se for arguida a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá, sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de três dias.

V) DECISÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DOS PERITOS, INTÉRPRETES, SERVENTUÁRIOS OU FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA: nos termos do estudado art. 105 do CPP, as partes poderão também arguir de suspeitos os peritos, os intérpretes e os serventuários ou funcionários de justiça, decidindo o juiz de plano e sem recurso, à vista da matéria alegada e prova imediata.

### 1.3.2. TAXATIVIDADE DOS RECURSOS

De acordo com o princípio da taxatividade, "para que seja possível o manejo de um recurso, é preciso que o ordenamento jurídico o preveja expressamente: o rol não é exemplificativo, porém *numerus clausus*", não se admitindo, no processo penal, "recurso inominado ou recurso de improviso. A previsão legal é condição necessária para que a decisão seja recorrível, e para que o recurso exista" (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 1334).

Todavia, apesar da taxatividade dos recursos,

não se pode concluir pela impossibilidade de interpretação extensiva da norma processual penal, nem tampouco pela inviabilidade de aplicação analógica, como expressamente admitido, aliás, pelo art. 3º do CPP. É exatamente o que ocorre, a título de exemplo, com as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, previstas no art. 581 do CPP. Há quem diga que não é possível a interpretação extensiva do referido rol. Na verdade, o que não se admite é a ampliação para casos em que a lei evidentemente quis excluir (LIMA, 2020, p. 1710).

### 1.3.3. UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES

De acordo com o princípio da unirrecorribilidade das decisões, também conhecido como unicidade ou singularidade recursal, "cada espécie de decisão judicial, em regra, comporta um único recurso, sendo ônus da parte escolher o recurso adequado para que haja seu reexame" (TÁVORA; ALENCAR, p. 1335). É dizer: pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, uma mesma parte, contra uma mesma decisão, em regra, somente poderá se valer de um único recurso.

Todavia, o princípio da unirrecorribilidade das decisões não impede que as duas partes da ação penal recorram da mesma decisão, desde que ambas as partes possuam interesse recursal. Exemplo: contra uma determinada sentença, o Ministério Público interpõe apelação, objetivando o aumento da pena-base. A Defesa, por sua vez, também interpõe apelação, com a finalidade de conseguir a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Ademais, tendo em vista que existem decisões objetivamente complexas, com capítulos distintos, a legislação processual admite o cabimento de dois ou mais recursos concomitantemente. Assim, como exceções ao princípio ora em análise, a doutrina costuma citar:

a) RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL: "desde que presentes fundamentos constitucionais e legais que autorizem as duas impugnações, incumbe à parte interpor, simultaneamente, ambos os recursos. Nesse caso, é bom lembrar que, na hipótese de o relator do recurso especial considerar que o recurso extraordinário é prejudicial daquele em decisão irrekorribil, sobrestará o seu julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal, para julgar o extraordinário (NCPC, art. 1.031, §2º). Porém, se o relator do recurso extraordinário, em decisão irrekorribil, rejeitar a prejudicialidade, devolverá os autos ao Superior Tribunal de Justiça, para o julgamento do recurso especial (NCPC, art. 1.031, §3º)" (LIMA, 2020, p. 1740); e

b) EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE E RECURSO EXTRAORDINÁRIO E/OU ESPECIAL: outra exceção citada pela doutrina é a interposição de "embargos infringentes e de nulidade contra a parte não unânime de decisão proferida pelos Tribunais de Justiça (ou TRF's) no julgamento de apelações,

recursos em sentido estrito e agravos em execução (CPP, art. 609, parágrafo único), e recurso extraordinário e/ou especial se houver fundamentos constitucionais e legais que autorizem tais impugnações" (LIMA, 2020, p. 1740).

#### 1.3.4. FUNGIBILIDADE RECURSAL ("TEORIA DO RECURSO INDIFERENTE", "TEORIA DO 'TANTO VALE'", PRINCÍPIO DA PERMUTABILIDADE DOS RECURSOS OU PRINCÍPIO DA CONVERSIBILIDADE DOS RECURSOS)

Pelo princípio da fungibilidade recursal, "não havendo erro manifesto ou má-fé na interposição de um recurso equivocado, e atendido o prazo limite do recurso que seria cabível, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro" (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 1336). É o que se extrai do art. 579, *caput*, do CPP, segundo o qual, salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Na visão da doutrina, a má-fé, que impede a aplicação do referido princípio, é presumida quando:

a) NÃO FOR OBSERVADO O PRAZO PREVISTO EM LEI PARA O RECURSO ADEQUADO: "caso a parte venha a interpor o recurso errado, porém o fazendo no prazo legal do recurso adequado, presume-se que agiu de boa-fé. Por outro lado, se, a título de exemplo, a parte sucumbente, diante da perda do prazo para eventual apelação — 5 (cinco) dias, nos termos do art. 593 do CPP —, interpor recurso extraordinário para tentar se beneficiar de seu prazo mais elástico — 15 (quinze) dias —, afigura-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto presumida sua má-fé" (LIMA, 2020, p. 1740); e

b) NÃO HOUVER ERRO GROSSEIRO: o erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, "é aquele que evidencia completa e injustificável ignorância da parte, isto é, havendo nítida indicação na lei quanto ao recurso cabível e nenhuma divergência doutrinária e jurisprudencial, torna-se absurdo o equívoco, justificando-se a sua rejeição" (NUCCI, 2016, p. 908). Assim, a *contrario sensu*, o erro grosseiro não se faz presente quando há discussão doutrinária e/ou jurisprudencial acerca de qual é o recurso cabível. Noutro giro, se não há dúvida alguma quanto ao recurso correto, restará configurado o erro grosseiro, que, como dito, impedirá a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Exemplo: no rito comum, nos termos do art. 581, inciso I, do CPP, contra a decisão que não receber a denúncia ou a queixa, caberá recurso em sentido estrito, não havendo nenhuma discussão quanto ao ponto. Se a parte, nesse caso, interpor apelação, ter-se-á consubstanciado um erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio em tela.

Nos termos do art. 579, *caput*, do CPP, se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Exemplo: a parte interpõe apelação contra determinada decisão de primeira instância. O Tribunal, todavia, entende que o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Nesse caso, considerando que o recurso em sentido estrito possibilita o juízo de retratação (art. 589, *caput*, CPP), deverá o Tribunal determinar a baixa dos autos ao juízo *a quo* para que verifique a possibilidade de se retratar. Isto é: no exemplo, o rito do recurso em sentido estrito deve ser observado.

#### 1.3.5. VOLUNTARIEDADE

Como visto na parte introdutória deste capítulo, os recursos são gravados pela característica da voluntariedade, isto é, o "recurso é um ato processual decorrente da manifestação de vontade da parte que queira ver reformada ou anulada uma decisão." (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 1333). Assim, a voluntariedade, ao mesmo tempo, é uma característica e um princípio atinente às espécies recursais.

Nos termos do art. 574, primeira parte, do CPP, os recursos são voluntários, isto é, trata-se o recurso de um ônus processual: "não há obrigatoriedade de recorrer, porém, se não exercida



essa faculdade, a parte sucumbente pode sofrer consequências a ela desfavoráveis" (TÁVOR; ALENCAR, 2017, p. 1333).

De mais a mais, apesar de a primeira parte do art. 574 do CPP dispor que os recursos são voluntários, a segunda parte do citado artigo aduz que, em algumas situações, os recursos "deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz", o que é chamado pela doutrina de recurso de ofício, recurso obrigatório, recurso necessário ou recurso anômalo, que somente é cabível contra decisões proferidas por juiz singular. Frise-se: não há falar em recurso de ofício contra decisões de órgãos judiciários colegiados, mesmo que proferidas em processos de competência originária dos Tribunais (LIMA, 2020, p. 1744).

Conforme já introduzimos, o recurso de ofício não é um recurso propriamente dito, porquanto lhe falta a característica da voluntariedade. Em verdade, o ideal é entender que o reexame necessário é condição imprescindível à preclusão ou ao trânsito em julgado de uma decisão ou sentença (LIMA, 2020, p. 1743-1744). Aliás, esse é teor da Súmula nº 423 do STF, segundo a qual "não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso *ex officio*, que se considera interposto *ex lege*".

Ainda remanescem na legislação processual penal as seguintes hipóteses de recurso de ofício:

I) SENTENÇA CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS (ART. 574, INCISO I, CPP): nos termos do art. 574, inciso I, do CPP, havendo a prolação de uma sentença concessiva de *habeas corpus*, deverá haver o seu reexame necessário. Dois detalhes se mostram importantes: a.1) apesar da necessidade de recurso de ofício, contra a sentença concessiva de *habeas corpus*, também caberá recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, inciso X, do CPP; e a.2) somente há falar em reexame necessário da sentença concessiva de *habeas corpus*. É dizer: se a sentença for do tipo denegatória, não haverá reexame necessário. Nesse caso, isto é, se a sentença denegar a ordem de *habeas corpus*, caberá recurso em sentido estrito (art. 581, inciso X, do CPP).

No caso de crimes federais, dispõe a Súmula nº 344 do STF que a "sentença de primeira instância concessiva de *habeas corpus*, em caso de crime praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, está sujeita a recurso *ex officio*".

O art. 574, inciso II, do CPP, diz que também haverá reexame de ofício da sentença que desde logo absolver o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, evitando sua submissão ao julgamento pelos Jurados (absolvição sumária no rito do Júri). Todavia, diante dos arts. 415 e 416 do CPP, com redação dada pela Lei nº 11.689/08, a doutrina e a jurisprudência entendem que tal hipótese restou revogada. É dizer: no rito do Júri, contra a absolvição sumária, somente caberá apelação (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 1333).

II) DECISÃO QUE CONCEDER A REABILITAÇÃO (ART. 746, CPP): "a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) não revogou o art. 746 do CPP, haja vista que os dispositivos referentes à reabilitação são plenamente compatíveis com a LEP" (LIMA, 2020, p. 1744);

III) ABSOLVIÇÃO DE ACUSADOS EM PROCESSOS POR CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR OU CONTRA A SAÚDE PÚBLICA (ART. 7º, PRIMEIRA PARTE, LEI Nº 1.521/51): de acordo com o citado dispositivo legal, os juízes recorrerão de ofício sempre que absolverem os acusados em processo por crime contra a economia popular ou contra a saúde pública. Frise-se: no caso de sentença condenatória, não há falar em reexame necessário.

Nos termos do art. 7º, segunda parte, da Lei nº 1.521/51, os juízes também recorrerão de ofício quando determinarem o arquivamento dos autos do respectivo inquérito policial. Todavia, diante da nova redação do art. 28, *caput*, do CPP, que, até o fechamento desta obra, está com a eficácia suspensa, o arquivamento do inquérito não mais se sujeita à homologação judicial. Por essa razão, caso não seja declarada a inconstitucionalidade do novo art. 28, *caput*, do CPP, a segunda

parte do art. 7º da Lei nº 1.521/51 estaria tacitamente revogada, porquanto o arquivamento se dará, exclusivamente, no âmbito do Ministério Público (LIMA, 2020, p. 1745).

IV) SENTENÇA CONCESSIVA DO MANDADO DE SEGURANÇA: "de acordo com o art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09, concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição" (LIMA, 2020, p. 1745).

Ainda em relação ao reexame necessário, é importante assentar que, nos termos da Súmula nº 160 do STF, "é nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício". Desse modo, a regra geral é que, em se tratando de recurso exclusivo da acusação, o Tribunal não poderá acolher, contra o réu, nulidade que não tenha sido alegada, ainda que do tipo absoluta. Contudo, nos casos de recurso de ofício, o Tribunal poderá reconhecer uma nulidade em prejuízo do réu, desde que a mácula existente seja do tipo absoluta. Nesse sentido: "Não pode o órgão julgador de segunda instância reconhecer, de ofício, nulidade não invocada no recurso da acusação, mesmo sendo ela de caráter absoluto (aplicação da Súmula nº 160 do STF), devendo ficar limitado à matéria impugnada pelo recorrente"<sup>28</sup>.

### 1.3.6. DISPONIBILIDADE

Assim como a parte é livre para recorrer ou não (voluntariedade), também lhe é dado o direito de desistir do recurso que haja interposto. É dizer: pelo princípio da disponibilidade, a parte pode abrir mão do recurso que outrora interpôs. Logo, ao contrário do que ocorre no princípio da voluntariedade, que tem incidência em momento anterior à interposição do recurso, o princípio da disponibilidade atua após a interposição recursal.

Quanto ao ponto, muita atenção deve ser dispensada ao art. 576 do CPP, segundo o qual o Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto, razão pela qual o princípio da disponibilidade não se aplica ao Ministério Público. É dizer: o Ministério Público não estava obrigado a recorrer (voluntariedade), contudo, caso tenha interposto um recurso, não poderá dele desistir.

### 1.3.7. NON REFORMATIO IN PEJUS (EFEITO PRODRÔMICO DA SENTENÇA)

Pelo princípio da vedação da "*reformatio in pejus*", pode-se dizer que, em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa — ou em virtude de *habeas corpus* impetrado em favor do acusado —, não se admite a reforma do julgado impugnado para piorar sua situação, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo, nem mesmo para corrigir eventual erro material" (LIMA, 2020, p. 1745). Frise-se: só há falar na vedação da *reformatio in pejus* no caso de recurso exclusivo da defesa. Se a acusação e a defesa recorrerem, a situação do réu poderá ser piorada pelo juízo *ad quem*.

Outro ponto que também deve ser bem fixado diz respeito ao fato de que a vedação da *reformatio in pejus* alcança meros erros materiais. É dizer: pela vedação da *reformatio in pejus*, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, o juízo *ad quem*, mesmo diante de simples erro material na decisão, não poderá piorar a situação do recorrente. Exemplo: na sentença, o juiz fixa a pena intermediária (2ª fase) em 6 anos e diz que, na 3ª fase, reconhece uma causa de aumento à razão de 1/6. Errando no cálculo, o juiz estabelece a pena definitiva em 6 anos e 6 meses. Ora, se a fração era de 1/6 e a pena intermediária de 6 anos, a pena definitiva deveria ser de 7 anos. Contudo, se somente a defesa recorrer, o Tribunal não poderá corrigir tal erro material.

<sup>28</sup> HC 73.180/SC, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2007, DJ 1º/10/2007, p. 313.

O conceito até aqui trabalhado se refere à chamada *non reformatio in pejus direta*, isto é, o juízo *ad quem*, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não poderá substituir a decisão inicial por uma que piore a situação do réu. É dizer: na denominada *non reformatio in pejus* direta, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, diferentemente do que ocorre na indireta, que será estudada abaixo, o juízo *ad quem*, em confronto direto com a decisão inicial, não poderá piorar a situação do recorrente.

É importante assentar que "a vedação da *reformatio in pejus* não está restrita à *quantidade final de pena*, porquanto não se trata de mero cálculo aritmético, mas sim de efetiva valoração da conduta levada a efeito pelo sentenciado". Exemplo: se, no acórdão, o Tribunal, ao analisar recurso exclusivo da defesa, afasta uma qualificadora do furto e reconhece uma causa de aumento, ainda que a pena final seja diminuída, haverá *reformatio in pejus* (LIMA, 2020, p. 1747).

Conforme dito no capítulo anterior, nos chamados recursos de ofício, não incide a vedação da *reformatio in pejus*, podendo, inclusive, ser acolhida, contra o réu, nulidade do tipo absoluta (Súmula nº 160 do STF).

### 1.3.7.1 NON REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA

Pela vedação da "'*reformatio in pejus*' indireta, se a sentença impugnada for anulada em recurso exclusivo da defesa (ou em *habeas corpus*), o juiz que vier a proferir nova decisão em substituição à anulada também ficará vinculado ao máximo da pena imposta no primeiro *decisum*, não podendo agravar a situação do acusado" (LIMA, 2020, p. 1748).

Novamente, frise-se: só há falar na vedação da *reformatio in pejus* indireta se o recurso que originou a anulação da sentença foi exclusivo da defesa. Exemplo de aplicação da vedação da *reformatio in pejus* indireta: na sentença, o juiz condena o réu a uma pena de 6 anos. O Tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, anula aquela sentença. O juízo *a quo*, ao proferir nova sentença, estará limitado pelo patamar de 6 anos. Exemplo de não incidência da vedação da *reformatio in pejus* indireta: na sentença, o juiz condena o réu a uma pena de 4 anos. A acusação e a defesa recorrem. O Tribunal, ao analisar os recursos, anula a sentença. Nesse caso, o juízo *a quo*, ao proferir nova sentença, não estará limitado ao patamar de 4 anos, já que o recurso que deu origem à anulação não era exclusivo da defesa.

Como se vê, na *reformatio in pejus* indireta, houve uma decisão judicial anterior, a qual, em recurso exclusivo da defesa, foi anulada pelo juízo *ad quem*. Nesse caso, o juízo *a quo* ficará adstrito à pena que havia sido imposta na sentença anulada, daí advindo o nome indireta, já que o juízo *a quo* está vinculado a algo que não mais existe, mas que, indiretamente, ainda produzirá o efeito de limitar a nova sentença.

De mais a mais, convém ressaltar que, nos termos do art. 617 do CPP, é cabível a *emendatio libelli* na segunda instância, desde que, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, a pena imposta não seja agravada. Assim, é possível que o Tribunal, Câmara ou Turma, sem modificarem a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, atribuam-lhe nova definição jurídica, contudo, se for recurso exclusivo da defesa, diante da vedação da *reformatio in pejus*, a pena não poderá ser agravada.

Noutro giro, nos termos da Súmula nº 453 do STF, na segunda instância, não se aplica o instituto da *mutatio libelli*, que possibilita ao julgador dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa. Em resumo, na 2ª instância: I) é permitida a *emendatio libelli*, desde que, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, a pena não seja agravada; e II) não é permitida a *mutatio libelli*.

### 1.3.8. REFORMATIO IN MELLIUS

Como estudado acima, vigora, no processo penal, "em relação ao recurso da defesa, o sistema da proibição da *reformatio in pejus*, ou seja, não se admite que a situação do acusado seja piorada em virtude do julgamento do seu próprio recurso" (LIMA, 2020, p. 1751).



Todavia, "quanto ao recurso da acusação, a despeito de não haver consenso na doutrina, prevalece o entendimento de que se aplica o sistema do benefício comum, isto é, do recurso interposto pelo Ministério Público, querelante ou assistente da acusação, pode resultar benefício à parte contrária, leia-se, ao acusado" (LIMA, 2020, p. 1751). Nesse sentido: "Esta Corte firmou compreensão no sentido de que é admitida a *reformatio in melius*, em sede de recurso exclusivo da acusação, sendo vedada somente a *reformatio in pejus*"<sup>29</sup>.

#### 1.4. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS (JUÍZO DE PRELIBAÇÃO)

Todas as espécies recursais, sem exceção, estão sujeitas ao juízo de prelibação, "que consiste na verificação da presença dos pressupostos recursais de admissibilidade" (AVENA, 2017, p. 794). É dizer: todos os recursos devem se submeter ao juízo de prelibação, o que pode variar de um recurso para outro é a quantidade de verificações.

A maioria das espécies recursais "possui duas verificações – uma realizada no juízo *a quo*, outra no juízo *ad quem*, a exemplo da apelação, do recurso em sentido estrito, do agravo em execução, entre tantos outros. Nestes casos, ainda que julgado admissível o recurso no juízo *a quo*, nada impede seja considerado inadmissível no juízo *ad quem*" (AVENA, 2017, p. 794).

Todavia, há espécies recursais "que possuem prelibação apenas em um grau de jurisdição. É o caso da carta testemunhável, que tem sua admissibilidade examinada tão somente em segundo grau, razão pela qual, ainda que intempestiva ou descabida, mesmo assim deverá ser encaminhada ao Tribunal competente, que decidirá pelo seu conhecimento ou não. O mesmo ocorre com os embargos declaratórios, os quais, opostos contra sentença (art. 382 do CPP) ou contra acórdão (art. 619 do CPP), são acolhidos ou desacolhidos pelo próprio órgão prolator da decisão" (AVENA, 2017, p. 794-795).

Caso o recurso de apelação, em sede de juízo de prelibação, não seja admitido pelo juízo *a quo*, deverá a parte interessada interpor recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, inciso XV, do CPP. Em se tratando de qualquer outro recurso, contra a decisão que o inadmitir caberá carta testemunhável, nos moldes do art. 639, inciso I, do CPP. Se a parte que viu seu recurso inadmitido não interpor novo recurso, restará preclusa a via recursal (LIMA, 2020, p. 1758-1759).

Os pressupostos recursais, que, como dito, serão analisados no juízo de prelibação, são de duas ordens (AVENA, 2017, p. 795):

I) PRESSUPOSTOS RECURSAIS OBJETIVOS: a) cabimento do recurso; b) tempestividade da interposição; c) forma legal; e d) preparo; e

II) PRESSUPOSTOS RECURSAIS SUBJETIVOS: a) legitimidade para recorrer; e b) interesse na interposição.

Para que haja a admissibilidade do recurso interposto, todos os pressupostos recursais deverão se fazer presente, sob pena de um juízo negativo de prelibação.

##### 1.4.1. PRESSUPOSTOS RECURSAIS OBJETIVOS

###### 1.4.1.1. CABIMENTO DO RECURSO

O primeiro pressuposto recursal objetivo é o cabimento, o qual envolve a análise conjugada de duas condições: a recorribilidade e a adequação (AVENA, 2017, p. 796).

<sup>29</sup>REsp 628.971/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 16/3/2010, DJe 12/4/2010.

#### 1.4.1.1.1. RECORRIBILIDADE

Por recorribilidade, deve ser entendida a situação na qual a decisão proferida desafia recurso (AVENA, 2017, p. 796). Conforme estudamos neste capítulo, no tópico atinente ao duplo grau de jurisdição, há várias decisões judiciais irrecorríveis, isto é, que não desafiam recursos. Exemplo: a parte interpõe RESE (recurso em sentido estrito) contra decisão que admitiu assistente de acusação, que, como visto, não admite recurso. Nesse caso, o recurso interposto não passará pelo juízo de prelibação, porquanto não preenchido o pressuposto recursal objetivo da recorribilidade.

#### 1.4.1.1.2. ADEQUAÇÃO

A adequação deve ser compreendida "como a utilização da via impugnativa correta para se insurgir contra a decisão" (LIMA, 2020, p. 1761). É dizer: dentre as várias espécies de decisões judiciais e de recursos existentes, a parte, caso queira combater um pronunciamento judicial recorrível, deve se utilizar do recurso especialmente desenhado para desafiar aquela decisão.

Nos termos do estudado art. 579 do CPP, o pressuposto objetivo da adequação é mitigado pelo princípio da fungibilidade, o qual, como visto, admite que um recurso considerado inadequado seja processado como se fosse adequado, desde que não haja má-fé do recorrente.

#### 1.4.1.2. TEMPESTIVIDADE NA INTERPOSIÇÃO

Tempestividade nada mais é do que a interposição do recurso dentro do prazo legal, sob pena de preclusão temporal. É dizer: a parte, caso queira desafiar um pronunciamento judicial, tem um prazo para fazê-lo. Caso não o faça, perderá o direito à via recursal.

Com o advento do novo Código de Processo Civil, restou superada a discussão que havia sobre a tempestividade ou não do recurso interposto antes do início do prazo recursal. Nos termos do art. 218, §4º, do CPC, será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo, razão pela qual, "à luz dos princípios da celeridade, da razoabilidade e do amplo acesso à Justiça, não se pode admitir o reconhecimento da intempestividade do denominado recurso prematuro" (LIMA, 2020, p. 1761).

Por esse motivo, o STJ, na sessão de 1º de julho de 2016, cancelou a sua Súmula nº 418, a qual dizia que "é inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação". Por sua vez, o STF já possui precedente no sentido de que não é extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do acórdão<sup>30</sup>.

Logicamente, nos termos do art. 575 do CPP, não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo. No mesmo sentido, a Súmula nº 428 do STF dispõe que "não fica prejudicada a apelação entregue em cartório no prazo legal, embora despachada tardiamente".

#### 1.4.1.2.1. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL

Conforme art. 798, *caput*, do CPP, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado, salvo nos casos de impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária, nos termos do art. 798, §4º, CPP. No ponto, é importante frisar que ainda existem os chamados recessos forenses, que suspendem os prazos recursais.

<sup>30</sup>HC 113826, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 10/4/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-108 DIVULG 30/5/2018 PUBLIC 19/6/2018.





De acordo com o art. 61, inciso I, da Lei nº 5.010/66, além dos fixados em lei, serão feriados na Justiça Federal, inclusive nos Tribunais Superiores, os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, inclusive.

No âmbito dos Tribunais de Justiça dos Estados, a Resolução nº 244, de 12 de setembro de 2016, do CNJ, em seu art. 1º, *caput*, diz que os Tribunais de Justiça dos Estados poderão suspender o expediente forense, configurando o recesso judiciário no período de 20 de dezembro a 6 de janeiro, garantindo atendimento aos casos urgentes, novos ou em curso, por meio de sistema de plantões. Nos termos do art. 2º, *caput*, da referida resolução, o recesso judiciário importará em suspensão dos prazos processuais.

Ademais, apesar de o novo CPC ter previsto que, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis (art. 219, *caput*, CPC/15), tal dispositivo não se aplica ao direito processual penal. É dizer: no processo penal, o prazo continua sendo contado de forma contínua e, uma vez iniciado, em regra não se interromperá<sup>31</sup>. Frise-se: a regra da contagem somente dos dias úteis (CPC/15) não se aplica ao processo penal.

Na contagem dos prazos, não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento, conforme §1º do art. 798 do CPP. Caso o prazo termine em dia sem expediente forense, considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato, nos termos do §3º.

À luz do §5º, poderão funcionar como dia do começo, que, como dito, deve ser excluído da contagem, os seguintes marcos: a) data de intimação; b) dia da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte; e c) dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho.

Caso a intimação tenha se dado de forma pessoal, deve ser rememorado que, nos termos da Súmula nº 710 do STF, "no processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem".

Ademais, "quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir" (Súmula nº 310 do STF).

Se a intimação se der por diário de justiça eletrônico, o dia da intimação, que, repita-se, deve ser excluído, se dará no primeiro dia útil subsequente à data da publicação, e não a partir do momento em que a decisão se tornou pública, nos termos do art. 4º, §4º, da Lei nº 11.419/06<sup>32</sup>. Exemplo: se a publicação no diário de justiça eletrônico de deu no dia 22 de abril de 2020 (quarta-feira), será considerado como dia da intimação a data de 23 de abril de 2020 (quinta-feira), porquanto não é feriado forense. O primeiro dia que, de fato, o prazo estará correndo é o dia 24 de abril de 2020 (sexta-feira). Se for um prazo de cinco dias, terminará em 28 de abril de 2020 (terça-feira), que também não é feriado. Nesse caso, os 5 dias foram: 24, 25, 26, 27 e 28 de abril de 2020.

#### 1.4.1.2.2. INÍCIO DO PRAZO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA

A Defensoria Pública, nos termos da Lei Complementar nº 80/94, goza da prerrogativa da intimação pessoal de seus membros e da contagem em dobro dos prazos. Frise-se: mesmo no processo penal, a Defensoria Pública tem prazo em dobro para recorrer.

No que diz respeito à intimação pessoal, especial atenção deve ser dada ao fato de que, no caso do Defensor Público, ainda que este tenha sido intimado pessoalmente em audiência (art. 798, §5º, alínea b, do CPP) ou por certidão cartorial (art. 798, §5º, alínea c, do CPP), o início da contagem do prazo somente ocorrerá com a efetiva entrada dos autos na repartição administrativa

<sup>31</sup> AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017.

<sup>32</sup> MS 16.180/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/10/2011, DJe 1º/2/2012.



da Defensoria Pública. É dizer: para a Defensoria Pública, não se confundem a "intimação do ato" e o "início da contagem do prazo"<sup>33</sup>.

Assim, no caso da Defensoria Pública, pouco importa se houve ou não a intimação pessoal do membro em audiência ou no cartório, o prazo somente terá início quando da remessa dos autos à Instituição.

#### 1.4.1.2.3. INÍCIO DO PRAZO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público, nos termos da Lei nº 8.625/93, também goza da prerrogativa da intimação pessoal, contudo, não há prazo em dobro para o *Parquet*. Frise-se: diferentemente do ocorre com a Defensoria Pública, no processo penal, o Ministério Público não goza de prazo em dobro.

De mais a mais, assim como ocorre em relação à Defensoria Pública, o prazo do Ministério Público se iniciará do dia em que formalizada a entrega dos autos no setor administrativo do *Parquet*. É dizer: entrou no Ministério Público, o dia do começo ocorreu, pouco importando quando aqueles autos chegarão, de fato, ao membro responsável por aquele processo<sup>34</sup>.

Também de forma semelhante à Defensoria Pública, o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado<sup>35</sup>. Em resumo:

|                    | DEFENSORIA PÚBLICA                                                                                                                                                      | MINISTÉRIO PÚBLICO                                                                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTIMAÇÃO PESSOAL? | Sim                                                                                                                                                                     | Sim                                                                                                                                                                     |
| PRAZO EM DOBRO?    | Sim                                                                                                                                                                     | Não                                                                                                                                                                     |
| DIA DO COMEÇO      | Entrada dos autos na repartição administrativa da Defensoria Pública, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado. | Entrada dos autos na repartição administrativa do Ministério Público, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado. |

#### 1.4.1.2.4. PRAZO PARA RAZÕES

O pressuposto processual objetivo da tempestividade diz respeito à interposição do recurso e não à apresentação das razões. É dizer: no juízo de prelibação, será analisada se a interposição foi tempestiva, pouco importando se a apresentação das razões recursais se deu fora do prazo legal. Nesse sentido: "A apresentação extemporânea das razões recursais pela parte, mesmo acusadora, não tem o condão de prejudicar recurso em sentido estrito tempestivamente interposto"<sup>36</sup>.

<sup>33</sup> STJ. HC 296.759-RS. Terceira Seção. Min. Rogério Schietti Cruz. Julgado em 23/8/2017.

<sup>34</sup> STF, Pleno, HC 83.255/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 12/3/2004.

<sup>35</sup> STJ. 3ª Seção. REsp 1 349.935-SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 23/8/2017 (recurso repetitivo) (Info 611).

<sup>36</sup> HC 365.333/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017.

#### 1.4.1.3. FORMA LEGAL

Nos termos do art. 578 do CPP, o recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. Caso o réu não saiba ou não possa assinar seu nome, o termo será assinado por alguém, a seu rogo, na presença de duas testemunhas (art. 578, §1º, CPP).

De acordo com a doutrina,

a expressão 'por termo' nos autos deve ser compreendida como a manifestação inequívoca da parte quanto à intenção de recorrer, como ocorre, por exemplo, quando o recorrente se dirige ao Diretor de Secretaria (ou escrivão) e diz que pretende recorrer, no que o servidor lavra um termo nos autos para documentar a interposição oral do recurso (LIMA, 2020, p. 1775).

Apesar de o art. 578, *caput*, do CPP ter sido genérico, apenas os recursos que não exigem a apresentação simultânea da interposição e das razões é que podem ser apresentados por termo nos autos. É dizer: todos os recursos podem ser interpostos por petição, contudo, somente alguns podem ser interpostos por termo nos autos (inequívoca vontade de recorrer). Os que permitem a interposição por termo nos autos são (AVENA, 2017, p. 801):

I) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: interposição em cinco dias e posterior intimação para a apresentação das razões em dois dias (art. 586 c/c o art. 588 do CPP);

II) APELAÇÃO: interposição em cinco dias e posterior intimação para a apresentação das razões em oito dias (art. 593 c/c o art. 600 do CPP). Ressalve-se, aqui, a apelação em sede de Juizado Especial Criminal, pois, neste caso, o art. 82 da Lei nº 9.099/1995 prevê expressamente que a interposição deva ser feita, unicamente, por petição escrita, sendo que as razões já devem ser apresentadas no mesmo ato;

III) AGRAVO EM EXECUÇÃO: interposição em cinco dias e posterior intimação para a apresentação das razões em dois dias (por analogia ao recurso em sentido estrito, já que a Lei de Execução Penal não prevê forma e rito autônomos para esse recurso); e

IV) CARTA TESTEMUNHÁVEL: requerimento em 48 horas e posterior intimação para a apresentação das razões no mesmo prazo das razões do recurso denegado ou não encaminhado à instância superior (art. 640 c/c o art. 643 do CPP).

Também é interessante assentar que, no Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 83, §1º, da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Frise-se: no JECrim, os embargos de declaração podem ser opostos oralmente.

#### 1.4.1.4. PREPARO

Conforme art. 806, §2º, do CPP, a falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará em deserção do recurso interposto, o que somente se aplica ao querelante na ação penal privada comum ou personalíssima (AVENA, 2017, p. 802).

Nesse contexto, no que diz respeito a ambos os polos da demanda, a regra da deserção por falta de preparo não se aplica à ação penal pública e à ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública. Nesses casos, o polo passivo (réu) somente deverá pagar as custas após o trânsito em julgado de eventual condenação. Por sua vez, o polo ativo (Ministério Público ou querelante) não paga custas processuais (AVENA, 2017, p. 802).

Em relação à ação penal de iniciativa privada comum ou personalíssima, tal regramento não se aplica ao querelado, já que, assim como ocorre na ação penal pública ou privada subsidiária

da pública, o réu somente deverá pagar as custas após o trânsito em julgado de eventual condenação. É dizer: diferentemente do que ocorre em relação ao querelante, o querelado, na ação penal privada comum ou personalíssima, para recorrer, não é obrigado a pagar custas processuais (AVENA, 2017, p. 802).

#### 1.4.2. PRESSUPOSTOS RECURSAIS SUBJETIVOS

##### 1.4.2.1. LEGITIMIDADE

Nos termos do art. 577, *caput*, do CPP, o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor, o que é chamado pela doutrina de legitimados gerais, isto é, "sujeitos processuais que podem ingressar com qualquer recurso entre os previstos em lei" (LIMA, 2020, p. 1776).

Para além deles, em alguns recursos específicos, há outros legitimados, como ocorre, por exemplo, com o assistente de acusação, que será analisado em tópico próprio.

##### 1.4.2.1.1. LEGITIMIDADE DO RÉU

Conforme visto, o art. 577, *caput*, do CPP, possibilita ao réu, por força própria, isto é, mesmo desacompanhado de advogado, interpor recursos, o que, todavia, não se confunde com a possibilidade de arrazoa-los, que se trata de ato privativo de advogado.

Logo, o réu, em regra, tem capacidade postulatória autônoma para interpor recursos, contudo, caso não seja advogado, não poderá apresentar as razões recursais.

Em decorrência disso, pode se concluir que o réu, desacompanhado de advogado, somente poderá interpor os recursos que não exijam a apresentação simultânea da interposição e das razões, os quais foram vistos em tópico acima. Exemplo: como a apelação possibilita a apresentação das razões em momento posterior à interposição, o réu, por força própria, isto é, mesmo desacompanhado de advogado, poderá interpô-la. Nesse caso, o juiz, após receber a apelação interposta, abrirá prazo para que a defesa técnica apresente as razões recursais.

Noutro giro, a *contrario sensu*, se o recurso exige a apresentação simultânea da interposição e das razões, o réu não poderá interpor tal espécie recursal pessoalmente, o que deverá ser feito pela defesa técnica. Exemplo: nos termos do art. 1.029, *caput*, do CPP, o recurso extraordinário e o recurso especial exigem a apresentação simultânea da interposição e das razões. Logo, ao réu pessoalmente não é dada a interposição dessas espécies recursais, salvo, por óbvio, se o réu for advogado.

Ainda em relação à legitimidade do réu, tema muito cobrado em provas concursais diz respeito à Súmula nº 705 do STF, segundo a qual "a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta".

Pelo teor da súmula, se o réu, desacompanhado de advogado, renuncia ao direito de apelação, não restará impedido o conhecimento da apelação interposta por advogado. O contrário também é verdadeiro: se a defesa técnica renuncia ao direito de apelação e o réu manifesta interesse em recorrer, a apelação também deverá ser recebida. É dizer: prevalece a vontade de quem quer recorrer.

##### 1.4.2.1.2. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

Como visto acima, o assistente de acusação, que não é parte principal do processo penal, não consta do rol do art. 577, *caput*, do CPP, que trata dos sujeitos processuais que podem ingressar com qualquer recurso entre os previstos em lei (legitimados gerais).

Todavia, apesar de não constar do rol de legitimados gerais, o assistente do Ministério Público tem legitimidade para interpor recursos, desde que preenchidas determinadas condições, razão pela qual sua legitimidade é restrita e subsidiária (supletiva).

Diz-se que a legitimidade do assistente do Ministério Público é restrita, porquanto limitada a determinadas espécies recursais.

Nesse contexto, pela redação dos arts. 598, *caput*, 584, §1º, 416 e 581, inciso VIII, todos do CPP, o assistente de acusação somente poderia:

I) apelar da sentença absolutória (atualmente, entende-se que o assistente também poderá apelar da sentença condenatória e da sentença de absolvição sumária, conforme será visto mais à frente);

II) apelar da sentença de impronúncia (atualmente, entende-se que o assistente também poderá recorrer em sentido estrito da sentença de pronúncia, conforme será visto adiante); e

III) recorrer em sentido estrito da decisão que julgar extinta a punibilidade.

Nos termos da Súmula nº 210 do STF, se, como desdobramento dos recursos acima citados, o assistente tiver a necessidade de lançar mão de recursos diversos, inclusive para os Tribunais Superiores, a ele será dada tal prerrogativa. Exemplo: diante da inércia do Ministério Público (legitimidade subsidiária ou supletiva), o assistente de acusação interpõe recurso de apelação contra sentença absolutória. Todavia, em juízo de prelibação, apesar do preenchimento de todos os pressupostos processuais, o juiz *a quo* denega seguimento ao recurso interposto. Nesse caso, o assistente de acusação poderá se valer do recurso em sentido estrito (art. 581, inciso VI, do CPP), já que essa necessidade nasceu da denegação da apelação anteriormente por ele interposta. Caso o RESE também seja denegado, poderá o assistente do Ministério Público interpor carta testemunhável (art. 639, inciso I, do CPP). No exemplo, apesar de a lei não prever legitimidade recursal ao assistente de acusação em relação àquelas hipóteses, caso ele não tivesse essas possibilidades, em verdade, "estar-se-ia, indiretamente, negando a própria possibilidade de apelar contra a impronúncia e absolvição ou de interpor RESE contra a extinção da punibilidade, pois bastaria que o juiz denegasse tais recursos e nada poderia ser feito pelo assistente" (LIMA, 2020, p. 1179).

De mais a mais, apesar da previsão legal acima exposta, a doutrina e a jurisprudência têm alargado o rol de possibilidade recursal do assistente do Ministério Público, merecendo destaque os seguintes entendimentos:

I) STJ: não havendo recurso do Ministério Público (legitimidade subsidiária ou supletiva), o assistente de acusação tem legitimidade para apelar da sentença condenatória, objetivando o aumento da pena imposta, e da sentença de absolvição parcial (LIMA, 2020, p. 1779);

II) STF: não havendo recurso do Ministério Público (legitimidade subsidiária ou supletiva), com o fim de obter o reconhecimento de uma qualificadora do crime de homicídio, o assistente de acusação tem legitimidade para recorrer em sentido estrito da sentença de pronúncia (LIMA, 2020, p. 1779); e

III) DOCTRINA: se o próprio Código, no art. 598, *caput*, do CPP, permite que o assistente de acusação, ao final do procedimento, apele da sentença absolutória, também deverá ser outorgada ao assistente do Ministério Público a legitimidade para apelar da sentença de absolvição sumária, seja no âmbito do procedimento comum (art. 397, CPP), seja no rito do Tribunal do Júri (art. 415, CPP) (LIMA, 2020, p. 1780).

A legitimidade do assistente de acusação também é dita subsidiária ou supletiva, porquanto, "mesmo nas hipóteses em que pode se insurgir contra a decisão do juízo *a quo*, encontra-se ele condicionado à circunstância de o Ministério Público não recorrer contra tal decisão" (LIMA,

2020, p. 1780). É dizer: se o Ministério Público recorrer, o assistente de acusação, em regra, não poderá recorrer.

Dissemos em regra, porquanto, caso o recurso do Ministério Público seja parcial, isto é, não abranja todas as questões debatidas no processo, o assistente de acusação poderá recorrer da parte que o Ministério Público não tratou. Nesse sentido: "O assistente de acusação tem legitimidade para recorrer quando o Ministério Público abster-se de fazê-lo, como na hipótese dos autos, ou ainda, quando o seu recurso for parcial, não abrangendo a totalidade das questões discutidas. Precedentes desta Corte"<sup>37</sup>

Caso o Ministério Público recorra de todas as questões do processo (recurso total), o assistente de acusação somente poderá arrazoar o recurso interposto pelo *Parquet*, nos termos do art. 271, *caput*, CPP. Logo, nesse caso, o recurso contará com duas razões recursais: uma do Ministério Público e uma do assistente de acusação (LIMA, 2020, p. 1780). O prazo para o assistente de acusação arrazoar o recurso do *Parquet* é de 3 dias, após o Ministério Público (art. 600, §1º, do CPP).

Ainda em relação ao assistente, deve ser registrado que, para fins de interposição recursal, não se exige prévia habilitação.

Desse modo, "em se tratando de recursos, não há necessidade de habilitação prévia, valendo a própria petição de interposição do recurso como pedido implícito de habilitação. Nesse caso, a petição de interposição deve estar instruída com a prova de que se trata o assistente de uma das pessoas listadas no art. 268 do CPP, ou seja, ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, cônjuge (ou companheiro), ascendente, descendente, ou irmão" (LIMA, 2020, p. 1781).

Noutro giro, em que pese, para fins recursais, não se exija habilitação prévia, tal questão influenciará, de forma direta, no prazo recursal concedido ao assistente de acusação.

Quanto ao ponto, primeiramente, deve ser fixado que o prazo do assistente de acusação, em regra, somente começa a fluir após o esgotamento do prazo do Ministério Público, já que a legitimidade do assistente é supletiva ou subsidiária.

Assim sendo, se o assistente de acusação só poderá recorrer se o Ministério Público não recorrer, por óbvio, devemos esperar o esgotamento do prazo do Ministério Público. Aliás, esse é o teor da Súmula nº 448 do STF: "O prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público".

Esse raciocínio, contudo, não se aplica ao caso em que a intimação do ofendido se operou após o esgotamento do prazo recursal do Ministério Público, hipótese na qual o prazo da vítima somente começará a correr do dia de sua intimação, e não do esgotamento do prazo do *Parquet*. Elucida-se: I) se a intimação da vítima ocorreu dentro do prazo recursal do Ministério Público, seu prazo começará a correr logo após o esgotamento do prazo do *Parquet*; e II) se a vítima foi intimada após o esgotamento do prazo recursal do Ministério Público, seu prazo somente começará a contar do dia de sua intimação.

Em relação ao prazo em si, caso haja habilitação prévia, isto é, caso a vítima já havia se habilitado como assistente de acusação, seu prazo recursal será de 5 (cinco) dias, já que esse é o prazo de interposição da apelação e do RESE. Exemplo: se o assistente de acusação, que já estava habilitado, pretende apelar da sentença absolutória, seu prazo será de 5 (cinco) dias para interposição e 8 (oito) dias para razões.

Todavia, caso não tenha havido a habilitação prévia, o prazo será de 15 (quinze) dias para interposição, nos termos do art. 598, parágrafo único, do CPP. Exemplo: caso a vítima, que não havia se habilitado previamente, pretenda recorrer em sentido estrito da decisão que decretou a extinção da punibilidade do agente, terá o prazo de 15 (quinze) dias.

<sup>37</sup> REsp 828.418/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/3/2007, DJ 23/4/2007, p. 304.

#### 1.4.2.2. INTERESSE EM RECORRER

Nos termos do art. 577, *caput*, do CPP, não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão, o que é chamado pela doutrina de interesse recursal. É dizer: "a parte somente poderá provocar o reexame da matéria já decidida por determinado órgão, remetendo o feito à instância superior, quando eventual modificação da decisão lhe trouxer algum tipo de benefício. Recorrer por recorrer é algo inútil, constitutivo de obstáculo à economia processual, além do que o Judiciário é voltado à solução de conflitos e não simplesmente a proferir consultas ou esclarecer questões puramente acadêmicas" (NUCCI, 2016, p. 904).

Em relação ao interesse recursal, algumas questões merecem destaque. Vejamo-nas em separado.

##### 1.4.2.2.1. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E INTERESSE RECURSAL DEFENSIVO

No que diz respeito à sentença absolutória, a doutrina é bem tranquila ao afirmar que o réu tem interesse recursal em relação à chamada sentença absolutória imprópria, a qual lhe aplica uma medida de segurança. É dizer: tendo a sentença imposto ao réu uma medida de segurança, é evidente que ele tem interesse em modificar tal situação, alcançando, por exemplo, uma absolvição própria, a qual lhe desobrigará dos consectários atinentes às medidas de segurança.

Em relação à sentença absolutória própria, deve ser rememorado que, em determinadas situações, tal pronunciamento judicial não interferirá no juízo cível, daí advindo o interesse recursal do absolvido em modificar os fundamentos da sentença. Exemplo: o réu, que foi absolvido por insuficiência de provas, tem interesse em modificar o fundamento de sua absolvição para inexistência do fato, nos termos do art. 386, inciso I, do CPP, já que esta última fundamentação tem o condão de afastar a possibilidade de responsabilidade civil.

Assim, em resumo, pode-se concluir que o réu tem interesse recursal em relação à sentença absolutória imprópria e à modificação do fundamento de sua absolvição própria.

##### 1.4.2.2.2. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E INTERESSE RECURSAL DEFENSIVO NO JULGAMENTO DO MÉRITO

Calcada principalmente na Súmula nº 18 do STJ, a jurisprudência entende que não há interesse recursal da defesa em relação à declaração da extinção da punibilidade do réu. É dizer: diferentemente do que ocorre em outros ordenamentos jurídicos, extinta a sua punibilidade, o réu não poderá buscar o reconhecimento de sua inocência, mesmo que a declaração da extinção da punibilidade se dê durante o tramitar recursal (LIMA, 2020, p. 1783).

Portanto, "é firme o entendimento jurisprudencial segundo o qual, consumando-se o lapso prescricional (v.g., prescrição subsequente ou superveniente), ainda que na pendência de recurso interposto pela defesa (v.g., recurso especial), deve-se declarar, preliminarmente, a extinção da punibilidade, com prejuízo do exame do mérito da causa. Isso porque, uma vez declarada extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, mostra-se patente a falta de interesse do recorrente em obter a absolvição em face de, por exemplo, suposta atipicidade da conduta, em razão dos amplos efeitos do reconhecimento deste instituto" (LIMA, 2020, p. 1783).

##### 1.4.2.2.3. MINISTÉRIO PÚBLICO E AÇÃO PENAL PRIVADA COMUM OU PERSONALÍSSIMA

Na ação penal privada comum ou personalíssima, o Ministério Público poderá recorrer da sentença condenatória, buscando a absolvição do querelado ou, inclusive, o aumento de sua pena (LIMA, 2020, p. 1784-1785).

Todavia, se, na ação penal privada comum ou personalíssima, for proferida sentença absolutória, em razão da disponibilidade que rege tais espécies de ação, o Ministério Público não poderá recorrer da decisão prolatada (LIMA, 2020, p. 1784-1785).



#### 1.4.2.2.4. MINISTÉRIO PÚBLICO E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO

Imagine a seguinte situação: o Ministério Público, nas alegações finais, requer a absolvição do denunciado. O juiz, todavia, o condena. Nesse caso, a situação é simples: o Ministério Público tem interesse recursal e poderá recorrer.

Entretanto, a doutrina e a jurisprudência se debatem quanto à sentença absolutória. É dizer: discutem a doutrina e a jurisprudência se o Ministério Público poderia recorrer de uma sentença absolutória quando ele mesmo pediu a absolvição do réu.

Uma primeira corrente, fundada na ausência de sucumbência, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, aduz que o Ministério Público não teria interesse recursal, razão pela qual seu recurso não poderia passar pelo juízo de prelibação (LIMA, 2020, p. 1784). Nesse sentido: HC 171.306/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 4/11/2011.

Noutro giro, uma segunda corrente, embasada na independência funcional, nos termos do art. 127, §1º, da CF/88, e no fato de que a sucumbência do Ministério Público deve ser analisada em relação ao pedido fixado na denúncia, sustenta que é possível que um promotor de justiça, discordando do pedido de absolvição formulado por seu antecessor, recorra da sentença absolutória, buscando a condenação. Nesse sentido: AgRg no Ag 1322990/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/4/2011, DJe 4/5/2011.

Quanto à temática, adotando a segunda corrente, na prova para Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça da Bahia, organizado pelo Cebraspe/UnB em 2019, foi considerada incorreta a seguinte assertiva: "Determinado órgão do MP não terá interesse na interposição de apelação contra sentença absolutória quando outro órgão, em alegações finais, tiver se manifestado pela absolvição do réu".

#### 1.4.3. EFEITOS DOS RECURSOS

##### 1.4.3.1. EFEITO EXTENSIVO

Nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros, o que é chamado de efeito extensivo do recursos.

Desse modo, pelo efeito extensivo, que, apesar de estar previsto no capítulo dos recursos, também se aplica a outras espécies impugnativas. É possível que os efeitos do julgamento do recurso interposto por um dos réus seja estendido aos demais, ainda que estes tenham, expressamente, renunciado à via recursal.

Conforme se vê da própria redação do art. 580 do CPP, se a fundamentação da absolvição se deu por motivos de caráter pessoal, não há falar em efeito extensivo. Exemplo: João e José são condenados em primeira instância. Somente João recorre e, por falta de provas, é absolvido. Nesse caso, a situação de José não se altera. É dizer: o fato de não haver provas contra João não significa que não exista provas contra José.

Todavia, se a absolvição de João se deu por inexistência do fato, nos termos do art. 386, inciso I, do CPP, os efeitos desta decisão deverão ser estendidos a José, já que, se o fato não existiu para João, por óbvio, não existiu para José.

Sendo hipótese de aplicação do art. 580 do CPP, caberá ao próprio Tribunal que julgar o recurso do réu recorrente estender os efeitos do julgamento ao condenado que não recorreu. Caso o Tribunal não o faça, poderá o condenado remanescente impor embargos declaratórios em desfavor do acórdão que beneficiou o corréu, ou, desde logo, impetrar *habeas corpus* ou mandado de segurança, a depender se há ou não risco à liberdade de locomoção.

#### 1.4.3.2. EFEITO DEVOLUTIVO

Pelo efeito devolutivo, como o nome sugere, a matéria é devolvida ao Poder Judiciário, sendo postulada a reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão judicial combatida pelo recurso interposto (LIMA, 2020, p. 1785).

Todo recurso é dotado de efeito devolutivo e, em regra, será apreciado por órgão jurisdicional distinto do prolator da decisão guerreada, contudo, a depender do recorrente, a extensão (ou dimensão horizontal) da devolução variará. Confirmam-se:

I) RECURSO DA ACUSAÇÃO: no recurso do Ministério Público, querelante ou assistente de acusação, a extensão (ou dimensão horizontal) do efeito devolutivo é bastante limitada. É dizer: o recorrente deve indicar do que está recorrendo e o órgão julgador está adstrito ao objeto da insurgência, não podendo, em regra, analisar questões que não foram tratadas pela acusação, salvo se de tal análise puder advir uma melhora na situação do réu (*reformatio in melius*); e

II) RECURSO DA DEFESA: no recurso da defesa, em regra, a extensão (ou dimensão horizontal) do efeito devolutivo é integral, isto é, toda a matéria é devolvida ao juízo *ad quem*, restando-lhe vedada, tão somente, caso o recurso seja exclusivo da defesa, a *reformatio in pejus*.

Uma vez fixada a extensão (ou dimensão horizontal) do efeito devolutivo, tem-se que, no que diz respeito à profundidade (ou dimensão vertical) do recurso, o juízo *ad quem* poderá levar em consideração tudo que for relevante para a nova decisão. Inclusive, se entender necessário, ao juízo *ad quem* é dado converter o julgamento em diligência e proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências, nos termos do art. 616 do CPP, que, apesar de somente fazer referência às apelações, é aplicável às demais espécies recursais (LIMA, 2020, p. 1786).

#### 1.4.3.3. EFEITO SUSPENSIVO

Pelo efeito suspensivo, que, no processo penal, é excepcional, a interposição do recurso impede que a decisão guerreada produza, desde logo, os seus efeitos regulares (NUCCI, 2016, p. 504).

Como dito, a regra é que os recursos não são dotados de efeito suspensivo, como ocorre, por exemplo, com a apelação contra sentença absolutória, já que, nos termos do art. 596, *caput*, CPP, a apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Logicamente, se o réu foi absolvido, ainda que por sentença de primeira instância, ele deve ser imediatamente colocado em liberdade, isto é, a sentença absolutória deve produzir efeitos imediatos.

Outro exemplo bastante cobrado de recurso sem efeito suspensivo é o agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP.

Noutro giro, ao contrário do que ocorre em relação à apelação contra sentença absolutória, cujo efeito é meramente devolutivo, a apelação contra sentença condenatória possui efeito suspensivo, já que o início do cumprimento da pena imposta somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado daquela, nos termos do art. 597 do CPP (NUCCI, 2016, p. 504).

#### 1.4.3.4. EFEITO TRANSLATIVO

Em decorrência do efeito translativo, que somente ocorre nos chamados recursos de ofício, o juízo *ad quem* tem o poder de apreciar toda a matéria, pouco importando se beneficiará ou prejudicará qualquer das partes (LIMA, 2020, p. 1791).

#### 1.4.3.5. EFEITO REGRESSIVO, ITERATIVO OU DIFERIDO

Pelo efeito regressivo, permite-se que o órgão judiciário que proferiu a decisão guerreada, com fulcro nas razões alegadas pela parte recorrente, reveja seu posicionamento e altere o *decisum* inicialmente prolatado. Desse modo, pode-se concluir que o efeito regressivo dá ensejo ao juízo de retratação ou confirmação da anterior decisão.

### 2. DOS RECURSOS EM ESPÉCIES (ARTS. 581 A 620, CPP)

#### 2.1. DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (ARTS. 581 AO 592, CPP)

##### 2.1.1. CONCEITO, NOÇÕES ACERCA DO CABIMENTO E POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA

O recurso em sentido estrito "é o recurso cabível para impugnar as decisões interlocutórias do magistrado, expressamente previstas em lei" (NUCCI, 2016, p. 1797).

Apesar de o art. 581, *caput*, do CPP, ter feito referência a "decisão, despacho ou sentença", há uma impropriedade técnica do legislador ordinário, já que os despachos de mero expediente, a exemplo de uma designação de audiência ou intimação das partes, não possuem cunho decisório e, portanto, são irrecorríveis. Ademais, as sentenças, nos termos do art. 593, *caput*, do CPP, desafiam o recurso de apelação.

Considerando que as hipóteses de interposição do recurso em sentido estrito são limitadas àquelas arroladas no art. 581 do CPP, não é possível fazer um comparativo do RESE com o agravo de instrumento do Código de Processo Civil, mormente porque o cabimento deste último é mais abrangente. O RESE, como dito, somente é cabível em decisões interlocutórias previstas no rol taxativo do art. 581 do CPP, que, no entanto, pode ser interpretado extensivamente, nos termos do art. 3º do CPP, conforme estudamos em tópico inicial deste capítulo.

No ponto, apesar de alguma discussão doutrinária, prevalece "o entendimento no sentido da possibilidade de interpretação extensiva das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito" (LIMA, 2020, p. 1797).

Assim, o que se veda é a supressão de lacunas voluntárias do legislador, como ocorre, por exemplo, no caso do art. 581, inciso I, do CPP, o qual, de forma bastante clara, diz que cabe RESE da decisão que não receber a peça acusatória inicial. Logo, não pode o intérprete aumentar esse rol e concluir que também caberia RESE contra a decisão que receber a denúncia ou a queixa (LIMA, 2020, p. 1798).

Por outro lado, ainda se valendo do inciso I, o legislador não fez referência expressa à rejeição do aditamento à inicial, contudo, por se tratar de uma omissão involuntária, admite-se a interpretação extensiva da norma, possibilitando o manejo de RESE contra a decisão que não receber o aditamento à exordial acusatória (LIMA, 2020, p. 1798).

##### 2.1.2. HIPÓTESES FORA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Na legislação processual penal esparsa, é possível encontrar outros casos de interposição de RESE. Confirmam-se:

a) LEI Nº 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) — SUSPENSÃO CAUTELAR DA CNH OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR: de acordo com o art. 294, *caput*, do CTB, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. Nos termos do parágrafo único, contra a decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo.

Em relação ao *caput*, deve ser rememorado que, nos termos dos arts. 3º-A, 282, §§2º e 4º, e 311, todos do CPP, ao juiz, nem mesmo no curso da ação penal, não mais é dado o poder de decretar medidas cautelares de ofício, razão pela qual o art. 294, *caput*, do CTB, foi tacitamente derogado pelo Pacote Anticrime.

b) CONTRAVENÇÕES PENAIS DE JOGO DO BICHO E DE CORRIDA DE CAVALO FORA DO HIPÓDROMO: o art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 1.508/51, diz que, caso a investigação policial referente às contravenções de jogo do bicho e de corrida de cavalo fora do hipódromo seja arquivada, caberia recurso em sentido estrito.

Com a redação do novo art. 28, *caput*, do CPP, que, até o fechamento desta obra, está com a eficácia suspensa, o dispositivo acima mencionado estaria tacitamente revogado, porquanto não há mais a homologação judicial da promoção de arquivamento. Assim, se o arquivamento somente se dá no âmbito do Ministério Público, isto é, sem decisão judicial, desaparece a possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito.

### 2.1.3. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RAZÕES/CONTRARRAZÕES

#### 2.1.3.1. REGRA GERAL

Nos termos do art. 586, *caput*, do CPP, a regra é que o prazo de interposição do RESE é de 5 dias. Ademais, conforme o art. 588, *caput*, do CPP, o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões recursais é de 2 dias. Considerando que as razões podem ser apresentadas após a interposição, o RESE pode ser interposto por petição ou por termo nos autos (art. 578, *caput*, CPP). Em resumo:



De acordo com o art. 588, parágrafo único, do CPP, se o recorrido for o réu, será intimado do prazo na pessoa do defensor, o que deve ser visto com ressalvas em relação ao RESE interposto pela acusação contra a rejeição da peça acusatória, nos termos do art. 581, inciso I, do CPP, que será visto, com mais detalhes, em tópico separado.

Com efeito, é bastante comum aparecer em provas de concurso o teor da Súmula nº 707 do STF, segundo a qual "constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprimindo a nomeação de defensor dativo".

Nesse sentido, tem-se que, caso o juiz rejeite a peça acusatória (denúncia ou queixa), deverá haver a intimação do próprio acusado, para que, querendo, constitua advogado, não podendo a falta dessa intimação do acusado ser suprida pela nomeação de defensor dativo. É dizer: no mais das vezes, o investigado não conta com advogado. Caso a exordial contra ele formulada seja rejeitada, natural que ele tenha bastante interesse em manter essa decisão, razão pela qual deve ser intimado para que, por intermédio de advogado, ofereça uma boa peça de razões recursais, a fim de que sua situação processual não seja alterada.

### 2.1.3.2. LISTA GERAL DE JURADOS

Nos termos do art. 581, inciso XIV, do CPP, caberá recurso em sentido estrito da decisão que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. Conforme art. 586, parágrafo único, do CPP, nesse caso, o prazo de interposição será de 20 dias, contado da data da publicação definitiva da lista de jurados. O prazo para razões e contrarrazões permanece de 2 dias. Em resumo:



Apesar da literalidade do art. 581, inciso XIV, do CPP, há muita discussão doutrinária acerca de sua revogação tácita ou não. O Professor Renato Brasileiro de Lima, por exemplo, aduz que, "se o art. 426, § 1º, do CPP, com redação determinada pela Lei nº 11.689/08, passou a prever instrumento específico para impugnação da lista geral dos jurados — reclamação de qualquer do povo ao juiz presidente até o dia 10 de novembro —, isso significa dizer que houve a revogação tácita do art. 581, XIV, do CPP, que previa o cabimento de RESE contra a decisão que incluísse jurado na lista geral ou dela o excluísse" (LIMA, 2020, p. 1809).

Outra parcela da doutrina entende que o art. 581, inciso XIV, do CPP, permanece em vigor, devendo o RESE interposto contra a inclusão ou exclusão de jurado da lista geral ser julgado pelo presidente do Tribunal a que estiver vinculado o juízo responsável por organizar a referida lista (NUCCI, 2016, p. 923).

Adotando essa segunda corrente, a FCC, na prova de Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul, organizado em 2011, considerou correta a seguinte assertiva: "A defesa poderá interpor, no prazo de 20 (vinte) dias, recurso em sentido estrito da decisão que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir, sendo de 2 (dois) dias o prazo para o oferecimento das respectivas razões".

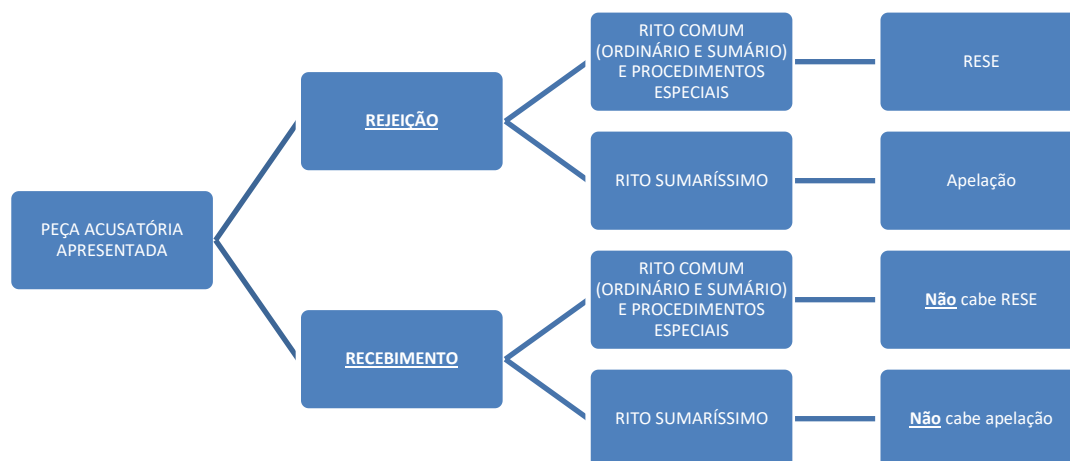
### 2.1.4. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RESE

#### 2.1.4.1. REJEIÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA

Nos termos do art. 581, inciso I, do CPP, caberá recurso em sentido estrito da decisão que não receber a denúncia ou a queixa, o que não é aplicável ao rito comum sumaríssimo. Frise-se: o art. 581, inciso I, do CPP, somente se aplica ao rito comum, ordinário e sumário, e aos procedimentos especiais, não incidindo sobre o rito comum sumaríssimo.

De acordo com o art. 82, *caput*, da Lei nº 9.009/95, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

De mais a mais, também não há falar no cabimento de RESE (ou apelação no JECrim) contra a decisão que receber a denúncia ou a queixa. Nesse caso, a depender se há ou não risco à liberdade de locomoção, caberá a impetração de *habeas corpus* ou de mandado de segurança. Em resumo:



Por fim, assenta-se que, nos termos da Súmula nº 709 do STF, "salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela".

#### 2.1.4.2. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

De acordo com o art. 581, inciso II, do CPP, caberá recurso em sentido estrito da decisão que concluir pela incompetência do juízo, o que também é aplicável à hipótese inserta no art. 419, *caput*, do CPP (desclassificação após a primeira fase do rito do Júri) (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 1381). No mais, caso o juiz reconheça a competência do juízo, não há falar no cabimento do recurso em sentido estrito.

#### 2.1.4.3. PROCEDÊNCIA DAS EXCEÇÕES (SALVO AS DE SUSPEIÇÃO, IMPEDIMENTO E INCOMPATIBILIDADE)

Conforme art. 581, inciso III, do CPP, caberá recurso em sentido estrito da decisão que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição, impedimento e incompatibilidade, já que, caso o juiz aceite essas últimas, conforme visto em capítulo próprio, deverá encaminhar os autos a seu substituto legal, não havendo recurso legalmente previsto para se discutir tal decisão (art. 99 do CPP).

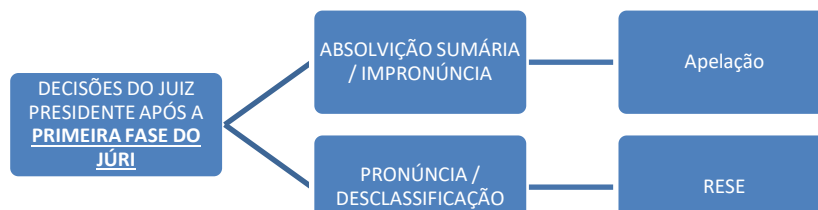
De mais a mais, conforme a própria redação do art. 581, inciso III, do CPP, caso o juiz julgue as exceções de incompetência, litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada improcedentes, não caberá recurso em sentido estrito. É dizer: somente cabe RESE da decisão que julgá-las procedentes.

No que diz respeito às exceções de suspeição, impedimento e incompatibilidade, caso não as reconheça, nos termos do art. 100, *caput*, do CPP, o juiz mandará autuar a petição em apartado, dará sua resposta dentro do prazo de 3 (três) dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e, em seguida, determinará sejam os autos da exceção remetidos, dentro de 24h (vinte e quatro horas), ao Tribunal a que competir o julgamento.

#### 2.1.4.4. PRONÚNCIA DO RÉU

Nos termos do art. 581, inciso IV, do CPP, caberá recurso em sentido estrito da decisão que pronunciar o réu. Assim, considerando o teor dos art. 416, 419, *caput*, e 581, incisos II e IV, todos do CPP, temos o seguinte panorama:





#### 2.1.4.5. DECISÃO QUE CONCEDER, NEGAR, ARBITRAR, CASSAR OU JULGAR INIDÔNEA A FIANÇA, INDEFERIR REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA OU REVOGÁ-LA, CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA OU RELAXAR A PRISÃO EM FLAGRANTE

Conforme art. 581, inciso V, do CPP, caberá a interposição de recurso em sentido estrito das decisões que:

- a) conceder a fiança;
- b) negar a fiança;
- c) arbitrar a fiança;
- d) cassar a fiança;
- e) julgar inidônea a fiança;

f) indeferir requerimento de prisão preventiva. Aqui, atente-se que, contra a decisão que defere o pedido de requerimento de prisão preventiva não cabe a interposição de RESE, que somente poderá desafiar a decisão que indeferir tal postulação. Ademais, interpretando-se extensivamente tal dispositivo, é possível concluir que também caberá RESE contra a decisão que indeferir requerimento de decretação de prisão temporária e/ou de medida cautelar pessoal diversa da prisão (LIMA, 2020, 1802-1803);

g) revogar a prisão preventiva. Aqui, atente-se que, contra a decisão que decretar a prisão preventiva, não é cabível a interposição de RESE. Ademais, interpretando extensivamente o estudado dispositivo, o STJ assentou que é cabível recurso em sentido estrito contra a decisão que revoga medida cautelar diversa da prisão<sup>38</sup>;

- h) conceder liberdade provisória; e
- i) relaxar a prisão em flagrante.

#### 2.1.4.6. QUEBRAMENTO OU PERDIMENTO DA FIANÇA

Nos termos do art. 581, inciso VII, do CPP, caberá a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor.

Quanto ao ponto, considerando que a perda da fiança, nos termos do art. 344 do CPP, exige o trânsito em julgado da condenação e, em regra, é decretada pelo juízo da execução, em verdade, contra tal decisão será cabível o agravo em execução (art. 197 da LEP) (LIMA, 2020, p. 1804).

#### 2.1.4.7. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

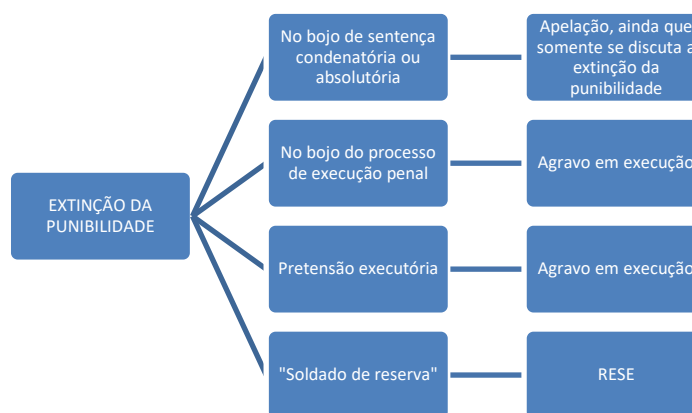
Conforme art. 581, inciso VIII, do CPP, caberá a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade. Aqui, bastante cuidado deve ser dispensado em relação ao momento dessa decretação (AVENA, 2017, p. 824).

<sup>38</sup>STJ, Sexta Turma, REsp 1628262/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/12/2016.

Nesse sentido, de acordo com o art. 593, inciso I e §4º, do CPP, que será estudado adiante, caso a declaração da extinção da punibilidade se dê no bojo de uma sentença condenatória ou absolutória proferida por juiz singular, ainda que o recorrente trate somente da extinção da punibilidade, o recurso cabível será o de apelação, à luz do princípio da unirrecorribilidade recursal. Exemplo: João é denunciado por ameaça e furto. O juiz, na sentença de mérito, o condena por furto e declara a extinção de sua punibilidade em relação ao crime de ameaça. Caso o MP queira recorrer somente da declaração da extinção da punibilidade, deverá fazê-lo por apelação e não por RESE (AVENA, 2017, p. 824).

Caso a extinção da punibilidade se dê no bojo do processo de execução penal ou se refira à prescrição da pretensão executória, o recurso cabível será o de agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP (AVENA, 2017, p. 824).

Assim, o art. 581, inciso VIII, do CPP, funciona como verdadeiro "soldado de reserva", isto é, caso a decisão não se dê em uma sentença de mérito, no processo de execução penal ou não se refira à prescrição da pretensão executória, aí sim é que será cabível o RESE (AVENA, 2017, p. 824). Em resumo:



Também deve ser rememorado que a declaração da extinção da punibilidade é uma das hipóteses expressas em relação às quais o assistente de acusação poderá recorrer, nos termos do art. 584, §1º, do CPP. Conforme já estudamos, caso o assistente de acusação já esteja previamente habilitado, seu prazo para interposição será de 5 dias. Caso não tenha havido a habilitação prévia, o prazo será de 15 dias, nos termos do art. 598, parágrafo único, do CPP.

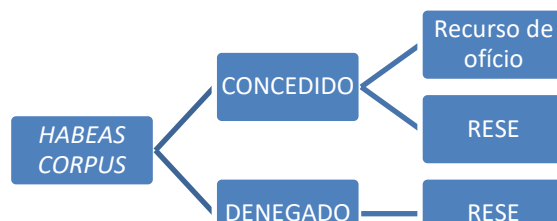
#### 2.1.4.8. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Nos termos do art. 581, inciso IX, do CPP, caberá a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade, valendo quanto ao ponto as mesmas observações que fizemos no item acima em relação ao momento da prolação dessa decisão.

#### 2.1.4.9. CONCESSÃO OU DENEGAÇÃO DA ORDEM DE *HABEAS CORPUS*

Conforme art. 581, inciso X, do CPP, caberá a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão que conceder ou negar a ordem de *habeas corpus*.

Aqui, deve ser rememorado que, à luz do art. 574, inciso I, do CPP, também caberá recurso de ofício da sentença que conceder *habeas corpus*. Desse modo, tem-se que:



#### 2.1.4.10. DECISÃO QUE CONCEDER, NEGAR OU REVOGAR A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

De acordo com o art. 581, inciso XI, do CPP, caberá a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena (art. 77, CP), o que não mais encontra guarida no ordenamento jurídico.

No que diz respeito à concessão ou negativa de suspensão condicional da pena na sentença de mérito, nos termos do art. 593, inciso I e §4º, do CPP, ainda que o recorrente se insurja somente quanto ao ponto, o recurso cabível será o de apelação e não o RESE (LIMA, 2020, p. 1806).

Noutro giro, se a decisão de concessão, denegação ou revogação da suspensão condicional da pena se der no bojo do processo de execução penal, será cabível a interposição do recurso de agravo em execução e não o RESE (LIMA, 2020, p. 1806).

Logo, em relação à suspensão condicional da pena, o art. 581, inciso XI, do CPP, encontra-se revogado tacitamente.

Contudo, interpretando extensivamente tal dispositivo legal, o STJ entende que é cabível a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão que concede, nega ou revoga a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95 (LIMA, 2020, p. 1807).

Também interpretando extensivamente o art. 581, inciso XI, do CPP, o STJ entende que é cabível recurso em sentido estrito para impugnar decisão que indefere a produção antecipada de prova, na hipótese de suspensão do processo insere no art. 366 do CPP (réu que é citado por edital e não comparece ao processo e nem constitui advogado)<sup>39</sup>.

#### 2.1.4.11. ANULAÇÃO DO PROCESSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NO TODO OU EM PARTE, OU DESENTRANHAMENTO DE PROVA DECLARADA ILÍCITA

Conforme art. 581, inciso XIII, do CPP, caberá a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte, o que deve ser interpretado extensivamente para alcançar toda a fase judicial da persecução criminal e não somente a instrução processual penal. Assim, se o processo é anulado, no todo ou em parte, antes mesmo de ter sido iniciada a fase instrutória, também é cabível o RESE, pouco importando se a decisão se deu de ofício ou por provocação das partes (LIMA, 2020, p. 1807).

Mais uma vez, é importante registrar que, caso a anulação se dê no bojo de uma sentença condenatória ou absolutória, nos termos do art. 593, inciso I e §4º, do CPP, ainda que o recorrente se insurja somente quanto ao ponto, o recurso cabível será o de apelação e não o RESE (LIMA, 2020, p. 1807).

De acordo com a doutrina, interpretando-se extensivamente tal dispositivo legal, é possível concluir que também caberá RESE contra a decisão que declarar a ilicitude da prova e determinar o seu desentranhamento, nos termos do art. 157, §3º, do CPP, salvo, como dito acima, se tal decisão se der no bojo de uma sentença condenatória ou absolutória (LIMA, 2020, p. 1808).

<sup>39</sup> EREsp 1630121/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 11/12/2018.

#### 2.1.4.12. INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DE JURADOS DA LISTA GERAL

Nos termos do art. 581, inciso XIV, do CPP, caberá a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. Para que evitemos repetições desnecessárias, remetemos o leitor ao tópico atinente aos prazos do RESE, no qual tal inciso já foi comentado.

#### 2.1.4.13. DECISÃO QUE DENEGA A APELAÇÃO OU A JULGA DESERTA

Conforme art. 581, inciso XV, do CPP, caberá a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta.

A denegação (ou não recebimento) da apelação se dará "pela ausência dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos que compõem a sua admissibilidade". Por outro lado, a apelação "será *julgada deserta* por falta de preparo (quando se tratar de apelação intentada pelo querelante)" (AVENA, 2017, p. 827).

O art. 595 do CPP dizia que, caso o réu condenado fugisse depois de haver apelado, seria declarada deserta a apelação por ele interposta, contudo, tal dispositivo foi revogado pela Lei nº 12.403/11. Inclusive, antes mesmo de sua revogação, já vigorava o entendimento exarado na Súmula nº 347 do STJ, segundo a qual "o conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão". Desse modo, o único caso de deserção que ainda existe é a falta de pagamento de preparo na apelação interposta pelo querelante na ação penal privada comum ou exclusiva.

Por fim, é importante lembrar que, nos termos do art. 639 do CPP, que será estudado, com mais detalhes adiante, da decisão que denegar o recurso, preenchidas determinadas condições, caberá carta testemunhável. Contudo, como o art. 581, inciso XV, do CPP, é especial em relação ao art. 639, se a apelação for denegada, cabível RESE e não carta testemunhável.

#### 2.1.4.14. SUSPENSÃO DO PROCESSO, EM VIRTUDE DE QUESTÃO PREJUDICIAL

Conforme dissemos no capítulo atinente às questões prejudiciais, nos termos do art. 581, inciso XVI, do CPP, caberá a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial, pouco importando se a questão prejudicial é de suspensão obrigatória ou facultativa (AVENA, 2017, p. 828).

Noutro giro, se a suspensão for denegada, não há recurso cabível, nos termos do art. 93, §2º, do CPP.

#### 2.1.4.15. DECISÃO SOBRE O INCIDENTE DE FALSIDADE

Nos termos do art. 581, inciso XVIII, do CPP, caberá a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão que decidir o incidente de falsidade. Desse modo, em qualquer caso, isto é, reconhecida ou não a falsidade invocada, a decisão do incidente de falsidade desafia recurso em sentido estrito.

#### 2.1.4.16. RECUSA À HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Conforme art. 581, inciso XXV, do CPP, incluído pelo Pacote Anticrime, caberá a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do mesmo Código.

Quanto ao ponto, rememora-se que, à luz do art. 28-A, §7º, do CPP, o juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º do mesmo artigo.

Desse modo, tendo o juiz se recusado a homologar o acordo de não persecução penal, o recurso cabível será o RESE, "o qual poderá ser interposto não apenas pelo Ministério Público, mas



também pela própria defesa, haja vista seu evidente interesse na homologação da avença como meio de se evitar a deflagração de um processo penal" (LIMA, 2020, p. 286).

Ademais, considerando a similitude entre as situações, a doutrina aduz que o inciso XXV do art. 581 do CPP "pode — e deve — ser interpretado extensivamente para fins de também se admitir a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão judicial que recusar homologação à proposta do acordo de colaboração premiada (Lei n. 12.850/13, art. 4º, §8º)" (LIMA, 2020, p. 1812).

### 2.1.5. ANTIGAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RESE QUE FORAM REVOGADAS PELA LEP

Com o advento do art. 197 da Lei nº 7.210/84 (LEP), algumas hipóteses de cabimento do RESE foram tacitamente revogadas. É dizer: algumas situações, que, antes da LEP, desafiavam recurso em sentido estrito, hoje são hipóteses de cabimento de agravo em execução. Assim, são recorríveis por agravo em execução as decisões que (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 1385):

- a) conceda, negue ou revogue a suspensão condicional da pena (art. 581, XI, CPP), desde que prolatadas no bojo do processo de execução penal. No ponto, rememora-se que, caso a concessão ou negativa da suspensão condicional da pena se dê na sentença de mérito, nos termos do art. 593, inciso I e §4º, do CPP, ainda que o recorrente se insurja somente quanto a isso, o recurso cabível será o de apelação e não o RESE;
- b) conceda, negue ou revogue livramento condicional (art. 581, XII, CPP);
- c) decida sobre a unificação das penas (art. 581, XVII, CPP);
- d) decrete medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado (art. 581, XIX, CPP);
- e) imponha medida de segurança por transgressão de outra (art. 581, XX, CPP);
- f) mantenha ou substitua medida de segurança no processo de execução penal (art. 581, XXI, CPP — a alusão ao Código Penal constante deste dispositivo está sem correspondência na sua parte geral promulgada em 1984). Portanto, o dispositivo não tem aplicação;
- g) revogue medida de segurança (art. 581, XXII, CPP);
- h) deixe de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação (art. 581, XXIII, CPP); e
- i) converta a multa em detenção ou em prisão simples (art. 581, XXIV, CPP). Essa hipótese, em verdade, encontra-se revogada tacitamente pelo art. 51 do CP, já que a pena de multa não mais poderá ser convertida em pena privativa de liberdade.

### 2.1.6. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DO RESE

#### 2.1.6.1. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO

O recurso em sentido estrito deve ser julgado pelas Câmaras dos Tribunais de Justiça ou pelas Turmas dos Tribunais Regionais Federais. Para a corrente que defende que o art. 581, inciso XIV, do CPP (inclusão ou exclusão de jurado da lista geral), não foi revogado, tem-se que tal recurso deverá ser julgado pelo Presidente do Tribunal a que estiver vinculado o juízo que organizou a lista impugnada (LIMA, 2020, p. 1814).

No ponto, é importante frisar que, para a parcela da doutrina que entende que o art. 581, inciso XIV, do CPP, não foi revogado, das ressalvas feitas pelo art. 582 do CPP, ela é a única que subsiste, conforme acima estudado. Desse modo, atualizando-se o citado art. 582, teríamos a seguinte redação: "os recursos em sentido estrito serão sempre julgados pelas Câmaras dos Tribunais de Justiça ou pelas Turmas dos Tribunais Regionais Federais, salvo na hipótese do art. 581, XIV, cujo julgamento é afeto ao Presidente do Tribunal a que vinculado o juízo que organizou a lista geral de jurados impugnada" (AVENA, 2017, p. 832).



### 2.1.6.2. FORMAÇÃO DE INSTRUMENTO

A regra geral é que o RESE deverá ser processado por instrumento, ou seja, em autos apartados, com peças trasladadas ou fotocopiadas. Nesse caso, nos termos do art. 587, *caput*, do CPP, o recorrente deverá indicar, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Conforme parágrafo único, o traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de 5 dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso e o termo de interposição (LIMA, 2020, p. 1812).

De acordo com o art. 590 do CPP, quando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o dobro.

Todavia, nos termos do art. 583, *caput*, do CPP, há casos em que o RESE subirá nos próprios autos, isto é, não haverá a formação de instrumento. São eles:

a) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO DE OFÍCIO: nos termos do art. 583, inciso I, do CPP, o RESE subirá nos próprios autos quando interposto de ofício. Conforme estudamos, a única hipótese remanescente de RESE que pode ser interposto de ofício se dá em relação à decisão concessiva de *habeas corpus* (art. 574, inciso I, c/c art. 584, inciso X, ambos do CPP);

b) DECISÃO QUE NÃO RECEBER A DENÚNCIA OU A QUEIXA: nos termos do art. 583, inciso II, do CPP, o RESE subirá nos próprios autos no caso de desafiar a decisão que não receber a inicial acusatória (art. 581, inciso I, CPP);

c) DECISÃO QUE JULGAR PROCEDENTES AS EXCEÇÕES, SALVO AS DE SUSPEIÇÃO, IMPEDIMENTO E INCOMPATIBILIDADE: nos termos do art. 583, inciso II, do CPP, o RESE subirá nos próprios autos no caso de desafiar a decisão que julgar procedentes as exceções, salvo as de suspeição, impedimento e incompatibilidade (art. 581, inciso III, CPP);

d) DECISÃO QUE PRONUNCIAR O RÉU: nos termos do art. 583, inciso II, do CPP, o RESE subirá nos próprios autos no caso de desafiar a decisão que pronunciar o réu (art. 581, inciso IV, CPP). Quanto ao ponto, muita atenção deve ser dispensada ao art. 583, parágrafo único, do CPP, segundo o qual o recurso da pronúncia subirá em traslado, quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. Exemplo: em um mesmo processo, João e José são acusados e pronunciados em relação ao homicídio de Pedro. Somente João recorre da pronúncia. Nesse caso, o RESE de João deverá subir por instrumento. Em relação a José, o procedimento terá seu regular processamento, havendo, pois, necessidade de cisão do feito (LIMA, 2020, p. 1812-1813);

e) DECISÃO QUE DECLARAR A PRESCRIÇÃO OU JULGAR, POR OUTRO MODO, EXTINTA A PUNIBILIDADE: nos termos do art. 583, inciso II, do CPP, o RESE subirá nos próprios autos no caso de desafiar a decisão que declarar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade (art. 581, inciso VIII, CPP);

f) DECISÃO QUE CONCEDER OU NEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS: nos termos do art. 583, inciso II, do CPP, o RESE subirá nos próprios autos no caso de desafiar a decisão que conceder ou negar a ordem de *habeas corpus* (art. 581, inciso X, CPP); e

g) QUANDO A REMESSA DO RECURSO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO PROCESSO NÃO PREJUDICAR O ANDAMENTO DO FEITO: nos termos do art. 583, inciso III, do CPP, quando a remessa do RESE nos próprios autos do processo principal não prejudicar o andamento do feito, não haverá a formação de instrumento. Exemplo: nos termos do art. 581, XVI, caberá RESE contra a decisão que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial. Nesse caso, o processo já está suspenso, não havendo nenhuma necessidade de se formar um instrumento e deixar os autos do processo principal parados. Assim, considerando que o procedimento já estava sobrestado, o RESE subirá nos próprios autos do processo principal, sem a formação de instrumento (LIMA, 2020, p. 1813).





### 2.1.6.3. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO

Em regra, o recurso em sentido estrito não é dotado de efeito suspensivo, isto é, não impede que a decisão guerreada produza seus efeitos regulares. Contudo, o art. 584 do CPP traz algumas situações nas quais o RESE será dotado de efeito suspensivo. Apesar de o referido artigo citar várias decisões, somente permanecem em vigor as seguintes:

a) DECISÃO QUE DENEGAR A APELAÇÃO OU JULGÁ-LA DESERTA: nos termos do art. 581, inciso XV, do CPP, caberá recurso em sentido estrito contra a decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta. Conforme art. 584, *caput*, do CPP, esse RESE é dotado de efeito suspensivo;

b) DECISÃO QUE PRONUNCIAR O RÉU: nos termos do art. 581, inciso IV, do CPP, caberá recurso em sentido estrito contra a decisão que pronunciar o réu. Conforme art. 584, §2º, do CPP, o recurso da pronúncia suspenderá tão-somente o julgamento. Não obstante, em verdade, o RESE contra a pronúncia não suspende somente o julgamento, porquanto, nos termos do art. 421, *caput*, do CPP, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri somente quando preclusa a decisão de pronúncia. Ademais, deve ser rememorado que o RESE contra a decisão de pronúncia subirá nos próprios autos do processo principal, o que, por óbvio, obsta que o juízo de primeira instância realize outras diligências naqueles autos. Logo, o RESE contra a decisão de pronúncia, além de suspender o julgamento, também impossibilita que se dê início à fase de preparação do processo para julgamento em Plenário (arts. 422 a 424, CPP). Todavia, se, por ocasião da pronúncia, tenha sido decretada ou mantida a decretação da prisão preventiva (art. 413, §3º, CPP), o RESE contra a decisão de pronúncia não impedirá a execução da prisão, podendo o acusado, caso queira impugnar a ordem de prisão, impetrar *habeas corpus*. Ainda em relação ao RESE contra a pronúncia, tem-se que restou tacitamente revogado o art. 585 do CPP, segundo o qual o réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança, nos casos em que a lei a admitir. Conforme o citado art. 413, §3º, do CPP, a pronúncia, por si só, não é motivo para a decretação da prisão preventiva do acusado. Além do mais, ainda que a prisão tenha sido decretada ou tenha sido mantida a sua decretação por ocasião da pronúncia, a admissibilidade do RESE independe do efetivo recolhimento do pronunciado ao cárcere (LIMA, 2020, p. 1815-1816);

c) DECISÃO QUE JULGAR QUEBRADA A FIANÇA: nos termos do art. 581, inciso VII, primeira parte, do CPP, caberá recurso em sentido estrito contra a decisão que julgar quebrada a fiança. Conforme art. 584, §3º, do CPP, esse RESE suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do seu valor. Elucida-se. De acordo com o art. 343 do CPP, o quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva. Assim, o quebramento da fiança, além de acarretar perda da metade de seu valor, poderá implicar na imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão ou, até mesmo, na prisão preventiva daquele que a quebrou. Caso isso ocorra, isto é, se o juiz, por exemplo, além de declarar o quebramento da fiança, decretar a prisão preventiva do sujeito, o RESE interposto contra esta decisão não impedirá a execução da ordem de prisão preventiva, cabendo ao interessado discutir a decretação de sua prisão por intermédio da impetração de *habeas corpus* (LIMA, 2020, p. 1816).

Por fim, conforme será visto, com mais detalhes, no capítulo atinente ao mandado de segurança, vedando prática bastante corriqueira, o STJ, por intermédio de sua Súmula de nº 604, assentou que "o mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público". Assim, ao Ministério Público não mais é dado impetrar MS com o fim de dotar o RESE de efeito suspensivo, o que, como dito, será analisado melhor em capítulo próprio.

#### 2.1.6.4. EFEITO REGRESSIVO (ITERATIVO OU DIFERIDO)

O recurso em sentido estrito é dotado do efeito regressivo, também chamado de iterativo ou diferido, o qual permite que o órgão prolator da decisão impugnada, em juízo de retratação, diante da fundamentação trazida pelo recorrente, adote posicionamento diverso daquele inicialmente abraçado.

Nos termos do art. 589, *caput*, do CPP, com ou sem as contrarrazões ao RESE interposto, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará a sua decisão, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Desse modo, caso não se retrate e houver a necessidade de formação de instrumento, o próprio juiz poderá indicar outras peças para serem trasladadas.

Conforme parágrafo único, se o juiz reformar a decisão recorrida, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Nesse caso, independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em traslado.

Imagine a seguinte situação: no curso de procedimento comum ordinário, isto é, em momento anterior à prolação da sentença de mérito, o juiz, por intermédio de decisão interlocutória, declara a extinção da punibilidade do acusado. Irresignado, o Ministério Público, com fulcro no art. 581, inciso VIII, do CPP, interpõe RESE. Nos termos do art. 589, *caput*, do CPP, após a apresentação das razões e contrarrazões recursais, o juiz se retrata, ou seja, conclui que não era caso de declaração da extinção da punibilidade do acusado. Nessa hipótese, considerando que, nos termos do art. 581, inciso IX, a nova decisão também desafia RESE, o acusado, por simples petição, poderá interpor tal recurso, contudo, nesse caso, o juiz não poderá mais se retratar, devendo o recurso, sem novas razões ou contrarrazões recursais, ser apreciado pelo juízo *ad quem* (LIMA, 2020, p. 1813-1814).

### 2.2. DA APELAÇÃO (ARTS. 593 AO 603, CPP)

#### 2.2.1. APELAÇÃO PLENA (OU AMPLA) OU LIMITADA (PARCIAL OU RESTRITA)

##### 2.2.1.1. REGRA GERAL

Nos termos do art. 599 do CPP, as apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação a parte dele. Assim, é cabível tanto a apelação plena ou ampla (contra todo o julgado) como a apelação limitada, parcial ou restrita (contra parte do julgado).

Em regra, essa delimitação deve ser feita pela parte na peça de interposição, isto é, logo na interposição, a parte deve indicar os fundamentos do apelo, o que vale tanto para a acusação (Ministério Público, assistente de acusação ou querelante) como para a defesa. Frise-se: a regra geral é que a extensão (dimensão horizontal) do apelo é definida pela interposição e não pelas razões recursais. Todavia, caso a parte não delimite os fundamentos do apelo por ocasião de sua interposição, a depender de quem é o recorrente, os efeitos desta omissão serão distintos.

No que diz respeito à acusação, a jurisprudência tem assentado que, caso não tenha havido a indicação dos fundamentos do apelo quando de sua interposição, o Tribunal *ad quem* estará adstrito aos fundamentos invocados nas razões recursais, ou seja, ainda assim, nem toda a matéria poderá ser apreciada pelo juízo *ad quem*, salvo se isso importar em melhoria na situação do réu (*reformatio in mellius*)<sup>40</sup>.

Em relação à defesa, a regra é bem mais flexível, já que, no apelo exclusivo da defesa, a extensão (ou dimensão horizontal) do efeito devolutivo é integral, isto é, toda a matéria é devolvida ao juízo *ad quem*, restando-lhe vedada, tão somente, caso o recurso seja exclusivo da defesa, a *reformatio in pejus*. Desse modo, ainda que a defesa, quando da interposição do apelo, tenha ou

<sup>40</sup>HC 139.335/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 3/11/2011.

não delimitado os seus fundamentos, toda a matéria é devolvida ao Tribunal *ad quem*, que estará limitado, tão somente, à vedação da *reformatio in pejus*.

### 2.2.1.2. RITO DO JÚRI

No rito do Júri, nos termos da Súmula nº 713 do STF, "o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".

Desse modo, em se tratando de crimes dolosos contra a vida, a regra é que a parte deverá, por ocasião da interposição, de forma expressa, aduzir os fundamentos de seu apelo, ficando o Tribunal *ad quem* a eles limitados. Exemplo: a parte, na interposição, diz que sua apelação é calcada no art. 593, inciso III, alínea *a*, do CPP (nulidade posterior à pronúncia). Assim, ainda que a parte, nas razões recursais, traga fundamentação em relação às outras alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, o Tribunal não poderá conhecê-las, já que está adstrito à alínea *a* do citado inciso.

Todavia, caso a parte, por ocasião da interposição, não indique os fundamentos do apelo, a jurisprudência entende que o Tribunal estaria adstrito às matérias tratadas nas razões recursais. É dizer: caso a parte, nas razões, não traga fundamentação em relação a todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, o Tribunal estará adstrito às alíneas que foram ventiladas pela parte na fundamentação de suas razões recursais.

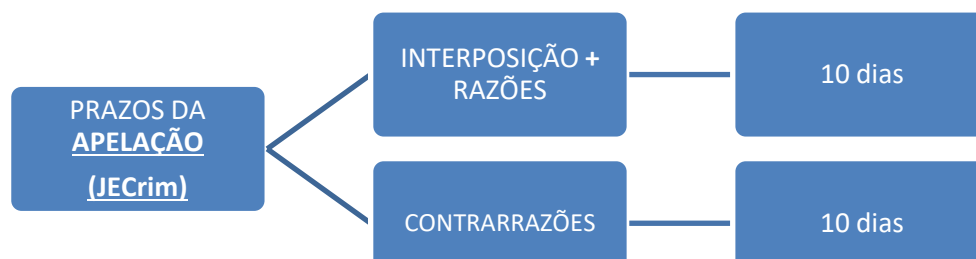
Em resumo, caso a parte não indique o fundamento da apelação quando de sua interposição, o alcance do apelo contra decisão do Júri será determinado pelo teor das razões recursais (LIMA, 2020, p. 1817).

### 2.2.2. PRAZOS

Nos termos do art. 593, *caput*, do CPP, o prazo para a interposição da apelação é de 5 dias, pouco importando se o apelo se dará em relação à sentença proferida por juiz singular ou no âmbito do Tribunal do Júri. Conforme art. 600, *caput*, primeira parte, do CPP, o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões recursais é de 8 dias. Considerando que as razões podem ser apresentadas após a interposição, a apelação pode ser interposta por petição ou por termo nos autos (art. 578, *caput*, CPP). Em resumo:



Tais prazos não se aplicam à apelação interposta no rito do Juizado Especial Criminal, porquanto, em se tratando do rito sumaríssimo, o prazo comum para interposição e razões será de 10 dias, nos termos do art. 81, §2º, da Lei nº 9.099/95. Logo, considerando que a interposição e as razões recursais devem ser apresentadas de forma simultânea, no JECrim, a apelação somente poderá ser interposta por petição escrita. O prazo para a apresentação das contrarrazões também é de 10 dias, conforme art. 81, §2º, da Lei nº 9.009/95. Em resumo:



A segunda parte do *caput* do art. 600 do CPP diz que, no caso das contravenções penais, o prazo para as razões e contrarrazões recursais é de 3 dias. Contudo, considerando que todas as contravenções penais se sujeitam ao rito sumaríssimo, tal regra foi tacitamente revogada pelo art. 81 da Lei nº 9.099/95, conforme acima estudado. Desse modo, à apelação em relação às contravenções penais aplica-se o prazo de 10 dias para interposição, razões e contrarrazões recursais.

### 2.2.3. RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS: AUSÊNCIA E POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR

Nos termos do art. 601, *caput*, do CPP, findos os prazos para as razões e/ou contrarrazões recursais, os autos serão remetidos à instância superior, com ou sem elas. Assim, mesmo que o apelante não apresente suas razões ou não o faça no prazo legal, caso a interposição tenha sido tempestiva, o recurso passará pelo juízo de prelibação. De igual forma, a intempestividade das contrarrazões recursais em nada interfere no processamento do recurso<sup>41</sup>.

Conforme art. 600, §4º, do CPP, se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância serão os autos remetidos ao Tribunal *ad quem* onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. Assim, no recurso de apelação, é dado ao apelante optar por apresentar suas razões somente na superior instância, o que não se aplica ao recurso em sentido estrito, já que, conforme estudamos, no RESE, há a possibilidade do juízo de retratação (art. 589, CPP), motivo pelo qual as razões devem ser apresentadas perante o próprio juízo prolator da decisão guerreada.

### 2.2.4. HIPÓTESES DE CABIMENTO

As hipóteses de cabimento da apelação não estão restritas ao art. 593 do CPP, já que o próprio Código, em seu art. 416, diz que, no rito do Júri, contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária também caberá apelação. Além do mais, conforme já adiantamos, a Lei dos Juizados Especiais Criminais também faz menção à apelação. Vejamos cada hipótese de cabimento em separado.

#### 2.2.4.1. JUÍZO SINGULAR

##### 2.2.4.1.1. SENTENÇA DEFINITIVA DE CONDENAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO PROFERIDA POR JUIZ SINGULAR

Nos termos do art. 593, inciso I, do CPP, caberá apelação, no prazo de 5 dias, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular.

Também será cabível apelação contra a absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP, segundo o qual, após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do

<sup>41</sup>HC 281.873/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016.

agente, salvo inimizabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do agente.

Especificamente no que diz respeito ao inciso IV (extinção da punibilidade do agente), há bastante discussão doutrinária acerca de qual seria o recurso cabível para desafiar a absolvição sumária por esta razão. Parcela da doutrina entende que o recurso cabível seria o de apelação, porquanto tal decisão tem natureza absolutória (MARCÃO, 2016, p. 1017). Todavia, a corrente majoritária, considerando que tal decisão tem natureza declaratória, e não absolutória — vide Súmula nº 18 do STJ, entende que a impugnação adequada é o recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, inciso VIII, do CPP (LIMA, 2010, p. 1820).

Ademais, conforme já dissemos, nos termos do art. 416 do CPP, no rito do Tribunal do Júri, contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária também caberá apelação.

#### **2.2.4.1.2. DECISÕES DEFINITIVAS, OU COM FORÇA DE DEFINITIVAS, PROFERIDAS POR JUIZ SINGULAR NOS CASOS EM QUE NÃO CAIBA RESE**

Conforme art. 593, inciso II, do CPP, caberá apelação, no prazo de 5 dias, das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. É dizer: se não couber recurso em sentido estrito, contra as decisões definitivas ou com força de definitivas, caberá apelação.

As decisões definitivas aludidas pelo art. 593, inciso II, do CPP, são as denominadas decisões definitivas *lato sensu*, isto é, julgam o mérito, encerram a relação processual, mas não são sentenças absolutórias ou condenatórias. Exemplo: decisão que julga o pedido de restituição, nos termos do estudado art. 120, §1º, do CPP. Nesse caso, tal decisão julga o mérito do pedido e encerra aquele incidente, contudo, não é sentença absolutória ou condenatória. Contra tal decisão, como não cabe RESE, isto é, não está elencada no art. 581 do CPP, caberá a interposição de apelação (LIMA, 2020, p. 1820).

Por outro lado, as decisões com força de definitivas, as quais também são chamadas de decisões interlocutórias mistas, são aquelas que não decidem o mérito, mas encerram a relação processual (terminativas) ou uma etapa do procedimento (não terminativas). Como exemplo de decisão interlocutória mista terminativa, cita-se a rejeição da peça acusatória, já que, apesar de não julgar o mérito, encerrará a relação processual. Nesse caso, como é cabível RESE, não caberá a interposição de apelação. Como exemplo de decisão interlocutória mista não terminativa, cita-se a pronúncia, já que, apesar de não julgar o mérito, encerrará a primeira fase do rito do Júri. Nessa hipótese, como é cabível RESE, não caberá a interposição de apelação. Assim, caso não haja previsão legal de RESE, contra as decisões com força de definitivas, caberá apelação (LIMA, 2020, p. 1820).

#### **2.2.4.2. DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI**

Nos termos do art. 593, inciso III, do CPP, das decisões do Tribunal do Júri, caberá apelação, no prazo de 5 dias, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; e d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Conforme dissemos nas notas introdutórias deste capítulo, no rito do Júri, nos termos da Súmula nº 713 do STF, "o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".

Desse modo, em se tratando de crimes dolosos contra a vida, o Tribunal *ad quem* não poderá conhecer de alínea não mencionada pela parte quando da interposição do recurso, ainda que, nas razões recursais, a parte traga fundamentação em relação a outras alíneas. Exemplo: a parte, na interposição, diz que sua apelação é calcada no art. 593, inciso III, alínea *a*, do CPP (nulidade posterior à pronúncia). Assim, ainda que a parte, nas razões recursais, traga

fundamentação em relação às outras alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, o Tribunal não poderá conhecê-las, já que está adstrito à alínea *a* do citado inciso.

Noutro giro, o contrário também é verdadeiro, porquanto, caso a parte, na interposição, diga que seu recurso está calcado em todas as alíneas, ainda que, nas razões, somente traga fundamentação acerca de uma ou algumas das alíneas, o Tribunal *ad quem* deverá tratar de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP. Exemplo: a parte, na interposição, diz que seu recurso está embasado nas alíneas *a*, *b*, *c* e *d* do inciso III do art. 593 do CPP. Todavia, nas razões recursais, somente traz fundamentação em relação à alínea *c* (erro na aplicação da pena). Nesse caso, o Tribunal *ad quem* deverá tratar de todas as alíneas e não somente da alínea *c*.

De mais a mais, conforme já trabalhamos, caso a parte, por ocasião da interposição, não indique os fundamentos do apelo, a jurisprudência entende que o Tribunal estaria adstrito às matérias tratadas nas razões recursais. É dizer: caso a parte, nas razões, não traga fundamentação em relação a todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, o Tribunal estará adstrito às alíneas que foram ventiladas pela parte na fundamentação de suas razões recursais.

#### 2.2.4.2.1. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA

Conforme art. 593, inciso III, alínea *a*, do CPP, das decisões do Tribunal do Júri, caberá apelação, no prazo de 5 dias, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia.

Apesar de a alínea somente fazer referência à nulidade posterior à pronúncia, desde que atendidos determinados requisitos, também poderão ser ventiladas nulidades ocorridas em momento anterior à pronúncia. Confirmam-se (LIMA, 2020, p. 1822):

I) NULIDADE RELATIVA, OCORRIDA ANTES DA PRONÚNCIA, E NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO: se a nulidade é do tipo relativa e ocorreu antes da pronúncia, o momento oportuno para sua alegação é o RESE contra a decisão de pronúncia (art. 581, inciso IV, CPP). Caso a parte não tenha a alegado nesse momento, operou-se a preclusão. Logo, esse vício não poderá ser objeto da apelação;

II) NULIDADE RELATIVA, OCORRIDA ANTES DA PRONÚNCIA, E ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO: caso a parte tenha, no RESE contra a pronúncia, alegado a existência de nulidade relativa ocorrida em momento anterior à pronúncia, tal matéria estará acobertada pela coisa julgada, não podendo ser rediscutida na apelação;

III) NULIDADE ABSOLUTA, OCORRIDA ANTES DA PRONÚNCIA, E ALEGADA NO RESE CONTRA A PRONÚNCIA: de igual forma, se a parte, por ocasião do RESE contra a pronúncia, já alegou determinada nulidade absoluta ocorrida antes da pronúncia, a matéria não poderá ser rediscutida na apelação, já que é protegida pelo manto da coisa julgada; e

IV) NULIDADE ABSOLUTA, OCORRIDA ANTES DA PRONÚNCIA, E NÃO ALEGADA NO RESE CONTRA A PRONÚNCIA: nesse caso, considerando que não há preclusão e nem proteção pela coisa julgada, mesmo que a nulidade absoluta tenha ocorrido antes da pronúncia, a parte poderá sustentá-la na apelação ora em análise.

Noutro giro, caso as nulidades posteriores à pronúncia sejam do tipo relativa e ocorram antes do início do julgamento, deverão ser alegadas logo nesse momento, isto é, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do art. 571, inciso V, do CPP. Caso a parte não o faça, verificar-se-á o fenômeno da preclusão. Logicamente, caso as nulidades ocorridas após a pronúncia sejam do tipo absoluta, não há falar em preclusão, podendo ser alegadas na apelação em estudo.

De mais a mais, caso o Tribunal *ad quem* reconheça a nulidade alegada, deverá determinar a realização de novo julgamento ou a renovação dos atos inquinados de nulidade, podendo tal hipótese de cabimento ser utilizada mais de uma vez, já que, caso se verifique, também



no novo julgamento, alguma nulidade, a parte poderá sustentá-la em nova apelação (LIMA, 2020, p. 1822).

#### **2.2.4.2.2. SENTENÇA DO JUIZ PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS**

Nos termos do art. 593, inciso III, alínea *b*, do CPP, das decisões do Tribunal do Júri, caberá apelação, no prazo de 5 dias, quando for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados.

Em complementação à alínea ora em estudo, diz o §1º que, se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o Tribunal *ad quem* fará a devida retificação.

Logo, caso a sentença do juiz presidente incorra em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, não há necessidade de anulação do julgamento, podendo o Tribunal *ad quem* corrigir o equívoco, já que tal ato não afrontará a soberania constitucional dos veredictos.

#### **2.2.4.2.3. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA OU DA MEDIDA DE SEGURANÇA**

Conforme art. 593, inciso III, alínea *c*, do CPP, das decisões do Tribunal do Júri, caberá apelação, no prazo de 5 dias, quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança.

Em complementação à alínea ora em estudo, diz o §2º que, se houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, o Tribunal *ad quem* retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Exemplo: apesar de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal serem favoráveis ao condenado, o juiz de primeira instância fixou a pena-base acima do mínimo legal. Nesse caso, pode o Tribunal *ad quem* retificar a pena cominada.

Noutro giro, muita atenção deve ser dispensada à exclusão ou inclusão de qualificadoras, privilégios, causas de aumento ou de diminuição de pena. Como tais circunstâncias dizem respeito à chamada tipicidade derivada, isto é, integram o próprio crime doloso contra a vida e são objeto de quesitação (art. 483, incisos IV e V, CPP), quando reconhecidas pelos Jurados, não podem ser afastadas pelo Tribunal *ad quem*, ou, quando não reconhecidas, aplicadas pela superior instância. Conforme será visto no estudo da alínea *d*, se tais circunstâncias destoarem do acervo probatório, o caso é de anulação do julgamento e não simples retificação da pena imposta (LIMA, 2020, p. 1823).

Assenta-se, por oportuno, que, considerando que as circunstâncias atenuantes e/ou agravantes não são objeto de quesitação, estas poderão ser reconhecidas ou afastadas pelo Tribunal *ad quem*, independentemente da decisão dos Jurados quanto a elas (LIMA, 2020, p. 1824).

Desse modo, à fora o reconhecimento ou afastamento de qualificadoras, privilégios, causas de aumento ou de diminuição de pena, pode o Tribunal *ad quem* retificar a pena imposta, sem necessidade de anulação do julgamento, assim como ocorre no caso de o juiz presidente proferir sentença em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados.

#### **2.2.4.2.4. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS**

Nos termos do art. 593, inciso III, alínea *d*, do CPP, das decisões do Tribunal do Júri, caberá apelação, no prazo de 5 dias, quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Inicialmente, registre-se que, conforme a própria redação do dispositivo legal em comento, somente há falar na invocação desta alínea *d* no caso de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Logo, não é qualquer decisão que poderá ser anulada com base no art. 593, inciso III, alínea *d*, do CPP.

Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, entende-se "aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria" (LIMA, 2020, p. 1824).

Nesse sentido, quando os Jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. É dizer: se há, nos autos, provas de duas versões, tendo os Jurados optado por uma delas, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos<sup>42</sup>. Exemplo: duas testemunhas falaram que viram o acusado matando a vítima. Noutro giro, duas testemunhas disseram que, no exato horário do crime, o acusado estava em uma festa distante do local do crime. Nesse caso, nem a absolvição nem a condenação serão manifestamente contrárias à prova dos autos (LIMA, 2020, p. 1824-1825).

Conforme introduzimos no tópico acima, "essa decisão manifestamente contrária à prova dos autos, que desafia a apelação prevista na alínea "d" do inciso III do art. 593 do CPP, pode estar relacionada tanto ao fato principal, à autoria, às causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, como versar sobre questão secundária, como o reconhecimento de uma qualificadora, causa de aumento ou de diminuição da pena" (LIMA, 2020, p. 1825).

De acordo com a primeira parte do art. 593, §3º, do CPP, caso o Tribunal *ad quem* se convença que a decisão dos Jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento, isto é, não pode o Tribunal *ad quem*, sob pena de violação à soberania constitucional dos veredictos, simplesmente, alterar a decisão dos Jurados. Exemplo: os Jurados condenam o réu por homicídio consumado qualificado por motivo torpe (art. 121, §2º, inciso I, do CP). Caso o Tribunal *ad quem* entenda que a qualificadora não encontra nenhuma guarida nos autos, deverá anular o julgamento concretizado e não apenas retirar a qualificadora reconhecida.

Nos termos da segunda parte do art. 593, §3º, do CPP, em razão da alínea c, pouco importando de quem partiu o primeiro recurso, não caberá uma segunda apelação. É dizer: anulado o primeiro julgamento, por ser a decisão dos Jurados manifestamente contrária à prova dos autos, não poderá haver nova apelação pelo mesmo motivo, o que não significa dizer que não caberá outra apelação contra este novo julgamento. Exemplo: contra um primeiro julgamento, a defesa, com fulcro no 593, inciso III, alínea d, do CPP, sustenta que a condenação é manifestação contrária à prova dos autos. O Tribunal *ad quem* concorda. Nesse caso, contra o novo julgamento, independentemente do resultado, isto é, se houve nova condenação ou absolvição, nem a defesa nem a acusação poderão se valer da alínea d. Todavia, poderão elas se valerem das alíneas a, b e/ou c contra esse novo julgamento.

#### 2.2.5. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES (UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL)

Conforme o já estudado princípio da unirrecorribilidade das decisões, nos termos do art. 593, §4º, do CPP, quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Frise-se: se é cabível apelação, mesmo que a parte somente recorra da matéria que, isoladamente considerada, desafiaria RESE, o recurso adequado será o de apelação.

Imagine o seguinte exemplo: João e José são denunciados pelo homicídio doloso de Pedro. Ao final da primeira fase do rito do Júri, na mesma decisão, o juiz desclassificou o fato em relação a João e impronunciou José. Nesse caso, isoladamente considerada, a decisão desclassificatória desafiaria RESE (art. 581, inciso II, do CPP). Também isoladamente avaliada, a

<sup>42</sup> AgRg no AREsp 96.517/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 30/4/2013.

decisão de impronúncia desafiaria apelação (art. 416, CPP). Contudo, ainda que o MP recorra somente da desclassificação, deverá interpor recurso de apelação, porquanto, nessa situação, nos termos do art. 593, §4º, do CPP, será esse o recurso cabível.

## 2.2.6. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO

O recurso de apelação deverá ser julgado pelas Câmaras dos Tribunais de Justiça e Turmas dos Tribunais Regionais Federais (LIMA, 2020, p. 1829).

## 2.2.7. EFEITO SUSPENSIVO

A apelação, que não é dotada do efeito regressivo (possibilidade de retratação), poderá ou não ser dotada de efeito suspensivo. Confirmam-se:

a) SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PRÓPRIA: nos termos do art. 596, *caput*, do CPP, a apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. No mesmo sentido, o art. 386, parágrafo único, inciso I, do CPP, diz que, na sentença absolutória, o juiz mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade. Assim, nota-se que a sentença absolutória própria implica na imediata soltura do absolvido, conseqüente esse que não está condicionado ao trânsito em julgado daquela sentença e nem estará impedido pela interposição de apelação pela acusação. Portanto, pode-se afirmar que a apelação contra sentença absolutória própria não é dotada de efeito suspensivo, pois não impede que a sentença absolutória produza seus regulares efeitos (LIMA, 2020, p. 1830);

b) SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA: de acordo com o art. 386, parágrafo único, inciso III, do CPP, na sentença absolutória, o juiz aplicará medida de segurança, se cabível. Nos termos do art. 171 da LEP, a execução da medida de segurança somente terá início após o trânsito em julgado da sentença que lhe aplicou. Assim, tendo em vista que a interposição de apelação impede o trânsito em julgado da sentença, indiretamente, também impedirá o início da execução da medida de segurança. Desse modo, apesar de não haver dispositivo legal expresso, a doutrina assenta que a apelação contra sentença absolutória imprópria é dotada de efeito suspensivo indireto, porquanto, ao impedir o trânsito em julgado, impedirá o início da execução da medida de segurança, que é o efeito regular da sentença absolutória imprópria. De mais a mais, deve ser rememorado que, à luz do art. 319, inciso VII, do CPP, é possível que o juiz, no curso da persecução penal ou no bojo da sentença absolutória imprópria, aplique a medida de internação provisória, desde que preenchidos os seus requisitos. Se a internação provisória for aplicada na sentença absolutória imprópria, a apelação não impedirá a sua imediata execução, cabendo ao absolvido impropriamente impetrar *habeas corpus*. Por fim, embora o art. 596, parágrafo único, do CPP, disponha que a apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente, é importante registrar que a medida de segurança provisória não mais existe no ordenamento jurídico, já que fora revogada pela reforma da Parte Geral do Código Penal e pela Lei de Execução Penal (LIMA, 2020, p. 1830); e

c) SENTENÇA CONDENATÓRIA: a pena imposta na sentença condenatória, seja multa, seja restritiva de direitos, seja prisão, somente poderá ser executada após o trânsito em julgado da condenação, razão pela qual se conclui que a apelação contra sentença condenatória é dotada de efeito suspensivo, já que impede a produção de seus regulares efeitos (AVENA, 2017, p. 841).

Por fim, convém ressaltar que, no caso do assistente de acusação, ainda que determinado recurso seja dotado de efeito suspensivo, quando interposto pelo assistente, a impugnação não terá tal efeito, nos termos da parte final do art. 598, *caput*, do CPP.

## 2.3. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (ART. 619, CPP)

### 2.3.1. INTRODUÇÃO E CABIMENTO

Disciplinados no art. 609, parágrafo único, do CPP, "os embargos infringentes e de nulidade funcionam como a impugnação destinada ao reexame de decisões não unânimes dos Tribunais de 2ª instância no julgamento de apelações, recursos em sentido estrito e agravos em execução, desde que desfavoráveis ao acusado" (LIMA, 2020, p. 1835).

Apesar de sempre serem referidos de forma conjunta, os embargos infringentes e os embargos de nulidade são recursos distintos. Os primeiros — embargos infringentes — são cabíveis quando o acórdão guerreado divergir sobre matéria de mérito. Noutro giro, os segundos — embargos de nulidade — são cabíveis quando o acórdão combatido divergir em matéria de nulidade processual (LIMA, 2020, p. 1835).

De tais notas introdutórias, já é possível extrair algumas características importantes acerca dos embargos infringentes e de nulidade:

I) somente cabem tais recursos contra acórdãos de apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução, que segue o mesmo rito do RESE, desde que desfavoráveis ao acusado;

II) não cabem embargos infringentes e de nulidade contra acórdãos não unânimes proferidos por Tribunais de 2ª instância no julgamento de *habeas corpus* e de revisão criminal;

III) os embargos infringentes e de nulidade são recursos exclusivos da defesa. Observe-se que há quem defenda que o Ministério Público poderá interpor embargos infringentes e de nulidade em favor do réu<sup>43</sup>;

IV) para que se possa pensar nos embargos infringentes e de nulidade, o acórdão não pode ter origem em julgamento unânime ("acórdão não unânime");

V) não são cabíveis embargos infringentes e de nulidade no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, porquanto estas não são Tribunais de 2ª instância (por óbvio, não cabem embargos infringentes e de nulidade contra sentença de primeira instância); e

VI) como o acórdão deve ser oriundo de apelação, RESE ou agravo em execução, não cabem embargos infringentes e de nulidade contra acórdão oriundo de julgamento originário dos Tribunais de 2ª instância (foro por prerrogativa de função)

### 2.3.2. DIVERGÊNCIA PARCIAL

Nos termos da parte final do art. 609, parágrafo único, do CPP, se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Exemplo: em julgamento de apelação defensiva, em uma Turma com três desembargadores, todos votam pela manutenção da condenação e da pena imposta na sentença. Contudo, no que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, dois deles votam pela manutenção do regime fechado, que havia sido imposto na sentença, e um deles vota pela fixação do regime semiaberto. Nesse caso, os embargos infringentes somente poderão versar sobre o regime inicial de cumprimento de pena.

### 2.3.3. PRAZO E FORMA DE INTERPOSIÇÃO

Conforme art. 609, parágrafo único, do CPP, o prazo comum para interposição e razões será de 10 dias, a contar da publicação do acórdão. Logo, considerando que a interposição e as

<sup>43</sup> REsp 10.715/PR, Rel. Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, SEXTA TURMA, julgado em 7/4/1992, DJ 4/5/1992, p. 5899.

razões recursais devem ser apresentadas de forma simultânea, os embargos infringentes e de nulidade somente poderão ser interpostos por petição.

De mais a mais, tem-se que a petição de interposição é apresentada ao Desembargador Relator do acórdão combatido, ao passo que as razões são endereçadas ao respectivo órgão julgador, que será definido de acordo com as leis de organização judiciária de cada Tribunal (LIMA, 2020, p. 1837).

## 2.4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

### 2.4.1. INTRODUÇÃO E CABIMENTO

Os embargos de declaração podem ser definidos "como o instrumento facultado às partes visando à integração (não à substituição) de decisões judiciais, sejam estas acórdãos, sentenças ou decisões interlocutórias" (AVENA, 2017, p. 846). São vícios que permitem a oposição dos embargos de declaração:

I) AMBIGUIDADE: "ocorre quando a decisão, em qualquer ponto, permite duas ou mais interpretações" (LIMA, 2020, p. 1840);

II) OBSCURIDADE: "ocorre quando não há clareza na redação da decisão judicial, de modo que não é possível que se saiba, com certeza absoluta, qual é o entendimento exposto na decisão" (LIMA, 2020, p. 1840);

III) OMISSÃO: "vício decorrente da falta de pronunciamento da decisão sobre ponto relevante" (AVENA, 2017, p. 846); e

IV) CONTRADIÇÃO: "ocorre quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si" (LIMA, 2020, p. 1840).

Os embargos de declaração podem ser opostos contra os seguintes pronunciamentos judiciais (AVENA, 2017, p. 846):

- decisões ou sentenças do juiz singular (art. 382, CPP);
- acórdãos dos Tribunais (arts. 619 e 620, CPP);
- decisões do juiz singular e acórdãos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais (art. 83, Lei nº 9.099/95);
- acórdãos do STJ (arts. 263 a 265, Regimento Interno do STJ); e
- acórdãos do STF (arts. 337 a 339 do Regimento Interno do STF).

### 2.4.2. PRAZOS

#### 2.4.2.1. JUÍZO SINGULAR ("EMBARGUINHOS")

Nos termos do art. 382 do CPP, qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Logo, considerando que a interposição e as razões recursais devem ser apresentadas de forma simultânea, os embargos de declaração contra decisão ou sentença de juízo singular somente poderão ser interpostos por petição, que deverá ser endereçada ao próprio juiz prolator da decisão ou sentença guerreada (AVENA, 2017, p. 847).

A princípio, não há intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, salvo se o embargante pretender que o juiz singular atribua efeitos modificativos (infringentes) aos embargos e não meramente integrativos da decisão ou sentença embargada (AVENA, 2017, p. 847), tema que será visto em tópico separado.



Nos termos do art. 1.026, *caput*, do CPC/15, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição dos demais recursos, ainda que não sejam acolhidos pelo juiz singular. No entanto, "se os embargos de declaração não forem conhecidos, em virtude, por exemplo, da intempestividade, não haverá a interrupção do prazo para oposição dos outros recursos. O início do prazo recursal terá tido início, portanto, no primeiro dia útil subsequente à intimação da decisão embargada" (LIMA, 2020, p. 1841-1842).

#### 2.4.2.2. ACÓRDÃOS DE TRIBUNAIS DE 2ª INSTÂNCIA

De igual forma, nos termos do art. 619 do CPP, o prazo dos embargos de declaração contra acórdãos dos Tribunais de 2ª instância é de 2 dias. Conforme art. 620, *caput*, do CPP, os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omissivo.

Logo, considerando que a interposição e as razões recursais devem ser apresentadas de forma simultânea, os embargos de declaração contra acórdãos dos Tribunais de 2ª instância somente poderão ser interpostos por petição, que deverá ser endereçada ao desembargador relator do acórdão combatido (AVENA, 2017, p. 847).

De mais a mais, os embargos de declaração serão apresentados pelo relator e julgados, independentemente de revisão, na primeira sessão (art. 620, §1º, CPP). Caso não preencham as condições de admissibilidade, o relator indeferirá desde logo os embargos (art. 620, §2º, CPP).

Também não há intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, salvo se o embargante pretender que o Tribunal atribua efeitos modificativos (infringentes) aos embargos e não meramente integrativos do acórdão embargado (AVENA, 2017, p. 847), tema que será visto em tópico separado.

Conforme art. 1.026, *caput*, do CPC/15, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição dos demais recursos, ainda que não sejam acolhidos pelo Tribunal de 2ª instância. Contudo,

se os embargos de declaração não forem conhecidos, em virtude, por exemplo, da intempestividade, não haverá a interrupção do prazo para oposição dos outros recursos. O início do prazo recursal terá tido início, portanto, no primeiro dia útil subsequente à intimação da decisão embargada (LIMA, 2020, p. 1841-1842).

#### 2.4.2.3. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

Nos termos do art. 83, *caput*, da Lei nº 9.099/95, cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Note-se que tal dispositivo legal não se refere à ambiguidade na decisão.

Diferentemente do que ocorre no CPP, a Lei nº 9.099/95 permite que os embargos de declaração sejam opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 5 dias, contados da ciência da decisão (art. 83, §1º). Frise-se: na Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração podem ser opostos de forma oral e o prazo é de 5 dias.

O art. 83, §2º, da Lei nº 9.099/95, com redação dada pelo CPC/15, passou a prever que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição dos demais recursos, o que ocorrerá ainda que os embargos não sejam acolhidos. Entretanto,

se os embargos de declaração não forem conhecidos, em virtude, por exemplo, da intempestividade, não haverá a interrupção do prazo para oposição dos outros recursos. O início do prazo recursal terá tido início, portanto, no primeiro dia útil subsequente à intimação da decisão embargada (LIMA, 2020, p. 1841-1842).



Por fim, conforme art. 83, §3º, da Lei nº 9.099/95, os erros materiais podem ser corrigidos de ofício, isto é, a correção de erros materiais não depende de oposição de embargos de declaração.

#### 2.4.3. EFEITOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Conforme já introduzimos, em regra, não há necessidade de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, já que estes visam, tão somente, esclarecer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão da decisão guerreada. Todavia,

na hipótese de *embargos de declaração com efeitos infringentes*, ou seja, aqueles que, diante da apreciação de ponto omissos da decisão, podem provocar a modificação do sentido do *decisum*, doutrina e jurisprudência são uníssonas em afirmar a necessidade de se intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões, em fiel observância ao princípio do contraditório (LIMA, 2020, p. 1841).

#### 2.5. CARTA TESTEMUNHÁVEL (ARTS. 639 AO 646, CPP)

##### 2.5.1. INTRODUÇÃO

A carta testemunhável é o "instrumento criado para obstar os problemas decorrentes de os juízes se ocultarem para não receber os recursos ou de determinarem aos escrivães que não lhes deem andamento" (LIMA, 2020, p. 1844).

##### 2.5.2. CABIMENTO

De acordo com o art. 639 do CPP, dar-se-á carta testemunhável: I - da decisão que denegar o recurso; e II - da que, admitindo embora o recurso, obstar à sua expedição e seguimento para o juízo *ad quem*.

Apesar de o inciso I do art. 639 do CPP dispor que caberá carta testemunhável da "decisão que denegar o recurso", tal dispositivo deve ser lido de forma subsidiária (caráter residual), isto é, somente será cabível a carta testemunhável se não couber outro recurso, como ocorre, por exemplo, em relação à apelação. Conforme estudamos, nos termos do art. 581, inciso XV, do CPP, da decisão que denegar a apelação ou julgá-la deserta caberá RESE. Logo, no caso do recurso de apelação, não caberá carta testemunhável.

Conforme inciso II do art. 639 do CPP, a carta testemunhável também é cabível contra a decisão que obstar o seguimento à instância superior de um recurso que já havia sido recebido pelo juízo *a quo*. É dizer: caso o recurso tenha sido recebido, mas, mesmo assim, não seja remetido ao juízo *ad quem*, também é cabível a carta testemunhável, desde que não haja outro recurso.

Tendo em vista que o art. 645 do CPP diz que o processo da carta testemunhável na *instância superior* seguirá o processo do recurso denegado, a doutrina entende que não é cabível carta testemunhável contra decisão que denega ou obsta seguimento a recursos que devam ser julgados pelo próprio juízo de 1ª instância, como ocorre, por exemplo, no caso dos embargos de declaração. É dizer: se a carta testemunhável deve ser processada pela instância superior, não poderá se prestar a combater decisões que denegam ou obstar seguimento a recursos que não alcançam tal instância.

Diante do que dissemos acima, e considerando, especialmente, o caráter subsidiário ou residual da carta testemunhável, de forma indene de dúvidas, tal recurso é cabível nas seguintes hipóteses (AVENA, 2017, p. 850):

- não recebimento ou negativa de seguimento ao recurso em sentido estrito; e
- não recebimento ou negativa de seguimento ao agravo em execução.

### 2.5.3. PROCEDIMENTO

Nos termos do art. 640 do CPP, a carta testemunhável é dirigida ao escrivão (justiça estadual), diretor de secretaria (justiça federal) ou secretário da presidência do tribunal respectivo, já que sua admissibilidade não é examinada na instância junto à qual foi proposta, mas unicamente no juízo *ad quem*. É dizer:

mesmo se intempestiva ou descabida, deverá ser encaminhada ao tribunal competente para seu julgamento, apenas este podendo deixar de conhecê-la sob o fundamento da ausência de pressuposto de admissibilidade. Por isso é que o art. 642 do CPP estabelece que o escrivão ou secretário do tribunal poderá ser suspenso se, por qualquer pretexto, não processar a carta testemunhável (AVENA, 2017, p. 850).

Conforme acima dito, nos termos do art. 645 do CPP, o processo da carta testemunhável na instância superior seguirá o processo do recurso denegado.

### 2.5.4. PRAZO E FORMA DE PROCESSAMENTO

Nos termos do art. 640 do CPP, a carta testemunhável será requerida ao escrivão, ou ao secretário do tribunal, conforme o caso, nas 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser trasladadas. Desse modo, a carta testemunhável sempre será processada por instrumento.

#### 2.5.4.1. EFEITO REGRESSIVO (ITERATIVO OU DIFERIDO)

Caso o recurso que tenha sido denegado ou obstado seguimento seja dotado de efeito regressivo, como ocorre no RESE e no agravo em execução, a carta testemunhável também será dotada de tal efeito.

### 2.5.5. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO

Conforme art. 646 do CPP, a carta testemunhável não terá efeito suspensivo, não impedindo, pois, que a decisão combatida produza seus regulares efeitos.

### 2.5.6. POSSIBILIDADE, NO JULGAMENTO DA CARTA, DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO OBJETO DO RECURSODENEGADO OU OBSTADO

De acordo com o art. 644 do CPP, Tribunal, Câmara ou Turma a que competir o julgamento da carta testemunhável, se desta tomar conhecimento, mandará processar o recurso, ou, se estiver suficientemente instruída, decidirá logo, *de meritis*.

Exemplo: o juiz indeferiu o pedido defensivo de declaração da extinção da punibilidade do réu. A defesa, com fulcro no art. 581, inciso IX, do CPP, interpõe recurso em sentido estrito. O juiz denega seguimento ao RESE. A defesa, com base no art. 639, inciso I, do CPP, interpõe carta testemunhável. Nesse caso, o juízo *ad quem* poderá: I) mandar processar o RESE denegado pelo juízo *a quo*; ou II) já enfrentar a questão atinente ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido defensivo de declaração da extinção da punibilidade do réu (AVENA, 2017, p. 852).

## 2.6. AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEI Nº 7.210/84 — LEP)

### 2.6.1. INTRODUÇÃO

Trazido pelo art. 197 da Lei nº 7.210/84 (LEP), "o agravo é o recurso cabível contra qualquer decisão do juiz da Vara de Execuções Criminais, por exemplo, saída temporária, progressão



e regressão de regime, livramento condicional, unificação de penas, *sursis*, incidentes da medida de segurança, conversões, homologação de faltas graves, trabalho externo etc." (AVENA, 2020, p. 848).

### 2.6.2. PROCEDIMENTO

Calcadas no art. 2º da LEP, a doutrina e a jurisprudência afirmam que o agravo em execução deve seguir o mesmo procedimento do recurso em sentido estrito (arts. 581 ao 592, CPP), razão pela qual o agravo em execução também é dotado do efeito regressivo (iterativo ou diferido — art. 589 do CPP).

### 2.6.3. PRAZO E FORMA DE INTERPOSIÇÃO

Tendo em vista que segue o mesmo procedimento do RESE, à luz do art. 586 do CPP e da Súmula nº 700 do STF, o prazo para a interposição do agravo em execução é de 5 dias. Nos termos do art. 588 do CPP, o prazo para as razões e contrarrazões recursais é de 2 dias. Considerando que as razões podem ser apresentadas após a interposição, o agravo em execução pode ser interposto por petição ou por termo nos autos (art. 578, *caput*, CPP).

### 2.6.4. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO

Nos termos do art. 197 da LEP, das decisões proferidas pelo Juiz da Execução Penal caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

Desse modo, a regra é que o agravo em execução não é dotado de efeito suspensivo, isto é, não impede que a decisão guerreada produza seus regulares efeitos.

Todavia, especial atenção deve ser conferida ao art. 179 da LEP, segundo o qual, transitada em julgado a sentença, o Juiz expedirá ordem para a desinternação ou a liberação. Assim, considerando que o art. 179 da LEP condiciona a desinternação ou liberação do inimputável ou semi-imputável cuja periculosidade tenha cessado ao trânsito em julgado da sentença, o agravo em execução interposto contra tal decisão é dotado de efeito suspensivo, já que, ao impedir o trânsito em julgado, impedirá a liberação ou desinternação do sujeito (LIMA, 2020, p. 1844).

## 2.7. CORREIÇÃO PARCIAL

### 2.7.1. INTRODUÇÃO

A correção parcial é "o instrumento destinado à impugnação de decisões judiciais que possam importar em inversão tumultuária do processo, sempre que não houver recurso específico previsto em lei" (LIMA, 2020, p. 1846).

Em outras palavras, a correção parcial é a medida cabível "contra ato do magistrado que, por erro ou abuso de poder, acarreta inversão tumultuária de atos processuais, dilatação abusiva de prazos ou paralisação injustificada de processos" (AVENA, 2017, p. 907).

Nesse contexto, deve ser registrado que a correção parcial não pode ser invocada para impugnar atos praticados pelas partes, serventuários da justiça, dos Tribunais ou de seus membros, prestando-se, unicamente, à correção de atos tumultuários dos juízes (LIMA, 2020, p. 1847).

### 2.7.2. HIPÓTESES DE CABIMENTO

Como dito nas notas introdutórias, a correção parcial destina-se "ao questionamento de decisões judiciais não impugnáveis por outros recursos e que representem erro ou abuso dos quais resulte a inversão tumultuária do processo. Visa à correção do *error in procedendo*, sendo incabível a sua interposição para impugnar as razões jurídicas da decisão judicial (*error in judicando*)" (LIMA, 2020, p. 1847).

Assim sendo, a correção parcial tem caráter subsidiário ou residual, já que não poderá ser utilizada nos casos em que há recurso legalmente previsto. Ademais, não poderá ser utilizada para questionar o mérito das decisões judiciais. Por esta razão, o STJ assentou, por exemplo, que não cabe correção parcial para questionar a decisão judicial que concede prisão domiciliar, já que não se trata de *error in procedendo* (LIMA, 2020, p. 1847).

A doutrina, assentando que a correção parcial pode ser utilizada em qualquer fase da persecução criminal, inclusive no rito sumaríssimo, cita alguns exemplos práticos de sua utilização, confirmam-se (LIMA, 2020, p. 1847):

a) decisão judicial negando a devolução dos autos de inquérito à Polícia para fins de realização de diligências complementares requisitadas pelo Ministério Público, tidas como imprescindíveis à formação da *opinio delicti*;

b) decisão judicial indeferindo o pedido formulado pelo Ministério Público de dilação do prazo para diligências necessárias à formação da convicção do titular da ação penal pública;

c) decisão que determinou o prosseguimento do feito, ao invés de determinar a suspensão do processo e do prazo prescricional na hipótese de acusado que, citado por edital, não compareceu, nem constituiu advogado, tal qual determina o art. 366 do CPP.

### 2.7.3. NATUREZA JURÍDICA

A doutrina, de forma bastante intensa, discute a natureza jurídica da correção parcial. Para alguns, sua natureza jurídica é de medida administrativa/disciplinar tendente a apurar uma atividade tumultuária do juiz, não passível de recurso. Para outra corrente, a correção parcial, no âmbito processual penal, tem natureza jurídica de recurso, porquanto serve para o Tribunal reformar a decisão judicial que tenha causado problemas ao regular desenvolvimento do processo, estando seu julgamento, em regra, afeto às Câmaras ou Turmas dos Tribunais (LIMA, 2020, p. 1848).

Também há corrente no sentido de que a correção parcial é recurso administrativo e outra no sentido de que, em verdade, a correção parcial é um sucedâneo recursal, isto é, uma categoria intermediária entre os recursos propriamente ditos e as medidas de natureza administrativa (AVENA, 2017, p. 907).

### 2.7.4. LEGITIMIDADE

Todos os atores do processo penal têm legitimidade para interpor a correção parcial. Apesar de alguma controvérsia na doutrina, o STJ tem assentado que o assistente de acusação não tem legitimidade para interpor correção parcial<sup>44</sup>.

### 2.7.5. EFEITO REGRESSIVO (ITERATIVO OU DIFERIDO)

Por economia processual,

a jurisprudência tem conferido efeito regressivo à correção parcial (juízo de retratação), facultando-se ao magistrado reconsiderar a sua decisão por ocasião do pedido de informações que lhe for encaminhado pelo Tribunal competente quando do processamento da medida (AVENA, 2017, p. 908).

<sup>44</sup>REsp 604.379/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2006, DJ 6/3/2006, p. 428.

## 2.7.6. PRAZO

Geralmente, o prazo da correição parcial tem sido fixado em 5 dias, contados da ciência da decisão ou despacho impugnado. Todavia, as leis de organização judiciária e os regimentos internos dos Tribunais podem prever prazo diverso (LIMA, 2020, p. 1848).

## 3. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA

### 3.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Súmula nº160, STF: “É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.”

Súmula nº 210, STF: “O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Cód. de Proc. Penal.”

Súmula nº 310, STF: “Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir.”

Súmula nº 344, STF: “Sentença de primeira instância concessiva de *habeas corpus*, em caso de crime praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, está sujeita a recurso *ex officio*.”

Súmula nº 423, STF: “Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso *ex officio*, que se considera interposto *ex lege*.”

Súmula nº 428, STF: “Não fica prejudicada a apelação entregue em cartório no prazo legal, embora despachada tardiamente.”

Súmula nº 448, STF: “O prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público.”

Súmula nº 453, STF: “Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.”

Súmula nº 700, STF: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.”

Súmula nº 707, STF: “Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo.”

Súmula nº 709, STF: “Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.”

Súmula nº 710, STF: “No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem.”

### 3.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Súmula nº347, STJ: “O conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão.”

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTERPOSIÇÃO DESSE RECURSO CONTRA DECISÃO DO JUIZ SINGULAR QUE REJEITOU O PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE PEÇAS, POR JULGÁ-LAS PERTINENTES AO DESLINDE DA CAUSA. DESCABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se interpretação extensiva ou analógica às

hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, "desde que a situação a que se busca enquadrar tenha similitude com as hipóteses do art. 581 do CPP" (REsp 197.661/PR, 6.ª Turma, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 1º/12/2008). 2. No caso, pretende o Recorrente interpretar extensivamente o inciso XIII do art. 581 do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento do referido recurso em face de decisão "que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte". No entanto, essa previsão não se assemelha à hipótese dos autos, na qual a Defesa pretende reformar decisum que indeferiu pedido de desentranhamento de peças admitidas pelo Magistrado Singular como prova emprestada. 3. Recurso desprovido. (REsp 1179202/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 6/9/2011, DJe 21/9/2011.)

### QUESTÕES

- 1- TJ/ES (Cebbraspe/UnB 2011 – adaptada)** Não se admite interpretação extensiva ou analógica às hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, ainda que a situação a que se busca enquadrá-la tenha similitude com as hipóteses descritas taxativamente no Código de Processo Penal.
- 2- PGR (PGR 2008 – adaptada)** O princípio da unirecorribilidade não é aplicável quando da interposição concomitante de recursos especial e extraordinário.
- 3- TJ/CE (Cebbraspe/UnB 2018 – adaptada)** O princípio da unirecorribilidade, singularidade ou unicidade prevê que a cada decisão judicial caberá apenas um único recurso.
- 4- MPE/PB (MPE/PB 2010 – adaptada)** Não podem ser objeto dos embargos infringentes e de nulidade, os acórdãos proferidos no julgamento de ações penais originárias.
- 5- TJ/SC (Cebbraspe/UnB 2019 – adaptada)** O princípio da fungibilidade deverá ser aplicado a todos os recursos que forem apresentados de forma indevida.
- 6- TJ/AL (Cebbraspe/UnB 2008 – adaptada)** Da sentença que absolver sumariamente o acusado, deverá o juiz recorrer de ofício ao tribunal de justiça.
- 7- TJ/BA (Cebbraspe/UnB 2012 – adaptada)** O órgão julgador de segunda instância não pode reconhecer, de ofício, nulidade não invocada no recurso da acusação, ainda que de caráter absoluto, em desfavor do réu.
- 8- TJ/RR (FCC 2015 – adaptada)** A proibição da *reformatio in pejus* não impede que o tribunal, mesmo em recurso da defesa, corrija erro material na sentença consistente em erro na somatória dos fatores considerados no processo de individualização, conforme já decidido pelo STF.
- 9- TJ/RS (TJ/RS 2009 – adaptada)** Quando a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça decide absolver o réu, mesmo diante de recurso exclusivo do Ministério Público, que pretendia aumentar a pena do acusado, fala-se em aplicação do princípio da *reformatio in mellius*.
- 10- MPE/PR (MPE/PR 2016 – adaptada)** É consolidado o entendimento dos Tribunais admitindo a possibilidade de *reformatio in mellius* no recurso impetrado exclusivamente pela acusação.
- 11- TJ/SC (TJ/SC 2013 – adaptada)** Denomina-se de juízo de prelibação a análise prévia sobre a admissibilidade de um recurso.
- 12- MPE/PR (MPE/PR 2019 – adaptada)** O juízo de prelibação pode ser feito de ofício pelo juízo *ad quem*.
- 13- MPE/GO (MPE/GO 2019 – adaptada)** A jurisprudência dominante do STJ tem entendido que com o advento do novo Código de Processo Civil, os prazos no âmbito penal também devem ser computados apenas nos dias úteis.
- 14- TJ/BA (Cebbraspe/UnB 2019 – adaptada)** O termo inicial para a interposição de recurso pelo MP é a data de prolação da sentença em audiência em que haja promotor de justiça presente.



**15- TJ/BA (Cebbraspe/UnB 2019 – adaptada)** Em razão do princípio da voluntariedade dos recursos, o defensor dativo regularmente intimado não estará obrigado a recorrer.

**16- TJ/BA (Cebbraspe/UnB 2019 – adaptada)** Em razão do princípio da voluntariedade, havendo conflito entre a manifestação do acusado e a de seu defensor a respeito da interposição de recurso, deverá prevalecer a vontade do réu.

**17- DPE/MA (Cebbraspe/UnB 2011 – adaptada)** A apresentação das razões de apelação fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso.

**18- DPE/PR (NC/UFPR 2014 – 2014)** O Ministério Público tem legitimidade para recorrer de sentença absolutória proferida em ação penal de iniciativa privada (ação privada propriamente dita), pois atua como fiscal da lei.

**19- MPE/GO (MPE/GO 2014 – adaptada)** A teoria do tanto vale não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro.

**20- MPE/PR (MPE/PR 2016 – adaptada)** São recursos dotados do efeito regressivo o RESE, a carta testemunhável e o agravo em execução, que segue o mesmo procedimento do RESE.

**21- MPE/PR (MPE/PR 2016 – adaptada)** Nas hipóteses de recurso *ex officio* (remessa obrigatória) opera o efeito translativo, devolvendo-se à instância superior o conhecimento integral da causa, vedada apenas ao órgão *ad quem* proceder à *reformatio in pejus*.

**22- MPE/MS (MPE/MS 2011 – adaptada)** Caberá Recurso em Sentido Estrito da decisão, despacho ou sentença que rejeitar a Denúncia ou Queixa no procedimento sumaríssimo

**23- DPE/MA (Cebbraspe/UnB 2011 – adaptada)** A extensão do recurso de apelação interposto pelo MP é aferida pelas razões de recurso, e não pela mera petição de sua interposição.

**24- DPE/MA (FCC 2018 – adaptada)** Acerca dos recursos no processo penal, é correto afirmar que segundo entendimento dominante dos Tribunais Superiores, a apresentação tardia das razões implica em intempestividade do recurso, ainda que interposto dentro do prazo legal.

**25- MPE/RO (Cebbraspe/UnB – adaptada)** O fato de a sentença do juiz-presidente ser contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados ou o fato de haver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança não implicam a anulação do julgamento, já que, nesses casos, o próprio tribunal deverá proceder à correção, quando do exame do recurso de apelação.

**26- MPE/PA (FCC 2014 – adaptada)** Em relação às ações de impugnações e aos recursos no processo penal, é correto afirmar que não tem efeito suspensivo o recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que denegar a apelação.

**27- DPE/RS (FCC 2018 – adaptada)** É possível ao Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação exclusiva do réu, aplicar a *emendatio libelli* (art. 383 do CPP), dando à imputação nova definição jurídica sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa mas, em qualquer caso, não poderá aplicar ao réu pena mais grave do que aquela definida em sentença, pela vedação da *reformatio in pejus*.

**28- MP/DFT (MP/DFT 2004 – adaptada)** Ainda que o provimento dos embargos declaratórios resulte em modificação do julgado, não há espaço para manifestação prévia da parte contrária, haja vista a natureza e os fins desse meio de impugnação.

**29- TJ/RJ (VUNESP 2011 – adaptada)** Réu que teve declarada extinta a punibilidade por prescrição pode recorrer pedindo decisão de mérito da acusação.

**30- DPE/MG (FUNDEP 2019 – adaptada)** Da decisão que determinar a desinternação do inimputável caberá agravo em execução, que será recebido com efeito suspensivo.

## COMENTÁRIOS

## 1. ERRADO. Apesar da taxatividade dos recursos,

não se pode concluir pela impossibilidade de interpretação extensiva da norma processual penal, nem tampouco pela inviabilidade de aplicação analógica, como expressamente admitido, aliás, pelo art. 3º do CPP. É exatamente o que ocorre, a título de exemplo, com as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, previstas no art. 581 do CPP. Há quem diga que não é possível a interpretação extensiva do referido rol. Na verdade, o que não se admite é a ampliação para casos em que a lei evidentemente quis excluir (LIMA, 2020, p. 1710).

## 2. CORRETO. Uma das exceções ao princípio da unirrecorribilidade recursal é a interposição concomitante do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial.

## 3. CORRETO. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como unicidade ou singularidade recursal, "cada espécie de decisão judicial, em regra, comporta um único recurso, sendo ônus da parte escolher o recurso adequado para que haja seu reexame" (TÁVORA; ALENCAR, p. 1335).

## 4. CORRETO. Como o acórdão deve ser oriundo de apelação, RESE ou agravo em execução, não cabem embargos infringentes e de nulidade contra acórdão oriundo de julgamento originário dos Tribunais de 2ª instância (foro por prerrogativa de função).

5. ERRADO. Nos casos em que for verificada a má-fé, nos termos do art. 579, *caput*, do CPP, não há falar na aplicação do princípio da fungibilidade.

## 6. ERRADO. O art. 574, inciso II, do CPP, diz que também haverá reexame de ofício da sentença que desde logo absolver o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, evitando sua submissão ao julgamento pelos Jurados (absolvição sumária no rito do Júri). Todavia, diante dos arts. 415 e 416 do CPP, com redação dada pela Lei nº 11.689/08, a doutrina e a jurisprudência entendem que tal hipótese restou revogada. É dizer: no rito do Júri, contra a absolvição sumária, somente caberá apelação (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 1333).

## 7. CORRETO. Não pode o órgão julgador de segunda instância reconhecer, de ofício, nulidade não invocada no recurso da acusação, mesmo sendo ela de caráter absoluto (aplicação da Súmula nº 160 do STF), devendo ficar limitado à matéria impugnada pelo recorrente (HC 73.180/SC, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2007, DJ 1º/10/2007, p. 313).

8. ERRADO. Em se tratando de recurso exclusivo da defesa, o juízo *ad quem*, mesmo diante de simples erro material na decisão, não poderá piorar a situação do recorrente.9. CORRETO. Quando, em recurso exclusivo da acusação, o juízo *ad quem* melhora a situação do réu, fala-se em *reformatio in mellius*, que, a despeito de alguma controvérsia na doutrina, é admitida no âmbito da jurisprudência dos Tribunais Superiores.10. CORRETO. De acordo com o STJ, "é admitida a *reformatio in melius*, em sede de recurso exclusivo da acusação, sendo vedada somente a *reformatio in pejus*" (REsp 628.971/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 16/3/2010, DJe 12/4/2010).

## 11. CORRETO. O juízo de prelibação "consiste na verificação da presença dos pressupostos recursais de admissibilidade" (AVENA, 2017, p. 714).

12. CORRETO. Na maioria das espécies recursais, o juízo de prelibação ocorre no juízo *a quo* e no juízo *ad quem*, a exemplo da apelação, do recurso em sentido estrito, do agravo em execução, dentre tantos outros. Nesses casos, ainda que julgado admissível o recurso no juízo *a quo*, nada impede seja considerado inadmissível no juízo *ad quem* (AVENA, 2017, p. 714).

**13. ERRADO.** Apesar de o novo CPC ter previsto que, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis, tal dispositivo não se aplica ao processual penal. É dizer: no processo penal, o prazo continua sendo contado de forma contínuo e, uma vez iniciado, em regra não se interromperá (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017).

**14. ERRADO.** De forma semelhante à Defensoria Pública, o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado (STJ. 3ª Seção. REsp 1.349.935-SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 23/8/2017, recurso repetitivo - Info 611).

**15. CORRETO.** A característica da voluntariedade dos recursos também se aplica ao Defensor Público ou dativo, isto é, mesmo os defensores não constituídos pelo réu não estão obrigados a recorrer (HC 153.909/RO, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 6/2/2012).

**16. ERRADO.** Pelo teor da Súmula nº 705 do STF, se o réu, desacompanhado de advogado, renuncia ao direito de apelação, não restará impedido o conhecimento da apelação interposta por advogado. O contrário também é verdadeiro: se a defesa técnica renuncia ao direito de apelação e o réu manifesta interesse em recorrer, a apelação também deverá ser recebida. É dizer: prevalece a vontade de quem quer recorrer.

**17. CORRETO.** O pressuposto processual objetivo da tempestividade diz respeito à interposição do recurso e não à apresentação das razões. É dizer: no juízo de prelibação, será analisada se a interposição foi tempestiva, pouco importando se a apresentação das razões recursais se deu fora do prazo legal. Nesse sentido: "A apresentação extemporânea das razões recursais pela parte, mesmo acusadora, não tem o condão de prejudicar recurso em sentido estrito tempestivamente interposto" (HC 365.333/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).

**18. ERRADO.** Na ação penal privada comum ou personalíssima, em razão da disponibilidade que rege tais espécies de ação, o Ministério Público não poderá recorrer de eventual sentença absolutória (LIMA, 2020, p. 1784-1785).

**19. ERRADO.** A fungibilidade recursal, que também é chamada de teoria do recurso indiferente", "teoria do 'tanto vale'", princípio da permutabilidade dos recursos ou princípio da conversibilidade dos recursos, encontra guarida no art. 579, *caput*, do CPP.

**20. CORRETO.** São recursos dotados do efeito regressivo o RESE, a carta testemunhável e o agravo em execução, que segue o mesmo procedimento do RESE.

**21. ERRADO.** Em decorrência do efeito translativo, que somente ocorre nos chamados recursos de ofício, o juízo *ad quem* tem o poder de apreciar toda a matéria, pouco importando se beneficiará ou prejudicará qualquer das partes (LIMA, 2020, p. 1791).

**22. ERRADO.** Nos termos do art. 581, inciso I, do CPP, caberá recurso em sentido estrito da decisão que não receber a denúncia ou a queixa, o que não é aplicável ao rito comum sumaríssimo. Frise-se: o art. 581, inciso I, do CPP, somente se aplica ao rito comum, ordinário e sumário, e aos procedimentos especiais, não incidindo sobre o rito comum sumaríssimo. De acordo com o art. 82, *caput*, da Lei nº 9.009/95, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

**23. ERRADO.** Em regra, a delimitação da extensão do recurso deve ser feita pela parte na peça de interposição, isto é, logo na interposição, a parte deve indicar os fundamentos do apelo, o que vale tanto para a acusação (Ministério Público, assistente de acusação ou defesa) como para a defesa.

**24. ERRADO.** A jurisprudência entende que a apresentação das razões de apelação fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta o conhecimento do apelo (HC n. 269.584/DF, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 9/12/2015).

**25. CORRETO.** Nos termos do art. 593, §§2º e 3º, do CPP, à fora o reconhecimento ou afastamento de qualificadoras, privilégios, causas de aumento ou de diminuição de pena, pode o Tribunal *ad quem* retificar a pena imposta, sem necessidade de anulação do julgamento, assim como ocorre no caso de o juiz presidente proferir sentença em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados.

**26. ERRADO.** Nos termos do art. 584, *caput*, do CPP, o RESE contra a decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta (art. 581, inciso XV, CPP) é dotado de efeito suspensivo.

**27. CORRETO.** Nos termos do art. 617 do CPP, é cabível a *emendatio libelli* na segunda instância, desde que, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, a pena imposta não seja agravada. Assim, é possível que o Tribunal, Câmara ou Turma, sem modificarem a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, atribuam-lhe nova definição jurídica, contudo, se for recurso exclusivo da defesa, diante da vedação da *reformatio in pejus*, a pena não poderá ser agravada.

**28. ERRADO.** Em regra, não há necessidade de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, já que estes visam, tão somente, esclarecer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão da decisão guerreada. Todavia, "na hipótese de embargos de declaração com efeitos infringentes, ou seja, aqueles que, diante da apreciação de ponto omissos da decisão, podem provocar a modificação do sentido do *decisum*, doutrina e jurisprudência são uníssonas em afirmar a necessidade de se intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões, em fiel observância ao princípio do contraditório" (LIMA, 2020, p. 1841).

**29. ERRADO.** Calcada principalmente na Súmula nº 18 do STJ, a jurisprudência entende que não há interesse recursal da defesa em relação à declaração da extinção da punibilidade do réu. É dizer: diferentemente do que ocorre em outros ordenamentos jurídicos, extinta a sua punibilidade, o réu não poderá buscar o reconhecimento de sua inocência, mesmo que a declaração da extinção da punibilidade se dê durante o tramitar recursal (LIMA, 2020, p. 1783).

**30. CORRETO.** Nos termos do art. 197 da LEP, das decisões proferidas pelo Juiz da Execução Penal caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Todavia, especial atenção deve ser conferida ao art. 179 da LEP, segundo o qual, transitada em julgado a sentença, o Juiz expedirá ordem para a desinternação ou a liberação. Assim, considerando que o art. 179 da LEP condiciona a desinternação ou liberação do inimputável ou semi-imputável cuja periculosidade tenha cessado ao trânsito em julgado da sentença, o agravo em execução interposto contra tal decisão é dotado de efeito suspensivo, já que, ao impedir o trânsito em julgado, impedirá a liberação ou desinternação do sujeito (LIMA, 2020, p. 1844).

## CAPÍTULO 24 – HABEAS CORPUS (ARTS. 647 A 667, CPP)

### 1. CONCEITO, NATUREZA JURÍDICA E ESPÉCIES (ART. 647 DO CPP)

À luz do art. 5º, inciso LXVIII, CF/88, "conceder-se-á *habeas corpus* sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder", tratando-se o *habeas corpus*, nesse sentido, de ação autônoma de impugnação (não é recurso), de índole constitucional, que visa manter ou reestabelecer a liberdade ambulatorial.

De forma bastante semelhante à CF/88, dispõe o art. 647 do CPP que "dar-se-á *habeas corpus* sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar".

Assim sendo, considerando as suas finalidades, traz a doutrina duas espécies de *habeas corpus*:

I) REPRESSIVO OU LIBERATÓRIO: tem por objetivo restituir a liberdade de quem já se encontra ilegalmente encarcerado, sendo, no caso de concessão da ordem de *habeas corpus*, expedido o competente alvará de soltura, colocando-se o paciente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, conforme art. 660, § 1º, do CPP; e

II) PREVENTIVO: tem por finalidade evitar que eventual ameaça ilegal à liberdade se materialize na expedição de um mandado de prisão, concedendo-se, em caso de deferimento da ordem, um salvo-conduto ao paciente, conforme art. 660, § 4º, do CPP.

É importante ressaltar, em relação ao *habeas corpus* do tipo preventivo, que o STJ tem sustentado que tal espécie somente "tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, isto é, sempre que fundado for o receio de ser o paciente preso ilegalmente. E tal receio haverá de resultar de ameaça concreta de iminente prisão" (AgRg no HC 108.655/SP).

Além dessas, a doutrina ainda elenca outras duas espécies de *habeas corpus*, as quais, embora menos recorrentes em provas de concurso, merecem alusão:

III) SUSPENSIVO: tem por objetivo impedir o cumprimento de um mandado de prisão ilegalmente expedido, concedendo-se, no caso de deferimento da ordem, um contramandado de prisão ao paciente, evitando-se que ele seja efetivamente encarcerado; e

IV) PROFILÁTICO: tem por finalidade "suspender atos processuais ou impugnar medidas que possam importar em prisão futura com aparência de legalidade, porém intrinsecamente contaminada por ilegalidade anterior", como ocorre, por exemplo, no caso de impetração de *habeas corpus* com o objetivo de trancar um inquérito policial em curso ou no caso do juiz julgar improcedente a exceção de incompetência (AVEVA, 2017, p. 880).

#### 1.1. PUNIÇÃO DISCIPLINAR (ART. 647, PARTE FINAL, DO CPP)

Em consonância com o art. 142, § 2º, CF/88, diz a parte final do art. 647 do CPP que não é cabível o *habeas corpus* nos casos de punição disciplinar, o que deve ser lido com ressalvas.

Quanto ao tema, o STF, no julgamento do RHC nº 88.543/SP, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, assentou que, por intermédio do *habeas corpus*, de fato, não é possível se discutir o mérito da punição disciplinar, todavia, poderão ser objeto de análise seus aspectos formais, tais como a competência da autoridade que a aplicou.

Assim, se um militar das Forças Armadas, em razão de falta injustificada ao serviço, é punido com 5 (cinco) dias de prisão, não se pode discutir a justeza da medida, se exagerada ou não,

entretanto, poderá ser usado o *habeas corpus* se, por exemplo, a autoridade que a aplicou somente tinha atribuição de punir seus inferiores hierárquicos com, no máximo, 2 (dois) dias de prisão.

### 1.2. NECESSIDADE DE RISCO OU EFETIVO CERCEAMENTO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO

Funcionando como verdadeira condição de admissibilidade do *habeas corpus*, somente há falar na possibilidade de seu manejo se à infração penal imputada ao paciente for cominada pena privativa de liberdade, prevendo a Súmula nº 693 do STF que "não cabe *habeas corpus* contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada".

No mesmo sentido, prevê a Súmula nº 694 do STF que "não cabe *habeas corpus* contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública".

A Súmula nº 695 do STF, pela mesma razão, dispõe que "não cabe *habeas corpus* quando já extinta a pena privativa de liberdade", porquanto não há mais risco à liberdade de locomoção.

É interessante assentar que o STF, no julgamento dos HC nº 147.426/AP e 147.303/AP, ambos de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que é cabível a impetração de *habeas corpus* com a finalidade de impugnar medidas cautelares pessoais de natureza criminal diversas da prisão, porquanto há restrição à liberdade ambulatorial e, a depender das circunstâncias, possibilidade de decretação de prisão.

Por fim, convém mencionar que, à luz do art. 659 do CPP, se, no curso do processamento do *habeas corpus* impetrado, o juiz ou o Tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, como ocorre, por exemplo, no caso em que, antes do julgamento do HC perante o Tribunal de Justiça, o juiz de primeira instância revoga a prisão preventiva outrora decretada.

### 1.3. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO

O chamado *habeas corpus* substitutivo "consiste na faculdade outorgada ao interessado de optar pela impetração de novo *habeas corpus* ao Tribunal imediatamente superior, ao invés de ter que interpor o recurso previsto em lei" (LIMA, 2017, p. 1766).

Seu cabimento se fundava no fato de que, ao denegar a ordem do anterior HC, o juiz ou o Tribunal passavam à condição de autoridade coatora, razão pela qual o interessado podia impetrar novo *writ* em substituição a eventual recurso previsto em lei (LIMA, 2017, p. 1766).

Ocorre que, mais recentemente, visando dar efetividade aos arts. 102, inciso II, alínea *a*, e 105, inciso II, alínea *a*, ambos da CF/88, o STF (HC nº 109.956/PR) e o STJ (HC nº 169.556/RJ) têm inadmitido a impetração do *habeas corpus* substitutivo, devendo a parte, caso queira impugnar decisões denegatórias proferidas em única instância por Tribunais Superiores, interpor o recurso ordinário constitucional junto ao STF. De igual forma, deverá manejar o recurso ordinário constitucional junto ao STJ se quiser reverter decisões denegatórias proferidas em única ou última instâncias pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e dos Territórios.

Assim, nota-se que, objetivando fazer cessar o excessivo incremento das hipóteses de admissibilidade do HC, os Tribunais Superiores "passaram a rechaçar a sua utilização em substituição das vias recursais ordinárias (apelação, agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso ordinário constitucional etc.)" (AVENA, 2017, p. 890).

Frise-se, entretanto, que, mesmo sendo impetrado o chamado *habeas corpus* substitutivo, o Tribunal poderá conceder, de ofício, a ordem, nos casos em que restarem demonstradas a ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia jurídica (TÁVORA; ALENCAR, 2017, 1599).



#### 1.4. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DA REVISÃO CRIMINAL

Assim como acontece em relação aos recursos propriamente ditos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores também não tem admitido a impetração de *habeas corpus* em substituição à revisão criminal, "salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia" (STF, RHC 118.994/BA, 2ª T., rel. Min. Ricardo Lewandowski).

#### 1.5. HABEAS CORPUS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

A suspensão condicional do processo, aplicável aos crimes cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 (um) ano, impõe ao réu o cumprimento de uma série de condições, nos termos do art. 89, *caput* e §§1º e 2º, da Lei nº 9.099/95.

Nesse contexto, tendo em vista que, descumpridas as condições, durante o período de prova, o processo penal em desfavor do beneficiário poderá ser retomado, a jurisprudência entende que, ainda que haja a suspensão condicional do processo, é possível a impetração de *habeas corpus* em favor do beneficiário, postulando, por exemplo, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa (STJ. 5ª Turma. RHC 41527-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 3/3/2015 - Info 557).

#### 1.6. HABEAS CORPUS E TRANSAÇÃO PENAL

A transação penal, aplicável às infrações penais de menor potencial ofensivo, isto é, todas as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não supere a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa, consiste na aplicação imediata de penas restritivas de direitos, nos termos do art. 76 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, como dito acima, em relação à suspensão condicional do processo, a jurisprudência se mostra pacífica quanto à admissibilidade do *habeas corpus* em favor do beneficiário de tal instituto, o que não se pode dizer em relação à transação penal, porquanto, no que diz respeito a esse último instituto, há importante divergência entre o STJ e o STF.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da transação penal impede a impetração de *habeas corpus* em que se busca o trancamento da ação penal (STJ. 6ª Turma. HC 495.148-DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/9/2019 - Info 657).

Noutro giro, o Supremo Tribunal Federal, assentando que não se pode admitir que a transação penal possa impor obrigações ao beneficiário que nem poderia ser submetido à persecução penal por ausência de justa causa ou atipicidade da conduta, por exemplo, decidiu que a aceitação do acordo de transação penal não impede o exame de *habeas corpus* para questionar a legitimidade da persecução penal (STF. 2ª Turma. HC 176785/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 17/12/2019 - Info 964).

### 2. FORMALIDADES

#### 2.1. IMPETRANTE, PACIENTE E IMPETRADO

Atuam no processo de *habeas corpus* três sujeitos processuais: o impetrante, o paciente e o impetrado.

O impetrante é a pessoa, física ou jurídica, que ajuíza o *habeas corpus*, não sendo dela exigida capacidade postulatória, isto é, não é necessário que o impetrante seja advogado, nos termos do art. 654, *caput*, do CPP, o qual, aliás, diz que o Ministério Público é dos legitimados à impetração do *writ*.

Ainda no que diz respeito ao impetrante, registre-se que não é exigida deste nem mesmo capacidade civil, isto é, o *habeas corpus* poderá ser impetrado por pessoa civilmente incapaz, sendo cabível, ainda, sua impetração por analfabeto, desde que alguém assine a seu rogo, conforme art. 654, §1º, alínea c, do CPP (AVENA, 2017, p. 883).



É importante frisar, ademais, que, à luz do art. 654, § 2º, do CPP, "os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de *habeas corpus*, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal", sendo aqui verificada uma exceção ao princípio da inércia.

A seu turno, o paciente é a pessoa física que está sofrendo ou está em vias de sofrer coação ilegal em sua liberdade de locomoção, sendo, pois, "a pessoa em favor de quem o *habeas corpus* é ajuizado" (TÁVORA; ALENCAR, 2017, 1591).

Como visto, o impetrante pode ser pessoa física ou jurídica, todavia, somente a pessoa física poderá figurar como paciente, já que a pessoa jurídica não poderá ser cominada pena privativa de liberdade, sendo a ela facultado o manejo do mandado de segurança em matéria criminal.

O impetrado, também denominado de demandado, parte passiva ou coator, "é a pessoa — autoridade ou não — responsável pelo ato apontado como lesivo à liberdade de locomoção" (TÁVORA; ALENCAR, 2017, 1591), devendo ser frisado que o impetrado pode ser um particular, como ocorre, por exemplo, no caso de um diretor de hospital privado que se recusa a liberar determinada pessoa por falta de pagamento das despesas existentes.

## 2.2. PETIÇÃO INICIAL (ART. 654, § 1º, DO CPP)

Dispõe o art. 654, § 1º, CPP, que a petição inicial do *habeas corpus* deverá preencher os seguintes requisitos:

- a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça;
- b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor;
- c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências.

Nesse contexto, apesar de não ser exigida capacidade postulatória do impetrante, é necessário que a petição inicial do *habeas corpus* esteja assinada, vedando-se a impetração apócrifa.

Ademais, alerta a doutrina que, embora o estrangeiro possa figurar como impetrante, a petição deverá ser redigida em português (NUCCI, 2016, p. 1029).

## 2.3. HIPÓTESES DE IMPETRAÇÃO (ART. 648 DO CPP)

As hipóteses de impetração ou de cabimento do *habeas corpus*, que, como visto, somente se presta à tutela da liberdade de locomoção, estão previstas, de forma não taxativa, no art. 648, *caput*, do CPP, sendo elas individualmente trabalhadas a seguir:

I) QUANDO NÃO HOUVER JUSTA CAUSA: duas são as espécies de justa causa retratadas no art. 648, inciso I, do CPP, existindo, nesse contexto, a denominada justa causa formal, cuja ausência se verifica pela inexistência de lastro probatório mínimo, e a justa causa material, que é visualizada pela ilegalidade flagrante da persecução penal, possibilitando-se o seu trancamento ou o relaxamento da prisão. Portanto, deve a expressão justa causa, para fins de cabimento do *habeas corpus*, ser interpretada de forma abrangente (LIMA, 2017, p. 1776);

II) QUANDO ALGUÉM ESTIVER PRESO POR MAIS TEMPO DO QUE DETERMINA A LEI: conforme art. 648, inciso II, do CPP, se alguém estiver preso por período superior ao legalmente permitido, é possível a impetração de *habeas corpus* em seu favor.

É interessante registrar, quanto ao ponto, que a Lei nº 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade), positivando o que já era assentado pela jurisprudência, alterou o art. 2º, § 7º, da Lei nº 7.960/89 (Lei da Prisão Temporária), dispondo que, expirado o prazo da medida, a autoridade

responsável pela custódia, sem necessidade de nova ordem judicial, deverá colocar em liberdade o preso, salvo se a temporária for renovada ou tiver sido decretada a preventiva.

Nesse contexto, se, expirado o prazo da temporária, a autoridade responsável pela custódia não restituir a liberdade do preso, poderá haver a impetração de *habeas corpus* em seu favor, sendo o pedido fundado no art. 648, inciso II, do CPP.

III) QUANDO QUEM ORDENAR A COAÇÃO NÃO TIVER COMPETÊNCIA PARA FAZÊ-LO: em consonância com o art. 5º, incisos XXXVII, LIII, LXI, LXII, LXV e LXVI, CF/88, disciplina o art. 648, inciso III, do CPP, que também é cabível a impetração de *habeas corpus* quando alguém estiver preso ou em vias de ter sua liberdade de locomoção restringida em virtude de ordem emanada por autoridade que não tenha competência para tanto, já que se trata de ordem manifestamente ilegal.

Com base em tal inciso, o STJ, no julgamento do HC 103.134/MT, de relatoria do Min. Jorge Mussi, assentou a ilegalidade de prisão determinada por juiz estadual em decorrência de fatos sujeitos a julgamento perante a Justiça Federal, independentemente da motivação do ato prisional.

IV) QUANDO HOUVER CESSADO O MOTIVO QUE AUTORIZOU A COAÇÃO: considerando que os pressupostos autorizadores das medidas cautelares pessoais, prisionais ou não, devem estar presentes não só no momento da imposição de tais medidas, caso eles desapareçam, elas deverão ser revogadas, a teor do disposto no art. 282, § 5º e art. 316 do CPP.

Nesse contexto, decretando-se a prisão preventiva do acusado, porquanto este estava ameaçando uma testemunha ao longo da persecução penal e vindo esta a falecer em decorrência de um acidente automobilístico, por exemplo, não há mais pressuposto fático à manutenção do encarceramento provisório, devendo haver a revogação da prisão preventiva. Caso contrário, poderá ser impetrado um *habeas corpus* em favor daquele preso, com fundamento no art. 648, inciso IV, do CPP.

V) QUANDO NÃO FOR ALGUÉM ADMITIDO A PRESTAR FIANÇA, NOS CASOS EM QUE A LEI A AUTORIZA: em consonância com o art. 5º, inciso LXVI, CF/88, dispõe o art. 648, inciso V, do CPP, que é ilegal a restrição à liberdade de quem não foi admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a admite.

O CPP não traz, de forma expressa, quais as infrações que comportam o arbitramento de fiança, contudo, em seus arts. 323 e 324, disciplina os casos em que não caberá a fiança: a) nos crimes de racismo (devendo ser aqui incluído o crime de injúria racial, nos termos assentado pelo STF no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 983.531/DF, de relatoria do Min. Roberto Barroso); b) nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos; c) nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; d) aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os arts. 327 e 328 deste Código; e) em caso de prisão civil ou militar; e f) quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312).

Destarte, cabível a fiança e não havendo o seu arbitramento, elucida o art. 660, § 3º, CPP, que, sendo, com base nesse fundamento, concedida ordem, o julgador do *habeas corpus* impetrado arbitrar o valor da fiança, que poderá ser prestada perante ele, remetendo, nesse caso, à autoridade os respectivos autos, para serem anexados aos do inquérito policial ou aos do processo judicial.

VI) QUANDO O PROCESSO FOR MANIFESTAMENTE NULO: o *habeas corpus* fundado na manifesta nulidade do processo (art. 648, inciso VI, CPP) poderá ser impetrado, inclusive, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria, desde que se trate de nulidade absoluta, porquanto, no caso de nulidade relativa, não sendo esta arguida no momento oportuno,

ocorrerá a preclusão temporal, convalidando-se o ato, nos termos do art. 571 do CPP (LIMA, 2017, p. 1786);

VII) QUANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE: assim como na hipótese anterior, o *habeas corpus* baseado na extinção da punibilidade do agente (art. 648, inciso VII, CPP) poderá ser impetrado, inclusive, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria (LIMA, 2017, p. 1786).

### 2.3.1. NOVO PEDIDO DE *HABEAS CORPUS*

A decisão judicial referente a determinado processo de *habeas corpus* não faz coisa julgada, sendo admissível a impetração de um novo pedido objetivando fazer cessar o mesmo constrangimento ilegal que ensejou o *writ* anterior, desde que sejam utilizados novos fundamentos. A ameaça ou coação ilegal à liberdade é a mesma, contudo, a fundamentação do pedido deve ser distinta. É dizer: admite-se, por exemplo, um segundo pedido de *habeas corpus* contra um mesmo decreto prisional, sendo exigido, todavia, que os fundamentos utilizados não sejam idênticos (LIMA, 2017, 1776).

### 2.4. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO

Para fins didáticos, transcreve-se tabela organizada pelo Professor Norberto Avena, que compilou as disposições constitucionais e jurisprudenciais atinentes ao tema, trazendo um quadro-resumo bastante útil às provas de concurso. Confira-se (AVENA, 2017, p. 886-887):

| <u>COMPETÊNCIA P/<br/>JULGAMENTO</u>        | <u>PACIENTE/COATOR</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>PREVISÃO<br/>CONSTITUCIONAL</u> |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <u>SUPREMO<br/>TRIBUNAL FEDERAL</u>         | Quando forem <u>PACIENTES</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente da República;</li> <li>• Vice-Presidente da República;</li> <li>• Membros do Congresso Nacional;</li> <li>• Ministros dos Tribunais Superiores;</li> <li>• Procurador-Geral da República;</li> <li>• <u>Ministros de Estado</u>;</li> <li>• <u>Comandantes das Forças Armadas</u>;</li> <li>• Ministros do TCU;</li> <li>• Chefes de missão diplomática em caráter permanente.</li> </ul>                                    | Art. 102, inciso I, alínea "d"     |
|                                             | Quando forem <u>COATORES</u> Tribunais Superiores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Art. 102, inciso I, alínea "i"     |
|                                             | Quando forem <u>COATORES</u> ou <u>PACIENTES</u> autoridades ou funcionários cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 102, inciso I, alínea "i"     |
|                                             | Quando se tratar de crime sujeito à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, em uma única instância.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art. 102, inciso I, alínea "i"     |
| <u>SUPERIOR<br/>TRIBUNAL DE<br/>JUSTIÇA</u> | Quando forem <u>COATORES</u> ou <u>PACIENTES</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Governadores dos Estados e do Distrito Federal;</li> <li>• Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal;</li> <li>• Membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal;</li> <li>• Desembargadores ou Juizes dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho;</li> <li>• Membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos</li> </ul> | Art. 105, inciso I, alínea "c"     |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Municípios;<br>• Membros do Ministério Público da União que oficiarem perante Tribunais.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                            | Quando for <u>COATOR</u> tribunal sujeito à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, <u>Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica</u> , ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.                        | Art. 105, inciso I, alínea "c"                                                                                                                                                                                               |
| <u>TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS</u>                        | Quando for <u>COATOR</u> Juiz Federal.                                                                                                                                                                                                            | Art. 108, inciso I, alínea "d"                                                                                                                                                                                               |
| <u>JUÍZES FEDERAIS</u>                                     | Compete-lhes julgar o <i>habeas corpus</i> em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição.                                               | Art. 109, inciso VII                                                                                                                                                                                                         |
| <u>TRIBUNAIS DE JUSTIÇA E TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS</u> | Além da competência ordinária para o julgamento do <i>habeas corpus</i> (contra ato de Juízes, Promotores etc.), incumbe-lhes também o julgamento do <i>writ</i> impetrado contra ato de <u>Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais</u> . | É posição consolidada no âmbito do STF que compete ao Tribunal de Justiça do Estado e aos TRFs processar e julgar <i>habeas corpus</i> emanado das Turmas Recursais do JEC. <u>Superada</u> , assim, a Súmula nº 690 do STF. |

#### 2.4.1. MINISTROS DE ESTADO E COMANDANTES DO EXÉRCITO, MARINHA OU AERONÁUTICA

Conforme quadro acima, se os Ministros de Estado ou Comandantes das Forças Armadas figurarem como pacientes, o julgamento do *habeas corpus* impetrado competirá ao STF (art. 102, inciso I, alínea *d*, CF/88); se tais autoridades figurarem como coatores, o julgamento, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, competirá ao STJ (art. 105, inciso I, alínea *c*, CF/88).

#### 2.4.2. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

Durante bastante tempo, à luz de sua Súmula nº 690, o STF entendeu que a ele competia o julgamento de *habeas corpus* contra decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais Criminais.

Todavia, no julgamento do HC nº 86.834-7/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, o Supremo alterou o seu posicionamento, passando a entender que compete ao próprio Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal o julgamento de HC contra decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, devendo a Súmula nº 690 do STF ser tida por cancelada.

Se o ato provier de juiz de Juizado Especial Criminal, o HC contra ele impetrado será julgado pela Turma Recursal respectiva.

#### 2.4.3. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO AUTORIDADE COATORA

Conquanto não esteja expressamente previsto na CF/88 ou no CPP, prevalece o entendimento de que competirá ao Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal respectivo o julgamento de *habeas corpus* impetrado contra ato de membro do Ministério Público atuante na primeira instância, isto é, Promotor de Justiça ou Procurador da República. Caso atue perante o Juizado Especial Criminal, há vozes no sentido de que competirá à Turma Recursal respectiva (TÁVORA; ALENCAR, 2017, p. 1589).

#### 2.4.4. JUIZ DAS GARANTIAS

A Lei nº 13.964/19 acrescentou ao CPP o art. 3º-B, inciso XII, o qual estabelece que compete ao juiz das garantias "julgar o *habeas corpus* impetrado antes do oferecimento da denúncia", merecendo tal dispositivo legal duas observações (LIMA, 2020, p. 140):

I) NECESSIDADE DE RELEITURA DO MARCO TEMPORAL: o texto final do Pacote Anticrime acabou estabelecendo que a competência do Juiz das Garantias se estende até o recebimento da peça acusatória (art. 3º-C, *caput*, e §2º, CPP). Por esta razão, o legislador deveria também ter alterado o texto do citado art. 3º-B, inciso XII, do CPP, já que restou evidenciada uma lacuna temporal entre a competência para julgar o HC e a cessação de competência do próprio Juiz das Garantias. É dizer: da forma como foi promulgado, a competência para o julgamento do HC vai até o oferecimento da peça acusatória, enquanto a competência do próprio Juiz das Garantias se estende até o recebimento da inicial. Logo, de quem seria a competência para o julgamento do HC impetrado após o oferecimento da peça exordial e antes de seu recebimento? Para evitar tal ausência normativa, entende a doutrina que o art. 3º-B, inciso XII, do CPP, deve ser lido de forma que compete ao Juiz das Garantias julgar o *habeas corpus* impetrado antes do recebimento da peça acusatória (denúncia ou queixa-crime); e

II) AUTORIDADE COATORA COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: como visto, o citado art. 3º-B, inciso XII, do CPP, dispõe que compete ao Juiz das Garantias julgar o HC impetrado até o oferecimento da peça acusatória. Todavia, se a autoridade coatora for detentora de foro por prerrogativa de função, não será de competência do Juiz das Garantias julgar o *writ*, já que este deve ser processado pelo Tribunal competente. É o que ocorrerá, por exemplo, se figurar como autoridade coatora membro do Ministério Público, porquanto, nesse caso, conforme visto no tópico acima, prevalece o entendimento de que competirá ao Tribunal perante o qual atue processar e julgar o *habeas corpus* impetrado.

#### 2.4.5. CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA (ART. 650, § 1º, CPP)

De acordo com o art. 650, § 1º, CPP, cessará a competência do juiz sempre que a violência ou coação ilegal provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição.

Nesse contexto, imagine que, em razão da lavratura de auto de prisão em flagrante delito pela autoridade policial de determinada cidade, tenha sido impetrado um *habeas corpus* em favor do autuado. Pelo fato de o *writ* ter sido impetrado contra ato de delegado de polícia e fora do expediente judiciário, o remédio constitucional foi distribuído a um juiz plantonista de primeira instância, que indeferiu o pedido de liminar e solicitou informações à autoridade coatora. Ocorre que, antes da prestação de informações, a prisão em flagrante foi, por outro juiz, convertida em preventiva. Nessa hipótese, cessará a competência do primeiro juiz, já que o magistrado que converteu o flagrante em preventiva passará a ser a autoridade coatora.

#### 2.5. RITO PROCEDIMENTAL (ARTS. 655 A 664, CPP)

##### 2.5.1. DISPOSIÇÕES GERAIS

O rito procedimental para o processamento do *habeas corpus* está previsto nos arts. 655 a 664 do CPP, que serão aplicados, inclusive, perante os Tribunais Superiores, já que, no que diz respeito ao *writ*, a Lei nº 8.038/90, a qual disciplina o procedimento dos processos perante tais órgãos, faz remissão expressa ao rito procedimental doravante analisado.

##### 2.5.2. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR

Apesar de não haver disposição expressa, a doutrina e a jurisprudência pátrias, com bastante tranquilidade, admitem a concessão de liminar em *habeas corpus*, desde que recomendada



"a imediata antecipação da restituição da liberdade de locomoção do paciente, ou, na hipótese de *habeas corpus* preventivo, da adoção de providências urgentes para que coação ilegal não cause prejuízos irreversíveis ao direito de ir, vir e ficar" (LIMA, 2017, p. 1799).

Sustenta a doutrina que, sendo possível a concessão de liminar no âmbito do mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09), no qual, muitas das vezes, são discutidos interesses apenas patrimoniais, com maior razão deve ser cabível tal medida no bojo do HC, porquanto este tutela a liberdade de locomoção (LIMA, 2017, p. 1799).

Destaca-se, por oportuno, que a concessão de liminar em *habeas corpus* independe de pedido expresso da parte impetrante, já que, se é dado aos juízes e Tribunais conceder a ordem de ofício, conforme art. 654, § 2º, CPP, evidentemente podem deferir a liminar independentemente de provocação (LIMA, 2017, p. 1799).

#### 2.5.2.1. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO HC CONTRA DECISÃO LIMINAR

No âmbito do processamento de *habeas corpus* junto a Tribunais, sendo o pedido de liminar denegado pelo relator, discute-se a possibilidade de impetração de novo *writ* contra essa decisão. Prevalece o entendimento de que, em regra, isso não seria possível, porquanto, ao menos em tese, haveria supressão de instância, já que, após a decisão em caráter liminar, o *habeas corpus* ainda deve passar pelo julgamento do mérito propriamente dito, a ser feito por órgão colegiado (LIMA, 2017, p. 1800).

Nessa toada, aduz a Súmula nº 691 do STF que "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de *habeas corpus* impetrado contra decisão do relator que, em *habeas corpus* requerido a tribunal superior, indefere a liminar".

Portanto, em regra, indeferida a liminar pelo relator, não há falar em novo ajuizamento de *habeas corpus* perante Tribunal imediatamente superior.

Entretanto, tal regramento comporta exceções, já que, se a decisão do relator se mostrar teratológica e o constrangimento ilegal for manifesto, como ocorre, por exemplo, no caso de não haver nenhuma fundamentação para tanto, afigura-se possível o manejo de novo *habeas corpus* contra o indeferimento do pedido de liminar, a ser apreciado por Tribunal imediatamente superior (LIMA, 2017, p. 1800).

#### 2.5.3. PEDIDO DE INFORMAÇÕES

Estando a petição inicial de *habeas corpus* em conformidade com o art. 654, § 1º, do CPP, aduz o art. 662 do mesmo Código que "o presidente, se necessário, requisitará da autoridade indicada como coatora informações por escrito".

Apesar de constar no referido artigo o termo "presidente", explica a doutrina que qualquer autoridade judiciária competente para o julgamento do *habeas corpus*, inclusive o juiz de primeira instância, poderá requisitar à autoridade apontada como coatora informações por escrito, que consistem "em verdadeira contestação da autoridade coatora à suposta ilegalidade ou abuso de poder" (LIMA, 2017, p. 1801).

#### 2.5.4. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

Por conta da simplicidade e da sumariedade inerentes ao *habeas corpus*, seu procedimento não comporta fase de instrução probatória, incumbindo à parte ingressante, isto é, "ao impetrante, sem prejuízo de eventual complementação ministrada pela autoridade coatora ao prestar informações, subsidiar o juízo competente para a apreciação do *writ* com elementos documentais pré-constituídos que comprovem a existência do constrangimento ilegal" (LIMA, 2017, 1798-1799).

### 2.5.5. RITO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

Conforme art. 656, *caput*, do CPP, o juiz, ao receber a petição inicial de *habeas corpus*, julgando necessário, poderá determinar a imediata apresentação do paciente preso, isto é, o juiz, entendendo haver necessidade e estando o paciente preso, ao receber o pedido de HC, poderá ordenar a apresentação deste em dia e hora que designar, procedendo-se à sua oitiva, nos termos do art. 660, *caput*, CPP. Não se trata, pois, de uma obrigatoriedade do magistrado, que somente ordenará a apresentação do paciente preso se entender conveniente.

Se o magistrado ordenar a apresentação do paciente preso e não for obedecido, dispõe o parágrafo único do citado artigo que será expedido mandado de prisão contra o detentor, que será processado na forma da lei, providenciando o juiz as diligências necessárias para que o paciente seja tirado da prisão e apresentado em juízo.

Com o advento da Lei nº 12.403/11, restou suplantada a possibilidade de expedição de mandado de prisão contra o detentor em caso de desobediência à ordem de apresentação do paciente preso, havendo, contudo, a possibilidade da prisão em flagrante do detentor por crime de desobediência à ordem judicial, lavrando-se o competente termo circunstanciado de ocorrência (TÁVORA; ALENCAR, 2017, 1593), sem prejuízo da possibilidade do magistrado ordenar, liminarmente, a imediata liberação do paciente (AVENA, 2017, p. 887).

De forma semelhante, prevê o art. 655 do CPP que será multado o carcereiro ou o diretor da prisão, o escrivão, o oficial de justiça ou a autoridade judiciária ou policial que embarçar ou procrastinar a expedição de ordem de *habeas corpus*, as informações sobre a causa da prisão, a condução e apresentação do paciente, ou a sua soltura, sem prejuízo de sua responsabilização criminal.

Considerando a desatualização do valor da multa, esta se tornou inaplicável, todavia, mostra-se possível, mediante decisão fundamentada, a fixação de *astreinte*, conforme art. 77 do CPC/15, além da aplicação de sanções disciplinares ao agente público responsável pelos atos arrolados no art. 655 do CPP (TÁVORA; ALENCAR, 2017, 1593).

Tendo o juiz assim determinado, conforme art. 657, *caput*, do CPP, "nenhum motivo" poderá obstar a apresentação do paciente preso, salvo: I) se estiver gravemente enfermo (inciso I), caso em que o magistrado poderá se deslocar ao local da prisão, conforme parágrafo único do art. 657 do CPP; e II) não estar o paciente sob a guarda da pessoa a quem se atribui a detenção (inciso II).

Ressalta-se, por oportuno, que, ao invés de determinar a apresentação do paciente preso, valendo-se, por analogia, do art. 662 do CPP, o juiz poderá requisitar à autoridade apontada como coatora a prestação de informações acerca do constrangimento ilegal indicado na petição inicial do *habeas corpus* (AVENA, 2017, p. 888).

Efetuada as diligências determinadas pelo magistrado e interrogado o paciente, se assim entender necessário o julgador, a decisão deverá ser prolatada em até 24 (vinte e quatro) horas, conforme art. 660, *caput*, do CPP, devendo o juiz ordenar a imediata cessação do constrangimento, quando os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, nos termos do § 2º do mesmo artigo.

Conforme o caso, o juiz determinará a expedição de alvará de soltura (art. 660, § 1º, CPP) ou de salvo-conduto em favor do paciente (art. 660, § 4º, CPP), nos termos estudados quando da análise das espécies de *habeas corpus*.

Por fim, convém mencionar que, no processamento perante o juízo de primeira instância, não exige a lei que, antes de decidir o pedido de *habeas corpus*, o magistrado intime o Ministério Público para manifestação (AVENA, 2017, p. 888).

### 2.5.6. RITO PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA OU TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS

Inicialmente, assenta-se que, à luz do art. 666 do CPP, nos regimentos internos dos Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais, serão estabelecidas as normas complementares

para o processo e julgamento do pedido de *habeas corpus* de competência originária daqueles órgãos.

Uma das grandes diferenças em relação ao julgamento perante o juízo de primeira instância é que, nos Tribunais, conforme Decreto-Lei nº 552/1969, haverá a concessão de vista dos autos ao Ministério Público para manifestação no prazo de 2 (dois) dias, findos os quais "os autos, com ou sem parecer serão conclusos ao relator para julgamento, independentemente de pauta".

Em linhas gerais, tem-se que, impetrada a petição de *habeas corpus* junto ao Tribunal, conforme art. 661 do CPP, esta será conclusa ao Presidente (ou ao relator, ou à autoridade judiciária determinada no Regimento Interno do respectivo Tribunal), que poderá solicitar informações à autoridade coatora ou indeferi-la liminarmente, nos termos do art. 662 do CPP.

No caso de indeferimento liminar, dispõe o art. 663 do CPP que a petição deverá ser encaminhada ao tribunal, à câmara ou à turma, para que delibere a respeito.

Não sendo o caso de indeferimento liminar e prestadas as informações, ou sendo elas dispensadas, o *habeas corpus* será julgado na primeira sessão, podendo, todavia, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte, em conformidade com o art. 664, *caput*, do CPP.

A decisão será tomada por maioria dos votos. Ocorrendo empate, o presidente, caso ainda não tenha votado, desempatará. Se o presidente já votou, e, mesmo assim, terminou empatado, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente, nos termos do parágrafo único do art. 664 do CPP.

#### 2.5.7. CONCESSÃO DO *HABEAS CORPUS* E PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO

Dispõe o art. 651 do CPP que a concessão do pedido de *habeas corpus* não porá termo ao processo, nem obstará o seu prosseguimento, quando os fundamentos do deferimento do *writ* não estiverem em conflito com os da própria ação penal. Elucida-se.

Suponha-se que, ao fundamento de que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, seja concedida determinada ordem de *habeas corpus*. Nesse caso, a concessão do *writ* em nada interfere no prosseguimento da ação penal, já que, no bojo do HC, tão somente, se discutiu a legalidade/necessidade da prisão provisória, o que não influi no andamento da persecução penal propriamente dita.

Por outro lado, se a concessão do *habeas corpus* se fundar, por exemplo, no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, a própria ação penal estará obstada, já que não se pode admitir a manutenção de persecução criminal em relação à uma infração penal cuja punibilidade já esteja extinta.

#### 2.5.8. CONCESSÃO DE *HABEAS CORPUS* E RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCESSO

À luz do art. 652 do CPP, se a ordem de *habeas corpus* for concedida em virtude de nulidade do processo, este será renovado, salvo, evidentemente, se a infração penal já estiver prescrita.

#### 2.5.9. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS

Com fincas no art. 5º, inciso LXXVII, da CF/88, o ajuizamento de *habeas corpus* é gratuito.

Todavia, no caso de má-fé ou evidente abuso de poder, é possível que haja a condenação da autoridade coatora ao pagamento das custas processuais, caso em que será remetida ao Ministério Público cópia das peças necessárias à promoção da responsabilidade da autoridade, nos termos do art. 653 do CPP.



### 2.5.10. EXTENSÃO DA CONCESSÃO DA ORDEM AO CORRÉU

Fundando-se no art. 580 do CPP, a doutrina e a jurisprudência pátrias sustentam que, se a infração penal for praticada em concurso de agentes e a concessão do *habeas corpus* a um deles não se basear em motivo de caráter pessoal, a ordem deverá ser estendida aos demais.

Assim, por exemplo, se, no bojo de um *habeas corpus*, for reconhecida a atipicidade formal da conduta, trancando-se a persecução penal em relação ao paciente, os efeitos desta ordem deverão ser estendidos a eventuais corréus, já que, se a conduta é formalmente atípica para um coautor, não poderá haver a persecução criminal em relação aos demais (LIMA, 2017, p. 1801).

### 2.5.11. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

Em regra, não se admite a intervenção de terceiros no processo de *habeas corpus*, salvo no caso de ação penal de iniciativa privada, na qual é possível a intervenção do querelante no julgamento do *writ*, já que ele tem interesse jurídico na decisão, conforme assentado pelo STJ no RHC nº 41.527/RJ, de relatoria do Min. Jorge Mussi.

## 2.6. RECURSOS CONTRA AS DECISÕES PROFERIDAS EM *HABEAS CORPUS*

A decisão de juiz de primeira instância que concede ou indefere o pedido de *habeas corpus* desafia recurso em sentido estrito - RESE, nos termos do art. 581, inciso X, do CPP, não sendo possível o manejo dessa espécie recursal perante os Tribunais.

Importa destacar que, se o *habeas corpus* for julgado prejudicado, também se afigura possível a interposição de RESE, porquanto tal decisão se equipara à denegação do pedido (LIMA, 2017, p. 1802).

Poderão interpor recurso em sentido estrito contra a decisão concessiva de *habeas corpus* o Ministério Público, o querelante e, durante a ação penal, o assistente de acusação, já que este último pode, no curso da persecução penal em juízo, requerer a decretação da prisão preventiva, o que lhe confere interesse recursal contra a sentença concessiva da ordem de *habeas corpus* (LIMA, 2017, p. 1802).

Também é relevante rememorar que, à luz do art. 574, inciso I, do CPP, a sentença concessiva de *habeas corpus* ensejará recurso de ofício, o que não ocorre com a decisão denegatória, sendo essa disparidade objeto recorrente em provas concursais.

Caso o juiz de primeira instância não encaminhe sua sentença concessiva de *habeas corpus* ao Tribunal a que estiver vinculado para o reexame necessário, não haverá o trânsito em julgado daquela decisão, nos termos da Súmula nº 423 do STF.

É interessante assentar que não se considera sentença concessiva de *habeas corpus* de ofício a decisão do juiz que, à luz do art. 310, inciso I, do CPP, relaxa a prisão em flagrante ilegal, não estando sujeita, nesse sentido, ao reexame necessário (LIMA, 2017, p. 1802).

Na Constituição Federal, encontra-se a figura do recurso ordinário, também chamado de recurso ordinário constitucional, que poderá ser manejado perante o STF ou STJ, conforme a situação fática.

De acordo com o art. 102, inciso II, alínea *a*, da CF/88, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o *habeas corpus* decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.

Semelhantemente, nos termos do art. 105, inciso II, alínea *a*, da CF/88, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso ordinário, os *habeas corpus* decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória.

Assenta-se que o recurso ordinário constitucional, além de desafiar decisões denegatórias propriamente ditas, poderá ser interposto contra decisões nas quais a postulação de *habeas corpus* não for conhecida ou julgada prejudicada (LIMA, 2017, p. 1802).



Também se mostra possível a interposição de recurso extraordinário junto ao STF e especial perante o STJ, desde que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, podendo eles, ao contrário do que ocorre com o recurso ordinário constitucional, desafiar decisões denegatórias e/ou concessivas da ordem de *habeas corpus* (LIMA, 2017, p. 1802).

Se, na decisão proferida no bojo do pedido de *habeas corpus*, houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, cabível o manejo dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.

Por fim, registre-se que não é cabível a interposição de embargos infringentes e de nulidade contra decisão prolatada em processo de *habeas corpus* (TÁVORA; ALENCAR, 2017, 1599). Em resumo: em processo de *habeas corpus*, são cabíveis os embargos de declaração, mas não são admissíveis os embargos infringentes e de nulidade.

## 2.7. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL

Questão importante diz respeito à impossibilidade de o Tribunal, ao analisar *habeas corpus* interposto contra ato de juiz de primeira instância, inovar ou suprir eventual falta ou deficiência de fundamentação da decisão combatida.

O Tribunal, portanto, está adstrito à fundamentação utilizada pelo juiz de primeira instância. Caso verifique ausência ou deficiência de fundamentação, deve restituir a liberdade do paciente, mesmo que haja nos autos elementos concretos hábeis à sua prisão.

Exemplificando: ao decretar a prisão, o juiz de primeira instância diz que assim está procedendo para "garantir a ordem pública", sem explicar as razões pelas quais o paciente a coloca em risco, isto é, limitou-se o magistrado a reproduzir ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, o que, nos termos do art. 315, § 2º, inciso I, CPP, será considerado ausência de fundamentação.

No caso acima, não pode o Tribunal, percebendo que o paciente ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude e responde, por fatos recentes e graves, a outros processos criminais, usar tais anotações, que estavam no processo, diga-se de passagem, mas que não foram usadas pelo juiz de primeira instância, que se limitou a reproduzir ato normativo.

Em resumo: não pode o Tribunal, mesmo havendo elementos para tanto, fundamentar a decisão não fundamentada do juiz de primeira instância. Confira-se precedente recente do STJ quanto ao ponto:

Embora o Tribunal a quo tenha afirmado que a Recorrente “responde a outra ação penal, por fato semelhante, na Comarca de Coxim/MS”, verifica-se que tal fundamento não constou do decreto de prisão preventiva, e, consoante a orientação desta Corte, “[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação” (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). (HC 545.697/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019.)

## 2.8. HABEAS CORPUS COLETIVO

Valendo-se, entre outros argumentos, da possibilidade de concessão de *habeas corpus* de ofício, a 2ª Turma do STF, no julgamento do HC nº 143.641/SP, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, assentou que é cabível a impetração de *habeas corpus* coletivo, sendo seus legitimados os mesmos do Mandado de Injunção Coletivo, nos termos do art. 12 da Lei nº 13.300/16. Isto é, o *habeas corpus* coletivo poderá ser impetrado por:

I - pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis;



II - por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária;

III - por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial;

IV - pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

### 3. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA

#### 3.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Súmula nº 395, STF: “Não se conhece de recurso de *habeas corpus* cujo objeto seja resolver sobre o ônus das custas, por não estar mais em causa a liberdade de locomoção.”

Súmula nº 692, STF: “Não se conhece de *habeas corpus* contra omissão de relator de extradição, se fundado em fato ou direito estrangeiro cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito.”

**CABIMENTO DE *HABEAS CORPUS* E PREQUESTIONAMENTO.** É desnecessária a prévia discussão acerca de matéria objeto de “*habeas corpus*” impetrado originariamente no STJ, quando a coação ilegal ou o abuso de poder advierem de ato de TRF no exercício de sua competência penal originária. (INF 778 - RHC 118622/ES, rel. Min. Roberto Barroso, 17.3.2015)

***HABEAS CORPUS* E TRANCAMENTO DE PROCESSO DE *IMPEACHMENT*.** “*Habeas corpus*” não é o instrumento adequado para pleitear trancamento de processo de “*impeachment*”. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, negou provimento a agravo regimental em que se pretendia trancar o aludido processo movido em face da Presidente da República. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que provia o agravo por não considerar cabível a negativa de seguimento a “*habeas corpus*” por força de decisão monocrática tendo em conta a manifesta improcedência do pedido (RISTF, art. 21; e CPC, art. 557). (INF 830 - HC 134315 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, 16/6/2016.)

***HABEAS CORPUS* E CABIMENTO.** O “*habeas corpus*”, cuja finalidade é a tutela da liberdade de locomoção, não é cabível para o reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos. (HC 114293/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, 1º/12/2015.)

***HABEAS CORPUS*. EXECUÇÃO PENAL. ATO IMPUGNADO. RESTRIÇÃO DE VISITA DE MÃE A FILHO PRESO AO PARLATÓRIO (ART. 41, X, DA LEI Nº 7.210/84). MEIO INIDÔNEO PARA QUESTIONAR SUA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA RESTRIÇÃO AO STATUS LIBERTATIS DA PACIENTE. *WRIT* DO QUAL NÃO SE CONHECE.** O *habeas corpus* não constitui meio idôneo para se discutir a legalidade da proibição de visita a paciente preso, por inexistência de efetiva restrição ao seu *status libertatis*. (HC 133305, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/5/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 10/10/2016 PUBLIC 11/10/2016.)

***HABEAS CORPUS* E INTERNAÇÃO DE MENOR DE IDADE.** O *habeas corpus* também é cabível para modificar decisão de internação de menor e adolescente, por aplicação de medida socioeducativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (INF 393 - HC nº 85.503/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, em 21/6/2005).

***HABEAS CORPUS* E SUSTENTAÇÃO ORAL.** Cabe sustentação oral no agravo regimental interposto contra a decisão monocrática do Ministro do STF que negou seguimento ao *habeas corpus*. Fundamento: aplicação, por analogia, da regra do § 3º do art. 937 do CPC/2015. (INF 937 - HC 152676/PR, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 9/4/2019.)





### 3.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**HABEAS CORPUS E OBTENÇÃO DE CÓPIAS DE PROCESSO CRIMINAL.** O *habeas corpus* não constitui meio idôneo para se pleitear o fornecimento, sem custos, de cópias de processo criminal, uma vez que ausente qualquer violação ou ameaça à garantia do direito à liberdade de locomoção. Precedente. (HC 111.561/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/3/2011, DJe 25/4/2011.)

**RECURSO EM HABEAS CORPUS E DESNECESSIDADE DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA.** "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" - enunciado n. 115 da Súmula deste Tribunal - A comprovação da capacidade postulatória somente é dispensada na hipótese em que o leigo impetra o *habeas corpus* e contra a decisão do *writ*, ele próprio interpõe recurso ordinário. Remanescendo o mesmo vício que impediu o conhecimento do recurso ordinário, ou seja, a ausência de procuração outorgada aos advogados do ora agravante, o presente agravo não pode ser conhecido. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RHC 69.183/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017.)

#### QUESTÕES

**1- TJ/AL (FCC 2019)** Cabível *habeas corpus* quando:

- a) o processo for manifestamente nulo, mas não para o reconhecimento de extinção da punibilidade do paciente.
- b) não houver justa causa para o inquérito policial, mas não quando já extinta a pena privativa de liberdade.
- c) relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada, mas não quando já proferida decisão condenatória exclusivamente a pena de multa.
- d) imposta pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública.
- e) não for admitida a prestação de fiança e quando seu objeto consistir em resolução sobre o ônus das custas.

**2- DPE/AC (Cespe/UnB 2017)** É cabível *habeas corpus*:

- a) contra decisão que condene, unicamente, a pena pecuniária.
- b) contra decisão que tenha indeferido liminar em outro *habeas corpus*.
- c) caso se busque o reconhecimento da decadência.
- d) quando já extinta a pena privativa de liberdade.
- e) contra decisão ofensiva à legislação federal nos fundamentos da condenação criminal com pena privativa de liberdade.

#### COMENTÁRIOS

**1. Gabarito: B.**

- a) Nos termos do art. 648, incisos VI e VII, do CPP, considera-se ilegal a coação, cabendo o manejo do HC, quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade do agente.
- b) Nos termos do art. 648, inciso I, do CPP, considera-se ilegal a coação, cabendo o manejo do HC, quando não houver justa causa, não sendo possível a sua impetração quando já extinta a pena privativa de liberdade, já que não há mais risco à liberdade de locomoção, nos termos da Súmula nº 695 do STF.
- c) Conforme a Súmula nº 693 do STF, "não cabe *habeas corpus* contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada".
- d) Nos termos da Súmula nº 694 do STF, "não cabe *habeas corpus* contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública".
- e) Nos termos do art. 648, inciso V, do CPP, considera-se ilegal a coação, cabendo o manejo do HC, quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza, todavia, "não se conhece de recurso de *habeas corpus* cujo objeto seja resolver sobre o ônus das custas, por não estar mais em causa a liberdade de locomoção", conforme Súmula nº 395 do STF.

**2. Gabarito: C.**

- a) Conforme a Súmula nº 693 do STF, "não cabe *habeas corpus* contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada".

b) Em regra, indeferida a liminar pelo relator, não há falar em novo ajuizamento de *habeas corpus* perante Tribunal imediatamente superior. Todavia, se a decisão do relator se mostrar teratológica e o constrangimento ilegal for manifesto, como ocorre, por exemplo, no caso de não haver nenhuma fundamentação para tanto, afigura-se possível o manejo de novo *habeas corpus* contra o indeferimento do pedido de liminar, a ser apreciado por Tribunal imediatamente superior (LIMA, 2017, p. 1800).

c) Nos termos do art. 648, inciso VII, do CPP, considera-se ilegal a coação, cabendo o manejo do HC, quando extinta a punibilidade do agente, podendo ser o *writ* utilizado com a finalidade de se reconhecer a decadência, que é uma das causas extintivas da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, CP.

d) Não é possível a impetração de HC quando já extinta a pena privativa de liberdade, já que não há mais risco à liberdade de locomoção, nos termos da Súmula nº 695 do STF.

e) Com a finalidade de fazer cessar o excessivo incremento das hipóteses de admissibilidade do HC, os Tribunais Superiores "passaram a rechaçar a sua utilização em substituição das vias recursais ordinárias" (AVENA, 2017, p. 890), devendo ser interposto, no caso da questão, o Recurso Especial perante o STJ, conforme art. 105, inciso III, alínea *a*, CF/88.

## CAPÍTULO 25 – DO MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA CRIMINAL

### 1. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA

Nos termos do art. 5º, inciso LXIX, CF/88, o mandado de segurança em matéria criminal é ação autônoma de impugnação (não é recurso), que visa "proteger direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Diferentemente do *habeas corpus* e da revisão criminal, sua regulamentação não está prevista no próprio Código de Processo Penal, sendo aplicável ao mandado de segurança em matéria criminal as disposições trazidas pela Lei nº 12.016/09.

À luz do dispositivo constitucional acima transcrito, percebe-se o caráter residual do mandado de segurança em relação ao *habeas corpus* e ao *habeas data*, porquanto, somente há falar no ajuizamento de MS quando não se tratar de violação ao direito de locomoção ou ao direito à informação.

Nesse contexto, importa mencionar que, além do caráter residual em relação ao HC e ao HD, diz-se que o MS é subsidiário em relação a tais ações constitucionais de impugnação, porquanto cabível o seu manejo quando não forem admissíveis aqueles remédios.

É dizer: somente há falar em MS quando não for cabível HC ou HD (caráter residual ou residualidade), ao passo que, se não forem admissíveis tais ações, ajuizável será o MS (caráter subsidiário ou subsidiariedade).

Interessa assentar que o mandado de segurança também será cabível nos casos em que não houver previsão legal de recurso propriamente dito para impugnar determinada decisão, como ocorre, por exemplo, com a decisão que admite ou inadmite o assistente do Ministério Público, em relação a qual não há recurso legalmente previsto, nos termos do art. 273 do CPP (LIMA, 2017, p. 1832).

Por fim, ainda se extrai do texto constitucional que, ao contrário do que ocorre na ação de *habeas corpus*, o mandado de segurança somente poderá ser impetrado em desfavor de "autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público", não sendo cabível o seu manejo contra ato de particular que não esteja desempenhando funções públicas ou de caráter público.

### 2. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO

Conforme art. 23 da Lei nº 12.016/90, o prazo para impetração do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data em que o interessado tomou conhecimento do ato a ser impugnado, prevalecendo o entendimento no sentido de que se trata de prazo decadencial, não estando, pois, sujeito a causas interruptivas e/ou suspensivas (LIMA, 2017, p. 1832).

Importa mencionar que, à luz da Súmula nº 632 do STF, "é constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança", devendo ser frisado que a perda do prazo não retira do interessado o direito propriamente dito, que poderá ser atingido pelas vias ordinárias (LIMA, 2017, p. 1832).

### 3. CABIMENTO

Como dito, a admissibilidade do mandado de segurança em matéria penal é verificada, inicialmente, ante à impossibilidade do manejo do *habeas corpus* e do *habeas data*, sendo também cabível a sua impetração nos casos em que não houver recurso propriamente dito para impugnar

determinada decisão, trazendo o art. 1º da Lei nº 12.016/19 alguns requisitos específicos quanto ao cabimento do MS, a saber:

I) ORIGEM DO ATO IMPUGNADO: só há falar em MS se o ato impugnado provier de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, sendo a eles equiparados os "os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições", conforme art. 1º, §1º, da Lei nº 12.016/09 (LIMA, 2017, p. 1834);

II) DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO: tendo em vista que somente poderá haver o ajuizamento de MS diante da violação de direito líquido e certo, não amparado por HC ou HD, e "considerando os limites estreitos da cognição e do rito do mandado de segurança, é indispensável que, por ocasião da impetração, o autor faça a comprovação da lesão ou ameaça de lesão por meio de prova documental pré-constituída" (LIMA, 2017, p. 1834); e

III) COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE OU DO ABUSO DE PODER: a parte impetrante deverá apontar a existência de "atos concretos que possam causar, direta ou indiretamente, perigo ou restrição ao direito líquido e certo não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*", não podendo ser impetrado o MS, "em sua versão preventiva, quando o alegado risco for meramente hipotético", o que é confirmado pela Súmula nº 266 do STF, a qual dispõe que "não cabe mandado de segurança contra lei em tese" (LIMA, 2017, p. 1834).

### 3.1. VEDAÇÕES AO AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA

Além de não poder ser usado nos casos em que forem admissíveis as ações de HC ou HD, o art. 5º da Lei nº 12.016/19 traz outras situações nas quais são vedadas o uso do MS, a saber:

I) ATO DO QUAL CAIBA RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO, INDEPENDENTEMENTE DE CAUÇÃO: conforme inciso I, se o ato desafiar recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução, não caberá o ajuizamento do MS, devendo ser tida por superada a Súmula nº 429 do STF, a qual dizia que "a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra omissão da autoridade" (AVENA, 2017, p. 903);

II) DECISÃO JUDICIAL DA QUAL CAIBA RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO: o inciso II obriga que façamos uma releitura da Súmula nº 267 do STF, a qual diz que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Assim, tendo a Lei nº 12.016/19 vedado o uso do MS somente no caso de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, deve-se concluir que "na hipótese de decisão judicial manifestamente ilegal, contra a qual não haja previsão legal de recurso, ou quando o recurso cabível não for dotado de efeito suspensivo, o mandado de segurança revelar-se-á instrumento adequado à tutela do direito líquido e certo da parte" (LIMA, 2017, p. 1835); e

III) DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO: positivando o que já era previsto pela Súmula nº 268 do STF, o inciso III vedou a utilização do MS contra decisão judicial já transitada em julgado.

No ponto, é importante mencionar que, no julgamento do EDcl no MS 22.157/DF, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, o STJ assentou que, se o MS tiver sido impetrado antes do trânsito em julgado de determinada decisão judicial, ainda que o trânsito em julgado ocorra durante o processamento do *mandamus*, deverá haver o julgamento do mérito do MS, não podendo ser sustentado o seu não cabimento ou a perda de seu objeto.

### 3.1.1. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO

Vedando prática bastante corriqueira, o STJ, por intermédio de sua Súmula de nº 604, assentou que "o mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público".

No dia a dia forense, quando o juiz concedia a liberdade provisória ao réu, o Ministério Público, irresignado, interpunha recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, inciso V, do CPP e impetrava, de forma concomitante, mandado de segurança para que o RESE, que não é dotado de efeito suspensivo, impossibilitasse que a decisão liberatória produzisse seus efeitos imediatamente.

É dizer: o MS, nesse caso, tinha por objetivo conferir ao RESE efeito suspensivo, impedindo a imediata eficácia da decisão, o que restou vedado pelo STJ.

Por fim, importa mencionar que, "no mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo", conforme Súmula nº 701 do STF, devendo ser dispensada especial atenção a esse enunciado, porquanto é bastante cobrado nas provas de concurso.

## 4. LEGITIMIDADE

### 4.1. LEGITIMAÇÃO ATIVA

A legitimação ativa para a impetração do mandado de segurança recai sobre a pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, que vier a sofrer constrangimento ilegal em seu direito líquido e certo, não amparado por HC ou HD. No processo penal, o MS poderá ser impetrado pelo MP, pelo querelante, pelo assistente de acusação, pelo acusado, por seu defensor e até mesmo por terceiros interessados (LIMA, 2017, p. 1832).

Caso o processo criminal envolva vários acusados, sendo proferida uma decisão teratológica em relação a qual não haja previsão legal de recurso adequado, à luz do art. 1º, § 3º, da Lei nº 12.016/09, é possível que o mandado de segurança contra tal decisão seja impetrado por apenas um dos acusados (LIMA, 2017, p. 1832-1833).

Diferentemente do que ocorre com o *habeas corpus*, que não é ato privativo de advogado, o MS deverá ser subscrito por alguém que tenha capacidade postulatória (AVENA, 2017, p. 904).

### 4.2. LEGITIMAÇÃO PASSIVA

Embora haja divergência doutrinária e jurisprudencial quanto ao tema, entende-se que a legitimação passiva do MS recai sobre a própria autoridade responsável pela violência ou ameaça ao direito líquido e certo do impetrante. Não figura no polo passivo da demanda, portanto, a pessoa jurídica de direito público, mas sim a autoridade que tiver praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1º, *caput*, c/c art. 6º, § 3º, ambos da Lei nº 12.016/09 (LIMA, 2017, p. 1833).

## 5. FORMALIDADES

### 5.1. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO

Inicialmente, assenta-se que, quando o ato questionado provier de órgão colegiado ou de Tribunal, há uma diferença importante entre o *habeas corpus* e o mandado de segurança. No caso do HC, via de regra, a competência será do órgão jurisdicional imediatamente superior. Por outro lado, em se tratando de MS, a competência recairá sobre o próprio Tribunal, nos termos do art. 21, inciso VI, da LC nº 35/79 (LOMAN), o qual aduz que compete aos Tribunais, privativamente, julgar,



originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções (LIMA, 2017, 1839).

Compilando os dispositivos constitucionais quanto ao ponto, chega-se ao seguinte quadro-resumo:

| <u>COMPETÊNCIA P/ JULGAMENTO</u>    | <u>AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELO ATO</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>PREVISÃO</u>                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <u>SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL</u>     | Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança contra atos do(a): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente da República;</li> <li>• Mesa da Câmara dos Deputados;</li> <li>• Mesa do Senado Federal;</li> <li>• Tribunal de Contas da União;</li> <li>• Procurador-Geral da República;</li> <li>• próprio Supremo Tribunal Federal.</li> </ul> | Art. 102, inciso I, alínea <i>d</i> |
| <u>SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA</u> | Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança contra atos de(o): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministro de Estado;</li> <li>• Comandantes das Forças Armadas;</li> <li>• próprio Superior Tribunal de Justiça.</li> </ul>                                                                                                                 | Art. 105, inciso I, alínea <i>b</i> |
| <u>TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS</u> | Compete aos Tribunais Regionais Federais processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança contra atos do(e): <ul style="list-style-type: none"> <li>• próprio Tribunal Regional Federal;</li> <li>• Juiz Federal.</li> </ul>                                                                                                                                                                    | Art. 108, inciso I, alínea <i>c</i> |
| <u>JUÍZES FEDERAIS</u>              | Compete aos Juízes Federais julgarem o mandado de segurança contra ato de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoridades federais em geral, excetuados os casos de competência dos Tribunais Regionais Federais.</li> </ul>                                                                                                                                                                           | Art. 109, inciso VIII               |

### 5.1.1. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

Se o ato impugnado provier de juiz de Juizado Especial Criminal, competirá à Turma Recursal julgar o mandado de segurança contra ele impetrado.

De igual forma, ao contrário do que ocorre com o *habeas corpus*, caberá à própria Turma Recursal julgar o mandado de segurança impetrado contra ato por ela praticado, aplicando-se, por analogia, o art. 21, inciso VI, da LC nº 35/79, o qual aduz que compete aos Tribunais, dentre outras competências, julgar, originariamente, os mandados de segurança impetrados contra seus próprios atos (LIMA, 2017, p. 1839).

Portanto, há, nesse ponto, uma diferença muito importante entre as ações de *habeas corpus* e de mandado de segurança, já que, impetrado HC contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial Criminal, competirá o seu julgamento ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal respectivo. Por outro lado, ajuizado mandado de segurança contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial Criminal, seu julgamento competirá à própria Turma Recursal.

Em resumo, temos o seguinte:

| <u>AUTORIDADE COATORA</u>         | <u>REMÉDIO IMPETRADO</u> | <u>COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO</u> |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Juiz de Juizado Especial Criminal | <i>Habeas Corpus</i>     | Turma Recursal                     |





|                                             |                      |                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Turma Recursal de Juizado Especial Criminal | <i>Habeas Corpus</i> | Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal |
| Juiz de Juizado Especial Criminal           | Mandado de Segurança | Turma Recursal                                   |
| Turma Recursal de Juizado Especial Criminal | Mandado de Segurança | <u>Turma Recursal</u>                            |

### 5.1.2. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Na Constituição Federal e na legislação federal infralegal, não há regramento específico quanto à competência para julgamento de MS impetrado contra membro do Ministério Público, prevalecendo, no âmbito doutrinário, o entendimento de que deverão ser seguidas as regras estatuídas nas Constituições Estaduais e nas normas locais de organização judiciária. Se os citados atos normativos nada dispuserem sobre o tema, a competência para julgamento recairá sobre o juízo *a quo* perante o qual o membro do Ministério Público atue (LIMA, 2017, p. 1840).

### 5.2. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR

Dispõe o art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, que o juiz, ao despachar a inicial, ordenará "que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica".

Em razão de seu caráter provisório, tal decisão, que poderá ser tomada sem oitiva da parte contrária, isto é, liminarmente (*inaudita altera pars*), produzirá efeitos até a prolação da sentença, salvo se revogada ou cassada, conforme art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.016/09.

Em primeira instância, observado o disposto no Código de Processo Civil, a decisão que concede ou denega pedido de liminar desafiará recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Nos Tribunais, conforme art. 16, parágrafo único, da Lei nº 12.016/09, da decisão do relator que conceder ou negar o pedido de liminar caberá agravo regimental ao órgão competente do Tribunal que integre.

É interessante assentar, por fim, que, sendo concedida a medida liminar e criando o impetrante obstáculo ao regular andamento do processo ou deixando de promover, por mais de 3 (três) dias úteis, os atos e as diligências que lhe cumprirem, será, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, decretada a preempção ou caducidade da medida liminar, conforme art. 8º da Lei nº 12.016/09.

### 5.3. PROCEDIMENTO

#### 5.3.1. PROCEDIMENTO PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E TRIBUNAIS SUPERIORES

No geral, o procedimento para o processamento do mandado de segurança no âmbito dos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais Superiores será definido pelos respectivos regimentos internos, todavia, a Lei nº 12.016/09 trouxe algumas disposições a respeito, a saber (AVENA, 2017, 903-904):

I) RECURSO CABÍVEL DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELO RELATOR: conforme art. 10, § 1º, a decisão do relator que indeferir o processamento da petição inicial desafiará recurso de agravo regimental para o órgão competente do Tribunal que integre;

II) COMPETÊNCIA PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO: conforme art. 16, *caput*, caberá ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento do mérito ou do pedido liminar; e

III) RECURSO CABÍVEL CONTRA A DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE OU INDEFERE O PEDIDO DE LIMINAR: nos termos do art. 16, parágrafo único, caberá agravo regimental contra a decisão do relator que defere ou indefere o pedido de liminar, a ser julgado pelo órgão competente do Tribunal que integre.

### 5.3.2. PROCEDIMENTO PERANTE O JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

Se for de competência de juiz de primeira instância, o procedimento para processamento e julgamento do mandado de segurança seguirá a seguinte cronologia (AVENA, 2017, p. 905):

I) A petição inicial do mandado de segurança deverá ser apresentada em 2 (duas) vias, nos termos do art. 6º da Lei nº 12.016/09, que merece ser lido à inteireza;

II) Após a distribuição, o juiz poderá:

II.A) indeferir a petição inicial de plano, se verificar que não era caso de mandado de segurança ou que já se esgotou o prazo decadencial, nos termos do art. 10, sendo cabível a interposição de apelação contra tal decisão, conforme § 1º do mesmo artigo;

II.B) Receber a petição inicial e, ato contínuo, ordenar:

II.B.1) a notificação da autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações (art. 7º, inciso I);

II.B.2) em sendo o caso, que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inciso II); e

II.B.3) a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, conforme analisado anteriormente, nos termos do art. 7º, inciso III.

III) Expirado o prazo das informações, com ou sem elas, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, conforme art. 12, *caput*; e

IV) Por fim, à luz do parágrafo único do art. 12, vindo ou não o parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz, para a decisão, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 (trinta) dias.

### 5.4. RECURSOS CABÍVEIS

Em primeira instância, caberá apelação da sentença que conceder ou denegar o pedido de mandado de segurança, conforme art. 14, *caput*, da Lei nº 12.016/09, estando a sentença concessiva sujeita ao duplo grau obrigatório, nos termos do § 1º do mesmo artigo.

Bastante atenção merece a hipótese de duplo grau obrigatório, também chamado de reexame necessário, já que esta é adstrita à sentença concessiva do mandado de segurança, sendo condição imprescindível ao seu trânsito em julgado, não ocorrendo no caso de sentença denegatória. É dizer: a sentença denegatória não está sujeita ao duplo grau obrigatório.

É interessante assentar que, à luz do art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/09, em que pese esteja sujeita ao duplo grau obrigatório, admite-se a execução provisória da sentença concessiva do mandado de segurança, salvo nos casos em que for vedada a concessão de medida liminar.

Nos termos do art. 10, § 1º, da Lei nº 12.016/09, se o juiz de primeiro grau indeferir o processamento da petição inicial, caberá apelação. Se tal decisão provier de relator, caberá agravo regimental para o órgão competente que integre.

Tratando-se de acórdão proveniente de Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais, necessária se faz a seguinte distinção: I) se a segurança for denegada, caberá o manejo do

recurso ordinário constitucional ao STJ, conforme art. 105, inciso II, alínea *b*, CF/88; e II) se a segurança for concedida, poderá o prejudicado se valer do recurso especial para o STJ, nos termos do art. 105, inciso III, CF/88, ou, à luz do art. 102, inciso III, CF/88, do recurso extraordinário para o STF, conforme o enfoque seja lei federal ou direito constitucional, respectivamente (AVENA, 2017, p. 905).

Se o acórdão provier do STJ, TSE, STM ou TST, também se faz necessária a seguinte distinção: I) denegando-se a segurança, cabível recurso ordinário constitucional ao STF, nos termos do art. 102, inciso II, alínea *a*, CF/88; e II) concedendo-se a segurança, admissível o recurso extraordinário para o STF, nos termos do art. 102, inciso III, CF/88, se preenchidos os seus requisitos (AVENA, 2017, p. 905).

No âmbito do próprio STF, denegando-se ou concedendo-se a segurança, não há recurso legalmente previsto, sendo possível, todavia, que seu regimento interno eventualmente crie uma via impugnativa para tanto (AVENA, 2017, p. 905).

Por fim, convém registrar que, à luz do art. 14, § 2º, da Lei nº 12.016/09, estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer.

## 6. HIPÓTESES COMUNS DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA CRIMINAL

Como dito, o cabimento do MS depende, dentre outros pressupostos, da ausência de meio legal para se recorrer de determinada decisão, sendo ele comumente utilizado nas seguintes hipóteses:

I) DECISÃO QUE INDEFERE A HABILITAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: tendo em vista que, nos termos do art. 273 do CPP, não cabe recurso do *despacho* que inadmitir o assistente de acusação, entende-se cabível o manejo do mandado de segurança, porquanto a habilitação é "direito líquido e certo, podendo ser indeferida pelo juízo, tão somente, se o requerente não for um dos legitimados para tal ou se, mesmo legitimado, não estiver assistido por procurador legalmente habilitado" (AVENA, 2017, p. 906);

II) TRANCAMENTO DE IP OU DE PROCESSO PENAL EM ANDAMENTO EM RELAÇÃO À INFRAÇÃO PENAL A QUE NÃO SEJA COMINADA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: nos termos da Súmula nº 693 do STF, "não cabe *habeas corpus* contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada". Assim, para se encerrar anormalmente um inquérito policial ou a própria ação penal nesses casos, cabível o manejo do MS, já que o direito não é amparado por HC (LIMA, 2017, p. 1836);

III) PROTEÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO PROCESSO PENAL: a pessoa jurídica, por não ser dotada de liberdade de locomoção, não pode se valer do HC. Logo, tendo ela interesse em, por exemplo, trancar um inquérito policial ou uma ação penal deflagrada em seu desfavor, poderá se valer do mandado de segurança (LIMA, 2017, p. 1836);

IV) ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO: nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF, sendo vedado ao advogado o acesso às diligências já documentadas nos autos da investigação, poderá ele se valer da reclamação junto ao próprio STF ou do mandado de segurança (AVENA, 2017, p. 907).

## 7. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA

### 7.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Súmula nº 405, STF: "Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo. dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária."

Súmula nº 423, STF: “Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso *ex officio*, que se considera interposto *ex lege*.”

Súmula nº 510, STF: “Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.”

## 7.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Súmula nº 105, STJ: “Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.”

Súmula nº 169, STJ: “São inadmissíveis embargos infringentes no processo de mandado de segurança.”

Súmula nº 376, STJ: “Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”

### QUESTÕES

**1- MPE/BA (MPE/BA 2018 – prova anulada)** Assinale a alternativa correta:

- a) Denegado ou concedido o mandado de segurança pelo juiz, impetrado contra delegado de polícia, cabe recurso em sentido estrito da parte interessada.
- b) Denegado o mandado de segurança pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, cabe recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça.
- c) Concedido o mandado de segurança pelo Superior Tribunal de Justiça, cabe recurso ordinário constitucional dirigido ao Supremo Tribunal Federal.
- d) No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo.
- e) Cabe *habeas corpus* contra órgão de execução do Ministério Público que não permite o acesso do advogado constituído pelo investigado, aos autos, ainda que o procedimento investigatório criminal tramite em segredo de justiça.

**2- TJ/AL (FCC 2019 – adaptada)** Em matéria de competência, cabe ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar o mandado de segurança contra ato do juizado especial.

**3- MPE/SP (MPE/SP 2012 – adaptada)** O direito de recorrer da sentença que concede o mandado de segurança não se estende à autoridade coatora.

**4- MPE/RO (Cespe/UnB 2010 – adaptada)** O mandado de segurança em processo penal — ao contrário do *habeas corpus*, que dispensa advogado — deve ser impetrado por advogado e tutela direito líquido e certo, como no caso de decisão arbitrária que não admita a habilitação do assistente de acusação.

**5- MPE/MG (MPE/MG 2010 – adaptada)** Embora o Código de Processo Penal o arrole como recurso, a doutrina considera o Mandado de Segurança uma ação autônoma de impugnação.

### COMENTÁRIOS

**1. Gabarito:** D.

- a) Caberá apelação da sentença que conceder ou denegar o pedido de mandado de segurança, conforme art. 14, *caput*, da Lei nº 12.016/09, estando a sentença concessiva sujeita ao duplo grau obrigatório, nos termos do §1º do mesmo artigo.
- b) Tratando-se de acórdão proveniente de Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais, se a segurança for denegada, caberá o manejo do recurso ordinário constitucional ao STJ, conforme art. 105, inciso II, alínea b, CF/88.
- c) Se o acórdão provier do STJ, concedendo-se a segurança, é admissível o recurso extraordinário para o STF, nos termos do art. 102, inciso III, CF/88, se preenchidos os seus requisitos.



d) Conforme Súmula nº 701 do STF, "no mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo".

e) Sendo direito líquido e certo do advogado o acesso às diligências já documentadas nos autos de investigação criminal, é cabível o manejo de reclamação perante o STF ou de MS.

**2.** Gabarito: ERRADO. Nos termos da Súmula nº 376 do STJ, "compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial".

**3.** Gabarito: ERRADO. À luz do art. 14, § 2º, da Lei nº 12.016/09, estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer contra a sentença proferida no mandado de segurança.

**4.** Gabarito: CORRETO. Diferentemente do que ocorre com o *habeas corpus*, que não é ato privativo de advogado, o MS deverá ser subscrito por alguém que tenha capacidade postulatória, sendo cabível o seu manejo contra a decisão que inadmitir o assistente do Ministério Público.

**5.** Gabarito: ERRADO. Diferentemente do *habeas corpus* e da revisão criminal, a regulamentação do MS não está prevista no próprio Código de Processo Penal, sendo aplicável ao mandado de segurança em matéria criminal as disposições trazidas pela Lei nº 12.016/09.

## CAPÍTULO 26 – DA REVISÃO CRIMINAL (ARTS. 621 A 631, CPP)

### 1. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA

Trata-se de ação autônoma de impugnação que visa desconstituir o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória ou absolutória imprópria, nas hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II e III, do CPP, corrigindo eventuais erros judiciários.

Logo, apesar de constar no capítulo dos recursos, é pacífico que a natureza jurídica da revisão criminal é de ação autônoma de impugnação, não sendo, pois, um recurso propriamente dito.

### 2. PRESSUPOSTOS

Somente há falar em revisão criminal quando houver: I) sentença penal condenatória ou absolutória imprópria (imposição de medida de segurança), isto é, não cabe revisão criminal contra sentença absolutória própria (art. 386 do CPP), sendo tal ação impugnativa um instituto a ser aplicado em benefício do réu, exclusivamente (*pro reo*); II) trânsito em julgado, ou seja, se a sentença penal condenatória ou absolutória imprópria ainda não transitou em julgado, não é cabível a medida (art. 621, *caput*, CPP — "processos findos"), devendo o requerimento ser instruído com a certidão de trânsito em julgado e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos (art. 625, § 1º, CPP); e III) demonstração de erro judiciário (art. 621, I, II e III, CPP).

#### 2.1. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS

O pressuposto fundamental da revisão criminal é o trânsito em julgado de sentença penal condenatória ou absolutória imprópria, sendo desimportante o fato de não ter havido o manejo de todos os recursos de que dispõe a Defesa, sendo admissível tal ação ainda que o trânsito em julgado tenha se operado na primeira instância.

#### 2.2. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

A depender do momento em que se deu a declaração da extinção da punibilidade, será cabível ou não o ajuizamento da revisão criminal, isto é, se ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria, como se verifica, por exemplo, na Prescrição da Pretensão Punitiva (PPP), não será cabível. Por outro lado, se ocorreu após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria, como se dá, por exemplo, no caso de Prescrição da Pretensão Executória (PPE), será admissível.

No que diz respeito à sentença concessiva do perdão judicial, também chamada de "absolvição anômala", não é cabível o manejo da revisão criminal, já que tal sentença não é do tipo condenatória ou absolutória imprópria, mas, sim, "declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório", a teor da Súmula nº 18 do STJ (LIMA, 2017, p. 1813-1814).

#### 2.3. TRIBUNAL DO JÚRI (SOBERANIA DOS VEREDICTOS — ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88)

É cabível o manejo de revisão criminal contra sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias oriundas do Tribunal do Júri, sendo possível a fundamentação do pedido em qualquer das hipóteses insertas nos incisos do art. 621 do CPP, não havendo falar em violação à soberania dos veredictos.





## 2.4. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

A Lei nº 9.099/95, em seu art. 59, vedou o cabimento de ação rescisória nas causas de competência do Juizado Especial Cível, contudo, no âmbito do Juizado Especial Criminal, é admissível o ajuizamento de revisão criminal, que será julgada pela Turma Recursal e não pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal respectivo.

## 3. PRAZO

A revisão criminal, conforme art. 622, *caput*, do CPP, poderá ser requerida a qualquer tempo (inexiste prazo decadencial), antes ou depois da extinção da pena, sendo cabível tal medida, inclusive, após a morte do réu, caso em que poderá ser pedida pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão (art. 623, CPP).

## 4. LEGITIMIDADE ATIVA

Conforme dispõe o art. 623 do CPP, a revisão criminal poderá ser requerida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge (incluído o companheiro, nos termos do art. 226, § 3º, CF/88 c/c o art. 3º, CPP), ascendente, descendente e irmão.

Importa relembrar que, na APn 912/RJ, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, o STJ assentou que a(o) companheira(o) homoafetiva(o) também tem legitimidade para ingressar com queixa-crime, devendo tal entendimento ser replicado à revisão criminal.

Se, no curso da revisão, morrer a pessoa cuja condenação tiver de ser revista, dispõe o art. 631 do CPP que o presidente do Tribunal nomeará curador para a defesa, não havendo a suspensão do procedimento para eventual habilitação dos herdeiros, os quais, havendo interesse, poderão ingressar posteriormente. Isto é: o procedimento continua. O fato da pessoa que pleiteou a revisão criminal falecer não implica arquivamento.

### 4.1. DESNECESSIDADE DE ADVOGADO

Embora se reconheça a existência de respeitável lição em sentido diverso (AVENA, 2017, p. 896), a doutrina majoritária sustenta que o réu não necessita estar representado por advogado constituído, sendo encontrados precedentes do STF<sup>45</sup> e do STJ<sup>46</sup> nesse sentido.

Seguindo tal posicionamento, no concurso para Defensor Público do Estado do Espírito Santo, organizado pela FCC no ano de 2016, foi considerada INCORRETA a alternativa que rogava “Sobre a revisão criminal, ao contrário do *habeas corpus*, é necessária capacidade postulatória para a revisão criminal”.

De igual forma, no concurso para Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, ocorrido no ano de 2016, foi considerada CORRETA a seguinte assertiva: “A revisão criminal pode ser proposta diretamente pelo acusado, sem necessidade de representação advogado”.

### 4.2. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Por ser um instituto exclusivamente favorável ao réu (*pro reo*), não pode o Ministério Público ingressar com uma revisão criminal para prejudicá-lo.

<sup>45</sup> RvC 4886, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 29/3/1990, DJ 2/4/1993.

<sup>46</sup> HC 315.594/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 7/11/2016.



Em contrapartida, a maioria da doutrina defende a legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de revisão criminal em favor do acusado.

Todavia, no âmbito da jurisprudência do STF, encontra-se o RHC nº 80.796/2001, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, no qual aquela Corte assentou que “O Estado-acusador, ou seja, o Ministério Público, não tem legitimidade para formalizar a revisão criminal, pouco importando haver emprestado ao pedido o rótulo de *habeas corpus* (...)”.

Seguindo a orientação da Suprema Corte, no concurso para Promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, realizado no ano de 2011, foi considerada INCORRETA a assertiva que dizia que a revisão criminal “poderá ser pedida pelo próprio réu, por procurador legalmente habilitado ou pelo Ministério Público”.

No concurso para a Magistratura de São Paulo, organizado pela VUNESP em 2009, também foi considerada INCORRETA a assertiva que aduzia que “em tema de revisão criminal, é correto afirmar que pedido pode ser ajuizado pelo Ministério Público em favor do condenado”.

De igual forma, no concurso para Assessor de Estabelecimento Penal da Defensoria Pública do Estado do Paraná, realizado em 2011, foi considerada INCORRETA a assertiva que dizia que “de acordo com os Tribunais Superiores, o Ministério Público poderá propor revisão criminal a favor do condenado”.

#### 4.3. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO À PRISÃO

À luz da Súmula nº 393 do STF: “Para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão”.

#### 5. HIPÓTESES DE CABIMENTO

Por afastar a coisa julgada, constitucionalmente garantida no art. 5º, XXXVI, CF/88, as hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente previstas no art. 621 do CPP, que assim dispõe:

Art. 621, CPP. A revisão dos processos findos será admitida:

- I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
- II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
- III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

##### 5.1. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL

Em regra, de acordo com a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, não cabe o ajuizamento de revisão criminal para se requerer a aplicação de nova interpretação jurisprudencial de dispositivos legais a caso já definitivamente julgado, ressalvadas a *abolitio criminis* e a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos. Por ser bastante elucidativa, transcreve-se ementa extraída do STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL EM RAZÃO DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. “A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de *abolitio criminis* ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive *incidenter tantum*), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 153805

AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16/10/2018 PUBLIC 17/10/2018.) (Grifos nossos.)

## 6. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO

A competência para julgamento da revisão criminal será determinada de acordo com o órgão jurisdicional responsável pela prolação da decisão condenatória ou absolutória imprópria:

I) se o *decisum* provier do STF, nos termos do art. 102, I, *j*, CF/88 c/c 624, I, CPP, a ele caberá julgar a respectiva ação;

II) se a decisão tiver sido prolatada pelo STJ, conforme art. 105, I, *e*, CF/88, será de sua competência o processo e o julgamento da revisão criminal ajuizada;

III) caso provenha de TRF ou de Juiz Federal, a teor do art. 108, I, *b*, CF/88 c/c art. 624, II, CPP, será julgada pelo respectivo TRF;

IV) se for emanada de TJ ou de Juiz de Direito, nos termos do art. 624, II, CPP, será julgada pelo respectivo TJ;

V) caso seja originária de Juizado Especial Criminal, competirá à Turma Recursal o seu processo e julgamento, não havendo falar em competência do Tribunal respectivo, conforme orientação do STJ<sup>47</sup>.

## 7. PROCEDIMENTO

Conforme se verifica no art. 625 do CPP, que deve ser lido à inteireza, a revisão criminal não comporta contraditório, não sendo prevista fase voltada à produção probatória, devendo o pedido ser instruído com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória ou absolutória imprópria e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, nos termos do já mencionado § 1º, sob pena de indeferimento liminar do pedido pelo relator, conforme § 3º.

Questão interessante diz respeito ao pedido de revisão criminal fundado em depoimento falso, que poderá demandar a produção de nova prova oral para comprovar a falsidade da anterior.

Nesse caso, a parte deverá ajuizar, perante o juízo criminal de primeira instância, o procedimento de justificação prévia, nos termos do art. 381, § 5º, CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP.

## 8. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO

A procedência do pedido de revisão criminal somente poderá beneficiar o réu, restando vedada a chamada *reformatio in pejus*, nos termos do art. 626, parágrafo único, CPP, que proíbe o agravamento da pena anteriormente imposta.

Nesse contexto, à luz do *caput* do mencionado artigo, em sendo procedente o pedido, poderá o Tribunal: I) alterar a classificação da infração; II) absolver o réu; III) modificar a pena; e IV) anular o processo.

Havendo a absolvição do interessado, nos termos do art. 627 do CPP, todos os direitos perdidos em virtude da condenação serão reestabelecidos, devendo o Tribunal, se for o caso, impor a medida de segurança cabível.

Ocorrendo a cassação da sentença anteriormente proferida, o juiz, à vista da certidão do acórdão que determinou tal medida, mandará, imediatamente, juntá-la aos autos, para inteiro cumprimento da decisão, conforme art. 629 do CPP.

<sup>47</sup>CC 47.718/RS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/8/2008, DJe 26/8/2008.

## 8.1 JUS RESCINDENS E JUS RESCISORIUM

Convém diferenciar dois institutos atrelados à procedência do pedido de revisão criminal: *jus rescindens* (rescindente ou revidente) e *jus rescisorium* (rescisório ou revisório).

O *jus rescidens*, que é motivado por um *error in procedendo* (erro de procedimento), conduz à anulação da sentença combatida, submetendo o interessado a novo julgamento, no qual não poderá lhe ser imposta pena superior, sob pena de violação à proibição da *reformatio in pejus*.

A seu turno, o *jus rescisorium* se verifica quando há o chamado *error in judicando* (erro no julgamento), possibilitando que o Tribunal substitua a decisão guerreada por outra, sempre melhorando a situação do interessado (*pro reo*).

Quanto ao *jus rescisorium*, frise-se que este somente poderá se verificar se houver pedido expresso da parte requerente nesse sentido, não sendo deferido de ofício.

Logo, é a parte quem define se quer ver a decisão cassada, submetendo o interessado a novo julgamento, ou se deseja a reforma da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria, melhorando a situação do réu.

## 9. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO

Em consonância com o art. 5º, LXXV, CF/88, o art. 630 do CPP traz a possibilidade de o Tribunal, caso haja requerimento do interessado, “reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos”, que deverá ser liquidada no juízo cível, à luz do §1º do mesmo dispositivo legal.

Note-se que somente há falar em fixação de indenização se houver pedido do interessado, não sendo uma decorrência automática da procedência do pedido de revisão criminal.

Conforme art. 630, § 1º, CPP, sendo o órgão prolator da sentença combatida vinculado à justiça federal ou do Distrito Federal e dos Territórios, a responsabilidade pela indenização será da União. Caso tal órgão seja estadual, a indenização será devida pelo Estado respectivo.

Nos termos do §2º, não será devida a indenização “se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder” (alínea *a*) ou “se a acusação houver sido meramente privada” (alínea *b*).

É importante mencionar, quanto à alínea *b*, que a doutrina, de forma maciça, defende que, mesmo no caso de ação penal de iniciativa privada, caberá a indenização por erro judiciário, já que o *jus puniendi* foi exercido pelo Estado, não sendo tal dispositivo recepcionado pela CF/88.

Em todo caso, mostra-se viável que o Poder Público ajuíze “ação regressiva contra o particular que deu ensejo ao erro judiciário, para se ver ressarcido da indenização fixada na ação rescisória” (TÁVORA; ALENCAR, 2017, 1621).

## 10. REITERAÇÃO DE PEDIDOS

Conforme art. 622, parágrafo único, do CPP, é possível a reiteração de pedidos de revisão criminal, desde que o novo requerimento esteja fundado em novas provas.

A par do surgimento de novas provas, justamente por ser uma ação autônoma de impugnação, é possível a reiteração de pedidos com fulcro em outro fundamento, porquanto, nesse caso, não se verificaria identidade de ações, já que distintas as causas de pedir. Assim, por exemplo, seria possível um primeiro pedido fundado no inciso I do art. 621 do CPP (“sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”) e um segundo requerimento com base no inciso II (“sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos”) (LIMA, 2017, p. 1809).

## 11. RECURSOS CABÍVEIS

Tendo em vista que a revisão criminal é ação originária de Tribunais ou de Turmas Recursais, não falar em apelação criminal contra as decisões proferidas por tais órgãos jurisdicionais. De igual forma, considerando que somente são cabíveis os embargos infringentes e de nulidade contra acórdãos não unânimes desfavoráveis à Defesa oriundos de apelação, de recurso em sentido estrito ou agravo em execução, que segue o mesmo rito do RESE, também não se pode cogitar do manejo de tais recursos contra decisões proferidas no âmbito de revisões criminais (LIMA, 2017, p. 1828).

Por outro lado, podem ser usados os Recursos Extraordinário e Especial, com particular atenção à inadmissibilidade deste último quando se tratar de julgado oriundo de Turmas Recursais (LIMA, 2017, p. 1809).

No ponto, relembre-se que, a teor da Súmula nº 640 do STF, é cabível Recurso Extraordinário contra decisão de Turmas Recursais, contudo, nos termos da Súmula nº 203 do STJ, não é admissível Recurso Especial "contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais".

## 12. LEI PENAL MAIS BENÉFICA

Sobrevindo, na fase de execução penal, *novatio legis in melius*, que importe, por exemplo, em redução da pena, bastará ao condenado requerer ao juízo da Vara das Execuções Penais a aplicação da nova disposição legal, nos termos do art. 66, inciso I, da LEP, que deve ser lido em conjunto com a Súmula nº 611 do STF.

Logo, não é cabível o manejo da revisão criminal para se requerer a aplicação de eventual lei penal mais benéfica no curso da execução penal.

## 13. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA

### 13.1. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO DE REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO CORRESPONDE AO JULGAMENTO DO ÓRGÃO COLEGIADO. O Tribunal pode, a qualquer momento e de ofício, desconstituir acórdão de revisão criminal que, de maneira fraudulenta, tenha absolvido o réu, quando, na verdade, o posicionamento que prevaleceu na sessão de julgamento foi pelo indeferimento do pleito revisional. (Informativo nº 555 - REsp 1.324.760-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 16/12/2014, DJe 18/2/2015.)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a revisão criminal é um instituto que somente poderá beneficiar o réu (*pro reo*), contudo, no caso acima, o que se viu foi uma fraude na publicação do julgamento da revisão criminal, que não sido provida. Isto é: o interessado ingressou com pedido de revisão criminal e não obteve êxito, entretanto, ao contrário do que restou decidido na sessão de julgamento, foi publicada a procedência do pedido. Nesses termos, verificada a fraude, o Tribunal de Justiça desconstituiu o acórdão fraudulento, o que foi referendado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em revisão criminal *pro societate*.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL NA HIPÓTESE EM QUE A QUESTÃO ATACADA TAMBÉM TENHA SIDO ENFRENTADA PELO STF EM HC. O julgamento pelo STF de HC impetrado contra decisão proferida em recurso especial não afasta, por si só, a competência do STJ para processar e julgar posterior revisão criminal. (Informativo nº 578 - RvCr 2.877-PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 25/2/2016, DJe 10/3/2016.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE EQUÍVOCO NO RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA. No caso em que o reconhecimento da reincidência tenha origem em infração anterior cuja pena tenha sido cumprida ou extinta há mais de 5 anos, deferido o pedido revisional para diminuir a pena equivocadamente fixada, será devida a indenização ao condenado que tenha sofrido prejuízos em virtude do erro



judiciário. (Informativo nº 590 - REsp 1.243.516-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/9/2016, DJe 30/9/2016.)

## QUESTÕES

### 1- DPE/ES (FCC 2016) Sobre a revisão criminal,

- a) é vedada discussão sobre indenização por erro judiciário em sede de revisão criminal, devendo ser proposta ação própria em caso de revisão procedente.
- b) é cabível a revisão criminal da sentença absolutória imprópria.
- c) em virtude da soberania dos veredictos, é vedada a revisão criminal de sentença do Tribunal do Júri.
- d) sem a falsidade da prova utilizada para condenar o réu ou de nova prova capaz de inocentá-lo não há possibilidade jurídica do pedido de revisão criminal.
- e) ao contrário do *habeas corpus*, é necessária capacidade postulatória para a revisão criminal.

### 2- TJ/CE (FCC 2014) A revisão criminal

- a) não admite reiteração, ainda que fundada em novas provas.
- b) não se presta a modificar a pena.
- c) é aceita no caso de sentença absolutória imprópria.
- d) obriga o recolhimento à prisão para ser requerida.
- e) pode ser requerida em qualquer tempo, mas apenas antes da extinção da pena.

## COMENTÁRIOS

### 1. Gabarito: B.

- a) Em consonância com o art. 5º, LXXV, CF/88, o art. 630 do CPP traz a possibilidade de o Tribunal, caso haja requerimento do interessado, “reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos”, que deverá ser liquidada no juízo cível, à luz do §1º do mesmo dispositivo legal.
- b) É cabível a revisão criminal no caso de sentença condenatória ou absolutória imprópria, desde que tenha havido o trânsito em julgado, nos termos do art. 621, *caput*, CPP.
- c) É cabível o manejo de revisão criminal contra sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias oriundas do Tribunal do Júri, sendo possível a fundamentação do pedido em qualquer das hipóteses insertas nos incisos do art. 621 do CPP, não havendo falar em violação à soberania dos veredictos.
- d) A possibilidade jurídica do pedido de revisão criminal é extraída dos incisos do art. 621 do CPP, sendo a falsidade da prova apenas um dos fundamentos de tal ação autônoma de impugnação, que também poderá ser intentada “quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos” ou “quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.
- e) Embora haja vozes importantes em sentido contrário, a doutrina majoritária sustenta que o réu não necessita estar representado por advogado constituído para ingressar com revisão criminal, sendo encontrados precedentes do STF e do STJ nesse sentido.

### 2. Gabarito: C.

- a) Conforme art. 622, parágrafo único, do CPP, é possível a reiteração de pedidos de revisão criminal, desde que o novo requerimento esteja fundado em novas provas.
- b) À luz do art. 626, *caput*, CPP, em sendo procedente o pedido, poderá o Tribunal: I) alterar a classificação da infração; II) absolver o réu; III) modificar a pena; e IV) anular o processo, sendo vedado o agravamento da pena anteriormente imposta, conforme parágrafo único do mesmo artigo.
- c) É cabível a revisão criminal no caso de sentença condenatória ou absolutória imprópria, desde que tenha havido o trânsito em julgado, nos termos do art. 621, *caput*, CPP.
- d) À luz da Súmula nº 393 do STF, “Para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão”.
- e) A revisão criminal, conforme art. 622, *caput*, do CPP, poderá ser requerida a qualquer tempo (inexiste prazo decadencial), antes ou depois da extinção da pena, sendo cabível tal medida, inclusive, após a morte do réu, caso em que poderá ser pedida pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão (art. 623, CPP).



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

---

- ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. **Princípios Fundamentais do Processo Penal**. São Paulo: Ed. RT, 1973.
- ALVES, Reinaldo Rossano. **Direito Processual Penal**. Editora Impetus, 2013.
- ARAS, Vladimir. **Debaixo de Vara**: a condução coercitiva como cautelar pessoal autônoma. Disponível em: <https://vladimiraras.blog/2013/07/16/a-conducao-coercitiva-como-cautelar-pessoal-autonoma/>. Acesso em: 20 de abril de 2020.
- AVENA, Norberto. **Processo Penal**. 9ª ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.
- BADARÓ, Gustavo. **Correlação entre Acusação e Sentença**. 3. ed. São Paulo: RT, 2013.
- BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivany. **Processo Penal**. 6. ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: ED. RT, 2018.
- BARBOSA, Manoel Messias. **Inquérito Policial**. Editora Método, 2009.
- BLACK, Matt; SMITH, Russell G. **Electronic Monitoring in the Criminal Justice System**. Australian Institute of Criminology, maio de 2003, nº 254. Disponível em: [http://www.antoniocasella.eu/nume/Black\\_electronic\\_2003.pdf](http://www.antoniocasella.eu/nume/Black_electronic_2003.pdf). Acesso em: 20 de abril de 2020.
- BONFIM, Edilson Mougenot. **Curso de Processo Penal**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
- CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. **Teoria Geral do Processo**. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2007.
- COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. In: LOPES JR, Aury. **Direito Processual Penal**. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
- COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. **Observações sobre os Sistemas Processuais Penais**, observatório da mentalidade inquisitória.
- CRUZ, Rogério Schietti. **Prisão Cautelar**: dramas, princípios e alternativas. 3ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017.
- CUNHA, Rogério Sanches. **Pacote Anticrime - Lei 13.964/2019**: Comentários às Alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.
- DEZEM, Guilherme Madeira. **Curso de Processo Penal**. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.
- FERNANDES, Antonio Scarance. **Processo Penal Constitucional**. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2002.
- FERRAJOLI, Luigi. **Derecho y Rázon**— teoria del garantismo penal. Madrid: Editorial Trotta, 1999.
- GRECO FILHO, Vicente. **Manual de Processo Penal**. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
- GUILHERME TAVARES, João Paulo Lordelo. **Das Medidas Cautelares no Processo Penal**: um esboço à luz do regramento da tutela provisória do novo CPC. In: **Processo Penal**. Coleção Repercussões do Novo CPC, v. 13. Obra Coletiva. Coord. Geral: Fredie Didier Júnior. Coordenadores: Antonio do Passo Cabral, Eugênio Pacelli e Rogerio Schietti Cruz. Salvador: JusPodivm, 2016.
- LIMA, Renato Brasileiro de. **Código de Processo Penal Comentado**. 2ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017.
- LIMA, Renato Brasileiro de. **Manual de Processo Penal**: volume único. 5ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017.
- LIMA, Renato Brasileiro de. **Manual de Processo Penal**: volume único. 7ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019.
- LIMA, Renato Brasileiro de. **Manual de Processo Penal**: volume único. 8ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.
- LOPES JR., Aury. **Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
- LOPES JR., Aury. **Fundamentos do Processo Penal**: introdução crítica. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

- LOPES JR., Aury; GLOECKNER, Ricardo Jacobson. **Investigação Preliminar no Processo Penal**. Saraiva, 2013.
- LOPES JUNIOR, Aury. **Direito Processual Penal**. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017
- MARCÃO, Renato. **Código de Processo Penal Comentado**. São Paulo: Saraiva, 2016.
- MARQUES, José Frederico. **Elementos de Direito Processual Penal**. Campinas: Bookseller, 1997. V. 1.
- MELCHIOR, Antonio Pedro. **Gestão da Prova e o Lugar do Discurso do Julgador – o sintoma político do processo penal democrático**. Rio de Janeiro: 2012. Disponível em: <http://portal.estacio.br/media/4120373/antonio%20pedro%202011.pdf>.
- MENDONÇA, Andrey Borges de. **Prisão e Outras Medidas Cautelares Pessoais**. São Paulo: Método, 2011.
- MIRABETE, Julio Fabbrini. **Processo Penal**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
- NUCCI, Guilherme de Souza. **Código de Processo Penal Comentado**. 15ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016.
- NUCCI, Guilherme de Souza. **Manual de Processo Penal e Execução Penal**. 12ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro, 2015.
- NUCCI, Guilherme de Souza. **Manual de Processo Penal e Execução Penal**. 13ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro, 2016.
- NUCCI, Guilherme de Souza. **Provas no Processo Penal**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
- PACELLI, Eugênio. **Curso de Processo Penal**. 21ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2017.
- PACELLI, Eugênio. **Curso de Processo Penal**. 23ª. ed. São Paulo: Atlas, 2019.
- PAIVA, Caio. **Audiência de Custódia e o Processo Penal Brasileiro**. São Paulo: CEI, 2015 e OLIVEIRA, Gisele Souza de ; BRASIL JUNIOR , Samuel Meira ; SOUZA, Sérgio Ricardo ; SILVA, William. **Audiência de Custódia: dignidade humana, controle de convencionalidade, prisão cautelar e outras alternativas (Lei 12.403/2011)**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2015.
- PRADO, Geraldo. **Sistema Acusatório**. A conformidade constitucional das leis processuais penais. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
- RANGEL, Paulo. **Direito Processual Penal**. 17ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
- REIS, Alexandre Cebrian Araújo; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. **Direito Processual Penal Esquemático**. Saraiva, 2013.
- SILVA, Márcio Alberto Gomes. **Inquérito Policial – uma análise jurídica e prática da fase pré-processual**, Salvador: JusPodivm, 5. ed, revista, ampl. e atualiz., 2020.
- TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. **Curso de Direito Processual Penal**. 12ª ed., rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017.
- TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. **Curso de Direito Processual Penal**. 15ª ed., rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.
- TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. **Manual de Processo Penal**. Saraiva, 2013.